

**LA ACTIVIDAD DE LA BANCA Y LOS NEGOCIOS
MERCANTILES EN EL MARE NOSTRUM
(Estudios en homenaje a Antonio Díaz Bautista)**

**LA ACTIVIDAD DE LA BANCA Y
LOS NEGOCIOS MERCANTILES
EN EL MARE NOSTRUM**
(Estudios en homenaje a Antonio Díaz Bautista)

(Coordinadores)

CRÉDITOS

La actividad de la banca y los negocios mercantiles en el Mare Nostrum (Estudios en homenaje a Antonio Díaz Bautista)

ISBN:

Depósito Legal:



ÍNDICE

Presentación	00
<i>Juan Ramón Robles Reyes, M^a Dolores Parra Martín, Adolfo Díaz-Bautista Cremades, Juana María del Vas</i>	
Depreciación monetaria e inflación en la crisis del bajo imperio	15
<i>Luis Rodríguez Ennes</i>	
La asunción de riesgos y la seguridad en el transporte marítimo	35
<i>José Luis Zamora Manzano</i>	
Una hipótesis sobre el origen y estructura de la comunidad de pescadores de “el palmar” de la albufera de valencia	55
<i>Carmen Lázaro Guillamón</i>	
Comercio y piratería en Roma en la época republicana	73
<i>Belén Fernández Vizcaíno</i>	
Los extranjeros y el comercio en indias, el caso de los navarros y los aragoneses.	89
<i>Francisco Cuenca Boy</i>	
La responsabilidad del banquero por los depósitos de los clientes. Una reflexión desde las fuentes romanas	103
<i>Alfonso Murillo Villar</i>	
La legislación de Justiniano del Código en materia de negocios bancarios	117
<i>Fabiana Mattioli</i>	
El primer tratado romano-gaditano: interrogantes e hipótesis	127
<i>Bernardo Perinián Gómez</i>	
Algumas considerações sobre a banca em Roma. (História e direito)	135
<i>António dos Santos Justo</i>	

A proibição da usura e a constituição da sociedade em conta de participação	169
<i>João Luis Nogueira Matias</i>	
La influencia del Derecho Romano en la actividad mercantil y bancaria del Nuevo Mundo	181
<i>Mirta Beatriz Álvarez</i>	
Un supuesto de adaptación al Derecho europeo en materia de incumplimiento contractual a la luz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo del 2013	199
<i>Amparo Montaña Casaní</i>	
Algunos ejemplos sobre medidas bancarias de naturaleza pública en la antigua Roma	209
<i>Ana I. Clemente Fernández</i>	
Privilegios de la banca respecto de los intereses en los préstamos: ¿legalidad y/o utilidad?	221
<i>María Salazar Revuelta</i>	
La participación del argentarius en las subastas según la Lex Metalli Vipascensis . .	239
<i>Elena Sánchez Collado</i>	
La actio exercitoria como medio para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico comercial marítimo	253
<i>Eva María Polo Arévalo</i>	
Exégesis de “ulpianus libro xiv ad edictum” (d. 13, 5 De pecunia constituta, 27)	271
<i>Victoriano Sáiz López</i>	
La regulación de los intereses del préstamo en la <i>eisagoge</i>	283
<i>Francisco J. Andrés Santos</i>	
<i>Figulus et figlina</i> : reflexiones sobre la actividad comercial en  <i>nia (isturgi)</i> bajo el dominio romano	301
<i>María-Eva Fernández Baquero</i>	
Matrizes societárias do Banco do Brasil de 1808. Contributo para a história do direito bancário português	323
<i>Rui Manuel De Figueiredo Marcos</i>	
La función de los <i>argentarii</i> en la subasta romana	335
<i>Olga Gil García</i>	

El contrato de mutuo en la republica argentina y su proyección legislativa: una mirada desde derecho romano	353
<i>Marilina Miceli y Dra. Esther H. S. Ferrer de Fernández</i>	
Concluding of the legal affairs in medieval eastern adriatic towns	361
<i>Nevenka Bogojević-Glušćević</i>	
O comércio em roma	375
<i>André Augusto Alcher Meira</i>	
Reflexiones romanistas jurídico críticas	395
<i>Ricardo Panero Gutiérrez</i>	
D. 50,6,6,3 (Call. 1 de Cogn.) Los privilegios a favor de los navicularii: entre iniciativa privada e intervencionismo estatal	413
<i>Guerrero Lebrón, Macarena</i>	
Las societates publicanorum y el edictum provinciale: Sobre la autonomía de la obligación del banquero respecto a la del deudor (a propósito de d. 13, 5, 27 Ulpianus libro 14 ad edictum)	437
<i>Ana Alemán Monterreal</i>	
La protección a menores y adolescentes en negocios mercantiles: precedentes romanos y su proyección en el derecho actual	451
<i>M^a Teresa Duplá Marín, Patricia Panero Oria y Elisabeth García-Cueto</i>	
Direito Marítimo Romano. A Disciplina Jurídica do Alijamento	473
<i>Rodrigo de Lima Vaz Sampaio</i>	
Breves refflexões sobre banqueiros, juros e usura— da. Lei das XII Tábuas ao século XXI	489
<i>Aloísio Surgik</i>	
La “datio in solutum” como figura sustitutiva del pago del crédito; sus antecedentes en Derecho Romano y su consideración en el derecho actual”	507
<i>Luis Mariano Robles Velasco</i>	
La nave como unidad jurídica en Derecho romano: algunas reflexiones en torno a D. 47, 9, 3, 8 (Ulp. 56 ad edict.)	525
<i>Emilia Mataix Ferrándiz</i>	
El secreto bancario: precedentes romanos	541
<i>Paula Domínguez Tristán</i>	

Negocios financieros en la legislación de  eciano  financial business in diocletian  law.....	557
<i>Adolfo A. Díaz-Bautista Cremades</i>	
Aspectos sobre la tutela procesal del comodatario y su evolución histórica	569
<i>Javier Belda Mercado</i>	
La publicidad de la conventio pignoris	589
<i>Margarita Fuenteseca</i>	
<i>Ut honestas postulat</i> : el control tributario en el tráfico mercantil	595
<i>Rosalía Rodríguez López</i>	
Ventaja competitiva de roma en el mare nostrum. Especial referencia al puerto de carthago nova..... 	611
<i>María Dolores Parra Martín</i>	
Evolución de la competencia jurisdiccional en negocios bancarios	623
<i>Juan Ramon Robles Reyes</i>	

PRESENTACIÓN

La primera línea que escribiera Cervantes en su Quijote fue para desear que su libro fuese el más hermoso, gallardo y discreto que pudiera imaginarse. Así nos gustaría que fuesen estas palabras, hermosas, gallardas y discretas, para honrar a Antonio Díaz Bautista y a Hans Ankum, así como para invocar el apoyo de los dioses para trasladar esta obra, con la brillantez que merece, a los investigadores del Derecho Romano que constituyen una gran familia a nivel mundial.

Este libro tiene su origen en la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano reunida en Almería en la primavera del año 2012, en donde se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de que la sede para la celebración del Congreso del año 2014 fuese la ciudad de Murcia, siendo el encargado de su organización el Catedrático D. Antonio Díaz Bautista. Según se manifestó en dicho acto, la dirección de dicho evento correspondía por méritos propios al citado profesor, ya que concurrían en él, así como en la Universidad a la que pertenecía, circunstancias de importante consideración, como eran su propio prestigio internacional, sus aportaciones a la romanística, el hecho de que se hubiese acordado nombrar por la Universidad de Murcia Doctor Honoris causa al profesor Hans Ankum o la brillante celebración del Segundo Congreso de la Asociación que tuvo lugar en esta ciudad en el año 1996. El ofrecimiento fue aceptado con agradecimiento por el profesor Díaz Bautista, adquiriéndose el compromiso de su organización por parte del mismo, así como por su equipo de colaboradores y la propia universidad.

La designación de la ciudad de Murcia fue ratificada en la Asamblea celebrada en Lisboa, el día 15 de febrero de 2013, pero con una importante y dolorosa variación, como fue la de hacer constar en el acta que el Congreso sería, no ya en homenaje al profesor Díaz Bautista, como era la intención originaria, sino *in memoriam*, debido a su fallecimiento, solo unas semanas antes.

La voluntad del grupo de profesores que trabajaba con el profesor Díaz Bautista, apoyado incondicionalmente por la Asociación Iberoamericana y los cientos de componentes que en Europa y América lo conocían y querían, así como por la mayoría de las instituciones murcianas, fue celebrar un brillante Congreso. En él se daría cumplimiento a los objetivos perseguidos desde el inicio, como eran fomentar el saber, honrar al maestro y apoyar a la Universidad Murcia, dando entrada en el elenco de sus Doctores Honoris Causa al insigne romanista Dr. D. Hans Ankum. Pero los designios de los dioses son en muchas ocasiones

caprichosos y quisieron que la ceremonia de investidura del profesor Ankum hubiese de postponerse por una súbita enfermedad de éste. A pesar de ello, el Congreso se celebró con brillantez gracias a la asistencia de los mejores investigadores en Derecho Romano, tanto europeos como americanos.

El tema escogido para el Congreso fue, por su actualidad e interés, “La actividad de la Banca y los Negocios Mercantiles en el *Mare Nostrum*” siendo los negocios bancarios y mercantiles uno de los ejes en los que gira, desde el principio de los tiempos, la economía y la vida de los pueblos. Otro motivo por el que se escogió este tema fue porque el Profesor Díaz Bautista era especialista en esta materia, habiendo escrito el libro *La Banca Bizantina*, monografía básica para el conocimiento de la actividad de los bancos en el Bajo Imperio y Época Bizantina, precedentes de nuestro actual sistema bancario.

El tema es lo suficientemente relevante y rico en enfoques como para permitir aportaciones desde los más diversos puntos de vista. La vida comercial en torno al *Mare Nostrum*, a nuestro Mar Mediterráneo, fue muy intensa, dilatada en el tiempo y con una diversidad de contratos y supuestos casi inimaginable. La práctica que se desarrolló por la actividad de navieros, comerciantes y prestamistas dio lugar a una regulación normativa que acabaría conformando las primeras regulaciones legales, en muchos casos de gran altura técnica. Hablar de hipotecas, préstamos, prenda, contratos con cláusulas condicionales o los documentos bancarios y notariales que se derivaban de ellos, supone el reconocimiento de una fuente de conocimientos e información imprescindible para conocer el porqué de nuestros códigos y sentencias y, sobre todo, el porqué las cosas se deben hacer bien hechas y las leyes bien promulgadas, para que la justicia, la prosperidad y la paz sigan existiendo en los pueblos. Esta es una meta del Derecho Romano en la actualidad y a la que se dirigen sus investigaciones, como se refleja en los capítulos de la presente monografía que, con altura técnica y rigor, deja constancia, una vez más, de que el Derecho Romano sigue conformando los cimientos del derecho actual.

Finalmente, es de justicia manifestar el amplio apoyo institucional y privado que la iniciativa, impulsada por la Universidad de Murcia, tuvo en la ciudad de Murcia. Magistrados, Jueces, Registradores y profesionales de todos los ámbitos del Derecho mostraron su apoyo. Imprescindible ha sido la colaboración de Instituciones como la Fundación Séneca, Comunidad Autónoma, entidades privadas o, en un congreso sobre la actividad bancaria, la generosa aportación del Banco Mare Nostrum. Todos ellos han hecho posible este proyecto que, como actividad universitaria, redundará en toda la sociedad.

Reproduciendo las palabras del profesor Antonio Díaz Bautista, “estos trabajos enriquecerán nuestras mentes, pero también nuestras voluntades, pues, como dice Justiniano en la Constitución *Deo Auctore .. nihil tam studiosum in ómnibus rebus quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit...*”.

Juan Ramón Robles Reyes
M^a Dolores Parra Martín
Adolfo Díaz-Bautista Cremades
Juana María del Vas

DEPRECIACIÓN MONETARIA E INFLACIÓN EN LA CRISIS DEL BAJO IMPERIO*

CURRENCY DEPRECIATION AND INFLATION IN THE CRISIS OF THE LAW EMPIRE

LUIS RODRÍGUEZ ENNES
Catedrático de Derecho Romano
Universidad de Vigo

SUMARIO: I. Introducción. II. Causas de la crisis. III. Política monetaria. IV. Decadencia y cese de las explotaciones mineras. V. Medidas antiinflacionistas. VI. Bibliografía.

I

El Imperio Romano fue el estado de mayor tamaño que haya conocido nunca la Eurasia occidental. Durante más de cuatrocientos años se extendió desde el Muro de Adriano hasta el río Éufrates, transformó las vidas de todos los habitantes circunscritos por sus fronteras y dominó tierras y pueblos situados a centenares de kilómetros de sus confines. Una serie de sistemas íntimamente relacionados y compuestos por fortalezas, por redes estratégicas en calzadas y por ejércitos profesionales excelentemente entrenados constituyen a un tiempo el símbolo y la garantía de este dominio. Sin embargo, en el plazo de una generación, el orden romano se vio conmocionado hasta la médula.

¿Por qué se hundió Roma? En el mundo anglófono la caída está inevitablemente ligada a la “decadencia”, debido a que el título de la monumental obra de Edward Gibbon –*The History of Decline and Fall of the Roman Empire* (Londres, 1776-1788)– ha quedado firmemente grabado en la memoria colectiva. Como ha señalado Goldsworthy: “ningún otro libro de historia del siglo XVIII ha sido publicado con tanta regularidad en diversas formas y ediciones hasta el siglo de hoy”¹. Se han escrito muchísimas obras sobre el tema y cabe que algunas hayan presentado un análisis más perspicaz del asunto, pero ninguna ha cuestionado el puesto de la *History* Gibboniana como uno de los hitos fundamentales de la literatura inglesa. En los últimos años de su vida, a Gibbon le gustaba

1 GOLDSWORTHY, A., *La caída del Imperio romano. El ocaso de Occidente*, trad. esp. Martín Lorenzo (Madrid, 2009) p. 13.

pensar que convertirse en historiador y escribir la crónica de la caída de Roma había sido una elección del destino. Afirmaba que la inspiración le llegó en un momento específico.

“Estaba en Roma, era 15 de octubre de 1764 y me hallaba sentado meditando en las ruinas del Capitolio mientras tres monjes descalzos cantaban las vísperas en el templo de Júpiter cuando la idea de relatar la decadencia y caída de la Ciudad brotó en mi mente por primera vez”².

Gibbon escribió varias versiones de esta anécdota, lo que dio pie a la sospecha de que había embellecido o incluso inventado ese recuerdo³. Con todo, no cabe duda que fue un impulso romántico el que lo indujo a dedicar sus esfuerzos a la descripción de la caída del Imperio Romano, y con ello a la creación de una de las obras clásicas de la lengua inglesa. Para Gibbon la decadencia de Roma era algo tan natural que no exigía una explicación: “The story of his ruin is simple and obvious; and instead of inquiring why the Roman Empire was destroyed, we should rather be surprised that it had subsisted so long”⁴. Para Momigliano⁵: en estas palabras “hay cierto grado de insinceridad”; empero, tal vez el juicio más adecuado sobre la talla de Gibbon se deba al gran especialista de Cambridge, J. B. Bury que preparó la mejor edición de la historia gibboniana y que señala sin ambages que las investigaciones posteriores más exhaustivas “no han alterado ni embotado la naturaleza de los argumentos (...) su admirable descripción del cambio desde el principado a la monarquía absoluta y el sistema de Diocleciano y Constantino sigue siendo de gran valor (...) en lo principal, sigue siendo nuestro maestro y se encuentra por encima del presente efímero”⁶. Y es que en cierto sentido, la formulación de Gibbon fue de una importancia fundamental; rompió simple e inequívocamente con todas las teorías cíclicas, místico-biológicas y metafísicas de la decadencia, y afirmó con claridad el punto de vista “naturalista”. Había que buscar la causa dentro del mismo sistema⁷. Este punto de vista ha sido confirmado por nuestro propio análisis. Porque éste ha demostrado que el Imperio Romano no decayó a causa de una sola característica: el clima, la tierra, la salud de la población -ni tampoco a causa de los factores sociales y políticos que desempeñaron un papel tan importante en el proceso real de su decadencia- sino porque en cierto momento se vio sometido a tensiones que toda la estructura de la sociedad antigua le impedía soportar.

2 GIBBON, E., *The History*, cit., II, p. 509. La cita procede de la edición original de Penguin Classic (1995). Ha habido muchas ediciones diferentes de Gibbon y la numeración de las páginas varía enormemente.

3 Santa María d' Aracoeli, donde Gibbon escuchaba a los frailes, está en el sitio del templo de Juno Moneta, el lugar consagrado a Júpiter se alzaba en el otro lado del Capitolio [Cfr. WHITE, L., *The Transformation of the Roman World: Gibbon's Problem after Two Centuries* (Berkeley-Los Ángeles, 1966) p. 201].

4 GIBBON, E., *The History*, cit., IV, p. 161.

5 MOMIGLIANO, A., “Gibbon's Contribution to Historical Method”, en *Studies in Historiography* (Londres, 1966) p. 40.

6 GIBBON, E., *The History*, J. B. Bury (ed.) I (Nueva York, 1906) p. 14.

7 WALBANK, F. W., *La pavorosa revolución. La decadencia del Imperio Romano en Occidente*, trad. esp. D. Rolfe (Madrid, 1978) p. 135, donde añade: “No era algo trascendental o apocalíptico, el cumplimiento de una profecía o un eslabón en una cadena de hechos destinada a repetirse a lo largo de la eternidad; tampoco era algo fortuito, como los ataques bárbaros, ni un error de juicio por parte de uno u otro emperador o de sus asesinos respectivos”.

Nunca es fácil aislar el instante en que una sociedad deja de progresar y empieza a decaer. Los factores implicados son tan numerosos y se refieren a fenómenos en etapas de desarrollo tan diversas que la vigorosa expansión de una esfera bien puede coincidir con la decadencia ya avanzada de otra. Desde que el hombre aprendió por primera vez a registrar su propia historia en forma duradera, ha recurrido a los anales del pasado para iluminar los problemas del presente; y se ha referido una y otra vez a ciertos períodos y acontecimientos porque le parecían especialmente vivos y pertinentes a su propia situación. Este es el caso de la caída del Imperio Romano en Europa occidental. Desde los tiempos de los primeros padres de la Iglesia hasta la actualidad, la causa de aquel ocaso ha sido un punto central de la especulación histórica. Así las cosas, la caída de Roma también tiene una moraleja que subrayar y una lección que enseñar. “Los acontecimientos pasados –escribió Polibio (XII, 25e, 6) nos hacen prestar especial atención al futuro, si realmente indagamos a fondo cada paso del pasado”. Siguiendo el espíritu de esta declaración se han escrito estas páginas.

II

La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo es un terreno abonado para el ejercicio de la polémica. Crisis y decadencia no son conceptos históricos, quiero decir, científicos. Que puedan y deban serlo es otra cuestión. Como acertadamente pone de manifiesto Fernández Ubiña⁸, lo cierto es que las más diversas adversidades han sido consideradas como efectos o causas de los “tiempos de crisis y decadencia” que, normalmente, estarían precedidos de una “edad de oro” y que –en no menos ocasiones– eran seguidos de otros tiempos felices que, en el peor de los casos, constituían una “edad de plata”. Pero, si existe tal momento en la historia del Imperio Romano, los autores coinciden en que corresponde al año 117 d. C. cuando Adriano sucedió a Trajano en el Principado⁹. Con todo, resulta obvio que un análisis como el nuestro es muy general y requeriría para una comprensión a fondo un estudio pormenorizado de cada caso. Rechazadas –a partir de la genial aportación de Gibbon– la atribución de las épocas críticas a factores “sobrehumanos”¹⁰, debemos centrar el análisis de la situación en la asimilación de las profundas transformaciones socio-políticas a las adversidades naturales.

Tradicionalmente, la crisis del siglo III ha sido descrita como un período nefasto. Fue una época en la que los romanos sufrieron derrota tras derrota a manos de enemigos extranjeros nuevos y poderosos. Los ejércitos persas tomaron Antioquía, las flotas de piratas godos saquearon Grecia y Asia Menor y otras tribus bárbaras atravesaron las fronteras irrumpiendo en la Galia, Italia e Hispania¹¹. También hubo brotes de peste en amplias zonas

8 FERNÁNDEZ UBIÑA, J., *La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo* (Madrid, 1982) p. 8.

9 Vid., por todos, WALBANK, F. W., *La pavorosa revolución*, cit., p. 79.

10 Con lógicas variantes, esta interpretación acientífica de los hechos nos la vamos a encontrar en la literatura clásica griega, desde Hesíodo a Platón y, por supuesto, en Roma [Cfr. MAZZARINO, S., *El fin del mundo antiguo*, 5 (México, 1961) p. 189.190].

11 En punto a Hispania escribe J. M. BLÁZQUEZ: “El impacto de las invasiones y los restantes hechos de armas de la segunda mitad del siglo III en lo económico fue enorme. Por primera vez, regiones económicamente tan ricas como la Bética y el Levante fueron arrasadas, con villas y ciudades destruidas y mermada la población. Algunas no volvieron a levantar cabeza” [Cfr. *Aportaciones al estudio de la España romana en el Bajo Imperio* (Madrid, 1990) p. 238].

del Imperio, que muy posiblemente rivalizaron con la epidemia antonina en su virulencia y el número de víctimas causadas. Al mismo tiempo, la economía entró en crisis debido a la enorme devaluación de la moneda que llevaron a cabo los sucesivos emperadores para poder hacer frente al pago de sus guerras. También cambió la sociedad y algunos de los ciudadanos más pobres de las zonas rurales se vieron reducidos a poco más que siervos. Todo esto vino acompañado de una crisis de fe, a medida que en todo el Imperio la población fue abandonando las antiguas creencias por nuevas religiones y descabelladas supersticiones.

No cabe duda que la “clave” de todos estos desastres debe buscarse en la tercera centuria y fueron muchos autores contemporáneos los que tuvieron conciencia de la crisis, a la que naturalmente designaban con otras palabras: *corrupta, occasus saeculi, inclinatio fatorum...* pero que supieron describir con gran realismo, acertando incluso a poner sus inicios con el fin de la dinastía de los Antoninos¹². Ya en época de los Severos pudieron los contemporáneos calibrar algo de su alcance; las consecuencias de la crisis política interna de Roma llevaron a Tertuliano a hacer la observación de que *humiles sublimitate, sublimes humilitate mutantur* (Apol. 20, 2); parecidamente también Dión Casio hubo de presenciar como todas las cosas se volvían del revés en la jerarquía social de Roma¹³. San Cipriano pergeñaba un cuadro muy sombrío hacia el 252: los medios de subsistencia escaseaban, los precios subían, las minas estaban agotadas, las fuerzas artesanales mermaban; se añadía a esto la falta de campesinos en la agricultura¹⁴. No era posible detener la inflación que hacia mediados del siglo III alcanzó dimensiones catastróficas. Decayó el número de habitantes¹⁵; la *penuria hominum* es denunciada por Ulpiano de forma explícita¹⁶. En esta alarmante despoblación influyeron diversos factores: las guerras, las condiciones higiénicas, las miserias de las familias, la anarquía militar y las epidemias –abundantes en este período– pero quizá con orígenes en el siglo II en el que se produjo una gran epidemia de peste bajo el reinado de Marco Aurelio¹⁷, a la que siguieron otras epidemias y catástrofes naturales¹⁸. Por todo ello decayó el número de habitantes y se hizo más corta la esperanza general de vida¹⁹.

Fuente fundamental para la crisis del siglo III y para muchos aspectos del siglo IV es la *Historia Augusta* o *Scriptores Historiae Augustae* (SHA), conjunto de biografías latinas de los emperadores desde Adriano hasta Numeriano. También aquí aparecen consignados

12 A la crisis de su tiempo aluden Herodiano, 4, 4, 7 y Lactancio, *De mart. pers.*, 7, 3, entre otros.

13 Dion Casio, 80, 7, 2.

14 *Ad Demetr.*, 3 ss: “El número de agricultores disminuye y faltan en los campos. Menos marinos en el mar, menos soldados en los campamentos”.

15 Sobre la despoblación, vid.: SALMON, P., *Population et dépopulation dans l'Empire romain*, (Bruselas, 1974); WHITTAKER, C. R., en FINLEY, M. I. (ed) *Studies in Roman Property* (Cambridge, 1976) p. 137 ss.

16 D. 50, 6, 3 (2, 1) Ulp. de off. Proc.: *Impuberes, quamvis neccesitas penuriae hominum cogat*.

17 Zósimo, I, 26; 36, 7, 45-46. BRUUN, C., “The Antonine Plague and the Third Century Crisis”, en Hekster, Kleijn y Sootjes (eds.), *Crises and the Roman Empire* (Leiden-Boston-Brill, 2007) p. 201-207, JONGMAN, W., “Gibbon was Right: The Decline and Fall of the Roman Economy”, en *ibid.*, p. 188-189.

18 A ellas alude con rica aportación de fuentes contemporáneas, CANSINOS MORA, F. J., “Intervencionismo económico en la legislación imperial romana del siglo IV: Líneas generales”, en V.V.A.A. *Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano*, A. Fernández de Buján, Gabriel Gerez Kraemer, Belén Malavé Osuna (Co-editores) (Madrid, 2011) nt. 10, p. 255.

19 Dionisio de Alejandría, contemporáneo de San Cipriano, aparecía profundamente impresionado por estos fenómenos acaecidos en su ciudad natal (en Eus. *Hist. eccl.*, 7, 21, 9 ss.).

diversos enfoques de la crisis y de los peligros que comportaba²⁰; pero su valor como fuente fidedigna ha sido ampliamente discutida²¹, así como su fecha de redacción, pues algunos investigadores consideran que se escribió a finales del siglo IV o comienzos del siglo V, y que muchos datos son inventados²². En cambio, otros autores creen que fue escrita en tiempos de Diocleciano-Constantino, por lo cual son de inapreciable valor para el análisis del siglo III, considerando que los anacronismos existentes fueron introducidos en fechas posteriores²³. La composición tardía explicaría la falsificación: bajos los césares cristianos la propaganda pagana ya no es posible en forma directa, sino solamente como proyección literaria en el pasado²⁴.

III

Pocos detalles conocemos de la economía del mundo romano. No hay cuentas gubernamentales, ni registros oficiales de la producción, el comercio, la distribución de las ocupaciones, los impuestos. A causa de ello, no está a nuestro alcance efectuar una descripción sistemática de la economía romana. Los historiadores económicos, más aún que los historiadores que se interesan por los aspectos tradicionales, deben fijarse unos objetivos limitados y hacer uso de la imaginación y el discernimiento para tratar de alcanzarlos²⁵. Un autor de referencia en esta materia, Rostovteff²⁶ señala sin ambages que “uno de los fenómenos más acusados de la vida económica del siglo III fue la rápida depreciación de la moneda y el aumento –más rápido aún– de los precios”. De Martino ha demostrado que de varios textos romanos se infiere la denominada teoría cuantitativa de la moneda ya que en época republicana Cicerón y César eran sabedores de los efectos derivados de la escasez o del aumento de la moneda circulante. También los escritores del Imperio, y en particular Plinio, habían considerado con atención los fenómenos monetarios²⁷.

El mundo de las monedas es harto complejo, sobre todo si se propone uno hacer de ellas un tratamiento económico. Cuando hablamos de inflación se nos ocurre obnubilar

20 Cfr. *Tyr. Trig.*, 5, 7; *Vit. Aurel.*, 21, 1; *Vit. Car.*, 3, 2.

21 La *Historia Augusta* ha sido editada en Loeb Class. Libr. Por De Magie, 3 vols. (Londres, 1922-1932), reimpr. 1954), cfr. SYME, R., *Ammianus and the Historia Augusta* (Oxford, 1971); Id., “The composition of the *Historia Augusta*: recients theories”, en *JRS*, 62 (1972) p. 123 ss.

22 *Ad ex.*, BAYNES, N. H., *The Historia augusta: its date and purpose* (Oxford, 1926); STERN, H., *Date et destinataire de l'Histoire Auguste* (París, 1953). Este autor –en la p. 17– señala que la *Vit. Sev.*, 17, 5-19 está claramente tomada de Aurelio Victor, que escribió hacia el 360-361. Para LORiot, X., “Les premières années de la grande crise du III^e siècle : De l'avènement de Maxim le Thrace (225) á la mort de Gordien III (244) », en *ANRW*, II, 2 (Berlín-Nueva York, 1975) p. 657 ss., se escribió a fines del siglo IV por un solo autor que falseó constantemente los hechos, inventó otros y adaptó todo a las circunstancias de su tiempo.

23 Esta es la tesis seguida, entre otros, por L. HOMO, “Les documents de l'Histoire Auguste et leur valeur historique” en *RH* 151 (1926) p. 161 ss.

24 Cfr. ALBRECHT, *Historia de la literatura romana*, trad. esp. Dulce Estefanía-Andrés Pociña (Barcelona, 1999) p. 1265, con amplísima bibliografía en p. 1264, nt. 5.

25 GARNSEY P.-SALLER, R., *El Imperio Romano: economía, sociedad y cultura*, trad. esp. (Barcelona, 1990); FINLEY, M., *The Ancient Economy* (Londres, 1985), HOPKINS, K., *Trade in the Ancient Economy* (Londres, 1985).

26 ROSTOVTEFF, M., *Historia social y económica del Imperio Romano*, trad. esp. López Ballesteros, II (Madrid, 1973) p. 385.

27 DE MARTINO, F. de., *Storia económica di Roma antica*, II (Florenia, 1980) p. 353.

nuestra mente con ideas modernas, cuando –como bien dice De Martino²⁸– el sistema monetario antiguo era muy diverso del nuestro y no concurrían varios factores que en nuestro tiempo puedan ser causa de inflación. En primer lugar la moneda era metálica, no existía la moneda diduciaria, no había títulos de créditos que pudieran facilitar el crecimiento de la actividad económica sin medios monetarios para las inversiones, no existía una función bancaria que pudiera cooperar al proceso inflacionista y no existía la tensión por los aumentos salariales que hoy –no siempre con razón– son reputados responsables de la crisis. Los emperadores controlaban la acuñación de monedas de oro y plata, por lo que estaban sometidos a la constante tentación de acrecentar sus recursos devaluando la moneda mediante su depreciación reduciendo el peso o disminuyendo la cantidad del metal precioso con ley.

Augusto había estabilizado la relación entre el *aureus* de oro, acuñado desde tiempos de Julio César y el más viejo *denarius* de plata, en 25:1, lo que representaba una razón oro-plata de 12:1 aproximadamente²⁹. Por su parte, Plinio nos cuenta (N. H. XXXIII, 47) que Nerón redujo el *aureus* de 1/40 a 1/45 y el *denarius* de 1/84 a 1/96. En tiempos de Trajano un denario contenía un poco más del 90 por ciento de plata. Bajo el gobierno de Marco Aurelio el porcentaje de plata frente a los metales de baja ley cayó por debajo del 75% en un momento en que la guerra y la enfermedad hacían estragos en el Imperio. Septimio Severo redujo el contenido de plata del *denarius* al 50% con el resultado de ser rechazado por completo en Germania donde tesoros del siglo III revelan una crecida cantidad de oro³⁰. Todo ello demuestra que el método de depreciar el denario disminuyendo en proporción no relevante la cantidad de plata, sin reducir el peso, es muy importante para comprender las escasas reacciones de los poseedores de moneda, ya que era asaz difícil de establecer –sin ayuda de medios técnicos perfeccionados– cuál fuese el porcentaje de la quita³¹. Lo cierto es que la enérgica devaluación severiana determinó que el denario romano fuese poco aceptado más allá de las fronteras del Imperio. Esta rebaja de la moneda en circulación fue equivalente a una inflación de la plata con respecto al oro. Hubo una repentina subida de los precios y cuando las legiones protestaron contra la paga en dinero de aleación más baja, tuvieron éxito al conseguir un aumento de sueldo. Pero, al parecer, consiguieron más que eso. Porque es en el reinado de Septimio Severo en el que debemos buscar los comienzos del sistema según el cual se pagaba al ejército y a la administración civil, para sus necesidades básicas, no en moneda, sino en especie³². Por medio de una orden especial, que llegó a ser cada vez más frecuente, se dieron instrucciones a las provincias por las que iban a pasar las legiones, para que suministraran sus provisiones, y este impuesto fue conocido como la *annona militaris*. Aparecen testimonios de la existencia de este tributo –que representó el primer intento regular de establecer una organización per-

28 *Ibid.*, p. 359-360.

29 PASSERINI, A., *Linee di storia romana in età imperiale* (Milán, 1940) p. 210 ss.

30 BIRLEY, A. R., “The economics effects of Roman frontier policy”, en *The Roman West in the Third Century*, King-Henig (eds.) (Oxford, 1981) p. 39 ss.

31 R. HERZOG informa que los *nummularii*, al igual que sus predecesores del mundo oriental y griego, para calibrar la genuinidad de la moneda se servían sólo de medios físicos: la vista, el tacto, el olfato y el oído (cfr. s. v. *nummularii*, en RE (17) p. 1416.

32 BIRLEY, A. R., “Septimius Severus and the Roman Army”, en *Epigraphische Studien* 8 (1969) p. 63-82.

manente para pagar al ejército- en Egipto a finales del siglo II, y se recaudó regularmente a lo largo del siglo III. Un edicto anual definía su alcance para el año siguiente. Este sistema tenía alguna ventaja para el ejército y la burocracia durante los períodos de inflación del siglo III, porque les permitía evitar el pago con moneda devaluada³³.

El punto culminante de la depreciación gradual de la valuta de plata y de la desaparición del oro del mercado fue el reinado de Caracalla quien substituyó el *denarius* por el *antoninianus*. El *antoninianus* era una moneda más pesada que el *denarius*, esto es, en torno a los cinco gramos y contenía una cantidad de plata del 46%, doble que la del denario por lo que verosíblemente equivalía a dos denarios. Es difícil sustraerse a la consideración de que la nueva moneda fue introducida debido a que la vieja estaba perdiendo su crédito. Con todo, esta moneda no duró mucho y desde el 219 el *antoninianus* no va a ser acuñado más veces en Roma³⁴. A partir de ese momento, el poder adquisitivo de la moneda imperial descendió sin tregua con lo que crecieron desmesuradamente los artículos de primera necesidad. En efecto, tras la fuerte devaluación de Galieno, los precios aumentan el 800%. Las investigaciones de Callu nos han proporcionado una masa imponente de datos, que permiten seguir las vicisitudes monetarias emperador tras emperador y lugar por lugar³⁵. La conclusión es obligada. Desde Marco Aurelio en adelante, se inicia un proceso de devaluación monetaria que con la crisis se descontrola y se transforma en una catástrofe: la moneda de plata se va a convertir en un pedazo de cobre plateado, con una cantidad irrisoria de plata, provocando la salida de circulación de la vieja de mayor valor³⁶.

Con Aureliano se impone un enérgico intento de restauración dada su preocupación por la legitimidad de las monedas en circulación. En la Galia, especialmente, las monedas de pago de los veinte años anteriores habían sido acuñadas por un régimen oficialmente ilegítimo, y en Egipto, a principios de la década de 260, un gobernador se vio obligado a ordenar a los banqueros que aceptaran monedas con la imagen de algún emperador, algo a lo que aquellos se mostraban muy reacios, porque las imágenes eran las de dos usurpadores³⁷. Por esos mismos años, en Hispania se observa la desaparición progresiva de la circulación

33 Sobre la *annona militaris*, vid.: BERCHEN, D. van., "L'Annone militaire", en MSAF LXXX (1937) p. 117-202; JONES, A. H. M., *The Later Roman Empire : a Social, Economic and Administrative Survey* (Oxford, 1964), 4 vols.; el problema específico de la *annona militaris* se examina en el vol. 2, p. 1025-1068.

34 E. lo CASCIO, "Del Antoninianus al 'laureato grande', l'evoluzione monetaria del III secolo alla luce de la nuova documentazione di età diocleziana", en *Opus* 3 (1984) p. 133-201.

35 CALLU, J. P., "La circulation monétaire de 313 à 318", en *Actes du 8ème Congrès International de Numismatique* (Paris-Bale, 1976) p. 227-242, 1D., *Les dévaluations à Rome* (Roma, 1978) p. 107-121.

36 A este respecto, señala ROSTOVTEFF que no es de extrañar que, en tales condiciones, un de los caracteres más acusados de la vida económica de este período fuera la más desenfadada especulación, especialmente con los cambios. Los especuladores acaparaban el dinero saneado, pagando una considerable demasía por el cambio. En el 260 d. C. durante el breve reinado de Mariano y Quieto, la extraordinaria depreciación de la moneda provocó en Oxyrhynchus una huelga de los bancos de cambio que cerraron sus puertas y se negaron a aceptar y cambiar la moneda imperial. Es de observar que en muchos contratos de este mismo período no se menciona la moneda de vellón imperial en curso, sino la antigua moneda de plata ptolemaica, de la cual había seguramente ocultas grandes cantidades en Egipto (Cfr. *Historia social y económica*, cit., II, p. 387-388).

37 POTTER, *Constantino El Grande* (Barcelona, 2013) p. 44, con bibliografía en nt. 8.

predominante del sestercio, desplazado poco a poco por la moneda de vellón³⁸. Con todo, la situación monetaria de Hispania es parecida en líneas generales a la del resto del Imperio³⁹.

Uno de los problemas más confusos de la vida y hechos de Aureliano⁴⁰, es la llamada reforma monetaria⁴¹. Y es que, durante su reinado, el sistema monetario romano se encontraba muy desestructurado y la moneda ofrecía muy poca confianza al usuario que en pocos años había visto como estaban cada vez más devaluadas y presentaban un aspecto muy poco cuidado⁴². Ante esta situación, el emperador se propuso restaurar el sistema monetario. Mejoró sensiblemente la calidad de la moneda creando el *aurelianus*, que contenía un 5% de plata⁴³, pero no consiguió sanear el sistema monetario, porque no acuñó la suficiente cantidad, pese a que Zósimo –única fuente que menciona el *aurelianus*– afirma que se trataba de una nueva moneda destinada a sustituir a la falsa y hacer seguros los cambios⁴⁴. Así las cosas, las acuñaciones fraudulentas siguieron teniendo un fuerte impacto en la masa monetaria, ya de por sí bastante deteriorada, ya que la inundaron en cantidades importantes y se difundieron a lo largo y ancho del Imperio⁴⁵. Se puede asegurar que la moneda mala no fue retirada de la circulación, pues aún las falsificaciones de época son notorias en los hallazgos de estos años. De lo expuesto anteriormente hay que deducir que Aureliano intentó mejorar el sistema monetario existente y nunca renovarlo. A modo de conclusión sobre este punto, cumple señalar que sólo se ve en todo el proceso un intento de mejora del numerario, para dar confianza al usuario romano especialmente, pero ninguna de las características de una verdadera “reforma” monetaria. Como bien dice Mattingly⁴⁶, la supuesta reforma de Aure-

38 FARIÑA, F., “Notas sobre la circulación monetaria a mediados del siglo III después de Cristo en el noroeste peninsular”, en *Congreso Arqueológico Nacional –en lo sucesivo CAN-* 12, p. 747 ss.

39 CALLU, J. P., *La politique monétaire des empereurs romains de 238 a 311* (París, 1969) ; 1D., “Approches numismatiques de l’histoire du III^e siècle (238-311) », en *Aufstieg* II/2 p. 594 ss. ; CRAWFORD, M., “Finance, Coinage and Money from the Severians to Constantine”, en *ibid.*, p. 560 ss..

40 El estudio histórico de la figura de Aureliano se basa como principal fuente en la *Historia Augusta*, *Divus Aurelianus*, atribuido a Flavio Popisco de Siracusa. Sin embargo, los documentos que contiene la *Vita* han sido rechazados en general por la crítica moderna, al menos en cuanto a su época de redacción (sobre esta cuestión cfr. la nt. 21 de este trabajo). La segunda fuente es la de Zósimo que escribió en el siglo IV su *Nueva Historia* basándose para el reinado de Aureliano en los relatos de Dexipo y Eunapio. Entre los autores latinos conviene citar a Aurelio Victor en *Los Césares* y las referencias puntuales de Orosio y Eusebio

41 En punto a esta cuestión vid., por todos, GUADÁN, A. M., “Algunas cuestiones sobre la reforma monetaria de Diocleciano”, en *Anejos de Gerión* I (Madrid, 1988) p. 307 ss.

42 RIPOLLÉS, P. P., “La circulación monetaria en la ciudad de Valentia durante la época imperial”, en *La ciudad de Valencia*, coord. por J. Hermosilla Pla, vol. I (Valencia, 2009) p. III.

43 El *aurelianus* llevaba diversas marcas monetarias en los exergos o en el campo de los reversos, como son las de XX o bien XXI y su equivalente griego en KA. Para DE MARTINO, dichos símbolos bien pueden hacer referencia al valor de la moneda: XXI=1/21; XX=1/20, esto es veinte partes de bronce por una de plata (cfr. *Storia económica*, cit., II, p. 380). En opinión de GUADÁN, loc. cit. en nt. 41, “la interpretación de estas marcas es precisamente la base que nos puede proporcionar el sentido oculto de la reforma”.

44 Zósimo, I, 61, 3. Con todo, estas citas literarias tan tardías y de segunda o tercera mano, hay que tomarlas con toda clase de precauciones, ya que su efectiva fuente se desconoce y el valor de todo comentario es directamente proporcional al valor de su fuente histórica.

45 No hay ningún hallazgo del período de Aureliano o posteriores que no tenga una gran cantidad de ejemplares de Gallieno, las peores monedas en todo caso del conjunto (cfr. GUADÁN, A. M., “Algunas cuestiones”, cit., p. 314, nt. 21).

46 MATTINGLY, H., *Roman Coins, from the earliest times to the fall of the Western Empire* (Londres, 1960) p. 186-187.

liano, no fue sin embargo, un completo fracaso; al menos sirvió para marcar el camino hacia la ulterior y profunda reforma diocleciana. No cabe duda de que Aureliano había intentado abordar un auténtico problema mas, al no solucionarlo, el resultado fue el desplome de la divisa imperial, la inflación galopante y la destrucción de las reservas acumuladas por todo el Imperio. Así se vino abajo un sistema monetario que había permanecido razonablemente estable durante siglos y los esfuerzos por restaurar la confianza en dicho sistema serían una constante fuente de tensión a lo largo de los siglos siguientes.

Unos veinte años después de que Aureliano reformase la moneda de vellón y restituyera la calidad de las emisiones de oro, Diocleciano volvió a reformar el sistema monetario en un proceso que se extendió desde 293 a 298⁴⁷. Estabilizó el peso del oro e introdujo el *argenteus*, de plata pura; eran monedas fuertes que trataban de restituir la confianza del público⁴⁸. Tenemos indicios de la reforma en las monedas del período, troqueladas conforme a un modelo nuevo y mucho más pesado, y en una inscripción procedente de Afrodísias –Turquía occidental-. Esta comprendía un edicto y una carta explicativa que tenía por destinatario al gobernador local. La información que nos transmite señala, en suma, que había que asignar a las monedas imperiales un valor doble del nominal⁴⁹. También puso en circulación calderilla de metal vil, en este caso vellón, cuyo valor intrínseco dependía de la plata que contenía. Con ello queda patente que la reforma diocleciana constituye la primera tentativa orgánica de restaurar la moneda, pero no referida a todo el dinero circulante, sino sólo al oro y la plata, dejando sobrevivir una gran masa de monedas –*folles, radiati o denarii*– cuyo valor intrínseco era inferior al nominal.

Para asegurar su distribución uniforme, Diocleciano creó un nuevo sistema de cecas repartidas por todo el Imperio que, tras diversos cambios se estabilizaron en quince ciudades ubicadas estratégicamente en grandes puertos marítimos o fluviales. Con todo, la *Diocesis Hispaniarum* no tuvo ceca de producción de moneda en ningún momento del siglo IV. Hecho significativo y de consecuencias históricas importantes⁵⁰. Naturalmente, esto no quiere decir que la moneda no circulara en la diócesis y a veces abundantemente⁵¹. El poder

47 Sobre la reforma monetaria diocleciana, vid, entre otros, HARL, K. W., *Coinage in the Roman Economy 300 BC to AD 700*, John Hopkins University (Maryland, 1996); ERIM-REYNOLDS-CRAWFORD, “Diocletian’s Currency Reform. A New Inscription”, en JRS 61 (1971) p. 171 ss.

48 Cfr. HARL, K. W., “Marks of value on tetrarci nummi and Diocletian’s monetari policy”, en *The Phoenix* (1985) p. 263-270.

49 Esta inscripción ha sido publicada por C. ROUCHÉ, *Aphrodisias in Late antiquity* (Londres, 1989) nt. 230.

50 M. HENDY [“Mint, Fiscal Administration under Diocletian, his colleagues and his sucesors”, en JRS 62 (1972) p. 81] ha puesto de relieve este detalle, y ha concluido que la producción de moneda en el siglo IV no era arbitraria o hecha al azar y que quizá sólo en un segundo plano tenía miras propagandísticas. La producción estaba relacionada o bien con el sistema de administración fiscal o bien con la importancia de un establecimiento militar en una región determinada y que sólo en tercer lugar venía determinada por razones políticas. Según estos criterios, Hendy observa que la diócesis de África o la Viennense (en Galia) únicamente tuvieron ceca muy esporádicamente y España nunca la tuvo. La razón era simplemente porque la Península no tenía un fuerte contingente de tropas.

51 Hispania se nutría del numerario por otras cecas, frecuentemente las cercanas de la Galia –Lyón y Arlés– aunque también en ocasiones de las cecas orientales. Al existir un reducido ejército en Hispania, el bronce es el metal más circulante para atender a necesidades que podíamos determinar “civiles” y su misión es fundamentalmente la de intercambio comercial (cfr. CALLU, J. P. “Role et distribution des espèces de bronze de 384 à 392”, en *Imperial Revenue*, p. 41 ss.). Los especímenes de plata y oro constituían el elemento principal para el *donativum* al ejército.

adquisitivo de cada moneda estaba determinado por su valor en la unidad de cuenta, el llamado “denario común”. Mientras que tanto el oro como la plata se ajustaban a su valor intrínseco, las piezas de vellón estaban muy sobrevaloradas, lo que fue la perdición del sistema. Tal como explica el economista austríaco Von Hayek en unas reflexiones sobre la ley de Gresham, la moneda mala sólo expulsa a la buena si existe un precio mínimo para aquella y uno máximo para ésta. En cualquier otro caso la gente opta por la buena⁵². Debido a ello, desde sus inicios el vellón de Diocleciano estuvo condenado a no ser aceptado al cambio oficial, y a devaluarse en relación a las monedas buenas, que se atesoraron de forma masiva mientras el *nummus* copaba el mercado, empleándose en toda clase de transacciones y no sólo en las menudas⁵³. Y ante la disyuntiva de pagar con oro y plata puros que conservaban o incrementaban su valor, la elección era obvia. Ni el carácter sagrado de la moneda⁵⁴, ni las draconianas medidas represivas lograron salvar la situación. Así, por chocante que pueda resultar, el resultado fue una carestía estructural de dinero: al dominar la moneda mala todos los intercambios⁵⁵, la gente común no tenía suficiente como para realizar las transacciones diarias, haciendo necesaria la emisión de cantidades incluso mayores, carencia que se alió con la codicia fiscal del Estado⁵⁶. En suma, la reforma de Diocleciano tuvo muy buenas intenciones, pero no consiguió el propósito de sanear el sistema monetario.

Como dice A. D'ORS⁵⁷ “el acontecimiento más importante del siglo IV, que dominó la historia de ese siglo y aún de los que le siguieron, fue la aparición del *solidus* de Constantino, esto es, la difusión de la moneda de oro por todo el ámbito del Imperio Romano”. Merced a esta medida, fundamentalmente, el siglo IV va a ser una época de progreso general en términos macroeconómicos. El juicio negativo de algunos historiadores se debe a que está inserto entre dos períodos dramáticos y porque la influencia de la política religiosa y de las fuentes cristianas favoreció una interpretación negativa de la realidad económica⁵⁸. Este

52 HAYEK, F. A., von., *Choice of Currency: A Way to Stop Inflation* (Londres, 1976) p. 18-19. La formulación correcta de la ley de Gresham es, por tanto, “la moneda mala expulsa a la buena si sus tipos de cambio están fijados por ley”.

53 DEPEYROT, G., *Crisis e inflación entre la Antigüedad y la Edad Media* (Barcelona, 1996) p. 211.

54 Podemos apreciarlo en los reversos con figura entrante de la diosa Juno Moneta sosteniendo una balanza y una cornucopia, acompañada por la leyenda SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR, es decir, “la sagrada moneda de nuestros augustos y césares”. De tal modo, atentar contra la moneda constituía no sólo un crimen de lesa majestad, sino un sacrilegio.

55 Es relativamente frecuente en S. Juan Crisóstomo que se haga mención de monedas falsas o de problemas relacionados con el tema. “Si alguien recibe unos pocos denarios los mete en un arca y la cierra bien” (*In Mt.*, V, 1=PG, 57, 55); “pescó el señor un gran pez. Y lo mismo que sucedió en el pez que capturó Pedro, por orden del señor, aconteció también en éste También este pez tenía una moneda en la boca; moneda, cierto, pero adulterina” (*De mut. nom.* 1, 3=PG 51, 117). En sentido real alude, en ocasiones, a la explotación que se hacía de las monedas para ver si eran buenas o falsas (*In princ. Act.*, 4, 2=PG 51, 99, *In Is.*, 1, 7=PG 56, 23; *In Gal.* 1, 6=PG 61, 622). Una amplia visión del pensamiento socioeconómico de este padre de la Iglesia en GONZÁLEZ BLÁNCO, A., *Economía y sociedad en el Bajo Imperio según San Juan Crisóstomo* (Madrid, 1980).

56 K. W. HARL, *Coinage*, cit., p. 155, cree que la emisión de cantidades excesivas de moneda se debió a la imposibilidad del gobierno de reemplazar con eficacia todo el numerario del Imperio.

57 D'ORS, A., “Un arbitrista del siglo IV y la decadencia del Imperio Romano”, en *Cuadernos de la Fundación Pastor* 7 (Madrid, 1963) p. 41-69.

58 BERNARDI, A., “Los problemas económicos del Imperio Romano en la época de su decadencia”, en C. M. Cipolla y otros, *La decadencia económica del Imperio* (Madrid, 1973) p. 27 ss.

progreso se va a apoyar en una moneda fuerte –el *solidus aureus*– implantada por Constantino y que pondría fin a la confusión monetaria del siglo III. El *solidus* pesaba 1/72 de libra y permaneció estable –salvo pocas excepciones– hasta la época bizantina. De hecho, se mantenía prácticamente sin cambios en el año 1070, cuando empezaron a aparecer muestras degradadas de esta moneda⁵⁹. Además, se divulgan entonces técnicas de producción más racionales, se repueblan ciudades y se realiza una auténtica actividad constructora por lo que –y aquí seguimos a A. H. M. Jones⁶⁰–, la crisis del siglo III se palió en gran medida merced a las medidas enérgicas de la dinastía Iliria.

Mientras tanto, el bronce o el bronce plateado seguía disminuyendo de valor, quizá porque el gobierno –preocupado sólo con su propia ventaja fiscal– continuaba acuñando cada vez más, mientras insistía en que se pagaran los impuestos únicamente en oro o *in natura*. La tendencia general fue que el aumento de precios en relación con la moneda devaluada se hace vertiginosamente. Mientras, en el 310 los precios se duplican y veinte años después se triplican. Pero tras esta época y en particular después del 338, a juzgar de los documentos provenientes de Egipto, el aumento de los precios en relación con la moneda de baja aleación deviene en desaforado⁶¹. Para el ejército y los empleados públicos había repartos públicos de productos de primera necesidad, complementados con sueldos en la moneda de bronce devaluada, que servían para la compra de menudencias adicionales en el mercado libre. Al mismo tiempo, los ricos disfrutaban de las ventajas de una buena moneda de oro con la que podían comprar toda clase de artículos de lujo del mundo conocido. De ahí que el anónimo autor de *De rebus bellicis*⁶² le atribuya a Constantino –con duras palabras– el haber sustituido en el *commercium* la moneda de oro por la de cobre provocando así la ruina de la *afflicta pauperitas* y las revueltas que siguieron⁶³. Sobre la base de este texto, Mazzarino⁶⁴ ha construido la teoría de que las reformas de Diocleciano y Constantino tuvieron un significado político y social diverso: el primero habría proseguido la política tradicional del Principado, consistente en la defensa del denario como moneda de cambio de la gente humilde. El segundo habría por su parte realizado una auténtica revolución económica, abandonando la defensa del *denarius* anclando la moneda al oro, con la consiguiente ruina de la gente humilde, cuya moneda era la de cobre y el absoluto predominio de los poseedores de oro, esto es, de los *beati possidentes*. Y es que mientras los precios en oro no registraban sensibles aumentos, los precios en denarios sufrieron veloces y fuertes subidas.

59 WALBANK, F. W., *La pavorosa revolución*, cit., p. 104.

60 JONES, A. H. M., *The Later Roman Empire 284-602. A social Economic and Administrative Survey II* (Oxford, 1964) p. 1025-1068.

61 Vid., en este sentido, BOLIN, S., *State and Currency in the Roman Empire* (Estocolmo, 1958).

62 Sobre el *Anonymus de rebus creditis*, vid.: SEECK, O., s.v., en RE 1, p. 2325. Acerca de Seeck, cfr. GONZÁLEZ BLANCO, A., “Evocando a Otto Seeck”, en *Studia Historica. Historia Antigua* 6 (1988).

63 A. D’ORS, comentando este texto dice. “Cuando el oro fue lanzado a la calle sirvió de estímulo para la avaricia; los ricos atesoraron oro y los pobres se vieron hundidos en la miseria, pues sus monedas de cobre no valían nada. La *afflicta pauperitas*, como dice nuestro autor, ... No es sorprendente que, irritada por la injusticia, esa miseria haya explotado en conatos tiránicos como los que el emperador para gloria suya hubo de sofocar” (Cfr. loc. cit. en nt. 57, p. 63).

64 MAZZARINO, S., “Precetti del buon Governo (Principio Gubernatione Rei P.) e problema di economia militare”, en *Bonner Historia-Augusta Colloquium*, 1971 (Bonn, 1974) p. 103-112.

IV

La conquista del sur y el centro de España en el siglo II a. D. puso a disposición de Roma cantidades sin precedentes de cobre, plata y oro, y favoreció la propagación de la acuñación y la monetización dentro del Imperio. Este proceso se vio acelerado en tiempo de Augusto con la explotación hidráulica de las minas de *Gallaecia* y las guerras dacias de Trajano proporcionaron importantes fuentes de plata y oro⁶⁵.

Las fuentes posteriores a Plinio –quien, como es sabido, murió con ocasión de la erupción del Vesubio en el 79– dejaron de interesarse por la Península, pues los datos sobre las explotaciones mineras en el siglo II son escasos. Esta parquedad de constancias textuales constituye lógico corolario, en cierto modo, de una ralentización del ritmo de laboreo. Las causas han sido señaladas con precisión: disminución de la masa de esclavos que, al decir de Rostovtezz⁶⁶, constituían “la columna vertebral de la economía”, el progresivo agotamiento de los yacimientos auríferos⁶⁷, la obtención de metales estratégicos en los países septentrionales⁶⁸ y, muy especialmente, la conquista por Trajano de Dacia, provincia donde abundaba el oro⁶⁹. Empero, a lo largo del siglo II el rendimiento de las explotaciones auríferas puede calificarse de aceptable⁷⁰; en realidad, el cese de las extracciones, de acuerdo con Domergue⁷¹, cabe situarlo cronológicamente durante la dinastía de los Severos, coincidiendo con la crisis generalizada que asoló al imperio. Jones-Bird llegan a la misma conclusión: no hay laboreo en las minas más allá del año doscientos⁷².

Como apunta Arce⁷³, el *argumentum ex silentio* está revestido, en este caso, de gran valor. Es difícil imaginar que una explotación aurífera –con la necesidad constante que de ese metal se tiene en los siglos III y IV⁷⁴– no haya dejado ninguna referencia en los textos

65 Sobre este punto, vid. RODRÍGUEZ ENNES, L., “Las explotaciones mineras y la romanización de Galicia”, en *Estudios de Derecho Romano en memoria de Benito M^o Reimundo Yanes II* (Burgos, 2000) p. 305-327.

66 ROSTOVTEZZ, M., Historia social y económica del Imperio romano, cit., 1, p. 195.

67 HERTEL, T., dice al respecto: “Mining is probably declining somewhat by the second century, owing to partial exhaustions of the veins of gold” (Cfr. *Cambridge Ancient History* 12, p. 243).

68 Para A., BALIL, el incremento en la explotación, en la segunda mitad del siglo III de las minas de plomo y estaño en Britania, se interpreta por algunos autores como indicio seguro del cese del suministro hispano de este mineral, lo cual es posible, debido al estado de inseguridad y desorden producido por las invasiones de francos y alamanes en época de Galieno, que arrasaron prácticamente toda la Península Ibérica. [Cfr. “Hispania en los años 260 a 300 después de Jesucristo”, en *Emerita* 27, (1954), p. 269]. Esta tesis ya había sido defendida por RICHMOND, *Roman Britain*, (Londres, 1955) p.149 ss.

69 Empero, J., GUEY opina que el oro dacio se gastó muy pronto [Cfr. “De ‘l’or des daces” au livre de Stude Bolin”, en *Mélanges Carcopino*, (París, 1966) p. 455 y ss.].

70 BIRD, D. J., “The Roman Gold- Mines of North-West Spain”, en *BJ* 152, (1972), p. 36 y ss.

71 DOMERGUE, C., *Les explotations auríferes du Nord-Ouest de la Peninsule*, cit., p. 174. En otro trabajo, señala como causas: la escasez de mano de obra y el agotamiento del mineral (*Introduction a l’estude de mines d’or*, cit., p. 79 y ss.).

72 JONES-BIRD, “Roman Gold-Mining”, en *JRS* 62, 1972, pp. 62-74; EDMONSON, J. C., “Mining in the Later Roman Empire and beyond”, en *ibid.* (1989) p. 88-91.

73 ARCE, J., *El último siglo de la España romana*: 284-409, (Madrid, 1982) p. 124.

74 La política monetaria de Constantino y sus sucesores de crear una moneda fuerte de oro -el *solidus aureus*- no se concibe sin disponer de unas buenas explotaciones auríferas [Cfr. CRAWFORD, M., “Le problème des liquidités dans l’Antiquité classique”, en *Annales* 26, (1971) p. 1228]. MROZEK, S., es harto expresivo al respecto cuando afirma: «Jamais, dans l’histoire de l’Antiquité, aucun système monétaire n’a été nourri par une

literarios o jurídicos. Por lo que hace a los vestigios arqueológicos, tanto las excavaciones como los estudios de campo son igualmente elocuentes en punto al cese de la actividad minera⁷⁵. El propio Domergue observa ya este hecho y recuerda la existencia señalada en la *Notitia dignitatum* de un *Comes metallorum per Illyricum*, así como de sus homólogos de otras regiones del Imperio: Dacia, Macedonia, Mesia, pero ninguno de la *Diocesis Hispaniarum*⁷⁶. Estos datos empíricos permiten dejar en sus justos términos la mención a las famosas minas de oro del Noroeste que –a finales del siglo IV– efectúa el Retor Licinio Pacato, en el panegírico a Teodosio: *aurum quod de montium venis aut fluminum glareis (...) scrutator gallaicus eruisset*⁷⁷. En este mismo contexto, la afirmación del poeta Claudiano de que los centros mineros auríferos de nuestro suelo siguieron perviviendo no puede, en modo alguno, constituir prueba de su laboreo, ya que la obra *–Laus serenae–* está escrita en una época –hacia el año 404– en la que la explotación de las minas de oro galaicas no era más que un mero recuerdo histórico. Se trata –creo– de una licencia poética que el vate bajoimperial exorna con parejos vocablos y tópicos literarios a los empleados por su antecesor Silio Itálico⁷⁸ e, incluso, por escritores mucho más antiguos como Plinio⁷⁹.

No se comprende bien cómo un historiador como C. R. Whittaker ha podido hablar de la recuperación de las minas de *Gallaecia* y Lusitania en el siglo IV con la ligereza de utilizar como apoyo los versos de Claudiano, *Laus Serenae*, 54, 5 [*Gallaecia: pretiosa metallis, principibus fecunda piis*] [Cfr. C. R. WHITTAKER, “Inflation and Economy in the Fourth Century A. D.”, en *Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century A. D.*, BAR Suppl. Series 76 (1980) p. 5 y 7. De estos versos ningún historiador de la economía puede concluir absolutamente nada. En todo caso, la última palabra está en manos de los arqueólogos y de sus trabajos de campo. Y en este terreno, lo poco que sabemos apunta al agotamiento o abandono de las minas en el siglo IV [DOMERGUE, C., *Minas de oro romanas en la provincia de León* (Madrid, 1977) p. 93-94].

Algunos autores han tratado de confirmar la explotación de las minas del N.O. peninsular basándose en la cierta abundancia de miliarios de emperadores de la Anarquía militar y el Bajo Imperio⁸⁰, hecho éste que constituiría –según ellos– claro indicio de que las vías de la zona minera habían sido arregladas para facilitar el transporte del mineral⁸¹. Con razón

masse de monnaie si grande. Même le plus pauvre avait accès à la circulation monétaire. Car dans l’empire romain la monnaie avait atteint un domaine qui dépassait celui des besoins de l’armée et de la fiscalité. Le commerce extérieur pour une grande partie devait être soutenu par la monnaie ainsi que le vie économique des villes». (Cfr. “Le travail des hommes libres dans les mines romaines”, en *La Minería*, 2, p. 163).

75 Bien claros son LEWIS-JONES al afirmar: “Las Médulas it was never re-worked after the end of Roman activity” (“Roman Gold-Mining in North-West Spain”, cit., p. 171).

76 DOMERGUE-HERAIL, *Mines d’or romaines d’Espagne*, (Toulouse, 1978) p. 14.

77 Pacat, *Pan.* 28, 2.

78 Sil. Ital., *Pun.* 1, 231-233.

79 Plin. *N.H.* 33, 76-78.

80 Vid., entre otros, CAAMAÑO, GESTO, J. M., “Los miliarios del alto de la Cerdeira (Puebla de Trives)”, en *CEG* 28, (1973) p. 212 y ss.; Id., “Aportaciones a los miliarios del tramo orensano de la vía XVIII”, en *Bol. Aur.* 6, (1976) p. 121 y ss.

81 VAN NOSTRAND, R., *An Economic Survey of Ancient Rome* 3, (1959) p. 126 e ss. Participa de esta opinión Blázquez cuando dice que “la concentración de miliarios en el Noroeste en unas cuantas explotaciones y alrededor de *Bracara Augusta* obedece a las explotaciones mineras probablemente”. (Cfr. *Fuentes literarias referentes a minas*, cit., p. 146).

ha señalado D'Ors, que estos miliarios –las más de las veces– pueden ser honoríficos⁸². En nuestra opinión, aquellos que interrelacionan la concentración de miliarios en el N.O. con la persistencia de las explotaciones auríferas quizás no reparan en el valor primordialmente propagandístico que encierran estos hitos viarios. Su presencia puede obedecer a simples motivaciones políticas cual es el caso de emperadores como Magencio y Decencio de, como es sabido, efimeros gobiernos y que –parece– consiguieron el apoyo de *Gallaecia* en su usurpación⁸³. En conclusión, cabe afirmar con Arce que el argumento de los miliarios es débil y no ayuda nada al conocimiento real de las explotaciones mineras en el periodo tardoimperial⁸⁴. Dado, pues, el estado actual de nuestros conocimientos debemos colegir que el laboreo de las minas galaicas había cesado hacia el siglo III.

V

El gran aumento de los gastos provocado por la ambiciosa política reformista de Diocleciano⁸⁵ va a coincidir con la disminución de las rentas: el abandono de los campos –que castiga sobre todo a los propietarios ausentes– alcanza los bienes del emperador; la regresión económica disminuye el rendimiento de los impuestos sobre la circulación de las riquezas⁸⁶. Los problemas de los campos y de las ciudades perjudican el pago de la recaudación regular de los impuestos en efectivo y en tarifas fijas; el Estado es víctima del alza de precios y recurre a la alteración de la moneda –por la disminución de su peso o la reducción de su título– más sensible de sobreestimación. Pero muy pronto el aumento del

82 D'Ors, A., *Epigrafía jurídica de la España romana*, cit., p. 71.

83 Vid. la nt. 80.

84 Lo mismo cabe decir de los tesorillos encontrados en *Gallaecia* durante los siglos postreros del Imperio que, en opinión de algunos, constituyen base suficiente para sustentar la pervivencia del laboreo en los yacimientos auríferos. No creemos que ello deba erigirse en argumento decisivo. Para Arce, ciertamente la presencia de monedas en sí misma no es un argumento que demuestre “producción a buen ritmo”. Su hallazgo en algunos poblados mineros puede deberse a asentamientos posteriores, a la realización de estructuras de habitación. Pero no dice nada de explotación verdadera (Cfr. *El último siglo de la España romana*, cit., p. 123). Estimamos que deben traerse a colación, por lo ilustrativas que resultan las siguientes palabras de N. Santos: “En este contexto creemos que es en el que debe situarse la creación y pronta desaparición de la provincia *Hispania Nova Citerior Antoniniana* por parte del emperador Caracalla, quien buscaría como objetivo prioritario y casi único el revitalizar las explotaciones auríferas del N.O. por medio de la presencia de una organización administrativa más compleja y a través de un control más directo sobre los diferentes distritos mineros en explotación. Sin embargo, puesto que los resultados no serían plenamente satisfactorios y la reactivación de las explotaciones tampoco generaría una rentabilidad apropiada, este último intento por intensificar la producción en los centros mineros resultaría vano, dándose paso a renglón seguido a un debilitamiento en las explotaciones y, en consecuencia, a la desaparición inmediatamente después de la nueva división administrativa” (Cfr. *El ejército y la romanización de Galicia*, cit., p. 93).

85 Uno de los elementos más determinante del aumento de las partidas presupuestarias lo constituye el sostenimiento del ejército ante las incursiones bárbaras [Cfr. MALAVÉ OSUNA, B., “La administración financiera en el Bajo Imperio”, en RGDR 8 (2007) p. 7 ss.]. Otro capítulo de gastos igualmente importante fue la burocracia con aproximadamente doscientos mil funcionarios encargados de los varios servicios de la administración imperial [vid., en este sentido, MUÑOZ COELLO, *La finanzas públicas del Estado romano en el Alto Imperio* (Madrid, 1990)].

86 JONES, A. H. M., “Obertaxation and the decline of the Roman Empire”, en *Antiquity* 33 (1959) p. 39-43.

volumen de la moneda circulante⁸⁷, añadida a los restantes factores en alza⁸⁸, precipita la inflación. Las antiguas emisiones de mayor calidad, la plata sin acuñar, el oro –cuyo valor oficial en relación con la plata se deprecia– desaparecen en los tesoros particulares. Para sacar la moneda buena de sus escondrijos, el Estado aplicó una legislación draconiana y premió a los cambistas, incentivándolos para comprar monedas de oro y vendérselas al Estado –*solidorum venditio*–⁸⁹.

Las pruebas comparadas sugerían que transcurría aproximadamente un mes antes que los comerciantes se percataran de que las nuevas monedas eran aún peores que las viejas y subieron los precios, así que cada desvalorización no concedía a los apurados emperadores más que un leve respiro. A largo plazo, una desvalorización seguida de una fijación de precios no constituía una solución porque los comerciantes se limitaban simplemente a retirar sus artículos de los anaqueles y a distribuir su mercancía en el mercado negro y a un plazo aún mayor; el único remedio era extraer una mayor riqueza del Impero –del producto imperial bruto– por vía impositiva. Esto había venido provocado también por los peores momentos de la crisis del siglo III, ya que los emperadores, en períodos de tensión concretos podían exigir impuestos extraordinarios en forma de alimentos. Ello evitaba los problemas de la acuñación pero, debido a su carácter impredecible, resultaba muy impopular. Por último, en la época de Diocleciano, se sistematizó plenamente un nuevo impuesto periódico que gravaba la producción económica y al que ya hemos hecho referencia: la *annona militaris*⁹⁰.

Las más modernas investigaciones sugieren que, a pesar de las devaluaciones de los primeros años del siglo III, la gran inflación comenzó realmente tras la muerte de Alejandro Severo en 235 y fue más aguda de lo que se suponía, en torno a una media del 8,6-8,8% anual, llegando a su culmen con Diocleciano y su Edicto de Precios, al exceder el 100% en el último trimestre de 301⁹¹. En esta fecha, el emperador intenta acabar con la escalada de precios que él mismo había provocado mediante el expeditivo método de ilegalizarla. En diversos anales encontramos, para el año 302, esta noticia: “Entonces

87 El ínfimo valor de la moneda de cobre debió hacer prohibitivo su traslado físico. En el siglo IV un único sólido áureo de 4,4 gramos equivalía a 7.600 *nummi*, los cuales pesaban nada menos que 11,4 kilogramos (cfr. DEPEYROT, G., *Crisis e inflación*, cit., p. 157-158]. Debido a su escaso valor, por tanto, debía ser muy engorroso transportar las enormes cantidades de monedas que se precisaban para las transacciones de relativa cuantía. Como apunta A. GONZÁLEZ GARCÍA: “con seguridad fue por ello que se introducían en cantidades determinadas en sacas selladas y garantizadas por el Estado, ahorrando el tener que contarlas y pesarlas una y otra vez, y de ahí que se les llamara *folles* (sing. *follis*, “bolsa de cuero”) [Cfr. “La inflación en el Imperio Romano de Diocleciano a Teodosio”, en *Documenta et Instrumenta* 9 (2011) p. 139].

88 “Las minas de oro y plata se agotan (...) la tierra es menos fértil, los productos del suelo disminuyen (...) el número de agricultores disminuye y faltan en los campos. Menos marineros en el mar, menos soldados en los campamentos” (Cfr. Cipriano, *Ad Dometrius*, 3, ss).

89 Símaco, *Epistulae*, IX, 49; Procopio, *Anecdota*, 25. Sobre la actividad bancaria tardoimperial, cfr. A. DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la Banca Bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)* (Murcia, 1987).

90 Sobre estas medidas, vid.: JONES, A. H. M., *The Later Roman Empire*, cit., p. 623-630.

91 Cfr. PRODOMÍDIS, P. I. K., “Another View on an Old Inflation: Environment and Policies in the Roman Empire up to Diocletian’s Price Edict”, en *Centre of Planning and Economic Research Discussion Papers* 85 (Atenas, 2006); WASSINK, A., “Inflation and Financial Policy Under the Roman Empire to the Price Edict of 301 AD”, en *Historia*, 40-4 (1991) p. 465-493; ROBLES VELASCO, L. M., “Notas sobre las crisis económicas en el Imperio Romano: entre la libre iniciativa y el intervencionismo”, en *RGDR* 12 (2009) p. 1 ss.

mandaron los emperadores que hubiera baratura⁹², es decir, que Diocleciano fijó precios topes a las subsistencias⁹³. Su edicto establecía un precio y un salario máximo legal para virtualmente todos los productos y ocupaciones. La seriedad con la que consideró el problema puede apreciarse por el hecho de que prescribiera la pena de muerte para todo el que violara sus disposiciones. El edicto fue un fracaso, Lactancio nos cuenta que subieron más los precios y que al fin hubo “gran efusión de sangre a causa de pequeños e insignificantes detalles”⁹⁴. Sin embargo, es evidente que de nada iba a servir tal seriedad cuando era la propia política monetaria imperial la que causaba el problema. Lactancio registró exactamente lo que pasó: a pesar de la represión, hubo una retirada masiva de bienes y aumento de precios aún mayor que condujo a la rescisión final del edicto⁹⁵ y es que, prescindiendo de la saña antidiocleciana de Lactancio⁹⁶, en la práctica el Edictum de Pretiis fue un acto de demencia económica. En lo más básico, el mandato hace caso omiso a la ley de la oferta y la demanda, la dependencia de los precios respecto a la disponibilidad de los bienes y el hecho de que el valor de éstos se veía también afectado por el coste del transporte. Tales circunstancias –unidas a su aplicación únicamente en Oriente⁹⁷– podrían significar que el mandato se revocó poco tiempo después de promulgarse, tras su estrepitoso fracaso. Lactancio asevera que “la ley se disolvió por necesidad de manera natural”⁹⁸. De toda la administración de Diocleciano, lo que más se le puede reprobar sea acaso la introducción de estos precios fijos, pero tampoco se podría desconocer por completo su buena intención⁹⁹. Teniéndolo todo en cuenta acaso sea su gobierno uno de los más eficaces y mejor intencionados que conoció el Imperio. Si se libera uno de las persecuciones de los cristianos y de las deformaciones y exageraciones de Lactancio, los rasgos de este emperador cobran una dimensión diferente.

92 BURCKHARD, J., *Economía y Sociedad*, cit., p. 60.

93 El emperador se expresa así en el preámbulo: “Los precios de las cosas que se compran en el mercado o que se traen cada día a las ciudades han sobrepasado todos los límites, de tal suerte que el afán desatado de ganancia no se atempera ni por las cosechas abundantes ni por el excedente de mercancías... El latrocinio merodea por todas partes a donde se trasladan nuestros ejércitos por exigencias del bien público, y no sólo en la aldeas y ciudades sino en todas las calzadas, de modo que los precios de las subsistencias e han cuadruplicado y hasta octuplicado sino que sobrepasan toda medida (...) Esta voracidad tiene que encontrar un tope en nuestra ley” [MOMMSEN, T., “Das Edict Diocletians de pretiis rerum venalium”, en *Bericht Sächs Gessells d. Wiss.* 3 (1851)].

94 Lactancio, *De mortibus persecutorum*, 7, 6-7.

95 Ibidem.

96 La hostilidad de Lactancio hacia Diocleciano raya en la paranoia: lo califica de “inventor de crímenes” y “creador de diablos” y de “subvertir el mundo con su avaricia” (cfr. Ibid. 7, 7 (1). Acerca de Lactancio, vid.: CHRISTENSEN, A. S., *Lactantius the Historian: An Analysis of the Mortibus Persecutorum* (Viborg, 1980).

97 Sobre la parca aplicación del edicto en Hispania, vid.: ARCE, J., “El ‘Edictum de pretiis’ y la ‘Diocesis Hispaniarum’”. Notas sobre la economía de la Península Ibérica en el Bajo Imperio Romano”, en *Hispania* 39 (1979) p. 5 ss.

98 Lactancio, *De mortibus Persecutorum* 7, 7 (2). Acerca de este texto, vid.: CORCORAN, S., *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324* (Oxford, 2000) p. 232-233.

99 Traemos a colación la autorizada opinión de J. P. CALLU quien no duda en calificar a Diocleciano de “justiciero social” que pretendía restablecer la moneda buena y la “verdad económica de los precios”, combatiendo la especulación –juzgada como única causa del aumento de los mismos– (cfr. *La politique monétaire*, cit., p. 405 ss).

VI

BIBLIOGRAFÍA

- ALBRECHT, M. von., *Historia de la literatura romana*, trad. esp. Dulce Estefanía-Andrés Pociña (Barcelona, 1999).
- ARCE, J., “El ‘Edictum de pretiis’ y la ‘Diocesis Hispaniarum’”. Notas sobre la economía de la Península Ibérica en el Bajo Imperio Romano”, en *Hispania* 39 (1979) p. 5 ss.
- El último siglo de la España romana: 284-409, (Madrid, 1982).
- BALIL, A., “Hispania en los años 260 a 300 después de Jesucristo”, en *Emerita* 27, (1954), p. 269.
- BAYNES, N. H., *The Historia Augusta: its date and purpose* (Oxford, 1926).
- BERCHEN, D. van., “L’Annone militaire”, en *MSAF LXXX* (1937) p. 117-202.
- BERNARDI, A., “Los problemas económicos del Imperio Romano en la época de su decadencia”, en C. M. Cipolla y otros, *La decadencia económica del Imperio* (Madrid, 1973) p. 27 ss.
- BIRD, D. J., “The Roman Gold- Mines of North-West Spain”, en *BJ* 152, (1972), p. 36 ss.
- BIRLEY, A. R., “Septimius Severus and the Roman Army”, en *Epigraphische Studien* 8 (1969) p. 63-82.
- “The economics effects of Roman frontier policy”, en *The Roman West in the Third Century*, King-Henig (eds.) (Oxford, 1981) p. 39 ss.
- BOLIN, S., *State and Currency in the Roman Empire* (Estocolmo, 1958).
- BRUUN, C., “The Antonine Plague and the Third Century Crisis”, en Hekster, Kleijn y Slootjes (eds.), *Crises and the Roman Empire* (Leiden-Boston-Brill, 2007) p. 201-207.
- CAAMAÑO, GESTO, J. M., “Los miliarios del alto de la Cerdeira (Puebla de Trives)”, en *CEG* 28, (1973) p. 212 ss.
- “Aportaciones a los miliarios del tramo orensano de la vía XVIII”, en *Bol. Aur.* 6 (1976) p. 121 ss.
- CALLU, J. P. “Role et distribution des especes de bronze de 384 á 392”, en *Imperial Revenue*, p. 41 ss.
- “La circulation monétaire de 313 á 318”, en *Actes du 8éme Congrès International de Numismatique* (París-Bale, 1976) p. 227-242.
- Les dévaluations á Rome (Roma, 1978).
- CANSINOS MORA, F., “Intervencionismo económico en la legislación imperial romana del siglo IV: Líneas generales”, en V.V.A.A. *Hacia un Derecho administrativo y Fiscal romano*, A. Fernández de Buján, Gabriel Gerez Kraemer, Belén Malavé Osuna (Co-editores) (Madrid, 2011) p. 255 ss .
- CASCIO, E. LO., “Del antoninianus al laurento grande, la evoluzione monetaria del III secolo alla luce de la nuova documentzione di età diocleziana”, en *Opus* 3 (1984) p. 133-201.
- CORCORAN, S., *The Empire of the Tetraerchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324* (Oxford, 2000) p. 232-233.

- CRAWFORD, M., "Finance, Coinage and Money from the Severians to Constantine", en *Aufstieg* II/2 p. 560 ss..
- "Le problème des liquidités dans l'Antiquité classique", en *Annales* 26, (1971) p. 1228 ss.
- CHRISTENSEN, A. S., *Lactantius the Historian: An Analysis of the Mortibus Persecutorum* (Viborg, 1980).
- DEPEYROT, G., *Crisis e inflación entre la Antigüedad y la Edad Media* (Barcelona, 1996).
- DÍAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)* (Murcia, 1987).
- DE MARTINO, F. de., *Storia economica di Roma antica*, II (Florenca, 1980).
- DOMERGUE, C., "Les exploitations auríferes du Nord-Ouest de la Península Ibérique sous l'occupation romaine", en *La minería hispana e iberoamericana* 1 (León, 1970) p. 151-193.
- DOMERGUE-HERAIL, *Mines d'or romaines d'Espagne*, (Toulouse, 1978).
- D'ORS, A., *Epigrafía jurídica de la España romana* (Madrid, 1953)
- "Un arbitrista del siglo IV y la decadencia del Imperio Romano", en *Cuadernos de la Fundación Pastor* 7 (Madrid, 1963) p. 41-69.
- EDMONSON, J. C., *Two industries in Roman Lusitania: Mining and Garum production* (Oxford, 1987).
- ERIM-REYNOLDS-CRAWFORD, "Diocletian's Currency Reform. A New Inscription", en *JRS* 61 (1971) p. 171 ss.
- FARIÑA, F., "Notas sobre la circulación monetaria a mediados del siglo III después de Cristo en el Noroeste peninsular", en *Congreso Arqueológico Nacional* 12, p. 747 ss.
- FERNÁNDEZ UBIÑA, J., *La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo* (Madrid, 1982).
- GARNSEY P.-SALLER, R., *El Imperio Romano: economía, sociedad y cultura*, (Barcelona, 1990).
- GIBBON, E., *The History of Decline and Fall of the Roman Empire* (Londres, 1776-1788).
- GOLDSWORTHY, A., *La caída del Imperio romano. El ocaso de Occidente*, trad. esp. Martín Lorenzo (Madrid, 2009).
- GONZÁLEZ BLANCO, A., *Economía y sociedad en el Bajo Imperio según San Juan Crisóstomo* (Madrid, 1980).
- "Evocando a Otto Seeck", en *Studia Historica. Historia Antigua* 6 (1988).
- GONZÁLEZ GARCÍA, A., "La inflación en el Imperio Romano de Diocleciano a Teodosio", en *Documenta et Instrumenta* 9 (2011) p. 139 ss.
- GUADÁN, A. M., "Algunas cuestiones sobre la reforma monetaria de Diocleciano", en *Anejos de Gerión* I (Madrid, 1988) p. 307 ss.
- GUEY, J., "De l'or des daces au livre de Stude Bolin", en *Mélanges Carcopino* (París, 1960) p. 455 ss.
- HARL, K. W., *Coinage in the Roman Economy 300 BC to AD 700*, (Maryland, 1996).
- "Marks of value on tetrarci nummi and Diocletian's monetari policy", en *The Phoenix* (1985) p. 263-270.
- HAYEK, F. A., von., *Choice of Currency: A Way to Stop Inflation* (Londres, 1976).
- HENDY, M., "Mint, Fiscal Administration under Diocletian, his colleagues and his successors", en *JRS* 62 (1972) p. 81.
- HERTEL, T., s.v. "mining" en *Cambridge Ancient History* 12, p. 243 ss.

- HERZOG, R., s. v. “nummularii”, en RE (17 p. 1416).
- HOMO, L., “Les documents de l’Histoire Auguste et leur valeur historique », en RH 151 (1926) p. 161 ss.
- HOPKINS, K., *Trade in the Ancient Economy* (Londres, 1985).
- JONES, A. H. M., *The Later Roman Empire: A Social, Economic and Administrative Survey* (Oxford, 1964).
- “Obertaxation and the decline of the Roman Empire”, en *Antiquity* 33 (1959) p. 39-43.
- JONES-BIRD, “Roman Gold-Mining”, en JRS 62, 1972, pp. 62-74.
- JONGMAN, W., “Gibbon was Right: The Decline and Fall of the Roman Economy”, en Hekster, Kleijn y Slootjes (eds.) *Crises and the Roman Empire* (Leiden-Boston-Brill, 2007) p. 188 ss.
- LEWIS-JONES, “Roman Gold-Minings in North West Spain”, en *La Minería*, 2, p. 171 ss.
- LORIOT, X., “Les premières années de la grande crise du III^e siècle: De l’avènement de Maxim le Thrace (225) á la mort de Gordien III (244)”, en ANRW, II, 2 (Berlín-Nueva York, 1975) p. 657 ss.
- MALAVÉ OSUNA, B., “La administración financiera en el Bajo Imperio”, en RGDR 8 (2007) p. 7 ss.
- MATTINGLY, H., *Roman Coins, from the earliest times to the fall of the Western Empire* (Londres, 1960).
- MAZZARINO, S., *El fin del mundo antiguo*, 5 (México, 1961) p. 189 ss.
- “Precetti del buon Governo (Principio Gubernatione Rei P.) e problema di economia militare”, en *Bonner Historia-Augusta Colloquium*, 1971 (Bonn, 1974) p. 103-112.
- MOMIGLIANO, A., “Gibbon’s Contribution to Historical Method”, en *Studies in Historiography* (Londres, 1966) p. 40 ss.
- MOMMSEN, T., *Ueber das Römischen Münzwesen* (Berlín 1850).
- MROZEK, S., “Le travail des hommes libres dans les mines romaines”, en *La Minería*, 2, p. 163 ss.
- MUÑOZ COELLO, *La finanzas públicas del Estado romano en el Alto Imperio* (Madrid, 1990).
- PASSERINI, A., *Linee di storia romana in età imperiale* (Milán, 1940).
- POTTER, *Constantino El Grande* (Barcelona, 2013).
- PRODOMÍDIS, P. I. K., “Another View on an Old Inflation: Environment and Policies in the Roman Empire up to Diocletian’s Price Edict”, en *Centre of Planning and Economic Research Discussion Papers* 85 (Atenas, 2006).
- RICHMOND, I. A., *Roman Britain* (Londres, 1955).
- RIPOLLÉS, P. P., “La circulación monetaria en la ciudad de Valencia durante la época imperial”, en *La ciudad de Valencia*, coord. por J. Hermosilla Pla, vol. I (Valencia, 2009) p. III ss.
- ROBLES VELASCO, L. M., “Notas sobre las crisis económicas en el Imperio Romano: entre la libre iniciativa y el intervencionismo”, en RGDR 12 (2009) p. 1 ss.
- RODRÍGUEZ ENNES, L., “Las explotaciones mineras y la romanización de Galicia”, en *Estudios de Derecho Romano en memoria de Benito M^a Reimundo Yanes II* (Burgos, 2000) p. 305ss.

- ROUCHÉ, C., *Aphrodisias in Late Antiquity* (Londres, 1989).
- ROSTOVTEFF, M., *Historia social y económica del Imperio Romano*, trad. esp. López Ballesteros, II (Madrid, 1973).
- SALMON, P., *Population et dépopulation dans l'Empire romain*, (Bruselas, 1974).
- SYME, R., *Ammianus and the Historia Augusta* (Oxford, 1971).
- “The composition of the Historia Augusta: recients theories”, en *JRS* 62 (1972) p. 123 ss.
- SEECK, O., s. v. “anonymus de rebus creditis”, en *RE* (1) p. 2325.
- VAN NOSTRAND, R., *An Economic Survey of Ancient Rome* 3, (1959) p. 126 e ss.
- WALBANK, F. W., *La pavorosa revolución. La decadencia del Imperio Romano en Occidente*, trad. esp. D. Rolfe (Madrid, 1978).
- WASSINK, A., “Inflation and Finantial Policy Under the Roman Empire to the Price Edict of 301 AD”, en *Historia*, 40-4 (1991) p. 465 ss.
- WHITE, L., *The Transformation of the Roman World: Gibbon's Problem after Two Centuries* (Berkeley-Los Ángeles, 1966) p. 201 ss.
- WHITTAKER, C. R., en Finley, M. I. (ed) *Studies in Roman Property* (Cambridge, 1976) p. 137 ss.

LA ASUNCIÓN DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

JOSÉ LUIS ZAMORA MANZANO
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Aunque el Derecho mercantil, según la opinión tradicional¹, nace a partir de los siglos XII y XIII, no podemos negar la existencia de instituciones en el Derecho romano que aparecen para atender las nuevas necesidades que surgen con el auge del tráfico comercial marítimo y que inexorablemente conforman un derecho comercial romano que deja su impronta en el derecho mercantil vigente, como veremos en relación al contrato de seguro de prima fija y de mutualidad.

El seguro es hoy un elemento indispensable en el transporte marítimo, sin él comercio y la navegación serían inconcebibles ya que existen intereses amenazados en cada expedición marítima. Sin su existencia, sería impensable que los distintos sujetos del transporte actuasen, al menos por su propia cuenta y riesgo; de ahí que su importancia es tal que, sin el menor género de dudas, el progreso de la humanidad se debe en grandísima medida a la existencia del seguro marítimo. En el Derecho romano encontramos el embrión de los seguros marítimos en la asunción de riesgos por parte del prestamista en el *foenus nauticum*², en base a la estructura aleatoria del contrato y a la situación de incertidumbre hasta la llegada a buen puerto de la nave³ y el *pretium periculum* que se configura como una prima del riesgo. Veremos, también, cómo se establecen una serie de medidas que trataron de incentivar el transporte, dado que éste se ve sometido a cuantiosos intereses ligados a la expedición, de ahí que, como tendremos ocasión de analizar, surjan también una serie de figuras tendentes a atenuar o a eliminar los riesgos que pueden acaecer durante la navegación.

1 GOLDSCHMIDT, L., *Universalgeschichte des Handelrecht*, Stuttgart, 1981.I, 3 ss.

2 Este préstamo ha sido objeto de numerosas monografías DE MARTINO F., *Sul foenus nauticum* en Riv. Dir. Nav. I, 1935, 226. Ancora sul *foenus nauticum* id. II, 1936, 433 ss. BISCARDI A., *La struttura classica del foenus nauticum*, Studi Albertario II, Milano, 1953, 349 ss. ROUGE J., *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris, 1966, 345 ss. VISKY, *Das Seedarlehen und die damit verbundene Konventionalstrafe in römischen Recht*, RIDA 16, 1969, 394 ss. CASTRESANA A., *El préstamo marítimo griego y la pecunia traiectica romana*, Salamanca, 1982. PURPURA G., *Ricerche in tema di prestito marittimo* Ann. Palermo 39, 1987, 189 ss.

3 Purpura considera que el *periculum creditoris* de este préstamo y las *usuræ nauticae* eran computadas por empresa marítima y no por el tiempo PURPURA G., *Ricerche in tema di prestito marittimo...*, 279.

I. INCENTIVOS, ASUNCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

La transformación de Roma por su crecimiento, con la consiguiente necesidad de abastecer al ejército desplazado a gran distancia de la capital, exigió disponer de productos y transporte para solucionar los problemas de avituallamiento. De ahí la importancia de controlar y asegurar el aprovisionamiento de la ciudad de Roma y del ejército, sobre todo en las dos materias básicas de consumo el grano, vino y aceite⁴. En este sentido, precisamente, nos encontramos con fuentes donde es notorio como el Estado asume el riesgo de la navegación como observamos del testimonio de Livio en:

Liv 23.48.10-12: Prodeundum in contionem Fulvio praetori esse, indicandas populo publicas necessitates cohortandosque qui redempturis auxissent patrimonia, ut rei publicae, ex qua creuissent, tempus commodarent, conducereutque ea lege praebenda quae ad exercitum Hispaniensem opus essent, ut, cum pecunia in aerario esset, iis primis solueretur. Haec praetor in contione edixit quo uestimenta frumentum Hispaniensi exercitui praebenda quaeque alia opus essent nauilibus sociis esset locaturus.

Liv. 23.49.1-3: Ubi ea dies uenit, ad conducendum tres societates aderant hominum undeiginti, quorum duo postulata fuere, unum ut militia uacarent dum in eo publico essent, alterum ut quae in naues imposuissent ab hostium tempestatisque ui publico periculo essent. Vtroque impetrato conduxerunt priuataque pecunia res publica administrata est

Concretamente, los textos citados, hacen referencia a cómo durante las guerras púnicas la República asume el riesgo de la pérdida de las mercancías destinadas al avituallamiento de los ejércitos en Hispania, en los supuestos de tempestad y de ataques de los enemigos⁵. Es obvio que, a primera vista, no se trata de un contrato de seguro marítimo sino de la asunción de riesgos por parte del Estado en aras a garantizar un contrato de transporte de servicio público al estar en juego la defensa de la República. Así, del texto se desprende un compromiso, por parte de los transportistas, de desempeñar el servicio con la condición de quedar exentos del servicio militar y de los riesgos que acaecieran durante la travesía, ya que estos pasan al Estado; esto último, se inserta como cláusula accesorio al contrato de transporte en el que se produce una inversión en la carga del *periculum* porque la mercancía es la que el estado quería transportar para pertrechar sus ejércitos.

4 Es importante destacar los llamados *tituli picti* que nos informan acerca de la comercialización y control del producto, tanto por su origen como por su calidad; arrojando más luz sobre la comercialización del producto desde el punto de vista económico y del proceso de distribución y el régimen jurídico del mismo, vid a este respecto GÓMEZ- IGLESIAS CASAL, A. *Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los tituli picti*, REHJ 32, 2010, 59 ss.

5 A partir de la lex Gabina de bello pirático se mantiene una política más exhaustiva contra la piratería y también contra el contrabando, vid. MONACO L., *Persecutio piratarum*, Napoli 1996.

A priori, estas convenciones⁶ por las que se producía la asunción del riesgo, por parte del Estado, de contingencias derivadas de las inclemencias meteorológicas y del ataque del enemigo, e incluso algún que otro incidente marítimo⁷, tuvieron también un efecto negativo dado que provocaron el fraude y la simulación de naufragios⁸. Así, contextualizando esta afirmación, algunos mediante astucia aprovecharon esta responsabilización para realizar carga de género de escaso valor en naves anticuadas y destartaladas para hundirlas y realizar la conveniente protesta alegando pérdidas superiores o declarando haber sufrido el incidente, como se desprende de Livio, 25.3.10-11:

Hi, quia publicum periculum erat a ui tempestatis in iis quae portarentur ad exercitus et ementiti erant falsa naufragia et ea ipsa quae uera renuntiauerant fraude ipsorum facta erant, non casu. in ueteres quassasque naues paucis et parui pretii rebus impositis, cum mersissent eas in alto exceptis in praeparatas scaphas nautis, multiplices fuisse merces ementiebantur.

Ahora bien, durante los meses de invierno, en los que la navegación era bastante complicada, sobre todo entre noviembre y abril, existe la necesidad de incentivar el transporte para evitar la falta de provisiones, así Claudio induce a los *negotiatores* a que acometan el porte reembolsando a los mismos gastos por los daños o pérdidas que puedan acaecerles durante la navegación a fin de incentivar los viajes, como nos informa Suetonio en su *De vita Caesarum*, en su capítulo 18 de los destinados a Claudio 18.4:

Nihil non excogitavit ad inuehentos etiam tempore hiberno commeatus. Nam et negotiatoribus certa lucra proposuit suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset, et naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro condicione cuiusque

Esta medida, sin lugar a dudas, constituía un acicate para los comerciantes que no querían exponer sus naves sin una garantía; en este sentido, también el emperador Trajano garantizó esta política de incentivos, mediante *vacatio muneris publici* a los *navicularii* que servían a la *annona*⁹. En este mismo contexto, también es lapidario el rescripto de Adria-

6 CHECCHINI A., *I precedenti e lo sviluppo storico del contratto di assicurazione*, Scritti giuridici e storico-giuridici II, Padova, 1958, 344, nos comenta el autor que se trata de convenciones de asunción de riesgos por parte del Estado y no de un contrato de seguro.

7 Con un análisis pormenorizado de los accidentes principales en relación al abordaje, naufragio, saqueo, asalto Vid. ZAMORA MANZANO J., *Averías y accidentes en Derecho marítimo romano*, Madrid, 2000, 75 ss. También en *Derecho comercial romano*, Madrid, 2013 66 ss.

8 Sobre la protesta e investigación del naufragio vid. SOLAZZI S., *Su CI 11.6 de naufragiis*, en Scritti v.III, Napoli 1963, 165 ss. Se procedía a la tortura de la tripulación para poder realizar la diligente investigación de todas las naves sumergidas tal y como se desprende de C.11.6.3: *Quotiens obruta vel submersa fluctibus navi examen adhibetur competentis iudicis, duorum vel trium nautarum quaestione habita ceteri ab huiusmodi nexu liberentur. quid est enim, quod non abunde intra praefinitum numerum sollers quaesitor inueniat?*.

9 D.50.6.6.3 (Calistrato 1 De Cog.): *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem*

no al que alude Calistrato en D.50.6.6.5: *Divus hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt*, que concedió la inmunidad de las cargas municipales a aquellos que se dedican al transporte en beneficio de la *annona* de la ciudad, garantizándose así el servicio público: *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt*. (D.50.6.6.(5).3). A priori, lo ya señalado obedece a compensar el riesgo que asumen al desempeñar este servicio fuera de su ciudad, eximiéndoles de cualquier gasto.

Pero retomando el texto de Claudio, la medida mencionada en el fragmento iba dirigida a promover el transporte de productos de primera necesidad, sobre todo del trigo, por los problemas y desórdenes que se produjeron debido a la carestía del cereal, lo que propició una serie de medidas políticas intervencionistas en el orden económico¹⁰.

Es obvio que los riesgos inherentes a la navegación y la importancia creciente del transporte marítimo provocaron numerosas providencias que trataron de garantizar el comercio en aras al interés general, en este último caso, según se desprende de Suet. Claud. 18-19.4, salvaguardando a los transportistas, sin que ello implique un verdadero y propio contrato de aseguramiento de las posibles contingencias, sino una simple asunción del riesgo por parte del Estado. En definitiva, se trata de una transferencia del *periculum* al Estado por la asunción del mismo en los supuestos de transporte de *species publicae*.

Así las cosas, en este mismo contexto, existió la necesidad de preservar los riesgos que derivaron del transporte de *pecunia publica* como nos indica la respuesta que Cicerón da a una carta de Salustio sobre la entrega de cuentas provenientes de un botín¹¹, veamos el fragmento Cic. Ad fam 2.17.4:

Rationes mei quaestoris nec verum fuit me tibi mittere nec tamen erant confectae. Eas nos Apameae deponere cogitabamus. De praeda mea praeter quaestores urbanos, id est populum Romanum, terruncium nec attigit nec tacturus est quisquam. Laodiceae me praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae, ut et mihi et populo

publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse, en igual sentido vid. Bas.54.6.6.3

10 Frente al liberalismo económico, que no controlaba la provisión y la especulación del grano, se produce la intervención y el control de mercados con la creación del *Prefecto annonae*, encargado de la política de racionamiento y control de los cereales y alimentos y por el marco jurídico que instituye la *lex iulia annonaria* del año 18 a efectos de mantener el orden en los mercados ya que trato de reprimir el acaparamiento de productos alimenticios a fin de provocar una subida de precios artificial, en particular los cereales, ya sea mediante la creación de monopolios o agrupaciones de proveedores, auténticos *trusts*, con el fin de acaparar y provocar la alteración de los precios. Por ello, la política económica trato de incentivar a aquellos que desempeñaban un servicio a favor de la *annona*, consiguiendo a cambio ventajas y exenciones fiscales; de una política liberal de mercado pasamos a una política *annonaria* intervencionista.

11 El régimen jurídico del botín de guerra es controvertido, si bien no se duda de que existía una directa administración y disposición del mismo por el interés público que conlleva. Se debe distinguir si el botín proviene de un saqueo permitido a los soldados o del propio del comandante. Lo cierto es que, a pesar de muchas de las conjeturas recogidas por DE MARTINO F., *Su pretesi precedenti dell'assicurazione, en Diritto privato e società romana*, Roma, 1982 p.226 ss, la carta alude a la administración pública de la pecunia del cuestor que estaba sometido a ciertas garantías de devolución

cautum sit sine vecturae periculo. Quod scribis ad me de drachmum CCCIccc, nihil est quod in isto genere cuiquam possim commodare. Omnis enim pecunia ita tractatur ut praeda a praefectis, quae autem mihi attributa est a quaestore curetur.

En la primera parte, se infiere como Cicerón desmiente el haber enviado las cuentas de su cuestor a Salustio, como este efectivamente creía; asimismo, también se afirma que las mismas no estaban completas y que la intención era depositarlas en Apamea. El texto ofrece muchas conjeturas y una interpretación poco clara ya que falta saber que le había solicitado Salustio a Cicerón, siendo este último procónsul de Cilicia y los motivos por los que se habría enviado el dinero a Salustio, que era procuestor en Babilonia provincia de Siria, y qué podía haber sugerido en relación al uso del mismo. Dejando a un lado los motivos del envío, hay que ver si realmente las relaciones contractuales¹² se construyen para preservar la *pecunia publica* (cien mil dracmas) procedente del botín del riesgo de la navegación. Es obvio, siguiendo a De Martino, que dichas relaciones no pueden ser consideradas como un seguro, tal y como lo conocemos hoy en día. Podría incluso considerarse como una venta con precio diferido, para ser este reenviado a Roma, e incluso, podría darse otra interpretación que justifique el nexo contractual, considerando el mismo en base a una especie de letra de cambio, en tanto en cuanto Cicerón, habría depositado el dinero en *Laodicea*, Siria, para posteriormente acreditar su equivalente en Roma¹³. A pesar de todas estas conjeturas, y siendo obvio que no existía un contrato de seguro de la pecunia, se trató de garantizar la contingencia que podía afectar el transporte marítimo de la pecunia publica procedente del botín; así, el fragmento menciona la presencia de los *praedes* que van a actuar como garantes de esa relación comercial entre particulares y el Estado. Llegados a este punto, es más lógico pensar que el nexo se basó en un contrato de mutuo de transferencia de la *pecunia publica* con la obligación de restituirla en Roma, con el pago de intereses y la dación de *praedes*, a fin de minimizar los riesgos de su transporte.

Retomando nuestras medidas destinadas a estimular o incentivar el transporte, al margen de las ya comentadas, en las que el Estado asumía de forma directa las contingencias, existieron otras que otorgaban privilegios y la inmunidad fiscal, e incentivaban la construcción de naves de cierto tonelaje para el transporte de la annona, con el privilegio de acceder a la ciudadanía, como nos comenta Gayo en relación a un Edicto de Claudio que obligaba a destinar dichas naves al menos un periodo de seis años para mantener la concesión de dichas prebendas Gai 1.32c: *Item edicto Claudii Latini ius Quiritium consecutur, si nuven marinam aedificaverint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Roman portaverit.*

En época de Marco Aurelio también el jurista Scévola 3 libr. Reg. D.50.5.3: His, qui naves marinas fabricaverunt et ad annonam populi romani praefuerint non minores quinqu-

12 HUVELIN P., Droit comercial romain, Paris, 1904, p. 97 ss; e Études d'histoire du droit commercial romain, Paris, 1929, p. 96 ss.

13 Vid. DE MARTINO F., *Su pretesi precedenti dell'assicurazione...* 225 n. 10; con citas a GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913, 275 ss. GLÜCK, *Commentario alle pandette*, XII (trad. Bertolini- Di Marzo), Milano, 1905, p. 191.

ginta milium modiorum aut plures singulas non minores decem milium modiorum, donec hae naves navigant aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob navem. senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege iulia repetundarum licet.

Del texto se infiere, como se incentivaba la construcción de naves de cincuenta mil modios¹⁴ o varias de diez mil, aproximadamente medio millón de litros, destinados a la *annona*, concediéndose, también exención fiscal *vacatio* o *excusatio* de *munera publica*, mientras mantengan las mismas. La finalidad es obvia, remunerar el peligro que éstos corrían al realizar numerosos viajes para aprovisionar a los municipios de productos de primera necesidad. Ahora bien, la concesión de dicha inmunidad no supuso una falta de control para poder acceder a este régimen de exenciones, ya que podía producirse evasión de impuestos¹⁵ o fraude fiscal, al igual que se producía con la simulación de naufragios. En previsión de esta eventualidad, se establecen dos requisitos que debían de reunir los comerciantes: por un lado, tener invertido en el negocio de porte la mayor parte de su patrimonio: *Navicularii et mercatores olearii, qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent* (Scevola, 1 Reg. D.50.4.5); y, por otro, aumentar la inversión de capital conforme van incrementando los beneficios del transporte¹⁶, así se infiere del texto de Calistrato en la que alude a una providencia de Adriano en D.50.6.6 (5).8: *Negotiatio pro incremento facultatum exercenda est. alioquin si quis maiore pecuniae suae parte negotiationem exercebit, rursus locuples factus in eadem quantitate negotiationis perseveraverit, tenebitur muneribus, sicuti locupletes, qui modica pecunia comparatis navibus muneribus se publicis subtrahere temptant: idque ita observandum epistula divi hadriani scripta est.*

En este mismo contexto, en el Derecho postclásico también encontramos fragmentos que implican la asunción del riesgo y la inmunidad fiscal en los supuestos de transporte y de echazón, como se desprende de la providencia de los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio del año 391, CTh.13.9.4:

Quae in naufragiis pereunt, nolumus nobis cum possessoribus, vel senatoribus vel privatis, esse communia, si quidem naufragii detrimentum fiscus agnoscat; quod interdum non grandis dispendii esse monstratur, si vexatam fluctibus navem levis iactura defendat quam si pondere suo gravatam pelagi unda submergat. Ubi vero non

¹⁴ Las naves podían ser confiscadas para realizar transporte al servicio público sobre todo las de tonelaje superior a los dos mil modios, vid. C.11.3(4).2.

¹⁵ Previsión que realizó Antonino Pío en relación a aquellos que simulaban realizar transporte público para eludir tributos como se infiere de D.50.6.6(5).9: *Divus quoque pius rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutatur, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat.*

¹⁶ Los *navicularii* prestaron uno de los servicios públicos de mayor relevancia y envergadura durante la tardía época imperial, vinculados de modo permanente al desempeño de la *annona* publica, los *navicularii* eran los encargados de transportar productos esenciales para la vida cotidiana. No es posible establecer un momento histórico exacto en el cual éstos comenzaron a encargarse del aprovisionamiento de las ciudades, pero si se sabe que inicialmente debieron ser propietarios de embarcaciones destinadas a l porte de mercancías, si bien en las fuentes se emplean otras expresiones para referirse a ellos tales como *mercatores* y *negotiatores*, vid. PENDÓN MELÉNDEZ E., *Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho romano*, Madrid 2002, p 312 ss.

est testis periculi, restituantur damna naufragii et dispendia prosecutoris fraudibus inferantur, ut ad eorum iniuriam retorqueantur, qui minus idoneos nominarunt, non ad eos redeant, quos semel constiterit fuisse devotos¹⁷.

El texto recogido en el título *de naufragiis* hace referencia al *iactus* de la mercancía para salvar la nave, es decir la causación del alijo, que se produce de forma voluntaria en los supuestos de avería. Otro aspecto interesante a destacar, según se infiere del texto, es que los dueños de la mercancía son dispensados de la contribución, respecto a lo que estos hayan aportado como contribuyentes por la parte que corresponde al estado. A este respecto, parece ser que continua una asunción por parte del Fisco de los riesgos inherentes al viaje y a los privilegios de los que desempeñan el servicio público de transporte *annonario*, encomendado, principalmente a los *navicularii*¹⁸.

Además de los incentivos, el estado se preocupa por la seguridad de las naves, frente a los posibles actos de depredación¹⁹ con relación al transporte de *publicas species*, esta garantía se establece en una Constitución del año 357 dada por Constancio, CTh 13.5.9: *nullam vim oportet navicularios sustinere delegatas species annonarias transferentes nec concussionem perpeti nec aliquod genus incommodi, sed venientes ac remeantes omni securitate potiri, decem auri libras multa proponenda his, qui eos inquietare temptaverint*²⁰.

A este respecto, el texto, *ad pedem litterae*, establece una pena de diez libras contra aquellos que perturban la seguridad en el transporte o realicen cualquier acción que pueda comprometer el mismo. Es evidente, que la piratería y los actos de latrocinio eran una

17 Reproducida de forma parcial en C.11.6.4: Pro his, quae semel a collatoribus illata naufragiis perierunt, nolumus nobis aliquam cum possessoribus, sive senatores sive privati sint, esse communionem vel aliquid periculi ad eos redundare.

18 A éstos, como venimos comentando, se les concedían privilegios y porcentajes en función de la mercancía transportada y distancia, como el *epimetrum*. Sobre las exenciones en el Edicto de precios vid. In. 80,87,89, 104 *praeter onera fiscalia quae formam suam optinent/ praeter frumenta fiscalia quae ex singulis*. Ed. GIACCHERO M. *Edictum Diocleciani et Collegarum de pretiis rerum velarium*, Genova, 1974, p. 226. Sobre los privilegios de los navicularii y su retribución por el servicio, vid. DE SALVO L, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina, 1992, 325 ss. Desde el punto de vista de la categoría de los *navicularii* se distinguían los que navegaban por los ríos o lagos los *amnici* o *nautae* de los *marini* o armadores de barcos o incluso aquellos que explotaban económicamente un barco coincidiendo con la expresión *exercitor*, vid. SIRKS, *Food for Rome. The legal structure of transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991, p. 26 ss.

19 Vid. Teniendo en cuenta la importancia que tuvo la legislación imperial en orden a crear una serie de normas específicas, que evitaran las apropiaciones ilegítimas en los casos de naufragio, tratando de dar una regulación uniforme en el ámbito marítimo, dado el despliegue del transporte de mercancías y también de viajeros, sin dejar de reprimir aquellos delitos que afectaban a los mismos vid. PINZONE A., *Naufragi, fisco e trasporti marittimi nell'età di Caracalla (Su C.I.11.6.1) obra publicada en Quaderni Catanesi di studi classici e medievali*, 4 (1982), 64. Vid. Sobre la investigación de los naufragios PERALTA ESCUER T., *La responsabilidad penal a causa del naufragio en el Derecho romano*, RGDR 16 (2011) (www.iustel.com) (fecha consulta: 28.01.14).

20 C.11.1.3, ROUGE J., *Recherches sur l'organisation du commerce...* p. 72.

constante²¹, muchas veces provocando naufragios desde la costa²² o asaltando la embarcación con otra nave²³. A fin de poder luchar contra este tipo de contingencias y garantizar la seguridad del transporte marítimo, se promulgaron normas para evitar este tipo de incidentes, tutelando también los naufragios²⁴; si bien, es en el Bajo imperio donde se produce una regulación exhaustiva buscando el transporte seguro de mercancías destinadas a la *annona*, de esta forma, se mantiene la pena del cuádruplo establecida en el edicto del pretor y a la que se refieren los emperadores Arcadio y Honorio en una providencia del año 400 d.C., CTh 13.5.29: *deprehensae fraudes iure puniuntur. solidos itaque, quos sublimitas tua eruerit valuit ab his, qui in navicularios praedas egerunt, volumus naviculariorum commodis reservari. et ne simpli poena in raptos constituta crescat audacia, in posterum sancimus, ut, quicumque in rapinis fuerit deprehensus, in poenam quadrupli teneatur*

21 Fueron frecuentes, junto a las situaciones bélicas, el ataque de piratas, que llevaban a cabo el asalto de la nave o incluso el secuestro y la solicitud de rescate para su recuperación, ZAMORA MANZANO J., *Averías y accidentes en Derecho marítimo...*p.103.

22 Se provocaron naufragios mediante falsas señalizaciones luminosas como se infiere del fragmento de Ulpiano 1 libr. Opin.D.47.9.10: *Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves et qui in eis sunt deducant sibi execrandam praedam parent, praesidis provinciae religiosa constantia efficiat.*

23 En ocasiones hubo que buscar flotas que garantizaran la navegación segura, sobre todo desde los almacenes de la *annona* en Alejandría, donde nos encontramos una disposición de Honorio y Teodosio que trata de establecer inmunidad fiscal como acicate a los portadores vid. CTh 13.5.32: *cum navarchorum coetus circiter provincias orientis inopia navium titubaret et investigandae classis optentu insularum secessus obiret et navigandi opportunitate transacta iudiciorum indignatio sine transvectionis expectaretur effectu, merito celsitudo tua praefecto augustali et insularum praeside conventis alexandrinae et carpathiae classis summates et nonnullos alios naucleros eo professionis adduxit, ut onus frumentarii commeatus, qui per orientales nauarchos ex alexandrinae civitatis conditis consuevit ad sacratissimam urbem transferri, in suam fidem susceptum ad eadem augustissimae urbis horrea comportarent, solaciis pro mercedula praestitis ex tributariae pensationis immunitate vel ex eo, quod vocatur filikon, nec non etiam aliis, quae tuae cognitionis limavit examen; ita ut, super naufragiorum, quae contingerint casibus usitato more habita quaestione, si qui calculus modulationis dicatur tempestate maris deperisse, sub tuae sedis auditione nequaquam feratur acceptus, sed haec dispendii lacuna in omne naviculariorum concilium, pro rata scilicet contingentis muneris, deferatur. haec igitur nostra lege firmamus.* Otras medidas incentivadoras en relación a la falta de armadores orientales se habían tomado ya por Valente en el año 371 (Th 13.5.14) que permitieron completar las flotas con el *corpus naviculariorum* e incluso con senadores, dado que eran los que más dinero invertían en este tipo de expediciones, siendo normal las inmunidades fiscales a los mismos.

24 El Edicto del pretor recogía la acción al cuádruplo para tutelar los actos de latrocinio cometidos con ocasión del naufragio Ulpiano 56 Ed., D.47.9.1-5 en los supuestos de sustracción: *in eum, qui ex incendio ruina naufragio rate nave expugnata quid rapuisse recepit dolo malo damnum quid in his rebus dedisse dicitur: in quadruplum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo. item in servum et in familiam iudicium dabo.* Los depredadores son identificados como *piratae* en los supuestos de apoderamiento de objetos del naufragio, fijándose el castigo de la *relegatio* o del *opus publicum* en función de la *qualitas personarum*, según el rescripto del emperador Antonino Paulo 54 Ed., D.47.9.4.1: *Divus antoninus de his, qui praedam ex naufragio diripuerint, ita rescripsit: "quod de naufragiis navis et ratis scripsisti mihi, eo pertinet, ut explores, qua poena adficiendos eos putem, qui diripuerint aliqua ex illo probantur. et facile, ut opinor, constitui potest: nam plurimum interest, peritura collegerint an quae servari possint flagitiose invaserint. ideoque si gravior praeda vi adpetita videbitur, liberos quidem fustibus caesos in triennium relegabis aut, si sordidiores erunt, in opus publicum eiusdem temporis dabis: servos flagellis caesos in metallum damnabis. si non magnae pecuniae res fuerint, liberos fustibus, servos flagellis caesos dimittere poteris". et omnino ut in ceteris, ita huiusmodi causis ex personarum condicione et rerum qualitate diligenter sunt aestimandae, ne quid aut durius aut remissius constituitur, quam causa postulabit.*

La responsabilidad de estos actos de latrocinio, según se desprende de la Constitución, se salda mediante los bienes de los que actúan contra la seguridad cometiendo despojo, al mismo tiempo que se confirma la pena del cuádruplo, establecida ya en el edicto²⁵.

Por otro lado, también resulta preciso destacar que existe una preocupación por la malversación de género público así se desprende de otra de las constituciones promulgadas por los mismos emperadores nueve años más tarde recogida en CTh.13.5.33²⁶: *qui fiscales species susceperit deportandas, si recta navigatione contempta litora devia sectatus eas avertendo distraxerit, capitali poena plectetur*. En suma, del texto se infiere que aquel que trato de eludir la navegación segura buscando malversar la mercancía que viaja como un transporte de servicio público de *fiscales species*, será castigado con la pena capital. Está claro que la intención del armador podía ser: por un lado, la de obtener ventajas y privilegios fiscales por desempeñar el transporte, y, por otro, obtener un lucro aprovechándose del género que transportaba mediante su malversación y posterior venta.

Siguiendo con nuestro contexto, otra medida dirigida a garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del transporte, es lo concerniente al hecho de que las naves pudiesen zarpar de forma libre y sin obstaculización fraudulenta, para dar cumplimiento a esta previsión, se dictó en el 410, una providencia por parte de los emperadores Honorio y Teodosio, contenida en CTh.13.5.34²⁷: *iudices, qui in portibus dioeceseos suae onusta navigia, cum prosperior flatus invitat, sub praetextu hiemis inmorari permiserint, una cum municipibus et corporatis eiusdem loci fortunarum propriarum feriantur dispendiis. navicularii praeterea poenam deportationis excipiant, si aliquid fraudis eos admisisse fuerit revelatum*

Lógicamente, no se trata de un supuesto en el que se impedía la navegación por condiciones meteorológicas adversas, sino que se pretendía garantizar la salida de las naves sin que, los portadores o transportistas, se vieran afectados por medidas arbitrarias, quizá con la finalidad de impedir la libre concurrencia de productos de la *annona* o comportamientos colusivos que trataban de crear un monopolio provocando que las naves quedasen retenidas de forma injusta. De esta forma la Constitución establecía la responsabilización específica de los implicados en la retención u obstaculización de las naves, como jueces, munícipes y las corporaciones, a los que, en caso de cometer dichos actos ilícitos, se les aplicaba la pena de confiscación de sus bienes. Además, la providencia contempló la posibilidad de aplicar la pena de deportación a aquellos patrones que habían provocado algún fraude, en relación con la salida, por ejemplo induciendo a que no se llevara a cabo una estiba o carga de la nave o, simplemente, obstaculizando la salida de otras embarcaciones.

Por otro lado, existía también, una previsión en torno al transporte de *species publicae* en relación a los *portitores frumenti*, a fin de evitar la mezcla de cargamento privado en los supuestos de naufragio. Así, en la providencia del año 395 d.C., de Arcadio y Honorio dirigida al prefecto Pretorio contenida, CTh.13.8.1: *oneri publico sarcinam privatam ne quis imponat nec audeat portitores frumenti ad suscipiendum onus aliqua necessitate compellere. hoc enim facto adque commissio non in dispendium solum adque naufragii damnum tenebitur obligatus, verum etiam publicae coercitionis experietur vigorem*, se observa que

25 CARNAZZA RAMEZZA G., *Studio sul diritto penale de romani*, Roma, 1972, p. 208 ss.

26 C.11.1.7 (5).

27 C.11.1.8(6).

los responsables por mezclar cargamento público con privado, en caso de naufragio, responden de los gastos y perjuicios ocasionados, que, conforme a las disposiciones anteriores, se realizará con cargo a su patrimonio.

II. *PRETIUM PERICULI* Y LA CONFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE SEGURO

A nuestro juicio, dejando a un margen la asunción de riesgos y los mecanismos dirigidos a estimular y asegurar el transporte en el elenco de textos anteriormente citados, encontramos un precedente o un germen de los elementos del seguro marítimo en el préstamo marítimo o *foenus nauticum*²⁸, instituto que permitía obtener capitales para comprar mercancías²⁹ o transportar el dinero para proceder a la compra en otros puertos, siendo el porte del dinero o, en su caso, la mercancía a riesgo del acreedor. Por ello, la amortización del capital estaba condicionada a la llegada de la nave a buen puerto. La ventaja para el prestatario era encontrarse cubierto de los riesgos de la navegación, como contrapartida el acreedor entregaba su capital a interés muy elevado, muchas veces hasta el doble del capital prestado, de esta forma el préstamo marítimo cumplía una función aseguradora, y en él se vislumbra el antecedente remoto de los seguros marítimos.

Ciertamente, la ventaja para el deudor era encontrarse cubierto de los riesgos de la navegación, mientras que el acreedor colocaba su pecunia a interés muy elevado *usurae supra duplum*. Se aprecia, desde un punto de vista financiero, una técnica jurídica mixta entre préstamo y un mecanismo asegurativo del riesgo³⁰. La asunción de los mismos no

28 Sobre este préstamo marítimo Modestino en D.22.2.1 señala: *Traiecticia ea pecunia est quae trans mare vehitur: ceterum si eodem loci consumatur, non erit traiectionis. sed videndum, an merces ex ea pecunia comparatae in ea causa habentur? et interest, utrum etiam ipsae periculo creditoris navigent: tunc enim traiectionis pecunia fit vid.* PURPURA G., *Ricerche in tema di prestito marittimo*, ...op. cit., p. 189. CASTRESANA A., *El préstamo marítimo griego y la pecunia traiectionis romana*, p.64 y ss. DE MARTINO F., op. cit. p. 226.id. *Ancora sul foenus nauticum*, p.433 lo considera como un mutuo con *stipulatio usurarum*, en el que solo la pecunia constituye el objeto del contrato. vid. RODRIGUES ROCHA, F., *Do foenus nauticum no Direito romano: o dealbar e a recompreensão do contrato de seguro*, *Direito Romano Poder e Direito*, Coimbra, 2013, p.477 ss.

29 El dinero se podía consumir en el puerto de salida para la compra y exportación de mercancías viajando las mismas a riesgo del prestamista, lo cual no desvirtúa el negocio, vid. BISCARDI A., *La struttura classica del foenus nauticum*, Studi E. Albertario II, Milano, 1953, 349 ss. VISKY K., *Das Seedarlehen und die damit verbundene Konventionalstrafe in römischen Recht*, Rida 16, 1969, p.394 ss. En contra y considerando que la consumición del dinero en puerto de salida si desvirtúa el negocio CASTRESANA A., *El préstamo marítimo griego... op. cit.* p.67. LITEWSKI W., *Römisches Seedarlehen*, Iura 24, 1974, p.123 ss.

30 Algunos autores consideran la asunción del mismo como elemento accidental que debe pactarse por el acreedor cuando hace la *datio pecuniae*, vid. DE MARTINO F., *Sul foenus nauticum...*, p. 126 apoyándose en C.4.33.5: *Traiectionis quidem pecuniae, quae periculo creditoris mutuo datur, casus, antequam, ad destinatum locum navis perveniat, ad debitorem non pertinet, sine huiusmodi vero conventionem infortunio naufragii non liberabitur*. LITEWSKI W., *Römisches op. cit.* p. 128 el a. lo considera como elemento accidental según D.22.2.4 y C.4.33.2-5 y esencial en D.22.2.1 y 45.1.122.1. Como elemento esencial BISCARDI A., op. cit. 353 y en *Actio pecuniae traiectionis*, Torino, 1974, p. 119 ss; el a. sostiene la necesidad de una *stipulatio poena*, como promesa de pagar una suma de dinero en el caso en que no fuese realizada la prestación, esta afirmación constituye el punto de partida para considerar que la *actio pecuniae traiectionis*, derivaba de la *stipulatio* penal que solían introducir las partes en el negocio marítimo. No podemos olvidar que este negocio se formalizaba a través de una *stipulatio* genérica que revestía la *numeratio* y los distintos *pacta usurarum* que abarcaba la restitución del capital y de los intereses.

necesitaba de un acuerdo explícito, ya que constituía un elemento esencial³¹, siendo el prestamista el que asumía los riesgos de la navegación haciendo suyas todas las contingencias marítimas. De esta forma, el prestamista al asumir el riesgo elevaba los intereses³².

Existe una relación directa entre riesgo e intereses, para ello existía una *stipulatio*³³ que englobaba todos los acuerdos adoptados³⁴ por las partes, según la cual a mayor riesgo mayor interés, *cum o sine periculum creditoris* ya que este según D.22.2.4.pr podía ser pactable, según nos comenta Papiniano 3.Resp.:

Nihil interest, traiecticia pecunia sine periculo creditoris accepta sit an post diem praestitutum et condicionem impletam periculum esse creditoris desierit. utrobique igitur maius legitima usura faenus non debetur, sed in priore quidem specie semper, in altera vero discusso periculo: nec pignora vel hypothecae titulo maioris usurae tenebuntur

A este respecto, las sentencias de Paulo 2.14.3 también aluden al principio de proporcionalidad interés-riesgo y que permiten al prestamista un interés superior como se desprende del final del fragmento: “*traiecticia pecunia propter periculum creditoris quandiu navigat navis, infinitas usuras recipere potest...*”

En la misma línea, nos encontramos con una providencia del año 286 de los emperadores Diocleciano y Maximiano que hace alusión a que el préstamo está a riesgo del acreedor y que, por tanto, está exento de intereses hasta que la nave haya llegado a buen puerto³⁵, si bien, se considera que no es dudoso que se puedan exigir intereses de la cantidad prestada más allá de lo lícito C.4.33.2 :*cum dicas pecuniam te ea lege dedisse, ut in sacra urbe tibi restitueretur, nec incertum periculum, quod ex navigatione maris metui solet, ad te pertinuisse profitearis, non dubium est pecuniae creditae ultra licitum te usuras exigere non posse.*

31 Es opinión común de la doctrina anteriormente citada, que se basa principalmente en D.22.2.1 *utrum etiam ipsae periculo creditoris navigent, tunc enim traiecticia pecunia fit* y también C.4.33.2 *nec incertum periculum, quod ex navigatione maris metui solet, ad te pertinuisse profitearis non est dubium, pecuniae creditae ultra licitum te usuras exigere non posse.*

32 Tanto DE MARTINO, op. cit 233, como LITEWSKI op. cit 165 consideran necesaria la estipulación de los intereses, BISCARDI, *Actio pecuniae* op. cit 288 considera que la *stipulatio poena* englobaría los intereses en virtud de la conventio traiecticiae pecuniae, generando el pacto una exceptio; el mismo autor en *Struttura classica*, op. cit p. 359 hace referencia a la fusión de pactos en una única cláusula aludiendo al conocido texto del préstamo de Calímaco recogido en D.45.1.122.1, la cláusula penal permitía reclamar la pena pero no el *nudum pactum*.

33 CASTRESANA A., op. cit p. 161 señala que la *stipulatio* solía practicarse bajo la forma de cláusula estipulatoria transcrita en la parte final de una *cautio*. Si bien esta *cautio* final pudo ser sustituida posteriormente por una *syngrapha* náutica que hacía las veces de documento probatorio del préstamo y de sus cláusulas contractuales.

34 Era importante revestir el *pactum usurarum* de la formalidad necesaria, de ahí que los comerciantes extranjeros también utilizaran este negocio y su operatividad a través del *pactum* que en base a las costumbres marítimas daba una mayor agilidad a las transacciones comerciales aunque no generaba acción según Paul. *Sent* 2.14.1 de ahí la necesidad de una estipulación como fórmula jurídica eficaz para fijar los intereses y salvaguardar los mismos y su tutela procesal vid. KUPISZEWSKY H., *Sul prestito marittimo nel diritto romano classico: profili sostanziali e processuali*, Index 3, 1972, p.374 ss.

35 C.4.33.1: *Traiecticiam pecuniam, quae periculo creditoris datur, tamdiu liberam esse ab observatione communium usurarum, quamdiu navis ad portum appulerit, manifestum est*

Es cierto que, inicialmente, no existía una limitación, si bien Justiniano en el 528 d.C. suprime esa libertad fijando el tipo de interés³⁶ a un doce por ciento según se recoge en la C. 4.32.26.1³⁷; sin lugar a dudas esta limitación supuso la retirada de capital del sector comercial marítimo al no poder los acreedores asumir, con tan poco margen de beneficio con dicho límite, las contingencias de la navegación³⁸; lo que a la larga provocó un derrumbe en la actividad comercial arrastrada también por la crisis del imperio.

Se aprecia, a primera vista, algunos elementos que configuran un primer estadio embrionario en la conformación del contrato de seguro por la existencia, por un lado, de la asunción de riesgos derivados de las contingencias de la navegación asumidas por el acreedor y que afectan a la posibilidad de que la nave llegue o no a buen puerto. Y, por otro, el *pretium* que conlleva dicha asunción que permite el cobro de unos intereses *pretium periculi* y que configura una especie de prima de riesgo.

En lo que interesa a nuestra investigación, es obvio, que no existió en el mundo romano un contrato específico de asunción de riesgos, si bien, desde un punto de vista práctico podían existir dos estipulaciones inversas por la cual una de las partes pagaba el *pretium periculi* a cambio de que la otra parte dejase indemne a la otra al asumir ésta el riesgo³⁹. Ahora bien, ante la ausencia de un contrato de seguro que proporcionara la asunción de riesgos tal y como lo conocemos hoy en día, lo cierto es que la aparición del mismo está relacionado con el desdoblamiento del *foenus nauticum* en el préstamo a la gruesa⁴⁰ y el contrato de seguro.

36 Fue frecuente la exigencia de intereses elevados en los préstamos a provinciales documentados en los syngrapha que daba testimonio del mismo y que continuaban acreditando los de época postclásica vid. CASTRESANA A., *El préstamo marítimo...*, p. 154.

37 Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari: illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari: in traiectionibus autem contractibus vel specierum feneratorum usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent. HUVELIN P., op. cit. 108 entiende que inicialmente se permite un pacto de intereses superiores en el derecho clásico si bien posteriormente opera la limitación de C.4.32.26.1. En la misma línea, vid. ROUGÉ J., *Recherches sur l'organisation...* p. 351

38 Excede nuestra pretensión analizar todos los problemas derivados de la usura de intereses y los que afectan a las condiciones del *foenus*, vid. HERRERA BRAVO, R. *Problemática jurídica de los intereses en derecho romano*, Jaén, 1997.

39 IMPALLOMENE G., *Profilo storico comparativo dell'evoluzione del contratto di assicurazione*, Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Milano, 1996, p. 440 ss. Le fonti sembrano ignorare esempi del genere, il che depone per la probabile assenza dell'utilizzazione della stipulatio in tal senso. El autor alude también a la importancia que tuvo la Lex Rhodia en el ámbito de la distribución de los riesgos a modo de responsabilidad societaria, debido a la contribución al riesgo comparando la misma con el seguro mutuo citando de forma expresa el artículo 1792 de nuestro código civil, artículo derogado, que ya recogía la indemnización en proporción al valor de los bienes que cada uno tiene asegurado en caso de daño.

40 El préstamo a la gruesa como medio de financiación ordinario para la construcción o aprestamiento de buques, cayó en desuso por la introducción de la hipoteca naval a fines del siglo XIX, que presenta más ventajas técnicas vid. GABALDÓN GARCÍA JL.- RUIZ SOROA JM., *Manual de la navegación marítima*³, Barcelona, 2006, p. 673 ss.

Ahora bien, a fin de poder garantizar la seguridad y el tráfico mercantil vía marítima, fue necesario el *foenus*, eso sí, a cambio de unos elevados intereses que no dejan de ser un *pretium periculi*, prima de riesgo empleando convencionalismos modernos, que asume el prestamista. El *pretium*, no deja de ser un *plus* de usura que cobraba el prestamista precisamente por ese riesgo al que exponía la inversión de capital; por tanto, la capitalización simple de intereses se hacían inicialmente en base a una tasa alta, antes de la limitación que introduce Justiniano, haciéndose frente a posibles contingencias derivadas de cualquier evento marítimo y perecimiento fortuito o por fuerza mayor⁴¹, excepto aquellas que se producen a consecuencia del dolo o culpa del prestatario, que supongan la infracción de lo pactado como por ejemplo excederse del tiempo de la travesía⁴² o cambiar el destino o derrota en la navegación⁴³.

En relación al *pretium*, debemos analizar el texto de Scévola 4 Resp., D. 22.2.5 donde se alude al precio del riesgo que asume el prestamista:

Periculi pretium est et si condicione quamvis poenali non existente recepturus sis quod dederis et insuper aliquid praeter pecuniam, si modo in aleae speciem non cadat: veluti ea, ex quibus conditiones nasci solent, ut “si non manumittas”, “si non illud facias”, “si non convaluero” et cetera. nec dubitabis, si piscatori erogatur in apparatus plurimum pecuniae dederim, ut, si cepisset, redderet, et athletae, unde se exhiberet exerceretque, ut, si vicisset, redderet.

De acuerdo con lo que señala el jurista, se insertaba en el negocio una cláusula en relación al *pretium*, por el riesgo dependiente del carácter aleatorio de la prestación⁴⁴; siendo éste, una verdadera prima de riesgo pagada por el deudor en caso de tener éxito el negocio. La rúbrica del título *De nautico foenore* nos permite extrapolar la interpretación del *pretium* referido, lógicamente, de una *condictio iuris salva nave*, que constituye un elemento inherente a la propia estructura del préstamo marítimo. Asimismo, el hecho de que el prestamista pueda experimentar una ganancia o una pérdida, según se produzca o no la contingencia marítima, nos permite pensar que estamos ante un mutuo aleatorio. Ahora bien, ese *alea*⁴⁵ al que va referido D.22.2.5 no tiene nada que ver con los supuestos mencionados en el texto referente a la pesca, a la convalecencia del sujeto que parece asumir el riesgo de la muerte o de la invalidez o del entrenamiento del atleta con vistas a ganar una competición. El

41 CASTRESANA A., *El préstamo marítimo...*, p.89.

42 Uno de los supuestos más estudiado lo encontramos en relación a D.45.1.122.1 en relación al *foenus* de Calimaco, vid. REINOSO BARBERO, F., *El foenus nauticum de Calimaco*, in Studi A. Biscardi V, Milano, 1984, p. 297-310.

43 Es significativo, el texto de Diocleciano y Maximiano, C.4.33.3 en relación a la audacia del deudor cambiando el destino y realizando compras de mercancías ilícitas: *Cum proponas te nauticum fenus ea condicione dedisse, ut post navigium, quod in africanam dirigi debitor adseverabat, in salontanorum portum nave delata fenebris pecunia tibi redderetur, ita ut navigii dumtaxat quod in africanam destinabatur periculum susceperis, perque vitium debitoris, nec loco quidem navigii servato, illicitis comparatis mercibus quae navis continebat fiscum occupasse: amissarum mercium detrimentum, quod non ex marinae tempestatis discrimine, sed ex praecipiti avaritia et incivili debitoris audacia accidisse adseveratur, adscribi tibi iuris publici ratio non permittit.*

44 DE MARTINO F., *Su pretesi precedenti dell'assicurazione...*, p. 231.

45 Sobre el concepto de alea, vid. BOSELLI, v. *alea* en NDI 1, Torino 1957, p. 469.

jurista, *a priori*, parece extender las reglas propias del préstamo marítimo a otros préstamos aleatorios fuera del ámbito del derecho comercial marítimo⁴⁶; en estos casos existe un matiz más aleatorio⁴⁷ que en la *pecunia traiectica*, si bien, en esta última el *periculum* que lleva aparejada supone un riesgo de perecimiento mayor que acompaña siempre a la navegación a la que está sometida, en base al principio de universalidad del riesgo que opera en cualquier empresa marítima.

Teniendo en cuenta lo antedicho, la exigencia o no del plus de interés, está marcada por la condición de la llegada de la nave a buen puerto, se aprecia desde un punto de vista financiero la mezcla entre préstamo y técnica asegurativa, teniendo presente: por un lado, si la nave llega al punto final de la travesía el prestamista obtiene las ganancias derivadas de la recuperación de capital y el pago del *pretium periculum*; por el contrario, si no logra arribar a puerto de destino, el prestamista es el que sufre la pérdida y asume las contingencias que se hayan producido.

De la parte del fragmento donde señala *aliquid praeter pecuniam* se infiere la entrega de toda ganancia al margen del capital y en su caso los intereses⁴⁸, podía establecerse una pena por el retraso del pago.

Por otro lado, creemos que la llegada a buen puerto de la nave y la demora en el pago del capital no pueden devengar intereses marítimos sino terrestres como se especifica en la Novela 106 de Justiniano y por ende, desaparecería la asunción de riesgos por parte del prestamista: *...si tamen post reversionem navis salvae et nequaquam navigare propter tempus valentes revertantur, triginta solum dierum inducias dari a creditoribus debitoribus, et nihil pro debitis usurarum causa exigere, donec vendi contingat onus, parcentes apud alium esse debitum non reddendum duas partes centesimae dominis pecuniarum dare usuras et mutare et mos mutuum in terrenum transponere modum nequaquam maritimis periculis creditoribus molestandis...*

Retomando el fragmento D. 22.2.5, también observamos tres cláusulas que constituyen ejemplos de condiciones suspensivas de cara a la devolución del capital según las hipótesis del fragmento *ut* “*si non manumittas*”, “*si non illud facias*”, “*si non convaluero*”. La construcción que plantea Huvelin⁴⁹, según la mayoría de los autores⁵⁰, es arriesgada a la vez que ingeniosa ya que considera que se trata de estipulaciones condicionales de garantía del riesgo por medio de *pretium periculum* identificándolo con el seguro, aplicados a supuestos

46 HUVELIN P., op. cit 99.

47 CALONGE A., La compraventa civil de cosa futura, V, 1963, p. 49 ss.

48 RICCOBONO S, *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, ZSS 43, 1922, p. 358, el a. señala sin duda, que en el periodo clásico era siempre necesaria una estipulación para exigir los intereses por medio de acción y sin embargo, las obligaciones derivadas del contrato innominado *ex quibus conditiones nasci solent* y aleatorios no admitían en el momento de la restitución algún aumento por la cantidad prestada, al menos que eso no hubiese estado previsto en una *stipulatio poena nomine*. Pero el texto, permite el simple pacto como generador de obligaciones vid . Paul Sent 2.14.1 y C. 32.26.2. Esto último, ha sido criticado por PURPURA G., op. cit 294, tras el análisis de D. 46.3.102.1 y h.t 5.2 afirma la irrepetibilidad del pago *usurae ex pacto*, calificando la usura indebida *ex pacto* como supuesto de obligación natural. De ahí la necesidad de concluir una *stipulatio usurarum* para conseguir la tutela procesal y dar formalidad a los acuerdos adoptados por las partes para regular el préstamo.

49 Études d'histoire...p.98 ss.

50 VALERI G., Il pretium e i precedenti romani della assicurazioni Studi riccobono IV, 1936, p. 233 y ss. CHECCHINI A., I precedenti e lo sviluppo storico..., p. 348. DE MARTINO F., Su pretesi precedenti..., p. 231 ss

fuera del ámbito del comercio marítimo y de otros riesgos *foenus quasi nauticum*. Como se observa, el *periculum* en el caso del *foenus* es pagado por el *creditor* y, sin embargo, en el caso del *pretium periculi* viene pagado por el deudor en caso de verificarse el evento futuro.

Castresana sólo da una visión parcial del posible antecedente actual del contrato de seguro señalando que el prestamista pretendía obtener un lucro superior al resto de operaciones crediticias, préstamo que interesaba al naviero a fin de obtener el capital suficiente para emprender la travesía, sin arriesgar el capital. Asimismo, señala porque la *pecunia traiectica* se aleja del seguro: por un lado, por el hecho de que el prestatario no solamente cargaba las mercancías compradas con la pecunia, sino otras que había podido comprar con su propio patrimonio; luego participa también en los riesgos, ya que, el prestamista sólo asumía las mercancías adquiridas con el capital prestado. Otro motivo, deriva del hecho de que en el contrato de seguro la indemnización opera una vez se ha producido el siniestro, mientras que en la *pecunia* se adelanta la pretendida indemnización a la realización efectiva del riesgo, ya que el prestatario actúa como asegurado, y se trasladan los riesgos al prestamista asegurador, y éste recibe, en caso de llegada de la nave, el exceso de interés o prima⁵¹.

En relación a la primera consideración de la autora, debemos puntualizar, por un lado, sí las mercancías que eran transportadas pertenecían a terceros el naviero podía eximirse de responsabilidad derivada de la custodia *salvan fore receperint*, ante determinadas contingencias⁵². De otra parte, hay que traer a colación el hecho de que se hayan perdido por *iactus*⁵³ las mercancías compradas por el prestatario con su patrimonio, a fin de poder salvar las compradas con la *pecunia traiectica*. Este supuesto, a pesar de no quedar expresamente recogido en las fuentes, supone una contingencia derivada de una avería gruesa, de ahí que el reparto de los daños y la correspondiente contribución a los mismos suponga, en sí misma, un antecedente del llamado seguro mutuo⁵⁴ que concurre con un préstamo marítimo. *A priori*, lo que es evidente, es que del *foenus nauticum* surgieron dos contratos uno crediticio llamado préstamo a la gruesa, en declive hoy en día, y el contrato de seguro propiamente dicho, que también toma aspectos y principios de la contribución de las averías.

Por otro lado, Valeri⁵⁵, se centra en una crítica a Huvelin y al texto que hemos analizado, concluyendo que el *pretium periculi* no se asimila directamente al contrato de seguro, si bien, constituyen el germen o embrión de la estructura del contrato de seguro marítimo que se va a generar en otro ambiente y condiciones económicas más propicias⁵⁶, señalando al

51 CASTRESANA A., op cit. p. 89 ss.

52 Ulpiano 14 Ed, D.4.9.3.1:..., at hoc edicto omnimodo qui receperit tenetur, etiam si sine culpa eius res perit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. inde labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit

53 ZAMORA MANZANO J., *Averías y accidentes...*, p.168.

54 IMPALLOMENI G., *Profilo storico*..p.438 ss considera *mutatis mutandi* en relación a la contribución de la *lex Rhodia* que se podría considerar una “*mutua assicuratrice forzosamente contrattata*”.

55 Il *pretium* e i precedenti romani della assicurazioni..., p. 238, señala que: “non esiste una assunzione di rischio, di cui l’obbligo del pagamento d’una data somma venga a costituire la eventuale conseguenza. Economicamente, il “quasi nauticum foenus” con la clausola si non convaluerò avrà anche compiuto funzioni assicurative: ma questo é troppo poco, per desumere conseguenze giuridiche concrete”.

56 Desde el punto de vista de la aparición del seguro con prima, se supone que al principio del siglo XIV, los mercaderes sedentarios inventaron un nuevo tipo de contrato, cuando descubrieron que no existían formas satisfac-

respecto, que la génesis del mismo se observa en el desplazamiento de riesgos que afectan a todos los intereses comprometidos en la expedición y en la existencia de una prima de aseguramiento. Sin embargo, Valeri omite toda referencia a la aportación de la *Lex Rhodia* en el reparto de los riesgos, elemento imprescindible en el seguro mutuo o de mutualidad, ya que los componentes implicados en la expedición al estar sometidos a unos mismos riesgos y un peligro común, necesitan de la asociación de intereses.

A este respecto, Checchini no niega que el instituto del *foenus* contenga unos principios del futuro contrato de seguro a prima, pero se opone a la existencia de un verdadero contrato accesorio de seguro adjunto al mutuo⁵⁷. Por otro lado, De Martino, considera que ni en modo directo, ni mediante el empleo de otros tipos contractuales, el Derecho romano conoció el contrato de seguro, ni siquiera para los riesgos marítimos, aunque no puede decirse que existiera una falta de instrumentos técnicos, a partir de los cuales se desarrollara⁵⁸.

Corroborando estas posiciones doctrinales, teniendo presente que, a pesar del desconocimiento en el Derecho romano del contrato de seguro, existieron los elementos y las herramientas jurídicas previas a su posterior conformación. Es difícil tratar esta materia sin utilizar convencionalismos modernos que muchas veces pueden llegar a conclusiones erróneas, si bien, creemos que la estructura del *foenus nauticum* nos permite, en cierta medida, aportar los elementos del contrato de seguro moderno junto a otros institutos como la contribución al riesgo, en base a los siguientes argumentos:

- Por un lado, la referencia al *pretium periculi* del texto de Scévola D.22.2.5 inserto en la rúbrica de *náutico foenore*, que constituye una cuasi prima retributiva del riesgo, constituye el germen de la prima de seguro actual, representada, como hemos visto, por una suma fuerte de intereses, si bien, constituye en concreto, el precedente del seguro a prima fija.
- Asimismo, el capital de la *pecunia traiectica*, configura *a sensu* contrario, la suma indemnizatoria que en el contrato de seguro actual paga el asegurador al verificarse el evento dañoso.
- Además, en relación a los riesgos, éstos no sólo giran en torno al prestamista *in náutica pecunia ex ea die periculum spectat creditorem, es quo navem navigare conveniat* (D.22.2.3), también hay que tener presente la importancia de la regulación contenida en la *lex Rhodia* y en el ordenamiento jurídico romano que permite el fraccionamiento y la atomización de los riesgos en los supuestos de echazón y otras contingencias que no dejan de ser el antecedente del seguro mutuo.

torias de transferencia y división del *periculum*. En este contexto, los comerciantes aprendieron que las mercancías solían llegar correctamente a puerto y que muy pocas veces se perdían; si bien, necesitaban valorar la posibilidad de esas pérdidas. No debía resultar fácil de calcular, los aseguradores medievales carecían de bases estadísticas que les permitieran evaluar los riesgos y por ello elevaban sus tarifas en el momento en que les llegaban noticias de peligros marítimos o guerras.

57 CHECCHINI A., I precedenti e lo sviluppo..., p. 346 considera que: l' istituto contenga il primo germe del futuro contratto di assicurazione a premio non negò: ma che contenga già un vero contratto accessorio di assicurazione, riunito a quello di mutuo, mi pare si debba assolutamente escludere.

58 DE MARTINO F., Su pretesi precedenti dell'assicurazione...p. 232

- Finalmente, aunque no existía el contrato de seguro, existe un intervencionismo estatal, que se agudiza en época postclásica, con la asunción de los riesgos en los supuestos de transporte público que operaba al servicio de la *annona* y otros servicios, que ya hemos visto, en relación con el abastecimiento de tropas militares en las provincias, a fin de dar incentivo y constituir un acicate a los empresarios navieros.

III. BREVE REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA EVOLUCIÓN Y NOTA CONCLUSIVA

Excedería nuestro cometido comentar todas y cada una de las vicisitudes del Derecho intermedio sobre la evolución ulterior, si bien haremos una breve reflexión al respecto dado que las previsiones del ordenamiento jurídico romano constituyen parte del armazón jurídico del desarrollo ulterior de la legislación medieval que se va a ir generando en torno a los institutos analizados, principalmente *foenus nauticum*⁵⁹ y la contribución, como se reflejan en las Partidas 5.9.3 a 12, donde se aborda el reparto de daños en relación a los accidentes y averías⁶⁰, en las ordenanzas para los seguros marítimos que formaron el Prior y los Cónsules de la Universidad de mercadores de Sevilla y la casa de contratación de Sevilla⁶¹ con respecto a la navegación de las Indias occidentales⁶², y en cuanto al resto del acervo mercantilistas como las Ordenanzas de Burgos de 1538, Bilbao 1531 y 1737. Posteriormente, en nuestro Código de comercio de 1885 aparece una regulación detallada de la avería gruesa y del *foenus nauticum* como figuras tendente a atenuar y eliminar los riesgos comerciales del transporte por mercancías por mar, en las que incide la regulación romana y a su vez conforman el contrato de seguro actual.

59 El *foenus nauticum* considerado también usurero en el Decretal de Gregorio IX, *Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniae quantitatem eo quod suscipit in se periculum recepturus aliquid ultra fortem usurarius est censendus. Ille quoque quid at X solidos ut alio tempore totidem sibi grani, vini, vel olei mensura reddantur: quae licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutiones tempore fuerint valiturae verisimiliter dubitatur non debet ex hoc usurarius reputari. Ratione huius dubii etiam excusatur qui pannos, granum, vinum, oleum, vel alias mercem vendit, ut amplius, quam tunc valeam in certo termino recipiat pro eisdem si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus.*

60 ZAMORA MANZANO J., *Averías y accidentes...* p. 75 ss.

61 Ord.37.1 destaca la importancia de asegurar los riesgos para poder desempeñar el transporte “..no habiendo aseguradores, no habría quien osase cargar, y osase aventurar a perder lo que se cargase. Y por esto conviene que haya muchos aseguradores que aseguren a otros lo que cargen y que entre los cargadores y aseguradores haya mucha verdad y llaneza” y también ord.37.6 “ la nulidad de seguros por fraude o una vez producida la pérdida de la nave... que si algunos asegurasen después de la pérdida de la nao o naos, o la pérdida hubiere sido en lugar que a la lengua por hora por tierra lo pudiese saber el asegurador en tal caso que el seguro sea ninguno...”

62 Existieron también las llamadas escrituras a riesgo como instrumento de financiación en el comercio con América, particularmente en Canarias ante la carencia de seguros marítimos, se utilizaron hasta 1737 préstamos a la gruesa mediante escrituras a riesgo de ida, cuyo pago se realizaba en las Indias y también las de ida y vuelta ampliamente testimoniadas en el Archivo histórico provincial de las Palmas en protocolos notariales entre 1690 y 1725, vid. al respecto TORRES SANTANA, *El riesgo en el comercio canario-americano 1690-1725* en Derecho y el mar en la España moderna, Granada, 1995, p. 81 ss. Sobre la evolución en el Derecho medieval vid. IMPALLOMENI G., op cit. 440 ss. Id. En relación a la especulación del riesgo y el traspaso convencional vid. BENEDETTO, *Appunti per una ricerca sul contratto di assicurazioni marittima*, Studi G. Grosso IV, Torino, 1981, p.485 ss.

La avería gruesa trata de lograr la división de riesgos y la contribución, y en ella encontramos el seguro mutuo, donde la puesta en común de los riesgos no suprime el aleas⁶³; por otro lado, en el préstamo a la gruesa, se permite la financiación de la expedición basándose en los principios observados ya en el Derecho romano, nos encontramos con la dispensa del reembolso de la suma prestada en caso de accidente o fortuna de mar, o en su caso, si la expedición llega a buen puerto, la restitución del capital y el pago de intereses extraordinarios al prestamista; este se asemeja, como ha puesto de manifiesto la doctrina mercantilista actual, al contrato a prima fija⁶⁴. Se aprecian numerosas semejanzas entre el préstamo actual y el seguro ya que se integran los elementos del riesgo, su desplazamiento, la prima e indemnización, si bien, ésta última, en el seguro se entrega *a posteriori* en caso de que se produzca el siniestro y no anticipadamente como en el préstamo a la gruesa recogido en el art.719 del CCo⁶⁵.

A modo de breve reflexión final, podemos señalar que en el Derecho romano se fijan los instrumentos jurídicos y técnicos que conforman las medidas tendentes a garantizar y asegurar el comercio marítimo mediante la atenuación e incluso la eliminación de los riesgos, no sólo mediante el fraccionamiento o la contribución de los mismos según las previsiones de la regulación de la echazón contenida en D.14.2, que conforma el antecedente del seguro mutuo o de mutualidad⁶⁶, sino también en el *foenus nauticum*, de la cual se configuran los elementos estructurales del seguro de prima fija actual; *pretium periculi* (del D.22.2.5) como *quasi-prima* retributiva, *periculum creditoris* y traslado de los riesgos hasta la llegada de la nave a buen puerto, y la cantidad del préstamo que entregaba al prestamista que derivará en la indemnización del seguro; por tanto, no dejan de ser dos instituciones vecinas, en las que se da una inversión en el procedimiento de desplazamiento de los riesgos. Es evidente la presencia de los instrumentos técnicos para afrontar en el Derecho romano siniestros importantes y sobre todo garantizar las expediciones marítimas, que como hemos visto, también quedan garantizadas por el intervencionismo estatal en la asunción de los riesgos. Pero también hay notables influencias de parte de los elementos de los institutos que evolucionaron tanto de la distribución de los riesgos en las averías como en el *foenus*, que han facilitado

63 Así en nuestro código de comercio se establece en su art. 812: a satisfacer el importe de las averías gruesas o comunes contribuirán todos los interesados en el buque y el cargamento existente en él al tiempo de ocurrir la avería.

64 HILL PRADOS C., *Los clubs de protección e indemnización en el campo del seguro marítimo*, Barcelona 1992, 21 y ss establece el análisis de la avería gruesa y el préstamo como antecedentes del seguro a prima fija y a mutualidad. Sobre los intereses asegurados en el derecho moderno vid. GABALDÓN GARCÍA JL.- RUIZ SOROA JM., *Manual de la navegación* p.870 ss.

65 Se reputará como préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo, aquel en el que, bajo cualquier condición, dependa el reembolso de la suma prestada y el premio por ella convenido, del feliz arribo a puerto de los efectos sobre que esté hecho, o del valor que obtengan en caso de siniestro. Vid. nota 67 sobre el proyecto de la Ley General de Navegación marítima que suprime toda referencia a esta figura.

66 En el artículo 1792 ya derogado del C.Civil antes de la reforma señalaba que: “pueden asegurarse mutuamente dos o más propietarios el daño fortuito que sobrevenga en sus bienes respectivos. Este contrato tiene el nombre de seguros mutuos y cuando en él no se haya pactado otra cosa, se entiende que el daño debe ser indemnizado por todos los contratantes en proporción a sus bienes que cada uno tiene asegurado”.

la distribución y atomización del riesgo en diferentes figuras en el derecho moderno como el coaseguro⁶⁷ y reaseguros.

En este contexto, y en relación a la distribución del riesgo y su aseguramiento, no podemos olvidar la importancia, hoy en día de los P&I o *Pandi, Protection and Indemnity Clubs*, asociaciones de armadores y fletadores que aportan en común sus recursos para hacer frente a las pérdidas sufridas por sus socios, que parecen tomar muchos de los principios de la contribución romana. Así, las primas de mutualidad pagadas por sus miembros cada año bastan para satisfacer todas las reclamaciones, reaseguros y gastos del P&I durante el año operativo salvo aquellos en los cuales haya que pagar la *supplementary call*. Así el P&I Club protege en proporción del buque por avería gruesa, y los gastos especiales o salvamento no recuperables bajo la póliza de casco en virtud a que el valor establecido para el buque en el ajuste de avería gruesa, excede el valor del mismo en la póliza de casco.

⁶⁷ La reforma que opera con el Proyecto de ley de navegación marítima aprobada el 29 de noviembre de 2013 en el boletín del Congreso de los diputados 121/00073 hace desaparecer la figura del préstamo a la gruesa manteniendo la regulación de los seguros art.436 al 497 y la hipoteca naval art.176 al 194.

UNA HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PESCADORES DE “EL PALMAR” DE LA ALBUFERA DE VALENCIA

CARMEN LÁZARO GUILLAMÓN

Universitat Jaume I (Castellón)

Afirmaba Henry Adams, historiador y filósofo americano (1838-1918), que “un profesor trabaja para la eternidad, nadie puede precedir dónde acabará su influencia”, sirvan las palabras de Adams para abrir este trabajo en homenaje al Prof. Díaz Bautista para quien la cita se confirma.

En línea de principio, debemos advertir al lector que la falta de datos y, por tanto, de investigaciones que permitan encontrar noticias sobre los habitantes de la Albufera¹ de Valencia hasta la reconquista es un hecho² y que, de esta forma, la hipótesis fundada en el análisis de textos literarios, de fuentes jurídicas y la similitud con las actividades de explotación pesquera en lugares próximos, es el hilo argumental de este trabajo.

Siguiendo a Parodi Álvarez³, las lagunas litorales ocupan un puesto de relevancia en la economía de Hispania, en particular, la importancia de estas lagunas costeras radica en el papel de comunicadoras entre las zonas de costa y las comarcas del interior, especialmente, así se configuran y se entienden las lagunas mediterráneas del Levante valenciano y murciano (la Albufera de Valencia, el Mar Menor de Murcia y el desaparecido Almarjal de Cartagena), junto a esta función de facilitadoras de las comunicaciones, estas lagunas costeras presentan, desde un punto de vista económico, una alta productividad en cuanto a labores extractivas –caza y pesca– desarrolladas, en el caso de la pesca, desde embarcaciones de dimensiones reducidas y poco calado que debieron suponer una de las principales dedicaciones de sus pobladores. A esta actividad extractiva acompaña el comercio del excedente

1 Conocido es su origen etimológico del árabe قريح (al-boheira), diminutivo de بحر (bahr), pequeño mar.

2 CARUANA TOMÁS, C. *Estudio histórico y jurídico de la Albufera de Valencia*, Valencia: Sucesor de Vives Mora, 1954, p. 12; MOMBLANCH Y GONZÁLEZ, F. *Historia de la Albufera de Valencia*, Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 2003, p. 27.

3 PARODÍ ÁLVAREZ, M.J. Algunas notas sobre el papel de lagos y lagunas costeras peninsulares como soportes para la navegación en época altoimperial. En *SPAL, Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla* 8 (1999) 207-206, pp. 209 y 210; no ocurre lo mismo con las lagunas interiores en las que su papel, en principio, parece irrelevante y difícil de precisar y no va más allá de su aprovechamiento como fuente directa de alimento.

proporcionado por las faenas pesqueras⁴. No en vano, como afirma Salcedo Ferrándiz⁵, aunque desde una posición moderada, es necesario tener en cuenta “la influencia que el medio físico ha ejercido y continúa todavía ejerciendo sobre la vida social de los pueblos, sobre la formación mental de los hombres, su gobierno y estado cultural”.

En el concreto supuesto de la Albufera de Valencia, las alusiones en los autores clásicos y su categorización como lago no son pocas; muy probablemente, la más antigua sea la del geógrafo Estrabón en el siglo I a.C., quien en su *Geographika* III, 4, a pesar de que no menciona directamente a la Albufera, diferencia la desembocadura del Júcar como algo separado completamente del río, lo que hace pensar en un estuario amplio, suficientemente importante para ser tenido en cuenta como un accidente geográfico distinto que puede relacionarse con un lago⁶. Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., caracteriza a la Albufera como “estanque ameno” cuando relata que la colonia *Valentia* estaba situada a 3.000 pasos del mar (unos 4,5 km)⁷, en concreto, *Nat. His.*, III, 20⁸: *Mox Latinorum Lucentum, Dianium stipendiarium: Sucro fluvius, et quondam oppidum, Contestaniae finis. Regio Edetania, amoeno praetendente se stagno, ad Celtiberos recedens. Valentia, colonia, III M. pass. a mari remota: flumen Turium, et tantundem a mari Saguntum civium Romanorum oppidum, fide nobile, flumen Vduva: regio Ilergaonum*. En tiempos de Plinio, la Albufera era el mayor lago de la Península, ocupaba 30.000 hectáreas, diez veces más de las que suma ahora. Aulo Gelio, en sus Noches Áticas, hace referencia a una laguna que muy posiblemente sea la Albufera al relatar la desaparición de la cierva de Sertorio –*Noct. Att.* XV, 22–. Incluso Rufo Festo Avieno –siglo IV d.C.– en su poema geográfico, *Ora Maritima*, incluye topónimos que pueden hacer pensar en la Albufera, de hecho, cuando se refiere al litoral valenciano alude a una zona pantanosa, el *Palus Naccararum* (marisma o laguna de los Nácaros), en cuyo centro había una isla con olivos consagrada a Minerva, que puede llegar a identificarse con la Albufera y el pueblo de El Palmar⁹.

4 En este sentido, es relevante el estudio de restos arqueológicos hallados en el río Turia y la Albufera. Vid. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A. *Las ánforas romanas de Valencia y de su entorno marítimo*, Valencia: Delegación Municipal de Cultura, Arqueología nº 3, 1984; RIBERA I LACOMBA, A. y FERNÁNDEZ, A. Prospecciones arqueológicas submarinas en la zona del Saler. En *Actas del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina* (Madrid 1985) 83-91. Aunque en referencia a pueblos prerromanos, nada obsta a la continuidad de estas labores. Vid. al respecto UROZ SÁEZ, J. La agricultura ibérica del Levante en su contexto mediterráneo. *Estudios de Economía Antigua en la Península Ibérica. Nuevas aportaciones. Studia Historica. Historia Antigua* 17 (1999) 59-85, pp. 63 y 72.

5 SALCEDO FERRÁNDIZ, S. Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y de sus aprovechamientos. *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura* 32.2 (abril-junio 1956) 77-88, p. 79.

6 RIBERA I LACOMBA, A. - JIMÉNEZ SALVADOR, J.L. *Valentia*, ciudad romana: su evidencia arqueológica. En: BELTRÁN FORTES J. y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. *Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas*, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, 77-120, p. 79.

7 Según RIBERA I LACOMBA, A. La fundación de Valencia y su impacto en el paisaje. *Historia de la ciudad II. Territorio, sociedad y patrimonio*, Valencia: Universitat de València, Servei de Publicacions, 2002, 29-54 p. 31, en la actualidad el área ocupada por la ciudad romana se halla a 5,5 km. es decir, 1 km. más lejos que hace dos milenios, lo que indica un lento pero continuo avance de la línea de costa debido al aluvión del Turia.

8 Se ha utilizado Caii Plinii Secundi. *Historia Naturalis* ex recensione I. HARDIVINI et recentiorum adnotationibus (tomus secundus) (Augusta Taurinorum 1831) p. 42, en particular, el autor afirma que “stagnum hodie Albufera vocatur”.

9 RIBERA I LACOMBA, A. - JIMÉNEZ SALVADOR, J.L. *Valentia, ciudad romana*, cit. p. 79. Según SCHULTEN, A. *Fontes Hispaniae Antiquae I*, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1922, p. 134 sería la entonces isla de El

En cualquier caso, es indudable que la principal característica de las más antiguas referencias al paisaje de Valencia es que siempre mencionan un entorno lagunar y pantanoso que tenía una extensión muy superior a la actual y que permitía el acceso de barcos hasta la misma ciudad de Valencia a través del Turia¹⁰. La poca profundidad de las aguas pudo suponer una limitación salvable por la utilización de naves de poco bordo que servirían para conectar con la tierra firme y para la pesca, que debió suponer una de las principales actividades económicas de la zona¹¹. A decir de Fernández Izquierdo¹², los restos que aparecen en la playa del Saler tienen su arranque cronológico en el momento en que se produce la fundación de la Valencia romana (2ª mitad del s. II a.C.)-. Siguiendo a García Bellido¹³, una posible representación del desarrollo de las actividades humanas en estas lagunas litorales levantinas es la mostrada por los vasos de Liria; en estos vasos hallados en Liria (Valencia), se recogen escenas cuyo entorno natural debe haber sido cualquiera de las charcas litorales de las cercanías de Valencia, en particular, en uno de los vasos se hallan casas construidas sobre el agua, barcas de escaso bordo y, lo más relevante, la representación de un ave estilizada y de diez peces, es más, no sólo en ese vaso, sino en el resto, los peces son el elemento más repetido y numeroso y con ello, muy probablemente, se destaca la principal actividad económica desarrollada en la zona. Aunque estos ejemplos se fechan en época de conquista romana (los vasos de Liria o la ayuda brindada por pescadores de la laguna situada en el murciano lago del Almarjal a las tropas de Escipión para conquistar la ciudad) la situación no variaría sustancialmente en época romana. Precisamente, de los pescadores del Almarjal

Palmar en la Albufera de Valencia, en el mismo sentido, LILLO CARPIO, P.A. Incidence de la religiosité et des mythes dans le processus de colonisation de La Méditerranée occidentale. En *Méditerranée* 62 (1996) 2-21, p. 15. En cambio para BLÁZQUEZ, A. *Ora Maritima. Festo Rufo Avieno*, Madrid: Impr. del Patronato de huérfanos de intendencia e intervención militares, 1923, p. 126, estaría en el estanque de Alcalá de Chivert en la provincia de Castellón. También se dice que el lago Nacaros se hallaría en la desembocadura del río Ebro FERNÁNDEZ NIETO, F.J. Beribaces, edetanos e ilercones (Pueblos pre-romanos en la actual provincia de Castellón). En *Zephyrus* 19-20 (1968) 116-142, siguiendo a ALCINA, J. "as ruinas romanas de Almenara (Castellón). En *BSCC* 26 (1959) 92-128, afirma que "la marisma de Las Naccaras hay que buscarla [...] en el lugar que hoy ocupan los estanques de Almenara".

10 RIBERA I LACOMBA, A. *Valentia (Hispania citerior)*, una fundación itálica de mediados del siglo II a.C. Novedades y complementos. En: UROZ, J. NOGUERA J.M. y COARELLI F., *Iberia e Italia. Modelos romanos de integración territorial*, Murcia: Tabularium, 2008, 169-198, p. 171, recoge una ilustración sobre el entorno de la ciudad de Valencia y su supuesta red de canales fluviales. IZQUIERDO I TUGAS, P. Introducció a l'arqueologia portuària romana de la Tarraconense. En [www. http://independent.academia.edu/PerelIzquierdoiTugas/Papers](http://independent.academia.edu/PerelIzquierdoiTugas/Papers), 443-455, p. 449. RIBERA I LACOMBA, A. - JIMÉNEZ SALVADOR, J.L. *Valentia, ciudad romana*, cit. p. 78.

11 PARODI ÁLVAREZ, M. Algunas notas sobre el papel de lagos, cit. p. 213.

12 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A. *Las ánforas romanas de Valencia*, cit., p. 105, según la autora, en tiempos romanos la ciudad de Valencia no poseía un puerto propiamente dicho a orillas del mar por las condiciones del terreno y porque parte del cargamento podía llegar a la ciudad remontando el río Turia. Los hallazgos submarinos en las aguas inmediatas a la ciudad corresponden a los restos propios de un desembarcadero, utilizando para ello las desembocaduras de los ríos y barrancos como lugares más propicios desde los que los productos, en ánforas y otros recipientes, remontaban hasta llegar a un punto cercano a la ciudad. A tal efecto también podría utilizarse la Albufera, que abarcaba mucha mayor extensión, llegando incluso hasta las cercanías de la ciudad. Este camino de la Albufera podría ser utilizado por las barcas que transportaban las ánforas desde la playa actual de El Saler hasta *Valentia*, ya que la zona de El Saler-Pinedo constituye un lugar muy abundante en ese tipo de cerámica.

13 GARCÍA BELLIDO, A. La navegación ibérica en la Antigüedad según los textos clásicos y la Arqueología. En *Estudios Geográficos* V, 16 (1944) 511-560, *passim*.

nos habla una inscripción que hemos tenido ocasión de estudiar¹⁴, se trata de CIL II, 5929: C(AIO) LAETILIO M(ARCI) F(ILIO) A[PALO] / II VIR(O) QUINQ(UENNALI) / LARES AUGUSTALES ET / MERCURIUM PISCATORES / ET PROPOLAE DE PECUN(IA) SUA / F(ACIENDUM) C(URAUERUNT) I(DEM) Q(UE) P(ROBAUERUNT); se trata del homenaje de una asociación de pescadores y revendedores de pescado a C. Laetilio¹⁵, duunviro quinquenal de la ciudad¹⁶, el epigrama incluye una dedicatoria votiva a los Lares Augustales y a Mercurio –Dios del comercio y patrono de colegios de mercaderes y comerciantes– circunstancia bastante común en los *collegia* por cuanto que junto a la veneración a un Dios protector se busca la defensa corporativa frente al intrusismo de pescadores privados. Para Santero¹⁷ no hay duda de que se trata de un *collegium* de pescadores y revendedores de pescado al por menor que formaban en Carthago Nova un colegio de *negotiatores* privados cuya actividad debía limitarse a la provincia o a un comercio interprovincial¹⁸. Asimismo, a decir de Santero¹⁹, fue el colegio en conjunto y no únicamente el *magister* el que votó la aprobación para erigir el monumento. Ya quedó suficientemente tratada la actividad de pesca y comercial llevada a cabo por esos pescadores, no obstante, resumimos a continuación alguna de las notas claves de su organización que nos servirán para dar soporte a la hipótesis sobre el origen y estructura de la comunidad de pescadores de El Palmar; no en vano, siguiendo a Fernández Izquierdo²⁰, “la ciudad romana de Valencia presenta un aspecto muy interesante y del que no se ha efectuado hasta hoy estudio alguno. Se trata de su representabilidad en el mundo comercial de época romana [...] existen numerosas lagunas por la falta de excavaciones tanto en el subsuelo de la ciudad como en sus aguas inmediatas”. En concreto, el análisis girará alrededor de estos dos puntos esenciales: La asociación de pescadores y la concesión de derechos de explotación exclusiva de pesca sobre lagos y la forma y naturaleza jurídica de dicha concesión.

14 LÁZARO GUILLAMÓN, C. Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana a la luz de una inscripción de Carthago Nova –CIL II, 5929–. En: BELLO RODRÍGUEZ, S. y ZAMORA MANZANO J.L. *El Derecho comercial, de Roma al Derecho moderno*, Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 425-439; igualmente en LÁZARO GUILLAMÓN, C. Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a Carthago Nova: Esempio di economia sociale? En *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 11 (2013) <http://www.dirittoestoria.it/11/memorie/Lazaro-Guillamon-Associazione-pescatori-commercianti-Carthago-Nova.htm>.

15 La inscripción es recogida por VIVES, J. *Inscripciones latinas de la España romana. Antología de 6800 textos*, Barcelona: Universidad de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1970, p. 167, con el número 1414 y entre inscripciones honorarias y monumentales que conmemoran a personajes ilustres, en este caso C. Laetilio hijo de C. Apalo. La inscripción aparece en una columna de mármol de un templo construido en Cartagena probablemente dedicado a Mercurio.

16 A decir de TORRENT, A. *Diccionario de Derecho romano*, Madrid: Edisofer, 2005, p. 297, s.v. *duoviri de iure dicundo*, se trata de los magistrados supremos locales que tienen competencias generales de gobierno, administrativas y financieras. Cada cinco años tenían encomendada la elaboración del censo y la revisión del *album decurionum* recibiendo en tales ocasiones la denominación de *duoviri quinquennales*.

17 SANTERO SATURNINO, J.M^a. *Asociaciones populares en Hispania romana*, Sevilla: Publ. de la Universidad de Sevilla, 1978, pp. 39 y 142.

18 En el mismo sentido WEST, L.C. *Imperial roman Spain. The objects of trade*, Oxford: B. Blackwell, 1929, p. 37, estos pescadores no prepararían el pescado para exportarlo, es decir, no se dedicarían al comercio a gran escala de forma directa.

19 SANTERO SATURNINO, J.M^a. *Asociaciones populares*, cit. p. 59.

20 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A. *Las ánforas romanas de Valencia*, cit. p. 97, es más, la autora afirma (p. 100) que junto con el vino, el producto más abundante en Valencia y aguas próximas son las salazones y conservas de pescado.

Como afirma Marzano²¹, en la Roma imperial, muchas profesiones –entre ellas la de pescadores y vendedores de pescado– se organizaron en *collegia* y designaron como patronos a personajes más ricos y poderosos, dichas asociaciones tuvieron un relevante papel en el apoyo a las actividad profesional privada ya que permitía el beneficio del trabajo en red. En la epigrafía se encuentran inscripciones (esencialmente funerarias) que hacen referencia al oficio de *piscator* o *piscatrix*, igualmente, aunque no muy abundantes, algunas inscripciones recogen testimonio de asociaciones de pescadores. Siguiendo esta estela, ¿por qué no una asociación de pescadores en la Albufera de la Valencia romana? A decir de Cordero Rivera²², la continuidad de los *collegia* romanos en la Península Ibérica se ve interrumpida por las nuevas estructuras socio-económicas de la época visigoda y posterior islámica. Sin embargo, quizá esta última apreciación tan generalista no pueda decirse de o aplicarse a todos los *collegia*, entre otras circunstancias porque “el estudio del asociacionismo durante la Edad Media implica el manejo de una bibliografía específica caracterizada por el localismo, el escaso rigor científico y unos planteamientos ideológicamente conservadores”. Se aduce igualmente una abundante legislación en la España medieval de marcado carácter anticorporativo –fenómeno idéntico y general en el resto de reinos europeos–, sin embargo, según González Arce²³, no se produjo una prohibición genérica de corporaciones y gremios por parte de los monarcas españoles, prueba de ello es la proliferación de corporaciones fundadas y privilegiadas por aquéllos, de forma que es más correcto hablar de una “limitación gremial” que no de prohibición en el contexto de otro fenómeno limitativo más amplio contra todo tipo de asociaciones con fines diversos –sí que hubo persecución de corporaciones y gremios que incurrieron en abusos laborales, económicos y políticos–. En cualquier caso, aunque no hay acuerdo doctrinal en cuanto al origen de las cofradías de pescadores, éstas constituyen según Bárcena²⁴ “sin duda alguna, el órgano de más remota tradición asociativa que actualmente se conserva en el país”. A decir de Barrio García²⁵, los antecedentes históricos de las cofradías de pescadores son remotos, agrupaban a todos aquellos que se dedicaban a la actividad extractiva de pesca conformando asociaciones que se desligaron del tronco común de las cofradías religioso-benéficas al tener características definitorias y

21 MARZANO, A. *Harvesting the sea: The exploitation of marine resources in the Roman Mediterranean*, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 38ss.

22 CORDERO RIVERA, J. Asociacionismo popular: Gremios, cofradías, hermandades y hospitales. En: DE LA IGLESIA DUARTE, J.I. *La vida cotidiana en la Edad Media. VIII Semana de Estudios Medievales*, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1998, 387-399, pp. 387-388.

23 GONZÁLEZ ARCE, J.D. Asociacionismo y restricciones corporativas en la España medieval (siglos XIII-XV). En *Investigaciones de Historia Económica* 10 (2008) 9-34, p. 10. Es más, el autor establece un claro paralelismo entre la Roma clásica y la España de los siglos XII al XV, donde la recepción del Derecho romano propició la prohibición de cofradías subversivas de forma genérica, reiterativa y retórica, si bien este hecho, como en Roma, no supondría que la prohibición se extendiese a las corporaciones lícitas; en definitiva, “no es casualidad la coincidencia entre la recepción del Derecho común y la proliferación de normativa anticorporativa” (*loc. ult. cit.* p. 26).

24 BÁRCENA, A. Las cofradías sindicales de pescadores. En *Revista de Estudios Sindicales* (1974) 116-134, p. 117.

25 BARRIO GARCÍA, G.A. Las cofradías de pescadores en el Derecho español. En *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 1998 (2) 161-188, pp. 162-163. El autor afirma que su antigüedad es casi inmemorial remontándose al siglo XI; los primeros testimonios escritos se hallan en el siglo XII en la referencia a existencia de cofradías en Bayona (tanto en Francia como en España). Sin embargo, muy posiblemente, el origen todavía sea más antiguo.

propias, dependientes de la vida marinera, que las distinguen del resto de gremios y organizaciones de su época. Sin embargo, como se ha afirmado, la doctrina no es pacífica²⁶ aunque, en nuestra opinión, muy probablemente las asociaciones de personas entorno a la actividad pesquera se remontan a tiempos prerromanos, las propias características de las faenas del mar hacen necesaria esa vinculación y colectivización laboral.

En el caso de la Albufera, la primera referencia rigurosamente histórica y documentada proviene del rey Jaume I, quien se reserva para su patrimonio personal el lago y su Dehesa²⁷, y así se lo hace saber al común de pescadores de la Ciudad de Valencia –así se recoge en el Llibre de Repartiments, disposición que se copia en 1568, en valenciano, en el registro llamado Seqüela del libro negro de la Corte de la Baylía General-. Los orígenes de la comunidad de pescadores de la Albufera resultan ciertamente oscuros²⁸, documentalmente, la primera referencia explícita a la comunidad de pescadores de la Albufera que existe se encuentra en el Privilegio que Martín I el Humano dicta el 11 de julio de 1404²⁹ confirmando a la comunidad de pescadores de la Albufera la serie de capítulos que éstos presentan

26 TABOADA MELLA, M^a.S. Las prácticas contables de las cofradías de pescadores gallegas. La coerción como vehículo de institucionalización cultural normativa. En *Revista Galega de Economía* 16, 2 (2007) 1-26, pp. 6-7, n.12, recoge la bibliografía más autorizada en relación con la controversia sobre el origen de las cofradías de pescadores, así, CALO, F. Prehistoria e Idade Antiga. En *Historia Xeral de Galicia*, Vigo: Promocions Culturais Galegas, 1997, 7-91, lo sitúa entre la prehistoria y la Edad Antigua; en los *collegia* romanos de los siglos III-IV lo ubica FILGUEIRA, M.A. Gremios. En *Gran Enciclopedia Gallega*, t. XVI (1974) 214-216; RUMEU DE ARMAS, A. *Historia de la previsión social en España. Cofradías-gremios-hermandades-montepíos*, Barcelona: El Albir, 1981, lo concreta en el siglo X; un poco más adelante, en el siglo XI, lo sitúan PÉREZ, A. Las cofradías de pescadores: una institución original. En *El Campo* 97 (enero-marzo 1985) 101-106, VILA, J.M. El devenir histórico de las cofradías de pescadores y las prioridades de actuación de las cofradías en el momento actual, *Comunicación presentada con motivo dunhas xornadas organizadas pola Consellería de Pesca*, Santiago de Compostela, y MOREDA, G. Las cofradías de pescadores en España. En *Revista Internacional del Trabajo* 2 (1966) 586-549; entre los siglos XI y XII lo concretan BIKANDI, J.J. Cofradías de pescadores. En *VVAA* vol. VI (1989) 19-44, y ASTORKIZA, K. - DEL VALLE, I. - ASTORKIZA, I. Fisheries Policy and the Cofradías in the Basque Country: the Case of Albacorde and Anchovy. En *Límites de la Travesía. VII Conferencia de la Asociación Internacional para el Estudio de la Característica Común*, Vancouver: B.C. Universidad Simon Fraser, 1998; entre los siglos XII y XIII: LÓPEZ, A. Idade Media. En *Historia Xeral de Galicia*, Vigo: Promocions Culturais Galegas, 1997, 95-204; por último, REBOLLO, M. - FALCÓN, R. - LÓPEZ, M. *Naturaleza y régimen jurídico de las cofradías de pescadores*, Córdoba: Universidad de Córdoba, 1996, lo sitúan en el siglo XV.

27 Desde ese momento la Albufera y su Dehesa pertenecen al Patrimonio Real, salvo breves períodos históricos: de 1708 a 1761 perteneció al Conde de Torres y Marqués de Cullera; de 1798 a 1808 a Godoy; en 1812 Napoleón nombró al mariscal Suchet Duque y Señor de la Albufera; hasta que en 1865 pasó al patrimonio de la Nación y en 1911 fue adquirida por el Ayuntamiento de Valencia al que actualmente pertenece. En relación con la historia de la Albufera desde la Reconquista hasta nuestros días *vid.* SALCEDO FERRÁNDIZ, S. *Estudio histórico-jurídico*, cit. pp. 83ss.

28 CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca en la Albufera de Valencia. En *Instituciones de Derecho Privado valenciano*, Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, 323-335, p. 325.

29 FREIRE MOLINER, M.J. El libro de registro de los privilegios de la Albufera de Valencia, Edición e Índices, Zaragoza: Anubar, 1995, n° 60, pp. 95-107. En particular: A la vostra gran senyoria humilment suplicant demostren los jurats e prohomens pescadors de la Albufera de Valencia que com aquells e predecessor lurs en lur offici practicats e usants en lo regimient de aquell e experiencia los haja declarat quals ne quines coses son profitoses o dapnoses a les regalies vostres e a presente de la senyora reyna dona Yolant del alt senyor en Johan, de bona memoria relict a e conservacio del bon estament del comu desls dits pescadors axi de mar com de la Albufera [...]. Plau al senyor rey si e segons, que mils de aquells han usat. Primerament, senyor, que jassia los dits iurats ab privilegis reals hajen plen e bastant poder de jutgar totes e sengles questions que son e sdevenen per rao del peix

basados en *privilegios de sus antecesores* –la cursiva es nuestra-. A decir de Caruana³⁰ se trata de la primera vez que se recoge en un documento legislativo la referencia explícita al “Común de Pescadores”, según la autora, “constituye el solemne reconocimiento de su personalidad como comunidad, por la facultad concedida –aplicación y modificación de ordenanzas- y por el alcance verdaderamente normativo de que se reviste a la hasta entonces amorfa asociación de los pescadores de la Albufera”. Quizá no sea muy afortunada la expresión de la autora cuando se refiere a que la asociación de pescadores de la Albufera fuera, hasta ese momento “amorfa”, dado que el privilegio no hace más que reconocer lo que había sido costumbre –*com aquells e predecessor lurs en lur offici practicats*- a modo de “positivización” del derecho consuetudinario. En opinión de Clemente Meoro³¹, probablemente con anterioridad cabe hablar de una realidad corporativa entre los pescadores de la Albufera, que si bien no se recoge en los documentos relativos al lago, sí que se contiene implícita. Sirvan de claro ejemplo el Privilegio de Pedro I de Valencia (o III El Grande de Aragón) de 30 de noviembre de 1283 que concede a los pescadores de la Albufera un cierto ámbito de autonomía concretado en la posibilidad de autorregular sus intereses a través de cuatro prohombres, elegidos anualmente entre los pescadores por el Bayle o por el comprador de las rentas de la Albufera, con el mandato de vigilar durante el año de su elección la caza y la pesca de la Albufera y cuanto a ella concierne. A decir de Sanmartín Arce³², el hecho de que el privilegio se promulgue a solicitud de *piscatores Albufariae Valentiae* nos da muestra de la entidad y vigor que poseía el grupo de pescadores en la segunda mitad del siglo XIII aunque no conste formalmente el reconocimiento de su asociación separada o distinta del *Comú de Pescadores de la Ciutat de Valencia* en la que se comprendían tanto los pescadores del mar como los de la Albufera³³.

El privilegio de Pedro IV de 19 de julio de 1337 donde se aprueban a favor de los pescadores de la Albufera una serie de capítulos que contienen las gracias y privilegios concedidos por sus antecesores establece, además, que [...] *quod iurati pesquerie, qui anno quolibet in principio vendicionis quinq[ue] nostre iurant in posse nostri baiuli generalis, ordinant et ordinare teneatur pesquerias Albufaire supradicte, pro ut hactenus est fieri usitatum ad commodum regaliarum nostrarum; et quod possint, si eis bene videbitur, in ordinationibus faciendis per eos penas ponere de consilio et assensu nostri bajuli supradicti [...]*, esto es, nuevamente a petición de los pescadores de la Albufera, el Rey ordena que los Jurados (aparece por primera vez este término para designar a los pescadores a los que se asignan funciones de guarda y vigilancia) ordenen la pesca *como hasta aquí ha sido costumbre* –la cursiva es nuestra-, así como que establezcan las penas correspondientes, es decir, se reconoce en el articulado del privilegio que la decisión de las controversias y la ordenación de la pesca se realice según costumbre antigua –*fieri usitatum*-. En definitiva, el sustrato

e pesquera, axí de la mar com de la Albufera, dels pescadors entre si companyers lurs e encara altres estrangers sens alcun salari.

30 CARUANA TOMÁS, C. Estudio histórico y jurídico, cit. p. 137.

31 CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca, cit. p. 327.

32 SANMARTÍN ARCE, R. *La Albufera y sus hombres*, Madrid: Akal Universitaria, 1982, p. 224.

33 A decir de SANMARTÍN ARCE, R. *La Albufera*, cit. p. 225, en el 1378 el Bayle general provee que los jurados de los pescadores de la Albufera “no se entremetan en las cuestiones de los que pescan en el mar”.

normativo comunitario consuetudinario parece haber existido ya antes de que oficialmente se mencionara la comunidad. De esta forma, ya desde antiguo y según costumbre de la comunidad de pescadores, ésta ha ejercido el control de la pesca en el lago y ha disfrutado de sus aprovechamientos pesqueros y ello no por expresa concesión del titular de la Albufera, sino más bien por la fuerza de la costumbre³⁴. Por tanto, no es aventurado suponer que, desde antiguo, la pesca y el aprovechamiento de esta labor extractiva ha sido elemento constante en el lago de la Albufera y que, aun sin “derecho positivo” los pescadores de la Albufera y, en particular, de El Palmar han organizado la práctica y gestión de esta actividad principal tanto para su sustento como para la comercialización de los excedentes con un soporte normativo (*lex collegii*). En este contexto corresponde sumar otros indicios a los ya analizados que pudieran reflejar los orígenes más remotos de la comunidad de pescadores. Así, por cuanto respecta a su organización, hay que distinguir tres órganos esenciales: La *Junta General*, la *Junta Directiva* y el *Consell Assessor*”. La *Junta General* está formada por todos los miembros de la comunidad y se reúne en juntas ordinarias y extraordinarias; las ordinarias pueden ser: de *capítols* –donde se adoptan acuerdos en torno al ingreso de nuevos miembros, depósitos y donaciones de *redolins*³⁵ y se aprueban las normas que rigen internamente la comunidad–, de *redolins* –donde se lleva a cabo el sorteo del mismo nombre en cuya virtud se determinan los puestos de pesca o calada que corresponderán para ese año a cada uno de los miembros de la comunidad–, o de *cónters* –donde se rinden cuentas y toman posesión los cargos de la *Junta Directiva*–. La *Junta Directiva* es el órgano ejecutivo, formado por los Jurados primero y segundo, los Secretarios primero y segundo, el Tesorero y seis Vocales. Sus miembros son elegidos por cuatro años. El *Consell Assessor*, está formado por pescadores elegidos por los Jurados entre los más ancianos, expertos y prestigiosos y sus funciones son: asesorar a los Jurados cuando éstos le pidan consejo y entender en primera instancia de las infracciones cometidas por comuneros. No escapa el hecho de que la organización de los elementos personales de la comunidad no está muy alejada de la organización de los *collegia* romanos *ad exemplum rei publicae*. La Junta General bien sería la Asamblea general (*populus*) de todos los asociados (*populus collegii*). El órgano ejecutivo, es decir, la *Junta Directiva*, cuadraría con los *syndici*, representantes permanentes, y los *actores*, representantes con carácter especial (*magistratus*). El *Consell Assessor* bien pudiera ser el *ordo collegii* (*senatus*), se trata de un grupo más reducido y se constituía como órgano asesor.

34 CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca, cit. p. 331.

35 El término *redolí* en la legislación foral de principios del siglo XIV designaba el procedimiento de elección de Justicias municipales por medio de pequeñas bolas huecas de cera engomada en cuyo interior se introducía un papel con el nombre de los candidatos, dejando su designación al azar de la extracción. En el concreto caso de la Albufera, cuando se hace referencia al *redolí* se alude al concreto puesto o caladero de pesca que corresponde por sorteo anual a cada pescador a la vez que al derecho de pesca inherente a ser miembro de la comunidad, dado que la condición de miembro es lo que otorga el derecho de participar en el sorteo de *redolins*. El derecho de pescar –es decir, el concreto *redolí*– se puede donar a otro pescador y también depositar, por ejemplo, por haber decidido su propietario no pescar en esa temporada, de forma que el depósito garantiza la permanencia. Vid. SANMARTÍN ARCE, R. *La Albufera*, cit. pp. 161ss.

Respecto del segundo punto: la concesión de derechos de explotación exclusiva y la naturaleza jurídica de dicha concesión, como afirma Mommsen³⁶, los romanos tuvieron el espíritu de empresa para la pesca, por tanto, entra dentro de esta forma de entender la actividad el hecho de que se produjeran concesiones de pesca exclusiva sobre estanques y lagos tal y como advierte D. 43.14.1.7³⁷ -ubicado en el título XIV del libro XLIII sobre el interdicto *ut in flumine publico navigare liceat*- donde Ulpiano da cuenta de las opiniones de Labeón y Sabino en cuanto a la protección vía útil a través del interdicto si se prohibiera pescar a quien tuvo en arrendamiento un lago o estanque, del mismo modo que si el lago o estanque fuera arrendado por el municipio³⁸. A decir de Castán Pérez-Gómez³⁹, la administración pública romana manifiesta un interés fiscal⁴⁰ en las pescas exclusivas en lagos y estanques públicos, dado que estos pueden arrendarse a los particulares a modo de concesión de la explotación exclusiva de la pesca. Estas concesiones de pesca exclusiva se circunscriban a lagos y estanques⁴¹, conviene tener en cuenta que, desde el fundamento de la libertad de ríos y mares, no parece posible prohibir la pesca marítima a tenor del sentido de D. 47.10.13.7, ubicado en el título dedicado a las injurias y a los libelos difamatorios, donde Ulpiano, siguiendo la *opinio* de Pomponio, concede el ejercicio de una *actio iniuriarum* a quien se le prohibiera la pesca, al igual que si se impidiera a alguien sentarse o lavarse en lugar público, que se sentara en las gradas del anfiteatro, que condujera un carro, que conversara o que usara de cosa propia. Como consecuencia, no puede prohibirse a nadie que pesque frente a una propiedad privada siempre y cuando no entre en predio ajeno; la pesca sólo puede ser prohibida en los lagos, por tanto, no carece de sentido lógico el hecho de que únicamente en lagos y estanques quepa hablar de concesiones exclusivas para la explotación pesquera. Como hemos tenido ocasión de verificar, la Albufera de Valencia tiene, a todos los efectos, la consideración de lago, por tanto, no debe sorprendernos el hecho de que hubiera podido ser objeto de concesión de explotación exclusiva de pesca.

36 MOMMSEN, Th, Sopra una iscrizione scoperta in Frisia. En *BIDR* 2 (1889) p. 131.

37 (Ulpianus 68 ad ed). Publicano plane, qui lacum vel stagnum conduxit, si piscari prohibeatur, utile interdictum competere Sabinus consentit: et ita Labeo. ergo et si a municipibus conductum habeat, aequissimum erit ob vectigalis favorem interdicto eum tueri.

38 En opinión de MATEO, A. *Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander: Universidad de Cantabria, 1999, p. 178, Ulpiano realiza una extensión a un supuesto de arrendamiento de un lago municipal del interdicto que Sabino y Labeón ofrecieron a favor de un publicano, en definitiva, se trata de la adopción de las formas procesales y extraprocesales de la contratación pública romana en el ámbito de la contratación pública municipal.

39 CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S. Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho romano, Madrid: Dykinson, 1996, pp. 219ss.

40 Juvenal, *Sat.* IV, 46-56, la administración pública solía ejercitar una industria pesquera que era tutelada escrupulosamente.

41 Sobre los ríos, exclusivamente podemos hablar del denominado *ius praeoccupationis* de D. 41.3.45pr y D. 44.3.7, textos que permiten el reconocimiento del derecho exclusivo de pesca en un punto determinado de un río a quien la hubiera ejercitado durante años en ese punto y en tanto la pesca fuera ejercitada. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S. Régimen jurídico de las concesiones administrativas, cit. p. 229 afirma que las fuentes no aluden a concesiones sobre pesca marítima.

En cuanto a la forma jurídica de la concesión, Castán Pérez-Gómez defiende que dichas concesiones se regulaban mediante una *locatio conductio* pública⁴². En efecto, en el catálogo de los *publica vectigalia* aparece citado el *vectigal piscarium* –D. 50.16.17.1 (Ulpianus 10 ad ed.)– “*publica*” *vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus vel venalium rerum, item salinarum et metallorum et piscariorum*-. Además, estos derechos de pesca podían ser arrendados tanto por individuos particulares –normalmente, grupos de pescadores libres- como por contratistas de la concesión de pesca⁴³. En definitiva, desde el período republicano la administración pública romana sacó a concurso los servicios públicos que no podían ser explotados directamente, y como hemos dicho en líneas anteriores, dicha concesión tomaba la forma de una *locatio-conductio* que particularmente consiste en un contrato entre el *populus romanus* y los particulares –asociaciones, etc.- a los que se adjudica la concesión contra la satisfacción del *vectigal* correspondiente. Entre las concesiones administrativas en general se encuentran, obviamente, las concesiones del derecho de pesca. Desde un punto de vista general Mentxaka⁴⁴ manifiesta que las fuentes epigráficas recogen, en el caso de Hispania, “la realidad fáctica del fenómeno asociativo”, esencialmente el cap. 74 de la *Lex Irnitana* proporciona datos muy valiosos sobre la aplicación de la legislación romana⁴⁵ en las provincias hispánicas. Del cap. 74 de dicha *Lex* se infiere que en los municipios provinciales en los que existiera ley municipal, se encargaban de la vigilancia y control de los colegios profesionales los magistrados municipales, no obstante, la autorización para constituir un *collegium* a finales del siglo I d.C. todavía correspondía al Senado; en aquellas provincias donde no existieran municipios con ley municipal propia, la vigilancia y control correspondería al mismo Senado. En las colonias y en los municipios de derecho latino⁴⁶ nos vamos a encontrar con

42 CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S. *Régimen jurídico*, cit. pp. 220-221, así se desprende de una inscripción hallada en Leeuwarden –en la Germania Inferior– que se recoge en CIL XIII, 8830 y que transcribimos: *DEADE HLUDANAE CONDUCTORES PISCATUS MANCIPE(Q) Q(UINTO) VALERIO SECU(ND)O V(OTUM) S(OLVERUNT) L(IBENTES) M(ERITO)*, en particular, nos ofrece testimonio de cómo una *societas publicanorum* por medio de su *manceps* Quinto Valerio Secundo, tenía en arrendamiento la pesca sobre la costa de Frisia. En el mismo sentido, Festo, s.v. *Lacus Lucrinus* (Lach, p. 108): habla de una concesión de pesca de un lago realizada a través de una *locatio-conductio*: *Lacus Lucrinus in vectigalibus publicis primus locantur fruendus ominis boni gratia*. Es más, el órgano que se encargaba de realizar estas concesiones sería con alto grado de probabilidad los censores romanos, así lo afirma CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S. *Régimen jurídico*, cit. p. 221, quien sigue a MOMMSEN, Th. *Sopra una iscrizione*, cit. p. 131, al recordar que Polibio afirmaba que los ríos y lagos eran arrendados por los censores romanos. Durante la república eran efectivamente los encargados del demanio, no hay noticias de que lo hiciera otra magistratura, sin embargo, durante el imperio las dudas aumentan, quizá el *curator aquarum*, el *curator rei publicae*...

43 En este sentido vid. PARÁSSOGLU, G.M. A Lease of Fishing Rights. En *Aegyptus* 67.1 (1987) 87-93, p. 87. ROSTOVITZEF, M.I. *Historia social y económica del imperio romano II*, Madrid: Espasa-Calpe, 1962, p. 170-171 n. 85, recuerda una inscripción greco-latina en Istrus que contiene los autos de un pleito que versa sobre el antiguo derecho de pesca de un templo y el mismo derecho que pretenden unos publicanos cuya pretensión es la que prospera.

44 MENTXAKA, R. El derecho de asociación en Roma a la luz del cap. 74 de la *Lex Irnitana*. En *BIDR* 98-99 (1995-1996) 199-218, p. 199.

45 Sobre el desarrollo de la legislación romana en materia de asociaciones remitimos a lo recogido por MENTXAKA, R. El derecho de asociación, cit. pp. 202ss.

46 *Valentia* aparece mencionada en Plinio *Nat. Hist.* III, 3, 20, parece ser que se trata del único texto literario que precisa su estatus de colonia, hay que tener en cuenta que la obra se acabó de redactar poco después de que el emperador Vespasiano otorgara el derecho latino a todos los habitantes de Hispania. Sobre esta referencia

unos magistrados –los duunviros– encargados de efectuar las concesiones administrativas en calidad de representantes del municipio, en definitiva eran los magistrados locales ordinarios –los duunviros– los titulares de la *potestas locandi*⁴⁷.

Por lo que respecta a la comunidad de pescadores de El Palmar, ésta ostenta un derecho de aprovechamiento pesquero sobre un bien ajeno por el que paga un canon, en principio fue de un quinto de lo pescado –Real Privilegio dado en Morella el 21 de enero de 1250 por Jaime I que veremos a continuación–, después pasó a ser un décimo –acuerdo del Procurador del Real Patrimonio de 1835– y finalmente se concretó en el pago de una cantidad periódica fija en virtud de las escrituras otorgadas el 1 de octubre de 1857 entre el Bayle General, autorizado para ello por Isabel II, y la comunidad de pescadores de El Palmar. En definitiva, está claro que la relación jurídica entre el titular de la Albufera y la comunidad de pescadores existe desde mucho antes de que la Albufera pasara a ser propiedad del Ayuntamiento de Valencia y parece tener un origen consuetudinario⁴⁸. Ahora bien, cuál es la naturaleza jurídica de esa concesión. Profundicemos un poco más: la primera noticia de pago de un canon por el aprovechamiento se recoge en el único fuero⁴⁹ del rey Jaime I que hace referencia a la pesca en la Albufera (Fur IX-xxxiv-59) sobre la quinta parte de lo pescado que se encuentra en la rúbrica *De leuda e hostalatge e altres drets reals. Y de corredors*⁵⁰:

Iacobus I, rex.- Los pescadors vehins e estrayns no donen a Nós ne als nostres successors o alguns altres, alcuna cosa d'alcuns peixs, los quals pendran en aygües dolçes e en estayns, e en basses e en rius de la ciutat de València ne del terme de aquella, mas

y la de Pomponio Mela (II, 7, 124) pueden verse los comentarios de PENA, M^a J. Problemas históricos en torno a la fundación de Valentia. En: JIMÉNEZ J.L. y Ribera A. *Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania*, Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 2002, 267-278, p. 277. La onomástica es uno de los argumentos utilizados por algunos autores para confirmar la fundación de la ciudad como colonia latina, MARÍN DÍAZ, M^a A. *Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana*, Granada: Universidad de Granada, 1988, p. 139. CORELL I VICENT, J. *Inscripcions romanes del País Valencià. I. (Saguntum i el seu territori)*, Valencia: Universitat de València, 2002, pp. 27-28 recoge la controversia doctrinal entre quienes proponen que se trató de una colonia romana y los que opinan que la ciudad se conformó como colonia latina, el mismo autor (p. 33) considera que se trata de una colonia latina desde el mismo momento de su fundación.

47 Vid. MACKIE, N. Local Administration in Roman Spain AD 14-212. En *British Archaeological Reports* 172 (1983) p. 165.

48 Así, CLEMENTE MEORO, M.E. *Los aprovechamientos de pesca*, cit. p. 332.

49 La edición utilizada de los Furs es: COLON, G. - GARCIA, A. *Furs de València*, 8 vols. Barcelona: Barcino 1980-1999, de los vols. 9 a 11 COLON, G. - GARCIA, V. Barcelona: Barcino, 2002-2007. El otro fuero del rey Jaime I que recoge una referencia explícita a la Albufera es el Fur IX-xxxiv-62, donde se determina gratuita la caza en el paraje de la Albufera y que también se encuentra incluido en la rúbrica *De leuda e hostalatge e altres drets reals. Y de corredors*.

50 En los textos de la rúbrica se recogía qué era la “leuda” (o más correctamente “lleuda” en valenciano y “leзда” en castellano –según la RAE, tributo o impuesto que grava las mercancías–) de la ciudad de Valencia y una lista de más de cien artículos sometidos a esta tarifa que se acompañaban de la correspondiente valoración impositiva. A decir de COLON, G. - GARCIA, A. *Furs de València*, cit. vol. VIII, p. 142, n. 1, esta rúbrica no tiene concordancia con el Código de Justiniano, pero sí con la Costum de Tortosa IX, XIX *De les leudes*. PERE HIERONI TARAÇONA, *Institucions dels Furs, y Privilegis del Regne de Valencia*, Valencia: Estampa de Pedro de Guete, 1580, p. 94, bajo la nota marginal *franquea del peix* y en la rúbrica del libro I, título XV dedicada a los *diversos tributs*, recoge que *Los peixcadors de qualssevol aygues dolces no donen ningun rebut, excepto los de la mar, que dehuen donar al Rey la deena part: y los de la Albufera, la quinta part, y no mes [...]*.

aquells peixs hajan franchs e liures per totes lurs voluntats a fer, mas de tots los altres peixs, los quals pendran e pescaran en la Albufera de la ciutat de València, donen a Nós la quinta part e no més en negun temps; mas dels peys los quals pendran en la mar donen solament per tots temps la deena part e no més.

¿Es posible la relación entre este canon de la quinta parte de lo pescado y el *vectigal piscariarum*? Recordemos que el término *vectigalia (populi Romani)* se usaba para indicar los ingresos periódicos o rentas públicas, consistentes en los cánones que deben pagar los arrendatarios del *ager publicus* o quienes explotan las minas o las pesquerías así como impuestos de aduana, sobre manumisiones, ventas públicas o herencias –recordemos D. 50.16.17.1–. Simplemente con la revisión del *Repertori General* de Ginart⁵¹ observamos que la impronta del Derecho romano es muy clara. Ginart afirma taxativamente que *Peixcar cascu pot en la ribera del Mar. foro 8. rub. de rerum divis. fol 208*, y reenvía a lo que así confirma el Fur IX-XII-8 que dispone que (Iacobus I, rex).– *A negú no és vedat que no-s puscha acostar a la riba de la mar per rahó de pescar*, texto que se recibe casi literalmente de D. 1.8.4pr⁵² –ubicado en el título VIII del libro I del Digesto dedicado a la división y cualidad de las cosas– donde según Marciano, no puede prohibirse la pesca en aguas públicas en tanto el pescador no vulnere las casas de recreo, edificios o monumentos. El mar es de derecho de gentes, tal y como señaló el emperador Pío en un rescripto dirigido a los pescadores Formianos y Capenates. Marciano continua con la calificación como cosa común de casi todos los ríos y puertos –D. 1.8.4.1 (Marcianus 3 inst) *Sed flumina paene omnia et portus publica sunt*–; así como del tenor de las Instituta, en particular, del título I del libro II dedicado a la división de las cosas –Inst. 2.1.1–, donde se dispone que: *Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis absteineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare*, esto es, se consideran cosas comunes el aire, el agua corriente y el mar –así como sus costas–, únicamente se puede prohibir el acceso a predios y monumentos dado que son susceptibles de propiedad privada. En cuanto al uso de esas cosas y del mismo mar, dispone en Inst. 2.1.5⁵³ que son de carácter público, de forma que el pescador puede construirse una cabaña en las costas para albergarse o por ejemplo secar las redes. Por lo que respecta a los ríos y puertos –Inst. 2.1.2– preceptúa que: *Flumina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in portibus fluminibusque*, es decir, todos pueden pescar en ríos y puertos libremente dado que son públicos. En cuanto al uso

51 GINART N.B. *Repertori General y Breu Sumari per orde alphabetich de totes les matèries dels Furs de Valencia, fins les Corts del Any 1604 inclusive*, y dels Privilegis de dita Ciutat y Regne, Valencia: Pere Patricio Mey, 1608, p. 175.

52 (Marcianus 3 Inst).– *Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen ullius et aedificiis et monumentis absteineatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit*. En este sentido Vid. COLON, G. – GARCIA, A. *Furs de València*, cit. vol. VII, p. 161, nn.1 y 2 al texto.

53 *Litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est, casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia siccare et ex mare deducere. proprietates autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiusdem iuris esse cuius et mare, et quae subiacent mari terra vel arena*.

de las riberas y del propio río dispone en Inst. 2.1.4⁵⁴ que, además de la libre navegación, se puede atracar libremente la barca así como atar maromas a los árboles ribereños, sin embargo, es de naturaleza privada la propiedad de los predios ribereños y de los árboles nacidos en éstos⁵⁵. En la misma línea, Ginart continúa refiriendo que *Peixcar cascu pot en los rius, Mar, estanchs, y aygues dolces etc. sens impediment algu. for 13. eod. fol. 208. Y sens pagar dret algu. for. 59. rub. de lleuda. Etc. Fol. 255*, en este caso la llamada es, en primer lugar, al Fur IX-XII-13⁵⁶ y posteriormente al ya analizado Fur IX-XXXIV-59; en cuanto al primero sus fuentes siguen siendo Inst. 2.1.5 y D. 1.8.5pr. Lo mismo ocurre con las sucesivas afirmaciones de Ginart: *Peixcar ningu pot en la Albufera, sens pagar dret al Rey. eod. de lleuda, etc. Peixcadors poden fer cases en la ribera del Mar, y seran sehues ab lo fol. eod. for. 13. rub. de rerum diviss. fol. 208. Peixcadors del peix que peixcaran en la Albufera, dehuen lo quint. for. 59. rub. de lleuda, etc. fol. 255*.

Si la recepción del Derecho romano se produjo de forma tan directa, ¿por qué no pensar en la continuidad de la estructura asociativa romana? A decir de Clemente Meoro⁵⁷, el caso de la Albufera se trata de un supuesto muy particular que no resulta equiparable a ninguno de los actualmente existentes y cuyo contenido ha venido determinado por la costumbre, intentar aplicar una de las actuales categorías no deja de ser anacrónico, es más, califica el autor de conceptualismo huero al intento de encontrar coincidencias dogmáticas entre las figuras del Antiguo Régimen y aun de la Edad Media y las costumbres inmemoriales por las que se han desenvuelto las relaciones entre los sucesivos propietarios de la Albufera y la comunidad. La relación jurídica la describe el autor como de carácter real en virtud de la cual tiene la comunidad derecho a aprovechar la pesca del lago con arreglo a normas por ella misma dadas, con carácter perpetuo⁵⁸. En este contexto, no puede ponerse excesiva objeción al paralelismo entre el *vectigal piscariarum* y este canon pagado al municipio... Pensemos en sede de costumbre inmemorial... Según Clemente Meoro⁵⁹ esta comunidad es de tipo germánico⁶⁰ dado que no existen cuotas, los comuneros se encuentran unidos por vínculos de carácter personal y no resulta divisible ya que la comunidad no se rige por

54 *Riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietates earum illorum est quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in iisdem natae eorundem sunt.*

55 En el contexto de los Furs de València, es de notar, además, la concordancia con Fur IV-XI-11 (Iacobus I, rex).- Los ribatges de la mar, qui's tenrran ab lo camp que serà venut, no sien comptats en mesura ne en compte d'aquel camp venut, car no són de negú, mas per dret natural deuen servir a tots, axí com carreres públiques o camins públics, que a decir de COLON, G. - GARCIA, A. Furs de València, cit. vol. IV, p. 144, n.1 al texto se recibe literalmente de C. 18.1.51.

56 (Iacobus I, rex).- Cascú ha laer e poder de pescar en mar e en estayns e en aygües dolces e salades liurament e francament, tretes les albuferes nostres reyalas, en les quals nengú no pusque pescar si no dóna a nós nostre dret. E ls pescadors pusquen fer cases e l ribatge de la mar en les quals se pusquen reebre e recüller. E si alcú bastirà e hedificarà cases e l ribatge de la mar, aquell sia senyor del sòl e de la casa mentre que aquella casa durarà. E quant la casa serà desfeita aquell loch sia tornat axí públic e comú, com si negun temps no y hagués casa ne hedifici estat.

57 CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca, cit. p. 334.

58 En la actualidad, el Ayuntamiento de Valencia debe recibir el pago de un canon periódico.

59 Así CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca, cit. p. 334.

60 RUMEU DE ARMAS, A. Historia de la previsión social, cit. p. 43 sitúa el origen de la cofradía medieval, al menos de la gremial, en la Gilda germánica y no el colegio profesional romano.

las prescripciones del título del Código Civil dedicado a las mismas al tener contratos o disposiciones especiales (sólo supletoriamente será aplicable el artículo 392.2 del Código Civil); sin embargo, quizá la continuidad de la organización del *collegium* romano se halle presente en la específica estructura de la comunidad de pescadores de El Palmar y no sea necesario recurrir a instituciones de Derecho germánico, sobre todo si el punto de partida no es la figura jurídica de la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y siguientes del Código Civil, sino el *collegium* –o la *societas*– de pescadores, figura típicamente asociativa.

Sí que es cierto que la comunidad de pescadores disgrega la población en función de la pertenencia o no a dicha comunidad, sus miembros se configuran como los que tienen el control de los recursos y, con ello, el sustento; por el contrario, los que no forman parte de la comunidad dependen económicamente de ésta o se ven obligados a salir del contexto social y territorial de El Palmar. En concreto, la condición de miembro de la comunidad era objeto de transmisión “patrivilirineal”⁶¹ –la condición de comunero derivaba de la existencia de vínculos personales (ser hijo de comunero) y ser varón– y sólo la pertenencia a la comunidad daba⁶² derecho al puesto fijo de pesca –*redolí*–, es decir, las normas consuetudinarias impedían la entrada de la mujer como miembro de la comunidad aunque se les llegaran a reconocer ciertos derechos, por tanto su acceso a la actividad económica principal era imposible, la consecuencia inmediata es que la mujer de El Palmar era, en todo caso, económicamente dependiente. Otra cosa es la transmisión del *redolí* dado que no es un derecho que pertenezca a la herencia, no es un derecho atribuido a los herederos en cuanto tales, sino que cuenta con mecanismos sucesorios propios por cuanto se trata de un derecho vinculado a la pertenencia a la comunidad⁶³, por ejemplo, en el *redolí* pueden suceder la hija o nieta de pescador, pero sin poder usarlo más que cuando contraigan matrimonio con un hijo de pescador que aún no tenga *redolí*, será su marido quien sucederá en él. Esto significa que las hijas o nietas de pescador sólo pueden obtener el rendimiento propio del *redolí* contrayendo matrimonio con hijo de pescador, lo que no deja de ser una norma favorecedora del matrimonio endogámico: la hija de pescador no puede obtener los ingresos propios del *redolí* si no se casa, y él se ahorrará los gastos que suponen un *redolí* nuevo⁶⁴. La viuda de patrón tiene derecho a explotar el *redolí* a través de otro pescador –especie de usufructo viudal que no le confiere la cualidad de comunero–, de forma que el sucesor no recibe el *redolí* hasta que la viuda muere o renuncia, incluso puede depositar el *redolí* si no lo hizo su marido. Pero este trabajo se incardina en un proyecto mucho más amplio que analizará estructura familiar y social, por tanto dejamos aquí el tratamiento de estos temas, no sin advertir la sintonía entre lo brevemente expuesto y la conformación y estructura de la familia romana...

61 Las normas de base consuetudinaria dejaban claro que sólo podían ingresar en la comunidad quienes fueran hijos varones de pescador de la propia comunidad y hubieran cumplido 24 años o estuvieran casados para el caso de que todavía no hubieran alcanzado tal edad; en un tiempo también fue requisito el contar con un mínimo de artes de pesca.

62 A mediados de la década de los años 90 del siglo pasado, un grupo de mujeres emprendió acciones legales contra la comunidad de pescadores de El Palmar por discriminación por razón de sexo a la hora de ingresar y pertenecer a dicha institución. En 1998 la Audiencia Provincial de Valencia obliga a la comunidad a permitir el ingreso de estas mujeres y en 2005, un auto de la Audiencia reitera la sentencia y condena de nuevo a la comunidad de pescadores de El Palmar.

63 CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca, cit. p. 329.

64 CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca, cit. p. 330.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCINA, J. Las ruinas romanas de Almenara (Castellón). En *BSCC* 26 (1959) 92-128.
- ASTORKIZA, K. - DEL VALLE, I. - ASTORKIZA, I. Fisheries Policy and the Cofradías in the Basque Country: the Case of Albacore and Anchovy. En *Límites de la Travesía. VII Conferencia de la Asociación Internacional para el Estudio de la Característica Común*, Vancouver: B.C. Universidad Simon Fraser, 1998.
- BÁRCENA, A. Las cofradías sindicales de pescadores. En *Revista de Estudios Sindicales* (1974) 116-134.
- BARRIO GARCÍA, G.A. Las cofradías de pescadores en el Derecho español. En *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 1998 (2) 161-188.
- BLÁZQUEZ, A. *Ora Maritima. Festo Rufo Avieno*, Madrid: Impr. del Patronato de huérfanos de intendencia e intervención militares, 1923.
- CALO, F. Prehistoria e Idade Antiga. En *Historia Xeral de Galicia*, Vigo: Promocions Culturais Galegas, 1997, 7-91.
- CARUANA TOMÁS, C. *Estudio histórico y jurídico de la Albufera de Valencia*, Valencia: Sucesor de Vives Mora, 1954.
- CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S. Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho romano, Madrid: Dykinson, 1996.
- CLEMENTE MEORO, M.E. Los aprovechamientos de pesca en la Albufera de Valencia. En *Instituciones de Derecho Privado valenciano*, Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, 323-335.
- COLON, G. - GARCIA, A. *Furs de València*, 8 vols. Barcelona: Barcino 1980-1999.
- COLON, G. - GARCIA, V. *Furs de València*, Barcelona: Barcino, 2002-2007.
- CORDERO RIVERA, J. Asociacionismo popular: Gremios, cofradías, hermandades y hospitales. En: DE LA IGLESIA DUARTE, J.I. *La vida cotidiana en la Edad Media. VIII Semana de Estudios Medievales*, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1998, 387-399.
- FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A. *Las ánforas romanas de Valencia y de su entorno marítimo*, Valencia: Delegación Municipal de Cultura, Arqueología nº 3, 1984.
- FERNÁNDEZ NIETO, F.J. Beribrases, edetanos e ilercaones (Pueblos pre-romanos en la actual provincia de Castellón). En *Zephyrus* 19-20 (1968) 116-142.
- FILGUEIRA, M.A. Gremios. En *Gran Enciclopedia Gallega*, t. XVI (1974) 214-216.
- FREIRE MOLINER, M.J. El libro de registro de los privilegios de la Albufera de Valencia, Edición e Índices, Zaragoza: Anubar, 1995.
- GARCÍA BELLIDO, A. La navegación ibérica en la Antigüedad según los textos clásicos y la Arqueología. En *Estudios Geográficos* V, 16 (1944) 511-560.
- GINART N.B. Repertori General y Breu Sumari per orde alfabetic de totes les matèries dels Furs de Valencia, fins les Corts del Any 1604 inclusive, y dels Privilegis de dita Ciutat y Regne, Valencia: Pere Patricio Mey, 1608.
- GONZÁLEZ ARCE, J.D. Asociacionismo y restricciones corporativas en la España medieval (siglos XIII-XV). En *Investigaciones de Historia Económica* 10 (2008) 9-34.
- IZQUIERDO I TUGAS, P. Introducció a l'arqueologia portuària romana de la Tarraconense. En [www. http://independent.academia.edu/PerelIzquierdoiTugas/Papers](http://independent.academia.edu/PerelIzquierdoiTugas/Papers), 443-455.
- JIMÉNEZ J.L. y RIBERA A. *Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania*, Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 2002, 267-278.

- LÁZARO GUILLAMÓN, C. Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana a la luz de una inscripción de Carthago Nova –CIL II, 5929-. En: BELLO RODRÍGUEZ, S. y ZAMORA MANZANO J.L. *El Derecho comercial, de Roma al Derecho moderno*, Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 425-439.
- LÁZARO GUILLAMÓN, C. Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a Carthago Nova: Esempio di economia sociale? En *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 11 (2013) <http://www.dirittoestoria.it/11/memorie/Lazaro-Guillamon-Associazione-pescatori-commercianti-Carthago-Nova.htm>.
- LILLO CARPIO, P.A. Incidence de la religiosité et des mythes dans le processus de colonisation de La Méditerranée occidentale. En *Mediterranea* 62 (1996) 2-21.
- LÓPEZ, A. Idade Media. En *Historia Xeral de Galicia*, Vigo: Promocions Culturais Galegas, 1997, 95-204.
- MACKIE, N. Local Administration in Roman Spain AD 14-212. En *British Archaeological Reports* 172 (1983).
- MARÍN DÍAZ, M^a A. Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada: Universidad de Granada, 1988, p. 139. CORELL I VICENT, J. Inscripciones romanas del País Valencià. I. (Saguntum i el seu territori), Valencia: Universitat de València, 2002.
- MARZANO, A. Harvesting the sea: The exploitation of marine resources in the Roman Mediterranean, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- MATEO, A. Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma, Santander: Universidad de Cantabria, 1999.
- MENTXAKA, R. El derecho de asociación en Roma a la luz del cap. 74 de la Lex Irnitana. En *BIDR* 98-99 (1995-1996) 199-218.
- MOMBLANCH Y GONZÁLEZ, F. *Historia de la Albufera de Valencia*, Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 2003.
- MOMMSEN, Th. Sopra una iscrizione scoperta in Frisia. En *BIDR* 2 (1889).
- MOREDA, G. Las cofradías de pescadores en España. En *Revista Internacional del Trabajo* 2 (1966) 586-549.
- PARÁSSOGLU, G.M. A Lease of Fishing Rights. En *Aegyptus* 67.1 (1987) 87-93. ROŠTOVTZEFF, M.I. *Historia social y económica del imperio romano II*, Madrid: Espasa-Calpe, 1962.
- PARODÍ ÁLVAREZ, M.J. Algunas notas sobre el papel de lagos y lagunas costeras peninsulares como soportes para la navegación en época altoimperial. En *SPAL, Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla* 8 (1999) 207-206.
- PÉREZ, A. Las cofradías de pescadores: una institución original. En *El Campo* 97 (enero-marzo 1985) 101-106.
- REBOLLO, M. - FALCÓN, R. - LÓPEZ, M. *Naturaleza y régimen jurídico de las cofradías de pescadores*, Córdoba: Universidad de Córdoba, 1996.
- RIBERA I LACOMBA, A y FERNÁNDEZ, A. Prospecciones arqueológicas submarinas en la zona del Saler. En *Actas del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina* (Madrid 1985) 83-91.

- RIBERA I LACOMBA, A. - JIMÉNEZ SALVADOR, J.L. *Valentia*, ciudad romana: su evidencia arqueológica. En: BELTRÁN FORTES J. y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. *Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas*, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, 77-120.
- RIBERA I LACOMBA, A. La fundación de Valencia y su impacto en el paisaje. *Historia de la ciudad II. Territorio, sociedad y patrimonio*, Valencia: Universitat de València, Servei de Publicacions, 2002.
- RIBERA I LACOMBA, A. *Valentia (Hispania citerior)*, una fundación itálica de mediados del siglo II a.C. Novedades y complementos. En: UROZ, J. NOGUERA J.M. y COARELLI F., *Iberia e Italia. Modelos romanos de integración territorial*, Murcia: Tabularium, 2008, 169-198.
- RUMEU DE ARMAS, A. Historia de la previsión social en España. Cofradías-gremios-hermandades-montepíos, Barcelona: El Albir, 1981.
- SALCEDO FERRÁNDIZ, S. Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y de sus aprovechamientos. *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura* 32.2 (abril-junio 1956) 77-88.
- SANMARTÍN ARCE, R. *La Albufera y sus hombres*, Madrid: Akal Universitaria, 1982.
- SANTERO SATURNINO, J.M^a. *Asociaciones populares en Hispania romana*, Sevilla: Publ. de la Universidad de Sevilla, 1978.
- SCHULTEN, A. *Fontes Hispaniae Antiquae I*, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1922.
- TABOADA MELLA, M^a.S. Las prácticas contables de las cofradías de pescadores gallegas. La coerción como vehículo de institucionalización cultural normativa. En *Revista Galega de Economía* 16, 2 (2007) 1-26
- TARAÇONA, P.H. *Institucions dels Furs, y Privilegis del Regne de Valencia*, Valencia: Estampa de Pedro de Guete, 1580.
- TORRENT, A. *Diccionario de Derecho romano*, Madrid: Edisofer, 2005.
- UROZ SÁEZ, J. La agricultura ibérica del Levante en su contexto mediterráneo. Estudios de Economía Antigua en la Península Ibérica. Nuevas aportaciones. *Studia Historica. Historia Antigua* 17 (1999) 59-85.
- VILA, J.M. El devenir histórico de las cofradías de pescadores y las prioridades de actuación de las cofradías en el momento actual, *Comunicación presentada con motivo dunhas xornadas organizadas pola Consellería de Pesca*, Santiago de Compostela.
- VIVES, J. *Inscripciones latinas de la España romana. Antología de 6800 textos*, Barcelona: Universidad de Barcelona. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1970.
- WEST, L.C. *Imperial roman Spain. The objects of trade*, Oxford: B. Blackwell, 1929.

COMERCIO Y PIRATERÍA EN ROMA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA

BELÉN FERNÁNDEZ VIZCAÍNO

Universidad de Alicante

En el mundo antiguo bandas criminales organizadas actuaban en el mar, y alrededor de las costas de los Estados mediterráneos, constituyendo una grave amenaza para la comunidad, lo que llevó a Roma a organizar diferentes campañas militares destinadas a asegurar las rutas comerciales marítimas.

A este respecto, es opinión general la prevención de los romanos hacia el medio marítimo, tal como afirma Álvarez-Ossorio, para los romanos el mar siempre fue contemplado como un elemento extraño y peligroso¹, un espacio líquido, hostil y desconocido; esta visión tenía un arraigo importante en la conciencia colectiva romana, lo que llevaba a acompañar el inicio de una navegación con ciertos rituales, y no solía emprenderse si existían malos augurios sobre la misma; asimismo, mostraban mayor recelo al extranjero que llegaba por mar que aquél que lo hacía por tierra²; no obstante, el viaje por mar fue en multitud de ocasiones inevitable por la dificultad o peligro de las rutas terrestres, además de existir relaciones comerciales que sólo se podían establecer por vía marítima, lo que obligó a aumentar la flota romana y a construir puertos, como el de *Ostia* o el de *Misenum*.

A pesar de este escenario nos encontramos ante un pueblo con grandes triunfos navales a lo largo de su historia, debido principalmente al escaso desarrollo técnico en materia naval y a que la navegación de la época era de cabotaje, el poder marítimo y el terrestre estaban unidos; por lo tanto, para controlar el mar era necesario controlar la tierra, y esa era la

1 En opinión de ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., en “Seguridad, piratería y legislación en el tráfico comercial romano en la península ibérica durante la República y el Alto Imperio”, en *Mainake*, XXX, 2008, pp. 91 y ss., el mar para los romanos fue considerado como *res communis*, esto es, cosa no susceptible de propiedad, porque no tenían forma de controlar algo que consideraban sobrenatural.

2 El miedo a los viajes por mar debido a los peligros que acechaban durante los mismos se puede observar en el pasaje de Paulo D. 39, 6, 3.- (*Paulus 7 ad sab.*) - *Mortis causa donare licet non tantum infirmæ valetudinis causa, sed periculi etiam propinquæ mortis vel ab hoste vel a praedonibus vel ab hominis potentis crudelitate aut odio aut navigationis ineundæ*:

especialidad de Roma³. Una parte importante de estas exitosas campañas navales romanas se encuentra en su lucha contra los piratas⁴ en el Mediterráneo.

La piratería⁵ se había estado desarrollando en el Mediterráneo sin la intervención de Roma, que actuaba como mera observadora, dejando el control de la zona oriental del mar a sus aliados, hasta que en el siglo II a.C. sobrepasa los límites afectando los intereses comerciales romanos, comenzando por Oriente, pero llegando a amenazar todo el *Mare Nostrum*; pero no es hasta alrededor del año 100 a.C. cuando declara a los piratas enemigos del pueblo romano y de sus aliados⁶, si bien, aun sentando las bases de lo que en el futuro sería la lucha contra la piratería, en un principio se trató más de una declaración de intenciones que de una política activa⁷.

La actividad pirática tuvo repercusiones notables en el ejercicio de la actividad comercial romana, tanto en el tránsito de mercancías como de personas, de forma que a finales de la República era un problema acuciante para Roma, pues los ataques piratas amenazaban la supremacía romana e incluso la supervivencia de la urbe⁸; primero desde

3 ORMEROD, H.A. *Piracy in the Ancient World: an essay in Mediterranean history*, Liverpool, 1978, Rep. facsímil 1ª ed. 1924, p. 260; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., "Seguridad, piratería y legislación en el tráfico comercial romano en la península ibérica durante la República y el Alto Imperio", en *Mainake*, XXX, op.cit., p. 93.

4 El término "pirata" se recoge en las fuentes con diferentes significados vid. *Cic. Post Red. Sen.* 11; *Cic. in Verr.* 2, 1, 90; *Cic. in Verr.* 2, 4, 23; *Caes. bell. civ.* 3, 110; *Caes. bell. civ.* 3, 112; *Plaut. Mil.* 118; *Plaut. Trin.* 1088; *Liv. Per.* 68; *D.* 44, 7, 20; *D.* 47, 9, 3, 2; *D.* 49, 15, 24.

5 Sobre la piratería en la antigüedad vid. SESTIER, J.M., *La piraterie dans l'antiquité*, Paris, 1880, pp. 249 y ss.; SANDIFORD, R., voz: "Piratería", en *NNDI*, 13, 1968, pp. 109 y ss.; GARLAN, Y., "Signification historique de la piraterie grecque", en *Dialogues d'histoire ancienne*, 4, 1978, pp. 1 y ss.; DELL, H.J., "The origin and nature of Illyrian piracy", en *Historia*, 16, 1967, pp. 344 y ss.; BRULÉ, P., "La piraterie Crétoise hellénistique", en *Annales littéraires de l'Université de Besançon*, 223, Paris, 1978, pp. 138 y ss.; GIUFFRIDA, M., *La piratería tirrenica: momento e fortuna*, Roma, 1983, pp. 30 y ss.; ORMEROD, H.A., *Piracy in the Ancient World: an essay in Mediterranean history*, op.cit., pp. 7 y ss.; TRAMONTI, S., "La piratería ligure e sardo-corsa nel Tirreno nel II sec. a.C.", en *A&R*, 40, 1995, pp. 197 y ss.; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli, 1996, pp. 6 y ss.; SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, 1999, pp. 15 y ss.; FERONE, C.-SASSATELLI, G.-PIANEZZOLA, E., "La piratería nell'Adriatico antico", en *Atti dell'incontro di Studio. Venezia 2002*, Roma, 2004; ALVAR, J., "Piratas de la antigüedad: el mediterráneo en peligro", en *Clío: Revista de historia*, 130, 2012, pp. 32-41; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, Warszawa, 2009, pp.17 y ss.

6 CLAVEL-LÉVÊQUE, M., "Brigandage et pratiques imperialistes au dernier siècle de la République", en *Dialogues d'histoire ancienne*, 4, 1978, pp. 18-20; TRAMONTI, S., *Comunes Hostes Omnium. La piratería e la fine della Repubblica romana (145-33 a.C.)*, Ferrara, 1994, pp. 42 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, Sevilla, 2008, p. 34; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 21 y ss.; MATAIX, E., *El edicto de incendio ruina naufragio rate nave expugnata (D. 47, 9, 1). Responsabilidad penal por cuestión de naufragio*, Tesis de próxima publicación cedida amablemente por su autora, pp. 37 y ss. *App. Bell.Civ.* 1, 60, 73-75; *Cic. de Off.* 3; *D.* 49, 15, 24.

7 SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, op.cit., pp. 108 a 115.

8 Vid. WARD, A.M., "Notes and Discussions. Caesar and the pirates", en *CPh*, 70, 1975, pp. 267-268; WARD, A.M., "Caesar and the pirates", II, en *AJAH*, 2, 1977, pp. 26 y ss.; SCHULZ, R., "Caesar und das meer", en *HZ*, 271, 2000, pp. 283 y ss.; CANFORA, L., *Giulio Cesare: il dictatore democrático*, Bari, 2006, p. 9; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., p. 44 (nota 143); TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 32 y ss-119 y ss. *Cic. leg. Man.* 32-33-53; *Dio Cass.* 36, 22, 2; *App. Mith.* 93; *Vell.* 2, 31, 2; *Vell.* 2, 42, 3; *Valerius*

sus bases al sur de Asia Menor en las costas de Cilicia⁹ y, más tarde en todo el Mediterráneo, los piratas llevaban a cabo sus actividades llegando a atacar ciudades de la costa itálica no sólo por el botín sino también por el temor que infundían en sus habitantes¹⁰, como se puede observar en las fuentes literarias *Flor. Epit.* 1, 41, 1 y *Oros. Hist.* 6, 4, 1, lo que llevó a Roma a emprender acciones en defensa de los intereses de sus comerciantes¹¹, pues los piratas interrumpían el comercio y las comunicaciones en el Mediterráneo, siendo de especial relevancia sus efectos sobre las líneas de suministro de las regiones productoras de Roma, en especial del trigo, por la cada vez mayor frecuencia y gravedad de los ataques, de manera que el abastecimiento se encontraba amenazado. Los barcos con grano procedentes de Sicilia, África y Sardinia no partían de sus puertos, o si lo hacían no alcanzaban su destino, en consecuencia, el precio del pan sufrió un gran incremento, enfrentándose las autoridades de Roma tanto a la perspectiva del hambre en la población como a los probables disturbios callejeros provocados por la misma¹². Esta situación se agrava en las primeras decenas del siglo I a.C., con riesgos crecientes e incontrolables que pusieron en peligro la continuidad en el abastecimiento de una serie de insumos vitales para Roma

Otra cuestión a tratar en el problema de la piratería es la colaboración de Roma con los piratas en diversos negocios, siendo el tráfico de esclavos sin duda el más importante; estas relaciones entre piratas y ciudadanos romanos, sobre todo senadores, propietarios de enormes latifundios necesitados de gran cantidad de mano de obra esclava, se fundamentan en la capacidad de los piratas para proporcionar estos recursos a la élite romana¹³; así, mientras fue admisible un equilibrio entre las ventajas y los daños producidos por la piratería, la política respecto a esta actividad no varió, sin embargo, cuando los daños causados fueron excesivos se produjo el hecho determinante para el cambio producido

Maximus 6, 9, 15; *Plut. Pomp.* 24, 6; *Plut. Pomp.* 24, 7; *Plut. Pomp.* 24, 8; *Plut. Pomp.* 25, 1-3; *Plut. Caes.* 1, 8; *Suet. Caes.* 4, 1-2; *Suet. Caes.* 74, 1.

9 La región de Cilicia fue definida por Mommsen como “república de corsarios”, lo que da señal de la actividad de sus gentes desde antiguo, *vid.* MOMMSEN, Th., *Historia de Roma*, 3, (Trad. García Moreno), Madrid, 1988, pp. 2 y ss.; TRAMONTI, S., *Comunes Hostes. La piratería e la fine della Republica romana (145-33 a.C.)*, *op.cit.*, pp. 24 y ss.; AVIDOV, A., “Were the Cilicians a nation of pirates?”, en *MHR*, 12, 1997, pp. 5 y ss.; JEAN, E.-DINCOL, A.M.-SERRA, D., “La Cilicie: espaces et pouvoirs locaux, (2e millénaire av. J.-C.-4e siècle ap. J.-C.)”, en *Actes de la Table Ronde Internationale d'Istanbul, 2-5 novembre 1999*, Istanbul, 2001, pp. 15 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, pp. 23 y ss.; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, *op.cit.*, pp. 237 y ss.; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, *op.cit.*, pp. 31 y ss. *Plin. Hist. Nat.* 3, 152.

10 AMELA, L. “La campaña de Pompeyo Magno contra los piratas en Hispania (67 a.C.)”, en *Hispania Antiqua, Revista de Historia Antigua*, 30, 2006, pp. 7-20.

11 TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, *op.cit.*, p.29. *Cic. leg. Man.*, 3-7. *Cic. leg. Man.* 7-17.

12 *App. Mith.* 91-93; *Cic. Leg. Man.* 31; *Cic. Leg. Man.* 53; *Dio Cass.* 36, 23, 1-2; *Liv. Per.* 99, 3; *Plut. Pomp.* 25, 1-2

13 A este respecto, SESTIER, J.M., en *La piraterie dans l'antiquité*, *op.cit.*, pp. 289 y ss., sostiene que la escasa reacción inicial de Roma al problema de la piratería está relacionada con la trata de esclavos, afirmando que la avaricia de los piratas como secuestradores y traficantes de esclavos era igualada, e incluso superada por los *publicani* romanos, en el mismo sentido *vid.* ORMEROD, H.-CARY, M., “Roma e l'Oriente”, en *Università di Cambridge. Storia Antica IX.I. Roma: La Repubblica 133-44 a.C.*, Milano, 1973, p. 412.

a partir del siglo I a.C. en la forma de enfrentar el problema, y son estas élites las que promueven el cambio de política de Roma respecto a los piratas, pues si bien es el orden ecuestre el que ejerce principalmente presión para que Roma intervenga contra aquéllos, debieron contar con el apoyo de este poderoso grupo que buscaba no sólo los beneficios de una guerra en Oriente, sino que también debía tener intereses comerciales, así, como afirma De Martino¹⁴ la ideología dominante causaba que los terratenientes despreciaran cualquier otra actividad económica, pero el ejercicio de la misma provocaba una fascinación irresistible por su alta rentabilidad, a pesar de que como afirma la doctrina y la legislación romana al respecto, a la élite romana no les estaba permitido el tráfico comercial¹⁵.

A este respecto, seguimos la opinión de Monaco¹⁶ cuando afirma que influyeron especialmente en el cambio de política los actos de pillaje sobre el grano que llegaba a la capital por vía marítima, ya que se había producido un notable incremento en las importaciones de trigo de las provincias, debido a la competitividad de sus precios, si bien, el desencadenante de este cambio hay que buscarlo en la saturación del mercado de esclavos provocado por las campañas de Mario del 102 a.C., lo que llevó a los piratas a modificar sus vías de sustento hacía el secuestro y la petición de rescate¹⁷.

Este problema fue tratado con diferentes estrategias militares, por otros tantos generales encargados por Roma para luchar contra los piratas, acompañando tales campañas de medidas legales para dar mayor eficacia a su lucha.

Contra las bases piratas en Cilicia la primera expedición fue dirigida por el pretor Marco Antonio el Orador en el 102 a.C.¹⁸, las causas de tal mandato son diversas según la doctrina, para algunos autores se trataba de poner coto a la actividad de aquéllos en el mercado de esclavos, ahora controlado por Roma¹⁹, mientras otros afirman que el motivo se encuentra en una grave escasez de grano en Roma, debida a la acción de los piratas²⁰; los principales

14 DE MARTINO, F., *Storia della costituzione romana*, 2, Napoli, 1973, p. 284.

15 DE MARTINO, F., *Storia della costituzione romana*, 3, *op.cit.*, pp. 143 y ss.; D'ARMS, J.H., "Senators' Involvement in Commerce in the Late Republic: Some Ciceronian Evidence", en *Memoirs of the American Academy in Rome*, 36, 1980, pp. 77-90; MILLAR, F., "The Political Character of the Classical Roman Republic 200-151 BC", en *JRS*, 74, 1984, pp. 1-19; MEIJER, F., *A history of seafaring in the Classical World*, London, 1986, pp. 189 y ss.; MOMMSEN, Th., *Historia de Roma*, 4, (Trad. García Moreno), Madrid, 1988, p. 121; ROLDAN, J.M., *Historia de Roma I. La república romana*, Madrid, 1999, pp. 186-1987; AVIDOV, A., "Were the Cilicians a nation of pirates?", en *MHR*, 12, *op.cit.*, pp. 36 y ss.; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, *op.cit.*, pp. 86 y ss.; TCHERNIA, A., "Le plebiscitum Claudianum", en *Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde antique*, Bordeaux, 2007, pp. 253-278; TCHERNIA, A., *Les Romains et le commerce*, Napoli, 2011, pp. 175 y ss. *Vid. Liv. Ad. Urb.* 21, 63, 3-4; *Str.* 14. 5. 2.

16 MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, *op.cit.*, pp. 76 y 82.

17 ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, pp. 95 y ss.

18 *Liv. Per.* 68.- M. Antonius praetor in Cilician marítimos praedonesis est piratas-per-seculus est.

19 MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, *op.cit.*, pp. 76 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, pp. 35 y ss.; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, *op.cit.*, p. 31.

20 CASSON, L., "The grain trade in the Hellenistic World", en *TAPA*, 85, 1954, pp. 168 y ss.; RICKMAN, G., *The corn supply of ancient Rome*, Oxford, 1980, p. 443. Para el estudio de otras teorías sobre el motivo del mandato otorgado a Marco Antonio el Orador, *vid. BADIAN, E., Roman Imperialism in the Late Republic*, Oxford,

objetivos de esta campaña se centraron en los puertos donde los piratas encontraban refugio, Side y Fáselis, y gracias a la misma, se le concedió celebrar un triunfo²¹; pero la medida legal más importante respecto a esta cuestión fue, sin duda, la constitución de la provincia de Cilicia.

Asimismo, en esta fecha se promulga en el año 101 ó 100 a.C. la *lex de Provinciis Praetoriis*, también conocida como *lex de Piratis Persequendis*²² cuya misión principal fue proteger la seguridad de los ciudadanos romanos y de sus aliados, a fin de evitar los peligros de la navegación²³.

Como la expedición llevada a cabo por Marco Antonio no resuelve el problema, en el 78 a.C. Publio Servilio Isaurico obtuvo el gobierno proconsular de la provincia de Cilicia a la que llegó con una importante flota y ejército; el mandato encomendado a Publio Servilio tenía como finalidad acabar con las bases piráticas, como medida más efectiva que combatir en alta mar, asegurando así el tráfico comercial de la zona, pues el planteamiento era que sólo destruyendo los puntos desde los que lanzaban sus ataques los piratas, así como sus bases de interior para el aprovisionamiento, el problema quedaría zanjado, pacificando la zona de forma definitiva. El general celebró un triunfo en el 75 a.C. por sus éxitos frente a los cilicios pero no contra los piratas que seguían siendo una carga para Roma, en este sentido, sus objetivos fueron el monte Olimpo y Fáselis, asoló Córico y sometió a los isaurios, de donde toma su *cognomen*, su campaña duró unos tres años²⁴.

Poco después, y teniendo como telón de fondo la Tercera Guerra Mitridática, la situación se vuelve todavía más desoladora, pues la inestabilidad en Asia provoca el cambio de

1968, pp. 53 y ss.; GARNSEY, P., *Famine and food supply in the graeco-roman world. Responses to risk and crisis*. Cambridge, 1988, pp. 90 y ss.; KALLET-MARX, R., *Hegemony to Empire. The development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley, 1995, pp. 234 a 239.

21 Plut. Pomp. 24.

22 Para un estudio en profundidad de las inscripciones que se encuentran de esta ley y de su interpretación legal vid. CUQ, E., “La loi gabinia contre la piraterie de l’an 67 avant J.-C.”, en *Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belle Lettres*, 67, 2, 1923, pp. 129 y ss.; CUQ, E., “La loi contre la piraterie d’après une inscription de Delphes”, en *Revue Archéologique*, 1924, pp. 212 y ss.; CUQ, E., *Note complémentaire sur la loi romaine contre la piraterie*, Paris, 1924, p. 293; CARY, M., “Is it the *lex Gabinia*?”, en *The Classical Review*, 38-3/4, 1924, p. 60; CARY, M., “The *lex Gabinia* once more”, en *The Classical Review*, 38-7/8, 1924, pp. 162-164; ORMEROD, H.A., “The so-called *lex Gabinia*”, en *The Classical Review*, 39-1/2, 1925, pp. 15-16; STUART JONES, H., “A Roman Law concerning piracy”, en *JRS*, 16, 1926, pp. 155 y ss.; SUMNER, G.V., “The Piracy law from Delphi and the law of the Cnidos inscription”, en *GRBS*, 19, 1978, pp. 211 y ss.; KALLET-MARX, R., *Hegemony to Empire. The development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, op.cit., pp. 232-233; CRAWFORD, M.H., *The Roman Statutes, I*, London, 1996, pp. 231 y ss.; SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, op.cit., pp. 108 y ss.; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., pp. 106 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., pp. 36-94 y 103; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 38 y ss.

23 SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, op.cit., p. 135.

24 ORMEROD, H.A., “The campaigns of Servilius Isauricus against the Pirates”, en *JRS*, 12, 1922, pp. 35 y ss.; TRAMONTI, S., *Comunes Hostes. La piratería e la fine della Repubblica romana (145-33 a.C.)*, op.cit., pp. 42 y ss.; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., pp. 76 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., p. 44; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 34 y ss-68 y ss.

territorio de los piratas, desplazando su actividad a Occidente, llegando a las costas de la península Itálica²⁵, tomando como cautivos a ciudadanos romanos y, llevando el terror a sus habitantes²⁶; en este contexto, concurre una circunstancia que, entre otros motivos, había provocado las anteriores campañas militares contra los piratas: la falta de grano y sus consecuencias, esto es, la hambruna en la ciudad de Roma, la inevitable subida de precios en los productos básicos y el temor de las clases dominantes a una posible revuelta en la plebe.

Estas razones llevaron a Roma a emprender acciones, desde la perspectiva legal crearon un *imperium* extraordinario junto a un serie de medidas legislativas, y en el lado militar encargaron a Marco Antonio Crético en el 75 a.C. la misión de limpiar el Mediterráneo de piratas. Para ello se le dota de un ejército y del control de las costas del Mediterráneo hasta 75 km. hacia el interior; obtiene algunos éxitos iniciales pero, tomando como punto de partida una demoledora requisita de trigo en Sicilia, llega a Oriente²⁷, optando por atacar Creta con la excusa de un acuerdo entre piratas y cretenses, pero sufre una gran derrota que le obliga a firmar la paz con los insulares por medio de un tratado que nunca fue ratificado por el Senado, que en cambio envió a Q. Cecilio Metelo para enderezar la situación; Marco Antonio moría en el 72 a.C., siendo denominado por sus detractores *creticus* en escarnio por su derrota²⁸.

Para entonces la situación en Roma ya es insostenible, se necesitan medidas drásticas, y es precisamente en este momento cuando se otorga a Pompeyo un *imperium extraordinarium*, así, el mismo motivo que fundamenta el *imperium* concedido a M. Antonio Crético sirve para el que posteriormente se otorga a Pompeyo en el 67 a.C. Durante los años posteriores a la actuación de Marco Antonio se incrementaron las actividades piráticas, cada vez se hacían más osadas y graves, la crisis de aprovisionamiento de grano que la actividad de los piratas provocaba daba lugar a situaciones de extrema gravedad en la propia metrópolis y en las provincias.

La situación era tan grave que, antes de otorgar el *imperium* a Pompeyo, Roma toma una serie de medidas para tratar de paliar la situación creada por los cruentos asaltos y saqueos reiterados de los piratas en la segunda mitad del siglo I a.C.²⁹. Éstas son, por una parte, el envío de Q. Marcio Rex como procónsul³⁰ a Cilicia en el 68 a.C. con la misión de acabar con las actividades de los piratas, y por otra, la ya citada designación por el Senado de Q. Cecilio Metelo para solucionar el problema de Creta, con una campaña de extrema dureza³¹.

25 MARASCO, G., "Roma e la pirateria cilicia", en *RSI*, 99, 1987, pp. 135-136.

26 Cic. Pomp. 33.

27 Con relación a las actividades de rapiña de Marco Antonio Crético durante su cometido vid. *Sall. Hist. Fr.* 3, 3; Cic. *in Verr.* 3, 213; OGIS 3-748.

28 Vell. 2, 31, 3. MARÓTI, E., "On the problema of M. Antonius Creticus' Imperium Infinitum", en *Acta Antiqua Acad. Scient. Hungaricae*, 19, 1971, pp. 259 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., p. 49; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., p. 35.

29 MARASCO, G., "Aspetti della pirateria cilicia nel I secolo a.C.", en *GFF*, 10, 1987, pp. 129 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., pp. 51 y ss.

30 Dio Cass. 36, 2, 2; Dio Cass. 36, 4, 1; Cic. *Har.* 42.

31 ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., pp. 52 y 69. Valerius Maximus 7, 6, 1.

Podemos concretar los episodios piráticos más importantes ocurridos en el Mediterráneo Occidental durante el siglo I a.C. y que fueron el preludio y la justificación de la concesión a Pompeyo del mandato de acabar con los piratas, así: Sertorio y los cilicios atacan África en el 81 a.C.; los piratas se alían con Sertorio en las bases de Denia, 74 a.C.; acuerdo entre Espartaco y los piratas, 72 a.C.; relaciones de Verres y los piratas durante su gobierno de Sicilia en el 71 a.C.³²; actividades de los cilicios en las costas de Cirene, década de los 70 a.C. siglo I; secuestros de ciudadanos romanos en la *Vía Appia*, y por último, la destrucción de una flota consular en Ostia en el 67 a.C.

Como se puede observar en la relación expuesta, a comienzo de la década de los sesenta del siglo I a.C. los daños causados por la piratería fuerzan a Roma a abandonar las campañas puntuales contra lugares concretos, optando por la campaña militar a gran escala³³.

La situación reclamaba medidas extraordinarias y urgentes con el fin de aliviar las tensiones populares, es éste el cometido encomendado a Pompeyo³⁴, siendo su primera medida garantizar el grano para Roma, cuyo suministro se había visto amenazado e incluso interrumpido por la acción de los piratas, pues como afirma Plutarco³⁵, “Ocupaban con sus fuerzas todo el Mar Mediterráneo, de manera que estaban cortados e interrumpidos enteramente la navegación y el comercio. Esto fue lo que obligó a los romanos, que se veían turbados en sus acopios y temían una gran carestía, a enviar a Pompeyo a limpiar el mar de piratas...”, el mismo sentido, se puede observar en las fuentes en *Cic. leg. Man.* 44; *Liv. Per.* 99; *Dio Cass.* 36, 22, 1-2-3.

Por lo tanto, la primera preocupación de Pompeyo fue, sin duda, la de conseguir que los barcos de transporte de grano navegaran de nuevo a la ciudad de Ostia, el puerto de Roma³⁶. Así lo atestiguan las fuentes, que afirman que el día de su elección como general al mando de las tropas contra los piratas el precio del pan cayó, tal como lo refiere Plutarco: “Como repentinamente hubiese bajado el precio de los objetos de comercio, dio esto ocasión al pueblo para manifestar gran contento y decir que el nombre de Pompeyo había acabado la guerra...”³⁷.

Para llegar a la elección de Pompeyo se llevaron a cabo una serie actuaciones política y jurídicas que comenzaron en el año 68 a.C. con la elección como tribuno de la plebe de A. Gabinio³⁸ junto con C. Cornelio; a principios del 67 a.C. el primero presenta la *lex de uno*

32 TARWACKA, A., Romans and pirates. Legal perspective, op.cit., pp. 124 y ss.

33 ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.), op.cit., pp. 57 y ss.; TARWACKA, A., Romans and pirates. Legal perspective, op.cit., p. 21.

34 RIDLEY, R.T., “The extraordinary commands of the Late Republic”, en *Historia*, 30, 1981, pp. 280 y ss.; SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, op.cit., pp. 149 y ss.; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., pp. 199 y ss.; GIRARDET, K.M., “Imperia und provinciae des Pompeius 82 bis 48 v. Chr.”, en *Chiron*, 31, 2001, pp. 153 y ss.

35 Plut. Pomp. 25, 1; ídem Eutrop. Brev. 6, 12.

36 CASSON, L., “The grain trade in the Hellenistic World”, en *TAPA*, 85, op.cit., pp. 168-181 y 187; RICKMAN, G., *The corn supply of ancient Rome*, op.cit., p. 48; TARWACKA, A., Romans and pirates. Legal perspective, op.cit., pp. 49-50 y ss.

37 Plut. Pomp. 26, 4, en el mismo sentido *Cic. leg. Man.* 44.

38 MATTHEWS SANFORD, E., “The Career of Aulus Gabinus”, en *The American Philological Association*, 70, 1939, pp. 64 y ss.; BADIAN, E., “The early career of Aulus Gabinus (cos. 58 b.c.)”, en *Philologus*, 103,

imperatore contra praedones constituendo, para promover una campaña militar contra los piratas ante la Asamblea del pueblo, consciente de la oposición que la misma suscitaría en el Senado, en contraste con el favor que contaba no sólo por parte del pueblo, sino también por un amplio sector de los caballeros y en particular por los *negotiatores*³⁹.

A. Gabinio presentó, en una primera Asamblea su proyecto en términos generales, sin citar nominalmente ninguna preferencia: el pueblo debía escoger entre los consulares un general para tomar el mando contra la piratería y dar una solución global al problema; con un mandato de tres años de duración, un ámbito territorial que incluyera todo el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, así como toda la costa hasta una distancia de 400 estadios, esto es, 75 kilómetros, lo que incluía a Roma; con poder para nombrar quince legados y disponer de todo el dinero que necesitara de la tesorería pública, así como de los fondos de los publicanos de las provincias. Reuniría una gran flota, un gran ejército y su *imperium* en las provincias tendría que ser igual al de los gobernadores provinciales⁴⁰.

El general que fuese nombrado podría ser considerado por el nivel de su autoridad como el primer *imperator* del mundo romano, según afirma parte de la doctrina⁴¹, entre ellos Amela en su extensa obra sobre Pompeyo⁴², y lo refleja Plutarco: "Propuso al efecto Gabinio, uno de los más íntimos amigos de Pompeyo, una ley, por la que se le confería a éste, no el mando de la armada, sino una monarquía y un poder sin límites sobre todos los hombres..."⁴³.

El plebiscito *lex Gabinia de bello piratico* no señalaba quién debería ser el líder de la campaña pero era obvio que, si se aprobaba, sería nombrado Pompeyo por aclamación popular, como así ocurrió⁴⁴. Este plebiscito generó grandes debates entre los romanos, lo que se confirma en los problemas surgidos durante su proceso de aprobación, ya que varias propuestas de la *lex Gabinia* eran contrarias a las normas básicas del sistema republicano romano. Este motivo llevó al Senado a debatir la propuesta adoptando una oposición a la misma casi mayoritaria⁴⁵, lo que obligó al tribuno a celebrar la votación de su propuesta en

1959, pp. 99 y ss.; WILLIAMS, R.S., "The role of *Amicitia* in the career of A. Gabinius (cos. 58)", en *Phoenix*, 32, 1978, pp. 195 y ss.; WILLIAMSON, C., *The laws of the Roman People: Public law in the Expansion and Decline of the Roman Republic*, Michigan, 2005, pp. 368 y ss.; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 47 y ss.

39 MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., p. 200.

40 *App. Mith.* 94; *Cic. leg. Man.* 46-53; *Dio Cass.* 36, 17a; 36, 23, 4; *Plut. Pomp.* 25, 3-6; *Vell.* 2, 31, 2-3; 2, 35, 2; *Zonar.* 10, 3; *Sall. Cat.* 39, 1.

41 BETTI, E., "Sulla fondazione del Principato", en *RIL*, 48, 1915, pp. 475 y ss.; MEYER, E., *Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius. Innere geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.*, Stuttgart, Berlin, 1922, pp. 245 y ss.; SCHÖNBAUER, E., "Untersuchungen zur röm. Staats und Wirtschaftsrecht. I. Wesen und Ursprung d. röm. Principats", en *ZRG*, 47, 1927, pp. 264 y ss.; CANCELLI, F., voz: "Principato", en *NNDI*, 13, 1966, pp. 870 y ss.; MAZZARINO, S., *L'Impero romano*, 3, Roma-Bari, 1973, pp. 96 y ss.; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 44 y ss.

42 AMELA, L., "La campaña de Pompeyo Magno contra los piratas en Hispania (67 a.C.)", en *Hispania Antiqua, Revista de Historia Antigua*, 30, op.cit., p. 10.

43 *Plut. Pomp.* 25, 2.

44 *Dio Cass.* 36, 23, 5; *Dio Cass.* 36, 24, 1; *Cic. leg. Man.* 44.

45 Es conocida la oposición de Q. Lutecio Catulo, Q. Hortensio y de Calpurnio Pisón, siendo el único favorable Julio César, que había sufrido en persona las consecuencias de la piratería, si bien parece que las razones van

la Asamblea, donde fue aprobada, ofreciendo el mando extraordinario a Pompeyo, quien aceptó⁴⁶. Este asentimiento popular se puede observar en las fuentes en un texto referido a esta *lex* de Cicerón, *Cic. Pomp.* 56.- “*Una lex, unus vir, unus annus*”⁴⁷.

La *lex Gabinia de bello piratico*⁴⁸ si bien no fue la primera en materia de piratería fue la más efectiva, y a nivel legislativo, en el marco de la guerra contra los piratas, significó para Roma cambios constitucionales impensables en otra época, pero la necesidad de garantizar los suministros de las provincias orientales, así como de controlar las rutas comerciales en todo el Mediterráneo llevaron a las clases dirigentes a tomar tal decisión con fundamento en el bien común.

La fuerza militar aprobada estaría constituida por 500 barcos, sin duda, la parte principal de los recursos de Pompeyo, 120.000 soldados de infantería y 4.000 ó 5.000 jinetes de caballería⁴⁹, más veinticuatro legados de rango pretorio y dos cuestores, así como 6.000 talentos, además de poder hacer requerimientos a reyes, jefes, pueblos y ciudades aliadas; no obstante, esto no eran más que cifras, ya que la celeridad de la puesta en marcha de la operación militar no es compatible con la magnitud de tal contingente de tropas, la realidad debía ser un número menor de barcos, unos 270⁵⁰ entre *trirremes*, *quinquerremes* y *hemio-las*, cuya mayor virtud sería no la cantidad sino la velocidad en la acción⁵¹.

Esta característica era de primordial importancia ante un enemigo que controlaba casi todo el *Mare Nostrum*, y cuya gran ventaja era su movilidad⁵², por lo que era inútil el

más allá, no lo hacía para favorecer a Pompeyo, sino por cuestiones políticas, pues aprobar esta *lex* significaba, en principio, la ausencia de Roma por tres años de un importante adversario político, que quizá hubiera impedido sus actividades posteriores, además, con ello se atraía al pueblo, muy partidario de Pompeyo. A este respecto, entre las principales objeciones de los senadores en contra del *imperium ex lege Gabinia* estaría su resistencia a perder la competencia y el control para conceder autorizaciones extraordinarias a sujetos individuales, como es el caso que nos ocupa, pues el poder de Pompeyo le privaba del monopolio legal que tenían de inspección y control de todas las transgresiones al *status quo* republicano. *Plut. Pomp.* 25, 7; *Dio Cass.* 36, 24; *Cic. leg.Man.* 52-57-58-59-67.

46 *Cic. leg. Man.* 44-56-57-63; *Plut. Pomp.* 26, 1-2; *Sall. Cat.* 39,1

47 Ídem *App. Mith.* 94.

48 Para un estudio del proceso de aprobación de la *lex Gabinia*, vid. MONACO, L., *Persecutio piratarum*. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana, *op.cit.*, pp. 203 y ss.; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, *op.cit.*, pp. 44 y ss.

49 Lo que significa que Pompeyo ya preveía que la campaña no sólo iba a ser en el mar, además el tipo de navegación de la época, basada en el cabotaje hacían necesaria una fuerza móvil capaz de atacar de forma rápida las bases piratas, como afirma ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, p. 59, el poder marítimo y terrestre debían ir de la mano. *App. Mith.* 94; *Plut. Pomp.* 26, 3; *Dio Cass.* 36, 37.

50 SMITH, W., *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, 1875, pp. 783 y ss.; ORMEROD, H.A., “The distribution of Pompey’s forces in the Campaign of 67 B.C.” en *Liverpool Annals of Arch & Anth.* 10, 1923, pp. 43 y ss.; CASSON, L., *Navi e marinai nell’antichità*, (Trad. de Celia Boero Piga), Milano, 1976, p. 128; GUILLERM, A., *La marine de guerre antique*, Paris, 1993, pp. 92 y ss. *App. Mith.* 94; *Sil. Ital. Pun.* 14, 284-285.

51 Establecido el volumen de tropas comandadas por Pompeyo así como la extensión de los territorios controlados, se puede afirmar que fue el auténtico “Señor del Imperio” durante los años que duró su *imperium*, hasta el 62 a.C. que disolvió sus tropas, como lo afirma TWYMAN, B., “The Metelli, Pompeius and Prosopography”, en *ANRW I.1*, 1972, pp. 816 y ss.

52 La embarcación preferida por los antiguos piratas era la *hemiola*, barco ligero que les daba la rapidez que necesitaban en sus ataques, si bien también utilizaban en sus actividades los *birremes* y la *liburnae*, vid. SMITH, W., *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, *op.cit.*, p. 786; CASSON, L., “*Hemiolia and tremiola*”, en *JHS*, 78, 1958, pp. 14 y ss.; CASSON, L., *Navi e marinai nell’antichità*, *op.cit.*, p. 128; AMELA, L., “La campaña de

ataque en una sola área, por ello Pompeyo dividió el mar en trece áreas, cada una bajo el mando de sus legados⁵³. Cada legado tenía a su disposición una flotilla de barcos y cierto número de soldados de infantería y de caballería; patrullaba su zona tanto por tierra como por mar e interceptaban cualquier navío pirata que entrara en su sector, impidiendo su salida. Los piratas que estuvieran en puerto eran bloqueados por mar hasta que llegaran fuerzas terrestres o intentaran forzar ese bloqueo, si escapaban entraban en otro sector vigilado, comenzando la misma estrategia, privando a los piratas de puertos seguros donde refugiarse o abastecerse⁵⁴.

Pompeyo tenía una flota armada propia que se encargaba de supervisar todas la regiones; su misión comenzó dirigiéndose a Sicilia, desde allí cruzó el mar hasta la costa de África, y luego marchó al norte para encontrarse con la flotilla de P. Atilio en las costas de las islas de Corsica y Sardinia, de manera que la aguas que circundaban las tres mayores áreas de producción de trigo fueron limpiadas de piratas, como recoge *Cic. leg. Man.* 34.

En cuarenta días, desaparecieron los piratas de toda la parte occidental del mar Mediterráneo, algunas fuentes aplican este plazo al total de la campaña, pero es difícil asumir tan corto espacio de tiempo⁵⁵, ahora bien, es cierto que tuvo algunos problemas de competencia de poder en las provincias, como el suceso con Calpurnio Pisón, pero una vez neutralizado este peligro en el Senado y la Asamblea de Roma pudo seguir con su campaña contra los piratas con libertad y celeridad.

Llegados a este punto quedaba limpiar el Mediterráneo oriental, en especial Cilicia, principal objetivo de la misión de Pompeyo, donde se concentraban la mayor parte de las fortalezas piratas, así como sus recursos⁵⁶; la batalla más importante se situó en *Cora-caesium*, en la costa meridional de Anatolia, donde atacó tanto por tierras como por mar,

Pompeyo Magno contra los piratas en Hispania (67 a.C.)”, en *Hispania Antiqua, Revista de Historia Antigua*, 30, *op.cit.*, p. 12; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, p. 60; MORRISON, J.S.-COATES, J.-RANKOV, N.B., *The Athenian Trireme: the history and reconstruction of and ancient Greek warship*, Cambridge, 2000, p. 9; DONATO, G., “Mare nostrum, la mer des romains”, en *L'encyclopédie d'archéologie sous-marine*, 3, London 2003, pp. 4-5.

53 Pompeyo puso al frente de Iberia y de las columnas de Hércules a Tiberio Claudio Nerón y a Aulo Manlio Torcuato; los mares de Liguria y Galia fueron asignados a Marco Pomponio; África, Cerdeña y Córcega, así como las islas de los alrededores a Cneo Cornelio Léntulo, Marcelino y Publio Atilio; Lucio Gelio Póbllico y Cneo Cornelio Léntulo Clodiano fueron los legados de las costas italianas; Aulo Plotio Varo y Marco Terencio Varrón los de Sicilia y el Adriático hasta Acarnania; Lucio Cornelio Sisena vigilaba las costas del Peloponeso, el Ática, Eubea, Tesalia, Macedonia y Beocia; las islas griegas del Egeo y el Helesponto fueron responsabilidad de Lucio Lolio; a Marco Pupio Pisón se le asignó Bitinia, Tracia, la Propóntide y la boca del Ponto; y por último, Quinto Cecilio Metelo Nepote fue el legado de Licia, Panfilia, Chipre y Fenicia. *Vid.* ORMEROD, H.A., *Piracy in the Ancient World: an essay in Mediterranean history*, *op.cit.*, pp. 235 y ss.; TRAMONTI, S., *Comunes Hostes. La piratería e la fine della Repubblica romana (145-33 a.C.)*, *op.cit.*, pp. 73 y ss.; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, *op.cit.*, p. 53 (nota 194). *App. Mith.* 95; *Flor. Epit.* 1, 41, 9-10; *Plut. Pomp.* 26, 2-3-4.

54 *App. Mith.* 94-95; *Dio Cass.* 36, 37, 3-4; *Flor. Epit.* 1, 41, 1

55 AMELA, L., “La campaña de Pompeyo Magno contra los piratas en Hispania (67 a.C.)”, en *Hispania Antiqua, Revista de Historia Antigua*, 30, *op.cit.*, p. 16.

56 En este sentido, cuando le es conferido el mandato a Pompeyo, Roma ya domina algunos territorios de Cilicia y zonas adyacentes, pero faltarían por controlar la Cilicia Traquea y parte de Panfilia, estando la Cilicia Pedías en poder de los Seléucidas, restaurados por Lúculo tras la retirada de Triganes, *vid.* ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, p. 59.

asestando una derrota definitiva a los últimos piratas, capturando a más de 10.000 hombres, un importante botín, y una enorme cantidad de material naval y barcos, siendo saludado por sus hombres como *imperator*⁵⁷.

La campaña emprendida por Pompeyo contra los piratas en el Mediterráneo fue, en palabras de Casson⁵⁸ “una de las operaciones más notables de la historia naval”, de la que sólo se han conservado tres breves testimonios: *App. Mith.* 95; *Flor. Epit.* 1, 41, 9; *Cic. leg. Man.* 35⁵⁹.

Los datos de la campaña militar de Pompeyo son asombrosos, diez mil piratas ajusticiados, veinte mil prisioneros, mil trescientas naves hundidas, ochenta confiscadas, ciento veinte ciudades ocupadas, ricos arsenales y armerías incendiados, y en cuestión de cautivos, encontró a gran cantidad de ellos, algunos a la espera de ser rescatados y otros que se creían muertos⁶⁰, lo que da una idea del desarrollo que tuvo la piratería, y por ende, lo mucho que incidió negativamente en el desarrollo comercial de las regiones mediterráneas⁶¹.

La victoria de Pompeyo se encuadra dentro de la política propagandística romana, ya que la piratería se había convertido en un problema de imagen para Roma, con peligros materiales y morales⁶², lo que justificó que esta victoria se incluyera en el triunfo que le fue concedido en el 61 a.C.⁶³ por su victoria en la guerra contra Mitrídates y Triganes, en vez de una *ovatio*, que era lo que proporcionaba la victoria sobre los piratas ya que no se consideraba como *bellum* en sentido técnico, debido a la falta de una declaración de guerra ya que los piratas no pertenecían a ningún Estado, sino una guerra injusta o servil, aunque su celebración se podía recoger en los *fastis triumphales*, pues para los romanos su victoria en la campaña contra los piratas era parte significativa de ese triunfo⁶⁴, como lo demuestra Cicerón en *Cic. Pomp.* 56.

57 Sin embargo, GUILLERM A., en *La marine de guerre antique*, op.cit., pp. 92 y 132, sostiene que las fuentes literarias no conservan rastro de la campaña de Pompeyo contra los piratas, porque no hubo ninguna batalla. En *Coracaesium* se produjo una rendición total, presionados por haber sido sobrepasados militarmente. Ya que con independencia del número de naves piratas, el mayor tonelaje de la flota romana decantó la victoria hacía Pompeyo.

58 CASSON, L., Los antiguos marinos. Navegantes y guerreros del mar en el Mediterráneo de la antigüedad, Buenos Aires, 1969, p.194

59 SCHULTEN, A. *Fontes Hispaniae Antiquae*, V. Las guerras del 72-19 a. de J.C., Barcelona, 1940, pp. 78 y ss.

60 Con relación al *status* de las personas capturadas por los piratas, sus derechos y la situación de los *redemptus a piratis*, vid. TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 86 y ss.

61 MONACO, L., *Persecutio piratarum*. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana, op.cit., p. 208.

62 Pues, como afirma ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., en “Seguridad, piratería y legislación en el tráfico comercial romano en la península ibérica durante la República y el Alto Imperio”, en *Mainake*, XXX, op.cit., p. 93, cualquier potencia que se precie debe, necesariamente, garantizar la seguridad en los mares, eliminando, o al menos reduciendo hasta los límites tolerables el fenómeno pirático.

63 *Cic. leg. Man.* 54-56. KALLET-MARX, R., *Hegemony to Empire. The development of the Roman Empire in the East from 148 to 62 B.C.*, op.cit., pp. 234 a 237

64 ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.), op.cit., p. 103; CALORE, A., *Forme giuridiche del “bellum iustum”*, Milano, 2003, pp. 137-138; TARWACKA, A., *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 56 y ss. Gell., *Noct. Att.* 5, 6, 21; *Eutrop. Brev.* 6, 16; *Plin. Hist. Nat.* 7, 26; *Valerius Maximus* 8, 15, 8.

Una cuestión primordial a tomar en consideración en el fin del problema de la piratería es el trato dado por Pompeyo a los piratas vencidos, o que se habían rendido, pues si bien castigó a los culpables de crímenes imperdonables⁶⁵, en cuanto al resto, no se podían dejar libres, y la crucifixión, solución dada por Roma a los pueblos que consideraban criminales y eran vencidos por las armas, tampoco parecía del gusto de Pompeyo, por lo que su actuación se apartó de esa línea tradicional, mostrando misericordia con los mismos; así, los prisioneros fueron transportados a zonas interiores, lejos del mar, para que pudieran dedicarse a la agricultura o, a aquella actividad que hubieran dejado para unirse a los piratas⁶⁶; mediante este asentamiento de antiguos piratas y la concesión de recursos para cambiar de vida, Pompeyo utiliza la misma táctica que los romanos ya habían empleado con otros pueblos vencidos: la civilización⁶⁷.

Los motivos de esta política son diversos, por un lado, trata de modificar el estilo de vida de los piratas, entendiendo que su actividad venía dada más por su precaria situación económica que por una voluntad de delinquir, y para Pompeyo mejorar esa situación era la mejor forma de acabar con la piratería, y si bien la propaganda pompeyana pudo exagerar tal acontecimiento, esta reubicación de piratas prisioneros se llevó a cabo en realidad⁶⁸, como se puede observar en el pasaje de Appiano, *App. Mith.* 96 referido al desarrollo de la guerra contra los piratas en Cilicia, y donde se establece que en Mallos, Adena y Epifania, y en cualquier otra ciudad de la Cilicia Traquea que estuviese desierta, o con carencia de población, Pompeyo asentó a los piratas que parecían haber practicado la piratería como consecuencia de los desastres causados por la Guerra Mitridática. Si bien, la intención siempre fue alejar a los piratas lo más posible del mar, en realidad, una cantidad importante de ciudades donde se asentaron estaban en las costa, y el mar continuó siendo su medio de vida, aunque no con actividades ilícitas⁶⁹.

Otra motivación sería más personal que la simple clemencia, pues como destaca la doctrina, Pompeyo con esta medida adquirió una serie de clientelas orientales muy útiles⁷⁰, pues debió valorar la oportunidad de conservar al menos parte de la potencia bélica de los

65 SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, op.cit., pp. 170-171. Plut. Pomp. 27, 4.

66 Vell. 2, 32, 4-5-6; Flor. Epit. 1, 41, 14; Plut. Pomp. 28; Dio Cass. 36, 37, 6; App. Mith. 96.

67 ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.), op.cit., p. 63.

68 Verg. Georg. 4, 125-148.

69 Entre otras Pompeiopolis, Dime, Malos, Tarento y Side. La doctrina mayoritaria sostiene que a Pompeyo se debe el resurgir de la vida ciudadana de Oriente, a este respecto vid. LANGLOIS, V., "Soli et Pompeiopolis", en *Rev. Arch.*, 19, 1853, pp. 358 y ss.; FLETCHER, W.G., "The pontic cities of Pompeius the Great", en *TPAPhA*, 70, 1939, pp. 17 y ss.; MARSHALL, A.J., "Pompey's organization of Bithynia-Pontus; two neglected texts", en *JRS*, 58, 1968, pp. 103 y ss.; JONES, A.H.M., *The cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford, 1975, pp. 16 y ss.; MARTINA, M., "Le clientele piratiche di Pompeo", en *La Rivoluzione romana. Inchiesta tra glia antichisti*, Napoli, 1982, pp. 175 y ss.; AMIRANTE, L., *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1991, p. 325; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., p. 208.

70 Esta red de clientes tuvo un papel fundamental más tarde para su hijo Sexto, vid. MARTINA, M., "Le clientele piratiche di Pompeo", en *La Rivoluzione romana. Inchiesta tra glia antichisti*, op.cit., p. 179; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., pp. 237 y ss.; AMELA, L., "Las inscripciones honoríficas dedicadas a Pompeyo Magno", en *Faventia*, 23, 2001, pp. 87 a 102; WELCH, K.-POWELL, A., *Sextus Pompeius*, London, 2002, pp. 215 y ss.; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., pp. 74

piratas con el fin de utilizarlos para su ascenso personal, lo que ha llevado a diversos autores a afirmar que la guerra contra los piratas fue una “falsa guerra”⁷¹, posición que apreciamos demasiado radical⁷². No obstante, como sostiene Mommsen⁷³ queda clara la imposibilidad de los corsarios para medirse con las fuerzas de Roma, que en este caso fueron utilizadas sin escatimar medios, estando el verdadero éxito en el triunfo de una dura política de confrontación contra los poderes del Senado.

Ahora bien, aunque ciertas fuentes declaran que tras Pompeyo no se volvió a ver piratas en el Mediterráneo, esto es una exageración, pues el hecho de que tras su campaña se continuasen enviando gobernadores de rango consular o proconsular a Cilicia indica que se seguía necesitando la dirección de magistrados con *imperium*⁷⁴.

Por lo tanto, desde el Principado hasta el siglo III la piratería fue una actividad latente en el *Mare Nostrum*, pero redimensionada y diferente en su naturaleza; se puede afirmar que hubo un resurgimiento a pequeña escala de la piratería, pero ya no supuso ningún peligro para la existencia de Roma ni jugó un papel en su política. Esto es, podemos hablar de una actividad pirática de niveles tolerables, con episodios aislados y poco frecuentes, controlables por la maquinaria de guerra romana⁷⁵, sobre todo, cuando los piratas ya no tenían acceso a su principal fuente de ingreso, el tráfico de esclavo, pues la campaña de Pompeyo termina con dicha actividad⁷⁶.

El problema de la piratería ha continuado presente en el mar en mayor o menor medida durante siglos, incluso siendo apoyada por los Estados como medio de control del comercio internacional, o de rivalidad entre potencias estatales, apareciendo con mayor virulencia en épocas de crisis, como ya ocurría en la antigüedad.

En la actualidad se puede hablar de una situación de alta actividad pirática en determinadas zonas del planeta, de hecho, ha llegado a ser un serio problema a principios del tercer milenio, lo que ha provocado una reacción internacional a gran escala, a fin de terminar, o al

y ss.; VALENTINI, A., “Un motivo di propaganda politica nella lotta triumvirale: la morte di Sesto Pompeo”, en *RCCM*, 51, 2009, pp. 39 y ss.; TARWACKA, A., en *Romans and pirates. Legal perspective*, op.cit., pp. 74 y ss.

71 MARTINA, M., Le clientele piratiche di Pompeo, en *La Rivoluzione romana. Inchiesta tra glia antichisti*, op.cit., p. 177 (nota 30-31).

72 Seguimos en este sentido la opinión de MONACO, L., en *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., p. 209.

73 MOMMSEN, Th., *Historia de Roma*, 3, (Trad. García Moreno), op.cit., p. 98.

74 Así, en el año 62 a.C. el gobernador de Asia necesitó una flota para luchar contra los piratas, como afirma Cicerón en su *Cic. pro Flacc.* 31-32. Y Siria fue asolada por los piratas durante la restauración de Ptolomeo XII en el 55 a.C., mientras era gobernador Gabinio. Además vid. AMELA, L., “La campaña de Pompeyo Magno contra los piratas en Hispania (67 a.C.)”, en *Hispania Antiqua, Revista de Historia Antigua*, 30, op.cit., p. 17; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, op.cit., pp. 61 y 70. *Flor. Epit.* 1, 41, 15; *Cic. Flacc.* 28-30.

75 A este respecto, cabe destacar la opinión de ORMEROD, H.A. en *Piracy in the Ancient World: an essay in Mediterranean history*, op.cit., pp. 13 y ss., que sostiene que el desarrollo de la piratería tuvo como uno de sus elementos favorables la ausencia de imperios marítimos o terrestres susceptibles de poner orden en el mar.

76 PULCI DORIA, L., “La provincia di Cilicia e gli ordinamenti di Pompeo”, en *RAAN*, 47, 1962, pp. 327 y ss.; CRAWFORD, M.H., “Republican Denarii in Romania: the suppression of Piracy and the slave-trade”, en *JRS*, 67, 1977, pp. 117 y ss.; GARLAN, Y., “War, Piracy and slavery in the Greek world”, en *Classical Slavery*, 8, London, 1987, pp. 7 y ss.; SOUZA, P., *Piracy in the Graeco-Roman World*, op.cit., p. 180; MONACO, L., *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, op.cit., pp. 247 y ss.

menos, controlar el mismo, tal como se hiciera en la última etapa de la República romana⁷⁷. En este sentido, la mitad de los ataques piratas que se denuncian ocurren en las costas de Somalia o en el Golfo de Guinea, así como en algunas zonas de Asia⁷⁸.

Ahora bien, la zona más activa es Somalia, donde los piratas tuvieron un importante desarrollo en el inicio de la década de los 90, a raíz de la guerra civil en ese país; no obstante, en los últimos años cada vez tienen menos presencia los piratas, en parte por el esfuerzo internacional que se ha realizado por erradicarlo⁷⁹.

En consecuencia, esta actividad ha variado su ubicación a las aguas del golfo de Guinea, donde en el primer semestre de 2013 los ataques piratas aumentaron un 35% respecto al año anterior, según un informe la Oficina Marítima Internacional (en adelante IMB)⁸⁰. La mayor parte de los ataques que se registran en esa región ocurren en Nigeria, que tiene como características sus graves problemas sociales, una corrupción generalizada, mucho desempleo, abandono del Estado, y el robo de petróleo en tierra, así como la piratería como salidas laborales posibles para la población, que ve estas actividades como una fuente de inversión, un incremento del consumo, y una oportunidad de trabajo⁸¹.

Ahora bien, a la política represiva llevada a cabo por la comunidad internacional contra la piratería, hay que añadir medidas de corte social para poder hablar de una solución definitiva, ya que una salida permanente requiere la puesta en marcha de una estrategia coherente y coordinada para atacar, simultáneamente, las causas profundas del problema en tierra y la actividad de los piratas en el mar, si es que se quiere restringir eficazmente su libertad de acción y reducir sus posibilidades de éxito⁸².

Como se puede observar, la piratería sigue suponiendo siglos después de la República romana un impedimento a la actividad comercial, pues no solo ha impuesto al comercio mundial en términos generales un tributo oculto, sino que afecta negativamente a la actividad económica de países vecinos a las zonas de gran actividad pirática, así, los países de África oriental han experimentado un acusado descenso en llegadas de turistas y en su producción pesquera.

77 A este respecto, España participa en las misiones «Atalanta» y «Ocean Shield» de 2009 de la OTAN, para la lucha contra la piratería en estas zonas del planeta, en especial por el problema pesquero. Con el mismo fin, en enero de 2009 se creó la Task Force TF-151, en el marco de la coalición de fuerzas marítimas lideradas por EEUU.

78 Los mares de Indonesia registraron más de la mitad de los casos de piratería, aunque la mayoría son considerados de bajo nivel y oportunistas, una tipología que también identifica a los puertos de India y Bangladesh.

79 En 2012 la piratería en la costa somalí ya había retrocedido un 68% respecto a 2011, continuando en la actualidad esta tendencia.

80 División de la Cámara Internacional de Comercio dedicada a seguir los delitos marítimos.

81 Nigeria es el principal exportador de crudo de África y el segundo país del mundo lo que conlleva una especial preocupación por los asaltos piratas a buques petroleros en impulsados por el contrabando de crudo, según explica el Sr. Pottengal Mukundan, Director del IMB.

82 Según el director de IMB además de las medidas preventivas privadas, así como de las fuerzas navales internacionales que patrullan la zona, se deben dar pasos para estimular las comunidades locales a denunciar a los piratas: “Esto es muy importante porque en el mar se puede resistir, pero al fin y al cabo la piratería sólo puede ser derribada en tierra”. Vid. el informe titulado *The Pirates of Somalia: Ending the Threat; Rebuilding a Nation* (“Piratas de Somalia: Acabar con la amenaza y reconstruir una nación”), editado por el Banco Mundial, presentado en Mogadiscio con el apoyo del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

Por ello, como ya se hizo hace más de dos mil años, se debe modificar el enfoque actual de la lucha contra la piratería, pues las políticas que se aplican actualmente en tierra y en mar para acabar con la misma son eficaces parcialmente, o probablemente insostenibles, pues las patrullas navales fuertemente armadas y una seguridad mejorada a bordo de los buques comerciales explican el desplome de la piratería en 2011 y en 2012, pero estas medidas solo son efectivas mientras se sigan aplicando.

El propósito de las intervenciones en tierra, como el desarrollo económico local o las iniciativas para el cumplimiento de la ley, tienen como principal misión disuadir a los jóvenes de convertirse en piratas mediante el incremento de empleos interesantes alternativos o, a través del compromiso de imponer largas penas de cárcel en caso de captura.

La piratería está regulada a nivel internacional, pues se puede considerar el primer crimen de este carácter, sobre el que todos los Estados tenían por sí mismos capacidad y legitimidad suficiente para determinar y perseguir. Esta regulación se centra en la Convención ginebrina de Alta Mar de 1958 y, posteriormente la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar de 1982, arts. 100 al 107. En el art. 101 de la Convención se define la piratería como los actos de violencia o detención, o de depredación cometidos para un fin privado por la tripulación de una embarcación privada contra cualquier otro barco en alta mar, o fuera de cualquier jurisdicción estatal. Esta definición está en consonancia con la expresión latina que identifica al pirata con un *hostis humani generis*: enemigo de toda la humanidad⁸³.

En conclusión, estamos probablemente ante un crimen de carácter internacional al que la sociedad trató de dar soluciones, primero de forma puntual, cuando se producían los ataques, para llegar a una solución integral, militar, legislativa y social, repeliendo los actos de piratería con dureza por un lado, y por otro alejando a los piratas de la actividad ilegal, dándoles oportunidad de llevar una vida digna dentro de los márgenes legales, solución romana que sigue todavía vigente después de veinte siglos a tenor de las noticias que periódicamente aparecen en los medios de comunicación relacionadas con la actividad pirática actual.

83 MACKINLAY, A., *La lucha contra la piratería en aguas del Océano Índico: la necesidad de una aproximación integral*, Real Instituto Elcano, Madrid, 2010, pp. 3 y ss.

LOS EXTRANJEROS Y EL COMERCIO EN INDIAS, EL CASO DE LOS NAVARROS Y LOS ARAGONESES

FRANCISCO CUENA BOY

Catedrático de Derecho Romano. Universidad de Cantabria

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El comercio y la verdadera importancia del derecho de gentes. 3. Hevia Bolaños y Solórzano Pereira sobre los navarros y los aragoneses. 4. Escalona Agüero y Veitia Linage sobre la misma cuestión. 5. Conclusiones.

1. Los extranjeros¹ tenían prohibido ejercer el comercio en Indias, tal era la regla general y en algún momento habrá que preguntarse por su fundamento. De todos modos, la finalidad de este trabajo es más modesta: queremos saber concretamente a quiénes se consideraba extranjeros a efectos de la prohibición. Ello porque, si bien la respuesta es clara en el caso por ejemplo de los franceses o los holandeses, en el de los portugueses lo es un tanto menos, y en el de los aragoneses y los navarros empieza a ser decididamente oscura. Para delimitar bien nuestro interés, conviene señalar que la pregunta que hemos formulado se detiene en un aspecto particular de una cuestión mucho más amplia, a saber, la de las restricciones que se ponían a los extranjeros para pasar a Indias y para ejercer allí casi cualquier actividad. De esta cuestión más amplia no nos vamos a ocupar sino en la medida, que prevemos no mucho más que incidental, en que nos deje tranquilos para poder avanzar en nuestro tema.

De él se ocupaba Solórzano Pereira sea en el *De Indiarum iure* sea en la *Política Indiana*. En principio, de tratadista tan acreditado debemos esperar razones sólidas y argumentos bien contruidos. Tendremos ocasión de comprobar si los que utiliza son verdaderamente de tales características; por de pronto, valga su nombre de mojón para señalar el momento cronológico en el que nos colocamos para hacer las observaciones que siguen.

1 Las obras de Juan de Solórzano Pereira se citan conforme a las ediciones siguientes: el tratado *De Indiarum iure* I-III (1629) por la del Corpus Hispanorum de Pace, segunda serie, con traducción española y diversos estudios preliminares [Madrid, I (2001), II/1 (1999), II/2 (2000), III (1994)]; la *Política Indiana* (1647) por la de Francisco Tomás y Valiente y Ana María Barrero, en tres tomos, Madrid, 1996. Las referencias de la *Curia Philipica* de Juan de Hevia Bolaños proceden de la ed. de Madrid, 1797, reprod. facsimilar Valladolid, 1989; la única cita de la *Suma de tratos y contratos* de Tomás de Mercado se ajusta a la ed. de Nicolás Sánchez Albornoz, Madrid, 1977; las del *Norte de la contratación de las Indias* de Joseph de Veitia Linage se toman de la edición original, Sevilla, 1672, reimpr. facsimilar por el Ministerio de Hacienda, Madrid, 1981, con estudio introductorio y varios apéndices de Francisco de Solano; por último, las citas del *Gazophilacium regium Perubicum* de Gaspar de Escalona Agüero son de la primera ed., Madrid, 1647, incluida en el CD *Textos clásicos de literatura jurídica indiana* I, compilador Ismael Sánchez Bella, Madrid, 1999.

“Los comercios son del derecho de las gentes”: sobre esta idea construye Solórzano el capítulo de la *Política* que dedica específicamente a los mercaderes y contratantes de las Indias²; no es la primera vez que acude a ella, también lo ha hecho en dos lugares por lo menos del *De Indiarum iure*³, aunque en contextos y para fines distintos en principio de los que tiene a la vista en el capítulo en cuestión. A la hora de fundamentar aquella idea, es indispensable la cita de la ley *Ex hoc iure* del Digesto (D. 1.1.5) y, con ella, la del versículo *ius autem gentium* de I. 1.2.2. Solórzano recuerda ambos pasajes y explica también que esto de ser el comercio de derecho de gentes se debe a que no hay pueblo que pueda pasar sin él; tampoco, en consecuencia, sin los que son sus agentes naturales⁴. A partir de aquí, el capítulo de la *Política* se extiende en los privilegios e inmunidades de que gozan los comerciantes⁵, en algunos límites que se les imponen (la prohibición del juego)⁶, en precisar a quiénes conviene el nombre de comerciante y los privilegios consiguientes⁷, en la prohibición de ejercer el comercio que pesa sobre los clérigos⁸, en los Consulados de comercio⁹ y en otros varios asuntos. Entre ellos, aquel por el que aquí nos preguntamos, cuyo tratamiento se ubica en los números 14 a 17 del capítulo.

2. Brevemente, el problema se plantea en los siguientes términos: supuesto que el comercio es de derecho de gentes, parece injusto que los españoles prohíban a otros pueblos ejercerlo en Indias, “no menos que si los franceses prohibiesen a los italianos comerciar con los españoles o navegar por sus mares”¹⁰. Nótese el vocablo “españoles” (*hispani*) que aparece en la frase entrecomillada: es verdad que Solórzano se está refiriendo a la exclusión de los que son extranjeros *absolute*, pero no cabe duda de que bajo el nombre de *hispani* incluye a todos los peninsulares con excepción, quizá, únicamente de los portugueses. Esto en el *De Indiarum iure*.

En el capítulo de la *Política* se precisa que los excluidos son “los extranjeros de los reinos de Castilla y León”; son éstos los que no pueden ser mercaderes en las Indias “por sí, ni por terceras personas”¹¹. En esta situación se encuentran en particular los portugueses, mandados expulsar de aquellas tierras por muchas cédulas respecto de las que se pregunta Soló-

2 *Política Indiana*, VI, 14, 3; el título de este capítulo es “De los mercaderes y contratantes de las Indias, de su Consulado, favores y privilegios y otras cuestiones de la materia”.

3 *De Indiarum iure*, II, 25, 38; cfr. también II, 20, 34.

4 Para esto se apoya, entre otras autoridades, en D. 50.6.6.3 (con la glosa), C. 10.48.7 (con el comentario de Amaya) y D. 50.11.2; en este último texto leemos lo siguiente: *summae prudentiae et auctoritatis apud Graecos Plato cum instituerit, quemadmodum civitas bene beate habitari possit, in primis istos negotiatores necessarios duxit*; cfr. *Política Indiana*, VI, 14, 3, nt. 4.

5 *Política Indiana*, VI, 14, 5-6 y 18-21.

6 *Política Indiana*, VI, 14, 7.

7 *Política Indiana*, VI, 14, 8-10.

8 *Política Indiana*, VI, 14, 11-13.

9 *Política Indiana*, VI, 14, 22-28.

10 *De Indiarum iure*, II, 25, 40; el contexto es aquí el de las razones por las que la Sede Apostólica prohibió “a cualesquiera otros reyes, príncipes o personas privadas [distintos de los españoles] llegar a este Nuevo Mundo o surcar sus mares”.

11 Para la prohibición, vid. *Recopilación de leyes de Indias*, IX, 27, 7 y III, 13, 8.

rzano si se aplicarán también a los navarros y los aragoneses¹². No resuelve aquí el punto, limitándose a remitir al tratamiento que le dispensa Hevia Bolaños y al suyo propio en un lugar anterior de la *Política*¹³. En todo caso, sin especial preocupación por la coherencia, lo que sí hace de forma inmediata es afirmar la justicia de aquellas cédulas no embargante el hecho inconcuso de “ser los comercios del derecho de las gentes”¹⁴. El párrafo presenta una redacción poco afortunada, cosa insólita en la *Política*, y su sustancia se reduce a la afirmación de que “los señores de las tierras” pueden prohibir la entrada y contratación a los mercaderes extranjeros así como expulsarlos después que hubieren entrado, todo ello sin necesidad de justa causa “y por su sola comodidad”. El exceso de este dictamen —que Solórzano ha introducido con la fórmula “lo más cierto es que...”— se intenta limar a continuación alegando una serie de autores que refieren ejemplos de muchas expulsiones en las que sí hubo causa legítima¹⁵. Y así concluye ufano nuestro tratadista: “que es lo que Yo también tengo dicho más largamente que todos en el capítulo particular en que trato de esta prohibición en nuestras Indias occidentales”¹⁶.

Tenemos pendiente el tema de los navarros y los aragoneses pero, antes de afrontarlo, nos parece conveniente parar un momento en eso que Solórzano tiene dicho más largamente que todos. De esta forma acabaremos de entender la *ratio* de la prohibición de ejercer el comercio en Indias que —en contra del *ius gentium*, por lo que parece— afectaba a los extranjeros. Para abreviar, el argumento decisivo en torno al que giran todos los demás es la propagación de la fe cristiana: el “Sumo Pastor de la Iglesia” puede, con todo derecho, “prohibir no sólo la predicación, sino también el comercio dentro de esas mismas fronteras [scil. las de las Indias], si ello es más conveniente para la propagación de la religión cristiana”¹⁷. No se discute que las libertades de comercio y navegación sean de derecho de gentes, pero tales libertades ceden ante el derecho de otro príncipe que se haya anticipado “por justas y legítimas causas” o al que la Sede Apostólica haya concedido el monopolio. En el caso concreto de las Indias, anticipación, causa legítima y concesión pontificia vienen a ser una misma cosa y determinan la subordinación del interés particular al “bien general de la Iglesia y de los indios”¹⁸. En definitiva, escribe nuestro autor, “[e]l precepto divino de procurar la conversión de las almas supera y está por encima de ese otro que, introducido por el derecho de gentes, deja libre a todos la travesía del mar y admite el comercio de pueblos extranjeros con los indios y con cualesquiera naciones”¹⁹.

Siguiendo su costumbre, que es método más que costumbre, Solórzano invoca textos y autoridades en respaldo de sus afirmaciones. La Auténtica *Res quae subiacent* (pero no el

12 *Política Indiana*, VI, 14, 14.

13 Concretamente, en *Política Indiana*, IV, 19.

14 *Política Indiana*, VI, 14, 15.

15 Baldo, Rebufo, Estraca, Matienzo, Valenzuela y Egidio Benedictino; la causa legítima es “el temor de que con la admisión y mezcla de tales extranjeros se pueda temer alguna turbación en el reino, inteligencia y descubrimiento de sus fuerzas y secretos, o perversión y corrupción en la fe, religión y buenas costumbres”.

16 El capítulo particular en cuestión es *De Indiarum iure*, II, 25, concretamente los párrafos 38-89; también se toca el tema de los extranjeros en *Política Indiana*, III, 6, 33-37, en relación con la concesión de las encomiendas.

17 *De Indiarum iure*, II, 25, 44-46.

18 *De Indiarum iure*, II, 25, 63-64.

19 *De Indiarum iure*, II, 25, 65.

texto de C. 6.51.1.15, que no hace al caso) le suministra aquella idea de que lo que aprovecha a todos en común se debe anteponer a lo que es útil para algunos en particular²⁰; en la misma línea se sitúan el comentario de Jasón de Mayno sobre D. 1.14.3 y D. 30.41.5, el de Tiberio Deciano sobre D. 50.17.11 y las citas de Juan de Coras y Andrés Gayl que añade al final. En cuanto a la primacía del derecho divino sobre el de gentes, señala que los doctores muestran con muchos ejemplos la frecuencia con que preceptos cardinales o primordiales del derecho natural cesan, ceden o se suavizan cuando “chocan con otros en los que se halla un mayor y más apremiante aspecto de bien común, necesidad o utilidad”. No vamos a seguir la pista a estos doctores²¹; sólo queremos indicar que en la frase de Solórzano no nos queda claro si esos “otros” preceptos más apremiantes que menciona son asimismo de derecho natural o de derecho de gentes.

Por lo demás, al margen de lo bien razonado que pueda parecernos, lo anterior presupone un contexto ideológico global que, por su carácter anterior a todo discurso jurídico, desborda ampliamente el campo del derecho. Se trata, en todo caso, de un andamiaje sin el cual el argumento solorciano, tal y como nos lo presenta su autor, sencillamente no funciona²².

¿Era, sin embargo, necesario ese contexto para la justificación que Solórzano pretendía? Podemos afirmar que no. Hevia Bolaños se ocupa también de la cuestión —*Si los extranjeros pueden tratar en las Indias*— y la expone y la resuelve con mucho menos aparato, recordando simplemente dos leyes de la *Recopilación* de 1567 que se refieren a la prohibición y enumerando los inconvenientes que podrían seguirse de la inexistencia de la misma: la saca de moneda, la depravación de las leyes y costumbres de los naturales, el uso de monopodios y usuras prohibidas, el develamiento de secretos, etc.²³

3. Y con Hevia Bolaños volvemos por fin al problema de si los navarros y los aragoneses eran considerados extranjeros de manera de prohibírseles el ejercicio del comercio en Indias. Hevia traza una clara distinción. De los navarros dice que se reputan “naturales del Reyno” por particular concesión real de 1553; en cambio, los aragoneses, y por la misma razón los portugueses, se consideran extranjeros. Esa razón la expone con toda sencillez diciendo que los nacidos en el reino de Aragón son extranjeros porque “aunque fué puesto [dicho reino] en la Corona Real, y juntado á ella, no fué en modo de natural, sino en su propio, y primer estado, y fuerza en que quedó, rigiéndose por sus propias leyes, y costumbres”²⁴. Se trata, así pues, de la conocida arquitectura de la unión dinástica en cuya

20 Ea enim quae communiter omnibus prosunt his quae specialiter quibusdam utilia sunt praeponimus; cfr. Nov. 39, c. 1.

21 Solórzano remite primero de forma genérica a los doctores sobre I. 1.2.11, I. 1.2.6 pr., D. 4.5.8 y D. 46.3.95.4; después menciona a Pedro Gregorio y a Pichardo de Vinuesa, éste sobre C. 11.7(8).3: *De Indiarum iure*, II, 25, 65.

22 Basta pensar en la idea de la donación o concesión pontificia de las Indias, que presupone toda una teoría política acerca de la comunidad internacional que por la época en que Solórzano escribía ya había sido superada o estaba, por lo menos, en franco retroceso; vid. por todos MESNARD, 1956, pp. 434 ss.

23 Juan DE HEVIA BOLAÑOS, *Curia Philipica* (1603), t. 2, I, 1, 36; las leyes de la *Nueva Recopilación* son éstas: VI, 18, 5 y VII, 2, 3 i.f. La exclusión de los extranjeros tampoco le supone ningún problema a Tomás DE MERCADO, *Suma de tratos y contratos* (1571), vol. 1, lib. 2, cap. 6, al comienzo.

24 *Curia Philipica*, t. 2, I, 1, 37.

virtud los reinos, aun enlazados por arriba, son y siguen siendo diferentes²⁵: la extranjería de los aragoneses procedía de esta arquitectura, era una consecuencia o implicación de la misma.

¿Qué tiene que decir acerca de esto Solórzano en aquel otro lugar de la *Política* al que había remitido el tratamiento del tema? Puede sorprendernos, en primer lugar, la ubicación²⁶: el problema se discute a propósito de la provisión de oficios y beneficios eclesiásticos, con el resultado de que, cuando mucho más adelante llega el momento de ocuparse de los mercaderes de las Indias, la cuestión de los navarros y los aragoneses ya ha sido decidida sin necesidad de mencionar siquiera el *ius gentium*, sino a la única luz de la legislación real y de la práctica. En efecto, lo que interesa dilucidar a Solórzano es “si los navarros y aragoneses se han de reputar por naturales de Castilla y León y particularmente de nuestras Indias, o por extranjeros *para poder tener o no los oficios y beneficios de ellas*”²⁷. Esto no sólo es muy distinto del ejercicio del comercio, sino algo sobre lo que el derecho de gentes no tiene nada que decir. Sin embargo, lo importante es darse cuenta de que para el autor de la *Política*, tal como indica la organización de su discurso, lo que se diga en relación con la provisión de beneficios, eso mismo ha de valer para el ejercicio del comercio.

Pues bien, por lo que toca a los oficios y beneficios de las Indias, “parece” —así es como se expresa Solórzano— que a los navarros y aragoneses se los debe contar “en la clase de extranjeros, como a los portugueses, italianos, flamencos y otros cuyas provincias no están unidas a los reinos de Castilla y León, y las Indias accesoriamente, sino con igual principado y conservando sus leyes y fueros con que se gobernaban antes de su unión y agregación”²⁸. Como se puede ver, se trata del mismo razonamiento basado en la unión personal de reinos que Hevia Bolaños había empleado en el caso de los mercaderes: Solórzano lo dirige ahora a esta otra finalidad. La idea, por supuesto, no es invención de estos autores, que se sirven ambos para darle cuerpo poco más o menos de las mismas fuentes doctrinales²⁹, siendo muy probable que Solórzano se remontara hasta ellas con ayuda de

25 Con la fórmula de Tomás y Valiente, unidad de la Monarquía y diversidad de los reinos: vid. TOMÁS Y VALIENTE 1983, pp. 282 ss.; BARRIENTOS GRANDON 2000, pp. 111 ss.; cfr. OTS CAPDEQUÍ, 1945, p. 188: al tiempo del descubrimiento de América, España “era, políticamente considerada, una federación de naciones sujetas a una misma monarquía, y en último término, un Imperio. Los territorios de Indias fueron incorporados a la Corona de Castilla y esto hizo que, con respecto a ellos, fueran considerados como extranjeros los súbditos de los monarcas españoles, no castellanos”; HERZOG 2006, pp. 107 s.; GAUDIN 2013, pp. 10 s.

26 Recordemos: *Política Indiana*, IV, 19, concretamente los párrafos 31 ss., que son fiel traducción de los 48 ss. del cap. 19, lib. III, del tratado solorciano *De Indiarum iure, sive de iusta Indiarum Occidentalium gubernatione*.

27 *Política Indiana*, IV, 19, 31 (cursiva nuestra). Sobre la llamada “reserva de oficio”, vid. HERZOG 2006, pp. 107 s., 112 ss.

28 *Ibid.*; cfr. *Política Indiana*, IV, 19, 37: “No obsta que todos estos reinos se hallen reunidos y constituyan hoy una como Monarquía... Porque lo más cierto es que también en este caso los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos”.

29 Solórzano, *Política Indiana*, IV, 19, 32-33, va citando los autores y obras siguientes: Diego PÉREZ DE SALAMANCA, *Commentaria in quatuor priores libros ordinationum Regni Castellae*, Salamanca, 1575, ad l. 18, tít. 3, lib. 1; Alfonso DE AZEVEDO, *Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regias constitutiones*, Salamanca, 1583-1598, in l. 14, tít. 3, lib. 1, núms. 1 ss.; Marcos SALÓN DE PAZ, *Ad leges Taurinas insignes comentarii*, Valladolid, 1568, in l. 1, núm. 451; Juan MARTÍNEZ DE OLANO, *Concordia et nova reductio antinomiarum iuris communis et Regni Hispaniarum*, Burgos, 1575, praef. núm. 20; Ignacio LÓPEZ DE SALCEDO, *Additiones ad Ioannis Bernardi Diaz Praxim criminalem canonicam*, Venecia, 1614, cap. 54, núm. 24: “Et potissima ratio est, quia licet dicta

la identificación que encontró en Hevia. Pero, más que esto, lo que importa es destacar el alcance material del argumento: los extranjeros no pueden tener oficios y beneficios en las Indias ni tampoco habitar, tratar y contratar en ellas³⁰; ésta es la regla general que resulta aplicable también a los navarros y los aragoneses, por lo menos en principio y por las razones dichas³¹.

Recordemos sin embargo que Solórzano se muestra muy poco categórico desde el momento mismo en que rompe a hablar del tema: “[L]o que *he visto dudar algunas veces* es si los navarros y aragoneses se han de reputar por naturales de Castilla y León... Y *parece que* los debemos contar en la clase de extranjeros...”³². Su circunspección se explica fácilmente por lo que respecta a los navarros, dado que no ignora la cédula real de 28 de abril de 1553 que —dice— los había “connaturalizado”³³, medida ésta que poco después califica como privilegio³⁴. Respecto de los aragoneses, en cambio, subraya que no encuentra nada parecido y recuerda incluso que Hevia Bolaños “los tiene por extranjeros para todo lo tocante a las Indias y pasar, estar y comerciar en ellas”³⁵. ¿Los tenía, pues, él también por extranjeros? No es fácil dar una respuesta terminante. Solórzano señala en primer lugar que no vio nunca “que esto se ejecutase” e infiere de ahí que de Fernando el Católico en adelante se había venido formando una costumbre favorable a los aragoneses; de tal costumbre dice que “ya pasó en fuerza de ley”. Esta última observación hace referencia a una cédula de 3 de enero de 1596 en la que, siempre según Solórzano, se manda que “no se proceda contra los de las islas de Mallorca y Menorca como contra extranjeros”, aunque lo cierto es que el texto que se incorporó a la *Recopilación de leyes de Indias* declara extranjeros, con más detalle y precisión, a “los que no fueren naturales de estos nuestros Reynos de Castilla, Leon, Aragon, Valencia, Cataluña, y Navarra, y los de las Islas de Mallorca, y Menorca, por ser de la Corona de Aragon”³⁶. Luego añade que el Consejo de Indias, advertido por él de la existencia de esa ley, acordó no innovar nada “en cuanto al poder pasar los aragoneses a las Indias, residir, tratar y contratar en ellas” y dispuso igualmente que el privilegio concedido

regna fuerunt adiuncta regiae coronae, non tamen hoc in modum submissionis factum est”; Tomás DE CARLEVAL, *Disputationes iuris variae ad interpretationem regiarum legum Regni Castellae*, disp. 2, núm. 99. Inesperadamente, Azevedo señala una raíz de la exclusión de los extranjeros nada menos que en el *ius divinum*.

30 Cfr. *Política Indiana*, IV, 19, 28.

31 La obtención de cartas de naturaleza y la llamada “composición” eran las excepciones principales; cfr. HERZOG 2006, pp. 149 ss., 166 s.

32 *Política Indiana*, IV, 19, 31 (cursiva nuestra).

33 *Política Indiana*, IV, 19, 33; vid. *Recopilación de leyes de Indias*, I, 6, 32; en el mismo número recuerda Solórzano otras dos cédulas (una de ellas de 3 de noviembre de 1581) que aprueban para los navarros “la permisión para los beneficios de las Indias”. En el *De Indiarum Occidentalium gubernatione*, III, 19, 48, Solórzano menciona dos cédulas de 28 de abril de 1553 relativas a los navarros: una “quoad beneficia regnorum Castellae, et Legionis”, y otra “quoad prebendas, et beneficia nostrarum Indiarum”.

34 *Política Indiana*, IV, 19, 36.

35 *Política Indiana*, IV, 19, 35.

36 En efecto, la cedula que menciona Solórzano es la misma ley incluida en la *Recopilación*, IX, 27, 28; “... y asimismo declaramos por Extrangeros á los Portugueses”, se lee en la disposición de Felipe III que se incluye ahí mismo de inmediato; cfr. OTS CAPDEQUÍ 1945, p. 189; HERZOG 2006, p. 307, nt. 4 y p. 316 nt. 1; GAUDIN 2013, p. 11.

a los navarros para poder tener en ellas prebendas y beneficios eclesiásticos se conservara en sus propios términos³⁷. Por todo ello cuesta entender lo que dice a continuación:

No obsta que todos estos reinos se hallen unidos y constituyan hoy una como Monarquía, por donde parece que importa poco que todos los vasallos de ellos se igualen o, por mejor decir, que no se pueden tener por extranjeros ni peregrinos los que están debajo del dominio de un mismo rey... Porque lo más cierto es que también en este caso los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos³⁸.

¿Acaso esto no invita a concluir que Solórzano era de la opinión de que a los aragoneses —careciendo de un privilegio similar al de los navarros— se los debe tratar como extranjeros y, en consecuencia, debe prohibírseles el ejercicio del comercio en Indias? Tal pensamiento coincidiría exactamente con lo afirmado por Hevia Bolaños (que, dicho sea de paso, parece no haber conocido la real cédula de 1596 o no haberle dado importancia en relación con la prohibición de comerciar en Indias). ¿Es creíble sin embargo que Solórzano Pereira dejara de plegarse en esto, como siempre y en todo se plegaba, a la voluntad del legislador real que ya se había manifestado en 1596? Véase, en todo caso, cómo remata la discusión del punto:

Pero ya hoy, cuando esto se imprime, cesan en cuanto a los aragoneses todas disputas, pues el Rey, nuestro señor, don Felipe IV, que Dios guarde, se ha servido de concederles que aun en todos sus Consejos, Audiencias y Tribunales de Castilla y de las Indias haya de haber precisamente por lo menos un ministro que sea natural de aquel reino, y así se ha puesto en ejecución, con que parece quedan habilitados para todos los demás cargos, negociaciones y contrataciones cuando aun de antes no lo estuvieron³⁹.

O sea, el insigne tratadista insiste en que la consideración de los aragoneses ha sido cuestión controvertida hasta ese momento tan tardío en que una nueva norma —muy alejada por cierto de lo que es la regulación específica del comercio— parece haberla zanjado de forma definitiva. Si no es por la influencia doctrinal de Hevia Bolaños, no acertamos a explicar un tratamiento tan reticente por parte de Solórzano.

4. Contemporáneo riguroso de Solórzano fue Gaspar de Escalona Agüero⁴⁰. Este escritor, en un capítulo de su monumental *Gazophilacium regium Perubicum*, ofrece una visión muy diferente del tema en su conjunto⁴¹. Resumiendo los datos que más de cerca nos tocan, los

37 Política Indiana, IV, 19, 36.

38 Política Indiana, IV, 19, 37.

39 Política Indiana, IV, 19, 38.

40 Nacido en La Plata (Sucre) en 1590, formado en la Universidad de San Marcos de Lima, nombrado oidor de la Audiencia de Chile en 1649 y fallecido allí en 1650; uno de los grandes tratadistas del derecho indiano; cfr. BRAVO LIRA 1989, pp. 153 ss.

41 Gaspar DE ESCALONA AGÜERO, *Gazophilacium regium Perubicum* (1647), I, 39; Escalona cita varias veces a Solórzano, pero sólo el *De Indiarum iure* porque su obra se publicó el mismo año que la *Política Indiana*; en cambio, Solórzano sí pudo ver el *Gazophilacium* antes de publicar esta última obra.

que aporta son éstos⁴²: una real cédula de 1591 dispuso que saliesen de las Indias “los que no fuesen naturales de Castilla, Aragon, Valencia y Cataluña, y que no pudiesen tratar en ellas”; por otra cédula de 1593, los navarros y los aragoneses se tienen por naturales y no caen bajo la citada prohibición; según cédula de 18 (por 28) de abril de 1553, los clérigos de Navarra pueden tener beneficios en Indias “por la razón referida arriba” (o sea, por ser considerados naturales). Escalona no trae a colación ni la ley de 1564 que Veitia recordará⁴³ ni tampoco —salvo que equivoque la fecha y sea la cédula referida de 1593— aquella otra de 3 de enero de 1596 aludida de forma tan imperfecta por Solórzano en la *Política*⁴⁴. Pero poco importa: para él es claro que los navarros y los aragoneses no caen en modo alguno bajo el concepto de extranjeros, por lo que no se les prohíbe comerciar en Indias. En cuanto a lo demás, de las muchas razones que acumula Escalona al principio de su capítulo con el fin de justificar la prohibición de ejercer el comercio en Indias que pesaba sobre los extranjeros⁴⁵, cabe destacar la alegación de dos constituciones imperiales de época postclásica⁴⁶ y también, aunque en otro orden de cosas, la ausencia de cualquier alusión a aquellos pasajes del *Corpus Iuris Civilis* según los cuales el comercio es de derecho común y de las gentes⁴⁷. Conviene recordar a este respecto que Solórzano, en el *De Indiarum iure*, partía precisamente de esos pasajes, por lo que muy bien podemos presumir que el autor del *Gazophilacium* era consciente de la importancia que podían tener para el problema del que se estaba ocupando.

El último autor del que nos vamos a ocupar es José de Veitia y Linage, cuyo *Norte de la contratación de las Indias Occidentales* se publicó en 1672. Como no podía ser de otro modo, uno de los puntos discutidos en el capítulo dedicado a la “prohibición que para navegar à las Indias, o comerciar en ellas tienen los estrangeros” es el referido a los navarros y los aragoneses⁴⁸. Explicando “quales devemos tener por comprehendidos en la voz *estrangeros*”⁴⁹, Veitia señala que a los navarros se los tiene por naturalizados en virtud de sendas cédulas de 28 de abril de 1553 y 3 de noviembre de 1581⁵⁰. En cambio, respecto de los aragoneses dice haberle extrañado (“me causó novedad”) que Solórzano no hubiese encontrado “permisión semejante”; y de Hevia Bolaños, que afirmaba directamente que eran extranjeros, señala su desconocimiento de una real cédula de 30 de abril de 1564 (ignorada también por Solórzano) que ordenaba expulsar de las Indias a los portugueses y no permitir la entrada de “*qualesquier estrangeros, que han ido de fuera destos Reynos de Castilla, y Aragón*”⁵¹. En definitiva, para este tratadista no es dudoso que “desde el descubrimiento de

42 *Gazophilacium*, I, 39, 10, 11 y 14.

43 Vid. *infra*, en este mismo apartado.

44 Vid. *supra*, nt. 36.

45 *Gazophilacium*, I, 39, 1-3.

46 C. 4.63.2 y 4.

47 D. 1.1.5 e I. 1.2.2.

48 Norte de la Contratación, I, 31.

49 Norte de la Contratación, I, 31, 3.

50 De acuerdo con Escalona añade en el mismo sentido una cédula del año 1593: Norte de la contratación, I, 31, 4.

51 Siguiendo una vez más a Escalona recuerda una cédula de 1591 que mandó que saliesen de las Indias y que no pudiesen tratar en ellas “los que no fuessen naturales de Castilla, Aragon, Valencia, y Cataluña”: Norte de la Contratación, I, 31, 4.

las Indias fueron tenidos por naturales dellas [sic] los Aragoneses”; antes por tanto que los navarros. Ahora bien, ¿cómo puede sostener tal cosa? Sencillamente, mediante la inversión del argumento de la unión personal de reinos en el que se habían basado Hevia y Solórzano para rechazar o discutir la condición de naturales de los aragoneses. Afirma en efecto Veitia que “el Reyno de Aragón estaba incorporado con el de Castilla al tiempo que las Indias se descubrieron”, mientras que el de Navarra se incorporó solamente veinte años más tarde, o sea, en 1512. La conclusión formal del autor es la siguiente: “son extranjeros de los Reynos de las Indias, y de todas sus Costas è Islas los que no fueren naturales de los Reynos de *Castilla, Leon, Aragon, Valencia, Cataluña, y Navarra*”⁵². Por lo demás, es de advertir que la “naturaleza” a la que se refiere Veitia de forma constante no es la de los reinos de Castilla y León sino la de las Indias: “naturales dellas”, “extrangeros de los Reynos de las Indias”. Hay en ello una novedad significativa con respecto a Hevia y Solórzano, cuya preocupación explícita consistía en establecer si los navarros y los aragoneses eran naturales de los reinos de Castilla y León.

5. Tenemos que concluir. Tal y como lo hemos presentado, a un foro de romanistas como éste el tema le puede parecer relativamente intrascendente. Creemos posible, sin embargo, extraer de él alguna lección ulterior. La primera tiene que ver con el carácter meramente teórico de la influencia del *ius gentium* en el marco jurídico del comercio. Hevia Bolaños, Escalona Agüero y Veitia Linage no le conceden en absoluto ninguna; para ellos, en efecto, lo determinante es la legislación real, aquello que Veitia llama “las leyes, y ordenanças de nuestro municipal derecho”⁵³. Pero es que las cosas no son muy distintas si hablamos de Solórzano: por mucho que comience recordando que “[l]os comercios son del derecho de las gentes”, su mayor empeño es anular las consecuencias de la aplicación de tal principio a los extranjeros. Y si a este fin invoca la primacía del *ius divinum* sobre el *ius gentium*, el primero representado por el bien supremo de la propagación de la fe cristiana y el segundo por la libertad de comercio y navegación, lo cierto es que la impresión que todo ello transmite es la de tratarse de una argumentación meramente pro forma. Porque al fin y a la postre, pese a su mayor propensión teórica Solórzano se acaba agarrando también al “derecho municipal de estas nuestras Indias”⁵⁴; es decir, hace lo mismo que los otros autores que hemos manejado con la única y extraña diferencia de que, en él, el derecho municipal en cuestión parece estar legitimado directamente por el *ius divinum*.

Otra lección bien interesante, sobre todo si admitiéramos sin reserva el relato solorciano acerca de los navarros y los aragoneses, es la impotencia no ya de las leyes, sino de las mismas estructuras constitucionales (perdón por el término tan anacrónico) frente a unas prácticas que las ignoraban y que tendían a superarlas. Tamar Herzog, de cuya investigación vengo aprovechándome, ha escrito a este respecto que hacia finales del siglo XVI hace su aparición en Hispanoamérica “una naturaleza española común, que incluía a los naturales de todos los reinos españoles... como resultado de un nuevo monopolio que únicamente permitía a los ‘naturales de los reinos de España’ emigrar y comerciar en el Nuevo Mundo”⁵⁵.

52 Norte de la contratación, I, 31, 5.

53 Norte de la contratación, I, 31, 1 i.f.

54 Política Indiana, VI, 14, 6.

55 HERZOG 2006, p. 108.

Ya por aquel entonces las cosas se desarrollaban en buena parte por cauces distintos —paralelos o contrarios— a los de la ley; más o menos como vemos que sucede hoy, aunque la dirección actual sea la opuesta a la de antaño y el desatino al que estoy queriendo referirme amenace consumarse, para mayor vergüenza de todos quienes lo alientan, en un marco jurídico-político radicalmente diferente al de los siglos XVI y XVII. De todas formas, ¡qué innobles resultan algunas discusiones modernas!, ¡qué anticuadas, retrógradas y cansinas!

Si nos la tomamos por este último lado, la lección anterior es bastante sombría. Intentaremos disipar el fastidio que haya podido causarnos con otra enseñanza, que será la última y de carácter estrictamente técnico. La enseñanza versa sobre el tipo de razonamiento aplicado por algunos autores —en concreto por Hevia y Solórzano— a la interpretación de las cédulas reales con el fin de abrir las puertas del comercio indiano a los navarros o a los navarros y los aragoneses. Por orden cronológico, esas cédulas son las siguientes:

- 1) de 28 de abril de 1553, citada por Hevia, Solórzano, Escalona y Veitia: particular concesión (Hevia) o privilegio (Solórzano) en virtud del cual los clérigos de Navarra pueden tener prebendas y beneficios eclesiásticos en las Indias; Solórzano y Veitia mencionan en el mismo sentido una cédula de 3 de noviembre de 1581;
- 2) de 30 de abril de 1564, citada sólo por Veitia: prohíbe estar en las Indias a los extranjeros “de fuera destos Reynos de Castilla y Aragón”;
- 3) de 1591, citada por Escalona y Veitia: se expulsa de las Indias y se prohíbe comerciar en ellas a los que no son naturales de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña;
- 4) de 1593, citada por Escalona y Veitia: a los navarros y a los aragoneses se los tiene por naturales;
- 5) de 3 de enero de 1596, citada nada más por Solórzano (pero acaso es la misma que la anterior): declara extranjeros a los que no son naturales de los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra y las islas de Mallorca y Menorca.

Conviene recordar asimismo que entre la cédula de 1553 (1) y la de 1596 (2), Solórzano dice no saber de ninguna otra que interese al asunto, en particular, ninguna referida a los aragoneses.

Pues bien, ¿cómo razonaban Hevia y Solórzano? En nuestra opinión, aunque no lo adviertan explícitamente, ambos autores llevan a cabo una interpretación extensiva de las leyes a las que acuden. Esto es clarísimo en Hevia, que pudo encontrar parte del camino ya hecho en los precedentes doctrinales que alega: sabemos por Escalona que la cédula de 1553 (1) permitió que los clérigos navarros tuviesen beneficios eclesiásticos en Indias; por su parte, el propio Hevia y Solórzano califican esa medida de privilegio. De todo ello se infieren dos cosas; la primera es que la norma en cuestión no se refería de ningún modo a la regulación del comercio, y la segunda, que se trataba de una norma especial que no podía operar por sí sola la “naturalización castellano-leonesa” (incluidas sus proyecciones indianas) de los navarros en general. No obstante, Hevia esquivo toda discusión e, invocando aquella única cédula, concluye que los navarros “se reputan por naturales del Reyno” a efectos de poder ejercer el comercio en las Indias. El caso de Solórzano es similar: él sabe que la cédula de 1553 (1) y la posterior de 1581 (1) se refieren

a las prebendas y beneficios eclesiásticos, no al comercio, y que ambas representan una “permisión” o dispensa —en definitiva, una excepción— respecto de la norma general de exclusión derivada de la diferencia y separación de los reinos a la que atribuye tanta importancia. Sin embargo, de forma no menos expeditiva que Hevia, considera que el efecto de aquellas dos cédulas ha sido la “connaturalización” de los navarros. Y téngase en cuenta una vez más que, aunque trata el tema en el capítulo sobre la provisión de las iglesias y beneficios de las Indias⁵⁶, en el específico sobre los mercaderes y contratantes remite la decisión a ese lugar⁵⁷.

En cuanto a los aragoneses, lo que nos permite conjeturar la predisposición solorciana hacia una interpretación extensiva es la misma observación del autor cuando dice no haber hallado respecto de aquéllos “permisión semejante” a la que acaba de reseñar para los navarros. También el párrafo final que antes hemos transcrito⁵⁸, donde la reserva a los naturales del reino de Aragón de por lo menos un puesto en todos los Consejos, Audiencias y Tribunales de Castilla y de las Indias, dispuesta por Felipe IV, se entiende como habilitación general “para todos los demás cargos, negociaciones y contrataciones”.

Quedaría por examinar el entramado de la interpretación extensiva ante la que nos encontramos. En primer lugar, conviene insistir en que se trata sin duda posible de lo que venimos diciendo; o sea, de extensión de la ley en sentido propio y no de simple declaración o comprensión, caso éste en el que hay sólo una estrechez (o una holgura) de los *verba* legales que puede corregirse recurriendo a la *mens legis*⁵⁹. La operación que realizan Hevia y Solórzano, y de la que sólo nos muestran el resultado, no puede ser de esta naturaleza, toda vez que no parece sostenible que el legislador de 1553 y 1581 estuviera pensando en producir la naturalización general de los navarros al promulgar unas normas que hablaban solamente de dispensar a los clérigos de ese reino para que pudiesen tener beneficios en Castilla y en Indias. Y por otro lado, la misma frase que emplea Hevia —“se reputan por naturales del Reyno”— apunta con claridad suficiente a una verdadera extensión. ¿Cuál pudo ser su fundamento? Conforme a la doctrina de la época⁶⁰, la interpretación extensiva supone la dilatación de la ley más allá de lo que indica su *mens*, bien porque entienda el intérprete que hay una *ratio* semejante a la *ratio* específica que determinó la *mens* del legislador, bien porque presuma una *ratio* de la que no sabe con seguridad si la *mens* del legislador la tuvo presente. En nuestra opinión, en el caso que nos ocupa es difícil pronunciarse por cualquiera de estas dos posibilidades. La semejanza de *ratio* no es fácil de sostener si uno se pregunta, sin ir más lejos, qué parecido podía haber entre los clérigos⁶¹ y los comerciantes, entre el acceso a los beneficios eclesiásticos y el permiso para ejercer el comercio. La *ratio* presunta tampoco se nos muestra con suficiente nitidez; en realidad, lo

56 *Política Indiana*, IV, 19; vid. *supra*, el apartado 4 de este trabajo.

57 *Política Indiana*, VI, 14, 14 nt. 30.

58 *Política Indiana*, IV, 19, 38; vid. *supra*, hacia el final de nuestro tercer apartado.

59 Seguimos aquí las valiosas indicaciones de SCHRÖDER, 2001; cfr. pp. 52 s., 65.

60 Vid. SCHRÖDER 2001, pp. 65 s.

61 Recordemos que los clérigos tenían prohibido “por todo derecho” (*Política Indiana*, VI, 14, 11) dedicarse al comercio.

manifiesto de la *mens legis* en las reales cédulas de 1553 y 1581, que se nos presentan además como un privilegio⁶², parece dejar muy escaso margen para ese tipo de especulación.

Así las cosas, acaso convenga preguntarse no tanto por el entramado sino por el trasfondo de la extensión. Nosotros hemos llegado a formularnos estas preguntas tan especiales llevados por nuestro interés inicial en el tema de los comerciantes, pero, acercándonos al final de nuestro recorrido, creemos intuir que lo que dicen Hevia y Solórzano —y lo dicen no acerca de los clérigos o de los mercaderes navarros, sino de los navarros sin más— tiene como telón de fondo la naturalización general de los originarios de dicho reino producida de facto antes de que ninguna ley la consagrara formalmente. Podemos concluir por tanto este punto con una frase de Ots Capdequí que él refiere al caso de los aragoneses pero que cuadra igualmente al de los navarros: “Una vez más los hechos fueron más fuertes que las artificiosas distinciones de la ley”⁶³.

Extensión es también, ya por último, la conclusión de Solórzano en el sentido de que la reserva de altos puestos establecida por Felipe IV para los aragoneses comprende la habilitación de éstos para ejercer el comercio en Castilla y en las Indias⁶⁴. Extensión (o analogía, pero el resultado es el mismo) que opera con el *locus a comparatione*, concretamente en la formulación *a maiore ad minus*⁶⁵ que podemos ver recogida en el título *De diversis regulis iuris antiqui* del Digesto⁶⁶.

BIBLIOGRAFÍA:

- BARRIENTOS GRANDON 2000 = Javier BARRIENTOS GRANDON, Historia del derecho indiano del descubrimiento colombino a la codificación I. Ius commune-ius proprium en las Indias Occidentales, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 2000.
- GAUDIN 2013 = Guillaume GAUDIN, “Expulser les étrangers de la monarchie hispanique : un sujet épineux (1591-1625)”, en *Les Cahiers de Framespa* [on line] 12 (2013), consultado el 13 de marzo de 2014. URL: <http://framespa.revues.org/2085>
- BRAVO LIRA 1989 = Bernardino BRAVO LIRA, *Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1989.
- GUZMÁN BRITO 2000 = Alejandro GUZMÁN BRITO, *Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano*, Ediciones del Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, Santiago de Chile, 2000.

62 Lo que según ciertos autores hacía más problemática, aunque por ello no imposible, la interpretación extensiva: cfr. SCHRÖDER 2001, p. 69. Solórzano Pereira, *Política Indiana*, II, 30, 25, decía que “la naturaleza de ellos [los privilegios] es estrecha, que no se extienden ni pasan a más casos y personas que las que en ello vinieren especificadas, según lo dispone el derecho”. En nuestro caso concreto, Salón de Paz (vid *supra*, nt. 29) explicaba la real cédula de 1553 diciendo que, como consecuencia de ella, los originarios de Navarra se consideraban naturales de los reinos de Castilla y León “quoad beneficia”.

63 Ots Capdequí 1945, p. 189.

64 *Política Indiana*, IV, 19, 38.

65 Vid. SCHRÖDER 2001, pp. 39 s.; para la relación entre analogía e interpretación extensiva, pp. 73 s.

66 D. 50.17.110 pr.: *In eo, quod plus sit, semper inest minus*; cfr. algunas aplicaciones de este *locus* en A. GUZMÁN BRITO 2000, p. 329; advierte este autor (*ibid.* nt. 1009) que las *regulae* contenidas en D. 50.17 no son *loci* en sentido lógico, pero quizá nuestro texto representa una excepción.

- HERZOG 2006 = Tamar HERZOG, *Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna*, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
- MESNARD 1956 = Pierre MESNARD, *El desarrollo de la filosofía política en el siglo XVI*, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, México, 1956.
- OTS CAPDEQUÍ 1945 = José María OTS CAPDEQUÍ, *Manual de historia del derecho español en las Indias y del derecho propiamente indiano*, Editorial Losada, Buenos Aires, 1945.
- SCHRÖDER 2001 = Jan SCHRÖDER, *Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule*, C.H. Beck, München, 2001.
- TOMÁS Y VALIENTE 1983 = Francisco TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho español*⁴, Editorial Tecnos, Madrid, 1983.

LA RESPONSABILIDAD DEL BANQUERO POR LOS DEPÓSITOS DE LOS CLIENTES.

UNA REFLEXIÓN DESDE LAS FUENTES ROMANAS

ALFONSO MURILLO VILLAR

Universidad de Burgos

Pasará el tiempo y la sociedad cometerá los mismos errores. Roma y su historia son un banco de pruebas inexorable en el que siempre podremos apreciar las miserias humanas. Han pasado veinticinco siglos desde que en Roma existen las monedas acuñadas, el dinero como medio legal de pago; con la presencia del dinero el comercio se desarrolla y para ello se requiere de crédito¹, actividad básicamente ejercida por los banqueros. El banquero es un comerciante dedicado al tráfico de dinero y su actividad se plasma en la realización de múltiples operaciones de préstamo y garantía, que versan sobre una mercancía absolutamente fungible, y que se toma exclusivamente en función de su valor². Por ello, el negocio bancario fundamental ha sido siempre captar dinero de los clientes para prestarlo a interés, lucrándose el banquero entre lo que ofrece por los depósitos a sus clientes y lo que cobra a los terceros por la disponibilidad crediticia. Así ha funcionado el crédito desde que el mundo es mundo³.

En este trabajo no se pretende comparar la banca actual con la romana, no son comparables ni por sus dimensiones ni por su complejidad, pero sí coincide una dramática realidad en ambos momentos de la historia, y es que los bancos quiebran. Se sabe que la bancarrota⁴ de pequeños negocios bancarios debió de ser frecuente en Roma, pues las imposiciones solían ser a la vista y a finales del s. II d.C. aún no existían normas que exigiesen a la banca disponer de reservas para hacer frente a situaciones imprevistas⁵. Es verdad que la posición

1 Vid. GIUFFRÈ, V., *Mercato e credito di danaro in Il bisogno del diritto. Momenti dell'esperienza romanistica*, Napoli, 2007, 77 ss.

2 DÍAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987, 13.

3 TORRENT, A., *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, en AUPA (Annali dei Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo), LVI, 2013.

4 La palabra bancarrota viene del italiano del siglo XVI "*Banca Rotta*", literalmente "banca rota", por la antigua costumbre de Italia de romper las sillas de los prestamistas que caían en insolvencia financiera.

5 BOGAERT, R., *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leiden, 1968, 391 ss.

social de los *argentarii*⁶ romanos era muy diferente de la de los banqueros de hoy⁷, pero lo que no ha cambiado es que la relación cliente banquero sigue basándose en la confianza. La banca de todos los tiempos ha sido un negocio basado en la confianza en sus gestores. Por ello, Ulpiano menciona la *fides publica* en D.42,5,24,2 (*Ulp. 63 ad. ed.*), Gayo dice en D.2,13,10,1 (*Gai. 1 ad ed. prov.*) que la actividad de los *argentarii* tiene una estrecha relación con la vida pública, y Papiniano en D.16,3,8 (*Pap. 9 quaest.*) afirma que su trabajo era indispensable en los negocios⁸. En definitiva, como inspiraban confianza los clientes confiaban en ellos. La alusión a la fe pública sobre los bancos, es una manifestación evidente de que la finalidad económica que pretenden los que entregan el dinero es tenerlo en un lugar seguro⁹. En Roma, al igual que hoy¹⁰, la función del depósito bancario fue tanto financiera como de conservación. Es decir, el depositante siente la necesidad de conservar una suma de dinero con más seguridad de la que él mismo puede ofrecerse. Y a quién mejor para encomendárselo que a quien te inspira confianza: un banco, de ahí que en los supuestos de insolvencia o quiebra el depositario banquero deba responder con todo su patrimonio pues frustró las legítimas aspiraciones del depositante.

Hoy nadie pone en duda que también la relación con la banca se basa en la confianza que inspiran sus gestores, pero a veces esa confianza es traicionada y el sistema es puesto en cuestión. Lo que ha ocurrido en los últimos años en España y anteriormente a partir de 2007 en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, está llevando a la sociedad a reaccionar y a buscar mecanismos de seguridad jurídica que eviten la repetición de tan grandes errores. Como ya se ha apuntado, no se puede olvidar que la banca en todos los tiempos es ante todo un negocio de confianza: los ahorradores e inversores confían en que los banqueros conocen bien el negocio y ejercitan una correcta administración de los recursos ajenos con la esperanza de obtener rendimientos satisfactorios de las cantidades confiadas, y, por supuesto, su devolución cuando las reclame el cliente o a la extinción del contrato¹¹.

Con los últimos acontecimientos de quiebras, fusiones, absorciones, impagos, preferentes, etc., de bancos y cajas de ahorros, la banca en su conjunto ha sufrido un gran desprestigio social y una pérdida casi absoluta de confianza. La percepción ciudadana es que se trata de un sector que los poderes públicos controlan poco, y en el que se permiten remuneraciones muy generosas y grandes privilegios, y que en caso de peligro inminente el Estado sale en su auxilio con dinero público de todos los contribuyentes para evitar un

6 En la antigua Roma existieron diferentes tipos de banqueros. Además del *argentarius* (banquero privado), también hubo banqueros públicos (*mensarius*, *nummularius*, *mensularius*, *trapezita*, incluso el *argentarius coactor*). Todos ellos reflejan la gran variedad de actividades bancarias existentes: cambistas, probadores de monedas, intermediarios en subastas, recaudadores, etc. Vid. ANDREAU, J., *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent (IVe. siècle av. J.C. – IIIe. siècle ap. J.C.)*, Roma, 1987. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. M^a, *El receptum argentarii en el derecho romano clásico. Una propuesta de análisis*, Madrid, 2004, 56 ss.

7 Vid. CHURRUCA, J. de, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über die argentarii im klassischen römischen Recht*, ZSS, 108, 1991, 307.

8 Vid. GARCÍA GARRIDO, J. M., *La sociedad de los banqueros (societas argentaria)*, en *Studi in onore de A. Biscardi III*, Milano, 1982, 375. También en *Miscelanea romanística*, v.II, Madrid, 2006, 571.

9 VALMAÑA, A., *El depósito irregular en la jurisprudencia romana*, Madrid, 1996, 115.

10 MADRAZO LEAL, J., *El depósito bancario a la vista*, Madrid, 2001, 25 ss.

11 TORRENT, *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, cit., 189.

caos en el sistema de pagos. Ni que decir que todo ello ha generado una enorme desafección social hacia el sector bancario, con el inconveniente de que no hay economía que funcione si no lo hace la banca y el sistema de pagos¹².

En definitiva, nada nuevo. Críticas a los banqueros y a los bancos ha habido siempre¹³, lo de ahora no es nada inédito. Se incrementarán los controles y aumentará la legislación para evitar que vuelva a suceder, pero ya sucedió en Roma, después de Roma¹⁴, y pasados unos cuantos años, no sé si siglos, se repetirá la misma historia. La ingeniería financiera llevará a cometer los mismos errores, la confianza será defraudada por la avaricia, la prudencia por el descontrol, y así la sociedad volverá a cometer las mismas equivocaciones. Sirva de ejemplo una famosa comedia de Plauto¹⁵ (254-184 a.C.), *Curculio*¹⁶, en donde se retrata a un usurero y avaro mercader de esclavos que está convencido de que el mejor método de enriquecerse es exigir imperiosamente las deudas de los demás, pero no devolver a nadie el dinero confiado; a tal propósito se dice lo siguiente: “El pueblo ha aprobado contra vosotros (los banqueros) infinidad de leyes, pero tan pronto como han sido votadas han sido violadas: siempre encontraréis una escapatoria. Para vosotros la ley es como el agua hirviendo: enseguida se enfría”¹⁷.

Son muy pocos los textos jurídicos que nos hablan de la quiebra de un banquero en Roma¹⁸: D.16,3,7,2-3 (*Ulp. 30 ad ed.*), D.16,3,8 (*Pap. 9 quaest.*) y D.42,5,24,2 (*Ulp. 63 ad ed.*). Además, entre ellos, como seguidamente veremos, existen evidentes contradicciones que hacen sospechar de su manipulación bizantina, aunque no se alcanza bien a saber por qué dicen cosas contrarias, pues incluso podrían llegar a conciliarse, como finalmente se propondrá. Los autores de estos textos, Papiniano y Ulpiano, juristas de la época de los Severos, de finales s.II comienzos s.III d.C., necesariamente tuvieron que tener conocimiento de la quiebra de un negocio de banca del esclavo cristiano Calisto, futuro Papa San Calisto (217-222 d.C.). Sucedieron los hechos en tiempos de Cómodo (180-192 d.C.) entre el 185 y 190 d.C. y la información se recoge en la obra “*Refutatio omnium haeresium*” (Refutación de todas las herejías), escrito en griego y atribuido tradicionalmente a Hipólito de Roma. El texto contiene muchos puntos de interés, actividades financieras de los cristianos, con-

12 Vid., muy interesante, BARRÓN ARNICHES, I. de, El hundimiento de la banca. Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español, Madrid, 2012.

13 PEÑALVER, M.A., *La banca en Roma*, Madrid, 1994, 34 ss.

14 Vid. OBARRIO MORENO, J.A., *La quiebra y el concurso de acreedores en derecho medieval español*, Revista Jurídica del Notariado, 82, 2012, 323 ss.

15 Vid. COSTA, E., *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890 (ed. anastatica, Roma, 1968), 305 ss.

16 Cfr. ÁLVAREZ, M.B., - ALONSOPÉREZ, G.M., Un perfil de los banqueros a la luz de la comedia plautina y de la crisis económica argentina del siglo XXI, en *El derecho comercial, de Roma al Derecho moderno I*, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 101 ss.

17 *Curculio* IV,2,23.- “Rogitationes plurimas propter vos populus scivit, Quas vos rogatas rumpitis; aliquam reperitis rimam; Quasi aquam ferventem frigidam esse ita vos putatis leges”.

18 Un supuesto extraído de fuentes literarias puede verse en TORRENT, *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, cit., 182 ss. Sobre los *argentarii* en general en los textos literarios y jurídicos, ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent (IVe. siècle av. J.C. - IIIe. siècle ap. J.C.)*, cit., 61 ss.

secuencias de la bancarrota, y otros que para nuestros objetivos son menos trascendentes. Asimismo, se ha estudiado desde muchos puntos de vista, y el análisis más reciente lo ha realizado Torrent¹⁹ quien afirma que le pasó a Calisto lo mismo que ha ocurrido en España, y sobre todo en los Estados Unidos a partir del 2007. La quiebra de Calisto se debió a no poder recobrar ni el capital ni los intereses debidos de quienes habían recibido créditos de su banca. Estaríamos ante una quiebra fraudulenta que a juicio de Torrent más que por dolo de Calisto se debió a que éste no pudo o no supo calcular el riesgo de los créditos concedidos con el dinero de sus clientes, no teniendo su banca capital propio para en caso de créditos fallidos poder devolver su capital a los depositantes ni reservas para provisionar la eventual morosidad de los prestatarios.

El banquero Calisto daba la apariencia de actuar por cuenta de Carpóforo (persona de intachable reputación, liberto de la casa imperial, quizá de Marco Aurelio) o al menos los clientes confiaban su dinero a Calisto debido a su cercanía a Carpóforo, actuando Calisto como gestor de un negocio de banca que recibía depósitos de sus clientes, mayoritariamente cristianos, a los que defraudó malgastando o invirtiendo negligentemente el dinero confiado, hasta el punto de no poder devolver ni el capital ni los intereses debidos a sus acreedores. Antiguamente, la no devolución del depósito era un hecho particularmente reprochable para los cristianos²⁰; Plinio *Ep.* 10,96,7 nos informa que cuidaban mucho su devolución, y el cristiano Hipólito dirige su anatema contra Calisto por haber defraudado a viudas y huérfanos que habían confiado su dinero a Calisto por su presencia cercana a Carpóforo (*Ref.* 9,12,1,6). Además, era una actuación especialmente reprehensible sancionada mediante el ejercicio de la *actio depositi* que implicaba *infamia*, según afirman Juliano D. 3,2,1 (*1 ad ed.*) y Gayo 4,182. El fraude a los depositantes en el Mundo Antiguo se entendía como un ataque brutal a la *fides* negocial. Los depositantes podían exigir la devolución del dinero confiado al banquero interponiendo la *actio depositi*, que como es sabido tenía una doble formulación pretoria y civil, lo que prueba su primera reprobación y consiguiente instrumentación procesal en el ámbito del *ius honorarium*.

Los banqueros por su profesión eran un interés público, al igual que hoy, lo que, sin embargo, no impide calificarlos como un mal necesario. Cuando un banquero no puede hacer frente a la totalidad de sus pasivos se dice que quiebra. En ese caso se procede a la ejecución de su patrimonio, normalmente a través de un concurso pues se presume la existencia de varios acreedores; se suele vender el patrimonio entero del deudor, *venditio bonorum*²¹, es decir, a través de un procedimiento ordinario, pues hasta donde sabemos no había un procedimiento específico para los banqueros, si bien del análisis de los textos puede inferirse cómo se introducían algunas cautelas particulares dirigidas a salvaguardar a determinados clientes del banquero quebrado frente a los demás. Para Petrucci²² la crisis

19 TORRENT, Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto, cit., 184.

20 CHURRUCA, J de, La quiebra de la banca del cristiano Calisto (ca. 185-190), en SCDR 3 (1992), 61-86, recogido en Cristianismo y mundo romano. Colección de artículos sobre este tema, con presentación de R. MENTXAKA, Bilbao, 1998, 553.

21 Vid. PÉREZ ÁLVAREZ, M^a del P., La bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en derecho romano clásico, Madrid, 2000.

22 CERAMI, P., DI PORTO, A., PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 2^a ed., Torino, 2004, 197.

de una empresa bancaria no está regulada por ningún procedimiento especial, sino por el procedimiento concursal común de la *bonorum venditio*, en el cual se introducían una serie de cautelas para salvaguardar la condición de algunas categorías de clientes.

Un proceso de bancarrota, en teoría, sirve para decidir quién cobra qué y cuánto. De acuerdo a las fuentes, las distintas operaciones bancarias pueden resultar muy variadas: desde depósitos abiertos y cerrados de dinero, hasta mutuos con interés, préstamos garantizados con prendas, promesas de pagos o pagos por encargo de un cliente, novaciones de créditos, intermediaciones en subastas, etc. Centrándonos en los depósitos efectuados por un banquero se observa que estos pueden ser regulares, es decir, aquellos en los que se busca la guarda y custodia de dinero en arcas o saquitos cerrados, de tal suerte que la restitución se efectuaba con el mismo objeto confiado; no obstante, desde comienzos del principado se empezó con la práctica de autorizar al banquero el uso de las sumas de dinero depositado, pero con la obligación de restituir otro tanto (*tantundem*), e incluso la posibilidad de pagar intereses por usarlo (*usurae*). De ello se infiere que un depósito bancario encerraba tres posibilidades básicas: depósito regular, depósito irregular con intereses y depósito irregular sin intereses²³.

A su vez, el depósito irregular tiene elementos del depósito y del mutuo²⁴. Es un contrato que generalmente tiene por objeto cosas genéricas o numerario: es el moderno depósito bancario. Los juristas romanos tomaron esta institución de las prácticas de los banqueros griegos, probablemente a principios del s. II a.C. Al igual que hoy, los juristas han considerado esta operación, unas veces como un mutuo (D.16,3,26,1 y D.16,3,1,34) y otras veces como un depósito (D.16,3,24)²⁵. Ciertamente que la opinión de considerarlo un depósito es la que terminó triunfando; sin embargo, el depósito irregular se aproxima al préstamo cuando el depositario concede un interés al depositante.

Para los que defienden la inexistencia de un depósito irregular en época clásica (plenamente aceptado en la justinianeana), la utilización del dinero depositado por el banquero sólo podía instrumentarse mediante un contrato de préstamo o *mutuum*. Pero desde que el mundo es mundo el préstamo de dinero -salvo *interfamiliares* o *inter amicos*- nunca ha sido gratuito; por supuesto no lo fue en Roma. Está documentado que la vida económica de Roma lanzada desde el s. II a. C. a una gran expansión comercial, requería préstamos de financiación que lógicamente devengaban intereses (*usurae*)²⁶.

Conocemos tres textos del Digesto sobre los que se ha vertido mucha literatura, y aunque aparentemente exponen ideas contradictorias, sin embargo es posible su conciliación. Los tres abordan la quiebra de un banquero y las consecuencias para los depositantes que le habían confiado su dinero.

23 Vid. SORIANO, C., Banca, navegación y otras empresas en el derecho romano, México, 2007, 49.

24 Vid. VALMAÑA, El depósito irregular en la jurisprudencia romana, cit.

25 OURLIAC, P., - DE MALAFOSSE, J., *Derecho romano y francés histórico I. Derecho de obligaciones*, (trad. esp.), Barcelona, 1960, 415.

26 PETRUCCI, A., Prime riflessioni su banca ed interessi nell'esperienza romana, en *L'usura ieri ed oggi* (Convegno, Foggia, 7-8 aprile 1995), Bari, 1997, 64 ss.

Comenzaremos por el estudio de D.16,3,7,2-3 (*Ulp. 30 ad ed.*).

D.16,3,7,2 (*Ulp. 30 ad ed.*).- *Quotiens foro cedunt nummularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum, hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas faenore apud nummularios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant; et ante privilegia igitur, si bona venierint, depositariorum ratio habetur, dummodo eorum, qui vel postea usuras acceperunt ratio non habeatur, quasi renuntiaverint deposito.*

D.16,3,7,3 (*Ulp. 30 ad ed.*).- *Item quaeritur, utrum ordo spectetur eorum qui deposuerunt an vero simul omnium depositariorum ratio habeatur. Et constat simul admittendos: hoc enim rescripto principali significatur.*

Para Ulpiano, parágrafo 2, cuando los banqueros se declaran en quiebra, se suele tener en cuenta, ante todo, a los depositantes, es decir, a los que tuvieran cantidades entregadas en depósito, distinguiéndolos claramente de aquellos que hubieran prestado su dinero a los banqueros a cambio de intereses a modo de inversión. Asimismo, nos informa que cuando los bienes del banquero quebrado son vendidos en conjunto, sobre el dinero obtenido con la venta a los depositantes se les reconocía una posición preferente incluso respecto de los acreedores privilegiados. Por consiguiente, si se hubieran vendido los bienes, tendrán preferencia los depósitos sobre los créditos privilegiados, de tal modo que no se tengan en cuenta aquellos dineros que devengaron intereses aunque se hubieran pactado posteriormente, ya que es como si hubiera renunciado al depósito. Es decir, cuando se pacta la remuneración de determinados intereses se presupone que se renuncia al depósito.

Seguidamente, en el parágrafo 3, se responde a la pregunta de si deberá establecerse un orden de prelación de los depositantes en orden a cobrar con preferencia, o si se deben considerar a todos los depósitos a la vez (*an vero simul omnium depositariorum ratio habeatur*). La respuesta es que han de ser admitidos simultáneamente todos los créditos, pues así se dispone en un rescripto imperial. Se observa, pues, que cuando un banquero quiebra, es decir, no puede hacer frente a la totalidad de sus pasivos, se procede a la ejecución patrimonial, normalmente a través de un concurso pues generalmente existen varios acreedores. Lo habitual es que se proceda a una *bonorum venditio* de todo el patrimonio del deudor, de donde se infiere que no había un procedimiento de ejecución específico para los banqueros.

De los dos fragmentos anteriores se deduce la clara diferencia que existe entre quienes habían efectuado un depósito al banquero recibiendo a cambio interés de aquellos que no habían pactado intereses. Ante tal situación, Ulpiano mantiene que los depositantes que no habían percibido intereses ocupan una posición preeminente incluso frente a los acreedores privilegiados. Además, precisa que entre aquellos que no recibieran intereses no hay distinción y todos concurrirán en igualdad de condiciones sin que entre ellos haya diferencias por razón de tiempo. Todos son admitidos simultáneamente.

Por si ello no fuera suficiente, Papiniano, en un texto que los compiladores concatenaron al anterior, nos precisa aún más la concurrencia entre iguales frente a la ejecución patrimonial del banquero quebrado.

D.16,3,8 (Pap. 9 quaest.).- Quod privilegium exercetur non in ea tantum quantitate, quae in bonis argentarii ex pecunia deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris facultatibus; idque propter necessarium usum argentariorum ex utilitate publica receptum est. Plane sumptus causa, qui necessarie factus est, semper praecedit: nam deducto eo bonorum calculus subduci solet.

Dice Papiniano en este texto que aquellos depositantes que tienen una posición privilegiada por no recibir intereses, ésta se ejercitará no sólo sobre la cuantía que resulte del dinero depositado que se encontró en el patrimonio del banquero, sino sobre todos los bienes del defraudador; tal planteamiento lo justifica el jurista en la necesidad de la existencia de banqueros por razón de la especial utilidad pública de la profesión que ejercen. Claro que siempre es preferente el crédito para impensas necesarias (del refaccionario), ya que el cálculo de los bienes suele hacerse una vez deducido aquel.

La ejecución de los créditos de los acreedores defraudados será sobre todos los bienes del deudor (banquero). Por lo tanto, el privilegio del que gozan los acreedores, si se puede hablar de privilegio en tales circunstancias, no se reduce únicamente al dinero depositado que se encuentre en el patrimonio del banquero. Se extenderá a todos los bienes por defraudador, *sed in omnibus fraudatoris facultatibus*. Ulpiano define al banquero quebrado como *fraudator*, calificativo que conlleva un comportamiento condenable por cuanto ha traicionado la relación de confianza que habían depositado en él los clientes. En definitiva, como bien dice Salazar Revuelta²⁷, “el empleo del calificativo “defraudador” viene a denotar la ruptura de la confianza con sus clientes de la parte más fuerte en la relación financiera y justifica, así, que la responsabilidad se extienda a todo su patrimonio. Dicha confianza se entiende por la utilidad pública que trae consigo el negocio de la banca, esto es, por la necesidad de recurrir a ella para asegurar el propio dinero y en el carácter de servicio público de ésta”.

Pero esta explicación, no carente de lógica y ciertamente coherente, se contradice con la adjudicada al mismo jurista Ulpiano en el siguiente texto.

D.42,5,24,2 (Ulp. 63 ad ed.).- In bonis mensularii vendundis post privilegia potiore eorum causam esse placuit, qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. Sed enim qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non separantur; et merito: aliud est enim credere, aliud deponere. Si tamen nummi exstent, vindicari eos posse puto a depositariis et futurum eum qui vindicat ante privilegia.

Dice así, cuando se produce la enajenación total de los bienes de un banquero quebrado, los que depositaron dinero en el banco llevados por la confianza que suele otorgarse públicamente al mismo tienen derecho a ver satisfechos sus créditos después de los créditos privilegiados. Continúa informando que los que cobraron intereses por las

²⁷ SALAZAR REVUELTA, M^a., El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos, RIDROM, (www.ridrom.uclm.es), 11-2013, 133.

cantidades depositadas en el banco no se distinguen de los otros acreedores; y con razón, dice el jurista, porque una cosa es prestar y otra depositar (*aliud est enim credere, aliud deponere*)²⁸; ahora bien, si subsisten las monedas depositadas, podrán reivindicarlas los depositantes, según Ulpiano, y entonces el que las reivindica tendrá preferencia sobre los acreedores privilegiados.

En este texto se invierten, frente a lo plasmado en D.16,3,7,2-3 y 8, las facultades de preferencia de cobro del depositante sobre el patrimonio ejecutado del banquero quebrado. Ahora, según D.42,5,24,2, se establece que 1) cuando existen en el patrimonio del concursado las monedas depositadas, los depositantes las podrán reivindicar con preferencia a los acreedores privilegiados; 2) si no existen, los depositantes tendrán preferencia una vez que hayan visto satisfechos sus créditos los acreedores privilegiados, y 3) en caso de depósitos irregulares con interés, los depositantes no tienen ningún privilegio sobre los demás acreedores.

Llama la atención la contradicción de ambos textos (D.16,3,7,2-3 y D.42,5,24,2)²⁹, del mismo jurista, Ulpiano y de la misma obra, Comentarios al Edicto, y con respuestas absolutamente contradictorias. Igualmente, sorprende la posición que ocupan los depositantes que no reciben intereses cuando se produce el concurso de acreedores en los supuestos de quiebra de un banquero. Mientras en D.16,3,7,2 a los depositantes se les presenta como acreedores preferentes incluso frente a los acreedores privilegiados, por el contrario en D.42,5,24,2 se sostiene lo contrario. No entraremos ahora en ver cual de los dos está alterado por los compiladores justinianeos, pero los intentos por explicar la aparente contradicción han sido muchos y con acusaciones hipercríticas de interpolacionismo³⁰ que creo ya están más que superadas. Para Litewski el fragmento D.42,5,24,2 está sin lugar a dudas mejor conservado, tanto desde el punto de vista lingüístico como sustancial³¹.

La doctrina ha tratado de buscar todo tipo de justificaciones para explicar las opiniones contrarias del jurista, y para ello se han esgrimido diferentes argumentos, varios de los cuales se exponen y rebaten por Herrero Chico³² y cuya reproducción omitimos. Se quiere sustentar la antinomia en que el privilegio existe cuando el dinero está en la caja del banquero pero no cuando no está. También se ha querido basar en la distinción entre el carácter público del *mensularius* y el privado del *argentarius* o *nummularius*. Incluso en una interpretación inadmisibile, a juicio de Herrero Chico, de la palabra *depositarii* de D.16,3,7. Asimismo, se ha sustentado la diferencia de criterio en la existencia de dolo o fraude en la quiebra y no en el simple concurso. Igualmente, se quiere distinguir según los depósitos sean regulares o irregulares³³.

28 Vid. PANERO, R., *Deponere y reddere en la actio depositi in factum*, Barcelona, 1989, 28 n.38.

29 Cfr. SCOTTI, F., *Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento*, Torino, 2008, 56 ss., especialmente las notas, y 130.

30 Vid. Index Interpolationum I, 273 ss. y III, 245. Cfr. BONIFACIO, F., *Ricerche sul deposito irregolare in diritto romano*, BIDR, 49-50, 1948, 148 ss.

31 LITEWSKI, W., *Le dépôt irrégulier II*, RIDA, 22, 1975, 287 ss.

32 HERRERO CHICO, R., *Argentarii. Estudios sobre el régimen jurídico de la banca en Roma*, Granada, 1978, 37 ss.

33 Vid. SALAZAR REVUELTA, *El deber de información, transparencia y responsabilidad*, cit., RIDROM, (www.ridrom.uclm.es), 11-2013, 138 ss.

En un estudio reciente, Pérez Álvarez defiende que es preciso distinguir el ejercicio de la *actio depositi* en dos supuestos diferentes, en primer lugar, para el caso en que se produzca la *datio rei* de una suma de dinero con la obligación por parte del depositario de devolver *tantundem*, y, en segundo lugar, para el caso de los depositantes ordinarios que sufren un *furtum usus*³⁴ por parte del banquero. Según la Autora española, “para el jurista clásico el carácter de gratuidad es un elemento esencial del contrato de depósito y es posible que ante el depósito de dinero *ut tantundem redderetur* pero sin fijación de intereses, el jurista concediera la *actio depositi* como si de un contrato de depósito puro y simple se tratase, sin que las consecuencias derivadas de la *datio pecunia* ... fueran suficientes para desnaturalizar esta figura; solo cuando posteriormente se concedió la *actio depositi* para pedir la devolución de las usuras se dio un paso más, apareciendo una figura intermedia entre el contrato de depósito y el mutuo”³⁵.

Es difícil aceptar la existencia de una figura intermedia de contrato entre el depósito y el mutuo, y que además tuviera como protección la *actio depositi*; de ser cierto no se explica su escaso o nulo eco posterior. Sin embargo, y sin forzar ni los textos ni las figuras contractuales, cada vez existe más literatura que tiende a conciliar ambos textos. Así, Petrucci³⁶, los retiene conciliables partiendo de las diferentes ópticas con las que el jurista Ulpiano afronta el problema de la ejecución de los bienes del banquero en el libro 30 o en el libro 63 de sus Comentarios al Edicto. En D.16,3,7,2 donde se comenta la *actio depositi*, las mayores preocupaciones de Ulpiano debieron ser las de diferenciar en el ámbito jurídico el contrato de depósito abierto de una suma de dinero de aquellas inversiones y especulaciones del banquero realizadas por cuenta del cliente, reconociendo a los depositantes una prioridad en el concurso de acreedores, y precisando que la aceptación, incluso con posterioridad, de intereses sobre la suma depositada debía de considerarse como una renuncia al depósito, con la consiguiente pérdida del derecho a ver satisfechos los créditos propios frente a los créditos privilegiados. En definitiva, dice Petrucci, al jurista no le interesaba tanto fijar con exactitud en aquel momento la posición de los depositantes frente a los acreedores privilegiados como excluir de la prelación a aquellos depositantes que comúnmente hubieran recibido intereses de la suma obtenida de la ejecución de la masa del banquero. Por consiguiente, el orden establecido en este fragmento es secundario.

Por el contrario, continua Petrucci, en D.42,5,24,2 el jurista al tratar de forma específica la parte del edicto que se dedica a los acreedores privilegiados cuando se produce la venta de todos los bienes del banquero que ha quebrado, está muy atento a recoger con exactitud el orden de los depositantes en el concurso de acreedores, dando una prioridad absoluta, incluso antes que a los acreedores privilegiados, a aquellos que habían efectuado depósitos cerrados de dinero, colocando seguidamente a los acreedores privilegiados, y equiparando

34 Sobre el *furtum usus* y el ejercicio de la *actio furti* en concurso con la *actio depositi*, BONIFACIO, *Ricerche sul deposito irregolare*, cit., 150. En contra, LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier II*, cit., 290 ss.

35 PÉREZ ÁLVAREZ, M^a del P., El privilegio de los depositantes sobre el patrimonio del banquero en derecho romano clásico, en Estudios de derecho romano en Memoria de B. M^a Reimundo Yanes II, Burgos, 2000, 227, y en *La bonorum venditio*, cit., 364 ss.

36 PETRUCCI, A., *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)*, Napoli, 1991, 208 ss. También en CERAMI, DI PORTO, PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit, 196 ss.

a todos los otros acreedores chirografiarios que también percibían intereses de la suma depositada. En definitiva, Petrucci mantiene la validez de todos los textos, justificando su no alteración en que varía el objetivo del jurista al comentar el edicto, es decir, que no es necesario concluir que D.16,3,7,2-3 y 8 están interpolados para resaltar la vigencia y exactitud de contenido de D.42,5,24,2, y que en este fragmento se desciende hasta el último detalle.

El romanista italiano concluye del análisis conjunto de ambos textos, que el objetivo de Ulpiano era individualizar un grado de protección jurídica diferente en atención a las circunstancias de los acreedores (clientes) cuando quebraba un banco. Se protegía a los ahorradores frente a los especuladores y ese proceso queda reflejado en las propias expresiones de los textos: *solet* (se suele) en D.16,3,7,2; *placuit*, (se acepta, parece bien) en D.42,5,24,2; *receptum est* (ha sido recibido) en D.16,3,8 y *rescripto principali significatur* (ha sido establecido en un rescripto imperial) en D.16,3,7,3. Lo que si es cierto, opinión a la que me adhiero, es que si el derecho persigue el trato equitativo y justo cuando se produce la quiebra de un banco, la posición de los acreedores a la hora de ver satisfechos sus créditos tiene que ser diferente y no pueden aparecer en igualdad de condiciones, es necesario un orden de prelación de créditos, de ahí que bien debido a la práctica interpretativa, bien a la decisión puntual de un jurista o de la cancellería imperial se fuera dando solución a todos aquellos problemas que iban surgiendo en la sociedad.

En conclusión, es verosímil la diferencia de tres grados: uno de protección absoluta para la situación de aquellos clientes que hubieran concluido con el banquero un contrato de depósito cerrado o regular, es decir, sin cobro de intereses a cambio, razón por la cual se les atribuía un derecho preferente frente a todos los demás acreedores. Un segundo grado de posición preferente, la de aquellos acreedores que con posterioridad a los acreedores privilegiados hubieran concluido un contrato de depósito abierto o irregular, y una tercera posición paritaria para todos aquellos depositantes chirografiarios que hubieran depositado una suma de dinero abierto y hubieran pactado con el banquero, incluso con posterioridad, la percepción de intereses y para cuantos ya desde el comienzo quisieran especular a través del banco³⁷.

También García Garrido³⁸ entiende que los textos son conciliables y que la contradicción es más aparente que real. Dice que el texto de Ulpiano, D.16,3,7,2, quizás abreviado por los compiladores, se completa con D.42,5,24,2. El romanista español compaginando el estudio de ambos textos propone el siguiente orden de prelación en la ejecución del patrimonio del banquero quebrado. 1.- Cuando existan las monedas depositadas en la caja del banquero los depositantes tienen preferencia sobre todos los acreedores, incluso los privilegiados, ya que pueden reivindicar las monedas. 2.- Cuando el depósito sea irregular pero sin interés y el banquero haya invertido las sumas depositadas, todo su patrimonio responde primero ante los acreedores privilegiados y después ante los depositantes que tienen preferencia sobre los demás acreedores y 3.- Cuando se trate de un depósito irregular o de un préstamo con interés, los depositantes reclamarán con los demás acreedores y no existirá ningún privilegio a favor de ellos. Ciertamente, con leves matices, este orden de prelación coincide con

37 CERAMI, DI PORTO, PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., *ibidem*.

38 GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros (Societas argentaria)*, en *Studi in onore di A. Biscardi III*, cit., 382; en *Miscelánea romanística*, vol II, 576 ss.

la gradación propuesta por Petrucci de protección absoluta, preferente y paritaria siempre que los acreedores pretendan ejecutar su derecho de reembolso sobre todo el patrimonio del banquero, asunto este último sobre el que la coincidencia doctrinal es absoluta.

Existen tantas diferencias en el ámbito de la actividad financiera entre Roma y la actualidad, que una comparativa de conjunto no soportaría la más mínima crítica. Sin embargo, en ambos periodos históricos se observa la necesaria existencia de entidades que prestan el dinero previamente captado del público, que llevan aparejada la obligación de restitución, y que en el ínterin se ha prestado a terceros en forma de créditos u otras operaciones de naturaleza análoga. Es decir, entidades cuya función principal es intermediar en la concesión de créditos. El objetivo de este trabajo, como al inicio se indicó, es reflejar las posibles consecuencias que acarrearán la insolvencia o quiebra del depositario cuando no puede hacer frente a la devolución del capital que recibió. Ceñiremos el comentario a aquellas entidades de crédito³⁹ en sentido estricto: los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, soslayando todas aquellas otras empresas o personas jurídicas que también emiten medios de pago en forma de dinero electrónico.

Dada la práctica desaparición actual de las cajas de ahorro y su transformación por fusión o absorción en bancos, constituidos necesariamente aunque revistan especialidades en sociedades anónimas, en los que su forma de funcionamiento, gestión y administración difiere sustancialmente de los bancos romanos, pues se encomienda a un consejo de administración, nos ceñiremos al análisis de la responsabilidad del mismo y sus representantes en aquellos supuestos de insolvencia frente a los depositantes. Los administradores de un banco, como tal sociedad de capital, tienen sus deberes y sus responsabilidades. Tienen la responsabilidad general por incumplimiento de los deberes de los administradores, conforme establece la Ley de Sociedades de Capital⁴⁰. Y tienen también la responsabilidad particular que les sea imputable en caso de que se declare un concurso calificado como culpable, de acuerdo a lo establecido en la Ley Concursal⁴¹. A pesar de todo es muy difícil por no decir imposible que un banco entre en concurso de acreedores (quiebra).

La vigente Ley Concursal en su exposición de motivos opta por los principios de unidad legal, de disciplina, de sistema y de procedimiento, estableciendo un régimen único para todo tipo de comerciantes y no comerciantes. Pero también existen excepciones al principio de unidad. Estas excepciones vienen determinadas por la naturaleza de la persona del concursado y afectan al mercado financiero, (entidades de crédito), mercado de valores y al mercado de seguros (aseguradoras). En el concurso de acreedores de bancos la ley regula unas especialidades que se refieren principalmente a la fase común y a la figura del administrador concursal, así como la calificación de la actuación del órgano de administración de la entidad en caso de disolución y liquidación del banco. En caso de quiebra de un banco, los fondos garantizan la percepción por todo inversor del valor monetario de

39 Por cierto, término bastante confuso fomentado por el propio legislador ya que admite diferentes acepciones.

40 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. CAPÍTULO III Los deberes de los administradores: arts. 225 a 232. CAPÍTULO V La responsabilidad de los administradores: arts. 236 a 241.

41 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

su posición acreedora global frente a dicha empresa, con el límite cuantitativo de 100.000 euros. Situación asumida por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito que fue creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre. El Fondo tiene por objeto garantizar los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito⁴².

Es importante la calificación del concurso (art.163) bien como fortuito bien como culpable, lo cual se definirá en la sentencia (art.172), pues de dicha calificación dependerá la responsabilidad de los administradores. El concurso se calificará como culpable (art. 164) cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, lo que dependerá de la concurrencia de diferentes supuestos, entre otros, llevar doble contabilidad; irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera; cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores; simular una situación patrimonial ficticia, etc. (art.164,2). Asimismo, la Ley Concursal (art.165) presume la existencia de dolo o culpa grave cuando se hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso; el deber de colaboración con el juez del concurso y cuando el deudor no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil.

De la calificación culpable derivará que el juez (art.172 bis) pueda “condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit”. Además, la sentencia indicará si procede la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos (art.172,2,2º) y como consecuencia las personas inhabilitadas cesarán en sus cargos (art.173). Por supuesto, los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos.

La imposibilidad del banquero para hacer frente a la restitución de los depósitos de los clientes, independientemente del momento histórico en que nos establezcamos, es siempre factible. Cosa diferente es cómo se haya resuelto en cada época, pero tanto en Roma como hoy en día las coincidencias en determinados puntos son evidentes. El banquero que quebraba en Roma no sólo respondía con todo su patrimonio para satisfacer el pago a sus acreedores sino que además como había sido condenado como consecuencia del ejercicio de la *actio depositi*, acción infamante que no solamente conllevaba un gran desprestigio social y la imposibilidad de acceder a cargos públicos, es verosímil que no volviera a ejercer la profesión de banquero pues había defraudado grandemente la confianza de sus conciudadanos. En la actualidad, salvando la complejidad de la estructura bancaria con sus administradores y otros sujetos responsables, y superada por la Ley Concursal la vieja regulación de la quiebra contenida en el Código de Comercio que se centraba en el deudor persona física, ahora la inmensa mayoría afecta a personas jurídicas de ahí que la Ley busque dar respuesta a los principales problemas que puedan plantear un concurso de sociedades. Por ello, ahora

42 Información detallada y actualizada en <http://www.fgd.es/es/index.html>

rige el principio de universalidad (art.76), y la masa activa está integrada por los bienes del deudor en el momento de la declaración del concurso y todos aquellos que se reintegren al mismo hasta la conclusión del procedimiento, obviamente teniendo en cuenta las oportunas excepciones de todos aquellos bienes y derechos que sean inembargables.

Si una de las cuestiones claves de la quiebra romana era establecer una prelación de acreedores, nuestra Ley Concursal del año 2003 también establece un orden de pagos. Por supuesto, para nada coincide con el romano, pero también se observa la preocupación del legislador por no equiparar igualitariamente todos los créditos sino anteponer la satisfacción de algunos frente a los demás. Así, en la Sección 4, intitulada “Del pago a los acreedores”, arts.154 a 158, establece el orden por el cual deben ir pagándose los créditos: 1) art.154: Pago de créditos contra la masa, 2) art.155: Pago de créditos con privilegio especial, 3) art.156: Pago de créditos con privilegio general; 4) art.157: Pago de créditos ordinarios, que se efectuará una vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados y 5) art.158: Pago de créditos subordinados que no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios.

Sirva esta reflexión para demostrar, una vez más, que de la historia se aprende; que el derecho romano aún tiene “vigencia” no como precedente invocable en sede procesal pero sí como conjunto de normas en las que aprender que la condición humana nunca cambiará aunque el tiempo transcurra de forma inexorable. Ignoro si estamos en el punto de llegada de la evolución jurídica, probablemente no, pero no ahondar en las raíces romanas de nuestro ordenamiento nos impedirá conocer la historia evolutiva de lo jurídico.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:

- ÁLVAREZ, M.B., - ALONSO PÉREZ, G.M., *Un perfil de los banqueros a la luz de la comedia plautina y de la crisis económica argentina del siglo XXI*, en *El derecho comercial, de Roma al Derecho moderno I*, Las Palmas de Gran Canaria, 2007.
- ANDREAU, J., *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent* (IVe. siècle av. J.C. – IIIe. siècle ap. J.C.), Roma, 1987.
- BARRÓN ARNICHES, I. de, *El hundimiento de la banca. Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español*, Madrid, 2012.
- BOGAERT, R, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leiden, 1968.
- BONIFACIO, F., *Ricerche sul deposito irregolare in diritto romano*, BIDR, 49-50, 1948.
- CERAMI, P., DI PORTO, A., PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 2ª ed., Torino, 2004.
- CHURRUCÁ, J. de, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über die argentarii im klassischen römischen Recht*, ZSS, 108, 1991.
- CHURRUCÁ, J de, *La quiebra de la banca del cristiano Calisto (ca. 185-190)*, en SCDR 3 (1992), 61-86, recogido en *Cristianismo y mundo romano. Colección de artículos sobre este tema*, con presentación de R. MENTXAKA, Bilbao, 1998.
- COSTA, E., *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890 (ed. anastática, Roma, 1968).

- DÍAZ BAUTISTA, A., Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano), Murcia, 1987.
- GARCÍA GARRIDO, J. M., *La sociedad de los banqueros (societas argentaria)*, en Studi in onore de A. Biscardi III, Milano, 1982.
- GIUFFRÈ, V., Mercato e credito di danaro en Il bisogno del diritto. Momenti dell'esperienza romanistica, Napoli, 2007.
- HERRERO CHICO, R., Argentarii. Estudios sobre el régimen jurídico de la banca en Roma, Granada, 1978.
- LITEWSKI, W., *Le dépôt irrégulier II*, RIDA, 22, 1975.
- MADRAZO LEAL, J., *El depósito bancario a la vista*, Madrid, 2001.
- OBARRIO MORENO, J.A., La quiebra y el concurso de acreedores en derecho medieval español, Revista Jurídica del Notariado, 82, 2012.
- OURLIAC, P., - DE MALAFOSSE, J., *Derecho romano y francés histórico I. Derecho de obligaciones*, (trad. esp.), Barcelona, 1960.
- PANERO, R., Deponere y reddere en la actio depositi in factum, Barcelona, 1989.
- PEÑALVER, M.A., *La banca en Roma*, Madrid, 1994.
- PÉREZ ÁLVAREZ, M^a del P., La bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en derecho romano clásico, Madrid, 2000.
- PÉREZ ÁLVAREZ, M^a del P., *El privilegio de los depositantes sobre el patrimonio del banquero en derecho romano clásico*, en Estudios de derecho romano en Memoria de B. M^a Reimundo Yanes II, Burgos, 2000.
- PETRUCCI, A., Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.), Napoli, 1991.
- PETRUCCI, A., Prime riflessioni su banca ed interessi nell'esperienza romana, en L'usura ieri ed oggi (Convegno, Foggia, 7-8 aprile 1995), Bari, 1997.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. M^a., El receptum argentarii en el derecho romano clásico. Una propuesta de análisis, Madrid, 2004.
- SALAZAR REVUELTA, M^a., El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos, RIDROM, (www.ridrom.uclm.es), 11-2013.
- SCOTTI, F., Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento, Torino, 2008.
- SORIANO, C., Banca, navegación y otras empresas en el derecho romano, México, 2007.
- TORRENT, A., *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, en AUPA (Annali dei Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo), LVI, 2013.
- VALMAÑA, A., El depósito irregular en la jurisprudencia romana, Madrid, 1996.

LA LEGISLACIÓN DE JUSTINIANO DEL CÓDIGO EN MATERIA DE NEGOCIOS BANCARIOS¹

FABIANA MATTIOLI
Universidad de Bolonia

SUMARIO: 1. La legislación en materia de *usurae*: la reforma de C.I. 4, 32, 26 y los problemas de interpretación resueltos por C.I. 4, 32, 27. - 2. Los banqueros y la adquisición de *militiae*: las previsiones de C.I. 8, 13 (14), 27 en relación con las previsiones generales de C.I. 12, 34 (35), 1 que imponía a los *negotiatores*, con la única exclusión de los *argentarii* *constantinopolitanos*, la prohibición absoluta de adquirir *militiae*. - 3. La prohibición de emplear la compensación en los contratos de depósito: las previsiones de C.I. 4, 34, 11 y su probable extensión a los depósitos interbancarios. - 4. La abolición del *receptum argentarii* y la reforma del *constitutum debiti alieni*.

1. La monografía, ya clásica, del Profesor Antonio Díaz Bautista dedicada a los negocios bancarios en la legislación de Justiniano reclamó, desde su publicación, la atención de los romanistas sobre un tema, por lo general, mal atendido por la doctrina, al centrarse en particular en el marco complejo que la materia reviste en la legislación de las Novelas ².

Más específicamente, las investigaciones de Díaz Bautista – a cuya memoria hoy tenemos la intención de honrar mediante esta conferencia, aquí, en Murcia, en la ciudad que le vio nacer y donde ejerció su magisterio durante más de un cuarto de siglo – proporcionaron, por primera vez, una tentativa orgánica de reconstrucción de esta interesante legislación, hasta el punto de que sus conclusiones aún siguen siendo hoy día un punto ineludible de referencia para el desarrollo de cualquier nueva investigación sobre el tema ³.

1 Agradezco al Prof. Fermin Camacho de los Rios por su excelente disponibilidad para la discusión y traducción del texto al castellano conmigo. Agradezco también al Dr. Xesús Pérez López por su exquisita disposición a revisar la redacción final del texto y de las notas.

2 A. DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987, pp. 1-221. Para la aportación innovadora de esta monografía dentro del panorama ofrecido de los estudios sobre el tema, v. las observaciones contenidos en la recensión de G. LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, en *BIDR* 94-95, 1991-1992, pp. 449-472. Por lo demás, el profesor Díaz Bautista se había ya ocupado de esta materia en *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien*, en *RIDA* 3^e s. 29, 1982, p. 165 ss.

3 La bibliografía sobre los negocios bancarios en edad justiniana no es, a día de hoy, y a diferencia de aquélla relativa a las *usurae* a la que nos referiremos a continuación, particularmente rica: F. LA ROSA, *La pressione*

El tema de los negocios bancarios, aunque, como es sabido, esta más ampliamente desarrollado en la legislación de las Novelas, también es ya tratado, sea directamente o indirectamente, en la legislación de Justiniano incluida en el *Codex repetitae praelectionis*. Es específicamente sobre esta legislación sobre la que hoy me gustaría proponer algunas reflexiones, a fin de destacar la aparición de ciertas tendencias de la política legislativa de Justiniano, que más tarde tendrán una expresión más completa y madura –y en algunos aspectos menos episódica– en la legislación novelar.

En este sentido es necesario comenzar la discusión por una ley muy conocida (calificada expresamente como *generalis sanctio*) promulgada el 13 de diciembre de 528 y destinada, en el contexto de una política normativa inspirada por el *favor debitoris*⁴, a redefinir la disciplina de los intereses convencionales, con el objetivo de reducir la tasa máxima del 12%, hasta entonces utilizada generalmente en la práctica comercial⁵.

degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti (C. 4, 18, 2, 2), en *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, I, Napoli, 1997, pp. 445-451; J.-M. CARRIÉ, *Les métiers de la banque entre public et privé (IV^e-VII^e siècle)*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore di M. Sargenti*, Napoli, 1998, pp. 65-93; G. LUCHETTI, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustiniana riguardante gli argentarii costantinopolitani*, en *Studi senesi* 117, 2005, pp. 40-70 (= *Contributi di diritto giustiniano*, Milano, 2004, pp. 151-176). Se consagra a la profundización en algunos aspectos históricos y prosopográficos la contribución de S. COSENTINO, *La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano*, in *Polidoro. Studi offerti ad A. Carile*, Spoleto, 2013, pp. 347-362.

4 La disposición lleva la subscriptio D. id. Dec. Constantinopoli Iustiniano pp. A. II Cons., mientras que la lex iungenda C.I. 7, 39, 8 (sobre la cual v. también infra, nt. 7), lleva la subscriptio D. III id. Dec. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II con. Cfr. sobre la cuestión KRÜGER, *Editio maior*, ad h. l. I. Acerca de la leve divergencia entre las subscriptiones de las dos constituciones, v. igualmente M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 252 y nt. 103. En cuanto al favor debitoris como motivo inspirador de C.I. 4, 32, 26 y de la siguiente 4, 32, 27 del 529, v. las consideraciones de M. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, en *Studi in onore di A. Biscardi*, II, Milano, 1982, en particular p. 398. Acerca de las motivaciones de las intervenciones normativas justinianas en materia de usurae y en particular por el encuadre de las mismas en el contexto de una política legislativa dirigida, de manera más general, a favorecer el crecimiento económico, v. también S. TAFARO, *Giustiniano e i limiti alla condanna del debitore*, en *L'usura ieri e oggi. Convegno su "L'usura ieri e oggi"*, Foggia, 7-8 aprile 1995, Bari, 1997, pp. 215-230; F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, 2006, pp. 153-158 y, más recientemente, A. ARNESE, *Usura e modus. Il Problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari, 2013, p. 83.

5 Sobre las tasas de interés practicadas hasta entonces cfr. en particular E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht Das Obligationenrecht*, Weimar, 1956, p. 160 e ss. Sobre la cuestión, para un cuadro de conjunto, v. también M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II², München, 1975, p. 341 y s. Para la permanencia de la tasa legal de la centésima hasta la reforma justiniana v., por último, brevemente, A. CHERCHI, *Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012, p. 106 e nt. 14. No debe olvidarse, sin embargo, que la reforma monetaria de Constantino (sobre la cual v. en particular E. BABELON, v. *Solidus*, en *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, t. IV, deuxième partie (R-S), Paris, 1911 [reimpr. Graz, 1969], pp. 1390-1391; F. CARLÀ, *L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino, 2009, pp. 78-93), con la sustitución del nummus aureus, o denarius aureus, por el solidus aureus, había determinado, en la práctica, un incremento de medio punto en la tasa de interés. Sobre este punto, cfr. G. BILLETTER, *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898, p. 332; F. KLINGMÜLLER, v. *Fenus*, en *PWRE*, VI.2, Stuttgart, 1909, col. 2198; E. BIANCHI, *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, en *Athenaeum* 72, 1984, p. 142; FASOLINO, *Studi sulle usurae*, cit., p. 166 y nt. 30; D. GOFAS, *The Byzantine Law of Interest*, en *The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century* (A. E. Laiou, Editor-in-Chief), III, Washington D.C., 2002, p. 1095.

Me refiero a la ya citada (pienso en particular en la comunicación de Carmen López-Rendo) C. I. 4, 32, 26 ⁶, una constitución que, después de un párrafo de naturaleza principalmente procesal (en el que se establecía con mayor precisión el principio por el que la acción sobre las *usuræ* y los frutos debe estar condicionada por la existencia de la *actio principalis*)⁷, se refiere precisamente a la tasa de las *usuræ* (párr. 1-5), fijando el límite máximo ordinario en un valor del 6% pero, al mismo tiempo, estableciendo un amplio conjunto de excepciones para aquéllos casos en los que esta medida era considerada, según las circunstancias, demasiado baja o demasiado alta (pár. 2)⁸.

6 Imp. Iustinianus A. Menae pp. Eos, qui principali actione per exceptionem triginta vel quadraginta annorum, sive personali sive hypothecaria, ceciderunt, non posse super usuris vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere quaestionem dicendo ex his temporibus eas velle sibi persolvi, quae non ad triginta vel quadraginta praeteritos annos referuntur, et adserendo singulis annis earum actiones nasci: principali enim actione non subsistente satis supervacuum est super usuris vel fructibus adhuc iudicem cognoscere. 1. Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes. 2. Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari: illos vero, qui erga steris praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari: in traiectionibus autem contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem *usuræ* exigi solent. 3. Nec liceat iudici memoratam augere taxationem occasione consuetudinis in regione obtinentis. 4. Si quis autem aliquid contra modum huius fecerit constitutionis, nullam penitus de superfluo habeat actionem, sed et si acceperit, in sortem hoc imputare compelletur, interdicta licentia creditoribus ex pecuniis fenori dandis aliquid detrahare vel retinere siliquarum vel sportularum vel alterius cuiuscumque causae gratia. nam si quid huiusmodi factum fuerit, principale debitum ab initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minuenda pars quam *usuræ* eius exigi prohibeantur. 5. Machinationes etiam creditorum, qui ex hac lege prohibiti maiores *usuras* stipulari alios medios subiciunt, quibus hoc non ita interdictum est, resecantes iubemus, si quid tale fuerit attemptatum, ita computari *usuras*, ut necesse esset, si ipse qui alium interposuit fuisset stipulatus: in quo casu sacramenti etiam illationem locum habere sancimus. D. id. Dec. Constantinopoli Iustiniano pp A. II cons. (13 de diciembre de 528).

7 El *principium*, en el cual se preveía precisamente que la caída de la *actio principalis* por prescripción a los treinta o cuarenta años habría comportado el correspondiente venir menos de las acciones relativas a las *usuræ* y a los frutos, constituye, por lo demás, el nexo de unión con la *lex iungenda* conservada en C.I. 7, 39, 8, a pesar de la leve divergencia de datación entre ambas disposiciones (sobre la cual, v. *supra*, nt. 4), en cuyo último párrafo (pár. 4) se preveía, correspondientemente, que la prescripción de la *actio principalis* comenzase, en los contratos que previesen el pago de los intereses, precisamente en el momento de impago de las *usuræ* maduras: en cuanto a C.I. 7, 39, 8 y a las conexiones con C.I. 4, 32, 26 pr., cfr., por todos, M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 195 y ss.; p. 205 y ss.; p. 251 y s.

8 Acerca de lo dispuesto en C.I. 4, 32, 26, con especial hincapié en lo previsto en los párr. 2 y ss., existe una amplia literatura: sobre la cuestión v., entre otros, en la doctrina más antigua, G. BILLETTER, *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig 1898, p. 320 y s.; 333; 345 y s., así como G. CASSIMATIS, *Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin*, Paris, 1931, en particular p. 49 y ss.; entre la literatura más reciente, cfr. en particular R. BONINI, *Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustiniane*, in *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1990, p. 259 y ss., y BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., concretamente p. 391 y ss. (ambos con ricas referencias bibliográficas); sobre la cuestión v. también M. SALAZAR REVUELTA, *La gratuidad del mutuum en el Derecho Romano*, Jaén, 1999, p. 196 y ss. Con particular referencia al tema de las *usuræ rei iudicatae* en el derecho justiniano, cfr. A. SALOMONE, *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico*, Napoli, 2007, pp. 580-585.

A este respecto, se establecía específicamente que los *illustres*, o las personas de rango superior, podrían estipular *usurae* observando un límite del 4%⁹ y que, en cambio –detalle en el que el texto hace hincapié– a los banqueros y a todos los mercaderes (“*qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt*”) no se les permitía superar un límite máximo del 8%¹⁰.

Al mismo tiempo, se establecía un límite más alto, del 12% “*in traiecticiis contractibus vel specierum fenori dationibus*”¹¹ y, asimismo, se establecía que no le era lícito al juez exceder los límites legales “*occasione consuetudinis in regione obtinentis*” (pár. 3)¹².

A este respecto, y para el caso de violación de los límites así fijados, se establecía que el acreedor no tendría acción “*de superfluo*”, y que los intereses recibidos a pesar de ello deberían ser siempre imputados al capital, considerando coherentemente que si los acreedores hubieran deducido o retenido algo del capital prestado, el importe de la deuda se debería reducir en cumplimiento de los límites de interés legales (pár. 4)¹³.

9 Esta disposición agrava ulteriormente las limitaciones impuestas a los senadores por la constitución contenida en C. Th. 2, 33, 4 (Arcad., *Honor. et Theod. AAA. Optato pu.*, a. 405). Al respecto, v. en particular P. GARBARINO, ‘*Senatores in annis minoribus constituti*’ e ‘*usurae*’. Contributo all’*esegesi di CTh. 2, 33, 3*, en *BIDR* 91, 1988, pp. 337-339 y D. GOFAS, *The Byzantine Law of Interest*, cit., p. 1096.

10 La disposición examinada es recordada por la Nov. 136, 4. Sobre este punto, v. en particular DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, cit., pp. 35-36.

11 Estos dos casos no eran sometidos en derecho al límite de la *centesima*. En lo que se refiere al préstamo marítimo, una parte de la doctrina considera que el límite podría ser aplicable únicamente a los intereses terrestres, a calcular desde la llegada de la nave a puerto: cfr. R. VON JHERING, *Das angebliche gesetzliche Zinsmaximum beim foenus nauticum*, en *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts* 19, 1881, pp. 18-23 (= *Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts*, III, Jena, 1886, pp. 227-232); P. HUVELIN, *Études d’histoire du droit commercial romain (histoire externe - droit maritime)*, Paris, 1929, p. 208. Esta tesis ha sido renovada por G. PURPURA, *Ricerche in tema di prestito marittimo*, en *AUPA* 39, 1987, pp. 318-328 (= *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli, 1996, pp. 222-232). Al respecto, v. sin embargo las observaciones de I. PONTORIERO, *Il prestito marittimo in diritto romano*, Bologna, 2011, p. 162 e nt. 9. De un rescripto de Gordiano reproducido en C.I. 4, 32, 16 (Gord. A. Flavio Sulpicio, a. 242?) resulta que para los préstamos de productos de productos alimenticios no habría antes valido el límite de la *centesima*. La razón de la derogación residía en las fuertes oscilaciones características del precio de estos bienes (v. C.I. 4, 32, 23 [*Diocl. et Max. AA. et CC. Iasoni*, a. 294]). Costantino sometió por primera vez a estos préstamos a la tasa de interés del 50% (C.Th. 2, 33, 1 [*Constant. A. ad Dracilianum agentem vices pp.*, a. 325 vel a. 326: v. O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919 (reimp. Frankfurt am Main, 1984), p. 68 y p. 176]). Sobre la disciplina de los mutuos de productos alimenticios, v. L. SOLIDORO, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale*, en *Index* 25, 1997, pp. 558-559.

12 Cfr. sobre la cuestión G. CIVENCA, Contributo allo studio delle «*usurae*» c.d. legali nel diritto romano, Milano, 1969, pp. 281-288; ID., v. Usura (diritto romano), en *ED* 45, Milano, 1992, pp. 1125-1135; SOLIDORO, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale*, cit., pp. 556-557; FASOLINO, *Studi sulle usurae*, cit., pp. 174-177.

13 Acerca de esta parte del texto v. en particular BONINI, *Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustinianee*, cit., p. 262. Cfr. igualmente, entre la literatura más reciente, FASOLINO, *Studi sulle usurae*, cit., pp. 177-179; y, últimamente, ARNESE, *Usura e modus. Il Problema del sovraindebitamento dal mondo antico all’attualità*, cit., p. 84.

También se castigaba adecuadamente la conducta de aquéllos acreedores que, con el fin de recibir intereses en una medida superior a la que legítimamente podían reclamar, urdiesen una interposición fraudulenta de terceros (pár. 5)¹⁴.

La dificultad de hacer observar en la práctica los límites máximos de las *usurae* según lo determinado por la Cancillería, se deduce claramente, sin embargo, del tenor del principium de C.I. 4, 32, 27, una constitución del 1 de abril de 529, en la que se rechazaba, ante todo, la “*prava interpretatio*” de aquéllos que consideraban que los límites máximos fijados por la constitución del 528 no habrían podido ser aplicables a las *usurae* ya estipuladas en el momento de la entrada en vigor de la ley¹⁵.

A este respecto se establecía, a través de la interpretación, que podían ser cobradas dentro de los límites pactados (y por lo tanto también en medida superior a la taxativamente fijada por la constitución de 528) sólo las usuras devengadas en el momento de la emanación de C.I. 4, 32, 26¹⁶.

En este mismo contexto se confirmaba en términos generales la prohibición de las *usurae ultra duplum*, a través de su extensión a cualquier estipulación de intereses, independientemente del tipo de acto constitutivo del vínculo, de modo que parecería poder concluirse en todos los casos en los que podrían ser debidas *usurae*, tanto convencionales como legales¹⁷.

2. Un problema que podría parecer muy particular, pero que en la época era fuertemente sentido, es el que resulta de C.I. 8, 13 (14), 27¹⁸, una constitución de 1 de junio de 528 que

14 Sobre el pasaje, v. PONTORIERO, *Il prestito marittimo nel diritto romano*, cit., p. 164, nt. 13, que cita Bas. 23, 3, 74 (= Scheltema - van der Wal, A III, p. 1135). Este último pasaje pone como ejemplo la posibilidad de que un *illustris* recurra a la interposición ficticia de una persona con respecto a la cual hubiese sido, en cambio, lícito estipular la tasa del 6% anual.

15 Imp. Iustinianus A. Menae pp. De usuris, quarum modum iam statuimus, pravam quorundam interpretationem penitus removens iubemus etiam eos, qui ante eandem sanctionem ampliores quam statutae sunt usuras stipulati sunt, ad modum eadem sanctione taxatum ex tempore lationis eius suas moderari actiones, illius scilicet temporis, quod ante eandem fluxit legem, pro tenore stipulationis usuras exacturos. 1. Cursum insuper usurarum ultra duplum minime procedere concedimus, nec si pignora quaedam pro debito creditori data sint, quorum occasione quaedam veteres leges et ultra duplum usuras exigi permittebant. 2. Quod et in bonae fidei iudiciis ceterisque omnibus in quibus usurae exiguntur servari censemus. D. k. April. Constantinopoli Decio vc. cons. (1 de abril de 529).

16 Sobre esta parte del texto y, en general, sobre la interpretación auténtica provista por la constitución analizada respecto a C.I. 4, 32, 26 v. en concreto BONINI, *Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustinianee*, cit., pp. 262-263.

17 Sobre este punto y para un examen de conjunto de C.I. 4, 32, 27, incluyendo el problema de la anche *computatio dupli*, dejado sin resolver por la constitución (ya sea en lo que se refiere a la cuestión de la relevancia o no de los intereses ya pagados, ya sea en lo que se refiere a la efectividad de la prohibición en caso de que el monto de los intereses hubiese alcanzado una cifra equivalente al capital prestado [así más tarde Nov. 121 del 535] o más bien del doble de éste), cfr. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., pp. 394-398. Más generalmente, sobre el tema de las *usurae ultra duplum*, v. G. CERVENCA, *Sul divieto delle cd. «usurae supra duplum»*, en *Index* 2, 1971, pp. 291-312; L. SOLIDORO, «*Ultra sortis summam usurae non exiguntur*», en *Labeo* 28, 1982, pp. 164-179; CERVENCA, v. *Usura (diritto romano)*, cit., p. 1128; SOLIDORO, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, cit., pp. 555-571.

18 Imp. Iustinianus A. Menae pp. Super hypothecis, quas argenti distractores vel metaxarii vel alii quorumcumque specierum negotiatores pecunias sibi credentibus dare solent, hoc specialiter super amputanda omni machinatione sancimus, ut, si post huiusmodi contractum liberis suis vel alio modo cognatis quamcumque

trataba acerca de la adquisición de *militiae* realizada a favor de hijos y familiares, y además, eventualmente, de extraños, por los *argentarii*, los *metaxarii* o los *negotiatores* en general¹⁹.

Con una norma que, se dice expresamente, era aplicable sólo a los hechos futuros, se establecía que los acreedores hipotecarios pudieran exigir el pago del débito directamente de la persona que había obtenido la *militia*, o, alternativamente, actuar *iure hypothecae* y obtener la venta para satisfacer el crédito. A este respecto, en el caso de que la adquisición hubiera sido realizada a favor de hijos y familiares se establecía una suerte de inversión de la carga de la prueba, previendo que fuera el titular de la *militia* quien tuviese que probar que la adquisición había sido realizada con su propio dinero, y no que fuera el acreedor quien probase que el dinero prestado había sido invertido en la adquisición²⁰.

La cuestión así resuelta surgía, en cualquier caso, dentro de los límites fijados en C.I. 12, 34 (35), 1²¹, una constitución de fecha incierta, pero que se puede datar en los años 528-529, puesto que es dirigida al prefecto del pretorio Mena. Por esta última, a todos los

militiam idem negotiatores adquisierint, ea tamen vendi vel ad heredes sub certa definitione transmitti potest, liceat creditoribus eorum, etiam non probantibus ex pecuniis eorundem negotiatorum liberos eorum vel cognatos militasse (dum tamen contrarium non probetur alios e suo patrimonio dedisse pecunias), creditum ab his qui militarunt exigere vel tantum eos efflagitare, quanti vendi eadem militia possit. 1. Quod ita obtinere sancimus, et si extraneis quibusdam idem negotiatores de suis pecuniis huiusmodi militiam adquisisse probentur, ut, quod generaliter in ipsis debitoribus militantibus talem militiam, quae vendi vel ad heredes transmitti potest, permisum est, ut liceat creditoribus et adhuc viventium debitorum iure hypothecae vindicare militias, nisi satis sibi fiat, et post mortem eorum exigere, quod pro isdem militiis pro tenore communis militantium placiti vel divinae sanctionis tale praestantis beneficium dari solet, hoc in negotiatorum personis, licet ipsi militantes minime debito obnoxii sint, integrum creditoribus eorum servetur. 2. Quod scilicet in futuris militiis, non etiam in his, quas liberi vel cognati eorundem negotiatorum vel extranei pecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus. D. k. Iun. dn. Iustiniano A. pp. II cons. (1 de junio de 528).

19 Sobre el significado asumido por el término *negotiator* en las fuentes del tardo imperio, v. por último P. CERAMI, en P. CERAMI - A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino, 2010, p. 35. En cuanto a los *metaxarii* (que eran los comerciantes de seda), que residían a menudo, por lo demás, en Constantinopla v. en particular A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, II, Oxford, 1964, p. 862 (= *Il tardo impero romano [284-602 d. C.]*, III, Milano, 1981, p. 1302).

20 Para un encuadre de la constitución y para la difundida tendencia social de los *argentarii* a adquirir *militiae* para ellos o para sus familiares v. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, II, cit., p. 571 y p. 864 (= *Il tardo impero romano [284-602 d. C.]*, II, Milano, 1974, p. 798 y III, cit., p. 1304 e s.), quien recuerda a un *Flavius Anastasius, argentarius* constantinopolitano que revestía el cargo de *castrensianus sacrae mensae* (cfr. P. Cair. 67126, en el cual el personaje en cuestión da un préstamo a cuestro meses con una tasa de interés del 8%). Acerca de los desarrollos posteriores, con especial referencia a lo dispuesto Nov. 136, 2, cfr. DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, cit., pp. 93-97. Sobre la cuestión, cfr. también LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, cit., p. 460 y nt. 29; para un bosquejo, v. Id., *Spunti per una indagine sulla legislazione giustiniana riguardante gli argentarii constantinopolitani*, cit., pp. 44-45, nt. 6 (= *Contributi di diritto giustiniano*, cit., pp. 154-155, nt. 6).

21 Imp. Iustinianus A. Menae pp. Eos, qui vel in hac alma urbe vel in provinciis cuidam ergasterio praesunt, militare de cetero prohibemus, exceptis argenti distractoribus, qui in hac alma urbe negotiantur. 1. Hos enim utpote omnium contractibus utiles armata quidem militia penitus abstinere sancimus, aliam vero quamcumque sine metu praesentis sanctionis posse sibi acquirere. 2. Si qui vero negotiatores, quos omni militia prohibuimus, iam militarunt, licentiam eis damus negotiationem quidem relinquere, militiam vero retinere, scientibus quod, si postea negotiantes appareant, militia privabuntur. 3. Quod et in argenti distractoribus huius almae urbis, si armatam militiam iam sortiti sunt, tenere volumus, ut relicta negotiatione liceat eis in eadem militia durare. 4. Negotiantes etenim post hanc sanctionem huiusmodi militia privabuntur: illis, qui ad armorum structionem suam professionem contulerint, minime prohibendis ad competentem suae professionis venire militiam et huiusmodi negotiationem nihilo minus retinere (a. 528-529).

que ejerciesen actividades comerciales se les prohibía ser titulares de *militiae*, a excepción precisamente de los banqueros constantinopolitanos, respecto de los cuales la prohibición fue limitada sólo a las *militiae armatae*²².

Tal y como la propia Cancillería había clarificado ulteriormente, la disposición se aplicaba también a las *militiae* ya obtenidas, a menos que el interesado no optase por renunciar al ejercicio de la actividad comercial²³.

En este contexto, C.I. 8, 13 (14), 27 concernía particularmente las *militiae* adquiridas por los *negotiatores* a favor de hijos y familiares en general (y por lo tanto no por sí mismos), y esto porque, entre dichos *negotiatores*, como se desprende también de Nov. 136, 2, sólo los *argentarii* podían ahora –aunque dentro de los límites así fijados– *militare*²⁴.

3. De un cierto interés para nuestro tema, aunque en ausencia, en este caso, de toda referencia textual directa y específica a las actividades bancarias, es una constitución, del 30 de octubre de 529, que figura en C.I. 4, 34, 11²⁵. Es un texto en el que se corroboraba la imposibilidad para el depositario de utilizar la compensación, precisando, además, que este último no podría ejercer el *ius retentionis* o oponer la *exceptio doli* para escapar de la obligación de devolver lo que había sido depositado²⁶.

22 En este sentido C.I. 12, 34 (35), 1 pr.-1. Para una excepción v. sin embargo C.I. 12, 34 (35), 1, 4. La razón de este privilegio reside en la relevante función de los banqueros, en interés de la comunidad y de los individuos: cfr. LUCHETTI, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustiniana riguardante gli argentarii constantinopolitani*, cit., p. 46 y nt. 9 (= *Contributi di diritto giustiniano*, cit., p. 156 y nt. 9). En cuanto a la prohibición impuesta a los *argentarii* de obtener *militiae armatae*, cfr. también, posteriormente, Ed. 9, 6, pr.

23 Cfr. C.I. 12, 34 (35), 1, 2, donde se preveía en todo caso la pérdida de la *militia* en caso de inobservancia: *...scientibus quod, si postea negotiantes appareant, militia privabuntur*. En cuanto a los banqueros para la *militiae armatae* ya obtenidas v. C.I. 12, 34 (35), 1, 3: *Quod et in argenti distractoribus huius almae urbis, si armatam militiam iam sortiti sunt, tenere volumus, ut relicta negotiatione liceat eis in eadem militia durare*.

24 C.I. 8, 13 (14), 27 pr.: *...si post huiusmodi contractum liberis suis vel alio modo cognatis quaecumque militiam idem negotiatores adquisierint...*; pár. 2: *Quod scilicet in futuris militiis, non etiam in his, quas liberi vel cognati eorum negotiatorum vel extranei pecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus*. En lo que se refiere a Nov. 136, 2 y para la mención expresa de la posibilidad para los *argentarii* de adquirir *militiae* para sí aquí contenido v. LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, cit., p. 460, nt. 29.

25 Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. Si quis vel pecunias vel res quasdam per depositionis accepit titulum, eas volenti ei qui deposuerit reddere ilico modis omnibus compellatur nullamque compensationem vel deductionem vel doli exceptionem opponat, quasi et ipse quasdam contra eum qui deposuit actiones personales vel in rem vel hypothecarias praetendens, cum non sub hoc modo depositum accepit, ut non concessa ei retentio generetur, et contractus qui ex bona fide oritur ad perfidiam retrahatur. 1. Sed et si ex utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu compensationis praepeditio oriatur, sed depositae quidem res vel pecuniae ab utraque parte quam celerime sine aliquo obstaculo restituantur, ei videlicet primum, qui primus hoc voluerit, et postea legitimae actiones integrae ei reserventur. 2. Quod obtinere sicut iam dictum est oportet et si ex una parte depositio celebrata est, ex altera autem compensatio fuerit opposita, ut integra omni legitima ratione servata depositae res vel pecuniae prima fronte restituantur. 3. Quod si in scriptis attestatio non per dolum vel fraudem fuerit ei qui depositum suscepit ab alio transmissa, ut minime depositum restituat, hocque per iusiurandum adfirmaverit, liceat ei qui deposuit sub defensionis cautela idonea praestita res depositas quantocius recuperare. Recitata septimo miliario in novo consistorio palatii Iustiniani. d. III k. Nov. Decio cons. (30 de octubre de 529).

26 Sobre la imposibilidad para el depositario de oponer la compensación, v. ya PS. 2, 12, 12: *In causa depositi compensationi locus non est, sed res ipsa reddenda est*. Acerca de la reforma justiniana del 529, también con referencia a la evolución del derecho justiniano con respecto al texto de las *Pauli Sententiae*, v., en concreto, P. PICHONNAZ, *L'interdiction de compenser dans le contrat de dépôt*, in *RIDA* 3^e s., 46, 1999, p. 406 y ss. Otras

Para nuestros propósitos, es significativo que la prohibición se refiriese no sólo a los depósitos de cosas específicas, sino también a los depósitos en dinero (y por ende, también al depósito irregular)²⁷, un dato que sugiere, junto con la aplicabilidad de la prohibición también en el caso de depósitos recíprocos (pár. 1), que la disposición sería aplicable incluso a los depósitos bancarios, tanto en los casos en los que el depositante fuese un cliente de la banca, como en los que fuera un banquero, y, con mayor razón, en relación con los depósitos interbancarios²⁸.

4. Mucho más conocida, y esta vez directamente concerniente a los *argentarii*, es la intervención de Justiniano de 20 de febrero de 531 (C.I. 4, 18, 2)²⁹, mediante la cual se esta-

fuentes de época justiniana insisten en esta prohibición; es, ante todo, reproducida, en el marco de la fijación del sistema justiniano de compensación, en C.I. 4, 31, 14, 1 (a. 531): *...excepta actione depositi secundum nostram sanctionem, in qua nec compensacioni locum esse disposuimus*. Posteriormente, en I. 4, 6, 30: *...excepta sola depositi actione, cui aliquid compensationis nomine opponi satis impium esse credidimus, ne sub praetextu compensationis depositarum rerum quis exactione defraudetur*. La legislación novelar insiste aún en esta prohibición: cfr. Nov. 88, 1 (a. 539). En cuanto a la aplicabilidad de la reforma a la retención v. E. NARDI, *Studi sulla ritenzione in diritto romano*, I, *Fonti e casi*, Milano, 1947, pp. 424-425.

27 En este sentido, por último, PICHONNAZ, *L'interdiction de compenser dans le contrat de dépôt*, cit., p. 409. Para una opinión distinta v. sin embargo S. SOLAZZI, *La compensazione nel diritto romano*², Napoli, 1950, p. 182, nt. 20, que sugiere la hipótesis de que los justinianos se refiriesen, incluso para el caso del depósito de dinero, únicamente al depósito regular.

28 Se puede indicar ulteriormente, en el plano histórico-comparatístico, que la disposición en cuestión ha tenido cumplido reflejo en las codificaciones modernas: cfr. Code civil francés, art. 1293, n. 2; ABGB § 1440; Código civil español, art. 1200 (1); Código de las obligaciones suizo, art. 125, n. 1; Codice civile italiano, art. 1246, n. 2. Recientemente ver también el Código civil brasileño, art. 373, n. 2. En cambio, la prohibición de compensación en el depósito no figura en el BGB (§ 393) ni en el nuevo Nederlands Burgerlijk Wetboek (art. 6.135).

29 Imperator Iustinianus A. Iuliano pp. Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliari. 1. Cum igitur praefata actio, id est pecuniae constitutae, in his tantummodo a veteribus conclusa est, ut exigeret res quae in pondere numero mensura sunt, in aliis autem rebus nullam haberet communionem et neque in omnibus casibus longaeva sit constituta, sed in speciebus certis annali spatio concluderetur, et dubitaretur, si pro debito sub condicione vel in diem constituto eam possibile est fieri et si pure constituta pecunia contracta valeret, hac apertissima lege definimus, ut liceat omnibus constituere non solum res quae pondere numero mensura sunt, sed etiam alias omnes sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem possunt homines deducere: et neque sit in quocumque casu annalis, sed (sive pro se quis constituat sive pro alio) sit et ipsa in tali vitae mensura, in qua omnes personales sunt actiones, id est in annorum metis triginta: et liceat pro debito puro vel in diem vel condicionali constitui: et non absimile penitus stipulationi habeat dignitatem, suis tamen naturalibus privilegiis minime defraudata: sed et heredibus et contra heredes competat, ut neque recepticiae actiones neque alio indigeat res publica in huiusmodi casibus adminiculo, sed sit pecuniae constitutae actio per nostram constitutionem sibi in omnia sufficiens, ita tamen, ut hoc ei inhaereat, ut pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam recepticiam actionem exigeretur et si quid non fuerat debitum), cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permittere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas proponere conditiones, quae et pecunias indebitas et promissiones corrumpi et restitui definiunt. 1a. Ut non erubescat igitur tale legum iurgium, hoc tantummodo constituatur, quod debitum est, et omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complectens, qui et per stipulationem possint explicari. 1b. Et neminem moveat, quod sub nomine pecuniae etiam omnes res exigi definimus, cum et in antiquis libris prudentium, licet pecunia constituta nominabatur, tamen non pecuniae tantum per eam exigebantur, sed omnes res quae pondere numero mensura constitutae sunt. 1c. Sed et possibile est omnes res in pecuniam converti. si enim certa domus vel certus ager vel certus homo vel alia res quae expressa est in constituendis rebus ponatur, quid distat a nomine ipsius pecuniae? 1d. Sed ut et subtilitati eorum

bleció la refundición del *receptum argentariorum* en el *constitutum debiti* y la consiguiente abrogación del primero³⁰.

La reforma reconocía que l'*actio recepticia*, caracterizada por su estricto régimen formal, había caído en desuso y que, por lo tanto, era necesario ampliar el ámbito de aplicación de l'*actio pecuniae constitutae*, eliminando de tal suerte toda una serie de restricciones y limitaciones que han impedido su uso generalizado en la práctica³¹.

A tal fin, se remodelaba el *constitutum* según el paradigma del *receptum*, estableciéndose, ante todo (pár. 1), que l'*actio pecuniae constitutae* ya no fuese ejercitable sólo con respecto a las cosas fungibles (es decir, a las "*res quae in pondere numero mensura sunt*"), sino que fuese aplicable también a las cosas infungibles, muebles o inmuebles ("*sed etiam alias omnes sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem possunt homines deducere*"). Además, se establecía, de la misma manera que para todas las otras acciones personales, que ya no fuese considerada anual, sino que prescribiese, según el régimen ordinario, a los treinta años, que pudiera ser empleada para obligaciones a término o sujetas a condición, y que fuese transmisible a los herederos³².

La única característica del *receptum* que no había sido incorporada al *constitutum* era la de la abstracción, que consistía, como se sabe, en la autonomía de la obligación que nacía en la persona del banquero respecto a la del deudor, y esto porque, como significativamente

satisfiat, qui non sensum, sed vana nominum vocabula amplecti desiderant, ita omnes res veniant in constitutam, tamquam fuisset ipsa pecunia constituta, cum etiam veteres pecuniae appellatione omnes res significari definiunt et huiusmodi vocabulum et in libris iuris auctorum et in alia antiqua prudentia manifestissime inventum est. 2. His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus. D. X k. Mart. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. cc. (20 de febrero de 531).

30 Sobre la cuestión cfr. también I. 4, 6, 8 y el pasaje correspondiente de la Paráfrasis de Teófilo (Theoph., *Paraph.* 4, 6, 8). Sobre la controvertida reforma justiniana v., para un cuadro de la bibliografía menos reciente, la literatura indicada por G. LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, cit., p. 470, nt. 57. Entre las contribuciones posteriores señalo en concreto LA ROSA, *La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti*, cit., p. 445 y ss.; FASOLINO, *Sulle tecniche negoziali bancarie: il «receptum argentarii»*, en Labeo 46, 2000, p. 169 y ss.; A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, p. 57 y ss.; 189 e ss.; ID., en CERAMI - PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, cit., pp. 143-149.

31 Explicitamente en este sentido el pr.: *recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare*. Avanza dudas sobre el hecho de que el *receptum* hubiese caído en desuso LA ROSA, *La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti*, cit., p. 446. Ha de recordarse, por lo demás, que la abolición justiniana del *receptum* conllevó como consecuencia que los compiladores eliminasen toda noticia de la institución en los textos jurisprudenciales (cfr. C.I. 4, 18, 2, 1a: ... et omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complexens...) y que, paradójicamente, las noticias sobre ella de las que disponemos sea obtenibles, en buena medida, precisamente a través de C.I. 4, 18, 2: para la reconstrucción de las líneas generales de este negocio v. por todos PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II sec. a. C. - metà del III sec. d. C.)*, Napoli, 1991, p. 196 y ss., así como, del mismo autor, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 57 y ss.; ID., en CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, cit., p. 143 y ss.

32 Sobre esta parte del texto y sobre las características del *constitutum* tal y como la reforma justiniana lo había modelado v., entre la literatura más reciente, en particular FASOLINO, *Sulle tecniche negoziali bancarie*, cit. p. 175. Sobre este punto, para un cuadro sintético, v. también LA ROSA, *La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti*, cit., p. 447.

afirmaba la Cancillería en la parte final del pár. 1, debía ser considerado absurdo, y además “*iustis legibus contrarium*”, que alguien pudiera obtener lo que no le era debido³³.

Según las palabras del legislador, la promesa de pagar la deuda de otro mediante *constitutum* debía por lo tanto referirse a una deuda realmente existente, excluyéndose, como era el caso en el *receptum*, que el banquero debiera cumplir su prestación de garantía también en el caso en el que el deudor garantizado no estuviera obligado³⁴. Esto no impedía, por otra parte, según nos refiere el párrafo final de la constitución (v. C.I. 4, 18, 2, 2), que debieran considerarse, sin embargo, todavía válidos los negocios concluidos por los banqueros (y, eventualmente, por otros *negotiatores*), con renuncia a oponer excepciones (“*indefense*”), según los usos entonces en vigor³⁵.

Podemos colegir por tanto –incluso si la interpretación del texto no es, en este sentido, totalmente pacífica– que con la cláusula final de C.I. 4, 18, 2 el legislador entendiese exceptuar, no obstante lo dispuesto, ciertas formas negociales probablemente generalizadas en la praxis del mundo bancario y mercantil bizantino, formas negociales por las cuales se creaba un vínculo de garantía absoluto y que, como tales, permanecían consiguientemente libres de las limitaciones de la responsabilidad del promitente *pro alio* establecidas para el *constitutum*³⁶. Y es precisamente a este respecto que me complace concluir volviendo a recordar que el Prof. Díaz Bautista discernía en el *indefense constituere* la prueba de la supervivencia del antiguo *receptum argentarii* en la forma de la *καθαρὰ ἀντιφώνησις* mencionada en el Ed. 9 *praef.*-1³⁷.

Vaya, pues, desde aquí, nuestro más sentido homenaje al añorado Profesor, cuyo buen tino y maestría arrojaron luz, como hemos advertido en este caso y en tantos otros, sobre cuestiones difíciles, creando así una deuda impagable por todos aquéllos que nos dedicamos con pasión y modestia a la investigación romanista.

He dicho. Muchas gracias por su amable atención.

33 C.I. 4, 18, 2, 1: ...cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permittere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas proponere conditiones, quae et pecunias indebitas et promissiones corrumpi et restitui definiunt.

34 Sobre el carácter abstracto del *receptum* v. por último, por todos, PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 63; ID., en CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, cit., p. 149.

35 Sobre esta parte del texto, v., por último, todavía PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 189 y ss. Para el contraste del pár. 2 con el resto de la constitución y para la posibilidad de que éste pueda haber sido añadido en el momento de la compilación del segundo Código v. recientemente LA ROSA, *La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti*, cit., p. 449 y ss.

36 Sobre el punto, para una hipótesis en este sentido, v. ya las observaciones de G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*, II, Milano, 1941, p. 290 y ss. Y en particular pp. 302-303.

37 La opinión de Astuti ha sido criticada, aunque para retomarla de manera más radical, esto es, barajando una supervivencia del *receptum* en la *καθαρὰ ἀντιφώνησις* a la que hace referencia Ed. 9 *praef.*-1, por DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., concretamente p. 193 y ss.

EL PRIMER TRATADO ROMANO-GADITANO: INTERROGANTES E HIPÓTESIS

BERNARDO PERIÑÁN GÓMEZ
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla

Resulta ineludible, cuando se trata del estudio de la expansión de Roma, la alusión a los *foedera*. Después de una práctica pactista consolidada dentro de Italia, que acompañan su extensión con o sin conquista militar efectiva, Roma emplea en ocasiones ese mismo esquema en su expansión extra-italica¹. En tales casos, la *Urbs* da a sus actos de imposición un tinte de juridicidad y paridad para garantizar una relación pacífica entre las dos partes del acuerdo, aunque difícilmente podrán verse éstas en pie de igualdad siendo Roma la potencia dominante y victoriosa. En esas ocasiones, hay que entender que no bastaba a la *Urbs* el empleo de las armas o la imposición de la propia administración para garantizar la estabilidad, y era la expansión política y económica la que reclamaba de Roma cierta consideración hacia determinadas comunidades.

En este orden de ideas, y más si hablamos de la consolidación del *mare nostrum* como espacio comercial seguro, resultan singularmente interesantes los tratados de Roma con la ciudad hispana de Gades, que sin ser mediterránea se convierte en la entrada de ese mar desde su refugio natural en la costa atlántica y, muy señaladamente, en su puerto para el tráfico de minerales, aceites y salazones hispanos con destino a la *Urbs*. Quizá por esa razón se puede distinguir a Gades de otras ciudades hispanas, simplemente estipendiarias, proveedoras de tropas y tributos, y encuadradas en la administración provincial romana.

Si bien en esta ocasión trataremos sólo del primero, se constata la existencia de dos convenios, pero hay que tener presente que cualquier acuerdo no es siempre un *foedus*. Por ejemplo, no tendría esa naturaleza un simple acuerdo de rendición, resignadamente asumido por la ciudad vencida frente a la potencia dominante. Por otra parte, hablar de dos tratados supondría excluir la idea de renovación o reforma del primero, para pensar en su lugar en dos instrumentos diferentes.

1 P. FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano* I, en SDHI. 4 (1938) pp. 363 ss. y II, en SDHI. 5 (1939) pp. 161 ss.; M. LEMOSSE, *Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain* (Paris, Sirey, 1967)

En cualquier caso, deben tenerse presente dos fechas: el año 206 a.C. y el 78 a.C.; la primera coincide con la fase final de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.). Como veremos a continuación, el ejército romano llegó a Gadir en el año 206 a.C. y habría suscrito un primer acuerdo entonces.

Los principales interrogantes que se plantean alrededor de esta relación inicial, que como veremos se puede calificar de peculiar, servirán de guión para lo que sigue: ¿cuál es la naturaleza de ese primer acuerdo?, ¿cuál pudo ser su contenido?, ¿hasta cuándo extiende su vigencia? y, lo que quizá resulte más arriesgado, ¿qué motiva a Roma a tratar a Gadir, vencido por las armas, con singular benevolencia?

Bien es verdad que para dar cumplida respuesta a estas preguntas, hay que tener presente lo parcial de nuestra fuente fundamental sobre este instrumento jurídico, pues buena parte de la información al respecto proviene de la *Oratio pro Balbo* pronunciada por Cicerón en defensa de L. Cornelio Balbo *maior*, en el año 56 a.C.:

Cic. Balb. 34: Nec vero oratio mea ad infirmandum foedus Gaditanorum, iudices, pertinet; neque enim est meum contra ius optime merita civitatis, contra opinionem vetustatis, contra auctoritatem senatus dicere. Duris enim quondam temporibus rei publicae nostrae, cum praepotens terra marique Carthago nixa duabus Hispaniis huic imperio immineret, et cum duo fulmina nostri imperi subito in Hispania, Cn. et P. Scipiones, extincti occidissent, L. Marcius, primi pili centurio, cum Gaditanis foedus fecisse dicitur. Quod cum magis fide illius populi, iustitia nostra, vetustate denique ipsa quam aliquo publico vinculo religionis teneretur, sapientes homines et publici iuris periti, Gaditani, M. Lepido Q. Catulo consulibus a senatu de foedere postulaverunt. Tum est cum Gaditanis foedus vel renovatum vel ictum; de quo foedere populus Romanus sententiam non tulit, qui iniussu suo nullo pacto potest religione obligari.

No en vano, para esta causa resultó especialmente importante concretar la naturaleza y alcance de los pactos romano-gaditanos, a fin de determinar lo adecuado o no de la concesión de la *civitas romana* a Lucio Cornelio Balbo, originario de Gades². Por ello, el contexto y el resto de las fuentes alusivas a estos tratados serán especialmente importantes a la hora de contrastar esa información con la ofrecida por el arpinate³.

I. Acerca de la naturaleza de los acuerdos hay que examinar separadamente el primero y el segundo. Sobre el del año 206 a.C. llega a decir Livio:

Liv. 28.37.10: post Magonis ab Oceani ora discessum Gaditani Romanis deduntur.

2 Si bien la *oratio* en su conjunto resulta de interés para esta cuestión, los textos en que se alude expresamente a esta relación *internacional* son Balb. 34 y 39. Sobre el proceso a Balbo en su conjunto, vide B. PERINÁN GÓMEZ, *El proceso contra L. Cornelio Balbo "maior": estudio jurídico* (Pamplona, Aranzadi, 2011)

3 Destacan por su importancia dos textos aparentemente contradictorios del mismo autor: Liv. 28.37.10 y Liv. 32.2.5.

Es decir, que el primer acuerdo romano-gaditano no habría pasado de ser un simple convenio de rendición, lo que habría convertido a los gaditanos en dediticios. La huida del general cartaginés Magón habría propiciado según Livio la entrega de la ciudad. Ahora bien, el mismo autor da cuenta de un incidente que tuvo lugar en el año 199 a.C., que tendría como argumento el incumplimiento de un acuerdo entre Roma y Cádiz, en virtud del cual los gaditanos protestaron ante la presencia en su ciudad de un prefecto romano.

Liv. 32.2.5 Gaditanis item petentibus remissum ne praefectus Gadis mitteretur, adversus id quod iis in fidem venientibus cum L. Marcio Septimo convenisset

Es decir, que sólo siete años después de la rendición de Gades se cursa una protesta contra el envío de un prefecto, sobre la base de un acuerdo cerrado con un tal L. Marcio Séptimo⁴. Hay que suponer que el mando militar que se envió a Gades en el 199 a.C. estaba acompañado de una guarnición y tenía la función de tomar parte en el gobierno de la ciudad, pues en otro caso no tendría sentido la protesta. También hay que entender que esta reclamación fue exitosa, como afirma el mismo Livio, pues no se repite –que sepamos– ni es defendible que las instituciones políticas propias de Gades dejaran de ejercer sus funciones⁵.

¿Cómo interpretar esa aparente contradicción entre dos informaciones provenientes del mismo autor? Si atendemos al primero de los textos, Cádiz se rinde a los romanos tras la huida del general cartaginés Magón; pero si atendemos al segundo, el acuerdo no fue una simple *deditio*, pues los gaditanos se consideraban legitimados para pedir a Roma que no interfiriera en las labores de su gobierno enviándoles un alto funcionario.

Por otra parte, Cicerón trata de restarle todo el valor posible al acuerdo del 206 a.C. al identificar a su signatario por parte romana como un *primi pili centurio*, un simple comandante de la fuerza romana encargada de rendir la plaza⁶.

Llama la atención sin embargo que el defensor de Balbo sitúe la actuación de este mando militar al frente de las tropas aludiendo a la muerte de los Escipiones, Cneo y Publio Cornelio, que como es sabido tuvo lugar en el 211 a.C., es decir, cinco años antes. Como es sabido, en el momento de la firma del primer acuerdo ya estaba al mando de las operaciones militares en Hispania Publio Cornelio Escipión, el Africano, que se había incorporado a tales funciones en otoño del año 210 a.C. Si Cicerón hubiera aludido a la ausencia del Africano en la firma del acuerdo con Gades, habría ofrecido un argumento a favor del escaso valor del mismo, por lo que entendemos que pudo cometer un error en la fecha del acuerdo. El relato del orador en este punto es además indirecto, pues se hace depender de un poco concreto y prudente, casi despreciativo, *dicitur*.

Otra posibilidad, para explicar la confusa información que ofrece el arpinate en este punto, es que el baile de fechas fuera más bien un ardid destinado a restar valor a un acuerdo que

4 Sobre este último texto puede verse E. BADIAN, *The praefect at Gades*, en *C. Ph.* 49-4 (1954) pp. 250 ss. y W. DAHLHEIM, *Struktur und Entwicklung des röm. Völkerrechts im 3. und 2. Jahrhundert* (München 1968) p. 58, n. 25.

5 Sobre el éxito de la reclamación gaditana, Liv. 32.2.5.

6 Cic. *Balb.* 34.

superaba con mucho la simple rendición, sobre todo si tenemos en cuenta que Lucio Marcio pudo ser un *legatus* y no un simple centurión, como opina buena parte de la doctrina⁷.

En cualquier caso, el propio Cicerón habla repetidamente de *foedus*, de su firma y de su renovación, y quizá era consciente de que tenía poco que hacer –tal vez sólo confundir o sembrar dudas– respecto al valor de un tratado bien conocido al que trata de restarle relevancia para la parte romana⁸. Que esa pudo ser su intención –no olvidemos que estamos ante un discurso de parte en un proceso criminal– puede constatarse en otro momento de la *oratio*, como cuando se refiere despectivamente a un acuerdo que los gaditanos reconocían como vinculante a pesar de su escasa fuerza obligatoria para Roma, a través de una pregunta retórica: *qui et veterem illam speciem foederis Marciani semper omni sanctionem arce duxerunt*⁹.

Con estos datos, casi indiciarios, las conclusiones a las que se puede llegar son simplemente aproximativas, pero permiten descartar dos extremos: el primer acuerdo de Roma con Gadir no fue ni un convenio de rendición, ni un *foedus sacrosanctum*. Lo primero habría privado a Gades de subjetividad alguna, y no tendría ni instituciones ni capacidad para quejarse ante Roma por su presencia militar en la ciudad, como cuenta Livio que ocurrió en el 199 a.C.; tampoco habría habido lugar a la duda prudente de Cicerón o a su presumible maniobra de despiste retórico, según se mire, si estuviéramos hablando de una simple *deditio*¹⁰. Lo segundo tampoco habría dejado lugar a la duda, pues un *foedus sacrosanctum* tendría el mismo valor y procedimiento que una *lex publica* y en ningún caso podría haber sido suscrito por un militar al frente de las tropas romanas, por elevado que fuera su rango¹¹.

Ambas afirmaciones pueden considerarse sólidas, pero la primera lo es aún más si tenemos en cuenta que Gades adquiere una subjetividad propia frente a Roma y sus habitantes una relevancia tal que excluye la posibilidad de considerarlos dediticios. Por ejemplo, de haberse dado tal circunstancia, no tendría sentido la renovación del acuerdo

7 Así L. RUBIO, *Los Balbos y el Imperio romano I*, en *Anales de Historia Antigua y Medieval* 4 (1949) p. 78, en la misma línea se sitúa J. L. LÓPEZ CASTRO, *El Foedus de Gadir del 206 a.C.: Una revisión*, en *Fl. Ilib.* 2 (1991) pp. 274 ss., quienes indagan en la identidad de L. Marcio y su rango.

8 Cic. Balb. 34: *Quod cum magis fide illius populi, iustitia nostra, vetustate denique ipsa quam aliquo publico vinculo religionis teneretur [...]*

9 Cic. Balb. 39.

10 Según se describe en Liv. 1.38.2-3.:

Rex interrogavit: “estisne vos legati oratoresque missi a populo Conlatino, ut vos populumque Conlatinum dederetis?”

Sumus.

Estne populus Conlatinus in sua potestate?

Est.

Deditisne vos populum Conlatinum, urbem agros aquam terminos delubra utensilia, divina humanaque omnia in meam populi que Romani dicionem?

Dedimus.

At ego recipio.

Otras formas para la misma finalidad son descritas en B. PARADISI, *Dai ‘foedera iniqua’ alle ‘crisobulle’ bizantine*, en *SDHI.* 20 (1954) p. 36, n. 103.

11 En este sentido, P.A. BRUNT, *The legal issue in Cicero, Pro Balbo*, en *The Classical Quarterly* 32 (1982) p. 138.

inicial en el año 78 a.C. por la falta de entidad propia como sujeto político¹², ni el tránsito de los gaditanos hacia la ciudadanía romana, individual o colectivamente, vetada a los que se habían rendido pura y simplemente¹³. Sencillamente, el mismo proceso contra Balbo no habría tenido lugar. Por ejemplo, de haberse dado tal circunstancia, no tendrí que excluiría haber tenido lugar¹⁴. Dicho esto, huelga prácticamente añadir otros detalles en la misma línea, como que no consta que Roma tomara rehenes gaditanos en garantía del cumplimiento del acuerdo, como era habitual en los acuerdos de rendición¹⁵, y sí es sabido que L. Cornelio Léntulo fue nombrado *hospes publicus* de Gades después de que se suscribiera el primero de los acuerdos¹⁶.

Nuestro tratado sería por tanto un *foedus* ordinario, con sus particularidades y no un instrumento de rendición, pero no se puede afirmar de ningún modo que tuviera carácter *sacrosanctum*.

II. Pasemos ahora a lo tocante al contenido del tratado. Si excluimos a Cádiz del régimen aplicable a las ciudades estipendiarias y entendemos que el *foedus* del 206 a.C. tendría un carácter ordinario aunque *iniquum*, su contenido se concretaría en aceptar la dirección romana de su acción exterior, garantizar su lealtad y orden interno¹⁷, auxiliar militarmente a Roma en caso de necesidad y facilitarle aprovisionamientos que le serían remunerados. Quedarían al margen del acuerdo una hipotética obligación de pagar tributos, al tiempo que se permitía que Gadir mantuviese sus propias instituciones políticas y jurídicas en todo aquello que no estorbase a su alianza con Roma¹⁸. La *Urbs* mantendría pues una vigilancia más o menos lejana sobre el Derecho interno de Cádiz, controlando su evolución, como muestra el hecho de que se reformasen algunos aspectos del mismo con ocasión de la propretura de César en la Hispania Ulterior, ya en el año 61 a.C.¹⁹ Consta igualmente, que Gades tendría sus propios magistrados, los sufetes²⁰, y un senado local²¹. El tratado

12 Liv. 28.37.10.

13 Gai. 1.14-15.

14 A favor de considerar que el primer acuerdo romano-gaditano fue una *deditio* está P. FREZZA, *Le forme federative* cit. II p. 165, n. 11, opinión que no compartimos ante las evidencias ya expuestas.

15 Vide, sobre esta práctica habitual en los tratados de rendición, C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Proceso de la romanización de España desde los Escipiones hasta Augusto*, en *AHAM*. 4 (1949) p. 9, n. 18.

16 Cic. *Balb.* 51. Al respecto, vide J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *El municipio romano de Gades* (Cádiz, *Instituto de Estudios Gaditanos*, 1980) pp. 91 s.

17 J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *Gades* cit. p. 37.

18 Cic. *Balb.* 32. M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la Guerre Sociale* (Roma, École française de Rome, 1978) p. 304.

19 Cic. *Balb.* 43. Pudo referirse a alguna forma concreta de aplicación de la pena de muerte, quizá por viví-combustión, procedente del Derecho púnico. Balbo el Menor volvería a aplicarlo en la ciudad bajo su mandato, sin embargo, cfr. Cic. *Fam.* 10.32. Para J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *Gades* cit. p. 43, es más probable que se tratase de sacrificios humanos.

20 Liv. 28.37.2.

21 Cfr. Cic. *Balb.* 41. Sobre la administración local prerromana, vide J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *Gestión administrativa en las comunidades indígenas hispanas durante la etapa pre-municipal*, en *Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía* (Córdoba 1993) pp. 385 ss.

respetaría igualmente la autonomía económica de Gades, lo que incluiría la facultad de emitir moneda²², la exclusión de sus tierras del *ager publicus* y la libertad comercial²³.

III. Resultado de lo anterior es que Gades se pueda calificar como una ciudad *foederata et libera* desde el año 206 a.C.²⁴, de probada lealtad como muestra el hecho de que no se sumase a la rebelión contra Roma que tuvo lugar en la *Hispania Ulterior* en el año 197 a.C.²⁵ y que auxiliase a la *Urbs* cuando fue necesario, como el mismo Cicerón reconoce²⁶.

El primer tratado, el del 206 a.C., queda derogado como consecuencia de su renovación en el 78 a.C., si bien mantiene un valor simbólico importante en el momento del proceso contra Balbo, de ahí que Cicerón se refiera al mismo aunque careciera de vigor en el momento en que Balbo recibe la *civitas* romana, *ex lege Gellia Cornelia*, en el año 72 a.C.

Por otra parte, aunque no es una cuestión pacífica para la doctrina, la corriente mayoritaria opta por considerar que Gades se transforma en un *municipium civium romanorum* a partir del año 49 a.C., cuando se concede a los gaditanos la ciudadanía romana²⁷. No consta la derogación expresa del tratado, pero carecería de sentido considerarlo en vigor una vez que perdió su razón de ser al integrarse Cádiz en la administración romana²⁸. Aunque los municipios –a diferencia de las colonias– mantenían algunas peculiaridades jurídicas²⁹, el tratado habría ido perdiendo sentido a medida que Gades se romanizaba con el paso del tiempo. Todo lo más, y dada la perennidad que caracterizaba a los *foedera*³⁰, se podría considerar que el *foedus gaditanus* quedó reducido a un elemento de identificación, ya simbólico, del otrora pueblo federado.

IV. Las razones de la singularidad del trato que Roma ofrece al Gadir púnico, sin opciones de resistencia militar y a merced de la maquinaria de guerra romana, no son conocidas directamente. Hay que buscarlas en el contexto histórico y en la identificación de los intereses de Roma, por supuesto. La más compleja de las explicaciones, que pone en relación los

22 F. PONCE CORDONES, *Las monedas de Gades. Catálogo para su identificación y clasificación*, en *Gades* 5 (1980) pp. 27 ss.; C. ALFARO ASINS, *Las monedas de Gadir/Gades* (Madrid, Fundación para el Fomento de los Estudios Numismáticos, 1988)

23 Para un panorama general, vide F. J. LOMAS SALMONTE-R. SÁNCHEZ SAUS, en M. BUSTOS RODRÍGUEZ (Dir.), *Historia de Cádiz I Épocas Antigua y Media* (Madrid, Sílex, 1991); sobre la decisiva actividad marítima gaditana, vide J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *El municipio romano* cit. pp. 135 ss.; G. CHIC, *Portus gaditanus*, en *Gades* 11 (1983) pp. 105 ss.

24 Sobre las distintas opciones al respecto, vide J. L. LÓPEZ CASTRO, *El foedus de Gadir* cit. pp. 270 s.

25 L. RUBIO, *Los Balbos y el Imperio romano* I cit. p. 78.

26 Cic. *Balb.* 40.

27 Dio. 41.24.1-2; Liv. per. 110. J. GONZÁLEZ, *Itálica*, *municipium ivris latini*, en *MCV* 20 (1984) pp. 27 s. y esp. pp. 36 ss. y J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *Gades en tiempos de Columela*, en J. M.^a MAESTRE *et al.* (eds.), *Estudios sobre Columela* (Cádiz, Ayuntamiento, 1997) pp. 46 ss., difieren en que la concesión de César se hubiera referido a la latinidad o la ciudadanía, respectivamente, si bien convienen en que la consideración municipal de Cádiz es de la época de Augusto.

28 Plin. Nat. 4.119: *Habet oppidum civium Romanorum, qui apellantur Augustani Vrbe Iulia Gaditana*. También, en ID., *Ibid.* 3.15.

29 Gel. 16.13.4.

30 P. FREZZA, *Le forme federative* I cit. p. 386.

testimonios de Cicerón y de Livio, se debe a López Castro³¹, quien recoge una línea interpretativa anterior³² y recibe además un eco favorable en la doctrina³³. Esta tesis apunta a que los notables gaditanos se habrían rendido ante el procónsul Espición el Africano, antes de la rendición militar propiamente dicha y a espaldas de los gobernantes púnicos de la plaza. De ser así, el *foedus* habría precedido a la *deditio* en su fase de negociación y L. Marcio Séptimo habría actuado de acuerdo con las indicaciones del procónsul. A nuestro modo de ver, esta tesis no explica el por qué del desplazamiento de tropas romanas hasta las puertas de Gadir, pero tiene un apoyo adicional en un texto de Cicerón que López Castro no menciona y que hace referencia a la abrupta ruptura de negociaciones entre Gades y Cartago.

Cic., Balb. 39: “[...] qui a principio sui generis aut studio rei publicae ii ab omni studio sensuque Poenorum mentis suas ad nostrum imperium nomenque flexerunt [...]”

Es decir, Roma habría llegado a ser una plaza aliada antes de su conquista efectiva, que se produce en virtud de un acuerdo de asociación que reconoce la superioridad de Roma a cambio de una cierta autonomía y una lealtad que el tiempo y las circunstancias pondrían a prueba satisfactoriamente.

31 *El Foedus de Gadir* cit. pp. 269 ss., esp. pp. 271 ss.

32 Ya L. RUBIO, *Los Balbos y el Imperio romano* I cit. p. 78, y E. BADIAN, *The prefect* cit. p. 252, apuntaron hipótesis en esa dirección.

33 J. F. RODRÍGUEZ NEILA, *Gades* cit. pp. 35 s.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A BANCA EM ROMA (HISTÓRIA E DIREITO)

ANTÓNIO DOS SANTOS JUSTO

1. ANTELÓQUIO

Repetidamente tem sido dito que a actividade bancária em Roma continua a suscitar dúvidas que justificam o seu estudo renovado. DÍAZ-BAUTISTA adverte para as dificuldades, sintetizando que não é fácil compreender a actividade bancária antiga¹.

Conforta-nos, no entanto, o velho princípio de que não há livro, por mais gasto que esteja, que não consinta nova leitura. Justifica-se, por isso, que continuemos o estudo da banca em Roma, embora com especial ênfase na época de Justiniano da qual derivam os direitos contemporâneos.

Não ignoramos também que se trata de uma das áreas de estudo predilecto do Prof. António DÍAZ-BAUTISTA, Mestre de Mestres, de cuja amizade nos sentimos sempre devedores e aqui vimos homenagear com o sentimento profundo duma gratidão autêntica. Conheci-o mais de perto em Coimbra e logo me tornei admirador de um romanista sólido e profundo. Se é verdade que um homem só morre quando é esquecido, António DÍAZ-BAUTISTA não morreu: vive sempre connosco.

A propósito da banca romana, o nosso Mestre advertia que se movia num contexto social, económico e jurídico muito diferente dos nossos dias, mas não deixava de aí observar algumas operações que constituem verdadeiros precedentes da actividade bancária dos nossos tempos².

Eis, Senhoras e Senhores, Prezados Congressistas, a tarefa de que me incumbi quando aceitei o honroso convite do discípulo do Prof. DÍAZ-BAUTISTA, o Colega Juan Ramón Robles, que cumprimento com especial consideração e estima.

Permitam-me também que não silencie a estima, o respeito e a admiração que me merece a Excelentíssima Senhora que foi Esposa de DÍAZ-BAUTISTA. A sabedoria popular diz, em Portugal, que não existe um grande homem sem uma grande mulher. Aconteceu assim com o Prof. DÍAZ-BAUTISTA.

1 Vide Antonio DÍAZ-BAUTISTA, *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien* em RIDA XXIX (1982) 165.

2 Vide Manuel J. GARCÍA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano* (Bolsa de Madrid / Madrid, 2001) 74.

Os meus respeitosos cumprimentos, Minha Senhora. Cumprimentos que estendo ao filho romanista que igualmente muito estimo.

2. HISTÓRIA

Embora sem ignorar a sábia advertência de Alvaro D'ORS de que em “*cuestiones de orígenes, debemos practicar la ars ignorandi*”³ e perdendo-se na longa noite do tempo a história das actividades mais tarde denominadas bancárias, não me parece ousado afirmar que a *mensa* romana é fruto duma evolução que acompanhou o progresso da vida comercial.

Fora de Roma e nos alvares da civilização ocidental, a banca desenvolveu-se em estreita relação com os templos em que se armazenavam grandes tesouros cuidadosamente guardados por sacerdotes. O respeito religioso destes lugares oferecia a segurança necessária não só às oferendas à divindade, mas também a riquezas pessoais.

Assim aconteceu na Grécia (em Delfos e em Olímpia), no Egipto e em Jerusalém, em cujos templos surgiram os primeiros bancos. O Evangelho de São Mateus documenta operações de compra e venda e de câmbio⁴ e a parábola dos *talentos*⁵ mostra que, no tempo de Jesus Cristo, era normal o depósito retribuído de dinheiro⁶.

Sobretudo, tem-se visto, na Grécia, o antecedente mais importante da banca romana que acompanhou as grandes transformações económicas e sociais, consequência das conquistas que, durante os séculos III e II a.C., depois das guerras púnicas, abriram Roma ao mundo⁷.

Mas importa também não esquecer os tempos mais antigos, dominados pela *amicitia* dos povos vizinhos que regulava e conciliava os seus interesses⁸. Dominava-os uma mentalidade agrária⁹ pouco propensa a operações financeiras e cuja actividade, pautada pela confiança, lealdade e fraternidade, não gerava grande conflitualidade.

Todavia, com o progresso das relações comerciais ligado a contactos com outros povos, sobretudo gregos, surgiram novas exigências cujas soluções jurídicas os homens do direito procuraram oferecer. As relações com os povos da bacia do Mediterrâneo e sobretudo com as cidades da costa e do arquipélago grego criaram uma nova classe de cidadãos que se dedicaram ao comércio de produtos de luxo e de escravos especializados que enriqueceu Roma, onde se concentraram enormes riquezas até então dispersas nas distantes regiões do Império¹⁰.

3 Vide Alvaro D'ORS no *AHDE* 20 (1950) 901. No mesmo sentido, vide Sebastião CRUZ, *Da “Solutio”* I (Ed. do Autor / Coimbra, 1962) 17³.

4 Cf. XXI,12.

5 Cf. XXV,27.

6 Seguimos de perto Miguel Angel Peñalver RODRÍGUEZ, *La banca en Roma em Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias III* (Seminários de derecho romano “Ursicino Alvarez” / Madrid, 1988) 1532-1533. Vide também GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 79.

7 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 18.

RODRÍGUEZ, *ibidem* 1533.

8 Vide Emile DEL CHIARO, *Le contrat de société en droit privé romain sous la République e au temps des jurisconsultes classiques* (Recueil Sirey / Paris, 1928) 98.

9 Vide Antonio DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina (negócios bancarios en la legislación de Justiniano)* (Universidad de Murcia / Murcia, 1987) 4.

10 Vide Vincenzo ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano* (Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene / Nápoles, 1950) 27; e GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 19 que refere o saque de sete milhões de denários e as quantias

Neste contexto social e económico, foram surgindo paulatinamente banqueiros que se instalaram no *Forum* romano¹¹ e sucessivamente na Basílica, nos bairros velhos e nos locais mais distantes das províncias¹². O que se compreende, por se tratar duma actividade que se desenvolvia (e continua a desenvolver) nas cidades mais povoadas e ricas¹³.

Assinala-se a presença de banqueiros profissionais em Roma nos anos 318-310 a.C.¹⁴, sendo famosas as *tabernae argentariae* que se fixaram no norte do *Forum*, reconstruídas no ano 193 a.C. por iniciativa dos plebeus *M. Junius Brutus* e *L. Oppidius Salinator*. Eram, provavelmente, propriedade do Estado romano que as locava a homens que exerciam a actividade bancária¹⁵.

Posteriormente, para evitar as dificuldades das relações jurídicas pessoais criadas por contratos de locação (*locatio-conductio rei*), que ocorriam quando os locatários trespassavam as suas *tabernae*, a *iurisprudencia* romana construiu o direito de superfície a que mais tarde foi reconhecida a natureza de direito real, embora sobre coisa alheia (*ius in re aliena*)¹⁶. ULPIANO é claro:

D. 18,1,32: “quem vende locais em que se encontram bancos ou outros que estão no solo público vende não o solo, mas o direito, porque estes locais são propriedade pública e o uso deles pertence a privados”¹⁷.

Com o fortíssimo incremento das relações económicas, a importância dos bancos cresceu, coexistindo banqueiros públicos e privados, embora com funções próprias. Enquanto aqueles (denominados *mensarii*, *mensalarii*, *numularii* ou *argentarii coactores*)¹⁸ se ocupavam da *probatio* de moedas, da cobrança de impostos, do manejo de dinheiro, além de fazerem negócios com particulares, os banqueiros privados (*argentarii*) desenvolviam a sua diversificada actividade bancária¹⁹, embora, aproveitando-se da sua larga experiência

que os vencidos eram obrigados a entregar para compensar os gastos de guerra, além de tributos anuais em dinheiro e em espécie, como cereais, vinho, frutas, legumes, etc.

11 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 34, que assinala o ano 310 a.C.; e refere VARRÃO que situa o aparecimento dos *argentarii* na segunda metade do século IV e na primeira metade do século III a.C.

12 Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1535-1537, para quem nas Gálias nenhum habitante realizava um negócio sem o auxílio de um cidadão romano; e em Cartago havia uma rua dos *argentarii*, o que prova a existência de um grémio numeroso. Ainda segundo este Autor, na Basílica estavam os banqueiros que emprestavam a curso prazo, por meio de *stipulationes*; no *Forum*, a alta banca que negociava com os cidadãos mais estimados; e nos bairros velhos e sórdidos, os que emprestavam a juro elevado.

13 Neste sentido, vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1537-1538, que refere Alexandria, cidades da Ásia Menor, Atenas, Roma, Cartago e Pompeia.

14 Vide Jean ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent* (IVe. siècle av. J. C. – IIIe. siècle ap. J.C.) (École Française de Rome. Palais Farnèse / Paris, 1987) 340.

15 Vide ANDREAU, *o.c.* 339; e GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 36.

16 Vide A. SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – III (direitos reais)* em *Studia Iuridica* 26 (Coimbra Editora / Coimbra, 1997) 210-211; e RODRÍGUEZ, *o.c.* 1537 e 1575

17 D. 18,1,32: “Qui tabernae argentarias, vel ceteras, quae in solo publico sunt, vendit, non solum, sed ius vendit, cum istae tabernae publicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet”. Vide Aldo PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane* (G. Giappichelli Editore / Turim, 2002) 14.

18 Cf. D. 40,7,40,8. Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 41.

19 Vide *infra*, nº. 4.

profissional, não raro os poderes públicos a eles recorressem para lançarem em circulação a nova moeda cunhada nas oficinas imperiais.

Os bancos públicos, ainda que dispusessem de uma caixa central em Roma, estavam espalhados pelas províncias, onde cumpriam uma função eminentemente recolhedora. Assinala-se-lhes, também, certo trabalho social no Império, como a gestão do fundo público, criado por Augusto, constituído por riquezas confiscadas aos criminosos e de que foram emprestadas grandes quantidades de dinheiro, sem juros, a cidadãos romanos²⁰ e cuja vigiância foi confiada ao *praefectus urbi*²¹.

Nem sempre é fácil distinguir os banqueiros de outros profissionais que, por manejarem dinheiro, eram igualmente chamados *argentarii* com algum qualificativo para identificar a sua ocupação. Sucede com ourives (*argentarii fabri* ou *argentarii vascularii*) e cambistas (*numularii*, *mensularii*, *colectarii*). Aqueles confeccionavam objectos de ouro e de prata, mas também recebiam, em depósito, metais preciosos e exerciam uma espécie de banca. Já os cambistas comprovavam e avaliavam moedas²² e faziam as suas contas como os banqueiros, segundo esclarecem os seguintes textos de ULPIANO:

D. 2,13,9,2: “Pompónio escreve que não é injusto que também os cambistas de cobre sejam obrigados a exhibir as contas, porque estes cambistas, como os de prata, fazem contas, posto que também recebem dinheiro e o distribuem por partes...”²³.

D. 2,13,4pr.: “O pretor diz: “os directores de bancos de câmbio exibam a conta que lhes pertence, com expressão do dia e do cônsul””²⁴.

Em breve síntese, o desenvolvimento comercial e bancário conheceu, em Roma, diversas fases ou épocas, de que destacamos, na sequência de GARCIA GARRIDO²⁵, as seguintes:

1. Época primitiva: decorre até ao ano 100 a.C. Caracteriza-se por uma economia rudimentar e fechada, em que predomina a exploração agrícola. Troca-se gado por gado, a que se seguiu a introdução do lingote de bronze (ou *aes rude*) que funciona de preço pesado pelo portador duma balança (*libripens*) nas compras e vendas (*mancipationes*)²⁶. Mais tarde, no ano 269 a.C., foi introduzida a moeda de prata, cuja utilização iria facilitar as trocas com estrangeiros na época seguinte. Com a introdução da moeda, tornou-se necessária a intervenção de cambistas que comprovavam o seu valor;

20 Continuamos a seguir RODRÍGUEZ, *o.c.* 1534-153 que, citando os *Annales* de TÁCITO (VI,17), refere que Tibério seguiu o mesmo sistema, pondo em diversos bancos cem milhões de sestércios destinados a empréstimos sem juros.

21 Cf. D. 1,12,1,9.

22 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 32-41.

23 D. 2,13,9,2: “Numularios quoque non esse iniquum cogi rationes edere, Pomponius scribit, quia et hi numulari sicut argentarii, rationes conficiunt, quia et accipiunt pecuniam et erogant per partes...”.

24 D. 2,13,4pr.: “Praetor ait: Argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edant adiecto die et consule”.

25 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 18-43.

26 Sobre a *mancipatio*, vide SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – III (direitos reais)* em *Studia Iuridica* 26 (Coimbra Editora / Coimbra, 1997) 94-97.

2. Época do apogeu: coincide com a expansão imperial e situa-se entre os anos 100 a.C. e 300. É marcada pelo maior desenvolvimento do comércio e das actividades financeiras de banqueiros. A vitória sobre os povos itálicos e Cartago e a invasão da Grécia e da Ásia abriram novos horizontes ao comércio e indústria, convertendo-se Roma em centro das finanças e sede do comércio internacional;
3. Época tardia: começa no ano 300 e é caracterizada pelo declínio da actividade bancária que acompanha a grande crise económica e social do mundo romano. Para resporem a estabilidade económica, os Imperadores controlam as moedas e fixam o preço de mercadorias e serviços. Ao mesmo tempo, são punidos falsificadores e traficantes de moedas e metais preciosos, embora os Imperadores nem sempre tenham sido exemplares: v.g., desde Caracala que falsificam as moedas, cunhando-as com peso inferior ao legal. E, em consequência, surgiu uma inflação incontrolável. É também o tempo dos *collectarii* que cuidam do regresso das moedas de ouro à administração e que, organizados em corporações, concedem empréstimos²⁷.

Assinala-se, nos séculos III e IV uma decadência profunda da actividade bancária que se reflecte no silêncio desolador das fontes jurídicas. Todavia, no século V assiste-se ao “renascimento” desta actividade que se prolonga na época de Justiniano²⁸, apesar da grave epidemia da peste que se estendeu pelo Mediterrâneo nos anos 542 e 543, agravando a situação económica²⁹.

Haja em vista que Bizâncio era “*una ciudad cruzada por rutas comerciales, cuya principal riqueza era el tráfico mercantil*”³⁰. Por isso, compreende-se bem a influência que os *argentarii* tinham perante o Imperador³¹ que não raro satisfaz as suas pretensões e não se cansou de os elogiar, destacando a sua *utilitas* à comunidade³².

Importa finalmente referir que os banqueiros nem sempre gozaram de grande projecção social. Segundo SUETÓNIO, Marco António reprovava Octávio Augusto por o seu bisavô ter sido um liberto cambista. E há mesmo frases muito duras contra os banqueiros, como as de PLAUTO: “*se se discute uma conta com o banqueiro, acaba sempre por se ser deverdor*”; e “*o costume dos banqueiros é reclamar aos outros, mas jamais devolver, pagando só se forem muito pressionados*”³³.

27 À famosa história de Calisto parece ligar-se a deterioração da moeda e subida dos preços. Vide GARCÍA GARRIDO, o.c. 98-100; e Juan de CHURRUCÁ, *La quiebra de la banca del cristiano Calisto (ca. 185-190) en Seminarios complutenses de derecho romano (Febrero – Mayo, 1991) III (Facultad de Derecho. Fundación Seminario de Derecho Romano “Ursicino Alvarez” / Madrid.)* 61-72.

28 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit. 6-7; e PETRUCCI, o.c. 200-203.

29 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem* 29.

30 Transcrevemos DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem*, 7.

31 Vide PETRUCCI, o.c. 205; e DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit. 23.

32 Cf. N. 136. Vide DÍAZ-BAUTISTA, *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien*, cit. 166-168 e *Estudios...*, cit.8-9.

33 Cf. *Alularia*, III,5,55; e *Curculio*; III,1,7.

No entanto, em geral os banqueiros gozavam de elevada consideração e a grande maioria da população confiava neles³⁴. Eram pessoas respeitadas que se tinham tornado credoras de confiança³⁵. Por isso, a profissão de banqueiro era protegida, não sendo indiferente a esta protecção o facto de, para não vexar o *argentarius*, quem lhe pedisse judicialmente contas devesse prestar juramento de não calúnia (*ius iurandum non calumnia causa*), como observamos no seguinte fragmento de ULPIANO:

D. 2,13,6,2: “Mas exige-se, ao adversário do banqueiro, juramento de que não pede, por causa de calúnia, que lhe exhiba, para que não peça acaso que se lhe exibam ou contas inúteis ou as que tem com o objecto de molestar o banqueiro”³⁶.

3. TERMINOLOGIA

São enormes as dificuldades que as fontes proporcionam quando, com grande frequência, referem profissionais que, com nomes diferentes, exercem as mesmas funções³⁷.

Com efeito, falam de *argentarius*, *coactor*, *coactor argentarii*, *colectarius*, *nummularius*, *mensarius*, *mensularius*, *danista*, *trapezitas*, *praeteco*, *stipulator argentarii*, *fenurato* e de *negotiator* cujas funções nem sempre aparecem devidamente separadas³⁸.

Todavia, para não incorrerem em confusões e seguindo GARCÍA GARRIDO³⁹, distinguimos os seguintes profissionais:

- a) *argentarius*: é o banqueiro que guarda ou administra depósitos de dinheiro, faz empréstimos, participa em subastas e presta garantias;
- b) *nummularius*: é o cambista que comprova e avalia moedas. A partir do século II, realiza também operações bancárias, como depósitos e empréstimos;
- c) *coactor* (ou *coactor argentarii*): é o intermediário que cobra dívidas por conta dos seus clientes e, a partir do século II a.C., participa em subastas como prestamistas. Desaparecem nas inscrições latinas do século III;
- d) *stipulator argentarii*: é o redactor de contratos em subastas;
- e) *colectarius*: é o encarregado de assegurar o regresso das moedas de ouro à administração: Nos séculos IV e V concedem empréstimos;
- f) *mensarius*, *mensularius* ou *trapezista*: é o banqueiro público, mas também referido como agente financeiro privado. Na época de CÍCERO, é membro da administração financeira da cidade e actua cumprindo ordens dadas pelos questores. Segundo

34 Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1539.

35 Cf. D. 16,3,8; -42,5,24,2; -12,34.

36 D. 2,13,6,2: “Exigitur autem ab adversario argentarii iusiurandum, non calumniae causa postulare edi sibi; ne forte vel supervacuas rationes, vel quas habet, edi sibi postulet vexandi argentarii causa”.

37 Vide CHURRUCA, *o.c.* 74.

38 Vide PETRUCCI, *o.c.* 15-16 e 173; ARANGIO-RUIZ, *o.c.* 145; e GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 40.

39 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 32, 36-43.

PETRUCCI, *trapezista* é nome de origem grega dado ao banqueiro mais antigo que surgiu em Roma nos finais do século IV a.C.⁴⁰;

g) *danista*: é o indivíduo que profissionalmente empresta dinheiro⁴¹;

h) *fenerator* ou *negotiator*: é o operador especializado no empréstimo de dinheiro a juros em ligação ou não a outras actividades⁴²;

g) *praeteco*: é o pregoeiro em negócios e subastas;

h) *stipulator argentarii*: é o redactor de contratos em subastas.

De todas estas figuras, é o *argentarius* que apresenta maiores semelhanças com a actual profissão de banqueiro, cuja actividade tanto podia ser exercida individualmente com recurso ou não a *filiifamilias*, a libertos e a escravos, como em sociedade com outros *argentarii*⁴³.

Justifica-se, por isso, que centremos a nossa atenção nesta figura jurídica⁴⁴.

4. ACTIVIDADES

4.1. Enumeração

O *argentarius*, nome que etimologicamente está ligado a *argentum* que designa prata⁴⁵, é o banqueiro que dirige um banco (*mensa*) com vista à obtenção de fins lucrativos⁴⁶.

A sua actividade é abundante e diversificada, destacando a literatura romanista: a comprovação da autenticidade de moedas; a recepção de depósitos, selados ou não, de dinheiro e de coisas preciosas; a concessão de empréstimos (mútuos) e de créditos; o serviço de caixa; a abertura de contas; a organização, gestão ou intervenção em vendas em leilões (*auctiones*), apoiando clientes; operações de câmbio de moedas; transporte de dinheiro em sacos selados entre províncias; cumprimento de ordens de clientes para pagamento a terceiros ou liberação de dívidas; prestação de garantias ou assunção de outras responsabilidades; aceitação de penhores em garantia de empréstimos e obrigações de clientes; compra e venda ou arrendamento de armazéns; depósitos de cereais; administração e gestão de patrimónios de clientes⁴⁷; etc.

40 Vide PETRUCCI, *o.c.* 15; e Maria Vittoria Giangrieco PESSI, “*Argentarii*” e *trapeziti* nel teatro de Plauto em AG CCI (1981) 94.

41 Vide ARANGIO-RUIZ, *o.c.* 145.

42 Vide PETRUCCI, *o.c.* 16.

43 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 32-33; e PETRUCCI, *o.c.* 104.

44 Também RODRÍGUEZ, *o.c.* 1533, entende que devemos distinguir o *argentarius* de outras profissões que também se dedicavam ao manejo de dinheiro e de metais preciosos.

45 Vide ANDREAU, *o.c.* 61; RODRÍGUEZ, *o.c.* 1533; e PESSI, *o.c.* 95.

46 Vide PETRUCCI, *o.c.* 13; e GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 42.

47 Vide ANDREAU, *o.c.* 75-77, 349, 402, 643, 645 e 670; GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 34, 36, 74-75; e PETRUCCI, *o.c.* 16, 21 e 25.

4.2. Depósito de dinheiro

O depósito de dinheiro ou de outras coisas fungíveis é considerado em Roma um depósito irregular⁴⁸. Traduz-se na transferência da propriedade de *res* fungíveis, sobretudo dinheiro (*pecunia*), cuja origem continua a dividir os romanistas⁴⁹.

Como características, podemos assinalar as seguintes marcas que influenciam decisivamente o seu regime jurídico: 1) o objecto, constituído por *res* fungíveis; 2) a faculdade de uso e de consumo; 3) o pagamento de juros que funcionam como preço da utilização; 4) a restituição do *tantundem, eius generis et qualitatis*.

Todavia, estas características, que afastam o depósito irregular do depósito normal, aproximam-no do mútuo, questionando a romanística que se trata dum depósito, dum mútuo ou doutro contrato⁵⁰. No entanto, importa observar que, além da causa, o mútuo distingue-se do depósito irregular pela gratuidade (ausência de juros) e pelas acções que os tutelam: no mútuo, a *condictio certae creditae pecuniae*, cujo carácter de *actio stricti iuris* a torna inadequada para reclamar juros; no depósito irregular, a *actio depositi* que é de boa fé. E é exactamente esta distinção que criou dificuldades à *iurisprudencia* na tentativa de caracterizar o depósito irregular⁵¹.

Fixada esta figura, não surpreende que os banqueiros romanos a utilizassem para receberem dinheiro⁵² dos seus clientes que depois se obrigavam a restituir com juros. Dinheiro que iria permitiria aos *argentarii* a concessão de mútuos, cujos juros resultavam de negócios acessórios, como a *stipulatio usurarum*⁵³. Se considerarmos que recebiam juros mais elevados dos que se obrigavam a pagar, compreende-se facilmente que este fosse, nas palavras de Miguel Ángel Peñalver RODRÍGUEZ, “*um contrato clave en la actividade bancaria*”⁵⁴.

Este depósito (irregular de dinheiro) não afastava o depósito (regular) de moedas em saquinhas fechadas e identificadas que o banqueiro se obrigava a guardar e restituir, sem, certamente, deixar de receber um preço pela sua *custodia*⁵⁵. A circunstância de o depositante não deixar de ser proprietário permitia-lhe não só recuperar as *res* depositadas através da acção de reivindicação⁵⁶, como evitar o concurso dos credores em situações de falência da banca (*mensa*).

48 A expressão *depósito irregular* terá sido introduzida na linguagem jurídica por JASON DE MAINO. Vide Wieslaw LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier* em RIDA XXI (1974) 215.

49 Vide A. SANTOS JUSTO, O depósito no direito romano. Algumas marcas romanas no direito português em O sistema contratual romano: de Roma ao direito actual (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Lisboa, 2010) 59-60.

50 Vide ASTUTI *apud* SANTOS JUSTO, *ibidem* 60.

51 Cf. D. 16,3,24; -16,3,26,1; -16,3,25,1; -16,3,29,1; -16,3,1,34. Vide SANTOS JUSTO, *ibidem* 61-62.

52 Assinala-se também o depósito de objectos preciosos de ouro e prata, jóias ou documentos. Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1554.

53 Cf. D. 17,1,10,4; -19,5,24.

54 Transcrevemos RODRÍGUEZ, *o.c.* 1554.

55 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 77; e PETRUCCI, *o.c.* 32-33.

56 Cf. D. 42,5,24,2.

Mas, embora fosse prática habitual, não se afastava a possibilidade de os depósitos irregulares não vencerem juros, circunstância que, no caso de a banca falir, justificava que aos clientes depositantes fosse concedida certa preferência sobre os credores comuns, entre os quais se encontravam os depositantes com juros⁵⁷.

Esta situação, a que já se chamou “depósito infrutífero”⁵⁸ -- que provavelmente se justificava pela confiança que o cliente tinha no banqueiro, fortalecida pela ausência de outro interesse, como a cobrança de juros -- é expressamente abordada nos seguintes fragmentos de ULPIANO:

D. 16,3,7,2: “Sempre que os banqueiros se apresentem em falência, é costume, em primeiro lugar, ter em conta (...) aqueles que tivessem quantidades depositadas, não os que as emprestavam aos banqueiros com juros (...) e assim, se se tiverem vendidos os bens (...) se têm em conta os depositários, contanto que não se tenham em conta os que depois receberam juros...”⁵⁹.

D. 42,5,24,2: “Determinou-se que, vendendo-se os bens de um banqueiro, seja preferente, depois dos privilégios, a condição que, atendendo à fé pública, depositaram dinheiro no banco. Mas não se separam dos demais credores os que receberam dos banqueiros juros pelo dinheiro depositado; e com razão, porque uma coisa é dar a crédito, outra depositar...”⁶⁰.

De todo modo, a actividade principal dos banqueiros passava por depósitos com juros, situações que, já referimos, dividiram os jurisconsultos romanos sobre a sua natureza jurídica. Basta cotejar alguns fragmentos:

D. 16,3,7,2: (ULPIANO): “Sempre que os banqueiros se apresentem em falência (...) não se têm em conta os que depois receberam juros, como se tivessem renunciado ao depósito”⁶¹.

D. 42,5,24,2 (ULPIANO): “... mas não se separam dos demais credores os que receberam dos banqueiros juros, porque uma coisa é dar a crédito, outra depositar...”⁶².

PS II, 2,12,9: “Se depositaste dinheiro e foi permitido usá-lo, considera-se dado em mútuo mais do que depositado...”⁶³.

⁵⁷ Vide GARCÍA GARRIDO, o.c. 78.

⁵⁸ Vide PETRUCCI, o.c. 33.

⁵⁹ D. 16,3,7,2: “Quoties foro cedunt nummularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum, hoc est, eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas foenore apud numularios (...) et si bona venierint (...) depositariorum ratio habetur, dummodo eorum, qui vel postea usuras acceperunt, ratio non habeatur...”.

⁶⁰ D. 42,5,24,2: “In bonis mensularii vendundis post privilegia potiorum eorum causam esse placuit, qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. Sed enim qui depositis numis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non separantur; et merito, aliud est enim credere, aliud deponere...”.

⁶¹ D. 16,3,7,2: “Quoties foro cedunt nummularii (...) dummodo eorum, qui vel postea usuras acceperunt ratio non habeatur, quasi renuntiaverint deposito”.

⁶² D. 42,5,24,2: “... Sed enim qui depositis numis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non separantur; et merito, aliud est enim credere, aliud deponere”.

⁶³ PS II,12,9: “Si pecuniam deposuero eaque uti tibi permisero, mutua magis videtur quam deposita...”.

D. 16,3,28 (CÉVOLA): “Quinto Cecílio Cândido escreveu a Pácio Rogaciano uma carta nos seguintes termos: (...) “Faço-te saber por esta carta que as vinte e cinco moedas que quiseste estiverem em meu poder, ingressarão na minha conta (...) e procurarei que recebas juros”. Perguntou-se: poderão pedir-se, em virtude desta carta, também os juros ? Respondi que se devem os juros por acção de boa fé, quer se os recebeu quer se empregou o dinheiro em negócio próprio”⁶⁴.

D. 16,3,24 (PAPINIANO): “...Faço-te saber por esta carta escrita por minha mão, para que tenhas entendido, que estão em meu poder as cem moedas que neste dia me encomendaste por entrega feita pelo escravo Estico, administrador, as quais te entregarei no momento, quando e onde quiseres. Pergunta-se por causa do incremento dos juros. Respondi que tem lugar a acção de depósito porque que outra coisa é encomendar senão depositar ? (...) E se acha certamente estabelecido que nos juízos de boa fé, pelo que respeita aos juros, pode tanto o ofício do árbitro como a estipulação (...) mas se, desde o princípio se acordou sobre a prestação de juros, observar-se-á a lei do contrato”⁶⁵.

D. 16,3,26,1 (PAULO): “Lúcio Tício obrigou-se deste modo: recebi e tenho em meu poder a título de depósito, os subscritos de dez mil denários de prata e prometo e confesso que os entregarei todos no tempo fixado, tendo-se acordado que até se devolver o dinheiro, se pague juros em cada mês (...) Pergunto: podem pedir-se os juros ? Paulo respondeu que este contrato é de depósito de dinheiro e, por isso, conforme ao acordado podem pedir-se também os juros com a acção de depósito”⁶⁶.

Olhando para o primeiro fragmento, ULPIANO exclui que o empréstimo de dinheiro com juros seja considerado depósito (regular). E como também não será mútuo (que é gratuito, por natureza), a existência de juros leva-o a evitar uma qualificação precisa⁶⁷. No segundo texto, esta dificuldade mantém-se, embora a faculdade de usar o dinheiro leve o jurisconsulto a inclinar-se para um mútuo. De todo o modo, as dificuldades são óbvias.

Posição contrária têm CÉVOLA, PAPINIANO e PAULO que concedem ao depositante uma acção de boa fé com vista ao pagamento de juros⁶⁸. Trata-se, como expressamente

64 D. 16,3,28: “Quintus Caecilius Candidus ad Paccium Rogatianum epistolam scripsit: (...) Vigintiquinque numorum, quos apud me esse voluisti, notum tibi hac epistola facio, ad ratinculum meam ea pervenisse (...) ut usuras eorum accipias, curare habeo. Quaesitum est, an ex ea epistola etiam usurae peti possunt ? Respondi, deberi ex bona fidei iudicio usuras, sive percepit, sive pecunia in re sua usus est”.

65 D. 16,3,24: “... Centum numos, quos hac die commendasti mihi annuerate servo Stico actore, esse apud me, ut notum facio; hac epistola manu mea scripta tibi notum facio; quae quando voles, et ubi voles, confestim tibi numerabo. Quaeritur propter usurarum incrementum. Respondi, depositi actionem habere (...) Et est quidem constitutum, in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet, ut tantundem possit officium arbitri, quantum stipulatio (...) si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur”.

66 D. 16,3,26,1: “Lucius Titius ita cavit: suscepit habeoque apud me titulo depositi supra scripta denarium argenti decem millia, neque ad praescriptum omnia praestitutum et promitto et profiteor, conventionem scilicet initia, ut quoad omne argentum reddatur, in singulos menses (...) Quaero, an usurae peti possunt ? Paulus respondit, cum contractum, de quo quaeritur, depositae pecuniae modum excedere; et ideo secundum conventionem usurae quoque actione depositi peti possunt”.

67 Neste sentido, vide PETRUCCI, *o.c.* 34.

68 Vide PETRUCCI, *o.c.* 35.

referem os dois últimos jurisconsultos, da acção de depósito na qual o depositante, com base neste contrato, pode pedir a condenação do depositário nos juros acordados. Ou seja, a necessidade duma *stipulatio usurarum* está afastada, prejudicada pela existência de um contrato de depósito *sui generis* ou irregular que pode prever a existência de juros.

Não vemos, por isso, que os banqueiros devessem recorrer a pactos (*pacta*) ou estipulações (*stipulationes usurarum*) para que os seus clientes pudessem reclamar juros⁶⁹.

Resta referir que esta nova prática, que se traduz no recurso a depósitos irregulares, facilitou imenso a actividade bancária, até aí asfixiada pela necessidade de, paralelamente ao contrato de depósito (regular), se recorrer a outro negócio (*pactum* ou *stipulatio usurarum*).

4.3. Mútuo

Na sequência de GAIO⁷⁰, o mútuo tem sido definido como um contrato unilateral, através do qual uma pessoa, que recebe de outra a propriedade de determinada *pecunia* ou de outras *res* fungíveis, se obriga a restituir igual quantidade do mesmo género e qualidade⁷¹.

Trata-se dum contrato gratuito e, por isso, o mutuário não é obrigado a restituir mais do que recebeu⁷², embora circunstancialmente possa restituir menos⁷³. A eventual obrigação de pagar juros não resulta deste contrato, mas dum contrato formal (ordinariamente, uma *stipulatio* dita *usurarum*)⁷⁴ e, provavelmente a partir da época pós-clássica, de um contrato literal. Deste modo, enquanto a restituição do capital é tutelada pela *actio* que nasce do contrato de mútuo, à obrigação de pagar juros corresponde a *actio* que surge da relação obrigacional que os tem por objecto.

Relativamente ao valor dos juros, desde cedo se impuseram limites que combatessem a especulação⁷⁵. Numa brevíssima síntese, a Lei das XII Tábuas fixou, como limite máximo, o *unciarum foenus* que ascendia a 8,33% ao mês e, depois de um ano, a 100%. Posteriormente, várias leis regularam o cálculo e o montante dos juros e chagaram mesmo a proibi-los, concedendo a *manus iniectio* pura contra os usurários⁷⁶. No entanto, a proibição não se manteve por muito tempo, porque nos finais da República o limite foi fixado em 12% ao ano, mais tarde reduzido por Justiniano para 6%, com excepções em casos particulares. Fica, no entanto, por saber se, nas palavras de GARCÍA GARRIDO, “*los agentes profesionales y banqueiros respetaban o no nos limites e tasas de los intereses, pero podemos imaginarlo por las fuertes multas y penas que se imponían a algunos transgresores*”⁷⁷.

69 Contra, parece, PETRUCCI, *o.c.* 69-72.

70 Cf. GAIO 3,90.

71 Vide A. SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – II (direito das obrigações)*⁴ em *Studia Iuridica* 76 (Coimbra Editora / Coimbra, 2011) 34-35.

72 Cf. D. 2,14,17pr.; -12,1,11,1.

73 Cf. D. 12,1,11,1.

74 Cf. D. 19,5,24.

75 Vide, a propósito, GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 92 que traça um quadro de luta contínua contra especuladores e prestamistas usurários.

76 Assim, a *Lex Licinia Sextia de aere alieno*, do ano 367 a.C., a *Lex Genucia*, do ano 342 a.C. e a *Lex Marcia*, do ano 104 a.C. Cf. GAIO, 4,23. Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 93; PETRUCCI, *o.c.* 91-95; RODRÍGUEZ, *o.c.* 1558; e SANTOS JUSTO, *ibidem*, 36.

77 Transcrevemos GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 94.

Olhando agora para os mútuos concedidos por bancos, os romanistas observam que, dada a natureza gratuita do mútuo, a concessão de mútuos com juros (*foenus*) era feita acrescentando, ao contrato real de *mutum*, um contrato verbal (*stipulatio*) que também podia compreender o capital a devolver (*sors*) e os juros (*usurae*)⁷⁸. CÍCERO refere, a propósito, três formas negociais: 1) entrega de dinheiro (*pecunia numerata*) que corresponde ao contrato (real) de mútuo; 2) obrigação de entregar a *pecunia* por meio de um contrato verbal (*pecunia stipulata*); 3) registo nos livros de contabilidade (*expensa lata*)⁷⁹.

A segunda forma, que verdadeiramente constitui uma promessa de concessão de mútuo, é muito importante, porque permite ao banqueiro obrigar-se, perante o cliente, a entregar o dinheiro a terceiro, eventualmente pagando uma dívida daquele a este⁸⁰.

Todavia, subsiste o problema dos juros que, excluídos do contrato de mútuo (por ser gratuito), deviam ser acordados em contrato acessório, como a *stipulatio usurarum*⁸¹. Mesmo aqui, observa-se uma evolução: enquanto na época clássica a conversão do mútuo em *stipulatio* provocava efeitos negativos -- v.g., se a *stipulatio* fosse nula, o *trans* não podia recuperar o dinheiro entregue, porque nem gozava da *actio certae creditae pecuniae* do mútuo nem a *actio ex stipulatu stipulatio*⁸² --, esta situação alterou-se no direito justiniano: mesmo que a *stipulatio* fosse nula, subsistia o contrato inicial (o mútuo), por exigência de justiça. Há, aqui, uma evidente protecção do mutuante⁸³.

Como já referimos, a possibilidade de os juros serem reclamados numa acção de boa fé implicava que pudessem ser acordados num simples *pactum*. Pelo contrário, a *actio certae creditae pecuniae* que tutela o mútuo é uma *actio stricti iuris* e, portanto, não comportava essa possibilidade. PAULO procura resolver o problema, considerando que “(relativamente a) os pactos feitos imediatamente, crê-se que estão compreendidos na estipulação” e acrescenta que “era o mesmo que, tendo sido estipulada certa quantidade para cada mês, tivessem sido acrescentados juros pelo tempo que tiver atrasado o pagamento”⁸⁴. Trata-se, no entanto, duma ficção que atesta a dificuldade desta situação: finge-se que o acordo sobre juros se enquadra na *stipulatio* e, por isso, o mutuário pode ser demandado. Mantêm-se, no entanto, as duas acções: a que tutela o mútuo e a que permite reclamar os juros.

Este problema, que chegou até à época justinianeia, foi resolvido por uma *constitutio* de Justiniano do ano 541, que se transcreve:

N. 136,4: “mas como demos uma lei para que quem se encontra à frente de estabelecimentos bancários não prestasse juros superiores a 8% e nos manifestaram que costumavam emprestar com juros também sem escrito, mas que, quanto aos juros, não se lhes considerava crédito por se ter contraído o mútuo sem documento escrito e sem se ter interposto estipulação (com respeito ao que vulgarmente se diz que não

78 Vide GARCÍA GARRIDO, o.c. 82.

79 Vide GARCÍA GARRIDO, o.c. 82.

80 Cf. D. 2,14,47,1.

81 Cf. D. 19,5,24. Vide PETRUCCI, o.c. 67; e DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit. 34.

82 Cf. D. 45,1,126,2.

83 Vide RODRÍGUEZ, o.c. 1559.

84 D. 12,1,40: “... Dicebam, quia pacta in continenti facta stipulationi, inesse creduntur, perinde esse, ac si per singulos menses certam pecuniak stipulatus, quoad tardius soluta esset, usuras adiecisset...”.

é conveniente que sem estipulação corram juros, ainda que sejam muitos os casos em que, não se tendo estipulado os juros, nascem ainda que só de pacto e por vezes também se extinguem não em virtude de pacto, mas espontaneamente), por isso mandamos também que se lhes dêem não só em virtude de estipulação, mas também não tendo mediado escrito, os juros que ali lhes concede que estipulem, isto é, até 8%. Porque não é justo que quem está disposto a prestar auxílio a quase todos os que necessitam, sejam prejudicados por tal subtileza”⁸⁵.

Justiniano fala de subtileza e da injustiça de prejudicar quem presta auxílio, emprestando dinheiro. Por isso, insere no contrato de mútuo a possibilidade de juros. Ou seja, os mútuos concedidos por banqueiros podem ser onerosos: basta que haja acordo. Como observa DÍAZ-BAUTISTA, “*las circunstancias de le tradición helénica y posiblemente la presión de los banqueiros hicieron desdeñarse al Emperador*”⁸⁶. Mais: entende que, embora o texto⁸⁷ não o diga, “*puede deducir-se de él que la presunción de intereses al 8% en los contratos de préstamo ya documentados era iuris et de iure, con lo que la forma documental del préstamo tenía valor constitutivo respecto al pago de intereses*”⁸⁸.

É óbvio que, facilitando-se o empréstimo de dinheiro com juros, favoreceu-se o desenvolvimento da actividade bancária que gira, fundamentalmente, à volta de depósitos e de mútuos.

4.4. Intervenção em hasta pública (*auctio*)

Uma das grandes actividades que os banqueiros realizaram em Roma durante vários séculos consiste no apoio que dispensavam a clientes na aquisição de bens vendidos em hastas públicas (*auktiones*).

Ordinariamente eram vendidos bens de alto valor (como, v.g., prédios, casas, móveis ou objectos de luxo), de valor médio (como, v.g., escravos e mulos) e até de pequeno valor (como, v.g., pescado fresco)⁸⁹. No entanto, estas hastas serviam também para a concessão de: a) terras públicas (*ager publicus*); construção de grandes obras públicas, como pontes, faróis, estradas, aquedutos, templos, foros, praças públicas, termas, anfiteatros e teatros; explorações de minas, pedreiras e salinas; cobrança de impostos e rendas públicas; exploração de águas públicas; serviços de correios e transportes; etc⁹⁰.

85 N. 136,4: “Quoniam vero legem tulimus, ne argentariae mensae praepositi ultra besses usuras fenerentur, illi autem nos docuerunt, etiam sine scriptose fenerari solere, quantum vero ad usuras, fidem sibi non servari, utpote mutuo sine scriptis contrato nec stipulatione interposita, (iuxta vulgatum illud, non convenire, ut usurae absque stipulatione currant, licet multi sint casus, in quibus non stipulatae etiam usurae, vel ex solo pacto nascuntur, nonnunquam etiam ne quidem ex pactis, sed sua sponte introductae tamen exiguntur) propterea etiam sancimus, non solum ex stipulatione, sed etiam ex non scripto tales usuras illis dari, quales lex illis stipulari concedit; hoc est usque ad bessem centesimae. Nam qui omnibus fere indigentibus opem ferre parati sunt, iustum non est eiusmodi subtilitate laedi”.

86 Vide DÍAZ-BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina, cit. 35.

87 O Autor segue, agora, a N. 136,5,1 que admite a validade dos pactos de juros.

88 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem* 37.

89 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 116.

90 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 124.

As hastas públicas realizavam-se em certas datas, no mercado público ou em edifícios especiais (como a *atria auctionaria*, a *atria Licinia*, situada em Roma, ao norte da via Sacra)⁹¹. E eram organizadas por pregoeiros (*praecones*) que se ocupavam da publicidade, apresentavam os bens postos em hasta e faziam a sua adjudicação (*adiudicatio*) ao melhor ofertante. Os banqueiros (*coactores* ou *coactores argentarii*) registavam, em livros especiais chamados *tabulae auctionariae*, as vendas, os objectos vendidos, o preço e os nomes dos compradores, cobrando uma comissão⁹².

O *argentarius*, que servia de intermediário entre vendedores e compradores, entregava os valores adjudicados aos vendedores e, se necessário, proporcionava aos clientes compradores o serviço de caixa e concedia-se empréstimos⁹³.

Parece óbvio que a relação de compra e venda de bens em hasta pública tinha como sujeitos o vendedor (*dominus actionis*) e o adquirente, actuando o banqueiro externamente numa relação que o liga ao comprador, a quem empresta dinheiro para proceder ao pagamento. PAULO refere, a propósito o seguinte:

D. 44,4,5,4: “Se um escravo foi vendido por aquele a quem o dono permitiu e tiver sido devolvido ao dono, ao vendedor, que reclama o preço, se lhe opõe a excepção da redibição, mesmo que quem vendeu tenha entregado o preço ao dono...”⁹⁴.

Este fragmento tem suscitado algumas dúvidas que alimentam a ideia de que o banqueiro era o vendedor. Todavia, a opinião dominante sustenta que quem vendeu é o o proprietário, embora por intermédio do leiloeiro; e que, se reclama o preço, o comprador pode opor-lhe a *exceptio* fundada num vício redibitório. Portanto, o banqueiro é estranho à relação de compra e venda e tão-só aparece, se emprestar dinheiro ao comprador, criando-se, então, uma relação de crédito entre o banqueiro credor e o comprador devedor⁹⁵.

4.5. Concessão de crédito

Outra das actividades bancárias muito importantes é a concessão de crédito que um banqueiro faz a um cliente.

Trata-se dum contrato consensual, por efeito do qual o *argentarius* se obriga a fazer pagamentos por conta do seu cliente até determinado valor, obrigando-se este a devolver o dinheiro que haja disposto⁹⁶.

91 Cf. CÍCERO, *De leg. Agr.*, 1,7.

92 Vide PETRUCCI, *o.c.* 36-43; e RODRÍGUEZ, *o.c.* 1753, que fala, citando CÍCERO, de 2% do preço.

93 Vidde GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 117-118.

94 D. 44,4,5,4: “Si servus venit ab eo, cui hoc dominus permisit, et redhibitus sit domino, agenti venditori de pretio exceptio opponitur redhibitionis, licet iam is, qui vendidit, domino pretium solverit...”.

95 Vide PETRUCCI, *o.c.* 28 e 56.

96 Seguimos RODRÍGUEZ, *o.c.* 1560-1561.

Através desta actividade bancária, o banqueiro ganha juros relativamente ao crédito efectivamente utilizado pelo cliente e este pode fazer pagamentos sem que, no momento, disponha do dinheiro necessário. Entretanto, enquanto não movimentar o crédito, não paga juros.

À importância referida, acresce que a concessão de crédito permitia ao cliente bancário viajar sem o risco de, transportando dinheiro, ser assaltado e roubado, risco que, na Antiguidade, era muito frequente: atente-se na dificuldade dos caminhos, na lentidão dos transportes, na existência de malfeitores e de bandoleiros em locais inóspitos, etc. E que se evitavam quando o banqueiro dava uma ordem a uma sucursal distante para aí pôr o dinheiro à disposição do cliente até certo montante⁹⁷.

LABEÃO aborda, genericamente a concessão de crédito, falando de abertura de conta nos seguintes termos:

D. 2,13,6,3: “Mas diz Labeão que a conta é uma negociação do que por uma e outra parte se deve dar, receber, prestar ou obrigar por causa do pagamento do que é seu; e que nenhuma conta começa só com o nu pagamento do devido, nem a ninguém se deve compelir a manifestar se recebeu penhor ou mandato; porque este caso cai fora da conta. Mas o banqueiro deve exhibir também o que estabeleceu que seja pago, porque também isto provém do seu ofício”⁹⁸.

Como observamos, o jurisconsulto refere que concessão de crédito passa pela abertura duma conta que permite dar, receber, prestar ou obrigar e, deste modo, permitir ao cliente pagar o que deve. E a abertura do crédito antecede o pagamento duma dívida, necessariamente posterior.

Na concessão de crédito bancário destacam-se duas formas: a assunção de dívida dum cliente; e o crédito para a realização de negócios. Aqui se insere o crédito ao consumo que foi muito frequente em Roma⁹⁹.

Tratando-se de assunção de dívida, o *argentarius* torna-se devedor, substituindo o seu cliente. Do ponto de vista do banqueiro, estamos perante a *assunção de dívida*, enquanto, olhando para o cliente, trata-se de *delegação passiva*¹⁰⁰.

Resultando, segundo parece, a concessão de crédito de um contrato consensual, não repugna pensar que a sua tutela tenha passado, no processo das fórmulas, por uma *actio in factum* depois identificada com a *actio de pecunia constituta*, embora também não se possa excluir o recurso a uma acção de restituição (*condictio*) a que parece apontar a fórmula *cum compensatione* reportada em GAIO¹⁰¹.

⁹⁷ Vide RODRÍGUEZ, o.c. 1561.

⁹⁸ D. 2,13,6,3: “Rationem esse Labeo ait, ultro citro dandi, accipiendi, credendi, obligandi, solvendi sui causa negotiationem; nec ullam rationem nuda duntaxat solutionem debiti incipere, nec sipignus acceperit aut mandatum, compellendum edere; hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi constituit, argentarius edere debet; nam et hoc es argentaria venit”.

⁹⁹ Vide RODRIGUEZ, o.c. 1563.

¹⁰⁰ Cf. D. 46,2,11pr.

¹⁰¹ Cf. GAIO 4,64. Vide PETRUCCI, o.c. 89.

4.6. Receptum argentarii

O *receptum argentarii* é o pacto em que um banqueiro se compromete, perante determinada pessoa a pagar uma dívida (existente ou futura) de um cliente seu¹⁰².

Contrariamente ao que sucede na abertura de crédito, o *argentarius* recebe previamente do cliente o dinheiro para depois pagar a dívida deste para com terceiro: daí o vocábulo *receptum* dado a este acordo. E pode consistir na entrega de dinheiro, na afectação de fundos depositados junto do banqueiro e, mesmo, numa entrega fictícia que se reduz, na verdade, a uma abertura de crédito¹⁰³.

Na época clássica, entre o banqueiro e o terceiro (credor do seu cliente) surgia uma obrigação independente da que ligava o banqueiro ao seu cliente e, por isso, o *argentarius* não podia subtrair-se ao seu compromisso, invocando a nulidade ou inexistência da dívida do cliente que prometeu pagar¹⁰⁴.

Todavia, numa *constitutio* do ano 531, Justiniano consagrou um regime diferente, permitindo ao *argentarius* invocar que a obrigação, que prometeu pagar, não é devida. Vejamos:

C. 4,18,2,1: “...para tudo seja suficiente, em virtude da nossa constituição, a acção de dinheiro constituído, mas de modo que a ela seja inerente que o constituto se faça por uma dívida (quando segundo a antiga acção receptícia se exigia, ainda que não se devesse alguma coisa), pois é bastante absurdo e contrário tanto aos nossos tempos como às leis justas permitir que pela acção receptícia se consigam as coisas não devidas...”¹⁰⁵.

Estamos perante mais uma alteração significativa do regime jurídico do *receptum argentarii*: antes, o banqueiro arriscava-se a pagar uma dívida inexistente sem poder opor-se à pretensão do credor; doravante, não, porque podia opor-lhe uma *exceptio*.

No entanto, Justiniano acabou por abolir esta figura, fundindo-a com o *constitutum debiti alieni*, por lhe parecer inútil, como observamos em:

I. 4,6,8: “O pretor também introduziu, em virtude da sua jurisdição, acções pessoais, por exemplo: a acção de pecunia constituta, a que se assemelha a acção receptitia; mas como por uma constituição nossa trasladamos para a acção de pecunia constituta todas as vantagens da acção receptitia, esta última, como inútil, fizemos que desaparecesse das nossas leis...”¹⁰⁶.

102 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 104; PETRUCCI, *o.c.* 59; e A. SANTOS JUSTO, *Direito privado romano --- II (direito das obrigações)*, cit. 147.

103 Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1568.

104 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 104; e PETRUCCI, *o.c.* 62.

105 C. 4,18,2,1: “...sed sit pecuniae constitutae actio per mostram constitutionem sibi in omnia sufficiens, ita tamen, ut hoc ei inhaereat, ut pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam receptitiam actionem exigebatur, et si quid non fuerat debitum), cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est, permittere per actionem receptitiam res indebitas consequi...”.

106 I. 4,6,8: “In personam quoque actiones ex sua iurisdictione propositas habet praetor. Veluti de pecunia constituta, cui similis videbatur receptitia: sed ex nostra constitutione, cum, et, si quis plenius habebat, hoc in pecuniam constitutam transfusum est, ea qui supervacua iussa est cum sua auctoritate a nostris legibus recedere...”

Numa breve apreciação, o *receptum argentarii*, figura exclusiva da actividade bancária, constituía uma garantia que o *argentarius* prestava a um credor do seu cliente de que determinado crédito seria pago. E, porque nos primeiros tempos implicava o risco de o banqueiro pagar uma dívida inexistente, é provável que Justiniano o tenha abolido, fundindo-a com a figura mais vasta do *constitutum debiti alieni*.

4.7. Constitutum debiti alieni

O *constitutum debiti alieni* é o acordo em que uma pessoa se compromete a satisfazer, em determinada data ou num certo lugar, uma dívida alheia, cujo objecto consiste numa soma de dinheiro¹⁰⁷. Para o tutelar, o pretor concedeu uma *actio in factum*, denominada *actio de pecunia constituta*¹⁰⁸. Esta acção teria carácter penal que os juristas romanos justificaram invocando a “*falta grave de confiança*”¹⁰⁹.

Não surpreende, portanto, que o comércio bancário tenha utilizado frequentemente este instrumento jurídico porque, assumindo a obrigação de satisfazer uma dívida, proporcionava ao *argentarius* uma fonte de rendimento¹¹⁰. E, simultaneamente, oferecia ao comércio jurídico a necessária garantia de que as dívidas seriam satisfeitas por entidades que reuniam maiores condições de solvência. Mais: a possibilidade de um *argentarius* assumir a obrigação de pagar a dívida de um cliente numa sucursal situada em lugar distante evitava que este, transportando somas consideráveis, corresse riscos enormes¹¹¹.

Trata-se duma figura jurídica que não foi exclusivamente utilizada por banqueiros, embora, como referimos, estes a tenham utilizado com muita frequência¹¹². E que tinha a particularidade de depender da existência ou validade da dívida que o autor do *constitutum* se obrigava a satisfazer, ou seja, gozava de acessoriedade. Assim escreveu ULPIANO:

D. 13,5,11pr.: “Assim, pois, somente será válido o constituto, se for devido aquilo por que se contrai o constitutum...”¹¹³.

D. 13,5,11,1: “Se alguém, devendo cem áureos, contrair constituto por duzentos, fica obrigado tão-só pelos cem, porque esta é a quantia devida; por conseguinte, também o que contraiu constituto pelo capital e juros que não se deviam, fica obrigado somente pelo capital”¹¹⁴.

107 Vide SANTOS JUSTO, *ibidem* 145-146; e RODRÍGUEZ, *o.c.* 1566.

108 Cf. D. 13,5,3,2.

109 Cf. D. 13,5,1pr.

110 Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1567.

111 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 105.

112 Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1567.

113 D. 13,5,11pr.: “Hactenus igitur constitutum valebit, si, quod constituitur, debitum sit...”.

114 D. 11,5,11,1: “Si quis centum aureos debens ducentos constituat, in centum tantummodo tenetur, quia ea pecunia debita est; ergo et is, qui sortem et usuras, quae non debebantur, constituit, tenebitur in sortem duntaxat”.

Portanto, o *constitutum debiti alieni* distinguia-se, na época clássica, do *receptum argentarii*. Haja em vista que, enquanto aquele era acessório da obrigação que o *constituans* se obrigava a pagar, este teve carácter abstracto até ao direito justinianeu¹¹⁵.

Por outro lado, a obrigação de pagar a dívida surge no momento da realização do *constitutum* e, por isso, não a afasta o eventual pedido do devedor da primeira obrigação para que não a satisfaça. E o compromisso não exige nenhuma formalidade, podendo ser feito ou não por *stipulatio*.

Mas há outra particularidade: não pode utilizar o *constitutum debiti alieni* quem se proponha pagar a dívida de um banqueiro¹¹⁶.

Como também referimos¹¹⁷, esta figura absorveu, no direito justinianeu, o *receptum argentarii* que, como se observa na *constitutio* do ano 531 de Justiniano, tinha caído em desuso:

C. 4,18,2pr.: “Desaparecida a acção receptícia, que composta de palavras solenes tinha caído em desuso, pareceu-nos necessário ampliar a natureza da de dinheiro constituído. Porque como a referida acção, isto é, de dinheiro constituído, foi limitada pelos antigos só a casos em que se exigissem coisas que constam de peso, número ou medida, mas sem que tivesse nenhuma aplicação às demais coisas (...) determinamos nesta claríssima constituição que a todos seja lícito contrair constituto não só pelas coisas que constam de peso, número ou medida, mas também por todas as demais, ora móveis ora imóveis, ora semoventes ao por instrumentos ou por outras quaisquer coisas ...”¹¹⁸.

5. ORGANIZAÇÃO

5.1 Actividade individual

A actividade bancária era, em Roma, exercida individual ou colectivamente por banqueiros¹¹⁹.

Individualmente, o *argentarius* podia exercer a sua actividade directamente ou servindo-se de filhos, libertos e escravos¹²⁰. Enquanto o banqueiro devia ter personalidade e capacidade jurídicas¹²¹, já os filhos e escravos deviam dispor de capacidade negocial¹²². De fora

115 Cf. C. 4,18,2,1, que transcrevemos supra, nota 104. Vide também GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 104.

116 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 105.

117 Vide *supra*, n.º 4.6.

118 C. 4,8,12pr: “Recepticia actione cessante, quae solemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare. Cum igitur praefata actio, id est, pecuniae constitutae, in his tantummodo casibus a veteribus conclusa est, ut exigeret res, quae in ponderenumero-mensurave sunt, in aliis autem rebus nullam haberet communionem (...) hac apertissima lege definimus, ut liceat omnibus constituere non solum res, quae pondere numero mensurave sunt, sed etiam alias omnes, sive mobiles, sive immobiles, sive sese moventes, sive instrumenta vel alias quascunque res...”

119 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 33.

120 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 29-31, 33 e 46; e PETRUCCI, *o.c.* 96⁵⁰ e 103-104.

121 Vide A. SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – I. Parte geral (Introdução. Relação jurídica. Defesa dos direitos)*⁵ em *Studia Iuridica* 50 (Coimbra Editora / Coimbra, 2011) 109-110.

122 Vide SANTOS JUSTO, *ibidem* 117-118, 137-138 e 141-142.

ficaram as mulheres, mesmo que acompanhadas de tutor, enquanto a tutela não foi afastada¹²³. O seguinte fragmento de CALISTRATO é elucidativo:

D. 2,13,12: “As mulheres estão excluídas do ofício de banqueiro, porque esta actividade é de homens”¹²⁴.

Relativamente aos menores de vinte e cinco anos, é provável que também fossem proibidos do exercício desta actividade, mesmo servindo-se de tutores. Por isso, se um menor fosse herdeiro de um banqueiro, há quem entenda que o tutor devia limitar-se a liquidar a *mensa*¹²⁵.

Dispondo da necessária capacidade jurídica (de gozo e negocial), o cidadão romano *paterfamilias* podia, como já referimos, exercer a actividade bancária através de um filho, liberto ou escravo. Confirma esta situação o seguinte fragmento de ULPIANO que, a propósito da obrigação de exhibir as contas, recolhe a opinião de LABEÃO e de SABINO:

D. 2,13,4,2: “Mas também está compreendido o filho de família, de sorte que também ele seja obrigado a exhibir; mas, pergunta-se, e o pai ? Labeão escreve que não se deve obrigar o pai, excepto se, sabendo, (o filho) exercer o ofício de banqueiro; mas Sabino respondeu acertadamente que isto deve ser admitido quando ao pai corresponder o ganho”¹²⁶.

A exigência de conhecimento relativamente ao *paterfamilias* e a sua responsabilidade dependente do ganho obtido pelo filho, apontam para a existência de um *peculium* concedido por aquele a este, cuja administração beneficia o *pater* enquanto *dominus peculii*¹²⁷.

Tratando-se de escravo, a situação é semelhante porque, enquanto homem, o *servus* dispunha de inteligência para não ser desperdiçado pelo seu dono que o utilizava no exercício das mais diversas actividades negociais, inclusivamente a bancária. De novo ULPIANO é claro:

D. 2,13,4,3: “Mas se um escravo fizer de banqueiro – como pode --, se o tiver sido com autorização do seu dono, este deve ser compelido a exhibir (as contas) e contra ele deve dar-se a acção, exactamente como se o mesmo o tivesse sido; mas se o foi ignorando o seu dono, é bastante que este jure que não tem aquelas contas. Se o

123 Vide SANTOS JUSTO, *ibidem*, 143-144.

124 D. 2,13,12: “Feminae remotae videntur ab officio argentarii, cum ea opera virilis sit”. Também ULPIANO (D. 50,17,2pr.) refere que “as mulheres estão afastadas de todas as funções civis e públicas”. São tempos em que, observa GARCÍA GARRIDO, o.c. 58, “la actividade de la mujer quedaba reducida al ámbito doméstico de la familia y, sobre todo, al cuidado de los hijos. Se le prohibía salir garante por negocios ajenos e incluso del propio marido”. No entanto, como GARCÍA GARRIDO (o.c. 63-69) igualmente refere, não faltam referências à mulher como imprescindível colaboradora nos negócios do marido e mesmo a mulheres empresárias em fábricas de materiais de construção.

125 Neste sentido, vide RODRÍGUEZ, o.c. 1535.

126 D. 2,13,4,2: “Sed et filiusfamilias continetur his verbis, ul vel ipse cogatur edere; an et pater, quaeritur, Labeo scribit patrem non cogendum, nisi sciente eo argentaria exercetur; sed Sabinus respondit, tunc id admissendum, cum patri quaestum refert”.

127 Vide PETRUCCI, o.c. 118.

escravo fizer de banqueiro com o seu pecúlio, o seu dono está obrigado pela acção de pecúlio ou do que se converteu em seu proveito; mas se o dono tem as contas e não as apresenta, está obrigado solidariamente”¹²⁸.

Como vemos, depois de afirmar que o escravo pode exercer a função de banqueiro, ULPiano distingue se actuou com ou sem autorização do seu dono. Agindo autorizado, o *dominus* é obrigado a apresentar as contas aos clientes. E, havendo pecúlio, aquele responde pela *actio de peculio* ou pela *actio de in rem verso*¹²⁹.

Estamos perante as famosas *actiones adiecticiae qualitatis* cuja fórmula com transposição de sujeitos vencia as dificuldades da ausência duma verdadeira representação. Graças e este mecanismo, o dono (e o *paterfamilias*) respondia pelas dívidas contraídas pelo escravo (ou *filiusfamilias*), assim como podia demandar os seus devedores¹³⁰.

Merece também especial referência a *actio institoria* que responsabilizava o *paterfamilias* e o *dominus* por dívidas, respectivamente de filhos e de escravos, no âmbito da gestão de um estabelecimento terrestre, no nosso caso, duma banca (*mensa*). Nestes casos, o *paterfamilias* ou o *dominus* mandava afixar, à porta da *mensa*, um edital (*praepositio*), no qual publicitava a nomeação do *filius* ou do escravo como gestor (*institor*) e assumia as responsabilidades pela sua gestão no âmbito da actividade bancária¹³¹. ULPiano é claro:

D. 14,3,5,3: “Mas também se alguém teve um escravo à frente de uma banca, obrigar-se-á em nome dele”¹³².

Na mesma situação encontrar-se-ia o dono de banca que tivesse nomeado como gestor um liberto, situação que, aliás, parece ter sido muito frequente¹³³.

Há, no entanto, uma questão que pode suscitar algum incómodo. Tratando-se de escravo nomeado *institor*, de que modo responderá o seu *dominus* se aquele, não gozando de capacidade jurídica de gozo, só pode contrair obrigações naturais? Sendo a *actio institoria* uma acção translativa e, portanto, dispondo de uma *intentio in ius*, a *condemnatio* do dono do escravo (o *argentarius*) implicaria certamente a ficção *si liber esset* relativamente ao *servus*. Assim, fingindo-se livre, a obrigação contraída era civil e, por ela, podia o ser *argentarius* ser condenado¹³⁴.

128 D. 2,13,4,3: “Sed si servus argentariam faciat – potest enim – siquidem voluntate domini fecerit, compellendum dominum edere ac perinde in eum dandum esse iudicium, ac si ipse fecisset; sed si inscio domino fecit, satis esse dominum iurare, eas se rationes non habere. Si servus peculiarem faciat argentariam, dominus de peculio, vel de in rem verso tenetur; sed si dominus habet rationes, nec edit, in solidum tenetur”.

129 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 46-47.

130 Vide GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 46; e Julio Hernando LERA, *El contrato de sociedad. La casuística jurisprudencial clásica* (Dickinson / Madrid, 1992), 51. Sobre estas *actiones*, vide SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – I. Parte geral*, cit. 202-203.

131 Vide PETRUCCI, *o.c.* 96⁵⁰ e 160-161; GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 51; e ARANGIO-RUIZ, *o.c.* 88.

132 D. 14,3,5,3: “Sede t si in mensa habuit quis servum praepositum, nomine eius tenebitur”.

133 Cf. D. 14,3,19,1; -14.3.20. Vide PETRUCCI, *o.c.* 118; e GARCÍA GARRIDO, *o.c.* 41 e 51, para quem, nas províncias, pelo menos 3/4 eram libertos.

134 Vide SANTOS JUSTO, A situação jurídica dos escravos em Roma no BFD LIX (1983) 25⁴⁶ e A “fictio iuris” no direito romano (“actio ficticia”). Época clássica. I no suplemento ao BFD XXXII (1988) 402.

5.2. Sociedade bancária

5.2.1. Considerações preliminares: a *societas*

Em Roma, a sociedade (*societas*) é uma organização de duas ou mais pessoas (*socii*) que, por virtude de um contrato consensual, se obrigam reciprocamente a pôr em comum determinados bens ou trabalho com vista à obtenção de um fim patrimonial, repartindo os lucros e as perdas segundo a proporção acordada. Trata-se também dum contrato de boa fé que se inspira na *fraternitas* que influencia o seu regime jurídico¹³⁵.

A sociedade assim criada não é pessoa jurídica; por isso, não há relações jurídicas entre a *societas* e terceiros, mas tão-somente créditos e obrigações de cada sócio com o (terceiro) ou terceiros com quem negociou. Posteriormente, deve prestar contas aos outros¹³⁶.

Entretanto, os bens levados por cada sócio à sociedade tornam-se compropriedade de todos os sócios¹³⁷. E, dissolvida a sociedade, cada sócio pode demandar os outros com a *actio pro socio* –que é uma acção de prestação de contas– e, tratando-se da partilha dos bens comuns, com a *actio communi dividundo*¹³⁸.

Aquela acção dava lugar a um *iudicium bonae fidei* e o sócio condenado incorria na declaração de *infamia*. Todavia, a condenação não podia superar o limite determinado pelas possibilidades patrimoniais do condenado, ou seja, gozava do *beneficium competentiae*¹³⁹.

Circunstancialmente, podia ser também intentada a *actio furti* e a *actio legis Aquiliae* que se acumulavam com a *actio pro socio*¹⁴⁰.

Como referimos, este contrato não cria uma pessoa jurídica distinta dos sócios que agem individualmente e em nome próprio e só depois prestam contas entre si. PAULO não suscita dúvidas:

D. 17,2,67pr.: “Se um dos sócios tiver vendido uma coisa comum com o consentimento dos sócios, deve dividir-se o preço ...”¹⁴¹.

D. 17,2,74: “Se alguém tiver contraído sociedade, o que comprou torna-se dele mesmo, não comum; mas pela acção de sociedade é obrigado a fazer a coisa comum”¹⁴².

135 Vide SANTOS JUSTO, Direito privado romano – II (direito das obrigações), cit. 72-73.

136 Vide Mario TALAMANCA, *Società in generale (diritto romano)* em ED XLII (1990) 814, 820-821 e 827; ARANGIO-RUIZ, o.c. 78-79 e 84-87; Emilio BETTI, *Istituzioni di diritto romano II. Parte prima* (CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani / Pádua, 1962) 265; CANCELLI, o.c. 509; e TORRENT, o.c. 440-441. Vide também Emile De CHIARO, *Le contrat de société en droit privé romain sous la République e au temps des jurisconsultes classiques* (Recueil Rirey / Paris, 1928) 222¹, que aponta diversas teorias sobre a personalidade moral das sociedades.

137 Discute-se, ainda hoje, se a transformação da propriedade individual de um sócio em compropriedade dos sócios se realizava *ex lege* (fala-se de *transitus legalis*) ou através de negócios jurídicos idóneos previstos no *ius civile*. Vide CANCELLI, *Società (diritto romano)* em NNDI XVII (1970) 504; TALAMANCA, o.c. 824; e TORRENT, o.c. 440 e *Consideraciones sobre la societas omnium bonorum* em RISG XCIV (1963-1967) 205 ss.

138 Cf. D. 19,3,1; -17,2,65,13.

139 Vide Filippo CANCELLI, o.c. 515.

140 Cf. D. 17,2,45; -17,2,47pr.; -17,2,48; -17,2,49; -17,2,50. Vide CANCELLI, o.c. 514-515.

141 D. 17,2,64pr.: “Si unus ex sociis rem communem vendiderit consensu sociorum, pretium dividi debet...”.

142 D. 17,2,74: “Si quis societatem contraxerit, quod emit, ipsius fit, non commune; sed societatis iudicio, cogitur rem communicare”.

Há, no entanto, quem veja uma excepção na sociedade de publicanos (*societas publicanorum*)¹⁴³ e na sociedade constituída para a compra e venda de escravos (*societas venaliciaria*)¹⁴⁴.

Finalmente, porque os fins podem ser muito diferentes, os romanistas classificam as *societates* em vários tipos: a sociedade de todos os bens (*societas omnium bonorum*) e a *societas quaestus* que compreende a sociedade constituída para determinada espécie de operações (*societas alicuius negotiationis*) e a sociedade constituída para a realização de um negócio determinado ou para a construção ou reparação de certa coisa (*societas unius* (ou *alicuius*) *rei*)¹⁴⁵.

É óbvio que a sociedade bancária pertence à categoria das *societates alicuius negotiationis*¹⁴⁶. Por isso, dedicar-lhe-emos as páginas seguintes.

5.2.2. *Societas argentaria*

I. Introdução

A sociedade bancária (*societas argentaria*) é uma sociedade de banqueiros e, portanto, constituída para o exercício da actividade bancária. ULPiano fala-nos deste tipo de sociedade:

D. 17,2,52,5: “Sendo sócios dois banqueiros e um deles tinha adquirido, em separado, alguma coisa e obtido ganho, perguntava-se se o ganho devia ser comum. E o Imperador Severo respondeu por rescrito a Flávio Félix nestes termos: “Ainda que a sociedade tenha sido constituída especialmente para o câmbio de prata, todavia, o que cada um dos sócios adquiriu não por causa do câmbio de prata, é de direito definido que não pertence à comunhão””¹⁴⁷.

143 As *societates publicanorum*, já muito desenvolvidas no século II a.C., podem ser definidas como companhias de capitalistas empreiteiros de obras públicas e concessionários na cobrança de impostos. A sua configuração como pessoa jurídica é sustentada pela unanimidade dos romanistas. Vide ARANGIO-RUIZ, *o.c.* 27, 33 e 81 e *La società in diritto romano* (Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene / Nápoles, 1950) 158 e 160; CANCELLI, *o.c.* 497; e TORRENT, *o.c.* 439.

144 Vide TALAMANCA, *o.c.* 830-833; ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, cit. 80; PETRUCCI, *o.c.* 265; e TORRENT, *o.c.* 441.

145 Cf. D. 17,2,5pr. Vide TALAMANCA, *o.c.* 822; e Armando TORRENT, *Manual de derecho romano* (Mira Editores, S.A. / Zaragoza, 1991) 441. e SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – II* (direito das obrigações), cit. 75.

146 Vide BETTI, *o.c.* 263; TALAMANCA, *o.c.* 822; GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros* (“*societas argentaria*”) em *Studi in onore di Arnaldo Biscardi III* (Istituto Editoriale Cisalpino – La Goliardica / Milão, 1982) 377; e PETRUCCI, *o.c.* 263.

147 D. 17,2,52,5: “Cum duo erant argentarii socii, alter eorum aliquid separatim quaesierat, et lucri senserat, quaerebatur, an commune esse lucrum oporteret; et Imperator Severus Flavio Felici in haec verba rescripsit: “Etiamsi maxime argentariae societas inita est, quod quisque tamen socius non ex argentaria causa quaesiit, id ad communionem non pertinere, explorati iuris est”.

A opinião de ULPIANO é clara e juridicamente correcta: pela actividade de um sócio desenvolvida no âmbito da actividade societária, deve prestar contas aos demais sócios; não assim, se a sua actividade não corresponde ao exercício da banca.

II. Regime específico

1. Solidariedade activa e passiva

Mas, se a *societas argentaria* não passa duma *societas alicuius negotiationis*, importa ter presente que os sócios são solidários entre si e, por isso, os clientes tanto podem demandar o sócio com quem agiram, como os outros; e podem ser demandados por qualquer dos sócios. Ou seja, estamos perante a solidariedade activa e passiva que produz uma limitada relevância externa da relação social determinada pela necessidade de tutelar a confiança que une banqueiros e clientes¹⁴⁸.

A solidariedade passiva, que permite a um cliente demandar os sócios não intervenientes, terá sido introduzida por costume ou prática bancária. Mostram-na os seguintes textos de PAULO, que se complementam¹⁴⁹:

D. 2,14,24: “Mas se um fiador prometeu como em coisa própria, neste caso o fiador deve ser considerado como devedor solidário e o pacto feito com ele considera-se como feito com o outro devedor”¹⁵⁰.

D. 2,14,25: “O mesmo ocorre no caso dos devedores solidários ou dos banqueiros em sociedade”¹⁵¹.

Relativamente à solidariedade activa, observa-se no seguinte fragmento também de PAULO:

D. 2,14,27pr.: “Se um dos sócios banqueiros tiver pactuado com um devedor, prejudicará acaso também ao outro a excepção ? Nerácio, Atiliciano e Próculo dizem que nem ainda que se tivesse pactuado sobre uma coisa prejudica ao outro...”¹⁵².

148 Vide CANCELLI, *o.c.* 498 e 507; TALAMANCA, *o.c.* 830; PETRUCCI, *o.c.* 128, 130 e 133-135; GARCÍA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano*, cit. 54 e *La sociedad de los banqueros*, cit. 378-380; Del CHIARO, *o.c.* 232; e LERA, *o.c.* 54 e 146-147.

149 A romanística apoia-se, sobretudo, nestes textos. Vide TALAMANCA, *o.c.* 822 e 830¹⁷⁷; e GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros*, cit. 378-379, que refere ainda a posição de SAVIGNY: “Savigny afirmaba que, independientemente de la solidariad derivada da la stipulatio ou expensilatio, por el hecho mismo de la existência de la sociedad, cada uno de los banqueros asociados reponde del total de la deuda y podía demandar al deudor”.

150 D. 2,14,24: “Sed si fideiussor in rem suam spondit, hoc casu fideiussor pro reo accipiendus est, et pactum cum eo gactum cum reo factum esse videtur”.

151 D. 2,14,25: “Idem in duobus reis promittendi, et duobus argentariis sociis”.

152 D. 2,14,27pr.: “Argentariis sociis cum debitore pactus sit, an etiam alteri noceat exceptio ? Neratius, Atilicinus, Proculus, nec si in rem pactus sit, alteri nocere...”.

E, de uma e de outra, de novo PAULO se ocupa simultaneamente:

D. 4,8,34pr.: “Se, de dois credores ou devedores solidários, um só tivesse feito o compromisso e tivesse sido excluído que o credor reclame judicialmente o que reclama ao devedor, deve ver-se se não incorrerá na pena no caso de reclamar o outro credor ou de que se reclame do outro devedor. O mesmo, relativamente a dois banqueiros associados. E quiçá poderíamos acrescentar isto mesmo para os fiadores quando são sócios. Fora destes casos (de solidariedade, não se pode dizer que) se reclama de ti (quando) eu reclamo (do outro), nem que se reclama em meu nome quando (o outro) reclama de ti”¹⁵³.

A responsabilidade individual de cada sócio perante o cliente com quem realizou um negócio bancário exclui que a *societas argentaria* seja uma pessoa jurídica, mas a solidariedade activa e passiva dos sócios, determinada pelo interesse público reconhecido à actividade bancária, leva os romanistas, na sequência de CUIÁCIO, a falar de um regime específico, quiçá dum *ius singulare*¹⁵⁴.

2. Falência. Privilégio dos depositantes

O interesse público reconhecido à actividade bancária faz-se sentir também nos privilégios de que gozam alguns depositantes no caso de falência da banca. Destacamos os seguintes fragmentos de ULPIANO:

D. 16,3,7,2 (ULPIANO): “Sempre que os banqueiros se apresentem em falência, é costume, em primeiro lugar, ter em conta os depositários, ou seja, aqueles que tiveram quantias depositadas, não as que empregavam com juros em poder dos banqueiros ou com os banqueiros ou por si mesmos; e assim, pois, se os bens tiverem sido vendidos, antes dos privilégios têm-se em conta os depositários, com tal que não se tenham em conta os que depois receberão juros, como se tivessem renunciado ao depósito”¹⁵⁵.

D. 16,3,8 (PAPINIANO): “Cujo privilégio se exercita não só em relação àquela quantia que do dinheiro depositado se encontrou nos bens do banqueiro, mas relativamente a todos os bens do defraudador; e isto se admite por utilidade pública por causa do uso necessário dos banqueiros...”¹⁵⁶.

153 D. 4,8,34pr.: “Si duo rei sunt aut credendi, aut debendi, et unus compromiserit, isque vetitus sit petere, aut ne ab eo petatur, videndum est, an, si alius petat, vela b alio petatur, poena committatur. Idem in duobus argentariis, quorum nomina simul eunt. Et fortasse poterimus ita fideiussoribus coniungere, si socii sunt; alias nec a te petitur, nec ego peto, nec meo nomine petitur, licet a te petatur”.

154 Vide GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueiros*, cit. 374-375, que, neste sentido (de um *ius singulare*), refere a posição de CUIÁCIO.

155 D. 16,3,7,2: “Quoties foro cedunt numularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum, hoc est eorum, qui depositas pecunias habuerunt, non quas fœnore apud numularios, vel cum numulariis, vel per ipsos exercebant; et ante privilegia igitur, si bona venerint, depositariorum ratio habetur, dummodo eorum, qui vel postea usuras acceperunt, ratio non habeatur, quasi renuntiaverint deposito”.

156 D. 16,3,8: “Quod privilegium exercetur non in ea tantum quantitate, quae in bonis argentarii ex pecunia deposita reperta est, sed in omnibus frausatoris facultatibus; idque propter necessarium usum argentariorum ex utilitate publica receptum est...”.

No primeiro fragmento, os depositantes gozam de preferência, mesmo perante os credores privilegiados. Mas somente os depositantes cujos depósitos não vencem juros (depósitos improdutivos). E, no segundo, o privilégio dos depositantes (sem juros) executa-se não só sobre o dinheiro depositado, mas também sobre todos os bens do banqueiro em cuja falência haja fraude¹⁵⁷. É curiosa a protecção dos depositários cujos depósitos não vencem juros. ULPIANO justifica “*como se tivessem renunciado ao depósito*”¹⁵⁸ ou seja, deixaram de ser depositários para, quiçá, se tornarem mutuários e, nesta condição, não ser justo que sofram o risco da insolvência.

Há, no entanto, um fragmento de ULPIANO que coloca a preferência do depositante (sem juros) depois dos credores privilegiados. Vejamos:

D. 42,5,24,2: “Determinou-se que, na venda de bens de um banqueiro, seja preferente, depois dos privilégios, a condição de quem, atendendo à fé pública, depositou dinheiro no banco. Mas se separam dos demais credores os que receberam dos banqueiros juros pelo dinheiro depositado. E com razão, porque uma coisa é dar a crédito, e outra depositar. Mas se existisse dinheiro, opino que pode ser reivindicado por quem o depositou, e quem o reivindica será preferente aos privilegiados”¹⁵⁹.

Este texto permite algumas conclusões: 1^a.- os depositantes com juros não gozem de nenhum privilégio, no concurso com os demais credores; 2^a.- os depositantes sem juros gozam de preferência, porque mais do que de depósitos, trata-se de mútuos; 3^a.- se o dinheiro depositado ainda está em poder do *argentarius*, o depositante pode reivindicá-lo. Este direito só se entende se esse dinheiro consistir em moedas guardadas em saquinhas (ou outra embalagem), cujos depósitos são regulares; e sendo perfeitamente identificadas, o depositante, que é proprietário, pode reivindicá-las.

Relativamente à primeira parte que diz “*seja (o depositante) preferente depois dos privilégios*”, tem-se observado uma antinomia com o texto primeiramente transcrito (D. 16,3,7,2) que põe os depositantes (sem juros) à frente dos credores privilegiados. Segundo GARCÍA GARRIDO, “*la contradicción nos parece mas aparente que real*”, porque, relativamente ao depósito sem juros – a respeito do qual a contradição se observa –, se “*el banquero ha invertido las sumas depositadas, todo su patrimonio responde primero ante los acreedores privilegiados y después ante los depositantes que tienen preferència sobre los demás acreedores*”¹⁶⁰.

Duvidamos desta opinião porque, tratando-se de depósito irregular, não se vê como o dinheiro depositado (sem juros) possa permanecer isolado dos restantes valores pecuniários sem entrar no activo do *argentarius*. E, tendo entrado, o primeiro texto é claro,

157 Vide GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros*, cit. 380-381.

158 Neste sentido, cf. D. 42,5,24,2, que distingue: “*uma coisa é dar a crédito, outra depositar*”.

159 D. 42,5,24,2: “*In bonis mensularii vendundis post privilegia potiorum eorum causam esse placuit, qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. Sed enim qui depositis numis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non separantur; et merito, aliud est enim credere, aliud deponere. Si tamen numi extent, vindicari eso posse puto a depositariis, et futurum eum, qui vindicat, ante privilegia*”.

160 Transcrevemos GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros*, cit. 382.

dando preferência ao depositante. Parece-nos, assim, que subjacente a esta contradição existe uma deficiente alteração do segundo fragmento própria da época de vulgarismo.

3. *Hipoteca. Compra e venda*

Não se ignora que a hipoteca é uma garantia real que, em Roma, consistia na especial afectação de uma coisa móvel ou imóvel ao cumprimento duma obrigação. E, porque se trata duma especial afectação, sobre a mesma coisa podiam constituir-se várias hipotecas para garantir outras obrigações do mesmo ou diferentes credores. Por outro lado, a hipoteca podia ser especial (sobre *res* singulares) e geral (sobre o património do garante).

Sabemos também que as relações entre vários credores, cujas hipotecas incidissem sobre a mesma ou mesmas coisas, obedeciam a princípios jurídicos bem determinados, como a regra *prior in tempore potior in iure* e a regra *possidentis meliores esse conditionem*"; havia hipotecas privilegiadas que, embora posteriores, eram consideradas em primeiro lugar¹⁶¹; e, sendo o banqueiro credor, assumia natural importância a garantia hipotecária dos seus créditos.

Todavia, os banqueiros queriam mais: tornar-se proprietários das coisas adquiridas pelos clientes com o dinheiro que lhes tinham mutuado “*como se tais bens tivessem sido adquiridos por eles*” e, portanto, sendo proprietários, evitavam o concurso com os demais credores dos clientes¹⁶².

Como observou DÍAZ-BAUTISTA, “la argumentación de los banqueiros responde a la tendencia del vulgarismo postclásico que enfoca los problemas desde la perspectiva económica, sin importarle demasiado el respecto por las categorías jurídicas”.

E, na verdade, o afastamento dos princípios jurídicos é flagrante: é o comprador, e não quem lhe mutuou o dinheiro, que se torna proprietário depois de o vendedor cumprir a obrigação assumida no contrato de compra e venda¹⁶³. O banco que tenha mutuado a *pecunia* paga a título de preço não passa de simples credor, embora possa beneficiar de garantia real (v.g., penhor ou hipoteca) se devidamente constituída.

Havia hipotecas constituídas a favor de mutuantes sobre bens adquiridos com dinheiro mutuado, como vemos nos seguintes textos:

C. 8,17(18),7: “Ainda que tenham sido dados os mesmos penhores em diversos tempos, sejam considerados preferentes os primeiros; todavia, declara-se, por autoridade do direito, que se anteponham a todos aquele (credor) com cujo dinheiro se prova que se comprou o prédio, que desde logo se acordou que o tivesse especialmente em penhor”¹⁶⁴.

161 Vide SANTOS JUSTO, Direito privado romano – II (direito das obrigações), cit. 174-177.

162 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit. 60-62 e 76-79.

163 Sobre este contrato e seus efeitos, vide SANTOS JUSTO, *ibidem*, 49-63.

164 C. 8,17(18),7: “Licet iisdem pignoribus multis creditoribus diversis temporibus datis, priores habeantur potiores, tamen eum, cujus pecunia praedium comparatum probatus, quod ei pignori esse specialiter statim convenit, omnibus anteferri, iuris auctoritatē declaratur”.

N. 97,3: “ ... Sabemos que algumas hipotecas que são mais recentes se antepõem ainda a credores mais antigos por virtude de privilégios dados por leis, como sucede no caso em que alguém tenha facilitado que, com o seu próprio dinheiro, se compre, construa ou repare um navio, ou quiçá, edifique uma casa ...”¹⁶⁵.

Todavia, a hipoteca mesmo privilegiada pressupõe que os bens, adquiridos com o dinheiro dos credores, não deixavam de se tornar propriedade dos mutuários e não dos mutuantes.

No entanto, os banqueiros não queriam estas garantias reais (penhor ou hipoteca), mas, sim, tornar-se proprietários de bens que não adquiriam. Segundo DÍAZ-BAUTISTA, na base do desvio aos princípios romanos, está a influência do direito grego, segundo o qual, observa, “*no se transmitía al prestatario la propiedad de lo prestado*”¹⁶⁶; a compra e venda considerava-se perfeita “*quando se pagaba el precio o se llenaba la forma escrita*”¹⁶⁷; e o preço era entregue pelo cliente mutuário, mas com dinheiro do banco.

E, dando um passo mais, Justiniano promulgou, no ano 531, uma *novela* que transcrevemos no essencial:

N. 136,3: “E certamente não parece que disseram sem razão que se a alguém prestassem ou antes tivessem prestado dinheiro para comprar alguns bens móveis ou imóveis e lhe tivessem dado quantia certa e com o dinheiro prestado tiver sido adquirida a coisa, deveriam ter contra todos os direitos preferentes sobre a mesma coisa e não sofrer prejuízo algum, mas que se certamente probarem que a coisa foi comprada com dinheiro deles e que os devedores não podiam satisfazer-lhes o dinheiro, se lhes adjudicaria a mesma coisa comprada com o dinheiro deles, como se na realidade a coisa tivesse sido comprada por eles (...) Porque não é justo que os que gastam dinheiro seu não tenham também primeiro e indubitável lugar em relação às coisas compradas se nos contratos escritos se tiver feito menção da hipoteca. Mas se tiverem observado isto, conseguirão tudo o que nos rogaram e ainda mais do que nos pediram, posto que lhes damos direitos preferentes a todos sobre as coisas que se prove foram compradas com dinheiro deles...”¹⁶⁸.

Os banqueiros queriam ter a primeira preferência sobre os bens comprados com dinheiro que mutuassem e, se fossem titulares de hipotecas, nem sempre ocupariam o primeiro

¹⁶⁵ N. 97,3: “... Novimus et antiquioribus creditoribus aliquas hypothecas praeponi iuniores existentes ex privilegiis a legibus datis, quale est, quando aliquis propriis pecuniis procuraverit navem comparare, aut fabricare, aut reparare, aut domum forsam aedificare...”.

¹⁶⁶ Transcrevemos DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem*, 66-67.

¹⁶⁷ Voltamos a transcrever DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem*, 86.

¹⁶⁸ N. 136,3: “Atque illud profecto non alienum a ratione dicere visi sunt, si cuidam ad res quasdam mobiles vel immobiles emendas pecuniam credant vel antea crediderint, et certam pecuniam dederint, et ex nummis creditis res acquisita sit, omnium se in ipsa re precipua habere iura neque debere ullum pati damnum, sed si plena probent, pecuniis suis rem comparatam esse, neque illis debeatores pecunia satisfacere possint, ipsa res pecunia eorum empta eis addicatur, quasi revera ab illis empta (...) Neque enim iustum est, eos, qui sua expendant, non etiam primum et indubitatum locum in rebus emptis habere, si modo in scriptis contractibus hypothecae mentio facta fuerit. Nam si hoc observaverint, omne id consequentur, quod nos rogarunt, immo vero plus quam petierunt, siquidem potiora ipsis iura prae omnibus damus in iis rebus, quae ex eorum pecunia empta probantur...”.

lugar. Basta pensar no fisco, credor privilegiado acima de qualquer hipoteca¹⁶⁹. Justiniano concedeu-lhes a possibilidade de, provando esta aquisição com o seu dinheiro, adquirirem a coisa comprada e, assim, satisfazerem o seu crédito¹⁷⁰.

No entanto, a referência à coisa comprada com o dinheiro mutuado pelo banqueiro que ser-lhe-ia *adjudicada* implica que Justiniano não esqueceu o princípio romano de que as coisas são adquiridas pelos compradores e não pelos seus credores. Se o banqueiro se tornasse imediatamente proprietário não seria necessária a adjudicação.

De todo o modo, a adjudicação põe os banqueiros numa posição mais forte porque evitam o concurso com os demais credores. Junta-se a faculdade de demandarem os devedores dos seus devedores com as mesmas acções com que estes os podiam demandar; e a possibilidade de, sendo mutuantes, gozarem de hipoteca tácita sobre os bens adquiridos com o dinheiro mutuado, nos termos gerais¹⁷¹. Não se afasta, porém, a confusão que envolve o direito romano vulgar, como bem observou DÍAZ-BAUTISTA.

4. *Beneficium excussionis*

O *beneficium excussionis* funciona quando uma dívida é garantida por uma ou várias garantias (pessoais e ou reais). Justiniano determinou, no ano 535, que o credor deve, primeiro, demandar o devedor e, só depois, os garantes: havendo duas hipotecas (uma pessoal; a outra, real), deve promover a execução, sucessivamente, dos bens do devedor principal, da hipoteca especial e da hipoteca geral¹⁷². E havendo uma garantia pessoal (*fideussio*) e uma hipoteca, deve seguir esta ordem: primeiro, o devedor principal, depois o garante pessoal e, finalmente a hipoteca. Na primeira hipótese, temos o *beneficium realis*; na segunda, o *beneficium personalis*.

Perante a dívida de um cliente garantida por garantia pessoal ou real, os banqueiros queixavam-se de que o *beneficium excussionis* os obrigava a demandar primeiro o devedor principal e, por isso, pretendiam que este *beneficium* não lhes pudesse ser oposto¹⁷³.

De novo, Justiniano acedeu ao seu pedido e, pouco depois, no ano 541, promulgou uma nova *constitutio*, onde determina o seguinte:

N. 136,1: “Assim, pois, ordenamos que, se alguns dos que estão à frente dum estabelecimento bancário derem a alguém dinheiro em mútuo e receberem (...) ou fiadores, ou mandantes e se opuserem aos mesmos a constituição e a ordem por ela introduzida, tenha também lugar em relação a eles a constituição, se não tiverem feito pacto especial para que seja lícito aos credores dirigirem-se contra o devedor principal e contra o mandante e o fiador sem atender à ordem da constituição. Pois por razão do

169 Cf. D. 42,5,38,1; PS. V,12,10.

170 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem*, 101 e 104-105.

171 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *ibidem*, 106, 115 e 133, para quem o Imperador teria repelido esta hipoteca, mas posteriormente concedido “*por la presión de la corporación bancaria y por la grave crisis del año 542*”. Ainda segundo este Autor (*o.c.* 140), é provável que se trate de hipoteca geral.

172 Cf. N. 4.

173 Vide DÍAZ-BAUTISTA, *o.c.* 142-157.

cuidado dos banqueiros relativamente aos contratos comuns admitimos tais pactos, que não parece que sejam contra a lei, porque a cada qual é lícito prescindir do que pelas leis se lhe deu. Mas se se fizer tal pacto, seja-lhes lícito dirigirem-se assim contra o primeiro mandante, como contra o primeiro fiador e contra as demais pessoas, de sorte que se verdadeiramente no há pacto escrito, tenha lugar de todos os modos também em relação a eles a constituição, mas se se tiver escrito o pacto, seja por ele regido o contrato...”¹⁷⁴.

Justiniano não aboliu o *beneficium excussionis*, mas permitiu aos banqueiros que negociassem com os seus clientes o seu afastamento¹⁷⁵.

5. Contabilidade. Registos

A segurança dos clientes, a confiança que depositavam na banca e o interesse público por vezes reconhecido à *mensa romana* determinaram que os *argentarii* deviam ter a sua contabilidade e exibir e prestar contas.

Aliás, não se trata de prática estranha ao mundo romano: os *patresfamilias* costumavam anotar nos seus diários os movimentos pecuniários que faziam. São conhecidos os registos de caixa (*codeces*) estruturalmente constituídos por duas páginas (*accepti et expensi*), nas quais escreviam os valores que entravam e saíam. E se estas anotações tivessem o consentimento (expresso ou tácito) da outra parte, estaríamos perante contratos ditos literais¹⁷⁶.

Relativamente à actividade bancária, os *argentarii* deviam ter três livros: o livro diário, o livro de caixa e o livro de contas pessoais. No primeiro, anotavam-se os movimentos negociais, seguindo a ordem cronológica; no segundo, anotavam-se as entradas e saídas de dinheiro, nas páginas, respectivamente de *accepti* e de *expensi*; e, no terceiro (também dito livro de contas correntes), anotavam-se as diversas contas que cada banqueiro tinha com o seu cliente¹⁷⁷. Dispunham também de bloco de notas que até ao final do mês¹⁷⁸ deviam ser passadas para o livro de diário ou para o livro de caixa.

Depois, os *argentarii* deviam enviar periodicamente aos seus clientes um extracto das suas contas, nos quais os débitos se compensavam com os créditos¹⁷⁹.

174 N. 136,1: “Sancimus igitur, si quidam ex illis, qui mensae argentariae praesunt, alicui mutuum pecuniam dent, et vel (...) fideiussores, vel mandatores accipiant. Ipsis vero constitutivo et tordo per eam introductus opponatur, ut tum etiam in illis constitutivo obtineat, nisi pactum fecerint, licere creditori contra principalem debitorem et contra mandatorem et fideiussorem venire, non exspectato constitutionis ordine. Propter studium enim argentariorum circa communes contractus eiusmodi pacta admittimus, quae non videntur contra legem esse, quoniam unicuique ea, quae a legibus ipsi data sunt, contemnere licet. Sed si eiusmodi pactum fiat, liceat illis et contra primum mandatorem, et contra primum fideiussorem, et contra ceteras personas venire, ut si quidem pactum scriptum non est, etiam in illis constitutivo omnino obtineat, sine utem scriptum sit pactum, contractus rem regat...”.

175 Vide DÍAZ-BAUTISTA, o.c. 159-160, para quem “la Nov. 136 había cambiado la naturaleza imperativa del sistema de excusión previsto por la N. 4 al permitir en su cap. 1 el pacto previo en contrario”.

176 Vide SANTOS JUSTO, *Direito privado romano – II* (direito das obrigações), cit. 94.

177 Vide RODRÍGUEZ, o.c. 1544 e 1551-1553.

178 Segundo CÍCERO (Pro Roscio II, 6 e 7), as notas valem para um mês e os registos para sempre”. Vide RODRÍGUEZ, o.c. 1546.

179 Continuamos a seguir RODRÍGUEZ, o.c. 1552.

A relação de confiança dispensava a exigência de testemunhas, porque, se o *argentarius* se portasse mal, o seu negócio cairia¹⁸⁰. E a locução *sine scriptis*, que nas fontes¹⁸¹, surge referida a um contrato bancário, não exclui a existência de documentação privada redigida pelo banqueiro, cuja eficácia probatória, que remonta à época clássica¹⁸², foi reconhecida numa *constitutio* de Justiniano¹⁸³ e é constantemente reafirmada¹⁸⁴.

6. Obrigações

Do exercício da actividade bancária resultam diversas obrigações que oneram o *argentarius*. Destacamos as seguintes:

- a) a obrigação de confeccionar diligentemente as contas dos seus clientes. Esta obrigação concretiza-se no dever de celeridade, na exactidão das anotações, na redacção minuciosa sem interrupções nem vazios e na sua conservação¹⁸⁵;
- b) a obrigação de prestar contas aos clientes. Segundo um texto de ULPIANO, o pretor ordenava, no seu *edictum* que “os directores de bancos exibam a conta que lhes pertence, com expressão do dia e Cônsul”¹⁸⁶. E considera que “foi justo que se me exhiba o instrumento, de certo modo meu, que alguém confeccionou por minha causa”¹⁸⁷. É também significativo o seguinte fragmento de ULPIANO que refere o pensamento de LABEÃO:

D. 2,13,6,3: “Mas diz Labeão que a conta é uma negociação do que por uma e outra parte se tem de dar, receber, prestar e obrigar por causa de pagar o que deve; e nenhuma conta começa só pelo nu pagamento do devido, nem a ninguém se deve compelir a declarar se recebeu penhor ou mandato; porque isto cai fora da conta. Mas o banqueiro deve também exhibir o que estabeleceu que se pague, porque também isto provém do ofício de banqueiro”¹⁸⁸.

- b) a obrigação de exhibir o livro de contas (*codex rationum*) quando alguém necessita de intentar um litígio seja contra o próprio banqueiro seja contra outra pessoa¹⁸⁹. Na

180 Neste sentido, vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1539.

181 Cf. N. 136,3.

182 Cf. D. 2,13,10,3; -47,2,27,1.

183 Cf. C. 4,21,22,5.

184 Cf. N. 136. Vide PETRUCCI, *o.c.* 219-223; e DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit. 14, 16, 23 e 42.

185 Cf. CÍCERO, *Pro Roscio* II,7; D. 2,13,6,6; 2,13,10,2. Vide RODRÍGUEZ, *o.c.* 1546.

186 D. 2,13,4pr.: “Praetor ait: Argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edant adiecto die ex Consule”.

187 D. 2,13,4,1: “...aequum fuit, id quod mei causa confecit, meum quodammodo instrumentum mihi edi”

188 D. 2,13,6,3: “Rationem autem esse Labeo ait, ultro citro dandi, accipiendi, credendi, obligandi, solvendi sui causa negotiationem; nec ullam rationem nuda duntaxat solutione debiti incipere, nec, si pignus acceperit aut mandatum, compellendum edere; hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi constituit, argentarius edere debet; nam et hoc ex argentaria venit”.

189 Cf. D. 2,13,6,1; -2,13,10,pr.-1. Vide GARCÍA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas*, cit. 108; e PETRUCCI, *o.c.* 144 RODRÍGUEZ, *o.c.* 1546-1549.

sua base, invoca-se a *causa publica*¹⁹⁰, mas, para garantia do segredo bancário, esta obrigação só tem por objecto a parte referida às partidas do cliente em litígio¹⁹¹. O *argentarius* que recusasse dolosamente exibir o livro de contas incorria na obrigação de indemnizar o cliente pelos danos causados, estimados pelo juiz na sentença¹⁹². É provável que esta *actio* tenha sido *in factum concepta*¹⁹³. Esta obrigação transmitia-se aos herdeiros e sócios do *argentarius* e permanecia mesmo depois da cessação da actividade bancária¹⁹⁴;

- c) a obrigação de fazer a compensação dos débitos com os créditos dos clientes¹⁹⁵. Por isso, se demandasse um cliente incumpridor, a *petitio* devia limitar-se ao saldo, como esclarece GAIO:

4,64: “... o banqueiro unicamente pode litigar praticando previamente a devida compensação (...) de forma que a sua pretensão se circunscreverá ao saldo que lhe resulta favorável...”¹⁹⁶.

Em consequência dessa obrigação, se, após a compensação, o banqueiro pedisse mais, a *pluris petitio* implicaria a perda do litígio¹⁹⁷. Mas era também um direito, pelo que o *argentarius* podia opor a *exceptio pensatae pecuniae* se algum cliente o demandasse sem ter em conta a sua dívida¹⁹⁸.

7. Tutela

Durante o Império, a actividade bancária foi colocada sob a vigilância do *praefectus urbi*, como refere ULPIANO:

D. 1,12,1,9: “Ademais disto, o prefeito da cidade deverá cuidar de que os banqueiros se conduzam com probidade em todos os seus negócios e se abstenham do que está proibido”¹⁹⁹.

Entretanto, o Imperador Adriano atribuiu-lhe o poder de julgar as causas pecuniárias em que um banqueiro fosse parte quer como demandante quer como demandado²⁰⁰. Invocam-se,

190 Cf. D. 2,13,10,1.

191 Cf. D. 2,13,4,1. Vide GARCÍA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas*, cit. 35; e PETRUCCI, *o.c.* 146 e 150-151.

192 Cf. D. 2,13,8pr.1. Vide GARCÍA GARRIDO, *ibidem* 110; e RODRÍGUES, *o.c.* 1550.

193 Neste sentido, vide PETRUCCI, *o.c.* 143-144.

194 Cf. D. 2,13,6,1; -2,13,4,4.

195 Cf. GAIO 4,64.

196 GAIO 4,64: “... nam is cogitur compensatione agere (...) adeo quidem, ut statim ab initio compensatione facta minus intendat sibi dari oportere”.

197 Cf. GAIO 4,68. Vide PETRUCCI, *o.c.* 154-158.

198 Cf. D. 22,3,19,3.

199 D. 1,12,1,9: “Praeterea curare debet Praefectus Urbi, ut numularii probe se agant circa omne negotium suum, et temperent his, quae sunt prohibita”.

200 Cf. D. 1,12,2.

como razões justificativas da criação desta competência jurisdicional civil, a necessidade de conceder protecção aos novos negócios da prática bancária, sobretudo os depósitos irregulares produtores de juros que havia dificuldade em enquadrar nos esquemas existentes, ou seja, nas acções concedidas pelo pretor²⁰¹. Mas pesou também significativamente a dificuldade de gerir a banca e o elevado conhecimento daquele magistrado²⁰².

Todavia, a circunstância de a *iurisdictio* das questões bancárias ter sido confiada a um magistrado especial não implica o afastamento das acções e excepções da jurisdição comum que tutelavam os diversos negócios jurídicos realizados. Nem a criação de novos expedientes considerados necessários. É significativa a criação de uma *actio in factum* para o cliente demandar o *argentarius* que recusasse exibir o livro de contas.

António dos Santos Justo

RESUMO:

1. Como sucede com a história de qualquer instituição, também a história da banca em Roma suscita questões delicadas. No entanto, é possível determinar os seus antecedentes e a evolução em Roma que passou, fundamentalmente, por quatro fases: criação, afirmação, declínio e renascimento.

2. A terminologia é complexa e alimenta alguma confusão. Para simplificar, seleccionámos o vocábulo *argentarius*, com o qual identificamos o banqueiro que exercia a sua actividade individual quer por si mesmo quer através de algum filho, liberto ou escravo. Nesta hipótese, ganham especial interesse algumas *actiones adiecticiae qualitis*.

3. Os banqueiros também desenvolviam a sua actividade organizados em sociedades (*societates argentariae*) que não gozavam de personalidade jurídica. Todavia, tinham regime jurídico especial (há quem, como CUJÁCIO, fale de um verdadeiro *ius singulare*), marcado pela solidariedade activa e passiva dos sócios, pelos privilégios de depositantes sem juros na execução dos bens dos banqueiros falidos, pela faculdade de, por adjudicação, se tornarem proprietários dos bens adquiridos com dinheiro mutuado e pela faculdade de, pactuando com os clientes o afastamento do *beneficium excussionis*, poderem demandar imediatamente os garantes considerados com maior solvência.

4. As actividades bancárias eram numerosas e diversificadas. Destacamos o depósito de dinheiro, o mútuo, a intervenção em hastas públicas, a concessão de crédito, o *receptum argentarii*, e o *constitutum debiti alieni*. Observa-se grande proximidade à actividade que, nos nossos dias, os bancos exercem. Esta actualidade constitui uma nota que reforça o interesse pelo estudo da banca em Roma.

5. Refere-se igualmente a existência obrigatória de livros nos quais se registam as operações bancárias e constituem documentos probatórios. Os banqueiros eram obrigados a exibi-los nos litígios com os seus clientes ou de estes com terceiros, obrigação que se

201 Neste sentido, vide PETRUCCI, *o.c.* 20

202 Vide DÍAZ-BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina, cit. 8.

justificava no interesse público (*causa publica*) da sua actividade. Se o banqueiro recusasse dolosamente esta exibição, incorria na indemnização de danos causados ao cliente.

6. Além das obrigações referidas -- confecção diligente de contas dos clientes em livros adequados (*codices rationum*) e da sua exibição --, merecem ainda destaque a obrigação de prestar contas aos clientes e a obrigação de compensar os débitos com os créditos daqueles.

7. Os conhecimentos especiais que a actividade bancária exigia justificam que, no Império, tenha sido posta sob a vigilância do *praefectus urbi*. Mas não afastou o recurso às acções e excepções resultantes dos diversos negócios jurídicos realizados.

A PROIBIÇÃO DA USURA E A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

JOÃO LUIS NOGUEIRA MATIAS

Universidade Federal do Estado do Ceará

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em confirmação à regra de que em direito privado a técnica jurídica é decorrência das necessidades históricas, a sociedade em conta de participação foi criada na prática negocial medieval, com o fim de possibilitar o exercício da atividade comercial de forma anônima. Por motivos diversos, entre os quais a condenação social e a forte restrição à usura, o exercício da atividade comercial no medievo muita vez, preferencialmente, era realizada de forma anônima.

Apesar de não ter existido direito comercial em Roma, nos moldes em que consagrado na Idade Média, não se pode desprezar o impacto do direito Romano sobre o direito comercial, a partir da sua influência sobre diversos institutos. A regulação jurídica da usura, especialmente a sua proibição, foi importante para a conformação do direito hodierno, tendo sido determinante na criação da sociedade em conta de participação.

A presente comunicação versará sobre este tema.

De início, será caracterizado o direito comercial, em perspectiva que abrange a evolução histórica, a definição dos aspectos mais marcantes e a autonomia. Após, a velha questão da existência do direito comercial em Roma será analisada. Em seguida, será analisada a restrição à usura, na religião e no direito, como fundamento para a criação da sociedade em conta de participação. Por fim, serão identificadas as características definidoras da sociedade em conta de participação.

2. A REGULAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL: DA ATIVIDADE COMERCIAL AO DIREITO COMERCIAL

Pressuposto para a análise da existência do direito comercial em Roma e da influência do direito romano sobre a regulação da atividade comercial é a perfeita caracterização do direito comercial, o que se passa a fazer.

2.1. Caracterização do Direito Comercial

O direito comercial foi um regime jurídico criado pelos e para os comerciantes, ao longo da Idade Média. Esclareça-se que desde o invento da moeda, em razão de sua função de padrão único de troca, a atividade comercial já era exercida, sendo caracterizada pela intermediação do acesso a bens móveis. Contudo, apenas naquela fase histórica, em razão de suas condições sociais, políticas e econômicas, o aludido conjunto de normas se destacou do direito comum então em vigor, constituído por uma mescla do direito romano redescoberto, do direito canônico e de costumes locais.

O direito então vigente era extremamente formal, o que dificultava o exercício e a evolução da atividade mercantil. A ausência de um poder político central, com fronteiras bem definidas, assim como a divisão da sociedade em corporações de ofício, colaboraram para o fortalecimento da classe dos comerciantes e para o reconhecimento da validade e exigência das normas de regência da atividade comercial, inicialmente elaboradas pelos próprios comerciantes, com base nas práticas negociais.

Tratando-se de uma atividade muito lucrativa, o comércio ensejou a acumulação de capitais à classe dos comerciantes, os quais passaram a exercer influência na disputa pelo poder político por meio de fornecimentos de recursos e capitais, exigindo por contra partida a liberdade de auto-regulação da sua atividade.

Assim surgiu o direito comercial, como direito autônomo, direito distinto do direito comum, de base fundamentalmente consuetudinária, criado pelo comerciante no seio de sua corporação e aplicado, de forma exclusiva, à sua classe. Com a sua evolução, o direito comercial deixou de ter aplicação restrita, excepcional, e passou a ser a regra na regulação do exercício das atividades econômicas.

2.1.1. A evolução do direito comercial: a comercialização da economia

A partir do âmbito de aplicação, pode-se dividir o direito comercial em fases que expressem os diferentes momentos de sua evolução.

O direito comercial, em uma primeira fase, pode ser definido como o conjunto de princípios e normas que regem a atividade dos comerciantes. Destaca-se o caráter subjetivo do direito comercial nesta fase, em razão da definição do seu âmbito de aplicação a partir da caracterização do comerciante.

Configurava-se como um regime jurídico mais ágil e bem menos burocrático do que o decorrente do direito comum então em vigor, em que se destacavam novos institutos jurídicos, criados ou aperfeiçoados pelos comerciantes, tais como os títulos de crédito e a falência.

A aplicação restrita do direito comercial, como já destacado, aplicado inicialmente de forma exclusiva ao comerciante, limitava a utilização dos novos e úteis institutos. Era fato que havia bastante interesse de pessoas que desenvolviam atividades econômicas diferenciadas do comércio em utilizar os novos instrumentos na realização de negócios. A efetivação utilização dos mesmos por não comerciantes acarretou a superação da primeira fase do direito comercial.

Na segunda fase, o direito comercial pode ser conceituado como o conjunto de princípios e normas que regulam a atividade dos comerciantes e os atos de comércio. Tal formulação jurídica possibilita a explicação teórica da extensão do âmbito de aplicação do direito comercial, que passou a ser aplicado ao comerciante e aos que praticassem atos de comércio, independentemente de sua condição subjetiva.

O direito comercial previsto nas codificações do Século XIX era expressão desta fase. Assim era previsto no Código de Comércio de Napoleão, o qual influenciou inúmeras outras codificações. No Brasil, em 1850 foram editados o Código Comercial e o Regulamento 737 (Código de Processo Comercial), sendo neste último definidos os atos de mercancia:

“Artigo 19. Considera-se mercancia:

§ 1º. A compra e venda ou torça de efeitos móveis ou semoventes, para os vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso;

§ 2º. As operações de câmbio, de banco e corretagem;

§ 3º. As empresas de fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos públicos;

§ 4º. Os seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo;

§ A armação e expedição de navios”

A segunda fase do direito comercial importou em considerável ampliação de seu alcance, passando as suas normas a serem aplicadas aos comerciantes e aos praticantes dos atos de comércio, independentemente de sua qualidade pessoal.

A partir da segunda década do Século XX, novos valores passaram a repercutir no direito, como reação aos excessos decorrentes do ideário liberal. As ideias de solidariedade social, depois de maturadas no plano religioso e político, assim como de igualdade material, influenciavam os novos regramentos jurídicos, suprimindo privilégios e exigindo o tratamento igualitário daqueles que se encontrassem nas mesmas situações.

Tais ideias haviam de repercutir no âmbito do direito comercial, como de fato repercutiram. Embora não mais existissem as abissais diferenças entre o direito comercial e o direito civil, regime do direito comum (a diferença central que se mantinha era a restrição ao comerciante da submissão à falência), em pleno Século XX não havia como sustentar que um regime jurídico qualificado, criado pelo e para o comerciante, em razão de condições históricas específicas, não fossem estendido àqueles que assumissem os mesmos riscos e dificuldades inerentes às atividades econômicas.

No Código Civil Italiano de 1942, o regime originalmente aplicado ao comerciante passou a ser aplicado à empresa. Inicia-se nova era no direito comercial, que passa a ser definido como o conjunto de princípios e normas que regulam a atividade da empresa. No direito nacional, com o advento do Código Civil de 2002, passou-se a ter no empresário (perfil subjetivo de empresa), cuja definição consta do artigo 966, do Código Civil, o núcleo central do exercício da atividade econômica e marco da aplicação do direito comercial.

Trata-se de nova ampliação do alcance do direito comercial. Alguns autores passaram a denominar o tradicional “direito comercial” como “direito da empresa”, a partir da definição dos novos parâmetros normativos.

O regime jurídico aplicado um dia ao comerciante, como exceção, passa a ser aplicado a todos os que se enquadrarem na noção de empresário. Sepultando qualquer dúvida sobre o tema, o Código Civil de 2002, em seu artigo 2037, dispõe que salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas pelo Código referentes a comerciantes ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis.

2.1.2. As características do direito comercial

São apontadas como características do direito comercial a onerosidade, a simplicidade de formas, a elasticidade e a internacionalidade.

A onerosidade decorre da busca do lucro. Esta é a grande motivação do exercício da atividade empresarial. A existência efetiva do lucro pode não ocorrer, mas a finalidade da atuação é sempre lucrativa.

As formas das relações empresariais tendem a ser simplificadas, com o objetivo de adaptarem-se à dinâmica da atividade empresarial. Não há a supressão das formas, muitas vezes essenciais ao reconhecimento dos efeitos jurídicos, o que há é a adaptação das mesmas aos fins do direito comercial e à dinâmica da atividade empresarial.

Como consequência da liberdade típica do direito privado, o direito comercial é aberto a novos institutos, estando em freqüente atualização, assimilando, por exemplo, novos modelos contratuais, o que caracteriza a sua elasticidade.

A internacionalidade decorre da situação de que o direito comercial disciplina aspectos econômicos que transcendem fronteiras específicas. Ao contrário do direito civil, que é expressão da evolução histórica e cultural de cada nação, o direito comercial resulta e evolui como decorrência da experiência dos operadores econômicos, sendo influenciado por influxos que não se vinculam a bases territoriais específicas.

2.1.3. A autonomia do direito comercial

Constituído a partir da Idade Média, o direito comercial atende ao fim específico de ensejar um regime jurídico mais adequado ao exercício da atividade comercial.

O direito comercial é ramo do direito privado, entendido este como o conjunto de regras que regula as relações entre particulares, no campo pessoal, familiar e patrimonial, assim como as relações entre particulares e o Estado, quando este atuar sem poderes de império. Ao lado do direito comercial, é ramo do direito privado o direito civil. Tal dicotomia se estabelece pelo fato de que o direito comercial, pelos fins a que se destina, é revestido de peculiaridades que definem a sua especialidade e autonomia.

A fundamentação da distinção é baseada na necessária divergência entre a regulação dos atos de conservação e uso de bens próprios e na regulação dos bens utilizados no processo produtivo.

A questão a autonomia deve ser apreciada sob o ponto de vista formal e material.

Diz-se que há a autonomia formal de um ramo do direito quando a sua regência decorre de diploma normativo específico, destacado da regulação do direito comum. No Brasil, com o advento do Código Civil de 2002, a autonomia formal do direito comercial restou comprometida, uma vez que toda a parte geral do Código Comercial de 1850 foi revogada, permanecendo em vigor apenas a sua parte intermediária, que regula o direito marítimo.

A autonomia material decorre de institutos e princípios específicos. A unificação da regência do direito privado pelo Código Civil de 2002 em nada alterou a autonomia material do direito comercial. É fato que o direito comercial se expandiu, passando a reger todos os que se enquadram na definição de empresário, prevista no artigo 966, do Código Civil, entretanto, tal ampliação não elimina a especificidade dos institutos e princípios do direito comercial. A falência e recuperação de empresas, por exemplo, são institutos típicos do regime jurídico empresarial. Embora possam ser apontadas vozes dissonantes sobre a autonomia do direito comercial, a doutrina majoritária é pelo seu reconhecimento.

3. AINDA A VELHA QUESTÃO: EXISTIU DIREITO COMERCIAL EM ROMA?

A questão sobre a existência do direito comercial em Roma já foi exaustivamente debatida em doutrina, inúmeros autores se dedicaram ao tema. É certo que não existiu direito comercial nos moldes em que consagrado a partir da Idade Média, como um conjunto de princípios e normas sistematicamente organizado.

O que pode justificar a inexistência? É o que se pretende explicar ao longo do presente capítulo.

Já no direito Grego, que exerceu forte influência no direito romano, a distinção entre o direito comercial e o direito civil era muito nítida. No direito grego eram previstos processos comerciais («*emporikáí díkai*») regidos por regras especiais, assim como também existiam regras específicas de direito marítimo, autônomas, de base costumeira ou legislativa.¹

Apesar da influência grega, a distinção não se materializou no direito romano.

Na visão de PARDESSUS² e MOREL³, a inexistência do direito comercial, identificado como conjunto de normas sistematizadas, com unidade e coerência própria, pode ser justificada pela sua inutilidade, ou não necessidade ao longo da civilização romana.

GOLDSCHMIDT⁴ também é adepto da mesma justificativa. Contudo, também reputa a inexistência de normas específicas para regular o direito comercial pela forte tendência à abstração e centralização dos romanos, o que teria por consequência a igualdade entre os homens, afastando regulações específicas.

ALEXANDRE DE CASTRO CORREIA⁵ é crítico da posição de GOLDSCHMIDT, destacando que o alegado espírito de abstração dos romanos não os impediu de consagrarem

1 REHME, Paul. *História universal del derecho mercantil*. Madrid, 1941.

2 PARDESSU, Jean Marie. *Lois Maritimes*. Paris, 1847.

3 MOREL, François. *Les Jurisdictions commerciales au moyen age - etude de droit comparé*. Paris, 1847.

4 GOLDSCHMIDT, L. *Storia universale Del diritto commerciale*, trad. It. di V. Pouchaine e A. Scialoja, Torino, 1913.

5 Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 65: 67-103, 1970.

muitas desigualdades entre as pessoas, tais como as existentes entre cidadãos e estrangeiros, libertos e ingênuos, pessoas “sui jûris” e “alieni jûris”, entre outras. Assim, a abstração e centralização dos romanos não seria impedimento ao reconhecimento da dicotomia entre direito civil e comercial.

O autor, entretanto, reconhece a desnecessidade da regulação específica do direito comercial em Roma, sustentando que eram previstas instituições de direito privado tendentes a satisfazer as necessidades interiores das transações comerciais.

HUVELIN é mais um autor a compartilhar a mesma compreensão sobre o tema, defendendo que as necessidades do tráfego comercial eram atendidas por institutos de direito privado, sugerindo que o direito romano albergava, de forma embrionária e incompleta, os caracteres desenvolvidos pelas legislações comerciais modernas.⁶

THALLER⁷ também aponta que a inexistência do direito comercial em Roma pode ser explicada pela desnecessidade de regulação específica, uma vez que a regência das atividades comerciais era realizada por institutos de direito civil que protegiam e contemplavam os interesses mercantis. Em tal contexto, assumia papel nuclear a administração oficial da justiça pelo pretor romano peregrino, que assegurava meios processuais de satisfação dos interesses mercantis.

CASTRO também assim conclui, ponderando, contudo, que se é verdade que não existiu direito comercial em Roma, especializado, é possível distinguir institutos de caráter mercantil, diferenciados dos do direito civil clássico.⁸

Assim, a mais lógica explicação para a inexistência do direito comercial em Roma é baseada na desnecessidade da regulação específica da atuação do comerciante durante o período romano.

É certo que o fenômeno econômico não explica, de forma isolada, o surgimento do direito comercial. Os componentes social e político são marcantes. A constituição de uma civilização burguesa e cidadina, assim como, a influência da burguesia no destino político foram vitais para o surgimento do direito comercial.

Em Roma faltavam tais componentes. O comércio era conexo à propriedade fundiária. Os comerciantes não eram influentes politicamente e eram excluídos social e politicamente, inclusive, excluídos da magistratura.⁹

Contudo, não se pode desprezar o impacto do direito Romano sobre o exercício das atividades econômicas e, especialmente, sobre o direito comercial, a partir da sua influência sobre diversos institutos. Muitos deles não foram decorrentes apenas do gênio criativo do legislador, mas foram moldados pela prática negocial, ao longo dos tempos, preservando diversos aspectos do engenho jurídico das regulações jurídicas pretéritas.

A regulação jurídica da usura, especialmente a sua proibição, foi importante para a conformação do direito hodierno, tendo sido determinante na criação de um dos formatos societários que ainda hoje são bastante utilizados, a sociedade em conta de participação.

6 HUVELIN, Paul. *Étude d'histoire du droit commercial romain*, Paris, 1929.

7 THALLER, E. De la place du commerce dans l'histoire générale”, *Annales de Droit Commercial*, 1892.

8 CASTRO, Alfonso. *Derecho mercantil y derecho romano*. Nuevas observaciones sobre um problema antiguo. *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 2001, p.796-818.

9 CF. GALGANO, Francesco. *Lex Mercatoria – storia del diritto commerciale*. Bologna, Il mulino, 1993.

4. DA RESTRIÇÃO À USURA NO DIREITO E NA IGREJA

A restrição à usura compõe o ambiente que tornava o exercício explícito da atividade comercial pouco atrativo e que levou à criação da sociedade em conta de participação. No medievo, a restrição à usura decorria tanto do direito romano como do direito canônico.

4.1. Restrição à usura no direito romano

Na Roma antiga a maior característica do contrato de mútuo era a sua gratuidade, ou seja, a obrigação de restituir exatamente aquilo que se recebera. Talvez tal característica tenha decorrido da conexão existente entre as noções de mútuo e de fungibilidade, prevista no direito romano. A propriedade das coisas, possíveis de serem aferidas por peso, número e medida, era transferida efetivamente ao mutuário, que deveria devolvê-las nas mesmas condições.¹⁰

Ainda no Código de Justiniano a conexão se fazia presente, como se percebe no Título 14, do Livro III, das Institutas, *Quibus Modis Re Contrahitur Obligatio*.

Apesar do contrato de mutuo ser gratuito, nada impedia que, por pacto adjeto, fosse instituída a cobrança de juros.¹¹

A taxa máxima para a usura permitida no Direito Romano variou ao longo dos tempos, tanto em razão das condições econômicas que cambiavam como em decorrência do incremento do comércio marítimo e do risco assumido por aqueles que o financiavam.

Na Lei das XII Tábuas era fixada restrição, na Tábua Terceira, que regulava os direitos de crédito:

“TÁBUA TERCEIRA

Dos direitos de crédito

Se o depositário, de má fé, praticar alguma falta com relação ao depósito, que seja condenado em dobro; 2. Se alguém colocar o seu dinheiro a juros superiores a um por cento ao ano, que seja condenado a devolver o quádruplo; 3. O estrangeiro jamais poderá adquirir bem algum por usucapião; 4. Aquele que confessar dívida perante o magistrado, ou for condenado, terá 30 dias; para pagar; 5. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, que seja agarrado e levado à presença do magistrado; 6. Se não pagar e ninguém se apresentar como fiador, que o devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés com cadeias com peso máximo de 15 libras; ou menos, se assim o quiser o credor; 7. O devedor preso viverá à sua custa, se quiser; se não quiser, o credor que o mantém preso dar-lhe-á por dia uma libra de pão ou mais, a seu critério; 8. Se não houver conciliação, que o devedor fique preso por 60 dias, durante os quais será conduzido em três dias de feira ao comitium, onde se proclamará, em altas vozes, o valor da dívida; 9. Se não muitos os credores, será permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o corpo do devedor em tantos

10 PINHEIRO, Ivan Nogueira. Juros e usura no direito brasileiro: uma reflexão sob a perspectiva tomista. Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

11 L. A. SCAVONE JÚNIOR. Juros no direito brasileiro. São Paulo, RT, 2003.

pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou menos; se os credores preferirem poderão vender o devedor a um estrangeiro, além do Tibre.”¹²

No Código de Justiniano, a previsão era de fixação dos juros entre 4% e 8 % ao ano, dependendo das características pessoais do mutuário e da sua efetiva condição de pagamento (1.4, t. 32 “de usuris” e t. 33 “de náutico fenore”).¹³

Com a queda de Roma, a aparente marcha de flexibilização das restrições aos contratos de mútuo sob juros foi interrompida, principalmente pela forte interferência da Igreja.

4.2. Da restrição à usura pela Igreja

Nas escrituras muitos autores fundamentam a impossibilidade de exigência de cobrança de juros no contrato de mútuo. Duas passagens são bastante referenciadas, a Parábola dos Talentos, em Mateus 25, 13-30 e Lucas 6, 32-35, em que se predica, baseado na caridade, o dever de emprestar mesmo a quem não se espera receber.¹⁴

A primeira, na verdade, é usada com frequência para justificar a cobrança de juros, uma vez que é feita reprimenda ao que recebe talentos e não os faz multiplicar, impossibilitando o lucro ao patrão. Contudo, a defesa do argumento da restrição a usura se dá pelo claro sentido metafórico da passagem, que explora as responsabilidades dos que são aquinhoados por Deus na construção de uma nova realidade social.

A argumentação mais consistente decorre da citação de Lucas. O mútuo deve ser sempre realizado como decorrência da caridade cristã, entretanto, a cobrança de juros não poderia ocorrer, por configurar injustiça.

O mesmo argumento, a preservação da justiça, é utilizado para explicar a expressa permissão da cobrança de juros no Deuteronômio, 23,19, que faculta aos judeus cobrar juros de estrangeiros. Seria uma forma de reparação da injustiça a que foram submetidos os judeus, por não poderem usufruir da terra prometida. Argumento que é fortalecido pela proibição de cobrança de juros dos próprios irmãos.

A partir das interpretações das escrituras, criou-se uma longa tradição de restrição à usura, o que se expandiu por todos os países cristãos. A lei humana fundada na vontade divina criava restrições à usura. Assim ocorreu nas Ordenações Afonsinas, editadas em 1446, no Livro II, Título XCVI. A mesma regra foi prevista nas Ordenações Manuelinas, editadas em 1521, no Livro II, Título XIV.

Nas ordenações Filipinas, editadas em 1603, a matéria é regulada de forma mais abrangente, no Livro IV, em diversos títulos, especialmente no LXVII, em que se proíbe a usura, cuja prática é sancionada com a perda do principal e dos juros, caso já recebidos, além da obrigação de pagamento de tudo em dobro para a Coroa e degredo de dois anos para a África.

12 CF. VIEIRA, J.L. (Ed.) Código de Hamurabi – Código de Manu – Lei das XII Tábuas – Código de Excerptos. Bauru, Edipro, 1984.

13 Codex, 1.4, t.32-33, in W. KROLL; P. KRUGER; T. MOMMSEN; R. SCHOLL (ed.). Corpus Iuris Civilis, Berlin, Weidmann, 1954.

14 PINHEIRO, Ivan Nogueira. Juros e usura no direito brasileiro: uma reflexão sob a perspectiva tomista. Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Já o Alvará de 14 de fevereiro de 1609, proibia entregar-se direito à risco aos oficiais e marinheiros dos navios da Índia. A restrição foi ampliada pelo Alvará de 23 de agosto de 1623, para alcançar todos os tipos de oficiais e navios.

Percebe-se que a proibição causou fortes dificuldades para a ampliação dos negócios da navegação, que demandava grande aporte de recursos. Foi neste contexto que o contrato de comenda se consolidou como alternativa de financiamento das atividades de navegação.

Em razão da grande importância da atividade de navegação, por meio do Alvará de 11 de maio de 1655, a regra da proibição da usura foi flexibilizada, com a permissão do financiamento das atividades de navegação por meio do contrato de mútuo a juros, atendidas certas condições. Pelo Alvará de 16 de janeiro de 1757, foi fixada a taxa máxima de juros em 5% ao ano.

5. DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

A origem remota da sociedade em conta de participação reside no contrato de comenda, resultado da prática negocial medieval italiana, sendo que, segundo GRANDI, o seu documento mais antigo é de fonte veneziana, datado de 976.¹⁵ Do aludido contrato, a princípio utilizado para o exercício da atividade comercial marítima, surgiram as sociedades em conta de participação e a sociedade em comandita simples.¹⁶

A fundamentação econômica para a criação da sociedade em conta de participação não suscita grandes debates doutrinários, como atesta LOPES: *‘As causas foram evidentemente a proibição da usura e o clima medieval que impedia a nobres e prelados o exercício do comércio.’*¹⁷

De fato a proibição à usura impedia o empréstimo de recursos a juros, fazendo com que os proprietários de bens procurassem empregar os seus capitais de forma dissimulada, por meio da sociedade em conta de participação.

No direito nacional, as sociedades em conta de participação foram instituídas por meio do Código Comercial de 1850, com nítida influência dos Códigos Comerciais Espanhol (1829) e Português (1833).

Atualmente, a regulação da sociedade em conta de participação é prevista no Código Civil de 2002.

A sociedade em conta de participação é sociedade empresária de pessoas, em que, salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. A sua não personalização é consequência da sua peculiar maneira de funcionar. É regida pelos artigos 991 a 996 do Código Civil. Subsidiariamente são aplicadas as regras das sociedades simples.

É aquela onde existem duas espécies de sócios, o ostensivo, em nome do qual são feitos os negócios, e o sócio oculto, que não aparece perante terceiros. É possível ter mais de um sócio ostensivo e oculto.

15 GRANDI, Salvatore Giovanni. *L'associazione in partecipazione*. Milano: Vallardi, 1939.

16 FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1960.

17 LOPES, Mauro Brandão. *A sociedade em conta de participação*. São Paulo: Saraiva, 1990, página 08.

A sociedade existe apenas entre os sócios e não possui personalidade jurídica, nome social, capital, sede ou estabelecimento, sendo todos os negócios operacionalizados pelo sócio, ou sócios, ostensivos, que os farão em seus nomes e por eles responderão pessoalmente perante terceiros.

Pode ser formada para realização de apenas um negócio ou para funcionamento perene.

É uma sociedade oculta, entretanto, não é instrumento de fraudes. É formato expressamente admitido por lei e sua constituição não depende das formalidades exigidas para as demais sociedades. A existência da sociedade pode ser provada por qualquer dos meios admitidos na Lei. Com o advento do Código Civil, faculta-se o arquivamento do contrato social na Junta Comercial. Caso assim ocorra, o contrato não será disponibilizado a terceiros. O contrato social opera efeitos apenas entre os sócios.

A responsabilidade dos sócios ostensivos para com terceiros é sempre ilimitada, já que realizam as operações sociais em seu próprio nome. Os sócios ocultos só se responsabilizam para com os sócios ostensivos, e não de forma ilimitada, mas apenas na forma do que previsto no contrato social. O sócio participante não pode participar das relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de com ele responder solidariamente nas operações em que intervier.

A contribuição dos sócios constitui patrimônio especial, devotado aos negócios sociais, com feitos apenas entre os sócios. A falência do sócio ostensivo implicará na dissolução da sociedade e liquidação da conta social, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Falindo o sócio participante, será aplicado o previsto nos efeitos da falência em relação aos contratos bilaterais do falido.

6. CONCLUSÕES

É certo que em Roma não existiu direito comercial, autônomo, independente do direito comum, considerado como conjunto sistematizado de normas jurídicas. Mas não existiu pela absoluta desnecessidade, já que as demandas dos comerciantes eram atendidas por institutos de direito privado.

No medievo vigia uma mescla de direito canônico, direito romano redescoberto e costume bárbaros, incapaz de servir de regulação à dinâmica econômica que se desenhava a partir da consolidação de um novo modo de vida, de uma civilização urbana e burguesa. Tais fatores levaram à constituição do direito comercial.

É este espírito inovador e contestador que enseja a criação da sociedade em conta de participação. Trata-se de forma peculiar de sociedade, despersonalizada e que não se apresenta a terceiros. A melhor compreensão do aludido formato pressupõe a análise de sua historicidade, das motivações que levaram à sua criação.

Moldada na prática comercial medieval, a partir do contrato de comenda, a sociedade em conta de participação atendeu ao interesse de todos aqueles que pretendiam aplicar os seus capitais sem o risco de serem acusados de praticantes da usura, sendo este o fundamento de sua criação.

Percebe-se, assim, a influência do direito romano e do direito canônico na evolução do direito comercial, algumas vezes pela recepção e outras, como na hipótese em análise, pela rejeição de institutos neles previstos.

7. BIBLIOGRAFIA

- CASTRO, Alfonso. Derecho mercantil y derecho romano. Nuevas observaciones sobre um problema antiguo. Revista de Derecho Privado, Madrid, 2001, p.796-818.
- Codex, 1.4, t.32-33, in W. KROLL; P. KRUGER; T. MOMMSEN; R. SCHOLL (ed.). Corpus Iuris Civilis, Berlin, Weidmann, 1954.
- CORREA, Alexandre Castro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 65: 67-103, 1970.
- GALGANO, Francesco. Lex Mercatoria – storia del diritto commerciale. Bologna, Il mulino, 1993.
- FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1960.
- GOLDSCHMIDT, L. Storia universale Del diritto commerciale, trad. It. di V. Pouchaine e A. Scialoja, Torino, 1913.
- GRANDI, Salvatore Giovanni. *L'associazione in partecipazione*. Milano: Vallardi, 1939.
- HUVELIN, Paul. Étude d'histoire Du droit commercial romain, Paris, 1929.
- LOPES, Mauro Brandão. A sociedade em conta de participação. São Paulo: Saraiva, 1990.
- L. A. SCAVONE JÚNIOR. Juros no direito brasileiro. São Paulo, RT, 2003.
- PARDESSUS, Jean Marie. Lois Maritimes. Paris, 1847.
- MOREL, François, Les Jurisdictions commerciales au moyen age, Paris, 1897.
- PINHEIRO, Ivan Nogueira. Juros e usura no direito brasileiro: uma reflexão sob a perspectiva tomista. Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
- REHME, Paul. História universal Del derecho mercantil. Madrid, 1941.
- THALER, E. De la place du commerce dans l'histoire générale”, Annales de Droit Commercial”, 1892.
- VIEIRA, J.L. (Ed.) Código de Hamurabi – Código de Manu – Lei das XII Tábuas – Código de Excertos. Bauru, Edipro, 1984.

LA INFLUENCIA DEL DERECHO ROMANO EN LA ACTIVIDAD MERCANTIL Y BANCARIA DEL NUEVO MUNDO

MIRTA BEATRIZ ÁLVAREZ

Universidad de Buenos Aires y Universidad de Flores

I. INTRODUCCIÓN

Como ha sostenido Fadda¹, no debemos creer que en Roma se había desarrollado un “Derecho Comercial”, sino que nos debemos contentar con indagar de qué manera el Derecho Romano había previsto en sus distintas etapas de desarrollo, y por la necesidad del comercio, normas que nos permiten comprender y enseñar la disciplina en la actualidad^{2,3}.

En el presente trabajo se analizarán algunos supuestos en los que se establecieron medidas de protección en la actividad mercantil y bancaria de Roma.

Tal es el caso de los deudores del mutuo a los que se les concedió la *exceptio non numeratae pecuniae*, para disminuir la prepotencia de los prestamistas. Por medio de este remedio procesal, se invertía la carga de la prueba, debiendo el mutuuario probar que se había realizado la *numeratio*.

Otro supuesto a analizar es el *receptum argentarii*, que permite que dos personas distintas y desconocidas entre sí, puedan celebrar contratos de compraventa, con la intermediación de un banquero.

Por último, nos referiremos a la situación de los banqueros en tiempos de Justiniano. Los banqueros atraviesan una importante crisis y Justiniano -para salvaguardar el crédito- dicta medidas que favorecen a los banqueros, medidas que son políticamente imprescindibles, pero discutibles desde la perspectiva jurídica⁴.

1 FADDA, C., *Istituti Commerciali del Diritto Romano*, Napoli, Jovine Editore 1987, pág. 5.

2 GARCIA GARRIDO, M., *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo Romano*, Madrid, Dykinson S.L. 2001: “Algún autor destaca una serie de paralelismos entre el sistema moderno y el romano, como serían el cruce entre conducción política y realizaciones bancarias, el planteamiento consumístico de los recursos, y el sustancial liberalismo del estado en relación con el crédito, debido a factores económicos, sociales y culturales en muchos aspectos análogos”.

3 CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Lezioni di Diritto Commerciale Romano*, Torino, Giappichelli, 2002 pág. 12 manifiestan que es preferible hablar, más que de un derecho comercial romano unitariamente entendido, de una historia de la disciplina romana del comercio.

4 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina: negocios bancarios en la legislación de Justiniano, Murcia, Editum, 1987, pág. 29 s.

En los tres supuestos analizados se hará referencia a la recepción que estas medidas han tenido o podrían tener en la situación actual de la República Argentina.

II. EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE⁵

Paulo en D. 12, 1, 30 establece: “Si el que hubiere de recibir dinero prestado prometió a su futuro acreedor, tiene en su poder no obligarse a él, no recibéndole”. Este fragmento, extraído del Libro V de los Comentarios a Plaucio, se encuentra en la Palingenesia sin alteraciones, bajo el número 1110 encabezando el tema de la Fiducia⁶.

Resulta claro que, quien ha prometido devolver un dinero que aún no recibió, puede no quedar obligado si decide no recibirlo. La situación que analizaremos en este acápite, es qué defensa tiene quien ha prometido devolver un dinero que aún no recibió, si es demandado por el prestamista requiriendo el pago.

Desde una constitución del emperador Caracalla⁷, se concedió una excepción –la *exceptio non numeratae pecuniae*⁸–, por medio de la cual el mutuario podía manifestar que no se le había hecho entrega del dinero por el cual se había realizado la estipulación, o le había sido entregado en menor cantidad, y con ello, se invertía la carga de la prueba, debiendo el mutuante acreditar que le había entregado la *numeratio*⁹. Esta excepción tenía

5 SALAZAR REVUELTA, M., *La gratuidad del mutuum en el Derecho Romano*, Jaen, Universidad de Jaen, 1999, pág. 53 nota 70, citando a Cruz, sostiene: “En la misma línea justifica (Cruz) la denominación de la *exceptio non numeratae pecuniae*, viendo su causa en el hecho de no haber sido contada la pecunia en la presencia de la persona a quien, mediante *traditio*, fue dada *credendi causa* y no en la *non datio pecuniae* (de ahí que no se llame *exceptio non datae pecuniae*). Más tarde, a partir de la Constitución Antoniniana y, sobre todo, desde que los *chyrographi*, como documentos caucionales, sustituyen a los *sygraphae* tanto los casos de *pecunia non numerata* como los de *pecunia non data*, bien no dada o bien entregada en cantidad menor a la que constaba en la *cautio* (*stipulatio* documentada), traen como consecuencia la *exceptio non numerate pacuniae* (C. 4, 30, 1; 4, 30, 2; 4, 30, 3; 4, 30, 7)”.

6 SALAZAR REVUELTA, *La gratuidad...* cit. pág. 97: “Entendido el mutuo primitivo como una relación entre *amici* vinculados por lazos de lealtad, fundados en la *fides* sacra, no podemos obviar su posible afinidad con una de las primeras manifestaciones de la *fides*: la fiducia...No hay que descartar, en consecuencia, un origen similar, dado que ambas instituciones (mutuo y fiducia) son *datationes fiduciae causa* que implican la devolución de la cosa (*reddere rem*) por parte de aquel a quien le ha sido confiada y, por ello, tienen el denominador común en la confianza o fidelidad ajena”. Podría ser la explicación a la ubicación del fragmento en la Palingenesia.

7 SACCOCCIO, A., *Mutuo reale, acordó di mutuo e promessa di muto in diritto romano*, en *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, Napoli, Jovene Editore, 2011, pág. 384: “Caracalla riconosce l’assoluzione al debitore che, convenuto dal creditore stipulante sulla base della *cautio* stipulatoria, abbia opposto quest’ultimo l’*exceptio doli* o *non numeratae pecuniae* senza che il creditore stesso sia stato in grado di provare la *numeratio*, che ancora una volta è riconosciuta come elemento decisivo per la nascita dell’*obligatio*.”

8 TORRENT, A. *Diccionario de Derecho Romano*, Madrid, Edisofer, 2005, pág. 337 afirma: “El origen de esta *exceptio* no está nada claro, aunque en todo caso está en relación con la causa y la forma de la *stipulatio*, sirviendo esta *exceptio* (literalmente “de suma no percibida”) para hacer valer la ausencia de *numeratio* (entrega efectiva del dinero prometido) en una operación de crédito documentada por escrito, e introduciendo a favor del demandado un particular régimen probatorio trasladando al acreedor la carga de probar la *numerario*”.

9 PUGLIESE, G., *Istituzioni di Diritto Romano*, Torino, Giappichelli, 1991, pág. 892: “Durante il periodo preclásico e classico l’astutezza della *stipulatio* si era attenuata per effetto, prima, dell’*exceptio doli*, poi in età tardo-classica, dell’*exceptio* e della *querela non numeratae pecuniae*, rimedi questi ultimi, grazie ai quali se lo stipulante (creditore) non provava di avere dato a mutuo la somma oggetto della *stipulatio* o non giustificava

un plazo para interponerse que fue cambiando con los emperadores (un año con Caracalla, C. 4, 30, 3, cinco años con Diocleciano, y dos años con Justiniano, C. 4, 30, 14, I. 3, 21). Transcurrido ese plazo, el mutuante podía reclamar la devolución de la *datio*, y la *estipulatio* alcanzaba un efecto absolutamente abstracto y sin posibilidad de ejercitar, ni siquiera, la *exceptio doli*.

El promitente, demandado por el estipulante, podía obligarlo a demostrar la causa de la *estipulatio*, es decir, la obligación subyacente que había servido como causa de la promesa –en principio– abstracta. Más adelante, el promitente podría adelantarse a la acción del estipulante y tomar la iniciativa, interponiendo la *querella non numeratae pecuniae*¹⁰. Tenía el mismo efecto que la *exceptio*, es decir que era el acreedor quien debía probar la entrega efectiva del dinero¹¹.

Lo que el deudor alegaba, era que la obligación había nacido *verbis* pero no *re* y con ello forzaba a que el estipulante probara la causa. Recordemos que en el derecho clásico, el promitente sólo contaba con la *exceptio doli*¹² en esos casos.^{13 14}

Se llegó a abusar tanto de esta *exceptio*, que en el derecho justiniano se observa una tendencia restrictiva hacia ella (Ed. 7, Cap. 2, 1). Esta tendencia es en parte debida a la petición formulada por los banqueros en la Novela 136, 5 pr. sobre la limitación de la utilización de este remedio procesal¹⁵. Por otra parte, en la Novela 18, 8, 9 se pena con el duplo, al que negara injustamente la *numeratio* y luego perdiera el juicio¹⁶.

comunque l'impegno assunto verso di lui dal promittente con un'altra idonea causa (CI 4,30,3, a.215, eod.,5 di Alessandro Severo), la *stipulatio* risultava inefficace e il promittente liberato. D'altra parte, le parti potevano indicare la causa (e spesso lo facevano) o nel formulario orale o nel documento probatorio."

10 TALAMANCA, M., *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, Giuffrè, 1990, pág. 567: "Al profilo della decadenza collegata la possibilità di una dichiarazione unilaterale, presentata nei termini, per contestare la avvenuta *numeratio* e conservare al debitore il beneficio dell'inversione dell'onere della prova. A questa possibilità si riferisce, in generale, la *querela non numeratae pecuniae*: si tratta di un'impugnativa unilaterale, muniziosamente regolata da Giustiniano, la quale prescinde dall'esercizio dell'azione da parte del creditore."

11 SALAZAR REVUELTA, M., *La gratuidad...*, cit., pág. 251: "...En primer lugar (Justiniano) limita la aplicación de la *querella non numeratae pecuniae* a dos años (C. 4, 30, 14 pr.), pasados los cuales –sin que se produjera impugnación alguna– el documento escrito adquiriría eficacia constitutiva, dando así un paso más hacia el reconocimiento del documento escrito de carácter abstracto".

12 SCHULZ, F., *Derecho Romano Clásico*, Barcelona, Bosch, 1960, pág. 460: "En tiempo de Gayo (*Inst.* 4,116), el demandado podía defenderse con la *exceptio doli*, pero había de probar haber sido hecha la estipulación *mutui causa* y no haber recibido el dinero".

13 DI PIETRO, A., *Derecho Privado Romano*, Buenos Aires, Depalma, 1996, pág. 222 en el mismo sentido sostiene que en tiempos de Gayo, el *promissor* (deudor) tenía la *exceptio doli mali*.

14 DIAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la banca...*, cit., pág. 44 s.

15 DIAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca...*, cit. pág. 108 s. y agrega en pág. 110 que Justiniano en un sentido retórico acaba interrogando quien sería tan descuidado que firmase o diese confesión por una cantidad que no recibió.

16 SCHULZ, *Derecho Romano Clásico*, cit. pág.460: "...pero los compiladores justinianos fundieron la *exceptio non numeratae pecuniae* con la *exceptio doli* de modo que en derecho justiniano el demandado una vez transcurridos dos años, no podía oponer ya la *exceptio doli*. Si el *stipulator* no lo demandaba dentro de este período de tiempo, el promitente podía, siempre en Derecho justiniano, demandar al *stipulator* dentro del plazo de dos años, para exigir de él la liberación (*condictio liberationis*)."

Esta excepción sería de utilidad para favorecer al mutuuario (la parte más débil del contrato) con la tendencia que se viene reafirmando en la actualidad, a considerar al mutuo como contrato consensual.

La consensualización de los contratos, ya había comenzado con el Código Civil Francés, y Vélez Sarsfield en el Código Civil Argentino, al tratar las clasificaciones de los contratos, se aparta del Código Francés, manteniendo la distinción romanista entre contratos reales y consensuales¹⁷.

El Proyecto de García Goyena, en cambio, siguió en el mismo sentido que el Derecho Francés. Así, en el artículo 978 se establece: “*Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; y desde entonces obligan, no solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley*”.

En la nota al citado artículo, García Goyena se remite a lo expuesto en las notas a los artículos 973 y 976, donde dice: “*Ahora todos los contratos son consensuales*”. En efecto, en la extensa nota al artículo 976 del Proyecto, se consigna: “*...Ahora todos los contratos son consensuales, en cuanto todos ellos obligan por el solo consentimiento, lo que no sucedía entre los Romanos respecto de los reales, pues sin la entrega de la cosa quedaban en la esfera de simples pactos o promesas.*” Y a continuación, García Goyena, sostiene: “*Pueden, no obstante llamarse reales en cuanto la obligación principal que nace de ellos, supone necesariamente la entrega de la cosa. En el depósito, por ejemplo, no puede el depositario quedar obligado a restituir la cosa si no la recibe; pero si prometió recibirla, queda obligado y podría ser compelido a ello...*”

El avance de la consensualidad sobre el realismo en los contratos es una tendencia generalizada en la legislación comparada¹⁸.

En el Proyecto de Unificación del Código Civil y el Código de Comercio de la Nación Argentina (2012) que cuenta con media sanción del Senado, se advierte este avance. Así, son contratos consensuales: el depósito (art. 1356), el préstamo bancario (art. 1408), el mutuo (art. 1525) y el comodato (art. 1533)¹⁹. No hay en este Proyecto exposición

17 Vide ALVAREZ, M, *Contratos: de las diferentes acepciones del término a la consensualidad como principio general*, Cuarta Jornada sobre orígenes Romanísticos de los principios generales del Derecho, Buenos Aires, Universidad de Flores, 2013, págs. 19-37.

18 GUZMAN BRITO, A., *La consensualización de los contratos reales*, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso N° 29, Valparaíso, julio 2007, cit.: “Nos formamos la impresión que el sacrificio de los contratos reales en el altar del consensualismo es un sacrificio a cierto mito. El consensualismo, como principio general, es algo más bien moderno. Los romanos, que inventaron los contratos consensuales, desconocidos en otros pueblos de la Antigüedad, y particularmente en el mundo helenístico, no pensaron en elevar el canon que los rige a la categoría de tal principio; lo propio hicieron los medievales. La generalización del consensualismo fue obra del derecho natural moderno”

19 GUZMAN BRITO, *La consensualización...* cit. sostiene: “Antes dijimos que la supresión de los contratos reales y su conversión en consensuales contiene dos conversiones: la del convenio causal no vinculante de aquellos en contrato, y la de su tradición o entrega perfeccionadoras en actos de cumplimiento del nuevo contrato. Ahora debemos agregar que también contiene una nueva conversión, la de la promesa unilateral misma de contrato real en contrato consensual substitutivo del real. Se produciría así una suerte de fusión de la promesa de cada uno de los contratos reales con el convenio causal de la tradición o entrega perfeccionadora de los mismos.

de motivos. Solamente la presentación del Proyecto que es muy sintética y no incluye mención alguna acerca de la posición tomada sobre el consensualismo de los contratos.

Dentro de las disposiciones del Proyecto de Unificación de Código Civil y Comercial citado, podemos mencionar lo dispuesto en el artículo 1526 que establece “el mutuante puede no entregar la cantidad prometida, si con posterioridad al contrato, un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución²⁰”. En la normativa citada se protege al mutuante quien puede negarse a entregar la suma prometida en mutuo, si considera que la situación económica del mutuario ha variado, lo que haría peligrar la devolución. Nada se establece en protección al mutuario, quien se encuentra obligado a la devolución desde que se perfeccionó el contrato por el mero consentimiento, vale decir, aún antes de la *datio*. Por este motivo, entendemos que un remedio procesal similar a la *exceptio non numeratae pecuniae* romana, podría proteger al deudor de un mutuo. Ante el reclamo del mutuante, para la devolución del mutuo, el mutuario podría alegar no haber recibido el dinero, quedando a cargo del mutuante la carga de demostrar la entrega.

III. EL RECEPTUM ARGENTARII

Otro ejemplo de protección, lo vemos desarrollado en el derecho clásico con el *receptum²¹ argentarii²²*, que permite que dos personas distantes y desconocidas entre sí, puedan celebrar contratos de compraventa, con la intermediación de un banquero, *argentarius*, que adelanta la suma al vendedor por cuenta de su cliente comprador y, podrá percibir el importe adelantado, cuando presente a su cliente, comprador, la orden de despacho de las mercaderías.

El término *argentarius²³* designa el nombre y oficio que comprende la más amplia especialidad de los actos y operaciones financieras, y es el que presenta mayores similitudes con la actual profesión de banquero²⁴.

20 SACCOCCIO, *Mutuo reale...*, cit. pág. 408: “Appare quindi conosciuta dalla pratica del I secolo d.C., la possibilità di promettere, attraverso il meccanismo della *stipulatio* cd. ‘*de mutuo dando*’, la concessione di una somma in prestito, rispetto alla quale pare possibile ipotizzare un rifiuto di adempimento da parte del promittente (futuro mutuante), di fronte ad una evidente (sopravvenuta) infidabilità dello stipulante (futuro mutuatario).”

21 DI PIETRO, *Derecho privado Romano*, cit. pág. 218 sostiene: “El verbo *recipere* significa “tomar sobre sí” “asumir un encargo, un emprendimiento”.

22 En *Curculio* de Plauto encontramos un ejemplo claro de *receptum argentarii*. Vide ALVAREZ, M. y MEDEROS, A., *Sobre los banqueros y el receptum argentarii en Roma*, Revista de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, Volumen VI, General Roca, Publifadecs, 2010, págs. 31-44.

23 ANDREAU, J., *Banking and business in the Roman world*, Cambridge University Press, 1999, pág. 39 afirma que para los juristas, lo que caracterizaba al banquero era el doble servicio que proveía: recibir depósitos y adelantar crédito. El banquero no prestaba su dinero sino al menos, parte del dinero que había recibido de sus clientes. Por el vínculo que se establecía entre banquero y cliente, éste último podía depositar su dinero con el banquero y dejarlo en depósito o ir retirando a medida que lo deseara, o podía solicitarle al banquero que realizara pagos con el dinero depositado.

24 GARCIA GARRIDO, *El comercio, los negocios...*, cit. pág. 33.

Entre las actividades del banquero²⁵ había una que desarrollaba exclusivamente él, la asunción de deudas ajenas o *receptum*^{26 27}. Se trataba de la obligación asumida por el argentario hacia un acreedor al que prometía pagar el dinero que le debía su cliente²⁸. Aunque participan tres personas (banquero, cliente y acreedor), esta operación vincula a dos: el banquero y el tercero acreedor. Al ser un acto abstracto e independiente de la obligación anterior, el banquero no está obligado a verificar la veracidad de la deuda y su cuantía²⁹. En caso de incumplimiento por parte del banquero, y por el solo hecho de haber asumido la deuda, el acreedor puede ejercitar contra aquél, la *actio recepticia*³⁰.

La obligación que asume el *argentarius* es jurídicamente independiente de la del comprador (ni es la misma, ni es accesoria) y constituye una extraordinaria seguridad no sólo para el vendedor, sino también para el comprador³¹.

25 RODRIGUEZ GONZALEZ, A., *Mensam exercere. El servicio de caja y los pagos y cobros a terceros: Scaevola, libro I Digestorum (D.2,14,47,1)*, en “El Derecho Comercial, de Roma al Derecho Moderno”, Palmas de Gran Canaria, 2007, Volumen 2, pág. 835: “La actividad del banquero romano comprendía la prueba y verificación de la autenticidad de las monedas y el cambio de las mismas, la aceptación de depósitos, la concesión de préstamos, la prestación de garantías especiales como el mencionado *receptum argentarii*, la participación en las ventas privadas a subasta y, por último, la intermediación en cobros y pagos. Este sería el contenido de lo que en las fuentes se expresa recurriendo a los términos *argentariam exercere*, *argentariam administrare*, *argentariam facere*, y *mensam nummulariam (o argentariam) exercere*.” Y continúa en pág. 848: “En nuestra opinión, el banquero no es otra cosa que un gestor del dinero de sus clientes, vinculado por las indicaciones que éstos le diesen en cuanto a las operaciones concretas a realizar, que, por otra parte, quedarían siempre circunscritas al ámbito de la *mensa*, esto es, a la actividad “bancaria” del *argentarius/ nummularius*.” En el mismo sentido ver CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Lezioni di Diritto Commerciale*, cit., pág. 79.

26 SCHULZ, F. *Derecho Romano Clásico*, cit. pág. 538: “Este *receptum* fue un pacto no formal, en que un banquero prometía pagar la deuda de su cliente. A debía 100 a C. A requería a su banquero B, para que éste prometiese a C la expresada suma de 100 (*recipere solvi*). Si B prometía, el pretor otorgaba una acción pretoria especial (*actio recepticia*) a C contra el banquero. El *receptum* ofrece gran semejanza con el *constitutum debiti alieni* y Justiniano llevó a cabo la fusión de ambos. *Recipere* significa en este caso, ‘tomar sobre sí, emprender, asumir la ejecución de una obra, de un encargo’ ”.

27 PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, Giappichelli Editore, 2002, págs. 25-26, se pronuncia en igual sentido, afirmando que el *receptum* era exclusivo de los banqueros, mientras otras actividades, como por ejemplo, el depósito, el crédito con garantía, eran realizados por diversas categorías de operadores financieros.

28 DI PIETRO, A. *Derecho Privado Romano*, cit.: “En el caso del *receptum argentarii*, estamos en presencia de una asunción de responsabilidad de deuda por parte de un banquero...Esta práctica, netamente bancaria, se realizaba en forma informal. No era necesario una *stipulatio* por la cual el *argentarius* prometiera pagar. El banquero actuaba como agente financiero de su cliente, ya contando con dinero de éste, o ya adelantándole dinero en descubierto...Es un negocio abstracto, es decir, no interesa si hay o no una obligación preexistente. Por ello, el acreedor que reclama por la *actio recepticia*, sólo tiene que probar el *receptum*, es decir, la asunción de deuda por el *argentarius*, sin necesidad de probar otra obligación.”

29 DI PIETRO, *Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el Derecho Romano*, Buenos Aires, Abaco, 2004, cit., pág. 154: “En este supuesto (*actio recepticia*), a diferencia de lo que ocurría en la *actio de pecunia constituta*, el negocio pierde su carácter causal y se vuelve abstracto. Por ello el acreedor que acciona por la *actio recepticia* sólo tiene que probar el hecho del *receptum* por parte del banquero y no la existencia de la deuda asumida.”

30 GARCIA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo Romano*, Madrid, Dykinson S.L., 2001.

31 CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Lezioni di Diritto Commerciale*, cit., pág. 111, concluyen: “I.- Il *receptum argentarii* era un negozio di diritto professionale riservato ai soli banchieri. II.- Aveva come finalità quella di svolgere un servizio di cassa in favore dei clienti, in quanto provvedeva ai loro pagamenti anche in loro assenza e

La situación del *receptum argentarii* fue descubierta por Lenel a través de una observación sistemática de los comentarios de los juristas, principalmente de Ulpiano, Paulo y Gayo³², quienes habían comentado el Edicto de Salvio Juliano, pero habían sufrido la censura que Justiniano había impuesto a esta figura en su compilación.

Podemos decir que el *argentarius* que se compromete por *receptum*, se obliga a realizar una *solutio*. El pretor concedía una acción *in factum*, perpetua, transmisible activa y pasivamente al sujeto acreedor de un *receptum argentarii*, cuando el banquero no cumpliera su obligación de realizar el pago prometido. Este es el resultado al que se compromete el *argentarius* y el que genera su responsabilidad en caso de incumplimiento³³.

Esta institución ofrece a las partes múltiples ventajas: el comprador tiene la certeza de no pagar antes de la entrega de los bienes y además, no inmoviliza el importe de su precio, el vendedor cobra al despachar la mercadería. Si el banquero no cumple con esta obligación, podrá demandarlo en la jurisdicción en que se encuentra, no en la correspondiente al comprador (que podía no sólo ser lejana, sino incluso regirse por un derecho distinto al suyo) y por último, el banquero cobra por intervenir en la operación.³⁴

Debemos destacar dos notas características del *receptum argentarii*: la celeridad y la seguridad.

De la *palliata* plautina en la comedia *Curculio*³⁵, es en donde encontramos un interesante desarrollo del *receptum argentarii*³⁶.

En esta comedia aparece el personaje de un banquero llamado Licón³⁷, que si bien no es esencial para la trama, juega un rol importante. Licón se encuentra continuamente pre-dispuesto a engañar, con tal de obtener un provecho. Las escenas donde se lo menciona o en las que interviene, son una clara evidencia del trabajo de re-escritura de Plauto sobre el original griego que le sirvió de modelo³⁸.

senza necessità di incarichi dati volta per volta. Rappresentava una forma di garanzia particolarmente sicura per i creditori, che vedevano adempiuto il proprio credito a prescindere dall'assistenza e dalla validità dell'obbligazione principale, favorendo in tal modo la circolazione monetaria ed i traffici commerciali”.

32 SALAZAR REVUELTA, M, La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma, Madrid, Dykinson, 2007.

33 RODRIGUEZ GONZALEZ, A., El *receptum argentarii* en el derecho romano clásico. Una propuesta de análisis”, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2004, pág. 199.

34 MARTINEZ CASAS M, *El crédito documentario en el Derecho Romano*. Revista de Economía del Banco de la Prov. De Córdoba, Año IV, Núm 8, Córdoba, 1952.

35 ALVAREZ, M. y MEDEROS, A., Sobre los banqueros y el *receptum argentarii* en Roma, cit., págs. 31-44.

36 Con la colaboración en la parte filológica y de traducción de textos de la Doctora Marcela Alejandra Suárez, Doctora en Letras Clásicas y Directora del Proyecto de Investigación UBACYT: “RECORRIDO GENERATIVO DE DOS COMEDIAS DE TERENCE: DE LA TRADUCCIÓN FILOLÓGICA AL TEXTO ESPECTACULAR Y PUESTA EN ESCENA”

37 ANDREAU, J., *Banking and business in the Roman world*, cit., pág.30, sostiene: “It is true that Plautus gives his bankers Greek names and sometimes calls them “trapezites”, but he was writing *palliatae* (“cloaked”) comedies, which were set in Greece. And the only banker from the third century whose name is known to us was called Lucius Fulvius, a thoroughly Latin name....In Plautus’ works, at any rate, they were money- changers, assayers and deposit bankers, all at once” y en pág 34, agrega: “A number of literary texts, both Greek and Latin, allude fleetingly to the banking professions and to financiers, and a few, such as Plautus’*Curculio* and Cicero’s *Pro Caecina*, refer to them at greater length.”

38 MOORE, T., *The Theatre of Plautus*, Austin University of Texas Press, 1998.

Como señalan Cerami y Petrucci, el *Curculio* de Plauto es la única fuente de la edad republicana, donde aparece una referencia explícita de la sujeción de la actividad crediticia de los *argentarii* a la tasa máxima de los intereses convencionales dispuestos por las leyes³⁹, en los versos 506-11 donde se los compara con los lenones y se hace alusión a la falta de respeto de los banqueros por las leyes⁴⁰. La alusión a las leyes romanas y la forma de evitar su aplicación -señala Moore⁴¹- dejan en claro lo que Plauto ha sugerido en el desarrollo de la comedia: Licón es un retrato satírico no tanto de un hipotético banquero griego, sino de un *argentarius* romano (si bien se indica que la acción transcurre en Epidauró).

Curculio corresponde al llamado período intermedio de la carrera de Plauto⁴² (193 y 191 a. C. aproximadamente)⁴³.

Los pasajes que han sido seleccionados se refieren a dos temas estrechamente vinculados: la no devolución de las sumas confiadas en depósito al banquero Licón y el *receptum argentarii*^{44 45}.

En *Curculio* la situación es la siguiente: el soldado Terapontígono le compra una doncella al lenón Capadocio, confirmando el contrato con juramento. Para este fin, le deja en depósito al banquero el dinero con la orden de entregarlo al *leno* cuando un enviado suyo se presente a recoger a la muchacha, debidamente acreditado por una carta firmada con su sello⁴⁶. Sin embargo, Capadocio no se siente obligado por el contrato y le ofrece a Fédro-mo, el *adulescens*, la misma doncella vendida al *miles*.

Al enterarse del negocio por boca del propio soldado, el parásito apodado Curculio (Gorgojo) le roba el anillo y con las falsas tablillas se presenta como liberto de aquél, ante el banquero, quien debe ejecutar la orden dada por Terapontígono. Banquero y lenón caen en la trampa, la suma es pagada y la muchacha liberada.

La primera aparición del banquero intensifica la asociación entre Roma y la decepción.

Licón entra en escena haciendo una declaración confidencial: que es rico en tanto y en cuanto no tenga que devolver el dinero que las personas le han confiado en depósito.

39 PETRUCCI, A., *Prime riflessioni su banca ed interessi nell'esperienza romana*, en *L'usura ieri ed oggi*, a cura di Sebastiano Tafaro, Cacucci Editori, Bari, 1997, pag. 92, en el mismo sentido.

40 CERAMI, P. -PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino, Giappichelli, 2002, pág. 137.

41 MOORE, The Theatre of Plautus..., cit., pág. 131.

42 PLAUTO, *Comedias I*, Traducción de José Román Bravo, Madrid, Ediciones Cátedra, 1994, 466 y 513

43 PETRUCCI, *Profili giuridici della attività...*, cit., pág.140, al referirse al *Edictum de rationibus argentariis edendis*, sostiene que se trata de la referencia jurídica más antigua a la actividad bancaria. Afirma que ese edicto probablemente fue dictado en el curso del siglo II a. C. cuando la actividad bancaria tuvo una posición relevante en la economía romana, como lo demuestran algunas fuentes literarias y epigráficas. En la nota 2 cita, entre otras, al *Curculio* de Plauto.

44 Se ha utilizado la versión erudita de W. M. LINDSAY.

45 Conforme PETRUCCI *Profili giuridici della attività...*, cit., pág. 59, el nombre de *receptum argentarii* proviene del nombre de la acción (recepticia) y de la noticia transmitida por Teófilo en su Paráfrasis al indicar en el comentario al fragmento I. 4, 6, 8 que esta acción sólo podía intentarse contra un banquero (*trapezites*).

46 GARCIA GARRIDO, *El Comercio...*, cit., pág. 84: "En las comedias de Terencio y Plauto, el depositante de dinero o lo retira en persona o se hace acompañar de su acreedor, al que el banquero paga, o manda al banquero que pague al acreedor que se presenta con una carta del cliente".

LY. “diues sum, si non reddo eis quibu’ debeo; si reddo illis quibu’ debeo, plus talienit est” (373-374)

(LI. “Soy rico si no les devuelvo a quienes les debo <dinero>; si les pago el saldo es negativo”).

LY. “habent hunc morem plerique argentarii ut allius alium poscant, reddant nemini, pugnīs rem soluant, si quis poscat clarius » (377-379)

(LI. “¿No es esto lo que hace la mayoría de los banqueros, reclamar dinero a los demás, no devolvérselo a nadie y resolver el asunto a golpes de puño, si alguien viene a reclamar en un tono demasiado alto?”).

Como ya hemos referido, el parásito Gorgojo le roba el anillo al soldado, redacta las falsas tablillas y se presenta ante el banquero, quien debe ejecutar la orden dada por Terapon-tígono. La orden de pago del cliente al banquero para que pague a un tercero es el negocio conocido como *receptum argentarii*.

LY. “tecum oro et quaeso, qui has tabellas adferet, / tibi, ut ei detur quam istic emi uirginem, / quod te praesente isti egi teque interprete, et aurum et uestem (432-435)

(LI. “Te pido, por favor, que al que te presente estas tablillas le sea entregada la doncella que compré allí, lo cual llevé a cabo en tu presencia y por tu mediación, y también las joyas y la ropa.”)

El arreglo consiste en *argentum des lenoni, huic des uirginem* (436), es decir, darle el dinero al *leno* y la *virgo* al mensajero, en este caso a Gorgojo, quien no le entregará la doncella al soldado, sino al adolescente Fédromo (enamorado de la muchacha).

En el v. 457 Licón concluye el contrato en términos que hacen de Capadocio el único agente de venta:⁴⁷

CA. “dicas quid uelis / LY. argentum accipias, cum illo mittas uirginem”

(CA. “Di lo que quieras. LI. Que cobres el dinero y dejes ir a la muchacha con él”).

Según manifiesta Arangio-Ruiz⁴⁸, en *Curculio* existe una cierta correspondencia (al menos en los efectos económicos) entre el régimen supuesto del modelo griego y el derecho romano. Es por ello, que la fábula del *Curculio* resulta más convincente que las otras para el romanista.

No se trata de un contrato *arrale*, sino de la entrega anticipada por parte del comprador, de todo el precio en las manos de un banquero. Este se ha comprometido a entregar la suma al lenón vendedor, siempre que el comprador presente un mensajero que se identifique con su sello y acompañe una orden de pago⁴⁹. A su vez, el lenón se ha comprometido a entregar al mensajero la muchacha cuando reciba el dinero.

47 BROPHY, R, *Mancipium and Mancipatio in Plautus: Once Specimen of Plautine Legal Humor and Metaphor*, Tesis doctoral defendida en la Universidad de Michigan, Michigan, 1974, pág.120

48 ARANGIO-RUIZ, V., *La compravendita in diritto romano I*, Napoli, Eugenio Jovene, 1956, pág. 81 s.

49 PETRUCCI, *Profili giuridici della attività...*, cit., pág. 61: “Una...dichiarazione, libera da forme contenuta in una lettera, è reputata sufficiente verso la fine del II secolo d.C. a configurare un *receptum* e a consentire pertanto l'esercizio della relativa azione contro il banchiere.”

Se desconoce si la triple contratación entre comprador, banquero y lenón estaba jurídicamente concebida en el modelo griego. En cuanto a la adaptación para los espectadores romanos, seguramente podemos decir que aquí tenemos un vendedor obligado a la entrega sin haber recibido arras.⁵⁰

Cerami y Petrucci afirman que es una conjetura plausible que el *receptum argentarii* continuó subsistiendo aún alrededor de la mitad del siglo III d.C. hasta la época de Justiniano⁵¹.

Justiniano derogó este instituto en parte debido a la fuerte presión de los banqueros y en parte pues sostenía que era extremadamente formal. Lo confunde con el *constituto debiti alieni* (ver Código 4, 18, 2), aunque se trata de dos institutos diferentes⁵² y en la edad media, el *receptum argentarii* reaparece y se refuerza⁵³.

No es cierto que el *receptum argentarii* fuera solemne⁵⁴ como sostiene Justiniano; el problema era —como afirma Díaz Bautista— que era abstracto y Justiniano no estaba de acuerdo con la abstracción, ya que ésta deja de lado la justicia por la seguridad jurídica. La causalización sirve a la Justicia y la abstracción a la seguridad⁵⁵. Los anhelos de grandeza de Justiniano lo llevaron a preferir la causalización, aunque las exigencias de la *praxis* lo forzasen a hacer concesiones a la abstracción.

Como señala Martínez Casas⁵⁶, si es en general beneficiosa la comunicación entre los que estudian derecho romano y moderno, particularmente lo será en este punto, entre el derecho romano y el derecho comercial, pues, quizás en ninguno como en éste, uno y otro tengan más actualmente que decirse: el primero, porque el **receptum argentarii** es una institución del derecho clásico borrada por el derecho bizantino, que hasta hace poco se ha mantenido ocultada y que empieza recién a estudiarse; el segundo, porque el **crédito documentario** es una “nueva” operación de la práctica bancaria cuyas vinculaciones y fórmulas jurídicas recién también empiezan a depurarse.

50 ARANGIO-RUIZ, *La compravendita...*, cit., pág. 81 s.

51 CERAMI, P. —PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto commerciale romano*, cit., pág. 219: “...è allora una congettura plausibile che il *receptum argentarii* abbia continuato a sussistere anche tra la metà circa del III secolo d.C. a l'età di Giustiniano, malgrado non sappiamo con quali adattamenti e con quale diffusione”.

52 GARCIA GARRIDO, *El comercio, los negocios...*, cit., pág. 105: “A diferencia del *receptum* que era un acto abstracto, el *constitutum* quedaba subordinado a la existencia de una obligación precedente que podía ser propia o ajena. En este último caso, la determinación de un plazo para pagar una deuda ajena supone una especie de garantía personal”.

53 MARTINEZ CASAS, *El crédito...*, cit. pág. 73: “Collinet, fundado en las investigaciones referidas, enseña que el contrato del cual tomó origen el *receptum* romano siguió viviendo en el mundo oriental y que la institución habría logrado en Occidente su propio ámbito de vida. Cree, por esa circunstancia, que no sería verdadera la razón de desuso invocada por Justiniano en el Código (4, 18, 2) y que producida la división del Imperio Romano, el *receptum* habría subsistido en Italia, aunque con vida muy lánguida, para reaparecer en la práctica de los banqueros medievales.”

54 MARTINEZ CASAS, *El crédito...*, pág. 75: “Si era, como sabemos, una operación netamente bancaria (solamente los *argentarii* podían realizarla), lo lógico era que esas formas no fueran las solemnes del derecho civil sino las que había puesto en uso la misma práctica bancaria.”

55 DIAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina...*, cit., pág. 198.

56 MARTINEZ CASAS, *El crédito...*, cit. pág. 26

Las características del mercado internacional hacen que las compraventas internacionales conlleven un elevado grado de incertidumbre: posibles percances durante el transporte de mercancías, existencia de formalidades aduaneras, control de cambio, diferencia de legislación, entre otras⁵⁷.

El crédito documentario moderno, puede ser definido como el contrato por el cual un comprador-importador de mercaderías, conviene con un banco-emisor- que se comprometa a pagar, aceptar o negociar letras de cambio, o hacerlas pagar, aceptar o negociar por otro banco –corresponsal–, a favor del vendedor-proveedor y contra la entrega de ciertos documentos⁵⁸.

El crédito documentario es una operación en virtud de la cual el comprador de una mercancía o receptor de un servicio, presta, por medio de un tercero (normalmente un banco), una garantía de pago al vendedor o suministrador, según la definición del artículo 2 de las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (en adelante “las RUU”).⁵⁹

Mediante el crédito documentario, el exportador minimiza los riesgos que conlleva su operación, pues el pago será efectuado por una entidad de crédito, evitando así la necesidad de evaluar la capacidad de pago de un comprador lejano y, a menudo, desconocido⁶⁰.

El crédito documentario se encuentra indisolublemente unido con un contrato, generalmente de compraventa internacional de mercaderías. Empero, el contrato de crédito documentario es totalmente autónomo de dicho negocio básico, y ajeno a sus vicisitudes⁶¹.

El crédito documentario es el instrumento de garantía más generalizado en el comercio internacional, hasta el punto de que ha sido descrito por los jueces ingleses como “la sangre del comercio internacional⁶²”.

57 LUPICINIO EVERSHEDES, *El Crédito documentario*,_4907_.pdf, pág. 1.

58 GARRONE J. y CASTRO SAMMARTINO, M., *Manual de derecho Comercial*, 2ª edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, pág. 964 s.

59 RUIZ MOLINA, M.E., *El crédito documentario en la fase inicial de la estrategia exportadora*, Boletín Económico de ICE N 781, del 6 al 12 de Octubre de 2003, pág.2: “El crédito documentario cuenta con una regulación específica, las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios, publicación 500 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI, 1993). La Cámara de Comercio internacional es un organismo privado, con sede en París, que agrupa a empresas y entidades de diversos países. Sus publicaciones, si bien carecen de rango legal, tienen gran influencia en el mundo de los negocios internacionales. Entre sus publicaciones más influyentes, figuran los Incoterms. Las RRU, por su parte, son aceptadas internacionalmente”.

60 RUIZ MOLINA, *El crédito...*, cit. pág. 8, en el mismo sentido sostiene que la principal ventaja del crédito documentario para la empresa exportadora es la seguridad en el cobro y en pág. 10 sostiene que la empresa exportadora mediante la recepción del crédito documentario, aumenta su cuota de mercado y su poder de negociación frente a proveedora, banco y clientes y con ello, mejora sustancialmente su posición competitiva.

61 GARRONE y CASTRO SAMMARTINO, *Manual de derecho Comercial*, cit. pág. 964.

62 LUPICINIO EVERSHEDES, cit. pág. 1 nota 1, afirma: El juez Donaldson L. J., junto con Ackner L. J., han dicho del Crédito Documentario: “Irrevocable letter of credit and bank guarantees given in circumstances such that they are equivalent to an irrevocable letter of credit have been said to be the life blood of commerce. Thrombosis will occur if, unless fraud is involved, the courts intervene and thereby disturb the mercantile practice or treating rights there under as being equivalent to cash in hand.”

Según las Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (versión 1993), un crédito documentario (CD, “Letter of Credit” L/C.) puede definirse como un convenio en virtud del cual un banco (banco emisor) obrando a petición de un cliente (el ordenante), y de conformidad con sus instrucciones:

- i. se obliga a efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o a su orden, a pagar o aceptar las letras de cambio (giros) que libre el beneficiario,
- ii. autoriza a otro banco a efectuar dicho pago o a aceptar y pagar tales letras de cambio (giros), o
- iii. autoriza a otro banco a negociar contra los documentos exigidos, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y condiciones del crédito.

El crédito documentario tiene una triple función:

1. **Instrumento de pago:** el comprador paga el precio de las mercancías objeto del contrato a través del crédito emitido por un banco, que abonará al vendedor el importe de la compra.
2. **Instrumento de garantía:** lo es para la empresa exportadora, puesto que el importe de la operación será abonado por una entidad financiera.
3. **Instrumento de crédito:** el comprador no reembolsará al banco hasta el momento en que éste le presente los documentos recibidos del vendedor.

Los créditos documentarios están regulados, a nivel internacional, por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) a través de los Usos y Reglas Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios (UCP).⁶³

El contrato de crédito documentario nació en el plano mundial como un instrumento de seguridad de las compraventas de mercaderías efectuadas entre plazas ubicadas en distintos países. En el derecho comercial argentino, es un contrato innominado y no ha sido objeto de reglamentación, habiéndose regido a través del tiempo, por fuentes no formales como los usos y costumbres y la jurisprudencia⁶⁴.

IV. LA SITUACIÓN DE LOS BANQUEROS EN ÉPOCAS DE JUSTINIANO

La situación económica en época de Justiniano era crítica, con la peste que asoló al Imperio entre los años 542 y 543, llegando incluso a enfermar al emperador, hecho que llevó a una gran cantidad de muertes inesperadas y una insolvencia generalizada debido a la crisis económica.

La guerra contra los persas y la presencia del banquero Pedro Barsymés en el puesto de *Comes Sacrorum Largitionum*, fueron también factores que influyeron en las decisiones

63 LUPICINIO EVERSEHDS, cit., pág. 2.

64 GARRONE y CASTRO SAMMARTINO, *Manual de derecho Comercial*, cit. pág. 964 s.

del emperador⁶⁵. Además de los factores mencionados anteriormente, Justiniano necesitaba fondos para las campañas militares de conquista de Italia y para las obras monumentales-caso de la inauguración de Santa Sofía.

Justiniano en Edicto 7, Cap. 6 establece la competencia exclusiva del *Comes Sacrorum Largitionum* cuando los banqueros sean parte en los pleitos, tanto como actores como demandados.

La legislación justiniana (535-545) en materia bancaria, señala repetidamente la utilidad que suponen los banqueros para la comunidad y los riesgos que asumen⁶⁶.

Como ya hemos mencionado, los banqueros atraviesan una importante crisis y Justiniano –para salvaguardar el crédito– dicta medidas que favorecen a los banqueros, medidas que son políticamente imprescindibles, pero discutibles desde la perspectiva jurídica⁶⁷.

Una de las medidas que toma Justiniano en la Novela 136, 4⁶⁸ y que abordaremos en este acápite, es permitir que los banqueros perciban intereses por los mutuos, aunque no se hubieran pactado por escrito y que serán del 8%^{69,70}.

Los intereses se convierten así, en un elemento natural del negocio bancario⁷¹. Recordemos que en el derecho romano clásico, los intereses debían convenirse mediante *estipulatio*. Alejandro Severo en una Constitución contenida en C. 4, 32, 12 establece que se debe pagar aún en virtud de nudo pacto, la accesión de trigo o de cebada, que se dio en mutuo. Como bien señalan Cerami y Petrucci⁷², esta Constitución puede, en cualquier caso, constituir la consagración en el plano jurídico, de una práctica consolidada también, en el ejercicio de la banca.

Justiniano mantiene en el Digesto los comentarios en ese sentido de los juristas clásicos, pero altera el régimen en la Novela citada. Como sostienen Cerami y Petrucci⁷³, en la Novela 136, 5, 1, se plantean dos diferentes hipótesis: a) En los mutuos que se concluyan por escrito con la mención de ser “con intereses” sin determinación del porcentaje, se niega

65 CERAMI, P. –PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto commerciale romano*, cit., pág. 230: “...la corporazione dei banchieri della capitale fosse in grado di esercitare forti pressioni sulla cancelleria imperiale al fine di ottenere importanti provvedimenti normativi in proprio favore. Qui è opportuno soffermare la nostra attenzione sui tre fondamentali, consistenti in altrettante *pragmaticae sanctiones* aventi ad oggetto i contratti dei banchieri (*de argentiorum contractibus*), che sono raccolte al di fuori delle parti ufficiali della Compilazione: La Novella 136...e gli Editti 7 e 9, tutti scritti in greco...e databili fra il 535 ed il 542”.

66 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 9 nota 22.

67 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 29 s.

68 SALAZAR REVUELTA, *La gratuidad...*, cit, pág. 301: “...Justiniano reconoce una excepción a favor de los *argentarii*, permitiéndoles cobrar intereses- dentro de una tasa legal determinada: el 8%- en virtud de un simple acuerdo con el prestatario, sin que ninguna estipulación hubiera mediado, ni ningún escrito hubiera sido firmado, es decir, sin ningún tipo de fomalidad; y ello sólo con el fin de beneficiar a los negocios bancarios. Este es el sentido en el que se ha de interpretar el capítulo cuarto de la Novela 136.”

69 ANDREAU, *Banking and business in the Roman world*, cit., pág. 142, sostiene: “Down to the time of Justinian, the stipulation of interest on the *mutuum* was not legally regarded as a contradiction of the interest-free nature of the contract itself”.

70 PETRUCCI, A., *Prime riflessioni...* cit., pág. 87: “Prendendo atto di una tale situazione, l'imperatore, nell'ambito della sua politica di favore verso i banchieri, riconosce agli stessi il diritto di pretendere il pagamento degli interessi-sempre ni limiti del tasso legale- ance si non hanno formato oggetto di una *stipulatio*, ma sono concordati con un *pactum verbale*.”

71 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 112.

72 CERAMI, P. –PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto commerciale romano*, cit., pág. 128.

73 CERAMI, P. –PETRUCCI, A., *Lezioni...*, cit., pág. 135.

a los contratantes la posibilidad de sostener la gratuidad del mutuo, presumiéndose la tasa legal del 8%; b) En el caso de los créditos ya concluidos por escrito, en los que no se haya hecho mención de los intereses, éstos igualmente podrán exigirse en la medida del 8%, presumiéndose siempre onerosos los contratos similares donde interviene un banquero⁷⁴.

Este cambio se debe a la presunción de onerosidad⁷⁵ que tienen los contratos comerciales y que va a receptarse en el Derecho mercantil moderno.

Con relación a este tema, el artículo 2248⁷⁶ del Código Civil Argentino establece que el mutuo es esencialmente gratuito y el artículo 560⁷⁷ Código de Comercio Argentino reitera este principio y sostiene que la tardanza en el cumplimiento hace que corran intereses desde el día de la demanda. En cambio, el artículo 1527⁷⁸ del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación Argentina de 2012, avanza hacia la presunción de onerosidad del mutuo como principio, excepto pacto en contrario.

Justiniano otorga también importantes prerrogativas a los banqueros, tales como otorgar fuerza probatoria a los apuntes de los banqueros, en Ed. 7, Cap.2⁷⁹ y establece un importante privilegio a su favor: la posibilidad de hacerse de las mercaderías que el cliente compró con el dinero prestado (Novela 136,3).

Otras medidas tomadas por Justiniano, son: conceder a los banqueros la acción subrogatoria para dirigirse contra los deudores de sus deudores insolventes, para cobrar sus créditos, y la posibilidad de ejercitar en los contratos bancarios, las acciones hipotecarias aunque no se hubieren pactado en forma expresa conforme Edicto 7, Cap. 3⁸⁰ y una defensa procesal –la *exceptio pensatae pecuniae*– cuando el cliente demanda al banquero el crédito que tiene contra él, sin realizar compensación por lo que el banquero le debe⁸¹.

74 PETRUCCI, A., *Prime reflessioni...*, cit. págs. 89 s. en el mismo sentido.

75 PETRUCCI, A., *Prime reflessioni...*, cit. pág. 91: “...la seconda (se refiere a la Constitución del 528), giustamente ritenuta *iuris et de iure*, adduce la naturale onerosità non solo dei mutui, ma piu in generale dei crediti bancari documentati...”

76 Artículo 2248 del C. C. Argentino: “No habiendo convención expresa sobre intereses, el mutuo se supone gratuito, y el mutuante sólo podrá exigir los intereses moratorios, o las pérdidas e intereses por la mora”. El artículo citado no tiene nota del codificador indicando la fuente.

77 Artículo 560 del C. Com. Argentino: “En los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses, o cuando éstos no están estipulados en el contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obligación, hace que corran los intereses desde el día de la demanda, aunque ésta excediera el importe del crédito, y aunque el acreedor no justifique pérdida o perjuicio alguno, y el obligado creyese de buena fe no ser deudor.”

78 Artículo 1527 del Proyecto C. C. y Com. : **Onerosidad** “El mutuo es oneroso, excepto pacto en contrario. Si el mutuo es en dinero, el mutuario debe los intereses compensatorios, que se deben pagar en la misma moneda prestada... Los intereses se deben por trimestre vencido, o con cada amortización total o parcial de lo prestado que ocurra antes de un trimestre, excepto estipulación distinta. Si se ha pactado la gratuidad del mutuo, los intereses que haya pagado el mutuario voluntariamente son irrepetibles...”

79 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 23

80 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 106

81 RODRIGUEZ GONZALEZ, A., *El receptum argentarii...* cit., pág. 144: “En consecuencia, pensamos que la obligación de compensar previa a la demanda no se impuso de la misma forma al cliente que al *argentarius*, para quien se trataba de una compensación legal. Esto significa que el cliente podría demandar a su banquero sin necesidad de compensar previamente. No se le negaría la acción por este hecho, pero el *argentarius* gozaría de la posibilidad de interponer una *exceptio pensatae pecuniae* para hacer valer tal ausencia de compensación. La obligación de compensar créditos y deudas recíprocos afecta al cliente y al banquero, pero no de la misma forma, puesto que en el caso del cliente se haría valer únicamente a través de la *exceptio pensatae pecuniae*.”

Señala Justiniano (en Cap.4 *in fine* de Ed.7) que la corporación de los banqueros y quienes contratan con ellos, cooperan al bien común, ya que sus contratos no sirven a unos pocos, sino a casi toda la República.⁸²

Como hemos referido, debido a la crisis económica, Justiniano protege a los banqueros y va aceptando las peticiones que ellos le formulan. Esta protección hacia los banqueros, tiene incidencia en la suerte corrida en época justiniana por los otros dos supuestos analizados precedentemente: las limitaciones impuestas a la *exceptio non numeratae pecuniae* y la derogación del *receptum argentarii*.

Con las medidas que toma Justiniano, se ponen en evidencia principios que van a regir el Derecho mercantil moderno, tales como la celeridad en la contratación, la tendencia a la abstracción exigida por el tráfico, el reconocimiento de la onerosidad como inherente a los negocios y la necesidad de obtener vías rápidas y seguras para la realización de los créditos⁸³.

En la República Argentina durante la llamada crisis del 2001, cuyos efectos se verificaron a partir el año 2002 y por mucho tiempo, se tomaron medidas que -de alguna manera- beneficiaron a los bancos, en perjuicio de los ahorristas.⁸⁴

En efecto, la salida de la convertibilidad, por un lado y el llamado “corralito” que impedía retirar los depósitos en moneda extranjera, por el otro, quebraron la confianza de los ahorristas. Los amparos judiciales realizados, tuvieron diversos resultados y no todos los afectados recurrieron a la vía judicial, con lo que el costo político de esas medidas se trasladó en el tiempo y quedó afectada, aún luego de una década, la *fides*.

Las medidas económicas tomadas en los últimos días de enero del corriente año, conocidas como una atenuación del “cepo cambiario”, que habilitaron la compra de divisas para tenencia, llamado “dólar ahorro”, establecieron que, si los dólares adquiridos quedaban depositados en el sistema financiero, se bonificaba el recargo del 20% en concepto de anticipo al Impuesto a las Ganancias que se debe tributar por esas operaciones. Aún así, menos del 10% de lo adquirido permaneció depositado en el sistema financiero⁸⁵.

V. CONCLUSIÓN

Como señala Martínez Casas⁸⁶: “Si el derecho romano ha sido, además de fundamento, la guía y el maestro del derecho nuevo, no lo ha sido por la seducción de su imponente arquitectura, por el equilibrio de las masas y la armonía de las líneas que todavía se muestran en la grandeza de sus ruinas, sino por el espíritu que movió a esas formas.

Si el derecho romano debe conservar ese alto magisterio, es menester que quien lo enseñe no se detenga en admirar y describir sus ruinas, sino que penetre y descubra la

82 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 167.

83 DIAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina...cit., pág. 7s.

84 Vide ALVAREZ, M. y ALONSOPÉREZ G., *Un perfil de los banqueros a la luz de la comedia plautina y de la crisis económica argentina del siglo XXI*, IX Congreso Internacional y XII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 2007, Volumen I, págs. 101-118.

85 Fuente: Diario Perfil del sábado 1º de Febrero de 2014, pág. 19.

86 MARTÍNEZ CASAS, *El crédito*...cit. pág. 25s.

razón de su antigua existencia, muestre los principios que entonces presidieron a aquellos monumentos y diga cómo los mismos principios pueden todavía ordenar y perfeccionar las nuevas construcciones”.

En el mismo sentido, Rodríguez Ennes⁸⁷, en su último libro concluye: “Bien dijo Savigny que en nuestra ciencia toda verdad arranca de un cierto número de principios fundamentales y estos son los que constituyen verdaderamente la grandeza de los juristas romanos, de aquellos juristas que nunca abrigaron la pretensión de ser “originales “ y “elocuentes”. Los juristas romanos-como los romanistas auténticos de nuestro tiempo- rezuman Derecho. Los prototipos, las bases arquitecturales, los principios fundamentales del Derecho Romano tienen todavía validez”.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ALVAREZ, M. y ALONSOPEREZ G., *Un perfil de los banqueros a la luz de la comedia plautina y de la crisis económica argentina del siglo XXI*, IX Congreso Internacional y XII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 2007, Volumen I.
- ALVAREZ, M. y MEDEROS, A., *Sobre los banqueros y el receptum argentarii en Roma*, Revista de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, Volumen VI, General Roca (Río Negro), Publifadecs, 2010.
- ANDREAU, J., *Banking and business in the Romano world*, Cambridge Cambridge University Press, 1999.
- ARANGIO-RUIZ, V., *La compravendita in diritto romano I*, Napoli, Eugenio Jovene, 1956.
- CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Lezioni di Diritto Commerciale Romano*, Torino, Giappichelli, 2002.
- DIAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la banca bizantina: negocios bancarios en la legislación de Justiniano*, Murcia, Editum, 1987.
- DI PIETRO, A. *Derecho Privado Romano*, Buenos Aires, Depalma, 1996.
- DI PIETRO, A., *Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el derecho romano*, Buenos Aires, Abaco, 2004.
- FADDA, C., *Istituti Commerciali del Diritto Romano*, Napoli, Jovine Editore, 1987.
- GARCIA GARRIDO, M., *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo Romano*, Madrid, Dykinson S. L., 2001.
- GARRONE J. y CASTRO SAMMARTINO, M., *Manual de derecho Comercial*, 2º edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996.
- GUZMAN BRITO, A., *La consensualización de los contratos reales*, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso N° 29, Valparaíso, 2007.
- MARTINEZ CASAS M., *El crédito documentario en el Derecho Romano*. Revista de Economía del Banco de la Prov. De Córdoba, Año IV, Núm 8, Córdoba, 1952.
- MOORE, T., *The Theatre of Plautus*, Austin, Austin University of Texas Press, 1998.

87 RODRIGUEZ ENNES, L., *El Padre Feijoo y el derecho de su tiempo: Una visión premonitoria de problemas candentes en la actualidad*, Madrid, Dykinson, 2013, pág. 218.

- PETRUCCI, A., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, Giappichelli Editore, 2002.
- PETRUCCI, A., *Prime riflessioni su banca ed interessi nell'esperienza romana*, en *L'urura ieri ed oggi*, a cura di Sebastiano Tafaro, Bari, Cacucci Editori, 1997.
- RODRIGUEZ ENNES, L., *El Padre Feijoo y el derecho de su tiempo: Una visión premonitoria de problemas candentes en la actualidad*, Madrid, Dykinson, 2013.
- PUGLIESE, G., *Istituzioni di Diritto Romano*, Torino, Giappichelli, 1991.
- RODRIGUEZ GONZALEZ, A., *El receptum argentarii en el derecho romano clásico. Una propuesta de análisis*", Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2004.
- RUIZ MOLINA, M.E., *El crédito documentario en la fase inicial de la estrategia exportadora*, Boletín Económico de ICE N 781, del 6 al 12 de Octubre de 2003.
- SALAZAR REVUELTA, M., *La gratuidad del mutuum en el Derecho Romano*, Jaen, Universidad de Jaen, 1999.
- SALAZAR REVUELTA, M., *La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma*, Madrid, Dykinson, 2007.
- SACCOCCIO, A., *Mutuo reale, acordó di mutuo e promessa di mutuo in diritto romano*, en *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, Napoli, Jovene Editore, 2011.
- SCHULZ, F. *Derecho Romano Clásico*, Barcelona, Bosch, 1960.
- TALAMANCA, M., *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, Giuffrè, 1990.
- TORRENT, A. *Diccionario de Derecho Romano*, Madrid, Edisofer, 2005.

UN SUPUESTO DE ADAPTACIÓN AL DERECHO EUROPEO EN MATERIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A LA LUZ DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE MARZO DEL 2013

AMPARO MONTAÑANA CASANÍ
Universitat Jaume I.

No puedo dejar de aprovechar la ocasión para dedicarle unas palabras de afectuosa recuerdo al profesor Díaz Bautista, hombre culto, buen jurista y persona entrañable.

Al modo de los juristas romanos partimos del planteamiento de un caso concreto, fallado por el del Tribunal Supremo el 4 de marzo de 2013.

El supuesto de hecho es el siguiente:

- PRIMERO, “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” encargó para la campaña de Navidad del año 2007 a “Supermercados de Alimentación de Madrid S.L.” el suministro de lotes y cestas de Navidad.
- SEGUNDO, Los lotes entregados, según queda acreditado en juicio, contenían productos de peor calidad a los contratados y algunos estaban en mal estado. Además algunos fueron entregados con retraso.
Esto provocó numerosas quejas en los clientes de “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” y además, que al año siguiente bajara su facturación un 64%.
- TERCERO, “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” dejó de abonar una parte del precio estipulado.
- CUARTO, “Supermercados de Alimentación de Madrid S.L.” reclama en Primera Instancia el pago de la totalidad del precio 323.766 euros.
- QUINTO, “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” plantea la *exceptio non adimpleti contractus* del artículo 1124 del Código civil. Alegando que “Supermercados de Alimentación de Madrid S.L.” incumplió el contrato y subsidiariamente, que lo cumplió defectuosamente y que por tanto debe reducirse el precio en proporción a los defectos y perjuicios causados.
- SEXTO, En Primera Instancia se estima parcialmente la demanda y se condena al demandado (Madrigal Lotes y Regalos S.L.) a pagar 305.955,64 euros.

- SÉPTIMO, “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” recurre en apelación ante la Audiencia Provincial de Santander.
- OCTAVO, La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso y revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, rebajando la cantidad que debe pagar “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” a 298. 600,01 euros alegando, como lo había hecho antes el Tribunal de Primera Instancia, que no estamos ante un incumplimiento esencial que justifique el incumplimiento de la obligación principal del demandado, a saber, el pago del precio, sino ante un incumplimiento defectuoso, que justifica descontar del precio pactado el valor de los daños y perjuicios ocasionados con dicho incumplimiento defectuoso.
- NOVENO, “Madrigal Lotes y Regalos S.L.” recurre en casación ante el Tribunal Supremo alegando infracción del art. 1124 del Código civil y su jurisprudencia interpretativa, en concreto respecto a la excepción *non adimpleti contractus*, en relación con la consideración contenida en la sentencia de que el incumplimiento no es esencial y grave para justificar el impago del precio convenido.
Se argumenta que la contratación no era un suministro ordinario sino especial, atendiendo que eran regalos típicamente navideños que únicamente reportan finalidad si llegan unos días antes de las fiestas navideñas y resultan de la total satisfacción del que recibe el regalo.
Entiende que en este caso la insatisfacción ha sido total como demuestra el hecho de que al año siguiente bajara su facturación más de un 60%. Esto demuestra que se frustró la finalidad del contrato, constituyendo un incumplimiento total y absoluto, a juicio del recurrente.
- DÉCIMO, El Tribunal Supremo desestima el recurso explicando la jurisprudencia sobre la *exceptio non adimpleti contractus*.

La sentencia recoge las siguientes consideraciones:

1. Explica qué debe entenderse por cumplimiento de la obligación.
2. Señala que la función de la *exceptio non adimpleti contractus* en el marco de las obligaciones sinalagmáticas se ha consolidado como el derecho a rechazar el cumplimiento de una obligación que no se ajuste a una exacta ejecución de la prestación debida, persiguiendo paralizar o enervar la pretensión dirigida a obtener el cumplimiento de la prestación. En otras palabras, es un medio de defensa que supone suspender el pago provisionalmente mientras la otra parte no cumpla con exactitud. La *exceptio non adimpleti contractus* no persigue la resolución del contrato.
3. Al valorar el incumplimiento del contrato hay que distinguir la aplicación de la *exceptio* en cuyo caso el incumplimiento produce la quiebra básica y esencial respecto a la exactitud de la prestación, pero ésta seguirá siendo útil a los intereses del acreedor si se cumple satisfactoriamente. En el caso del ejercicio de la resolución del contrato el incumplimiento debe generar una situación de quiebra básica de los elementos básicos respecto de la posible satisfacción que da lugar a la tipología básica de los incumplimientos esenciales.

4. En el presente caso se opone la *exceptio non adimpleti contractus* una vez que la contraparte ya había ejecutado su prestación, los lotes y cestas ya habían sido entregados, para justificar la improcedencia del pago convenido. No es éste el supuesto de hecho contemplado en la *exceptio* que, como se ha dicho, supone que la prestación está pendiente de su exacto cumplimiento y, por tanto, aún es posible el cumplimiento satisfactorio.
5. En este caso, y puesto que la prestación ya se ha ejecutado, sólo cabe exigir la resolución del contrato si estamos ante un incumplimiento esencial; o la rebaja del precio estipulado pendiente de pago, en función del valor de los daños y perjuicios ocasionados, si estamos ante un incumplimiento defectuoso o no esencial.

La sentencia desestima el recurso de casación, pues la sentencia recurrida no ha infringido el art.1124 del Código civil ni su jurisprudencia.

La sentencia aplica los principios del Derecho anglosajón en materia de incumplimiento de contrato, frente a los principios propios de nuestro Código civil de tradición romanística, propia de los códigos continentales. Los principios del Derecho anglosajón giran en torno a dos conceptos, A saber:

1. Incumplimiento esencial: resolución del contrato.
2. Incumplimiento no esencial: exigencia del correcto cumplimiento.

En ambos casos cabría reclamar daños y perjuicios.

Estos principios fueron los acogidos por la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. La doctrina ha señalado que parte del éxito de la Convención se debe a haber seguido el esquema anglosajón.¹

La Directiva 44/1999 sobre Determinados Aspectos de la Venta y las Garantías de los Bienes de Consumo adoptó el sistema anglosajón en materia de incumplimiento de contratos, por influencia de la Convención de Viena. En este caso aplicándolo a las compraventas de bienes de consumo y por tanto al Derecho de los consumidores.

La Directiva opta por la siguiente configuración:

1. Abandona la dualidad incumplimiento del contrato / vicios ocultos propia de los códigos continentales y heredada de una incorrecta recepción e interpretación de los remedios edilicios².

1 VICENT CHULIA, F. *Introducción al Derecho Mercantil*. 18ª edición. Valencia. Tirant lo Blanch, 2005. p. 834ss. ISBN: 84-8456-437-1. Resalta la errónea filosofía que inspira el régimen de compraventa en nuestros códigos al elevar todo supuesto de incumplimiento a causa de resolución o ruptura del contrato. A la vez que valora positivamente que en la Convención de Viena, todas sus soluciones tienden a conservar el contrato, como bien valioso que es, y a darle una solución de acuerdo con la buena fe y los usos del comercio internacional.

2 MORALES MORENO, A.M. Adaptación del Código civil al Derecho Europeo: la compraventa. *Anuario de Derecho Civil*. 2003, Tomo LVI, Fascículo IV, p. 1609-1651, en concreto p.1614-1617. ISSN: 0210-301X. Señala que la existencia en el Código civil de un sistema especial de responsabilidad por saneamiento de vicios ocultos contrapuesto al general no se debe a la exigencia de un adecuado tratamiento del problema, sino que tiene

2. La *quantum minoris* se mantiene como uno de los remedios dentro del sistema del incumplimiento contractual³.
3. No se mantiene la distinción entre vicios ocultos y vicios aparentes.
4. El “principio de conformidad” incluye también los supuestos de error, vicio en la voluntad, dolo y vicios ocultos.
5. La *quantum minoris* forma parte de una serie de remedios que se presentan jerarquizados.
6. La *quantum minoris* será posible cuando:
 - a. No se pueda exigir ni la reparación, ni la sustitución. O esto resulta desproporcionado.
 - b. Si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento en un plazo razonable
 - c. Si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento sin mayores inconvenientes para el consumidor.
7. El comprador sólo le quedará el remedio de la *quantum minoris*, en lugar de la reparación o sustitución cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia, pues en este caso queda excluida la resolución del contrato.

Podemos concluir que la *quantum minoris* amplía los supuestos en los que cabe su utilización y, aunque concebida como un remedio subordinado a la imposibilidad de hacer uso de otros, está en un plano superior a la opción de la resolución del contrato cuyo uso queda muy limitado. Si a eso añadimos la limitación impuesta a los remedios “principales”, podemos afirmar que la *quantum minoris* adquiere una relevancia práctica que había perdido en los códigos continentales europeos.

La Directiva ha sido transpuesta de distinto modo en los distintos Estados de la Unión Europea, y en aquellos ordenamientos continentales con código civil se han seguido tres vías:

- a. Países como Alemania, Austria y Holanda han incorporado la Directiva mediante una reforma del Código civil que ha supuesto la incorporación del régimen de la Directiva a todas las ventas. Francia proyectó igualmente incorporar la Directiva a través de una reforma del Código civil, finalmente optó por transponerla a través de un texto especial incorporado al Código de consumo.

su razón de ser en la técnica legislativa utilizada en el momento de la codificación. El codificador traslada unas acciones propias del contrato de compraventa, creadas dentro del régimen de ese contrato, al régimen general de obligaciones y contratos. Como pongo de manifiesto en MONTAÑANA CASANÍ, A. La *actio quantum minoris* en la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. en RESINA SOLA, P. (ED). *Fundamenta Iuris. Terminología, principios e interpretatio*. Almería. Universidad de Almería, 2012. p. 393-408, en concreto p. 404. ISBN 10: 8415487177. ISBN 13: 978-8415487173. No puede entenderse el juego de los remedios edilicios en el incumplimiento contractual de los códigos continentales si no se estudia el origen de los remedios edilicios en el marco de la compraventa romana, no como remedios al incumplimiento contractual sino como remedios específicos creados para las compraventas de esclavos y animales en los mercados y como en el proceso de Recepción del Derecho Romano en Europa se pervierte su sentido originario y acaban incorporados al régimen del incumplimiento del contrato.

3 MORALES MORENO, A.M. Adaptación del Código civil al Derecho Europeo: la compraventa. cit., p.1641 aboga por incorporar la reducción del precio como remedio general en caso de incumplimiento en una futura reforma del Código civil.

- b. Italia o Bélgica optaron también por una reforma del Código pero esa reforma no ha supuesto una generalización del régimen de la Directiva a todas las ventas sino la creación dentro del Código de un régimen especial para las ventas a consumidores.
- c. España y Portugal han incorporado la Directiva mediante una ley especial.

La Directiva fue transpuesta al Derecho español en la Ley 23/ 2003 sobre Garantías en la Venta de Bienes de Consumo⁴.

La ley 23/2003 sigue el esquema del incumplimiento contractual de la Directiva y por tanto introduce la *quantum minoris* con su nueva concepción. Ahora bien, modifica el esquema de la Directiva en los siguientes puntos:

1. En lo que se refiere a la jerarquización de los remedios y la entrada en juego de la *quantum minoris*, la Ley en este caso dice que “la rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución...” ⁵

4 MORALES MORENO, A.M. Adaptación del Código civil al Derecho Europeo: la compraventa, cit., p. 1610. El autor pone de manifiesto que la transposición de la Directiva a los distintos Derechos europeos ha planteado mayores problemas que en otros casos debido precisamente a que su esquema no coincide con los Derechos continentales europeos. En la p. 1623 recoge los problemas que el sistema de transposición de la Directiva y su concurrencia con las normas del Código civil ha provocado. A nuestro entender, una vez más, en nuestro Derecho se ha optado por el camino menos recomendable y que no ha hecho más que introducir mayor confusión en esta materia. Una vez más, se ha perdido una oportunidad de oro para adaptar el Derecho a las necesidades del mercado.

5 El artículo 7 establece las reglas para que entre en juego la rebaja del precio o la resolución del contrato. Nos dice que éstas entran en juego a elección del consumidor, cuando no se puede exigir la reparación o sustitución o estas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin inconvenientes para el consumidor. Se adopta un criterio alternativo para dar entrada a esta segunda opción, mientras que en la Directiva para dar entrada a esta segunda opción debía resultar imposible ambas opciones (reparación y sustitución). MARÍN LÓPEZ, M.J. Las garantías en la venta de bienes de consumo en la Unión Europea. La Directiva 1999/44/CE y su incorporación en los Estados miembros. Madrid. Instituto Nacional de consumo, 2004. T.I p. 361. ISBN: 84-96450-00-7 cit por FENOY PICÓN, N. *El sistema de protección al comprador*. Madrid. Cuadernos de Derecho Registral, 2006. p. 159, nt.101. ISBN: 9788496347809. El autor interpreta igualmente el precepto, en este caso en el Texto Refundido Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Ver: MARÍN LÓPEZ, M.J. Garantía y servicios postventa. en BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R. *Comentario al Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 2007)*. Pamplona. Aranzadi, 2009. p. 1405-1605, concretamente p. 1525. ISBN: 978-84-9903-264-1. Interpreta el precepto de acuerdo con su literalidad, basta con que el consumidor no pueda exigir alguno de los remedios primarios o no se hayan llevado a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para poder acudir a los remedios subsidiarios (rebaja del precio y resolución del contrato).

Parte de la doctrina se aparta a la hora de interpretar el precepto de la estricta interpretación literal, pues entienden que se aparta del espíritu de la ley. Una primera interpretación, propuesta por MARTÍN ARESTI, P. *Las garantías de los productos de consumo*. Pamplona. Aranzadi, 2010. p. 148-149. ISBN: 9788499035024. Sobre la posibilidad de elección del consumidor según interpretación hecha por la doctrina del art 7 a la luz del art. 5.1, el texto normativo deja claro que cuando una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada, el consumidor perderá su derecho a elección, y por tanto esto puede llevarnos a pensar que para que se pueda optar por la rebaja del precio o la resolución del contrato será preciso que sean imposibles o desproporcionadas ambas opciones, tanto la reparación como la sustitución. Esto se deduce, según la autora, de las normas que rigen la aplicación de los remedios primarios frente a la falta de conformidad. Entiende que en contra de la literalidad del precepto, a la hora de valorar bajo que supuestos procede el acceso a los remedios secundarios lo relevante no es aquello que el consumidor no haya podido exigir (reparación o sustitución), sino lo que este sujeto no ha podido obtener.

Luego no es necesario que el consumidor agote las dos vías, podrá exigir la rebaja del precio cuando habiendo optado en primer lugar por cualquiera de las opciones: reparación o sustitución no subsanara el incumplimiento. Por tanto en ese caso queda en manos del consumidor elegir entre la opción no escogida o la rebaja del precio o la resolución del contrato, advirtiendo que ésta última queda restringida a los casos en que la falta de conformidad no sea de escasa importancia.

La rebaja en el precio juega en la ley española un papel más relevante que en la Directiva y especialmente será el remedio más factible en el caso de compraventa de bienes no fungibles o de segunda mano donde la sustitución está excluida legalmente y donde la reparación puede resultar excesivamente costosa.

2. La Ley establece los criterios para la rebaja en el precio: “será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega.”

VÉRGEZ SÁNCHEZ, M. *La protección del consumidor en la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo*. Pamplona. Aranzadi, 2004. p.99-100. ISBN: 978-84-9767-334-1. cit. por MARTÍN ARESTI, P. *Las garantías de los productos de consumo*, cit., p. 149, manteniendo la misma interpretación que Martín Aresti, añade la interpretación del supuesto del art.7 cuando se permite elegir al consumidor entre la reducción del precio o la resolución del contrato cuando la reparación o la sustitución no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor, plantea si en estos dos supuestos basta con que esto suceda con la opción elegida por el consumidor o si es necesario que se dé con las dos alternativas. Él entiende que debería permitirse al consumidor optar por los remedios secundarios si la concreta elección hecha (sustitución o reparación) no se hubiera llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor.

Otra interpretación cabe a la luz de art. 6. apartados e y f. AVILÉS GARCÍA, J. *Los contratos de compraventa de bienes de consumo*. Granada. Comares, 2006. p.373ss. ISBN: 9788498361469. Entiende que interpretando análogamente el art.7 con estos supuestos citados cabe entender que basta con que la primera opción elegida por el consumidor no se lleve a cabo dentro de un plazo razonable o sin mayores inconvenientes, para que pueda entonces elegir indistintamente la otra opción no escogida (reparación o sustitución) o la rebaja del precio o la resolución del contrato, teniendo presente que ésta última no se admitirá si la falta de conformidad fuera de escasa importancia.

CASTILLA BAREA, M. *El nuevo régimen legal del saneamiento en la venta de bienes de consumo*. Madrid. Dykinson, 2005. p. 252. ISBN 10: 8497726499. ISBN 13: 9788497726498 cit. por FENOY PICÓN, N. *El sistema de protección del comprador*. cit., p.166, entiende que hay tres casos en los que el consumidor puede directamente disponer de la opción de la reducción del precio o la resolución del contrato: 1º cuando desde el primer momento la reparación o la sustitución son imposibles; 2º cuando el vendedor rechaza la viabilidad de la reparación o de la sustitución por ser ambas desproporcionadas; 3º cuando una medida es imposible y la otra desproporcionada; y que en cualquier otro caso distinto de estos tres, entiende preciso haber puesto en marcha una de las medidas que señala el art.5.1 (reparación –sustitución) y si resulta insatisfactoria para el comprador, entonces podrá ejercitar alguna de las medidas subsidiarias.

Nosotros entendemos que ésta es la interpretación que responde al espíritu de la Ley, que debe interpretarse de acuerdo con sus fuentes de inspiración, léase la Convención de Viena, en virtud del principio *favor negotii* y por tanto dando opciones al comprador a favor de la no resolución, en este caso poniéndolas a un mismo nivel y no estableciendo unos criterios jerárquicos de estricto cumplimiento. Añadir a favor de esta interpretación *favor negotii* que la opción entre la rebaja en el precio y la resolución del contrato no son equivalentes en cuanto a su elección por el consumidor pues la ley añade que la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Podemos entender que la resolución del contrato sólo tendrá lugar en caso de falta de conformidad equivalente al “incumplimiento esencial” del sistema anglosajón adoptado por la Convención de Viena. Luego el remedio de la resolución quedaría relegado a los casos excepcionales en los que es imposible solventar la falta de conformidad con cualquiera de los otros remedios.

En este caso, nuestra Ley especifica claramente el criterio de la reducción del precio, siguiendo en esto a la Convención de Viena⁶ y alejándose de la indefinición de la Directiva que habla de “reducción adecuada del precio”.

También la Ley española sigue a la Convención de Viena al fijar, en el momento de la recepción del bien, el momento de calcular su valor. El cambio queda justificado por ser más realista, pues es en el momento de la entrega cuando cobra sentido la opción de la reducción del precio, atendiendo al mercado. Y además supone una distribución de riesgos que no supone agravio para ninguna de las partes. Entiendo que se trata de buscar el beneficio y la utilidad para el consumidor que apreciará el interés del objeto defectuoso en el momento de la entrega⁷.

3. La rebaja en el precio no tiene carácter indemnizatorio⁸ y por tanto será compatible con las correspondientes acciones de daños y perjuicios⁹.

Al calor de esta Ley, la doctrina criticó que no se hubiera utilizado la ocasión de la obligación de transponer la Directiva 44/1999 al Derecho interno para cambiar el sistema del incumplimiento contractual del Código civil¹⁰.

6 Art 50 Convención de Viena: “ Si las mercaderías no fueran conformes al contrato, háyase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al art. 37 o el artículo 48 o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos.”

7 CARRASCO PERERA, A.F. y otros, Transposición de la Directiva comunitaria sobre venta y garantía de los bienes de consumo. *Estudios sobre Derecho de consumo*. 2000, nº 52, p.125-146, concretamente p. 129. ISSN-e 0212-9469.

8 Fue su distinta naturaleza el argumento utilizado por los juristas continentales para introducir el remedio de la rebaja en el precio en el sistema anglosajón adoptado por la Convención de Viena.

9 FENOY PICÓN, N. *El sistema de protección del comprador*. cit., p.31, detalla el sistema de responsabilidad por daños al que el consumidor podría acudir: art.1101 Código civil, art. 25 y ss de la Ley General de Defensa Consumidores y Usuarios, Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil de Daños Causados por Productos Defectuosos. MORALES MORENO, A.M., Adaptación del Código civil al Derecho Europeo: la compraventa, cit., p.1624, limita la posibilidad de acudir a la Ley 22/1994, de Responsabilidad de Productos Defectuosos sólo a los casos en que el vendedor sea a la vez fabricante o importador. Además matiza el autor que esta ley sólo contempla la indemnización en caso de daños a otros bienes y no por la insatisfacción contractual. Este autor interpreta la disposición relacionando la incompatibilidad de utilizar, según la ley, los remedios del saneamiento del Código civil y los remedios de la Ley , a la vez que la compatibilidad del uso de los remedios de la Ley con el derecho a una indemnización por daños y perjuicios en el sentido de que la compatibilidad de ambos remedios lo sería con el derecho a una indemnización por daños y perjuicios derivada del régimen del incumplimiento del Código civil y no la indemnización de daños y perjuicios que deriva del saneamiento.

También MORALES MORENO pone de manifiesto que esa remisión que hace la Ley a la Legislación civil y mercantil, no regulando la misma Ley la pretensión indemnizatoria crea un desajuste en los plazos de prescripción de las acciones (tres años desde la entrega del bien, según la Ley 23/2003; quince años Código civil) que a juicio del autor es una diferencia excesiva y no tiene razón de ser.

10 AVILÉS GARCIA, J. *Los contratos de compraventa de bienes de consumo*, cit., p.XIX. En el prólogo, CADARSO PALAU critica al legislador por no haber aprovechado la transposición de la Directiva 44/1999 para revisar de forma total y a fondo el régimen codificado de la compraventa civil y mercantil. El autor, AVILÉS GARCIA, p. 161ss. hace hincapié en esta necesidad, citando a un gran número de autores que se pronuncian en este sentido. Con anterioridad a la transposición algunos autores plantearon propuestas para la adaptación de nuestro sistema de responsabilidad al mandato de la Directiva en los que se proponía una reforma integral. Obviamente no fueron tomados en consideración. En este sentido ver: PANTALEÓN PRIETO, F. Las nuevas bases de la respon-

Si retomamos la sentencia analizada, vemos que el Tribunal Supremo sigue el esquema anglosajón antes referido, en cuanto que admite la distinción entre incumplimiento esencial y no esencial y en torno a él dicta sentencia. Nos interesa, llegado este punto ver el papel que dentro de este esquema le ha dado el Tribunal Supremo a la *quanti minoris*.

- 1º. Tal y como el remedio aparece configurado, lo aparta totalmente de su sentido originario en cuanto que no lo circunscribe a los vicios o defectos ocultos.
- 2º. La rebaja en el precio entra en juego en el caso de un incumplimiento no esencial que por tanto no supondría la resolución del contrato.
- 3º. A la hora de cuantificar la rebaja del precio lo relaciona directamente con los daños y perjuicios sufridos. Aquí se aparta del criterio de la Convención de Viena, de la Directiva 44/1999 y de la Ley 23/2003, a mi modo de ver produciendo una confusión entre el valor intrínseco que puede tener la *quanti minoris* y lo que sería una indemnización de daños y perjuicios.

Creo que el criterio de valoración de la reducción del precio debe ser, como dice la Convención de Viena y recoge nuestra ley, una acomodación al valor realmente recibido. La *quanti minoris* nos sirve para establecer un equilibrio entre el precio estipulado y el valor recibido; su función no es compensar al comprador de otras posibles pérdidas, que en su caso se perseguirían con la acción de daños y perjuicios.

Llegado este punto, en el que hemos visto el juego de la institución en las compraventas mercantiles, en las compraventas de bienes de consumo y por tanto de protección al consumidor y su juego según esta sentencia del Tribunal Supremo, en este caso en una compraventa mercantil, quiero acabar haciendo hincapié en el valor añadido que tiene la institución como solución extrajudicial al problema del incumplimiento contractual¹¹.

La opción de la reducción del precio como una solución extrajudicial en los casos de incumplimiento no esencial puede resultar una enorme ventaja dentro del sistema del incumplimiento contractual. En este sentido venía interpretada en el Convenio de Viena, que, como ya hemos visto, podía en ocasiones evitar la necesidad de exigir daños y perjuicios que quedarían compensados con la adecuada reducción del precio. Como mecanismo negociador la concibieron los ediles curules y creo que ésta es la esencia que hay que potenciar¹². Me arriesgaría

sabilidad contractual. *Anuario de Derecho Civil*. 1993, Tomo XLVI, Fascículo IV, p. 1719-1746. ISSN: 0210-301X; MORALES MORENO, A.M. Adaptación del Código Civil al Derecho Europeo: La compraventa, cit. *passim*; FENOY PICÓN, N. *El sistema de protección del comprador*. cit., p. 220-244 recoge las propuestas de modificación planteadas en "La propuesta de Anteproyecto de Ley de Modificación del Código civil en materia de contrato de compraventa. (Propuesta de Anteproyecto) de la Comisión General de Codificación, publicado en el Boletín de información del Ministerio de Justicia de 1 de mayo de 2005.

11 En este sentido se manifiesta MARÍN LÓPEZ, M.J. Garantías y servicios postventa, cit., p. 1534. Sobre la necesidad de una ley de jurisdicción voluntaria y las ventajas de desjudicializar algunas cuestiones ver, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. Jurisdicción voluntaria: rectificar es de sabios, *El notario del Siglo XXI*. (mayo- junio 2013) nº 49.

12 NAVAS NAVARRO, S. El incumplimiento no esencial de la obligación, *Análisis del incumplimiento no esencial de las obligaciones contractuales de dar*. Madrid. Reus, 2004. p. 112. ISBN: 978-84-290-1399-3. cit. por FENOY PICÓN, N. *El sistema de protección del comprador*. cit., p. 55 pone en valor la Ley General de Venta de Bienes de Consumo precisamente porque todos los remedios que contempla son de ejercicio extrajudicial.

a decir que debía ser la primera de las opciones presentada a las partes para resolver problemas de incumplimiento puesto que en caso de acuerdo evitaría judicializar el problema¹³.

Hemos puesto de relieve como lo usual es que el pago del precio en la compraventa de bienes muebles se posponga a la entrega o incluso se aplaze, en estos casos basta que, ante un incumplimiento no esencial, el comprador, interesado en la cosa, renegocie el precio, opción menos costosa en términos de tiempo que exigir la reparación o la sustitución y desde luego mucho menos que exigir la rescisión del contrato. Esto agilizaría sin duda el tráfico jurídico.

CONCLUSIONES:

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2013 avala la extensión de los principios de Derecho anglosajón en materia de incumplimiento contractual más allá de la venta de bienes de consumo (ley 23/2003).

1. En el marco de estos principios del common law, tal y como hace la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, la Directiva 44/1999 sobre Determinados Aspectos de la Venta y las Garantías de los Bienes de Consumo y la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, es conveniente introducir la *actio quanti minoris* o acción de rebaja del precio propia de los sistemas continentales, pero adaptando su configuración a los casos de incumplimiento contractual, apartándola de su configuración en los códigos como remedio al saneamiento por vicios ocultos.
2. La nueva *quanti minoris* amplía su contenido y se reconduce como solución a los supuestos de incumplimiento no esencial.
3. La nueva *quanti minoris* debe poder plantearse como remedio extrajudicial al incumplimiento contractual.
4. La nueva *quanti minoris* recupera sus valores originarios como un sistema de responsabilidad objetiva que la retrotrae a su origen romano.

13 Aquí nos plantearíamos ir más allá y concebir la opción de la rebaja del precio como un remedio que el consumidor pudiera escoger desde el principio, tal y como ocurre en la Convención de Viena. Autores como MARÍN LÓPEZ, M.J. *Garantías y servicios postventa*, cit., p. 1524, aun partiendo de la premisa de que el consumidor adquiere productos estandarizados, por tanto cosas genéricas, y que estará más interesado en la sustitución que en la rebaja del precio, siendo, por otro lado, la sustitución el remedio más factible, añade que no ve motivo para que no se haya permitido al consumidor desde el principio exigir una rebaja del precio, si así lo quiere ¿por qué impedirlo? El mismo autor pone de manifiesto que aquí el legislador español optó, siguiendo en esto a la Directiva, por proteger los intereses de los vendedores y fabricantes para quienes recurrir a la reducción del precio supondría un coste añadido en el sentido de renegociar continuamente los contratos, perdiendo ingresos. A los fabricantes o vendedores les es más fácil reparar o sustituir el bien, prueba de ello es que ésta es la opción que dan en las garantías comerciales.

MARTÍN ARESTÍ, P. *Las garantías de los productos de consumo*. cit., p.82, entiende que el legislador ha pretendido con la jerarquización buscar un equilibrio entre los intereses del consumidor y el interés del empresario, evitando la opción masiva por la resolución del contrato, que desde luego no beneficiaría en absoluto los intereses de vendedores y fabricantes ni los intereses de los mercados y favoreciendo, igualmente la opción de la reparación frente a la sustitución, medida que favorece el mercado de servicios de reparación y piezas de recambio, a la vez que se permite mantener el equilibrio entre los mercados de productos nuevos y de segunda mano.

BIBLIOGRAFÍA:

- AVILÉS GARCIA, J. *Los contratos de compraventa de bienes de consumo*. Granada. Comares, 2006. ISBN 9788498361469.
- CARRASCO PERERA, A.F. y otros. Transposición de la Directiva comunitaria sobre venta y garantía de los bienes de consumo. *Estudios sobre Derecho de consumo*. 2000, nº 52. p. 125-146. ISSN-e 0212-9469.
- CASTILLA BAREA, M. *El nuevo régimen legal del saneamiento en la venta de bienes de consumo*. Madrid. Dykinson, 2005. ISBN 10: 8497726499 ISBN 13:9788497726498.
- FENOY PICÓN, N. *El sistema de protección al comprador*. Madrid. Cuadernos de Derecho Registral, 2006. ISBN 9788496347809
- FERNANDEZ DE BUJÁN, A. Jurisdicción voluntaria: rectificar es de sabios. *El notario del Siglo XXI*. (mayo - junio 2013) nº 49.
- MARÍN LÓPEZ, M.J. Las garantías en la venta de bienes de consumo en la Unión Europea. La Directiva 1999/44/CE y su incorporación en los Estados miembros. Tomo I. Madrid. Instituto Nacional de Consumo, 2004. ISBN 84-96450-00-7.
- MARÍN LÓPEZ, M.J. Garantía y servicios postventa. en BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R. Comentario al Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 2007). Pamplona. Aranzadi, 2009. p. 1405- 1605. ISBN: 978-84-9903-264-1.
- MARTÍN ARESTI, P. *Las garantías de los productos de consumo*. Pamplona. Aranzadi, 2010. ISBN: 9788499035024.
- MONTAÑANA CASANÍ, A. La *actio quanti minoris* en la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, en RESINA SOLA, P. (Ed.) *Fundamenta Iuris. Terminología, principios e interpretatio*. Almería. Universidad de Almería, 2012. ISBN-10: 8415487177. ISBN13: 978-8415487173.
- MORALES MORENO, A.M. Adaptación del Código civil al Derecho Europeo: la compraventa. *Anuario de Derecho Civil*. 2003, Tomo LVI, Fascículo IV, p. 1609-1651. ISSN: 0210-301X
- NAVAS NAVARRO, S. El incumplimiento no esencial de la obligación, Análisis del incumplimiento no esencial de las obligaciones contractuales de dar. Editorial Reus. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-290-1399-3
- PANTALEÓN PRIETO, F. Las nuevas bases de la responsabilidad contractual. *Anuario de Derecho Civil*. 1993, Tomo XLVI, Fascículo IV, p.1719-1746. ISBN: 0210-301X.
- VÉRGEZ SÁNCHEZ, M. La protección del consumidor en la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Pamplona. Aranzadi, 2004. ISBN: 978-84-9767-334-1.
- VICENT CHULIA, F. *Introducción al Derecho Mercantil*. 18º edición. Valencia. Tirant lo Blanch, 2005. ISBN: 84-8456-437-1.

ALGUNOS EJEMPLOS SOBRE MEDIDAS BANCARIAS DE NATURALEZA PÚBLICA EN LA ANTIGUA ROMA

SOME EXAMPLES ABOUT BANK MEASURES OF PUBLIC NATURE IN THE ANCIENT ROME

ANA I. CLEMENTE FERNÁNDEZ

Universidad de Castilla-La Mancha

Corre el año 33 d. C., al frente del Imperio romano se halla el emperador Tiberio¹. Se desata una violenta confrontación entre acreedores y deudores. Tácito² relata con detalle

1 En los Anales de Tácito, crónica con una pretensión moralizante y política, hallamos una semblanza del emperador Tiberio teñida de una visión parcial; no obstante, también se reconoce su valía, al destacar su respeto por la tradición, su interés en la grandeza del Imperio, su sensatez en política, el hecho de ser contrario a las adulaciones y reacio a los honores, etc. Este enfoque no equitativo de Tácito parece tener su causa en su propia opción política, pues se muestra partidario del antiguo gobierno republicano y de sus instituciones, y al mismo tiempo reivindica la falta de igualdad política en el reinado de Tiberio, pero referida a la pérdida de privilegios de la clase senatorial a la que pertenecía. En esta descripción Tiberio aparece como un simulador de personalidad ambigua, que mantiene algunos de los principios del gobierno republicano y que conserva la *pax augustea*. Su carácter tuvo un peso importante en el desarrollo de su gobierno. Así, vemos que aunque Tácito pretende desempeñar su trabajo de analista *sine ira et studio*, como él mismo afirma (Tac., *Ann.*, 1.1), es decir, bajo el lema de la imparcialidad y sin odio, no puede evitar estar condicionado por su propio tiempo y por su pertenencia a un estamento social que ha dejado de ser protagonista de la dirección del gobierno político de Roma. Vid., BALMACEDA, C., *El emperador Tiberio en los Anales de Tácito*, en Onomazein, 6, 2001, pp. 281 ss.

2 Tac., *Ann.* 6. 16-17: Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris qua de modo credendi possidendique intra Italiam caventur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postponitur. sane vetus urbi faenebre malum et seditio discordiarumque creberima causa eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura. multisque plebi scitis obviam itum fraudibus quae toties repressae miras per artes rursus oriebantur. sed tum Gracchus praetor, cui ea quaestio evenerat, multitudine periclitantium subactus rettulit ad senatum, trepidique patres (neque enim quisquam tali culpa vacuus) veniam a principe petivere; et concedente annus in posterum sexque menses dati quis secundum iussa legis rationes familiaris quisque componerent.

Hinc inopia rei nummariae, commoto simul omnium aere alieno, et quia tot damnatis bonisque eorum diven- ditis signatum argentum fisco vel aerario attinebatur. ad hoc senatus praescripserat, duas quisque faenoris partis in agris per Italiam conlocaret. sed creditores in solidum appellabant nec decorum appellatis minuire fidem. ita primo concursatio et preces, dein strepere praetoris tribunal, eaque quae remedio quaesita, venditio et emptio,

esta crisis financiera surgida. En el desarrollo de su narración se acusa a quienes aumentaban sus caudales a través del método de la usura contraviniendo una norma que limitaba el crédito y la posesión dentro de Italia, regulación cuyo artífice fue el dictador César³. El historiador denuncia el olvido en que ha caído esta ley, puesto que el interés público se doblega frente al beneficio privado. La usura es la causa de estos males que generan tales desavenencias y alzamientos, que Tácito retrotrae a época antigua donde ya era reprimido este comportamiento, a pesar de ser un tiempo de mayor respeto a las costumbres. En este sentido, nos recuerda los límites impuestos por la legislación decenviral fijando una tasa de interés no superior a una onza con el objetivo de evitar las arbitrariedades de los ricos, para después, a petición de los tribunos, ser rebajado a media onza, y por último, quedar prohibido el interés. A pesar de esta reglamentación no faltaron las argucias que hacían resurgir nuevos fraudes. La investigación de este asunto correspondió al pretor Graco que, presionado por la situación, informó al Senado, cuyos miembros, ante la posibilidad de verse afectados, pidieron gracia al príncipe, que tuvo a bien determinar un plazo de un año y seis meses con el fin de que fueran puestas al día las cuentas patrimoniales.

Como corolario de este trance surgió una insuficiencia de numerario que Tácito explica aludiendo a las masivas reclamaciones de deudas y a las profusas condenas, con su consiguiente subasta de bienes, quedando retenida la plata amonedada por el fisco o el erario. Dadas estas circunstancias, el Senado prescribió que se invirtiera en tierras itálicas dos tercios del dinero prestado, medida contra la que reaccionaron los acreedores que podían ver mermar sus créditos. Así, la venta y la compra resultaban contraproducentes, habida cuenta de que los prestamistas habían atesorado el dinero con el fin de comprar tierras. Un aumento de las ventas trajo consigo una subsiguiente caída de precios, y el incremento de deudas provocó mayores dificultades para enajenar las tierras, con el consiguiente desfondamiento de patrimonios familiares. Estos efectos perniciosos quisieron ser paliados por el César poniendo a disposición de las bancas cien millones de sestercios a fin de autorizar préstamos sin interés durante tres años, si con antelación el deudor ofrecía al pueblo una garantía del doble en predios. Esta fue la fórmula que sirvió para restaurar el crédito, aunque no se realizó finalmente la compra de tierras que estipuló el Senado, según las noticias que nos facilita Tácito.

in contrarium mutari quia faeneratores omnem pecuniam mercandis agris condiderant. copiam vendendi secuta vilitate, quanto quis obaeratio, aegrius distrahebant, multique fortunis provolvebantur; eversio rei familiaris dignitatem ac famam praeceps dabat, donec tulit opem Caesar disposito per mensas milies sestertio factaque mutuandi copia sine usuris per triennium, si debitor populo in duplum praediis cavisset. sic reflecta fides et paulatim privati quoque creditores reperti. neque emptio agrorum exercita ad formam senatus consulti, acribus, ut ferme talia, initiis, incurioso fine.

3 La denominada *lex de modo credendi posidendique intra Italiam*. La *lex de pecuniis mutuis* (49 a.C.) introdujo cierto alivio para los deudores que habían contraído un préstamo de dinero, admitió la deducción de interés ya pagado del principal, la cancelación de interés en atrasos durante dos años, la admisión de pago en tierra en vez de en dinero efectivo, etc. Alguna modificación de esta ley fue prevista en una norma Cesárea posterior, aunque las nuevas disposiciones no son bien conocidas; no obstante, parece haber establecido que los capitalistas debían invertir en terrenos en Italia una determinada parte de sus haberes, y que la suma que se pudiese dar a préstamo fuese en proporción a los terrenos poseídos. Véase BERGER, A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, reimpr., 1991, p. 554, y ROTONDI, G., *Leges populi romani*, Milano, 1922, pp. 415 y 420.

Sobre esta delicada situación nos informa también Suetonio⁴. El tacaño y avariento Tiberio, según el autor, mostró su generosidad en escasas ocasiones, una de ellas cuando reembolsó a algunos propietarios de casas de vecindad que se habían incendiado en el monte Celio el precio que habían pagado por ellas, ante el horror de semejante catástrofe⁵; en otra ocasión ordenó poner a disposición del pueblo cien millones de sestercios sin interés por un período de tres años. La escasez de numerario obligó al emperador a tomar esta última medida ante la ayuda que demandaba el pueblo, y asimismo, decretó mediante el Senado que los prestamistas invirtieran en tierras dos partes de su patrimonio y que los deudores satisficieran otro tanto de su deuda.

Sobre estas mismas circunstancias, Dion Casio⁶ también atribuye a Tiberio haber renovado las leyes de César sobre los contratos⁷ que suscitaron una pérdida de confianza y una confusión financiera, y haber modificado su decisión sobre los préstamos poniendo a disposición del tesoro público cien millones de sestercios, con la indicación de que se destinaran para ser prestados por los senadores, sin interés.

Desde una perspectiva económica, la crisis del 33 d. C., a la que se refieren las fuentes mencionadas, se origina a raíz de ciertas vicisitudes adversas que afectan de lleno a la economía bajo el reinado de Tiberio. La acumulación de la riqueza gracias al empleo desmedido de la usura, junto al quebrantamiento de la ley promulgada por César sobre los límites del crédito y de la propiedad inmobiliaria en Italia, contrastaba con los serios apuros de los deudores para hacer frente al pago de las sumas debidas, de ahí sus frecuentes reivindicaciones contra los altos intereses⁸.

4 Sue., Tib., 48.2: *Publice munificentiam bis omnino exhibuit, proposito milies sestertium gratuito in trienni tempus et rursus quibusdam dominis insularum, quae in monte Caelio deflagrant, pretio restituto. Quorum alterum magna difficultate nummaria populo auxilium flagitante coactus est facere, cum per senatus consultum sanxisset, ut faeneratores duas patrimonii partes in solo collocarent, debitores totidem aeris alieni statim solverent, nec res expeditur; alterum ad mitigandam temporum atrocitatem.*

5 Tac. *Ann.*, 4.64.

6 Cass. Dio., 58.21.4-5: *About this time, however, a certain Vibullius Agrippa, a knight, swallowed poison from a ring and died in the senate-house itself; and Nerva, who could no longer endure the emperor's society, starved himself to death, chiefly because Tiberius had reaffirmed the laws on contracts enacted by Caesar, which were sure to result in great loss of confidence and financial confusion, and although Tiberius repeatedly urged him to eat something, he would make no reply. Thereupon Tiberius modified his decision regarding loans and gave one hundred million sesterces to the public treasury, with the provision that this money should be lent out by the senators without interest to such as asked for it; and he further commanded that the most notorious of those who were bringing accusations against others should be put to death in a single day.* [Loeb Classical Library edition, 1924, p241].

Como señala DE MARTINO, *Historia económica de la Roma antigua*, II, trad. E. Benítez, Madrid, 1985, p. 437, posiblemente la referencia de Dion Casio al suicidio del jurista Coceyo Nerva y a la renovación de las leyes de César es indicativo de que Nerva podría ser uno de los senadores afectados por las prescripciones del emperador.

7 Cass. Dio., 41.38.1, alude a una ley de César sobre la prohibición de poseer más de 60.000 sestercios en oro o plata: *Since also many were said to possess much wealth but to be concealing it all, he forbade any one to possess more than sixty thousand sesterces in silver or gold; and he claimed he was not enacting this law himself, but was simply renewing a measure introduced on some previous occasion.* [Loeb Classical Library edition, 1924, p67].

8 DE MARTINO, *op. cit.*, p. 436.

Otra circunstancia resulta coadyuvante para agravar esta delicada situación económica: la *inopia rei nummariae* o escasez de dinero en circulación. Ciertamente que bajo el gobierno de Tiberio la política de emisiones fue bastante restrictiva. ¿Esto explica la escasez de moneda circulante? DE MARTINO⁹ responde negativamente. El autor, ante el relato en cierta medida confuso de los efectos económicos de esta coyuntura de crisis que es realizado por Tácito, sólo puede concluir en lo esencial que las tierras que los deudores se veían obligados a vender por falta de liquidez disminuían el precio, lo que contribuía a la crisis general, y que esto se intentó remediar con un importante capital para créditos sin interés que facilitara afrontar a los deudores sus compromisos y dejar atrás los graves apuros económicos; aunque este estado de cosas tampoco posibilita establecer una relación de la crisis y las medidas adoptadas con la escasez de moneda en circulación, fruto de una política restrictiva del emperador Tiberio en el ámbito de la emisión de moneda¹⁰.

A tenor del relato de Tácito, ya se había producido una falta de liquidez debido a la venta de los bienes de las condenas de los cómplices de Sejano. Según ANDREAU¹¹, la venta de los bienes confiscados había colocado un exceso de tierras en el mercado y llevaba a las arcas del Estado una parte importante de existencias monetarias; así, para remediar esta falta de numerario, el emperador prestó sin interés, a partir de su fortuna personal, y por un plazo de tres años, una suma global de cien millones de sestercios, probablemente a través de oficinas financieras, dirigidas por senadores, y a cambio los prestatarios debían prestar garantías inmobiliarias. Fue un modo de reestablecer la *fides*, pero esta confianza, como se desprende del fragmento de Tácito, se vio de nuevo perturbada ante el laxismo y la negligencia imperantes que llevaron a dejar de aplicar la medida tomada por el Senado en materia de compra de tierras¹². Ciertamente, estos apuros financieros son susceptibles de interpretación con base a un simple principio económico según el cual el precio de la tierra y las tasas de interés son indisociables en una sociedad eminentemente agrícola¹³. Es más, el sistema de crédito romano pivotaba sobre tres pilares esenciales, a saber: la cantidad de dinero en circulación, la estabilidad del precio de la tierra y la confianza de los prestamistas en la capacidad de devolución de los deudores¹⁴.

Tornando al pasaje de Tácito, y ya bajo un prisma jurídico, el emperador Tiberio dispuso *per mensas* cien millones de sestercios destinados a ser puestos en circulación para conceder mutuos trienales sin intereses, siempre que mediara garantía *in duplum*. En

9 DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 435 ss.

10 En cuanto a la circulación monetaria, DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 435 ss., nos recuerda que en el principado de Augusto aumentaron las emisiones fruto de las exigencias políticas de consolidación del régimen, y diversas oscilaciones comenzaron a sucederse en torno a la depreciación de las monedas a partir de tiempos de Nerón.

11 ANDREAU, J., *Banque et affaires dans le monde romain. IV siècle av. J.-C. - II siècle ap. J.-C.*, Cambridge, 2001, p. 193.

12 ANDREAU, *Banque*, cit., p. 193.

13 Un análisis exhaustivo sobre los aspectos económicos concretos que atañen a la crisis del 33 ofrece TCHERNIA, A., *Remarques sur la crise de 33*, en *Credito e Moneta nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica* (Capri 12-14 ottobre 2000), a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2003, pp. 131 ss.

14 BARLOW, C.T., *The Roman Government and the Roman Economy, 92-80 B.C.*, en *AJPh*, 101, 1980, p. 212.

esta disposición del emperador observamos una particularidad al encontrarnos el término *mensa*¹⁵ en una medida referida a las tareas financieras del emperador¹⁶.

Pues bien, en esta esfera propia de las competencias de ámbito público que lidera el emperador llama la atención el empleo de la palabra *mensa*. Surge en este extremo un interrogante a partir del cual nos cuestionamos la utilización de este significante en un contexto que no es estrictamente el del ámbito privado. La decisión de Tiberio de colocar por *mensas* una importante suma de dinero podría ser considerada como un tipo de empresa bancaria privada¹⁷, de forma que el emperador habría acudido a los profesionales de la banca para que los fondos puestos a disposición por el Estado fueran distribuidos a los prestatarios. Sin embargo, también cabe la posibilidad de interpretar este mandato imperial como una actividad financiera pública, aunque la naturaleza jurídica de esta intervención haya sido sometida a debate. De manera que el modo de obrar del emperador ante estas crisis ha sido vista como una medida desarrollada mediante el aparato fiscal –*mensae fiscales*– a modo de una banca de Estado de época actual¹⁸, una especie de oficinas financieras de Estado, que funcionarían de modo permanente para tareas como la puesta en circulación de monedas nuevas o para el cobro de las sumas debidas al fisco¹⁹; por otra parte, también se piensa en una auténtica banca pública o comisión bancaria pública o comité bancario²⁰, ya que Tácito habla de *mensas* en plural; y, asimismo, se postula la idea de unas oficinas de pago para las que el emperador proveyó un servicio de crédito. Defiende esta última opinión ANDREAU²¹, partiendo del texto de Dion Casio (58.21) en el que se afirma que el pago de estos fondos públicos se materializó por la intervención de los senadores; según el citado autor, no habría habido necesidad de acudir a los senadores si el dinero hubiera sido entregado a empresas privadas o a *mensae fiscales*, por lo que las anteriores hipótesis son excluidas, y añade que el emperador creó esta institución excepcional que probablemente funcionó hasta el reembolso de los préstamos, articulando unas oficinas de pago para proveer el crédito por parte del Estado, cuya gestión estaría dirigida por los senadores, asumiendo la función financiera de distribuir los fondos que provenían del Tesoro Público.

15 El término técnico *mensa* designa en las fuentes romanas la empresa que actualmente denominamos banca, cuya acepción originaria es la de “banco” o “tabla” sobre la cual se desarrollaba la propia actividad, como nos recuerdan CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino, 2002, p. 71.

16 Un pasaje de Fírmico (Firm. Mat. Math. 8.19.7) también suscita controversias en torno a la expresión *mensae publicae*: In Arietes parte XVI quicumque habuerit horoscopum, erit negotiator sed affluentibus divitiis instructus, fenerator de mensis publicis colligens magna divitiarum subsidia, notus omnibus semperque perspicus. Generalmente, la citada expresión se ha interpretado como oficinas financieras bajo la gestión o control del Estado, según interpreta, ANREAU, J., *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent* (IV siècle av. J.-C. - III siècle ap. J.-C.), Roma, 1987, p. 453, nt. 41; sin embargo, PETRUCCI, *Mensam exercere*. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.), Napoli, 1991, pp. 50 ss, opone objeciones a esta apreciación, e invocando comparativamente un texto de Marcial (2.57.7), deduce que la calificación de *publicus* podría referirse más bien al hecho de que las *mensae* eran presentadas o dirigidas al público.

17 RODEWALD, C., *Money in the Age of Tiberius*, Manchester, 1976, pp. 2 y 70.

18 ROSTOVITZ, The social and economic history of the Roman Empire, I, reimpr., Oxford, 1963, p. 182.

19 Como aclara ANDREAU, *La vie*, cit., p. 462, oponiéndose a la interpretación de ROSTOVITZ.

20 LÉCRIVAIN, CH., *Magistratus extra ordinem creati*, en Daremberg et Saglio, III, p. 1538; FRANK, T., *et alii*, *An Economic Survey of Ancient Rome, V, Rome and Italy of the Empire*, Baltimore, 1933-1940, p. 34 s.

21 ANDREAU, *La vie*, cit., pp. 462 y 463.

Algunos precedentes permiten avalar la naturaleza pública de estas *mensae* dispuestas por Tiberio, tal y como también sostiene PETRUCCI²². En efecto, experiencias similares a la intervención de los senadores hallamos en las fuentes en el período republicano. Por ejemplo, la figura de los *quinqueviri mensarii* del año 352 a. C., que según Livio²³, ante los problemas que ocasionaba la gestión de los préstamos, ya que había demoras en los pagos y un abandono en su cumplimiento no siempre atribuible a la falta de medios, se creó una comisión designada por los cónsules, nombrando a cinco miembros que recibieron el apelativo de *mensarii* por la función que iban a cumplir distribuyendo el dinero ante la obligación pública del pago de deudas.

Esta comisión desarrolló su peliaguda tarea con éxito, y es un dato a destacar que no incurrieran en la malversación de fondos públicos y que no generaran malestar social, figurando finalmente los nombres de sus miembros en los anales; así, empleando fondos públicos cubrieron la deuda de los que podían proporcionar una buena garantía, y, a falta de esa garantía, los deudores pudieron transferir su propiedad a acreedores en concepto de reembolso de sus deudas²⁴. Esto fue posible en virtud de un plebiscito de *quinqueviris mensariis creandis*, disposición que vino a establecer una especie de banco público ante una situación de una deuda social considerable; según el panorama que describe Livio, no necesariamente parece que fuese una ley obligatoria para todos los ciudadanos, sino que pudo estar dirigida esta normativa principalmente a los plebeyos ante sus acuciantes problemas financieros, además de ser emitido en un contexto político tenso: recalcar que Publio Valerio Publícola tuvo de colega al plebeyo Gayo Marcio Rútulo, y que un plebeyo fue por vez primera elegido censor²⁵, se trataba por tanto de una comisión mixta²⁶. En palabras de NIZCYPORUK²⁷, los *quinqueviri mensarii* actuaron como banqueros en nombre y en beneficio del Estado, llevando a cabo transacciones financieras especialmente con los prestamistas; de forma que analizaron la deuda de los menos favorecidos y les ofrecieron ayuda financiera para evitar disturbios sociales. Este colegio de magistrados *mensarii*, de carácter extraordinario, trató de solventar los problemas de deuda con la intervención y el aval de la *res publica*, como asevera POLLERA²⁸. Según señala el citado autor, en definitiva, estamos

22 PETRUCCI, *op. cit.*, pp. 49 ss.

23 Liv. 7.21.5-8: Inclínatis semel in concordiam animis novi consules fenebrem quoque rem, quae distingere una animos videbatur, levare adgressi solutionem alieni aeris in publicam curam verterunt quinqueviris creatis quos mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt. Meriti aequitate curaque sunt, ut per omnium annalium monumenta celebres nominibus essent; fuere autem C. Duilius P. Decius Mus M. Papirius Q. Publilius et T. Aemilius. Qui rem difficillimam tractatu et plerumque parti utrique, semper certe alteri gravem cum alia moderatione tum impendio magis publico quam iactura sustinuerunt. Tarda enim nomina et impeditiora inertia debitorum quam facultatibus aut aerarium mensis cum aere in foro positus dissolvit, ut populo prius caveretur, aut aestimatio aequis rerum pretiis liberavit, ut non modo sine iniuria sed etiam sine querimoniis partis utriusque exhausta vis ingens aeris alieni sit.

24 NIZCYPORUK, P., *Mensarii, bankers acting for public and private benefit*, en *Studies in logic, grammar and rhetoric*, 24 (37), 2011, p. 108 s.

25 NIZCYPORUK, *op. cit.*, p. 108, nt. 14. Ver también Storchi Marino, *Quinqueviri mensarii: censo e debiti nel IV secolo*, en *Athenaum*, 81, 1993, pp. 213 ss.

26 *Concordia ordinum* en virtud de la presencia plebeya en la magistratura, según STORCHI, M., *op. cit.*, p. 235.

27 NIZCYPORUK, *op. cit.*, p. 110.

28 POLLERA, *op. cit.*, pp. 450 y 452.

ante una comisión de magistrados no ordinarios que actuaban como banqueros de una banca temporal de préstamos del Estado en cuyo nombre llevaban a término operaciones previstas en la ley; de modo que, en el ejercicio de su función, ofrecerían a los deudores de préstamos vencidos la posibilidad de liberarse con el dinero recibido del erario a cambio de una pública garantía, o bien darían la opción, a voluntad del deudor, de ceder sus propiedades, bajo estimación equitativa, obteniendo el acreedor como contrapartida el fundo o el bien mueble estimado.

La difícil situación económica que origina esta actuación de los *quinqueviri mensarii* tiene su origen en las transformaciones económicas sucedidas en la segunda mitad del siglo IV a. C.: la multiplicación de cambios, el comercio de ultramar, el juego de precios, el flujo de préstamos, el uso de la moneda de bronce, el mayor recurso al crédito, la insuficiente circulación de moneda, los altos tipos de interés, etc.; en un contexto como el descrito no bastaban para afrontar este panorama meras disposiciones sobre la regulación de las tasas de interés²⁹.

Efectivamente, solventar los problemas que generaban los débitos se convirtió en una cuestión de interés público, y la magistratura de los *quinqueviri mensarii* fue creada especialmente para cumplir con este objetivo. La tarea que realizaron transcurrió en un clima de concordia social *-homonoia-* y acorde con un concepto de *aequitas* ubicado en un punto intermedio entre *clementia* e *iustitia*³⁰. Estamos ante una propuesta de intermediación pública para resolver la cuestión de los adeudos, sin dañar a los deudores, y que quiere poner fin a la *inertia* o falta de iniciativa económica imperante en el momento³¹.

Más adelante, con ocasión de la segunda guerra púnica, fueron creados los *triumviri mensarii*, otras figuras de naturaleza similar a los mencionados *quinqueviri mensarii* y que se aproximaban a institutos seguidos en el área cultural griega³². En el año 216 a. C., la ausencia de medios para la paga de las tropas en Sicilia y Cerdeña provocó una situación crítica para la *res publica*, lo que condujo a la creación de esta magistratura, como narra Livio³³. Poco tiempo después, en el 214 a. C., ante las apremiantes necesidades bélicas, se realizó una manumisión de esclavos, convocando los *triumviri* a los dueños de los mismos para ofrecerles el precio de la liberación, pero la oferta fue rechazada por éstos y el reembolso fue retardado para después de la conclusión de la guerra³⁴. Más tarde, en el 210 a. C., se pidió a los magistrados y senadores que entregaran voluntariamente a los *triumviri* a favor del erario el mayor número posible de oro, plata y bronce acuñado para que cundiera el ejemplo en el resto del pueblo, proposición que resultó muy exitosa³⁵. A juicio de MASELLI³⁶, los *triumviri mensarii* se caracterizaron por ser una magistratura de carácter excepcional, pues no fue retomada posteriormente, y además los deberes que desempeñaron

29 POLLERA, *op. cit.*, pp. 449 y 454.

30 STORCHI, *op. cit.*, p. 215, nt. 13.

31 STORCHI, *op. cit.*, pp. 228 y 248.

32 MASELLI, G., *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione, propopografia, terminologia*, Bari, 1986, p. 14.

33 Liv., 23.21.6.

34 Liv., 24.18.12.

35 Liv., 26.36.8-11.

36 MASELLI, *op. cit.*, p. 14.

respondían a una coyuntura inusual en la que actuaron como cajeros públicos ante las necesidades económicas del Estado. El citado autor asimila esta magistratura romana a uno de los tipos de banca pública en el ámbito helénico, esto es, a órganos ciudadanos de tesorería –banca de Estado verdadera y propia frente a las bancas públicas titulares del monopolio del cambio–, salvando algunas diferencias entre estos institutos³⁷.

Junto a estos institutos jurídicos, que como hemos podido confirmar asumen ciertas funciones propias de la banca pública, y en relación con la medida adoptada en el 33, no podemos obviar que la cuantía económica que pone en circulación Tiberio –cien millones de sestericios– es muy elevada, de modo que se hace difícil sostener que para transferir estas vastas sumas el emperador se hubiese servido de empresas privadas, como asevera PETRUCCI³⁸. Y es razonable pensar, desde esta óptica, que a través de empresas públicas se podría someter esta actividad de provisión de crédito público a una mayor fiscalización debido a la ingente cuantía que suponía esta operación financiera. A esto cabe añadir la dificultad que una empresa de banca privada tendría para verificar el cumplimiento de la *conditio iuris* para la concesión del mutuo, así como el inconveniente para articular jurídicamente una *stipulatio* de garantía efectuada entre prestatario y banquero privado, teniendo como beneficiario al *populus*³⁹, trabas que, a nuestro juicio, son superables si se defiende la naturaleza pública de estas *mensae*.

Otra cuestión añadida a este tema pone el acento en encuadrar estas *mensae* en el aparato administrativo. Bien insertarlas en la esfera de la administración fiscal, bien considerarlas como un tipo de banca pública permanente, o bien como una oficina financiera temporal. Realmente, en ausencia de una planificación de directrices a seguir en el ámbito económico tal y como podemos entenderla hoy día, pues conviene matizar que en estas economías de las sociedades antiguas no faltan reglas y regulaciones en cierta manera predecibles, aunque no se hallen todas conceptualizadas⁴⁰, la política de intervención pública es esporádica, y entra en juego en momentos especialmente comprometidos en los que se requiere el empleo de dinero del tesoro público; a esta renuncia del aparato estatal a intervenir en las cuestiones socio-económicas contribuye la preponderancia que van asumiendo progresivamente los banqueros privados en conexión con el desarrollo de la monetización⁴¹.

Bajo el punto de vista de ANDREAU⁴², los romanos eran conscientes de un sistema de relaciones financieras que actuaba de manera autónoma, a modo de un mecanismo que tenía que reactivarse en caso de disfunción, y dejan de lado la teorización en estos aspectos; por ello, es en los casos de anomalías económicas cuando se hace visible la política financiera de los poderes públicos, en tanto que, en los períodos de normalidad, la tendencia es a no intervenir.

37 MASELLI, *op. cit.*, p. 15.

38 PETRUCCI, *op. cit.*, p. 49 s.

39 PETRUCCI, *op. cit.*, p. 50.

40 Aunque la falta de método y de sus ulteriores teoremas dificultan catalogar como ciencia a la economía política de las sociedades de la antigüedad, ello no es óbice para estudiar dichas economías, evitando adulterar aquella lejana realidad económica. Estas puntualizaciones responden a los análisis y reflexiones de FINLEY, M.I., *La economía de la antigüedad*, trad. J.J. Utrilla, Madrid, 1974, p. 23 s.

41 POLLERA, *op. cit.*, p. 455 s. El mencionado autor circunscribe sus aseveraciones a una gran parte del período republicano.

42 ANDREAU, *Banque, cit.*, p. 200.

ROSTOVTZEFF⁴³ habla incluso de una falta de política económica de los emperadores, en cuya gestión prevaleció la política del *laissez faire*, salvando las situaciones de emergencia, como por ejemplo sucedió en el reinado de Tiberio, tras los grandes terremotos en Asia Menor, momento en el que se adoptaron medidas relativas al perfeccionamiento del sistema de recaudación de impuestos, a la introducción de nuevos impuestos, a los transportes, etc.; pero tales medidas no tienen como objetivo mejorar o reajustar las condiciones económicas, sino que el fin principal radica en aumentar los ingresos del Estado desde una perspectiva puramente fiscal.

No obstante, si repasamos los ejemplos analizados, tanto la comisión de los *quinqueviri mensarii* creada ex profeso para gestionar temporalmente la concesión de créditos, como los magistrados *triumviri mensarii* actuando en un momento puntual como gestores de la caja pública estatal, y asimismo la disposición de Tiberio *per mensas* de una cuantiosa suma para realizar préstamos bajo la dirección de los senadores, todos ellos constituyen acciones encaminadas a lograr ciertos fines que aunque no están encuadrados en un diseño previo en el marco de una planificación político-financiera por parte del aparato estatal, sin embargo, es innegable que en cierta manera son coincidentes las funciones que cumplen estos institutos jurídicos con algunas de las finalidades propias del modelo de banca pública. Pensemos, por ejemplo, dentro de nuestro sistema financiero, en las Cajas de Ahorros⁴⁴, entidades de crédito que, además de asumir una función financiera, realizan una labor benéfico-social, ya que una gran parte de su beneficio se reinvierte en la sociedad a través de la obra social, canalizan el ahorro popular, además de financiar a familias o pequeñas y medianas empresas. Igualmente, el Instituto de Crédito Oficial (ICO)⁴⁵, configurado como

43 ROSTOVTZEFF, *op. cit.*, p. 89 s.

44 Los denominados Montes de Piedad fueron los antecedentes de las Cajas de Ahorros, instituciones apoyadas en fundamentos religiosos y que tenían como fin primordial otorgar préstamos a las clases sociales menos favorecidas, tratando de luchar contra la usura de la época. Andando en el tiempo las Cajas de Ahorros, a partir del RD. 2290/1977, sufren una equiparación operativa a los bancos y una tendencia general a liberalizar su actividad. La reciente crisis financiera y la mala praxis de los políticos que controlaban estas entidades ocasionaron las intervenciones y rescates por parte del Banco de España de algunas de ellas, lo que ha llevado a un relevante proceso de consolidación y reordenación bancaria a través de las fusiones y absorciones de las mismas, aunque estos procesos de ordenación, en opinión de los expertos, no son presididos por criterios de homogeneidad en el modelo de negocio de estas entidades, sino que son otras cuestiones (personales, políticas, administrativas, etc.) las que lamentablemente han guiado este proceso de reestructuración. Las medidas de saneamiento financiero no han sido las deseadas. De ahí que en la actualidad existan plataformas que reivindican la nacionalización de las Cajas de Ahorro o la creación de bancos públicos autonómicos. <http://www.expansion.com/diccionario-economico/caja-de-ahorros.html>.

45 El ICO es una entidad de crédito que realiza operaciones de financiación y que para obtener esos fondos se autofinancia acudiendo a los mercados financieros, con el respaldo de su carácter público, emitiendo bonos y títulos de deuda. Su objetivo principal consiste en sostener y promover las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan ser fomentadas. Sus principales funciones son contribuir a paliar los efectos económicos producidos por situaciones de grave crisis económica, catástrofes naturales u otros supuestos semejantes, y actuar como instrumento para la ejecución de determinadas medidas de política económica siguiendo las líneas fundamentales que establezca el Gobierno. Para llevar a cabo sus operaciones el ICO puede y suele utilizar la mediación de otras entidades financieras, por ejemplo, a través de los oportunos convenios de colaboración, suele conceder créditos a otras entidades bancarias para que estas los destinen a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Vid., <https://www.ico.es/web/ico/home>.

una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad y que tiene la consideración de Agencia Financiera del Estado, es una entidad que actúa principalmente como Banco Público concediendo créditos para financiar operaciones de inversión o necesidades de liquidez de las empresas, a través de grandes proyectos de inversión realizados por grandes empresas, o mediante intermediarios financieros (líneas de mediación), o bien adopta también la modalidad de Agencia Financiera del Estado, financiando a los afectados de catástrofes naturales, desastres ecológicos y supuestos de índole similar. Con independencia de que algunas de estas mencionadas entidades hayan incurrido en una praxis financiera no adecuada, al margen de la ética profesional que ha de regir estas actividades, sus acciones están motivadas por el interés público. En efecto, las Cajas de Ahorros, en concreto, tras el proceso de liberalización promovido en el año 1977, adoptaron el paradigma de los bancos privados, con una actuación negligente en la captación de pasivos, aventurándose en la financiación de inversiones de altísimo riesgo y sumamente especulativas, por no hablar también de la falta de transparencia en su gestión, bajo control de los políticos, que desembocó en un sistema de inversiones clientelar. Por todo ello, algunas corrientes de pensamiento, contrarias a las doctrinas del liberalismo económico, propugnan actualmente la defensa de la banca pública. Sin entrar en más valoraciones sobre esta cuestión, al menos no queremos dejar de subrayar que las Instituciones Financieras Públicas en momentos de crisis pueden resultar un motor clave en la recuperación económica al otorgar recursos para la financiación de proyectos o actividades que no tienen acceso al crédito mediante la banca privada.

De vuelta a la intervención de Tiberio, del año 33, ésta puede ser configurada como una estructura crediticia de carácter excepcional. Pero es innegable que estamos ante una provisión de fondos derivados de las arcas públicas ante las contingencias económicas surgidas⁴⁶. Además, que sea una medida puntual, no le resta oficialidad, y por supuesto no permite rebatir su naturaleza pública, ya que responde a una intervención del aparato estatal en tiempos de crisis financiera asimilable a la actividad crediticia que desempeñan en la actualidad los organismos adscritos a la banca pública. Podríamos denominarlo crédito oficial, aunque evidentemente aquí no nos encontramos ante un sistema institucionalizado, pero en todo caso nos hallamos ante una manifestación de una acción administrativa de fomento, que se caracteriza por una dilatada duración y que aparece dotada de unas condiciones de amortización que resultan más ventajosas que las ofrecidas por el crédito privado. En el

46 Volviendo de nuevo a los pasajes transmitidos por las fuentes, Dion Casio señala que Tiberio entregó la cuantiosa suma de dinero al tesoro público, por lo que esta cantidad debió proceder de los fondos del emperador, tal vez de sus bienes privados -su *patrimonium* estaría sustancialmente compuesto por bienes inmobiliarios- o del *fiscus caesaris* -nacido en el momento en el que los réditos del Imperio, especialmente de las provincias del *princeps*, comienzan a llegar no a la caja del *populus*, sino directamente al mismo *princeps*-, teniendo en cuenta que son dos esferas difícilmente escindibles, que se identifican y se confunden. En todo caso, es un capital procedente de las finanzas del emperador, que debido a su particular posición en la compleja realidad del Imperio asumen la función y destino de bienes en cierta medida públicos. Y esto vendría a afianzar el carácter público de la disposición financiera que emite Tiberio y de su articulación. El mismo patrimonio imperial, en la etapa julio-claudia, contaba con tales dimensiones que devino inevitablemente en uno de los pilares de la estructura financiera del Imperio. Para un mayor abundamiento en estos aspectos administrativos y financieros del Imperio romano, ver LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 50 ss.

fondo estos créditos oficiales son un estímulo instrumental para lograr una finalidad determinada. Un recurso empleado por el poder público para promover determinadas actuaciones cuya concreción es el corolario de opciones de naturaleza política. O dicho de otro modo, son opciones de política económica, operaciones que van a ser financiadas con el crédito oficial, dando respuesta a una delicada coyuntura económica. Y añadimos algo más que no podemos obviar: la *utilitas publica* de este tipo de medidas.

Las vicisitudes económicas de la etapa de Tiberio demuestran contraproducente la compra de activos inmobiliarios, puesto que los que habían concedido créditos habían acumulado todo el capital. La puesta en venta de propiedades provocaba seguidamente una bajada de precios, y a mayor endeudamiento, mayores reticencias a dejar las propiedades, acarreando una situación ruinosa. Previamente, la política económica de Augusto había fomentado, entre otros puntos de interés, las subvenciones a fondo perdido, había suavizado las exigencias para la concesión de créditos, y había potenciado masivamente las obras públicas⁴⁷. A la postre, sus medidas desencadenaron una expansión económica, que benefició a los menos favorecidos, pero que mermó en demasía las reservas del Estado. Podríamos compararlo, *mutatis mutandis*, con una burbuja económica como la que hemos vivido en tiempos recientes. Por su parte, Tiberio redujo el gasto público, fijó límites a los tipos de interés, endureció las condiciones para los créditos, etc., lo que provocó deflación, colapso en el crédito y desplome inmobiliario, y para solventar estos contratiempos financieros, emitió su medida de intervención económica, disposición que generó una expansión monetaria. En conclusión, podríamos calificar la intervención de Tiberio como una medida de rescate, concretada en una masiva inyección de fondos para superar la crisis bancaria del 33, restableciendo el flujo de créditos a través de una medida financiera pública, y es la *publice munificentiam*, según el pasaje de Suetonio, la que desencadena este gesto de generosidad de Tiberio⁴⁸.

BIBLIOGRAFÍA

- ANREAU, J., *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent* (IV siècle av. J.-C.- III siècle ap. J.-C.), Roma, 1987.
- ANDREAU, J., *Banque et affaires dans le monde romain. IV siècle av. J.-C.- II siècle ap. J.-C.*, Cambridge, 2001.

47 Desde el ámbito de la historiografía, en relación con estas cuestiones resulta de interés APARICIO, A., *Las grandes reformas fiscales del Imperio Romano (Reformas de Octavio Augusto, Diocleciano y Constantino)*, Oviedo, 2006, pp. 17 ss. Asimismo, es reseñable la particular visión de HOMO, L., *Nueva historia de Roma*, trad. J. Farrán y Mayoral, 7ª ed., Barcelona, 1981, pp. 236, que muestra a Augusto especialmente preocupado por no perturbar a los contribuyentes, evitando en general la creación de nuevos impuestos, procurando una mayor efectividad en las exacciones ya existentes y mejorando la administración, con la finalidad de obtener los recursos necesarios para un equilibrio presupuestario.

48 No obstante, esta apreciación de Suetonio es discutible, pues el emperador pudo verse impelido a tomar esta medida movido no tanto por su actitud generosa como por otros intereses más retóricos. Las mismas afirmaciones son válidas también para el relato, en cierta manera propagandístico, que viene de la pluma de Velejo Patérculo, historiador contemporáneo de Tiberio, cuyas referencias a la munificencia de este emperador (II.126.4; II.129.3; II.130.1-2), así como a otras muchas virtudes que le atribuye, desembocan en una caracterización del mismo como un emperador ideal. Vid., VÁZQUEZ, I., *La caracterización de César, Augusto y Tiberio en la Historia romana de Velejo Patérculo*, en *Myrtia*, 7, 1992, pp. 103 ss.

- APARICIO, A., *Las grandes reformas fiscales del Imperio Romano (Reformas de Octavio Augusto, Diocleciano y Constantino)*, Oviedo, 2006.
- BALMACEDA, C., *El emperador Tiberio en los Anales de Tácito*, en *Onomazein*, 6, 2001, pp. 281 ss.
- BARLOW, C.T., *The Roman Government and the Roman Economy, 92-80 B.C.*, en *AJPh*, 101, 1980, pp. 202 ss.
- BERGER, A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, reimpr., 1991.
- CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino, 2002.
- DE MARTINO, *Historia económica de la Roma antigua*, II, trad. E. Benítez, Madrid, 1985.
- FINLEY, M.I., *La economía de la antigüedad*, trad. J.J. Utrilla, Madrid, 1974.
- FRANK, T., et alii, *An Economic Survey of Ancient Rome*, V, Rome and Italy of the Empire, Baltimore, 1933-1940.
- HOMO, L., *Nueva historia de Roma*, trad. J. Farrán y Mayoral, 7ª ed., Barcelona, 1981.
- LÉCRIVAIN, CH., *Magistratus extra ordinem creati*, en *Daremberg et Saglio*, III, p. 1538.
- LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000.
- MASELLI, G., *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione, propopografia, terminologia*, Bari, 1986.
- NIZCYPORUK, P., *Mensarii, bankers acting for public and private benefit*, en *Studies in logic, grammar and rhetoric*, 24 (37), 2011, pp. 105 ss.
- PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)*, Napoli, 1991.
- RODEWALD, C., *Money in the Age of Tiberius*, Manchester, 1976.
- ROSTOVITZEFF, *The social and economic history of the Roman Empire*, I, reimpr., Oxford, 1963.
- ROTONDI, G., *Leges publicae populi romani*, Milano, 1922.
- STORCHI, M., *Quinquaginta mensarii: censo e debiti nel IV secolo*, en *Athenaum*, 81, 1993, pp. 213 ss.
- TCHERNIA, A., *Remarques sur la crise de 33*, en *Credito e Moneta nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 12-14 ottobre 2000)*, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2003, pp. 131 ss.
- VÁZQUEZ, I., *La caracterización de César, Augusto y Tiberio en la Historia romana de Velejo Patérculo*, en *Myrtia*, 7, 1992, pp. 103 ss.

PRIVILEGIOS DE LA BANCA RESPECTO DE LOS INTERESES EN LOS PRÉSTAMOS: ¿LEGALIDAD Y/O UTILIDAD?

MARÍA SALAZAR REVUELTA

Universidad de Jaén

I. PREMISA

Es evidente que una de las actividades más usual e importante realizada por parte de los *argentarii* (si bien no exclusiva de ellos) era el préstamo de capitales a interés, comúnmente designado por las fuentes jurídicas con las expresiones *pecunias faenerare* o bien *mutuas pecunias dare*¹. Se trataba de un negocio muy difundido en el ámbito comercial y financiero, unido al desarrollo comercial y al crecimiento económico que la sociedad romana experimenta, sobre todo a partir del siglo III a. C.

Técnicamente se configuró a través de la *stipulatio usurarum* añadida a la conclusión del contrato de mutuo, accesoria e independiente de éste². Esta práctica, dejada a la *bona fides creditorum*, propició, como no, abusos y originó toda una política legislativa con la finalidad de acotar los intereses convencionales.

Precisamente, la continuada fijación de tasas de interés³ mediante la sucesión de diferentes *leges fenebres*, que se remontan al menos a las XII Tablas⁴, revela la inutilidad e

1 D. 14,3,19,3 (Pap. 3 resp.): *servus pecuniis tantum faenerandis praepositus...*; D. 14,5,8 (Paul. 1 decret.): *Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis...*

2 Vid., por todos, KASER, M., “Mutuum und stipulatio”, *Ausgewählte Schriften* 2, 1976, pp. 156 ss.; MASCHI, C. A., *La gratuità del mutuo classico*, en *Studi Balladore Pallieri*, Milano, 1978, pp. 289 ss.; SALAZAR, M., *La gratuidad del mutuum en el Derecho romano*, Jaén, 1999, pp. 223 ss.

3 Es obvio que la evolución histórica de la fijación de límites legales al interés varía según las circunstancias económico-sociales de cada época. Así, en una primitiva economía pre-monetaria la limitación no se siente tan necesaria como cuando los préstamos devienen pecuniarios, en los que la determinación de los tipos de interés depende de la disponibilidad de moneda acuñada en cada momento y de la necesidad de impulsar el comercio y, por ende, las relaciones crediticias. Vid. DE MARTINO, F., “Riforme del IV secolo a. C.”, *BIDR* 78, 1975, p. 63; CERVENCA, G., “*Usura (dir. rom.)*”, *EdD* 45, 1992, p. 1.126; CAPONE, P., “Gli interventi edilizi nella repressione delle usure”, *Labeo* 45, 1999, pp. 237 ss.; TORRENT, A., “Moneda, crédito y derecho penal monetario en Roma (s. IV. a. C.- IV d. C.)”, *SDHI* 73, 2007, pp. 126; 140; ID., “Actividad bancaria e inflación en época diocleciana-constantiniana”, *Ivra* 57, 2008-2009, pp. 81 ss., donde sostiene la notable disminución, si bien la no desaparición, de la actividad bancaria coincidente con la crisis económica de finales del s. III. Del mismo autor, vid. *Contratos bancarios e inflación (284-361 d. C.)*, en *O sistema contratual romano: De Roma ao Direito actual*, Coimbra, 2010, pp. 233 ss.; “Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto”, *AUPA* 56, 2013, pp. 181 ss.

4 Para un estudio evolutivo sobre la fijación de los distintos tipos de interés en las denominadas *leges fenebres* vid. SALAZAR, M., *La gratuidad*, cit., pp. 174 ss., con bibliografía al respecto. Igualmente, para una

ineficacia de éstas y nos confirman cómo Roma padeció largamente los efectos devastadores de la usura a lo largo de toda su historia, hasta el extremo de constituir una de las más importantes reivindicaciones de la plebe⁵.

La regulación del interés en los préstamos da lugar, por tanto, a un proceso legislativo muy diferente y alternativo, plagado de disposiciones normativas limitadoras de la usura, junto a todo tipo de medidas tendentes a proteger al deudor y dotarlo de unas mínimas garantías para la satisfacción de sus créditos. No obstante, a pesar del espíritu de *favor debitoris* en el que estaban impregnadas las sucesivas prohibiciones legales, éstas no consiguieron otro resultado que abrir la puerta al fraude⁶. En el tema de la regulación de la usura se percibe muy claramente cómo la realidad social supera a la jurídica, de forma que la vía fraudulenta cubre las necesidades de la praxis económica.

En este contexto, conviene analizar el papel que juega el sector bancario respecto del préstamo feneraticio y su posición en el marco de las sucesivas disposiciones que determinan los tipos de interés. Partimos brevemente de la situación en las épocas republicana e imperial, afrontando el problema en su globalidad a través del examen de algunas fuentes literarias, ya que jurídicamente no hay datos para sostener un régimen diferenciado para la banca por lo que a las tasas usurarias se refiere. Ello nos sirve como primer acercamiento para poner el acento en las medidas de política legislativa adoptadas por el derecho justinianeo en orden a la corrección de los tipos en función de determinadas

visión global del crédito, el interés y sus tasas a partir de época republicana vid. entre la abundante literatura, ROTONDI, G., *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912 (reimpr. Hildesheim, 1962), pp. 99 ss; ID. *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, en *Scritti Giuridici* 3, Milano, 1922, pp. 390 ss.; APPLETON C., "Contribution a l'histoire du prêt à intérêt à Rome. Le taux du *foenus unciarium*", *RHD* 43, 1919, pp. 467 ss.; PAIS, E., *A proposito delle leggi sull'usura*, en *Ricerche sulla storia del diritto pubblico di Roma*, Roma, 1921, pp. 33 ss.; MICHEL, J., *Gratuité en droit romain*, Bruxelles, 1962, pp. 108 ss; ROYER, J. P., "Le problème des dettes à la fin de la République romaine", *RHDFE* 45, 1967, pp. 191-240 y 407-450; BARLOW, Ch. T. *Bankers, Moneylenders, and Interest Rates in the Roman Republic*, Michigan, 1978; DI LELLA, L., *Il plebiscito Sempronio del 193 a. C. e la repressione delle 'usurae'*, en *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche* 95, 1984, pp. 268 ss.; TILLI, G., "Postremo vetita versura", *BIDR* 86-87, 1984, pp. 147-163; WILLE, K., *Die 'Versur'. Eine rechtshistorische Abhandlung über die Zinskapitalisierung im alten Rom*, Berlin, 1984, pp. 34 ss.; JOANNIQUE, P., Rc. a Klaus Wille, *Die 'versur'*, *RHDFE* 63, 1985, pp. 371 ss.; FASCIONE, L., *La legislazione di Genucio*, en *Legge e società nella Repubblica romana* 2, Napoli, 1988, 5 estr.; CERVENCA, G., "Usura", cit., pp. 1.125 ss.; STORCHI MARINO, A., "Quinqueviri mensarii: censo e debiti nel IV secolo", *Athenaeum* 81, 1993, pp. 244 ss.; CIOCCA, P., *Moneta e credito nella Roma del Primo Impero*, en *Atti Acc. Roman. Costant.* 12, 1998, pp. 31 ss.; GELPÍ, R. M.-Labrúyère, F. J., *Historia del crédito al consumo*, Barcelona, 1998, pp. 29 ss.; MROZEK, S., 'Faenus': *Studien zu Zinsproblemen zur Zeit des Prinzipats*, Stuttgart, 2001, pp. 28 ss.; ANDREAU, J., *Banque et affaires dans le monde romain. IV^e siècle av. J. C.- III^e siècle ap. J. C.*, Paris, 2001, pp. 171 ss.; GIUFFRÉ, V., *Il 'mercato comune' nel s. IV a.C., il credito e la lex Silia*, en *Credito e moneta nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica*, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2003, pp. 32 ss.; SOLIDORO, L., "Tassi usurari e giurisdizione", *Diritto@storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 7, 2008, URL: <http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Solidoro-Tassi-usurari-giurisdizione.htm>.

5 Vid. TAFARO, S., "La limitazione dei debiti", *Diritto@storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 6, 2007, p.1.

6 OTERO DÍAZ, C., "Perspectiva histórica de la represión de la usura", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid*, vol. 8, nº 21, 1964, p. 425.; SALAZAR, M., *Les sanctions pénales des usurae illicitae dans les codes romains des périodes post-classique et byzantine et leurs antécédents historiques*, en J. M. Carbasse-M. Ferret, *Doctrine et pratiques pénales en Europe*, Montpellier, 2012, pp. 45 ss.

categorías de personas, entre las que se encuentra en primer plano la figura del banquero. Es en esta sede donde observaremos, con mayor precisión de fuentes jurídicas, el carácter privilegiado de la especial normativa aplicable a estos operadores financieros, dado que la Cancillería imperial es perfectamente permeable a la realidad económica, a las presiones de determinados sectores y, en suma, a las exigencias objetivas del momento. Además, como tendremos ocasión de constatar, se tenía muy presente en todo momento la *utilitas publica* del papel cívico que desempeñaba la banca.

II. POSICIÓN DE LA BANCA CON RESPECTO A LA REGULACIÓN DE LOS INTERESES EN LAS ÉPOCAS PRECLÁSICA Y CLÁSICA

El cuadro de la sociedad romana de época republicana nos muestra un fuerte combate hacia las prácticas usureras y los especuladores, a través de una profusa legislación –que, como hemos dicho, se remonta ya a las XII Tablas– para frenar los intereses excesivos en los préstamos. La abundancia y reiteración de medidas de este tipo indica precisamente que su ignorancia o vulneración no debió ser excepcional. Tampoco el negocio bancario está exento de estas prevenciones legislativas, ni al margen de estos hábitos transgresores.

Un pasaje del *Curculio* de Plauto (vv. 505-511) es una buena prueba de la exhaustiva regulación normativa que existía ya en época republicana sobre el tipo de interés que pesaba también sobre el *argentarius* en su actividad crediticia, sin exenciones, ni concesiones determinadas. No obstante, se destaca el frecuente quebrantamiento de esta legislación feneraticia. En este texto plautino Gorgojo dirige unas duras palabras al banquero Licón, descrito por el comediógrafo como deudor moroso y acreedor sin entrañas.

LI.— Caray, tuerto, tengo para mí que te conoces bien el gremio de los rufianes.

GO.— pues, por Hércules, a vosotros os pongo a la misma altura: sois lo mismísimo que ellos, y los rufianes al menos se ponen en lugares apartados, pero vosotros en la misma plaza; vosotros despedazáis a los demás con la usura, los rufianes induciendo a la gente al mal y con sus casas de trata. Muchas han sido las leyes dictadas por el pueblo por vuestra causa, pero, una vez dictadas, tiempo os falta para violarlas: siempre encontraréis alguna escapatoria; para vosotros son las leyes como el agua hirviendo, que no tarda mucho en enfriarse⁷.

Aquí, la figura del banquero es comparada con la del alcahuete o lenón en la búsqueda de la desgracia para los hombres, con la práctica abusiva de la usura por parte de aquél. Se alude a la gran cantidad de medidas legislativas que la regulan, pero al mismo tiempo se habla de su violación puntual mediante subterfugios o evasivas. Precisamente

⁷ Eodem hercle vos pono et paro ; parissimi estis hibus. Hi saltem in occultis locis prostant, vos in foro ipso ; vos fenore, hi male suadendo et lustris lacerant homines. Rogitationes plurimas propter vos populus scivit, quas vos rogatas rumpitis ; aliquam reperitis rimam ; quasi aquam ferventem frigidam esse ita vos putatis leges (Plaut. *Curc.* vv. 506-511. Vid. la traducción en Plauto, *Comedias II*, trad. revisada por J. A. Enríquez González, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 16).

la referencia a los plebiscitos *fenebres* es un importante argumento a favor de que toda la legislación limitadora de los intereses convencionales que observamos ya en el siglo III a. C. era igualmente aplicable a los *argentarii*, sin privilegios de “clase”⁸.

Sin embargo, no faltan en las fuentes literarias ejemplos en los que los banqueros se presentan como individuos cuya conducta no puede inscribirse en la esfera de la honestidad, ya que actúan con artificios y engaños. Así, los testimonios ciceronianos que describen las actividades financieras del *argentarius* son una buena muestra. Como en el *De officiis* 3,14,58-60 donde Cayo Canio es engañado por el banquero Pitio en la compra de una casa de éste último, valiéndose además de su posición de banquero, porque *qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratosus*⁹. Asimismo, en *Pro Fonteio* 5,11¹⁰, Cicerón hace una defensa de Fonteyo sosteniendo que las expoliciones y abusos que se le imputan *pro praetore* no son cometidas por él, sino por banqueros, cambistas y especuladores de Roma, que habían invadido las Galias. Ello revela la importante intervención de estas personas, como operadores de préstamos, depósitos o cambios de moneda, actuando de intermediarios entre la administración romana y los provinciales, en muchos casos con

8 PETRUCCI, A., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, p. 91.

9 De officiis 3,14,58-60 [58] Quod si vituperandi qui reticuerunt, quid de iis existimandum est, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otandi, ut ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod cum percrebuisset, Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed licere uti Canio, si vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in posterum diem. Cum ille promississet, tum Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratosus, piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixitque quid eos facere vellet. Ad cenam tempori venit Canius; opipare a Pythio adparatum convivium, cumbarum ante oculos multitudo, pro se quisque, quod ceperat, adferebat; ante pedes Pythii pisces abiciebantur.[59] Tum Canius “quaeso”, inquit, “quid est hoc, Pythi? tantumne piscium? tantumne cumbarum?” Et ille: “Quid mirum?” inquit, “hoc loco est Syracusis quidquid est piscium, hic aquatio, hac villa isti carere non possunt.” Incensus Canius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet. Gravate ille primo. Quid multa? impetrat. Emit homo cupidus et locuples tanti, quanti Pythius voluit, et emit instructos. Nomina facit, negotium conficit. Invitat Canius postridie familiares suos, venit ipse mature, scalum nullum videt. Quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret. “Nullae, quod sciam,” ille, “sed hic piscari nulli solent. Itaque heri mirabar quid accidisset.”[60] Stomachari Canius, sed quid faceret? Nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus, respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sane luculente, ut ab homine perito definiendi. Ergo et Pythius et omnes aliud agentes, aliud simulantes perfidi, improbi, malitiosi. Nullum igitur eorum factum potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum.

10 . . . hoc praetore oppressam esse aere alieno Galliam. A quibus versuras tantarum pecuniarum factas esse dicunt? a Gallis? Nihil minus. A quibus igitur? A civibus Romanis qui negotiantur in Gallia. Cur eorum verba <non> audimus? cur eorum tabulae nullae proferuntur? Insector ultro atque insto accusatori, iudices; insector, inquam, et flagito testis. Plus ego in hac causa laboris et operae consumo in poscendis testibus quam ceteri defensores in refutandis. Audaciter hoc dico, iudices, non temere confirmo. Referta Gallia negotiatorum est, plena civium Romanorum. Nemo Gallorum sine cive Romano quicquam negoti gerit, nummi in Gallia nulli sine civium Romanorum tabulis commovetur.

abusos que provocaron revueltas como la que describe Tácito (*Ann.* 3,40)¹¹ en el año 21 d. C. en las ciudades de la Galia ante la magnitud de las deudas contraídas¹².

No obstante, de otro texto de Cicerón (*ad fam.* 13,56) parece que no se puede inferir, en un principio, una desviación para los banqueros del régimen general sobre los límites legales de los intereses convencionales:

Caunii praeterea debent, sed aiunt se depositam pecuniam habuisse: id velim cognoscas et, si intellexeris eos neque ex edicto neque ex decreto depositam habuisse, des operam, ut usurae Cluvio instituto tuo conserventur. His de rebus eo magis laboro, quod agitur res Cn. Pompeii etiam, nostri necessarii, et quod is magis etiam mihi laborare videtur quam ipse Cluvius, cui satisfactum esse a nobis valde volo. His de rebus te vehementer etiam atque etiam rogo.

El texto refiere una misiva que Cicerón dirige al gobernador Q. Minucio Termo en orden a un préstamo que los habitantes de Cauno deben al banquero Cluvio, para que se cerciore de que el dinero está depositado según lo dispuesto en el edicto provincial o en base al decreto del gobernador, de modo que le sean también pagados a Cluvio los intereses convencionales¹³. De hecho, las palabras: *des operam, ut usurae Cluvio instituto tuo conserventur* parecen aludir a la disposición del magistrado (edicto o decreto) de reconocimiento de las *usurae* y su consecuente exigibilidad.

Este régimen conecta con cuanto emerge de otros testimonios ciceronianos acerca de las limitaciones sobre el tipo de interés contenidas en los edictos provinciales. No olvidemos el edicto del propio Cicerón emitido en Cilicia el año 51 a.C. (*ad Att.* 5,2,1,19)¹⁴, que a su vez tenía su precedente en el de Lúculo (72-70 a.C.)¹⁵. Asimismo, la alusión a los poderes

11 Eodem anno Galliarum civitates ob magnitudinem aeris alieni rebellionem coeptavere, cuius extimulator acerrimus inter Treviros Iulius Florus, apud Aeduos Iulius Sacrovir. nobilitas ambobus et maiorum bona facta eoque Romana civitas olim data, cum id rarum nec nisi virtuti pretium esset. ii secretis conloquiis, ferocissimo quoque adsumpto aut quibus ob egestatem ac metum ex flagitiis maxima peccandi necessitudo, componunt Florus Belgas, Sacrovir propiores Gallos concire. igitur per conciliabula et coetus seditiosa disserebant de continuatione tributorum, gravitate faenoris, saevitia ac superbia praesidentium, et discordare militem audito Germanici exitio. egregium resumendae libertati tempus, si ipsi florentes quam inops Italia, quam inbellis urbana plebes, nihil validum in exercitibus nisi quod externum, cogitarent.

12 A este respecto vid. GARCÍA GARRIDO, M. J., *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano*, Madrid, 2001, pp. 96 s.

13 Vid. D. 26,7,7,7 (Ulp. 35 *ad ed.*).

14 También *ad Att.* 6,1,7: illud quidem fatebitur Scaptius, me ius dicente sibi omnem pecuniam ex edicto meo auferendi potestatem fuisse. addo etiam illud quod vereor tibi ipsi ut probem. consistere usura debuit quae erat in edicto meo. deponere volebant: impetravi a Salaminus ut silerent. veniam illi quidem mihi dederunt, sed quid iis fiet, si huc Paulus venerit? sed totum hoc Bruto dedi; qui de me ad te humanissimas litteras scripsit, ad me autem, etiam cum rogat aliquid, contumaciter, adroganter, akoinonoetos solet scribere. tu autem velim ad eum scribas de his rebus, ut sciam quo modo haec accipiat; facies enim me certiore. atque haec superioribus litteris diligenter ad te per scripseram sed plane te intellegere volui mihi non excidis illud quod tu ad me quibusdam litteris scripsisses, si nihil aliud de hac provincia nisi illius benevolentiam deportassem, mihi id satis esse. sit sane, quoniam ita tu vis, sed tamen cum eo credo quod sine peccato meo fiat. igitur meo decreto soluta res Scaptio stat. quam id rectum sit tu iudicabis; ne ad Catonem quidem provocabo.

15 Plut. Luc. 20,3: Τοιαῦτα μὲν κατὰ Λεύχολλος εὐρὼν ἐν ταῖς πόλεσιν, ὀλίγω χρόνῳ πάντων ἀπῆλλαξε τοὺς ἀδικουμένους. Πρῶτον μὲν γὰρ ἑκατοστὴν ἐκέλευσε καὶ μὴ πλέον εἰς τοὺς τόκους

del magistrado provincial marcan una praxis que se materializará posteriormente en la jurisprudencia del Principado, por la que el *officio iudicis* encontrará limitaciones en la determinación del tipo de interés, estando llamado a determinar el *quantum usurarum* según la costumbre del lugar. Esta práctica era seguida por los gobernadores en las provincias, según las condiciones económicas de éstas, reduciendo los tipos de interés en función de la *consuetudo provinciae* o el *mos regionis*¹⁶.

La actividad mercantil en esta época empezaba a ser muy importante y dinámica. Ya a partir de mitad del siglo III a. C., comenzamos a asistir al nacimiento de una economía de mercado basada en la agricultura, las actividades de producción a gran escala de bienes esenciales y su transporte vía marítima, fluvial o terrestre¹⁷, además del desarrollo de los servicios financieros y bancarios¹⁸. Pero, sobre todo, al término de las guerras civiles y como consecuencia de la *pax romana* se comienzan a abrir amplios horizontes a la actividad comercial de la población de las diversas regiones del Imperio. La paz interior y exterior, la seguridad transaccional en el *Mare Nostrum* gracias a la protección de las flotas romanas, convertidas en una institución permanente, el número creciente de calzadas bien pavimentadas, construidas más bien con finalidades militares, pero de gran utilidad también para el intercambio comercial, la apertura de nuevos mercados... todos estos factores, entre otros, contribuyeron a un brillante incremento de las relaciones comerciales y de la necesidad de dinero circulante. En esta coyuntura económica y política, el crédito y las operaciones bancarias alcanzarían plena difusión con el florecimiento del comercio y la presencia creciente de propietarios agrícolas en las ciudades que requerían sumas de dinero para poder llevar a cabo sus empresas. No es extraño que dar dinero en préstamo fuera un negocio rentable, no solo para las personas especializadas como los banqueros (que jugaron un papel importantísimo en el desarrollo comercial), sino para cualquier individuo que poseyera *pecunia*¹⁹, ya

λογίζεσθαι, δεύτερον δὲ τοὺς μακροτέρους τοῦ ἀρχαίου τόκους ἀπέκοψε, τὸ δὲ τρίτον καὶ μέγιστον, ἔταξε τῶν τοῦ χρεωφειλέτου προσόδων τὴν τετάρτην μερίδα καρποῦσθαι τὸν δανειστήν· ὁ δὲ τόκον κεφαλαιῶ συνάψας ἐστέρητο τοῦ παντός· ὥστ' ἐν ἐλάττω χρόνῳ τετραετίας διαλυθῆναι τὰ χρέα πάντα, καὶ τὰς κτήσεις ἐλευθέρως ἀποδοθῆναι τοῖς δεσπόταις. MARTINI, R., *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano, 1969, p. 63; DE MARTINO, F., *Historia económica de la Roma antigua*, trad. E. Benítez, Akal, Madrid, 1985, p. 192; PIAZZA, M. P., 'Tabula novae'. *Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della Repubblica*, en *Atti II Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, 1980, pp. 91 ss.; PEPPE, L., "Note sull'Editto di Cicerone in Cilicia", *Labes* 37, 1991, 14 ss.; HERRERA, R., 'Usurae'. *Problemática jurídica de los intereses en Derecho romano*, Jaén, 1997, pp. 50 ss.; TORRENT, A., 'Usurae supra legitimum modum'. *Del Edicto de Lucullo a los Severos*, en *Studi per G. Nicosia* 8, Milano, 2007, pp. 255 ss.; PETRUCCI, A., *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, Torino, 2007, p. 189.

16 D. 13,4,3 (Gai., 9 *ad ed. prov.*); D. 30,39,1 (Ulp., 21 *ad Sab.*); D. 33,1,21 pr. (Scaev., 22 *dig.*).

17 Al respecto vid. SALAZAR, M., La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma. Estudio sobre el 'receptum nautarum, cauponum et stabulariorum: entre la utilitas contrahentium y el desarrollo comercial, Madrid, 2007.

18 Vid. CERAMI, P.-PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 3ª ed., Torino, 2010, pp. 27 ss.

19 Cualquier *paterfamilias* con recursos tenía en su casa una agenda que servía para anotar los pagos y, particularmente, los préstamos realizados: el *kalendarium*, que contenía los pagarés, un calendario sobre los vencimientos y las sumas de dinero destinadas a préstamos. Se podía legar el *kalendarium* y, con él, los derechos sobre los deudores. Sobre estos libros contables y otros utilizados comúnmente en el registro de la contabilidad de los banqueros, tales como el *Codex accepti et expensi*, los *adversaria* y el específico *liber rationum*, vid. ad ex., LÉCRIVAIN, Ch., "Trapezitai", *DS* 5 (1877-1919), pp. 408 ss.; MITTEIS, L., "Trapezitika", *ZSS* 19 (1898), pp.

que en Roma ni los préstamos feneraticios, ni el comercio en general eran actividad exclusiva de profesionales, ni atributo propio de una clase u orden determinado de la sociedad, sino de cualquier operador financiero o especulador ocasional²⁰.

Para dar salida a esta importantísima actividad financiera, el régimen clásico de la época comercial romana integra de forma dúctil y flexible la voluntad de las partes con los preceptos legales sobre fijación de las tasas de interés, a través del *officium iudicis*, con decisiones fundadas *ex bono et aequo*²¹ o sobre la costumbre de la región o provincia de que se trate. De forma que, por un lado, encontramos instrumentos legales útiles para la represión de las conductas ilícitas en torno a los intereses y, por otro, un margen de maniobra suficiente para que el magistrado o el *iudex*, en su caso, puedan adecuar la práctica usuraria a las diferentes realidades o circunstancias eventuales.

Como pone de manifiesto García Garrido, siguiendo a Gröschler, no se puede afirmar que en el período clásico existiera una tutela eficaz contra los intereses que excedían del límite legal (establecido en el 12% anual). Tampoco existen pruebas directas de que los banqueros pidiesen intereses superiores a este límite. Pero la falta de datos en los documentos pompeyanos de Murecine sobre los intereses que se pagaban significaría que los banqueros ocultaban los intereses pactados informalmente²². En los archivos de los Sulpicios no se hallan testimonios relacionados con la estipulación de intereses, ni los mutuos registrados presentan plazos para su devolución. La doctrina aduce que ambas circunstancias se explican porque los intereses sobre los préstamos eran simplemente pactados y liquidados de acuerdo

JOUANIQUE, P., "Le codex accepti et expensi chez Cicéron", *Revue historique de Droit français et étranger* 46, 1968, pp. 5 ss.; BARLOW, CH. T. *Bankers, moneylenders and interest rates in the Roman Republic*, London, 1982, pp. 264 ss.; SACCONI, G., *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano, 1971, pp. 144 s.; THILO, R. M., *Der 'Codex accepti et expensi' im römischen Recht: ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation*, Göttingen, 1980, pp. 109 ss.; BOVE, L., *Tabellae Eupliae. Testationes ex codice accepti et expensi*, en *Sodalitas. Studi in onore di Antonio Guarino*, vol. 4, Napoli, 1984, pp. 1.861 ss.; MASELLI, G., 'Argentaria'. *Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione, prosopografia, terminologia*, 1986, pp. 105 ss.; CREMADES, I., *El contrato literal*, en *Derecho romano de obligaciones: homenaje al prof. J. L. Murga*, Madrid, 1994, pp. 519 ss.; PETRUCCI, A., 'Mensam exercere'. *Studi sull'impresa finanziaria romana (II sec. a. C.- metà III sec. d. C.)*, Napoli, 1991, pp. 168 ss.; ANDREAU, J., *Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels*, en *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées de la Rome Antique*, Paris, 1994, pp. 1 ss.; SALAZAR, M., "La forma litteris como instrumentum crediticio en el derecho justiniano", *RIDA* 45, 1998, pp. 501 ss.; GARCÍA GARRIDO, M. J., *El comercio, los negocios y las finanzas*, cit., pp. 109-110; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. M., *El receptum argentarii en el Derecho romano clásico. Una propuesta de análisis*, Madrid, 2004, pp. 138; 152-155.

20 AA. VV., *Historia de la vida privada* (dirs. Ph. Ariès y G. Duby), Madrid, 1987, pp. 143-147; ROSTOVZEFF, M. I., *Historia social y económica del Imperio romano*, I, trad. L. López Ballesteros, Madrid, 1998, pp. 102 ss.; PETRUCCI, A., 'Mensam exercere', cit., pp. 397 ss.; ID., *Profili giuridici*, cit., p. 16, nt. 7; p. 85; ANDREAU, J., *Banque et affaires*, cit., pp. 19 s.; 29 ss.; 65 ss.; 101 ss.

21 Sobre los intereses en juicios de buena fe vid. D. 17,1,10,3 (Ulp., 31 *ad ed.*); D. 22,1,1, pr. (Pap., 2 *quæst.*); D. 22,1,37 (Ulp., 10 *ad ed.*); D. 26,7,7,10 (Ulp., 35 *ad ed.*); D. 27,4,3,1 (Ulp. 36 *ad ed.*); D. 30,39,1 (Ulp., 21 *ad Sab.*); D. 33,1,21 pr. (Scaev., 22 *dig.*). CERVENCA, G., *Contributo allo studio delle 'usuræ' cosiddette legali nel diritto romano*, Milano, 1969, pp. 217 ss.; CARDILLI, R., *Il 'periculum' e le 'usuræ' nei giudizi di buona fede*, en *L'usura ieri ed oggi* (a cura di S. Tafaro), Bari, 1997, pp. 13 ss.

22 ANDREAU, J., *Banque et affaires*, cit., p. 183; GARCÍA GARRIDO, M. J., *El comercio, los negocios y las finanzas*, cit., 153, nt. 1.; GRÖSCHLER, *Banchieri e limiti delle usuræ*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 12, 1998, p. 345 ss.

con la regla recordada por Pomponio, 5 *ad Sab.* (D. 50,17,14): *In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur*. De igual manera, operaba la *soluti retentio* de los intereses pactados pagados espontáneamente, por no resultar indebidos²³.

III. PRIVILEGIOS CONCEDIDOS AL SECTOR BANCARIO POR PARTE DEL DERECHO JUSTINIANO

A este régimen jurídico que hemos analizado opondrá el derecho justiniano uno más riguroso donde tanto la determinación de los tipos, como la corrección de su inobservancia, vienen establecidas rígidamente por la ley. Es en esta legislación, precisamente, donde encontraremos referencias específicas a la actividad de los banqueros en relación a los intereses en los préstamos.

En esta línea, el 13 de diciembre del año 528 d. C., la Cancillería justiniana aprueba una importantísima constitución relacionada con las *usurae*, con unas disposiciones muy directas en relación a sus tasas. Se trata de una *generalis sanctio* recogida en C. 4,32,26 (*Imp. Iustinianus A. Menae pp.*):

1. Super usurarum vero quantitatem etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes 2. Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari: illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari: in traiectionibus autem contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent 3. Nec liceat iudici memoratam augere taxationem occasione consuetudinis in regione obtinentis. 4. Si quis autem aliquid contra modum huius fecerit constitutionis, nullam penitus de superfluo habeat actionem. sed et si acceperit, in sortem hoc imputare compelletur, interdicta licentia creditoribus ex pecuniis fenori dandis aliquid detrudere vel retinere siliquarum vel sportularum vel alterius cuiuscumque causae gratia. nam si quid huiusmodi factum fuerit, principale debitum ab initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minuenda pars quam usurae eius exigi prohibeantur. 5. Machinationes etiam creditorum, qui ex hac lege prohibiti maiores usuras stipulari alios medios subiciunt, quibus hoc non ita interdictum est, resecantes iubemus, si quid tale fuerit

23 Vid. estas consideraciones en GRÖSCHLER, P., *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1997, pp. 149 ss.; VERBOVEN, K., "The Sulpicii from Puteoli and usury in the early Roman empire", *TR* 71, 2003, pp. 10 ss.; ANDREAU, J., *Ibid.*, pp. 137 ss.; PETRUCCI, A., *Profili giuridici*, cit., pp. 85 s.; CERAMI, P.-PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano*, cit., pp. 157 s.; SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho romano*, México, 2007, p. 77.

atemptatum, ita computari usuras, ut necesse esset si ipse qui alium interposuit fuisset stipulatus: in quo casu sacramenti etiam illationem locum habere sancimus.

La norma justiniana tiene por objeto reducir la *quantitas usurarum*, disponiendo el 6% anual como tasa legal máxima para los préstamos ordinarios (*dimidia centesima*), no permitiéndose al *iudex, occasione consuetudinis in regione obtinentis*, aumentar este tipo (§§2 y 3)²⁴. Para cierto sector doctrinal esta reducción obedece a una influencia del Cristianismo, sobre todo del pensamiento de la patrística especialmente reacio a la usura²⁵. Para otro, no sólo se deben encontrar motivaciones de orden moral, sino de corte económico a causa de la disminución de la demanda de capital. Pero lo que sí resulta evidente es que Justiniano legisla con el absoluto convencimiento de que puede modificar de forma absoluta, a través de su actividad normativa, instituciones y relaciones jurídicas que se encontraban fuertemente consolidadas, pero que necesitaban ser cambiadas debido a la evolución que tomaban las nuevas realidades económicas y sociales. Entiende, desde un principio, que el emperador debía ser el único *conditor et interpret legum*²⁶.

Por lo tanto, el tema del tipo de interés en esta época se inserta en el ámbito de las relaciones entre el pensamiento cristiano y la legislación imperial, existiendo una especial conexión entre las orientaciones de la patrística, las deliberaciones conciliares y la normativa justiniana, impregnada del principio del *favor debitoris*²⁷

24 En opinión de CHERCHI, A., *Il divieto di anatocismo nel sistema giuridico romano*. Tesi di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Università di Sassari, anno accademico 2008-2009, p. 214: la norma de c. 26.2 «sembra riferita tanto alle *usurae* convenzionali quanto a quelle legali, ma non a quelle giudiziali, che sono oggetto di due specifiche *constitutiones* del 529 e del 531 d.C. (CI. 7.54.2 e 7.54.3)». Para CERVENCA, G., *Contributo allo studio delle 'usurae' cosiddette legali*, cit., p. 283: «una norma siffatta deve appunto riguardare gli interessi c.d. legali, giacchè per ciò che attiene quelli *ex pacto* l'ammontare delle *usurae* viene rimesso alla volontà delle parti».

25 Al respecto vid. HERRERA, R.-SALAZAR, M., La doctrina de la usura en la tradición romano-cánónica europea, en *Estudios de Derecho romano en memoria de Benito M^a Reimundo Yanes* (coord. A. Murillo), Burgos, 2000, pp. 455 ss.

26 Sobre esta constitución vid. BILLETER, G., *Geschichte des Zinfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898, p. 122; ROTONDI, G., Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura, cit., p. 393; CASSIMATIS, G., *Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin*, Paris, 1931, pp. 49 ss.; BALOGH, E., *Adaptation of law to economic conditions according to Roman law*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto*. (Verona, 27-29 settembre 1948) 2, Milano, 1953, p. 322; ARCHI, G. G., «La legislazione di Giustiniano e un nuovo vocabolario delle costituzioni di questo imperatore», *SDHI* 42 (1976), pp. 6 ss.; BIANCHINI, M., La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana, en *Studi in onore di A. Biscardi* 2, Milano, 1982, p. 389; LUCHETTI, G., «Banche, banchieri e contratti bancari. Osservazioni a proposito di una recente ricerca di A. Díaz Bautista», *BIDR* 33-34, 1991-1992, pp. 463 ss.; SALAZAR, M., La gratuidad, cit., pp. 196 ss.; TAFARO, S., La limitazione dei debiti, cit., p. 5; ID., *CI. 7.47.1: Giustiniano e i limiti alla condanna del debitore*, en *L'usura ieri ed oggi* (a cura di S. Tafaro), Bari, 1997, p. 227.

27 BIONDI, B., *Il diritto romano cristiano*, Milano, 1954, p. 246; GIACCHERO, M., *Fenus, usura, pignus e fideiussio negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 3, Da Costantino a Teodosio, con particolare riguardo alla politica legislativa di Giuliano, Perugia, 1979, pp. 443-473; ID., *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 4, Teodosio il Grande e Teodosio II: gli aspetti giuridici, economico-sociali, religiosi, culturali, Perugia, 1981, pp. 307-365; BONINI, R., *Studi sull'età giustiniana*, Repubblica di S. Marino, 1990, p. 263; COPPOLA, R., *Il problema dell'usura nella visione e nel diritto della chiesa*, en *L'usura ieri ed oggi* (a cura di S. Tafaro), Bari, 1997, pp. 253 ss.

Ahora bien, este tipo del 6% cuenta con algunas excepciones, moduladas en base a la categoría de determinadas personas. De forma que si el prestamista es una persona ilustre o de alta condición no se le permite estipular intereses más allá del 4%. En cambio a los banqueros y demás comerciantes profesionales –aludiendo a ellos como *qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt*– se les autoriza a percibir un 8% anual.

Las razones de este privilegio para el sector de la banca no son unívocas. Así lo observaría magistralmente A. Díaz Bautista, aduciendo que: «Las numerosas peticiones que los banqueros dirigieron a Justiniano, casi siempre acogidas con complacencia, dejan traslucir una serie de rasgos característicos de la realidad jurídica de la época. En efecto, se dibuja en ellas vigorosamente esa tensión entre clasicismo y vulgarismo, entre romanismo y helenismo que va a constituir el complejo entramado del pensamiento jurídico justiniano. Por otra parte, la praxis bancaria se muestra en todas las épocas de la historia especialmente sensible a las exigencias del tráfico y a los avatares de la economía. No es por ello extraño que en las reglas referentes a la actividad bancaria se manifieste de forma acusada la tendencia postclásica naturalista que lleva a enfocar los problemas jurídicos desde una perspectiva preferentemente económica y social, aun a cambio de dislocar la arquitectura conceptual de las instituciones tal y como los clásicos las habían delineado desde la rigurosa autonomía de su pensamiento»²⁸. Precisamente, dicho privilegio concedido a los banqueros de poder superar la tasa de la *dimidia centesima* prueba que el emperador está legalizando una práctica ya existente previamente en la realidad cotidiana.

Son, por tanto, motivos económicos y de mercado, junto al vulgarismo oriental los que impregnan la legislación de Justiniano, además de la presión que debió de ejercer un sector que para la economía de la época resultaba de gran utilidad. Toda la legislación justiniana en materia bancaria se caracteriza por los frecuentes elogios a los banqueros en cuanto cooperan al bien común con sus contratos, asumiendo riesgos, y en consecuencia resultan de utilidad pública²⁹.

Por otro lado, la posibilidad de estipular *usurae infinitae* en los préstamos marítimos también encuentra una limitación en la constitución que estamos analizando, sin que pueda ser superior al 1% mensual, esto es, al 12% anual, el doble del tipo legal. Esta nueva excepción al tipo del préstamo ordinario se debe a las particulares exigencias del sector marítimo comercial. Desde el punto de vista económico-social, en ciertos ámbitos financieros de Bizancio encontramos múltiples dificultades para buscar los recursos necesarios para emprender las pertinentes expediciones marítimas. De ahí que los capitalistas de Constantinopla invoquen una legislación más favorable a los prestamistas en base a las antiguas costumbres. Fruto de estos requerimientos es la Novela 106 que viene a sancionar

28 DÍAZ BAUTISTA, A., Estudios sobre la banca bizantina. (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano), Murcia, 1987, p. 3.

29 DÍAZ BAUTISTA, A., Ibid., p. 9, nt. 22; SALAZAR, M., “El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos”, *RIDROM* 11, 2013, pp. 88 ss., con bibliografía en nt. 1. En particular, se puede aducir lo contenido en C. 12,35 (34) bajo la rúbrica ‘*Negotiatores ne militent*’, donde se prohíbe a los banqueros formar parte de la milicia armada porque son “útiles para todos los contratos”: *Imp. Justinianus A. Mennae P. P. C. 12, 34 (35)*, 1: *Eos, qui vel in hac alma urbe vel in provinciis cuidam ergasterio praesunt, militare de cetero prohibemus, exceptis argenti distractoribus, qui in hac alma urbe negotiantur. Hos enim, utpote omnium contractibus utiles armata quidem militia penitus abstinere sancimus...*

antiguas normas consuetudinarias, permitiendo pactar intereses más altos y derogando los planteamientos de C. 4,32,26,2. Esta Novela es considerada como una *lex specialis* aplicable exclusivamente a las relaciones entre *navicularii* y sus financiadores. Pocos meses después, el veintiséis de abril del año 541 el emperador Justiniano abroga la norma especial contenida en la Novela 106 e introduce la Novela 110³⁰. Las causas de este cambio obedecen a la contrastada incompatibilidad entre la Novela 106 y las disposiciones contenidas en C. 4,32,26,2 y a las presiones ejercitadas por el colegio de los *argentarii* que querían reservarse para sí la cualidad de intermediarios entre capitalistas y *negotiatores*, así como el control de tan lucrativas actividades. Concluyendo, pues, Justiniano acabó imponiendo en el *fenus nauticum* el tipo del 12% anual³¹.

Por último, la c. 26 enuncia también los criterios sobre los cuales operan los límites usurarios: en primer lugar, se prohíbe al juez liquidar *usurae* por encima de las tasas admitidas en consideración al *mos regionis* (§3). Por otro lado, se establece que los intereses obligacionales introducidos por estipulación de las partes con un valor superior al tipo fijado no legitiman al acreedor para el ejercicio de la acción correspondiente por la cantidad del *superfluum*, de manera que el interés debe venir imputado al capital. Es decir, se niega toda tutela jurídica al acreedor que acuerde *usurae* superiores al tipo máximo consentido y en el supuesto en el que éstas vengan consignadas, deben ser deducidas del importe del capital debido. Así, el acreedor que hubiera transgredido la prohibición del tipo de interés encontrará disminuido su crédito en concepto de reembolso al deudor, esto es, se prohíbe, además, a los acreedores retener cualquier suma, aunque sea módica, a título de intereses ilícitos, siendo también ésta detraída del capital. Finalmente, la última parte de la constitución determina que las tasas establecidas no pueden ser eludidas por los acreedores a través de *machinationes*, como la utilización de formas contractuales no expresamente prohibidas o la interposición de sujetos intermediarios (§§4 y 5)³².

No obstante, la c. 26 viene concretamente aplicada, en la práctica, sólo a futuros acuerdos de intereses. La reacción no se hace esperar y Justiniano, con una sucesiva intervención (C. 4,32,27 pr. a. 529)³³, calificará de *prava tal interpretatio*, entendiendo de aplicación las normas contenidas en c. 26 también a todos los acuerdos de *usurae* anteriores al 13 de

30 Sicque volumus causam procedere, tanquam si nec scripta fuisset memorata lex, sed secundum de talibus positas leges a nobis negotia et aestimatione et sententia potiantur.

31 En torno al contenido de estas Novelas vid. BIANCHINI, M., *La disciplina*, cit., pp. 418 ss.

32 BONINI, R., *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 259 ss.; BIANCHINI, M., *Ibid.*, p. 393; SOLIDORO, L., *Note sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, Napoli, 1996, p. 27; ID., *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, en *L'usura ieri ed oggi* (a cura di S. Tafaro), Bari, 1997, p. 211; HERRERA BRAVO, R., 'Usurae', cit., p. 49.

33 CI. 4.32.27 pr. (Imp. Iustinianus A. Menae pp.): De usuris, quarum modum iam statuimus, pravam quorundam interpretationem penitus removens iubemus etiam eos, qui ante eandem sanctionem ampliores quam statutae sunt usuras stipulati sunt, ad modum eadem sanctione taxatum ex tempore lationis eius suas moderari actiones, illius scilicet temporis, quod ante eandem fluxit legem, pro tenore stipulationis usuras exacturos. D. k. April. Constantinopoli Decio vc. cons. [a. 529]

diciembre del 528 y en relación a los intereses aún no madurados³⁴. No se trata, como pone de relieve Bianchini³⁵, de una simple aclaración, sino de una integración del dictado de la c. 26.

Otro texto que revela la importancia que jugaban los *argentarii* en la política legislativa de Justiniano relativa a los intereses convencionales es, sin duda, la Novela 136,4 del seis de febrero del año 535, que reproducimos a continuación en su versión latina:

Quoniam vero legem tulimus, ne argentariae mensae praepositi ultra besses usuras fenerentur, illi autem nos docuerunt se etiam sine scripto fenerari solere, nec tamen fidem sibi servari circa usuras, utpote cum mutuum sine scriptis contractum nec stipulatio interposita sit, (secundum illud quod vulgo dicitur non convenire ut usurae absque stipulatione currant, quantumvis multi sint casus in quibus et sine stipulatione usurae et ex solo pacto nascentur, nonnunquam etiam ne ex pactis quidem, sed sua sponte introductae nihilominus exigantur); propterea sancimus, ut non solum ex stipulatione usurae iis, sed etiam ex non scriptis tales praestentur quales lex ipsis stipulari concedit, hoc est usque ad bessem centesimae. Nam qui omnibus propemodum indigentibus open ferre parati sunt, eos par non est iniuria affici ex eiusmodi subtilitate.

La disposición legislativa³⁶ confirma el tipo de interés al 8% para los *argentarii*, aquí llamados *praepositi argentariae mensae*, expresión tomada de época precedente pero con diverso significado como ha puesto de relieve Petrucci³⁷, pues entre el siglo I a. C y la mitad del siglo III d. C. los *praepositi* en una *mensa argentaria* no eran los titulares de la misma, sino los esclavos o libertos encargados, mediante la *praepositio* o acto de otorgamiento de poderes, de la gestión del negocio bancario según un esquema que implicaba la responsabilidad ilimitada del emprendedor o empresario.

Después de la reafirmación de la tasa del 8% —establecida en C. 4,32,26,2—, la *novella* concede a los banqueros la ventaja de cobrar los intereses automáticamente o a través de simple pacto, sin necesidad de estipulación, pese al principio clásico, y más aún sin necesidad de documento escrito. La razón está como se puede transcribir del propio texto de la ley en que “no es justo que los que están dispuestos a prestar auxilios a casi todos los que lo necesitan sean perjudicados por tal sutileza”. A este respecto, la prerrogativa es clara. Y ello en base, de nuevo, a la *utilitas* de su actividad económica.

El emperador, en el ámbito de su política de favor hacia los *argentarii*, les reconoce el derecho a pretender el pago de los intereses —eso sí, siempre dentro de la tasa legal del 8%, que como hemos visto se trata también de una tasa privilegiada respecto de la ordinaria— aun

34 BILLETTER, G., *Geschichte des Zinsfusses*, cit., pp. 331 ss.; CASSIMATIS, G., *Les intérêts dans la législation de Justinien*, cit., pp. 63 ss.; SOLIDORO, L., *Sulla disciplina*, cit., pp. 211 s., quien afirma que con esta constitución Justiniano: «attribuisce alla disposizione emanata nell'anno precedente una parziale efficacia retroattiva...». Cf. BROGGINI, G., “La retroattività della legge nella prospettiva romanistica”, *SDHI* 32, 1966, pp. 46 ss.

35 BIANCHINI, M., *La disciplina*, cit., p. 395.

36 BIANCHINI, M., *Ibid.*, pp. 415 ss.; DIAZ BAUTISTA, A., “Les garanties bancaires dans la législation de Justinien”, *RIDA* 29, 1982, pp. 167 ss.; BARNISH, S. J. B., “The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy”, *Byzantion* 55, 1985, pp. 5 ss.; LUCHETTI, G., “Banche, banchieri...”, cit., pp. 451 ss.; CERVENCA, G., “Usura”, cit., p. 1.129, nt. 54.

37 *Profili giuridici*, cit., p. 96, nt. 50; pp. 103 ss.; CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano*, cit., pp. 164 ss.

sin haber sido objeto de *stipulatio*, sino a través de un simple *pactum* verbal, automáticamente (*sua sponte*), o sin estar documentados en actos públicos o notariales.

Por un lado, Justiniano rompe –privilegiando con ello a un sector concreto de la sociedad– con la tradición romana clásica en la que tan sólo se debían intereses de un capital prestado en mutuo si se habían estipulado previamente de manera expresa mediante *stipulatio usurarum*. El simple pacto no producía acción alguna para reclamar los intereses, aunque sí excepción para neutralizar la repetición del pago de los mismos indebidos, si bien la eficacia del pacto de intereses llegó a admitirse en derecho clásico en ciertos casos³⁸. A pesar de que Justiniano mantuvo en el Digesto los fragmentos de los autores clásicos donde se recogía su doctrina al respecto, quizás con importantes atenuaciones a través de la interpolación de textos, las circunstancias de la tradición helénica y posiblemente la presión de los banqueros hicieron desdecirse al emperador³⁹.

Por otra parte, la intervención imperial no sólo presupone la subsistencia de la obligación de pactar intereses por escrito –posibilidad explícitamente afirmada en el párrafo primero del capítulo sucesivo a la misma Novela–, sino que llega a admitir la oportunidad de acuerdos puramente orales, cuya difusión no sería nada desdeñable⁴⁰.

Completando el régimen expuesto, es necesario considerar la Novela 136,5,1, justamente a continuación de lo dispuesto en la anterior:

Usurae autem, si quidem certas pepigerint, pactae valeant. Sin hoc solum scriptum sit, mutuum sub usuris esse contractum, contrahentes dicere nequeant, quoniam usurae definitae non sint, propterea non fenebrem esse pecuniam, sed per praesumptionem quasi besses usurae nominatim expressae sint ita fiat exactio. Atque hoc quidem in posterum observeretur. In ratiociniis vero iam confectis, etsi mentio usurarum facta non sit (quoniam manifestum est apud quemlibet argentariae mensae praepositum contractus sub usuris fieri, nec qui ipse usuras dependit, absque usuris impensam facere poterit), liceat iis besses usuras exigere, in posterum tamen ea observantibus quae praesens sacra lex ipsis largitur.

El texto, siguiendo la tendencia postclásica a conceder legitimidad a los *pacta*, máxime cuando los intereses encuentran su fundamento en los negocios bancarios⁴¹, parte de la base

38 Estos casos excepcionales en los que son exigibles intereses *etiam ex nudo pacto* se refieren a los mutuos efectuados a las *civitates* (Paul. *l. sing. reg.* D. 22,1,30: *Etiam ex nudo pacto debentur civitatibus usurae crediturum ab eis pecuniarum*); a los préstamos de géneros (Alex. a. 223, C. 4,32,11 (12): *Fumenti vel hordei mutuo dati accessio etiam ex nudo pacto praestanda est*); a los casos de pactos usurarios adjuntos a un préstamo marítimo y a una *pollicitatio*. Si bien en estos dos últimos casos existe controversia doctrinal sobre su carácter clásico. Cf. DE VILLA, V., *Le 'usurae ex pacto' nel diritto romano*, Roma, 1937, pp. 93 ss.; 111 s.; LITEWSKI, W., "Römisches Seedarlehen", *Iura* 24, 1973, pp. 166 s.; BISCARDI, A., "Pecunia traiecticia e stipulatio poenae", *Labeo* 24, 1978, p. 283; KASER, M., *Das römische Privatrecht*, 2ª ed., München, 1971, p. 498, nt. 37. Vid., también, HIRONAKA, T., "Zur formlosen Zinsvereinbarung beim Naturaldarlehen im römischen Recht", *ZSS* 93 (1976), p. 290.

39 DELGADO JIMÉNEZ, M. A., *Protección de los deudores y usuarios de la banca en la experiencia jurídica romana*, XV Congreso Latinoamericano de Derecho romano, Morelia, Michoacan, México, 2006, p. 17.

40 En relación a la práctica bancaria de concluir contratos *sine scriptis* en época justiniana vid. LUCHETTI, G., "Banche, banchieri...", cit., pp. 455 s.

41 Al respecto, D. 16,3,7,2 (Ulp. 30 *ad ed.*); D. 16,3,24 (Pap., 9 *quaest.*) D. 16,3,26,1 (Paul. 4 *resp.*) D. 16,3,28 (Scaev. 1 *resp.*); D. 42,5,24,2 (Ulp. 63 *ad ed.*). Vid. estos textos en PETRUCCI, A., *Profili giuridici*, cit., pp. 69 ss.; CERAMI, P.- PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano*, cit., pp. 150 ss.; SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca*, cit., pp. 66 ss.

de la validez del *pactum usurarum* cuando las *usurae* fueran *certae*, pero al mismo tiempo se introducen otras dos reglas que vienen a quebrar el régimen clásico: por un lado, se establece que en los mutuos concluidos por escrito *sub usuris*, pero sin fijación de intereses concretos, se niega a los contratantes la posibilidad de sostener la gratuidad del negocio, antes bien se presumen los intereses legales del 8%. La eficacia de esta disposición se extiende no sólo a los contratos ya formalizados, sino también a los futuros. Por otro lado, se determina, asimismo, que en los créditos ya concluidos por escrito, pero privados de cualquier pacto acerca de los intereses, éstos puedan igualmente pedirse dentro del límite del 8%, presumiéndose siempre onerosos semejantes contratos en los que el mutuante sea un banquero. Y la razón aducida es que resulta manifiesto que con quien está al frente de un establecimiento de banco los contratos se celebrarán con interés, y que quien paga intereses no puede hacer desembolsos sin interés (*quoniam manifestum est apud quemlibet argentariae mensae prae-positum contractus sub usuris fieri, nec qui ipse usuras dependit, absque usuris impensam facere poterit*). Esto es, observamos el reconocimiento de la condición onerosa inherente a los contratos bancarios, característica por otra parte de los contratos mercantiles modernos⁴². Se vuelve a afirmar, aquí, a través de la exclusiva alusión a los negocios crediticios con los banqueros, y no con otro tipo de sujetos, la importancia de la actividad de estos operadores financieros en la época que estamos abordando.

Se aduce, pues, la natural onerosidad no sólo de los mutuos, sino en general de las operaciones bancarias documentadas en los *logothesia* (*In ratiociniis vero iam confectis*), esto es, en los documentos contables donde se registraban los resultados pecuniarios de todas las actividades realizadas por los banqueros, con lo cual la forma documental tenía valor constitutivo respecto al pago de los intereses⁴³.

Igualmente, esta segunda prescripción viene sancionada con previsión de futuro. De ahí las palabras: *in posterum tamen ea observantibus quae praesens sacra lex ipsis largitur*.

Poniendo en relación la normativa recogida en ambas Novelas, podemos observar que si bien en la Novela 136,4 el margen de libertad de las partes para acordar intereses se encontraba constreñido, si bien no excluido, por la tasa legal; en la Novela 136,5,1 se establece un verdadero régimen legal, en lugar de uno convencional. Efectivamente, en la primera hipótesis de esta última Novela viene eliminada la posibilidad de acordar las *usurae*, en los mutuos con interés no determinado, con parámetros diversos a los dispuestos para todas las actividades comerciales y financieras en la constitución del 528. E, igualmente, de la segunda hipótesis de la misma disposición normativa se deduce que la presunción de intereses del 8% en los contratos de préstamo ya documentados era *iuris et de iure*⁴⁴.

42 Ed. 9,2 pr. p. 773, lins. 20-21. DÍAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 37.

43 Sobre el papel asumido por los documentos bancarios en el derecho justiniano vid., TALAMANCA, M., "Documento e documentazione (diritto romano)", *EdD* 13, Milano, 1964, pp. 553 ss.; AMELOTI, M., *Il documento nel diritto giustiniano. Prassi e legislazione*, en G. G. Archi, *Il mondo del diritto nell' epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, pp. 131 ss.; SALAZAR, M., "La forma litteris", cit., pp. 501 ss.; SARADI, H. G., *Notai e documenti greci dall' età di Giustiniano al XIX secolo. Il sistema notarile bizantino*, Milano, 1999, pp. 3 ss. Vid., asimismo, DÍAZ BAUTISTA, A., *Ibid.*, pp. 24 ss.; LUCHETTI, G., "Banche, banchieri...", cit., pp. 454 ss.

44 DÍAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 37.

Además del trato de favor para los *argentarii* observado en las Novelas analizadas, no podemos obviar dos últimas disposiciones contenidas en los *Edicta Justiniani* que completan el régimen justinianeo relativo a los intereses derivados de los préstamos bancarios. Se trata de Ed. 9,5 y Ed. 9,6 pr. En el primer precepto se determina lo siguiente:

ipsis in mutuis dandis nostra opponatur constitutio, quam scripsimus nemini ultra duplum accipere quicquam permittentes... hoc ipsis emendantes sancimus, ut in veris contractibus argentariorum ad hunc diem factis facultas iis sit, etiamsi usurae supra duplum pro his debitis datae sint, exigendi debita cum constitutis usuris, non coactis imputare neque in usuras neque in antiquum debitum, quae supra sortem iam soluta sunt, et in hoc solo eis nostra de duplo constitutio non obstat, sed secundum contractuum naturam ea exigant...

La norma prescribe la no aplicación a los mutuos concluidos por banqueros de la prohibición de las *usurae supra duplum*, genéricamente contemplada en la constitución de C. 4,32,27,1 emanada por el mismo emperador en el año 529. En efecto, tal *constitutio* se expresa en los siguientes términos:

CI. 4.32.27.1 (Imp. Iustinianus A. Menae pp.): Cursum insuper usurarum ultra duplum minime procedere concedimus, nec si pignora quaedam pro debito creditori data sint, quorum occasione quaedam veteres leges et ultra duplum usuras exigere permittebant. Quod et in bonae fidei iudiciis ceterisque omnibus in quibus usurae exiguntur servari censemus. D. k. April. Constantinopoli Decio vc. cons. [a. 529].

Justiniano confirma aquí la prohibición de las *usurae supra duplum* ya existente desde época republicana, esto es, impone que en ningún caso pueden discurrir intereses cuando éstos ya han alcanzado el montante del capital debido⁴⁵; pero, además, amplía la aplicación de esta norma –a diferencia del régimen anterior que la circunscribía a los intereses nacidos exclusivamente de estipulación⁴⁶– a todos los acuerdos de intereses independientemente del tipo de acto constitutivo de la relación obligatoria e, igualmente, a todas las hipótesis en las que pueden surgir intereses, esto es, a las *usurae* tanto convencionales, como legales. El amplio alcance de la constitución justiniana resulta evidente: su aplicación a cualquier relación jurídica, incluso de buena fe, de la que deriven para el deudor intereses. Por consiguiente, parece que se refiere también a los *pacta*⁴⁷.

No obstante, Ed. 9,5 introduce una derogación de esta norma para los *argentarii*, sin llegar a abrogarla en términos generales, consintiéndoles –en claro perjuicio de los deudores– la posibilidad de cobrar intereses *ultra sortis summam* o *ultra alterum tan-*

45 CERVENCA, G., “Sul divieto delle c. d. *usurae supra duplum*”, *Index* 2, 1971, pp. 291 ss.; SOLIDORO, L., *Ultra sortis summam usurae non exiguntur*, en *Problemi di storia sociale nell’elaborazione giuridica romana*, Napoli, Jovene, 1994, pp. 29 ss.; MURILLO, A., “Anatocismo. Historia de una prohibición”, *AHDE* 59, 1999, 497 ss.; VITTORIA, C., “Le *usurae usurarum* convenzionali e l’ordine pubblico economico a Roma”, *Labeo* 49, 2003, pp. 291 ss.; TORRENT, A., ‘*Usurae supra legitimum modum*’, cit., pp. 257 ss.

46 Como se deduce de D. 12,6,26,1 de Ulpiano, mientras que CI. 4,32,10 de Caracalla no hace referencia al tipo de acto constitutivo de la relación obligatoria. Vid. BIANCHINI, M., *La disciplina*, cit., p. 395.

47 DE VILLA, V., *Le usurae ex pacto*, cit., pp. 77 ss.; Según CERVENCA, G., “Sul divieto delle c. d. *usurae supra duplum*”, cit., pp. 296 ss., la prohibición de las *usurae supra duplum* fue extendida al *pactum* y a los *bona fidei iudicia* con esta constitución, aunque sin embargo era probablemente ya aplicable al *pactum* en base a principios generales expresados en Ulp. D.12,6,26 pr-1. Vid., también, FASOLINO, F., *Le usurae rei iudicatae*, *Diritto@storia* 5, 2006, pp. 14. URL: http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione_romana/Fasolino-Usurae-rei-iudicatae.htm; SALAZAR, M., *Les sanctions pénales des usurae illicitae*, cit., especialmente, pp. 63 ss.

tum, esto es, intereses que con su decurso superen el importe de la cantidad prestada, sin resultar obligados a imputar el excedente ni a los intereses, ni al capital mismo⁴⁸. La excepcionalidad de la medida se encuentra sólo mínimamente atemperada por dos condiciones impuestas por la *lex*: por un lado, el beneficio se aplica únicamente a los contratos de préstamo concluidos con anterioridad a la fecha de emanación del propio Ed. 9,5 y, además, a todos aquellos efectuados por banqueros, también en el caso en que éstos revistieran el papel de deudores, hipótesis esta última infrecuente, a no ser en relaciones contractuales entre ellos mismos⁴⁹.

Finalmente, una segunda disposición contenida en Ed. 9,6 pr. vuelve a confirmar la condescendencia que muestra Justiniano hacia el sector bancario, con una medida sumamente benevolente para los banqueros de Constantinopla, quizá oportunamente solicitada⁵⁰:

Quoniam vero permisimus argentariae mensae praepositis in hac felice urbe excepta armata militia omnes alias gerere, deinde illi, cum mutuum dederunt aut etiam dant, besses usuras, quantas argentariis concessimus, stipulati sunt, improbi autem opponunt ipsis militias, dicentes aequum esse eos non argentariis, sed militantibus convenientes usuras capere, hanc eorum absurdam et improbissimam obiectionem omnino quiescere iubemus et quae pacto convenerint aut etiam convenient obtinere.

La norma prevé, para los banqueros de Constantinopla que gracias a una *militia* hayan conseguido alcanzar el rango de *illustres*, la legitimidad de continuar aplicando la tasa de interés del 8%, a pesar de que las personas pertenecientes a dicho rango no pueden exigir a título de usura más que el 4%, conforme a lo prescrito en la *constitutio* contenida en C. 4,32,26,2, antes analizada⁵¹.

Para Bianchini, esta concesión no se explica si no por la voluntad de compensar al colegio de banqueros de Constantinopla por sus favores al emperador o por los préstamos hechos a la alta burocracia para la consecución de prestigiosas *militiae*; en cualquier caso, para asegurar un trato preferencial a una de las más potentes corporaciones de la capital. Se trata de un beneficio instrumental diseñado por Justiniano hasta el punto de trastocar la reforma acometida en el 529. Quizá por ello, el emperador prefirió intervenir a través de *pragmaticae*, cuya eficacia está perfectamente circunscrita, es provisional y se confía al *officium* del destinatario⁵².

48 En particular vid. lo dispuesto en las Novelas 121,2 y 138. Sobre el contenido de éstas CASSIMATIS, G., *Les intérêts dans la législation de Justinien*, cit., pp. 63 s.; BIANCHINI, M., *La disciplina*, cit., pp. 399 ss.; ID., *Storia di una Novella: Nov. 138 fra Epitomi e Basilici*, en *Studi in onore di R. Martini* 1, Milano, 2008, pp. 275 ss.; BONINI, R., *Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle di Giustiniano*, en *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1990, 259 ss.; SOLIDORO, L., *Sulla disciplina*, cit., p. 212, nt. 98; FASOLINO, F., *Ibid.*, p. 16; SALAZAR, M., *Ibid.*, pp. 64 s.

49 Vid. BIANCHINI, M., *La disciplina*, cit., pp. 417 s.; LUCHETTI, G., “Banche, banchieri...”, cit., pp. 454; PETRUCCI, A., *Profili giuridici*, cit., pp. 217 s.;

50 BIANCHINI, M., *Ibid.*, p. 417.

51 LUCHETTI, G., “Banche, banchieri...”, cit., p. 464, nt. 39; PETRUCCI, A., *Profili giuridici*, p. 218.

52 BIANCHINI, M., *La disciplina*, cit., p. 418.

IV. RECAPITULACIÓN

Resulta innegable que el comercio bancario –cuyo mayor desenvolvimiento lo hemos situado en la época de expansión imperialista de Roma y de extensión del comercio a gran escala– trajo consigo una modificación sustancial de las antiguas instituciones para dotarlas de mayor flexibilidad y adaptarlas a las nuevas necesidades. Este carácter dúctil del Derecho romano por influencia de la actividad de los banqueros se observa particularmente en figuras jurídicas como el depósito, cuya originaria finalidad de custodia queda relegada al admitirse la posibilidad del uso del dinero por parte del banquero y, como no, en el mutuo, que en el ámbito bancario siempre lleva aparejada la producción de intereses. Si bien el *fenus* no fue una actividad exclusiva de los *argentarii*, sino también de cualquier *paterfamilias* con recursos o especulador ocasional.

Las épocas preclásica y clásica resultarán decisivas en la emersión y progresiva consolidación de una terminología jurídica propia en la esfera de la actividad bancaria y del tráfico especulativo, desarrollándose toda una gama de recursos técnicos, de formas y vías legales para abrir paso a uno de los movimientos económicos más importantes del derecho comercial romano.

Así, se viene observando en estas épocas toda una gama de criterios elásticos para integrar la voluntad de las partes en el régimen legal sobre la fijación del límite de interés. Lo que se traduce en edictos y decretos de magistrados o en el *officium iudicis* (con decisiones *ex bono et aequo* o fundadas sobre el *mos regionis*). De tal manera, por un lado, existe un suficiente espacio dejado a la discrecionalidad del magistrado o el *iudex*, quienes pueden tener en cuenta circunstancias eventuales. Por otro lado, rigen instrumentos eficaces predispuestos para adecuar el derecho a la práctica, respecto de los límites usurarios y la represión de su violación.

No obstante, durante el curso de toda la llamada “época comercial” (s. III a. C-s. III d.C.) no disponemos de elementos suficientes para poder deducir un régimen especial para la banca en relación a los límites legales de los intereses convencionales y podemos aventurarnos a suponer, sobre la base de los testimonios literarios en los que se presenta a la figura del banquero circunscrita a una actitud deshonestas, que no sería infrecuente el quebrantamiento de la legislación feneraticia por parte de éstos, dado el vínculo tan estrecho que liga el *lucrum* con la *fraus*.

A este régimen de discrecionalidad de los órganos políticos y judiciales, el derecho justiniano opone uno legal, más rígido y minucioso, en orden a la determinación de las tasas de interés. Es, precisamente, en esta regulación a través de *constitutiones*, *novellae* y *pragmaticae* donde observamos privilegios específicos para los operadores del sector bancario: desde la concesión de una tasa superior que les permite estipular intereses más allá de la *dimidia centesima* –incluso si llegan a alcanzar el rango de *illustres*–, hasta la ventaja de cobrar intereses automáticamente o a través de simple pacto oral o escrito, sin necesidad de estipulación. Además de la presunción de onerosidad para los mutuos concluidos *sub usuris*, pero sin fijación de intereses concretos y los formalizados por escrito, aun privados de *pactum usurarum*, otorgando valor constitutivo a los documentos contables donde se registran las operaciones financieras. Por último, se les permite, asimismo, en contra de la prohibición general, cobrar *usurae supra duplum*.

No se puede afirmar que exista una única causa en la determinación de este sistema privilegiado. Para la doctrina se pueden aducir tanto motivos económicos, como la influencia del vulgarismo oriental en el derecho justiniano, que lleva a una desviación respecto de las categorías clásicas. También se conjetura en relación a una posible presión de determinados sectores financieros. Pero lo que resulta fuera de duda, tal y como se desprende de las fuentes, es la utilidad pública del servicio que presta la banca.

Motivaciones de interés general se encuentran, en consecuencia, en la base de toda la disciplina de la actividad bancaria. Esta ratio, junto con la exigencia de la equidad y la buena fe, son las que debieran presidir las relaciones contractuales entre banquero y cliente, ya que “el nexo entre *utile* y *beneficium* en la función mercantil nos introduce en el corazón de uno de los problemas fundamentales referentes a las relaciones entre ética y actividad mercantil”⁵³.

En consecuencia, el ordenamiento jurídico romano se enfrenta, en sede bancaria, con el importante desafío de equilibrar los intereses en juego: por un lado, la necesidad de proteger con medidas legislativas a los terceros contratantes, dado que son la parte débil en una relación contractual con el sector bancario y, por otro lado, la exigencia de dar una debida respuesta a las necesidades del propio mercado y, en particular, de un sector clave para la economía como es el bancario. Se trata, por tanto, de conjugar la *publica utilitas contrahentium* y el desarrollo comercial.

53 GIARDINA, A., *El comerciante*, en AA.VV. *El hombre romano*, Madrid, 1989, p. 305.

LA PARTICIPACIÓN DEL ARGENTARIUS EN LAS AUCTIONES SEGÚN LA LEX METALLI VIPASCENSIS

ELENA SÁNCHEZ COLLADO

Universidad Rey Juan Carlos

Durante la época romana, tanto las fuentes jurídicas como literarias evidencian la participación de los banqueros profesionales -*argentarii*, *coactores* y *coactores argentarii*¹- en la organización de subastas, elaboración de los registros, cobro de sumas adjudicadas, o en la concesión de crédito al comprador² y el pago del precio al vendedor.

Aunque es indudable el abanico de testimonios literarios, epigráficos y jurídicos que nos informan sobre la relevancia de la intermediación financiera en la agilización de las transacciones monetarias derivadas de la venta –participación que era retribuida como en el caso del *praeco*, con una comisión o *merces*, que equivalía a un porcentaje fijo sobre el precio obtenido en la venta–, es, no obstante, discutible que la intervención de estos personajes en las *auktiones* resultase imprescindible³.

1 Cfr. ANDREAU, J., *La vie financière dans le monde romain, Les métiers de manieurs d'argent*, Roma, 1987, especialmente los capítulos 2, 3, y 4, pp. 61 a 167, en que se establece la siguiente clasificación: 1) Los *argentarii*, ya documentados en el *forum Romanum* a mitad del siglo IV a. C., se dedicaban al cambio y comprobación de moneda y a prácticas de depósito y préstamo. Las fuentes disponibles no atestiguan explícitamente entre sus ocupaciones el servicio de crédito hasta finales de la República; 2) Los *coactores* testimoniados en época republicana ya en tiempos de Catón, y cuya función principal era el cobro de las sumas a deudores y el consiguiente reintegro a los acreedores, operaciones por las que percibían una comisión (*merces*) que corría a cargo del deudor y que constituía normalmente, en el caso de las subastas, un porcentaje procedente del precio pagado por la cosa adjudicada. 3) Los *coactores argentarii*, en tanto que *coactores* se encargaban del cobro de la venta y de su entrega al vendedor y, como *argentarii*, proporcionaban un servicio de crédito al comprador, abrían cuentas de depósito y llevaban a cabo igualmente los registros de la subasta. Véase también TORRENT, A., *Diccionario de Derecho romano*, Madrid, 2005, voces *argentarius*; *coactor* y *coactores argentarii* (p. 118; 174). Sobre la posible quiebra del *argentarius* y la distinción entre acreedores particulares y comunes de los banqueros véase de este mismo autor, *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo*, vol. LVI, (2013), pp. 181-214.

2 En relación a esta materia, cfr. TORRENT, A., *Moneda, crédito y Derecho Penal monetario en Roma* (S. IV a. C.- IV d. C.), SDHI, 73, 2007, pp. 116 ss.

3 Cfr. GARCÍA MORCILLO, M., *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona, 2005, quien en p. 107 y 132- 133 pone de relieve cómo en determinadas esferas se documenta la presencia de otros intermediarios financieros, no incluidos en la categoría de banqueros profesionales, como aquellos que solían actuar, por ejemplo, en los negocios inmobiliarios de la élite tardo republicana y que figuran retratados en la correspondencia ciceroniana (así por ejemplo en Cic. *Ad Att.* 1, 13, 6). En cambio, para DOMERGUE, C., *La*

El interés historiográfico por la banca profesional romana se encuentra documentado entre otros textos en la *lex metalli Vipascensis* y en el archivo del pompeyano *Lucius Caecilius Lucundus*⁴.

Tanto los recibos del banquero pompeyano *Lucundus* como la *lex metalli Vipascensis* demuestran el uso efectivo de la *stipulatio* –en detrimento de otros tipos de contrato como por ejemplo, la *locatio-conductio*–, como instrumento legal que regulaba el compromiso de pago por parte del comprador al banquero, y de éste al *dominus*, y que permitiría la obtención de las diferentes comisiones, incluido el porcentaje de la tasa sobre las *auktiones*⁵.

El capítulo primero de la *lex metalli Vipascensis* presenta la figura de la *stipulatio argentaria* como el medio de recaudación del impuesto de la *centesima* por parte del *conductor*, concesionario de la tasa en el distrito minero, del que el *fiscus* era propietario⁶.

La alusión a esta *centesima argentariae stipulationis* muestra la necesaria presencia del *argentarius* en la operación, a través del servicio de crédito al comprador sobre el precio de la venta. Éste a su vez se comprometía al pago en una fecha determinada a través de *stipulatio*, que incluiría el porcentaje correspondiente a la tasa⁷.

mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, Talence, 1983, p. 64, no se conoce en el mundo romano, ejemplo alguno de *auctio*, que haya tenido lugar sin el concurso de un *argentarius*.

4 Cfr. ANDREAU, J., *Les affaires de Monsieur Lucundus*, Roma, 1974; CAMODECA, G. *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii, I-II, Roma 1999. Sobre la *lex metalli Vipascensis*, cfr. infra nota 9.

5 La *stipulatio* concebida como un contrato verbal de carácter vinculante, aplicado tanto en el ámbito público como en el privado, representa una huella irrefutable de la frecuente práctica del pago a término en las *auktiones* (véase GARCÍA MORCILLO, M., *Las ventas por subasta...* cit. p. 98). Por *auctio* entendemos la subasta pública, practicándose la *venditio in auctionem*, tanto para bienes públicos como de los particulares (cfr. TORRENT, *Diccionario...* cit. p. 122). SCHÖNBAUER, E., *Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis*, ZSS, 45 (1925) p. 371, contraponen el término *auctio*, que por regla general implicaba la subasta de un complejo patrimonial a través de sujetos privados al de *sectio* (instituto a través del cual el Estado vendía universalmente los bienes de un ciudadano como consecuencia de una actuación delictiva de éste, o por ser deudor del *aerarium*, o por quedar vacante su herencia (cfr. TORRENT, *Diccionario...* cit. p. 140; para más detalles, cfr. DONADIO, N., *Le 'auktiones' private all'epoca di Plauto*, en CANTARELLA, E. Y GAGLIARDI, L. [a cura di], *Diritto e teatro in Grecia e Roma*, Milán, 2007, p. 121).

6 Indica STURM, F. (cfr. *Stipulatio argentaria*, en *Mélanges Felix Wubbe*, Friburgo, 1993, p. 453) que la expresión *stipulatio argentaria* que encontramos en la rúbrica de la precitada inscripción representa un *απαξ*, es decir algo desconocido, por cuanto que no figura ni en el *Corpus Iuris* justiniano, ni en otras fuentes jurídicas. Los textos literarios parecen ignorarla igualmente. Podemos citar entre otros testimonios epigráficos en que se hace alusión a la mencionada figura, una inscripción funeraria de Ostia que se remonta al período que comprende entre el final del siglo I y el comienzo del s. III de nuestra era – se trata de CIL XIV 405- en la que se indica como profesión del difunto la de *stipulator argentarius*. En otra inscripción funeraria procedente de Milán, CIL V 5892, y que se remonta al reinado de Septimio Severo, encontramos la abreviatura *neg. stip. arg.* que ANDREAU (cfr. *op. cit.* p. 176) interpreta como *negotiator stipulator argentarius*.

7 En efecto, la *stipulatio argentaria* representa según ANDREAU (cfr. *op. cit.* p. 136) una obligación en la que intervienen el comprador y el *argentarius* o el *coactor argentarius*. Compromete al primero a pagar al segundo el precio de la cosa adjudicada en una fecha determinada. Según ANDREAU, en defecto de *argentarius* o de *coactor argentarius* no hay *stipulatio argentaria* posible. Es seguro por tanto, que al menos un *argentarius* o *coactor argentarius* trabajaba en el distrito de Vipasca y que intervenía en las subastas con concesión en las mismas del crédito correspondiente.

Pero veamos a continuación con un poco más de detalle cómo funcionaba este instituto.

Vipasca da nombre a todo el distrito minero del que se extraía cobre y plata, y cuya normativa reguladora de las distintas actividades, tanto la principal de la minería, como los servicios complementarios, queda recogida en el texto epigráfico de las dos tablas de bronce halladas entre las escorias mineras de los Algarés en Aljustrel, en la región del Baixo Alentejo portugués⁸.

La tabla de bronce llamada Vipasca I (*lex metalli Vipascensis*), cuyas medidas son 785×520×8/13 mm, fue encontrada en 1876⁹, y la Vipasca II (*lex metallis dicta*), con similares dimensiones (765×550×12 mm), en 1906¹⁰. La tabla II se conserva en el Museu Nacional de Arqueología e Etnologia de Belém, y la I en los Museos dos Serviços Geológicos en Lisboa.

La primera de las dos tablas encontradas en Aljustrel, al Sur de Portugal, contiene fragmentos del estatuto del territorio minero de Vipasca. Se la denomina por esta razón, *lex territorio metalli Vipascensis dicta*, o más brevemente, *lex metalli Vipascensis*. Se trata de una tabla opistógrafa que expresa el texto de una *lex locationis*, en la que se establecen las condiciones de arrendamiento de los servicios públicos del distrito minero en régimen de monopolio¹¹.

En general¹² se suele situar cronológicamente esta inscripción en el siglo II de nuestra era. Hübner considera en cambio por la forma que revisten los caracteres alfabéticos, la

8 G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion. Zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht*, Berlin, 1961, pp. 61-63, resume el sistema de gestión administrativa del distrito minero de Vipasca, dirigido por el *procurator metallorum*, y que en su conjunto se correspondía a un modelo presente en otras explotaciones mineras bajo el control del fisco en época imperial. En tanto que propietario de la mina, el *fiscus* imperial podía regular jurídicamente la explotación de los recursos así como los servicios y actividades de ella derivados, tales como las *auctiones*. Para STURM, (cfr. *op. cit.* p. 456) el Fisco no es el único propietario de las minas. En realidad, todo el territorio minero pertenece al emperador como *res privata* (véase Ulp. (68 ed.) D. 43, 8, 2, 4: ... *res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt...*). El Fisco puede por tanto reglamentar mediante *lex dicta* todas las actividades económicas que se ejerzan, lo que constituye un claro precedente del monopolio señorial existente en la Edad Media bajo el nombre de “banalidad”.

9 Respecto de las diferentes ediciones y comentarios cfr. entre otros, HUMBERT, M., *Les lois des Romains*, 7^e édition des Textes de droit romain de Girard/Senn, Naples, 1977, (nota 2), p. 591, FLACH, D., *Die Bergwerkssord von Vipasca*, Chiron 9 (1979), pp. 399 ss.; DOMERGUE, *La mine antique...* cit.; CAPANELLI, *Alcune note relative alle leges metalli Vipascensis*, BIDR 86/87 (1984), pp. 121 ss. Vid. texto y más referencias en http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Negotia/Metallis2_Girard.htm.

10 Cfr. edición reciente en LAZZARINI, S., *Lex metallis dicta*. Studi sulla seconda tavola di Vipasca, Roma, 2001; más recientemente, por él mismo, *Seconda Tavola di Vipasca*, en PURPURA, G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA)*. Studi preparatori, I. Leges, Turín, 2012, pp. 43 ss. (con más lit.).

11 Sobre ello, véase, ampliamente, MATEO, A., *Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana*, Santiago de Compostela, 2001, pp. 87 ss. Cfr. FERRER MAESTRO, J.J., ¿Gestión recaudatoria o fiscalidad racional? Otra visión de Vipasca, en *Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua: La Hispania de los Antoninos (98-180)*, Valladolid, 10-12 de noviembre de 2004, p. 547.

12 Cfr. BRUNS/GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui*, 7^a ed., Tubinga 1909, p. 289, nota 112; RICOBONO, *FIRA*, I, Florencia 1941, p. 502, nota 105; HUMBERT, *op. cit.* (nota 2), p. 82.

ortografía y el lenguaje empleado por el redactor, que dataría de la segunda mitad del siglo primero¹³. Sturm¹⁴, sin embargo, estima que esta opinión omite una doble consideración:

- a) El texto menciona en reiteradas ocasiones al *procurator metallorum*¹⁵, también llamado *procurator qui metallis praeerit*, funcionario que fundamentalmente encontramos en el siglo II¹⁶.
- b) Como ya hemos indicado, en 1906 en Aljustrel, se encontraría una segunda tabla a la que se suele denominar *lex metallis dicta*, que se podría considerar precursora de la primera¹⁷, y que parece que no fue grabada hasta el reinado de Adriano (117-138 d. C.)¹⁸.

Sturm¹⁹ se plantea cuál es la finalidad de este estatuto desgraciadamente fragmentario del territorio de Vipasca, y sobre este particular indica que la normativa que según el azar histórico se ha conservado no versa ni sobre la concesión del derecho de extraer el mineral (cobre y plata), ni sobre la atribución de los pozos, medidas cuya adopción estaba estrictamente reservada al *procurator metallorum*, es decir, al delegado en materia de minas, nombrado por el emperador, cuestiones todas ellas que reciben reglamentación en la segunda tabla, es decir, en la *lex metallis dicta* del emperador Adriano²⁰.

En relación a *Vip. I* indica A. D'Ors²¹ que como es frecuente en el estilo legal romano, no se observa un orden sistemático de materias. En los distintos capítulos se trata del régimen de arriendo de los distintos servicios del distrito minero²².

13 Cfr. HÜBNER, *Lex metalli Vipascensis*, Ephemeris epigraphica 3, 1877, pp. 165 ss. ; mantiene una posición similar CUQ, *Un règlement administratif sur l'exploitation des mines au temps d'Hadrien*, Mélanges Gérardin, Paris, 1907, pp. 87 ss.

14 Cfr. STURM, *Stipulatio argentaria*, cit. pp. 454-455.

15 Cfr. líneas 2, 3, 15, 21, 30, 57.

16 Cfr. MARQUARDT/DESSAU/DOMASZEWSKI, *Römische Staatsverwaltung*, II, reimpresión Darmstadt, 1957, pp. 264 ss.; con relación a los poderes administrativos y jurisdiccionales del *procurator metallorum* cfr. HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, 2ª ed., Berlin, 1905, pp. 160 ss. ; CUQ, *Un règlement administratif...* cit. (nota 5), pp. 87 ss; DOMERGUE, *op. cit.* (nota 3), pp. 174 ss., y CAPANELLI, *op. cit.* (nota 9), pp. 141 ss.

17 La referida *lex metallis dicta* figura mencionada en el capítulo 9 del texto de Vipasca I Cfr. *Vip. I*, 9: ... Qui intra fi[nes metalli Vipascensis puteum locum]/ que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabit e lege metallis dicta...

18 Indica STURM, *op. cit.* p. 455, nota 9 que el nombre de Adriano aparece en las líneas 5 y 6 de *Vip. II*, 1: "... quorum pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp. Hadriani Aug. obser/vabuntur, ita ut..." La expresión *sacratissimus* nos permite suponer que el emperador vivía todavía en el momento de redactarse esta disposición. Para DOMERGUE, (cfr. *op. cit.* pp. 179. 180), *Vip. I* al igual que *Vip. II*, siendo tal vez la redacción del texto de esta última un poco anterior que el de la primera, podrían fecharse ya hacia fines del siglo I, ya hacia comienzos del II, por ejemplo en el gobierno de Trajano o en los primeros años del reinado de Adriano.

19 Cfr. STURM, *op. cit.* p. 455.

20 LAZZARINI, *op. cit.* (nota 10), p. 14.

21 Cfr. D'ORS, A., *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953, pp. 80 ss.

22 Señala D'ORS, A (cfr. *op. cit.* p. 82) que los *conductores* de los distintos servicios de Vipasca eran, muy probablemente, personas distintas, no un único concesionario; también los concesionarios de la extracción de mineral eran varios. Generalmente tales arrendatarios del monopolio constituyeran sociedades, y a ellas alude *Vip. I*, cap. I, con el término *conductor socius actorve eius (vectigalis)*. El régimen de monopolio que se nos documenta en

La inscripción de la conocida como *lex metalli Vipascensis* comienza en el primer capítulo con los genitivos *centesimae argentariae stipulationis*²³, rúbrica a la que se refiere el primer párrafo, es decir, las líneas 1 a 9²⁴:

(1) Centesimae argentariae stipulationis. ¹Conductor ea[rum uenditionum, quae per auctio] nem intra fines metalli Vipascensis fient, exceptis iis, quas proc(urator) metallorum iu[ssu imp(eratoris) faciet, centesimam a uendito]re accipito. ²Conductor ex pretio puteorum, quos proc(urator) metallorum uendet, cent[tesimam ab emptore exigo]. / ³Si instituta auctione uniuersaliter omnia addicta fuerint, nihilo minus uenditor ce[ntesimam conductori socio acto]//riue eius praestare debeto. ⁴Conductor socio actoriue eius, si uolet stipulari au[t pignus capere liceto]. ⁵Conductor / socius actorue eius < eius> quoque summae, quae excepta in auctione erit, centesimam exigo. ⁶[Qui res sub praecone] / habuerit, si eas non addixerit et intra dies decem, quam sub praecone fuerint, de condici[one uendiderit, nihilo minus con] / ductori socio actoriue eius centesimam d(are) d(ebeto). ⁷Quod ex hoc capite legis conduct[ori socio actoriue eius debetur], / nisi in triduo próximo, quam debere coeptum erit, datum solutum satisue factum erit, du[plum d(are) d(ebeto)]//²⁵

Vipasca presenta gran semejanza con el de la organización financiera en el Egipto ptolomaico, continuado después bajo la dominación romana. Sobre las sociedades explotadoras de las minas, vid. Plinio *Naturalis Historia* 33, 118 y 34, 165. Tales *conductores* venían a ocupar una posición semi-pública y de ahí que se les concediese una *pignoris capio* en defensa de sus derechos contra los deudores morosos o por incumplimiento del pago de los impuestos, que muy probablemente recaudasen las *socitates publicanorum*. Un ejemplo particular de *pignoris capio* reside en la facultad reconocida a los *magistri pagi* -jefes locales de los distritos territoriales en zonas rurales- y a los *publicani* en la *Lex rivi Hiberiensis*, para pignorar bienes (*pignoris capiones*) de quien no haya podido o querido pagar las sumas debidas, pudiéndose, en caso de impago de la deuda dentro de los cinco días siguientes al requerimiento, procederse a la venta en subasta pública de los bienes pignorados (cfr. TORRENT, A., *Los publicani en la Lex rivi Hiberiensis*, Rivista di Diritto romano, 13, 2013 <<http://www.ledondine.it/rivistadirittoromano>>).

23 La generalidad de la doctrina defiende que *centesimae* es un genitivo singular. Así para DOMERGUE, (cfr. *op. cit.* p. 59), el término *centesimae* no está en nominativo plural, sino en genitivo singular, y si se le hace depender de la palabra *conductio* sobreentendida, el título del capítulo I *centesimae argentariae stipulationis*, significaría claramente el arriendo (cesión en arrendamiento) de un impuesto, procedimiento habitual en Roma.

24 Reproducimos aquí la inscripción según la interpretación de MICHEL HUMBERT, *Les lois des Romains*, 7^e édition des Textes de droit romain de Girard/Senn, Nápoles, 1977, pp. 592 ss.

25 Capítulo.- 1- (Disposiciones escritas relativas al impuesto de la *centesima* (sobre el importe de las ventas que conlleve) la estipulación hecha por el banquero: ¹Sobre las ventas que se efectúen en subasta en el interior del territorio de la mina de Vipasca, con excepción de aquellas que el procurador de las minas haga por orden del Emperador, el arrendatario (*conductor*) recibirá del vendedor una centésima. ²Sobre el precio de los pozos que venda el procurador de las minas, el arrendatario (*conductor*) reclamará del comprador una centésima. ³Si iniciada una venta en subasta, hubiese adjudicación universal, no con menos motivo deberá el vendedor proporcionar la centésima al arrendatario (*conductor*), a su asociado o a su agente. ⁴El arrendatario (*conductor*), su asociado o su agente podrá, si quiere, hacer una estipulación, o tomar una prenda. El arrendatario (*conductor*), su asociado o su agente reclamará también la centésima de la suma que en el curso de la venta en subasta haya sido recibida (por el banquero). ⁵Si el que hubiera subastado (*sub praecone*) unas mercancías no las hubiera adjudicado, y dentro de los diez días siguientes a la subasta, las vendiera por un acuerdo privado (*de condicione*), no por ello dejará de deber el pago de la centésima al arrendatario (*conductor*), su asociado o su agente. ⁷Para toda suma que, en virtud de este capítulo de la ley, se deba al arrendatario (*conductor*), a su asociado o a su agente, y que en el plazo de tres días a partir del momento en que fuese exigible, no haya sido ni pagada, ni satisfecha de otro modo, ni garantizada, habrá que pagar el doble.

El capítulo I versa sobre el derecho a la *centesima* (1 por 100) sobre la *argentaria stipulatio* y sobre qué sea la *centesima argentariae stipulationis* han surgido fundamentalmente dos líneas interpretativas:

- 1) La palabra *conductor* se interpretó primeramente en el sentido de que se trataba del arrendatario del monopolio de la banca de Vipasca. La *centesima* percibida en Vipasca y descrita en el capítulo I representaría una especie de salario percibido por el banquero activo en el distrito.

Para Th. Mommsen, J. Flach, F. Kniep, O. Hirschfeld y E. Hübner se trataría de la *merces* correspondiente al *argentarius* (o al *coactor argentarius*), es decir de la comisión que percibe por su intervención en las subastas públicas, y que se añadiría al montante de intereses que cobra sobre la cuantía del crédito que concede al comprador para la adquisición del bien adjudicado²⁶.

En efecto, sabemos que en las ventas por subasta (*aucciones*), cuyo régimen nos es mejor conocido desde el descubrimiento, contemporáneo del de Vip. I, de los díticos de tablillas pertenecientes a la banca pompeyana de Cecilio Jucundo²⁷ intervenía, además del pregonero (*praeco*), una persona intermediaria que era el *argentarius*, que venía a actuar como comisionista intermediario entre el vendedor y el comprador. Tal banquero cobraba por sus servicios una comisión, que deducía del precio que debía entregar al vendedor, y, generalmente, realizaba este pago antes de haber cobrado realmente del comprador, el cual prometía el precio para un momento ulterior, mediante una estipulación.

Así pues, según esta primera y extendida interpretación del texto con que comienza nuestro fragmento legal, existía en Vipasca un monopolio de la banca²⁸, y el banquero tenía derecho a cobrar un 1 por 100 sobre el precio de toda subasta. La *centesima* representaría un canon en concepto de salario (*merces*) a percibir por el banquero que ostentase en Vipasca el monopolio de la banca, al igual que en el capítulo 2 otra *centesima* constituiría el salario del pregonero.

Domergue, en cambio, objeta a esta primera línea interpretativa que no cabe una equiparación entre ambos capítulos, por cuanto que Vip. I, 2, precisa los derechos y obligaciones del *praeco* que desempeña su oficio en régimen de monopolio, mientras que Vip. I, 1 se ocupa tan solo de las circunstancias en las que es exigible la *centesima*, lo que hace pensar que más bien se trata de un impuesto²⁹.

26 Cfr. MOMMSEN, Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundus, Hermes 12, 1877, p. 101; HÜBNER, Lex metalli... cit. p. 174; WILLMANS, G., Die römische Bergwerksordnung von Vipasca, Zeitschrift für Bergrecht 19, 1878, 217-232; FLACH, D., Die Bergwerksordnung von Vipasca, Chiron 9, 1979, 399- 498; C. RE, C., La tavola Vipascense, Archivio Giuridico 23, 1879, 343-348; HIRSCHFELD, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten cit. p.94; KNIEP, F., Argentaria Stipulatio, en: Festgabe des Juristischen Fakultät Jena für August Thon, Jena, 1911, 1-62.

27 Cfr. SCHÖNBAUER, E., Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis, ZSS, 45 (1925) pp. 363 ss. Cfr. supra nota 4.

28 Para STURM, en cambio, (cfr. *op. cit.*) ignoramos si los banqueros que organizaban las subastas y a quienes por consiguiente se les llamaba *coactores argentari* eran igualmente beneficiarios de un monopolio. En efecto, su estatuto podría haber estado regulado en las dos tablas perdidas, precedentes a la que examinamos. En esta última figura en efecto escrito en su parte inferior a la izquierda, el número III.

29 Cfr. DOMERGUE, p. 62.

Añade Andreau³⁰ que, de adoptar esta primera posición, el que tome en arriendo como recaudador la centésima, es decir el *conductor*, de no ser él mismo el *argentarius* (o *coactor argentarius*) debería ser él quien proporcionara el *argentarius*, de igual modo que quien toma en arriendo la *scriptura praeconii* debe facilitar el *praeco*³¹. Y si bien las fuentes disponibles indican un vínculo entre la recaudación del impuesto sobre las *subastas* y los banqueros privados, no existen pruebas de alguna forma de concesión o de nexo entre estos últimos y las autoridades competentes³².

- 2) La segunda corriente interpretativa estima que la *centesima argentariae stipulationis* referida en la *lex metalli Vipascensis* debe generalmente identificarse con el impuesto que gravaba las *subastas* desarrolladas en este distrito minero, dado en concesión a un *conductor*.

Esta posición inicialmente adoptada por Binder³³ y Demelius³⁴ y con posterioridad por E. Schönbauer³⁵, M. Talamanca³⁶, G. Thielmann³⁷, C. Domergue³⁸, J. Andreau³⁹ y F. Sturm⁴⁰, conceptúa la *centesima* como un impuesto sobre las *subastas*.

Fue principalmente Demelius quien, siguiendo a Binder, iniciaría la consideración de que el objeto del arriendo no era el negocio de banca, la cual habría quedado libre y sin reglamentar, sino el impuesto mismo de la *centesima rerum venalium*, llamado también *centesima auctionum*⁴¹.

30 Cfr. ANDREAU p. 135.

31 *Qui praeconium conduxerit, praeconem intra fines praebe[re]*. (CIL II, 5181, l. 10= F.I.R.A., I, p. 504.) Asimismo, ANDREAU, *La vie financière* cit. (nota 1), p. 596 : « Mais le plus souvent, l'*argentarius* ou le *coactor argentarius* qui intervenait dans les enchères se chargeait probablement aussi de lever la taxe... »

32 Cfr. ANDREAU, *La vie financière*, cit. p. 596 : « Quant au mode de perception de la taxe... elle n'était pas levée par des administrateurs de l'Etat, mais par des fermiers. Le fonctionnement concret de cette ferme n'est pas connu. Rien n'oblige à penser que le fermier était, dans tous les cas, un banquier de métier... »

33 Cfr. BINDER, J. J., *Die Bergwerke im römischen Staatshaushalte*, Zeitschrift für Bergbaurecht 32, 1881, pp. 61 ss.

34 Cfr. DEMELIUS, G., *Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis*, ZSS 4, 1883, 33-49.

35 Cfr. op. cit.

36 M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, Atti Della Accademia Nazionale dei Lincei, Serie ottava, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. VI/2, Roma, 1954-55, p. 147-150.

37 G. THIELMANN, pp. 67-70.

38 ³⁰ C. DOMERGUE, pp. 48-49 y 66.

39 Cfr. op. cit.

40 C. op. cit. p. 465 n. 463: "C'est à tort que Mommsen considère la *centesima argentariae stipulationis* comme commission d'un pour-cent à laquelle a droit, à titre de *merces*, celui qui a affermé le monopole de commissaire-priseur ».

41 El mencionado impuesto sobre las ventas en pública subasta fue introducido por Augusto tras las guerras civiles en el año 7 d. C. (Tácito *Ann.* I, 78) y representaba el 1% del valor de la venta. Sería reducido al 0,50 % por Tiberio en el año 17. De este impuesto, según Suetonio (*Calígula*, I, 16), Calígula habría declarado exenta a Italia en el año 39, aunque probablemente subsistiría en las provincias como lo demuestra *Vip. I*, I, tal vez incluso hasta el final del Imperio. En efecto, versan todavía sobre la misma un texto de Ulpiano (10 ed.) D. 50.16.17.1: *Publica vectigalia intelligere debemus...* y dos pasajes del Código, a saber C. 12, 19, 4; 12, 46, 1, 6. Parece que con posterioridad, el impuesto llegaría de nuevo a ser introducido en toda su extensión como *centesima* (cfr. D'ORS, A, op. cit. p. 83, SCHÖNBAUER, E., op. cit. pp. 381 ss.; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, L., *Algunas precisiones en materia*

Para Demelius, el negocio bancario, en contraposición a los otros oficios, no habría estado monopolizado en el territorio de Vipasca. Como organizador de las subastas, habría que pensar más bien en algún *argentarius* privado.

Este mismo punto de vista sería con posterioridad aceptado por Rostovtzeff⁴², Beseler⁴³ y, parcialmente, por Schönbauer, quien, si bien explícitamente afirma que el primer inciso de la inscripción de Vipasca no versa sobre el negocio bancario, sino sobre el impuesto sobre las subastas⁴⁴, se distancia de la opinión de Demelius al considerar que no es que la banca quedara sin monopolizar, sino que la reglamentación de ese monopolio se hallaría probablemente en otro lugar perdido de la ley⁴⁵.

Para Schönbauer el negocio bancario se encontraba monopolizado en Vipasca en manos del titular de una concesión, cuyas competencias probablemente se encontrasen minuciosamente reguladas. Según el mismo autor⁴⁶, al menos para el distrito de Vipasca se habría decretado que en toda subasta, sin excepción, el titular del negocio bancario debería actuar como intermediario, por cuanto que, aunque entre los romanos era habitual servirse de un banquero, no existía ninguna prescripción obligatoria al respecto.

Añade Schönbauer que la *stipulatio argentaria* sería la estipulación por la que el banquero se hacía prometer por parte del comprador el pago del precio, estipulación que serviría para el cálculo de la *centesima*, y no, como creían Mommsen, Hübner y otros, la que exigía el vendedor del banquero para la entrega del mismo precio, deducida la comisión.

Respecto de a quién debiera dirigirse el recaudador de la *centesima* para el cobro de ese 1 por 100, aunque suele verse en las ediciones la expresión *a vendito]re accipito*, Schönbauer opta en cambio, por suplir las lagunas con los términos *a coacto]re accipito*⁴⁷, y en consecuencia estima que, para mayor comodidad, el perceptor del impuesto, en lugar de dirigirse contra el vendedor, por quien en esta hipótesis entenderíamos el *procurator metallorum*, formularía una reclamación directa contra el mismo banquero. Y que sería éste en consecuencia, quien debería deducir del precio a entregar al *procurator metallorum* un 1 por 100 en favor del *conductor centesimae*.

A continuación, se establece en la ley una excepción a la regla general consistente en que en todas las estipulaciones que se convengan en las subastas ha de transferir el banquero un porcentaje al arrendatario del impuesto. Dicha excepción (*exceptis iis...*), establecida a favor del Fisco y contra el interés del *conductor*, tiene aplicación cuando la venta se hiciese sin intervención del banquero, es decir, directamente por el *procurator* con la autorización

de impuestos indirectos en la época augustea, RIDA, 33, 1986, pp. 194 ss.; STURM, F., *Stipulatio argentaria*, cit. p. 458 n. 18; TORRENT, *Diccionario de Derecho romano*, cit. p. 159.

42 ROSTOVITZ, M., *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig, 1902, pp. 383 ss.

43 Cfr. BESELER, G., *Miszellen*, ZSS, 46, (1926), p. 267, en que señala el autor explícitamente que el *conductor* no es el banquero, sino el arrendatario de impuestos. Véase también CAPANELLI, *op. cit.* (nota 9), pp. 124 ss.

44 Cfr. SCHÖNBAUER, E., *op. cit.* p. 381.

45 Cfr. SCHÖNBAUER, E., *op. cit.* p. 359, precisamente el negocio bancario, con más frecuencia que otros negocios, es el que fue especialmente regulado y monopolizado en la Antigüedad.

46 Cfr. SCHÖNBAUER, E., *op. cit.* p. 383.

47 Cfr. *op. cit.* p. 385.

(*iu[ssu]*) del Emperador. Sin embargo, aun en este caso, si el objeto vendido fuese un pozo⁴⁸, indica la ley que el *conductor* sí podrá cobrar la *centesima*, pero no ya del banquero, que no ha intervenido en el negocio, sino del comprador del pozo. De ahí que Schönbauer realice la reconstrucción *cen[tesimam ab emptore exigit]*, y no *accipito*, como en el supuesto normal en que se cobra del banquero. En consecuencia, el que compraba el pozo al *procurator* debía pagar a éste el precio y al *conductor centesimae* un 1 por 100 del precio⁴⁹.

Todo el resto del capítulo trata de los casos en los que ese derecho del *conductor centesimae* podría verse frustrado, precisamente por no intervenir una *stipulatio argentaria* que sirva de base.

El primer supuesto de este tipo de venta gravable por la *centesima*, pero en la que falta la *stipulatio argentaria*, es el de una *auctio (institutum auctione)*⁵⁰, en la que no hay adjudicaciones singulares para cada uno de los objetos en venta, sino una adjudicación universal de todos ellos a un único comprador (*universaliter omnia addicta*) por un precio único.

En contra del parecer de Hübner, para quien en este supuesto la venta se realizaría al margen de la subasta, A. D'Ors⁵¹ estima que la utilización del término *addicta* indica una atribución dentro de la subasta, aunque es evidente que la *centesima* no es abonada aquí por el *argentarius-coactor*, sino por el *venditor*.

En este supuesto, probablemente la intervención directa del vendedor en la venta determinaría que el precio global le fuese prometido directamente a él y no al banquero. De esta suerte, el banquero habría inicialmente intervenido en la subasta, pero al no participar él en la *stipulatio*, faltaría la base para la percepción de su *centesima*. Sin embargo la ley considera que el *conductor* de ese impuesto no debe en ese caso quedar defraudado, y obliga al vendedor a pagarle un 1% del precio global de aquella venta.

Indica Schönbauer en relación con esta hipótesis⁵², que quien se haya dirigido a la autoridad pública para dar a conocer su deseo de organizar una subasta, se verá necesariamente afectado por el impuesto, al mismo tiempo que se realiza la transmisión del patrimonio.

48 El derecho de extracción del mineral de un pozo minero era adquirido por el empresario de minería con base en la ocupación de la mitad del *puteus*, con la obligación de rescatar la otra mitad, perteneciente al *fiscus*; en caso de no realizarse ese rescate de la parte fiscal (ya sea porque el *occupator* no ha querido optar por adquirir la parte fiscal, o porque tampoco ha encontrado comprador para su propia parte), el *occupator* perdería su parte y el *puteus* entero debería subastarse en favor del Fisco por el *procurator metallorum*: cfr. NEGRI, G., *Diritto minerario romano, I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milán, 1985, p. 134; MATEO, *Observaciones cit.* (nota 11), p. 165.

49 Para ANDREAU en cambio (cfr. *op. cit.* p. 134), no puede asegurarse que esta *centesima* sea igualmente recaudada, con ocasión de las ventas organizadas por el procurador que gobierne el distrito, como por ejemplo en las ventas de pozos mineros, por cuanto que la inscripción presenta en este punto importantes lagunas y las posibles reconstrucciones en modo alguno son evidentes, y así como SCHÖNBAUER, *op. cit.*, p. 386, y THIELMANN (cfr. *Die römische Privatauktion...* cit. p. 267) completan con los términos *cen[tesimam ab emptore exigit]*, RICCOBONO (cfr. *FIRA*, I n° 105), siguiendo la posición de DEMELIUS, reconstruye el texto (lin. 1-3), como *cen[tesimam ne exigit]*, sosteniendo por lo tanto que ninguna tasa habría sido exigida en este tipo de ventas emprendidas por las autoridades del distrito; en el mismo sentido, CAPANELLI, *op. cit.*, p. 125.

50 Para SCHÖNBAUER, *op. cit.* p.387 y D'ORS, A., *Epigrafía jurídica...* cit. p. 85 más habitualmente debiera decirse *constituta auctio*.

51 Cfr. *op. cit.* p.85.

52 Cfr. SCHÖNBAUER, *op. cit.* p. 387.

Señala D'Ors que aquí no se dice ya *centesimam accipere*, sino *praestare debeto*, porque aquí no es el *argentarius* quien deduce el impuesto, sino el vendedor quien debe pagarlo al *conductor*, el cual aparece designado en forma social como *conductor socius actorve*⁵³.

Si sucediere que el pago de ese precio global no se hiciese efectivo en el mismo momento, la ley prevé que el *conductor* pudiese desear (*si volet*) una garantía, y de ahí que le faculte para hacerse prometer la *centesima* por *stipulatio*, o incluso que pueda exigir una prenda⁵⁴. Para A. D'Ors⁵⁵, es natural que se conceda la posibilidad de una garantía real, ya que tratándose del 1 por 100 de un precio que debía de ser elevado precisamente por ser global, era muy probable que el riesgo de impago resultase relevante.

Otro caso en que la ley defiende el interés del *conductor centesimae* es aquel en el que figure en la *stipulatio argentaria* una cantidad inferior a la realmente alcanzada en la subasta. Podía ocurrir que por donación, por *datio in solutum* o, más frecuentemente, por compensación convencional, el *argentarius* se hiciera prometer una cantidad inferior al precio ofrecido por el comprador. En tal caso, la base para la *centesima* no debería ser la cantidad que figura en la *stipulatio*, sino la que realmente intervino en la subasta.

Así para Schönbauer⁵⁶, en la hipótesis, por ejemplo, con motivo de una compensación de créditos, de adjudicación de las cosas en la subasta por un precio más alto de lo que el vendedor hubiere realmente de recibir en pago, debe incluirse en la base para el cálculo del impuesto la parte del valor que el comprador no tiene obligación de pagar.

En sentido similar concluye D'Ors que si bien la denominada *summa excepta*, en cuanto que cantidad suplementaria, es evidente en todo caso que no podía figurar como precio estipulado en un sentido estricto, de ella no debe prescindirse en modo alguno para el cálculo de la *centesima*.

Otro supuesto análogo es aquél en el que, habiéndose iniciado una subasta (*sub praecone*), no se llegara a producir una *addictio* por no presentarse postor alguno que ofreciera la cantidad prefijada, pero que, ello no obstante, dicha venta se realizara libremente, al margen de la subasta, dentro de los diez días siguientes. Tal venta debía considerarse en tal hipótesis, como una consecuencia de la subasta iniciada, y por tanto, sujeta al impuesto al 1 por 100 en beneficio del *conductor centesimae*, a pesar de no haber mediado una *stipulatio argentaria* (por omitirse la *addictio*).

El capítulo termina señalando para el pago de la *centesima* el plazo de tres días, transcurrido el cual, si no se pagó o se liberó de otro modo el deudor o se garantizó su deuda (*datum solutum satis factum*), ésta se incrementa hasta el doble⁵⁷.

53 En opinión de CAPANELLI (*op. cit.*, pp. 129 ss.), la expresión *conductor socius actorve* alude verosíblemente al concesionario de la excavación minera –o de las otras muchas actividades previstas en la norma–, que se asocia, y al representante legal de la sociedad.

54 Ésta es la conjetura que sugiere SCHÖNBAUER (*cfr.*, *op. cit.* p. 388), sobre la base de que en el texto el único pasaje que se conserva comenzando por el dativo *conductor* se refiere justamente a la posibilidad de constituir una garantía real (lin. 16: *conductor pignus capere licet*).

55 *Cfr. op. cit.* p. 86.

56 *Cfr. SCHÖNBAUER op. cit.* pp. 388-389

57 *Cfr. D'ORS, A., op. cit.* p. 87.

Al margen de las cuestiones examinadas, el texto que comentamos ha suscitado otras posibles divergencias doctrinales, como la relativa a determinar quién sea la persona del *venditor*, mencionado en el capítulo I de *Vip. I*.

Sobre este particular, estima Sturm⁵⁸ que con el término *venditor* no se alude propiamente al *dominus auctionis* (propietario de los bienes vendidos en subasta), sino que como regla general, con dicho vocablo se designa a aquél que organiza estas subastas y contrata con el comprador que más ofrezca. En principio, por tanto, el *venditor* no es sino el *coactor argentarius*, es decir, el banquero que ejerciese la función de tasador de subastas.

Siguiendo esta afirmación, Sturm se opone a la opinión de numerosos autores, cuya opinión compartimos⁵⁹, que consideran que el *dominus auctionis* es el verdadero vendedor, y se basa para ello este investigador en algunos testimonios jurídicos⁶⁰, en algunos textos literarios⁶¹, así como en la consideración de que no existe contrato alguno de venta entre el *dominus auctionis* y el *emptor*.

Añade este autor que, al desconocer la representación directa, los juristas romanos excluían toda posible relación jurídica entre estas dos personas. Es el *argentarius* quien se hace prometer por estipulación el precio, y no debe por tanto denominarse *venditor* a una persona que en modo alguno interviene en el contrato concluido por el *argentarius* y el *emptor*.

Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene la opinión dominante, y partiendo de la consideración de que el deudor de este impuesto es en principio el mismo banquero, para Sturm⁶² la *stipulatio argentaria* nada tiene que ver con las promesas formuladas respectivamente por el *emptor* y por el *argentarius*: por el *emptor* por una parte, para asegurar al banquero el pago del precio, y por el *argentarius* por otra, para garantizar al propietario el pago del importe de la venta, con deducción, claro está, de la retribución correspondiente al mismo banquero y de un eventual anticipo.

Según este mismo autor, la *argentaria stipulatio* es un instrumento de derecho privado que el Fisco pone a disposición del *argentarius*, deudor de la *centesima*, a fin de que pueda eludir la imposición de la sanción grave que supone la falta de pago puntual de esta tasa y que consiste en el doble de la deuda fiscal.

Otra de las cuestiones respecto de la cual no nos informan nuestras fuentes, y sobre la que se ha suscitado controversia doctrinal, es la relativa a precisar si los *argentarii* eran al mismo tiempo recaudadores del impuesto que afectaba a las *subastas*.

58 Cfr. STURM, *Stipulatio argentaria*... cit. p. 460.

59 Así TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta*... cit. pp. 131 ss., THIELMANN, op. cit. pp. 76 ss. y ANKUM, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique*, Studi Scherillo I, Milan 1972, pp. 377 ss.

60 Y cita en apoyo de su afirmación Ulp. (15 ed.), D. 5, 3, 18; Paul. (71 ed.), D. 44, 4, 5, 4 y Scaev. (5 dig.) D. 46, 3, 88.

61 Cfr. por ejemplo Cic. Pro Sexto Roscio Amerino 128: *Opinor enim esse in lege quam ad diem proscriptionis venditionesque fiant*...

62 Cfr. STURM, op. cit. pp. 464-465.

Hirschfeld contempla la posibilidad de que el régimen de concesión de la *centesima* a un *conductor* hubiese sido aplicado en todo el Imperio romano⁶³. La idea del arriendo de la tasa es asimismo mantenida por Mommsen, quien según el modelo representado por la *lex metalli Vipascensis*, atribuye al banquero la función de cobro del impuesto así como su entrega al *conductor*⁶⁴. Rostovtzeff llegaría incluso a identificar ambas figuras y a afirmar que el *argentarius* tenía siempre o casi siempre la consideración de *conductor* de la *centesima*⁶⁵. Rostovtzeff, y también Cagnat⁶⁶, señalan a la propia figura del banquero como destinatario de la concesión pública del impuesto y encargado de ingresar la suma en la caja pública.

En una línea similar, Corbier⁶⁷ argumenta que la escasa relevancia económica de la tasa habría justificado el empleo de banqueros-recaudadores y la consecuente inexistencia de personajes especializados encargados de su percepción.

Según Hübner⁶⁸, una única sociedad de arrendatarios detentaría el monopolio de todos los oficios y profesiones de interés público. También para Thielmann⁶⁹, una sociedad de *conductores*, similar a las sociedades comerciales que explotaban las colonias en los siglos XVII y XVIII, sería la que arrendase todos los monopolios del distrito.

Pero como indican Andreau⁷⁰ y Sturm⁷¹, cuya opinión suscribimos, tal cúmulo de funciones es poco probable y no hay nada que pruebe que los banqueros que ejerciesen la actividad de tasadores de subastas operasen al propio tiempo como *actores*⁷² (gestores) al servicio de la sociedad de publicanos que hubiese arrendado el cobro de la *centesima*.

A diferencia de los publicanos a los que Roma garantizaba el cobro de cánones e impuestos⁷³, los *coactores argentarii* no parecía que poseyeran una organización nacional, ni tampoco establecimientos dispersos, distribuidos en diversas provincias. Antes al contrario, no representaban más que cuerpos de profesiones locales⁷⁴.

63 HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten* cit. pp. 92-93. El autor refuerza esta hipótesis con el testimonio de una inscripción de la *Gallia Narbonensis*, leída por el autor como *soci(i) [vec(tigalis)] c(entisimae) et rotari*. Según esta interpretación, la *centesima* habría sido en este caso percibida conjuntamente con el *rotarium*, un arancel de paso.

64 MOMMSEN, *Die pompeianischen...* cit. pp. 98 ss.

65 Cfr. ROSTOVITZEFF, cfr. *Geschichte der Staatspacht...* op. cit. pp. 383 ss. En sentido similar se pronuncia también PLATON, G., *Les banquiers dans la législation de Justinien*, NRH, 33, 1909, pp. 137 ss.

66 Cfr. CAGNAT, R., *Les impôts indirects chez les romains jusqu'aux invasions des Barbares*, d'après les documents littéraires et épigraphiques, Paris, 1882, p. 232.

67 CORBIER M., *L'aerarium militare*, en CHASTAGNOL, *Armées et fiscalité dans le monde Antique*. Colloques Nationaux du C.N.R.S., Paris 14-16 octobre 1976, Paris 1977, pp. 197 ss..

68 Cfr. E. HÜBNER, *Lex metalli Vipascensis...* cit. p. 174.

69 Cfr. THIELMANN, *Die römische Privatauktion...* cit. pp. 69-70.

70 Cfr. ANDREAU, op. cit. p. 136.

71 Cfr. STURM, op. cit. p. 459.

72 Cfr. ANDREAU op. cit. pp. 611 ss.

73 Incluso en la época de Adriano, como indica CIMMA, *Ricerche sulla società di publicani*, Roma, 1981, pp. 30 ss.

74 Como pone de relieve ANDREAU (cfr. op. cit. p. 629), las sociedades de manufactureros de la plata no se constituyeron para permitir a los asociados la celebración de negocios en numerosas provincias o para crear sucursales. Las sociedades de *argentarii* tenían una amplitud limitada y, en un principio, no estaban integradas más que por dos asociados.

De otro modo, no se comprendería por otra parte, el privilegio de fuero de que gozaban los *argentarii*. Ellos no podían, en efecto, ser demandados más que en el lugar en que hubiesen sido contratados⁷⁵.

Podemos concluir que en general, y a pesar de la progresiva tendencia a partir de la etapa augustea a recurrir a funcionarios imperiales para suplir en sus competencias a los publicanos, no parece claro que los testimonios constaten la absoluta desaparición del sistema de arriendo en la recaudación de tasas durante el Alto Imperio⁷⁶. De este modo, Ulpiano evoca entre otros el impuesto sobre las *auctiones*, denominándolo *vectigal venalium rerum*⁷⁷, incluyéndolo entre los *vectigalia* públicos objeto de *locatio* pública⁷⁸.

75 Así se establece en Pap. (3 resp.), D. 5, 1, 45, pr.: *Argentarium ubi contractum est conveniri oportet nec in hoc dilationem nisi ex iusta causa dari, ut ex provincia códigos adferantur...*

76 Cfr. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, *Algunas precisiones en materia de impuestos indirectos...* cit., p. 202. Señala TORRENT, A. (cfr. *Los publicani en la Lex rivi Hiberiensis*, Rivista di Diritto romano XIII, 2013, p. 5) que en efecto, a partir de la reorganización fiscal de Augusto, se trataría de controlar a los publicanos y de sustituirlos por causa del *odium populi*, mediante una nueva burocracia constituida por funcionarios delegados del Emperador. Según este mismo autor, en modo alguno tales *societates publicanorum* subsistirían en la Tarraconense, en tiempos de Adriano. Algunos autores, como NICOLET, C. (cfr. *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris, 2000, p. 314) llegan incluso a considerar que con Augusto, o quizá con Tiberio, desaparecieron los publicanos en su función de recaudadores de impuestos. Un curioso testimonio epigráfico, recogido por HIRSCHFELD, (*Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten* cit. p. 94), menciona al liberto imperial *T. Flavius Aug(usti) libertus Firmus Narcissianus relator auctionum* (CIL VI 9035; 9035 a.). Según dicho autor, entre los años 69 y 140-150 d. C., el personaje del *relator* (del latín *referre*) se ocuparía de las subastas del *fiscus*, quizás actuando como comisario imperial con la función de percibir la *centesima*, encargándose entre otras funciones, de la entrega o remisión de ingresos derivados de las *auctiones*.

77 D. 50. 16. 17. 1 (Ulp. 10. ed.): *Publica vectigalia intelligere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit, quale est vectigal portus, vel venalium rerum, ítem salinarum, et metallorum, et piscariarum.*

78 D. 48. 19. 9. 9 (Ulp. 10. offic. proc): *Sunt autem et aliae poenae, si negotiation quis abstinere iubeatur, vel ad conductionem eorum, quae publice locantur, accedere, ut ad vectigalia publica.*

LA ACTIO EXERCITORIA COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO NEGOCIAL MARÍTIMO

EVA MARÍA POLO ARÉVALO
Universidad Miguel Hernández de Elche

La actividad comercial desarrollada en Roma, sobre todo a partir de la época en que se produjo la expansión territorial, tuvo su máximo exponente en el tráfico comercial marítimo, llevado a cabo a través de empresarios que habitualmente eran propietarios del buque y lo explotaban de forma directa en su propio nombre, pero que también podían cederlo a un tercero para que lo dedicara a una actividad propia de la navegación¹; esta actividad comercial se presentaba en Roma como un factor de gran relevancia para su economía, exigiendo, por su especificidad, que se llevara a cabo con las máximas garantías de seguridad jurídica². En efecto, la vocación internacional que tenía el tráfico comercial marítimo –acentuada más si cabe a partir del siglo III a.C.– ocasionaba que las relaciones comerciales en éste ámbito se desarrollaran a una gran distancia de la sede empresarial, surgiendo algunas complicaciones que no tenían lugar en otras esferas de la actividad comercial; así, la interacción con ordenamientos jurídicos diversos o la imposibilidad por parte de los terceros para conocer las circunstancias relativas a la propiedad y explotación de la nave o las relaciones existen-

1 Vid. a este respecto, entre otros autores, SOLAZZI, S., *Appunti di diritto romano marittimo*, en *Scritti Solazzi*, III, Napoli, 1960, pp. 503 y ss. (= en *Riv. Dir., Nav.*, II, 1936, pp. 113 y ss); ARIAS RAMOS, J., *El transporte marítimo en el mundo romano*, en *Libro Homenaje al Dr. Ignacio Serrano y Serrano*, Vol. II, Valladolid, 1965, pp. 27 y ss.

2 La actividad de la navegación como fenómeno jurídico singular dió lugar a que los juristas romanos adoptaran decisiones específicas para este ámbito; no obstante, se debe tener en cuenta, como advierte FADDA, que ellos nunca crearon instituciones particulares para una determinada profesión y que, por tanto, no existió en puridad un derecho comercial romano ni tampoco se puede afirmar que se creara un cuerpo normativo complejo referido al comercio marítimo con leyes distintas a las aplicadas en el tráfico comercial común; sin embargo, sí se puede constatar que, dentro del derecho privado que Roma tenía como ordenamiento único, se generaron decisiones particulares que vinieron a regular aspectos concretos de relevancia dentro de ese ámbito comercial. En este sentido, FADDA entiende que las *actiones adiecticiae qualitatatis* son un ejemplo ilustrativo de que “*il diritto classico non abbia ignorato la distinzione fra il traffico commerciale ed il comune, come anzi abbia tenuto presente la natura speciale oggettiva del rapporto commerciale*”. FADDA, C., *Istituti commerciali del diritto romano*, Napoli, 1903, pp. 45 y ss. Vid. también en torno a esta materia, DI PORTO, A., *Il diritto commerciale romano. Una zona «d'ombra» nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, en *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne*, vol. III, pp. 413 y ss.

tes entre *exercitor* y *magister navis*, imponían la exigencia de una mayor rigurosidad en el cumplimiento del principio de buena fe, haciendo necesario también que la responsabilidad contractual quedara asegurada, no sólo respecto de las personas que habían contraído las obligaciones directamente, sino también respecto de aquellas por cuya voluntad se habían llevado a cabo los contratos de los que derivaban aquellas³.

La necesidad de dar mayor seguridad a las operaciones mercantiles hizo necesaria la intervención del pretor que, con la creación de la *actio exercitoria*⁴, dentro del marco de las *actiones adiecticiae qualitatis*⁵, vendrá a conceder esas garantías adicionales requeridas en el ámbito comercial marítimo. Así, la *actio exercitoria*, creada en el siglo II a.C. con

3 En efecto, la creciente complejidad de la práctica comercial romana —no sólo en el ámbito interno sino también en el internacional— desarrollada a partir del siglo III a.C. ocasionaba algunos problemas considerados totalmente normales en un mundo económico rico y exigente, pero que requirieron soluciones más contundentes, con independencia de la extensión de los instrumentos de garantía existentes para asegurar las obligaciones. Como afirma RICART, Roma sufre la contradicción entre un tráfico mercantil galopante y un ordenamiento poco flexible en lo que se refiere a las variaciones de los sujetos de las obligaciones. RICART, E., “Constitutum debiti” y “Solutionis causa adiectus”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense* (Homenaje al Prof. Arias Bonet), Madrid, 1990, p. 242.

4 La doctrina romanística se ha ocupado del análisis de diversos aspectos de la *actio exercitoria* en numerosos estudios, entre los que cabe citar los siguientes: COSTA, E., Le azioni exercitoria e institoria nel diritto romano, Parma, 1891, pp. 98 y ss.; VALERI, G., Plures exercitores, en *Riv. Dir. Comm.*, XXI, 1923, pp. 14 y ss.; BESELER, G., Romanistische Studien, en *ZSS*, XLVII, 1927, pp. 56 y ss.; GHIONDA, F., Sul magister navis, en *Riv. Dir. Nav.*, I, 1935, pp. 327 y ss.; CHIALVO, G., De exercitoria actione, en *Studi Berlingieri*, 1935, pp. 171 y ss.; ARIAS RAMOS, J., Representación y praepositio, en *Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela*, X, 1941, pp. 11 y ss.; SOLAZZI, S., L'età dell'actio exercitoria, en *Riv. Dir. Nav.*, VII, 1941, I, pp. 185 y ss. (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1938-1947, pp. 243 y ss.); DE MARTINO, F., Studi sull'actio exercitoria, en *Riv. Dir. Nav.*, VII, 1941, pp. 7 y ss. (= en *Diritto, Economia e Società*, I, 1995, pp. 495 y ss.); PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, en *LABEO*, III, 1957, pp. 308 y ss.; DE MARTINO, F., Ancora sull'actio exercitoria, en *LABEO*, IV, 1958, pp. 277 y ss. (= en *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, Napoli, 1995, pp. 629 y ss.); MOSCHETTI, C.M., Il gubernator navis. (Contributo alla storia del diritto marittimo romano), en *SDHI*, XXX, 1964, pp. 172 y ss.; GUARINO, A., Magister y gubernator navis, en *LABEO*, XI, 1965, pp. 36 y ss.; BUCKLAND, W., Roman Law and Common Law. A comparison in outline, II, Cambridge, 1965, pp. 217 y ss.; LONGO, G., Actio exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria, in *Studi Scherillo* II, 1972, pp. 620 y ss.; FÖLDI, A., Appunti sulla responsabilità per l'“exercitor in potestate”, en *Tanulmányok Benedek Ferenc Tiszteletére*, Pécs, 1996, pp. 73-81; METRO, A., Una “dissensio” giurisprudenziale a proposito dell'“exercitor navis in potestate”?, en *BIDR*, XXXIX, 1997, pp. 183 y ss.; FÖLDI, A., La responsabilità dell'“avente potestà per atti compiuti dall'exercitor suo sottoposto, en *SDHI*, LXIV, 1998, pp. 179 y ss.; FERCIA, R., Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e regime della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios, Torino, 2002; PETRUCCI, A., Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magistri navis nel diritto romano dell'età commerciale, en *IURA*, LIII, 2002, pp. 51 y ss.; BRAVO BOSCH, M.J., La responsabilidad de la actividad mercantil terrestre en el derecho romano, en *Anuario da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña*, X, 2006, pp. 99 y ss.; LAZO, P., Limitación e ilimitación de responsabilidad en una empresa de navegación (D. 14, 1, 1, 19-20 y D. 14, 6, pr.), en *Rev. Estud. Hist.-Jur.*, XXXIII, 2011, pp. 173 y ss.

5 Nacen las *actiones adiecticiae qualitatis*, que comprenden la *actio institoria*, *exercitoria*, *quod iussu, de peculio et de in rem verso* y *tributoria*, si bien hay autores que han destacado que la agrupación de estas acciones en el marco de una categoría unitaria —las *actiones adiecticiae qualitatis*— no tiene apoyo en las fuentes clásicas. Vid. BALESTRI FUMAGALLI, M., L'“actio tributoria” nel sistema delle opere istituzionali di Gaio, di Giustiniano e di Teofilo, en *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano*, Milano, 1987, vol. I, p. 190, seguida por MICELLI, M., Sulla struttura formulare delle “actiones adiecticiae qualitatis”, Torino, 2001, pp. 6 y ss.

anterioridad a la *actio institoria*⁶, nace con la finalidad de que el *exercitor*⁷ responda *in solidum* frente a los terceros que contrataban con el *magister navis*, dentro de la actividad negocial para la que fue propuesto⁸:

Gai, Inst., IV, 70.- In primis itaque si iussu patris dominiue negotium gestum erit, in solidum praetor actionem in patrem dominumue comparauit, et recte, quia qui ita negotium gerit, magis patris dominiue quam filii seruiue fidem sequitur. 71.- Eadem ratione comparauit duas alias actiones, exercitoriam et institoriam. tunc autem exercitoria locum habet, cum pater dominusue filium seruumue magistrum nauis praeposuerit et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus fuerit, [negotium] gestum erit. cum enim ea quoque res ex uoluntate patris dominiue contrahi uideatur, aequissimum esse uisum est in solidum actionem dari; quin etiam licet extraneum quisque magistrum nauis praeposuerit, siue seruum siue liberum, exercitoria actio in

6 SOLAZZI, S., L'età dell'actio exercitoria, cit., pp. 243 y ss. En efecto, tanto la *actio exercitoria* como la *actio institoria* se refieren a la extensión de la responsabilidad al dueño de determinados negocios por las deudas que hubieran contraído las personas puestas al frente del mismo, pareciendo más lógico que la *actio institoria* fuera posterior en el tiempo a la *exercitoria* –y ello pese al orden establecido por JUSTINIANO, que sitúa en el Digesto a ésta en segundo lugar–, no sólo porque de haberse regulado la *actio institoria* primero no habría existido necesidad alguna de regular la *exercitoria*, sino porque parecía más necesaria esta segunda ya que, como observa VALIÑO siguiendo a HUVELIN, “cuando se trataba de un comercio terrestre, el principal, que nunca debía de estar muy alejado del locus praepositionis, podía siempre obligarse él personalmente, en tanto que esto no era posible respecto al exercitor navis”. Vid. VALIÑO, E., “Las “acciones adiecticiae qualitatis y sus relaciones básicas en Derecho Romano”, XXXVII, 1967, pp. 339 y ss.

7 GAYO en sus Instituciones da cuenta que el nombre de la acción proviene del exercitor, que lo define como aquel ad quem cottidianus navis quaestus pervenit: Gai, Inst., IV, 71.- ...Ideo autem exercitoria actio appellatur, quia exercitor vocatur is, ad quem cottidianus navis quaestus pervenit... No obstante, en las fuentes el exercitor se asimila al nautae, término referido además al personal de la navegación. Vid. a este respecto D. 4, 9, 1, 2.- (ULPIANUS libro XIV. ad Edictum).- ...Nautam accipere debemus eum, qui navem exercet, quamvis nautae appellentur omnes, qui navis navigandae causa in nave sint... Según afirma FÖLDI, el termino exercitor tiene en el lenguaje jurídico un campo semántico delimitado específicamente, apareciendo en las fuentes de forma habitual con el significado de exercitor navis o armador del barco y más raramente como exercitor cauponae, exercitor stabuli o exercitor argentariae mensae. Vid. FÖLDI, A., La responsabilità dell'avente potestà..., cit., pp. 179 y ss.

8 De ahí que la doctrina romanística haya propuesto la reconstrucción de las fórmulas de las *actiones adiecticiae qualitatis* con una transposición de sujetos, donde en la *intentio* aparecerían el esclavo, *filius* o persona libre que lleve a cabo la actividad comercial y en la *condemnatio* el *dominus*, *pater* o *exercitor*; no obstante, la estructura formular de estas acciones no aparece en las fuentes, por lo que, según KELLER, ésta reconstrucción debe ser tomada con cautela. Vid. KELLER, F., Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem Römischem Recht, Zürich, 1827, pp. 420 y ss. y Der römische Civilprozess und die Actionen, Leipzig, 1883, pp. 152 y ss. Vid. también LENEL, O., Das Edictum Perpetuum, Leipzig, 1927, § 101-105. Referente a la reconstrucción de la fórmula de las *actiones adiecticiae qualitatis*, MICELLI sostiene que “sulla base delle fonti esaminate e delle ricerche condotte, siamo giunti alla conclusione che, molto probabilmente, tramite le a.a.q. si faceva valere un'obbligazione propria del pater, dominus o preponente, e che nell'intentio di tali azioni doveva essere menzionata l'obligatio che gravava direttamente in capo a tali soggetti. Ciò non toglie che l'origine fattuale dell'obligatio pretoria fosse costituita dal negotium filii; ed in proposito le fonti dicono, infatti, che ‘haec actiones filiorum nomine in parentes dari solent’ o, nel caso ad esempio dell'actio exercitoria, che ‘...sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri’. Tuttavia, non ogni negotium filii poteva essere causa d'obbligazione per il pater, dominus o preponente, ma solo quelli compiuti nei limiti della praepositio, del iussum, del peculio o dell'arricchimento causato all'avente potestà, o della merx peculiaris”. Vid. MICELLI, M., Sulla struttura formulare..., cit., pp. 13 y ss.

eum redditur. ideo autem exercitoria actio appellatur, quia exercitor uocatur is, ad quem cotidianus naus quaestus peruenit. institoria uero formula tum locum habet...

GAYO se refiere conjuntamente a la *actio exercitoria* y a la *institoria*, estableciendo para la primera un requisito básico para el reconocimiento de la responsabilidad *in solidum* del *exercitor* y es que la actividad comercial desarrollada por el patrón debía contar con su autorización. Aparte de ello, el texto se refiere al fundamento que justificó el nacimiento de la *actio*: en primer lugar, que los terceros confiaban más en el *pater* o *dominus* que en el hijo o esclavo puesto al frente del negocio; en segundo lugar, que el contrato *ex voluntate patris dominive contrahi videatur*; y por último, que las ganancias del negocio iban a beneficiar, en definitiva, al *exercitor*.

No obstante lo anterior, las fuentes contienen otro texto, esta vez de ULPIANO –D. 14, 1, 1, *pr.*– en el que se reitera en dos ocasiones que la *actio exercitoria* se concede por la dificultad que existía para poder conocer la identidad y la condición –personal, jurídica o económica– del *magister*, persona con la que los terceros se veían obligados a concluir los negocios –*sit maior necessitas contrahendi cum magistro quam institore*–:

D. 14, 1, 1, *pr.*– (ULPIANUS, libro XXVIII ad Edictum).– Utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret, nam cum interdum ignari, cuius sint condicionis vel quales, cum magistris propter navigandi necessitatem contrahamus, aequum fuit eum, qui magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur, qui institorem tabernae vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum magistro quam institore.

La falta de coincidencia en cuanto a la fundamentación ofrecida por los dos juristas ha llevado a algunos autores a considerar que el razonamiento de ULPIANO no es auténtico sino fruto de una elaboración posterior⁹, pero, dejando a un lado esta cuestión, a nuestro entender, lo que sí queda fuera de toda duda en los dos textos es la preocupación jurídica que existía por ofrecer a los terceros contratantes garantías suficientes para salvaguardar sus derechos en caso de que se produjeran incumplimientos contractuales por parte del *magister*; así, la creación de la *actio exercitoria* supondría que éstos podrían dirigirse, a su elección, contra el patrón o contra el *exercitor*; y ello, ya fuera por entender que el negocio se había concluido por voluntad de éste, ya porque era a él a quien, en definitiva, beneficia-

⁹ Entre los autores que entienden que la explicación ofrecida por ULPIANO en D. 14, 1, 1, *pr.* acerca del motivo por el que se crea la acción no puede ser clásica y que la posibilidad de poder exigir la responsabilidad de forma solidaria proviene de una intervención postclásica, se pueden citar, entre otros, a SOLAZZI, S., *L'età dell'actio exercitoria*, cit., p. 202; LONGO, G., *Actio exercitoria...*, cit., p. 587, nt. 14; BESELER, G., *Romanistische Studien*, cit., p. 57; DE MARTINO, F., *Studi sull'actio exercitoria*, cit., pp. 24 y ss. y FÖLDI, A., *Appunti sulla responsabilità...*, cit., p. 75 y *La responsabilità dell'avente potestà*, cit., p. 183. También PUGLIESE entiende que la justificación detallada en D. 14, 1, 1, *pr.* no es la correcta, inclinándose por tanto a favor de que la acción no se habría concedido sobre la base de la dificultad del tercero en conocer la identidad del *exercitor* sino en que el negocio había sido concluido por el *magister* según la voluntad de aquél y dentro de las instrucciones por él marcadas. Vid. PUGLIESE, G., *In tema di actio exercitoria*, cit., p. 311. A favor de la clasicidad del fragmento, vid. DI PORTO, A., *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984, pp. 228 y ss. y MAYER-MALY, T., *Necessitas constituit ius*, en *Studi Grosso I*, Torino, 1968, p. 190.

ban las ganancias que se hubieran obtenido, o también porque el tercero se veía obligado a contratar con el *magister* y no con el *exercitor*, aunque ésta hubiera sido su voluntad.

Por lo tanto, a nuestro juicio, lo que se intenta poner de manifiesto es la necesidad de llevar a su máximo exponente el principio de la buena fe contractual en un ámbito, el de la navegación, que era demasiado importante como para no ofrecer garantías sólidas a los terceros intervinientes; así, en caso de incumplimiento de los contratos concluidos con el *magister*, quedaba claro que respondería también aquél *ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt*. Todo ello porque, como se ha mencionado anteriormente, el comercio marítimo constituía uno de los medios de mayor interés para el tráfico negocial en Roma y por esto la salvaguarda de los derechos de los contratantes en el desarrollo de esta actividad constituía sin duda uno de los objetivos perseguidos con una mayor rigurosidad; el propio ULPiano deja constancia en otro texto que se analizará más adelante –D. 14, 1, 1, 20– de la relevancia que para Roma tenía la navegación cuando afirma que *ad summam rempublicam navium exercitio pertinet*. Prueba de la relevancia que para Roma tenía el comercio marítimo es que la *actio exercitoria* constituye una quiebra respecto de la regla que vetaba la posibilidad de contratar a favor de terceros¹⁰, presentándose, en realidad y aunque no fuera buscado de forma consciente, como una excepción a la representación en los contratos¹¹, que en este ámbito será admitida; es cierto que la ruptura con este principio no se formula de esta manera –como norma excepcional– en las fuentes y seguramente sería el resultado de la necesidad inexorable de otorgar una mayor protección de los intereses de las terceras personas intervinientes en el comercio marítimo. La singularidad en la aplicación del principio que rechazaba la representación en los negocios no es baladí, poniendo de manifiesto los juristas la primacía de la seguridad jurídica frente a la intervención directa exigida en la conclusión de los mismos, todo ello con base en la especialidad e importancia que tenía el comercio marítimo en Roma¹².

10 Vid. en torno a la representación en los negocios, entre otros autores, SCHLOSSMANN, A., *Die Lehre von der Stellvertretung insb. Bei oblig. Verträgen*, II, 1902, pp. 153 y ss.; SOLAZZI, S., *Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore*. Contributo alla storia della rappresentanza in diritto romano, en *Scritti di diritto romano*, I, Napoli, 1955, pp. 563 y ss.; RICCOBONO, S., *Lineamenti della dottrina della rappresentanza diretta in diritto romano*, en *Annali Palermo*, XIV, 1930, pp. 389 y ss.; HAMZA, G., *Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano*, en *INDEX*, IX, 1980, pp. 193 y ss.; ANGELINI, A., *Osservazioni sulla rappresentanza in diritto romano*, en *Actum lucc. Rivista di studi lucchesi*, XIII, 1984, pp. 111 y ss.; FERNÁNDEZ GREGORACI, B., *Representación directa e indirecta: definición y efectos conforme al DCFR y a los PECL*, en *InDret* 2008, Barcelona, pp. 15 y ss.

11 PUGLIESE llega a calificar la *actio* como “la prima importante breccia nel principio civilistico secondo cui non poteva alcuno essere obbligato in conseguenza di un contratto o di un negozio concluso da altri”. PUGLIESE, G., *In tema di actio exercitoria*, cit., pp. 309 y ss.

12 Todo ello finalmente se traduce en una exigencia de responsabilidad superior hacia los terceros que se ven en la obligación de entablar relaciones comerciales con el *magister*, quedando a su elección demandar a éste o al *exercitor*. Vid. a este respecto: D. 14, 1, 1, 17.- (*ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum*).- *Est autem nobis electio, utrum exercitorem an magistrum convenire velimus*. Ahora bien, aunque queda a voluntad del tercero contra quien interponer la acción, *magister* o *exercitor*, sin embargo, no puede demandar a ambos: D. 14, 1, 1, 24.- (*ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum*).- *Haec actio ex persona magistris in exercitorem dabitur, et ideo, si cum utro eorum actum est, cum altero agi non potest. sed si quid sit solutum, si quidem a magistro, ipso iure minuitur obligatio: sed et si ab exercitore, sive suo nomine, id est propter honorariam obligationem, sive magistris nomine solverit, minue-*

El tráfico negocial marítimo, por su propia idiosincrasia, hacía difícil que se pudiera conocer la condición personal o profesional de las personas con las que se contrataba, por lo que en las fuentes se percibe una constante referencia a la objetivización de la responsabilidad del *exercitor* por los negocios que el *magister* concluía, eso sí, siempre que se llevaran a cabo dentro de los límites de la actividad para la que fue propuesto. La confianza que el tercero depositaba en la apariencia que la realidad externa le proporcionaba se iba a plasmar jurídicamente en que éstos se van a ver exonerados de la obligación de indagar acerca de si el *magister* era libre o esclavo, si era dueño o no de la nave, si era mayor de edad o no, si había sido propuesto por el *exercitor* o por el *magister*, etc., bastando para ellos la conclusión de los contratos con la persona que, en apariencia, era el titular de la explotación, aunque no lo fuera. La buena fe que debía regir en las relaciones comerciales quedaba en la *actio exercitoria* más acentuada si cabe al objetivizar la responsabilidad al *exercitor* por las deudas contraídas por el *magister* en las actividades propias de la navegación.

Una vez constatada la justificación que ofrecen los textos para la concesión de la *actio exercitoria*, conviene profundizar en la cuestión de que entienden las fuentes por *exercitor* y *magister*. En referencia al primero, los textos aluden a dos circunstancias para definirlo: que es la persona por cuya voluntad se lleva a cabo el negocio y que es quien obtiene las ganancias y beneficios del mismo¹³, sin importar a estos efectos la titularidad dominical de la nave y careciendo de relevancia igualmente el género o *status* personal del naviero:

D. 14, 1, 1, 15.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et redditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum.

D. 14, 1, 1, 16.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Parvi autem refert, qui exercet masculus sit an mulier, pater familias an filius familias vel servus...

En los casos del *exercitor in potestate*¹⁴ el problema que se plantea no es si éste queda vinculado por los actos del *magister* —que evidentemente sería así, aplicando el régimen general establecido en el edicto— sino si la responsabilidad se podría extender también al *pater* o *dominus* del naviero, como garantía adicional hacia los terceros contratantes, por cuanto sería aquél el que podría contar con un patrimonio suficiente para responder de las deudas contraídas. A este respecto, lo que ponen de manifiesto las fuentes es la irrelevancia que tiene para la extensión de la responsabilidad del *pater* o *dominus* que el acto negocial se hubiera concluido por el *exercitor in potestate* o por el *magister* propuesto por éste, ya que en ambos casos respondería aquél, siempre y cuando hubiera mediado su consentimiento¹⁵:

tur obligatio, quoniam et alius pro me solvendo me liberat. Referente al texto anterior, vid. por todos, MICELLI, M., *Sulla struttura formulare...*, cit., pp. 208 y ss.

13 Gai, Inst., IV, 71.- ...cum enim ea quoque res ex uoluntate patris dominiue contrahi uideatur... Ideo autem exercitoria actio appellatur, qua exercitor vocatur is, ad quem cottidianus navis questus pervenit...

14 D. 14, 1, 1, 21.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- In potestate autem accipiemus utriusque sexus vel filios vel filias vel servos vel servas.

15 Vid. a este respecto, FÖLDI, A., *La responsabilità dell'ávente potestà...*, cit., pp. 180 y ss.

D. 14, 1, 1, 19.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Si is, qui navem exercuerit, in aliena potestate erit eiusque voluntate navem exercuerit, quod cum magistro eius gestum erit, in eum, in cuius potestate is erit qui navem exercuerit, iudicium datur.

D. 14, 1, 1, 23.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Quamquam autem, si cum magistro eius gestum sit, dumtaxat polliceatur praetor actionem, tamen, ut Iulianus quoque scripsit, etiamsi cum ipso exercitore sit contractum, pater dominusve in solidum tenebitur.

Se observa en los textos anteriores que el problema de la responsabilidad del titular de la *patria potestas* es resuelto con base en el criterio de la voluntad, siendo ésta el límite para marcar su responsabilidad y, por tanto, la aplicación de la *actio exercitoria*¹⁶. Así, sólo procederá la responsabilidad *in solidum* del *pater* o *dominus* en el caso de que hubiera prestado su consentimiento para que el *exercitor* que estuviera bajo su potestad pueda explotar el negocio¹⁷; no así cuando tuviera sólo un mero conocimiento del ejercicio de la actividad del hijo o esclavo¹⁸, ya que entonces, tal y como se pone de manifiesto en D. 14, 1, 1, 20, sólo respondería *in peculium*¹⁹:

D. 14, 1, 1, 20.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Licet autem detur datur actio in eum, cuius in potestate est qui navem exercet, tamen ita demum datur, si voluntate eius exerceat. ideo autem ex voluntate in solidum tenentur qui habent in potestate exercitorem, quia ad summam rem publicam navium exercitio perinet. at institorum non idem usus est: ea propter in tributum dumtaxat vocantur, qui

16 PUGLIESE, G., In tema di *actio exercitoria*, cit., pp. 322 y ss. En contra de esta interpretación, a favor de la interpolación íntegra del texto, DE MARTINO y BESELER entienden que el *pater* o *dominus* sólo respondían de la actividad del *exercitor in potestate* dentro de los límites del *peculio*, estando concedida tan sólo la *actio tributaria* y no la *actio exercitoria*. DE MARTINO, F., Studi sull' *actio exercitoria*, cit., pp. 24 y ss. y BESELER, Romanistische Studien, cit., pp. 56 y ss.

17 Esta idea se pone también de manifiesto en las Instituciones de GAYO, donde claramente se establece que al tercero le competen tanto la *actio exercitoria* como la *de peculio* contra el padre o dueño que autorizó el negocio: Gai, Inst., IV, 74.- *Ceterum dubium non est, quin et is, qui iussu patris dominiue contraxit cuique exercitoria uel institoria formula competit, de peculio aut de in rem uerso agere possit; sed nemo tam stultus erit, ut qui aliqua illarum actionum sine dubio solidum consequi possit, uel in difficultatem se deducat probandi habere peculium eum, cum quo contraxerit, ex quo eo peculio posse sibi satis fieri uel id, quod persequitur, in rem patris dominiue uersum esse.*

18 Respecto del problema de la *voluntas* y la *scientia*, vid. CHIUSI, T.J., Contributo allo studio dell'editto de tributaria actione, en *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Memorie*, serie 9, vol. 3, fasc. 4, Roma, 1993, pp. 324 y ss.

19 Vid. También D. 14, 1, 1, 22.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Si tamen servus pecularis volente filio familias in cuius peculio erat, vel servo vicarius eius navem exercuit, pater dominusve, qui voluntatem non accommodavit, dumtaxat de peculio tenebitur, sed filius ipse in solidum. plane si voluntate domini vel patris exerceant, in solidum tenebuntur et praeterea et filius, si et ipse voluntatem accommodavit, in solidum erit obligatus y D. 14, 1, 1, 2.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Sed si cum quolibet nautarum sit contractum, non datur actio in exercitorem, quamquam ex delicto cuiusvis eorum, qui navis navigandae causa in nave sint, detur actio in exercitorem: alia enim est contrahendi causa, alia delinquendi, si quidem qui magistrum praeponit, contrahi cum eo permittit, qui nautas adhibet, non contrahi cum eis permittit, sed culpa et dolo carere eos curare debet. Vid. a este respecto, FÖLDI, A., La responsabilità dell'avente potestà..., cit., pp. 190 y ss.

contraxerunt cum eo, qui in merce peculiari sciente domino negotiatur. sed si sciente dumtaxat, non etiam volente cum magistro contractum sit, utrum quasi in volentem damus actionem in solidum an vero exemplo tributoriae dabimus? in re igitur dubia melius est verbis edicti servire et neque scientiam solam et nudam patris dominive in navibus onerare neque in peculiaribus mercibus voluntatem extendere ad solidi obligationem. et ita videtur et pomponius significare, si sit in aliena potestate, si quidem voluntate gerat, in solidum eum obligari, si minus, in peculium.

La responsabilidad del *pater* o *dominus*, tal como se desprende del texto, no se sanciona solamente con base en la existencia de una relación potestativa con el *exercitor*, sino sobre todo porque *eius voluntate navem exercuerit*²⁰, siendo éstos los titulares efectivos de la actividad comercial²¹ y, por tanto, los que reciben los beneficios de los negocios. Por ello, el *pater* o *dominus* responde *in solidum* por los contratos concluidos por el *magister navis* si concurre *voluntas* respecto del ejercicio empresarial del *exercitor in potestate*, limitándose esa responsabilidad al *peculium* en caso de desconocimiento del mismo²².

No obstante, la discusión doctrinal ha venido suscitada para el caso de que el *exercitor in potestate* desarrollara su actividad sin la *voluntas* del *pater* o dueño pero concurriendo su conocimiento²³; en efecto, en D. 14, 1, 1, 20, ULPiano se hace la pregunta siguiente: *sed si sciente dumtaxat, non etiam volente cum magistro contractum sit, utrum quasi in volentem damus actionem in solidum an vero exemplo tributoriae dabimus?*; el jurista, basándose en la opinión de POMPONIO, parece equiparar el caso de la *scientia* al de la *ignorantia*, reduciendo la argumentación del texto a dos supuestos: en caso de concurrencia de *voluntas* se produciría la responsabilidad *in solidum* y el resto de casos –en el que se agruparían todos los supuestos de no concurrencia de *voluntas*, incluyendo el mero conocimiento o *scientia* y la *ignorantia*– la responsabilidad sería *in peculium*. Esta equiparación entre *ignorantia* y *scientia*, sin embargo, choca frontalmente con la solución que ofrece PAULO en D. 14, 1, 6, *pr.*, que pasa por escindir el régimen de responsabilidad del titular de la potestad en tres supuestos:

D. 14, 1, 6, *pr.* - (PAULUS libro VI. Brevium).- Si servus non voluntate domini navem exercuerit, si sciente eo, quasi tributoria, si ignorante, de peculio actio dabitur. 1.- Si communis servus voluntate dominorum exerceat navem, in singulos dari debebit in solidum actio.

20 Vid. a este respecto, PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, cit., p. 311; DI PORTO, A., Impresa collettiva, cit., pp. 228 y ss.

21 Como manifiesta FADDA “certamente avveniva per lo più che l’azienda commerciale non fosse direttamente esercitata dal paterfamilias, ma per via di figli, di liberti, di schiavi. Ma è semplice questione di forma, In realtà il capitale è del paterfamilias, è sua anche la responsabilità, come suo il lucro. Per via di institores e di exercitores tutto procedeva nel commercio terrestre e maritimo”. FADDA, C., Istituti commerciali..., cit., pp. 38 y ss.

22 Para FÖLDI la referencia a la responsabilidad limitada al peculio puede interpretarse de forma extensa en concordancia con la referencia a la falta de *voluntas* del patrón, calificando esta enunciación de ULPiano como una “vera crux interpretum”. Vid. FÖLDI, A., La responsabilità dell’ávente potestà, cit., p. 189.

23 Vid. SOLAZZI, S., Le azioni del pupillo..., cit., pp. 563 y 564; PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, cit., p. 331; DI PORTO, A., Impresa collettiva, cit., p. 230 y METRO, A., Una “dissensio” giurisprudenziale..., cit., pp. 190 y ss.

Conforme al texto anterior, el régimen de responsabilidad del *pater* o *dominus* del *exercitor in potestate* en D. 14, 1, 6, *pr.* varía con relación al establecido por ULPIANO²⁴, porque PAULO afirma que en el supuesto de que un esclavo fuera naviero concurriendo la voluntad de su dueño, éste responderá *in solidum* por sus deudas, pero si sólo tuviera conocimiento de su actividad, la acción que correspondería ejercitar contra él sería la *actio quasi tributoria* y no la *exercitoria*, concluyendo que en caso de que ni siquiera se diera conocimiento de la actividad armatorial desarrollada por el esclavo, correspondería la *actio de peculio*²⁵.

Por lo que aquí interesa, la idea de que la responsabilidad *in solidum* de *qui habent in potestate exercitorem* cuando el *exercitor* ha sido puesto al frente del negocio con la autorización de aquél se percibe de forma clara en las fuentes. Se produce así de nuevo una importante excepción respecto a la tradicional irresponsabilidad del *pater* o *dominus* frente a las obligaciones contraídas por los hijos o esclavos. Tan es así que en el ya transcrito D. 14, 1, 1, 20, se vuelve a acudir al interés público que representa para Roma la navegación; interés público que niega en otros ámbitos de la actividad comercial como sucede por ejemplo en el caso del *institor*; así, como afirma FÖLDI, se produce en el supuesto examinado una tensión entre las exigencias comerciales derivadas de la navegación —que imponían la extensión de la responsabilidad del *pater* o *dominus* por las deudas del hijo o esclavo puesto al frente del negocio— y la carencia de responsabilidad que, en general, éstos tenían respecto de las obligaciones contraídas por los hijos o esclavos²⁶. Debido a esta contraposición entre la empresa de la navegación y el resto del sector empresarial, ULPIANO se verá en la obligación de recurrir, como afirma METRO, “*a un forte argomento giustificativo delle peculiarità del primo, che valga a spiegare il differente regime giuridico che egli si accinge a sostenere*”²⁷.

24 La divergencia entre las soluciones ofrecidas por ULPIANO y PAULO ha sido interpretadas de distinta forma en la doctrina romanística. Así, FÖLDI entiende que el régimen de responsabilidad del patrono es delineado por ULPIANO de forma genérica, viéndose precisado por PAULO; en contra, METRO entiende que estaríamos ante uno de las muchas opiniones enfrentadas que existen entre los juristas romanos, añadiendo que el pensamiento que aparece claramente expuesto es el de PAULO “*mentre l’affermazione di Ulpiano, sull’opportunità di tenere distinti i campi di applicazione dell’actio exercitoria e di quella tributaria, induce a considerare negativa la soluzione data al problema da questo giurista. Saremmo dunque di fronte ad una delle tante dissensionis giurisprudenziali delle quali sono disseminati i Digesta giustiniane*”. Vid. FÖLDI, A., La responsabilità dell’ávente potestà..., cit., pp. 190 y ss.; METRO, A, Una “dissensio” giurisprudenziale..., cit., pp. 188 y ss. Vid. también respecto al texto CHIUSI, T.J., Contributo allo studio..., cit., pp. 322 y ss.

25 Vid. respecto de la *actio tributaria* y de *peculio*: Gai, Inst., IV, 72. Praeterea tributaria quoque actio in patrem dominumve constituta est, cum filius seruusve in peculiari merce sciente patre dominoue negotietur; nam si quid eius rei gratia cum eo contractum fuerit, ita praetor ius dicit, ut quidquid in his mercibus erit, quod inde receptum erit, id pater dominusve inter se, si quid debebitur, et ceteros creditores pro rata portione distribuant et si creditores querantur minus sibi distributum, quam oportet, in id quod deest hanc eis actionem pollicetur, quae ut diximus, tributaria uocatur. 72a. Est etiam de peculio et de in rem uerso actio a praetore constituta. licet enim negotium ita gestum sit cum filio seruoue, ut neque uoluntas neque consensus patris dominique interuenerit, si quid tamen ex ea re, quae cum illis gesta est, in rem patris dominique uersum sit, quatenus in rem eius uersum fuerit, eatenus datur actio.

26 FÖLDI afirma que en este caso se produce una “*vittoria assoluta degli interessi commerciali sul principio patriarcale*”. FÖLDI, A., La responsabilità dell’ávente potestà..., cit., pp. 184 y ss.

27 METRO, A, Una “dissensio” giurisprudenziale..., cit., p.186.

Una vez examinada la problemática existente en torno a la figura del *exercitor*, se examinará a continuación cómo se presenta la figura del *magister navis* en las fuentes. El *magister* es definido por los juristas romanos como aquel *cui totius navis cura mandata est*²⁸, pudiendo ser un *filius*, un esclavo –propio del *paterfamilias* o ajeno– o un tercero extraño, siendo indiferente además la edad del mismo o si es varón o mujer²⁹. Destaca que los textos hagan responsable de la minoría de edad del *magister* –y, por tanto, el hecho de haber concluido contratos con un menor– a *qui praeposuit*, puesto que con ello se está queriendo primar la seguridad de los terceros contratantes, que se verán exonerados de conocer las circunstancias personales que atañen al *magister*.

Respecto al nombramiento del *magister*, las fuentes establecen claramente que éste no sólo será la persona propuesta por el *exercitor*, *sed et eum quem magister*, porque se entiende que también fue nombrado por aquél³⁰:

D. 14, 1, 1, 5.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem magister: et hoc consultus iulianus in ignorante exercitore respondit: ceterum si scit et passus est eum in nave magisterio fungi, ipse eum imposuisse videtur. quae sententia mihi videtur probabilis: omnia enim facta magistri debeo praestare qui eum praeposui, alioquin contrahentes decipientur: et facilius hoc in magistro quam institore admittendum propter utilitatem. quid tamen si sic magistrum praeposuit, ne alium ei liceret praepondere? an adhuc iuliani sententiam admittimus, videndum est: finge enim et nominatim eum prohibuisse, ne titio magistro utaris. dicendum tamen erit eo usque producendam utilitatem navigantium.

ULPIANO analiza en el fragmento varios supuestos en los que el *magister* ha sido nombrado, no por el naviero, sino por el *magister* propuesto por él, llegando a la conclusión en todos los casos de que la responsabilidad del *exercitor* debe extenderse también a los actos concluidos por el *promagister*. El texto parte de una premisa inicial que servirá de base para el análisis posterior de los distintos supuestos que se pueden plantear al afirmar que *magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem magister*; sobre ésta premisa, y acogiendo la opinión de JULIANO, se afirma que procede la extensión de la responsabilidad al *exercitor*, aun-

28 D. 14, 1, 1, 1.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est.

29 D. 14, 1, 1, 4.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Cuius autem condicionis sit magister iste, nihil interest, utrum liber an servus, et utrum exercitoris an alienus: sed nec cuius aetatis sit, intererit, sibi imputaturo qui praeposuit.

30 No obstante, la *actio exercitoria* no extiende la responsabilidad del armador a los contratos que realicen los marineros: D. 14, 1, 1, 2.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- *Sed si cum quolibet nautarum sit contractum, non datur actio in exercitorem, quamquam ex delicto cuiusvis eorum, qui navis navigandae causa in nave sint, detur actio in exercitorem: alia enim est contrahendi causa, alia delinquendi, si quidem qui magistrum praeposit, contrahi cum eo permittit, qui nautas adhibet, non contrahi cum eis permittit, sed culpa et dolo carere eos curare debet.* Vid. además respecto a la diferencia entre *magister* y *gubernator navis*, vid. GUARINO, A., *Magister y gubernator navis*, cit., pp. 36 y ss. y MOSCHETTI, C.M., *Il gubernator navis*, cit., pp. 172 y ss.

que éste ignorase el nombramiento del *promagister* o incluso lo prohibiera, y todo ello sobre la base de la protección de los terceros contratantes y la *utilitas navigantium*.

La *ratio decidendi* del texto ha ocasionado que parte de la doctrina romanística considere interpolado el mismo, alegando que, en la etapa clásica, esta opinión no habría casado con el resto de decisiones jurisprudenciales³¹. Así, PUGLIESE entiende que la sustitución del *magister* en el caso de que el *exercitor* lo ignorase sí tendría eficacia frente a terceros, según el parecer ofrecido por JULIANO y acogido por ULPIANO, puesto que se entendería implícitamente conferido el poder de sustituir al *magister* en las facultades otorgadas en la *praepositio* originaria. Según el autor, en el pensamiento de JULIANO aparece presupuesta la idea de que, para que el *exercitor* no reconociera eficacia al nombramiento del *promagister* debería haberlo prohibido expresamente, interpretando ULPIANO que en este caso el *magister* habría actuado fuera de los límites establecidos en ella y, por tanto, ese nombramiento carecería de eficacia para vincular al *exercitor*. Con la alteración del inciso final del texto, según PUGLIESE, se habría dado cabida al pensamiento postclásico, más centrado en que los terceros no fueran engañados en ningún caso, quedando protegidos por la responsabilidad *in solidum* del *exercitor* por todos los actos del *magister*. La protección de los terceros contratantes primaría, por tanto, frente a los pactos establecidos entre *exercitor* y *magister*, con lo que se está otorgando mayor valor a la seguridad jurídica y a la buena fe que al hecho de que el *exercitor* hubiera prohibido el nombramiento de un sustituto³².

En contra de la falta de autenticidad del texto ulpiano, PETRUCCI³³ ha puesto de manifiesto que el razonamiento contenido en el texto no resulta incompatible con el pensamiento clásico, que tuvo una tendencia clara hacia la objetivización de la responsabilidad del *exercitor* adoptada sobre la base de la asunción del riesgo empresarial y motivada por las exigencias de seguridad comercial³⁴; la búsqueda de que garantías para que los terceros contratantes no se vieran defraudados en el desarrollo de la actividad comercial marítima llevaría a ofrecer una mayor protección en el tráfico comercial desarrollado a través de la navegación en comparación con otros ámbitos comerciales y, por ello, en el texto se afirma a propósito de la extensión de responsabilidad del *exercitor* que *et facilius hoc in magistro quam institore admittendum propter utilitatem*, estableciendo ULPIANO una diferenciación entre la *actio institoria* y la *exercitoria*, haciendo referencia a la *utilitas navigantium* para fundamentar la escisión en el régimen aplicable a una y otra acción.

Examinadas las figuras de armador y patrón en el marco de la *actio exercitoria*, y estando la responsabilidad del *exercitor* clara en las fuentes respecto de las deudas contraídas por el patrón propuesto por él, siempre y cuando se trate de contratos propios de la navegación, surge la cuestión acerca de la existencia o no de posibles límites de

31 En este sentido, SOLAZZI, S., L'età dell'actio exercitoria, cit., pp. 312 y ss. y DE MARTINO, F., Studi sull'actio exercitoria, cit., pp. 503 y ss. PUGLIESE, sin embargo, entiende que la primera parte del fragmento, en la que se admite la eficacia de la sustitución del *magister* operada *ignorante exercitore* "resiste alle critiche" y considera genuina la solución ofrecida. PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, cit., pp. 314 a 316.

32 PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, cit., p. 316.

33 PETRUCCI, A., Ulteriori osservazioni, cit., pp. 51 y ss.

34 BUCKLAND, W., Roman Law..., cit., pp. 217 y ss.

esa responsabilidad. En este orden de cosas, lo cierto es que las fuentes dejan patente la idea de que la responsabilidad del *exercitor* se encuentra delimitada por la *praepositio*³⁵:

Gai, Inst., IV, 71.- Tunc autem exercitoria locum habet, cum... qued cum eo il magister navis eius rei gratia cui praepositus fuerit, negotium gestum erit.

D. 14, 1, 1, 7.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Non autem ex omni causa praetor dat in exercitorem actionem, sed eius rei nomine, cuius ibi praepositus fuerit, id est si in eam rem praepositus sit, ut puta si ad onus vehendum locatum sit aut aliquas res emerit utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impensum est vel si quid nautae operarum nomine petent.

Los textos establecen que el *exercitor* queda vinculado respecto de aquellos contratos concluidos por el *magister* que son inherentes al ejercicio de la actividad empresarial para la que había sido otorgado la *praepositio*, citando ULPIANO a modo ilustrativo, el ejemplo del transporte de mercancías o de pasajeros³⁶, la compraventa de objetos y útiles para la navegación, el préstamo contraído con el fin de reparar la nave³⁷ o los contratos llevados a cabo con los marineros para trabajar en el barco³⁸. No obstante, como consta en D. 14, 1, 1, 8, también devenía responsable el *exercitor* por los contratos de mutuo concluidos por el *magister cuius ibi praepositus fuerit*, esto es, siempre que estuvieran unidos a la actividad para la cual ha sido otorgada la *praepositio*³⁹:

D. 14, 1, 1, 8.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Quid si mutuum pecuniam sumpserit, an eius rei nomine videatur gestum? et pegasus existimat, si ad usum eius rei, in quam praepositus est, fuerit mutuatus, dandam actionem, quam sententiam puto veram: quid enim si ad armandam instruendamve navem vel nautas exhibendos mutuatus est?

El texto muestra de nuevo con claridad la preeminente posición otorgada a los terceros al mantener ULPIANO la responsabilidad del *exercitor* incluso cuando el *magister* defraudara al mutuante, destinando el dinero a una finalidad distinta para la que había sido concedido el préstamo; ello siempre y cuando se hubiera hecho constar expresamente en el momento de concluir el contrato que el dinero iba destinado a la reparación del barco,

35 Vid. a este respecto ARIAS RAMOS, J., Representación y praepositio, cit., pp. 11 y ss.

36 El transporte de mercancías aparece regulado en D. 4, 9, 1, 6 y 8 y en D. 4, 9, 4, 2.

37 La nave está referida en este trabajo a la navegación marítima, pero, en general, se entiende por tal, como aparece reflejado en D. 14, 1, 1, 6, *sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget sive schedia sit*: D. 14, 1, 1, 6.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- *Navem accipere debemus sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget sive schedia sit*.

38 En D. 14, 1, 1, 3 se hace referencia a algunos ejemplos para los que el armador solía contratar patrones: D. 14, 1, 1, 3.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- *Magistri autem imponuntur locandis navibus vel ad merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis: sed etiamsi mercibus emendis vel vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem*.

39 También se concede la acción en el caso de que se contrate un mutuo para pagar el préstamo concedido para reparar la nave: D. 14, 1, 1, 11.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- *Sed si ab alio mutuatus liberavit eum, qui in navis refectionem crediderat, puto etiam huic dandam actionem, quasi in navem crediderit*.

puesto que de esa manera el mutuo se entendería realizado *navis causam*, esto es, dentro de las atribuciones concedidas al *magister*⁴⁰:

D. 14, 1, 1, 9.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Unde quaerit ofilius, si ad reficiendam navem mutuatus nummos in suos usus converterit, an in exercitorem detur actio. et ait, si hac lege accepit quasi in navem impensurus, mox mutavit voluntatem, teneri exercitorem imputaturum sibi, cur talem praeposuerit: quod si ab initio consilium cepit fraudandi creditoris et hoc specialiter non expresserit, quod ad navis causam accipit, contra esse: quam distinctionem pedius probat.

Dejando a un lado la más que probable alteración del texto en su parte final⁴¹, lo que sí queda claramente establecido es que si el contrato concluido por el *magister* quedaba dentro de la actividad para la que fue autorizado, el *exercitor* respondería al considerarse incluido en su ámbito competencial⁴². De esta manera, la *praepositio* tenía la función de determinar los poderes del *magister* y los límites de actuación que había marcado el *exercitor*, a fin de fijar la responsabilidad de éste último en relación con los terceros contratantes.

Sorprende, sin embargo, que siendo la *praepositio* determinante en orden a la fijación de la responsabilidad del *exercitor*, nada se diga en las fuentes respecto de la forma en que los terceros podían conocer los términos del apoderamiento o las funciones del *magister*. En efecto, el conocimiento de la *praepositio*, a nuestro juicio, resultaría esencial porque serviría para determinar si la actividad del *magister* quedaba o no enmarcada dentro de las funciones encomendadas⁴³, lo que supondría que el *exercitor* quedara obligado *in solidum* o exonerado de toda responsabilidad. No obstante, como afirma PETRUCCI⁴⁴, la publicidad de la *praepositio* no habría sido un tema previsto en el edicto, siendo probablemente obra de la jurisprudencia posterior. Y lo cierto es que ningún texto hace alusión a las solemnidades que debían respetarse al otorgar la *praepositio* –seguramente porque no debería revestir ninguna formalidad–, siendo plausible la idea de que el *magister* debiera llevar y entregar o, como mínimo, exhibir algún documento cuando fuera requerido para ello⁴⁵. La única referencia

40 Como afirma PUGLIESE en estos supuestos se trata de un problema de interpretación de la *praepositio* y así, si bien se manifiesta claramente que en D. 14, 1, 1, 8 que el *magister* tenía el poder de contratar un mutuo vinculando al *exercitor* porque el dinero había sido prestado para un caso que se encontraba comprendido dentro de la *praepositio*, surge la duda en D. 14, 1, 1, 9 cuando el dinero entregado para reparar el barco, posteriormente se utiliza para fines personales por parte del *magister*. PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, cit., pp. 316 y 317.

41 Vid. a este respecto DE MARTINO, F., Studi sull'actio exercitoria, cit., pp. 10 y ss. El autor entiende que el destino al que se había de dar al dinero era esencial para que el *exercitor* respondiera o no, ya que, en caso de que estuviera dentro de la actividad de la navegación, aunque luego el *magister* hubiera destinado el dinero a otros fines, aquél debería responder por él. No obstante, el autor entiende que el texto se altera con el pensamiento postclásico, introduciendo un elemento subjetivo cual es la intención de defraudar por parte del *magister*.

42 Vid. a este respecto, CERAMI, P., DI PORTO, A. y PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino, 2004, pp. 234 y ss.

43 En este sentido, vid también DE MARTINO, F., Ancora sull'actio exercitoria, cit., pp. 277 y ss.

44 PETRUCCI, A., Ulteriori osservazioni, cit., p. 48.

45 En este sentido, WACKE, A., Die adjektivischen Klagen im Überblick I, en ZSS, CXI, 1994, p. 306 y KARLOWA, O., Römische Rechtsgeschichte, II, Leipzig, 1892, p. 1.124. No obstante, otros autores sostienen que la *praepositio* debería ser publicada de forma análoga a la establecida para la *actio insistoria*. Vid. en este sentido, PETRUCCI, A., Ulteriori osservazioni, cit., pp. 48 y ss. y MICELLI, M., Sulla struttura formulare..., cit., pp. 193 y 202.

que figura en las fuentes se hace en D. 14, 1, 1, 12, donde se afirma que *praepositio certam legem dat contrahentibus*⁴⁶:

D. 14, 1, 1, 12.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Igitur praepositio certam legem dat contrahentibus. quare si eum praeposuit navi ad hoc solum, ut vecturas exigat, non ut locet (quod forte ipse locaverat), non tenebitur exercitor, si magister locaverit: vel si ad locandum tantum, non ad exigendum, idem erit dicendum: aut si ad hoc, ut vectoribus locet, non ut mercibus navem praestet, vel contra, modum egressus non obligabit exercitorem: sed et si ut certis mercibus eam locet, praepositus est, puta legumini, cannabae, ille marmoribus vel alia materia locavit, dicendum erit non teneri. quaedam enim naves onerariae, quaedam (ut ipsi dicunt) epibatygoi sunt: et plerosque mandare scio, ne vectores recipiant, et sic, ut certa regione et certo mari negotietur, ut ecce sunt naves, quae brundisium a cassiopa vel a dyrrachio vectores traiciunt ad onera inhabiles, item quaedam fluvii capaces ad mare non sufficientes.

En el texto se explica que las funciones fijadas en la *praepositio* servirán de límite en cuanto a la extensión de la responsabilidad el *exercitor*, por lo que, cuando el *magister* se hubiera excedido en las atribuciones concedidas, los terceros no podrán ejercitar la *actio* contra el naviero. Se citan así varios ejemplos en los que se exonera de responsabilidad al *exercitor*, como el caso en que se hubiera encargado al patrón tan sólo el cobro de fletes y éste hubiera arrendado el barco para transporte, o cuando se hubiera permitido el arrendamiento pero con un objeto determinado como el transporte de mercancías y se hubiera llevado a cabo el transporte de pasajeros. En estos casos, se exonera de responsabilidad al *exercitor*, toda vez que se habrían concluido contratos que no entraban dentro de su ámbito competencial.

Por ello, el conocimiento de la *praepositio* por parte de los terceros contratantes, a nuestro juicio, resultaría indispensable para que éstos pudieran actuar con seguridad dentro del marco establecido por aquella y así tener la garantía de que la responsabilidad se extendería al *exercitor* en caso de incumplimiento; ese conocimiento sería, en definitiva, lo que otorgaría seguridad jurídica al tráfico negocial marítimo. Ahora bien, surge la pregunta acerca de si se podría pedir responsabilidad al *exercitor* en el caso de que, por cualquier causa no imputable a los terceros contratantes, éstos no llegaran a conocer las funciones para las que había sido propuesto el *magister*; a nuestro juicio, parece lógico pensar en una respuesta afirmativa teniendo en cuenta, como afirman PETRUCCI⁴⁷ y DE MARTINO⁴⁸, que sería de aplicación el principio *praepositio contra legem dat contrahentibus* y que los contratos se entenderían concluidos dentro de la actividad de la navegación. Esta conclusión además se corrobora al comparar el régimen aplicado a la *actio institoria*, en la cual, para que al *institor* quedara exonerado de responsabilidad por actos del factor de comercio que había traspasado los límites de su apoderamiento, debía publicar a través de una *proscriptio* el contenido y ámbito de la *praepositio*⁴⁹.

46 LONGO, G., *Actio exercitoria*..., cit., pp. 590 y ss.

47 PETRUCCI, A., *Ulteriori osservazioni*, cit., p. 48.

48 DE MARTINO, F., *Ancora sull'actio exercitoria*, cit., pp. 277 y ss.

49 D. 14, 3, 11, 3.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco

Otro supuesto interesante es la posible responsabilidad del *exercitor* en el caso de que se hubieran contratado varios patronos; esta posibilidad se analiza en D. 14, 1, 1, 13 y 14, ofreciendo una solución distinta en función de que se hubiera procedido o no a distribuir entre ellos las funciones de la actividad para la que fueron propuestos:

D. 14, 1, 1, 13.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Si plures sint magistri non divisi officiis, quodcumque cum uno gestum erit, obligabit exercitorem: si divisi, ut alter locando, alter exigendo, pro cuiusque officio obligabitur exercitor.

D. 14, 1, 1, 14.- (ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum).- Sed et si sic praeposuit, ut plerique ^{plerumque} faciunt, ne alter sine altero quid gerat, qui contraxit cum uno sibi imputabit.

Según consta en el primer fragmento, en el caso de que el *exercitor* hubiera procedido a la división de las funciones, quedará obligado según el reparto efectuado, mientras que si no se hubiera llevado a cabo, respondería frente al tercero que hubiera contratado con cualquiera de ellos.

Para concluir, se puede afirmar que el examen de las fuentes referidas a la *actio exercitoria* presenta un régimen de especial protección para los terceros contratantes en el ámbito del tráfico comercial marítimo que se traduce, por una parte, en una exigencia de buena fe más acentuada que en otros ámbitos de la actividad comercial, dando prioridad a la confianza que ese tercero pone en la apariencia externa de la actividad negocial y, por otra, en la tendencia progresiva que marcan las fuentes hacia la objetivización de la responsabilidad del *exercitor*, que quedaría vinculado por los actos concluidos por el *magister*, siempre y cuando se encuentren enmarcados en las actividades para las cuales fue propuesto. Así, la *praepositio* marcaría el límite para dirimir la responsabilidad del *exercitor*, pudiendo percibirse no obstante una interpretación laxa a la hora de establecer los actos que quedarían incluidos dentro de la misma, exigiéndose únicamente que el contrato se encontrara dentro del ámbito de la navegación, con independencia de que posteriormente el *magister* defraude el objeto de ese contrato..

La concesión de veracidad a la apariencia de los hechos resulta, a nuestro entender, de máxima relevancia porque, con base en ella, no recaerá sobre el tercero obligación alguna de indagar acerca de las circunstancias personales o económicas que concurrían en el *magister*, esto es, si era libre, esclavo, *filiusfamilias*, mayor o menor de edad, si estaba bajo la potestad del *exercitor* o de otra persona, e incluso si había sido nombrado por éste o por el *magister* por él propuesto; así, en los textos se percibe una clara tendencia hacia la seguridad jurídica proporcionada por la apariencia con la que se presenta en la realidad y

remoto, sed in evidenti. litteris utrum graecis an latinis? puto secundum loci condicionem, ne quis causari possit ignorantiam litterarum. certe si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum erat, cum multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur. 4.- Proscriptum autem perpetuo esse oportet: ceterum si per id temporis, quo propositum non erat, vel obscurata proscriptio contractum sit, institoria locum habebit. proinde si dominus quidem mercis proscripsisset, alius autem sustulit aut vetustate vel pluvia vel quo simili contingit, ne proscriptum esset vel non pareret, dicendum eum qui praeposuit teneri. sed si ipse institor decipiendi mei causa detraxit, dolus ipsius praeponenti nocere debet, nisi particeps doli fuerit qui contraxit.

entendiendo la responsabilidad del *exercitor* incluida dentro del riesgo empresarial que éste asume al emprender el negocio de la navegación. La apariencia resultaría, por tanto, suficiente para entender que el *magister* actúa con la *voluntas* del *exercitor* y, por tanto, sus actos estarían incluidos en el ámbito competencial otorgado por la *praepositio*. El régimen de la *actio exercitoria* está basado, en definitiva, en la constante que se plasma en las fuentes sobre la base de que los terceros no se vean afectados, defraudados o engañados por circunstancias que, por las propias características que concurren en el comercio marítimo, les sería imposible averiguar, concediendo así un valor absoluto a la apariencia de realidad que se traduce jurídicamente en el intento de que la responsabilidad del *exercitor* se objetivase al máximo.

BIBLIOGRAFÍA:

- ARIAS RAMOS, J., Representación y *praepositio*, en *Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela*, X, 1941, pp. 11 y ss.
- El transporte marítimo en el mundo romano, en *Libro Homenaje al Dr. Ignacio Serrano y Serrano*, Vol. II, Valladolid, 1965, pp. 27 y ss.
- BALESTRI FUMAGALLI, M., L’*actio tributoria*” nel sistema delle opere istituzionali di Gaio, di Giustiniano e di Teofilo, en *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano*, Milano, 1987, vol. I, p. 190.
- BESELER, G., Romanistische Studien, en *ZSS*, XLVII, 1927, pp. 56 y ss.
- BRAVO BOSCH, M.J., La responsabilidad de la actividad mercantil terrestre en el derecho romano, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, X, 2006, pp. 99 y ss.
- BUCKLAND, W., Roman Law and Common Law. A comparison in outline, II, Cambridge, 1965, pp. 217 y ss.
- CERAMI, P., DI PORTO, A. y PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino, 2004, pp. 234 y ss.
- CHIALVO, G., De *exercitoria actione*, en *Studi Berlingieri*, 1935, pp. 171 y ss.
- CHIUSI, T.J., Contributo allo studio dell’*editto de tributoria actione*, en *Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Memorie*, serie 9, vol. 3, fasc. 4, Roma, 1993, pp. 324 y ss.
- COSTA, E., Le *azioni exercitoria e institoria* nel diritto romano, Parma, 1891, pp. 98 y ss.
- DE MARTINO, F., *Der römische Civilprozess und die Actionen*, Leipzig, 1883, pp. 152 y ss.
- Studi sull’*actio exercitoria*, en *Riv. Dir. Nav.*, VII, 1941, pp. 7 y ss. (= en *Diritto, Economia e Società*, I, 1995, pp. 495 y ss.).
 - Ancora sull’*actio exercitoria*, en *LABEO*, IV, 1958, pp. 277 y ss. (= en *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, Napoli, 1995, pp. 629 y ss.).
- DI PORTO, A., Il diritto commerciale romano. Una zona «d’ombra» nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti, en *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne*, vol. III, pp. 413 y ss.
- Impresa collettiva e schiavo “manager” in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.), Milano, 1984, pp. 228 y ss.

- FADDA, C., Istituti commerciali del diritto romano, Napoli, 1903, pp. 45 y ss.
- FERCIA, R., Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e regime della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios, Torino, 2002.
- FÖLDI, A., Appunti sulla responsabilità per l'«exercitor in potestate», en *Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére*, Pécs, 1996, pp. 73-81.
- La responsabilità dell'avente potestà per atti compiuti dall'exercitor suo sottoposto”, en *SDHI*, LXIV, 1998, pp. 179 y ss.
- GHIONDA, F., Sul magister navis, en *Riv. Dir. Nav.*, I, 1935, pp. 327 y ss.
- GUARINO, A., Magister y gubernator navis, en *LABEO*, XI, 1965, pp. 36 y ss.
- KARLOWA, O., Römische Rechtsgeschichte, II, Leipzig, 1892, p. 1.124.
- KELLER, F., Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem Römischen Recht, Zürich, 1827, pp. 420 y ss.
- LAZO, P., Limitación e ilimitación de responsabilidad en una empresa de navegación (D. 14, 1, 1, 19-20 y D. 14, 6, pr.), en *Rev. Estud. Hist.-Jur.*, XXXIII, 2011, pp. 173 y ss.
- LENEL, O., Das Edictum Perpetuum, Leipzig, 1927, § 101-105.
- LONGO, G., Actio exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria, in *Studi Scherillo* II, 1972, pp. 620 y ss.
- MAYER-MALY, T., Necessitas constituit ius, en *Studi Grosso* I, Torino, 1968, p. 190.
- METRO, A., Una “dissensio” giurisprudenziale a proposito dell'”exercitor navis in potestate”?, en *BIDR*, XXXIX, 1997, pp. 183 y ss.
- MICELLI, M., Sulla struttura formulare delle “actiones adiecticiae qualitatis”, Torino, 2001, pp. 6 y ss.
- MOSCHETTI, C.M., Il gubernator navis. (Contributo alla storia del diritto marittimo romano), en *SDHI*, XXX, 1964, pp. 172 y ss.
- PETRUCCI, A., Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magistri navis nel diritto romano dell'età commerciale, en *IURA*, LIII, 2002, pp. 51 y ss.
- PUGLIESE, G., In tema di actio exercitoria, en *LABEO*, III, 1957, pp. 308 y ss.
- SOLAZZI, S., “Appunti di diritto romano marittimo”, en *Scritti Solazzi*, III, Napoli, 1960, pp. 503 y ss. (= en *Riv. Dir., Nav.*, II, 1936, pp. 113 y ss).
- L'età dell'actio exercitoria, en *Riv. Dir. Nav.*, VII, 1941, 1, pp. 185 y ss. (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1938-1947, pp. 243 y ss.).
- VALERI, G., Plures exercitores, en *Riv. Dir. Comm.*, XXI, 1923, pp. 14 y ss.
- WACKE, A., Die adjektivischen Klagen im Überblick I, en *ZSS*, 111, 1994, p. 306.

EXÉGESIS DE “ULPIANUS LIBRO XIV AD EDICTUM” (D. 13, 5 DE PECUNIA CONSTITUTA, 27)

VICTORIANO SÁIZ LÓPEZ
Universidad de Alicante

El texto jurisprudencial que trataremos de analizar y comentar a continuación, incluido por los compiladores justinianos en el libro 13 del Digesto, bajo el Título 5 *De pecunia constituta*, fragmento 27, viene precedido por la inscripción correspondiente, de acuerdo con la cual podemos considerar que su fuente de procedencia inmediata se encuentra en el libro 14 de Ulpiano de los Comentarios al Edicto del Pretor, y presenta una redacción definitiva concebida en estos términos:

D. 13, 5 De pecunia constituta, 27.: Utrum praesente debitore an absente constituat quis, parvi refert; hoc amplius etiam invito constituere eum posse Pomponius libro trigensimo quarto scribit: unde falsam putat opinionem Labeonis existimantis, si, postquam quis constituit pro alio, dominus ei denuntiet ne solvat, in factum exceptionem dandam: nec immerito Pomponius: nam cum semel sit obligatus qui constituit, factum debitoris non debet eum excusare¹.

¹ Sin embargo, teniendo presente la reconstrucción de esta obra del jurista clásico que ha llevado a cabo O. LENEL (*Palingenesia Iuris Civilis, Vol. Alterum*, Graz, 1960, cc. 490-497), reuniendo todos los fragmentos que se encuentran dispersos en el Digesto, bajo la citada *inscriptio*, puede afirmarse que el libro décimo cuarto sobre el Edicto Perpetuo, en su redacción originaria ulpiana, no está dedicado a la *actio de pecunia constituta* ni al *constitut debiti*. En efecto, el Título genérico inicial de este *liber* es *De receptis* y comprende un primer apartado, bajo la rúbrica *Nautae caupones stabularii etc.*, seguido del que ahora nos interesa, dedicado a la *actio recepticia*. Asimismo, hemos de constatar que la citada *actio de pecunia constituta* es objeto de comentario, por parte de Ulpiano, en su *liber XXVII ad Edictum*; O. LENEL, *Palingenesia*, cit. cc. 574-579.

Estas conclusiones críticas tienen también su confirmación inmediata a través de una observación atenta y detallada de las *inscripciones* de los fragmentos que componen este Título V del Digesto, en el sentido de que la fuente clásica fundamental es precisamente el libro vigésimo séptimo, mientras que el décimo cuarto aparece una sola vez. En estas condiciones queda planteado el problema de las razones por las que la comisión compiladora ha alterado la redacción original y ha trasladado los contenidos propios de la acción recepticia al terreno de la *actio de pecunia constituta*. Como ha puesto de relieve A. DÍAZ-BAUTISTA, *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien*, RIDA XXIX, 1982, pp. 165 y ss., es preciso prestar atención, ante todo, a dos aspectos muy significativos, a saber, la influencia ejercida por los banqueros bizantinos en la actividad compiladora y legisladora del emperador Justiniano, así como la aversión de éste frente a los negocios jurídicos de carácter abstracto.

Puede advertirse, en una primera aproximación al texto, la existencia de una triple estratificación que, a modo de síntesis histórica que va del Derecho clásico al justiniano, comprende los elementos siguientes: En el estrato inferior, se encuentra la opinión de *Labeo*, a propósito de la *exceptio in factum*, concedida a quien ha asumido un compromiso en favor de otro, si éste le ordenara no pagar al acreedor; el estrato intermedio corresponde al criterio contrapuesto de *Pomponius*, que deniega dicha excepción y, por último, encontramos la síntesis final de *Ulpianus*, que habría consistido en añadir una regla general, en virtud de la cual aquel que se ha obligado por otro ya no puede excusarse por causa del deudor principal, “*semel obligatus, factum debitoris non excusat*”².

A través de la metodología crítica de las interpolaciones, aplicada al texto, se ha llegado a una *communis opinio*, según la cual las expresiones *constituat*, *constituere* y *constituit* han de ser sustituidas por *recipiat*, *recipere* y *recepit*. En el estudio contemporáneo del Derecho romano clásico, nos encontramos, pues, ante una nueva figura de *receptum*, tradicionalmente ignorada³, junto a las ya conocidas del *receptum arbitrii* y del *receptum nautarum cauponum stabulariorum*, que tienen su reflejo en D. 4, 7 *De receptis, qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant* y en D. 4, 8 *Nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant*. Esta figura que hoy denominamos *receptum argentarii* o *argentariorum* tiene sus raíces en el Edicto del pretor y, a través de las obras de la jurisprudencia clásica, va a llegar hasta los compiladores justinianos. De acuerdo con el criterio de éstos, Justiniano la declara en desuso y ordena que sea eliminada, excluyéndola como tal de la compilación pandectística, aunque al mismo tiempo expresa su voluntad de que los contenidos propios de ella sean transferidos al ámbito del *constitutum debiti*. Por lo que se refiere a la profunda transformación de este último negocio jurídico, hemos de entender que, por una parte, conserva su naturaleza causal, aunque, por otra, adquiere naturaleza abstracta, cuando es realizado *indefense* por *argenti distractores et alii negotiatores*.

C. 4, 18 De constituta pecunia, 2, Imp. Iustinianus A. Iuliano pp.: Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare
(...)

2 His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus (531)⁴.

2 O. LENEL, *Ob. cit.*, Vol. Prius, c. 508 y Vol. Alterum, c. 25, no se ha limitado a incluir el fragmento que aquí estudiamos en la reconstrucción de *Ulpianus libro XIV ad Edictum* sino que lo ha hecho, asimismo, en las obras de comentario *ad Edictum* de los otros dos autores citados.

3 Aunque también es cierto que los autores medievales y sobre todo los humanistas y pandectistas modernos, con anterioridad a O. LENEL, a partir de la *Glossa cui similis, ad lib. IV Inst. tit. 6* y de la *Glossa ad lib. IV tit. 18 Cod. lex Recepticia*, han identificado, de un modo u otro, la figura del *receptum argentariorum*, sin llegar a determinar con precisión el concepto, basándose en las disposiciones correspondientes del Código y las Instituciones. A. ROSELLO, *Receptum argentariorum*, AG, 45, 1890, p. 15.

4 Esta constitución imperial, publicada durante el brevísimo periodo en que se elabora el Digesto, trata de resolver la duda de orden sistemático y práctico que ha surgido en pleno desarrollo de la actividad compiladora de la jurisprudencia clásica.

La crítica contemporánea reciente viene llamando la atención a propósito de las dificultades que plantea este texto. ¿Cómo es posible que la supresión de la *actio recepticia* sea también el motivo que ha de dar lugar a la

Es posible que la presente constitución imperial sea uno de los más significativos exponentes de la ambivalencia tradición-innovación que inspira la totalidad de la obra compiladora. Se trata, ante todo, de mantener el espíritu de fidelidad a los clásicos, pero es también necesario realizar adaptaciones de mayor o menor importancia, debido a las exigencias que se plantean tanto de orden sistemático como de carácter práctico. Observando la obra justiniana con la benignidad de quien es consciente de la enorme dificultad o, a veces, imposibilidad de combinar elementos procedentes de la *scientia iuris*, elaborada por la jurisprudencia en lengua latina, con otros incorporados por la mentalidad helenística que preside la vida académica y negocial, en lengua griega, no tanto se asombra ante lo que parecen flagrantes contradicciones como se reconcilia con los límites de un trabajo que no merece ser cuestionado en aras de una hipercrítica que puede resultar demoledora.

Asimismo, en las Instituciones justinianas se reitera esta idea de no incorporar a la Compilación la antigua *actio recepticia*, a la vez que se insiste en la similitud con respecto a la *actio de pecunia constituta*, que va a absorber todo aquello que de la primera ha de ser conservado:

I. 4, 6 De actionibus, 8: In personam quoque actiones ex sua iurisdictione propositas habet praetor, veluti de pecunia constituta: cui similis videbatur recepticia; sed ex nostra constitutione, cum et si quid plenius habebat, hoc in pecuniam constitutam transfusum est, ea quasi supervacua iussa est cum sua auctoritate a nostris legibus recedere.

De acuerdo con estos testimonios, no puede resultar hoy sorprendente que la antigua acción recepticia, oponible frente al banquero, en los tiempos de Labeón, no sea ya utilizada en la praxis oriental del siglo VI d. C. y mucho menos lo sería en la occidental, con anterioridad incluso a la caída del poder imperial. Sin embargo, habría constituido un serio agravio contra la orientación clasicista y restauradora del *ius*, prescindir, por completo, de los textos en que la jurisprudencia romana ha logrado realizar aportaciones propias en materia de Derecho bancario. Ante las graves dificultades prácticas de mantener la *actio recepticia*, como figura autónoma del tráfico bancario, junto a los correspondientes recursos en materia de arbitraje y convenios sobre el transporte marítimo, etc., se opta por una vía intermedia, que consiste en abolirla formalmente, si bien aduciendo un cúmulo de razones que tratan de justificar tal medida, pero conservando algunos de sus elementos,

necesidad de ampliar la acción del *constitutum debiti* y que, además, se afirme la caída en desuso de la primera de estas figuras? Desde un planteamiento dominado por el escepticismo, surge una cuestión difícilmente resoluble, en torno a los verdaderos motivos que han llevado a los compiladores a tratar de justificar la ampliación de la *actio de pecunia constituta*, al mismo tiempo que declaran que la *actio recepticia* bancaria ya no es utilizada en la vida práctica. ¿Qué sentido tiene, entonces, mantener algo que no responde a las necesidades del comercio y el crédito?. A. M^a. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, *El receptum argentarii en el Derecho romano clásico. Una propuesta de análisis*, Madrid, 2004, pp. 30 y ss. A. DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987, p. 196, considera que, a pesar de las aportaciones de los romanistas en esta materia, el significado y alcance de la disposición legislativa justiniana permanece sin ser aclarado de un modo satisfactorio.

refundidos ahora bajo una denominación de origen clásico y acogidos en el seno de un régimen jurídico inspirado en criterios similares a los originarios, por lo que, al mismo tiempo, la institución de acogida va a quedar ampliada.

En estas condiciones, la reconstrucción del *Edictum Perpetuum*, propuesta por O. LENEL⁵, bajo el Título XI *De receptis*, comprende tres rúbricas que, a pesar de la denominación compartida, presentan contenidos heterogéneos, que no podemos considerar, en sentido estricto, susceptibles de inclusión en el marco del derecho civil común sino pertenecientes a nuevas secciones. Cada una de ellas responde a determinadas especialidades dentro del ordenamiento jurídico romano, en parte propio del pueblo romano, en parte común a todos los pueblos del orbe mediterráneo (G. 1, 1), como son el Arbitraje, el Derecho marítimo y el Derecho bancario. Los términos exactos de la rúbrica edictal que nos ocupa son los siguientes: *Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant*⁶. Suponemos que en esta sede va a quedar ubicada la *actio recepticia*, acción especial del acreedor frente al *argentarius* que, habiendo asumido el pago en favor del cliente, no lo lleva a cabo, alegando como justa una determinada causa. Los términos iniciales del Edicto pretorio van a ser objeto de desarrollo y comentario posterior, por parte de Labeón, Pomponio y Ulpiano, de modo que la redacción que realmente va a llegar a la comisión compiladora será la siguiente:

Ulp. XIV ad Ed.: Utrum praesente debitore an absente recipiat argentarius, parvi refert; hoc amplius etiam invito recipere eum⁷ posse Pomponius libro trigensimo quarto scribit: unde falsam putat opinionem Labeonis existimantis, si, postquam argentarius recepit pro alio, dominus ei denuntiet ne solvat, in factum exceptionem dandam: nec immerito Pomponius: nam cum semel sit obligatus qui recepit, factum debitoris non debet eum⁸ excusare⁹.

Hay otra razón importante que nos lleva a cuestionar la pretendida pertenencia de este fragmento al conjunto de la rúbrica *De pecunia constituta* y es que viene referido expresamente a la promesa de pago de una deuda ajena, *constitutum debiti alieni*, omitiendo toda referencia al llamado *constitutum debiti proprii*. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de los textos conservados en Digesto 13, 5 contemplan esta última hipótesis, puesto que sólo dos de ellos vienen referidos al *constitutum debiti alieni*¹⁰.

5 O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig, 1927, pp. 130 y ss. S. RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars prima*, Florencia, 1968, p. 347.

6 A tenor de esta terminología jurídica, podríamos suponer que la actividad bancaria denominada *mensam exercere* ha consistido, ante todo, en asumir el pago de la deuda o deudas de otro, *recipere pro alio*, y, en segundo término, en realizar el pago correspondiente, *solvere*, cargando tales operaciones, quizás, en una especie de cuenta a nombre del cliente beneficiario. Sería algo equiparable a la domiciliación bancaria de pagos contemporánea. A propósito de esta actividad bancaria, A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo – metà del III secolo d. C.)*, Nápoles, 1991, pp. 197 y ss.

7 Este pronombre hace referencia al banquero o *argentarius*.

8 Al igual que en el caso anterior, *eum* equivale a *argentarium*.

9 TH. MOMMSEN, P. KRUEGER, *Iustiniani Digesta*, Dublin/Zürich, 1973. E. LEVY, E. RABEL, *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, Tomus I, Weimar, 1929. c. 206.

10 Consideramos bien fundada la opinión según la cual el verbo *constituere* tiene el sentido técnico originario de “emplazamiento, con carácter accesorio, de la prestación de una obligación debida a causa de un negocio

El primero de ellos pertenece también a la obra de Ulpiano de Comentarios al Edicto perpetuo aunque, en realidad, viene a reproducir la respuesta dada por Juliano a una importante cuestión práctica. Se trata del caso de un documento escrito, mediante el cual su remitente asume, ante el destinatario, en cumplimiento de un mandato previo de otro, la garantía de pago *sine controversia* de la deuda que resulte entre éste y aquél. La respuesta del jurista se inclina por la admisión de la *actio de pecunia constituta* que puede interponer, frente al remitente del documento, el acreedor. Ulpiano viene a refrendar el parecer de Juliano, quizá por tratarse de una operación realizada sin la intervención de un banquero.

D. 13, 5 De pecunia constituta, 5, 3 (Ulpianus libro XXVII ad Edictum): Iulianus quoque libro undecimo scribit: Titius epistolam ad me talem emisit: “Scripsi, secundum mandatum Seii, si quid tibi debitum approbatum erit, me tibi cauturum, et soluturum sine controversia”; tenetur Titius de constituta pecunia.

El segundo fragmento, procedente de los *libri digestorum* de Juliano, resulta problemático, en el sentido de que aborda el caso de la garantía asumida por el progenitor con respecto a una deuda del hijo, dentro del marco de referencia del *peculium profecticium*. La cuestión consiste en determinar qué ocurre en el supuesto de que la deuda asumida sea superior al valor del peculio. Y dado que nos encontramos, en último término, ante el patrimonio familiar bajo la titularidad paterna, el fragmento no puede ser catalogado como un claro exponente de *constitutum debiti alieni*.

D. 13, 5 De pecunia constituta, 2 (Iulianus libro XI Digestorum): Quodsi filii nomine constituerit se decem soluturum, quamvis in peculio quinque fuerint, de constituta in decem tenebitur.

jurídico principal”. G. ASTUTI, *Studi preliminari intorno alla promessa di pagamento*, I, *Il costituito di debito*, Nápoles, 1938, p. 110. En cuanto a los caracteres de este emplazamiento, puede afirmarse, con seguridad, que no se trata de la inclusión de un mero término dilatorio o *dies ex quo incipit obligatio*, puesto que ésta sería más bien la hipótesis de un *pactum de non petendo*, constituido en favor del deudor y tutelado en el Edicto mediante la correspondiente *exceptio pacti de non petendo*. Ha de entenderse correctamente la expresión *constituere diem* en el sentido de emplazar de forma perentoria, a través del denominado *dies intra quem*, esto es, se trata de establecer un término final de cumplimiento favorable al acreedor. De este modo, transcurrido el tiempo fijado y, por tanto, expirado el plazo, el deudor moroso no tendría ya la facultad o posibilidad de realizar una oferta tardía válidamente, ni de evitar, de este modo, la reclamación de *pecunia constituta*. Dicho en otras palabras, quedaría excluida la opción de transformar la situación de *mora debitoris* en *mora creditoris*. En efecto, dado que la *solutio* no puede producirse más allá de la fecha prevista, se entiende que el acreedor está legitimado para rechazar, sin más, toda oferta y aquel que hubiere constituido la deuda responderá en los términos rigurosos prescritos. El pretor establece, por un lado, la acción *in personam* que tiene por objeto reclamar la cuantía de la obligación debida y, por otro, la *sponsio dimidiaie partis* cuya finalidad es imponer la pena sancionadora del retraso del deudor en el cumplimiento de dicha obligación (G. 4, 171).

Al llamado *dies constituti* se le atribuye, así, carácter extraordinario. Mientras que el régimen ordinario del *ius civile* autoriza la oferta tardía, por parte del deudor, en determinadas condiciones, produciéndose, en caso de falta de aceptación injustificada, la *purgatio morae*, el *constitutum* permite descartar esta posibilidad. A. MAGDELAIN, *Le consensualisme dans l'Édit du Préteur*, París, 1958, pp. 129 y ss.

En definitiva, el análisis de los contenidos del Título *De pecunia constituta* (D. 13, 5) nos lleva a la conclusión de que el supuesto ordinario, en Derecho clásico, de *constitutum debiti* no puede ser otro que aquel cuyo objeto es un *debitum proprium*¹¹, mientras que el pasaje de Ulpiano que analizamos y que ignora, por completo, esta modalidad no encaja fácilmente en el contexto de este Título¹².

Se impone, pues, una lectura del texto, considerado desde la perspectiva de la *actio recepticia* y del *receptum argentariorum*, institutos procedentes del Derecho clásico e incorporados a una nueva sede, bajo la rúbrica *De constituta pecunia*, por medio de la correspondiente ampliación del régimen primario de esta última. Los términos de su redacción permiten apreciar que nos hallamos ante un razonamiento jurisprudencial que, a partir de unas premisas, va estableciendo conclusiones sucesivas. Según la proposición inicial, *Utrum praesente debitore an absente recipiat argentarius, parvi refert*, resulta irrelevante que el banquero asuma la deuda de otro encontrándose éste presente o ausente ¿Significa esta primera afirmación que el consentimiento del deudor beneficiario puede ser manifestado por él mismo o bien por otra persona en su nombre? Si así fuera, nos encontraríamos ante la conocida alternativa “presencia-ausencia del sujeto que emite su voluntad negocial”, en el acto de *recipere pro alio*. Y no ante otra posible dualidad entendida en el sentido de que el “*receptum debiti alieni*” admite como modos de perfección, o bien la intervención del consentimiento del deudor beneficiario, o bien la sola manifestación del consentimiento del banquero, ante el acreedor. Esta segunda alternativa nos llevaría, incluso, ante la posibilidad de considerar el término *recipere* con el significado de acto jurídico que, carente de uniformidad, puede llegar a adoptar, según las circunstancias, carácter trilateral, bilateral o unilateral.

La disyuntiva “presencia o ausencia” sólo puede indicar que el acto, no estando sometido necesariamente a exigencias de solemnidad verbal, admite dos opciones viables en cuanto a la manifestación de la voluntad: *inter praesentes vel inter absentes*. En otras palabras, que la declaración de voluntad del *debitor*, al igual que la del *argentarius* y la del *creditor*, puede hacerse directamente por el mismo sujeto interesado o por mediación de un emisario. En realidad, este criterio favorable a la libertad de forma no parece ser algo exclusivo del *receptum* sino que se extiende a institutos diversos, entre los que se encuentra el *constitutum debiti*, a tenor de lo expresado más arriba en este mismo Título del Digesto, en un pasaje que procede también de Ulpiano.

D. 13, 5 *De pecunia constituta*, 14, 3 (Ulpianus libro XXVII ad Edictum): *Constituere autem et praesentes, et absentes possumus, sicut pacisci et per nuntium, et per nosmet ipsos, et quibuscunque verbis*¹³.

11 En opinión de G. ASTUTI, *Studi preliminari intorno alla promessa di pagamento*, I, *Il costituito di debito* cit., p. 108, el *constitutum debiti* no es, en sus orígenes, una promesa de pago que cree un nuevo vínculo obligatorio, con objeto idéntico a la prestación ya debida por otra causa, sino una vinculación de carácter accesorio, en relación con determinados negocios obligatorios como aquellos que tienen por objeto créditos dinerarios, defendidos en juicio a través de la *legis actio per condictionem*, en principio, y de la *actio certae creditae pecuniae*, más tarde. El objeto de tal negocio es, pues, el sometimiento a un término perentorio de la prestación ya debida.

12 A. ROSELLO, *Receptum argentariorum* cit., p. 20.

13 A pesar de las dudas que han sido planteadas, en torno a la expresión *sicut pacisci*, el texto ha de ser considerado genuino sustancialmente. E. LEVY, E. RABEL, *Index interpolationum* cit., c. 203.

En este orden de ideas, resulta sorprendente que el mismo jurista Ulpiano, también en una obra de Comentarios al Edicto del pretor, se exprese ahora de un modo directo y breve para referirse a la idea de la libertad de forma. Como vemos, prescinde de la construcción con el interrogativo *utrum an*, que viene a obtener respuesta inmediata con la expresión *parvi refert*, y ello nos lleva a considerar que, a pesar de la ambigüedad del enunciado inicial de D. 13, 5, 27, el jurista no se limita a responder una cuestión formal del tipo *Quomodo receptum contrahatur?* Se trata, más bien, de una premisa disyuntiva que actúa como antecedente lógico de la subsiguiente de carácter conclusivo, a propósito de la concurrencia de voluntades.

Así ha de ser entendida al primera afirmación textual, sin perjuicio del reconocimiento del carácter no solemne del *receptum*¹⁴, como criterio más probable a lo largo del periodo clásico, al igual que parece haber ocurrido con el *constitutum*. No sería, pues, acertado afirmar que, en un primer momento histórico, estos actos hayan consistido en una modalidad de convención revestida de carácter contractual, produciendo, como consecuencia, una obligación jurídica *stricto sensu*. Lo más probable es que tanto *constituere* como *recipere* hayan tenido el significado originario de un mero presupuesto de hecho o *factum*, consistente en la aceptación de condiciones muy rigurosas referidas a una prestación determinada, cuya fuerza vinculante no deriva de su reconocimiento jurídico sino de la existencia de deberes extrajurídicos difundidos en la vida económica y social como, por ejemplo, el de no defraudar la confianza o el de mantenimiento de la palabra dada. En efecto, la exposición de los contenidos del Título *De pecunia constituta* se inicia con una alusión a las ideas fundamentales de la *aequitas naturalis* y la *fides*. Aunque pueda pensarse con fundamento que se trata de una glosa añadida con posterioridad, puesto que el Edicto, en su redacción originaria, se habría centrado más bien en un planteamiento práctico y casuístico, prescin-

14 A. ROSELLO, *Ob. cit.*, pp. 42 y ss., ha realizado un amplio y documentado resumen sobre el *status quaestionis* a propósito de la naturaleza civil o pretoria del *receptum argentariorum*, sin llegar a pronunciarse de modo concluyente, por considerar que carecemos de información suficiente. En general, los antiguos comentaristas consideran, de común acuerdo, que se trata de un instituto de derecho civil, con arreglo a las palabras de la constitución justiniana citada: C. 4, 18, 2: *Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio* ... Además de los *sollemnia verba*, se encuentra el dato relativo a la perpetuidad de la acción. Entre los pandectistas, nos remitimos aquí a R. J. POTHIER, *Pandectae Justinianae in Novum Ordinem Digestae cum Legibus Codicis et Novellis*, Paris, 1818, p. 430, que añade un *Appendix de recepto*, al estudio que dedica al *Titulus V De pecunia constituta*. Al comienzo de dicho apéndice expresa las ideas siguientes: *Receptum erat constituti species, quo argentarii in se recipiebant seu solvere constituebant quod alicui deberetur. Ex recepto nascebatur actio recepticia, sollemnibus verbis composita, id est, civilis: ut ex Justiniano discimus in l. 2 Cod. h. t. In quo differt a constituto, ex quo praetoria duntaxat actio nascitur*.

Sin embargo, O. LENEL, *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare*, ZSS, 1881, pp. 62-71, ha rechazado las razones aducidas en favor de la naturaleza civil del *receptum*. Más en particular, no atribuye sentido técnico concluyente a la expresión *sollemnia verba*, puesto que se trata de una terminología referida a la acción, no al negocio o pacto, y empleada en una época en que, superado el procedimiento formulario, ya no existen las *actiones sollemnibus verbis compositae*.

Por su parte, M. ORTOLAN, *Explicación histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano*, Tomo II, Madrid, 1877, p. 365, incluye el *receptum argentariorum* bajo el epígrafe “Pactos provistos de acción por el Derecho pretorio, *pacta praetoria*”, indicando que la promesa del banquero, aunque hecha sin exigencias de solemnidad, por lo que resulta suficiente la simple convención, es reconocida como obligatoria por parte de la jurisprudencia civil y, por tanto, de ella resulta una acción de derecho civil denominada *actio recepticia*.

diendo de consideraciones de orden teórico o doctrinal, lo cierto es que la aseveración del jurista recopilador y sistemático puede servirnos hoy para comprender la razón de ser de esta institución. Por tanto, entendemos que, en un momento histórico posterior, difícil de determinar con precisión, el Edicto del Pretor, junto con la labor de los juristas, habrían comenzado a sancionar casos concretos de incumplimiento de esos deberes radicados en la conciencia compartida entre quienes intervienen en el tráfico comercial y crediticio. Podría tratarse, incluso, de un modo genuino romano de contratación bancaria, a pesar de que muchas de las instituciones jurídicas que se aplican y desarrollan en este ámbito de la vida económica proceden de la praxis oriental como, por ejemplo, los documentos escritos denominados *syngrapha* y *chirographa*.

Admitida, pues, la regla a tenor de la cual *Recipere autem et praesentes, et absentes possumus*, formulada a partir de la respuesta a la pregunta *Quomodo receptum contrahatur?*, insistimos en la reiterada expresión *Utrum praesente debitore an absente recipiat argentarius, parvi refert*, considerada ahora como respuesta a una pregunta del tipo *Quatenus quis alienum debitum recipere potest?*¹⁵, esto es, si nos preguntáramos hasta qué punto está capacitado el *argentarius* para asumir *per se* una deuda ajena, o bien, de qué grado de autonomía goza con respecto al deudor principal beneficiario. Esto supuesto, la expresión que nos ocupa no se traduciría diciendo simplemente que el deudor puede prestar su consentimiento por sí mismo o por representante. Más correctamente hemos de entenderla en el sentido de que este deudor puede estar presente, esto es, manifestar su voluntad, dando su orden, autorización o aprobación, o bien estar ausente, es decir, el *receptum* puede perfeccionarse sin necesidad de dicha orden o autorización o aprobación. ¿Y podríamos añadir nosotros la observación complementaria “ya lo sepa o lo ignore o incluso lo rechace este deudor”?

En efecto, esta es la idea que el jurista Pomponio ha venido a añadir a la redacción inicial de la cláusula pretoria, mediante su propia interpretación: *Hoc amplius etiam invito recipere eum posse Pomponius libro trigensimo quarto scribit*. La *interpretatio iuris* va desarrollando, a través de la dialéctica jurídica y a partir de una premisa concreta, un progresivo y complejo razonamiento jurisprudencial que permitirá enunciar *regulae iuris* más avanzadas, entre las que se encuentra la que podemos formular en los términos *recipere pro ignorante et invito cuique licet*. Nos encontramos ante una vieja *quaestio iuris*, que no habría dado lugar a una respuesta unánime por parte de la jurisprudencia clásica, a saber, si el banquero puede salir garante de una deuda ajena contra la voluntad del deudor, *invito debitore*. Frente a la posición de Labeón, la opinión del jurista Pomponio, a la que se habría sumado Ulpiano, sería la siguiente: “Poco importa que uno haga la aceptación de deuda ajena con la autorización del deudor o sin ella, a lo que se añade que puede hacerlo incluso contra la voluntad de éste”.

En cuanto al tipo de argumentación que ha permitido a los juristas llegar a tales conclusiones, entendemos que no se trata de la *analogia legis* puesto que, como ya enseña la Tópica ciceroniana, entre las nociones *praesentia-absentia* no existe similitud sino contra-

15 R. J. POTHIER, *Ob. cit.*, p. 427, analiza esta *lex 27 Ulp. Lib. 14 ad Ed.*, bajo el artículo tercero, dedicado no a las formalidades o solemnidades del negocio sino a las personas cuya voluntad es requerida para la perfección del mismo.

posición y lo mismo puede decirse a propósito de los conceptos que se expresan a través de los términos *volente-invito*. Procediendo por esta vía, no llegaríamos a los resultados finales enunciados sino a las proposiciones contrarias¹⁶, que han debido prevalecer en un primer momento histórico, al menos en la jurisprudencia de Labeón.

Pero, con el paso del tiempo, y el consiguiente desarrollo de la sistemática institucional, va a imponerse la necesidad de revisar todos los elementos del ordenamiento jurídico y establecer entre ellos la oportuna coordinación, de acuerdo con las reglas generales que van adquiriendo formulación casi definitiva, entre las que se encuentra la que viene enunciada en los términos *Solvere pro ignorante et invito cuique licet*¹⁷. Nos hallamos aquí ante una manifestación del modo de argumentación *a fortiori*, *a maiore ad minus*, cuya manifestación más utilizada en derecho es aquella que nos permite deducir la existencia de la facultad menor, a partir del reconocimiento normativo explícito de la mayor. En este sentido, se dice que, si el banquero puede pagar contra la voluntad del deudor, esto es, sin que sea relevante el consentimiento de éste, con mayor razón, puede obligarse a pagar y seguiría obligado, aunque el mismo deudor mostrase, más tarde, su disconformidad o contrariedad.

En cuanto al origen racional de esta regla específica del pago o cumplimiento de las obligaciones, *Solvere pro ignorante et invito cuique licet*, basta reproducir el texto completo de Gayo para comprender que nos hallamos ante un ejemplo ilustrativo de *analogia iuris*, esto es, del modo de interpretación que procede mediante apelación a los llamados en la actualidad principios generales del Derecho, entre los que se encuentra el que denominamos *favor debitoris*.

D. 46, 3 De solutionibus et liberationibus, 53 (Gaius libro V ad Edictum provinciale):
Solvere pro ignorante et invito cuique licet, cum sit iure civili constitutum, licere etiam ignorantis invitique meliorem conditionem facere.

Esta interpretación jurisprudencial ha prevalecido finalmente, siendo descalificada por falsa la opinión contraria de Labeón, en virtud de la cual, el *argentarius* podía defenderse, en su caso, mediante una *exceptio in factum*, basada en la alegación de que el deudor ha revocado su autorización, ordenando no pagar al acreedor que, más tarde, va a ser demandante. Por tanto, según el citado jurista, este negocio pecuniario sólo puede realizarse *praesente, id est, volente debitore*. Se entiende que la voluntad del deudor principal es requisito fundamental, dando autorización, de un modo u otro, al *argentarius* para que pueda obligarse válidamente. De este modo, con mayor razón ha de resultar admitido que el deudor beneficiario tenga el poder de revocar el *receptum* válidamente asumido, puesto que su conformidad es necesaria esencialmente. En definitiva, a la libertad de concesión de autorización corresponde la libertad de revocación.

16 Cic., Top. 15, 17. En esta obra, Cicerón ya distingue claramente el *argumentum a similitudine* y el *argumentum ex contrario*.

17 Así lo entiende R. J. POTHIER, *Ob. cit.*, p. 427, cuando añade una nota a pié de página, correspondiente a las palabras *invito constituere*, en estos inequívocos términos: *Nam et pro invito potest solvi.*

Esto no obstante, la exégesis de D. 13, 5, 27 nos lleva a la frase final del párrafo, *Nam cum semel sit obligatus qui recepit, factum debitoris non debet eum excusare*, con la que Ulpiano viene a reconocer que no carecía de razón su predecesor, el jurista Pomponio, y a añadir, por su parte, a modo de regla general, que una vez asumido el pago de deuda ajena por parte el banquero, en modo alguno puede excusarle el hecho del deudor.

Se enfrentan aquí dos concepciones, a propósito de la aceptación bancaria del pago de deuda ajena, *recipere pro alio*, que giran en torno a la relevancia del carácter dependiente o independiente de la declaración de voluntad del *argentarius* y la condición jurídica que ha de atribuirse al deudor principal. En el primer supuesto, desde la perspectiva del régimen de dependencia, hemos de considerar la coexistencia de una obligación principal y una obligación accesorio, que responden al tópico interpretativo fundamental *Accessorium sequitur naturam principalis*¹⁸. De este modo, el *receptum argentariorum* vendría configurado como instituto de carácter accesorio y sería dependiente de la relación jurídica obligatoria principal. En otros términos, nos encontramos ante una figura cuya naturaleza corresponde a la de una modalidad de “garantía causal” de las obligaciones.

Asimismo, reiteramos la exigencia de que el deudor beneficiario y cliente del banquero haya otorgado su autorización, de un modo u otro¹⁹, al mismo tiempo que resulta admisible la posibilidad de denuncia posterior, por parte de este *dominus negotii*, lo que constituye una circunstancia de exoneración que el garante puede alegar en juicio. Por medio de la *exceptio in factum* labeoniana, no entendida como alegación negativa del deber de pagar, sino como alegación positiva, el demandado puede traer a colación causas diversas, como las relativas a posibles defectos de constitución de la obligación garantizada o bien a la eventualidad de extinción de la obligación principal por alguno de los modos reconocidos legalmente, entre lo que puede citarse aquí la compensación, a tenor de la importancia que va adquiriendo a lo largo del tiempo en el desarrollo de la función bancaria de mediación en los pagos.

Sin embargo, ésta no ha sido una interpretación unánime, susceptible de adquirir vigencia, como si se tratara de una ley, en virtud del rescripto adrianeo a que se hace referencia en G. 1, 7, sino que estamos ante un campo propicio para el debate entre autores de diversas tendencias. Frente a ella, se alzan, en efecto, quienes tienden a concebir el *receptum argentariorum* o aceptación bancaria del pago de deuda ajena, como figura independiente y no subordinada con respecto a otra principal²⁰ que, además, va desligándose de la condición

18 D. 50, 17 De diversis regulis iuris antiqui, 178=129 (Paulus libro quadragesimo octavo ad Edictum): Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem quae sequuntur locum habent.

19 Hemos de pensar que tal autorización estaría a la base de la legitimación activa para el ejercicio de una eventual acción de reembolso por parte del banquero. A. ROSSELLO, *Ob. cit.*, p. 67.

20 Diversas expresiones latinas, como *indefense constituere*, avalan esta visión del *receptum* como negocio que vincula al *argentarius* a pagar, *solvere pro alio*, una cantidad determinada y en fecha fija o bien determinable en el momento en que se exija su cumplimiento, con independencia de la relación jurídica entre acreedor y deudor cliente, de un modo que, en terminología contemporánea, nos permite denominar al *receptum* negocio jurídico abstracto, no dependiente de causa alguna. Y, dicho esto desde la perspectiva de los recursos procesales contenidos en el Edicto pretorio, que es la que nos interesa sobre todo en Derecho clásico, hemos de añadir que este *argentarius* debe pagar, sin la posibilidad de oponer excepción alguna o *sine controversia*. Es indiferente, asimismo, que el cliente haya hecho o no provisión de fondos en poder del banquero. En opinión de A. ROSSELLO, *Ob. cit.*, p. 64, no era necesario, para que el *argentarius* asumiera la obligación de pagar, que el cliente fuera depositario de

jurídica del deudor beneficiario. Sin la voluntad de éste e incluso contra ella, el banquero puede obligarse ante el acreedor y se entiende que conserva la acción de reembolso²¹, siempre que pague por él. Queda configurado así como un vínculo independiente, válido y eficaz por sí mismo y exigible en juicio sin controversia. Podríamos llegar a afirmar que nos hallamos ante una especie de “garantía bancaria abstracta” que, en la práctica judicial, alcanza el rango de título ejecutivo, ante el que, quizás, no cabría ni siquiera alegar, por parte del banquero demandado, que la obligación ya se ha pagado o ha quedado extinguida por alguna de las justas causas admitidas en derecho. Todo ello viene reconocido de acuerdo con el criterio ulpiano más riguroso, acorde con la máxima *semel obligatus, semper obligatus*, o bien conforme a la decisión justiniana de admitir, aunque sea a título excepcional, la modalidad denominada *indefense constituere*.

A pesar de todas las perplejidades que ha suscitado, la labor de los compiladores parece estar dotada de una increíble coherencia, al menos en un punto concreto, el del paralelismo entre D. 13, 5, 27 y C. 4, 18, 2, 2. Se trata, por una parte, de la inclusión del fragmento 27 bajo la rúbrica D. 13, 5, que consigue romper la armonía del Título dedicado a la *actio de pecunia constituta*, debido al rigor con que Ulpiano excluye toda posibilidad de *exceptio* que pueda favorecer al banquero²². Y, por otra, tenemos la

cantidad suficiente para hacer frente a tal promesa. La exigencia de este tipo de condiciones habría sido muy desventajosa para el desarrollo del comercio, impidiendo el crédito, al permitir el juego de *exceptiones* incompatibles con la finalidad práctica del instituto.

Por este motivo, según dispone Justiniano, C. 4, 18, 2 pr., va a quedar abolida la *actio recepticia*: (cum secundum antiquam recepticiam exigebatur et si quid non fuerat debitum) cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est, permittere per actionem recepticiam res indebitas consequi.

21 La falta de información sobre la acción de reembolso del banquero que ha pagado por otro y las consiguientes dudas suscitadas en torno a ella han dado lugar a hipótesis diversas formuladas con la intención de colmar una laguna legal. Procediendo por analogía, se afirma en principio que, en el supuesto de que el *argentarius* pague en nombre del deudor, obrando en cumplimiento de un *mandatum solvendi*, podrá disponer de la *actio mandati contraria*. Por otro lado, en caso de que el pago obedezca a una gestión realizada en ausencia del deudor y sin su conocimiento, la *actio negotiorum gestorum contraria* será el medio idóneo. Se contempla, incluso, la eventualidad del pago ejecutado contra la voluntad explícita del deudor, ante la cual sólo cabría el recurso a la cesión de la acción, realizada por el acreedor en favor del banquero. A. M^a. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, *Ob. cit.*, p. 210.

Lo cierto es que, en D. 13, 5, 27, no se abordan tales cuestiones y quizá no sea correcto atribuir este hecho al descuido o la falta de precisión de los juristas clásicos. Puede entenderse, por el contrario, que ellos han planteado el tema del *receptum*, haciendo abstracción de los modos que tiene el banquero para cargar en cuenta del cliente la operación realizada o para realizar la oportuna compensación, evitando así la confusión entre figuras jurídicas heterogéneas.

22 En realidad, el estudio crítico de los textos de Ulpiano que comentan la cláusula edictal *De pecunia constituta* pone de manifiesto más bien el rigor con que responde también aquí el constituyente que la causalidad de su compromiso. En efecto, la fórmula de *pecunia constituta* condiciona la condena del reo estrictamente al hecho de que el deudor no haya pagado o que el acreedor no haya imposibilitado el pago (*neque Numerium Negidium fecisse quod constituit, neque per Aulum Agerium stetisse quo minus fieret quod constitutum est*, D. 13, 5, 16, 18). En su caso, el deudor-demandado sólo podría paralizar la acción pretoria del acreedor mediante la correspondiente excepción, alegando el pago o la existencia de causa de incumplimiento imputable al actor. Ahora bien, esta circunstancia no afecta al régimen ordinario de la obligación inicial principal, que permanece, al igual que ocurre con la acción correlativa. En efecto, frente al régimen civil general, el edictal adopta un carácter especialmente riguroso.

Esto supuesto, no sorprende que un sector de la opinión jurisprudencial, entre los clásicos, haya reaccionado, intentando mitigar la severidad con que era concebida esta responsabilidad derivada del *constituere diem intra quem*. Nos referimos, en particular, al intento de ir más allá de una interpretación literal del Edicto, de modo que

cuestionada redacción del párrafo segundo de la constitución reformadora de C. 4, 18, 2, a causa del contraste frontal que se produce en relación con el apartado precedente.

Aunque el régimen legal justiniano de *constitutum debiti*, nuevo y novísimo, comprendido tanto en el Digesto y el Código como en las *Novellae constitutiones*, se inspira en el modelo de la garantía personal causal de las obligaciones, el legislador es consciente, asimismo, de que es preciso dejar la puerta abierta al posible reconocimiento de usos y costumbres que se mantienen operantes en determinados ámbitos de la práctica bancaria: *His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus*.

Se impone, pues, una última consideración, a propósito del desarrollo legislativo posterior al año 531, inspirado en el principio causal, pero realizado con pleno respeto a los usos vigentes. Por lo que se refiere a la introducción del *beneficium excussionis*, en la hipótesis de que el constituyente fuera un banquero, quedaría excluida su operatividad, en un primer momento, siendo admitida después, salvo pacto en contrario²³. Por otro lado, a través del Edicto 9, la decisión del legislador, de acuerdo con este planteamiento, no es otra que asegurar a los banqueros *ex lege* la obtención del correspondiente reembolso de los pagos realizados *ex constituto*, sin perjuicio del reconocimiento del uso o práctica habitual que les permite renunciar a los beneficios concedidos por la ley²⁴.

fuera reconocida la posibilidad de posponer o prorrogar el término perentorio hasta el momento de la eventual *litis contestatio*. Sin embargo, Ulpiano se mantiene firme y refrenda con su autoridad el régimen tradicional de los *verba praetoris*, frente a cualquier *dubitatio* o innovación en esta materia. *Ulpianus libro XXVII ad Edictum. D. 13, 5 De pecunia constituta, 16, 4: Haec autem verba praetoris "neque fecisse reum quod constituit" utrum ad tempus constituti pertinent an vero usque ad litis contestationem trahimus, dubitari potest: et puto ad tempus constituti. La primera duda, surgida en torno a la expresión edictal "neque fecisse reum quod constituit", habría quedado así superada, de modo que el momento en que surge la estricta responsabilidad por incumplimiento de quien constituye una deuda es aquel que se hubiere fijado en el negocio y no otro posterior.*

Y se plantea, a continuación, otra cuestión, D. 13, 5, 18 pr., a propósito de las posibles justas causas de exoneración de responsabilidad del deudor, que no ha podido cumplir exactamente en el momento citado. Los *verba praetoris* "*neque per actorem stetisse quominus fieret quod constitutum est*" se limitan a reconocer que, tan sólo en la hipótesis de que el incumplimiento fuere imputable a la conducta observada por parte del acreedor-actor, por ejemplo, su falta de comparecencia no justificada, puede el reo defenderse, mediante la alegación y prueba de la excepción pertinente. Se entiende, en principio, que este comportamiento imputable viene referido únicamente al momento preciso de cumplirse el día preestablecido. Y de nuevo surge la duda de si el deudor-demandado puede alegar, también, como causa de exoneración una eventual falta de comparecencia del acreedor-actor en un momento anterior o posterior a esa fecha fija. Y la respuesta que da Ulpiano concuerda con la anterior, puesto que considera que el único momento relevante es el llamado *dies constituti* a todos los efectos y, por tanto, la conducta del acreedor-actor, con anterioridad o posterioridad, es indiferente, por lo que se refiere a la exoneración de responsabilidad del deudor-demandado. La obligación de éste permanece intacta, incluso en el supuesto de que pudiera alegar y probar la existencia de algún tipo de impedimento imputable al primero. A. MAGDELAIN, *Le consensualisme dans l'Édit du Préteur* cit., p. 128.

²³ Nov. 4, 1; 3, 1 (a. 535). Nov. 135 pr.; 1 (a. 535).

²⁴ G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*, II, Milán 1941, pp. 294-95. El estudio completo de los textos escritos en lengua griega correspondientes a las modalidades de la garantía abstracta bizantina se debe a A. DÍAZ-BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina* cit., pp. 168 y ss.

LA REGULACIÓN DE LOS INTERESES DEL PRÉSTAMO EN LA *EISAGOGÉ*

FRANCISCO J. ANDRÉS SANTOS

Universidad de Valladolid

1¹. Las aportaciones de Antonio Díaz Bautista a la bizantinística jurídica han sido muchas y relevantes. En particular, su excelente trabajo *Estudios sobre la banca bizantina* (Murcia, 1987) contribuyó a iluminar diversos extremos, poco entendidos hasta entonces, contenidos en las Novelas de Justiniano referidas al mundo de los negocios financieros en el Bizancio del siglo VI, y ha permanecido como una obra de referencia en ese terreno hasta la actualidad. No parece impertinente, por tanto, que en un volumen dedicado a su memoria prestemos atención a un problema que se mueve en el mismo ámbito temático que aquel, pero esta vez en el Bizancio del tránsito entre los siglos IX y X, justamente cuando se produce allí el fenómeno de la llamada ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων, *i. e.* la “purificación de las antiguas leyes”, es decir, la revivificación del Derecho justiniano en el Imperio bizantino. Nos referimos al problema de la regulación de los intereses crediticios en una obra muy concreta: la *Eisagoge* (antes conocida como *Epanagoge*).

Como es bien sabido, la *Eisagoge* (Εἰσαγωγή τοῦ νόμου)² es un compendio-síntesis del Derecho romano-bizantino que reúne un conjunto de textos, ordenados temáticamente en 40 títulos, tomados en lo esencial de la compilación justiniana, incluyendo las Novelas, pero también en algunos casos de la *Ecloga* de los emperadores isaurios León III y Constantino V (ca. 741), y con algunos materiales originales de gran interés, sobre todo en cuestiones de Derecho público. Tanto la fecha exacta de composición de la obra como su autoría son inciertas³. En cuanto a su fecha de elaboración, si atendemos a su rúbrica, la obra fue aprobada durante el reinado del emperador Basilio I junto con sus hijos Constantino y León (880-883) y es, por tanto, presumiblemente coetáneo de otro compendio-síntesis

1 El presente trabajo se enmarca dentro de las actividades del P.I. (Ref^o FF12009-07963, Período 01/01/2010 – 31/12/2012) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (España)

2 Sobre esta obra, véase ahora, en general, SIGNES CODONER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción al Derecho (Eisagoge) del patriarca Focio*. Madrid, 2007 (traducción española de la obra). Para el texto original, se sigue la edición de Leipzig, 1852, a cargo de Karl Eduard ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, reimpresa en ZEPOS, J. y ZEPOS, P. (eds.). *Jus Graecoromanum*, vol. 2, Athenis, 1931, pp. 229-368.

3 Véase, sobre las diversas posturas, SIGNES CODONER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción* cit., p. 139 ss.

del Derecho justiniano, el *Procheiros nomos* o *Prochiron* (ca. ¿870-879? ¿907?)⁴, y algo anterior a los *Basílicos* de León el Sabio (¿887-983?). Por lo que se refiere a su autoría, una serie de indicios cronológicos, ideológicos y estilísticos que se dejan traslucir en el texto han hecho pensar a muchos estudiosos que el verdadero autor material agazapado, si no de la obra completa, sí al menos de sus capítulos más destacados e influyentes y, posiblemente, de su importante proemio, es el famoso erudito, intelectual y político Focio (Φώτιος), patriarca de Constantinopla entre 858 y 867, y de nuevo entre 878 y 886. Este hecho tiene numerosas repercusiones en cuanto a las características de la obra, porque se ha querido ver en ella una fuerte influencia de los círculos patriarcales (en contra del césaropapismo de la corte de Constantinopla), que en parte tal vez habría sido causa para su probable rechazo por parte del emperador Basilio y, en consecuencia, su falta de promulgación como ley efectiva, por lo que habría quedado como un mero proyecto legislativo⁵. Con todo, a pesar de que nunca llegara a ser como tal Derecho vigente, sin embargo, no deja de ser una obra importante en la tradición jurídica bizantina, puesto que conoció una buena difusión manuscrita durante los siglos posteriores –aun mezclada en ocasiones con otros compendios jurídicos del período– y además encontró cierto reconocimiento intelectual (sobre todo, su importante proemio, en el que se ha querido ver directamente la mano de Focio) e incluso político en ciertos países eslavos. Además, es una obra útil tanto para conocer parte de la legislación vigente en el momento de su elaboración como para la reconstrucción del texto de los *Basílicos* e incluso para la crítica textual del *Corpus iuris* justiniano, particularmente gracias al aparato de escolios que acompaña siempre a las copias manuscritas de la obra, por lo que una mirada a su contenido y a sus implicaciones normativas, en conexión con otros textos de la tradición jurídica bizantina.

2. Una de las secciones más interesantes de esta obra (entre otros motivos, porque aporta datos importantes con respecto a su autoría y en cuanto a la relación de la obra con otras del período) es su título XXVIII, referido a los créditos y sus garantías (Περὶ χρέους καὶ ἐνεχύρων). Está compuesto por 15 “capítulos” de desigual extensión, tomados sobre todo de C. 4.24 y 25 y de la Novela 4 de Justiniano. Se trata de uno de los títulos más complejos y enjundiosos de la obra, puesto que mezcla elementos correspondientes a la garantía de las obligaciones con otros referidos a la disciplina del mutuo o préstamo de dinero o bienes fungibles (δάνειον), ya que la “deuda” (χρέος) en la que está pensando el autor es justamente la derivada de un negocio crediticio de préstamo de dinero⁶. Y así, en efecto, el capítulo 1, con un lenguaje un tanto impreciso y un tono moralizante, trata de aclarar el significado de la palabra χρέος (al mismo tiempo “crédito” y “deuda”) haciendo referencia expresamente a la “recepción y aceptación” (λήψις καὶ ἀναδοχή) *scil.* de dinero.

4 Existe una fuerte controversia doctrinal con relación a la auténtica fecha de publicación de esta obra: según la doctrina tradicional (K. E. Zachariä von Lingenthal), el Prochiron sería de época de Basilio I (ca. 870-879); en cambio, según la postura revisionista de A. Schminck, sería una norma promulgada por León VI en el año 907, tras los *Basílicos*. Vid. al respecto SIGNES CODOÑER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción* cit., p. 189 ss.

5 Este punto está igualmente muy discutido: vid. al respecto SIGNES CODOÑER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción*, cit., pp. 165 ss.

6 Cfr. Teoph. Par. 3, 14 pr.; Bas. 23, 1, 2.

En relación con esta materia del préstamo de dinero surge, lógicamente, la cuestión del pago de intereses (τόκοι). A esta problemática se le dedican en el título dos capítulos (2 y 4), en apariencia contradictorios entre sí, que son precisamente los que han suscitado la mayor curiosidad de los estudiosos y han abierto un interesante debate al respecto. Ellos son los que constituyen el centro de atención de este trabajo.

Su tenor es el siguiente⁷:

Eis. 28.2: Sabemos que el Derecho antiguo prescribía que se computaran para la deuda los frutos de las prendas entregadas, las rentas de las casas y los trabajos de los esclavos, de forma que, al alcanzar el importe de la deuda, liberaba al prestatario del préstamo, devolviéndole también la prenda, pero permitía que éste se viera oprimido por otra carga aún más gravosa, me refiero al pago de los intereses. Nosotros, en cambio, a través de la presente legislación, proscribimos del Estado incluso el nombre mismo de “intereses” y no permitimos que se computen sin más en la deuda los frutos, los arriendos y los trabajos, sino que el acreedor debe tener parte en los frutos de los fundos pignorados, las rentas de las casas y los trabajos de los esclavos hasta que los ingresos que vengan de ellos se equiparen a la tercera parte del préstamo y que después de eso, si alguien obtiene algo de los fundos o de las casas, que eso se compute y se considere dentro de la deuda. Pero si en el momento de acordar el préstamo se llegó a este pacto, a saber, que se considerarían desde el principio los frutos de los fundos pignorados, o las rentas o los trabajos, hasta que se satisfaga el total de la deuda, permitimos que esto ocurra. Pues si algo hace el acreedor por un sentimiento humanitario, decretamos que no se impida su alabanza. Al suprimir, como se ha dicho antes, los intereses, sólo permitimos que se paguen en favor de huérfanos y menores de edad, pero impedimos terminantemente que un campesino dé como prenda su fundo, pues, a decir verdad, esto no es pignorar un fundo, sino labrarse la ruina.

Eis. 28.4: Aunque a muchos antes de nosotros les pareció que debía aceptarse el pago de los intereses, no obstante, nosotros juzgamos que es execrable por ser indigno de nuestro Estado cristiano al estar prohibido por la legislación divina. Por eso nuestra Serenidad ordena que bajo ninguna circunstancia le sea a nadie posible de ningún modo recibir pago de intereses, para que, cuando creemos preservar la ley, no estemos en realidad transgrediendo la ley de Dios. Pero, en el caso de que alguien recibiera una cantidad cualquiera [en concepto de interés], que se compute dentro de la deuda.

Ambos pasajes, como se ve, se refieren a la prohibición de cobrar intereses de la deuda, pero con un alcance y un rigor muy distintos, por lo que ha tendido a pensarse incluso que son dos textos de mano distinta y que, en la medida en que se ha observado cierta contradicción en su contenido, uno de ellos no debía de formar parte del texto originario de

⁷ Las traducciones están tomadas de SIGNES CODOÑER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción* cit., p. 438-441.

la obra y habría sido objeto de interpolación posterior. Vamos a ver a continuación cada uno de estos textos más de cerca, a fin de verificar el horizonte de estas críticas y determinar si realmente existe una contradicción entre ambos pasajes y, en consecuencia, si alguno de ellos no estaba integrado en la compilación originaria.

3. El primero de estos pasajes presenta un estilo peculiar y ciertas imprecisiones técnicas que hacen pensar en la redacción por parte de alguien poco experto en Derecho. Trata, como corresponde a la rúbrica del título, del derecho de prenda. De entrada, el pasaje habla de lo prescrito en “el Derecho antiguo”, para hacer referencia sin duda al Derecho justiniano, por lo que debe pensarse que se trata de un texto de nueva factura añadido expresamente a esta compilación, ya que además carece de todo paralelo tanto en el *Prochiron* como en la *Ecloga*, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los textos de la *Eisagoge*. En efecto, en la primera parte del pasaje (“Sabemos... los intereses”), el texto se limita a reproducir el contenido de una norma justiniana referida al cómputo de los frutos producidos por las cosas dadas en prenda que son percibidos por el acreedor, aunque concluye con una afirmación que muestra una fuerte carga retórica y moralizante: el pago de intereses se presenta como una “carga aún más gravosa” que “opprime” al deudor. Así, efectivamente, según el Derecho justiniano, si la cosa entregada en concepto de prenda es fructífera, el acreedor puede hacerse con los frutos, pero estos, salvo pacto en contrario, han de aplicarse a reducir el importe de la deuda, hasta alcanzar el total si se diera el caso; pero ello no impediría que siguieran corriendo los intereses debidos hasta el momento de la extinción de la deuda, imputándose los frutos primeramente al pago de intereses, y una vez pagados estos, al capital.

El escoliasta⁸, en un largo escolio que acompaña al capítulo, nos informa de los textos justinianos que han servido de base para la redacción de la parte inicial de este capítulo, pero lo hace de una manera poco convencional. Comienza diciendo lo siguiente: “Los frutos percibidos de lo dado en prenda se calculan en concepto de deuda y si resultan ser suficientes para toda la deuda, se extingue la acción y se devuelve la prenda. Pero si los frutos superan la deuda, se devuelve lo que sobre”.

El texto reproduce con exactitud el tenor de Sev. Ant. C. 4.24.1 (= Bas. 25, 1, 43). Esta constitución imperial, sin embargo, al igual del texto de la *Eisagoge* que nos ocupa, resultan ambiguos respecto a lo que realmente se está prescribiendo: lo que se nos dice es que los frutos de la prenda percibidos por el acreedor pignoraticio se computan para reducir “la deuda”, pero no queda claro a qué se refiere, si al principal de la deuda (el capital) o a los intereses. Para aclarar este punto hay que avanzar un poco más en la lectura del escolio, cuando nos dice lo siguiente: “El que toma esclavos a título de hipoteca debe computar sus *operae*, esto es, sus trabajos, en concepto del interés que se le debe y, después de esto, en concepto del capital, y si se completa el pago gracias a esto, que entonces devuelva el resto al deudor.” El texto resume correctamente el contenido de C. 8.24(25).2, que a su vez

⁸ En la mayoría de los manuscritos de la *Eisagoge* el cuerpo de la obra aparece acompañado por un rico aparato de escolios de variada extensión en que fundamentalmente se comparan los contenidos de la *Eisagoge* con pasajes de la Compilación justiniana y el *Prochiron*. Se desconoce el nombre de su autor y la época de su composición: al respecto, vid. SIGNES CODONER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción cit.*, p. 169 ss.

está recogido en Bas. 25.7.22 con un tenor muy distinto del de nuestro escoliasta, y más próximo, en cambio, al pasaje original del *Codex*. Esta constitución diocleciana reproduce el régimen clásico correspondiente a esta problemática, como se observa igualmente en D. 36.4.5.21 (Ulp. 25 *ad ed.*): el valor de los frutos percibidos por el acreedor pignoraticio, salvo que hubiera mediado un pacto de anticresis, deben ser atribuidos en primer lugar a los intereses, y solo una vez pagados estos, al principal de la deuda, correspondiendo al deudor el eventual excedente. Este parece haber sido, pues, el régimen que se conservó en el Derecho justinianeo y que, a pesar de la expresión ambigua de nuestro texto, no ha pretendido ser alterado por el autor de la *Eisagoge*, aun cuando la afirmación final de esta primera parte del pasaje (“pero permitía que éste se viera oprimido por otra carga aún más gravosa, me refiero al pago de los intereses”) induzca a confusión, ya que parece suponer que, tras la extinción del principal de la deuda y la devolución del objeto de la prenda al deudor, este seguiría estando obligado al pago de los intereses pendientes durante el período de duración del préstamo. Nada de esto se desprende, sin embargo, de la explicación del escoliasta, que se ajusta en este punto estrictamente al régimen justinianeo. Hay que pensar, pues, que esa frase final de esta primera parte del pasaje es un producto original del autor de la *Eisagoge* (a lo que se añade al tono retórico y moralizante que hemos señalado antes), que parece no entender con exactitud el contenido de la norma.

El resto de esta primera parte del capítulo está igualmente construido sobre fuentes justinianas, como acertadamente refiere el escoliasta, si bien con una redacción muy distinta de la que se desprende de los textos del *Corpus iuris*. Así, la referencia a las rentas de las casas como fruto percibido por el acreedor pignoraticio (schol. *a i*) está tomada de Alex. C. 4.24.2 (a. 222) (= Bas. 25.1.44) y Alex. 4.32.14 (s. d.) (= Bas. 23.3.62). Este último texto presenta un caso más complejo, en que se considera que hay un pacto anticrético cuando un acreedor pacta con su deudor que, en vez de percibir intereses dinerarios, habitará una casa de este sin pagar renta: en este caso, se impide que se considere que el importe de la renta derivada del alquiler de la casa se pueda considerar superior al interés legítimo del dinero (6%), de modo que el acreedor pudiera reclamar la diferencia al deudor en concepto de interés. La conexión con el pasaje de la *Eisagoge* es, pues, muy lejana, y el escoliasta parece citarlo simplemente como ilustrativo de un caso de renta de inmueble percibida a modo de interés, que vagamente habría servido de inspiración al autor del capítulo que nos ocupa. Igualmente se alude a un pacto anticrético en la siguiente referencia que indica el escoliasta (Phil. C. 4.32.17 = Bas. 23.3.65), donde se comenta el caso de una mujer que pignora su tierra con el acuerdo de que el acreedor obtenga los frutos en vez del interés del dinero prestado, de modo que ni ella puede reclamar que se le restituya una parte cuando el valor de los frutos supere el interés legal del dinero, ni tampoco el acreedor puede reclamar un complemento cuando ese valor de los frutos no alcance al del interés. Se trata, asimismo, de una conexión remota con el texto de la *Eisagoge*, puesto que este, en esta primer parte, admite la posibilidad de reclamar el pago de intereses con independencia de la percepción de los frutos. Sí que pudo haber servido este texto tal vez como fuente de inspiración para la parte final del capítulo, donde el autor habla de la cesión en prenda de la tierra de labranza de un campesino (“pero impedimos terminantemente que un campesino dé como prenda su fundo”).

Por su parte, la mención del trabajo de los esclavos (schol. a ii) se ha tomado igualmente de C. 4.24.2 y del antes citado C. 8.24(25).2: de la combinación de estos dos textos en el escolio es de donde podemos deducir que el escoliasta (y seguramente también el autor de la *Eisagoge*) pensaban efectivamente en el régimen clásico de imputación de pagos primero a los intereses y, con posterioridad, al capital.

Una vez aclarados estos puntos, es preciso continuar con la lectura del pasaje. Tras esta exposición de lo que se considera el “Derecho antiguo”, el texto comienza a expresarse con más originalidad. Se abre con un contundente ἡμεῖς (“nosotros”), reforzado por un δὲ, que indica un contraste con lo que se ha dicho anteriormente. ¿Quién es ese misterioso ἡμεῖς? El escoliasta no nos lo aclara, como sí lo hace en otras ocasiones. En combinación con la expresión que aparece a continuación (“a través de la presente legislación”), es claro que el sujeto de la frase no es otro sino el emperador (o emperadores) a quien se atribuye la obra, esto es, Basilio I y sus hijos Constantino y León. Sin embargo, este texto que aquí figura no está ni en el *Prochiron* ni en los *Basílicos*, ni se encuentra transmitido en ninguna otra fuente de la tradición jurídica bizantina independiente de la *Eisagoge*, y tampoco nos dice el escoliasta, a diferencia de lo que sucede otras veces, que el texto provenga de “nuestro piadoso emperador” (Τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως ἐξῆς), como sí lo hace en relación con el otro capítulo que aquí nos interesa. Esta circunstancia de su aislamiento en la tradición bizantina, así como el tono y el estilo del pasaje y las posibles fuentes canónicas de inspiración, hacen pensar verosímilmente que el capítulo puede haber sido obra de un autor de inspiración eclesiástica, esto es, una innovación del autor de la *Eisagoge*, que, al introducirse en la obra, pasaría así a convertirse en ley, una vez admitida por el emperador. La falta de referencias a este texto en otros lugares obedecería, presumiblemente, al hecho de que, como hemos señalado al inicio, lo más probable es que el texto nunca hubiera recibido la sanción imperial, por lo que se habría quedado en una mera propuesta privada. Esto se verá corroborado por lo que diremos a continuación.

En efecto, en esta parte del capítulo se nos dice que los intereses deben quedar enteramente eliminados de la praxis jurídica, pero se introduce a cambio la regla según la cual el acreedor tiene derecho a percibir los frutos de la cosa pignorada (y el ejemplo de los frutos de la tierra, las rentas de bienes arrendados y las *operae servorum* están en conexión con lo dicho en el primer párrafo) hasta llegar a un máximo de un tercio del importe del préstamo y, una vez alcanzado esto, se prescribe que el resto de los frutos se imputen a la reducción del capital; no obstante, esta medida no se impone forzosamente, sino que se permite a las partes que desde el principio el valor de los frutos vaya reduciendo el principal de la deuda, y esto se introduce por motivos humanitarios, no en razón de la justicia del caso. Como se ve, a pesar de la firmeza con que se quiere excluir el pago de intereses, sin embargo, lo que sale por la puerta entra por la ventana, y al autorizarse la percepción por el acreedor de los frutos de la cosa hasta un tercio del capital prestado, teniendo en cuenta que el tipo de interés legítimo autorizado en la legislación justinianeana era del 6% anual con carácter general, eso supone que al acreedor se le permite obtener un interés en especie de en torno a cinco años de intereses de la deuda – lo que implicaría, lógicamente, desanimar la concesión de créditos por un plazo superior a ese tiempo, así como otros tipos de préstamo de más riesgo, como el préstamo marítimo.

No encontramos en las fuentes de la tradición del Derecho romano ninguna norma de este estilo, aun cuando, obviamente, el mutuo siempre fue considerado un contrato esencialmente gratuito. Como es evidente, esta disposición está relacionada con la firme oposición al cobro de intereses dinerarios por parte de la Iglesia cristiana. La mayor parte de los grandes autores de la Patrística expresaron su desaprobación hacia esta práctica, si bien nunca llegaron a formular una prohibición expresa. Esta se recogió en el marco de diversos textos normativos eclesiásticos, en particular en el canon 17 del Concilio de Nicea, referido a los clérigos. No obstante, las fuentes de inspiración pueden encontrarse en la tradición hebrea. Así, por ejemplo, en los diversos pasajes del Antiguo Testamento: Ex. 22.24-26; Lev. 25.35-37; Deut. 15.7-10; Deut. 23.20-21; Deut. 24.10-13. Todos estos pasajes se encuentran recogidos, con mínimas adaptaciones, en el capítulo 11 de una colección bizantina, de autoría y fecha desconocidas (pero no se descarta que provenga del círculo de Focio), de setenta extractos de los libros del Pentateuco (en la traducción griega de los Setenta) reunidos en cincuenta capítulos conocida como *Selección de la Ley dada por Dios a los israelitas por medio de Moisés*, o, simplificada, *Nomos Mosaikos*.⁹

Además, la inserción del inciso moralizante “[p]ues si algo hace el acreedor por un sentimiento humanitario, decretamos que no se impida su alabanza” refleja sin duda el estilo y la intención de los textos bíblicos, y lo mismo puede decirse de la frase que cierra el capítulo (“pues, a decir verdad, esto no es pignorar un fundo, sino labrarse la ruina”). En esta última no solo se prohíbe el préstamo con interés a los campesinos (que ya tenían un trato privilegiado al respecto en la legislación justiniana), sino que incluso se impide que se haga ninguna clase de pignoración de la tierra de cultivo, a fin de evitar la posible pérdida del medio principal de subsistencia del campesino y su familia. Esta norma no encontró acogida en la legislación bizantina posterior, pero sí que parece anticipar de algún modo las medidas que posteriormente adoptarían los emperadores de la dinastía macedonia en defensa de los pequeños agricultores frente a la creciente presión de los grandes propietarios.

En cualquier caso, pese la afirmación categórica del principio de este apartado, la prohibición del cobro de intereses no es absoluta, pues el mismo texto legal autoriza su pago a huérfanos sujetos a tutela y menores de edad, sin indicación de límite alguno, y ello se hace igualmente en el marco de una legislación humanitaria, como se desprende del hecho de que esta norma se sitúa inmediatamente después del inciso anteriormente citado. Tampoco encontramos en esto un precedente justiniano claro. Es cierto que hay normas que favorecen la inversión productiva del dinero del pupilo, y se hace al tutor responsable de ello. El escoliasta hace referencia a ese respecto a dos normas contenidas en el Código, Ant. C. 5.56.1 (a. 213) y Alex. eod. 2 (a. 224), que imponen, respectivamente, la obligación de pagar intereses por el tutor en caso de que utilice el dinero del pupilo, y también por lo que se adeude con ocasión de la tutela. Pero en ninguno de los dos casos se observa un trato privilegiado para los pupilos en cuanto al tipo de interés, como erróneamente indica el escoliasta, quien atribuye en ambos textos un interés del 1% mensual, y lo mismo vuelve a hacer un poco más adelante en

9 Ed. BURGMANN, L. y TROIANOS, Sp. *Nomos Mosaikos*. En *Fontes Minores*, vol. 3, ed. D. Simon, Frankfurt am Main, 1979, p. 126-167.

el mismo escolio con relación a Iust. C. 4.32.26.2, equiparando en este privilegio el préstamo dado con dinero pupilar con el préstamo marítimo y con el caso de entrega de especies a interés (con anticresis). No está claro si este testimonio del escoliasta obedece al hecho de que manejara fuentes distintas de las que han llegado hasta nosotros, o de que se hubiera producido una reforma legislativa poco conocida para nosotros en el tiempo que medió entre la promulgación de la Compilación justiniana y la elaboración de la *Eisagoge*. Ninguna de las dos hipótesis parece muy plausible porque, a la falta de datos precisos, se une el hecho capital de que dicha referencia al tipo de interés para los pupilos no aparece en la versión de los Basílicos ni de C. 5.56.2 (Bas. 28.17.2) ni de C. 4.32.26.2 (Bas. 23.3.74), mientras que en la versión de C. 5.56.1 (Bas. 28.17.1), en vez de una tasa de interés mensual del 1% se habla de media centésima, esto es, un 0,5% mensual o un 6% anual, es decir, el tipo de interés máximo permitido con carácter general por la legislación de Justiniano, que es precisamente lo que indica el texto original del *Codex* cuando habla de '*legitimas usuras*'. ¿Cabe pensar, pues, que el escoliasta está desfigurando las citas del Derecho justiniano a fin de apoyar las medidas que se proponen en el texto de la *Eisagoge*? No es una hipótesis descartable, sobre todo si se sostiene la tesis de la existencia de dos escoliastas de la obra, uno más próximo al círculo patriarcal y otro contrario a este, como sugiere Schminck. A ello se añade la circunstancia de que el escoliasta, asimismo, tras hacer referencia a los pasajes de C. 5.56.1 y 2 como apoyo del texto de nuestro capítulo, introduce un extracto (esta vez inalterado) de la Nov. 120.4 (= Bas. 5.2.4). Dicha Novela (a. 549) trata de los préstamos con interés con garantía real asumidos por iglesias y establecimientos de caridad en caso de necesidad perentoria, en los cuales se permitía que el acreedor se hiciese con los frutos de la cosa entregada en garantía, computando una parte como amortización de la deuda, y otra en concepto de intereses con un límite del 3% anual. En realidad, esta Novela no tiene nada que ver con el contenido del pasaje que comentamos, salvo por el hecho de que vuelve a referirse a la posibilidad de una anticresis, esta vez obligada (y no pactada), ya que, en principio, estos establecimientos religiosos o caritativos no están autorizados a enajenar sus bienes inmuebles (salvo al fisco) ni tampoco a gravarlos con derechos de garantía (Nov. 120 pr.). Pero por su colocación en el seno del escolio, esta referencia a la Novela parece más bien pensada para servir de ilustración a la existencia en el Derecho justiniano de determinadas excepciones en caso de prohibición de pago de intereses, como se pretende hacer en el texto de Eis. 28.2; es decir, que ante situaciones parecidas (estado de necesidad de personas débiles) pueden adoptarse soluciones semejantes. La cita, por tanto, parece más bien una muestra del razonamiento analógico del escoliasta que de la indicación concreta de fuentes del pasaje legal que está comentando. Ese mismo razonamiento es el que parece presidir el comentario posterior (llamado específicamente Σχόλιον) cuando enlaza el préstamo con bienes de los pupilos con el préstamo marítimo y el pacto de anticresis como casos en que es posible elevar el tipo de interés permitido frente al supuesto ordinario (del 6 al 12% anual), si bien en el caso de los pupilos no puede citar expresamente ninguna disposición legal vigente; asimismo, lo relaciona con otros supuestos de modulación del tipo de interés, como es el caso de los *illustres* (4%), los comerciantes (8%), los que prestan a campesinos (12,5% o 4%, dependiendo de si se

les presta son áridos o metálico) y a eclesiásticos (3%)¹⁰. Se diría que el escoliasta, en su afán por defender la solución de la Eisagoge, ofrece una pluralidad de ejemplos donde la cuantía y la modalidad de los intereses del préstamo varían notablemente, de modo que pueda sustentarse con la legitimidad del Derecho justinianeo la regulación propuesta. Todo ello se suma la declaración categórica que encabeza esa parte de la glosa titulada Σχόλιον: “Acerca de los intereses, esto es lo que afirman los antiguos, pero también que, como en todos los demás casos, excepto en los de los bienes de los huérfanos, si no se concierta un interés, no se da.” Parece, pues, que el escoliasta pretende dar una base justiniana incluso a la regla general que estatuye el cap. 2, esto es, la eliminación del concepto de intereses de la legislación bizantina: en el propio Derecho justinianeo no habría tampoco intereses en los préstamos por regla general, salvo que así se pactase expresamente, excepto en el caso de los menores sujetos a tutela. Por lo tanto, cuando la Eisagoge dice que debe prescribirse “incluso el nombre mismo de ‘intereses’” lo único que está haciendo es desarrollar una norma que estaba ya implícita en el Derecho de los “antiguos” con arreglo a una consideración conforme con la doctrina cristiana. Se trata, por tanto, de salvar como sea la regulación propuesta en la Eisagoge desde el punto de vista de la “purificación de las viejas leyes” (ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων), es decir, el programa focio-macedonio de recuperación del Derecho justinianeo.

4. El segundo capítulo de nuestro comentario es, en principio, de más fácil interpretación, pero no menos controvertido. En él se establece de forma categórica la prohibición del préstamo con interés en el Imperio bizantino, por considerarlo una práctica indigna de un “Estado cristiano”. En este caso, a diferencia del pasaje anterior, sí se especifica expresamente la causa de la prohibición: el hecho de que esa institución vulnera la ley divina y, si bien su existencia en la legislación justiniana llevaría, lógicamente en un texto que se supone que se propone una recuperación del Derecho justinianeo (“la masa de las viejas leyes”)¹¹, a conservarla como había hecho Justiniano y sus sucesores, sin embargo, aquí se nos dice textualmente que es preferible dejar de cumplir la ley (νόμος, i.e. la ley civil) a fin de no producir una lesión a la ley de Dios. En este sentido, esta decisión es conforme con el programa de Basilio I (y Focio) de llevar a cabo una “purificación” del Derecho antiguo, en el que se inscribe nuestra obra: no se trata de conservar toda la legislación justiniana, sino solo aquella parte de la misma que resulte vigente y justa, y no puede reputarse justo algo que va contra la ley de Dios. En consecuencia, el texto dispone una prohibición absoluta y sin excepciones del cobro de intereses, ya sean estos dinerarios o en especie, y cualquiera que sea la persona que pretenda cobrarlos. Y en el caso de que, no obstante, en un contrato de préstamo se hubiera pactado el pago de intereses, se prescribe que dichos intereses deberán ser computados inmediatamente para la reducción del principal de la deuda.

10 Sobre estos casos, vid. GOFAS, D. The Byzantine Law of Interest. En *The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century*, A. E. Laiou ed. in chief, vol. 3. Dumbarton Oaks, 2002, p. 1097 s.

11 Eis. proemio, ll. 31-32 (ed. SCHMINCK, A., *Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern*. Frankfurt am Main, 1986, p. 6).

El texto, dado que viene atribuido a un “nosotros” y a “nuestro Estado” y “nuestra Serenidad” y que luce un estilo imperativo muy propio del lenguaje normativo, ha de tratarse sin duda de un fragmento de una constitución imperial. Ello viene corroborado por el único escolio que presenta el capítulo, que dice de forma muy escueta: “lo que sigue es del piadoso emperador”. El escoliasta no entra, pues, a discutir el contenido del pasaje porque es ya Derecho vigente, procedente de la Majestad imperial, y que, por tanto, no puede ser objeto de crítica ni comentario.

Se trata, pues, del texto de la una ley imperial añadido al discurso de la *Eisagoge*. Ahora bien, ¿quién es ese enigmático “piadoso emperador”? Esta es una cuestión capital, porque aclarar a qué personaje se estará refiriendo el escoliasta significa inmediatamente dar una datación del aparato de escolios, que es objeto de gran discusión entre los estudiosos. Esta referencia aparece numerosas veces entre los escolios de la *Eisagoge* y remiten casi siempre a textos contenidos en el *Procheiros nomos*: el escoliasta suele mencionar el texto del *Prochiron*, atribuyéndolo a “nuestro (piadoso) emperador”, dando a entender así, aparentemente, que el texto de referencia sería anterior a la redacción de la *Eisagoge*; solo en el caso que estamos comentando el escolio se limita a apuntar al pasaje de la *Eisagoge* como el tenor de la ley imperial, sin citar el texto concreto de la *novela* mencionada. El epíteto “piadoso” referido al emperador reinante puede corresponder tanto a Basilio I como a León VI, los únicos en la dinastía macedonia llamados así. Siguiendo la cronología relativa tradicional, que antepone la promulgación del *Prochiron* a la elaboración de la *Eisagoge*, el misterioso emperador tendría que ser, pues, Basilio I, conclusión que se ve reforzada si se tiene en cuenta el hecho de que León VI, en cambio, promulgó una *Novela* (la número 83 de la colección), en la que se restaura la licitud del pago de intereses, si bien limitados al tipo máximo del 4%¹². En consecuencia, el texto que nos ocupa no sería otra cosa que una traslación de un pasaje del *Prochiron* (Proch. 16.14) –procedente, a su vez, quizás de una novela de Basilio I– al discurso de la *Eisagoge*, al considerarse un texto valioso que debería conservarse en la nueva “introducción al Derecho” destinada a sustituir al *Prochiron*.

Y aquí es donde surge el problema del que trae causa la elaboración de este comentario. Si esto es así, ¿qué sentido tiene introducir este pasaje del *Prochiron* en el título 28 de la *Eisagoge*, cuando ya antes en el capítulo 2 del mismo título se ha dicho expresamente que “Nosotros (i.e. Basilio I)... proscribimos del Estado incluso el nombre mismo de ‘intereses’”, si bien es verdad que con ciertas limitaciones y excepciones? Parece algo tan absurdo como contradictorio: por un lado, no tiene sentido reiterar casi inmediatamente una disposición normativa similar, atribuida además al mismo sujeto imperial, sobre todo teniendo en cuenta que –se supone– la *Eisagoge* tenía que ser un texto vendría a sustituir al *Prochiron* como introducción y compendio de la nueva legislación compilada y “depurada”, todo lo cual constituye una evidente violación del principio de economía normativa; y, por otro, entre los dos textos parece haber una diferencia radical de contenido, puesto que, si bien ambos prohíben la percepción de intereses del préstamo con carácter general, mientras el primero admite una excepción en el caso de los préstamos concedidos con medios

12 Vid. texto (con trad. francesa) en NOAILLES, P. y DAIN, A. *Les Nouvelles de Léon VI le Sage* (texte et traduction). Paris, 1944, p. 280-283.

del patrimonio de los pupilos y menores de edad, y además abre una vía oblicua para la obtención de un sucedáneo de intereses al permitir que el acreedor perciba hasta un tercio del importe de la deuda en la forma de frutos de la tierra dada en prenda, de rentas de los inmuebles pignoraticios arrendados y de trabajo de esclavos; el segundo pasaje, en cambio, prohíbe taxativamente y sin excepción el cobro de intereses, e impone que todas las cantidades que reciba el acreedor en concepto de intereses (prohibidos) se computen para la reducción del principal de la deuda. A la idea de la contradicción contribuyen además las confusas palabras del escoliasta en el σχόλιον al cap. 2, que ya hemos señalado. Sin embargo, el hecho de que ambos pasajes aparezcan en la tradición manuscrita de la *Eisagoge* sin asomo de dudas desde un punto de vista crítico-textual¹³ obliga necesariamente a encontrar alguna explicación. Ha habido diversas propuestas al respecto, que pasamos a glosar a continuación.

5. 1) El primer intento de explicación se debe a K. E. Zachariae von Lingenthal. Siguiendo su tesis de que el *Prochiron* es anterior a la *Eisagoge* y dado que el texto del cap. 4 es coincidente con el de Proch. 16.14, este erudito alemán sostiene que, en efecto, este cap. 4 procede de una novela de Basilio I y sugiere, por tanto, que debe ser expurgado, sin más, del contenido de la *Eisagoge*, ya que, a su juicio, nunca formó parte del mismo. Aparte de su contenido contradictorio con lo establecido en el cap. 2, el autor señala que este sería el único caso en toda la obra en que el texto de una novela de Basilio no aparece transcrito en un escolio, sino que se reproduce directamente en el texto de la norma¹⁴, lo cual no deja de ser anómalo. En consecuencia, a su juicio, el texto del cap. 4 no sería en su origen sino parte de un escolio referido seguramente al cap. 2, donde se contrastaría la innovación propuesta en la *Eisagoge* con el tenor de la norma vigente hasta el momento contenida en el *Prochiron*; posteriormente, en manos de algún copista el texto en cuestión se habría deslizado en el interior del cuerpo principal de la compilación, y así se habría transmitido erróneamente en la tradición textual. En cualquier caso, en la tradición bizantina –tanto en los escolios de los Basílicos como en el *Hexabiblos* de Harmenópulo– este pasaje se atribuye siempre al *Prochiron*, nunca a la *Eisagoge*, y se recoge con la literalidad que tiene en el *Procheiron* (como sabemos, un poco distinta de la que presenta en la *Eisagoge*).

Esta tesis, si bien suena bastante aceptable, sin embargo, presenta algunas dificultades. En primer lugar, resulta extraño que sea solamente aquí y en este capítulo donde se hubiera filtrado este resto de escolio en el texto principal de la obra, quedando otro fragmento en forma de escolio. Por otro lado, también parece raro que, siendo el resultado de un error textual, se haya repetido con tanta asiduidad en los diversos testimonios del contenido de la *Eisagoge* que han llegado hasta nosotros, y no encontremos copias que carezcan de este capítulo en el texto principal. Además, la propia falta de reproducción del texto literal del cap. 16.14 del *Prochiron*, sustituida por una versión “purgada” que ha eliminado un inciso que carece de sentido allí, hace pensar más bien en una intención positiva de introducir la

13 En la ed. de ZACHARIAE VON LINGENTHAL (1852), en ZEPOS y ZEPOS (eds.). *Jus Graecoromanum*, II. cit., p. 322, no se anotan variantes en los manuscritos.

14 ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *ibid.*, p. 322 n. 4: “Forte et ipsa § 4 ex Epanagoges textu expugnenda est, quum alioquin sanctiones a Basilio in Prochiro noviter introductae in Epanagogen non sint receptae”.

regla en el texto de la norma: tal vez podría pensarse en una caída de línea o algún otro problema de transmisión manuscrita, pero no deja de resultar chocante que justamente haya desaparecido esa frase poco coherente, y no cualquier otra. Podría conjeturarse que hubiera sido una supresión intencionada del escoliasta, por considerarla una frase con poco sentido en esa posición o exclusivamente retórica, pero resulta casi impensable que, al reproducir el texto de una disposición del emperador reinante (como allí mismo se reconoce), el escoliasta se hubiera permitido corregir el texto legislativo; es más sencillo suponer que la supresión se haya hecho expresamente para incluir el pasaje de la novela en otra disposición legal, en cuyo caso ya no tendría por qué pensarse que es una intervención ilícita de un comentarista, sino que la responsabilidad de la supresión correspondería al propio emperador.

Por otra parte, también resulta sorprendente que se haya filtrado en el texto transmitido de la *Eisagoge* un fragmento que, en realidad, correspondería a un escolio, cuando precisamente el contenido de ese texto presuntamente inserto en la tradición manuscrita resultaba contrario a las reformas legislativas introducidas poco después de las obras que nos ocupan, en el sentido de ser más proclives a admitir el préstamo con interés, en concreto la Novela 83 de León VI y una novela de Romano I Lecapeno del año 928¹⁵. Y, por fin, la existencia de otras referencias textuales que parecen poner en cuestión la atribución del texto de Proch. 16.14 a Basilio I también arroja dudas a la explicación de Zachariae.

2) Frente a este punto de vista, Andreas Schminck ha propuesto una interpretación alternativa, que no difiere mucho de la de Zachariae, salvo en la datación y atribución del texto de Eis. 28.4¹⁶. Con arreglo a su teoría sobre la cronología relativa de estas obras, que atrasa la elaboración y publicación del *Prochiron* al año 907, bajo el reinado de León VI, es evidente que el cap. 4 no podría haber formado parte del texto original de la *Eisagoge*. Este texto habría sido interpolado en esta obra por el escoliasta (que, según el autor alemán, actuaba en tiempos de León VI o muy poco después) en su trabajo de revisión de la *Eisagoge* a partir del *Prochiron*. Ese cap. 4 de Eis. 28 se corresponde con Proch. 16.14, que es el texto donde León VI habría reintroducido la prohibición del pago de intereses, después de haber publicado poco tiempo antes una Novela (Nov. Leon. 83) en la que los autorizaba en una cuantía limitada (4%). No habría, por tanto, contradicción de contenidos en la *Eisagoge*, que ya en ese momento esta habría dejado de ser un texto legal vigente y oficial, sino que, simplemente, el escoliasta habría querido destacar la diferencia de regulación del problema en la *Eisagoge* y en el *Prochiron*, como en muchos otros casos. A favor de esta teoría juega el apunte que aparece en el *Hexabiblos* de Constantino Harmenópulo (Hexab. 3.7.24), donde se introduce una reproducción del texto de Proch. 16.14 bajo el epígrafe: νεαρὰ τοῦ καίσαρος Λέοντος τὸν τόκον ἀπαγορεύουσα (“Novela del emperador León prohibiendo el interés”).

Frente a esta tesis, además de las mismas dudas ya comentadas que ofrece la tesis de Zachariä von Lingenthal, se añaden las no pocas objeciones que surgen en relación con la datación relativa de las obras que hace Schminck. Con independencia de eso,

15 Cfr. GOFAS, *Byzantine Law* cit., p. 1101.

16 SCHMINCK, *Studien* cit., 77-78 (esp. n. 122) y 81; asimismo, id., recensión a Van Bochove, *To Date* cit. En *Jahrbücher für die Österreichische Byzantinistik*, 48, 1998, p. 352.

sigue resultando extraño que se hubiera añadido un aparato de escolios a una obra que, formalmente, y de acuerdo con la tesis del propio autor, habría dejado de estar vigente a partir del 907. ¿Cuál podría ser el objetivo de hacer esa revisión de la *Eisagoge* una vez promulgado el *Prochiron*? Podría pensarse que, al menos el esolio que nos ocupa, junto con otros, procede de un momento anterior a la promulgación del *Prochiron* por León VI y que su objetivo sería, pues, contribuir a la revisión de la *Eisagoge* con vistas a la ulterior promulgación del nuevo compendio; pero la indicación de que el texto alternativo de Eis. 28.4 procede de “nuestro piadoso emperador” implica que se trata de un texto legal en vigor, por lo que, o bien se trataría de una novela independiente de León VI –en cuyo caso resulta anómalo que no hubiera sido recogida en la colección de Novelas de este emperador ni exista ninguna referencia a ella fuera del *Prochiron*, mientras que sí se encuentra recogida, en cambio, la Novela 83, que entra en contradicción con ella– o bien se está aludiendo al texto oficial del *Prochiron* –lo que entra en contradicción con la tesis de partida.

Por otra parte, esta explicación obliga a hacer una alambicada reconstrucción de la regulación del interés del préstamo en tiempos de León: primeramente estaría vigente la norma de Basilio I contenida en Eis. 28.2, prohibiendo parcialmente el interés; con posterioridad, León habría promulgado la Novela 83, que reintroduciría su licitud con moderación; y, por fin, Proch. 16.14 habría reintroducido la prohibición, esta vez sin excepciones. No se alcanza a comprender la razón de esta sucesión de normas y el caprichoso cambio de parecer del emperador en relación con este tema, adoptando de forma más radical que su padre el punto de vista eclesiástico (“es execrable por ser indigno de nuestro Estado cristiano”), sobre todo habida cuenta de que el *Prochiron*, desde este propio punto de vista, habría sido introducido justamente como una vía de reafirmación de la autoridad imperial (césaropapista) frente a las pretensiones dualistas, favorables a la Iglesia, de la *Eisagoge*¹⁷: resulta llamativo que León dé un paso atrás en su propia regulación del instituto, no solo en contra de sus propios actos, sino también de las necesidades económicas (a las que León VI pareció siempre ser sensible) y de la corriente de los tiempos (como demuestra la ulterior novela de Romano I Lecapeno, no muchos años después del reinado de León)¹⁸. Además, resulta poco verosímil que León hubiera reintroducido la prohibición sin hacer mención de su propia Novela.

Parece, por tanto, poco verosímil que el texto que nos ocupa proceda realmente de una ley de León VI. Sin embargo, sigue estando presente el dato de la referencia de Harmenópulo a León VI como autor de la norma que prohibía el interés. ¿Hay que pensar, pues, que nuestros razonamientos anteriores son erróneos, o bien que Harmenópulo pudo haberse equivocado en su atribución de la norma? A favor de esta segunda hipótesis actúa un hecho, y es que el propio León VI, en su Novela 83, atribuye a su padre, Basilio I, la promulgación

17 SCHMINCK, *Studien* cit., p. 101.

18 De hecho, los *Basílicos* reproducen la regulación justiniana de los intereses sin apenas variaciones, y ni siquiera recogen el contenido de Nov. Leon. 83 (si bien no es claro si esta Novela es anterior o posterior a la publicación de los *LX Libros = Basílicos*). En el supuesto de que fueran anteriores, eso indicaría que, implícitamente, la norma prohibitoria de Basilio I habría sido derogada, o al menos no era muy tenida en cuenta en la praxis; y si son posteriores, entonces sería la nueva regulación de León la que habría caído pronto en desuso: cfr. LAIOU, A. E. Exchange and Trade, Seventh-Twelfth Centuries. En *The Economic History of Byzantium* cit., vol. 2, p. 734.

de una norma que prohibía la percepción de intereses por el préstamo del dinero: καὶ τοῦτο συνιδὼν ὁ ἀείμνηστος ἡμῶν βασιλεὺς καὶ γονεὺς τὴν καταβολὴν τῶν τόκων οἰκείῳ διέγνω κωλύειν θεσπίσματος (“y sabiendo esto, el emperador de eterna memoria, nuestro padre, decidió prohibir, por una medida especial, la percepción de intereses”). Por tanto, antes de la Novela 83 ya debía de haber una norma prohibitiva en ese sentido. Esa norma prohibitiva se ha identificado tradicionalmente con Proch. 16.14, considerando que el *Prochiron* sería anterior a la *Eisagoge* y además que esta última no necesariamente habría tenido verdadera fuerza legal; sin embargo, Andreas Schminck, en coherencia con su teoría de la anterioridad tanto de la *Eisagoge* como de la colección de Novelas de León respecto al *Prochiron*, identificó la referencia de Nov. Leon. 83 con el pasaje de Eis. 28.2, que sí habría correspondido efectivamente a Basilio I. Por lo tanto, según este punto de vista, la indicación de Harmenópulo es perfectamente correcta y respalda su teoría. Pero el problema que presenta esta tesis es que debe afirmarse sin asomo de duda la vigencia efectiva de la *Eisagoge* en algún momento, aunque fuera brevemente, lo que se encuentra muy lejos de ser algo indiscutido¹⁹. Por otra parte, esta tesis no tiene en cuenta que León dice que su padre introdujo la prohibición a través de una “medida especial” (οἰκείῳ διέγνω κωλύειν θεσπίσματος): esto se compagina mal con un texto como el *Prochiron* o la *Eisagoge*, que, en general (y sobre todo el *Prochiron*) eran compendios de normas ya vigentes, y no propiamente disposiciones particulares. Es cierto que, forzando un poco la interpretación podrían verse estas compilaciones también como normas singulares, puesto que la constitución imperial que las aprueba aparenta ser una ley única; sin embargo, la expresión de León parece más apropiada para hacer referencia a una ley suelta, y no a una parte de un compendio, lo que abona la tesis de que el texto de Eis. 28.4 (= Proch. 16.14) podría estar extractado de una constitución imperial de Basilio I e incorporado después al *Prochiron* (o a la *Eisagoge* directamente). En todo caso, lo que se desprende de aquí es que no necesariamente hubo de ser la *Eisagoge* la obra a la que apuntaba León en su Novela, sino que también pudo ser el *Prochiron*, o más aún una ley concreta que después sería incluida en alguna compilación.

Por otra parte, también resulta significativo que el texto de Proch. 16.14, siendo presuntamente un texto reformador de la legislación contenida en la Nov. Leon. 83, haya sido incorporado como una interpolación en el texto de la *Eisagoge* y, en cambio, no lo fuera en los *Basílicos* y lo encontremos allí tan solo mencionado en un esolio, teniendo en cuenta que la *Eisagoge*, según esta teoría, habría dejado de estar en vigor a partir del 907 y, en cambio, los *Basílicos* sí serían un texto legal desde inicios del reinado de León. Si Proch. 16.14 hubiera sido realmente una reforma del Derecho contenido en la Nov. Leon. 83, la propensión a incluirlo –interpolado– en los *Basílicos* hubiera debido ser mayor que en un texto carente de validez legal. También es cierto, no obstante, que aunque tal reforma hubiera tenido lugar, estaba destinada a durar poco, porque ya en 928 la novela de Romano I Lecapeno la habría dejado prácticamente sin efecto.

¹⁹ Cfr. argumentos en contra en SIGNES CODOÑER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción cit.*, p. 165 ss.

En consecuencia con todo esto, parece más lógico y verosímil pensar que Harmenópulo cometió un error al imputar a León VI la autoría del texto de Proch. 16.14 y que, probablemente, esta norma ya existía antes de la promulgación de la Novela 83, que habría venido a reformar la regulación allí recogida.

3) Frente a estas dos teorías que suponen que el cap. 4 nunca formó parte del texto original de la *Eisagoge*, se alza una tercera que, en cambio, sostiene que tanto el cap. 2 como el cap. 4 habrían formado parte de la obra desde el inicio. Esta interpretación ha sido defendida en tiempos recientes por T. van Bochove y por J. Signes Codoñer, aunque con diversos matices cada uno de ellos. Así, ambos entienden que el *Prochiron* es obra de Basilio I y que antecedió a la *Eisagoge*. En consecuencia, el texto de Eis. 28.4 habría sido incorporado como tal a la *Eisagoge* por los autores de compendio a partir del *Prochiron*, y, por consiguiente, la referencia de Nov. Leon. 83 a una norma de Basilio I prohibitiva del préstamo con interés podría corresponder, en principio, tanto a Proch. 16.14 como a Eis. 28.4, puesto que ambas tienen prácticamente el mismo contenido.

Van Bochove²⁰ basa su interpretación en tres argumentos: a) la mención de Harmenópulo a una novela de León VI con relación a Proch. 16.14 se explica porque fue León quien dio realmente la regulación definitiva a la cuestión de los intereses del préstamo, asumiendo y reformando la legislación anterior, por lo que el autor del s. XIV podría haber querido dar una expresión sintética del proceso completo de adopción de la norma, y además, formalmente, el *Prochiron* fue promulgado en nombre de Basilio I y sus hijos Constantino y León; b) resulta incomprensible que, si León hubiera introducido la norma de Proch. 16.4, no haya hecho mención alguna en el texto a su propia regulación anterior contenida en Nov. Leon. 83, ni tampoco al hecho de que ya su padre había aprobado una prohibición similar; y c) el schol. b a Eis. 28.4 es el único de todo el compendio que no reproduce textualmente el tenor de la norma del emperador reinante que menciona, sino que se remite directamente al texto comentado de la *Eisagoge*, de modo que este debía de existir ya antes de que el escoliasta escribiera sus comentarios. Como consecuencia de esta argumentación, el autor concluye que Proch. 16.14 es la base de Eis. 28.4, que es, por tanto, parte integrante de la obra desde el primer momento; la referencia de Nov. Leon. 83 a la norma de su padre ha de ser, por tanto, Eis. 28.4, en la medida en que es idéntico a Proch. 16.14, pero al que habría sustituido una vez promulgada la *Eisagoge* como texto sustitutivo del *Prochiron*. Con todo, para él constituye una incógnita la razón por la que Proch. 16.14 es la única de las innovaciones legales de Basilio I que fue incorporada al texto mismo de la *Eisagoge*.

Por su parte, Signes Codoñer²¹ coincide sustancialmente los argumentos de Van Bochove, si bien para él el texto de referencia de Nov. Leon. 83 ha de ser necesariamente Proch. 16.14, y no Eis. 28.4, puesto que, desde su punto de vista, la *Eisagoge* nunca fue objeto de promulgación y nunca tuvo, por tanto, valor de ley, de modo que la norma derogatoria de la Novela habría de referirse forzosamente al único texto legal vigente en ese momento, es decir, Proch. 16.14.

²⁰ *To Date* cit., p. 159 ss.

²¹ SIGNES CODOÑER, J. y ANDRÉS SANTOS, F. J. *La Introducción* cit., p.

En cualquier caso, tanto uno como otro parten de la idea de que los dos textos que aquí comentamos (Eis. 28.2 y 4) resultan tan reiterativos como contradictorios. Van Bochove se instala en la duda (“it is also obscure why the latter law book includes a double ban on interest”) y no da una solución al respecto. Signes Codoñer, en cambio, aun considerando igualmente la existencia de una reiteración y una contradicción entre ambos textos, lo explica por la vía de la falta de promulgación de la *Eisagoge* y su permanencia en el estadio de simple proyecto o borrador legislativo: la presencia de esos textos contradictorios evidenciaría, a su juicio, el hecho de que la *Eisagoge* no fue debidamente revisada antes de su rechazo definitivo por la autoridad imperial. Esta explicación, si bien parece bastante lógica, tropieza con dos dificultades: en primer lugar, exige que se admita la falta de promulgación de la *Eisagoge* y su consideración, pues, de mero proyecto privado o semioficial, lo cual dista de ser del todo claro; y, por otro, no explica muy bien por qué, si realmente el *Prochiron* tuvo una “repetita praelectio” a la muerte de León VI, como el autor sostiene, el texto de Proch. 16.14 se mantuvo vigente y no fue eliminado, aun siendo contrario a la normativa contenida en la Nov. Leon. 83 y a los *Basílicos*, y, en tal caso, por qué no podría pensarse que hubiera sido incorporado a la *Eisagoge* con posterioridad a esa “segunda edición” del *Prochiron*.

5. A fin de disipar todas estas dudas tal vez pudiera recurrirse a una solución más simple –y quizá, por eso mismo, aplicando la doctrina de la *Occam’s razor*, más certera–, a saber: la ausencia de una verdadera contradicción entre la norma de Eis. 28.2 y la de 28.4. Signes Codoñer apunta correctamente que entre los dos pasajes puede verse una distinta autoría: el texto del cap. 2 se encuentra situado casi al inicio del título y presenta tanto un estilo literario depurado como una fuerte influencia canónica (véterotestamentaria) y moralista en su contenido; ambas son características de los capítulos de la obra redactados por Focio o por alguien de su círculo patriarcal; por el contrario, el cap. 4, aunque también exhibe cierta coloración religiosa, se muestra ostensiblemente como una pieza de legislación imperial, tal vez un extracto de una constitución más amplia perdida, lo cual viene además confirmado por el escolio que lo atribuye a “nuestro piadoso emperador”. Por tanto, podría pensarse que el autor de la *Eisagoge*, como es su costumbre, ha colocado al inicio sus propias aportaciones al compendio (como también lo es claramente el cap. 1), y a continuación, ha comenzado a disponer los pasajes de la legislación anterior (del *Prochiron* o, directamente, de la Compilación justiniana en su versión griega) a partir del cap. 3 (que está incuestionablemente tomado de Alex. C. 4.24.3 = Proch. 16.3, y es sin duda complementario de lo establecido en la segunda parte de Eis. 28.2). El cap. 4 se encontraría, pues, en esa serie. La norma del cap. 4 sería, por tanto, más antigua, y también más general, mientras que la del cap. 2 sería más moderna y más específica, porque introduce una excepción al principio general de la prohibición categórica del cap. 4. Aplicando las reglas básicas de interpretación, ‘*lex posterior derogat legi priori*’ y ‘*lex specialis derogat legi generali*’, el cap. 2 tendría que aplicarse con prioridad frente al cap. 4, pero eso no quiere decir que lo deje sin efecto: la prohibición general de percibir intereses del préstamo sigue estando vigente, tal como establece el cap. 4 y como también repite, forzosamente, el cap. 2. Lo único que sucede es que el cap. 2 introduce una excepción, también en nombre de la justicia y la caridad, que es el que se pueda pagar intereses a los huérfanos y menos por su dinero dado

en préstamo: el propio texto de Eis. 28.2 dice explícitamente que “al suprimir, tal como se ha dicho antes, los intereses, solo permitimos que se paguen en favor de los huérfanos y menores de edad”; es decir, que el autor es perfectamente consciente de la existencia previa de una disposición general prohibitoria. Esa disposición prohibitoria era ya la contenida en Proch. 16.14 y, si bien la *Eisagoge* se supone que estaba destinada a sustituir y dejar sin efecto el *Prochiron* una vez que fuera aprobada, sin embargo, dado que el texto de Proch. 16.14 probablemente provenía de una novela del emperador Basilio, podrían quedar dudas sobre su vigencia una vez promulgada la *Eisagoge* con el nuevo texto del cap. 2. Para disipar toda duda a ese respecto, la solución del autor de la *Eisagoge* hubo de ser reproducir en la nueva compilación el texto de Proch. 16.14, aunque en parte su contenido ya había sido recogido escuetamente en el cap. 2, pero envuelto entre la nueva norma permisiva de la percepción por el acreedor de los frutos de la cosa pignorada hasta la tercera parte de la deuda y la norma que excepcionaba a pupilos y menores de la prohibición de los intereses. Tal vez desde nuestro punto de vista moderno, dominado por las categorías codificadoras y racionalistas-iusnaturalistas, pueda parecer una deficiente técnica legislativa, pero no debemos imputar a los bizantinos necesariamente los mismos modos de escribir y organizar los conocimientos que tenemos nosotros.

Además de este motivo de una mayor claridad normativa hay otras razones que podrían explicar que el autor de la *Eisagoge* mantuviera el texto de Proch. 16.14 (con la oportuna rectificación que hemos señalado más arriba) en la nueva compilación.

Por un lado, ya fuera un texto tomado de Proch. 16.14, ya hubiera sido incorporado directamente a la *Eisagoge*, lo cierto es que lo más probable es que el texto del cap. 4 constituya un extracto de una constitución imperial de Basilio I, es decir, una norma del emperador reinante. Una norma, además, muy significativa, de alto valor simbólico y económico, en la cual, según se desprende del tenor de Nov. Leon. 83 (“nuestro padre... decidió prohibir, por una medida especial...”), Basilio I tenía un particular interés, ya fuera por motivos religiosos –como se asevera explícitamente en el texto de la norma– ya fuera por otros no explícitos, como los económicos. Una exclusión de esta norma en concreto del texto de la *Eisagoge* se habría considerado, seguramente, como una forma de contestación a la legalidad imperial y habría incrementado, por tanto, las probabilidades de rechazo del texto por parte del emperador reinante. Que fuera esta la única novela de Basilio I que fue incorporada directamente al texto de la *Eisagoge*, como bien indica van Bochove, es precisamente un sólido indicio de la significación especial que esa norma debía de tener en el contexto jurídico del momento. El autor de la *Eisagoge* debió de pensar que la única posibilidad de que la regla innovadora contenida en el cap. 2 fuera aceptada era justamente la de reproducir a continuación de modo literal el texto de la prohibición general de los intereses dictada con anterioridad por el emperador.

Por otro lado, no debe olvidarse que el texto del cap. 4 responde precisamente a la doctrina cristiana más ortodoxa en relación con los intereses de los préstamos. La interdicción general de esa práctica se introduce en nombre del respeto a la ley de Dios y a la prioridad de la ley divina sobre las leyes humanas. Hubiera resultado, por tanto, muy sorprendente que un texto normativo auspiciado justamente por el círculo patriarcal hubiera adoptado la medida de excluir dicha norma del ordenamiento jurídico, una vez que la autoridad secular

la había aceptado y reforzado. Esa norma de Basilio I reproducida en Proch. 16.14 hubo de haber estado fuertemente influida por elementos de índole religiosa, de modo que seguramente debía de estar muy bien vista en ámbitos de la esfera eclesiástica. No es extraño, por tanto, que un texto como la *Eisagoge* haya recogido esta norma por encima de muchas otras más técnicas y menos ideológicas procedentes de la legislación de Basilio I. Sin embargo, a pesar del hecho de que viera con simpatía esta tendencia a la supresión de los intereses, el autor de la *Eisagoge* también debía de ser realista y ver que una norma de estas características resultaba muy lesiva para el tráfico económico y además podía dar lugar a situaciones injustas y graves abusos de posición dominante, como nos dice explícitamente el texto de Nov. Leon. 83. De ahí, por tanto, la búsqueda de una vía intermedia a través del texto de Eis. 28.2: por un lado, se dejaba vigente la regla general de prohibición del pago de intereses (tal como ya se había establecido en Proch. 16.14 y se reiteraba aquí) y, al mismo tiempo, se le introducían algunas dosis de flexibilidad, a fin de que el respeto a la ley divina no trajera consigo malas consecuencias en el mundo terrenal y no resultara a la postre (como terminará por concluir León en su Novela 83) más negativa y contraproducente que positiva para la vida de los cristianos.

A través de estos textos y en esta compleja construcción podemos ver, en fin, la sutilidad y extraordinario sentido jurídico del autor de la *Eisagoge*, lo que explica que, a pesar de la falta de vigencia efectiva de este compendio como norma legal, su poderosa influencia se dejara notar de muchos y diversos modos en períodos ulteriores de la historia jurídica bizantina.

FIGULUS ET FIGLINA: REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN *HISPANIA (ISTURGI)* BAJO EL DOMINIO ROMANO

FIGULUS ET FIGLINA: REFLECTIONS ON COMMERCIAL ACTIVITY IN *HISPANIA (ISTURGI)* UNDER ROMAN RULE

MARÍA-EVA FERNÁNDEZ BAQUERO

Universidad de Granada

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. I. ESTADO DE LA CUESTIÓN: *ISTURGI* BAJO LA DOMINACIÓN ROMANA. II. SITUACIÓN JURÍDICA DEL *FIGULUS* Y LA FUNCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL *FIGLINA*. III. REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS INSTALACIONES ALFARERAS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CAPITULO 76 DE LA *LEX URSONENSIS*.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro de un ambicioso Proyecto de Investigación dirigido por la profesora M^a Isabel Fernández García, Catedrática de Arqueología de la Universidad de Granada, titulado: “*Ex Baetica Sigillatae: Transferencias tecnológicas, producción y circulación de vajillas cerámicas en el Sur de la Península Ibérica (s. I-II d.C.)*” y del que formo parte. Mi aportación al mismo ha sido requerida para el análisis e interpretación histórico-jurídica de la actividad comercial en torno a los restos romanos de cerámica (*terra sigillata*) encontrados en *Isturgi* (Los Villares de Andújar), donde se concentra uno de los centros alfareros más importantes de la Península. Ello supone el intento de reconstruir la situación jurídica del alfarero (*figulus*), la actividad artesanal de la alfarería (*figlina*) y, en concreto, sus estructuras socio-económicas de producción y comercialización en coherencia con la legislación romana, tanto central como municipal.

Así las cosas, este trabajo se estructuraría en tres partes: En la primera, realizaríamos una breve exposición del estado de la cuestión sobre el interés que ha despertado los yacimientos de *Isturgi* en la comunidad científica, especialmente entre los arqueólogos, y la

ausencia casi absoluta de una investigación histórico-jurídica en torno al papel que protagonizó este centro alfarero en el mundo romano. En la segunda, al ser Hispania territorio provincial, habría que analizar la situación jurídica del alfarero, tanto desde el punto de vista de su *status* personal y como profesional, interpretando la evolución jurídica sucedida en las distintas generaciones de alfareros que las fuentes arqueológicas nos muestran de la localidad de *Isturgi*, analizando la función económica y social que el trabajo de la alfarería tenían en el comercio y en la sociedad del momento. Y finalmente, en la tercera, nos detendremos en las condiciones de implantación de estos complejos artesanales, interpretando el tipo de goce y disfrute que los alfareros tenían sobre el suelo y construcciones arquitectónicas –como son los hornos de alfarería– en donde se desarrollaba este tipo de actividad económica; intentando conciliar la práctica desarrollada –según los datos arqueológicos– con la normativa establecida en la legislación municipal, con especial referencia al capítulo 76 de la *lex Ursonensis*.

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN: *ISTURGI* BAJO LA DOMINACIÓN ROMANA

Desde el punto de vista de la investigación arqueológica, los estudios sobre *terra sigillata* en Hispania son relativamente recientes. En los años sesenta del siglo XX, Mezquiriz, en su obra *Terra sigillata hispánica* (Valencia, 1961) recopiló todo el material conocido hasta ese momento sobre esta clase de cerámica, apreciándose una abundancia de talleres productores de *sigillata* en la zona norte de la Península Ibérica mientras que se daba un gran vacío en el sur¹. Los descubrimientos en esa misma década y en la siguiente de nuevos centros productores en el sur peninsular, como el alfar romano de Cartuja (Granada) y un poco después el complejo alfarero de Los Villares de Andújar (Jaén), dio la posibilidad a Sotomayor Muro para poder llenar el mencionado vacío del sur peninsular². Aunque en los años ochenta y noventa se han encontrado y documentado talleres de menor entidad, podemos decir que actualmente existen dos grandes focos alfareros productores de *terra sigillata* hispánica: Uno sería Tricio (*Tritium Magallum*) en la zona norte peninsular en la antigua provincia de la *Tarraconense* y, el otro, Los Villares de Andújar (*Isturgi*) en la zona

1 Vid., MEZQUIRIZ, M^a A., “Hallazgo de un taller de Sigillata Hispánica en Bezares (Logroño)”, *Príncipe de Viana*, 144-145, 1976, p. 299 ss.; ID., “Un taller de terra sigillata hispánica en Bezares”, *Rei Cretarie Romanae Favtorumvm*, XXI/XXII, 1982, p. 25 ss.; ID., “Alfar romano de Bezares”, *Cuadernos de Investigación Histórica*, IX, 1, Logroño, 1983, p. 167 ss.

2 Vid., SOTOMAYOR MURO, M., PEREZ CASAS, E., ROCA ROUMENS, M., “Los alfares romanos de Andújar (Jaén). Dos nuevas campañas”, *Noticiario Arqueológico Hispánico*, IV, 1976, p. 113 ss.; SOTOMAYOR MURO, M. *Marcas y estilos en la sigillata decorada de Andújar*, Jaén, 1977; SOTOMAYOR MURO, ROCA ROUMENS, M., SOTOMAYOR, N., “Los alfares romanos de Andújar. Campañas de 1974, 1975 y 1977”, *Noticiario Arqueológico Hispánico*, VI, 1979, p. 443 ss.; SOTOMAYOR MURO, ROCA ROUMENS, M., ATENCIA PAEZ, R., Los alfares romanos de Los Villares de Andújar (Jaén). Campaña de 1978-79”, *Noticiario Arqueológico Hispánico*, XI, 1981, p. 309 ss.; SOTOMAYOR MURO, M., “Fondos de sigillata de Andalucía con marcas interiores de entalles”, *Gerion* I, 1988, p. 253 ss.; ID (1998): “Los Villares de Andújar. Historia de la investigación”, en Fernández García, M^a I (Ed.), *Terra Sigillata Hispánica: estado actual de la investigación*, Univ. Jaén, 1988, p. 31 ss.; SOTOMAYOR, M., ROCA, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA, M^a I., “Centro de producción de Los Villares de Andújar (Jaén)” en Roca Roumens, M. y Fernández García, M^a (Coords.) *Terra Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales*, Univ.de Jaén/ Univ. de Málaga, 1999, p.19 ss.

sur en la provincia de la *Baetica*. Siendo, éste último, el único que ha conseguido mantener una investigación continuada desde los años setenta, convirtiéndose en un claro referente en las investigaciones sobre la *terra sigillata* hispánica. Por ello, el ámbito territorial de esta investigación se sitúa en la localidad actualmente conocida como Los Villares de Andújar que se correspondería con la antigua ciudad iberorromana de *Isturgi*.

Aunque algunos confundieron esta ciudad con la también romana *Iliturgi*, hoy está ampliamente aceptado que ésta última se corresponde con Maquiz (Mengíbar) e *Isturgi* con la ciudad de Los Villares de Andújar³. Ambas ciudades junto con otros asentamientos, como Porcuna (*Obulco*), Jaén (*Aurgi*), Arjona (*Urgavo*) y Martos (*Tucci*), constituyeron el primer nivel de la jerarquía de asentamientos en esta parte de *Hispania* conformando una red viaria que posibilitó el intercambio de bienes primarios y servicios, en definitiva, el desarrollo de una gran actividad comercial y mercantil.

Las fuentes literarias, en concreto, Plinio El Viejo, *Nat. Hist.*, III, 10 nos sitúa *Isturgi* en el *Conventus Cordubensis* y conocida como *Isturgi Triumphalis*:

conventus vero Cordubensis circa flumen ipsum Ossigi quod cognominatur Latonium, Iliturgi quod Forum Iulium, Ipra, Isturgi quod Triumphales, Ucia et XIII p. remotum in mediterraneo Obulco quod Pontificense appellatur, mox Ripa, Epura foederatorum, Sacili Martialium, Onuba et destra Corduba colonia Patricia cognomine, inde primum navigabili Baete oppida Carbula, Detumo, fluvius Singilis, eodem Baetis latere incidens.

La expresión *conventus*, *conventus iuridicus* significó un tipo de reunión o agrupación voluntaria convocada por el gobernador provincial o sus delegados y que servía para impartir la jurisdicción civil y penal en las cabeceras de los distritos que tenían bajo su mando⁴. Si bien los *conventus* en Roma empezaron a ser frecuentes desde el s. II a.C., también es verdad que pronto se trasladaron a las provincias constituyendo un instrumento de organización y administración esencial para el rápido proceso de romanización de la Bética. Así, el *conventus Cordubensis* estaba integrado por dos zonas separadas: La septentrional que abarcaría la mitad norte de la provincia con una parte de Badajoz y Ciudad Real junto con las zonas ribereñas del Guadalquivir y con cierta penetración hacia Jaén. La zona meridional de la provincia coincidiría con la parte sur del convento, introduciéndose en Málaga y Granada⁵. Entre las funciones principales que se le han atribuido a este *conventus* es la de realzar el culto imperial, considerando al emperador como héroe y divinidad, reforzándose en época de Vespasiano con la única finalidad de consolidar la romanización de estos territorios.

3 Vid., entre otros, JIMENEZ COBO, M., "Inscripciones romanas de *Isturgi* (Andújar), *Cautigi* (Espeluy), *Vcia* (Marmolejo) y *Urgao* (Arjona)", *Boletín Instituto de Estudios Giennenses*, nº 201, Enero-Junio 2010, p. 27 ss.; FERNÁNDEZ GARCÍA, M^a I., RUIZ MONTES, P., PEINADO ESPINOSA, M^a V., "De *Isturgi* et *Iliturgi* confusión", *Anales de Arqueología Cordobesa*, nº 20, 2009, p. 125 ss.

4 TORRENT, A., v. *conventus iuridicus*, *Diccionario de Derecho Romano*, Madrid, 2005, p. 219.

5 Vid., entre otros, RODRIGUEZ NEILA, J.F., *Historia de Córdoba*, vol. I, Córdoba, 1988, p. 294 ss.; ALBURQUERQUE, J.M. y JIMÉNEZ SALCEDO, C., "La administración provincial, colonial, municipal y la justicia en la Hispania romana (1): Especial referencia a la Bética romana, su capital *Corduba* y los magistrados municipales y órganos con *iurisdicatio* según la *lex Imitana*", *RGDR, Iustel*, nº 7, 2006, p. 23 ss.; TORRENT, A., "Ius Latii y Lex Imitana. Bases jurídico-administrativas de la romanización de España", *AHDE*, LXXVIII-LXXIX, 2008-2009, p. 51 ss.

En consecuencia, *Isturgi* formaba parte de este *conventus*, su grado de romanización era importante y de ahí que adquiriese el nombre de *Municipium Triumphale*. Ello lo confirman dos inscripciones halladas en Los Villares de Andújar. En una de ellas, aparece el nombre de *Municipium Triumphale*, con motivo de una estatua dedicada al dios Marte por Aulo Terencio Rústico:

C.I.L. II⁶. 7, 56. SIGNVM MART. AVg.
A. TERENTIVS A. F. GAL. RVSTICVS
AED. IIVIR PONT. M. M. TRIVMPH.
LVDIS SCAENICIS FACTIS
D. S. P. d.⁷

En otra inscripción, aparece la denominación de la *res publica* de los *Isturgitanos*:

C.I.L. II. 7, 60 IMP. CAES. L. SEPTI MIO SEVERO PIO
PERTINACI AVG.
ARABICO ADIABENICO PONTIF.
MAXIMO IMP. X TRIB. POTEST.
VI COS. II PACATORI ORBIS
RES PVBLICA ISTVRGITANORVM
D. D. D.⁸

Estas inscripciones demuestran la preocupación de las élites locales para proporcionar a su comunidad un complejo monumental en coherencia con las nuevas realidades sociales y económicas constituyendo una prolongación de las propias ciudades romanas⁹, de ahí la expresión *res publica Isturgitanorum*, así como la concesión del *ius latii*. El motivo primordial de las élites locales para colaborar con Roma en este proceso de romanización se debía al interés de alcanzar la ciudadanía romana mediante la adquisición y el desempeño de una

6 C.I.L. II, 2121, GARCÍA SERRANO, R., *Mapa arqueológico de la provincia de Jaén*, Granada, 1968. Corpus de Inscripciones latinas de Andalucía, III (CILAJA, III), 265.

7 AULO TERENCIO RÚSTICO HIJO DE AULO
DE LA TRIBU GALERIA
EDIL DUUNVIR PONTÍFICE DE LOS CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO TRIUNFAL
CELEBRADOS JUEGOS ESCÉNICOS

LA DONÓ CON SU DINERO
8 AL EMPERADOR CÉSAR
L. SEPTIMIO SEVERO
PIO PERTINAZ AUGUSTO
ARÁBICO ADIABÉNICO
PONTÍFICE MÁXIMO IMPERATOR X
CON POTESTAD TRIBUNICIA VI
CÓNSUL II PACIFICADOR DEL ORBE
LA REPÚBLICA DE LOS ISTURGITANOS
DADO POR DECRETO DE LOS DECURIONES

9 TORRENT, A., "Ius Latii y Lex Irnitana.", *op. cit.*, p. 73..

magistratura municipal, ciudadanía romana que además era extensible a sus hijos, otorgada a algunas ciudades extranjeras por el pueblo romano o por el Senado o por el Cesar, tal y como nos indica Gayo, *Inst.*, 1,95:

Alia causa est eorum, qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt; nam horum in potestate fiunt liberi. Quod ius quibusdam peregrinis vivitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatus vel a Caesare.

El resto de la población de este territorio provincial o tenía la condición de *peregrini* o de *latini*, esta última como resultado de la concesión del *ius latii*, consistente en un tipo de ciudadanía de segundo orden, es decir, ciudadanía intermedia entre la *civitas romana* y el estatuto del peregrino¹⁰, otorgada no de forma generalizada sino de manera individual dependiendo de cargo público desempeñado. De ahí que Gayo, *Inst.*, 1,96, nos diga que hay dos clases de *ius latii* pues la latinidad puede ser mayor o menor; es mayor la de aquellos que consiguieron la ciudadanía romana por haber sido elegidos decuriones o por haber tenido algún cargo público o alguna magistratura; y es latinidad menor la de aquellos que llegaron a la ciudadanía romana solamente por desempeñar sólo alguna magistratura o algún cargo público:

<Huius autem iuris duae species sunt; nam> aut maius est Latium aut minus; maius est Latium, cum et hi, qui decuriones leguntur, et ei, qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consequuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt

Este texto encuentra su correspondencia en las Rúbricas 21, 22 y 23 de la *lex Irnitana*¹¹, regulando la manera de poder conseguir la ciudadanía romana en este municipio, a la vez que posibilitaba mantener los derechos civiles que hasta el momento habían disfrutado, como la *patria potestas*, *manus*, *mancipio* y los *iura libertorum*. Por consiguiente, a *Isturgi* por su alto grado de romanización sería también objeto de los beneficios aportados por la legislación municipal romana.

Por otro lado, también disfrutó de la posibilidad de entrar dentro de las reformas que Augusto aplicó en la *Baetica* referentes al desarrollo de la red de comunicaciones, así como mejorar la producción y comercialización de materias primas, facilitando su distribución tanto a corta como a larga distancia¹²:

A corta distancia, las redes de comunicación se centraron por vía terrestre en los núcleos urbanos más próximos, interconectados por la *vía Augusta*, en el caso de las capitales provinciales, o por otras arterias no de menor importancia que discurrían por las campiñas del medio y bajo valle del Guadalquivir. En estas vías se establecían ferias y mercados locales donde poder distribuir, entre otros bienes, la cerámica fina generada en su propio territorio,

10 TORRENT, A., "Ius Latii y Lex Irnitana.", *op. cit.*, p. 76.

11 Vid., Vid., D'ORS, A. y J., *Lex Irnitana*, Santiago de Compostela, 1988, p. 16 y 17.

12 RUIZ MONTES, P., Nuevas lecturas en torno a procesos de producción y sustratos productivos en el complejo alfarero romano de Los Villares de Andújar (Andújar, Jaén), Granada, 2012, p.140; FERNÁNDEZ GARCÍA, M.I., "Estructuras de comercialización", Una aproximación a Isturgi romana. El complejo alfarero de Los Villares de Andújar, Jaén, España., Fernández García, M^a I., (Coord.), Roma, 2013, p.129 ss.

ya que el desplazamiento hacia tierras de larga distancia disminuiría mucho los márgenes de cualquier lucro ante el riesgo de destrucción del producto por su propia fragilidad.

Para distancias más largas, como señala Ruiz Montes, la distribución de los productos hasta los grandes centros de redistribución provinciales como *Corduba* o *Hispalis* se realizaría por las vías fluviales, esto es, a lo largo del tramo comprendido entre el Alto Guadalquivir y las campiñas cordobesa y jiennense al sur del río. Dicho río permitía una navegación mediante barcas desde *Isturgi* hasta *Corduba* donde las cerámicas serían embarcadas en naves de mayor importancia y, a partir de ahí, llegarían los productos a los distintos mercados. En este sentido, Fernández García nos informa de una prospección arqueológica superficial realizada en torno al yacimiento del Los Villares de Andújar (*Isturgi*) en 1996, se documentaron unas estructuras que posiblemente se correspondiesen con restos de un embarcadero romano sobre el que no se pudo actuar ya que la zona donde se ubicaba se valló siendo dificultoso su acceso¹³.

Otra gran parte de la producción de cerámicas acabaría directamente en los puertos marítimos-fluviales de los que partían rutas extraprovinciales¹⁴. En este sentido, hay que recordar que Augusto otorgó especial importancia a la política de aprovisionamiento a Roma, a otras partes del Imperio y a su ejército de las materias para el consumo, por lo que creó la *praefectura annonae*. Estas transacciones de gran volumen, como señala la mayor parte de la doctrina, se desarrollaron en el periodo de mayor esplendor de la expansión del Imperio, esto es, el periodo clásico que abarca desde Augusto hasta el final de la dinastía de los Severos, hacia el final del primer tercio del siglo III d.C.¹⁵. Las mercancías que abastecieron a Roma y a cualquier parte del Imperio fueron bienes considerados de consumo alimenticio: vino, cereales, aceite que, mediante ánforas, pudieron conseguir su traslado sin mayores problemas. Prueba de ello, es el gran número de ellas encontradas en el Monte Testaccio, considerado como un gran depósito de ánforas que, sirviendo de embase para trasladar dichos bienes de primera necesidad, no requerían su devolución al lugar de origen, de ahí el gran número de ellas encontradas y en las que se aprecian inscripciones o sellos que delatan su origen de la *Baetica*¹⁶.

13 FERNÁNDEZ GARCÍA, M.I., “Estructuras de comercialización”, *op. cit.*, p.130. Vid., además FORNELL MUÑOZ, A., “La navegabilidad del curso alto del Guadalquivir en época romana”, *Florentia Iliberritana*, 8, 1997, p. 195 ss.

14 RUIZ MONTES, P., *op. cit.* p.142 ss.

15 Sobre esta materia la bibliografía es muy abundante. Cfr., por todos, GARCÍA, GARRIDO, M.J., *El Comercio, los Negocios y las Finanzas en el Mundo Romano*, Madrid, 2001, p. 133 ss.; GÓMEZ-IGLESIAS CASAL, A., “Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los “Tituli picti””, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Derecho Romano]*, XXXII, Valparaíso, Chile, 2010, p. 59 ss.

16 El Monte Testaccio es una colina artificial de una altura de 50 m. y una circunferencia de 1500 m. que ocupa una superficie de 22000 metros cuadrados. Se encuentra situado entre el Aventino y el antiguo puerto fluvial del río Tíber, muy cerca de la Pirámide Cestia y de la Porta de San Paolo. Vid., IGLESIAS CASAL, A., *op.cit.*, p. 63, nt. 12, donde nos informa de que todos estos datos sobre el Monte Testaccio, sus excavaciones y estudios pueden verse esencialmente en las obras de los responsables de las diferentes campañas arqueológicas modernas, RODRIGUEZ ALMEIDA, *Il monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali*, Roma, 1984; BLAZQUEZ – REMESAL (Editores), *Estudios sobre el monte Testaccio*. Colección *Instrumenta*, 6, Barcelona, 1999, y 10, Barcelona, 2001.

En cuanto a la cerámica producida en *Isturgi*, probablemente, se transportó en cantidades inferiores (en comparación con otros bienes prioritarios mencionados) en las mismas embarcaciones pero su destino no quedó en el Monte Testaccio, sino en las casas de las familias ilustres y adineradas de la sociedad romana de cualquier parte del Imperio que pudieron permitirse la adquisiciones de bienes, como las vajillas de *terra sigillata*. En este sentido, Fernández García nos dice que este periodo histórico “es una etapa de apertura a los mercados mauritanos como parece desprenderse de los ejemplares isturgitanos recuperados en determinados puntos del Norte de África en la que posiblemente el río Guadalquivir desempeñaría un papel fundamental no sólo como portador de estas cerámicas sino también de otros productos básicos que eran objeto de un comercio más o menos establecido”¹⁷. En consecuencia, fue un producto de fácil acceso para las élites locales de *Hispania* y de alguna otra provincia más cercana, como podía ser África, siendo de mayor dificultad su adquisición en la propia capital del Imperio, por el coste que supondría el transporte más lejano y la fragilidad del producto.

Por otro lado, la política limitadora sobre el lujo de las leyes sumptuarias junto con la regulación del *crimen de ambitus*, esto es, represión en contra de aquellos candidatos a magistraturas que estuviesen tentados de atraer votos ofreciendo lujosas cenas a numerosos invitados¹⁸, influyó a que este producto de cerámica fina tuviera una demanda localizada principalmente entre aquellas familias que la desearan para su uso privado pero no para una excesiva proyección pública ante el control de banquetes y comensales que se desarrolló en *Hispania*. Así, en el capítulo 132 de la *lex Ursonensis* que regula los banquetes electorales, prohibiendo su celebración durante los dos años en que pendía la candidatura, es decir, en el año anterior y en el mismo año en que se celebraba la elección y solamente se admitía una comida ordinaria en el año de candidatura, siempre y cuando no excediera de nueve el número de comensales, estableciendo la sanción de cinco mil sestercios para el infractor¹⁹. De igual manera, también se refleja esta regulación en la *lex Irnitana*, estableciéndose en la

17 FERNÁNDEZ GARCÍA, M.I., “Estructuras de comercialización”, *op. cit.*, p.136.

18 Así entre la legislación que expresamente limita el número de invitados como resultado de la política de austeridad y contra el lujo podemos mencionar, entre otras: La *lex Orchia de coevis*, del año 181 a.C., la *lex Fannia cibaris*, del 161 a.C., la *lex Didia sumptuaria*, del 143 a.C., la *lex Aemilia sumptuaria*, del 115 a.C., la *lex Licinia sumptuaria*, del 103 a.C.; la *lex Cornelia sumptuaria*, del 81 a.C., la *lex Antia sumptuaria*, del 71 a.C., la *rogatio Pompeia sumptuaria*, del 55 a.C., la *lex Iulia sumptuaria*, del 46 y otra probablemente del 18 a.C. Vid., por todos, BOTTIGLIERI, A., *La legislazione sul lusso nella Roma Repubblicana*, Roma, 2002.

19 Ne quis in colonia Genetiva post hanc legem datam petitor candidatus*, quicumque in colonia Genetiva Iulia magistratum petet, magistratusve petendi causa in eo anno, quo quisque anno petitor candidatus* magistratum petet petiturusve erit, magistratus petendi convivium facito neve at cenam quem vocato neve convivium habeto neve facito sciens dolo malo, quo quis suae petitionis causa convivium habeat ad cenamve quem vocet, praeter dum quod ipse candidatus* petitor in eo anno, quo magistratum petat, vocarit dum taxat in dies singulos hominum VIII convivium habeto, si voelt, sine dolo malo. Neve quis petitor candidatus* donum munus aliudve quit det largiatur petitionis causa sciens dolo malo. Neve quis alterius petitionis causa convivium facito neve quem ad cenam vocato neve convivium habeto, neve quis alterius petitionis causa cui quit donum munus aliutve quit dato donato largito sciens dolo malo. Si quis adversus* ea fecerit, HS ICC colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae cui eorum volet recuperatorio iudicio apud Ilvirum praefectumve actio petitio persecutioque ex hac lege ius potestasque esto. Vid., D'ORS, A., *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953, p. 276.

Rúbrica 77²⁰ y 79²¹ los límites sobre gastos en ceremonias religiosas, espectáculos y cenas. Esta política restrictiva sobre el lujo para reprimir los excesos de la clase política, afectó de forma directa a la actividad de la alfarería y, en concreto, a la producción de cerámicas y vajillas finas al convertirlas en bienes de consumo más privado y local, frente al incremento de la producción en el ámbito público de otro tipo de pieza de la alfarería más demandadas, como podían ser las ánforas (embases de bienes primarios como cereales, aceite, vino,...para abastecer a todo el Imperio) y materiales de construcción (en orden a las obras públicas).

Así las cosas, el hecho cierto es que *Isturgi* fue un territorio fuertemente romanizado en el que, si bien por su situación estratégica pudo desarrollar una amplia actividad comercial y de producción de *terra sigillata*, como se aprecia en los yacimientos de Los Villares de Andújar; sin embargo, también se vio afectada por la política restrictiva del lujo que desarrollo la administración central y la provincial, tal y como quedó constancia en las leyes municipales mencionadas. En el Bajo Imperio la ciudad de *Isturgi* pierde la importancia y el protagonismo que tuvo con anterioridad ya que sufrirá las consecuencias de la crisis ciudadana y, como resultado, el progresivo deterioro de los espacios públicos y reorganización de los mismos, así como las fluctuaciones demográficas y los nuevos procesos sociales y económicos que se producirán a partir del siglo III d.C.²²

II. SITUACIÓN JURÍDICA DEL *FIGULUS* Y LA FUNCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL *FIGLINA*

Como resultado de lo expuesto, en el ámbito de la actividad alfarera, nos podemos encontrar un amplio abanico de situaciones o *status* jurídico de personas vinculadas –de una forma u otra– a este trabajo artesanal. Es verdad que, frente al trabajo intelectual, el físico o manual fue considerado por el pueblo romano –al igual que entre los pensadores y filósofos

20 R(ubrica). De inpensis in sacra ludos cenasque faciendis/

Duumviri qui in eo municipio iure dicundo praeiungunt / primo quoque tempore ad decuriones conscriptosve / referunt quantum in inpensas sacrorum, et quantum / in cenas quae municipibus aut decurionibus conscriptis/-ve communibus dentur erogetur, quantumque mai-/ior pars eorum censuerit, tantum eroganto uti quod / recte factum esse volent./. Vid., D'ORS, A. y J., *Lex Imitana*, op. cit., p. 58-60.

21 R(ubrica).Ad quem numerum decurionum conscriptorumve refer-/ri oporteat de pecunia communi municipum eroganda.

*Qu[od] mi-/nu[s] quantae pecuniae in sacra ludos cenas quibus decuriones cons[crip]ti municipesve [voca]ntur, aera apparitoria, legationes, opera ei[us] / municipi facienda reficienda, aedium sacrarum monumentorum/-que custodiam publica[m], cibaria vestitum, emptionesque eorum qui / municipibus serviant, item in eas res quae Ilviris aedilibus quaesto-/ribus sacrorum faciendorum municipum nomine, item officioru[m] / quae honoris eius nomine quem quis inierit explicari debebunt, / explicandorum<ve> causa praeberi oportebit, erogari debebunt, de is / ad decuriones conscriptosve referatur, dum ne ad minorem partem / eorum referatur, quantasque pecunias in easdem res decuriones con-/scriptive, post hanc legem datam, erogandas, etiam si neque iurati, / neque per tabellam sententis latis, censueri<n>t, erogentur h(ac) l(e)ge nihi-/lum min[us]./. Vid., D'ORS, A. y J., *Lex Imitana*, op. cit., p. 61-63.*

22 Cfr., entre otros, PEINADO ESPINOSA, M^a v., *Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir. El alfar de Los Villares de Andújar*. Granada, 2010, p. 81 ss.; RUIZ MONTES, P., op. cit. p.144 ss.

griegos- como una actividad de inferior categoría²³, ya que la aspiración mayor de cualquier ciudadano romano es prestar su servicio a la comunidad mediante el ejercicio de los puestos más relevantes en la política y las milicias. Así, el *cursus honorum* que iniciaba cualquier ciudadano romano solo podría culminar con éxito si demostraba en sus distintas actividades *decorum et dignitas*. En este sentido, CICERÓN, en su obra *De Officiis*, nos muestra una exhaustiva relación de trabajos u oficios calificados como decorosos, es decir, convenientes y decentes, frente a los indecorosos o socialmente despreciables, como podían ser los recaudadores de impuestos y los prestamistas de dinero a interés²⁴. Por consiguiente, en el campo de la alfarería podríamos encontrar distintas escalas de personas que ejercerían trabajos de los estimados más o menos dignos y decorosos si aplicamos los criterios ciceronianos.

Así, en el escalafón más humilde dentro del mundo alfarero nos encontraríamos a los propios artesanos libertos e ingenuos (ya que los esclavos al no tener la consideración jurídica de personas quedarían excluidos de esta clasificación) que, hasta la Constitución de Caracalla (año 212 d.C.), en *Isturgi* gozarían de la condición de *latini*, lo que implicaba el ejercicio de los derechos propios de esa ciudad, como podía ser el *ius suffragii*, el *ius commercii* y el *ius connubii* con ciudadanos o ciudadanas romanas siempre y cuando fuera expresamente concedido o autorizado. Entre los derechos mencionados, el *commercium* o *ius commercii* era esencial para poder estar al frente de un negocio como *mercator* (pequeño comerciante) o como *negotiator* (el que ejerce una actividad comercial a gran escala abarcando diversos campos en torno a la actividad de la alfarería: transporte, financiación, etc...)²⁵.

23 Vid., entre otros, CAMACHO EVANGELISTA, F., *Las profesiones liberales en Roma*, Granada, 1964; AAVV., *El hombre romano*, Andrea Giardina (Ed.), Madrid, 1991; RODRIGUEZ MONTERO, R.P., "Notas introductorias en torno a las relaciones laborales en Roma", *Anuario da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña*, nº 8, 2004, p. 727 ss.

24 De Officiis, I, 42, 150: En cuanto a las profesiones y otras fuentes de ganancias, cuáles deban de considerarse como dignas del hombre libre y cuáles propias del hombre innoble, se nos han transmitido las reglas siguientes: en primer lugar, son mal vistas las profesiones y oficios que incurren en el odio de los hombres, como los recaudadores de impuestos y los usureros. Vulgares y sórdidas se consideran las ganancias de todos los mercenarios que venden el trabajo de sus brazos, no su capacidad artística, porque el mismo salario en ellos constituye el precio del contrato de servicio. Bajo es también el oficio de los revendedores, que para ganar algo tienen que inventar mil patrañas. Todos los artesanos realizan también una arte servil, porque un taller no tiene nada digno de un hombre libre. Y no hay que aprobar de ninguna forma los oficios que están al servicio de los placeres: "Vendedores de pescado salado, carniceros, choriceros, pescaderos", como dice Terencio, y a éstos pueden añadirse los perfumistas, los bailarines y toda suerte de representaciones escénicas. I, 42, 151: Las profesiones para las que se requiere un saber mayor y que reportan una ganancia más que mediana, como la medicina, la arquitectura, la enseñanza de las artes literarias, son honestas para aquellos a cuya condición social es concebido practicarlas. El comercio, si es en pequeño, ha de tenerse como vil, si es en gran escala, importando grandes cantidades procedentes de todas partes, distribuyéndolas a muchos sin fraude, no es enteramente vituperable. Y también si, saciado o, mejor satisfecho, el mercader, de alta mar se retira al puerto, y del puerto al campo y emplea su dinero en comprar una hacienda, parece que hay que elogiarlo con toda justicia. De todas las cosas de las que se obtiene alguna ganancia, no hay nada mejor, ni más provechoso, ni que proporcione mayor gozo, ni más digno del hombre libre que la agricultura. Puesto que de ella ya dije cuanto puede decirse en Cato Maior; en esa obrita podrás encontrar lo que aquí falta.

25 GÓMEZ-IGLESIAS CASAL, A., "Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los "Tituli picti"", *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, op. cit., p. 72. Este autor nos comenta, además, que en el siglo XIX como motivo del la recopilación de inscripciones latinas antiguas que Mommsen pretende realizar elaborando el *Corpus Inscriptionum Latinarum* (CIL), al llegar el momento de recoger las inscripciones que aparecían en los

Por encima de los alfareros latinos, estaría la aristocracia local que a través del ejercicio de alguna magistratura municipal podrían adquirir, ellos y sus descendientes, la ciudadanía romana a la vez que se relacionaron con las actividades de los alfares. En este sentido, en *Isturgi* no se han descubierto todavía restos que confirmen esta noticia, lo que no significa rechazar esta posibilidad ya que sí contamos con referencias de otras zonas territoriales. El ejemplo está en *C. Iuventius Albinus*, edil, duunviro y patrono de *Axati* (*CIL* II, 1054). Este magistrado fue honrado con una estatua por los *municipes et incolae* de esta comunidad y aparece, no sólo en marcas de alfar, sino también en *tituli* de ánforas Dressel 20, concretamente en posición β , según el sistema epigráfico de estas ánforas. Por tanto, *Albinus* debió ser al mismo tiempo magistrado y titular de un derecho de explotación de la *figlina* situada en la zona de Casilla de Malpica, en el territorio de *Segida Augurina* y, además, estar involucrado en la comercialización del aceite bético²⁶.

Por otro lado, encontramos fuentes que mencionan a mujeres actuando en el ámbito de la alfarería. De nuevo no se refieren al territorio de *Isturgi*, pero al igual que en el caso anterior ampliamos la posibilidad de que estos datos sean confirmados en un futuro. En concreto, García Garrido nos recuerda fuentes epigráficas donde se mencionan a una mujer empresaria al frente de una fábrica de tejas y materiales de construcción sirviéndose de numerosos esclavos gestores y vicarios o subordinados. Los sellos de las tejas (C.I.L. XV, 263 y 264) fueron fabricadas entre los años 108 y 115 d.C., y tiene la inscripción “De Trofino de Agotobulo de *Domicia Lucila* de los fundos (o canteras) licinianos”. Trofino –sigue relatándonos el prof. García Garrido– es el esclavo encargado de la fabricación (*officinator*) y es el *servus vicarius* (esclavo asignado a otro esclavo) de Agotobulo, esclavo ordinario de la propietaria de las canteras de arcilla *Domicia Lucila* que años después los manumite y se convierten en libertos. Finalmente, sigue señalando García Garrido, estas empresas estaban organizadas en varios niveles, de libertos, esclavos ordinarios y esclavos vicarios, y en el vértice, a la cabeza de todos ellos estaba *Domicia Lucila*²⁷.

No nos debe extrañar la participación femenina en la medida de que, como señaló Pomeroy²⁸, las Guerras Púnicas si bien incrementó la mortalidad de los varones, sin embargo hizo suplir esa ausencia con el protagonismo de la mujer convirtiéndola en heredera de grandes patrimonios, aunque con la única limitación constante del sometimiento a la tutela. Con todo, a partir de Octavio el *ius liberorum* otorgaría a muchas ellas (ingenuas con tres hijos y libertas con cuatro) la capacidad de ser consideradas *sui iuris* y conseguir un mayor

utensilios domésticos. Dressel, del Gabinete Numismático de los Reales Museos de Berlín, realizó una campaña en la que descubrió que el Monte Tetaccio era un importante depósito de ánforas, en muchas de las cuales se conservaban ciertas inscripciones o sellos que ponían de manifiesto que la procedencia de la mayoría era la región de la Bética, *op. cit.*, p. 63.

26 Cfr., BERNI MILLET, P., *Epigrafía anfórica de la Bética: nuevas formas de análisis*, Barcelona, 2008, p. 30 ss.; PÉREZ ZURITA, A.D., *La edilidad y las élites locales en la Hispania romana. La proyección de una magistratura de Roma a la administración municipal*, Córdoba – Sevilla, 2011, p. 420 ss.

27 GARCÍA, GARRIDO, M.J., *El Comercio, los Negocios y las Finanzas en el Mundo Romano*, *op. cit.*, p. 66.

28 POMEROY, S.B., *Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica*, trad. De R. Lezcano, Madrid, 1987, p. 177ss.; Vid, además, CANTARELLA, E., *Pasado próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia*, trad. M^a Isabel Nuñez, Madrid, 1996, p.91 ss.; GARCÍA, GARRIDO, M.J., *El Comercio, los Negocios y las Finanzas en el Mundo Romano*, *op. cit.*, p.66; LÁZARO GUILLAMÓN, C., “Mujer, comercio y empresa en algunas fuentes jurídicas, literarias y epigráficas”, *RIDA*, 50, 2003, p. 155 ss.

grado de emancipación que les permitiese actuar en el ámbito comercial como *negotiatrix* (Paulo, *lib. Secundo ad Vittelium*, D.34,2,32,4: ...*quum testatrix negotiatrix fuerit*...) o como patrona (Ulpiano, *lib. LXI ad Edictum*, D. 50,16, 52: "*Patroni*" *appellatione et patrona continentur*), tanto en Roma como en los territorios provinciales. Ahora bien, la mayoría de los autores defienden que tanto los personajes varones influyentes dedicados a la política, como las mujeres actuarían en muchas ocasiones en un segundo plano por medio de *societates*, *collegia* que, mediante sus inversiones, podrían fomentar la actividad de la alfarería en todas sus vertientes (cerámica fina, ánforas, material para la construcción) a la vez que obtenían beneficios nada despreciables.

La existencia de estas agrupaciones y corporaciones viene recogida en las fuentes literarias situándolas en la época del rey Numa cuando dividió o distribuyó todos los oficios en distintas comunidades (*collegium*), tal y como relata Plutarco, *Numa*, XVII²⁹, entre los que se cita a los alfareros y que se mantuvieron a lo largo de la historia del Imperio por utilidad pública, según Waltzing³⁰. Si bien, el antiguo monarca romano las constituyó para intentar aplacar las revueltas y establecer la unidad entre la población artesana más humilde; sin embargo, el desarrollo de los mismos pudo mantenerse por medio de *societas*, a partir del periodo republicano, respondieron a la necesidad de activar la economía mediante la instauración de un organigrama de oficinas, sucursales, comerciantes (*mercatores*) y negociadores (*negotiatores*) que posibilitaran el desarrollo de distintos trabajos como podía ser la alfarería. En este sentido, la antigua ciudad de *Isturgi* es un ejemplo de ello, ya que los estudios realizados por Fernández García y Serrano Arnáez nos muestran cómo las estructuras humanas de producción encontradas en los yacimientos arqueológicos de estos territorios, han permitido la definición de tres fases relativas a productores de *sigillata* hispánica³¹:

- 1º) Primera generación de fabricantes de *sigillata*, de época preflavia, detectándose unas *officinae* especializadas en productos lisos y decorados, utilizando en ocasiones la fórmula hispánica *EX OF* y apareciendo firmas en *tria nomina* y a veces constituyendo asociaciones entre alfareros, como es el caso de *M.S.M.* con otros alfareros *C.P.F.* y *M.T.F.*, destacando también otras siglas como *CVDAS* y *QUARTIO*, y entre ellas parece tener un claro predominio jerárquico *MSM*, cuyo *offinator* era *M. SATRIVS MONTANVS* controlando la casi totalidad del sector productivo, dejando constancia de ello en su forma de firmar sus manufacturas asociándose con *C.P.F.* y *M.T.F.*, donde probablemente la letra *F* indique la filiación, lo que viene a mostrar que familias enteras podían dedicar su actividad a la producción de *sigillata*.

29 "...Hízose esta distribución por oficios de los flautistas, los orfebres, los maestros de obras, los tintoreros, los zapateros, los curtidores, los latoneros y los alfareros, y así, las demás artes, haciendo luego de cada una un solo cuerpo; y atribuyendo o concediendo a cada clase formar comunidad y tener sus juntas y su modo particular de dar culto a los dioses, entonces por la primera vez se quitó de la ciudad el decirse y reputarse sabinos o romanos, unos ciudadanos de Tacio y otros de Rómulo; de manera que la nueva división vino a ser armonía y unión de todos para con todos..."

30 WALTZING, J.P., *Etudes historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, IV tomos, Roma, 1968

31 FERNÁNDEZ GARCÍA, M.I. y SERRANO ARNÁEZ, "Estructuras humanas de producción", *Una aproximación a Isturgi romana*, op. cit., p. 91 ss.

- 2º) Una segunda generación de fabricantes de *sigillata* se centra en época flavia apreciándose una proliferación de *officinae* en la que predominan, a diferencia de la etapa anterior, un mayor número de productos lisos (con las firmas C.A.A., C.A.H., C.L., DACI, entre otras) y productores de moldes que dejan constancia de su trabajo (CAP, DAI, L.C.A, entre otros). En esta etapa, aunque la producción es menos decorada, sin embargo el aumento de *officinae* es muy significativo ante una probable mayor demanda del producto.
- 3º) Una tercera generación de fabricantes, en los últimos momentos del siglo I d.C. y durante el siglo II d.C., sufre una alteración en las estructuras humanas de producción, desapareciendo las firmas de carácter epigráfico, reduciéndose el repertorio a las denominadas marcas de entalle y apareciendo representaciones figuradas (divinidades, animales, escenas de género...). En este periodo, se observa que los *dua* y *tria nomina*, así como el desarrollo de la filiación que de una u otra forma había estado presentes en las primeras generaciones de alfareros, se suprimen totalmente y son sustituidas por las marcas de entalle mencionadas.

Este análisis de las distintas generaciones de alfareros nos muestra cómo en territorio hispano la actividad económica de las familias se materializó en sus trabajos de manera artesanal, cuya responsabilidad en sus producciones recaía en la única figura que concentraba el absoluto poder sobre la misma, esto es, el *paterfamilias* respondiendo frente a terceros de sus propios actos, como los de sus sometidos (*filius, servus, liberti*,...). Ahora bien, la gran producción de vajillas en *terra sigillata* hispánica, como de ánforas para el transporte y exportación de materias primas, así como la elaboración de otros materiales para la construcción, provocó que las distintas familias alfareras se unieran en agrupaciones que permitieran crear una mayor infraestructura para hacer frente a actividades empresariales de mayor alcance.

De ahí que, las distintas generaciones de alfareros que nos muestran los datos arqueológicos confirmen la teoría de la evolución social que experimentó la época clásica, esto es, el paso de los grupos familiares de *figulus* a la composición de *societates* más sofisticadas en sus estructuras, con un patrimonio común (y distinto de los patrimonios familiares) que servía para responder de las obligaciones generadas. La figura del *paterfamilias* como único jefe del grupo de familia artesanal es suplido por órganos directivos y de representación que las fuentes mencionan como: *mercator, negotiator, officinator*; así como las distintas sucursales (*officinae*) que una misma firma de alfareros podía abrir en distintos lugares del territorio hispano.

Por otro lado, el hecho de que esta actividad alfarera tuviera su momento de esplendor en época clásica y al final de la misma iniciara un proceso de declive puede deberse a la exigencia progresiva del poder público sobre estos grupos artesanales exigiéndoles sus servicios de forma forzada y convirtiéndoles en sus nuevos servidores; ya que, según señala Pendón Meléndez, a cambio de distintas inmunidades y privilegios que otorgaban el poder público, los artesanos se veían obligados a trabajar para ellos de manera voluntaria y gratuita, acelerando que a partir del siglo III d.C. muchas de estas corporaciones irán desapareciendo³². Situación

32 PENDÓN MELÉNDEZ, E., Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho Romano, Madrid, 2002, p. 311.

que, desde nuestro punto de vista, podría entenderse en el sentido de que las distintas fases de alfareros en *Isturgi* se desarrolló sólo en los primeros siglos de nuestra Era y, progresivamente, fue sufriendo un proceso de decadencia.

En efecto, en época clásica los alfareros (*figulus*) no aparecen como beneficiarios de ningún tipo de inmunidad, según apreciamos en D. 50, 6, 6, frente a un gran número de actividades artesanales, según *Tarruntenus Peternus libro primo militarium*:

Quibusdam aliquam vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt menses, optio valetudinarii, medici, capsarii, et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii, architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii, aerarii, bucularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquilices, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, lapidarii, et hi qui calcem cocunt, et qui silvam infundunt, qui carbonem caedunt ac torrent. In eodem numero haberi solent lani, venatores, victimarii, et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores corniculariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et praeco, et bucinator. Hi igitur omnes inter immunes habentur.

Ello podía suponer que tuviesen una mayor libertad a la hora de explotar su actividad en la medida que no se veían obligados a producir lo que Roma demandase, sino lo que la propia población necesitase y los alfareros quisieran. El esfuerzo de pagar los tributos requeridos, les otorgaba a las grandes firmas alfareras (como los de *Isturgi*) una libertad de acción y disposición que escapaba del control del poder público. Probablemente dichos tributos fueron de una cuantía muy inferior a las ganancias obtenidas.

Por el contrario, en épocas posteriores se produce una decadencia de las firmas alfareras, cuya causa pudo ser que comenzasen a ser contempladas como beneficiarias de dichas inmunidades fiscales pero, al mismo tiempo, controladas; lo que generó el declive de las mismas. Así vemos en el Código Teodosiano 13, 10 (en 374) *Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Italicum vicarium Italiae*.

Colonos rei privatae vel ceteros rusticanos pro speciebus, quae in eorum agris gigni solent, inquietari non oportet. Eos etiam, qui manu victum rimantur aut tolerant, figulos videlicet aut fabros, alienos esse a praestationis eius molestia decernimus, ut hi tantum, qui pro mercimonio et substantia mercis ex rusticana plebe inter negotiatores sunt, sortem negotiationis agnoscant, quos in exercendis agris ingenitum iam pridem studium non retinet, sed mercandis distrahendisque rebus institutum vitae et voluntatis implicuit. Dat. non. feb. Mediolano Gratiano III et Equitio v. c. cons. (374 febr. 5).

Y, de la misma manera, en el Código de Justiniano, 10, 64 (66) *Imperator Constantinus*:

Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit

accommodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire. et est notitia ista: architecti medici mulomedici pictores statuarii marmorarii lectarii seu laccarii clavicarii quadrigarii quadratarii (quos graeco vocabulo livovyktas appellant) structores (id est aedificatores) sculptores ligni musarii deauratores albi (quos graeci ckoniataasc appellant) argentarii barbaricarii diatretarii aerarii fusores signarii fabri braccarii aquae libratores figuli (qui graece κεραμεις dicuntur) aurifices vitrearii plumarii specula rii eborarii pelliones fullones carpentarii sculptores dealbatores cusores linarii tignarii blattearii (id est petalourgoi).^{*} constant. a. ad maximum pp.* <a 337 d. iiii non. aug. feliciano et titiano conss.>

En consecuencia, compartimos la opinión de aquellos que a cambio de determinadas inmunidades y privilegios, los artesanos se vieron obligados a trabajar para ellos de manera voluntaria y gratuita, acelerando un proceso de decadencia en sus actividades empresariales y comerciales, siendo el caso de los alfareros de *Isturgi* un claro ejemplo de ello.

III. REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS INSTALACIONES ALFARERAS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CAPÍTULO 76 DE LA *LEX URSONENSIS*

La opinión de los arqueólogos sobre los yacimiento de *Isturgi* es la de interpretar que la implantación de los hornos alfareros se ubicaron en las proximidades de la ciudad. En concreto, en una especie de barrio suburbano determinado por la existencia de actividades artesanales cuya materialización zonal quedó prácticamente definida desde el comienzo de los trabajos de campo en el yacimiento, según nos indica la profesora Fernández García³³.

Esta noticia parece encontrar ciertas contradicciones con el contenido del capítulo 76 de la *lex Ursonensis* en el que se establece, según interpreta D'Ors del texto de la misma, la prohibición de instalar alfarerías dentro de la ciudad³⁴:

Figlinas teglarias maiores tegularum CCC tegullariumq(ue) in oppido colon(iae) Iul(iae) ne quis habeto. Qui l habuerit it aedificium isque locus publicus l col(oniae) Iuli(ae) esto, eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) l G(enetiva) Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raerit), s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum redigito. l

Como interpreta el profesor D'Ors, del texto se desprende la distinción de dos tipos de alfarerías: las *figlinae teglariae* y el *tegularium*. Si bien para éste último la prohibición era absoluta, para el primero existía solo en el caso de que su extensión superara a la correspondiente a trescientas tejas, entendiendo esta medida como la extensión del tejado del edificio y no como el área que abarcaban cuando éstas se ponían a secar ni como la cantidad máxima de producción diaria. Igualmente, en dicha ley se establece la sanción de pagar al magistrado (cantidad que el magistrado ingresaba en la caja pública) el valor del

33 FERNÁNDEZ GARCÍA, M^a I., "Notas acerca de las estructuras de producción de Los Villares de Andújar", *Una aproximación a Isturgi romana. op. cit.*, p. 71 y 72.

34 D'ORS, A., *Epigrafía jurídica de la España Romana*, Madrid, 1953, p. 201 ss.

edificio para aquellos que infringían la norma, o bien el inmueble quedaba como *publicus*. A pesar que esta interpretación de D'Ors ha contado con una amplia aceptación por parte de arqueólogos, historiadores y romanistas, sin embargo, como señalaron otros autores³⁵, no terminó por solucionar tres cuestiones:

- I. La diferenciación entre la *figlinae teglariae* y el *tegularium*.
- II. Los motivos de la prohibición.
- III. El alcance jurídico de convertir en *publicus* el edificio y de la severa sanción cuando no se había actuado con *dolo malo*.

I. En cuanto al distinto significado entre la *figlinae teglariae* y el *tegularium*, las interpretaciones son muy variadas:

Rodriguez de Berlanga³⁶ consideró que *figlinae teglariae* consistía en un taller alfarero dedicado a cualquier trabajo de alfarería incluyendo la fabricación de tejas, mientras que *tegularium* se dedicaba a la exclusiva fabricación de tejas. Por tanto, en la *lex Ursonensis* lo que se prohibía terminantemente era la instalación en suelo urbano del *tegularium* y se admitía la *figlinae teglariae* con la limitación de 300 tejas, esto es, como lo relativo al espacio que ocupaba la cantidad de tejas expuestas al sol para secar antes de su cocción en los hornos. Por consiguiente, la prohibición hacía referencia a los hornos alfareros que ocupasen espacios superiores a dicha medida.

Mommsen³⁷, por su parte, interpreta que *figlinae teglariae* y *tegularium* eran dos expresiones que formaban parte de la actividad *tegularia* en general, explicando que el número de 300 tejas habría que entenderlo como referente a la producción máxima permitida en un determinado espacio de tiempo, tal vez un día. Así, la prohibición establecida en el texto legal afectaría a los hornos alfareros con un volumen de producción superior a la cantidad de 300 tejas.

Scialoja³⁸ tomando como base el número de tejas mencionado en la *lex Urso*, cap. 76, estimó que la prohibición recaería sobre toda instalación dedicada a la fabricación de tejas, cuyo tejado superase la superficie establecida. Para ello, toma como fundamento lo establecido en la *lex Tarentina*, 1, 28: *Aedificium quod non minus MD tegularum tectum sit...* y así como otros testimonios de las fuentes literarias³⁹.

Por su parte, Mingazzini⁴⁰ comparando el término *tegularium* con otros vocablos latinos de idéntica formación, llega a la conclusión de que dicho término significó almacén de tejas y se adhiere a la interpretación de Scialoja en lo referente a la prohibición de la fabricación de las mismas en edificios o en hornos cuyos tejados superasen la superficie de las trescientas expresadas en la *lex Ursonensis*. Por otro lado, dio una estimación entre ochenta

35 Vid., TSIOLIS, V.G., "La restricción de la producción de tegularia en la *Lex Ursonensis*", *Stvd. hist. H^a antig.*, 15, 1997, p. 119 ss

36 RODRIGUEZ DE BERLANGA, M., *Los nuevos bronce de Osuna*, Málaga, 1876, p. 111 ss.

37 MOMMSEN, Th., *Gesammelte Schriften*, I, Berlín, 1905, p. 263 ss.

38 SCIALOJA, V., *Studi giuridici. II. Diritto romano*, 2, Roma, 1934, p. 54 ss.

39 NON., 269; DION CAS. *Hist. Rom.*, XLVI, 31,3.

40 MINGAZZINI, P., "Tre brevi note sui laterizi antichi", *Bulletino della Commissione Archeologica Comunale in Roma*, 76, 1959, p. 77 ss.

y cien metros cuadrados lo que podía medir la superficie total, esto es, otorgó un valor absoluto a la superficie cubierta por trescientas tejas bipedales, las más grandes conocidas en la antigüedad⁴¹.

Por nuestra parte, compartimos la opinión ya señalada de aquellos que interpretan el significado de que *figlinae teglariae* podrían ser alfares de menor tamaño y situado en zona urbana, más acorde con una producción de cerámica destinada a un consumo más de carácter local; mientras que *tegularum* respondería a un edificio de mayor volumen destinado al almacenamiento y producción no solo de cerámica, sino también de tejas y otros materiales de construcción, como los ladrillos y que, probablemente, se ubicarían en zonas externas del casco urbano. De hecho, la palabra *tegularum*, que deriva de *tegula* (teja), puede estar relacionada con *tugurii*, *tugurium* y *tegularium*, ya que Pomponio, libro XXX *ad Sabinum*, en D. 50, 16, 180, nos dice que *tuguri* significa toda construcción más propia de un cobijo rústico que de una casa urbana, mientras que *tugurium* significaría de techado y *tegularium* tejado:

pr. "Tugurii" appellatione omne aedificium, quod rusticae magis custodiae convenit quam urbanis aedibus, significatur.

1. Ofilius ait tugurium a tecto tamquam tegularium esse dictum, ut toga, quod ea tegamur

Por consiguiente, si *tegularium* significa "tejado" que, a su vez, proviene de *tegula*, esto es, "teja", es lógico suponer que *tegularum* significase un edificio destinado a la producción de tejas u otros materiales de construcción que, dado el volumen de obras públicas y privada, exigiera un mayor volumen de actividad. Mientras que la expresión *figlinae teglariae* podría corresponderse a un tipo de alfarería que requiera un menor volumen de producción como pudiera ser la cerámica fina lisa o decorada, ya que el consumo de la misma es más específico y selectivo. Con todo, y aún tratándose de cerámica fina, impone el límite de no construir *figlinae teglariae* en zonas urbanas por encima de la medida de trescientas tejas, lo que nos hace suponer que se quiere evitar un volumen excesivo de actividad industrial en pleno núcleo urbano.

II. En cuanto a los motivos de la prohibición, las interpretaciones se establecen desde razonamientos económicos (por acercar lo más posible las grandes alfarerías junto a las materias primas de las que servirse), también se especula por motivos políticos (evitar que dentro de la ciudad se pudieran almacenar demasiadas tejas que sirvieran como armas de defensa o ataque en un momento y circunstancia determinado) y también se manifiestan

41 Este autor basa sus cálculos en tejas de tamaño 0'60 x 0'60 m., consiguiendo una superficie de 108 metros cuadrados. Sin embargo, como señalan un gran número de autores, las tejas son normalmente rectangulares, siendo lo más frecuente que sólo su longitud alcance los 0'60 m. La anchura media de cada teja apenas suele superar los 0'45 m., por tanto la superficie total ocupada por 300 tejas oscilaría entre 81 y 90 metros cuadrados aproximadamente. Sin embargo, ADAM, J.P., *La construction romaine. Matériaux et techniques*, Paris, 1984, considera que las tejas más grandes (75 x 110'5 cm) son las encontradas en el *sacellum* de *Paestum*. Cfr., TSIOLIS, V.G., "La restricción...", *op. cit.*, p. 123

aquellos que defienden las causas de higiene y defensa del medio ambiente evitando instalar grandes industrias en la misma ciudad⁴² que implicase un perjuicio sanitario para la vida urbana.

Postura –ésta última– que consideramos más acertada en la medida que objetiva y lógicamente es notorio que una gran industria en la misma ciudad desencadena una serie de peligros: incendios, humos,...que son mejor controlados si se ubican en territorios más alejados de la misma. E, incluso, sin ser peligrosos pueden suponer una molestia para el resto de la comunidad urbana. De ahí que Ulpiano, *libro LXVIII ad Edictum*, D. 43,8, 2pr., nos informa del interdicto prohibitorio en orden a no realizar o hacer en lugar público alguna cosa por la que cause un daño a alguien, salvo aquello que este permitido por la ley, el senadoconsulto, edicto o decreto del Príncipe:

pr. Praetor ait: “Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est. De eo, quod factum erit, interdictum non dabo”.

Definiendo Labeo, en D. 43,8,2,3 que “lugar público” se refiere a los solares, casas, a los campos, a las vías públicas y a los caminos:

Publici loci appellatio quemadmodum accipiatur, Labeo definit, ut et ad areas et ad insulas et ad agros et ad vias publicas itineraque publica pertineat.

Este interés de preservar los lugares públicos de actividades molestas se aprecia también en las medidas que se establecen en la misma *lex Ursonensis* en el capítulo 73 con referencia a la prohibición dentro de la ciudad de la inhumación, incineración y el de edificar un monumento funerario:

Ne quis intra fines oppidi colon(iae)ve, qua aratro l circumductum erit, hominem mortuom l inferto neve ibi humato neve urito neve homilnis mortui monimentum aedificato. Si quis l adversus ea fecerit, is c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) HS ICC d(are) d(amnas) esto, l eiusque pecuniae qui volet petitio persecutio [exactio(ue)] esto. Itque quot inaedificatum l erit Iivir aedil(is)ve dimoliendum curanto. Si l adversus ea mortuus inlatus positusve erit, l expianto uti oportebit. l

Siendo confirmada esta noticia en otras fuentes anteriores, como es en las XII Tablas (X, 1): *Hominem mortuum in urbe ne sepelio neve urito*. El motivo cree Cicerón que sea para evitar el riesgo de incendios, *De legibus*, II, 23,58: *Credo vel propter ignis periculum*, y también para defender el decoro e higiene de la ciudad, como señala D’Ors en base a otras fuentes literarias⁴³.

42 Vid. por todos, TSIOLIS, V.G., “La restricciones...”, *op. cit.*, p. 131.

43 D’ORS, A., *Epigrafía jurídica*, *op. cit.*, p. 197. Cfr., S. ISIDORO, *Etym.*, XV, 2,1; SERVIO, *In Aen.*, II, 206; VARRON, *Ling. lat.*, V,143. También vemos confirmada la noticia en otras fuentes jurídicas, *Sent. Pauli*, 1,21,2 y C., 3,44,12.

De igual modo en el capítulo 74 de la *lex Ursonensis*, se establece el lugar donde deben ser enterradas las cenizas de los cadáveres:

Ne quis ustrinam novam, ubi homo mortuus / combustus non erit, propius oppidum pas/sus D facito. Qui adversus ea fecerit, HS ICC c(olonis) / c(oloniae) G(enitivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae qui volet petiltio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. /

En ambos supuestos se exigen que dichas actividades se realicen fuera de las murallas de la ciudad, imponiendo la multa de cinco mil sestercios al infractor⁴⁴.

III. Por último, en cuanto al alcance jurídico de convertir en *publicus* la alfarería construida dentro de la ciudad y de la severa sanción cuando no se había actuado con *dolo malo*, hemos de decir que la *lex Ursonensis* impone un límite concreto de no construir alfarerías en las zonas urbanas por encima de la medida de trescientas tejas. Ahora bien, si en contra de la misma ley se construye alguna, no es objeto de demolición. Tan solo tendría el infractor que subsanar la irregularidad legal haciendo frente al pago del valor del inmueble (dinero que iría destinados a las arcas públicas) o bien quedaría como público. El motivo de no exigir la demolición del edificio e inclinarse por imponer una sanción económica puede deberse a la regla o principio *ne urbs ruinis deformatur*, en virtud del cual se prohibía estropear o deformar la ciudad con ruinas que provocaban dicha demolición, cuando la infracción no estorbase el uso público ya que, en caso contrario, sí habría que proceder a su demolición. Tal y como nos informa Ulpiano, *libro LXVIII ad Edictum*, D. 43,8,2,17:

Si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, non esse eum cogendum tollere, ne ruinis urbs deformatur, et quia prohibitorium est interdictum, non restitutorium. Si tamen obstat id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, debeat id deponere, aut si non obstat, solarium ei imponere: vectigal enim hoc sic appellatur solarium ex eo, quod pro solo pendatur.

Además, en la *lex Ursonensis* hay un especial interés en procurar que no se produjera el desteje (*detegito*), ni la demolición (*demolito*), ni la destrucción de cualquier forma (*disturbato*) de un edificio sin dar previamente la oportuna garantía de su futura reconstrucción, o bien porque así lo hubiese aprobado el senado reunido con la asistencia de al menos cincuenta decuriones⁴⁵, como así reza en el capítulo 75 de la mencionada *lex*:

Ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito / neve demolito neve disturbato, nisi si praedes / Ilvir(um) arbitratu dederit se redaedicaturum, aut /

44 Vid., entre otros, LÓPEZ MELERO, R., "Enterrar en Urso (Lex Ursonensis LXXIII-LXXIV), *Stud.hist., Hª antig.*, 15, 1997, p. 105 ss.; TABALES, M.A., "Algunas aportaciones arqueológicas para el conocimiento urbano de Hispalis", *Habis*, 32, 2001, p. 387 ss.; DUPRÉ RAVENTÓS, X. y REMOÀ VALLDERBÚ, J.A., "A propósito de la gestión de los residuos urbanos en Hispania", *Romula*, 1, 2002, p. 39 ss.

45 Vid. D'ORS, A., Epigrafía jurídica de la España Romana, op. cit., p. 199; MURGA, J.L., Protección a la estética en la legislación urbanística del Alto Imperio, Sevilla, 1976, p. 18.

nisi decuriones decreverint, dum ne minus L adlsint, cum e(a) r(es) consulatur. Si quis adversus ea fecerit, l q(uant) e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) lul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet peltitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. l

En el mismo sentido se pronuncia la lex Irnitana, en la rúbrica 62: Ne quis aedificia quae restitutus non erit destruat:

Ne quis in oppido municipi Flavi Irnitani, quaeque ei oppido / continentia aedificia erunt, aedificium detegito destrui-/to demoliundumve curato, nisi <de> decurionum conscriptorum-/ve sententia, cum maior pars eorum adfuerit, quod res-/titutus intra proximum annum non erit. Qui adversus / ea fecerit, is quanti ea res erit t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flavi / Irnitani d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi qui volet cuique per h(anc) l(egem) li-/cebit actio petitio persecutio esto.//

Esto explica la posibilidad de que supervivieran en el tiempo edificios destinados a las actividades alfareras por encima de las dimensiones señaladas siempre y cuando se sometieran al cumplimiento de las imposiciones o sanciones establecidas por la propia *lex*. Sanciones que eran de un elevado coste (el valor del edificio) al que solo podrían hacer frente aquellos alfareros u otros inversores de las élites industriales de la zona que tuviesen el poder económico suficiente, tal y como vimos que existieron personajes de la vida política romana que también dedicaron su tiempo y dinero a este tipo de actividad. Por otro lado, esta circunstancia de encontrar un alfar de gran dimensión dentro de la zona urbana no es exclusiva de *Isturgi*, ya que en otras zonas de la península hispana también se produjeron, como es el caso del alfar en el casco urbano de Calahorra⁴⁶.

En cuanto a lo establecido en la *lex Ursonensis* (en el capítulo 76) de convertir en público el edificio que supere las dimensiones establecidas hay que interpretar en su justa dimensión jurídica esta severa sanción, ya que la mayor parte de los autores hablan de expropiación, como es el caso de D'Ors cuando dice que: "La *pecunia* no sería así una alternativa respecto a la entrega del fundo, sino la última consecuencia de la expropiación forzosa"⁴⁷. O bien Delplace⁴⁸ al considerar que la implantación de los centros de producción en las proximidades de la ciudad o en los núcleos rurales obedecía a las diferentes condiciones de propiedad del suelo. Distinguiendo dos tipos de talleres alfareros: Los pequeños que podrían situarse en las zonas urbanas y los de mayor dimensión que se ubicarían en las zonas rurales, ya que las grandes propiedades solían tener sus propios alfares donde fabricaban tejas y vajilla de uso corriente, cuyos propietarios eran los únicos que poseían la tierra así como los fondos necesarios para el desarrollo de los grandes talleres.

46 Vid., CINCA MARTÍNEZ, J. L., "Elementos de Alfar en el casco urbano de Calahorra ¿un nuevo taller de producción de cerámica romana?, *IBERIA*, 3, 2000, p. 319 ss.

47 D'ORS, A., Epigrafía jurídica de la España Romana, op. cit., p.203

48 DESPLACE, Chr., "Les potiers dans la société et l'économie de l'Italie et de la Gaule au I siècle av. Et au I siècle ap. J.C.", *Ktema*, 3, 1978, p. 74-76.

Consideramos que, desde un punto de vista jurídico, ambas interpretaciones deben ser precisadas en orden a concretar el verdadero significado de “expropiación”, según D’Ors, y “propiedad del suelo”, según interpretan otros como Delplace. En este sentido, no podemos olvidar que el periodo objeto de nuestro estudio es finales de la época republicana y el periodo del Principado, cuando los territorios provinciales sólo pertenecían en propiedad soberana, como señaló Iglesias⁴⁹, al pueblo romano o al emperador, según se tratase de provincias senatoriales o imperiales, distinguiéndose además los fundos itálicos de los provinciales y solo sobre los primeros se admitía la propiedad o *dominium*. Situación que se mantuvo hasta la *constitutio Antoniniana*, del 212 d.C., inalterable.

Por consiguiente, hablar de expropiación o de propiedad como *dominium ex iure quiritium* nunca podría hacer referencia del suelo provincial por parte de los particulares, sino del disfrute del suelo mediante una *locatio conductio*, de un tiempo determinado o indefinido, tal y como se aprecia en los arrendamientos expresados en el capítulo 82 de la *lex Ursonensis*⁵⁰ y en la Rúbrica 63 de la *lex Irnitana*⁵¹. Convirtiendo al *conductor* en poseedor de un suelo y de un edificio ajeno (puesto que pertenece a Roma), aunque el mismo hubiese sido construido por un particular. En este sentido, Ulpiano, *lib. 44 ad Sab.*, D. 18, 1, 32, nos recuerda con motivo de las *tabernas argentarias* que siempre lo transmitido en realidad no es el suelo ni el edificio, sino el derecho de usar y disfrutar de una construcción, previo pago de un *solarium*:

Qui tabernas argentarias vel ceteras quae in solo publico sunt vendit, non solum, sed ius vendit, cum istae tabernae publicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet.

Estaríamos ante la presencia de concesiones de suelo que Roma hizo a los particulares sobre los terrenos provinciales y a través de sus magistrados, otorgando a los mismos un Derecho: El derecho de superficie⁵², esto es, un derecho real transmisible inter vivos y

49 IGLESIAS, J., *Derecho Romano. Instituciones de Derecho privado*, Madrid, 1987, p. 266 ss.; vid. SÁEZ, P., “La tierras públicas en la *lex Ursonensis*”, *Stud. Hist. Hª antig.*, 15, 1997, p. 137 ss.

50 *Qui agri quaeque silvae quaeque aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) l quibus publice utantur, data adtributa elrunt, ne quis eos agros neve eas silvas venldito neve locato longius quam in quinquenlnium, neve ad decuriones referto neve decurlionum consultum facito, quo ei agri eaeve l silvae veneant aliterve locentur. Neve is velnierint, itcirco minus c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) sunt. Quique iis l rebus fructus erit, quot se emisse dicat, is in l iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(annas) l [esto, eiusque pecuniae qui volet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto.*

51 Qui Ilvir iure dicundo praeit vectigalia ultroque / tributa, sive quid aliut communi nomine municipi-/pum eius municipi locare oportebit, locato. Quasque lo-/cationes fecerit, quasque leges dixerit et quanti quit / locatum sit, et qui praedes accepti sint quaeque praedia / subdita subsignata obligatave sint, quique praedio-/rum cognitores accepti sint in tabulas communes mu-/nicipum eius municipi referantur facito, et proposita / habeto per omne reliquum tempus honoris sui, ita ut / d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), quo loco decuriones conscriptive proponenda / esse censuerint.

52 Sobre el derecho de superficie, vid., entre otros, LUCCHI, A., “Del diritto di superficie”, *AG.*, 51-52, 1893-94, p. 250 ss. y 500 ss.; DE RUGGIERO, E., *Lo Stato e le opere pubbliche in Roma antica*, Torino, 1925, p. 147 ss.; BRANCA, G., “Considerazioni intorno alla proprietà superficiaria nel diritto giustiniano”, *RIDA*, IV, 1950, p. 190 ss.; MASCHI, C.A., “Proprietà divisa per piani, superficie e l’estensione ai provinciali del principio superficies solo cedit”, *Studi in onore di V. Arangio Ruiz*, vol. IV, 1952, p. 137 ss.; PASTORI, F., *La superficie nel Diritto romano*, Milano, 1962; ID., “Prospettiva storica del diritto di superficie”, *Studi in memoria di Guido*

mortis causa, otorgaba a su titular (superficiario) el goce a perpetuidad o por largo tiempo del pleno disfrute y disponibilidad del edificio o construcción levantado sobre el suelo ajeno (ager, solo, loco publicus) a cambio de un canon llamado solarium o pensio, para diferenciarla del vectigal como renta que cobraba del derecho de enfiteusis, tal como nos dice Ulpiano, lib. 58 ad Edictum, D. 43, 8, 2, 17 in fine: vectigal enim hoc sic appellatur, solarium ex eo, quod pro solo pendatur. Ello no significaba que se diera una separación de propiedades entre suelo y edificio. Significaba que el propietario del suelo también lo era del edificio (y ello en base al principio superficies solo cedit) pero concediendo al que lo ocupaba (superficiario) el derecho de uso y disfrute del mismo.

Esta circunstancia no es extraña en la historia de Roma, ya que en sus conquistas cuando arrebataban las tierras al pueblo vencido, solían encontrarse edificios –como las alfarerías– que los convertían en edificios públicos, o bien decidía construir edificios para ceder a particulares su explotación⁵³. Dicha explotación la concedía a través de una adjudicación por concurso que los magistrados locales (dunviros o decuriones) celebraban mediante subastas públicas. En las mismas, pujaban todos aquellos que tenían el *ius commercii* (entre los que se encontraban los habitantes de aquellas zonas) adjudicándolas al mejor postor.

En los supuestos de adjudicaciones de suelo urbano sin edificio, el adjudicatario adquiriría también sobre el solar un derecho de superficie que, a imagen y semejanza de la enfiteusis, disfrutaba del mismo pudiendo construir un edificio para su explotación privada pero con la condición de que la propiedad real del mismo era del Estado romano, en virtud del principio *superficies solo cedit*. Dicha propiedad la recuperaba Roma cuando finalizase el periodo de tiempo con el que se formalizó la concesión administrativa superficiaria o bien por cualquier causa de revocación del Derecho de superficie. De esta forma, Roma no sólo no perdía la titularidad de la propiedad del suelo (puesto que seguía teniendo el carácter de *publicus*) cuando hacía a particulares la concesiones del aprovechamiento de su suelo público, sino que –además– conseguía la adquisición de la propiedad de un edificio y de una renta periódica (*solarium* o *pensio*) cuando permitía que los beneficiarios de dichas concesiones edificasen por su propia cuenta un edificio para su uso y explotación privada.

Entre las distintas inscripciones que relatan la concesión superficiaria del suelo público, cabe destacar aquella *C.I.L. X, 1783*, del siglo II d.C., descubierta en la ciudad italiana de Pozzuoli en el año 1861, en la que se representa la concesión municipal *de loco publico*

Donatuti, vol. II, Milano, 1973, p. 871 ss.; ID., *Prospettiva storica della Superficie nel sistema dei diritti*, Milano, 1979, p. 155 ss.; GROSSO, G., *Schemi giuridici e società nella storia del Diritto privato romano*, Torino, 1970, p. 299 ss.; PALADINI, A., v. Superficie (Diritto romano), *NNDI.*, 18, 1971, p.491 ss.; SITZIA, F., *Studi sulla superficie in epoca Giustiniana*, Milano, 1979; BISCARDI, A., “Sul regime delle locazioni amministrative in Diritto romano”, *Studi in onore di Antonio Amorth*, vol. I, Milano, 1982, p. 84 ss.; FERNÁNDEZ BAQUERO, M.E., “*De Superficiebus*. En torno al Derecho de Superficie”, *Actas del I Congreso Iberoamericano de Derecho Romano*, Granada, 1995, p. 81 ss.; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S., *Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho Romano*, Madrid, 1996, p. 151 ss.; ZAERA GARCÍA, A., “La propiedad superficiaria en el derecho romano Justiniano”, *RIDA*, LI, 2004, p. 369 ss.; SUÁREZ BLÁZQUEZ, G., “Roma: edificación en altura. El negocio urbanístico-inmobiliario de la superficie en el Derecho Clásico”, *Revista de Derecho vLex*, nº 85, Octubre 2010, p. 11-75 y 77-156.

⁵³ Vid., CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S., *Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho Romano*, op. cit., p. 168 ss.

fruendo, conocida como *aedificium superficarium Puteolanum*⁵⁴. En ella se relata que M. Laelius Atimetus solicita al consejo municipal de los decuriones la exención del pago por la construcción de un edificio superficario en solar público tributario (*petiterit in ordine nostro uti solarium aedificium quod extruit in transitorio*). La respuesta del consejo municipal es la reconocer que dicho edificio fue construido de forma privada por *Atimetus*, pero le concede dicha exención, no por ese motivo, sino por ser un *optimi civis*. Por ello, le impone que hasta el último día de su vida (*ut ad diem vitae eius*) se le concede el poder jurídico del uso y disfrute del edificio superficario (*eius usus et fructus potestasque aedifici sui ad se pertineret*). Después el edificio superficario retorna *optimo iure* al patrimonio público (*postea autem rei publicae nostrae esset*).

En este ejemplo, se ve claramente que por el principio *superficie solo cedit* el edificio construido por *Atimetus* es un bien de dominio público, pero la concesión superficaria le permite la separación de la propiedad pública (*dominium ex iure quiritium publico*), de la posesión y disfrute por el particular del edificio como concesión superficaria (*usus fructus a potestaque aedifici sui ad se pertineret*). Llegado el momento en el que venza el plazo (en el caso de *Atimetus* será el último día de su vida) el poder de uso y disfrute del edificio retorna al dominio público del municipio.

Por tanto, nuestra interpretación de lo establecido en el capítulo 76 de la *lex Ursonensis* no es la de considerar privar al alfarero de una propiedad del edificio, sino la de revocar la concesión de un derecho, el derecho de superficie, consiguiendo el poder público recuperar la disponibilidad de un inmueble que por el derecho de superficie se había encontrado hasta ese momento en manos privadas. De admitirse la palabra propiedad, sólo podía ser admitida en cuanto a la propiedad o titularidad del Derecho de superficie otorgado al alfarero, ya que la amplia capacidad de disposición que tenía sobre el mismo lo situaba en unas condiciones jurídicas muy similares a las de un propietario.

54 ARANGIO RUIZ, v., *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars Tertia, Negotia*, Firenze, 1968, p. 361 ss.

MATRIZES SOCIETÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DE 1808. CONTRIBUTO PARA A HISTÓRIA DO DIREITO BANCÁRIO PORTUGUÊS

RUI MANUEL DE FIGUEIREDO MARCOS

1. Intentarei percorrer, em passo estugado, algumas das primeiras páginas da história do direito bancário português¹. A minguia de investigações do ponto de vista jurídico faz avultar o interesse da incursão que decidimos empreender. Não se ultrapassam lineamentos fundamentais e o voto disquisitivo circunscreve-se às «Matrizes Societárias do Banco do Brasil de 1808».

Em Portugal, até finais do século XVIII, apenas se registaram alvitreiros dispersos no tempo pelo que toca à criação de instituições bancárias. Vozes autorizadas pediram isso mesmo. À primeira metade de seiscentos pertencem as sugestões de Duarte Gomes Solis e do Padre António Vieira². O sábio jesuíta, a par de Companhias de comércio³, avançou a proposta de erguer um Banco, semelhante ao de Amsterdão, prevalecendo-se da experiência e dos capitais dos judeus portugueses⁴.

Utilizando assiduamente o termo Banco e com eco legislativo, convirá trazer à lembrança o Alvará de 31 de Dezembro de 1653 e o Regimento de 26 de Junho de 1655. Inscritos no reinado de D. João IV, representaram uma tentativa malograda de instituir um Banco curiosamente talhado para conseguir o resultado salvífico do «desempenho das rendas desta minha coroa». Impostura ou não de um D. Diogo de Preston, de nação irlandesa, a quem se ficou a dever a imaginosa proposta, o certo é que o regramento societário consagrava uma norma insólita. Dividia as pessoas que entrassem no Banco em oito classes, conforme as suas idades, sendo a primeira dos meninos de um a oito anos de idade e a última dos sócios

1 Para um panorama da história da banca no plano comparatista, são de valiosa consulta, nomeadamente, as obras de JEREMY ATTACK, LARRY NEAL, *The Origin and Development of Financial Markets and Institutions*, Cambridge, 2009; e GEOFFREY WOOD, TERENCE C. MILLS, NICHOLAS CRAFTS, *Monetary and Banking History*, Londres, 2010; e o clássico estudo de JOHN KENNETH GALBRITH, Moeda. *Das suas origens à economia contemporânea*, Lisboa, 1996, págs. 28 e segs.

2 Ver DAMIÃO PERES, *História do Banco de Portugal (1821-1846)*, Lisboa, 1971, págs. 33 e seg.

3 Ver RUI DE FIGUEIREDO MARCOS, *O Padre António Vieira e as Companhias de Comércio*, in «Boletim da Faculdade de Direito», vol. LXXIII (1997), págs 149 e segs.

4 Neste sentido, ver JOSÉ CALVET DE MAGALHÃES, *História do Pensamento Económico em Portugal*, Coimbra, 1967, pág. 251.

de cinquenta e seis anos em diante. A identidade dos sócios afigurava-se essencial. Ao ponto de se exigir prova pelo livro de baptismo, assento da pátria, estatura do corpo, feições do rosto e os mais sinais que parecessem convenientes para a certeza da pessoa⁵. Em vez de um Banco, seria antes uma tontina, como sustenta Damião Peres⁶.

Já a genealogia das operações avulsas de índole bancária inseridas em organizações entretecidas historicamente com uma vocação predominante para outro tipo de actividade, alonga as suas raízes bem mais longe. Não constituem o nosso ponto de mira, mas não deixaremos de proporcionar um quadro incompleto, simplesmente ilustrativo.

2. Admite-se que, em pleno século XIV, no seio da Bolsa do Comércio criada pelo rei D. Fernando, se realizassem actos reveladores de afinidades às funções de um Banco marítimo. O certo é que tal instituição fernandina surgira com o escopo precípua da partilha do risco do comércio marítimo através da constituição de um fundo segurador comum⁷.

As Misericórdias, como não se ignora, remontam ao reinado de D. Manuel I⁸. Assumiam a natureza de confrarias ou irmandades assistenciais e tinham como programa originário de acção velar pelas catorze obras de misericórdia evangélicas. No entanto, quando abastadas e até com o objectivo de robustecer os meios destinados à realização dos seus propósitos pios, as Misericórdias emprestavam, via de regra, os cabedais excedentários para fins diversos, incluindo o desenvolvimento da agricultura e da indústria. Por conseguinte, chamavam a si desempenhos que caberiam no âmbito de actuação de Bancos prestamistas⁹.

E se dúvidas subsistissem, dissipou-as o Alvará de 22 de Junho de 1768. A certa altura, perante a dificuldade sentida na cobrança de dívidas, a Misericórdia de Lisboa experimentava, na própria letra da lei, «o receio de dar novamente a juro outras importantes somas, que parão nos seus cofres»¹⁰. De sorte que a lei vinha agora, conquanto não colocasse em causa a prática repetida de contratos de mútuo oneroso, rodear os ditos empréstimos de um conjunto de cautelas jurídicas¹¹. Ou seja, o papel de Casa de financiamento mantinha-se imperturbável.

3. Os sinais mais ostensivos da presença de operações bancárias encontram-se nas grandes Companhias pombalinas do século XVIII. Nasceram rodeadas de um tutelar conjunto

⁵ Era o que dispunha o § 1 do Regimento de 26 de Junho de 1655. Ver MOSES BENSABAT AMZALAK, *O Banco de Lisboa*, Lisboa, 1919, pág. 11 e segs., em especial, pág. 12.

⁶ Ver DAMIÃO PERES, *História do Banco de Portugal*, cit., pág. 35.

⁷ Neste sentido, ver JOÃO PINTO DA COSTA LEITE (LUMBRALES), *Organização Bancária Portuguesa*, Coimbra, 1927, pág. 21.

⁸ Ver, por todos, MARIA ANTÓNIA LOPES, ISABEL DOS GUIMARÃES SÁ, *História Breve das Misericórdias Portuguesas*, Coimbra, 2008.

⁹ Ver o muito sugestivo estudo de AMÉRICO FERNANDO DA SILVA COSTA, *A Misericórdia de Guimarães: crédito e assistência (1650-1800)*, in «Misericórdias, Caridade e Pobreza em Portugal no Período Moderno», Braga, 1998, págs. 147 e segs.

¹⁰ Ver ANTÓNIO DELGADO DA SILVA, *Collecção da Legislação Portuguesa (1763-1774)*, Lisboa, 1829, págs. 352 e segs.

¹¹ Assim, exigia-se que constassem dos pedidos de empréstimo, a quantia exacta solicitada, os bens dados em garantia através de hipoteca, os títulos das propriedades hipotecadas e seus arrendamentos e, por fim, o justo cálculo dos anos que as consignações mostrarem necessários para a extinção dos capitais e juros devidos.

de privilégios que se ramificavam por benedições económicas e jurídicas. Mas os privilégios também se pagavam. E o seu preço consistiu precisamente num elenco de obrigações, de natureza muito diversa, políticas, militares, fiscais, que as Companhias deviam assumir de forma imperativa. Lucro e interesse público cruzavam olhares. A índole bifronte das Companhias transpirava ambiguidade¹².

Numa perspectiva de cariz não discordante, não causava estranheza que as Companhias, ao constituírem instrumentos de intervenção directa na vida económica, se sentissem arrojadas para trabalhos de suporte financeiro de certas políticas de fomento¹³. Acolheu, assinaladamente, a função de agência pública de crédito a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro em relação aos lavradores desprovidos de meios. Estes estavam habilitados a solicitar à Companhia a concessão de empréstimos que se aplicariam, de preceito, ao amanho das terras e à colheita dos vinhos¹⁴. O dinheiro saía do fundo da sociedade. Mas nem por isso a modelação do conteúdo contratual se realizava segundo a vontade exclusiva da Companhia¹⁵. Os mútuos ficaram vinculados, *ex vi legis*, à taxa de juro máxima de três por cento ao ano. Por outro lado, o montante dos empréstimos não deveria exceder o correspondente a metade do valor comum dos vinhos que cada um dos agricultores mutuários costumava recolher¹⁶. Em decorrência, tornava-se manifesto que o grande proprietário e produtor aparecia, amplamente beneficiado¹⁷. Sugestivamente, o legislador pombalino classificou mesmo a Companhia como Banco público em que não podia recluir-se falência.

12 Ver RUI MANUEL DE FIGUEIREDO MARCOS, *As Companhias Pombalinas. Contributo para a História das Sociedades por Acções em Portugal*, Coimbra, 1997, págs. 348 e segs.

13 Veja-se a assistência financeira à agricultura que a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba largamente praticou. Sobre o assunto, consultar, por todos, RODOLFO GARCIA, *A Capitania de Pernambuco no governo de José Cesar de Meneses (1774 1787)*, in «Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro», tomo 84 (1918), págs. 535 e segs., em especial, págs. 539 e segs..

14 Também se admitia que os empréstimos, além do necessário para a agricultura das vinhas, contemplassem algo mais reservado a despesas miúdas indispensáveis ao sustento dos agricultores.

15 De qualquer modo, a Companhia era totalmente arbitrária na escolha dos agricultores carenciados a quem resolvia conceder crédito. Aliás, neste ponto, a conduta adoptada nem sempre se pautou por critérios de isenção e de igualdade, relativamente àqueles que pediram dinheiro. Ressaltou a facilidade extraordinária com que os nobres contraíram empréstimos a juros baixos. Até João Pacheco Pereira de Vasconcelos, o homem mais pecunioso do Douro, surgiu contemplado. Vide SUSAN SCHNEIDER, *O Marquês de Pombal e o Vinho do Porto. Dependência e subdesenvolvimento em Portugal no séc. XVIII*, Lisboa, 1980, pág. 69.

A exclusão de centenas de candidatos e a parcialidade na atribuição do crédito constituíam defeitos de uma prática que aparece retratada no escrito anónimo *Memória sobre o estado da Agricultura, e Commercio do Alto Douro*, in «Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias», tomo III, Lisboa, M. DCC. XCI, pág. 109. Pode consultar-se a nova edição do Banco de Portugal, direcção de JOSÉ LUÍS CARDOSO, tomo III, Lisboa, 1991, pág. 75.

16 Não se esqueceu o traçar de um regime jurídico que garantia o cumprimento das obrigações dos devedores à sociedade. Assim, os vinhos «mediante, os referidos emprestimos ficarão com penhora filhada a favor da Companhia, que nelles terá a mesma preferencia que costumão ter os senhorios das casas nos móveis, que dentro dellas se achão, e sem que para isso sejam necessário outro titulo, ou facto mais que os dos assentos dos emprestimos nos livros da Companhia, virificados com escritos dos devedores, reconhecido por Official público». Vide Instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, § 11.

17 Detectámos registos quantificados desse encargo de prestar crédito aos agricultores. Ver, por exemplo, o «Mappa do Dinheiro que a Junta da Administração da Companhia Geral do Alto Douro deu de empréstimo a juros de três por cento aos Lavradores seguintes no anno prezente de 1758» no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, *Ministério do Reino*, maço 630, caixa 733, capilha 4.

Debaixo do propósito de descontar apólices pequenas com o rebate de seis por cento, deve ter-se estabelecido em Lisboa uma Caixa de Desconto, a crer no Decreto de 24 de Janeiro de 1800¹⁸. Enfim, uma série de ensaios bancários que nada retira ao facto de, em solo metropolitano, a primeira instituição que, em rigor, merece tal denominação ter sido o Banco de Lisboa em 31 de Dezembro de 1821. Esteve na origem do Banco de Portugal, quando, em 1846, se fundiu com a Companhia Confiança Nacional¹⁹.

4. À luz das fontes, porém, o verdadeiro alvorecer da história do direito bancário português achava-se na primeira década do século XIX. Por esse tempo, começaram a afluir à presença de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, então presidente do Real Erário, vários projectos de criação de Bancos²⁰. Ao que parece, Sousa Coutinho estimulava os portugueses a fornecerem ideias sobre o estabelecimento de um Banco nacional. Ele que, já em 1797, fora autor de uma bem urdida proposta que girava em torno de um designado Banco Real Brigantino.

A ausência de uma lei geral da banca motivava o aparecimento de projectos concretos que divergiam muito entre si. Obedeciam a modelos jurídico-societários diferentes. Não fugindo a um paradigma individualizado, a primeira instituição bancária que assinala o efectivo romper da história da banca portuguesa foi o Banco do Brasil fundado em 1808. Ao seu figurino jurídico dedicaremos as próximas considerações, mas sem esquecer o paralelo com soluções normativas anteriores.

5. A fundação do Banco do Brasil não teria sido possível se a Corte não houvesse estanciado em terras brasileiras. A família real, nas suas luzidias bagagens, não trazia consigo, já preparado para o Brasil, um novo direito. A sua construção iria iniciar-se à chegada, quando a Corte aportou na Baía, em Janeiro de 1808, e a persistência de velhos padrões coloniais, como observou Sérgio Buarque de Holanda, iria sofrer sérias ameaças²¹. Em 1818, José da Silva Lisboa falava mesmo, num tom encomiástico, em suspensão do regime colonial.

As faces da política legislativa de D. João VI no Brasil que mais cedo se aformosearam aos genuínos interesses brasileiros centraram-se nos domínios da legislação económica, da legislação de forte pendor político-administrativo e da legislação que reedificou a organização judiciária. De todos eles, o que gerou um quadro propício ao aparecimento de um Banco foi o conjunto das leis consagradoras do princípio da liberdade económica no Brasil.

O ano de 1808, na mira de tais propósitos, revelou-se de uma intensidade vertiginosa. Mal acabado de chegar à Baía, o príncipe regente, a instâncias das autoridades e das gentes locais das mais variadas extracções, tomou, de imediato, uma providência do maior alcance económico. Em termos legislativos, consagrou-a a Carta Régia de 28 de Janeiro de 1808 que determinou a abertura dos portos do Brasil ao comércio. Até então, por via directa, o

18 Ver MANOEL FERNANDES THOMAZ, *Repertorio Geral ou Indice Alphabectico das Leis Extravagantes do Reino de Portugal*, tomo I, Coimbra, 1843, pág. 84.

19 Ver JOSÉ PINTO DA COSTA LEITE, *Organização Bancária Portuguesa*, cit., págs. 58 e seg.

20 Ver JOSÉ LUÍS CARDOSO, *Novos Elementos para a História Bancária de Portugal. Projectos de Banco, 1801-1803*, Lisboa, 1997, págs 23 e segs..

21 Ver SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, *Raízes do Brasil*, 3.^a ed., Lisboa, 2000, pág. 166.

Brasil apenas se podia relacionar comercialmente com Portugal. Com a promulgação do mencionado diploma, consentia-se a entrada, nas alfândegas brasileiras, de todos os géneros, fazendas e mercadorias vindas de fora, ainda que transportadas em navios estrangeiros. Por outro lado, numa direcção oposta, facultava-se a exportação dos vários géneros e produções coloniais sem olhar ao destino portuário, quer recorrendo a navios portugueses, quer por intermédio de navios estrangeiros.

Uma justificação segura para o impulso legislativo não se julga fácil de lobrigar. Fosse por insinuação do Visconde de Cairú, José da Silva Lisboa, fosse por instilação do governo britânico, fosse por magreza do erário régio, o ponto é que a Carta Régia de 28 de Janeiro de 1808 sacudiu o jugo económico que oprimia o Brasil.

Mas, bem vistas as coisas, cremos que a máxima imperante foi a irrefutável *res ipsa loquitur*. A realidade fala por si mesma. Com efeito, como seria possível conservar o privilégio exclusivo entre Brasil e Portugal quando o território nacional se encontrava ocupado por tropas francesas e as forças britânicas barravam a entrada no nosso país. Manter o privilégio exclusivo redundaria numa decisão traiçoeira que só beneficiaria os invasores²².

As amarras que constrangiam o comércio internacional brasileiro não só se esboroaram em definitivo, como se começaram a desenhar os primeiros incentivos ao giro de manufacturas brasileiras entre nações. Sem reбуço, o Alvará de 28 de Abril de 1809 estabeleceu uma isenção tributária no tocante ao tráfego mercantil de manufacturas. Rezava assim a lei: «Todas as Manufacturas Nacionais serão izentas de pagar Direitos alguns na sua exportação para fóra dos Meus Estados e todas as do Reino serão izentos de os pagar por entrada nos meus Dominios no Brasil». Num ostensivo voto de estímulo ao aparecimento de uma poderosa marinha mercante, a mesma lei determinou, por outro lado, a redução para metade dos direitos alfandegários que pagavam as matérias primas destinadas à construção de navios e à sua armação²³.

Retiradas as peias ao tráfego internacional, em coerência, o princípio da liberdade económica não podia sofrer estorvo no plano interno. De tal modo que o Alvará de 1 de Abril de 1808, intentando promover a riqueza nacional, decidiu remover qualquer obstáculo legal que subsistisse, no Estado do Brasil e domínios ultramarinos, ao estabelecimento de indústrias nascentes. A liberdade soava estrídula da expressiva proclama legal: «daqui em diante seja licito a qualquer dos Meus Vassalos, qualquer que seja o Paiz em que habitem, estabelecer todo o genero de Manufacturas, sem exceptuar alguma, fazendo os seus trabalhos, em pequeno ou em grande, como entenderem que mais lhes convem». Para trás ficava, sumido na escuridão de ideias económicas já sepultadas, o Alvará de 5 de Janeiro de 1785 que ordenara a destruição de todas as fábricas existentes no Brasil. Agora resplandecia, enfundado pelos novos ventos, o pavilhão da liberdade de navegação, de comércio e de indústria.

22 Para um retrato do contexto internacional em que se movia a diplomacia portuguesa, consultar MARIA CÂNDIDA PROENÇA, *A Independência do Brasil. Relações externas portuguesas 1808/1825*, Lisboa, 1987, em especial, págs. 55 e segs.

23 Desfraldou ainda mais a bandeira do comércio livre o Alvará de 6 de Outubro de 1810 que concedeu significativos benefícios fiscais às indústrias brasileiras.

6. Precisamente a abertura económica do Brasil ao exterior e a liberdade de comércio reclamavam a existência de um sistema financeiro que, em linha precípua, conseguisse responder a uma procura muito acrescida de moeda. O financiamento de grandes despesas públicas e de investimentos privados careciam de um concerto institucionalmente organizado. Julgou-se achada a solução com o estabelecimento do Banco do Brasil.

Pela solidez e carácter pioneiro dos seus contornos jurídicos, também na perspectiva da história do direito bancário português, uma incursão autónoma reclama-a, sem dúvida, a fundação do Banco do Brasil em 1808.

Aponta-se, como figura central na gestão do Banco do Brasil, D. Rodrigo de Sousa Coutinho²⁴. Fora presidente do Erário Régio em Lisboa e passou ao Rio de Janeiro, onde ocupou, no governo, a pasta da Secretaria do Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra²⁵. Em Portugal, concebera os estatutos jurídicos de um Banco e recebeu para estudo e eventual aprovação vários projectos de instituições bancárias. Nenhum deles vingou.

7. Se D. Rodrigo de Sousa Coutinho assistiu ao malogro do projecto por si esboçado do Banco Real Brigantino, forcejou para que uma instituição congénere, filiável nas suas ideias rectoras, pudesse conhecer a luz do dia no Brasil. Concretizou o intento do ministro o Alvará de 12 de Outubro de 1808 que fundou o Banco do Brasil.

O diploma teve o cuidado de alinhar fundamentos económicos. Invocou, antes de tudo, a necessidade de criar um Banco nacional sediado na capital, de molde a animar o comércio e a promover os interesses reais e públicos. Estimular o giro das espécies cunhadas, bem como reunir capitais ociosos e isolados, em ordem, designadamente, ao possível financiamento de despesas públicas, constituíam propósitos ostensivos do Banco do Brasil²⁶.

Com o início da actividade do Banco, extinguia-se, no Rio de Janeiro, o chamado Cofre do Depósito. Doravante, qualquer depósito, fosse ele judicial ou extrajudicial, de prata, ouro, jóias ou dinheiro, far-se-ia na nova instituição bancária²⁷. Outrossim se impunha que os empréstimos a juro se realizassem unicamente através do Banco.

Um formidável privilégio legal se outorgava ao Banco do Brasil. Consistia na obrigação dos «Bilhetes do dito Banco Publico pagaveis ao portador, ou mostrador á vista» serem recebidos como dinheiro em todos pagamentos efectuados à Fazenda Real. Estávamos aqui perante uma prerrogativa que conduzia a um curso forçado.

24 Acerca dos planos e reformas financeiras de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ver JOSÉ LUÍS CARDOSO, *O Pensamento Económico em Portugal nos finais do século XVIII (1780-1808)*, Lisboa, 1989, págs. 159 e segs.

25 Ver ANDRÉE MANSUY DINIS SILVA, *Portrait d'un homme d'État: D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Comte de Linhares (1755-1812)*, 2 vols., Lisboa 2001/2006.

26 Para a leitura do Alvará de 12 de Outubro de 1808 e dos Estatutos do Banco, pode consultar-se RUI MANUEL DE FIGUEIREDO MARCOS, *Rostos Legislativos de D. João VI no Brasil*, Coimbra, 2008, págs. 119 e segs.

27 Apontava José da Silva Lisboa precisamente a natureza indispensável do Banco do Brasil, fundando-a, em primeiro lugar, na necessidade de evitar os efeitos da saída do ouro, ao tempo irresistivelmente atraído para Inglaterra e em seguida, na prudência que devia prevalecer no entesouramento de metais preciosos. As letras do Banco, sendo acreditadas, bem podiam suprir a moeda de ouro nas grandes transacções mercantis. Ver JOSÉ DA SILVA LISBOA, *Memoria dos Benefícios Politicos do Governo de El-Rey Nosso Senhor D. João VI*, Rio de Janeiro, 1818, págs. 95 e seg.

Não se julga destituído de sentido admitir que tal providência se tenha inspirado na legislação pombalina. Senão vejamos. Os bilhetes do Banco passaram a ser meios de pagamento, embora no horizonte das dívidas à fazenda. Ora, o Alvará de 21 de Junho 1766 advertira que as acções das grandes Companhias pombalinas, designadamente as do Grão Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba, representavam as quantias líquidas dos respectivos valores. As acções acabavam por cumprir as funções da moeda, uma vez que circulavam como dinheiro líquido. O mais entusiasmante do ponto de vista jurídico é que o poder liberatório dos títulos, que o Alvará de 21 de Junho de 1766 reconheceu, implicava o afastamento de uma eventual recusa em os aceitar na realização de pagamentos²⁸.

Com a lei de instituição do Banco do Brasil, baixaram os respectivos estatutos assinados por D. Fernando José de Portugal, Secretário de Estado dos Negócios do Brasil. Os estatutos do Banco do Brasil têm passado despercebidos aos olhos dos estudiosos. Um apagamento que a história do direito das sociedades por acções e do próprio direito bancário português não pode consentir. Vem de molde sublinhar que, em Portugal, no século XIX, os Bancos cresceram e multiplicaram-se à sombra da liberdade de constituição das sociedades anónimas permitida pela Lei de 22 de Julho de 1867²⁹.

8. No cotejo com o modelo societário proeminente no século XVIII em Portugal, o figurino jurídico do Banco do Brasil sustenta um confronto vitorioso. Os aspectos em que se avantajava eram múltiplos. Desde logo, uma definição clara do princípio da responsabilidade limitada. Os accionistas não respondiam «por mais cousa alguma acima do valor da entrada»³⁰. O capital social do Banco compunha-se de mil e duzentas acções, de um conto de réis cada uma, salvaguardando-se a possibilidade de futuros aumentos de capital. A nomenclatura e o engenho do direito das sociedades não cessavam de evoluir. Por ditame estatutário, constituía-se, no Banco do Brasil, um fundo de reserva que acumularia a sexta parte do que tocasse a cada acção³¹. Desaparecia assim a velha técnica do principal acrescentado que funcionara como fundo de reserva.

Mas onde a novidade faiscava com maior cintilância era na administração da sociedade. Como não se desconhece, o antigo modelo de governo das grandes sociedades portuguesas por acções fazia concentrar o poder na chamada «junta». Tratava-se do único órgão social existente. Dirigia e controlava a sociedade numa intencional confusão de atribuições, emitindo as suas ordens em sobranceira indiferença acerca da vontade dos accionistas.

28 Convirá não esquecer, porém, que, em golpe de inflexão, o Alvará de 30 de gosto de 1768 e o Alvará de 23 de Fevereiro de 1771 excluíram a força liberatória das acções. Vide RUI DE FIGUEIREDO MARCOS, *Apontamento histórico sobre a aquisição de acções próprias em Portugal. Da fantasia prática à magia do legislador*, in «Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura», Coimbra, 2003, págs. 271 e segs.

29 Os números falam por si. Em 1867, havia 11 Bancos no País. Em 1875, já se contavam por 51 os Bancos e as sociedades bancárias existentes em Portugal. Ver JOÃO PINTO DA COSTA LEITE, *Organização Bancária Portuguesa*, cit., págs. 23 e segs.

30 Veja-se o artigo III dos «Estatutos para o Banco Publico, Estabelecido em virtude do Alvará de 12 de Outubro de 1808».

31 Estipulava-o o artigo XIX dos Estatutos do Banco do Brasil.

Num lance progressivo e porventura inédito no nosso país, os estatutos do Banco do Brasil previam uma assembleia geral formada por quarenta dos seus maiores capitalistas, uma junta de dez e uma directoria constituída por quatro dos mais hábeis entre todos. Embora o Banco do Brasil admitisse sócios portugueses e estrangeiros, só podiam integrar a assembleia geral associados portugueses. Uma espécie de reserva patriótica³².

Um direito dos sócios que veio a lograr uma decisiva reponderação foi o direito de voto. Ao contrário do recorte legislativo setecentista em Portugal que afirmara o princípio do voto único, o Banco do Brasil acatou a tese oposta da proporcionalidade, embora com um travão. Para que um sócio dispusesse de direito de voto deliberativo, devia possuir, pelo menos, cinco acções. E quantas vezes perfizesse o dito cômputo, tantos votos teria na assembleia geral. Mas com um limite intransponível. Nenhum dos sócios, fosse por que motivo fosse, podia reunir em si próprio mais do que quatro votos³³. Em contraste com o passado societário português, forjava-se agora um panorama menos desfavorável aos sócios no que tocava à possibilidade de influir nos destinos da sociedade. Ainda assim, porém, o enlevo dos sócios pelos estatutos do Banco do Brasil decerto luziria apenas aos olhos dos ricos titulares das grandes participações accionárias que seriam, do mesmo passo, os senhores da maioria dos sufrágios.

9. Acompanharemos, doravante, as diferentes fases que o Banco do Brasil atravessou. Começou de um modo hesitante³⁴. Foi preciso aguardar um ano para que alcançasse o montante mínimo de subscrição de acções, imprescindível ao arranque da actividade. Na verdade, o Banco apenas podia iniciar o seu giro quando houvesse em caixa cem acções³⁵.

Diante dum quadro tão periclitante, não admira que, em 1812, o legislador lhe procurasse inculir um novo fôlego. E fê-lo através de um concerto de benemerências legais.

Num «Plano para o effectivo Melhoramento das Finanças Portuguezas no Rio de Janeiro», um documento que veio a lume em 6 de Fevereiro de 1812, o autor salientava as limitadas forças do Banco do Brasil e não omitia que tais forças se achavam então em grande risco «pelo abuzo que dellas se tem feito», sendo o Banco chamado em socorro do Estado. Apesar de tudo, mostrava-se esperançoso quando eram «novamente convidados os Negociantes de maior credito tanto Nacionais como Estrangeiros, sendo prometido honras e mercês aos que mais se distinguem em suas entradas no Banco»³⁶. Uma fonte que, insofismavelmente, confirma o cenário que se irá traçar.

32 Sobre o que se acaba de assinalar, ver os artigos IX e X dos Estatutos do Banco do Brasil.

33 Nesta matéria, o projecto do Banco Real Brigantino de 1797 consentia, um tanto perigosamente, que fosse a assembleia geral a determinar quantos votos teria um sócio que em si reunisse a titularidade de muitas acções. Pronunciava-se neste sentido o artigo 5.º do título III dos Estatutos.

34 Acerca das dificuldades que rodearam o início do funcionamento do Banco do Brasil, ver AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, *História do Banco do Brasil*, vol. I, Rio de Janeiro, 1979, págs 29 e segs.

35 Assim o impunha o artigo I dos Estatutos.

36 Ver Academia das Ciências de Lisboa, ms 648, n.º 34, fls. 283 e segs., em especial no tocante ao ponto em apreço, fl. 290 f. e v.

10. Em foco estiveram duas providências legislativas. Uma, como estímulo à realização do capital social, concedia honras e mercês aos subscritores de acções do Banco do Brasil³⁷. A significar que se reacendia a luminária cativante da velha linha de nobilitação dos grandes accionistas das Companhias de comércio setecentistas, a qual marcara a cisão entre nobreza originária e nobreza adquirida³⁸.

À vista dos sócios, isto juntava-se a um enorme privilégio jurídico já constante dos Estatutos do Banco. Radicava na insusceptibilidade de as acções do Banco serem objecto de penhora ou de execução, quer fiscal, quer civil³⁹. Por conseguinte, as participações sociais não respondiam perante os credores particulares dos sócios.

De subido relevo, cumpre apontar, em segundo lugar, a entrada da Fazenda Real no Banco do Brasil. Mas tudo envolto num regime jurídico assaz engenhoso. Pelo Alvará de 20 de Outubro de 1812, foram estabelecidos vários impostos que se destinavam a alimentar o Banco do Brasil.

Com tal intuito, passaram a tributar-se, posto que de modo diferenciado, as carruagens ou seges de quatro e duas rodas, bem como as lojas, armazéns ou sobrados, em que se vendesse, quer por grosso e atacado, quer a retalho e varejado. Também a propriedade de navios de três mastros e das diversas embarcações de dois ou de um mastro e, inclusive, de menor lote não escapavam à alargada incidência fiscal⁴⁰.

Durante dez anos, nos termos da lei, o produto dos novos impostos convertia-se em participação accionista da Fazenda Real. Só que, ao longo dos primeiros cinco anos, a Fazenda Real abdicava de quinhão nos lucros das suas acções em proveito dos outros sócios. Esgotado esse prazo, a Fazenda Real exercia, como era de preceito, o direito aos lucros.

O mencionado diploma de 1812 voltava a inserir o Banco do Brasil numa linha de continuidade histórico-societária no que tocava à existência de um poder de *iurisdictio* privativo. Pretendemos aludir à persistência das chamadas conservatórias das Companhias, cujas raízes, em Portugal, se alongam às sociedades comerciais da primeira metade do século XVII⁴¹. E agora surgia, de regresso, com a lei de D. João VI, o juiz privativo da sociedade, acompanhado do inerente privilégio avocatório de todas as causas e pendências que envolvessem o Banco do Brasil. Os ganhos de celeridade processual antolhavam-se evidentes. Demais a mais, quando o lugar deveria ser ocupado por um desembargador da Casa da Suplicação do Brasil⁴².

11. O sopro de 1812 suscitou um acicate forte à sua índole de Banco emissor de papel-moeda, sobretudo a partir de 1814. Uma tendência que tanto se sobrepujou que se tornaria nefasta, criando um clima propício ao tempo borrascoso que o Banco do Brasil viria, mais tarde, a conhecer.

37 Ver AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, *História do Banco do Brasil*, vol. I, cit., págs. 40 e segs.

38 No que respeita à dignificação da actividade mercantil e à nobilitação dos grandes accionistas no século XVIII, ver RUI DE FIGUEIREDO MARCOS, *As Companhias Pombalinas*, cit., págs. 301 e segs., e págs. 622 e segs., respectivamente.

39 Ver Estatutos do Banco do Brasil, artigo VI.

40 Ver Alvará de 20 de Outubro de 1812, §§ I, II e III.

41 Ver Alvará de 20 de Outubro de 1812, § XI.

42 Ver RUI DE FIGUEIREDO MARCOS, *A Conservatória das Companhias Setecentistas Portuguesas*, in «1.^{as} Jornadas de História do Direito Hispânico», Lisboa, 2004, págs. 285 e segs.

Os estímulos provocaram uma certa vertigem na administração do Banco. A quantidade do papel-moeda em circulação disparou. Os estatutos não previam nenhum limite, nem sequer um simples mecanismo de controlo das emissões de papel-moeda. De feição que não se tiveram em linha de conta as necessidades do mercado e muito menos se atendeu ao volume de fundos metálicos que deviam afiançar tais emissões a título de garantia. Nenhum cuidado houve em observar uma prudente regra de proporção entre as notas em giro e a existência de fundos que os pudessem pagar quando o papel fosse apresentado a desconto⁴³.

Um factor que muito embaraçou o Banco do Brasil residiu na amiudada interferência do governo na administração. Há muito que tamanho risco se encontrava detectado no panorama societário português. No século XVIII, caso se verificasse uma mudança no quadro normativo que regia a sociedade, assistia aos sócios o direito de exoneração, ou seja, o direito de se retirar da sociedade, recebendo o capital representativo das suas acções acompanhado dos lucros que até à altura lhe coubessem. Bem ostensivo revelava-se um artigo do projecto dos estatutos do Banco Nacional Brigantino que proibia a intromissão dos ministros nos actos eleitorais do Banco. A qualquer ingerência estava reservada uma severa punição⁴⁴.

O Banco do Brasil viu-se implicado em vultuosas obras públicas. A construção de edifícios estaduais fez-se à custa de crédito concedido pelo Banco. Não admira, pois, que, uma vez infiltrado o interesse público na lógica capitalista do Banco, o Alvará de 24 de Setembro de 1814 aparecesse, à guisa de regalia jurídica compensadora, a permitir que o regime da execução das dívidas fiscais se aplicasse às dívidas ao Banco do Brasil.

Do mesmo passo constituía um sinal evidente da protecção que o estabelecimento bancário merecia ao soberano. Por isso, houve por bem estabelecer que «as dívidas pertencentes ao Banco do Brasil, sejam reputadas em tudo, e por tudo, como Fiscaes, procedendo-se sem diferença alguma na sua cobrança e arrecadação»⁴⁵.

12. O Banco do Brasil ainda viria a agarrar-se ao Decreto de 23 de Março de 1821 como um moribundo à dobra de um lençol. O diploma assumiu, coerentemente, o passivo do Banco como dívida nacional, porquanto, em larga medida, o que o suscitara fora o financiamento desenfreado da despesa pública, tendo, inclusive, sido prestada a garantia de cumprimento por parte do Real Erário, através da *traditio* de diamantes e jóias. Um empréstimo externo também se contraiu para salvar o Banco.

Entretanto, o regresso da Corte a Lisboa não ajudou o destino do Banco. Desvaneceram-se os anteriores gestos legislativos de amparo régio. A Independência do Brasil não sustou a queda e a extinção do Banco acabaria por ser decretada em 23 de Setembro de 1829⁴⁶.

Vai longa a exposição. Será, com certeza, fruto de algum excesso de amabilidade elogiosa reputar o Banco do Brasil como um dos máximos benefícios políticos de D. João VI e um

43 Neste sentido, ver JOSÉ LUÍS CARDOSO, *Banco do Brasil (1808-1829)*, in «Dicionário de História Empresarial Portuguesa. Séculos XIX e XX», coordenação de MIGUEL FIGUEIRA DE FARIA e JOSÉ AMADO MENDES, vol. I (*Instituições Bancárias*), Lisboa, 2013, págs. 206 e segs., em especial, pág. 208.

44 Ver *Projecto do Banco Real Brigantino*, título III, artigo 3.º, in loc. cit., pág. 30.

45 É o que rezava o Alvará de 24 de Setembro de 1814.

46 Ver JOSÉ LUÍS CARDOSO, *Novos elementos para a história do Banco do Brasil (1808-1829): crónica de um fracasso anunciado*, in «Revista Brasileira de História», vol. 30, n.º 59 (2010), págs. 167 e segs., especialmente, págs. 179 e segs.

monumento de excelência do sistema liberal do Brasil. Do cimo desta convicção generosa, José da Silva Lisboa entendia, sem reboço, dever considerar-se a «Fundação do Banco do Brasil como abertura de inexaurível Mina Rica, Thesouro do Credito Nacional, e Grande Machina de economizar tempo e trabalho no giro mercantil»⁴⁷. Mas se vibração amorosa houve no juízo de Silva Lisboa, já não subsistirá réstia de exagero afirmar que a criação do Banco do Brasil assinala um ponto rútilo no trilho histórico logradamente progressivo do direito bancário luso-brasileiro.

⁴⁷ Ver JOSÉ DA SILVA LISBOA, *Memória dos Benefícios Políticos do Governo de El-Rey Nosso Senhor D. João VI*, cit., págs. 94 e 96.



LA FUNCION DE LOS ARGENTARII EN LA SUBASTA ROMANA

OLGA GIL GARCÍA
UNIVERSIDAD DE BURGOS

SUMARIO: 1. Subasta 2. Banqueros en las subastas, principalmente *argentarii*, *coactores* y *coactores argentarii* 3. Fases e intervención del banquero 4. Tipos 4.1 Subastas entre particulares y de bienes de origen privado: 4.1 a) Subasta voluntaria 4.1 b) Subasta forzosa: *Bonorum venditio*. 4.2 Subastas de bienes o servicios en el ámbito público. 5. Conclusiones.

1. SUBASTA

Muchas de las funciones que hoy día desempeña la banca, ya eran tareas que atendían las sociedades de banqueros y el propio banquero romano. Pero algunas nos llaman la atención singularmente, se trata de su participación en las subastas tanto de bienes privados, como públicos. Para estudiar más detenidamente estos cometidos, deberemos aproximarnos primero a los sujetos destinados a estas funciones bancarias para observar que papel ocupan en cada una de ellas.

Respecto de la subasta sabemos que es una forma de determinación del precio en una transacción, y es tan versátil que se conoce en múltiples culturas desde la antigüedad hasta la actualidad. Respecto a la terminología en español, hablamos de subasta o de almoneda para referirnos al concepto que tratamos de venta pública al mejor postor¹. Si atendemos a nuestro ordenamiento jurídico actual la celebración de una subasta pública se define como el ofertar, pública e irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste inicialmente, o mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto².

1 GARCÍA SÁNCHEZ, J. *La laesio enormis y el precio de la subasta*. Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano. Murcia. 1998. pp 75-77. Desarrolla el término y su significado con detalle.

2 Art. 56.1 ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Históricamente, tenemos noticias de ella en culturas como la egipcia, la griega, y por supuesto en Roma y se mantiene en el tiempo hasta la actualidad. Se aplica a múltiples negocios, ya sea públicos, ya sea privados. Documentalmente se adapta asombrosamente al momento, desde las tablillas, al papel o a la forma electrónica, pero su esencia es la misma, ofrecer varios precios para un bien, una obligación o un derecho, durante un tiempo de licitación y elegir así al adjudicatario más conveniente, quien ofrece la *melior conditio*. Se dice de la subasta que es tan vieja como el mundo, pero en Roma su origen se vincula al momento de la aparición del dinero³, cuando a un bien le corresponde un valor en moneda, y para conocer cuál es ese valor de cambio, se acude a la subasta. Este sistema, de forma dinámica da un valor de mercado para un lugar y un momento concreto. Pero la subasta es un instituto procesal para determinación de un precio, y como tal, la encontramos en realidades jurídicas absolutamente diversas, principalmente en ventas, en adjudicaciones forzosas, en concesión de servicios públicos, suministros, o ejecuciones de obra, como veremos más adelante. Y como consecuencia del manejo de dinero, aparecen diferentes sujetos que financian estas operaciones.

2. BANQUEROS EN LAS SUBASTAS, PRINCIPALMENTE *ARGENTARII*, *COACTORES* Y *COACTORES ARGENTARII*

Las primeras menciones de agentes bancarios en las subastas datan del siglo I a. C., concretamente con la intervención de los *coactores* y los *argentarii*; medio siglo más tarde, desde el último siglo de la República, los *coactores argentarii* se ocuparán además de la intermediación financiera en las subastas. En cuanto a las últimas menciones sobre las figuras del *coactor* y la del *argentarius*⁴ en el entorno de las subastas datan de la segunda mitad del siglo II d. C. y la del *coactor argentarius* un siglo después, en el siglo III d. C.

La intervención de los banqueros en las subastas, era usual en Grecia⁵ y en Roma durante los siglos III y II a. C., desarrollaban tareas relacionadas con las formas de pago, los contratos que se suscriben y con los registros de las subastas. La intervención de banqueros en ellas parece improbable con anterioridad al siglo I a. C. tal como indican TALAMANCA y ANDREAU⁶. Su función en las subastas puede venir dada de que resultara más rentable

3 GARCIA GARRIDO, M. J. El comercio, los negocios y las finanzas en el Mundo Romano. Madrid. 2001. pp 22 y ss.

4 MARQUES DOS SANTOS. C., *Reporte Inmobiliario. 2003-2004 Historia de la subasta y el corretaje*. <http://www.reporteinmobiliario.com/nuke> Este autor considera que el corredor de comercio tuvo funciones de mediador en la subasta como el *argentarius*. Y que en las Partidas (ley XXXVI Tit. XVI, Partida III) ya se conoce el corretaje, y ese derecho de corretaje en las subastas daba derechos de cobro de una sisa. Según el autor intervenían sobretodo en negociaciones públicas, y debían tener capacidad legal, pasar un examen ante la Curia, prestar juramento y ofrecer fianza. Estaban obligados por fidelidad, lealtad e imparcialidad, y no podían ser comerciantes, ni tomar interés, ni adquirir bienes en las ventas a su cargo.

5 PEÑALVER. M. A. *La Banca en Roma*. Madrid p. 19 cita a CUMONT. *Fouilles de Doura-Europos (1922-1923) I Paris. 1926. pp 291-292* Al parecer se hace referencia a un intermediario financiero en las subastas, que adelantaba la suma al vendedor, a cuenta del comprador, quien se convertía en deudor del banquero, atribución que luego adquieren los banqueros privados romanos en el Occidente romano.

6 TALAMANCA, M., *Contributi allo studio delle vendite all'asta del mondo classico*. Roma 1954. pp 110-114 y ANDREAU, J. *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV siècle ap.J.C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985). Rome : École Française de Rome, 1987 pp 64, 145-155.

acudir a un profesional, capaz de ocuparse tanto de la parte financiera como del aparato documental y organizativo de la venta, quienes además estaban radicados en el mercado y actuaban de forma permanente, y que se asentaron en urbes y enclaves comerciales donde era habitual la práctica de la subasta⁷. Sin embargo, el origen de la actividad bancaria en Roma, es anterior, concretamente tras las guerras púnicas⁸ en los siglos III y II a. C., por la necesidad del cambio de moneda, imprescindible para el desarrollo de su amplia actividad comercial⁹.

Otros sujetos con competencias en aspectos bancarios son además de los anteriores, los *mensarii* y *nummularii*. Los primeros, relacionados con las contratas públicas y los segundos, con operaciones de cambio de moneda¹⁰. Indicar que en asuntos de cambio, también los *argentarii* fueron encargados de verificar monedas extranjeras respecto a su calidad, valor y en su caso la falsedad o no, e incluso se recurrió a ellos para poner en circulación moneda nueva¹¹, también se dedicaban al cambio, la comprobación de moneda, al depósito. Los *coactores* se dedicaban al cobro a deudores, con reintegro a los acreedores, cobrando una comisión, un tanto, llamado *merces*. No concedían crédito en las subastas, función que si asumen el *argentarius* y el *coactor argentarius* a partir de finales de la República, también se ocupaban del registro de las ventas, geográficamente se localizan en el eje Roma-Ostia-Portus.

Los *coactores argentarii* desempeñan las funciones de los dos anteriores. Las primeras referencias son de finales de la República y las últimas del siglo III d.C. Su presencia es mucho más amplia geográficamente hablando. Así no sólo en Roma y su zona de influencia directa, sino también en provincias. Como *coactores*, cobran la venta y entregan el objeto, y como *argentarius* se ocupan de las funciones financieras de las operaciones en las que intervienen, abren cuentas de depósito y abordan las tareas documentales y de registro de la subasta. Su actividad se centra en un mismo lugar, normalmente el mercado, con operaciones de cantidades no muy cuantiosas, con préstamos a tan corto plazo que en el contexto de las subastas, quizás no fueran sino modos de pago aplazados, realización de cobros y pagos relacionados con servicios de depósito y caja¹². No parece que tuvieran encargadas operaciones económicas de gran envergadura, éstas se reservaban a los actores económicos

7 ANDREAU, J. *La vie financière dans* cit. p. 109

8 PEÑALVER. *La banca en Roma*. Madrid. pp. 19 y 20, explica su origen en ese momento histórico por la conjunción de varias razones, así la necesidad de avituallamiento y abastecimiento de los ejércitos, junto a la necesidad de cambio por el contacto entre diferentes monedas, y la acumulación de riquezas en manos de senadores y caballeros.

9 PEÑALVER, M.A., *La banca en Roma*. cit.. p. 17, nos indica como el origen estaba en las ofrendas hechas a los dioses en los templos

10 GARCIA GARRIDO, El comercio,... cit. pp. 32 y ss, considera agentes, factores e intermediarios financieros a los *argentarii*, los *nummularii*, los *praecones*, los *coactores*, *coactores argentarii*, los *stipulatores argentarii*, *collectarii*, *mensularii*, y *trapezitae*, y en sociedades las *mensae argentariae* y las *societates argentariorum*, pero no las tratamos porque no todos ellos tenían ocupaciones en la subasta. PEÑALVER, M.A., *La banca en Roma*. cit.. p. 23 separa los banqueros privados, *argentarii*, de los banqueros públicos *mensarii*, *nummularii* y *argentarius coactor*, aunque éste último no parece que se dedique sólo a asuntos públicos.

11 DARENBERG, SAGLIO, POTIER, LAFAYE, voz *Argentarii*, en *Dictionnaire des antiquités grecques et latines*. Paris 1877. pp. 406-7

12 Vid. ANDREAU. *La vie financière dans le monde romain*. ... cit. pp. 157-174.

de las élites sociales. Su función parece ser la de intermediarios comerciales. Según TALAMANCA la intermediación en el crédito fue con toda probabilidad la función originaria del *argentarius coactor* en la venta por subasta¹³ y aunque se recoge su intervención en todas las subastas conocidas, según los documentos y las fuentes jurídicas con las que contamos, posiblemente ésta no fuera obligatoria¹⁴.

La actividad financiera no sólo se desempeña de forma individual, los banqueros en ocasiones se asocian en *societas argentariorum*¹⁵. Será en el ámbito de las contratas públicas, y para el cobro de impuestos donde se conocen las sociedades de los publicanos, que se constituían para acudir a concursos sucesivos de contratas de obras, o de cobro de impuestos, explotaban minas, empresas de cerámica, vidrio... invertían continuamente los capitales y las ganancias obtenidas en sus negocios económicamente más relevantes¹⁶ pero que a la postre se autofinanciaban. En ellas los banqueros que hemos señalado anteriormente no participan, y menos con carácter individual, dadas las cuantías que se manejan. Las *societas publicanorum* se especializan en el préstamo de inversión, puesto que los préstamos dinerarios facilitados por los banqueros de profesión, *argentarii*, no se orientaban hacia la inversión, no eran capaces de discernir que además del préstamo al consumo podía existir el préstamo a la inversión, por lo que consecuentemente, no llegaron a existir establecimientos financieros especializados en este segundo tipo de préstamos¹⁷.

3. FASES DE LA SUBASTA E INTERVENCIÓN DEL BANQUERO EN ELLAS

La subasta, sea del tipo que sea, la podemos dividir en tres fases, anuncio o *proscriptio*, puja o *licitatio* y adjudicación con el registro de la operación.

Proscriptio es el anuncio de la subasta. En esta fase se emite un cartel con el anuncio de la citación de la subasta, que se proclama oralmente por el *praeco*. El anuncio, *libelli*, *tabula*, *tabella*, *titulus*, *libelus* contenía la lista de bienes, las condiciones de venta, la fecha y lugar de la subasta¹⁸ y daba publicidad al acontecimiento. La falta de determinación clara y con antelación suficiente de una subasta podía dar lugar a prácticas fraudulentas, consistentes en citar durante la celebración de los juegos o en señalar para su celebración un lugar remoto, si bien es cierto que acontecía más en las subastas de contrataciones públicas, que en las de derecho privado estricto o entre particulares. Hecho que critica el propio Cicerón,

13 TALAMANCA. Contributi allo studio delle vendite cit ...p 112

14 TALAMANCA. Contributi allo studio delle vendite cit t. p.114

15 GARCIA GARRIDO, *El comercio*,... cit. pp 55 y ss

16 GARCIA GARRIDO, *El comercio*,...cit pp 130-131. Señala este autor una sociedad de este tipo entre C. Quincio con gran patrimonio agropecuario y Sexto Nevio, *praeco*, que se dedicaban a la compra en subastas.

17 FERRER MAESTRO. J.J., *Los contratos publicos y el poder privado en la republica romana*. Castellon. POTESTAS. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867 p. 23

18 TALAMANCA *Vendite all'hasta*. ...cit. p.134.. PEREZ ALVAREZ P. *La bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho Romano clásico*. Madrid. 2000 p 155-166 opina, que la escasez de fuentes al respecto ha propiciado multitud de opiniones contradictorias sobre el concepto, origen, la función y el procedimiento de la *proscriptio* aunque concluye con la mayoría que la función principal es la de dar publicidad a las proclamas, con el fin de ayudar a extender el conocimiento de la situación de insolvencia a otros acreedores, para que concurran en su caso a la *bonorum venditio*, y así amigos del deudor acudan a pagar la deuda o traigan a terceros compradores a la ejecución.

y que compara con la venta de bienes de deudores en el ámbito privado que procuran vender en el mercado a ojos de todos¹⁹. Respecto al precio se determina uno de salida²⁰ y antes de la licitación se pueden revisar los bienes. Es importante la descripción de los posibles defectos o irregularidades que deben quedar de manifiesto en la propia publicidad de la subasta para evitar problemas de saneamientos o de cargas.

La segunda fase es la de aceptación de ofertas y puja, o *licitatio*. El *praeco* advierte los gestos de los compradores y determina el sujeto señalado para la adjudicación. Y la tercera será la adjudicación propiamente, en la que se elige la *melior conditio*. Este acuerdo queda plasmado en documento escrito. Será en esta fase en la que tenga más relieve la intervención de los banqueros romanos en sus diferentes manifestaciones, puesto que intervienen elaborando el contrato de *stipulatio* que cierra la operación y facilita los medios de pago con su financiación. Se dice que en algunas ocasiones la adjudicación resultaba provisional en D. 41,4,2, 8-9 (Paul. 54 ad ed.) en una venta de bienes del pupilo por parte del tutor, o D. 23,3,78,4 (Tryph. 11 disput.) en el caso de un marido que vende en pública subasta un fundo de los bienes dotales de su mujer. Pero esta afirmación es discutible, dado que la existencia de la *actio redhibitoria*, por la que el comprador podía resolver la compra por defectos en el bien, o por incumplimiento de las condiciones del contrato, son comunes a cualquier tipo de venta, por lo tanto no varía el que se lleve a cabo por subasta. No es un problema de provisionalidad de la adjudicación, que nace con vocación de permanencia, es *a posteriori*, cuando se aprecia el defecto, y cuando de forma retroactiva se ve afectada la eficacia de la transmisión. Otra cosa es el pacto *in diem addictio* por el que se puede retrasar el remate²¹ a un momento posterior a la celebración de la propia subasta²², y si en ese tiempo se logra un precio mejor se puede cerrar la operación con ese nuevo adjudicatario.

4. TIPOS DE SUBASTAS

La subasta se aplica a varias realidades jurídicas. Es por ello por lo que necesitamos clasificar los distintos supuestos en los que se acude a la subasta y ver la participación del banquero romano en ellas. La clasificación que vamos a seguir será la que divide este fenómeno atendiendo a los sujetos y los bienes subastados. Así, cuando los sujetos son particulares y los bienes privados, las denominamos subastas entre particulares, y quedan sometidas a derecho privado y cuando los sujetos que intervienen son funcionarios o magistrados y los bienes públicos, estaremos ante subastas de derecho público²³.

19 CICERON In Verres actio. 2,54.

20 GARCIA SANCHEZ, *La laesio enormis ... cit* pp 75 y ss.

21 MARQUES DOS SANTOS, *Historia de la subasta y el corretaje*.cit Advierte que el término remate aparece en el Fuero Real.

22 En D. 18,2,1 Paulo señala el modo de la adjudicación a término. Después de la determinación del precio se espera hasta las próximas calendas por si hay una mejor oferta, y entonces cambia la titularidad de la propiedad.

23 Precisamente la diferencia entre las subastas del mundo romano y del heleno es que en Roma, existe la subasta organizada de forma privada al margen de las autoridades públicas, así GARCIA MORCILLO *Las ventas por subasta ... cit* pp 38-39. Esta autora nos advierte de la gran especialización en el funcionariado que intervenía en las subastas helenas, que no encontramos en el mundo romano. Otro elemento de distinción lo será en el ámbito bancario, dado que la banca real como organismo del cobro del precio de venta, no se puede

4.1. Subastas entre particulares²⁴ y de bienes de origen privado

Dentro de las subastas entre particulares debemos a su vez separar dos casos, aquel que supone acudir a una subasta en un entorno mercantil libre, en el que ambas partes contratantes están en situación de igualdad, por tanto un negocio jurídico voluntario, cuyo contexto habitual es una compraventa, y por otra parte, caso distinto es acudir a una subasta para la realización de bienes de forma no voluntaria, lo que supone la ejecución forzosa de bienes.

4.1 a) Subasta voluntaria

En este tipo de subastas es dónde la intervención del banquero romano adquiere más importancia, como mediador entre comprador y vendedor. En Roma el banquero intervenía en las *auktiones argentariae* con o sin pacto *in diem addictio*²⁵ y entablaba dos relaciones paralelas una con el vendedor y otra con el comprador. Atendiendo al objeto y según ANDREAU distinguimos tres tipos de subastas de derecho privado, con intervención de banqueros: las ventas ocasionales normalmente consecuencia de un fallecimiento, las ventas periódicas de productos agrícolas solicitadas por los propietarios de las tierras o por los explotadores de los fundos, y las ventas organizadas por comerciantes en días de mercado²⁶.

La relación del banquero con el vendedor consiste en recoger ese encargo de venta, cerrando el precio por una *stipulatio* y hacerle efectivo el pago, hecho que recogerá en sus libros contables. Es muy probable que la cosa vendida quedara en custodia para poder ser vista por los licitadores, y que este hecho supusiera que el vendedor pudiera disfrutar de una cuenta de crédito, dada su condición de cliente habitual del banquero. El dueño contaba con el banquero para obtener un mayor y mejor número de posibles ofertas, de ahí, que con el vendedor compensara operaciones diferentes, realizara cobros, pagos, préstamos, adquisiciones,...

Por otro lado, el banquero con el comprador acordaba, por medio de *stipulatio*, el precio de adjudicación y las condiciones de pago, que bien podía ser al contado, con lo que su función era sólo cobrar el precio y entregarle la cosa. O bien pago a plazo, que era la ocasión para ofrecer sus servicios de financiación²⁷. Ciertamente sabemos que los plazos que se manejaban en ningún caso superaban el año, lo que hacer pensar si en realidad estamos ante un préstamo o simplemente a un pago aplazado.

comparar con el papel del banquero privado romano, quien por otro lado sí que tenía una función de financiación y concesión de crédito. Sí es común en ambos casos la percepción de una comisión de una tasa porcentual que también cobra el heraldo griego.

24 GARCIA MORCILLO, M., *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*. Barcelona 2005. Es interesante la consulta de esta monografía, para tener una visión general de la subasta privada en Roma desde el punto de vista histórico.

25 SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho Romano*. Mexico 2007. p 52.

26 ANDREAU, *Vie financière dans le monde romain..... cit . pp 74-76*

27 SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, ...cit pp 57-58*.

Pero más interesante resulta el valor fiduciario que adquiere el dinero, así el vendedor puede no cobrar al contado, sino aplazando el cobro por la apertura de un depósito o un acuerdo de crédito con el banquero, retirando la suma por plazos o en un término fijo, y quizá obteniendo un interés por ello. El banquero podía reutilizar el dinero y devolver el equivalente, *tantundem*, sin constituir un depósito sellado. Para que el pago fuera efectivo se cuenta con la mediación de los banqueros dada la necesidad de presentar garantías: *pignus*, *fiducia* o *hypotheca*. Cuando se garantiza el pago, en la práctica se está aceptando un pago a término, y se concede un crédito por parte del vendedor²⁸. Si este pago no se satisface en tiempo, el acreedor dispone de los bienes dejados en garantía. Concretamente las tablillas concernientes a las *auktiones* del archivo de *Jucundus* son el reconocimiento del vendedor del recibo del pago por parte del banquero con quien le unía un contrato de *stipulatio*. Al parecer los recibos A y B, indican, el primero, el escrito a instancia o por el banquero en que se concreta que el vendedor ha recibido el precio, y el segundo, B, a instancia o escrito por el vendedor o su representante, quien reconoce el pago. El pago que recibe el vendedor viene minorado por el pago de la *mercede minus*. El objeto de la venta no queda indicado, aunque se puede llegar a determinar en varios casos. Y el Acta de la venta, fechada más tarde, acompañada de varios testimonios estará precedida por el crédito del banquero al comprador sobre el precio de compra²⁹. Finalmente los recibos presentan otra segunda fecha con el plazo, inferior a un año, que es el tiempo en el que el comprador debe satisfacer la deuda con el banquero³⁰.

Estos compromisos del banquero con el comprador y vendedor resultan paralelos y coetáneos pero no hay nexo entre comprador y vendedor como se demuestra en dos casos relatados en el Digesto. El primero a propósito de una venta de legado por un heredero, contando con la intermediación del banquero, D. 5,3,18 pr (Ulp. 15 ad ed.) aquí la insolvencia del banquero provoca el impago al heredero y lo que es peor la imposibilidad de reclamación del precio directa al comprador. Y el segundo caso, en D. 46,3,88 (Scaev. 5 dig.) cuando una madre confía al *argentarius* la venta en subasta de propiedades de su hija, y esta última reclama la cantidad a los banqueros al representar a un no propietario. Estos presentan sus libros con la operación registrada, la *stipulatio* que le comprometía con la madre solamente, y como el pago ya se había hecho a la madre este hecho fue suficiente para que no prosperara la reclamación de la hija. De ahí el gran valor probatorio de los documentos que conserva el banquero y al que nos referiremos brevemente, más adelante.

El pago a término queda plasmado en la *stipulatio* como el contrato que recoge todas las condiciones de la operación, tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado. El *stipulator* pregunta al *promissor* y la respuesta de éste plasmada por escrito les vincula *ad*

28 En las *Comedias* de Plauto, men. 1159 Merc. 485-495 se observa ese pago a término y en *Vitarum Actio* de Luciano, Vic. Auct.1 contempla el pago a término y el pago con garantía en la subasta de filósofos que plantea, siendo que se admite garantía sólo para uno de ellos, el más valioso, la vida de los demás se paga al contado, evidenciando así su poco valor.

29 ANDREAU. J. *Les affaires de Monsieur Jucundus*. Rome : École Française de Rome, 1974, 408 p. (Publications de l'École française de Rome, 19) http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0000-0000_1974_mon_19_pp 17-18

30 ANDREAU, *Les Affaires del M. Jucundus*. cit. pp 99-100

solemnitatem. Las formas escritas de este contrato podían ser *diversas cautio, instrumentum, epistula, scriptum, subscriptio o chyrographum* y se exigían para tener carácter probatorio³¹.

La intervención de los banqueros romanos acontece precisamente en el pago acordado por *stipulatio en auctiones* de carácter privado. Así el *argentarius* o *coactor argentarius* interviene en estas actuaciones adelantando el pago al vendedor y fiando al comprador. Así tenemos referencias en las tablillas de *Lucius Caecilius Jucundus*, como en el archivo de los *Sulpicii* o la *lex metalli Vispaciensis*. Su intervención queda plasmada cuando incluso interviene para valorar las condiciones más favorables para conceder la adjudicación a un comprador. En D.18,2,4, (Ulp. 28 ad Sab.) considera mejor condición a igual precio el pronto pago del comprador, el lugar más oportuno e incluso el que el comprador sea una persona con más prestigio, o que no se constituya fianza, es decir, todo lo que sea útil para el vendedor debe tenerse como mejor condición. De hecho con el comprador también media una *stipulatio*. A la *stipulatio* cabe oponer excepciones por parte del adjudicatario, así en D. 44.4.5.4 de Paulo en el que se señalan las *exceptiones argentariae*, es decir, la *exceptio redhibitionis*, para caso de vicios ocultos, y la *exceptio mercis non traditae* si la cosa no se ha entregado aún.

Actualmente la compra por subasta en el ámbito privado puede parecernos lejana, pero en cuanto miramos a nuestro alrededor resulta frecuente, así las subastas habituales de mercaderías perecederas en puerto, las subastas de arte...y cada vez está más presente la venta por subasta en internet. Así hay fenómenos que nos lo indican y webs dedicadas a este tipo de venta por ejemplo ebay, y tradicionales ventas de monte de piedad de objetos dejados en depósito³². Precisamente estas últimas son ejemplo claro de intervención directa del banquero dado que es el vendedor e incluso el anunciante de los objetos de su montepío. En ellas se abren pujas y el valor del bien va subiendo durante un tiempo y se acaba adjudicando al mejor postor. Pero en todas ellas la intervención del banquero es un hecho, y resulta imprescindible por nuestra forma de pago, que además de la moneda utiliza el pago electrónico, como sucede cada vez más frecuentemente, con una tarjeta de crédito o débito. Esto no es otra cosa que financiación inmediata al comprador. El ser clientes de un banco determinado, en el que tenemos depósitos o productos que acreditan nuestra solvencia hace que podamos disponer de cierta cantidad diaria, o mensual sin más. Todo porque en ese banco tenemos depósitos suficientes para garantizar esos pagos. En el ámbito privado se regulan las subastas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y su capítulo V, se dedica precisamente a la venta en pública subasta³³.

Es curioso como la ley cuando define el contrato de subasta en el art. 57, también utiliza el verbo estipular³⁴. Pero aquí es la casa de subastas y no el *argentarius* quien cobra por

31 BIONDI, B. *Contratto e stipulatio*. Milano. 1953 p. 301.

32 Hemos elegido como ejemplo en el portal de La Caixa donde se anuncian continuas subastas https://portal2.lacaixa.es/apl/subastas/index_es.html

33 En la ley se fija su aplicación para aquellas empresas que se dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor. Las subastas de títulos, así como las subastas judiciales y administrativas, se regirán por su normativa específica. Esta ley ya está revisada por la *Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias* («B.O.E.» 20 diciembre). Vigencia: 9 enero 2003.

34 Concretamente dice que “En el supuesto de que los bienes a subastar no pertenezcan a la empresa que desarrolla esta actividad, las relaciones con el propietario de los mismos se ajustarán a lo estipulado entre las partes de acuerdo con la normativa general sobre contratación”

sus servicios aunque de forma diferente, así según la norma, todos los gastos de la subasta, incluidos los de custodia y, en su caso tasación, corresponden a la empresa de subastas, sin que el propietario deba entregar por este concepto remuneración adicional alguna, fuera del precio o gratificación establecido. En Roma se resta del precio que se cobra la *merces* que cobra el banquero. Y es curioso que al igual que el *argentarius*, la referida empresa, tenga la obligación de custodia y exposición de los bienes³⁵. También el encargo de la subasta, como hacía el banquero romano se deberá documentar por escrito en el que se identificarán las partes, el objeto y condiciones de la venta, así como la retribución de la empresa subastadora.

Como ocurriera en Roma también tiene tres fases. La primera el anuncio de la oferta de venta en subasta, (art. 58) que deberá contener una descripción veraz de los objetos que salen a la misma, con identificación de si sus calidades son ciertas o, simplemente, supuestas o averdadas por determinado experto³⁶. Y también como entonces la empresa tiene la posibilidad de pedir la constitución de fianza, hoy también a los licitadores, cuando expresamente se haya consignado esta condición en los anuncios de la subasta, aunque en ningún caso, el importe de las fianzas podrá ser superior al 5 por 100 del precio de salida de los bienes en cuya licitación se quiera participar³⁷. Sin embargo, en Roma la fianza parece que se constituyó sólo con el adjudicatario de los bienes y hasta el momento del pago, no con los licitadores. Por supuesto, nuestra ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista incluye el deber de documentación, en su artículo 60, es decir, adjudicado un bien se consignará inmediatamente por escrito procediéndose a la entrega del mismo una vez satisfecho el precio del remate. Las ventas en pública subasta deberán, necesariamente formalizarse mediante documento público o privado que, en su caso, podrá ser otorgado por la empresa subastadora como mandataria del propietario del bien subastado. Asimismo, la empresa subastadora responderá solidariamente con el titular del bien subastado por la falta de conformidad de éste con el anuncio de la subasta, así como por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, cuando hubiese incumplido las obligaciones de información que le impone el artículo 58 de la presente Ley.

35 La ley añade también el deber de inclusión en el catálogo, salvo estipulación en contrario.

36 Art. 58.2. En especial, cuando, en salas especializadas en objetos de arte o de valor, se oferte la venta en subasta de una imitación o de un artículo que, aunque aparentemente precioso, no lo sea en realidad, deberá hacerse constar, expresamente, esta circunstancia tanto en los anuncios como en las invitaciones en las pujas. Cuando se oferte la venta en subasta de un objeto acompañado del nombre o de las iniciales de un determinado autor o precisando que aparece firmado por el mismo, se considerará que se vende como original de dicho autor, a menos que consten con claridad las oportunas advertencias. 3. Lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo será también de aplicación a las ventas de objetos preciosos o artísticos que se oferten al público en forma distinta a la subasta.

37 Art 59.2 La fianza constituida por los licitadores a quienes no hubiese sido adjudicado el remate les deberá ser reintegrada dentro del plazo máximo de tres días a contar desde la finalización del acto. 3. En el caso de que el rematante no satisfaga el precio en las condiciones en que se hizo la adjudicación, perderá la fianza constituida que, en defecto de pacto, corresponderá al titular del bien subastado, una vez deducido el premio o comisión atribuible a la empresa subastadora, sin perjuicio del derecho del vendedor a exigir el cumplimiento del contrato.

Es decir, este tipo de subasta de bienes privados se da en el mercado, son frecuentes, voluntarias y con igualdad de partes y por tanto los fenómenos especulativos son menos probables.

4.1 b) Subasta forzada

Son aquellas subastas de bienes privados del deudor que no ha satisfecho su prestación y deberá saldar su deuda de forma obligada. Aquí no hablamos de venta, pues su naturaleza jurídica no es la de negocio jurídico, porque no existe voluntad en el deudor. En este caso estamos ante un acto procesal que provocará el cambio de titularidad del bien³⁸, pero que en ningún caso será un negocio jurídico, ya que el deudor ha perdido su capacidad negociadora dada la necesidad de hacer frente a sus pagos.

En Roma la ejecución es más compleja dado su origen en la ejecución personal, y no ser sólo patrimonial. De ahí, que dentro de esta última, primero se conciba como universal, y posteriormente se describa la ejecución singular. Pero a los efectos de este trabajo nos interesan ambas, por ser coetáneas con la aparición del banquero en Roma³⁹. Concretamente el concurso o la *bonorum venditio* se introduce por el pretor en el siglo II a. C.⁴⁰. Así, encontramos la ejecución universal, cuando lo que se enajena por subasta es un patrimonio, y además colectiva, cuando éste resulta insuficiente para satisfacer a varios acreedores. Por otro lado, también acudiremos a la subasta de un bien concreto por parte del acreedor, cuando se enajena un bien o bienes del deudor que estaban garantizando una deuda. Aquí el patrimonio del deudor es suficiente para satisfacer lo debido y lo que se plantea es un problema de liquidez, no de solvencia. Señala KUNKEL⁴¹ que hasta la *cognitio extraordinem* la ejecución general o concurso no quedaba limitada a los casos de insolvencia. A partir de una Constitución de Antonino Pio, D.42,1,31 (Calist. 2 cognit.) el magistrado otorgaba al vencedor del litigio un derecho de prenda, que al cabo de un tiempo, dos meses, sin que el crédito quedara satisfecho daba origen a la venta por subasta y con ella al cobro de la deuda.

Estos procesos de ejecución tienen su origen en la *bonorum sectio*, contra deudores del Erario público que referiremos más adelante, aquí vamos a tratar la *bonorum venditio* que se caracteriza por su inicio a instancia de parte⁴², ya que cualquier acreedor puede solicitar al magistrado la *missio in bona*, quien la acepta y elabora un decreto que sirve de *proscriptio bonorum*, describiendo los bienes que estaban en su posesión para ser vendidos, con determinación de plazo, mayor si el deudor está vivo, quedando desde ese momento el deudor

38 MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*. Valencia. 2013. pp 652-653.

39 PEREZ ALVAREZ, *La bonorum venditio*. ... cit. pp 63 y ss, particularmente pero todo el texto en general es muy adecuado para estudiar el fenómeno de la *bonorum venditio*.

40 PEREZ ALVAREZ,., *La bonorum venditio*. cit, p 75.

41 KUNKEL. *Derecho Privado Romano*. Barcelona 1965 p 535

42 GARCIA MORCILLO. *Las ventas* ... cit p. 83. Como hemos visto el impulso procesal recaía en los acreedores privados, por orden del magistrado y lo introduce el pretor en el siglo II a.C. Y su contenido según la documentación del archivo puteolano de los *Sulpicii* era la descripción del bien, el nombre de su propietario, su entrega como *pignus* o *fiducia* a los *Sulpicii*, la fecha de la *proscriptio*, la de la subasta, y lugar de celebración coincidente con fechas de mercado, normalmente treinta días más tarde y la participación del *praeco*.

como mero detentador de sus bienes⁴³. La necesidad de conocer el pasivo hace que el magistrado pueda por decreto, y previa *causae cognitio*, permitir a los acreedores consultar y copiar registros, y sólo por segunda vez a aquél acreedor que lo solicite, si jura no utilizarlo con intenciones injuriosas. En D. 42,5,15,1 (Ulp. 62 ad ed.) se otorga a estos documentos gran veracidad. El anuncio debe ser público y estar expuesto el tiempo necesario, de ahí la queja de CICERON cuando niega que puedan venderse los bienes de *Quinctio* porque los *libelli* han sido arrancados nada más ser colocados. (Pro Quintc. XXIII.73). Mientras dura el proceso se *puede* nombrar por el magistrado un *curator bonorum*; para aquellos casos en los que administrar el patrimonio suponga la venta de bienes perecederos o actuaciones urgentes en el patrimonio, que excedan la funciones de los acreedores y su representante, el *magister bonorum*, el primero resulta responsable frente a los segundos.

Una vez anunciada y publicada la subasta pasamos a la fase de *addictio*, o adjudicación de los bienes del *fraudator*. Es de señalar que no se pagan bienes, sino que la adjudicación lo será a aquél que pague más porcentaje de deudas del pasivo, conforme a la *lex venditiones*. Después de las pujas ante el *praeco*, se adjudica a quien presente la mejor postura, que será el *bonorum emptor*. Aquí el papel del banquero aflora. PEREZ ALVAREZ nos indica que, como es natural, a estos negocios concurrían principalmente los *argentarii* y se refiere al posible carácter especulativo de su función⁴⁴ que se advierte en la actualidad pero que no parece preocupar a los juristas clásicos, aunque señalen como CICERON las graves consecuencias que tienen estas prácticas en la parte deudora, (Pro Quintc. XV, 50.3)⁴⁵

Pero observamos que el papel del *argentarius* cambia en las subastas forzosas. De ser un intermediario, como hemos visto en las subastas voluntarias pasa a ser bien parte ejecutante, lo más habitual, o parte ejecutada, o bien acompaña a cualquiera de ellas en el proceso de ejecución. Por tanto, su función en principio no es financiera. Aún así, posiblemente la importancia de la banca en Roma fuera mayor de lo que advertimos en los textos, si como dice PEÑALVER⁴⁶ lo comparamos con la situación actual. Hoy tampoco se puede suponer la gran presencia de la banca con la sola lectura de las normas procesales, en las que las menciones a la banca son mínimas y sin embargo, los procesos civiles ordinarios y sobretudo los de ejecución hipotecaria, en los que aparece la banca como ejecutante son un porcentaje elevadísimo de los procesos incoados y fallados aunque no hay referencias expresas a los bancos en la ley de enjuiciamiento.

Se dice que la subasta judicial desde siempre fue un modo de malvender los bienes embargados⁴⁷ pero la nueva ley de enjuiciamiento ha abierto nuevas vías como son los convenios de realización (art. 640 Ley de Enjuiciamiento Civil). Nosotros no estamos de

43 PEREZ ALVAREZ. *La bonorum venditio*. cit, 147 y ss dónde recoge las diferentes opiniones doctrinales al respecto.

44 COSTA. E., *Profilo storico del processo civile romano*. Roma.1918, p. 99 ROTONDI ,G., *Una nuova ipotesi in materia di bonorum venditio*. scritti giuridici, V. III. Pavia 1922. p 167. PEREZ ALVAREZ., *La bonorum venditio*.....cit p 99.

45 Del deudor explica las consecuencias de que su nombre quede grabado en los carteles y en los lugares más frecuentados, ... llega a decir que quien oye la voz del pregonero público dando el precio en subasta de todo lo que posee, es testigo en vida de sus propios funerales.

46 PEÑALVER, *La banca en Roma*. cit., pp 40 41.

47 MONTERO AROCA. *Derecho Jurisdiccional II*. cit. pp 654-5

acuerdo con esta opinión generalizada que culpa a la subasta de la consecuencia de la enajenación forzosa que comporta la transmisión del bien a bajo precio. La subasta es un medio extraordinario y con una gran presencia en todos los ámbitos, pero para conseguir el resultado debido es imprescindible partir de la igualdad entre transmitentes y adquirentes. Términos como subastero lo que indican es esa desigualdad entre partes, y la quiebra de la libertad de puja que hoy se ampara desde nuestro orden penal.

No podemos desatender un aspecto crucial tanto en Roma como hoy respecto a la documentación de las subastas ejecutivas. Observamos los libros contables⁴⁸ y vemos como es función del *argentarius* y *coactor argentarius* la contabilidad, así llevan el *codex accepti et expensi* como libro de contabilidad romano por excelencia, determina gastos e ingresos de todo tipo⁴⁹. Cuando estos sujetos intervenían en las subastas, debían registrar estas operaciones e incluían como datos principales el nombre del adjudicatario, el objeto vendido y el precio obtenido en la subasta⁵⁰. Como consecuencia resultaban pruebas tanto los recibos privados, como comprobante de la transacción, como los libros registros de los banqueros, que incluso permitían la percepción de la tasa por las autoridades. En el *Edictum Praetoris* de la etapa altoimperial, se contempla la obligación de los banqueros privados de presentar sus registros y cuentas ante cualquier demanda⁵¹. Según D. 2.13.9.2 tales documentos tenían valor de prueba a propósito de la *editio actionis*, texto de Paulo, en el que citando a Pomponio, se considera injusto que además de los banqueros romanos se incluya a los cambistas en esta obligación de comunicar sus cuentas, valiendo como prueba la escritura de sus libros, y también en D. 2, 13, 4 pr. Ulpiano se refiere a los *argentariae mensae* para obligarles a comunicar la cuenta con indicación de la fecha exacta⁵² concepto similar al valor que se da a los libros de los *argentarius*⁵³.

48 SALAZAR REVUELTA, M., El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos. RIDROM octubre 2003. P 96 y también en PENÁLVER. M.A. La banca en Roma. Madrid pp 48- 49. En el edicto de ratinonibus edendis no se desprende que se utilizaran libros especiales de banqueros, el liber ratioum sólo se nombra una vez Gayo en D 2.13.10.2. (Gai. ad ed. prov). Por lo que es de suponer que llevaran los libros contables generales, tres libros: el diario, cronológico adversaria con notas provisionales de duración mensual que luego se transcribían en el Codex accepti et expensi que reflejaba la situación patrimonial de cualquier paterfamilias; el Kalendarium agenda con cobros y pagos y préstamos.

49 PETRUCCI, A., *Mensam Exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana. (II secolo a.C. metà del III secolo d. C.)* Napoli 1991 p. 102. advierte de la existencia de libros contables diferentes y especiales para la actividad bancaria con su especial eficacia probatoria.

50 GARCIA MORCILLO, M., *Las ventas ... cit.p.* 103 refiere una anécdota del esclavo que recordaba todos los objetos, precios y compradores de un día entero de subastas. La anécdota del puñal subastado que lo había sido de un crimen.

51 ANDREAU, J. Vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (Ive siècle ap.J.C.). 617-619 162 a 167

52 PEÑÁLVER, M. A. *La banca cit..* p 22.

53 Así y cuando se solicitan las cuentas, se exige al adversario del banquero que jure que no las pide para vengar al banquero es decir, *ius iurandum non calumniae causa*. (D 2,13,6.2 y D 2.13.9.3) Y se exige cierta protección al secreto bancario, en el sentido de que sólo se exhiben y sólo se pueden copiar aquella parte de las cuentas que interesan para la información de alguien. D 2.13.10.1. Obligación en la que incluso queda subrogado el heredero del banquero, D 2.13.9.1. según fragmento de Paulo y D 2.13.6.1 según texto de Ulpiano.

Posiblemente, esta obligación de aportar los libros a juicio lo sea porque el oficio y servicio de banquero es de interés público, Gayo en D2.13.10.1. Les obliga a llevar diligentemente sus cuentas. Por otro lado, según D 2.13.4.5 el lugar en el que el banquero está obligado a exhibir sus libros es el lugar dónde ejerció de banquero, lo que incluso procesalmente nos marca una regla de competencia territorial que indica cierta raigambre. Si nos atenemos al valor de los documentos en sí, tampoco es igual el valor de las anotaciones que el de los libros. En Cicerón *Pro Roscio II*. 6 y 7, lo vemos cuando para defenderse de su adversario ridiculiza el valor del préstamo documentado en una nota y no en un libro registro. Así lo considera falso, por ello, ya que entiende que si las notas tuvieran el mismo valor que los libros, ¿para qué hacerlos? ¿Para qué anotar en ellos todas las operaciones comerciales? ¿Para qué mantener las viejas cuentas? ¿Por qué tanto cuidado en redactar los libros?. Y señala que “los libros registros se instituyeron para quitar la fe de las notas. ¿Qué juez prestará atención o crédito a un papel manchado, sin peso ni fuerza legal?”⁵⁴

Su importancia resulta insoslayable cuando se pretende decretar la *missio in bona*⁵⁵. Y otro dato a tener en cuenta es que tenemos noticia de la obligación de aportarlos cuando el banquero es requerido por la autoridad judicial, pero es de suponer que esta aportación documental también fuera voluntaria, cuando así se lo requiera un cliente, o cuando actúe por sí mismo, como parte procesal⁵⁶.

Por supuesto, hoy también se acude a las subastas judiciales, en el Portal de Administración de Justicia: <https://www.administraciondejusticia.gob.es/> incluso las hay electrónicas, siendo la primera experiencia en Murcia, si bien aún no están implantadas de forma general en toda España. Y en ellas la ejecución es como consecuencia de un proceso de ejecución forzosa. También observamos como el banquero tiene una función determinante, puesto que en la mayoría de estos asuntos el banco es ejecutante. Y como sus documentos son de *facto* indiscutibles, los extractos bancarios pueden ser nuestros libros contables, y hoy en día tienen presunción de veracidad. El banco tiene obligación de aportarlos si se le piden por el órgano judicial ejecutante.

A modo de resumen de este punto decir, que no es un negocio jurídico dada la falta de libertad en el transmitente del bien, lo que provoca que el precio no lo ponga él, y como consecuencia que puedan surgir fenómenos especulativos, en este supuesto el papel del banquero romano cambia a parte ejecutante o ejecutada, o incluso adjudicatario, para dejar de ser intermediario.

54 Y en el punto 7 añade que las notas sólo valen para un mes, y los registros para siempre. Las notas se destruyen inmediatamente y los registros se conservan con religiosidad; las unas abarcan el recuerdo de un momento, y los otros abarcan la lealtad y el honor que aseguran la respetabilidad y la consideración de un ciudadano. Aquéllas se redactan sin ningún orden, y estos se redactan con todo el cuidado. Por eso nadie se atrevió hasta ahora a presentar en los procesos sus notas, sino sus libros, sus registros.

55 PEREZ ALVAREZ. *La bonorum* .. cit. pp 157-8, advierte que cuando la importancia del pasivo no era conocida un decreto del magistrado, previa *causae cognitio* permitía a los acreedores consultar y copiar los registros que estaban embargados de forma especial y que sólo custodiaba uno de los acreedores.

56 TORRENT, A., *Manual de Derecho Privado Romano*, Zaragoza. 2002 pp 377-8. Un indicio puede ser el hecho de que el banquero podía alegar compensación de créditos recíprocos en la *intentio*, reclamando sólo la diferencia el *agere cum compensatione*, para lo que aportara sus libros contables.

4.2. Subastas en operaciones de derecho público

Las subastas en el ámbito de derecho público son las originarias en Roma. De ellas recibirá su nombre *venditio sub hasta*, que era la venta bajo el estandarte de los botines de guerra. También se utilizan otros términos como *sub corona*, *sub praecone*. Las subastas se introducen para estas ventas y parte de lo adquirido iba a engrosar el erario público. Con estos ingresos se llevaban a término obras públicas, primero elegidas sin procedimiento de adjudicación, o adjudicación directa y con posterioridad, sujetas a subasta, lo que permite elegir entre pluralidad de concursantes⁵⁷, circunstancias que coinciden en el tiempo con la aparición de la magistratura del Censor. En el ámbito público eran objeto de subasta tanto obras públicas, como suministros, recaudación de impuestos, etc, ... resultando encargadas personas privadas de funciones propias del Estado. Este sistema de elección dónde más se desarrolla es en la realización de obras públicas o en el disfrute de bienes públicos. El adjudicatario en estas circunstancias será el *manceps*, y se utiliza precisamente cuando los bienes o servicios subastados lo son por el “estado” por tanto son de origen público, porque cuando son de origen privado, por ejemplo, en los decomisos, el adjudicatario será el *bonorum emptor*, y el medio procesal utilizado la *bonorum sectio*. En este último caso los bienes subastados son del erario público⁵⁸ pero de procedencia privada: de proscritos, del Estado cuando los adquiere por herencia⁵⁹, de bienes de ocupación bélica o bienes de insolventes deudores del tesoro público. Intervienen los *questores aerarii*, quienes procedían a la venta en bloque de los bienes en subasta pública al sector, *aedicto quaestoria*, para que este después los revendiera por partes⁶⁰. Pero la financiación no es necesaria puesto que el sector no debe pagar al erario público, hasta que no vende los bienes, sólo prestaba garantías, y para ello tenía un plazo en el que incluso buscaba socios para la adjudicación⁶¹.

La subasta estará presente en todas las contrataciones públicas y el adjudicatario será el *manceps*, término que incluso nombrará a quien se dedique a hacer de la adjudicación de las subastas públicas su profesión. Pero dependiendo del objeto de la subasta también reciben otras denominaciones, así *redemptor* o *publicanus*⁶². La contratación pública más frecuentemente mencionada son las *locationes* de obras públicas⁶³, prácticas en las que colaborarán otros sujetos como los *mensarii*, los *nummularii*, bajo vigilancia del *praefectus urbi* y que siempre se decidían por subasta. En ellas el *redemptor* es el contratista, que cobra al final, pero para realizar la obra o el servicio necesita en ocasiones mano de obra, en otras mate-

57 MATEO, A. *Manceps, redemptor, publicanus*. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma. Santander 1999. pp 25-29.

58 PEREZ ALVAREZ., *La bonorum venditio*. ... cit. pp. 96-7.

59 MURILLO VILLAR, A. *El llamamiento sucesorio a favor del Estado en ausencia de herederos: de Roma a la actualidad*. Direito Romano Poder i Direito XV Congresso Internacional e XVIII Congresso Iberoamericano de Direito Romano. Lisboa 2013. p 53 y ss.

60 PEREZ ALVAREZ, *La bonorum venditio*. ... cit. p 103. nosotros también defendemos con ella que el objeto de la *addictio* son los *bona*, no el derecho a revender como se indica desde otros sectores doctrinales.

61 TALAMANCA *Contributi allo studio*.....cit. p. 172.

62 MATEO. *Manceps, redemptor, publicanus*. ... cit. p 31.

63 MATEO. *Manceps, redemptor, publicanus*. ... cit. p. 28 dónde refiere a este respecto, en su cita 25, la hipótesis seguida por de la venta del botín de guerra como precedente de la *sectio bonorum*. PEREZ ALVAREZ, *La bonorum venditio*. ... cit. p. 94 reúne en su cita 392 amplia bibliografía sobre esta institución.

riales.... y por tanto necesita disponer de dinero. En ocasiones se financia con provisiones de fondos que se restan al final, en la entrega⁶⁴, también se financia con garantías para obtener la adjudicación. Pero estas obras no se financian por banqueros individuales, sino que la financiación lo será por sociedades. Concretamente en la cesión del cobro de impuestos son conocidas las sociedades publicanas que llegan a ser tan fuertes, que incluso estarán relacionadas con la financiación del propio estado romano⁶⁵.

No obstante, el mayor problema que encontramos, como advierte MATEO⁶⁶ es que tenemos poca información sobre el régimen jurídico de la contratación pública, tampoco nos informan sobre el modo de proceder en las subastas, ni si se legisló o se actuaba por costumbre⁶⁷. En el caso de las adjudicaciones de *locatios* de *ager publico* el banquero no privado, sino público, intervenía en el cobro de la adjudicación y en el de los cánones anuales pactados, controlando así la concesión⁶⁸ de estos arrendamientos, pero no el tipo de banca que nos ocupa.

Es curioso ver como hoy en día, dentro del derecho público se mantienen las subastas para tareas similares, tanto en decomisos, como en las concesiones públicas, en suministros.... para comprobarlo basta con asomarnos a la red y pulsar “subastas hacienda”, contrataciones públicas anunciadas en boletines públicos, y de las más variadas materias, por ejemplo en el campo de suministros sanitarios, todos ellos concursos vinculados con nuevos soportes electrónicos, con los que se gana en rapidez y agilidad⁶⁹

5. CONCLUSIONES

Respecto de la financiación del banquero en las subastas, entendemos que en el ámbito puramente privado, actúa con sus clientes como intermediario, registrando la operación y actuando como depositario de los bienes que luego entrega al adjudicatario, también asesora y conforma los contratos que relacionan a los sujetos intervinientes en la operación. En las ejecuciones forzosas su papel cambia y resulta ejecutante o acompaña a esta parte procesal en la realización de los bienes, pero no financia ni interviene en las subastas como tal. Y, finalmente, en el ámbito público la cuantía de las operaciones supera lo que es su campo de actuación y no interviene de forma individual.

64 MATEO. Manceps, redemptor, publicanus.... cit. pp 56-7. también GARCIA GARRIDO, El comercio,... ci. p. 136.

65 FERRER MAESTRO. J.J., *Los contratos publicos y el poder privado en la republica romana*. Castellón. POTESTAS. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009.

66 MATEO, A. Manceps, redemptor, publicanus. ... cit. p..84.

67 Procesalmente conocemos una legislación municipal sobre la publicidad de las contrataciones municipales, la *lex Irnitana* en cuyo capítulo 63 habla de la exigencia de publicidad en las contrataciones, pero parece ser que su incumplimiento fue frecuente. Así Cicerón menciona como abuso de Verres el que celebrara una subasta en fechas intempestivas, en fiesta *Verrem actio 1.141*. Otro ejemplo también resulta abusiva por falta de publicidad, la *sectio* de los bienes del proscrito Pompeyo por Marco Antonio, *Philippicae 2.103*.

68 GARCIA MORCILLO. *Las ventas* ... cit. p.34

69 Así las subastas de decomisos en la web del Ministerio de Hacienda, <http://www.minhap.gob.es/esES/AreasTematicas/PatrimoniodelEstado/GestionPatrimonialdelEstado/Subastas/buscar> subastas y concursos. La enajenación de bienes del patrimonio de la Administración General del Estado se rige en los artículos 131 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 91 y siguientes de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.

Como colofón decir que la subasta es un medio para determinar el precio de un bien, de una obra, de un derecho....., se acomoda a diferentes realidades jurídicas, tanto públicas como privadas y sobrevive históricamente a múltiples avatares. Es versátil y atemporal, pero para que resulte eficaz se necesita aplicar en actos jurídicos que impliquen voluntariedad e igualdad *interpartes*. A veces, una parte es inferior a otra, como en el caso del transmitente en las ventas forzosas, o bien cuando una parte es claramente diferente a la otra, por ejemplo en el caso del Estado cuando convoca concursos públicos. En ocasiones de desigualdad, el mecanismo cede ante presiones y se desequilibra con resultados que impiden el precio justo, apareciendo fenómenos como el subastero o de corrupción de los poderes públicos. Este problema hoy se intenta resolver penalizando actitudes como las que describe la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su capítulo VIII, cuando nos relata los tipos referidos a la alteración de precios en concursos y subastas públicas, dentro de la rúbrica del Título XIII. En este apartado se refiere a delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico, protegiendo el correcto funcionamiento del mercado, la transparencia, la competencia leal, la libre concurrencia de licitadores, en suma la libertad de puja. Así se refiere a todo tipo de subastas y concursos públicos, en el sentido de abiertos a cualquiera. Concretamente, en el art. 262 se tipifican conductas como *“1. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años”*. Incluso si se trata de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años⁷⁰.

La subasta es un medio de determinación del precio para diferentes realidades, tanto puramente privadas como públicas. Como tal medio y siendo cabales en su procedimiento, con reglas sencillas que ya conocieron en Roma, como fueron los anuncios públicos en tiempo y lugar conveniente, la determinación clara de los bienes y sus cargas o sus características, la celebración y participación que permita múltiples pujas, la adjudicación y pago del objeto de la subasta y en su caso entrega o puesta en posesión del mismo, y registro de la operación, resulta un mecanismo procesal técnicamente complejo pero adecuado. Sin embargo, cuando cualquiera de los requisitos anteriores se vulnera, y con ello la libertad de puja se trastoca, el resultado será malvender un bien o un patrimonio en el ámbito privado o quizá entregar un bien o servicio a quien no es el mejor postor en el ámbito público.

70 El art.262. 2. del código  al sigue otorgando al juez o tribunal la facultad de imponer mayor pena si el culpable perteneciere a alguna sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades

BIBLIOGRAFÍA

- ANDREAU, J. *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (Ive siècle ap.J.C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985). Rome : École Française de Rome, 1987.
- ANDREAU J. Les affaires de Monsieur Jucundus. Rome : École Française de Rome, 1974, 408 p. (Publications de l'Écolefrançaise de Rome, 19) http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0000-0000_1974_mon_19_1
- BIONDI, B. *Contratto e stipulatio*. Milano. 1953.
- COSTA. E., *Perfillo storico del proceso civile romano*. Roma. 1918. p. 99.
- DARENBERG, SAGLIO, POTIER, LAFAYE, voz *Argentarii*, en *Dictionnaire des antiquités grecques et latines*. Paris 1877. pp. 406-7.
- FERRER MAESTRO. J.J., *Los contratos publicos y el poder privado en la republica romana*. Castellón. POTESTAS. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867 - 2009.
- GARCIA GARRIDO, M. J. *El comercio, los negocios y las finanzas en el Mundo Romano*. Madrid. 2001.
- GARCIA MORCILLO, M., *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*. Barcelona 2005.
- GARCIA SANCHEZ, J. *La laesio enormis y el precio de la subasta*. Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano. Murcia. 1998. pp 75-77.
- KUNKEL. *Derecho Privado Romano*. Barcelona 1965.
- MARQUES DOS SANTOS. C., *Reporte Inmobiliario. 2003-2004 Historia de la subasta y el corretaje*. <http://www.reporteinmobiliario.com/nuke>
- MATEO, A. *Manceps, redemptor, publicanus*. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma. Santander 1999.
- MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*. Valencia. 2013.
- MURILLO VILLAR, A. *El llamamiento sucesorio a favor del Estado en ausencia de here-deros: de Roma a la actualidad*. Direito Romano Poder i Direito XV Congresso Internacional e XVIII Congresso Iberoamericano de Direito Romano. Lisboa 2013.
- PEÑALVER. M. A. *La Banca en Roma*. Madrid.
- PEREZ ALVAREZ, M. P., *La bonorum venditio*. Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho Romano clásico. Madrid. 2000.
- PETRUCCI, A., *Mensam Exercere*. Studi sull'impresa finanziaria romana. (II secolo a.C. metà del III secolo d. C.) Napoli 1991.
- ROTONDI, G., *Una nuova ipotesi in materia di bonorum venditio*. scritti giuridici, V. III. Pavia 1922
- SALAZAR REVUELTA, M., *El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos*. RIDROM octubre 2003.
- SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho Romano*. Mexico 2007.
- TALAMANCA, M. *Contributi allo studio delle vendite all'asta del mondo classico*. Roma 1954.
- TORRENT, A., *Manual de Derecho Privado Romano*, Zaragoza. 2002.

EL CONTRATO DE MUTUO EN LA REPUBLICA ARGENTINA Y SU PROYECCIÓN LEGISLATIVA: UNA MIRADA DESDE DERECHO ROMANO

MARILINA MICELI Y DRA. ESTHER H. S. FERRER DE FERNÁNDEZ

*Universidad Abierta Interamericana,
Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la UAI y Universidad de Buenos Aires*

FUNDAMENTOS

I. INTRODUCCIÓN:

El derecho romano es básicamente casuística en prolongada evolución, los romanos supieron componer y compaginar el derecho capitalizando cada concepto jurídico en su aplicación y cada laguna del derecho como faz creadora de legislación. Por eso nos expresa Costa, “Una de las características que han forjado la grandeza del derecho romano, fue el espíritu práctico de sus juristas, dar una solución inmediata al problema concreto que se les presentaba en análisis, es decir, decidir frente a la vida misma que pasaba ante sus ojos.”¹ Como señala Argüello la importancia del derecho romano radica en que allí “encontramos una fuente fecunda de comprensión y conocimiento de gran parte del derecho occidental. Al estudiar hoy las instituciones jurídicas vigentes las entendemos mejor recreándolas desde su origen a través de su evolución.”²

Es por eso que el presente trabajo fundamenta, desde el derecho romano, por ser cuna de nuestra cultura occidental y fuente directa de nuestra ciencia jurídica, al contrato de mutuo como contrato típicamente real, analizamos su proyección actual en los recientes proyectos de reforma legislativa, afianzando como conclusión, su condición originaria por guardar y preservar congruencia, entre caso y aplicación, siendo el presente, una muestra más de conocimiento y practicidad romana.

1 Costa, José Carlos, El derecho de familia y de las personas en Roma. Estudio. Bs. As. 1997 Pág. 133.

2 Argüello, Luís, Manual de Derecho Romano, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1976, Pág. 12.

II. EL CONTRATO ROMANO:

En relación a los contratos manifiesta Di Pietro que “no existió en el derecho romano una teoría general del contrato, esta se irá formando lentamente con la romanística posterior que, aprovechando ciertos rasgos propiamente romanos, alcanzará dicha sistematización generalizadora en el pensamiento jurídico moderno”³

En Roma no todo acuerdo de voluntades fue entendido como un contrato, si bien los romanos no conceptualizaron acabadamente al instituto, se lo *considera como toda convención reconocida como obligatoria, esto es así, por encontrarse dotada de causa civil y poseer su reclamo amparo jurídico*.⁴

Considerando que el derecho es un objeto cultural, producto de la sociedad que lo genera, reproduce las características de la propia comunidad y representa la impronta histórica del tiempo en que se lo crea, por ello, originalmente, los contratos, al no ser la escritura vulgarmente conocida, eran de carácter verbal, *verbis*, por oposición a los contratos escritos o *litteris*, que tienen origen cuando el conocimiento se expande y se masifica la escritura.

Con el transcurso del tiempo, el núcleo o centro de la relación jurídica, deja de ser el empleo de la forma (de carácter casi sacramental) y pasa a centrarse en la voluntad de las partes, ubicando así al concurso de voluntades como elemento esencial de los negocios jurídicos.

De ésta gran evolución se dará origen a la moderna clasificación de los contratos, en consensuales y reales; clasificación que depende, de si los mismos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, independientemente de la forma en que éste se manifiesta, o si es requisito indispensable la entrega o tradición de la cosa para constituir validamente el acto.

En relación a la clasificación en sí, debemos decir que, de la bibliografía recabada, pareciera una vez más ser la costumbre romana y su gran practicidad, la autora consuetudinaria de dicha clasificación y no la teoría racionalizada, este tema luego será retomado previo se hace necesario esbozar algunos conceptos referidos al contrato de mutuo, eje de nuestro análisis.

III. EL CONTRATO DE MUTUO EN EL DERECHO ROMANO

Sabemos que el contrato de mutuo o contrato de “préstamo de consumo” se encuentra conceptualizado en Gayo 3.90/ Inst. 3.13 pr. y D.12.1.2 como el acuerdo de voluntades mediante el cual una persona, llamada mutuante o prestamista, le entrega en propiedad a otra, llamado mutuario o prestatario, una determinada cantidad de cosas fungibles, con la obligación por parte de esta última de restituir dentro de cierto plazo la misma cantidad del mismo género y calidad.

³ Di Pietro, A, Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el derecho romano, Ábaco, Bs. As. 2004, Pág. 56.

⁴ D.2.14.7.1

La simple promesa de mutuo no autoriza al mutuante a exigir su cumplimiento porque, al tratarse de un contrato real la promesa solamente constituye un precontrato y, como tal, origina únicamente una obligación de carácter natural.⁵

Si bien no puede obligarse al deudor a entregar más cantidad que la recibida podemos mencionar que en las fuentes se hace referencia a entregas menores y, que en todos los casos, la devolución puede ser requerida una vez cumplido el plazo establecido por las partes.

García Garrido considera que de los textos encontrados, especialmente en el D.2.13.6.3 se encuentran enumeradas una extensa cantidad de operaciones bancarias, entre las cuales podemos mencionar los depósitos de sumas de dinero y el mutuo profesional o préstamo con intereses, entre otros.⁶

El mutuo o préstamo con intereses *foenus* se pactaba por la *stipulatio*, negocio jurídico que, originalmente, se consideraba diferente y acompañaba al mutuo.

Siguiendo a Cicerón podemos mencionar que existieron tres formas de realizar un préstamo; la entrega de dinero, *pecunia numerata*, compromiso verbal de entrega, *pecunia stipulata* y asiento de la cantidad a entregar en los libros de contabilidad, *expensa lata*.

El mutuo con intereses, entiende Di Pietro, presentaba un doble aspecto *re et verbis* “pero esto no quiere decir, de ningún modo, que aquí estemos en presencia de un contrato doble o de dos contratos en uno sino que estamos ante la única figura del “mutuo con estipulación,” que era la forma nominal como se realizaba el mutuo con intereses (*fenus*).”⁷

Podemos afirmar que, con el transcurso del tiempo, se permitió también pactar intereses dentro del mismo negocio, pero, no gozaba de protección jurídica, siendo su devolución un deber u obligación natural.⁸

Los romanos, fieles a su arquetipo y su *traditio*, inicialmente no estructuran pensamiento jurídico alguno y los negocios bancarios tienen más que ver con la conducta repetida de la inmensa mayoría de la comunidad y no tanto con una teoría específica de la materia, es por ello que Díaz Bautista manifiesta “Especialmente en materia bancaria, se advierte la huella helénica a lo largo de toda la historia de Roma”⁹

Mientras en Roma se ha cosechado el trigo, Bizancio, por tener una amplia hoja de ruta mercantil, ha cultivado y cosechado la figura del banquero, quiénes con el paso del tiempo se organizan corporativamente, requiriendo su desempeño, una normativa jurídica especial.

En nuestra legislación interna, tanto el contrato genérico de mutuo como el mutuo bancario y su aplicación, gozan, hasta el día de hoy, del mismo sentido originario, pero, es dable preguntarse, frente al hecho de que cada nuevo proyecto legislativo plantea la clasificación

5 D.12.1.30/D.45.1.68.

6 Ver comentario de pág. 76 en García Garrido Manuel J, El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, Fundación de Estudios Romanos, Bolsa de Madrid, Madrid. 2001

7 Ver Di Pietro, A, “Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el derecho romano”, Ábaco, Bs. As. 2004.

8 D.19.5.24. pr.

9 En Díaz Bautista, Estudios sobre la banca Bizantina, negocios Bancarios en la legislación justiniana, libro on line www.interclassica.um.es Murcia 2012, Pág. 4, “Ya en tiempos de Plauto se les llamaba, además, *argentarii*, con el nombre griego de *trapeziti*, vid. GIANGRECO-PESSI. “*Argentarii*” e “*Trapeziti*” nel teatro di Plauto, AG 201 (1981) 39 y sigs, LAUM, RE Supplementband IV, 1924, s.v. Banken.

del mutuo ya no como contrato real sino como contrato consensual, si es adecuada dicha propuesta, para ello es necesario dilucidar o develar la razón por la cual un contrato debe considerarse real o consensual.

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Gorla, al referirse a la obligación como causa del contrato, nos habla de la *causa civilis*, “aludida como el sentido de la razón que justifica la sanción de la promesa. Esta consiste en la *res* o entrega de la cosa en los cuatro contratos llamados reales, y en el carácter típico del negocio, ya consagrado por la práctica cotidiana en los cuatro contratos consensuales. En tanto que, en las obligaciones *verbis* y *litteris* se habla de causa, se aludirá no tanto a una razón justificadora de la sanción jurídica como a una forma que sirve para identificar y concretar la voluntad de obligarse jurídicamente, voluntad de la que nace el vínculo¹⁰. Por lo que resulta claro que, para los romanos, el origen del vínculo en los contratos reales será pues la entrega de la cosa.

En tal sentido, Díez Picazo, explica que la clasificación de contratos en consensuales, reales y formales tiene su origen en las causas civiles de obligarse establecida en el derecho romano. En tal sentido recuerda, que “en el derecho romano para constituir una obligación se necesitaba o el pronunciamiento de unas palabras solemnes o (*stipulatio*) o la suscripción de un documento o la entrega de una cosa o la prestación del consentimiento. De esta manera podía decirse que las obligaciones se contraían *verbis*, *litteris*, *re* y *consensu*. Los dos primeros casos se englobaban bajo la rúbrica de contratos formales. Se denominaban en cambio, contratos reales a aquéllos que se perfeccionaban mediante la entrega de una cosa, cuando la entrega opera como presupuesto de creación de la obligación.”¹¹

Tan ello ha resultado así que lo lleva a Gorla a sostener que “el concepto moderno de causa como razón justificadora de la sanción de un contrato (constituido por el consentimiento) es un concepto exclusivamente nuestro que no podemos atribuir a los romanos”. Concluyendo este autor que “esta tipicidad que impregna todo el derecho clásico no dejará de ejercer una honda influencia en el *civil law*...”¹²

En el derecho actual la regla general es que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, tanto en el derecho español como en el argentino¹³.

Mientras que en los contratos que la ley ha caracterizado como reales, la *datio rei*, la entrega de la cosa, cumple el papel de una forma esencial (*ad solemnitatem*)¹⁴

En referencia a este aspecto indica López de Zavalía que la *datio rei* desempeña el papel de una solemnidad absoluta en el comodato, mutuo gratuito y el depósito y el de una solemnidad relativa en el contrato oneroso de renta vitalicia y en la constitución de prenda

10 Gorla, Gino, “El contrato”, traducción de Ferrandis Vilella, José; tomo I, editorial Bosch, Barcelona, 1959, pág. 31.

11 Díez-Picazo, Luis “Fundamentos del derecho civil patrimonial.” Tomo I Introducción a la teoría del contrato. , editorial Civitas, quinta edición, Madrid, 1996, pág 139.

12 Véase Gorla. Gino. Op. loc. cit.

13 Véase Díez Picazo, op. loc cit y López de Zavalía, Fernando, Teoría de los contratos Parte General, Zavalía, Buenos Aires, 1984.

14 Véase López de Zavalía, op. citada pág. 64.

y anticresis¹⁵. En tanto que el incumplimiento de la promesa de mutuo oneroso ha sido sancionada por el Código Civil Argentino mediante indemnización de daños y perjuicios.¹⁶

Expresa Lorenzetti, autor del último proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la República Argentina que, la tendencia legislativa se inclina hacia la eliminación de la categoría de los contratos reales o bien a mantenerla reconociendo la validez de la promesa bilateral, confiriéndole una acción de cumplimiento.¹⁷ En la República Argentina el Proyecto de 1987, no daba acción de cumplimiento, si bien admitía el reclamo de daños en su Art. 2247, el Proyecto de la Comisión Federal conceptuaba al mutuo como contrato consensual, Art. 2240 y el presentado en el año 1993 por el Poder Ejecutivo por Art. 1379 siguió la solución del de 1987. Por último el Proyecto de 1998, al igual que el de 2012, elimina la categoría de los contratos reales y considera al mutuo como un contrato consensual.

Por nuestra parte creemos que la eliminación del carácter de real del contrato de mutuo no ha de generar considerables diferencias a la situación actual imperante ya que de hecho, el banco o mutuante no ha de obligarse frente al mutuario hasta tanto no cuente con el importe del mutuo a entregar. Lo que de hecho significaría una desprotección del mutuario frente a la contraparte, allí donde el derecho intenta proteger al más débil.

Consideramos que la solución debió ser el mantenimiento de los contratos reales, proveniente del derecho romano, asignándole al incumplimiento de la promesa de mutuo la acción de cumplimiento; modo este de mantener la practicidad del carácter real del contrato de mutuo que ellos mismos perfilaron, otorgándole protección al mutuario mediante la facultad de la celebración de una promesa de mutuo con el efecto consiguiente de generar el cumplimiento.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

La tradición en general y en particular, la tradición jurídica propia del continente europeo a la cual pertenece nuestro país, se remonta sin solución de continuidad hasta el antiguo derecho romano que logra evolucionar a través de la aplicación de justicia al caso concreto.

Si bien no existió en el derecho romano una teoría general del contrato, esta se irá formando lentamente con la romanística posterior que alcanzará dicha sistematización generalizadora en el pensamiento jurídico moderno

El concepto de contrato como el acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir derechos se comienza a analizar recién con Justiniano, la clasificación de contratos en consensuales, reales y formales tiene su origen en las causas civiles de obligarse establecida en el derecho romano.

En dicho sistema se denominaban, contratos reales a aquéllos que se perfeccionaban mediante la entrega de una cosa, cuando la entrega opera como presupuesto de creación de la obligación.

¹⁵ Véase López de Zavalía, op. loc. citada.

¹⁶ Véase López de Zavalía, op. cit. pág. 98.

¹⁷ Véase Lorenzetti, Ricardo. "Tratado de los contratos. Parte general." Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pag. 226.

Hemos dicho que entre estos contratos la entrega de la cosa cumple el papel de una formalidad esencial; absoluta en el comodato, mutuo gratuito y el depósito y relativa en el contrato oneroso de renta vitalicia y en la constitución de prenda y anticresis. En tanto que el incumplimiento de la promesa de mutuo oneroso ha sido sancionada por el Código Civil Argentino mediante indemnización de daños y perjuicios.

Hemos concluido que la eliminación del carácter de real del contrato de mutuo no ha de generar considerables diferencias a la situación actual imperante ya que de hecho, el banco o mutuante no ha de obligarse frente al mutuuario hasta tanto no cuente con el importe del mutuo a entregar, lo que de hecho significaría una desprotección del mutuuario frente a la contraparte, allí donde el derecho intenta proteger al más débil.

Hemos considerado que la solución debió ser el mantenimiento de los contratos reales, proveniente del derecho romano, asignándole al incumplimiento de la promesa de mutuo la acción de cumplimiento.

Una vez más, es la aplicación al caso concreto y la necesidad que brota de la realidad lo que hace al derecho, y no es, el derecho racionalizado como un sistema de normas programáticas con carácter de futuridad, el que regula las conductas humanas y forja una realidad predeterminada.

D'Ors expresa que el derecho romano en sí mismo es algo más profundo que trasciende lo meramente histórico¹⁸. Así Costa entiende que, "En el radica el numen del derecho del mundo occidental como claro forjador de las ideas jurídicas a través del paso del tiempo."¹⁹

V. BIBLIOGRAFÍA

- Argüello, Luís, Manual de Derecho Romano, Astrea, Buenos Aires, 1976.
Bonfante Pietro, Instituciones de Derecho Romano, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1959.
Carcopino, Jerome, Daily Life in Acient Rome, Londres, 1956.
Correa Horacio Esteban, Los Fundamentos de la Alta Estrategia, (Segunda Parte), Revista Anales, UAI, Bs. As.
Corpus Iuris Civilis.
Costa J. C., Manual de Derecho Romano Público y Privado, Lexis Nexis, Bs. As. 2007.
Costa José C., El Negocio Jurídico en Roma, Influencia en el Derecho Argentino, Estudio, Bs. As. 1998.
Costa, J. C. Los principios generales del derecho. Sistema latinoamericano, XI Jornadas Nacionales de derecho Civil, Bs. As., 1987; Costa, J. C. Temas de derecho romano, Bs. As. 1994.
Costa, José Carlos, El derecho de familia y de las personas en Roma. Estudio. Bs. As. 1997.
D'Ors, Documentos y notarios en el Derecho romano postclásico, Centenario de la Ley de Notariado, Estudios históricos, vol. I, 1964.

¹⁸ Ver D'Ors Pérez Peix, A, Presupuestos críticos para el estudio del derecho romano, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1943.

¹⁹ Costa, J. C. los principios generales del derecho. Sistema latinoamericano, XI Jornadas Nacionales de derecho Civil, Bs. As., 1987; Costa, J. C. Temas de derecho romano, bs. As. 1994, Pág. 17 y SS.

- D'Ors Pérez Peix, A., Presupuestos críticos para el estudio del derecho romano, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1943.
- Dei, Daniel, Poder y Libertad en La Sociedad Posmoderna, Informe sobre el sentido del porvenir, Almagesto, Buenos Aires, 1995.
- Di Pietro, A., Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el derecho romano, Ábaco, Bs. As. 2004.
- Díaz Bautista, Estudios sobre la banca Bizantina, negocios Bancarios en la legislación justiniana, libro on line www.interclassica.um.es, Murcia, 2012.
- Díez-Picazo, Luis, “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, Tomo I, Introducción a la teoría del contrato, editorial Civitas, quinta edición, Madrid, 1996.
- García Garrido Manuel J, El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, Fundación de Estudios Romanos, Bolsa de Madrid, Madrid. 2001.
- Gorla, Gino, “El contrato”, traducción de Ferrandis Vilella, José; tomo I, editorial Bosch, Barcelona, 1959.
- López de Zavalía, Fernando, Teoría de los contratos Parte General, Zavalía, Buenos Aires, 1984.
- Lorenzetti, Ricardo. “Tratado de los contratos. Parte general.” Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004.

CONCLUDING OF THE LEGAL AFFAIRS IN MEDIEVAL EASTERN ADRIATIC TOWNS

NEVENKA BOGOJEVIĆ-GLUŠČEVIĆ
University of Montenegro-Podgorica

The notary document had a constitutive character and represented a material and legal presupposition of the importance of some very significant legal matters in the life of the Adriatic coastal communes. That primarily refers to the turn over of immovable, personal and real provision of an obligation as well as establishing a dowry and wills.

Such attitudes in settling matters through notary maps came to the Adriatic Medieval towns from the towns of the Mediterranean area and represents acceptance of the reception Roman law (*ius commune*). In some less developed areas there were exceptions to these rules, which is quite understandable when the local specific characteristics are taken into consideration.

I

1. The statutes of the coastal cities of the Mediterranean sea originating from the twelfth century are based on the rules of *ius commune*.¹ The application of the rules of this law into statutory city rights is conditioned by the need to control the more intensive economic and legal traffic between the cities as well as the absence of the appropriate laws within the city itself. The more and more present private property and the right to make a contract with certain subject required a unique law regulation, first of all in the field of obligation law, for which the models, with all the rights were demanded and found in the Roman law. The statutes of the coastal Adriatic cities, such as Kotor, Budva, Dubrovnik, Split, Zadar and others on northerly, follow the general legal concepts of *negotium* and *instrumentum*, the questions to be discussed in this study.

1 Pertile, A., *Storia diritto Italiano*, Storia del diritto privato, Torino 1978, p. 680; Zordan, G., *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, Studi Veneziani, vol. VIII, Firenze 1966, p. 127-195; Margetić, L., *Histrica et Adriatica raccolta di saggi storica - giuridici e storici*, Trieste, 1983, p. 104; Marone, M., *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo 1985, p. 178; Cvitanić, A., *Pravno uređenje splitske komune po statutu iz 1312. godine*, Split 1964, p. 217-220; Danilović, J., *Obligacioni ugovori u dubrovačkom pravu od XIII do sredine XIV veka*, Beograd 1957, Pravni fakultet u Beogradu, unpublished theses (Library of Law faculty); Bogojević-Glušćević, N., *Reception of Roman law in Medieval Towns of the Eastern Adriatic*, Part one, Law Faculty University of Montenegro, Podgorica 2011, p. 219; Bogojević-Glušćević, N., *Ricezione del diritto romano nelle città medievali dell'Adriatico orientale*, Libro second, Facolta di Giurisprudenza di Podgorica, Podgorica 2011, p. 147.

First of all, there is not technical term for a legal transaction *stricto sensu*.² The word *negotium* which was often used in Rome meaning the contract³ was also used with the same meaning in the statutory laws, although not regularly.⁴ The reason for that should be sought in the fact that this term was widely spread in both city and Roman laws, but with different meanings, therefore it was used for marking out other law activities beyond contractual law. By this word in the statutes were also marked the activities of *tutor*, *curator* and *mandatory*, then economic activities of one person and some activities outside the area of the private law (public law activities of governmental officials).⁵ The contract as the most frequent legal transaction is in the statutes usually regulated as a named contract within Roman law, or as being the case in the statutes of the cities of the South Adriatic region, was expressed through various legal and financial means and through the obligations of the contracting parties.⁶

2. According to statutory rights of all the cities on the Adriatic coast the base of each contract was presented in the free will of contracting parties. Without an agreement of parties there is no obligation. It seems that consensualism is basic idea of medieval law of obligation in those statutes.⁷ It should also be pointed out that with such a rule concerning the contract, statutory laws contained regulations, establishing which agreement of the parties was legally relevant. If both parties respected those rules an agreement came into being which led to a contract having legal effect. Each contract was supposed, until it was proved to the contrary, to be signed *bona fide* by parties.⁸ The rule of making *bona fide* contract was protected by certain law-a proof for carrying out an obligation under oath⁹. A basic protection of *bona fides* resulted that the presence of witnesses wasn't considered as a constitutive element of the contract. However, in practice they are often present during the transaction for the sake of both creditors and debtors safety.¹⁰

The frequency of maritime and business transaction in the twelfth and thirteenth century between contracting subjects in both foreign and internal trade as well as considerably

2 Romac, A., *Dictionary of Roman law*, Zagreb 1975, Informator, p. 447.

3 Romac, A., *Dictionary of Roman law*, Zagreb 1975, Informator, p. 362.

4 For example in the Statute of Kotor from threteenth century (*Statuta et leges civitatis Cathari*), hereafter cited as *Stat. Cath.*, apud Robertum Mietum, Venetiis, 1616, & 172, p. 104.

5 Danilović, J., *Represalije u dubrovačkom pravu XII i XIII veka*, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 1972, No. VI, p. 275-295; Danilović, J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd 1987, No. 6., p. 637-661.

6 Bujuklić, Ž., *Pravno uređenje srednjekovne budvanske komune*, Nikšić 1988, Univerzitetska riječ, p.157-231; Bogojević, N., *Podaci o obligacionom pravu u kotorskim izvorima prve polovine XIV vijeka*, Zbornik Pravnog fakulteta u Titogradu, Titograd 1981, No. 6-7, p. 95-102; Bogojević- Glušćević, N., *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Podgorica 1966, Kulturno prosvjetna zajednica, p.176.

7 Cvitanić, A., *Pravno uređenje splitske komune po Statutu iz 1312. godine*, Split 1964, p.135.

8 For example in Statute of Split from 1312 (*Statuta et leges civitatis Spalati*) (hereafter cited as *Stat. Spal.*), *Monumenta historico-iuridica, Slavorum meridionalium*, pars. I, vol. 2, Zagreb 1878, *liber III*, & 8, *De testibus*; See: Rismondo, V., *Statut grada Splita*, Split 1987, p.132.

9 Stat. Spal., *liber III*, & 10, *De sacramento tam actoris, quam rei uidelicet*.

10 Kostrenčić, M., *Fides publica u pravnoj istoriji Srba i Hrvata*, Beograd 1930, p. 78; Sindik, I., *Komunalno uređenje Kotora od XII do druge polovine XIV stoljeća*, Beograd 1950, Srpska akademija nauka, p. 103; Čremošnik, G., *Nekoliko dubrovačkih listina*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo 1931, p. 31; Danilović, J., op. cit., p. 76.

started process of property differentiation between the population within the Mediterranean cities, required business certainly which couldn't be provided only by *consensus*. Contracting parties are very often strangers, unknown to one another, people to the city harbors, are the transit places for negotiation with both domestic and foreign population. A solution to this problem in the rights of coastal and other developed medieval cities was harmful to the principle of consensus. All statutory rights without exception, beginning with the twelfth century introduced the obligation of drawing up documents, notary charts of the legal transaction being signed in all the cases when the object of transaction was above certain statutory monetary fixed value.¹¹ Although in the statutes of some cities the standard wasn't explicitly legal,¹² the existence of that rule while making contract is uncontroverted for it or directed by other statutory standards or can be foreseen from the statute observed on the whole¹³. The cart drawn up by the notary was marked as a carta according to the kind of transaction (*carta emptionis, venditionis, donationis, dotale*) or just *instrumentum*.¹⁴ *Instrumentum* enjoyed public faith- *fidem publicam* i.e. it was valid as a proof which couldn't be refuted. A document made by notary *bonus ET legalize*, thus by an expert recognized by the municipality enjoyed its full legal strength. The only objection was of the falseness or the objection of payment of those contained in the document of debts with some other notary instrument of payment or canceled *instrument*.¹⁵ One of the widely used form was written contract. Written form was optional in early statutes, but from thirteenth century we could find provisions making literal form obligatory. Sometimes, not only ordinary written form, but notary document was requested¹⁶.

11 Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Sordonae et civitatis insulae Lesinae, Monumenta historico iuridica Slavorum meridionalium, pars. I, volumen. 3, by Ljubić, S., Zagreb 1882-1883 (hereafter cited as Stat. Bud), &.113, De querenti; &. 235, De non esser credita carta scritta di mano del debitore; Bujuklić, Ž.- Luketić, M., Statut grada Budve, Budva 1990, &. 235, &.113; Stat. Spal., liber III, &. 17; Statuta et leges civitatis Trauguri, Monumenta historico iuridica Slavorum meridionalium, pars I, volumen. 4, by Henel, J., Zagreb 1884 (hereafter cited as Stat. Trog.) liber. I, &. 47; Statuta Jadertina cum omnibus reformationibus in hunc usque diem factis, Venetiis MDLXIII, apud Domenicum de Farris (hereafter cited as Stat. Jad.) liber. II, &. 104; and all statute of cities in northern south (Margetić, L., Osnovi obveznog prava na kvarnerskom području u srednjem vijeku, RAD, JAZU, No. 445, liber. 28, Zagreb 1989, p.73-134; Margetić, L., Osnove istarskoga srednjovjekovnog obveznog prava, RAD, JAZU, No. 447, liber. 29, Zagreb 1991, p.1-64.

12 Statute of city Kotor wasn't contain rules about making notary carts for each transaction. For example: Stat. Cath., &.78, De debito postulanto super mortuum sine carta; &.392, De muliere vidua quod non respondeat super bonis viri sui sine carta.

13 Stat. Cath., &.133, De testibus in quantum sunt recipiendi ("Volumus, quod si aliquis productus fuerit in testem de aliquo debito, vel obligationem, possit testificari a yperperis decem infra, videlicet, duo testes de debito, vel obligatione facta in ciuitate et unus de debito, vel obligatione facta extra ciuitatem, et ultra yperperos decem eorum testimonium nihilo habeatur").

14 For example: Stat. Cath., &.386, Quod iudex et auditor se subscribant in cartis, alioquin non valeant.

15 Stat. Spal., liber.V, &. LXVIII.

16 In Kotor, for example, Statute provided that contracts dealing with value less than ten silver perpers should be drawn up in ordinary written form. For those exceeding that value should have also notary chart. Sources in books by Mayer, A., *Monumenta Catrensia, volumen. I*, Prva knjiga kotorskih notara, 1326-1331, Zagreb 1951, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti; *Monumenta Catrensia, volumen II*, Druga knjiga kotorskih notara, 1327, 1333-1336, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb –Podgorica 1981.

The regulations of making obligatory notary *charts* for law affairs through certain values are in most cases respected judging by the notary material taken from the archive of the cities of northern and southern Adriatic region.¹⁷ Naturally, the introduction of such rules didn't automatically abolish the practice of making of a contract without notary instrument-*sine carta*. As we could see from the documents from archives there were many problems which could be seen from the cases decided in the court.¹⁸ However, there isn't an irrelevant number of documents stating the managing of complicated court disputes because of the absence of a *chart* about the transaction whether it is marked in before statutory period or from the statutory time when was marked the disputable legal transaction. Similarly, very often in the court disputes, especially in the cities of south Adriatic region, the statements of witnesses are used in the presentation of evidence as an element for verdict giving for the transaction signed above the fixed financial amount for which the statute issues obligatory *chart*. The statements of witness are also used for establishing the existence of some legal transaction and its validity. Speaking in general a level of application of statutory regulation about the obligatory introduction and appliance of notary *charts* for certain law affairs depended first of all on the commune development and its willingness to apply in practice its own regulations as well as on adaptability of law regulation to the relation governing in everyday life.

II

1. The main question asked in this study is whether the notary *chart* is a written form of a contract, hypothesis of its validity (*forma ad sollemnitatem*) or whether a document of a contract as source of evidence enjoying public faith- *fides publica*, which in case of a dispute proves the evidence of legal transaction (*forma ad probationem*). In other words, was there in the statutes of coastal Adriatic cities a notary chart in practice, as a source of evidence with which the parties in the court attain more steady assurance of their rights or whether the document had a dispositive character and presented a prerequisite for the appearance of legal transaction, or if it, in some cases had simultaneously both meanings.

2. All the statutes of the coastal Adriatic cities from the north to the south point out that the notary *chart* in everyday law concerning transportation mainly had the importance as a source of evidence about the contract (*forma ad probationem*), in all the cases of a contract containing a transaction above a specific financial value.¹⁹ With a notary chart as a written

17 For example: in Kotor statutory rule of public announcement of immovable selling, from 1312, was applied in practice through XIV century. Only four selling were without that form. Bogojević-Gluščević, N., *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Podgorica 1996, Kulturno prosvjetna zajednica, p. 37.

18 Historic Archive of Kotor, *Acta notarialia, volumen III* (1395-1400), p. 676; notary chart document No. 2, p. 611(27.XI 1398); document No. 2, p. 669(24.XII 1399); document No. 1, p. 617 (2. XI 1398) cited by Bogojević-Gluščević, N., *Svojinski odnosi u Kotoru u XIV vijeku*, Nikšić 1988, Univerzitetska riječ, p.134; Bogojević-Gluščević, N., *Statutarni propisi i pravna praksa u Kotoru u XIV vijeku*, Glasnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica 1997, No. 11, p. 193-211; Bogojević-Gluščević, N., *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Podgorica 1996, Kulturno prosvjetna zajednica, p.176.

19 Danilović, J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1987, No. 6, p. 651; Bujuklić, Ž., *Pravno uređenje srednjovekovne budvanske komune*, Nikšić 1988, Univerzitetska riječ, p. 157.

proof of a contract, the parties involved were given a complete legal confidence, that in case of a possible dispute they could accomplish their rights through regular procedure in court. Therefore a testimony in the court had the importance of evidence only for contracts up to the certain money amount.²⁰ The kind of legal transaction –abstract or causal– was of no special importance for the contracting parties. Law circumstances are the same. The document is a guarantee that in case of a dispute a claim will be achieved in court.

City notary books show that very often in practice between contracting parties there charts were made showing the debts without quoting the aim of the transaction, a so-called abstract promissory note, possibly for the reason that in case of abstract work the diapason of possible dealing with different effects would be wider.²¹ In that way the possibility of various issues was open (which as shown in the disputes), existed in practice, indeed not in a great number. For the city conditions in the Middle Ages it was understandable.

As we see, notary books in medieval Adriatic cities show that very often between contracting parties were made *carts* about the debts in which wasn't marked *iusta causa* of legal transaction. Abstract promissory note between parties would be enough. The document of transaction is a guarantee that in case of a dispute a claim will be achieved in court. With a notary chart as a written proof the parties could accomplish their rights through regular procedure in court. In this case the notary chart was *form ad probationem* for legal transaction.

3. For some legal transaction of exceptional values for the commune was used a special statutory regime. Notary books confirm the existence of a great number of documents made in such a way. That legal transaction are strictly formal, valid after special procedure - form whose realization is constitutive element for legal validity of the *negotium*. In medieval law this procedure was used for buying and selling real estate²², and for regulating pledges²³, a dowries²⁴and wills²⁵. This legal transactions were in the *form of sollemnitate*.

a) Sale of real estate was legally valid if the parties had a notary *chart* about transaction which was done after procedure of public announcement of selling (*carta venditionis*). A notary *chart* must exist if the parties want to make the transaction. A solemn announcement

20 Stat. Bud., &. 113 and & 235.

21 For example in medieval Kotor were many documents in which is written that someone "will bring" or "will get" or "brought" or "got" certain value of money. From the 1333 documents (1326-1331) above one hundred were abstract promissory notes. For more detail see: Bogojević-Gluščević, N., *Statutarni propisi i pravna praksa u Kotoru u XIV vijeku*, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka Crnogorske akademije nauka, Podgorica, 1977, No. 11, p. 193-211.

22 Terminology in the Statute and documents for this contract is same as in Roman law.

23 Statutory law used different term for pledge: roman (*pignus*, *hypoteca*), greece (*ipyteca*). The meanings of pledge is widely than in roman law. Details at Danilović, J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1987, No. 6, p. 640.

24 The statutory term for dowry is roman ("*dos*") and byzantine ("*parchiuium*"). In practice was opposite. The most of chart contained term "*parchiuium*", someone "*dos*". The influences of the different culture on legal life of medieval Adriatic towns are evident and its signed in each institute of laws. More information about that in: Jireček, K., *Istorija Srba*, tom II i III, Beograd 1973, Srpska akademija nauka, p. 255-279; *Istorija Crne Gore*, knjiga. II, tom 1, Titograd 1970, p. 28-45.

25 Terminology and rules for wills is only roman. In Statute, except wills were regulated roman institute "*donatio mortis causa*", "*legatum*", "*codicil*" and "*qualche alia ultima voluntas*": For example: Stat. Spal., liber III, &. 18, *De testamentis et ultimis voluntatibus*.

occurring three times by the Municipality clerk was a usual procedure in most communes. The announcement was an obligatory part of the contract process. An incomplete, unclear or absent announcement nullified the sale. The notary *chart* as an important element of the form of contract making can be drawn after successfully carried out procedure for the public announcement of immovable.²⁶ Public announcement of immovable selling and notary *chart* making and selling the same came into the statutory laws of Adriatic cities from the Italian coastal cities already from the thirteenth century.²⁷ Such regulation at the end of the thirteenth century contains Dubrovnik,²⁸ and from the first and second decade of the fourteenth century other cities of central and south region, Split, Budva, Kotor and Bar, as well as the cities of Istra region with a large spectrum of possibilities concerning the public sale announcement.²⁹

Before passing the regulation of obligatory public announcement of immovable sale (*carta venditionis*) in the rights of coastal Adriatic cities the buying and selling contract was marked without any particular formalities. Buying and selling is a consensual contract which was perfect with “pure” consensus. The roman opinion that “*emptio et venditio contrahitur, simulatque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratam sit, ac ne arrha quidem data fuerit*”³⁰ was accepted in the law of Adriatic cities in the thirteenth century. The contract was agreed openly in the notary book. The notary document was a guarantee that in case of a possible dispute the parties would be protected and would

26 For example in Kotor. Stat.Cath., & 256 (“...possessiones huiusmodi vendere, seu alienare voluerit, teneatur ter facere per Vicarium seu Riparium communitatis, in platea nunciare, videlicet tribus diebus Dominiciis, et cum nunciatio fuerit, ut est dictum, Notarius de ipsa venditione faciat Instrumentum”). See: Bogojević- Glušćević, N., op. cit, p. 34-36.

27 Pertile, A., *Storia diritto Italiano*, Storia del diritto privato, Torino 1978, p. 680; Zordan, G., *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, Studi Veneziani, volumen. VIII, Firenze 1966, p. 127-195; Margetić, L., *Historica et Adriatica raccolta di saggi storica-giuridici e storici*, Trieste, 1983, p.132; Besta, E., *Le obbligazioni nella storia del diritto Italiano*, Padova 1936, p. 205; Special about selling in italian medieval cities see: Bogojević-Glušćević, N., *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Podgorica 1966, Kulturno prosvjetna zajednica, p. 18, 53, 60, 79, 81, 84, 98, 100, 107, 110, 116, 123, 138, 141, 152, 162, 166, 169, 171, 193.

28 Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272. Cum legibus aetate posteriore insertis atque cum summariis, adnotationibus et scholis a veteribus iuris consultis Ragusinis additis by V. Bogišić-K. Jireček, Monumenta historico iuridica slavorum meridionalium, volumen IX, Zagreb 1904 (hereafter cited as Stat. Rag.) liber. V, & 35, & 36 and & 72; Danilović, J., Obligacioni ugovori u dubrovačkom pravu od XIII do sredine XIV veka, Beograd 1957, unpublished thesis in Library of Law faculty, p. 66.

29 Stat. Bud., & 153 and & 155; Stat. Spal., liber. III, & 110; Stat. Trog., liber. I, & 78; Stat. Kopr., liber. II, & 37; Stat. Rovinja, liber. II, & 81; Stat. Senj., & 23; Stat. Pul., liber. III, & 23 (by Margetić, L., Osnovi obveznog prava na kvarnerskom području u srednjem vijeku, RAD, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, No. 445, liber. 28, Zagreb 1989, p. 73-134; Margetić, L., Osnove istarskoga srednjovjekovnog obveznog prava, RAD, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, No. 447, liber. 29, Zagreb 1991, p. 42-43; Margetić, L., Srednjovjekovno hrvatsko pravo, Zagreb 1982, p. 52-56; Beuec, I., Osnovi statutarnog prava u Istri, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1962, No. 3-4, p. 181-198; Stat. Pag., liber. III, & 31; Šamšalović, M., Statut grada Paga za 1372. godinu, Pag 1982, p.121; Stat. Antibari., (“publicamente et con sono de compona secondo li ordini et statuti”) Lett. di Lev. 11, f. 170. (by Bujuklić, Ž., op.cit., p. 168). Exceptional role was in law of Zadar (Stat. Jad., & 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22 and & 23); See: Cvitanić, A., Statut bračke komune iz 1305. godine, Supetar 1968, p.156.

30 Corpus iuris civilis, volume secundum, Codex Iustinianus, recognovit Paulus Krueger, Dublin/Cürich, 1973, Weidman, liber II, 23, pr; *Gai Institutiones* (Gaj: Institucije), translate by Stanojević, O., Zavod za udžbenike, Beograd 2009, liber III, 139.

accomplish their rights in court. The document of the sale had an evidentiary effect-in case it comes to a court dispute it showed that an actual signed purchase and sale had taken place. This practice however proved to be as very ineffective in everyday legal life and was the reason for many law disputes in the communes. Making contracts in which *bona fides* parties were greatly relied upon slowly led to the evasion of *bona fides* principles and resulted in multiple documents describing the same sale.³¹ Besides, all buying and selling were not compulsorily signed "*in scriptis*" with a written proof that the buying and selling was dealt with. There were also in practice buying and selling as well as those without drawn up documents of the sale, for sale of immovable in everyday life of the cities was legally very insecure. Therefore in the communes new regulations were passed suitable to the newly- created city circumstances making the legal sales easier and secure³². In this way buying and selling went from an informal, to a strictly formal contract for whose making, apart from the free will of the parties. It was necessary to publically announce the sale, after which the registration into the notary books was done. This form carries within itself some solemn characteristics but despite that it's not abstract but causal one. Adequate is the expression of real practice needs and it is of the essential importance for free functioning of legal sales of immovable.

b) The medieval cities issued a special proceeding for contracting a real security of carrying out an obligation by means of pledge³³ for the same reasons from which buying and selling of real estate was regulated in a new way. It was foreseen there to be several kinds of contracting real security with different legal consequences. Starting from the pledge in a form of so-called general mortgage on a debtors property³⁴ up to the most difficult form of a pledge for a debtor to the pledge in a form of buying up to a certain time.³⁵ Each of mentioned pledges required a necessary drawing up of a notary *chart* about the contracted. Without the existence of the notary *chart*, *carta pignorationis*, the contract about the pledge has no legal effect. The notary chart is a constitutive element for making a contract and

31 *Stat. Cath.*, &. 256; Details by Bogojević-Glušćević, N., *L'evizione nel diritto medievale di Cattaro*, Storia @ diritto, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, Sassari, n.3/2004.

32 More of these rules were given a beginning of XIV century. See footnote No. 29.

33 *Stat. Cath.*, &. 81, 264 and & 268; *Stat. Bud.*, & 153, 158, 159 and & 271; *Stat. Rag.*, *liber. VII*, &. 32; *liber. IV*, &. 2, 1; *liber. VI*, &. 42, 3; *Stat. Spal.*, *liber. III*, &. 2, 63, 81, 120 and & 121; *liber. VI*, &. 28 and &. 69; *liber. I*, &. 6 and &. 28; *Stat. Brach.*, *liber. III*, &. 4; *Reformationes*, *liber. I*, &. 58; *liber II*, &. 12; *Stat. Trst.*, *liber. I*, &. 2.

34 Compare: Danilović, J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, op. cit., p. 639; Bujuklić, Ž., *Pravno uređenje srednjevekovne budvanske komune*, op. cit., p. 160; Cvitanić, A., *Uređenje splitske komune po statutu iz 1312. godine*, op. cit., p. 131; Cvitanić, A., *Srednjevekovni statut bračke komune*, Supetar 1968, p. 64; Margetić, L., *Srednjevekovno hrvatsko pravo*, Čakovec 1983, p. 94.

35 Compare: Danilović, J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, op. cit., p. 644; Bujuklić, Ž., *Pravno uređenje srednjevekovne budvanske komune*, op. cit., p. 160; Cvitanić, A., *Uređenje splitske komune po statutu iz 1312. godine*, op. cit., p. 132; Cvitanić, *Srednjevekovni statut bračke komune*, Supetar 1968, p. 65; Margetić, L., *Srednjevekovno hrvatsko pravo*, Čakovec 1983, p. 94; Margetić, L., *Bračno imovinsko pravo prema Krčkom statutu na latinskom jeziku*, Krk, 1971, Krčki zbornik, No. 2, p. 145-177; Bogojević Glušćević, N., *The Law and Practice of Average in Medieval Towns of the Eastern Adriatic*, Journal of Maritime Law & Commerce, Vol.36, No.1, January, 2005, p.21-59. This practice was known also in medieval Italy, France and Swiss. See: *Revue historique de droit français et étranger*, Paris 1986, No. 4, *Resume of Congres » Journal d'histoire de droit*, Lousane, 1986, p. 124-138; About same practice of pledge from Creta notary books see in *Fonti per la Storia di Venezia*, a cura di R. Morozzo della Rocca, Venezia, 1950, p. 116.

it gave the right to the holder to realize such a pledge on the base of a special statutory regulations. The procedure was worked out very precisely and it required maximum respect of all foreseen formalities from the side of a pledge *creditor*.³⁶ Despite the existence of the chart the pledge creditor loses his rights which, according to the pledge *chart*, belong to him unless he respected the statutory procedure³⁷. The pledge in a form so-called buying up to a certain time, whose subject is immovable, required, concerning the realization, the same procedure which was also carried out during buying and selling of immovable. The pledge *creditor* must announce in public the selling and draw up the *chart* about the announced sale as well as with buying and selling of immovable, so that only after such carried out procedure he could become the owner of the pledge matter.³⁸ It's sure that in the cities each of pledge required a necessary drawing up of a notary *cart* about the contracted. The notary *cart* (*carta pignorationis*) is a constitutive element for making a contract. Despite the existence of the chart pledge creditor loses his rights.

c) Under the term the dowry document "*carta dotis*", "*instrumentum dotis*"³⁹ the medieval statutory rights and legal practice of the coastal Adriatic cities meant two kinds of documents with different meaning. In the first often present meaning that is a document which is a necessary form for making a written contract of parties about the dowry and in this case the notary document has the meaning of a *form of sollemnitatem*.⁴⁰ In another case

36 *Stat.Cath.*, &. 81 and & 264; *Stat. Rag.*, liber. VII, &. 32; *Stat. Bud.*, &. 153; See: Bujuklić, Ž., *op.cit.*, p. 161; Bogojević-Gluščević, N., *Recepcija rimskog i vizantijskog prava na balkanskom Jugu*, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Grafo Crna Gora, Podgorica 2011., p.56-71; Danilović, J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, *op. cit.*, p. 641; Margetić, L., *Bračno imovinsko pravo prema Krčkom statutu na latinskom jeziku*, Krk, 1971, Krčki zbornik, No. 2, p. 145-177.

37 Details see: Bogojević-Gluščević, N., *Prescrizioni statutarie e pratica giuridica nella città di Cattaro nel Trecento*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd 1998, anno XLVI, No. 4-6, p.410- 428. For other towns see: Cvitančić, A., *op. cit.*, pag. 131; Danilović, J., *Zaloga*, *op. cit.*, p. 651; Bujuklić, Ž., *op.cit.*, p. 161.

38 For example in Kotor. *Stat. Cath.*, &. 268, De rebus ad certum terminum remanentibus in venditione que sunt alijs obligata ("...statuimus, quoque quicque fecerit alicui concordium aliquod, vel obligationem de oppignoratione aliqua de bonis suis stabilibus per venditionem ad terminum, et ab ipsum terminum ipse impignator rerum non scompraret ipsas res, sed remanerent in venditione ipsi imprestatori, teneatur ipse imprestator veniente termino ipso facere nunciare ter per Vicarium, vel Riparium Communitatis in platea videlicet tribus diebus Doniniciis, quomodo illa possessio sibi oppignorata remanet apud eum in venditionem, quod si non fecerit, tale concordium, vel obligatio non teneat, nec praeiudicet alicui, cui ipsa bona essent obligata"); Details for application this rule in practice see: Bogojević-Gluščević, N., *Statutory regulation and legal practice in Kotor of XIV th century*, ATTI della 51 Session della SIHDA, Regle et pratique du droit, Rubettino, Napoli, 1999, p.241-260.

39 Regime of the dowry is mixed: roman classical, postclassical and byzantine (*Digesta*, 23, 3, 30; *Codex Iustinianus*, 5, 11, 6; 5, 11, 72; *Codex Theodosianus*, 3, 13, 14; *Ekloga*, tit. II, 3; Marrone, M., *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo 1985.p. 134-137; From contemporary law, for example, italian medieval law, see: Margetić, L., *Mletačka repromissa i "dar u ponedjeljak" i grosina (pellica vidualis)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1989, No.2, p.163-172; Margetić, L., *Neka pitanja starijeg mletačkog porodičnog prava*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1988, No. 9, p. 107-117; Margetić, L., *Porijeklo načela paterni paternis u srednjovjekovnim pravnim sustavima na jadranskoj obali*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1983, No. 1-2, p. 131-140.

40 *Stat.Cath.*, &. 150, 141, 142, 146, 147 and & 171 ("*dotem promittere, promittere in dotibus*"); *Stat. Bud.*, &. 73; *Stat. Spal. liber. III*, &. 50; *Stat. Rag.*, liber. IV, &. 4; Practice in cities had many documents of this kind. In Kotor its signed by terminology "*dotem promittere, promittere in dotibus*" (Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. I, Zagreb 1951, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, doc. No. 150, 167, 213, 1142 and 1320; Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. II, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Hrvatska akademija

the document-describing the giving of the dowry had the character of showing proof of specific performance. By this document it is proved that the husband received the dowry-the document of handing the dowry over as the act of carrying out a contract.⁴¹ Such a document has a character of a receipt as a paid and owed obligation, of a cessation which was owed by the pledge giver.⁴² By this document it is proved that the husband received the dowry and that according to that he has nothing to require from the pledge giver. In practice there were often present the cases when the moment of signing a contract about the dowry coincides with the moment of its carrying out so that at the same time the document about the dowry had a double character-of both a form of making a contract and a receipt about the paid off debt.⁴³ There aren't an irrelevant number of notary documents about dowry signed in a form very similar to abstract obligations where the obligation of paying off a certain sum of money or handing over some other matter is stated. It is about the cases when the dowry giver didn't or did only partially satisfy the contracting obligation.⁴⁴ In contrast to the abstract obligations these documents usually contained the *iusta causa* and are used in court as a proof of debt existence.⁴⁵

nauka i umjetnosti, Zagreb- Podgorica 1981, doc. No. : 681, 633, 433, 439, 1051 and ecetera). Comparison with Roman law at *Codex Theod.* 3, 13, 4; with Byzantine law at *Ekloga, tit.* II, 3.

41 Stat. Cath., &. 149, De dote et parchiuio (... si aliqua mulier, vel aliquis pr ea dotem dederit, uel parchiuum, de recepcione ipsius parchiui, maritus cartam publicam supra se facere teneatur, illi qui parchiuum sibi assignauerit de rebus predictis promissis in dotibus pwer cartam Notarij...). In practice by word ("dotem dare assignare, dare in parchiuio") in *Monumenta Catarensia*, volumen. I, documents. 273, 274, 279, 412 and ecetera; Stat. Spal., liber. III, &. 124.

42 About this differences between Adriatic and Italian cities in middle age see: Zordan, G., *I vari aspetti della comunone familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, Studi Veneziani, vol. VIII, Firenze 1966, p. 127-195; Margetić, L., *Mletačka repromissa i "dar u ponedjeljak" i grosina (pellica vidualis)*, Zagreb 1989, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, No.2, p. 163-172; Margetić, L., *Neka pitanja starijeg mletačkog porodičnog prava*, Rijeka 19988, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, No. 9, p. 107-117; Margetić, L., *Porijeklo načela paternae paternis u srednjovjekovnim pravnim sustavima na jadranskoj obali*, Zagreb 1983, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, No. 1-2, p. 131-140.

43 Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. I, Zagreb 1951, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, doc. 1147; Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. II, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb- Podgorica 1981, doc. 290, 461, 1448, 1483 and 1562.; Archive of Kotor city, *Acta notarilia*, vol. III, 1395-1400; doc. 588, 255, 317, 401, 434 and 605; doc. 605. 7. XI 1398 ("... Ego Giuro, fabro de Cataro, canonice matrimonium contraho cum Belano...dans sibi filiam meam... cum qua do sibi pro dote et nomine dotis vineam meam."); doc. 490. 21. XI 1397 ("... Ego Triphoye Cosica, aurifex de Cataro ...confiteor habuisse et recepissem cum dicta Agneta, uxore mea, in dotem et dotis nomine proprius in Lastua."); doc. 401, 7. II 1397. ("... Ego Seia, uxor quondam Jacobi Milani de Parma, olim notarius .. una cum Paulo, filio meo... canonice matrimonium contrahimus cum Gaurilo, filio quondam Micho Vrachien de catharo, dantis sibi in suam uxorem legitimum Alegrina, filiam meam... et sorore dictam Pauli, cum qua damus sibi in dotibus...").

44 Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. I, Zagreb 1951, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, doc. 1320, 22. VI 1335; Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. II, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb- Pogorica 1981, doc. 433, 19. IX 1333; doc. 1317, 13. X 1326; same in doc. 439, 1054 and 1404.

45 Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. II, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb- Podgorica 1981, doc. 1177, 2. VIII 335; doc. 1178, 2. VIII 1335 ("...Ego Triphon...confiteor me debere dare Vladi... de ratione dotum filie mee."); Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. I, Zagreb 1951, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, doc. 51, 52, 58, 59, 273, 274, 468 and 469 ("... de ratione parchiui, pro restandi dotis, de residio parchiui").

d) The wills, as the act of handling the last will of a testator had a special importance in statutory rights. According to statutory regulations each *testament* in order to be valid and to cause the derived legal effect, had to be reduced in a public form by the notary according to the procedure which is very precisely arranged by the statutory regulations.⁴⁶ If a testator made the will personally it was necessary to deliver it in a written form (*cedula testamentis*) closed and sealed to the notary of the commune in the presence of witnesses and executors of the will- *examinator*.⁴⁷ The will could be the valid legal document if it were made before the notary and in presence of two witnesses and the will executor.⁴⁸ The wills could also be made outside the city. That is outside the city office where its publicity had to be provided by the procedure a bit stricter than for the wills made in city itself.⁴⁹ The existence of any questionable part in a written form delivered by a testator or a witness or any other lack in the witness statement gave the notary the right to contest the validity of the will and all this can be an incontestable proof of the validity and respect of the notary *chart* in the transaction *mortis causa*.⁵⁰

III

From everything above mentioned it could be concluded that the statutory law and legal practice in those cities accepted and respected the legal validity of the notary instruments: both as a proof of a legal transaction and as the constitutive element for the origin and legal validity of the *negotium*. In this way the cities are following the usual medieval practice from the rest of the Mediterranean.⁵¹

At the end of the thirteenth century, the document appears with a new meaning. Such regulations are caused by the state of legal disorder and insecurity because of misuses in using the notary *instruments* and violation of principles of honest and conscientious behav-

46 Stat. Brach., liber. I, &. 28; liber. IV, &. 59, Reformationes. liber. III, &. 16; Stat. Spal., liber. III, &. 18, De testamentis et ultimis voluntatibus; liber. I, &. 28; Reformationes., &. 109; Stat. Cath., &. 435.

47 Stat. Spal., liber. III, &. 22, De comisoriibus; Stat. Brach., Reformationes., lib. II, &. 4; Stat. Bud., &. 235, 179, 168 and 180; Stat. Cath., &. 183, 186 and 435, De testamentis et commissaries testamentores correctionis ultimae.

48 Stat. Spal., liber. I, &. 28; Reformationes., &. 109; Stat. Cath., &. 435.

49 Stat. Bud., &. 180; Stat. Cath., &. 435.

50 For example in Kotor *notarius* verified the will after omission the doubtful texts. Mayer, A., *Monumenta Catarensia, volumen. II*, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb- Podgorica 1981., doc. 1042 ("...coram nobis notario infrascripto quandam cedulam presentarunt dicendo eam fore ultimum testamentum dicti Giue, et rogando eam reduci in publicam formam ut est moris. Cuius tenor intracibitur. Verum quia in dicta cedula quedam cancellatura suspecta apparebat, ubi mentio fiebat de aliqua possessione emenda... que per nos expresse requisita dicto testamento et omnibus contentis in ea concensit, ipsum approbando et ratificando, quantum in ea est, volens, quod ultra, quam sit expressum in dicto testamento, supplendo cancellaturam antedictam, que omittitur in publicatione testamenti memorati, debeat...").

51 Besta, E., *Le obbligazioni nella storia del diritto Italiano*, Padova 1936, p. 205; Astuti, G., *I contratti obbligatori nella storia del diritto Italiano*, parte generale, Milano 1952, p. 362; Pertile, A., *Storia diritto Italiano IV*, Storia del diritto privato, Torino 1978, p. 554, 555, 557, 560 and 568; Zordan, G., *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, Studi Veneziani, volumen. VIII, Firenze 1966, p. 127-195; Margetić, L., *Histrica et Adriatica raccolta di saggi storica- giuridici e storici*, Trieste, 1983, p. 134.

ior of contracting parties while making legal transaction.⁵² For same important legal transaction (such as will, sale of immovable, pledge, dowry) the statutes introduced the obligatory existence of the notary *chart* as the form for making the contract.⁵³ In some statutory rights the regulations like these have been stated because of the special importance which some of this transaction had in the legal life of the cities.⁵⁴ The statutory norms by which the dispositive character of a document “was introduced had some real effects in practice because they practically enabled incorporation of law with the document whose handling means the alienation of law”⁵⁵. In the variation of the notary document existence only as a proof about the making legal transaction, that wasn’t possible to provide. For the satisfaction of such needs in practice, the documents with dispositive meaning have been introduced into the legal transaction. It was considered to be *forma ad solemnitatem*. Such rule of law, according the documents of archives was followed by practice.

SOURCES:

1. *Acta notarilia*, vol. III, 1395-1400, Historic Archive of Kotor(manuscript unpublished source)
2. *Codex Theodosianus*, vol. I-XII, edit stereotipa, Berolini 1877.
3. *Corpus iuris civilis*, volume primum, *Digesta*, recognovit Paulus Krueger, Dublin/Cürich, 1973.
4. *Corpus iuris civilis*, volume secundum, *Codex Iustinianus*, recognovit Paulus Krueger, Dublin/Cürich, 1973.
5. Čremošnik, G., *Nekoliko dubrovačkih listina*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo 1931.
6. *Gai Institutiones* (Gaj: Institucije), translate by Stanojević, O., Zavod za udžbenike, Beograd 2009. *Gli statute di Arbe*, Trieste 1901.
7. *Fonti per la Storia di Venezia*, a cura di R. Morozzo della Rocca, Venezia, 1950.
8. *Lettera di Levante.*, Duloir, Manfredi Settala, Samuel Sorbriere per Abbondio Menafoglio, Venezia, 1671.
9. Margetić, L., *Ekloga iz 726. godine*, prevod teksta, Zbornik Pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, No.1, Rijeka 1980.
10. Margetić, L.- Strčić, P., *Senjski statut iz 1388.*, Senj 1985-1987.

52 For example in Kotor in Statute’ s provision 256 is describe the reason for bringing this role 1312 year (“.. quis multi possessiones suas vendebant occultem, propter quod veniebant litis, et damna, volumus praesenti statuto firmantes...”).

53 Stat. Bud., & 153 and 155; Stat. Spal., liber. III, & 110; Stat. Trog., liber. I, & 78; Stat. Kopr., liber. II, & 37; Stat. Rovinj, liber. II, & 81; Stat. Senj., & 23; Stat. Pul., liber. III, & 23; Stat. Pag., liber. III, & 31; Stat. Antibar., (“publicamente et con sono de compona secondo li ordini et statuti”) by Lettera di Levante., 11, f. 170. (See: Bujuklić, Ž., op. cit., p. 168).

54 Stat. Bud., & 54, 56, 184, 225, 59, 61, 67, 58, 60, 62, 63, 230, 224, 226, 245, 273, 269 and 274; Stat. Rag., liber. VII, & 17, 47, 63, 65, 75, 76, 77, 80, 82 and 83; Stat. Spal., liber. VI, & 19; liber. IV, & 118; liber. V, & 33, 36, 39, 34, 41, 42, 43 and 44; Stat. Cath., & 348, 329, 324, 335, 333, 334, 497, 180, 282, 387, 337 and 339; More about that in Danilović, J., *Zaloga*, op. cit., p. 646-651; Bujuklić, Ž., op. cit., p. 157-231; Bogojević-Glušćević, N., *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Podgorica 1996, Kulturno prosvjetna zajednica, p. 32-86.

55 Astuti, G., *I contratti obbligatori nella storia del diritto Italiano, parte generale*, Milano 1952, p. 205.

11. Statuta Communitatis Pagi, Venice 1637.
12. *Statute della citta di Veglia*, Atti Memorie della Societa Istriana di archeologia e storia patria, Trieste 1895-1896.
13. Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Sordonae et civitatis insulae Lesinae, Monumenta historico iuridica Slavorum meridionalium, pars. I, volumen. 3, by Ljubić, S., Zagreb 1882-1883.
14. *Statuta et leges civitatis Cathari*, apud Robertum Mietum, Venetiis 1616.
15. Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272. Cum legibus aetate posteriore insertis atque cum summariis, adnotationibus et scholis a veteribus iuris consultis Ragusinis additis by V. Bogišić-K. Jireček, Monumenta historico iuridica slavorum meridionalium, volumen IX, Zagreb 1904.
16. Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. I, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb 1951.
17. Mayer, A., *Monumenta Catarensia*, volumen. II, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti and Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb-Pogorica 1981.
18. Statuta et leges civitatis Spalati, Monumenta historico-iuridica, Slavorum meridionalium, pars. I, vol. 2, Zagreb 1878.
19. Statuta et leges civitatis Trauguri, Monumenta historico iuridica Slavorum meridionalium, pars I, volumen. 4, by Henel, J., Zagreb 1884.
20. Statuta Jadertina cum omnibus reformationibus in hunc usque diem factis, , apud Domenicum de Farris, Venetiis MDLXIII
21. Statuta et reformationes insulae Brachiae cum legibus, privilegiis, gratis and indultis ducalibus pro Communitate Brachiensi, Monumento historic iuridica Slavorum meridionalium, Jugoslovenska akademija nauka and umjetnosti, volume XI, Zagreb 1926.
22. Strohal, I., *Statuti primorskih gradova i općina, bibliografski nacrt*, Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, Zagreb 1871-1917. ISBN 10:1247857506/1-247-85750-6

BIBLIOGRAPHY

1. Astuti, G., I contratti obbligatori nella storia del diritto Italiano, parte generale, Milano 1952
2. Besta, E., Le obbligazioni nella storia del diritto Italiano, Padova 1936.
3. Beuec, I., *Osnovi statutarnog prava u Istri*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, No. 3-4, Zagreb 1962.
4. Bogojević-Gluščević, N., *Reception of Roman law in Medieval Towns of the Eastern Adriatic*, Part one, Law Faculty University of Montenegro, Podgorica 2011. ISBN 978-86-509-0070-3
5. Bogojević-Gluščević, N., *Ricezione del diritto romano nelle città medievali dell'Adriatico orientale*, Libro secondo, Facolta di Giurisprudenza di Podgorica, Podgorica 2011. ISBN 978-86-509-0072-7
6. Bogojević, N., *Podaci o obligacionom pravu u kotorskim izvorima prve polovine XIV vijeka*, Zbornik Pravnog fakulteta u Titogradu, No. 6-7, Titograd 1981.

7. Bogojević- Gluščević, N., *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica 1966.
8. Bogojević-Gluščević,N., *Svojinski odnosi u Kotoru u XIV vijeku*, Univerzitetska riječ, Nikšić 1988.
9. Bogojević-Gluščević,N., *Statutarni propisi i pravna praksa u Kotoru u XIV vijeku*, Glasnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, No. 11, Podgorica 1997.
10. Bogojević-Gluščević,N., *L'evizione nel diritto medievale di Cattaro*, Storia @ diritto, Rivista Internazionale di Scienze Qiuiridiche e Tradizione Romana, No.3 Sassari 2004.
11. Bogojević-Gluščević, N., *Recepcija rimskog i vizantijskog prava na balkanskom Jugu*, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Grafo Crna Gora, Podgorica 2011. ISBN 978-86-509-0069-7
12. Bogojević Gluščević,N., *The Law and Practice of Average in Medieval Towns of the Eastern Adriatic*, Journal of Maritime Law & Commerce, Vol.36, No.1., January, 2005
13. Bogojević-Gluščević,N., *Prescrizioni statutarie e pratica giuridica nella citta di Cattaro nel Trecento*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, anno XLVI, No. 4-6, Beograd 1998.
14. Bogojević-Gluščević,N., *Statutory regulation and legal practice in Kotor of XIV th century*, ATTI della 51 Session della SIHDA, Regle et pratique du droit, Rubettino, Napoli 1999.
15. Bujuklić,Ž., *Pravno uređenje srednjevekovne budvanske komune*, Univerzitetska riječ, , Nikšić 1988. Bujuklić,Ž- Luketić,M., *Statut grada Budve*, Budva 1990.
16. Cvitanić,A., *Statut bračke komune iz 1305. godine*, Supetar 1968.
17. Cvitanić, A., *Pravno uređenje splitske komune po statutu iz 1312. godine*, Split 1964.
18. Danilović, J., *Obligacioni ugovori u dubrovačkom pravu od XIII do sredine XIV veka*, Pravni fakultet u Beogradu ,Beograd 1957.
19. Danilović,J., *Represalije u dubrovačkom pravu XII i XIII veka*, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, No. VI, Novi Sad 1972.
20. Danilović,J., *Zaloga u starom dubrovačkom pravu*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, No. 6., Beograd 1987
21. *Istorija Crne Gore*, knjiga. II, tom 1, Titograd 1970.
22. Jireček,K., *Istorija Srba*, tom II and III, ,Srpska akademija nauka, Beograd 1973.
23. Kostrenčić,M., *Fides publica u pravnoj istoriji Srba i Hrvata*, Beograd 1930 .
24. Margetić,L., *Histrica et Adriatica raccolta di saggi storica - guiridici e storici*, Trieste 1983.
25. Margetić,L., *Osnovi obveznog prava na kvarnerskom području u srednjem vijeku*, RAD, JAZU, No. 445, liber. 28, Zagreb 1989.
26. Margetić,L., *Osnove istarskoga srednjovjekovnog obveznog prava*, RAD, JAZU, No.. 447, liber. 29, Zagreb 1991.
27. Margetić, L., *Bračno imovinsko pravo prema Krčkom statutu na latinskom jeziku*, , Krčki zbornik, No. 2, Krk, 1971 .
28. Margetić,L., *Mletačka repromissa i "dar u ponedjeljak" i grosina (pellica vidualis)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, No..2, Zagreb 1989
29. Margetić,L., *Srednjevjekovno hrvatsko pravo*, Zagreb 1982.

30. Margetić, L., *Neka pitanja starijeg mletačkog porodičnog prava*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, No. 9, Rijeka 1998.
31. Margetić, L., Porijeklo načela paterna paternis u srednjevjekovnim pravnim sustavima na jadranskoj obali, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, No. 1-2, Zagreb 1983.
32. Marone, M., *Instituzioni di diritto romano*, Palumbo 1985.
33. Pertile, A., *Storia diritto Italiano*, Storia del diritto privato, Torino 1978.
34. Romac, A., *Dictionary of Roman law*, Informator, Zagreb 1975.
35. Revue historique de droit français et étranger, Paris 1986, No. 4, Resume of Congres "Journal d'histoire de droit", Lousane, 1986.
36. Rismondo, V., *Statut grada Splita*, Split 1987.
37. Sindik, I., *Komunalno uređenje Kotora od XII do druge polovine XIV stoljeća*, Srpska akademija nauka, liber CLXV, Beograd 1950.
38. Šamšalović, M., *Statut grada Paga za 1372. godinu*, Pag 1982.
39. Zordan, G., *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, Studi Veneziani, vol. VIII, Firenze 1966.

O COMÉRCIO EM ROMA

ANDRÉ AUGUSTO MALCHER MEIRA
Universidade de Lisboa

1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TEMÁTICA

O que pretendemos neste estudo é abordar a evolução histórica do Direito Comercial ao longo dos tempos, levando-se em conta dois momentos específicos: a época romana e o direito brasileiro.

Importante frisar que não trataremos da questão histórica no que diz respeito às Idades Antiga e Média por questões meramente didáticas e objetivas, principalmente pelo fato de que o escopo é estudar como o comércio era lastreado pelo direito em Roma e qual a sua influência direta no ordenamento jurídico brasileiro, desde que o mesmo passou a existir como sistema jurídico independente da Coroa Portuguesa.

Contudo, sempre é ínsito ressaltar a importância destes dois momentos históricos, principalmente por duas codificações importantes, como o Código de Manu, na Índia, o Código de Hammurabi, na Babilônia, provavelmente no ano de 2083 a.C (que já previa o contrato de depósito e de sociedade, assim como o empréstimo a juros), o contributo dos Fenícios, e o Código de Napoleônico, já nos idos de 1808 d.C, além de todo o arcabouço que os gregos deixaram como importante influência jurídica para toda a humanidade. Posterior à codificação francesa seguiram-se os Códigos Comerciais Espanhol, de 1829, o Português, de 1833, o Holandês, de 1838, o Brasileiro, de 1850, o Alemão, de 1861 e o Italiano, de 1865.

Todos estes marcos legislativos do século XVIII beberam (e bebem) da fonte jurídica romana, inclusive nas suas revisões e alterações, o até os dias de hoje.

É sabido e ressabido que a evolução do Direito Comercial advém de sua fonte principal, qual seja, o Direito Consuetudinário (*consuetudini*), que é característica de fundamental importância para a sua posterior sistematização jurídica em todos os povos.

O binômio “troca” e “necessidade” foram dois preponderantes adjetivos para que a figura do comerciante viesse a surgir como intermediário na relação entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de lucro, fazendo com que a oferta e a procura passasse a ter importância financeira e mercadológica de alguma forma.

Remetendo-se aos tempos antigos, o homem produzia sozinho para a sua própria subsistência, sem alguma forma de obter lucro ou repasse do produto a terceiros, ou seja,

poderia ser considerado *produtor x produtor*, sem nunca imaginar que outras pessoas necessitariam daquele mesmo item e que ele, o mesmo homem, necessitaria de outras coisas para sobreviver.

Neste momento o Direito Comercial não existia simplesmente porque não havia atividade comercial em torno da sociedade, muito menos considerar-se-ia um mercado ativo de exploração de certa atividade. A figura do comerciante, na realidade, ainda não existia, justamente porque o homem produzia para o seu próprio consumo com o objetivo único de manter-se vivo.

Com o andar do tempo e a produção pessoal cada vez mais aumentando, o homem passou a perceber que havia produtos em excesso no seu dia-a-dia, assim como começou a verificar que outras pessoas também necessitariam daquilo que ele produzia e que ele, o mesmo homem, necessitaria do que os outros produziam. Tem-se aí o que chamamos de *economia de troca ou de escambo*, ou seja, o homem trocando produtos entre si levando-se em conta as suas necessidades de sobrevivência, o que é um verdadeiro marco fundamental da atividade comercial, que vem lastrear todas as justificativas de criação de um sistema jurídico que desse suporte às relações entre as pessoas ao longo do tempo.

Desta forma, com a oferta e a demanda cada vez mais aumentando entre os homens, eis que surge a figura do comerciante, aquele que se intromete na relação dos homens na tentativa de aprimorar e aumentar a troca, verificar com mais ênfase as necessidades do povo fazendo com que todos tenham suas necessidades satisfeitas com a sua intervenção. Por este trabalho, o comerciante objetivava o lucro e o crescimento da atividade entre as pessoas.

Posteriormente, sentiu-se a falta de algo que pudesse dar valor específico às relações comerciais, surgindo assim a *moeda* como forma de identificar monetariamente cada produto, expandido ainda mais a atividade comercial com a criação das instituições financeiras que auxiliariam a relação comercial entre as pessoas. Desde aí teremos o conceito de *economia de mercado*, o qual subsiste até os dias de hoje e não para de crescer.

Importante frisar que o ciclo da atividade econômica leva em consideração dois sujeitos de suma importância, quais sejam, o *produtor* e o *consumidor*. O primeiro é aquele que investe em tecnologia, organiza a sua atividade, visa o lucro mediante a produção ou circulação de bens ou de serviços; já o segundo torna-se o principal agente simplesmente porque é quem movimenta o mercado adquirindo os produtos ou serviços do primeiro, constituindo o que chamamos hoje de *aviamento, clientela e fundo de comércio*, elementos que, se não existirem, finda o comércio definitivamente.

É com esta sistemática de análise que pretendemos estudar nestas poucas páginas como se deu a evolução histórica do sistema jurídico comercial no Direito Romano, sendo este a espinha dorsal do direito privado internacional, assim como verificar, de forma clara e objetiva, a influência desta mesma evolução do ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, em dois capítulos sintéticos este estudo aborda questões conceituais do caráter histórico do Direito Comercial em Roma e no Brasil, com o escopo de definir um panorama mais amplo ao cientista jurídico, procurando focar o debate e a discussão do direito, visando contribuir com a doutrina e com a ciência jurídica.

2. A APLICAÇÃO DO DIREITO ROMANO AO COMÉRCIO

A época romana foi sem dúvida um verdadeiro marco jurídico para toda a civilização do ocidente, e o é até os dias de hoje, principalmente no campo do direito privado, mormente no direito civil. Sabe-se que os juristas romanos produziram diversas leis para balizar a sua civilização, criando institutos, princípios, etc, e, fundamentalmente, conceitos. Sem conceitos não vive uma sociedade, sem conceitos não se constrói um direito.

No gênero *direito privado* temos basicamente duas espécies que aprimoraram-se ao longo dos tempos, o *direito civil* e o *direito comercial*, irmãos que nunca deixarão de se dar as mãos na construção de relações jurídicas sistemáticas entre as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, com um imenso contributo da civilização romana. O comércio em Roma era florescente, crescente, movimentando toda uma sociedade em busca de produção e criação de mercado, recebendo dos gregos a orientação e os institutos jurídicos, principalmente na economia de agricultura, o que se tornou insuficiente para as suas necessidades.

A civilização romana viu e sentiu a evolução do comércio, introduzindo a moeda (prata e ouro) e as políticas de crédito através das instituições financeiras, fomentou o erário do Poder, estritamente capitalista, com o pagamento de altos impostos, criando as duas classes sociais básicas de sua época: a plebe e a aristocracia. A primeira acabaria por ser utilizada como mão de obra pela segunda, sem dar o menor valor ao trabalho mercantil artesanal produzido pela classe menos abastada, daí o porque de não existir caracterizada no âmbito jurídico em Roma a figura do *comerciante ou mercador*.

Em Roma, o comércio era tido como atividade sem importância, era praticado apenas por estrangeiros e não podia ser exercido pelo *pater familias* ou pelos *senadores*.

Contudo, antes de cuidar especificamente do direito comercial em Roma, faremos uma breve passagem à luz dos conceitos em Direito Romano, conceitos estes importantes e fundamentais para o entendimento do que pretendemos tratar.

É sabido e resabido que o direito romano é o conjunto de normas jurídicas que regeram o povo romano, desde a fundação de Roma (754 aC) até a morte do Imperador Justiniano (565 dC) e tem como objetivo principal o estudo das instituições de caráter privado¹. Segundo o grande jurista alemão LEIBNITZ², o estudo do Direito Romano dividiu-se em história interna (*antiquitatis iuris*), que estuda o Direito Romano em si, e história externa (*historia iuris*) – que seria uma introdução histórica para facilitar o estudo da história interna. Esta, por sua vez, estuda os órgãos que elaboraram o Direito Romano (e suas instituições políticas) e as fontes do Direito.

Pelos eminentes doutrinadores, a história interna divide-se em: a) pré-clássica ou antiga; b) clássica; c) pós-clássica ou Romana-Helênica. Já a história externa, quanto as formas de governo, divide-se em: a) Realza (754 a 510 aC); b) República (510 a 27 aC); c) Principado (27 aC a 284 ou 285 dC) ; d) Dominato (284 ou 285 dC a 565 dC).

Este, portanto, um panorama histórico, um mapa do Direito Romano para que o leitor entenda e se situe no tempo e no espaço em relação ao tema que estamos trabalhando.

1 MEIRA, Silvio A. B. **Curso de Direito Romano**. LTr, São Paulo, 1996, pág. 12.

2 LEIBNITZ, *op. cit* SILVIO MEIRA, Curso de Direito Romano. LTr, São Paulo, 1996, pág. 12.

Passaremos a analisar algumas fontes do Direito Romano à época Republicana, fontes estas que devem ser sempre consultadas pelos operadores do direito até os dias de hoje. São elas: *costumes, leis, senatusconsultos, editos dos magistrados e jurisprudentia*.

Entende-se por *costumes* aqueles direitos derivados dos hábitos (*jus moribus Constitutum*) e tiveram sua maior relevância no início da República, e sua observação era prescrita pela religião. Ao Direito Comercial o costume teve (e tem) grande importância, pois que, durante muitos anos na história da humanidade, foi a principal base jurídica do sistema comercial. Assim, como se vê, nada de novo se criou naquilo que os Romanos eram perfeitos e, por assim dizer, o Direito Comercial teve sim sua origem em Roma, seja como conceitos principiológicos, seja como conceitos formados ao longo dos anos.

As leis eram poderosas fontes de direito na República e possuíam a seguinte divisão³: a) quanto ao órgão elaborador (*leges curiatae* – elaboradas por curias, *leges centuriatae* – elaboradas por centúrias, *leges tributae* – elaboradas por tribos e plebiscita – elaboradas pela consilia plebis); b) quanto à iniciativa (*leges datae* – aquelas expedidas diretamente por cônsules, sem proposição às assembleias populares e *leges rogatae* – expedidas mediante proposição de um magistrado àquelas assembleias); c) quando à finalidade (*leges repetundarum* – aquelas que puniam os magistrados que recebessem propinas, *leges agrariae* – aquelas que visavam a distribuição de terras e o incentivo à produção, *leges caducariae* – visavam combater o Celibato e incrementar o casamento e *leges judicariae* – versavam sobre a organização do processo); quanto à extensão (*legges publicae* – eram promulgadas pelo poder público para terem aplicação à toda coletividade e *leges privatae* – aquelas que regiam as convenções entre particulares); quanto à sanção (*leges perfectae* – aquelas que tornavam nulos os atos que as infringiam, *leges imperfectae* – aquelas que não anulavam os atos infringentes, mas impunham multas, *leges minus quam perfectae* – aquelas que não anulavam e não impunham multas).

Como se vê, o Direito Romano possuía um poderoso arcabouço legislativo que deu base a toda a humanidade, inclusive ao Direito Comercial. Sobre ele, ainda, o Direito Romano colaborou com outras leis que dão mais ensejo ao comércio, como a *lex genúcia* (que proibia empréstimo a juro – 342 aC) e a *lex gabínia* (que versava sobre a usura), entre tantas outras que citaremos ao longo deste breve e singelo trabalho.

Contudo, a Lei das XII Tábuas foi a mais importante do período republicano e talvez de todo o Direito Romano, bem porque era praticamente a compilação de todo o sistema jurídico da época, denominada por alguns juristas de *fonte do direito público e privado*. Esta lei tratava de diversos temas jurídicos, desde o chamamento ao Juízo, do julgamento e do furto, do casamento, do pátrio poder, da propriedade e da posse, dos delitos, do processo, do direito público, etc, e, dentre eles, o direito de crédito (Tábua III), fundamental e importante para o crescimento do comércio em toda e qualquer sociedade. Mais uma vez, como se vê, havia sim no Direito Romano um nascituro, uma fonte, um conceito e preceito de Direito Comercial, dentro ou fora dele, mas com uma importância brutal para a sua formação como ciência jurídica própria.

3 MEIRA, Silvio A B. **Curso de Direito Romano**. LTr, São Paulo, 1996, pág. 57

Falar de Direito Romano é falar na magistral obra do Imperador Justiniano e suas compilações jurídicas, que culminaram com dois códigos (que consolidaram as LEGES existentes), o Digesto (que consolidou os IURA existentes), as Institutas (compêndio para o ensino do Direito) e as Novelas (novas constituições, não reunidas por Justiniano, e sim posteriormente). Ainda, não poderíamos deixar de citar o grande *Corpus Iuris Civilis*, que nada mais é do que toda a reunião da compilação Justinianéia em um só volume, obra de grande valor jurídico até os dias de hoje para diversos ordenamentos jurídicos, em todos os ramos do direito, principalmente o Direito Privado, entre eles o Direito Comercial, vez que a espinha dorsal das leis civis sempre foram e sempre serão primas-irmãs das leis comerciais em todo e qualquer sistema jurídico.

Ainda na seara conceitual, não poderíamos deixar de citar a divisão do estudo do direito pelos romanos, caso contrário ficaria difícil ao leitor o entendimento sistêmico deste humilde trabalho. Os romanos classificavam o direito objetivo da seguinte forma: a) *jus scriptum* – aquele que era escrito, as leis, os editos dos magistrados, etc; b) *jus non scriptum* – aquele que na era escrito, confirmado pelo uso, os costumes de longa duração e aprovados pelo povo eram semelhantes às leis – aqui vemos mais uma vez o embrião conceitual do Direito Comercial; c) *jus civili* – o direito que cada povo constitui para si mesmo e que é peculiar a sua cidade, ou seja, é um direito próprio de um povo independente; d) *jus honorarium* – era constituído pelo conjuntos dos editos dos magistrados; e) *jus commune* – era o direito aplicado a toda a coletividade, indistintamente; f) *jus singulare* – referia-se a preceitos aplicáveis a determinadas situações; g) *jus publicum* – direito a civitas, ao estado, ao populus; h) *jus privatum* – diz respeito ao indivíduo.

Da mesma forma, não podemos deixar de citar a importância (até os dias de hoje) da *jurisprudencia*, que segundo ULPIANO, é o conhecimento das coisas divinas e humanas, ou seja, a ciência do justo e do injusto. Infelizmente, hoje este verbete adquiriu outro conceito que não é este original, e é definido como o conjunto de decisões uniforme dos Tribunais, utilizado nos sistemas jurídicos atuais como importante fonte do estudo do direito e, de forma não diferente, ao Direito Comercial.

Tratar de Direito Comercial é tratar de exploração de uma atividade com fins lucrativos por pessoas físicas, seja individualmente, seja em grupo (pessoas jurídicas). Em Roma, da mesma forma como é realizado nos dias de hoje, havia a diferença entre esses dois tipos de pessoa, tanto pela sua capacidade como pela sua formação. Pessoas físicas ou naturais eram os indivíduos que satisfaziam os requisitos de ser livre, cidadão romano e chefe de família e, na falta de um desses requisitos, importava na perda da personalidade jurídica. Já as pessoas jurídicas eram a reunião de pessoas naturais (indivíduos) com um objetivo comum, e o seu nascimento se dava através de um ato de constituição, feito através de um registro, e sua morte se dava pela sua dissolução.

Como se vê, aí encontramos as raízes do Direito Comercial em agrupamento de pessoas para um fim comum, o que chamamos de sociedade, objeto este que vamos aclarar um pouco mais, visto a sua importância na exploração de uma atividade (seja comercial, seja civil), reunindo capital, ideias, ideais, objetivos e um só caminho.

Para os romanos as pessoas jurídicas (sociedades de pessoas capazes) eram pessoas fictícias, tendo sua existência reconhecida apenas o campo jurídico, assumindo direitos

e contraindo obrigações de toda ordem, conceituando-se como a organização de pessoas naturais com uma finalidade comum, repetimos, seja civil, seja comercial. Eram tratadas por diversas expressões, tais como *corpora, universitas e collegia*, remetendo-se sempre ao conceito de colegiado, reunião de pessoas em um só corpo jurídico. Como se vê, a base romana serve até os dias hoje quando estudamos o Direito Societário, importante espécie do gênero Direito Comercial, em qualquer ordenamento jurídico.

Para ilustrar ainda mais, a classificação das pessoas jurídicas de direito privado – a que interessa ao presente estudo – pelos romanos se dava da seguinte forma: a) *societates commerciales* – eram todas as corporações de direito privado; b) *societates recreativas* – o que hoje poderíamos chamar de associações clubísticas e c) *societates dos publicanos* – contratadas para cobrar impostos, administrar minas e outros atos que o poder público não podia por si só exercer, tais como uma espécie de concessionária de serviço público, muitas das vezes com o objetivo de lucro por seus sócios – aqui, mais uma vez, o conceito de comércio na união de pessoas em sociedade. Além disto, em relação às sociedades, citamos a *Lex Julia de Collegiis*, que alguns romanistas atribuem a Augusto.

Percebemos, assim, que qualquer doutrinador que alega que em Roma não existia Direito Comercial está, na verdade, tratando de uma heresia. Roma pode não ter tido um sistema de Direito Comercial como hoje temos, mas foi a base, foi a origem dos conceitos, a origem do que ao longo do tempo formou-se. Não existe nada em direito que não tenha seu embrião em Roma, mormente em Direito Privado, como o Comercial.

Ilustramos, ainda, para mais acrescentar, que no Direito das Coisas, em Roma, existiam as *coisas consumíveis* (aquelas que se destroem com o uso normal), as *coisas inconsumíveis* (aquelas que o uso normal não consiste em destruí-las), as *coisas in commercio* (aquelas suscetíveis de apropriação particular e alienação) e as *coisas extra commercium* (aquelas insuscetíveis de apropriação particular ou de alienação).

Ora, versar sobre Direito Comercial é versar sobre consumo, sobre mercado, sobre alienação, sobre apropriação de coisas pertencentes a pessoas (seja física, seja jurídica), seja para ofertar à sociedade como produto de venda, de troca, com ou sem vantagem financeira, seja considerando como patrimônio pessoal ou social (aqui, no sentido de sociedade). Aí está, mais uma vez, o Direito Romano demonstrando a sua importância ao Direito Comercial como pai, como avô do que os tempos apenas copiaram e aperfeiçoaram nesta especificidade sistêmica.

Como nos ensina o grande jurista brasileiro WALDEMAR FERREIRA⁴, os romanos não distinguiram o *comercial* do *civil*, nem muito menos quiseram separar o direito privado criando normas peculiares ao exercício do comércio, bastando o *jus civile* para disciplinar os negócios dos comerciantes, como forma de remediar a solução para suas lides. Percebemos, dessa maneira, que Roma não produziu um real sistema jurídico, uma real codificação específica para o direito comercial, mas sim utilizou como fundamento para as relações de comércio o Direito Civil, com muita propriedade.

Recolhemos um texto do DIGESTO de PAPINIANO, Livro I, Título I, De *Justitia et Jure*, 7, 1º, onde demonstra a importância do papel do Pretor na atividade comercial, no

4 FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. Volume I. Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 35.

anseio de atender as necessidades dos mercadores da época: “*Jus proetorium est, quod proetores introduxerunt, adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam: quod et honorarium dicitur, ad honorem proetorum sic nominatum*”.

Percebe-se claramente que o *jus civile* era chamado pelo Pretor na tentativa de suprir a necessidade pública daqueles que praticavam o comércio. O Pretor, na realidade, aplicava o que os romanos chamavam de Direito Honorário, sendo a voz viva do Direito Civil em auxílio aos mercadores. Como bem ponderou PAULRHEME⁵, o Direito Civil Romano não desfavorecia a atividade mercantil, admitindo em princípio o contrato abstrato, sendo a ideia de criação de um direito especial ao comércio um imenso choque com a essência romana da centralização. Ainda, importante ressaltar que os estrangeiros que comercializavam em Roma eram regidos pelo *jus gentium*, este completamente diverso do *jus civile*.

As atividades comerciais mais importantes da época romana sem dúvida alguma foram o marítimo (no Mediterrâneo) e o de moedas, este praticados pelos *argentarii* e pelos *nummularii*, na realidade o que chamamos hoje de banqueiros e cambistas.

Como nos bem ensina o saudoso mestre FRAN MARTINS⁶, os romanos não viam com bons olhos que seus cidadãos se dedicassem ao comércio justamente por ter a ideia de que a obtenção de lucro visava a usura e a agiotagem, teoria esta que foi lastreada principalmente pelo Direito Canônico.

Aqui abrimos um parêntese para dizer que, se percebemos este ponto fundamental veremos que a ideia de usura no Brasil não mais persiste nos dias de hoje, principalmente nas relações bancárias com o consumidor, onde a prática de juros abusivos estão institucionalizadas no Brasil, a ponto do Supremo Tribunal Federal liberar os bancos a praticarem qualquer taxa com a sociedade, afastando a ideia da existência de usura. Não se consegue no Brasil revisão contratual em Juízo por prática ilegal de usura (taxas elevadas de juro bancário) justamente pelo grande *lobby* das instituições financeiras no Poder Judiciário. Faz pena o ordenamento jurídico brasileiro ter esquecido os ensinamentos dos romanos em momentos como este.

Voltemos ao tema. No Direito Romano há pontos importantes e fundamentais para que se possa afirmar da sua contribuição à sistematização de um direito do comércio, principalmente no que diz respeito as regras dos contratos. Sabe-se que os romanos formaram a maior fonte civil deste tema, todas utilizadas nas relações comerciais da época, mesmo não existindo leis comerciais específicas sobre o assunto. Na realidade, recorria-se ao *jus civile* sempre que se necessitava de regras contratuais para as relações comerciais.

Mesmo não havendo um Direito Comercial sistematizado em Roma, diversas regras foram de grande utilidade para a criação de institutos comerciais que são utilizados até os dias de hoje em diversos ordenamentos jurídicos, como já citado alhures – e complementamos identificando ainda a *cessio bonorum*, que regulava o fato de que os bens do devedor insolvente devia ser desapossado pelo Estado para venda em *hasta pública*.

Contudo, é a *Lex Rhodia de Jactu* a mais antiga referência legislativa comercial de que se tem notícia, encontrada no Digesto de Justiniano, que determinava o direito do coman-

5 RHEME, Paul. *História Universal del Derecho Mercantil*. Madrid, 1941, pág. 56

6 MARTINS, Fran. *Curso de Direito Comercial*. 15ª Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 6,

dante do navio em jogar ao mar as mercadorias que trouxessem perigo à embarcação. Aqui, há de fazermos um breve relatório sobre o tema.

Dizia César que os romanos preferiram imitar os estrangeiros a tornarem-se invejosos. Tinham, assim, os romanos, a capacidade de adaptação a novas situações sociais. De agricultores e pastores transformaram-se em comerciantes e navegadores. Diz-se, ainda, que teriam muito lucrado com a dominação de Cartago. A exploração do mar, a construção de embarcações, aprenderam-nas com os vencidos, tomando-lhes o que poderiam oferecer de proveitoso.

Desta forma, os romanos não fugiram de sua missão histórica mediterrânea, pois povos poderosos como os cartagineses e os gregos deram imenso contingente para a formação espiritual romana. Foi o que aconteceu com os Ródios, habitantes de uma pequena ilha no mediterrâneo, mas grandes navegadores, intitulados se “senhores dos mares”.

Como é sabido, foi (e sempre será) a missão do Direito Romano servir de traço de união entre civilizações antigas, como a dos Ródios, e os que receberam a sua herança espiritual. A “*lex Rhodia de iactu*” é um exemplo disto. Lê-se no Digesto, XIV, II: “*Lege Rhodia ut si levandae nabis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod omnibus datum est*”.

Desta pequena ilha de Rhodes teria surgido a prática de proceder-se ao alijamento de carga, em caso de perigo iminente à embarcação, concorrendo todos os interessados para ressarcimento do prejuízo. Nada mais é do que a chamada avaria comum ou grossa, prevista, por exemplo, no Código Comercial Brasileiro de 1850 em seus artigos 764, inciso 2º. Inclusive, as Leis de Hamurabi já previam as avarias em geral.

Tais princípios atravessaram as idades, vindo a refletir-se no Consulado do Mar, nas Regras de York e Antuérpia e nos Códigos Modernos. Nos três séculos antes de Cristo eram os Ródios o povo mais poderoso na navegação do mediterrâneo, provindo daí a influência exercida sobre as demais nações marítimas. Eram condições para a aplicabilidade da lei ródia: a) um perigo iminente (força maior); b) perda real da coisa alijada; c) intenção de salvar o navio e a carga; d) que o navio e a carga sobressalente fossem salvos.

Na realidade, em ocorrendo a aplicabilidade da lei, a regra era de proceder-se o rateio, calculando um “monte” com o valor do navio salvo, o das mercadorias sobressalentes e das alijadas. O armador contribuiria com o valor do navio salvo, os proprietários das mercadorias sobressalentes pelo preço corrente por ocasião da descarga e os das mercadorias alijadas pelo valor da aquisição. A lei Ródia só se referia ao alijamento de mercadorias, mas os romanos passaram a aplicá-la a outros casos análogos, tais como: a) estragos de mercadorias; b) corte de mastros; c) abandono de mercadorias para resgate do restante das mãos de piratas.

A questão muito debatida na doutrina é saber se se tratava de contrato de fretamento ou se teria origem na responsabilidade delitual, na gestão de negócios ou, ainda, no enriquecimento sem causa. Contudo, havia, em rigor, um consórcio entre o navio e a carga.

Os efeitos benéficos da *Lex Rhodia*, ampliados pelo Direito Romano, repercutiram na legislação de muitos povos, entre eles o brasileiro, como já citado, inclusive no projeto de alteração do Código Comercial, em 1912 pelo grande jurista Inglês de Souza, no primeiro Código Brasileiro do Ar (de 1938), artigo 132 e no projeto do Código Marítimo de 1946, não sendo diferente do Código Civil Brasileiro de 2002, livro de Direito de Empresa.

Assim, tudo indica que, apesar do aperfeiçoamento da legislação referente aos seguros marítimos, os princípios da lei Rhódia continuarão a exercer influência no direito contemporâneo, sendo aconselhável sua extensão ao próprio direito aeronáutico, nos casos em que, para salvar a aeronave, ou parte da carga, seja necessário realizar alijamento.

Vê-se, aí, mais uma vez, uma importantíssima contribuição do Direito Romano ao Direito Comercial em toda a sua evolução histórica, em mais um item do ordenamento jurídico comercialista. Claramente, ignorante é quem afirma que em Roma não havia absolutamente nada em Direito Comercial e que, como muitos afirmam, o mesmo teve início na Idade Média, mais precisamente na França de Napoleão. Puro descaso à ciência e uma heresia jurídica.

Há que se entender que em Roma o *jus civile* era a pedra fundamental do direito, regulando a vida dos cidadãos de forma equitativa, de modo que o comércio não refletiu tamanha importância em ser regulamentado, muito menos de ter a pretensão de desfazer o grande tronco civilista de que vivia as leis romanas. O Direito Comercial não tinha como ganhar vida própria e independente do *jus civile*, e por esta razão o costume dos mercadores, principalmente os do mediterrâneo, ainda era a grande fonte legislativa comercial.

Desta forma, os romanos admitiam um Direito Comercial excepcional, de forma abstrata, não vislumbrando a hoje chamada unificação do direito privado, tentada em diversas legislações (inclusive a brasileira), sem o sucesso esperado.

Nesse sentido, o ilustre comercialista WALDEMAR FERREIRA⁷ nos ensina que em Roma as leis refletiam os seus costumes e esse era o porque no Digesto poucos títulos encontram-se consagrados ao comércio, como o que se vê no fr. 9, título 2, I.14, que um certo Eudemon, quando apresentado ao Imperador Antonino queixa-se contra um bando de salteadores que haviam roubado o seu navio carregado de mercadorias destinados a Roma. Naquele momento, o Imperador se recusou em conhecer da reclamação fundamentando que se ele era senhor do mundo (*mundi dominus sum*), a lei Rodhia era senhora do mar (*lex autem maris Lex rodhia*).

Como já salientado acima em diversos momentos, mas nunca é demais repetir, houve em Roma a introdução de diversos institutos de direito comercial, principalmente o marítimo, totalmente desconhecidos do *jus civile*, como por exemplo a *actio executoria*, *foenus nauticum*, *avarias commons*, entre outros.

A discussão da existência ou não de um Direito Comercial em Roma é bastante intensa na doutrina, trazendo a discussão para o campo dogmático de forma sistemática e extensiva. O ilustre e saudoso mestre brasileiro RUBENS REQUIÃO⁸ salienta que o *jus civile* romano tinha aversão às atividades lucrativas justamente por sofrer imensa influência do Direito Canônico, tomando por base e lastro o versículo bíblico do Deuteronômio: “Ao teu irmão não emprestarás com usura...”.

7 FERREIRA, Waldemar. **Curso de Direito Comercial**. Primeiro Volume. São Paulo, Salles, Oliveira, Rocha & C., 1927, pág. 18-19

8 REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 25. ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 2003 – Vol. 1, pág. 9.

Outro ilustre doutrinador, o grande jurista DILSON DORIA⁹, atesta que o regime feudal em Roma deixou diversos obstáculos à expansão do comércio, quando relata: “Além dos naturais óbices que o regime feudal impunha ao desenvolvimento do tráfico mercantil, prejudicava-o também a falta de uma legislação que estimulasse o seu incremento.”

No bárbaro Direito Romano, a base jurídica era que o corpo do devedor respondia pelas suas dívidas, sem nenhuma intervenção do Estado na relação privada entre as partes contraentes, onde o credor poderia dispor do que quisesse para reaver seu direito fazendo justiça com as próprias mãos. Contudo, a partir da LEI DAS XII TÁBUAS – fonte do direito público e privado, delinear-se as execuções singulares e coletiva, de grande contributo para as relações comerciais da época.

Contudo, felizmente a execução desumana não durou muito tempo, e mais precisamente nos anos de 428 ou 441 a.C., veio à tona a conhecida e famosa *Lex Poetelia Papiria*, a qual abolia a *manus injectio*, fortalecendo a atuação do magistrado romano, prescrevendo a execução extrajudicial. Assim, os bens do devedor, e não o seu corpo, passam a constituir a garantia dos credores.

Tal contributo de caráter processual teve (e tem) imensa importância nas relações comerciais como fundamento jurídico para configurar a quebra, insolvência do mercador, mesmo que este instituto ainda não existisse especificamente na legislação romana de forma individual. Da mesma forma, as regras de contratos e obrigações tiveram a mesma importância para a regulamentação das relações comerciais em Roma, sempre com base no desenvolvimento do *jus civile*, pedra fundamental da civilização.

Roma viveu todas as experiências fáticas/jurídicas em suas três fases, seja a anterior à República (período muito desigualitário), seja na República (onde se fixou o pilar do direito das magistraturas, organização do poder, etc), seja no Império (período torto por concentrar novamente o poder nas mãos do Imperador). E assim foi criando todo o arcabouço jurídico para a humanidade. Para a disciplina comercial não foi diferente, vez que, na seara privatista, o povo romano criou a espinha dorsal de todo o pensamento jurídico dos tempos, até a contemporaneidade. Jamais, em tempo algum, devem de ser esquecidos.

2. A EVOLUÇÃO DO DIREITO COMERCIAL. O DIREITO COMERCIAL BRASILEIRO

No item anterior tratamos de demonstrar a existência do âmago do Direito Comercial em Roma, tornando-se indiscutível a sua presença naquele sistema jurídico, mencionando diversas normas de Direito Romano que contemplavam a matéria. Todavia, não podemos falar de evolução histórica nem citar a entrada do Direito Comercial em qualquer ordenamento jurídico sem tratar dos primeiros traços do que hoje consideramos como Direito Comercial, isto é, “um conjunto sistematizado de normas regulando a atividade mercantil”.

O nascimento do Direito Comercial está intimamente ligado a atividade dos grêmios ou corporações de mercadores que se organizaram nas cidades comerciais medievais para melhor defesa dos interesses comuns da classe. As corporações, perfeitamente organizadas, não só eram redigidas por estatutos escritos, que em sua maior parte recolhiam práticas

9 DORIA, Dilson. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo, Saraiva, 1981, pág. 16

mercantis tradicionais, como também instituíram Tribunais de Mercadores (Jurisdição Consular), que resolviam as questões surgidas entre os associados, administrando a justiça segundo os usos e costumes do comércio, ou seja, do chamado *Direito Consuetudinário*.

Será interessante assinalar a organização dessas Corporações. Eram dirigidas por funcionários chamados “Cônsules”, eleitos pela coletividade dos comerciantes. Ao assumir o cargo, os cônsules prestavam juramento comprometendo-se a julgar sempre de acordo com as regras que, previamente, anunciavam como base de suas decisões. O conjunto dessas regras acabou por constituir um corpo de usos que tomou o nome de “Estatutos”, daí porque a regulamentação das corporações naquela fase histórica é chamada de “Legislação Estatutária”.

Não somente as relações entre comerciantes eram governadas pelas regras publicadas pelos cônsules, mas também os comerciantes não ficavam submetidos a justiça comum. As suas querelas eram julgadas por “Tribunais Consulares”, que eram compostos de um cônsule, assistido por um jurisconsulto e dois comerciantes. Assim, os comerciantes regulavam os litígios entre os membros da corporação, sem recorrer aos tribunais comuns.

Os “Tribunais Consulares” julgavam de acordo com a Legislação estatutária e o faziam sumariamente, segundo a equidade. Preliminarmente restrita aos comerciantes membros da corporação, a jurisdição desses Tribunais Consulares se estendeu aos poucos às pessoas estranhas que de fato praticavam atos de comércio, sem que se exigisse delas a qualidade de comerciantes.

Convém aqui citar as principais compilações de normas que constituíam os estatutos dos comerciantes. As mais importantes foram os “*Rolos de Oleron*”, o “*Consulado do Mar*” (este, como já vimos, influenciado pela *Lex Rhodia de Iactu, de origem Romana*) e as “*Leis de Wisby*”. Os primeiros contêm os julgamentos do tribunal da Ilha de Orelon, na costa atlântica da França, que eram redigidos com pergaminhos e conservados enrolados, daí o seu nome.

O “Consulado do Mar” era uma coleção de costumes marítimos de autor desconhecido, mas atribuída pela maioria dos autores como sendo originada de Barcelona. Essa compilação se aplicava em toda bacia do Mediterrâneo e, como já vimos, no tópico anterior, tem fundamentação e conceitos de origem romana, mormente no que diz respeito à Lei Ródia. Quanto as “Leis de Wisby”, tiraram o seu nome dos usos aplicados na cidade de Wisby, na Ilha Sueca de Gotland, no mar Báltico.

É oportuno registrar que naquela época prosperavam os lugares de troca, centros em que se encontravam comerciantes vindos das diversas partes de um mesmo país, ou de países estrangeiros, para trocar suas mercadorias.

Estes centros, locais ou regionais, eram chamados “Mercados” e, quando mais importantes e atraíam estrangeiros, denominavam-se “Feiras”. Estas últimas adquiriram na França um caráter internacional, mas, como se sabe, existiam desde Roma.

As feiras de Champagne, Lyon e Beucaire, exerceram uma grande influência na formação do Direito Comercial sistematizado, pois favoreceram a elaboração de usos fonte direta do nosso direito moderno. Institutos como a Letra de Câmbio e a compensação periódica das contas, as aperfeiçoaram nas feiras. Institutos novos também surgiram, valendo citar os processos severos de execução contra os maus pagadores, que são a origem da falência. Contudo, tais processos de execução, como já vimos em tópico anterior, também tem origem romana.

Quais são, nas vésperas dos tempos modernos, os caracteres específicos do Direito Comercial?

O Direito Comercial é, então, mais internacional que nunca, graças aos usos elaborados nos mercados e feiras, a legislação estatutária e aos costumes das cidades livres da Itália, legislação que hoje sustenta o Direito Comercial brasileiro¹⁰.

O Direito Comercial é, também, um direito profissional e corporativo, um direito subjetivo, elaborado e considerado a pessoa do comerciante. Mas a noção abstrata do ato de comércio desempenha ainda um papel secundário, não é tomada como pedra angular de um sistema de Direito Comercial, só sendo utilizada para delimitar a competência das jurisdições comerciais com relação aos particulares não comerciantes.

Os acontecimentos de ordem geográfica, econômica e política dos séculos XV e XVI influenciaram consideravelmente o Direito Comercial.

Pode-se dizer que tais fatores deram a esse período o valor de um esboço do mundo contemporâneo. São os tempos de Renascença e da Reforma. A preponderância mediterrânea se desloca para o Atlântico em favor de Portugal e Espanha e mais tarde Holanda, França e Inglaterra. É quando surgem, naqueles três últimos países, as famosas Companhias, antecessoras das modernas sociedades anônimas.

Constituíam-se essas Companhias através de vastos agrupamentos de capitais, assumindo grande importância política e econômica. As mais famosas foram as Companhias das Índias Orientais, a Companhia do Levante, a Companhia da Baía de Hudson, entre outras. Essas companhias detinham um poder tal, que foram as responsáveis pela expansão colonial dos países de que se originavam.

Nessa época observa-se o desenvolvimento das doutrinas protecionistas, que reforçaram a atividade de trocas internas, acentuando a atenuação do caráter internacional do direito comercial.

Também contribuiu para essa atenuação a formação dos grandes estados monárquicos, o que determinou o crescimento da autoridade legislativa, diminuindo a produtividade das fontes costumeiras, ao mesmo tempo que favorecia o desenvolvimento de uma legislação mais rígida, atingindo a liberdade de comércio.

Essa legislação emanava de um poder exterior aos comerciantes, enquanto a legislação estatutária, severa que fosse, era obra dos próprios comerciantes. Os tempos estavam amadurecidos para as primeiras codificações específicas de um Direito Comercial sistematizado, mas, sempre, com as fontes e conceitos em diversos preceitos e experiências romanas.

Na França, os documentos e regulamentos sob a forma de ordenanças, de declarações, de éditos, emanam de autoridade real, não muito diferente da sistemática romana. A primeira codificação moderna data do reinado de Luiz XIV, uma iniciativa de Colbert.

Compõe-se de duas ordenanças. A primeira, de março de 1673, diz respeito ao comércio terrestre e foi preparada por uma comissão de comerciantes e magistrados, tendo influenciados grandemente os autores do futuro Código Comercial Francês. A segunda Ordenança, data de 1681 e disciplina o comércio marítimo e é bastante superior a anterior, isto porque

10 ESCARRA, Jean. **Cours de Droit Commercial**. Librairie Du Recueil, Paris, 1952.

a elaboração técnica do direito marítimo era mais antigo que a do direito comercial terrestre e, acima de tudo, porque a comissão encarregada de sua elaboração era composta sobretudo por jurisconsultos¹¹.

No fim do século XVIII produziu-se a sombra das idéias da revolução francesa, uma profunda modificação na fisionomia do direito comercial. Foi o período do liberalismo econômico que durou intacto perto de um século. À ideologia revolucionária repugnava manter um direito de casta, pois preconizavam os filósofos da revolução a igualdade de todos perante a lei.

O direito comercial, de um direito profissional e autônomo, perdendo seu caráter subjetivo, passou a adquirir um caráter objetivo e marcante, pois era a noção abstrata do ato de comércio que o impregnava.

Sob o influxo de novas idéias que empolgavam os espíritos, Luiz XIV, na França, nomeou uma comissão revisora das Ordenanças de 1673, comissão essa presidida por Miroslaw, que elaborou Projeto de Código, chegando este a ser impresso. Ao mesmo tempo procedeu-se a coleta de material para revisão da Ordenanças Marítimas.

Tudo isso conheceu ao preparo do Código Comercial da França que, finalmente, veio a ser promulgado por Napoleão e convertido em lei de 15 de setembro de 1807, entrando em vigor em 01 de janeiro de 1808.

Foi ele o primeiro Código de Comércio Moderno. Surgindo em momento histórico oportuno, quando o comércio, devido as descobertas científicas e a rapidez dos meios de comunicação, havia sofrido uma notável transformação e alargado o volume de suas operações, constituiu o Código Comercial Francês de 1807 o marco legislativo da nova época do direito comercial.

Consolidou as velhas normas de direito costumeiro, consagradas pela prática mercantil e a sua influência foi decisiva em toda a legislação comercial contemporânea. Não avançada nas idéias, nem revolucionário nas diretrizes, antes impregnado do senso de universalidade, tornou-se o Código padrão reproduzido, imitado ou adaptado no velho e no novo mundo, como no Brasil e em Portugal.

Nos fins do século XIX começa a se desenhar uma evolução cujo termo ainda não atingimos e que tende, talvez, menos a deformar o caráter do Direito Comercial, que a de lhe restituir, em parte, sob formas modernas, a fisionomia de suas origens.

Essa evolução se caracteriza por um aumento contínuo das disposições de ordem pública e da intervenção cada vez maior no domínio das atividades comerciais e industriais e teve como causa as duas guerras que, com vinte anos de intervalo, assolaram o mundo.

Essa intervenção do Estado incidiu principalmente sobre a liberdade das atividades comerciais, com a criação de taxas e impostos que passaram a gravar aquelas atividades, de modo a fazer com que os comerciantes paguem hoje enormes somas ao fisco, somas que logicamente vão recuperar do consumidor.

Há a assinalar também a incidência sobre o comércio da legislação social, afetando de algum modo o consumidor.

11 MENDES, Otávio. **Direito Comercial Terrestre**. São Paulo, Ed. Saraiva, 1930.

Com efeito, desde o dia em que os operários puderam se organizar legalmente em sindicatos para a defesa dos seus interesses profissionais, os comerciantes tiveram que tomar conhecimento de suas reivindicações.

Hoje, a legislação trabalhista determina uma série de medidas protecionistas dos direitos do trabalhador, tais como fixação de um piso salarial, o seguro de acidentes de trabalho, as férias, o repouso remunerado, a previdência social e outras tantas vantagens que constituem um pesado encargo as empresas comerciais e industriais, que muitas vezes não podem repassar ao consumidor.

Mais recentemente se faz prever uma reviravolta no direito comercial, mercê da queda dos regimes comunistas na quase totalidade dos países em que dominavam, notadamente nos do leste europeu.

Certamente que a volta ao regime da livre iniciativa está trazendo transformações na legislação comercial. Muitas das atividades comerciais que o Estado vinha desempenhando através das empresas estatais voltaram a iniciativa privada e com isso há de se pensar em revisão de atitudes e normas que permitam a disciplina da nova ordem de coisas. Não é errado afirma-se que o Direito Comercial está voltando a sua vocação primeira, a de se constituir em um direito profissional.

No Brasil, cumpre destacar, inicialmente, que o primeiro Tratado de direito comercial escrito em língua portuguesa foi de autoria de um brasileiro, José da Silva Lisboa, o “Visconde de Cairu” e denominava-se *Princípios de Direito Mercantil e Leis da Marinha*.

Dividia-se o livro, considerado por Ferreira Borges como *Código Mercantil para Portugal* até a publicação do *Código Comercial Português de 1833*, em sete tomos a saber: o do seguro marítimo, o do câmbio marítimo, o das avarias, o da letra de câmbio, o dos contratos mercantis, o da polícia dos portos e alfândegas e o dos tribunais e causas do comércio.

Foi o Visconde de Cairu quem demonstrando largueza de vistas e valendo-se das circunstâncias, sugeriu a Dom João VI, em sua passagem pela Bahia, a abertura dos portos do Brasil ao comércio estrangeiro, fato que teria uma grande e decisiva influência na evolução comercial do país.

Em 23 de agosto de 1808, o governo de Portugal, instalado no Brasil, cuidou de aparelhar-se convenientemente, e assim, em Alvará, com força de lei naquela época, criou a Real Junta de Comércio, Agricultura, fábricas e Navegação do Estado do Brasil.

Entenderia Junta de tudo quanto se relacionasse ao comércio, agricultura, fábricas e navegação. Entre os seus membros estava José da Silva Lisboa, o que foi bastante para que a Real Junta lhe atribuísse o encargo de elaborar o projeto de *Código de Comércio para o Brasil*.

Um plano de *Código* chegou a ser apresentado, mas caiu no silêncio, reduzindo-se por fim a um esboço de regimento do comércio com a denominação de *Regras da Praça ou Bases de Regulamento Comercial*, conforme os *Códigos de Comércio da França e Espanha* e a *Legislação Pátria*, regras essas publicadas em 1832.

Tornando-se o Brasil independente, em 1822, cumpria-lhe elaborar seus *Códigos*. Em 1824, veio a *Constituição Política*, em 1830 o *Código Criminal* e, finalmente, em 1850, o *Código Comercial*, que começou a vigorar em 1851.

Compunha-se o Código Comercial do Império de 3 partes: a primeira, do Comércio em Geral, a segunda do Comércio Marítimo e a terceira e última, das Quebras. Completava-o um Título único: da administração da justiça nos negócios e causas comerciais, subdividindo-se em dois capítulos – dos Tribunais e Juntas Comerciais e da ordem do juízo nas causas comerciais.

Dois regulamentos foram baixados para a execução do Código: o Decreto 737, de 25 de novembro de 1850, redigido por Carvalho Moreira, que vigorou entre nós até 1939, quando foi promulgado novo Código processual; e o Decreto 738, da mesma data do anterior, destinado a execução do Título único do Código e em duas partes dividido – a dos Tribunais do Comércio e a do Processo das Quebras.

Em seguida, editaram-se mais três Regimentos – dos Corretores, pelo decreto 806, de 26.07.1850, dos Leiloeiros, pelo decreto 859, de 10.11.1851, e o dos Intérpretes do Comércio, pelo decreto 863, de 17.11.1851.

Não vigorava há muito o novo Código quando sofreu o primeiro embate com a realidade brasileira. A crise comercial financeira de 1864 originou a legislação de emergência sobre bancos de emissão, sociedades anônimas, cheques, falências de Banco, bilhetes ao portador, derogando-se ainda o juízo arbitral instituído pelo Código.

Em 1875, desferiu-se profundo golpe no Código, com a supressão dos Tribunais de Comércio, amputando-se todo o Título único. Em 1882, foi derogada toda a parte referente as sociedades anônimas, com a promulgação de uma lei especial regulando a constituição e funcionamento destas.

Com a proclamação da República, sofreu o Código um novo rude golpe, com a derrogação de toda a parte das Quebras, com a promulgação do decreto 917, de 24.10.1890, que instituiu a nova lei de falências, hoje em vigor pela Lei 11.101/2005.

Fertilíssima foi a faina legislativa subsequente. Decreto criando os Armazéns Gerais, regulando a letra de cambio e a nota promissória, derogando o código nessa parte, criando as sociedades por quotas de responsabilidade limitada, regulamentando os conhecimentos de transporte, o cheque, a hipoteca de navios, novo regulamento para os corretores e leiloeiros, o decreto regulando as sociedades de capitalização, a lei que disciplina as duplicatas e contas assinadas o decreto que instituiu o Código Brasileiro do Ar (que, como vimos, há origem romana na Lei Ródia), o que dispôs sobre as empresas de cabotagem, a nova lei de falência de 1945, o Código de propriedade industrial, o novo decreto-lei sobre as sociedades por ações e um número elevado de regulamentos sobre os mais variados assuntos, editaram em quantidade verdadeiramente impressionante.

Essa vasta elaboração legislativa revelava a necessidade da ampla reforma do nosso Código Comercial, mais do que centenário, mais ainda vigente sobre vários assuntos.

Aliás, desde cedo houve tentativas para reforma, valendo citar o empenho de Teixeira de Freitas ao propor ao Governo Imperial a unificação do Direito Privado, mas só em 1911 o Governo manifestou preocupação em reformar o Código, quando encarregou o jurista Inglês de Souza de elaborar projeto para um novo Código.

Desincumbiu-se o eminente comercialista apresentando dois projetos, um de Código Comercial e outro unificando o Direito Privado. Ambos foram discutidos no Congresso Nacional, mas sem que lograssem ser convertidos em lei.

Em 1935, nova tentativa do Governo com a designação de uma Comissão de juristas, constituída por Orozimbo Nonato, Filadelfio de Azevedo e Hannemann Guimarães, todos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com o encargo de elaborar um projeto de Código de Obrigações, tarefa que foi concluída, apresentado a comissão ser trabalho em 1941, quando foi divulgado. O estranho é que o Governo parece ter desistido da ideia, tanto que não chegou a encaminhar o projeto ao Congresso. Novas tentativas foram feitas no Governo do Presidente Dutra, em 1952 e no Governo Jânio Quadros, todas sem chegar a qualquer resultado prático, embora a elaboração de vários anteprojetos.

Finalmente, no Governo do Presidente Médici foi nomeada Comissão presidida pelo professor Miguel Reale e integrada pelos professores Sílvio Marcondes, José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alves, Ebert Chamoun, Clovis do Couto e Silva e Torquato de Castro, com a incumbência de elaborar e rever o Código Civil. A comissão preferiu, ao invés de simplesmente rever e elaborar um Código Civil, propor a unificação do Direito das Obrigações dentro do próprio Código Civil.

Depois de vários anos de tramitação no Congresso Nacional, finalmente, em 10 de janeiro de 2002, foi instituído no Brasil o NOVO CÓDIGO CIVIL, através da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Com o advento no novo Código Civil, já em pleno vigor, houve uma grande modificação no direito privado positivo, especialmente no regime geral das sociedades. A primeira parte do Código Comercial de 1850 foi totalmente revogada e a matéria passou a ser regulada no Código Civil de 2002 sob a forma de DIREITO DE EMPRESA.

Tendo em vista que o Código Comercial de 1850 se fundamentou no Código Comercial Francês e adotou em grande parte a Teoria dos Atos de Comércio, bem como pelas disposições do atual Código Civil de 1916, na sua vigência havia nítida necessidade de se identificar o que era ato de comércio e o que era ato civil, existindo, portanto, distinção entre empresário civil e empresário comercial, empresa civil e empresa comercial e, conseqüentemente, sociedade civil e sociedade comercial.

A maior importância da diferenciação se dava na aplicação do regime jurídico aplicável em caso de *bancarrota* que, para os empresários e sociedades civis era o da insolvência civil e, para os empresários e sociedades comerciais, era o falimentar.

Como o Código Civil de 2002 adotou o Sistema Italiano e a Teoria da Empresa, a partir daí passamos a ter apenas o empresário e a empresa, a atividade empresária e a atividade não-empresária e, conseqüentemente, a sociedade empresária e a sociedade não-empresária¹².

12 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

Com isso, a partir de janeiro de 2003 as pessoas físicas ou jurídicas que exercem no Brasil atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços, serão consideradas, respectivamente, empresários e sociedades empresárias e deverão ser registradas no Registro Público de Empresas Mercantis (arts. 996, 967 e 992), devendo ser constituídas sob qualquer dos tipos regulados em lei (art. 993), ressalvando-se as constantes em leis especiais (parágrafo-único).

Desapareceu, portanto, a distinção entre sociedade civil (que na vigência do Código Comercial de 1850 era a que tinha por objeto a prática de atos civis – prestação de serviços) e a sociedade comercial ou mercantil (a que tinha por finalidade a prática de atos de comércio), passando ambas (a partir do Código Civil de 2002), se exercerem as suas atividades como forma de empresa, a serem consideradas sociedades empresárias.(arts. 991, 992 e 996).

Desta forma, os empresários e as sociedades empresárias estão sujeitas ao regime jurídico-falimentar, hoje instituído pela Lei 11.101/2005.

São excluídas das chamadas atividades econômicas empresariais pelo Código Civil de 2002 as chamadas SOCIEDADES INTELECTUAIS DE CARÁTER CIENTÍFICO, LITERÁRIO OU ARTÍSTICO, excetuando-se aquelas em que o exercício da profissão constituir ELEMENTO DE EMPRESA (art. 996, parágrafo único).

O foco do legislador passou a ser, portanto, a atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços (empresa) com a exclusão das atividades intelectuais (salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa) e, não, a distinção entre ato civil e comercial.

Após estas considerações profundamente necessárias, vejamos quais as vantagens e desvantagens da revogação da primeira parte do Código Comercial de 1850 e da introdução do Direito de Empresa no Código Civil de 2002.

Esta parcial unificação legislativa do direito privado com a regulamentação da Empresa, Empresários, Sociedades Empresárias, Estabelecimento Empresarial, etc., no Código Civil e a conseqüente revogação da primeira parte do Código Comercial de 1850 deu a falsa impressão de que o Direito Comercial deixou de existir e foi substituído pelo Direito Empresarial

Alguns cursos jurídicos, precipitadamente, alteraram seus currículos e substituíram a cadeia de Direito Comercial pela de Direito Empresarial.

Ocorre que, na verdade, o Direito Comercial é gênero que comporta várias espécies, como o Direito Marítimo, o Direito Cambial, o Direito dos Contratos Mercantis e o próprio Direito de Empresa. Por outro lado, além da segunda parte do Código Comercial de 1850 que trata do Direito Comercial Marítimo permanecer em vigor, outras Leis Comerciais

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo.

Art. 2.037 – Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes, ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis.

também não foram atingidas, como, por exemplo, a Lei das Sociedades Anônimas, as Leis do Cheque e da Duplicata, etc.

Desta forma, é importante ressaltar que esta confusão legislativa e acadêmica não foi boa e a falta de uma sistematização do Direito Comercial, num novo Código Comercial é a solução mais plausível para o momento.

Por oportuno, é ínsito registrar que já tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 1.572, de 2011, sob a relatoria do Deputado Vicente Cândido, cujas diretrizes foram elaboradas pelo professor Fábio Ulhoa Coelho, da PUC/SP e que é um dos mais festejados comercialistas brasileiro da atualidade.

Lamentavelmente, o legislador não avançou tanto e ainda manteve fora da seara do Direito Comercial as atividades intelectuais de natureza artística, científica e literária, mesmo se exercidas sob forma de empresa.

Com isso, às sociedades de advogados, por exemplo, não se aplica o regime jurídico-empresarial, o que afasta a possibilidade do exercício da recuperação extrajudicial, judicial e da falência, o que, para nós, é um retrocesso.

O profissional intelectual é aquele que utiliza no exercício da atividade a sua inteligência, o seu saber, o seu conhecimento, o seu dom, como fazem as profissões liberais (advogado, médico, dentista, etc) e os artistas (escritor, ator, escultor, etc.).

Tais profissionais produzem pessoalmente para o seu próprio sustento e, ao mesmo tempo, são a eles que os clientes procuram e, não, a sua estrutura de trabalho, embora quase sempre o exercício de suas atividades seja feito sob a forma de empresa, mediante a organização do capital e o trabalho para fins de produção.

O Código Civil de 2002 excluiu estes profissionais do regime jurídico empresarial, mas, por outro lado, previu a inclusão dos mesmos neste regime quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E quando isto ocorre? Exatamente a partir do momento em que o cliente procura a estrutura econômica e, não, o profissional, deixando de existir entre aquele e este uma relação “*intuitu personae*”.

Entendo que, neste ponto, o legislador foi infeliz. Para que esta diferenciação?

Ora, se o profissional liberal está exercendo a sua atividade sob forma de empresa, é evidente que ele tem que ser considerado empresário e ficar sujeito ao regime jurídico empresarial, podendo, por exemplo, pleitear uma Recuperação Judicial e ser passível de falência, se os seus negócios entrarem em crise, nos mesmos moldes de qualquer outra atividade que explora uma atividade econômica organizada.

A introdução do Direito de Empresa no Código Civil brasileiro de 2002 só teve de positivo a incorporação definitiva da Teoria da Empresa no direito positivo do nosso país. Do ponto de vista prático esta parcial unificação do Direito Privado vem confundindo os operadores do direito e criando dificuldades no sentido de que além destas normas de Direito Comercial que estão dentro do Código Civil, existem outras normas em leis esparsas que tratam da matéria.

O eminente comercialista FÁBIO ULHOA COELHO, mentor intelectual do projeto de novo Código Comercial que tramita no Congresso Nacional, antes referido, assim se manifesta sobre o assunto: “*O Brasil precisa de um novo Código Comercial. Autônomo, para poder assentar as disposições normativas em princípios próprios, adequados à regulação privada da atividade econômica empresarial que atenda às demandas do nosso tempo.*”

Todos os advogados e demais profissionais da área percebem o quanto está difícil, na labuta diária do fórum, à mímica de lei moderna e específica para a matéria comercial, postular decisões que sejam, sem dúvida, justas segundo o direito, mas também empresarialmente consistentes. Com este livro, o autor pretende dar sua contribuição para esta importantíssima questão institucional, minutando um anteprojeto de Código Comercial. O diploma proposto trata, na Parte Geral, do conceito de empresa, do empresário individual, registro do comércio, escrituração, estabelecimento e comércio eletrônico; na Parte Especial, das sociedades empresárias, dos títulos de crédito, dos contratos empresariais e da crise da empresa (falência e recuperação). A minuta prevê, ainda, que o Livro II da Parte Especial do Código Civil passaria a disciplinar apenas as “sociedades civis.”¹³

Por isso, entendemos que é realmente necessário um “Novo Código Comercial” onde todas as normas da matéria sejam sistematizadas e reunidas numa única lei, facilitando, assim, a busca da fonte do direito e a efetiva e correta aplicação das normas referentes a este importante ramo do direito privado, levando-se em conta, como base maior, os ensinamentos e a experiência dos romanos.

3. CONCLUSÃO

Chegamos neste último tópico para trazer à baila nossa opinião sobre o debate jurídico ao qual nos submetemos, o que deve ser feito tomando-se em conta uma sistematização do trabalho como um todo.

Os romanos nos ensinaram justamente a separar a LEX do IURE, demonstrando a maior importância deste em detrimento daquele. *Ad argumentandum*, engana-se, por exemplo, quem acha que a LEI esgota-se na Constituição. Não é verdade, tanto que existem leis ditas constitucionais, mas que não são jurídicas porque não abarcam o direito que a sociedade clama pela transformação dos fatos sociais. Por esta razão, por exemplo, é que a LEI DAS XII TÁBUAS é muito mais concreta que a Carta Magna Americana.

Toda esta discussão hermenêutica leva-nos a entender que as experiências e os ensinamentos romanos estenderam-se ao Direito Comercial e que, mesmo persistindo na ideia de que em Roma não existiu Direito Comercial organizado e sistematizado, mas a sua evolução histórica (aí levada em consideração a brasileira), possuem um cordão umbilical eterno com o Direito Romano, aliás, como quase tudo em Direito Privado.

Por uma lei de 20/10/1823 mandaram-se observar no Brasil as Ordenações Filipinas, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções que estivessem em vigor até 25 de abril de 1821, em Portugal. Essa data é, inclusive, aquela em que D. João VI deixou o Rio de Janeiro, de regresso às terras lusas.

Assim, todo o romanismo de que estava impregnada a legislação lusitana continuou a projetar-se no Brasil Império, justamente por determinação desta lei, até que fosse elaborada uma nova codificação civil no Brasil, o que só veio a ocorrer na República, em 1916. Ou seja, o Brasil atravessou todo o Império sem lograr promulgar o Código Civil. De 1822 a 1889 vigorou, como Código Civil, o Livro IV das Ordenações Filipinas e toda a legislação lusitana aplicável.

13 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo, Ed. Saraiva, 2011

Aliás, este livro, por si só, já se encontra repleto de princípios romanos, mas a utilização do Direito Romano puro (que as Ordenações denominavam de *Direito Imperial*), continuou de caráter subsidiário.

Assim, exatamente pelo fato da legislação comercial brasileira ter sido promulgada em 1850, o Direito Privado nacional ficou refém das leis civis portuguesas por todo o Império e início da República, levando consigo o próprio Direito Comercial, demonstrando, mais ainda, a dependência do sistema jurídico privatista ao Direito Romano.

É bem verdade que as vinculações do direito brasileiro ao romano não são absolutas, isto é, não reproduzimos friamente prescrições romanas, antes as adaptamos ao nosso meio, ao nosso século, à nossa mentalidade. É o que ocorre, por exemplo, no contrato de mútuo (puramente comercial), que na classificação gaiana e justinianéia era um contrato real, que se efetiva *re*, enquanto que em alguns momentos surge como contrato consensual. Sabe-se que o mútuo romano, originário do *ex meo tuum*, segundo Gaio, contrato real, tomou aspectos novos no direito brasileiro moderno, passando à condição de contrato consensual, utilizando expressões das Institutas de Justiniano.

Desta forma, concluímos quão longe se encontram as raízes de preceitos que ainda vigem no século XXI na disciplina comercialista. Abundantes preceitos romanos se encontram em diversos artigos, itens, diplomas legais em todo o mundo, especialmente no Brasil. Como árvore solidamente presa à terra, o direito nacional tem as suas raízes plantadas no longínquo passado romano, que através dos séculos tem fornecido e continua a fornecer a seiva necessária para as florações do presente e do futuro.

Vem assim o direito romano como fonte eterna e perene aclarar caminhos e indicar rumos para os legisladores e juristas do século XXI.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011.
- COSTA, Philomeno. Autonomia do Direito Comercial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1956.
- DORIA, Dilson. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1981.
- ESCARRA, Jean. Cours de Droit Commercial. Paris: Librairie Du Recieily, 1952.
- FERREIRA, Waldemar. Curso de Direito Comercial. Primeiro Volume. São Paulo: Salles, Oliveira, Rocha & C., 1927.
- Tratado de Direito Comercial. Volume I. São Paulo: Ed. Saraiva, 1960.
- MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: 15ª Edição, Ed. Forense, 1990.
- MEIRA, Silvio A. B. Curso de Direito Romano. São Paulo: Ed. LTr, 1996.
- Clóvis Beviláqua, Sua Vida, Sua Obra. Fortaleza: Ed. UFCE, 1990.
- MENDES, Otávio. Direito Comercial Terrestre. São Paulo: Ed. Saraiva, 1930.
- REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 25. São Paulo: Saraiva, 2003.
- RHEME, Paul. História Universal del Derecho Mercantil. Madrid, 1941.
- SOUZA, Inglês de. Preleções de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves & Cia, 1910.

REFLEXIONES ROMANISTAS JURÍDICO CRÍTICAS¹



RICARDO PANERO GUTIÉRREZ

Universidad de Barcelona

Los 5 puntos sobre los que se vertebran estas Reflexiones Romanistas son: El Derecho; El Derecho Romano; La Tradición Romanista; El Derecho Civil Español y el Derecho Privado Europeo. Reflexiones centradas, sobre todo, en aspectos formales desde un punto de vista jurídico crítico.

Al Prof. Dr. Antonio Díaz Bautista

PRIMERA PARTE

I. KANT, LEIBNITZ, HERMOGENIANO, ARISTÓTELES y CICERÓN, son los *auctores*, en el sentido utilizado por Ulpiano de “garantes”,² de los que me sirvo, para dar plena validez al exordio de un acto, de quien, en mi caso, ante los Maestros presentes [e intimidado por ellos] duda de su plena capacidad y cuya *auctoritas* invoca para asegurar su eficacia.

Recuerdo: a) A KANT porque, parafraseando LEIBNITZ, muestra su fina ironía, diciendo “que incluso, en su tiempo, los juristas buscan aún una definición de su concepto de Derecho”. b) A HERMOGENIANO, por manifestar, en D.1.5.2 (1 *Iur Ep*) que *hominum causa omne ius constitutum est*. c) A ARISTÓTELES, por precisar que, al ser este (*zoós politikós*) debe tratarse del hombre en sociedad porque a un Robinsón, su propio aislamiento impediría que alguien pudiera discutirle la facultad de hacer algo. Y d) A CICERÓN, por resumir, con mano maestra, con su *ubi homo, ibi societas ubi societas ibi ius*, la relación “hombre, sociedad y derecho”, cuyos dos primeros términos [unidos] son presupuesto y fundamento del tercero³. Algo pacífico que solo, *per ludum*, ha sido

1 A mi entrañable colega y amigo, el Dr. Antonio Díaz Bautista, fidedigno representante de los *tria iuris precepta* de Ulpiano.

2 Ulpiano, D.50.17.137 (25 Ed).

3 Se reproducen algunas consideraciones recogidas en PANERO GUTIÉRREZ, R.: “Os novos xuristas e o Direito Romano” *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, AFDUDC, 12,2008, pp 723-746; en *Derecho Romano*, Valencia, 2008, p.38; en *Epítome de Derecho Romano*, Valencia 2010, p.28; en “Cupida legum iuventus” *Revista Internacional de Derecho Romano*, RIDROM [on line] 7, 2011, pp.10-14 www.ridrom.com; y en el *Derecho Romano y Europa, Teoría y Derecho, Revista del pensamiento Jurídico*, 12,2012, p.165

criticado, que no desmentido, por el pintor francés del XIX, EUGÈNE DE LAROCHE, al definir *al hombre como animal sociable que detesta a sus semejantes*. 

Siguiendo, pues, a CICERÓN⁴, el Derecho: se muestra como norma de convivencia y ejerce una función de “instrumento pacificador de conflictos entre hombres”. Gracias a él, por resumir: a) cada uno sabe lo que es suyo...; b) lo que debe y puede exigir a los demás y... c) lo que los demás a él pueden exigirle, evitando [en suma] lo que sin su presencia podría ser, en frase de HOBBS⁵ un *bellum omnium contra omnes*.

Ahora bien, al existir otras normas de conducta (como las religiosas, morales o sociales) que, también, ordenan en cierto modo, esta convivencia, se exige, que la norma a la que nos referimos presente ciertos caracteres que le otorguen el calificativo de jurídica y, en síntesis, un mecanismo de coacción socialmente establecido. En otras palabras, la norma ha de ser jurídica y para serlo exige una organización: el Estado, que [como dice LATORRE⁶] es en sí, una organización de poder, que muestra su triple faz (de legislador, juez y gendarme) *creándola, aplicándola, imponiéndola* y regulando, por ella: α) los actos externos del hombre indispensables para vivir en Sociedad β) cuyo cumplimiento pueda exigirse coactivamente. Lo que es tan cierto, precisa TALAMANCA⁷, como la afirmación inversa: *ubi ius, ibi societas*.

Partamos, pues de la idea general, de que el Derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, sin que utilizar una teoría *normativa*, comporte [como advierte TORRENT⁸] preterir otros factores: éticos, sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos, que ayuden, no ya a *aprender* [primera función del jurista, según LATORRE⁹] sino a *comprender* el fenómeno jurídico [segunda función de aquél] para así poder criticarlo y, en su caso, promover su reforma [completando, de esta manera, el triple cometido propio del *iurisprudens*].

Permítaseme recordar dos ejemplos, de sobra conocidos, que pretenden poner de relieve las dos primeras funciones. El más antiguo se refiere al *Sc Claudianum de nuptis*¹⁰, por el que se permite superar, excepcionalmente, la prohibición [*impedimentum* en términos canónicos] de los matrimonios hasta entonces incestuosos por vulnerar el límite de la *cognatio*, que se extendía hasta el 3º de la línea colateral. O sea, tíos y, sobrinos en general [ya lo hemos aprendido]. Vamos a intentar comprenderlo y, en su caso, criticarlo.

α) ¿Que extraño motivo, en principio ignoto e incomprensible, existe para derogar la anterior prohibición pero solo cuando se tratara de tío y sobrina y ésta fuera hija de un hermano β) ¿Por qué las tías, fueran paternas o maternas, no podían contraer matrimonio con sus sobrinos? γ) ¿Por qué los tíos, paternos o maternos, tampoco podían casarse con las

4 Con mínimos matices diferenciales, la frase que hemos atribuido *nominatim*, a CICERÓN, pero no fijado el lugar ni la obra en que figuraría, es negado por algunos, que vinculan su origen a la Edad Media. Cfr. por todos, referencias de autores y obras en RAFAEL DOMINGO OSLE (Coordinador) *Principios de Derecho Global. 1000 Reglas y Aforismos Jurídicos comentados*, Navarra, 2006, p. 410.

5 *De cive*, I, 12; 5, 2.

6 *Introducción al Derecho*, Barcelona, 1987, p. 21 ss.

7 *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1990, p. 15 if.

8 *Derecho Público Romano y Sistema de Fuentes*, Zaragoza, 1995, p. 11.

9 *Valor Actual del Derecho Romano* Barcelona, 1997 p. 18 ss.

10 TORRENT RUIZ, A. *Diccionario de Derecho Romano*, Madrid, 2005, s.h.v.

sobrinas hijas de hermanas? La razón, como sabéis, no incide en unos aspectos biológicos desconocidos hasta entonces y descubiertos por algún discípulo aventajado de Hipócrates, sino simple y llanamente porque quien da nombre al Senadoconsulto, el emperador Claudio, quería casarse [sólo era la cuarta vez que acometía tan arriesgada empresa] con su sobrina Agripina, hija de su hermano Germánico. ¿Qué fácil? El capricho del *princeps*, era suficiente para generar derecho a través de una de sus fuentes, *quod senatus iubet atque constituit*, en palabras de Gayo¹¹ y demostrar la veracidad del aserto que, después formulará Ulpiano para justificar las *constitutiones* imperiales, *leges* en su denominación imperial, de que: *quod principi placuit legis habet vigorem*¹². Aprendido y comprendido, la crítica y reforma correspondió en el 342 [según *Codex Theodosianus*] a Constancio que sancionará con pena de muerte al tío y sobrina que se unieran en matrimonio¹³.

El hecho de centrarnos en el *Ius Romanum* no quiere decir, lo anticipábamos, que falten ejemplos en nuestro derecho español más cercano. Solo uno más, no actual, sino de finales del XIX, Las peculiaridades jurídico-privadas de Galicia, en la época de la codificación, no eran mayores que las de cualquier otra zona española de *Ius commune* Derecho Común. Es cierto que algunas relaciones, de sustrato agrario, estaban sometidas a derecho consuetudinario, pero no lo es menos que otro tanto ocurría en el resto de nuestra geografía. Galicia, nunca tuvo normas escritas diferenciadas del derecho común y por tanto resulta llamativo que como consecuencia del Decreto Bugallal de 2,2,1880 se incorporara a la Comisión General de Códigos un representante de cada uno de los territorios forales, entre los que figuraba el de Galicia, que será considerada, desde entonces, con este carácter, cualidad que nunca antes había tenido. Por cierto, he omitido decir que el entonces ministro de gracia y justicia ÁLVAREZ BUGALLAL era gallego.

El civilista CARLOS LASARTE¹⁴, comentando este hecho, se limitará a concluir: ¡Así se escribe la historia! do a la frase el valor coloquial, con el que sin duda, la utiliza el autor, el no prescindir de otros factores [éticos, sociales, culturales, políticos, económicos y/o religiosos] ayudan a *comprender* el Derecho. En otras palabras, conocer la realidad social ayuda a comprender la realidad jurídica.

II. Tras este amplio *excursus* regresemos donde estábamos al iniciarlo, al Estado y su triple faz legislativa, ejecutiva y judicial. Algo que es sabido y pacífico, en el campo teórico y doctrinal. Pero que, sin embargo, al descender a la práctica “a pie de obra”, a la realidad de nuestros hechos cotidianos y a tenor de los mismos, el menos en España, posibilita formular, retóricamente, algunas preguntas o lo que viene a ser lo mismo, seguir con estas reflexiones críticas¹⁵.

11 I. 4

12 D.1,4,1 pr. (1 *Ins.*)

13 C Th. 3,12,1

14 Principios de Derecho Civil, I, Parte General y Derecho de la persona Madrid, 1992, p.53

15 Reproduzco, amplio y matizo unas preguntas que vengo formulando, siempre que hay ocasión, desde un ya lejano 1998: *La experiencia jurídica de Roma. Su proyección en el umbral del siglo XXI*, Valencia 1998, pp.12 y 13; RIDROM [on line] 7, 2011, “*Cupida legum iuventus*”, ob. cit. pp.10-14 y *El Derecho Romano y Europa* ob. cit. p.166.

A) ¿Que ocurre cuando se confunden los términos Nación y Estado, olvidando que es éste el que administra y gobierna a aquella? [Por cierto en donde resido, Barcelona, consciente y voluntariamente, se hace esto con harta frecuencia]; B) ¿Qué ocurre cuando para quienes, incluso apreciando la diferencia anterior, la idea de Estado está en crisis?; C) ¿Qué ocurre, Cuándo en su faz “legislativa”, el Estado, en algunos casos, parece convertirse, en instrumento “provocador” (no “pacificador”) de conflictos en la sociedad?; D) ¿Cuándo en su faz “judicial”, unas veces, olvidando a MONTESQUIEU, se pone en tela de juicio su independencia y otras, queda eclipsada, por la luz de algunos “jueces” convertidos en estrellas?; E) Que ocurre ¿Cuándo su faz gendarme se cuestiona?; F) ¿Cuándo la insumisión se proclama?... ¿Cuándo se alardea de ello?. ¡Los ejemplos están en la mente de todos...;

En fin, no dramaticemos, tan pronto, y permítaseme otro *excursus* que intentando ser *iocandi gratia*, a riesgo de herir alguna que otra sensibilidad pretende recordar al destinatario del Derecho.

III. Me refiero al texto de HERMOGENIANO, D.1,5,2 (1 *Iur. Ep*) “Causa de la constitución de todo Derecho es el hombre”. *hominum causa omne ius constitutum est*.

Pese a su claridad, sin embargo, no faltaría quienes, en amplios sectores de la sociedad [quiero presumir, aunque no con carácter *iuris et de iure*, que fuera del campo jurídico], terminarían por llevarse las manos a la cabeza, tildando de provocación evidente, sin duda obsoleta y ornada de tintes fascistoides, *el no considerar* a los componentes del reino animal, como sujetos de Derecho. Me referiré *ad exemplum* y para que nadie pudiera, *ex hipotesi*, sentirse aludido, a las musarañas, que como sabéis, [aunque no aparecen en el Digesto] son extraños, diminutos y misteriosos seres, [yo los imagino sonrientes, bondadosos y con una indescriptible *vis atractiva*] en los que desde siempre, y harta frecuencia, solemos pensar y dedicarles toda nuestra atención en actos como el presente y en los que, ineludiblemente, buscamos su recuerdo y compañía para que nos conforten ante el tedio que por su naturaleza representan.

Sin pretender entrar en el campo del filósofo del derecho me limitaré a recordar: A) que en Roma y en nuestro derecho privado general, aparecen los animales, como objeto [no sujeto] de lo que puede ser propio, *proprius*, de ahí *proprietas*, vocablo en donde se unimisma el derecho de propiedad con el objeto sobre el que recae y B) Que GAYO, en *Institutiones*, ratifica lo anterior. Por ello, restringiendo, cada vez más su tratamiento: α) incluye a los animales [en su libro II]: *ius quod ad res pertinet*; β) lo hace en *de singularum rerum acquisitione*; γ) dentro de ellas en las *naturales*, δ) cita como modos de adquirirse: la *traditio*, *occupatio* y *ex hostibus capio*, ε) y en la *occupatio*, trata, explícitamente, en general de las, *ferae bestiae*, pájaros y peces *aut volucres aut pisces* y en particular de las palomas, abejas y ciervos *columbis apibus, cervis*.

Siguiendo con el reino animal, y pasando de lo práctico a lo teórico-filosófico, no cabe silenciar que Ulpiano [a quien se le atribuye una definición reproducida por Justiniano] toma como base la naturaleza [unión y procreación] y habla de un *ius naturale*, que es, nos dicen: *quod natura omnia animalia docuit*. Descartado, hoy, la incorporación tras *animalia* del adjetivo *rationalia*, lo que también resulta claro es que este derecho

natural, va cambiando, diacrónicamente, de significado, lo que se aprecia en los cuatro principales textos que a él se refieren [2 del Digesto y 2 de Instituciones]¹⁶.

Así de la naturalidad (primer valor), equivalente, en lo físico, a material, se pasa, por oposición, en lo espiritual, a la lógica natural o si se prefiere [en términos de Paulo] a: *quod semper bonum et aequum*, idea, por tanto, de orden trascendente y de ideal de justicia (segundo valor). De aquí, y ya con Justiniano [que sustituye *leges* por *iura*] a) pasa a asumir los valores de firme, inmutable y permanente [*firma atque inmutabilia permanente*] b) adopta una visión teológica y cristiana y c) precisa su origen y configura como un derecho dispuesto por la providencia divina. *quidam providentia constituta*.

En fin dejémonos de *animaladas*, o sea, de lo que es propio de animales. Con la esperanza [si se me permite seguir con el tono distendido que he procurado presidan mis palabras] de que este ímprobo esfuerzo contra la *vis* atractiva de las musarañas, fructifique en su alejamiento, [sin que ello implique crueldad alguna, salvo el privarles de nuestra comfortable compañía] no sin antes recordar, en un último intento de rechazo, de su proximidad, que NAPOLEON define al hombre como *un animal el más perfecto de todos y, además, el que razona mejor*.

IV. Intentemos seguir siendo “pacíficos” y, *amato ludo*, retomemos la seriedad y recordemos, también, lo no cuestionado. A saber:

- A) Que todo pueblo, a lo largo de su historia, posee [en mayor o menor grado de perfección] ese conjunto de normas jurídicas, con las que hemos identificado Derecho y que, por tanto, Derecho Histórico se opone a Positivo (vigente): el *positus*, “puesto”, en unas determinadas coordenadas de tiempo y espacio.
- B) Que, a tenor de lo dicho, el Derecho Romano (el de los romanos, redundaría ORESTANO¹⁷): es, el conjunto de normas jurídicas por las que se rigió Roma a lo largo de su Historia.
- C) Que a la zaga de BIONDI¹⁸, se suele distinguir entre: a) Derecho Romano. Proceso de 14 siglos que abarca, desde la formación (mejor que fundación) de la ciudad hasta la muerte de Justiniano y b) Tradición Romanística. Segundo proceso que se proyecta, en el tiempo, desde finales del s. XI, en Bolonia hasta nuestros días y que [desde el particular prisma de VINOGRADOFF¹⁹] cabe definir como “la Historia casi de un fantasma, pues se trata de la segunda vida del Derecho Romano, después de la pérdida del cuerpo en que, por vez primera, vio la luz.

16 Los 4 fragmentos referidos en el texto son: Ulpiano, D.1.1.3 (1 *Inst*); = I.1.1.4; Paulo D.1.1.11 (14 Sab) e I.2.11

17 *Introducción al estudio del Derecho Romano*, traducción de Abellán Velasco, M, Madrid, 1997, pp. 499 ss.

18 *Prospettive romanistiche*, Milano, 1933, p. 1 ss.

19 *Derecho Romano en la Europa Medieval (Proceso formativo, Francia, Inglaterra, Alemania) Derecho Romano en Escocia*, traducción MANUEL J PELÁEZ y EDUARDO PARDO UNÁNUA, Grupo de Investigación Historia de las Instituciones Jurídicas de los Sistemas Políticos y de las Organizaciones sociales de la Europa Mediterránea, Barcelona 2000, p. 24.

Tal Tradición Romanística, no ha entendido siempre lo mismo por Derecho Romano. Unas veces, ha visto en él, la *reconstrucción* del Derecho del pueblo de Roma [visión histórica] y otras la *construcción* de un Derecho válido y actual para otras épocas, asentado sobre bases romanas [visión dogmática]. Esto se debe a que la *forma mentis* de los estudiosos se ven influidos por las corrientes culturales e ideológicas del momento en que ejercen su actividad, sin poder sustraerse a ellas y, en definitiva, responden, [WIEACKER²⁰] a 2 posturas fundamentales de la propia existencia humana.

En síntesis, y sin pretender proponer el estudio de la historia de la cultura jurídica europea [de la mano de KOSCHAKER y WIEACKER²¹] me limitaré a repetir, matizando, mínimamente, que distintas corrientes [ideológicas, políticas, culturales y prácticas] a lo largo de los siglos van a incidir en la concepción y estudio del Derecho en general y del Romano, [que no lo olvidemos, llegó a identificarse con aquel] en particular. Así, cronológica e históricamente, y sin ánimo exhaustivo, sucede con: α) Las ideas de *autoridad* e *imperio*; β) La propia decadencia de ésta y la difusión de la doctrina de Aristóteles [sin olvidar la labor de la Escolástica sobre ella asentada]; γ) el *humanismo renacentista* [con la búsqueda de la verdad por todos los medios]; y δ) el *iusnaturalismo racionalista* [con su libre examen... y fuerza ilimitada de la razón]²²;

V. En la edad Contemporánea²³ las nuevas *corrientes políticas*, (que cristalizan en unificación de Estados), *sociales*, (que lo hacen en el ideario de la Revolución Francesa), *culturales* (que plasman en el neoclasicismo y romanticismo)... sin olvidar, en fin, las influencias *racionalistas* anteriores y las *necesidades prácticas* de siempre, propiciarán [XVIII y XIX] una tendencia Codificadora, que va a encontrar: A) en el Código Napoleón de 1804 [un verdadero Código de exportación] a su más genuino representante... y B) en el BGB alemán, de 1900, el ejemplo de su técnica más depurada.

Con estos códigos y otros más que los siguen [tomándolos de guía y ejemplo], se logra en los distintos países su propio derecho *ius proprium* que vendrán a ser [en frase de TORRENT²⁴] el certificado de defunción del Derecho Común Romano; y tras doscientos años más hacen dudar de su necesidad y plantear su superación

Nada que objetar a lo expuesto, que podríamos proyectar hasta el presente siglo, cuyo primer decenio hemos superado. En esta época: a) el Derecho Romano, se configura como ciencia [más jurídico-histórica, que histórico-jurídica²⁵] y b) su descriptor académico, en las

20 En suma, dice, WIEACKER, F.; *Vom römischen Recht.*, 2ª Ed. Stuttgart, 1961, p. 195 y pp. 228 ss., en estas posturas late el dualismo entre “historia” e “idea”. PANERO GUTIÉRREZ, R.; *Derecho Romano*, ob. cit. en p. 121 resume sus consecuencias.

21 Sus dos obras: la de KOSCHAKER, P.; *Europa y el Derecho Romano*, traducción de SANTA CRUZ TEIGEIRO, Editorial Revista de Derecho Privado, (Madrid, 1955) y la de WIEACKER, F.; *Historia del Derecho Romano en la Edad Moderna*, traducción de FERNÁNDEZ JARDÓN, (Madrid, 1957) merecen, ya lo dijimos, en “Os novos xuristas”, ob. cit. p. 728 n. 21 el calificativo de “clásicas” y siguen siendo, en todo caso, fundamentales.

22 a) ss. XI-XI; b) XIII-XIV; c) XV-XVI; d) XVII y sobre todo el XVIII.

23 PANERO GUTIÉRREZ, R. *Derecho Romano*, Valencia, 2008, p. 130 [ss. XVIII y XIX]

24 *Fundamentos del Derecho Europeos*. Ciencia del derecho: derecho romano -*ius commune*- derecho europeo, Madrid, 2007, p.16.

25 D'ORS LOIS, X Posiciones programáticas para el Estudio del Derecho Romano, Santiago de Compostela, 1979, pp.15 y ss

Universidades de España, donde en casi todas sus Facultades de Derecho ha mantenido su autonomía docente, se ha ido modificando y pasado de llamarse *Historia e Instituciones de Derecho Romano* [en síntesis. la del plan Moyano de 1857] a ser el *Derecho Romano y su Recepción en Europa*, lo que obliga, no solo a agudizar una sensibilidad en el tiempo, sino a dilatar su perspectiva en el espacio, de conformidad, con una Sociedad en que se aprecia una indiscutida e indiscutible tendencia globalizadora²⁶.

Sigo con Hoy y no abandono esta tendencia social *globalizadora* donde conviene recordar: 1) que si “conocer” equivale, como dice BISCARDI²⁷, a *scire per causas*,...el Derecho Romano resulta necesario para conocernos a nosotros mismos y a nuestro Derecho; 2) que si la Historia del concepto de Europa muestra la continuidad de una tradición jurídica no interrumpida desde el mundo clásico hasta nosotros... es [precisamente] a través de la supervivencia del Derecho Romano y 3) que si se tiende a la construcción de un Derecho Común europeo, ello no es novedad si recordamos la Historia de la propia cultura jurídica europea.

SEGUNDA PARTE

Detengámonos en lo que, en este segundo milenio, todavía, hoy, 2014, puede ofrecer la Experiencia jurídica de Roma, en general y el Derecho Romano y su Tradición Romanista, en particular, que pretendemos [11.20] resumir en algunas reflexiones sobre aspectos: I) conceptuales; II) formales; III) legislativos; IV) terminológicos y V) ecuménicos [o al menos, europeos]; VI) y algún principio global.

I. Aspectos conceptuales. Roma suministra el repertorio de conceptos básicos en Derecho Privado, “*vertiente dogmática*”, y no sólo en España, (con todo el conjunto de diversos cuerpos legales de su ordenamiento), sino, también, en la mayor parte del mundo, vertiente de “*derecho comparado*”, lo que comporta como consecuencias: A) en particular, que los conceptos también tienen su “historia”; B) en general, que como ya defendió SAVIGNY: el Derecho es un producto histórico y C) en lo particular y en lo general, que, gracias a Roma, en los conceptos que nos ocupan, se aprecia una triple vertiente²⁸: a) *histórica*, con

26 Permítaseme [ante la amenaza de una nueva reforma de planes de estudio en España] que me detenga en su concepción académico universitaria entre nosotros y advierta, en lo académico, de un peligro probable. El que resultaría [en algunas Facultades de Barcelona, ya se ha producido, por eso hablo con conocimiento de causa] no ya de su desaparición [el vulgarismo jurídico en el que nos movemos no lo descarta y lo hace temer], sino el de su incorporación a la Historia del Derecho Español. El proceso es muy simple y bastaría con silenciar [una simple *omissio*] la palabra “español”. Intentaré explicarme: A veces, sin duda, en aras a una brevedad y concisión familiar, [o no], quizá, por no herir alguna sensibilidad política [hiriendo otras] en mi Universidad se omite lo de Español como determinante de la Historia. La consecuencia, en lo académico sería: Que la Historia del Derecho “Español” se convirtiera en Historia [en general] del Derecho “Europeo” y que el “Derecho Romano”, *corpus*, que es junto con el Canónico, *animus* [uno y otro derecho, *utrumque ius*] la Historia del Derecho “Europeo” se convirtiera [en particular] en un capítulo de la Historia del Derecho “Español”. Más amplio, detalles y referencias, en PANERO GUTIÉRREZ, R. *Cupida legum Juventus*, Revista Intverbnacional de Derecho Romano, RIDROM, (on line), 7, 2011, pp. 40-45.

27 El Derecho y la Ciencia del Derecho en los umbrales del año 2000, (Madrid, 1989), pp. 20 ss.

28 Vid. PANERO GUTIÉRREZ, R. *Derecho Romano y la formación del jurista*. Barcelona, 1988, IV: Los conceptos de Derecho Privado A), B) y C), que sigue a LATORRE SEGURA, A., *Valor Actual del Derecho Roma-*

el valor que bajo el prisma científico, todo conocimiento histórico comporta; b) *dogmática*, con la practicidad que le es inherente y c) de derecho comparado, *ecuménica* o al menos *europaea*, pues, como destaca FERNÁNDEZ BARREIROS²⁹, construir la Historia jurídica de Europa es reconstruir, en buena parte, la historia del Derecho Romano en Europa.

Por ello, tras defender el carácter troncal del Derecho Romano y postular su autonomía académica, me uno a la reflexión de que, nada impide, hoy, tras dos siglos de experiencia *post-codices* obviar la contraposición entre *construcción* o *reconstrucción* del *Derecho Romano*; y hablar [como MURILLO]: a) de *continuación del Derecho Romano, en una evolución secular*; b) ahondar en su impronta de elemento armonizador³⁰ [unificador para TALAMANCA]³¹ del Derecho Europeo y c) [como sugiere TORRENT³², a la zaga de la doctrina italiana] contribuir, a través de él, en un proceso *in fieri*, a la *inventio* y consagración de los *Fundamentos del Derecho Europeo*, que podría ser objeto de una asignatura universitaria en las Facultades de Derecho.

Unido a lo anterior, es hora, a mi juicio, de acabar con el fomento de la disociación [o choque frontal] denunciado y lamentado, por los más, entre los *neohumanistas* [en terminología de KOSCHAKER] nosotros profesores de Derecho Romano, por simplificar, y los profesores de Derecho Civil y, *a contrario*, momento de repetir e insistir en lo que nos une. En este sentido no se si es ocioso recordar a un ascendiente común, SAVIGNY³³ [no solo *Fundador de la Escuela Histórica del Derecho*, sino autor de *El sistema del Derecho Romano* “actual”] “presente y pasado”. En definitiva, debemos evocar que romanistas y civilistas, unos y otros, somos *collegae*, más aún, nietos de SAVIGNY y que, sobre todo, estos hijos de PUCHTA [como los denominaba con su fino humor CALONGE] no son otra cosa que herederos de la *Pandectística*, corriente alemana caracterizada, como su nombre anticipa [y conviene no olvidar] por el estudio realizado sobre el Digesto en su denominación griega, *Pandectas*.

II. Aspectos formales legislativos. Roma que, en frase de SCHULZ³⁴, es el “pueblo del Derecho”, no es en cambio el “pueblo de la Ley” pues, conviene recordar que su elenco legislativo [compilado por ROTONDI³⁵] no pasa de 800, de las que solo 30 son de Derecho Privado.

no, cit. y antes a ALVAREZ SUAREZ, U., *Horizonte Actual del Derecho Romano*, Madrid, 1944, pp. 24 ss.

29 “El derecho común como componente de la cultura jurídica europea”, *Seminarios Complutense de Derecho Romano* III, Madrid, 1991, pp. 83 ss y “Derechos nacionales y derecho común en la experiencia jurídico-cultural romana”, *Estudios Homenaje al Prof. F. HERNÁNDEZ TEJERO*, II, Madrid, 1994, pp. 157 ss.

30 “Fundamentación Romanística en la formación del jurista europeo”, *Estudios de Derecho Romano en memoria de BENITO M^o REIMUNDO YANES*, Tomo II, Servicio Publicaciones Universidad de Burgos, pp. 2000, pp. 52-53. *El Derecho Romano como elemento armonizador del nuevo derecho común europeo*. Temas de Direito Privado, Uma Honnenagem ao Proffesor Agerson Tabosa, Fortaleza, 2010, pp. 288-298.

Os novos xuristas e o Direito Romano, ob. cit. p. 744.

31 Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico, Studi Inmpallomeni, Milano 1999, pp. 64 ss.

32 *Fundamentos del Derecho Europeos*. Ciencia del derecho: derecho romano-*ius commune*-derecho europeo, ob. cit. p. 34

33 Hay traducción española, 6 tomos, de JACINTO MESÍA y MANUEL POLEY, prólogo de Don MANUEL DURÁN Y BAS, de la traducción francesa de M. CH GUENOUX, Madrid, 1878-1879.

34 *Principios del Derecho Romano*, traducción de MANUEL ABELLÁN VELASCO, 2ª Ed, Madrid, 2000, p. 27.

35 IGLESIAS, *El espíritu del Derecho Romano*, Madrid, 1991 pp. 80-81 reproduce la lista de ROTONDI

Reflexión, sobre la “economía de la norma”, de máxima utilidad ante una epidemia [diagnosticada] de *elefantiasis legislativa*. Permítaseme, pues, denunciar esta profusión de leyes y para detenernos, luego, en sus aspectos formales.

Hay veces, si se me permite el símil *per iocum*, que³⁶ “el legislador” recuerda a aquella asamblea de parlamentarios que al discutir las competencias recogidas en el futuro Estatuto de la región, decidió incorporar la pesca lacustre, aunque en su geografía no hubiera lagos... “*por si acaso*”.

Consciente de la iteración, resulta también axiomático que³⁷: “La Unión Europea, el Estado y la Comunidad Autónoma compiten en la producción normativa, sin menospreciar a las administraciones locales. Las Comunidades Autónomas, en particular, la acometen con verdadero entusiasmo: A) quizá por ser neófitas; B) quizá para reafirmar su existencia, C) quizá, más que por necesidad real y auténtica, como manifestación externa de su discurso nacionalista. En suma, insisten en regular hasta los más nimios aspectos de nuestra vida; no se recatan en hacer declaraciones de principios rimbombantes y por lo general inútiles... y linda lo, materialmente, imposible estar al día de esta efervescencia de nuestros gobiernos y parlamentos”. Esta inflación propicia el superar el Código como dogma y hace se cuestione, como apunta entre nosotros TORRENT³⁸, la propia idea de tenerlos.

III. Sigo con los Aspectos legislativos para incidir, dentro de ellos, en los propiamente formales. Roma, tras ofrecer dos modelos de leyes (XII Tablas y Comiciales) enseña que en ellas: debe prevalecer un estilo, claro, breve y conciso, frente a otro farragoso y pedante que, intentando prever todos los supuestos de violación olvidan lo fundamental: que la interpretación literal posibilita el *fraus legis*.

Sigamos, mínimamente, con las XII Tablas, a las que TITO LIVIO³⁹ califica como *fons omnis publici privatique est iuris* y como *corpus omnis Romani iuris* para recordar: A) que *brevitas* y *elegantia verborum* son elogios vertidos por gramáticos como AULO GELIO⁴⁰ y juristas como AFRICANO, al que cita aquél; B) que, por vez primera, fijan la norma con sus actuales caracteres, de general y abstracta; C) que manifiestan la igualdad, ante una misma situación de todos los *cives* ante la ley [*isonomia*, del griego, *iso*, igual y *nómos*, ley] y D) que ejemplifican, con reiteración, [incluso con una frecuencia, gramatical que sorprende] como un hecho real se subsume en una norma.

Resumido su interés material, paso a su forma, y abusando de vuestra paciencia [y riesgo de atraer a las musarañas] os recordaré, como ejemplo ¡lo innecesario!; que XII.T.V,4 y 5: A) Plantea, 1º, un supuesto de hecho: *Si intestato moritur cuius suus heres nec scit* [la muerte de una persona sin *heredes sui*, (por tanto si los tiene son los primeros llamados)]; B) dado la *species facti* [no tener herederos suyos] se le anuda un efecto jurídico, *Adgnatus*

36 Reproduzco un párrafo de ROCAFORT y PONT, Revista de L'Escola Universitària de la Universitat de Barcelona, Management-Empresa, nº 27, 2002, In pessima republica, plurimae leges, pp. 4.

37 Ibidem.

38 *Fundamentos del Derecho Europeos*. Ciencia del derecho: derecho romano-*ius commune*-derecho europeo, ob. cit. p.14

39 3,34,6 y 7.

40 Noctes Atticae 20,1,4 refieren que, según Africano, *eleganti atque absoluta brevitate verborum scriptas*

proximus familiam habento [2º llamamiento, ahora a favor del colateral más próximo del *de cuius*]; C) Si no lo hubiera, *Si agnatus nec scit* [nuevo supuesto de hecho] llegaríamos a una tercera consecuencia jurídica y tercer llamamiento D) *Gentiles familiam habento*. Resulta difícil no compartir la idea de TALAMANCA⁴¹ de estar ante la “racionalización del dato social, convertido en medio de solución pacífica de conflictos”.

Intentemos un mayor rigor gramatical⁴² y, recordando lo obvio, o sea, que tanto vale decir, por caso “Si uno muere intestado...” como “El que (o Cuando uno) muera intestado...”⁴³ me permito reiterar:

a) Que la mayoría de los preceptos palingenésicos de las XII T, atribuidos a los *Xviri* por los autores literarios latinos, presentan la estructura lógica de una regla hipotética; b) Que, superados [lógicamente] la inicial parataxis [que coordinaba dos oraciones sin interdependencia entre ellas], reflejan [sin dificultad] una posible herencia de giros expresivos y enfáticos, de acuerdo con su obligado aprendizaje y recitar memorístico de los niños, *ut carmen neccesarium* según testimonia Cicerón en *De Oratore* 1.43. c) Que no deja de ser revelador que en los tres primeros fragmentos de la T I, [relativa al proceso] se use la construcción condicional, apareciendo, nítidamente: α) por un lado, la condición, condicionante, antecedente, prótasis u oración subordinada y β) por otro, la consecuencia, condicionada, consecuente, apódosis u oración principal. Esto ocurre hasta 5 veces mediante el uso, como elemento introductorio, de las conjunciones *si* [en 4 ocasiones] o *ni* [en 1].

Esta *apódosis*: α) Se interpreta como efecto vinculado causalmente; β) refleja la secuencia cronológica de la *prótasis* dentro de una misma unidad enunciativa y γ) como hoy, en español, admite la estructura formal de su efecto mediante su construcción con imperativo [de *imperare* = mandar]. *Si in ius vocat...ito* [nos dice T1.1].

Concluyamos que esta estructura no es exclusiva del proceso, [III primeras Tablas] pues ya hemos puesto un ejemplo en el ámbito de sucesiones, *Si intestato moritur...familia habento*; se podría hacer, en el penal y no solo, en materia de lesiones y sus tipos, graves, leves e injurias, T.8,2 y 4 [pues se habla de *Si membrum rupsit... talio esto*; *Si os fregit... poenam subito*; o *Si iniuriam faxsit...poenae sunt*] y otro tanto en materia de familia, donde está en la mente de todos la *emancipatio* o *ex mancipatione* de T.IV,2 *Si pater filium ter venum duit...filius a patre liber esto*.

“Necesitamos, conviene repetirlo⁴⁴, menos leyes, más inteligibles y en lo técnico, mejor construidas. Leyes que regulen, genéricamente y abstracto, los mandatos surgidos de la realidad social y huyan de un casuismo enfermizo, fuente siempre de injusticias y de vacíos”.

Al lado de esa tendencia general globalizadora, nuestra Sociedad, al menos en particular la española, sin abandonar el prisma terminológico en el que pretendemos seguir, debe enfrentarse ante dos peligros: A) que en el ámbito universitario se difumina la imagen del futuro profesional del Derecho, porque la incidencia de las ciencias sociales y económicas parecen amenazar la autonomía de unos estudios propiamente jurídicos y B) que, las

41 Le “Istituzioni” fra diacronia e sistema, Index,18, 1990, p. 27.

42 Por todos: BASSOLS DE CLIMENT, M. *Sintaxis Latina*, II, 4ª Reimpr., Madrid, 1978, pp. 259-284

43 *Nueva gramática de la lengua española*, Sintaxis II, Real Academia de la Lengua, Madrid, 2009, p. 3592 (Otras construcciones de sentido condicional).

44 Cfr. nts. 32 y 33.

directrices de la docencia jurídico-universitaria, a instancia del legislador y so pretexto de unos nuevos planes de estudios (de grado los llama ahora) y un adecuar el contenido de las materias a las nuevas necesidades, se traducen en una reducción de los programas y en invitación a que los manuales y libros, en nuestras Facultades, angosten el Derecho a una serie de recetas de fácil aplicación. ¿El resultado? un vulgarismo jurídico notable ¿Causa teórica? el llamado Plan Bolonia, sobre el que, nuestro ANTONIO DIAZ BAUTISTA, con su fino instinto jurídico realizó no pocas acertadas observaciones críticas, en su artículo de divulgación [en La Verdad de Murcia] en el que Bolonia para el Derecho Romano ha sido, en sus propias palabras: *alfa y omega*.

El segundo peligro, en el aspecto formal, es la existencia en nuestra sociedad, no se olvide que el Derecho a ella va dedicado, de un Eufemismo político de tal calado que los tradicionales significantes amenazan abandonar sus significados clásico y, al menos a mi, empiezan a convencerme de cosas que, resultaban, en mis estudios de juventud, irreconciliables.

Recurro, otra vez, a la vía ejemplar y pretendo, de nuevo, traer a colación, algunas referencias que pretenden ser *per ludum* [jamás *animus iniuriandi*]. Así, y sin carácter exhaustivo, confesaré, que todavía me resulta forzada la representación mental: A) en mi proyecto derecho político, de unos federalismos que son asimétricos; B) en mi vetusto derecho fiscal, de unos impuestos, que son voluntarios [¡pero si son impuestos!]; C) en mi obsoleto derecho penal, [en donde el sexo ocupaba lugar preferente] en los entonces llamados delitos contra la honestidad [Violación, Abusos deshonestos, Escándalo público, Estupro, Corrupción de menores, Adulterio, Amancebamiento y Rapto] prescindir de éstos y no digamos de aquél [me refiero al sexo]. Sin embargo, muchísimo más duro, me resulta, tener que asumir [y así consta en los recientes diccionarios de la RAE, como significado más reciente] que hay distintas violencias según el género o que éste se circunscriba a la mujer, como en Barcelona, donde hay juzgados de vigilancia penitenciaria y violencia de la mujer [lo que, en lo fonético y terminológico me resulta acertado] o en la Comunidad de Madrid, donde hay Juzgados de violencia de género [sin más] lo que, a mi juicio, y en el campo terminológico en el que nos movemos, para mí, es más criticable.

Vds. conocen todo esto mucho mejor que yo, e incluso, sobre ello, escriben. Sin embargo, permítanme recuerde que en mi deficiente preparación morfológica, había creído entender, hasta fecha temprana, que el género se trataba de un mero accidente gramatical, cuando ahora resulta, al enriquecer su polisemia, que es, además, un rasgo biológico, al que jurídicamente se ha de proteger con preferencia que es lo que significa, cuando resulta acompañado de los significantes *discriminación* o *violencia* [quiebra pues el principio de *igualdad*, aunque se enmascare a través de algún ministerio con esta etiqueta]

ANTOINE MEILLET⁴⁵, señala tres causas en los cambios semánticos: las lingüísticas; las históricas y las sociales. Centrados en el idioma español, y en el vocablo género, pero siguiendo el sentir del gran maestro francés de la filología clásica resumo: 1) que son las causas sociales las que, a mi juicio, han determinado esta ampliación del campo semántico de la palabra género, partiendo de la base de que con sustantivos animados [y, obviamente,

45 Comment les mots changents de sens, Paris, 1938,

solo con ellos] podrían servir para definir el sexo; y 2) que, en este *iter*, su valor concreto es restrictivo, pues no se identifica con género en general, sino, dentro de él, con el femenino en particular [tomándose pues el *genero por la especie*, en un proceso de sinécdoque [que como es sabido, consiste en el tropo de dicción que comporta designar [el todo por la parte; el continente por el contenido; la materia por el objeto o] como en nuestro caso: el género por la especie en su modalidad de menos frecuente uso, empleo de *todo* el “género” para referir solo una *parte* del mismo “el femenino” y no viceversa “el femenino” para determinar *todo* “el género”. En definitiva, el valor de género, en nuestro caso, solo podrá especificarse, según la lingüística estructural, a través del propio contexto en el que la frase que lo contenga y los determinantes que la acompañen aparezcan reflejados.

Acabemos, antes que en el campo de mi vieja geometría, empiece a asumir la existencia de unos círculos cuadrados o de unos cuadrados circulares para pasar a otros aspectos formales.

La *elegantia verborum*⁴⁶, usada para destacar el estilo de las XII Tablas, es término que suple Justiniano⁴⁷ [al tratar de las *leges* en general] α) por *simplicitas*, β) a la que califica de *legibus amica*; γ) contrapone a *difficultas* y δ) señala como objetivo final: su necesaria comprensión: *intellegi ab omnibus debent*. Justiniano, también, hace hincapié en la claridad [de estilo], cuya polisemia es gusto, distinción o corrección. Hoy, en nuestros diccionarios del español, en sentido figurado, *claridad* es la palabra o frase con la que se dice a uno, *descaradamente*, algo desagradable u ofensivo, lo que nos da pie a otra reflexión.

Estamos de acuerdo en reprimir todo término o forma de expresión que pudieran ser ofensivo para una persona, grupo o sociedad determinados. En otras palabras: lo políticamente correcto [¿les suena?] es silenciar la disfemia y acudir a un eufemismo, a un a riesgo de fomentar la hipocresía social, o sea negar que se llame al pan, pan y al vino, vino [frase dedicada al Profesor Dr Juan Ramón Robles, de esta Universidad de Murcia, que fue quien me sugirió un trabajo de esta naturaleza y de lo que, *praesumptio iuris et de iure*, estará profundamente arrepentido].

Permitidme vuelva a pensar en voz alta, aunque me cuidaré mucho en decirlo y que proceda, a continuación, otra vez, *iocandi gratia*, a detenerme en algo que debe evitarse.

No digamos: A) aborto, sino interrupción del embarazo; B) no digamos independencia [ahora ya sí], sino nacionalismo pleno; C) no digamos viejos, sino personas de tercera o avanzada edad; D) no digamos sordos, sino deficientes auditivos; E) no digamos gordo, sino personas de volumen apreciable y F) no digamos sinvergüenzas o canallas, sino gente, socialmente, inadaptada.

G) En fin: el ciego, afortunadamente, en lo terminológico, está sufriendo una notable mejoría con la esperanza de que logre acabar, pronto, con la ceguera: pues, ha pasado [1º] de ciego a invidente [y dado que el prefijo *in* equivale a negación o privación, total, poco logró pues cabe atisbar en este primer paso] pero, luego, ha pasado de invidente a discapacitado visual [lo que está mejor, pues *dis* refleja más que falta de algo [en este caso vista, una dificultad o anomalía en ese algo, que existe], por lo que hay que felicitarle por su mejoría.

⁴⁶ Cfr. n. 36.

⁴⁷ I. 2,23,7; 3,2,3 y C. 1,14,9.

No me resisto a una reflexión postrera y evoco a los pastores, cuya *rusticitas* era *hier*i presunción *iuris et de iure*, y *hodie*, me imagino, que, en todo caso, la *urbanitas* les preside siendo graduados en bucólicas, con un postgrado, al menos, en églogas y algún master en pastoriles.

Extra iocum [bromas aparte] Volvamos a la seriedad pues, aunque no lo parezca en la forma, en el fondo, conscientemente, pretendo no abandonarla. Esta tendencia sobre lo políticamente correcto se presenta bajo la máscara de la tolerancia con apariencia de un pensamiento único [malo por tanto] que es el “buenísimo”. Sin embargo [y sigo a un murciano ilustre, el lingüista CELDRÁN GOMARIZ⁴⁸] sus *adeptos son del todo intolerantes* y encubre una falacia pseudo intelectual y peligrosa que se presenta con argumentos inocentes, de fácil asimilación. Su peligro es que se contagia por un vocabulario, *prima facie* asumible, aunque sus argumentos no resistirían la acción de espíritu crítico.

Para esos doctrinarios, manipuladores del lenguaje [sigue CELDRÁN GOMARIZ]⁴⁹ todo es bueno; nada es malo, o al menos todo es relativo y en ese relativismo se centra la esencia de una estúpida escuela de desinformación, intoxicación y ramplonería a menudo al servicio de un deseo inexplicable de que dar bien.

IV. Rompo una lanza frente a los ataques a la terminología jurídica y en la ayuda que pueda significar el propio Derecho Romano y el vehículo que le sirvió de instrumento el latín que, en Roma y hasta hoy, en el ámbito del Derecho ha actuado no de mero espectador, sino como efectivo participante.

A) La inexistencia de una total precisión en el lenguaje del *ius civile*; B) la orfandad de términos solo técnicos; C) la concepción ciceroniana de que el primitivo *ius* era a *natura ductum* y D) la ausencia de definiciones respecto a las instituciones fundamentales debido, más que a la incapacidad de los romanos a lo superfluo que resultaría toda definición por estar ínsito su concepto en la palabra... son, entre otros, argumentos sobradamente, conocidos para acreditar la afirmación de BIONDI⁵⁰ de configurar a la terminología latina como primera dogmática jurídica y que no se desvirtúa porque [parafraseando a LATORRE] en la mitología actual los números tiendan a sustituir a las palabras pues, prosigue mi maestro, son estas y no aquellos las armas del jurista. Sigamos pues con los *verba*.

Es notorio⁵¹: A) Que la terminología jurídica no se crea *sua sponte* por el Derecho, que la recibe del lenguaje común propio de la praxis social. B) Que son excepción los casos en que una palabra obtenida su lexicalización jurídica, caso de *novatio* [de *novare*, de *novus* comportando idea de nueva] se mantenga dentro del marco del Derecho con carácter exclusivo o cuasi exclusivo. C) Que lo más frecuente es que transmigren a otros campos distintos a

48 *Hablar bien no cuesta tanto*. Dudas, etimologías y curiosidades de la Lengua española, (booket) Barcelona, 2012, p. 97.

49 *Ibidem* p. 98.

50 *Terminología romana como primera dogmática jurídica*, en *Arte y Ciencia del Derecho*, tr. ÁNGEL LATORRE, Barcelona, 1953, pp. 84-118. Cfr. un desarrollo crítico de las ideas de BIONDI, en KASER, *Zur Juristischen Terminologie der Römer*, Studi in onore di BIONDO BIONDI, Milano, 1965, pp. 95 ss.

51 Los términos del texto aparecen ya en : PANERO GUTIÉRREZ, R, *Capitis deminutio y Capite deminutus*, Estudios de Derecho Romano en Memoria de Benito M^a Reimundo Yanes, Coordinador ALFONSO MURILLO VILLAR, T II, Burgos, 2000, p. 178 n.9.

los que les vieron nacer, alcanzando, a su vez, significados diferentes, matizados o no jurídicos. Compatibilizados pues su uso jurídico y extra jurídico solo el contexto...nos ayudará a precisar cual es, entre ellos, el allí reflejado. En definitiva: conocer la procedencia de un término ayuda a comprender, no pocas veces, los diversos valores que puede llegar a asumir, diacrónicamente, o incluso criticar su evolución pues al significante, en cuestión les será difícil desprenderse, por entero, de su primer significado y, de hacerlo, posibilitará la crítica. Aludamos, brevemente, a *rei vindicatio* y *solidum* como posibles ejemplos de uno y otro supuesto.

Lo normal, hemos dicho, es la referida transmigración. Eso ha ocurrido con *Rei vindicatio*. En origen, dos significantes α) *vindicatio* [de *vindicare*], sustantivo, cuyo sufijo, acabado en *io* [como *postulatio* o *actio*, o la anterior *novatio*] connota una acción que se está realizando, en nuestro caso, acción de reclamar = reclamación y β) *rei* [genitivo regido por *vindicatio*] = objeto material del mundo que nos rodea. Su significado jurídico, pues, se adecua perfectamente al latino y vulgar esto es: Reclamación de una cosa obviamente, por quien no la tiene, siendo suya, a quien la tiene, sin serlo

Posteriormente, se trivializa y aun manteniendo el primer sentido, así resulta del CC 387, pasa también a designar cualquier tipo de reclamación, aunque nada tenga que ver con la propiedad. Puede reclamarse: un derecho político o social, el buen nombre, la fama o la autoría de cierta acción. La palabra “Cosa”: aplicable a todo lo que puede ser objeto del pensamiento o sujeto u objeto de un juicio o una oración gramatical no plantea, por su amplio campo semántico, problema alguno, lo que es coherente con la posibilidad, incluso, de no traducirse en la lengua latina como en: *rerum natura* = naturaleza y haber matrimoniado, sin aparente esperanza de divorcio, en español con *vindicatio* en una sola palabra.

El segundo significante propuesto es solidaridad que, en español, hoy, ha sustituido, casi por completo, la idea paulina y religiosa de caridad por otra de carácter laico. Así GUSTAVO BUENO⁵² recuerda que solidaridad como término del vocabulario ético, moral o político fue voz acuñada por PEDRO LEROUX, en 1863, introduciendo el significado humanitario en el terreno político social. El mismo LEROUX, en transcripción de BUENO, dice “yo he sido el primero en tomar el término solidaridad de los legistas para introducirlo en la filosofía. He querido reemplazar la caridad del cristianismo por la solidaridad humana”.

Concluyamos de la mano de CASTÁN TOBEÑAS⁵³ con un apunte a nuestro CC y sus Art 1137 y ss. En rigor el término mancomunada “mano común” debería aplicarse a la obligación colectiva o pluripersonal. Sería pues el género, en el que, como tal, podría distinguirse, dentro de él (como especies): a) las obligaciones mancomunadas (o pluripersonales) simples o a *pro rata*, en las que el crédito o la deuda estaría dividido o prorrateado *pro parte* o *pro rata*⁵⁴, también llamadas, por ello, *parciarias* entre tantos acreedores y/o deudores como acreedores y/o deudores haya y b) mancomunadas solidarias⁵⁵ en las que permanecería sin dividir o integro. Nuestro CC no sigue este criterio y formalmente contrapone el género (obligaciones) mancomunadas [que identifica con *parciarias*] a la especie

52 *El pensamiento de Alicia*, Madrid, 2006 p.159 ss.

53 *Derecho Español, Común y Foral, III, 1, 9ª ed.*, Derecho de Obligaciones. La obligación y el Contrato en General, Madrid, 1958, pp. 91-102.

54 *Ibidem* p. 94.

55 *Ibidem* p. 95.

(solidarias), lo que admitido y consolidado, desde un punto de vista terminológico resulta criticable, ya que Solidaria, de *solidum* = integro, compacto, macizo, entero se aplica a la situación en la que habiendo varios deudores, cualquiera, está obligado a la totalidad de la deuda y, más en concreto, al pago de una completa suma de dinero, valor no muy lejano pues al que refleja el masculino *solidus* como moneda de oro.

V. Entramos en la recta final, y a dar respuesta a la incidencia del Derecho Romano en los aspectos ecuménicos, o al menos globales, del *Ius Privatum Europaeum* reiterando⁵⁶: A) que como *idea*, unidad y diversidad no son incompatibles y así el futuro jurista tiene que familiarizarse, con un ordenamiento jurídico global, en donde convivan un conjunto diverso de sistemas normativos (tanto en España, con sus autonomías, como fuera de ella, con los países comunitarios); B) que confirma, tampoco es novedad, recordar que la Tradición Romanística “enseña” que ya en la Baja Edad Media existió: un *Ius commune*, en esencia Derecho Romano de aplicación general en cada país, superando particularismos, modificado, a su vez, por el *ius proprium*, particular (*ius municipale*) del territorio y C) Que los comentaristas, dictaminadores [postglosadores, si se prefiere] llegan a la suprema *reductio ad unum* de todo un completo sistema jurídico: *Ius commune* de aplicación general, modificado en aquellos dichos territorios por sus propias normas, como *ius singulare*.

Hasta aquí, sabido, conocido y asumido. Sin embargo, Hoy, los Ordenamientos jurídicos, representando la opinión tradicional, [sintetiza CANNATA⁵⁷], se suelen agrupar en dos tipos, a) abiertos y/o cerrados; b) nombres que se deben a SCHULZ⁵⁸; c) su difusión a ESSER⁵⁹ y d) que superan la clásica polémica [ya aburrida dice WIEACKER⁶⁰] entre jurisprudencia de conceptos y de intereses.

Sus principales diferencias han descansado [tradicional cronológica y respectivamente] en la contraposición de: α) materias...codificadas, o no; β) modo de pensar clásico... axiomático o problemático y γ) categorías modernas [también de pensamiento] sistemático o aporético.

Tras el mínimo recordatorio doctrinal, conviene [de inmediato] advertir que estas notas diferenciales [hoy] no se producen, [parafraseando a KASER⁶¹] “en toda su pureza”. Al revés: [es opinión difundida] que en los sistemas jurídicos se difumina la tradicional distinción; ZIMMERMANN⁶², habla de una “diferencia evanescente” y PANERO ORIA⁶³, formu-

56 Ya en La Experiencia jurídica de Roma. Su proyección en el umbral del s XXI, Valencia, 1998.

57 *Historia de la Ciencia Jurídica Europea*, trad. LAURA GUTIÉRREZ MASSÓN, Madrid, 1996, p. 238

58 De la obra de SCHULZ están, como fundamentales: la versión originaria inglesa; *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946 (ed. anastática de 1953); la publicación alemana, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961 y la traducción italiana de NOCERA, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, que es sobre la que hacemos las citas.

59 De la obra de ESSER, *Grundsatz und Norm. Untersuchungen zur Methodik der Rechtsvergleichung*, 1956, hay traducción española de VALENTÍ FIOL, Barcelona, Bosch, 1961 y una destacada recensión crítica de DE CASTRO, en Anuario de Derecho Civil, XI,1, p. 235 ss. y 283 ss.

60 *Gesetz und Richterkunst. Zum Problem der aussergesetzlichen Rechtsordnung*, Karlsruhe, 1958, p.14.

61 En torno al método de los juristas romanos, tr. de MIQUEL, Valladolid, 1964, p.10.

62 “El legado de Savigny. Historia del Derecho. Derecho comparado y el nacimiento de una ciencia jurídica europea, en *Estudios de Derecho Privado Europeo*, traducción de VAZQUEZ ALOY, Madrid, p. 39 ss.

63 *El poder de los Digestorum Libri*, Direito Romano: Poder e Direito, Coimbra (Portugal), pp. 1019-1033, pp.1019 ss.

la [al menos tantas observaciones críticas] *a contrario* [a *repugnantibus*, es la terminología ciceroniana que usa], como criterios diferenciales antes, en doctrina, se habían señalado.

Es momento obligado de detenernos, porque de no hacerlo y proponer al Derecho Romano como “armonizador” entre lo que [por lo común] podría calificarse de dos tradiciones irreconciliables, resultaría *a priori* [incluso para un mero aprendiz de lo jurídico] fácil de rebatir [sin tener que argumentar].

- a) Respecto a las materias hay que precisar: α) que en los sistemas *abiertos*, hay partes importantes de Derecho reglado. Y β) en los *cerrados*, su interpretación, complemento y reelaboración se realiza dentro de las *categorías y los medios* del derecho casuístico.
- b) Que la oposición entre pensamiento problemático [tópico] y deductivo [axiomático] cuando menos, es equívoca, al ser conceptos de rango lógico diferente y operar en momentos distintos del proceso racional⁶⁴.
- c) Que sobre el valor [o valores] de la palabra Tópica, siendo unívoco, como significante es plurívoco como significado sin preterir [como apunta VIEHWEG⁶⁵] que, también, hay una tópica de segundo grado, que consiste en aplicar unos [sencillos repertorios de puntos de vista de tópicos ya elaborados, previamente]. Un catálogo así, con el título *de regulae iuris antiquae*, suministra Digesto. 50.17.
- d) Que siendo cierto que el modo de pensar sistemático procede desde el todo y el aporético al revés; no lo es menos que las dos funciones son compatibles y lo que exteriorizan es que... si se pone el acento en el “sistema”... su establecimiento opera en la selección de problemas... y si lo hacemos en el “problema”... éste buscará un sistema para encontrar la solución.

VI. [A título de conclusiones] Una vez apuntada la compatibilidad de las dos tradiciones europeas⁶⁶, resulta evidente que la necesaria y creciente unificación legislativa y la destacada internacionalización de la justicia exigen también la creación de tribunales supranacionales, aparte, incluso, de los ya existentes en Centro Europa, [La Haya, Estrasburgo o Luxemburgo por caso]. Sin embargo, de poco servirían estas nuevas instancias sin conocimiento previo y el consiguiente manejo de unos principios jurídicos *globales*, que nos permitan entendernos entre todos los componentes de una sociedad [la reiteración es consciente] *globalizada*. Se requieren unas reglas comunes, es decir un lenguaje jurídico global entre juristas. Este se encuentra en el Derecho Romano, pues, en definitiva, éste es, en frase

64 En otras palabras, la tópica puede cumplir además de una primera función analítica, otra segunda sintética, a través de la cual podría construir un sistema.

65 *Topica y Jurisprudencia*. Prólogo de García de Enterría, tr. LUIS DIEZ PICAZO, Madrid, 1963, p.53.

66 Sobre la compatibilidad de las dos Tradiciones jurídicas europeas Cfr. PANERO GUTIÉRREZ, R El Derecho Romano y Europa, Teoría del Derecho. Revista del Pensamiento Jurídico, Diciembre 12, 2012 pp174 y 175. También con referencias específica a Reino Unido y Escandinavia. KNÜTEL, R.; TOPICA. Principios de Derecho y Máximas Jurídicas Latinas II, “Ius commune y Derecho Romano en los tribunales de justicia de la Unión Europea”, (ARCANA-VERI, 2001), publicado, originalmente en la *Juristische Schulung* 36 fasc. 9. 1996, trad. Prof. Dr. G. PEREIRA-MENAUT. pp.15-16.

de MURILLO⁶⁷, [29.03] *la casa común del jurista europeo*, en donde encuentra principios y contenidos que le permiten el análisis y la crítica. Ahora bien, siendo el principal objetivo de esta exposición los aspectos terminológicos, abandonemos el *domus collere* de MURILLO y pasemos a la comunicación y al lenguaje oral o escrito de lo que en este *domicilium* se habla: al lenguaje, pues no cabe olvidar; a) que si la propia UE es un proyecto en la historia; b) el Derecho Romano; en nuestra opinión⁶⁸, será la grafía con la que deba cumplirse; c) pues, no en vano, IHERING lo calificó: de *alfabeto del Derecho*; d) ÁLVAREZ SUÁREZ de *humanismo de los juristas*; e) KUNKEL de su *lingua franca* y e) RODRIGUEZ ENNES de bilingüismo jurídico.

Como punto final a estas reflexiones nos limitaremos a poner de relieve: 1º) que, en doctrina, se van recopilando, en tanto se aplican, una serie de reglas y aforismos jurídicos [buena parte en latín] denominados genéricamente, *Principios de derecho global*; 2º) que puede servir como ejemplo dentro de la romanística española, la obra coordinada y dirigida, precisamente, con este título por DOMINGO OSLE⁶⁹; 3º) que siendo, de sobra, conocidos por los estudiosos de DR, no tanto fuera de su círculo, nos limitaremos, sin otra pretensión que el mero ejemplo, a recordar dos: a) uno relativo al propio *Ius Romanum*, y su impronta procesal, calificado, con razón, por RABEL, como Sistema de Acciones⁷⁰; y b) otro al hombre como sujeto de Derecho, primer texto con el que iniciábamos estas reflexiones y que nos servirá de cierre⁷¹.

A) El principio procesal de Audiencia, como es sabido: en general, es pilar informador en la mayoría de los ordenamientos europeos de la tutela judicial efectiva, y, en particular, se consagra, en el Art. 24,1 CE para evitar la indefensión del demandado. Hasta aquí podría tenerse, incluso, por notorio, sin embargo, no lo es tanto el que su raíz última se encuentra en un rescripto del Divino Severo y Antonino Magno, del que nos da cuenta Marciano, D.48,17,1.pr (2 *Pub*) en donde: a) se afirma su uso: *hoc iure utimur*, b) esgrime su fundamento: la *aequitatis ratio*, c) prohíbe la condena *inaudita causa* y c) lo resume como *audi alteram partem = audiatur et altera pars*.

67 *El Derecho Romano como elemento armonizador del nuevo derecho común europeo*. Temas de Direito Privado, Uma Honmenagem ao Proffesor Agerson Tabosa, Fortaleza, 2010, p. 294.

68 Os novos xuristas e o Direito Romano, ob. cit. p. 744.

69 *Principios de Derecho Global* 1000 Reglas y Aforismos Jurídicos comentados. Navarra, 2006.

70 *Grundzüge des römischen Privatrechts*, München, 1915. Sus primeras páginas bajo el epígrafe “*Actionen-system*”, difícilmente podrán ser superadas.

71 Este el Retorno a las reglas antiguas se va haciendo de forma metódica y ha sido expuesto con toda claridad [y la ironía, sobre sí mismo, típica de un jurista] por un juez de la Cámara de Recursos en los siguientes términos: “En la Cámara de Recursos de la Oficina de Europea de Patentes, [informa KNÜTEL, R *Tópica Principios de Derecho y Máximas Jurídicas Latinas*, *Ius commune* y Derecho Romano en los tribunales de justicia de la Unión Europea ob. Cit. p. 44]: las reglas de derecho latinas de nuestra historia jurídica común han dado lugar, hasta ahora a un consenso mayor que el conseguido por medio del uso de los derechos nacionales. La Gran Cámara también consulta el Digesto” Y continúa “Así que quien quiera tener buenos resultados ante esta Cámara debería olvidar las Codificaciones de los diferentes estados de los tres últimos siglos y volver al viejo derecho europeo común, tal y como ha sido formulado, de forma todavía bien comprensible en latín”. El mismo juez [sigue informando KNÜTEL] confiesa, a continuación, que él ha empezado ya a olvidar y a aprender de nuevo”.

B) Concluyo, como anticipé con HERMOGENIANO “Causa de la constitución de todo Derecho es el hombre”, que de la mano de KNÜTEL⁷² sintetizo así. 1) Es tan notorio como pacífico, que el respeto a la libertad y propiedad, a la afirmación de la igualdad, no discriminación y proporcionalidad, son parte constitutiva de la concepción jurídica que enmarca y determina, ya no un derecho particular, sino todo el sistema comunitario y representa la *ratio scripta* de la vida humana en sociedad. 2) Lo que no es tan difundido, y a lo peor, ni siquiera se conoce, es que si nos retrotraemos en el tiempo y deshacemos lo andado se observa que tales principios: A) se formulan, en términos solemnes, por las Constituciones políticas modernas; B) antes, en las codificaciones del siglo XIX, quedan configurados al plasmar, en artículos, las *sententiae* pretéritas que dan fe de su existir en los ordenamientos jurídicos antiguos; C) constituyen la *ratio scripta* de la vida humana en sociedad y D) que, en fin, por lo que a nosotros interesa, en esencia, se trata tan solo, de la mera aplicación del principio formulado, en el siglo IV, por HERMOGENIANO, junto a ARCADIO CARISIO, los dos últimos juristas postclásicos, recogidos en el Digesto, según el cual: “Causa de constitución de todo derecho [30.38] es el hombre” y que se recoge en D.2.1.5.2: *hominum causa omne ius constitutum est*.

Agotado el tiempo de la conferencia, permítanme, en lo que tal vez constituya el último acto de mi vida académica, les pida disculpas. Disculpas por no haber observado, *ab initio*, el rigor de cualquier protocolo institucional, al concedérseme la Venia para dirigirles la palabra, y, que como lenitivo adjunto, pretendiendo huir de cualquier falta de cortesía, les manifieste de la mano del poeta y ensayista RALPH WALDO EMERSON que ello ha sido debido a que: a través del Derecho Romano [mi viejo, muy querido y entrañable Derecho Romano] les he intentado tratar a todos como [lo que sin duda son] amigos, ... insisto, y reitero,... he procurado tratarles como amigos siempre que por tales entendamos [como EMERSON nos indica] aquellas personas con las que se puede pensar en alta voz.

Gracias a todos por su atención y audiencia y con el cariñoso recuerdo al Prof. Dr. Antonio Díaz Bautista *qui, hic et nunc, adest*,... a todos, sin excepción desde la lejana Roma les deseo que los dioses siempre les sean propicios.

⁷² *Ibidem* p. 45,

D. 50,6,6,3 (CALL. 1 DE COGN.)

LOS PRIVILEGIOS A FAVOR DE LOS NAVICULARII: ENTRE INICIATIVA PRIVADA E INTERVENCIONISMO ESTATAL

GUERRERO LEBRÓN, MACARENA
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

I. Las fuentes, tanto jurídicas como literarias, se hacen eco de la presencia y auge alcanzados por los *navicularii* en el Imperio romano¹. Nuestra atención en el presente estudio se centra en aquellos que realizaban el transporte de la *annona*, garantizando así el abastecimiento de productos de primera necesidad a la urbe. Tal y como se encarga de señalar Calístrato en el texto que sirve de base a nuestro trabajo, D. 50,6,6,3, la prestación de esos servicios, de especial interés para la comunidad, los convierte en beneficiarios de una serie de inmunidades a través de las cuales se trata de compensar e incentivar el ejercicio de su actividad. En las líneas que siguen vamos a profundizar en el análisis de esos privilegios, tratando de esclarecer algunas de las cuestiones que suscitan los mismos.

¹ La expansión geográfica unida a la necesidad de abastecimiento a la población llevan a otorgar una enorme importancia al tráfico comercial en general y al naval en particular, lo que conduce al progresivo auge de esta figura. Son numerosos los testimonios de la presencia e importancia de los *navicularii* y de las medidas que se establecen para promover el ejercicio de esta actividad favoreciendo así el transporte anónimo. Así, por ejemplo, Estrabón, refiriéndose a los *navicularii* de la Bética, señala que éstos son conocidos tanto en Ostia como en Puteoli y que sólo eran superados en número por los de África, cfr. *Estr.* 3,6,2. Tácito en sus *Anales* se refiere en múltiples ocasiones a los preciados navegantes, *Tac. Ann.* 12,55: “(...) *ac plerumque in mercatores et navicularios audebant* (...)” Una muestra del espíritu de incentivación de las actividades realizadas en favor del interés público nos lo muestra Livio, que relata que las sociedades que concurren a la adjudicación para el abastecimiento de las tropas de Hispania (al mando de los Escipiones), solicitan quedar exentas del servicio militar y que el tesoro público se hiciese cargo de los daños que los enemigos o la climatología adversa pudieran causarle. Vide *Liv.* 23,49,1-2.: “(...) *quorum duo postulata fuere, unum ut militia uacarent dum in eo publico essent, alterum ut quae in naues imposuissent ab hostium tempestatisque ui publico periculo essent*”. En la misma línea Suetonio describe las condiciones de favor que Claudio propone a ciudadanos romanos y latinos para incentivar las empresas navieras, cfr. *Suet. Claud.* 18-19.

II. El pasaje al que nos referimos², que sirve de eje a nuestro trabajo, está recogido en D. 50,6,6,3 (*Call. 1 de Cogn.*)³:

Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse.

El fragmento se abre con la alocución “*negotiatores, qui annonam urbis adiuvant (...)*”. El jurista comienza con esa referencia a los *negotiatores*, a continuación, ante la amplitud de significados que el término *negotiator*⁴ puede presentar, se encarga de determinar que se refiere a aquel que ayuda a la *annona*⁵ de la ciudad, expresión que, a priori y por su generalidad, no resulta del todo aclaratoria en la medida en que no se precisa qué actividad comercial es aquella con la que contribuye al abastecimiento de la urbe⁶. Seguidamente,

2 Sería imposible en una sede como ésta tratar de abarcar todas las cuestiones que suscita el presente texto junto a la abundantísima literatura que existe sobre el particular, por lo que nos centraremos sólo en el perfil que interesa de cara a nuestro trabajo y en los estudios doctrinales de interés para el mismo.

3 La predilección de los compiladores por Calístrato contrasta con su consideración de jurista menor, calificación que se le otorga porque no es citado por otros contemporáneos, ni historiadores ni literatos. La obra de la que se extrae el fragmento que comentamos es la mejor conservada del jurista y está dividida en seis libros datándose, aproximadamente, entre el 189-211. Vide MATEO, A. *Calístrato*. En Domingo R. (coord.), *Juristas Universales 1. Juristas antiguos*, Madrid, 2004, pp. 202 y ss.

4 Para García Brosa *negotiator* es una voz genérica que debe interpretarse por el contexto. Con frecuencia se usa para referirse a actividades comerciales, por lo general, marítimas y a gran escala. Un estudio detallado del significado del término *negotiator* en las fuentes puede verse en GARCÍA BROSÁ, G. *Mercatores y negotiatores: ¿simples comerciantes?*, en *Pyrenae* 30, 1999, pp. 183 y ss., *praepicue* p. 183 nt. 38. Para un análisis profundo de la regulación que sobre los negocios y el comercio existió en la antigua Roma, la evolución de la misma y la discusión doctrinal en torno a la existencia de un “Derecho comercial” en la experiencia jurídica romana vide GALLO, F. *Negotiatio e mutamenti giuridici nel mondo romano*, en F. Bona ; M. Miglietta (a cura di), *Opuscula Selecta*, Padova, 1999, pp. 823 y ss.

5 Como es sabido *annona* es un vocablo polisémico que se emplea para referirse tanto a los alimentos en general, como al tributo en forma de trigo que llegaba a Roma y a la distribución gratuita que se hacía a la población de porciones de trigo y harina, equivalente a la *frumentatio*. Para Remesal, además, tienen la consideración de productos *annonarios*, junto a los alimentarios, los manufacturados e instrumentos metálicos susceptibles de ser necesitados en grandes cantidades y de modo continuo por el Estado. Vide REMESAL, J. *El sistema annonario como base de la evolución económica del Imperio romano*, en *PACT* 27, 1990, p. 359. Las referencias a la *annona* en las fuentes son inagotables y la literatura sobre la misma amplísima, lo que resulta ilustrativo de su importancia. Igualmente significativas son las medidas encaminadas a reprimir prácticas ilícitas relacionadas con la *annona*. Una referencia a las distintas acepciones que aparecen en las fuentes, tanto jurídicas como literarias con citas bibliográficas puede verse en RESINA, P. *Prácticas monopolísticas e intervencionismo público en materia de mercados*, en Bello, S. ; Zamora, J.L. (coords.), *El Derecho comercial, de Roma al Derecho actual*, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, p. 777 nt. 19.

6 Las dificultades para el abastecimiento de la urbe y más adelante del Imperio, requerían de un complicado sistema de transporte que garantizase las importaciones de productos de primera necesidad, como el trigo, que se transportaba desde distintas provincias: Sicilia, Cerdeña, África y, particularmente, Egipto. Un análisis detallado de estas cuestiones puede verse, entre otros, en RUGGINI, L. G. *Economia e società nell'Italia Annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milán, 1961, ROSTOVZEV, M. *Storia Economica e Sociale*

sin embargo, se refiere a los *navicularii*. También en relación con esta figura se encarga de precisar que se refiere a aquellos *navicularii* que sirven a la *annona* de la ciudad, “*qui annonae urbis serviunt*”. El término *navicularii* concurre en las fuentes con otras denominaciones que designan, todas ellas, figuras que operan en el ámbito del antiguo comercio marítimo⁷. En ese sentido podemos señalar que reciben tal calificación las personas dedicadas al comercio marítimo, no siendo posible por el estado de las fuentes, ni de las distintas interpretaciones que de las mismas hace la doctrina delimitar con exactitud y en un sentido unívoco las funciones que desempeñaban los *navicularii*.

Respecto a esa inicial referencia que hace el jurista podemos señalar que la primera es más general que la segunda, de tal forma que cuando se refiere a “*negotiatores (...) adiuvant*”, tanto el sustantivo que maneja, que se refiere en general a aquellos que negocian, como el verbo “*adiuvo*”, cuyo significado es el de ayudar en el sentido de ser útil a algo, expresan una idea más amplia que la siguiente, que nos ofrece un panorama más definido y acotado tanto de los sujetos como de la acción que realizan; así, en segundo lugar se refiere a los “*navicularii (...) serviunt*”. Mientras que el *negotiator* engloba a cualquier sujeto que lleva a cabo negocios, ya sean terrestres o marítimos, la actividad de los *navicularii*, sin embargo, tal y como acabamos de apuntar, se centra en las actividades comerciales marítimas. Por otra parte, el verbo que emplea en esta ocasión es “*servio*”, con las connotaciones de prestación de asistencia que conlleva. En concreto el jurista parece aludir a la labor de transporte para el suministro de las *annonae* con que se abastecen las necesidades de la ciudad. Por otra parte, el uso de *item* para unir una y otra referencia, *negotiatores* y *navicularii*, nos lleva a pensar que los *navicularii* son un tipo concreto de *negotiator* que

dell'Impero Romano, Oxford, 1965, pp. 166 y ss., 185 y ss. y SIRKS, B. J. *Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991, pp. 26 y ss. Por otra parte, la insuficiencia del puerto marítimo-fluvial del que disponía Roma hasta mediados del s. I d.C. para su abastecimiento es una circunstancia constatada, vide, entre otros CHIC, G. *Rutas comerciales de las ánforas olearias hispanas*, acceso en línea a través de www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/57691.pdf (última consulta 4/04/2014), pp. 229 y s. Sobre las transacciones económicas que se producían por las necesidades del traslado de productos de consumo, especialmente el aceite de la Bética, vide GÓMEZ-IGLESIAS, A. *Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los “tituli picti”*, en *REHJ.* 23, Valparaíso, Chile, 2010, pp. 59 y ss. Los problemas sociales que se generaban en momentos de carestía de trigo quedan reflejados en las fuentes, cfr., a título de ejemplo, el relato de Tácito en el que se apunta que bajo el mandato de Tiberio se suceden las quejas y se llegó al borde de la sedición por la escasez de trigo, vide *Tac. Ann.* 6,13: “*Isdem consulibus gravitate annonae iuxta seditionem ventum multaue et pluris per dies in theatro licentius efflagitata quam solitum adversum imperatorem (...)*”, *Tac. Ann.* 4,6: “*(...) plebes acri quidem annona fatigabatur (...)*”

7 Vide ARNOUT A. ; MEILLET, A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, París, 2001, p. 431, donde se apunta que *navicularius* deriva de la voz *navis* y que indica concerniente al comercio marítimo o al armador. En la navegación como actividad mercantil se requiere del desempeño de varias funciones, que podían recaer en sujetos distintos o agruparse en uno solo. Términos como *exercitor*, *gubernator* o *magister* son algunos de los que aparecen en las fuentes y a los que se atribuyen funciones propias de la empresa naviera. Los mismos juristas se ocupan de ofrecer algunas definiciones al respecto; así, por ejemplo, Ulpiano señala qué debe entenderse por *exercitor*, D. 14,1,1,15 (Ulp. 28 ad ed.): “*Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et redditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum*”, o por *magister navis*, D. 14,1,1,1 (Ulp. 28 ad ed.): “*Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est*”. Para un análisis de la diversa terminología presente en las fuentes en torno a las empresas navieras y al comercio marítimo vide SORIANO, C. *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho romano*, México, 2007, pp. 26 y ss. y 121 y ss.

contribuyen a la prestación de los servicios anónarios; entendemos que con la referencia a los *navicularii* el jurista está precisando la afirmación inicial⁸. A continuación señala el jurisconsulto que éstos alcanzan la inmunidad de cargas públicas “*immunitatem a muneribus publicis consequuntur*” durante el tiempo que realizan esa labor “*quamdiu in eiusmodi actu sunt*”. La cuestión que se suscita de inmediato es la de determinar cuál es el alcance de esa exención de cargas públicas a que alude el jurista. Dejemos esa incógnita por ahora para continuar con el texto, que seguidamente ofrece una primera explicación de las causas que justifican el establecimiento de ese privilegio: “*nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis*”. El propio jurista precisa que se trata de estimular la labor que realizan con premios, reflejando en el mismo pasaje la doble finalidad que éstos presentan: remuneratoria (*remuneranda*)⁹ y estimulante (*exhortanda*)¹⁰, compensando así los riesgos que asumen (*pericula eorum*). En la medida en que los servicios que prestan esos profesionales son de especial interés para la comunidad porque contribuyen al aprovisionamiento de *annona* a la urbe merecen ser compensados. Por lo que respecta a los *navicularii*, es fácil intuir que los riesgos a que alude el jurisconsulto son los propios de la navegación que, además de implicar altos costes, podía acarrear cuantiosas pérdidas tanto económicas como personales por causas que escapan al control de quien ejerce la actividad de transporte; el caso paradigmático es el del naufragio¹¹. La explicación del jurista se hace más explícita al final del fragmento, donde señala que aquel que desempeña cargos fuera de la ciudad “*per-egre*”, asumiendo riesgos y esfuerzos “*cum periculo et labore*”, debe quedar libre de gastos y molestias domésticas “*a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur*”, pues mientras sirven a la *annona* se puede equiparar la situación de estos profesionales a la de aquellos que están ausentes *rei publicae causa*¹².

8 A nuestro juicio la traducción más correcta y que ofrece mayor coherencia es la de entender que “*item*” vendría a ser “así como”, entre otras cosas porque el resto del fragmento se refiere únicamente a los *navicularii* y la actividad que éstos realizan.

9 Los premios pueden presentar el doble efecto mencionado o simplemente el efecto compensatorio, en aquellos casos en que el sujeto no conoce con antelación la recompensa, por lo que no lleva a cabo su actividad impulsado por la idea de recibirla. Ejemplos de este tipo de premios en los que sólo se observa el efecto compensatorio son abundantes en las fuentes. Cicerón, por ejemplo, alude en varios pasajes del *pro Balbo* a la posibilidad de conceder premios, de forma discrecional, para compensar comportamientos ejemplares y valerosos en el campo de batalla, vide *Cic. Pro Balbo* 22; 37 y 38, entre otros.

10 El efecto estimulante del premio se refleja también en numerosas fuentes literarias, cfr., entre otros, *Liv.* 2,20,12; 4,35,8; 35,11,6 y 45,36,4.

11 Para un análisis de las cuestiones jurídicas que se plantean en torno al naufragio vide PERALTA, T. *El naufragio en el Derecho romano clásico*, en *Liber amicorum: Juan Miquel: estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo*, Linares J.L. (coord.), 2006, pp. 805 y ss. Junto al naufragio los riesgos más comunes son el de pérdidas sufridas por la piratería y por avería gruesa, siendo el caso más frecuente el de echazón de mercancía (“*iactus*”) para aligerar la nave. Sobre estas últimas cuestiones vide ZAMORA, J.L. *Averías y accidentes en Derecho marítimo romano*, Madrid, 2000.

12 El jurista establece una analogía entre los *navicularii* mientras prestan los servicios anónarios y aquellos que se ausentan *rei publicae causa* que, como sabemos, reciben ciertos beneficios. La asimilación entre situaciones de ausencia justificadas por un interés público con aquéllas en que el sujeto realiza un viaje oficial o está ausente por obligaciones militares no es novedosa. Sobre estas hipótesis vide PERIÑÁN, B. Un estudio sobre la ausencia en Derecho romano: *absentia y postliminium*, Granada, 2008, pp. 94 y ss. y 102 y ss. nt. 84.

Pasemos ahora a analizar con más detalle algunas de las cuestiones reseñadas. A lo largo del pasaje son varios los momentos en los que el jurista puntualiza que esos privilegios se dan para aquellos que contribuyen a la prestación del servicio anonario, especificando que sólo se verán beneficiados mientras lleven a cabo esa tarea: “*qui annonam urbis adiuvant*”, “*qui annonae urbis serviunt*”¹³, “*dum annonae urbis serviunt*”. Parece verosímil pensar que esa insistencia se debe a que en este periodo los sujetos que prestaban este servicio eran particulares¹⁴ que, previsiblemente, desarrollarían una actividad comercial paralela y al margen de la citada¹⁵, lo que debió dificultar el control de la misma y generar situaciones abusivas o fraudulentas de personas que trataban de aprovecharse de las exenciones previstas sin cumplir con el presupuesto exigible para ello. Las fuentes reflejan numerosos pronunciamientos en esa línea como veremos.

Para entender mejor algunos de los aspectos que se tratan en el texto que comentamos, particularmente la citada cuestión de las inmunidades, conviene ponerlo en conexión con otros pasajes. La alusión a los *munera publica*¹⁶ que hace el jurista, parece referirse, en este contexto, a las obligaciones a que se ven sometidos los ciudadanos de cada municipio, que son variables en cada uno de ellos. Las fuentes reflejan un amplio abanico de artimañas encaminadas a evadir el cumplimiento de esas cargas municipales o a aprovecharse de las exenciones previstas de forma ilícita¹⁷. Ofrecemos a continuación algunos de los textos más significativos y que dan muestra de esta realidad. Como veremos enseguida, ante estas situaciones los pronunciamientos van encaminados a acotar tanto los beneficiarios de la inmunidad como el alcance de la misma, para tratar de evitar situaciones abusivas o de fraude. Así, por ejemplo, en cuanto a las personas que abarca el privilegio, se apostilla que el beneficio no alcanza a los herederos¹⁸, ni a los hijos o libertos¹⁹; por lo que respecta

13 En la misma línea D. 50,6,6,5 (Call. de Cogn. 1): “*Divus Hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt*”.

14 Lo que no obsta al hecho de que se agrupasen en torno a la actividad profesional que realizan. En Roma es conocida esa práctica de agruparse en corporaciones en torno a una actividad profesional concreta. El fenómeno de asociacionismo profesional, por lo que respecta a los *navicularii*, está constatado en las fuentes. Cfr. D. 50,6,6,6 (Call. 1 Cogn.): “(...) *corpore naviculariorum* (...)”, D. 50,6,6,13 (Call. 1 Cogn.): “(...) *qui in corporibus allecti sunt, quae immunitatem praebent naviculariorum* (...)”. Los estudios doctrinales sobre el asociacionismo y los colegios profesionales en Roma en general, son abundantes. Por lo que respecta a los *navicularii*, vide, entre otros, DE ROBERTIS, F. *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, 2, Bari, 1971, pp. 114 y ss, *praepicue* 169-178 y DE SALVO, L. *Il corpus naviculariorum e la annonaria praestatio*, en *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti*, 54 (1977-78). En español vide PENDÓN, E. *Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho romano*, Madrid, 2002, pp. 312 y ss. Como cualquier corporación debió existir una regulación interna de la misma que fijara los derechos de sus miembros.

15 La realización de estos servicios a favor de la comunidad en el periodo republicano y los albores del Principado debió coexistir con el ejercicio de una actividad comercial paralela que permitiese su subsistencia. Las fuentes reflejan esa realidad, cfr., en ese sentido, D. 50,6,6,6 (Call. 1 Cogn.) y D. 50,6,6,8 (Call. 1 Cogn.) (nts. 21 y 22), donde se hace patente que desarrollan actividades al margen de la prestación del servicio anonario.

16 La polisemia de la palabra *munera* es señalada por los propios juristas, cfr. D. 50,16,18 (Paul. 9 ad ed.): “(...) *igitur municipes dici, quod munera civilia capiant*”.

17 Un análisis detallado de las concretas exenciones e inmunidades de que pudieron beneficiarse los *navicularii* puede verse en SIRKS, B. J. *Food for Rome* cit. pp. 45 y ss.

18 D. 50,6,1,1 (Ulp. 3 Opin.): “*Personis datae immunitates hereditibus non relinquuntur*”.

19 D. 50,6,6,4 (Call. 1 Cogn.): “(...) *quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam liberis aut libertis eorum praestatur* (...)”.

al alcance de la exención se apunta que no basta con que estén inscritos en la correspondiente corporación, siendo preciso que tengan nave y que se dediquen a la actividad que comentamos, pues según señala Calístrato, que para fundar su opinión se apoya también en un rescripto de los *Divi Fratres* del mismo parecer, había personas que fingían dedicarse a esa actividad²⁰ o que, sin tener empleado gran parte de sus bienes en la misma, pretendían beneficiarse de las exenciones²¹. En términos análogos se subraya, citando un rescripto de Adriano, que debe reinvertirse parte de la ganancia en la actividad, excluyéndose aquellos casos en que los *navicularii* se han enriquecido invirtiendo sólo una pequeña cantidad del patrimonio²². En la misma línea apuntada, Escévola subraya que los *navicularii* que invirtiesen la mayor parte de su patrimonio en el negocio, se benefician de una exención quinquenal de las cargas públicas²³.

Llegados a este punto conviene hacer una reflexión más general sobre los privilegios que comentamos. Cuando se alude al intervencionismo en el ámbito económico, frecuentemente se asocia esa expresión a medidas que limitan o prohíben la libertad del particular como sujeto económico²⁴. No obstante, en el caso que nos ocupa, la intervención por parte de las autoridades no es de carácter negativo, en la medida en que no se impiden o vetan el ejercicio de determinadas prácticas, por el contrario nos encontramos ante una injerencia que podríamos calificar de carácter positivo, que consiste en la previsión de una serie de privilegios para fomentar una actividad comercial de especial interés público, en este caso

20 En la misma línea, se cita un rescripto del Divino Pío que trata de combatir aquellas situaciones en las que se aparenta el ejercicio de la actividad para evadirse ilícitamente de las cargas, D. 50,6,6,9 (*Call. 1 Cogn.*): “*Divus quoque Pius rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutatur, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat*”.

21 D. 50,6,6,6 (*Call. 1 Cogn.*): “*Licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti. Idque et divi fratres rescripserunt in haec verba: (...) [id est: erant etiam alii quidam sub ea specie, quod navicularii quique frumentum oleumque ad annonam populi Romani advehunt immunes sunt, munera effugere volebant, cum neque naviculariam facerent neque maiorem partem rei familiaris in re navicularia et negotiatione collocassent: horum immunitas tollatur.]*”.

22 D. 50,6,6,8 (*Call. 1 Cogn.*): “*Negotiatio pro incremento facultatum exercenda est. Alioquin si quis maiore pecuniae suae parte negotiationem exercebit, rursus locuples factus in eadem quantitate negotiationis perseveraverit, tenebitur muneribus, sicuti locupletes, qui modica pecunia comparatis navibus muneribus se publicis subtrahere temptant: idque ita observandum epistula divi Hadriani scripta est.*”

23 D. 50,4,5 (*Scev. 1 Reg.*): “*Navicularii (...) qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent*”.

24 Las fuentes atestiguan la presencia de este tipo de medidas en la experiencia jurídica romana, que van desde la promulgación del *Edictum de pretiis rerum venalium* (*CIL. III, 801 y ss.*) hasta las sucesivas restricciones a la libertad de contratación de la que nos dan noticia los juristas y que se encaminan a evitar, entre otras prácticas, la especulación y algunas otras que generan un enriquecimiento injusto. Cfr., entre otros, D. 47,11,6 (*Ulp. 8 de Off. Proc.*) “*(...) annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent: quorum avaritiae obviam itum est tam mandatis quam constitutionibus (...)*” y D. 2,15,8,22 (*Ulp. 5 de omn. Trib.*): “*(...) nec enim debet ex alieno damno esse locuples*”. Para un análisis de las medidas intervencionistas restrictivas de la libertad de contratación vide, entre otros, DE LA ROSA, P. *Aspectos del intervencionismo estatal en el tráfico comercial durante la época imperial*, en *Estudios de Derecho romano en honor de Álvaro d’Ors*, 2, Pamplona, 1987, pp. 1017 y ss. y ROBLES, L.M. *Notas sobre las crisis económicas en el Imperio romano: entre la libre iniciativa y el intervencionismo*, en *RGDR. 12*, 2009, pp. 9 y ss.

25 La utilidad social del transporte marítimo de la *annonna* para el abastecimiento de la ciudad ha sido subrayada por la generalidad de la doctrina, vide, por todos, CERAMI, P.; PETRUCCI, A. *Lezioni di Diritto commerciale romano*. Torino, 2002, p. 36.

27 En este momento, por tanto, la prestación del servicio tendría carácter individual, voluntario y temporal, como se puede deducir de lo visto hasta ahora. El carácter individual y temporal, por contraste, con la situación que se dará posteriormente ya ha sido señalado, entre otros, por DE ROBERTIS, F. *El fenomeno associativo nel mondo romano. Dai collegi della Repubblica alle Corporazioni del Bassi Impero*. Modena 1955, p. 143.

28 En relación con la *utilitas* y la referencia a la misma en fuentes relacionadas con el comercio vide GALLO, F. *Negotiatio e mutamenti giuridici* cit., pp 857 y ss. El mismo autor apunta la conexión de estas ideas con el *aequum*.

29 Entendemos por premialidad la dimensión del Derecho que trata de recompensar y, a veces, de incentivar de las formas más variadas, las actuaciones del individuo o de ciertas colectividades que se consideran socialmente útiles. Un análisis conceptual del Derecho premial y promocional y una comprensión del debate que suscita esta cuestión en general puede verse en BOBBIO, N. *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoría del Diritto*, Milano, 1977. La postura de Bobbio sobre la cuestión suscitó reacciones críticas de lo más variadas, entre las cuales cabe destacar la de Gavazzi, que centra parte de su atención en las fuentes romanas, vide GAVAZZI, G. *Diritto premiale e Diritto promozionale*, en *Diritto premiale e sistema penale. Atti del Settimo Simposio di Studi di Diritto e Procedura Penali*, Milano, 1983, pp. 37 y ss. Una respuesta del propio autor a algunas de las críticas recibidas puede verse en BOBBIO, N. *La funzione promozionale del diritto rivisitata*, en *Sociologia del Diritto*, 3, 1984, pp. 7 y ss.

30 Vide LURASCHI, G. *Il "praemium" nella esperienza giurica romana*, en *Studi in onore di Arnaldo Biscardi* 4, Milano, 1983, pp. 239 ss., que presenta un interesante panorama general de la experiencia premial en Roma en sus diversos ámbitos.

419

conexión con la política premial puesta en marcha por las autoridades, cuya presencia es una constante en la experiencia jurídica romana, muestra el propósito de guiar la libre actuación del sujeto incentivando y recompensando la realización de actividades de especial interés.

III. Aquellos *navicularii* que prestan una actividad básica y, por ello, considerada de utilidad pública, como es el suministro de *annona* a la urbe, se convierten en beneficiarios de ciertos privilegios. Las dificultades y riesgos que estos profesionales asumen en el ejercicio de su actividad son los que fundamentan las exenciones previstas a su favor, que tratan de garantizar el aprovisionamiento de productos de primera necesidad a la urbe. La *immunitatem a muneribus publicis* señalada por el jurista que en mayor medida trata la materia, Calístrato, es una medida que podríamos calificar de intervencionista y que instaura el otorgamiento de un premio cuya finalidad es doble: incentivar, estimular el ejercicio de esa actividad y compensar, retribuir o premiar la dedicación a una tarea especialmente gravosa, dado los costes y riesgos que en el ejercicio de la misma se asumen. El hecho de que se trate de particulares que, previsiblemente, ejercían paralelamente su actividad privada dificulta el control de los beneficios y lleva a las autoridades a pronunciarse circunscribiendo las hipótesis subsumibles en el presupuesto que permite los privilegios frente a situaciones en las que los sujetos tratan de aprovecharse fraudulentamente de los mismos. En definitiva se puede concluir que esa previsión premial es una injerencia pública en la actividad privada en la que subyace la intención de estimularla promocionando un sector de máximo interés estratégico. Estamos ante una muestra de una política de incentivación que oscila entre la libertad individual o la iniciativa privada del sujeto y la garantía de la prestación de actividades ineludibles para el adecuado abastecimiento a la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA:

- ARIAS-RAMOS, J. *El transporte marítimo en el mundo romano*, en *Discurso de Apertura del curso 1948-1949*, acceso en línea a través de [file:///C:/Downloads/Disc.Apert.UVA1948-49%20\(1\).pdf](file:///C:/Downloads/Disc.Apert.UVA1948-49%20(1).pdf), (última consulta 4/04/2014).
- ARNOUT, A. ; MEILLET, A. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, París, 2001.
- BOBBIO, N. *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoría del Diritto*, Milano, 1977.
- BOBBIO, N. La funzione promozionale del diritto rivisitata, en *Sociologia del Diritto*, 1984, pp. 7 y ss.
- CERAMI, P. ; PETRUCCI, A. *Lezioni di Diritto commerciale romano*, Torino 2002.
- CHIC, G. *Rutas comerciales de las ánforas olearias hispanas*, acceso en línea a través de www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/57691.pdf (última consulta 4/04/2014).
- DE LA ROSA, P. Aspectos del intervencionismo estatal en el tráfico comercial durante la época imperial, en *Estudios de Derecho romano en honor de Álvaro d'Ors*, 2, Pamplona, 1987, pp. 1011 y ss.

publica, II, *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Milano, 2012, p. 317 nt. 46 y p. 344, quien señala que, sin negar las posiciones proclives a la negación de la paternidad ulpianea del final de ese fragmento y la intervención de los compiladores, el recurso a la *utilitas publica* resulta plenamente conforme con la mentalidad del jurista.

- DE ROBERTIS, F. El fenómeno asociativo nel mondo romano. Dai collegi della Repubblica alle Corporazioni del Bassi Impero, Modena, 1955.
- DE ROBERTIS, F. Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano, 2, Bari, 1971.
- DE SALVO, L. Il corpus naviculariorum e la annonaria praestatio, en Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, 54, 1977-78.
- GALLO, F. *Negotiatio e mutamenti giuridici nel mondo romano*, (a cura di) Bona, F ; Miglietta, M., *Opuscula Selecta*, Padova, 1999, pp. 823 y ss.
- GARCÍA BROSA, G. Mercatores y negotiatores: ¿*simples comerciantes*?, en *Pyrenae* 30, 1999, pp. 173 y ss.
- GAVAZZI, G. Diritto premiale e Diritto promozionale, en Diritto premiale e sistema penale. Atti del Settimo Simposio di Studi di Diritto e Procedura Penali, Milano, 1983, pp. 37 y ss.
- GÓMEZ-IGLESIAS, A. *Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los “tituli picti”*, en *REHJ.* 23, Valparaíso, Chile, 2010, pp. 59 y ss.
- LONGO, G. *Utilitas publica*, en *Labeo*, 18, 1972, 1, pp. 7 y ss.
- LURASCHI, G. Il “*praemium*” nella esperienza giurica romana, en Studi in onore di Arnaldo Biscardi 4, Milano, 1983, pp. 239 ss.
- MATEO, A. *Calístrato*. En Domingo R. (coord.), *Juristas Universales 1. Juristas antiguos*, Madrid, 2004, pp. 202 y ss.
- PENDÓN, E. Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho romano, Madrid, 2002.
- PERALTA, T. El naufragio en el Derecho romano clásico, en *Liber amicorum: Juan Miquel: estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo*, Linares, J.L. (coord.), 2006, pp. 805 y ss.
- PERIÑÁN, B. Un estudio sobre la ausencia en Derecho romano: *absentia y postliminium*, Granada, 2008.
- REMESAL, J. El sistema annonario como base de la evolución económica del Imperio romano, en *PACT* 27, 1990, pp. 355 y ss.
- RESINA, P. Prácticas monopolísticas e intervencionismo público en materia de mercados, en Bello, S. ; Zamora, J.L. (coords.), *El Derecho comercial, de Roma al Derecho actual*, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, pp. 771 y ss.
- ROBLES, L.M. Notas sobre las crisis económicas en el Imperio romano: entre la libre iniciativa y el intervencionismo, en *RGDR.* 12, 2009.
- ROSTOVZEV, M. *Storia Economica e Sociale dell’Impero Romano*, Oxford, 1965.
- RUGGINI, L. G. *Economia e società nell’Italia Annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milán, 1961.
- SCEVOLA, R. *Utilitas publica*, II, *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Milano, 2012.
- SIRKS, B. J. *Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991.
- SORIANO, C. *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho romano*, México, 2007.
- ZAMORA, J.L. *Averías y accidentes en Derecho marítimo romano*, Madrid, 2000.

LAS SOCIETATES PUBLICANORUM Y EL EDICTUM PROVINCIALE*

ARMANDO TORRENT
Universidad Rey Juan Carlos

Por regla general los magistrados que Roma enviaba a gobernar las provincias contaban con una gran experiencia de gobierno por las magistraturas desempeñadas anteriormente (cónsules, pretores), y tanto durante la República como durante el Principado tenían atribuidas amplísimas competencias para dirigir la provincia asignada, siendo frecuente que plasmasen en un edicto, el llamado *edictum provinciale*, las reglas jurisdiccionales que regirían durante su mandato, tema relativamente poco estudiado en la literatura del s. XIX si dejamos aparte el estudio de Bousseau¹. Hubo que esperar a los albores del s. XX para que se avivara el interés por el tema suscitado por Von Velsen², y poco más tarde por Kniep³, tema que necesariamente ya había sido apuntado en obras generales como la de Karlowa⁴ a

* La bonhomía, saber hacer, caballerosidad y la inmensa cultura de Antonio Díaz Bautista han sido hechos destacadísimos en la romanística española de los últimos cuarenta años. Conocí a Antonio en 1974 en un congreso en Poitiers de la Société de Droit. En aquella época Antonio era Prof. Adjunto en la Universidad de Murcia, y poco después ganó la cátedra, de San Sebastián entonces llamadas Agregaciones; (todas las reformas que ha sufrido la Universidad española, y todas para peor, en gran parte sólo han sido cambios semánticos), y las ultimísimas parecen ser apuestas decisivas del Ministerio de Educación para acelerar el deterioro imparable de la Universidad. Con Antonio y nuestras santas y abnegadas esposas hicimos un viaje juntos en coche una vez a Estocolmo y otra a Salzburgo a congresos de la SIHDA. Hombre cultísimo era un excelente pintor y gran amante de la música sinfónica, aficiones que no le apartaron nunca de su vocación romanística con una gran atención a los problemas de la banca bizantina. Ultimamente estaba centrado en las constituciones de Diocleciano que ya ha dado espléndidos frutos. Su inesperada muerte en un momento de gran madurez y claridad intelectual nos ha golpeado a los amigos que siempre lo tendremos en el recuerdo.

1 V. BOUSSEAU, *De l'édit provincial*, (Poitiers 1890), que no he podido consultar directamente; tomo la cita de R. MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, (Milano 1969) 1 nt. 1, del que recojo que ya se lamentaba (BOUSSEAU 72) que el edicto provincial “n’a pas été l’objet d’études spéciales de la part des modernes”

2 Cfr. F. VON VELSEN, *Das edictum provinciale des Gaius*, en ZSS 21 (1900) 73 ss., mas un breve apéndice que incluyó en *Beiträge zur Geschichte des edictum praetoris urbani*, (Leipzig 1909) 105-108,

3 F. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare* (Jena 1910) 149-314.

4 O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I (Leipzig 1885) 473 ss; 631 ss.

finales del s. XIX, y ya en el XX Krüger⁵, De Francisci⁶, Schulz⁷, y por supuesto Guarino en su copiosa producción referida al edicto⁸. Ya específicamente centrados en el edicto provincial hay que destacar los estudios de Weiss⁹ que apelando a fuentes epigráficas y papirológicas afrontó el tema desde un enfoque más amplio examinando el *ius edicendi* de los *praesides provinciarum*, y Falletti¹⁰ que se centró en la jurisdicción civil de los magistrados provinciales en el Alto Imperio.

Así estaban las cosas, que podríamos decir enfocadas desde aproximaciones muy peculiares, hasta que en 1934 Buckland¹¹ publicó un agudo análisis sobre el edicto provincial que fue acogido favorablemente por la doctrina aunque solo fuera al nivel de “sugestiva hipótesis”, como expresaron Volterra¹², Luzzatto¹³, y Wesenberg¹⁴. Otro hito importante en el estudio del edicto provincial se debe a Pugliese¹⁵ centrado en el edicto de Cic. para la provincia de Cilicia promulgado el 51 a. C. al que alude el Arpinate en diferentes partes de sus escritos. A partir de Pugliese se iban haciendo cada vez más precisos los estudios que permiten afrontar lo que podemos llamar una definición general del *genus provinciale*, y hubo que esperar a 1969 cuando Martini¹⁶ afrontó un estudio amplio y orgánico sobre el edicto provincial, y por supuesto no podemos nunca dejar de lado las siempre agudas referencias a nuestro tema recogidas desde la primera edición de su monumental *Storia della costituzione romana* ofrecidas por De Martino¹⁷. Desde entonces la literatura romanística tomó conciencia de la importancia del edicto provincial siendo analizado desde muy diversos ángulos, tomando gran impulso los realizados sobre la actividad jurisdiccional del *praefectus Aegypti*, estudios importantes que debemos tener en cuenta sin olvidar nunca la situación del todo particular de Egipto dentro del Imperio Romano sujeto al dominio directo del *princeps* ejercido en primer lugar mediante los *legati Augusti* y posteriormente por los *praefecti Aegypti*¹⁸.

Realmente no conocemos directamente ningún edicto provincial, pero sí contamos con numerosas noticias indirectas, en primer lugar por la información a veces muy pormenorizada de Cicerón; por el comentario de Gayo *ad Edictum provinciale*; por documentación

5 KRÜGER, *Geschichte der quellen und Literatur des römischen Rechts*², (Leipzig 1912) 95.

6 P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, II,1 (Milano 1938) 458, que ya había hecho un apunte relevante en *Συνάλλαγμα*, II (Pavia 1916) 259.

7 F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, (Oxford 1953) 127; 191 ss.

8 A. GUARINO,

9 E. WEISS, *Studien zu den römischen Rechtsquellen*, (Leipzig 1914) 63-147)

10 FALLETTI, *Evolution de la jurisdiction civile du magistrat provincial sous le Haut Empire*, (Paris 1926) 68-83.

11 W. W. BUCKLAND, *Edictum provinciale*, en *RHD* 4. s. 13 (1934) 81 ss,

12 E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, (Bologna 1937) 297.

13 G. I. LUZZATTO, *Epigrafia giuridica greca e romana*, (Milano 1942) 268; Id. v. *Provincia*, *NNDI* 14 (Torino 1967) 381,

14 G. WESENBERG, v. *Provincia*, en *RE* 23,1 (1957) c. 1006.

15 G. PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, en *Synteleia Arangio-Ruiz*, 2 (Napoli 1964) 972 ss. = *Scritti giuridici scelti*, III (Napoli 1985) 101 ss., (en adelante *Scritti III*).

16 MARTINI, *Ric*, cit.

17 F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II,2 (Napoli 1955) 320 ss.; IV,2 (Napoli 1965) 733 ss.

18 Sobre la administración de la justicia en Egipto, vid. con lit. TORRENT, *La constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 I*, (Madrid 2012)

papirológica referida especialmente a Egipto, y por las leyes epigráficas municipales. Tenemos menciones de este edicto en la *lex Irnitana* del 91 d. C. dictada para el *municipium iuris Latini* de Irni, ciudad hispana situada en la Bética a unos 30 kms. de Sevilla. Respecto al contenido procesal de estos edictos se puede decir que se promulgaban a imitación de los edictos de los pretores urbano y peregrino de Roma, con lo que desde un punto de vista procesal iban profundizando en la extensión y aplicación del derecho romano en provincias que de este modo se convirtió en un factor potentísimo de unificación jurídica en el Mundo Antiguo. En general los edictos provinciales se limitaban a una reproducción o incluso un mero reenvío al *Edictum praetoris urbani* como asimismo al *Edictum praetoris peregrini*¹⁹, como se comprueba por el uso del plural *edicta* en los edictos conservados²⁰.

Ciertamente que en esta sede me interesa especialmente analizar la conexión edicto provincial-*publicani*, pero también quiero destacar, aunque sea una obviedad decirlo, que el *edictum provinciale* es necesario para el conocimiento de los ordenamientos provinciales y especialmente de las reglas procesales aplicadas en provincias. No son muchas las fuentes que explícitamente traten el tema, pero entre éstas contamos con el edicto de Cic. para Cilicia, y él mismo decía que lo había compuesto en Roma²¹ donde decía a su amigo Tiberio Pomponio Atico (*ad Att.* 6,1,15) que había recogido en su edicto algunas reglas del edicto de Q. Mucio Scaevola gobernador de Asia en el 94 a. C.; asimismo menciona un edicto de Bíbulo²² (probablemente para la provincia de Siria), y como es sabido en *in Verr.* habla ampliamente de los edictos del venal propretor²³, también en *ad Att.* donde informa de un breve *edictum* para Cilicia con una doble serie de disposiciones: en la primera (*genus provinciale*) trata de las finanzas de las ciudades, el *aes alienum*, las *usurae*, las *syngraphae*, materias que mucho tienen que ver con la actividad de los publicanos en lo que podríamos llamar hoy muy sintéticamente (y acaso con cierta dosis de confusionismo) mercados financieros; en la segunda trata materias diversas como la *bonorum possessio* con la correlativa *missio in possessionem*, y del mecanismo de la *bonorum venditio* que a su vez tiene relación también con la actividad de los publicanos en el ejercicio de *pignoris capiones* y *commissa*

19 TORRENT, *Syngraphae cum Salaminii*, en IVRA 24 (1973) 99; L. MAGANZANI, *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo editale de publicanis*, (Torino 2002) 96 nt. 94.

20 Doctrina aceptada desde VON VELSEN, *Edictum prov.* 80; siguen esta tesis PUGLIESE, *Scritti* III, 105 nt. 9; F. SERRAO, *La "iurisdictio" del pretore peregrino*, (Milano 1954) 116 ss.; MARTINI, *Ric.* 34 nt. 43; L. PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, en *Labeo* 37 (1991) 47 nt. 116; K. HACKL, *Il processo civile nelle province*, en F. MILAZZO (cur.), *Gli ordinamenti giuridici di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano. Atti Copanello*, (Napoli 1989) 311 nt. 57. Esta tesis del reenvío a ambos edictos supera una doctrina más antigua defendida por F. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius* 331, WEISS, *Studien* 67, y W. W. BUCKLAND, *Edictum prov.*, 84 ss., que únicamente admitía la remisión al edicto del pretor urbano, tesis de la que participa MAGANZANI, *Publicani* 96: "il resto dell'editto (<descartado el *genus provinciale*>) era oggetto di mero rinvio alla corrispondente sezione degli editti urbani".

21 Cic. *ad Fam.* 3,8,4. Esta debía ser la práctica más frecuente para los gobernadores romanos, que conocían con cierta antelación su nombramiento; vid A. H. J. GREENIDGE, *The legal procedure of Cicero's time*, London 1901; reed. New York 1971) 119; H. GALSTERER, *Roman Law in the Provinces. Some problems and problems of transmission*, en M. H. CRAWFORD (cur.), *L'Impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, (Como 1986) 17.

22 Vid. las dudas sobre si efectivamente Cic. conoció este edicto en PEPPE, *Note* 30. Peppe hace una cuidadosísima disección de Cic. *D Att.* 6,1.

23 Cic. *in Verr.* 2,2,13,32; 2,2,37,90.

contra los contribuyentes morosos o simplemente incumplidores. Todavía añade Cic. *tertio de reliquo iure dicundo ἄγγραφον reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum. Itaque curo et satisfacio adhuc omnibus, Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur*. Con razón dice Buckland²⁴ que en realidad son tres partes, aunque la tercera²⁵ es *non scripta* por su remisión a los *edicta urbana*. El texto fundamental ciceroniano es su respuesta a una serie de cuestiones que le había planteado su amigo Atico:

Cic. ad Att. 6,1,15. De Bibulis edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras “nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum”. Ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσαν sed tectiorem ex Q. Mucii P. f. edicto Asiatico “extra quam si ita negotium gestum ut eo stari non oporteat ex fide bona” multaque sum secutus Scaevolae, in iis aliud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. Breve autem edictum est propter hanc meam διαίρεσιν, quod duobus generibus edicendum putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de sygraphis, in eodem omnis de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent; tertium de reliquo iure dicundo ἄγγραφον reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum. Itaque curo et satisfacio adhuc omnibus. Graeci vero exsultant quod peregrini iudicibus utuntur. “Nugatoribus quidem” inquires. Quid refert tamen se αὐτονομίαν adeptos putant. Vestri enim credo graves habent turpionem sutorium et vettium mancipem.

Realmente éste es el texto fundamental en torno al *edictum provinciale* que permitió a Buckland avanzar que el *genus provinciale* solo se refería a disposiciones de carácter administrativo, mientras que el resto del edicto para Cilicia en nada difería de otros edictos provinciales que se limitaban a repetir los *edicta urbana*, que también debían ser promulgados formalmente en provincias para su aplicación a los *cives Romani* residentes en aquellos territorios cada vez más alejados geográficamente de Roma, hipótesis que como hemos visto en un primer momento pareció sugestiva superando angosturas de autores anteriores que entendían aquella parte especial de los edictos provinciales como promulgación de normas de derecho privado para los *peregrini*. No comparto la visión de Buckland del *genus provinciale* que significa una comprensión muy particular del citado § ciceroniano, e incluso me atrevo a pensar que la consideración de “hipótesis sugestiva” de Volterra y Luzzatto acaso no fuera otra cosa que una argumentación compasiva —e irónica— para no atacar frontalmente la explicación de Buckland, que también tiene aspectos encomiables como la sutil distinción (que no desarrolla en su brevísimo escrito) entre *cives Romani* residentes y *peregrini* en Cilicia sin duda *Graeci* que *suis legibus utuntur*, por lo que parece acertada la exclusión en el *genus provinciale* del contenido privatístico para *peregrini*. En contra de Buckland, que fue el primero que afrontó el edicto provincial con ideas innovadoras, Pugliese no dudó en admitir que el *genus provinciale* podía tener un contenido privatístico aplicable a *Romani* y *peregrini* residentes en provincias, algo que en mi opinión habría que ir caso por caso, porque sería difícil que esto ocurriera en las cultas provincias helenísticas que conta-

24 BUCKLAND, *Ed. prov.* 82.

25 PUGLIESE, *Scritti* III.974, no pone objeciones a la sustantividad de esta tercera parte.

ban desde antiguo con un más o menos perfeccionado derecho propio; por el contrario en otras provincias, y pongo como ejemplo las *Hispaniae* donde la escasez y rusticidad de las normas ibéricas anteriores a la conquista romana eran muy inferiores a las reglas romanas, bien por problemas de calidad, o por evergetismo, se impusieron rápidamente las reglas del *ius civile Romanorum*.

A mi modo de ver la consideración ciceroniana del contenido del *genus provinciale* es mucho más amplia de lo que piensa Buckland, mencionando Cic. lo que podía o no podía recoger en el *genus provinciale*, y será precisamente en esta parte de su διαίρεσις donde trataba de *publicanis*, aparte de la remisión general a los *edicta urbana*. También necesariamente los gobernadores provinciales tenían que recoger cuando fuera oportuno las particularidades especiales de cada provincia, hasta el punto que la ciencia romanística ha podido construir a partir de Cic. la categoría de un *genus provinciale* edictal. Este *genus* interesa especialmente porque los respectivos edictos de modo más o menos prolijo contaban con rúbricas dedicadas a las finanzas e impuestos provinciales²⁶ (*de rationibus civitatum*), más otras rúbricas (*de aere alieno*, *de usuris*, *de syngraphis*) relativas a las deudas contraídas con *cives Romani* por individuos y *civitates* provinciales, tanto con *negotiatores* que les prestaban dinero a tasas usurarias (*foeneratores*)²⁷ que variaban en cada ciudad de forma que incluso entre las ciudades de una misma provincia podían haber diferentes tipos de interés pudiendo decirse que había libertad en la fijación de tipos, no cumpliéndose en provincias las numerosas *leges fenebres* que se habían venido promulgando durante la República, y aunque es cierto que Cic. estableció un tipo fijo en su gobierno de Cilicia, es más cierto que en las ciudades provinciales se fijaban tipos de interés superiores a los establecidos comúnmente en previsiones legales (12% anual a finales de la República que en ocasiones podían duplicar el capital debido (*usurae supra duplum*), y en otras incluían la capitalización de los intereses vencidos y no pagados (anatocismo)²⁸, siendo corriente que en las ciudades provinciales se fijasen tipos superiores a los establecidos en Roma, donde tampoco puede decirse que se respetaran escrupulosamente las *leges fenebres*.

En esta sede me propongo analizar la conexión *edictum provinciale-publicani*, y por tanto el papel que jugaron *publicani* y *soc. publ.* en la recaudación coactiva de las deudas

26 Tema de extraordinaria importancia para Roma pues de las provincias procedía la mayor cantidad de recursos económicos necesarios para soportar los gastos del Estado, acostumbrándose Roma desde la II Guerra Púnica a vivir cada vez más de la riqueza de las provincias.

27 Estas relaciones de los provinciales con *faeneratores* y *publicani* han sido analizadas con particular atención en los territorios romanos del Asia Menor; vid. C. DELPLACE, *Publicains, trafiquants et financiers dans les provinces d'Asie Mineure sous la République*, en *Ktéma*, 2 (1977) 250 ss.; cfr.: ROSTOFVZEFF, *The social and economic History of the Roman Empire*², II (Oxford 1957); T. R. S. BROUGHTON, *Roman Asia Minor*, en T. FRANK (ed.), *An economic Survey of ancient Rome*, IV (Paterson, New Jersey 1959) 534 ss.; A. J. N. WILSON, *Emigration from Italy in the republican age of Rome*, (Manchester 1966) 156 ss.; E. BADIAN, *Publicans and sinners: private enterprise in the service of the Roman Republic*, (Ithaca, New York 1972) 82 ss.; TORRENT, *Syngraphae* 90 ss.; M. BIANCHINI, *Cicerone e le singrafi*, en *BIDR* n. s. 12 (1970) 242 ss.; DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I (Firenze 1979) 134 ss.; E. FRÉZOUOLS, *La fiscalité provinciale de la République au Principate: continuité et rupture*, en *Ktéma* 11 (1986) 16 ss.; L. PEPPE, *Sulla giurisdizione in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone*, (Milano 1988) 81 ss.

28 TORRENT, *Usurae supra legitimum modum*. Del edicto de Luculo a los Severos, en *Studi Nicosia*, VIII (Milano 2007) 257.

tributarias (*vectigalia* por indicar una denominación genérica que abarca diversas figuras tributarias romanas) que explotaban en arrendamiento en virtud de una *licitatio publica*, estando recogida en la parte correspondiente del *genus provinciale* de un lado la regulación de las *pactiones* ente el Estado romano y los publicanos, que si durante la República generalmente se celebraban entre los censores a través de una *lex censoria* y las *soc. publ.*, desde el Principado se encargaban de ello los gobernadores provinciales, o en su caso (como en la *lex Irnitana*) los magistrados municipales; de otro los instrumentos procesales para facilitar a los publicanos el cobro de las deudas tributarias de los deudores morosos mediante el ejercicio (muchas veces abusivo) de *pignoris capiones* y *commissa*. Es cierto que en gran medida los gobernadores reproducían los edictos del pretor de Roma, pero no cabe dudar de la existencia de este *genus provinciale* que permite entrever Gayo 4,32 y había desvelado claramente Cic. en su gobierno de Cilicia y en sus alegatos de acusación contra Verres²⁹ al contraponer diversos edictos provinciales con el del venal propretor de Sicilia, apartándose Verres de modo aberrante del edicto del pretor urbano, de su propio edicto durante su pretura urbana del 74 a. C., de edictos provinciales anteriores, y de la misma legislación tributaria siciliana, (*lex Hieronica* fijando la *decima sícula*, y *lex Rupilia*,). Esta absoluta libertad que se tomó Verres dejando de lado una directriz jurídica ortodoxa para conseguir sus afanes ilegales de enriquecimiento personal extorsionando a los sicilianos, contradice la tesis mantenida mayoritariamente por la doctrina sobre la sustancial homogeneidad de los edictos provinciales hasta Adriano, lo que indirectamente hace resplandecer aquella homogeneidad basada en la trasposición del edicto pretorio de la que se apartaba Verres.

Cic. in Verr. 2,3,11,27. Cum omnibus in aliis vectigalibus Asiae, Macedoniae, Hispaniae, Galliae, Africae, Sardiniae, ipsius Italiae quae vectigalia sunt, cum in his, inquam, rebus omnibus publicanus petitor ac <aut> pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse, tu de optimo, de iustissimo, de honestissimo genere hominum, hoc est de aratoribus, ea iura constituebas quae omnibus aliis esse contraria. Utrum est aequius, decumanum petere an aratorem repetere? Iudicium integra re perdita fieri? Eum qui manu quaesierit, an eum qui digito sit licitus possidere?

Avanzando algunas ideas que espero exponer en otro trabajo³⁰, la jurisprudencia tardo-republicana tuvo que intervenir en las previsibles numerosas controversias que debieron surgir en la tarda República en la actuación diaria de las *soc. publ.* en sus relaciones con los contribuyentes, pero de esta presumible actividad jurisprudencial no quedan sino huellas muy aisladas aportadas por Gayo y juristas severianos conocidas trámite la compilación justiniana, y asimismo el pretor tuvo que actuar frecuentemente concediendo protección procesal a los contribuyentes abrumados por los abusos y extorsiones de los publicanos. Esta actividad pretoria tuvo que ser importante y mereció un edicto especial *de publicanis* confirmada en la rúbrica *de publicanis* de D. 39,4 que incluye *et vectigalibus et commissis*,

²⁹ Vid. TORRENT, Fraudes contables de “societates publicanorum”. Cic. in Verrem 2,2,71,173., de próxima publicación en IAH (2014).

³⁰ TORRENT, El aparente desinterés de la jurisprudencia tardo-republicana por las “societates publicanorum” pendiente de publicación.

extraña mezcla de una categoría socio-económica (los publicanos), un amplia figura fiscal (los *vectigalia*), y uno de los medios privilegiados de los publicanos (*commissa*) para hacer efectivo el cobro de los impuestos debidos, aparte de que, como yo creo, los juristas antoninos y severianos debían conocer algunos escritos de los últimos juristas republicanos en materia de *publicanis*. Es muy sintomático que algunos comentarios proceden de los *libri ad Sabinum* y otros de los comentarios *ad edictum*, lo que evidencia la importancia (y una cierta valencia autónoma) del tema en la jurisprudencia privatística y en la *iurisdictio prae-toria*³¹. También reflejan aquella autonomía los edictos provinciales de los gobernadores en los que fijaban las relaciones con los publicanos en base a las condiciones económicas de su provincia³², que asimismo repercutían en las relaciones (privatísticas) entre publicanos y contribuyentes, tema bien documentado por Cic. y analizado minuciosamente por Genovese³³ que se ha esforzado por aclarar las diferentes partes de los edictos de Verres sobre la materia.

La rúbrica de D. 39,4 tiene todas las trazas de ser prejustiniana, y no recoge la mención de los publicanos la rúbrica paralela de C. 4,61 que solo trata de *vectigalibus et commissis*, según De Martino³⁴ porque la figura de los publicanos era un fósil en época bizantina. Efectivamente la última mención de *publicani* es de los emperadores Arcadio y Honorio en el 401 d. C. (C.Th. 11,27,3). Otro hecho sin clara justificación³⁵ es que el contenido de D. 34,9 no guarda el orden de las masas ideadas por Bluhme³⁶, y aparentemente falta organicidad en D. 39,4, lo que para De Martino³⁷ se debe no a un trabajo realizado directamente por los compiladores sino por las escuelas (prejustinianas), que Triboniano habría querido recoger como una especie de prontuario en cuanto en época bizantina todavía podía darse en arrendamiento la recaudación de determinados tributos consiguientemente gestionados por compañías privadas. En realidad desde las amplias reformas de Augusto se inicia la decadencia de los publicanos de modo que la gestión y recaudación de impuestos llevada a cabo durante la República mediante las poderosas *soc. publ.* privadas, fue siendo paulatinamente sustituida por funcionarios imperiales, entre otros motivos por el *odium* en que habían incurrido los publicanos que perseguían implacablemente a los deudores para lo que contaban con medios ejecutivos suficientes³⁸.

A partir de Augusto empezará el Estado a encargarse de la gestión y recaudación directa de la carga tributaria, cerrando un ciclo documentado desde finales del s. III a. C. de finan-

31 TORRENT, *Syngraphae* 99.

32 PUGLIESE, *Riflessioni* 982, = *Scritti* III, 111 nt. 23.

33 M. GENOVESE, *Gli interventi edititali di Verre in materia di decime sicule*, (Milano 1999) que analiza pormenorizadamente cada uno de los edictos extorsionadores de Verres.

34 DE MARTINO, La storia dei publicani e gli scritti dei giuristi, en *Labeo* 39 (1993) 18

35 TORRENT, La lex locationis de las tres societates publicanorum concurrentes ad hastam en el 215 a. C., de próxima aparición en *SDHI* 80 (2014).

36 F. BLUHME, Die Ordnung der Fragmenten in den Pantektentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandekten, en *Zeitschrift für geschicht. Rechtswiss.* 4 (1829) 165 ss. (reed. *Labeo* 6 (1960) 50 ss.; 215 ss.; 368 ss.).

37 DE MARTINO. *Publicani* 19.

38 Vid. A. LOPEZ PEDREIRA, Reflexiones sobre las medidas ejecutivas reconocidas a los “publicani” (Gayo 4,28-32), en *BIDR* 103-104 (2000-2001) 449 ss.; Ead., Quantum audaciae, quantae temeritatis eius publicanorum factionem. Reflexiones acerca del edictum de publicanis (D. 39,4), en *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña*, 12 (2008) 583 ss.

ciación por los publicanos de los déficits del *aerarium*; en realidad desde un punto de vista económico concedían crédito al Estado muchas veces angustiado por la *inopia aerarii*, y así lo señala paladinamente Liv. 23,48,4 a propósito del *hasta* convocada en el 215 a. C. para avituallar las legiones que luchaban contra los cartagineses en España, en que por lo abultado del riesgo y grandes capitales a invertir tuvieron que presentarse unidas tres *soc. publ.*³⁹ que asumieron aquel contrato. El propio Augusto declara en las *Res Gestae* cap. 17⁴⁰, que en cuatro ocasiones había proporcionado de su propia fortuna (*pecunia mea*) al tesoro público 150 millones de sextercios⁴¹, y en otra ocasión puntual (18 a. C.) ante las carencias económicas del *aerarium* declaró que de su propio patrimonio distribuyó grano y dinero a la población de Roma (*RG* cap. 18).

Desde Augusto es obvia la paulatina sustitución en la recaudación tributaria de las *soc. publ.* por funcionarios imperiales encargándose el Estado directamente de esta tarea, y en el s. I a. C. ya no eran los censores sino los gobernadores provinciales los que señalaban los confines de la actividad recaudatoria publicana como demuestra la información ciceroniana, y por supuesto a partir de Augusto en que el *praeses* era la suprema autoridad jurisdiccional de la provincia fijando las reglas procesales en el *edictum provinciale*. Un ejemplo evidente de lo que vengo diciendo lo encontramos en la legislación municipal epigráfica española en la *lex Irnitana* cap. LXXXV que citaré siguiendo la edición de Lamberti⁴² (la *editio princeps* es de 1986⁴³).

Lex Irnitana cap. LXXXV lin. 28-42

26 R(ubrica) Magistratus ut in publico habeant album eius
qui provinciam optinebit exque eo ius dicant.

30 Quaecumque edicta, quasve formulas iudiciorum, quasque spon-

siones stipulationes satis acceptiones (praescriptiones) ex
ceptiones praescriptiones quaeque interdicta (i)is qui ei pro-

vinciae praeit in ea provincia proposita habebit, quae eo-

rum ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Fla-

35 vio Irnitano i(ure) d(cundo) p(raerit) pertinebunt, ea omnia is in eo mu-

nicipio, in suo magistratu, quotidie maiorem partem cuiusque di-

ci proposita proscripitaque habeto, ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egit) p(ossint)

et si ea inter-

39 TORRENT, *Lex locationis* cit.

40 RG 17. Quater pecunia mea iuvi aerarium, ita uti sextertium milliens et quingentiens ad eos qui praerant aerario detulerim.

41 Cfr. con lit. R. WOLTERS, The Empire and the financial deficits of the “aerarium” in the early Roman Empire, en E. LO CASCIO (cur.), *Credito e moneta nel mondo romano*, (Bari 2000) 147 ss. Cfr. Id., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, (Bari 2000).

42 F. LAMBERTI, “*Tabulae Irnitanae*”. *Municipalita e “ius Romanorum”* (Napoli 1993) 350-351 (con traducción del texto al italiano).

43 Llevada a cabo por J. GONZALEZ, *A new copy of the flavian municipal law*, en *JRS* 86 (1976) con traducción del texto al inglés y comentario de M. H. CRAWFORD. Ese mismo año y de modo independiente también fue editada y comentada por A. d’ORS, *La ley Flavia municipal*, (Roma 1986). La última edición la debemos a J. G. WOLF,

dicta edicta easque formulas sponsiones stipulationes satis ac-
ceptiones exceptiones praescriptiones in eo mu-
40 nicipio ius dicatur iudicia utentur fiant exerceanturve, et
id (fiat sine) d(olo) m(alo).

La *lex Irn.* se gestó y fue promulgada en la cancellería de Domiciano estableciendo que el gobernador debía ordenar a los magistrados locales publicarla en lugar relevante de las ciudades para su conocimiento público. A mi modo de ver su procedencia de la cancellería imperial se resiente de seguir el estado del derecho en la *Urbs*, recogiendo todas las figuras procesales del procedimiento formulario citadas tal como operaban en la *Urbs* que entiendo difícilmente aplicables en provincias por sus mismas complejidades técnicas, de modo que tenían que instrumentarse los procesos por modos más simplificados y siempre bajo la superior supervisión del *praeses* que se reservaba el conocimiento exclusivo de determinadas materias, y desde luego las de una elevada importancia económica. En este sentido creo que el procedimiento formulario encontraba serias dificultades para aplicarse en provincias donde no había un núcleo ilustrado de *cives Romani* buenos conocedores de la gran tradición jurídica que se había ido formando –y tecnificado– a lo largo de la República, de modo que en los territorios provinciales fue avanzando la completa estatalización del proceso que en definitiva constituyó la característica esencial de la *cognitio extra ordinem*⁴⁴ que importado a Roma llegó a arrumbar totalmente los antiguos procesos privados con la bipartición *in iure* y *apud iudicem*. En este sentido la intervención de los *praesides provinciarum* en las controversias procesales, bien directamente por sí mismos, bien mediante la jurisdicción delegada⁴⁵ en los magistrados municipales, fue un paso importante en la implantación arrolladora de la *cognitio extra ordinem*, como diría Peppe⁴⁶, *in populos liberos*.

Ya hemos visto que los gobernadores transponían en el edicto provincial los *edicta urbana*, y que también necesariamente tenían que recoger cuando fuera oportuno las particularidades provinciales, especialmente en materia económica. La intervención del *praeses* de la Bética evidenciada en la *lex Irn.* ordenando a los magistrados locales la publicación de su edicto *in celeberrimo loco*, es un factor preponderante que muestra la influencia absoluta del gobernador romano sobre la provincia de su mando⁴⁷. Al respecto entiendo muy significativo que el edicto de Cic. para Cilicia redactado por él mismo en Roma, tuvo que contar con una serie de innovaciones redactadas por Cic. después de su entrevista en Samos con los publicanos antes de iniciar efectivamente su gobierno de Cilicia; es muy significativo el introito de su respuesta a las preguntas de su amigo Atico en *ad Att.* 6,1,16: *De publicanos quid agam videris quaerere*. Entiendo muy razonable la argumentación de Peppe⁴⁸: Atico preguntaba a Cic. cómo se iba a comportar con los publicanos que sin embargo Peppe con-

44 Vid. con lit. TORRENT, *Lex rivi Hiberiensis*, desde el procedimiento formulario a la *cognitio extra ordinem*, en *Index* 41 (2013) 439 ss.

45 Cfr. X. PEREZ LOPEZ, *La delegación de la jurisdicción en Roma*, (Valencia 2013).

46 PEPPE, *Sulla giurisdizione in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone*, (Milano 1988).

47 PEPPE, *Note*, 74, a partir de la rúbrica de *Irn.* 85 plantea la duda sobre si se debería exponer todo el edicto o únicamente lo más relevante, en este caso, las reglas procesales.

48 PEPPE, *Note*, 28.

sidera que su pregunta era más exactamente cómo se iba a comportar con el *ordo equester*, que a mi modo de ver significa lo mismo dada la identificación *equites-publicani*⁴⁹. Necesariamente Cic. preocupado por desplegar una administración provincial honesta, diligente, eficiente, provechosa para los habitantes de Cilicia, tuvo que entrar en materia de *publicanis* en su διαίρεσις sobre el *genus provinciale* afectados directamente por el señalamiento de tipos de interés, factor importante en la conexión edicto provincial-*publicani*.

Se discute en la doctrina romanística si los edictos provinciales además de las reglas referentes a las *pactiones* asumidas, convenidas o impuestas a los publicanos, recogieran también íntegramente las reglas de *publicanis* de los *edicta urbana*, es decir, los instrumentos procesales ejercitables por las *soc. publ.* contra los contribuyentes. Esta segunda vía es admitida por Pugliese⁵⁰ y Peppe⁵¹, a la que se opone Maganzani⁵² que no admite este “doppio binario” que en definitiva significa protección de los privilegios procesales de los publicanos en los *edicta urbana* y en los edictos provinciales, “doppio binario” que niega para los últimos tiempos republicanos pero admite en el Principado en el sentido que al menos en algunas provincias la conclusión de las *pactiones* con los publicanos fueron trasferidas progresivamente a las *civitates* decayendo el papel estelar que hasta entonces habían tenido las *soc. publ.*, de modo que la responsabilidad por la efectividad de la recaudación tributaria, especialmente los impuestos sobre la riqueza inmueble, pasó de los publicanos a las *civitates*⁵³.

Para ir terminando este trabajo, y aunque no se trata propiamente de un *edictum provinciale*, debo recordar la *Lex portus Asiae* (también conocida como *Monumentum Ephesenum*) cuya *editio princeps* es de 1989 gracias a la diligencia de Engelmann y Knibbe⁵⁴, documento epigráfico cuyo contenido responde a una complicada gestación que parece proceder de un texto base (lin. 84) promulgado probablemente por los cónsules Lucio Octavio y Cayo Aurelio Cotta en el 75 a.C., que a su vez parece proceder de otro texto más antiguo contemporáneo a la constitución de la provincia de Asia, como es sabido de muy complicada constitución por Roma que se arrastraba desde el testamento de Atalo III de Pérgamo muerto en torno al 133 a. C. que al instituir heredero de su reino al *populus Romanus*⁵⁵ constituyó uno de los pretextos que condujeron a la oligarquía romana a asesinar

49 TORRENT, *Lex locat.*, cit.

50 PUGLIESE, *Scritti* III, 114.

51 PEPPE, *Note*, 67 nt. 180.

52 MAGANZANI, *Publicani*, 100-101.

53 Vid. LO CASCIO, *Le tecniche dell'amministrazione*, en A. SCHIAVONE (dir.), *Storia di Roma*. II. L'Impero mediterraneo. II. I principi e il mondo, (Torino 1991) 38 ss.

54 H. ENGELMANN – D. KNIBBE, *Das Zollgesetz der Provinz Asiae. Eine neue Inschrift aus Ephesus*, en *Epigraphica Anatolica* 14 (1989) con traducción al alemán y comentario. Otras ediciones las debemos a C. NICOLET, en *An. Ep.* (1989) n. 683, y W. PLEKET, en *SEG* 39 (1989) n. 1180. Add. La revisión del texto por G. D. MEROLA, *Autonomia locale e governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, (Bari 2001).

55 Liv. Per. 58: heredem autem populum Romanum reliquerat Attalus, rex Pergami, Eumenis filius; Per. 59: Aristonicus Eumenis regis filius, Asiam occupavit, cum testamentum Attali regis legato populo Romano libera esse deberet; add. Plin. El Viejo N. H. 33,148; Val. Max. 5,2,ext.3. Son tan numerosos los textos de autores del Mundo Antiguo que informan del testamento de Atalo III, que hoy parece tarea vana negar su autenticidad; el problema importante no es éste sino la capacidad jurídica del pueblo romano para ser instituido heredero, en el fondo el problema de su personalidad jurídica, que ha hecho correr ríos de tinta en la romanística. Vid. lit. en MEROLA, *Auton.*

a Tiberio Graco al atribuirle veleidades monárquicas sobre aquella región del Asia Menor, que además era una región riquísima; Cic. *pro lege Manilia* 6,14 la recuerda como la única provincia cuyos ingresos superaban los costes de su control y organización por Roma⁵⁶.

Asia fue constituida como provincia el 123 o 122 a.C.⁵⁷ (año de la *lex Sempronia Asiae*), que entre otros muchos problemas presenta la particularidad que la actuación de los *publicani* en Asia fué anterior a la presencia de la autoridad romana en la región, que para Merola⁵⁸ no era un caso único, a la vez que cree probable que los *publicani* no amenazasen (con la recaudación tributaria) a todo el territorio de Pérgamo, sino a una parte de éste en cuanto la ciudad de Pérgamo había sido declarada inmune por Atalo III, hecho que confirmaría el Senado romano en el 129 a. C. Esta sería la fecha en que los publicanos ya estarían plenamente respaldados por los sucesivos *edicta* provinciales, pero con anterioridad ya existían controversias de las *civitates* asianas con los *publicani*, es algo que se deriva del *Senatusconsultum de agro Pergameno* de ese mismo a. 129 a. C., de modo que parece evidente que los publicanos en Asia comenzaron a actuar antes de que Roma hubiese apobado su organización provincial.

Por lo que aquí interesa, todos los acontecimientos en torno a la provincia de Asia hacen discutible la fecha exacta de la *lex portus Asiae*⁵⁹ que recoge materiales desde los años 70 a. C. hasta la época neroniana, de modo que al texto original presumiblemente del 75 a. C. se fueron añadiendo a partir del § 37 nuevos temas entre el 72 (o 70) hasta el 62 a. C. en que se publicó la ley por los tres *consulares* propuestos para los *publica vectigalia*: Lucio Pisón, Ducenio Gemino y Pompeyo Paulino⁶⁰. El texto primitivo que ya había sido remanejado experimentó otra nueva sistematización alrededor del 46-44 a. C. que en consonancia con la política jurídica cesariana se dirigió a la protección de los contribuyentes obligando a exponer públicamente las *leges* de cada impuesto, algo que según Tac. *Ann.* 13,5,1 hasta ese momento habían sido inaccesibles, providencia que mucho tuvo que ayudar a lograr seguridad jurídica en las relaciones de los contribuyentes con los *publicani*. Tiene por tanto nuestro documento una historia complicada cuyos particulares han sido destacados por Engelmann/Knibbe, Spagnuolo-Vigorita y otros estudiosos atraídos por las novedades que

Locale 15 nt. 8, que además considera que se admita o se rechaze la capacidad del pueblo romano para recibir una herencia, es innegable que se trataba de testamentos difícilmente encuadrables en los esquemas civilísticos del derecho hereditario romano.

56 MEROLA, *Auton. locale* 14 nt. 5, considera hiperbólicos los términos con que se expresa Cic., pero en todo caso no duda que todos estos acontecimientos anteriores a las Guerras Mitridáticas y a la reacción conservadora silana, cambiaron el modo de explotar los territorios asiáticos, pero vid las reservas de R. M. KALLET-MARX, *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B. C.*, (Berkeley-Los Angeles-Oxford 1995) 118.

57 Pero D. MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor*, (Princeton 1950) I, 166; II, 1055.

58 MEROLA, *Auton. locale* 30-31.

59 Vid. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum et la delimitation du portorium d'Asie*, en MEFR 105 (1993) 955 ss. = I., *Censeurs et publicains dans la Rome Antique*, (Paris 2000) 382 ss.; add. T. SPAGNUOLO-VIGORITA, *Lex portus Asiae, un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, en I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica, "Atti del Congresso internaz. della Società italiana di storia del diritto", (Napoli 1997) 139 ss = Scritti scelti di diritto romano, (Napoli 2013) 254 ss.

60 Tac. *Ann.* 15,18,3.

aporta⁶¹. La *lex portus Asiae* no es propiamente un *edictum provinciale*, pero es muy útil para comprender la protección (o si se prefiere) los privilegios procesales concedidos a los publicanos contra los deudores fiscales, que si por una parte confirma las noticias de Cic. y Gayo, por otra ayuda al conocimiento de la evolución de las *pignoris capiones* y *commissa* atribuidas a los publicanos, facilitando, como dice Maganzani⁶², “risolvere i dubbi dottrinali sulle modalita del riscatto del *pignus* e sulla sorte del *pignus* non riscattato”.

Lo que interesa en este momento destacar en relación con la *lex portus Asiae*, es que los publicanos hacían negocios en la región, incluso antes de la configuración político-administrativa de Asia como provincia romana, situación documentada en el *Senatusconsultum de agro Pergameno* del 129 a. C., datación mayoritaria en la doctrina⁶³ frente a los que defienden que es del 101⁶⁴. Esta providencia ofrece importantes noticias sobre el modo de disfrute y explotación de aquel nuevo territorio anexionado a Roma, reclamaciones de las comunidades locales, actividad desplegada *in situ* por las *soc. publ.*, intervención de las autoridades romanas en la región. Precisamente este s.c. documenta el encargo del Senado a un magistrado, probablemente un *praetor urbanus*⁶⁵, para entender en una controversia entre los habitantes de Pérgamo y los *publicani*. Que Roma prestara gran atención a los conflictos entre poblaciones locales y publicanos lo demuestra el hecho que aquel magistrado contó con un *consilium senatorium* de 55 miembros⁶⁶, todos perfectamente identificados con sus nombres propios, familiares, gentilicios y tribales, de modo que el documento ha sido muy útil para los estudios prosopográficos⁶⁷ y para ir desentrañando las complicadas relaciones políticas entre Roma y el Asia postatálida que condujeron a la creación de la provincia por vía de ejecución del testamento de Atalo III, cuyas vicisitudes conocemos con bastante precisión por noticias de autores casi contemporáneos y otros posteriores que llegan hasta el s. IV d. C.

Sin duda el testamento de Atalo III dejando su reino al *populus Romanus* es un hecho importante, pero de muy compleja calificación jurídica que interesa más a los romanistas modernos que a historiadores y juristas del Mundo Antiguo, que sobre todo los historiad-

61 La lit, sobre la *lex portus Asiae* es cada vez más amplias; me remito a la citada por MAGANZANI, *Publicani* 46 nt. 132.

62 MAGANZANI, *Publicani* 47.

63 Defienden esta datación A. PASSERINI, Le iscrizioni dell'Agora di Smirne concernenti la lite tra i publicani ei Pergameni, en *Athenaeum*, 15 (1937) 261; E. V. HANSEN, The Attolids of Pergamon², (London-Ythaca 1971) 151; T. R. S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I (New York 1951) 496; II (New York 1952) 487 ss.; H. HILL, The Roman Middle Class in the republican period, (Oxford 1952) 67; G. TIBILETTI, Rome and the Acta Pergamenon: the Act of 129 B.C., en *JRS* 47 (1957) 136; L. ROSS TAYLOR, The voting districts of the Roman Republic, en *PMAAR* 20 (1966) 170; NICOLET, L'ordre équestre a l'époque republicaine, I (Paris 1966) 348-350; BADIAN, *Publicans* 132 nt. 42; R. K. SHERK, Roman Documents of the Greek East, (Baltimore 1969) 63 ss.; MEROLA, *Aut. locale* 30 ss.

64 MAGIE, *Roman Rule* I, 166; II, 1055; H. B. MATTINGLY, The date of the *Senatus Consultum de agro Pergameno*, en *AJPh* (1972) 412 ss.; DE MARTINO, Il *Senatusconsulto de agro Pergameno*, en *PP* 210 (1983) 161 ss.; KALLET-MARX, *Hegemony* 118.

65 SHERK, *Roman Doc.* 68; Id. The text of the *Senatus Consultum de agro Pergameno*, en *GRBS* 7 (1966) 361.

66 De este s.c. conocemos varias copias, y en la de Hadrameto sólo aparecen 33 nombres.

67 Vid G. DI STEFANO, Una nuova edizione del *Senatus Consultum de agro Pergameno*, en *RAL* (1998) 707 ss.

ores despreocupados de cuestiones dogmáticas utilizan diversos términos (*donare, legare, relinquere, hereditas*) que si tienen un significado mas preciso entre los juristas⁶⁸, parece demasiado pretencioso atribuir un conocimiento suficiente de las categorías romanas (además muchas aún *in fieri* en época atálida⁶⁹) a un rey helenístico, desde luego culto, oriental, que disponía de su reino como *res privata*, pero que en ningún momento había pensado en redactar su testamento con categorías jurídicas romanas. En este sentido me parece acertada la interpretación de Hopp⁷⁰ que considera redactado el testamento de Atalo según formulaciones helenísticas.

En esta sede no puedo profundizar más en estos temas, pero algo debo decir por modo de situar la actuación de las *soc. publ.* que en medio de los acontecimientos atálidos supieron hacer negocios provechosos en territorios aún no formalmente romanos, lo que hace pensar en una ancha libertad comercial a finales del s. II a. C. Tampoco voy a entrar en el discutidísimo tema de la capacidad sucesoria del *populus Romanus* y su aptitud para aceptar herencias, problema que me siguen pareciendo convincentes los argumentos en su día expuestos por Volterra⁷¹, ni en el no menos discutido problema de la personalidad jurídica, en definitiva problemas de calificación dogmática que estaban ausentes en la especulación de los juristas, y mucho menos de los historiadores que trataban la compleja época atálida. Acertadamente dice Merola⁷² “in realtà la necessità di inserire nel sistema giuridico romano atti di questo genere, e ancora di più la discussione sulla possibilità o meno per il popolo romano di ereditare, sono problemi esclusivamente moderni, che le fonti antiche non si pongono affatto”.

68 Desde un plano que pretende ser omnicompreensivo, Th. LIEBMANN-FRANKFORT, *Valeur juridique et signification politique des testaments faits par les rois hélénitiques en faveur des Romains*, en RIDA 13 81966) 73-94, divide en dos categorías las fuentes que hablan de testamentos de los reyes helenísticos a favor de Roma; en la primera categoría que corresponden a los autores a partir del Principado, entraban los que instituían heredero al *populus Romanus*; en la segunda, que corresponde a los autores mas antiguos y que la A. considera la más auténtica, se mencionan beneficios *mortis causa* a favor de los romanos, pero no hay propiamente *heredis institutio* a favor del *populus Romanus*, lo que entiendo puede interpretarse del siguiente modo: los autores republicanos se movían sin grandes preocupaciones formales, mientras que los de época imperial estaban más apegados a las instituciones jurídicas. En definitiva en gran medida el derecho no es e otra cosa que forma, y la historia del derecho no es otra cosa que historia de la dogmática jurídica.

69 Aún no había escrito Q-Mucio sus XVIII *libri iuris civilis*, aunque Atalo sea casi contemporáneo de aquellos juristas del s. II a. C. que al decir de Pomponio *fundaverunt ius civile*.

70 J. HOPP, Untersuchungen zur Geschichte der letzten Attaliden, (München 1977) 126-127.

71 VOLTERRA, Sulla capacità del *populus Romanus* di essere istituito erede, en Studi Mancaloni, (Sassari 1938) 203 ss. Cfr. F. GUIZZI, Miti e politica nella capacità successoria del *populus Romanus*, en Labeo 8 (1962) 169 ss.; M. LEMOSSE, A propos des royaumes légues au peuple romain, en Synteleia Arangio-Ruiz, I (Napoli 1964) 284-285.

72 MEROLA, Auton. locale 15.

SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA OBLIGACIÓN DEL BANQUERO RESPECTO A LA DEL DEUDOR (A PROPÓSITO DE D. 13, 5, 27 ULPIANUS LIBRO 14 AD EDICTUM)

ANA ALEMÁN MONTERREAL
Universidad de Almería

El punto de partida de este trabajo viene condicionado por un discutido fragmento de Ulpiano recogido en D. 13, 5, 27. El texto dice así:

“Utrum praesente debitore an absente constituat quis, parvi refert. Hoc amplius etiam invito constituere eum posse Pomponius libro trigensimo quarto scribit: unde falsam putat opinionem Labeonis existimantis, si, postquam quis constituit pro alio, dominus ei denuntiet ne solvat, in factum exceptionem dandam: nec immerito Pomponius: nam cum semel sit obligatus qui constituit, factum debitoris non debet eum excusare”.

La doctrina ha sostenido unánimemente que el fragmento ulpiano originariamente se refería al *receptum argentarii*. Los compiladores justinianos habrían sustituido el verbo *recipere* por su homólogo *constituere*¹.

Partiendo de esta premisa, y en consecuencia, aceptando la manipulación del fragmento, pasemos a comentar las palabras de Ulpiano. El fragmento no tiene desperdicio.

Ulpiano admite, siguiendo el parecer de Pomponio, la validez del *receptum absente et invito debitore*, y afirma que una vez surgida la obligación, el banquero no puede liberarse del vínculo obligacional, ni siquiera por el hecho de que su cliente le notifique que no pague. Estas afirmaciones, sin duda, apuntan a sostener una amplia autonomía de las obliga-

1 LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Roma 2000, pp. 490 ss.; “Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare. De maioris partis tribonorum sententiae aut eb eo, cuius de ea re iurisdicatio fuit, ea tutela curatiove data erit”, ZSS 2 (1881) pp. 62 ss.; *Das edictum perpetuum*, Leipzig 1927, pp. 130 ss.. Incluye el fragmento recogido en D. 13, 5, 27 dentro del grupo de textos que originariamente se referían al *receptum*. ROSELLO, “*Receptum argentarium*”, AG (1890) pp. 7ss.; FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano*. V. I, *Le garanzie personali*, Padova 1962, pp. 275 y ss.; ANDREAU, *Le vie financière dans le monde romain. Le métiers de manieurs d’argent (IV siècle av. J.C. – III siècle ap. J.C.)*, Roma 1987, pp. 599 ss., y p. 695; PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull’impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - metà del III secolo d. C.)*, Napoli 1991, p. 200; “Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a. C.” *Ius Antiquum* III (XXVIII), Moscovie 2013, p. 49; FASOLINO, “Sulle tecniche negoziali bancarie: Il *receptum argentarii*”, *Labeo* 46 (2000) 2, p. 174; “Garanzie autonome e attività bancaria”, *Studi Senesi* 1 (2001) pp. 11 ss.; RODRÍGUEZ GÓNZALEZ, *El receptum argentarii en el derecho romano clásico. Una propuesta de análisis*, Madrid 2004, pp. 36 ss., resumiendo acertadamente el trabajo palingenésico de Lenel.

ciones existentes; una, la efectiva entre el cliente deudor y el banquero, y otra, la nacida mediante el *receptum* entre el banquero y el acreedor de su cliente.

Esta proclamada independencia se desvirtúa cuando Ulpiano disiente de la opinión de Labeón, quien admite la concesión de una *exceptio in factum* a favor del banquero en el supuesto en que el deudor, con posterioridad al *receptum*, le hubiese ordenado que no pagara. Esta *exceptio* ante la reclamación del acreedor, no sólo contrapone el parecer de Labeón al de Ulpiano y Pomponio, sino que, además, y sobre todo, cuestiona dicha independencia, al menos, con anterioridad a la época de estos juristas.

I. En puridad, el fragmento de Ulpiano recogido en D. 13, 5, 27 ha sido uno de los textos que mayores problemas interpretativos ha generado en la doctrina.

Frezza, ya señalaba que la lectura del fragmento resultaba de gran utilidad para aclarar numerosos aspectos del *receptum argentarii*. El texto, dice Frezza, muestra claramente la estructura del negocio y sus funciones. El *argentarius* interviene en un negocio obligatorio existente entre dos sujetos, en el que uno o ambos son sus clientes, con la finalidad de garantizar al acreedor el cumplimiento de la obligación del deudor, es decir, el pago. La responsabilidad del *argentarius* surge en el momento en que el deudor le ordena el pago (*mandatum, iussum*), aunque, ciertamente, el texto demuestra que el *argentarius* puede asumir la responsabilidad *ex recepto* sin la voluntad e incluso contra la voluntad del deudor; e igualmente, demuestra que esta responsabilidad nace desde que el acreedor acepta la declaración del banquero².

Según Frezza la independencia del *receptum* de la obligación del deudor se evidencia del fragmento ulpiano. La jurisprudencia de la época de Adriano, a la que pertenece Pomponio, seguida por la de los Severos -Ulpiano- no concedía al banquero una *exceptio in factum* contra la acción del acreedor en el caso de que el deudor, posteriormente al *receptum*, le hubiese ordenado al banquero que no pagase. La *exceptio in factum* concedida por Labeón manifiesta que la independencia de la obligación del *receptum* se había desarrollado desde la época de Augusto a la de Adriano, probablemente, como exigencia del mundo de los negocios, requiriendo de un negocio ágil y rápido cuya protección se realizara separando la relación entre el banquero y el acreedor de aquella existente entre el banquero y el deudor³.

Y es que el *receptum argentarii* nace y se desarrolla en la práctica negocial, en la que el movimiento de dinero es atribuido a los bancos, los que se encargan de realizar pagos concretos de sus clientes o de administrar toda su hacienda, cobrar y pagar por su cuenta, e incluso, sin su conocimiento.

Partsch sostenía que la *exceptio in factum* concedida por Labeón al banquero era debida a que este pagaba en el *receptum* como un representante de su cliente, como un administrador de su patrimonio. Probablemente, la dificultad de discutir en juicio circunstancias relacionadas con el deudor, con amplia posibilidad de ser desconocidas por el *argentarius*, provocó que los juristas fueran desvinculando el *receptum* de la relación existente entre el deudor y el banquero, y por consiguiente, negando la posibilidad de que el *argentarius* pud-

2 FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni cit., pp. 276 ss..

3 FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni cit., p. 280.

iese interponer las excepciones del deudor; esta transformación justificaría, según Partsch, el diferente posicionamiento entre Labeón y Pomponio⁴. Demasiado atrevida la suposición de Partsch al considerar este hecho como determinante de la independencia obligacional y justificativa del diferente posicionamiento jurisprudencial.

Este fragmento ha sido objeto de un profundo y reiterado estudio por Petrucci. Partiendo de la referencia originaria de D. 13, 5, 27 al *receptum argentarii*, señala como Ulpiano sigue el parecer de Pomponio, según el cual el negocio puede concluirse contra la voluntad del deudor. Parecer que difiere del sostenido por Labeón, ya que en el caso de la declaración del *dominus ne solvat*, sucesiva al *receptum*, concede una *exceptio in factum*. Ulpiano se adhiere a la solución de Pomponio observando que una vez que surge la obligación del *receptum*, el hecho del deudor no *excusat* la obligación asumida por el banquero. Según Petrucci, la divergencia entre los juristas concierne en sustancia al carácter vinculante del *receptum* concluido contra la voluntad del deudor, pasando de una posición de menor rigidez del vínculo –Labeón– a aquella de extrema rigidez expresada por Pomponio y Ulpiano⁵.

Del estudio pormenorizado del fragmento extrae las siguientes conclusiones: Primero, en tiempo de Labeón (finales del siglo I a. de C. inicios del siglo I d. de C.) el *receptum* se presentaba como un negocio mediante el cual el banquero se obligaba *pro alio* –el cliente–, eventualmente también en su ausencia (*absente* deudor), a pagar un débito, asumiendo directamente el vínculo obligatorio con el acreedor. Segundo, de la utilización de la expresión *dominus* se deduce que en origen el deudor-cliente encarga mediante mandato al banquero el pago de su deuda, o bien, que tal encargo se lleva a cabo mediante una gestión de negocios. Tercero, si el deudor en un momento sucesivo a la conclusión del negocio de garantía intimaba al banquero de no cumplir, el banquero podía utilizar una *exceptio in factum* contra el acreedor que le requería en juicio el cumplimiento. Y cuarto, a partir del inicio del siglo II d. de C. el negocio concluido con el banquero era válido incluso contra la voluntad del deudor (*invito debitore*)⁶.

Esta transformación supone que no se requiera necesariamente de una relación de mandato o gestión de negocios, e igualmente, conlleva la imposibilidad de que el banquero pudiese utilizar una *exceptio* o cualquier hecho del deudor para liberarse de su responsabilidad respecto al acreedor. El *argentarius* no puede, por tanto, oponer al acreedor las excepciones relativas a la esfera del deudor; bien aquellas concernientes a la obligación, como su inexistencia o invalidez, bien aquellas, que atañen a las relaciones internas entre el deudor y el banquero.

Probablemente en época de Labeón se requería un encargo del cliente al *argentarius*, para que éste mediante un *receptum* saldase su deuda con un tercero. Lo que hace difícil aceptar que el negocio se pudiese concluir contra la voluntad del deudor. Pero, ciertamente, las dos relaciones negociales operan sobre planos diversos. Una, se refiere al encargo que el cliente da al *argentarius* de realizar el negocio, sin relación alguna con la cuenta del

4 PARTSCH, “Der ediktale Garantievertrag durch *receptum*”, ZSS 29 (1908) p. 414.

5 PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana cit.*, pp. 196 ss.; “Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a. C.”, cit., pp. 51 ss..

6 PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana cit.*, pp. 201 ss.; Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a. C.” cit., p. 53.

cliente; otra, que incide directamente sobre la cuenta del cliente, ya que el *argentarius* retira la suma que paga al acreedor de su cuenta, o bien, viene a instituir una nueva cuenta concediéndole un crédito, realizándose en este caso una operación análoga a la moderna apertura de crédito⁷.

El testimonio de este fragmento demuestra la existencia de esta forma de garantía ya en el siglo I a. de C., e igualmente, manifiesta la progresiva consolidación de dos características fundamentales del *receptum*. Una, en relación a la modalidad de conclusión: mandato del cliente o gestión de negocios ajenos; otra, la autonomía de la obligación accesoria del banquero respecto a la principal del cliente deudor, según la regla de que el garante no debe obligarse de modo más gravoso *in duriorem causa*⁸.

El *receptum argentarii*, a pesar de sus peculiaridades normativas se fija en el primer siglo del Principado, representando en cuanto negocio de derecho profesional reservado sólo a los banqueros una forma de garantía particularmente segura para los acreedores, desde el momento en que se configura como un servicio de casa a favor de los clientes procediendo a sus pagos; es evidente que esta modalidad de garantía favorecía la circulación monetaria y los tráficos comerciales⁹.

Como ha sostenido Fasolino se trata de un fragmento de densa información sobre varios aspectos del *receptum*. Uno, relativo a la modalidad de perfeccionamiento; otro, referente a la autonomía entre las dos obligaciones. El razonamiento seguido por Ulpiano, dice Fasolino, es el siguiente: la conclusión del contrato no necesita en absoluto la presencia del deudor, incluso, declara su validez contra su voluntad (*invito*), por lo que declara que tiene razón Pomponio al considerar errónea la opinión de Labeón, según la cual el banquero que sucesivamente a la conclusión del *receptum* recibe orden de no pagar (*dominus ei denuntiet ne solvat*) se le debe conceder una *exceptio in factum*, por lo que el hecho del deudor no puede ser aducido por el *argentarius* como causa que excuse el cumplimiento de su obligación contraída mediante el *receptum*¹⁰.

La afirmación final manifestada por Ulpiano sobre la oposición del deudor a la ejecución del *receptum*, después de su perfeccionamiento, constituye el punto principal para individualizar la independencia de la obligación que nace del *receptum*. En efecto, hablando de *factum debitoris* Ulpiano deja entender que eran inoponibles todas aquellas excepciones pertenecientes a la esfera del deudor, y por tanto, las relaciones existentes entre ambas obligaciones.

7 PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana* cit., p. 202. En el mismo sentido, ANDREAU, *Le vie financière dans le monde romain* cit., pp. 600 ss.. HUVELIN, *Cours élémentaire de droit romain. Le obligations*, Paris 1929, pp. 111 ss., sostenía que el objeto del *receptum* fuese originariamente una deuda futura del cliente, siguiendo a BEKKER, "Recipere und permutare bei Cicero", ZSS 3 (1882) pp. 8 ss..

8 PETRUCCI, "Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a. C." cit., p. 53; *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana* cit., p. 179.

9 PETRUCCI, "Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a. C." cit., p. 53. Sobre el tema, véase del mismo autor, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione dell'banche romane*, Torino 2002, pp. 59 ss.. Vid., además, MANNA, *Degli argentarii in diritto romano*, Lanciano 1886; ROSELLO, *Argentarii. Studio di diritto commerciale romano*, Lanciano 1891; FADDA, *Istituti commerciali del diritto romano. Gli argentarii ed il commercio bancario*, Napoli 1903.

10 FASOLINO, "Sulle tecniche negoziali bancarie: Il *receptum argentarii*" cit., pp. 178 ss. "Garanzie autonome e attività bancaria nel diritto romano: alcune considerazioni" cit., pp. 20 ss..

Y es que, el banquero no puede oponer al acreedor la invalidez o ineficacia de la obligación contraída con su cliente, ni siquiera puede oponer aquellas que alteran el correcto desarrollo del negocio asumido, como es el caso que el cliente *denuntiare* al banquero *ne solvat* al acreedor (*exceptio mercis non traditae o non numeratae pecuniae*). Lo mismo acontece en el ámbito de las relaciones internas entre el banquero y el deudor, generalmente asumidas mediante mandato o *negotiorum gestio*, de las que no resultan oponibles excepciones contra el acreedor. El banquero solo podría oponer al acreedor aquellas causas de invalidez o inexigibilidad referentes a su obligación nacida *ex recepto*, en consecuencia, salvo estas excepciones el banquero debe cumplir en cualquier caso con su obligación de garantía, y ello con independencia de que posteriormente, y tratándose de un *indebitum*, el deudor pueda dirigirse contra el acreedor y recuperar lo indebidamente percibido¹¹.

Considera Magdelain que la hipótesis de un *receptum* concluido sin o contra la voluntad del deudor son supuestos teóricos simplemente utilizados con la finalidad de presentar la amplia autonomía que existe entre las dos obligaciones¹².

Autonomía de la obligación del banquero que ya fue sostenida por Rosello cuando afirmaba que el banquero normalmente se obligaba mediante el *receptum* ante la orden de pago del deudor, sin embargo, ni la existencia del crédito ni la delegación de pago eran elementos indispensables del contrato; el banquero venía obligado únicamente porque había prometido, y una vez perfeccionado el contrato se excluía cualquier consideración sobre otras relaciones entre las personas interesadas, porque tratándose de un medio para agilizar los pagos había que eliminar cualquier obstáculo que retrasase el cumplimiento. La promesa del banquero por sí sola generaba obligación, dicha obligación sería absolutamente abstracta con la finalidad de agilizar el tráfico. Y es, precisamente, según Talamanca, el carácter abstracto de la obligación asumida por el banquero, el motivo por el que éste queda obligado aunque la deuda del cliente no existiera o resultara ineficaz¹³.

Esta independencia existente entre las dos obligaciones constituye precisamente la grave responsabilidad del *argentarius* con la conclusión de un *receptum*. Por este motivo, Fasolino justifica la concesión de la *exceptio in factum* a la que alude Labeón, de forma análoga al criterio manifestado por el jurista a la responsabilidad absoluta que nace del *receptum nautarum*, respecto a la cual introduce una *exceptio in factum* en las hipótesis de *naufragium* y de *vis piratarum* (D. 4, 9, 3, 1 *in fine*), o a la *cautio de damni infecti* excluyendo la responsabilidad por causa de fuerza mayor (D.39, 2, 24, 3-4).

Ulpiano y Pomponio, acogen la tesis de Labeón para los *recepta nautarum*, e incluso, extienden la eficacia de la *vis maior* a los *caupones* y a los *stabularii*, sin embargo no admiten la opinión del jurista augusteo en lo concerniente al *receptum*, y ello, probablemente por razones de funcionalidad, es decir, la solución más rigurosa respecto al *receptum argentarii*, esa amplitud y rigurosidad de la responsabilidad del banquero por deudas de otros, se debe a que el *receptum* representa un instrumento esencial para la finalidad del negocio¹⁴.

11 FASOLINO, "Sulle tecniche negoziali bancarie: Il *receptum argentarii*" cit., p. 179; "Garanzie autonome e attività bancaria nel diritto romano" cit., pp. 21 ss..

12 MAGDELAIN, *Le consensualisme dans l'édit du prêteur*, Paris 1958, pp. 152 ss..

13 ROSELLO, "*Receptum argentariorum*" cit., p. 4; TALAMANCA, "*Argentarii*", *NNDI* 8 (1978) p. 941.

14 FASOLINO, "Sulle tecniche negoziali bancarie: Il *receptum argentarii*" cit., p. 179.

La opinión de Pomponio seguida por Ulpiano de que no es necesario un encargo conferido por el deudor al banquero, pudiendo incluso concluirse un *receptum invito debitore*, evidencia la completa y total autonomía entre la obligación del garante y la del deudor. Esta independencia de las obligaciones se deduce, sin duda, del fragmento, pero también se confirma en dos fragmentos gaianos del libro V del comentario al *edictum*; en uno, D. 46, 1, 30 se dice que es válida la *fideiussio* aunque el deudor no tenga conocimiento, en el otro, D. 46, 3, 53 se admite la posibilidad de *solvere pro ignorante et pro invito* porque, explica el jurista, no está prohibido *etiam invitique et ignorantis meliorem condicionem facere*¹⁵.

En este sentido, señala Rodríguez González que, aunque la mayoría de los textos se decantan por el carácter accesorio entre la obligación principal y la garantizada, se muestran diversas excepciones a esta regla, las que prioritariamente afectan a distintos supuestos en función de los intereses en juego en cada caso concreto, señalando, entre ellos, la protección especial de los derechos del acreedor, la conservación de los actos realizados, o la seguridad jurídica¹⁶.

Ciertamente, esta independencia de las obligaciones asegura al acreedor la realización de su crédito, ya que el banquero garante no puede interponer ninguna excepción que eventualmente hubiera podido utilizar el deudor principal, y además, ni que decir tiene que la ventajosa situación económica del banquero aseguraba ampliamente el cumplimiento de dicha obligación¹⁷. Esta característica, probablemente, sirvió para convertir el *receptum* en un instrumento extremadamente funcional a las exigencias comerciales y que facilitaba las relaciones de cambio.

Rodríguez González intenta justificar el fragmento de Ulpiano en función de cual fuere la relación existente entre el banquero con su cliente-deudor. En principio, se plantea la existencia de un mandato, llegando a la conclusión, de que ni siquiera en el supuesto de su revocación, tendría sentido la discusión jurisprudencial; así que procede a un estudio pormenorizado de la obligación *ex recepto* y la *fideiussio*. Decantándose por esta modalidad de garantía, establece posibles interpretaciones del texto.

De un lado, partiendo de una probable identificación del *factum debitoris* del fragmento con la retirada de una cantidad previamente consignada por el deudor, entiende que Labeón protegiendo al *argentarius* limita su responsabilidad al tiempo en que el depósito estuviera en su poder; solución que, sin saber por qué motivo, no es aceptada por Pomponio y la jurisprudencia posterior. No obstante, continúa la autora, “puede ser que estos últimos juristas opinaran que, incluso en las situaciones en las que el deudor consignante retirara de la *mensa* del *argentarius* la cantidad debida, el banquero recipiente debía igualmente hacer frente al pago. Pero, más probable es que las circunstancias en que se acordaba el negocio fueran distintas en uno y otro momento histórico”. En cualquier caso, parece quedar convencida de una evolución en el *receptum argentarii*, en principio realizado taxativamente sobre un depósito del cliente, y que con posterioridad se desvincula del mismo, en consecuencia

15 FASOLINO, “Sulle tecniche negoziali bancarie: Il *receptum argentarii*” cit., p. 181.

16 RODRÍGUEZ GÓNZALEZ, *El receptum argentarii en el derecho romano clásico* cit., p. 119. A título de ejemplo, señala no pocos fragmentos que confirman esta excepción, entre otros: D. 12, 2, 42pr; D. 4, 8, 35; D. 16, 3, 1, 14; D. 46, 1, 2; D. 46, 3, 95, 4; D. 46, 1, 25; D. 46, 1, 29.

17 FASOLINO, “Garanzie autonome e attività bancaria nel diritto romano” cit., p. 9.

sólo requiere la detracción de cierta cantidad de la cuenta que mantiene con el banquero; de aquí que, la jurisprudencia vaya aumentando el grado de responsabilidad del banquero a medida que el *receptum* se independiza del depósito efectivamente realizado¹⁸.

Ciertamente, no creemos que la causa de esta autonomía de la obligación del banquero con el acreedor dependa exclusivamente de la relación existente entre el banquero y el deudor. Probablemente fuese un mandato o una gestión de negocios, pero aún en el caso de cualquier relación de garantía es posible hablar de accesoriedad exclusivamente en el sentido de adhesión a la obligación principal, sin que exista un criterio unívoco respecto a la disciplina de las relaciones e interrelaciones entre las dos obligaciones, cuyas soluciones diversas no dependen del carácter accesorio de la relación de garantía en cuanto tal, como confirman numerosas fuentes al respecto¹⁹.

En definitiva, la autonomía o independencia de la obligación que el banquero asume con el acreedor de su cliente es una realidad constatada en época de Pomponio y Ulpiano, como se deduce de las siguientes afirmaciones ulpianaeas: una, el *receptum* puede constituirse en ausencia del deudor, e incluso, contra su voluntad; otra, el banquero no puede interponer excepciones del deudor, ni siquiera en el supuesto de la notificación de no pagar; y finalmente, la afirmación declarada *in fine* de D. 13, 5, 27 afirmando *nam cum semel sit obligatus qui constituit, factum debitoris non debet eum excusare*, es decir, una vez concluido el *receptum* el banquero se ve obligado al pago sin que pueda excusarle del cumplimiento ningún *factum debitoris*.

Ahora bien, la posibilidad reconocida por Labeón de que el banquero pudiese interponer una *exceptio in factum* ante la reclamación del pago por el acreedor, en el supuesto de que el deudor le hubiese intimado a no pagar la deuda, cualquiera que fuera la causa, así como la probable imposibilidad de celebrar un *receptum* contra la voluntad del deudor, denotan, cuando menos, un vínculo jurídico reconocido entre ambas obligaciones²⁰. La posibilidad de interponer esta *exceptio* y el improbable *receptum invito debitore* no significa que no existiese cierta independencia, pero desde luego lo que es seguro que no con la amplitud sostenida por Pomponio y posteriormente por Ulpiano; lo que este último confirma, insistimos, negando la posibilidad de interponer dicha *exceptio*, afirmando taxativamente el *receptum invito debitore*, y adhiriéndose plenamente al parecer de Pomponio cuando afirmaba: “el que constituyó plazo para pagar no puede liberarle ya el hecho del deudor principal”.

Probablemente, las necesidades del tráfico comercial bancario obligaron a aumentar la independencia del *receptum* hasta el límite de no ser oponible al acreedor ni siquiera el *ne solvat* del deudor al banquero, adquiriendo, de este modo, el *receptum* un grado de abstracción idóneo que agilizaba y aseguraba las exigencias comerciales.

18 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El *receptum argentarii* en el derecho romano clásico cit., pp. 207 ss..

19 Por ejemplo, D. 12, 6, 47; D. 17, 1, 29; D. 46, 1, 15 pr.; D. 46, 1, 49pr.; D. 36, 4, 1. FASOLINO, “Garanzie autonome e attività bancaria nel diritto romano” cit., p. 18. Vid., por todos, FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni* cit., pp. 4 ss. y pp. 35 ss...

20 Una distinción de esta independencia en el ámbito económico y jurídico fue sostenida por WENGER, “*Receptum argentarii*”, PW col. 372-373, negándola en el primero y afirmándola en el segundo.

II. Pero, veamos que ocurre con posterioridad a esta época. Como podemos apreciar en C. 4, 18, 2 pr., *in fine*, se excluye categóricamente una de las características del *receptum*, y ésta es precisamente, la independencia de la obligación asumida por el banquero respecto a la obligación existente con el deudor. El *receptum* obligaba al banquero a pagar incluso en los supuestos de inexistencia del *debitum* garantizado, Justiniano considera este aspecto absurdo e injusto siendo contrario al espíritu de su tiempo y de las leyes. Según el emperador, es justamente eliminando esta autonomía la forma de evitar un mecanismo perverso de *condictiones*, y de este modo, reconstruir el equilibrio alterado por el pago de sumas o cosas *indebitae*:

“...sed sit pecuniae constitutae actio per nostram constitutionem sibi in omnia sufficiens, ita tamen, ut hoc ei inhaereat, ut pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur et si quid non fuerat debitum), cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permittere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas proponere condictiones, quae et pecunias indebitas et promissiones corrumpi et restitui definiunt”.

No parece existir duda de que en esta época se pretende impedir la independencia de la obligación de garantía del banquero respecto a la del deudor principal. Prohibición que, como apreciamos, se reitera dos veces en el fragmento negando dicha autonomía al *constitutum*. Lo que, por lo demás, confirma la autonomía entre las obligaciones banquero-acreedor y banquero-deudor con anterioridad al derecho justiniano, ya que no tendría sentido alguno esta insistente prohibición si no la hubiese.

Pero, ¿realmente desaparece esta autonomía? El primer motivo de duda se presenta en el apartado 2 de dicha constitución, que dice:

“*His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus*”.

Vemos que el emperador considera válidos aquellos negocios que los banqueros (a los que denomina *argentii distractores*) y otros comerciantes (*negotiatores*²¹) hubiesen concluido con arreglo a los principios precedentes sin posibilidad de poder valerse de *exceptiones*.

Según Rosello este fragmento es una disposición transitoria, en cuya virtud se permitía a los *recepta* (*indefense*) de *argentarii* y *negotiatores*, que se habían constituido legalmente con anterioridad a esta fecha, se rigiesen por las leyes anteriores. No se trata, dice Rosello, de una disposición inútil porque abolida la *actio recepticia* el banquero citado en juicio con la nueva *actio de constitutum* podría oponer la excepción de *non debitum*, y de este modo, un *receptum* válidamente perfeccionado quedaría sin validez y el acreedor dañado. El término *indefense* presenta el sentido, ya manifestado por Dirksen y Bekker, de *citra*

21 Según LA ROSA, “La pressione degli *argentarii*” cit., p. 448, este término indicaría a aquellos sujetos que ejercen una actividad en el campo financiero. Sobre el tema, CERAMI, DI PORTO, PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2004, p. 33.

prohibitionem, es decir, en las formas legales²². Se opone abiertamente a quienes afirman que con este apartado Justiniano permitía a los *argentarii* y otros negociantes obligarse en términos paritarios al antiguo *receptum*²³.

Para Frezza, *indefense* significa renunciar a la defensa de *exceptio* en caso de inexistencia de la obligación del deudor²⁴, por lo que Justiniano mantiene la posibilidad de un *constitutum* abstracto si ha sido expresamente pactado, limitando, por lo demás, el ámbito de este negocio a la esfera de los asuntos bancarios. Justiniano, como se aprecia, mantiene la norma clásica de la abstracción presunta del *receptum*. Como se ve, dice Frezza, la reforma es modesta ya que deja vivo un negocio que con el nombre de *constitutum* mantiene el carácter y la disciplina del abstracto *receptum*²⁵.

En este sentido, la doctrina más antigua ya había sostenido que el fragmento 2 de C. 4, 18, 2 no contenía una disposición de carácter transitorio sino, por el contrario, se trataba de una norma excepcional dirigida a conservar el derecho especial de los *argentarii* y de otros *negotiatores*. Y es que, el emperador, no obstante su condena a los vínculos obligatorios abstractos, la exigencia de seguridad y de certeza en determinadas relaciones de tráfico mercantil y bancario, le obligaba a admitir un régimen más riguroso, a pesar de las consecuencias que del mismo se pudieran derivar. En contra, Astuti y Archi considerando el apartado 2, al igual que Rosello, una norma transitoria aplicable a los *constituta* ya celebrados²⁶.

Fasolino, siguiendo la tesis iniciada por Díaz-Bautista y continuada por La Rosa²⁷, considera altamente plausible que Justiniano tras haber abolido el *receptum* por los graves inconvenientes que generaba su carácter abstracto, introdujese la modificación final a su constitución del 531, salvando la posibilidad, limitadamente a banqueros y negociantes, de continuar prestando *indefense* garantías. En la práctica bancaria y comercial bizantina existían formas de garantía *pro alio* de las que nacía una amplísima responsabilidad del garante, como es el caso de las ἀντιφωνήσεις. La realidad del tráfico comercial exigía, por tanto, esquemas contractuales de garantía absoluta, concluidos *indefense*. En este sentido, la exigencia de la práctica comercial ha demostrado históricamente la gran utilidad de instrumentos de garantía en los que el requisito de la accesoriedad se encuentre mermado, o

22 ROSELLO, “*Receptum argentariorum*” cit., pp. 59 ss..

23 ROSELLO, “*Receptum argentariorum*” cit., pp. 57 ss.. En este sentido, señala Rosello a KRAUT, *De Argentariis et nummularis commentatio*, Göttingen 1826, p. 114 y a IHERING, *Le Esprit du droit romain: dans le diverses phases de son développement*, IV, 1880, p. 210, admitiendo este último la exclusión de la actio recepticia para el comercio ordinario y su mantenimiento para banqueros y negociantes.

24 Según la interpretación dada por CUIACIUS, *Opera* X, Napoli 1758, p. 635: *ut nulla exceptione se tueri possint*.

25 FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni* cit., p. 284.

26 ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito* II, Milano 1941, pp. 301 ss.; ARCHI, “Contributi alla critica del *corpus juris*, II. Riforme giustiniane in tema di garanzie personali”, *BIDR* 65 (1962) p. 140.

27 DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia 1987, pp. 168 ss.; “Les garanties bancaires dans la législation de Justinien”, *RIDA* 29 (1982) pp. 165 ss., y pp. 187 ss.; “La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del *constitutum debiti* (C.4, 18, 2, 2)”, *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, Napoli 1997, pp. 445 ss..

incluso, totalmente eliminado; en el ámbito bancario puede afirmarse la necesidad de figuras de garantía autónoma, ya que la seguridad del acreedor requería de mecanismos jurídicos conjugados con la plena solvencia del garante²⁸.

En esta línea, dice Petrucci, que con esta disposición el emperador no pretende establecer una disciplina transitoria para conservar los pactos establecidos previamente, sino que, antes bien, pretende mantener la posibilidad de que banqueros y comerciantes puedan seguir realizando negocios con los acreedores de sus clientes según la práctica habitualmente establecida hasta esta fecha *secundum morem usque adhuc obtinentem*, o sea, creando un vínculo jurídico de garantía absoluta que venía privado de la defensa de eventuales excepciones oponibles de los clientes. Esta realidad confirma que habiéndose abolido el *receptum* por los problemas que planteaba la independencia de obligaciones, tanto los *argentii distractores* como los *negotiationes* quedaban autorizados a realizar en la práctica formas de garantía *indefense*²⁹.

Probablemente, esta disposición se dictase con carácter transitorio, pero es difícil determinar hasta qué punto se convirtió en una posibilidad de continuar prestando *indefense* garantías en el ámbito bancario. Lo cierto es que, fuese norma transitoria o excepcional, la independencia de esta obligación se mantiene en otros negocios como la ἀντιφώνησις.

En efecto, esta autonomía entre las obligaciones se constata en las καθαροὶ ἀντιφωνήσεις del Edicto 9 de Justiniano, configurada como un modo de financiación indirecta del banquero al cliente y que cumplía una función de garantía abstracta y absoluta, ya que permitía al acreedor dirigirse directamente contra el garante llegado el momento del cumplimiento, sin probar la causa del crédito y sin posibilidad para el banquero de utilizar eventuales excepciones oponibles por el cliente deudor.

Y es que, como decía Díaz Bautista esta promesa era pura, es decir abstracta, y por tanto, separada de la obligación del deudor principal que le servía de causa. El ἀντιφωνητής no era un garante accesorio, un deudor añadido como el *fideiussor* romano, a quien se le transmitía las excepciones del deudor principal, sino un garante independiente como había sido siempre el ἐγγυητής en la tradición griega y como el banquero romano que había aceptado un *receptum*. Pero esta independencia del banquero χαναρὸς ἀντιφωνητής era más acusada aún que la del simple ἐγγυητής, puesto que éste sólo debía pagar si la persona por la que se había prestado la garantía no observaba la conducta prevista, mientras que el banquero estaba obligado en virtud de la ἀντιφωνητής a pagar una deuda que no era exi-

28 FASOLINO, “Garanzie autonome e attività bancaria” cit., pp. 30 ss.; “Sulle tecniche negoziali bancarie” cit., pp. 183 ss.. La Novela establece en el prefacio: “*Legem antiquam positam quidem olim, usu vero, nescimus quemadmodum, non approbatam, per causas autem semper exquisitas atque necessarias apparentem, rursus revocare et ad rempublicam reducere bene se habere putavimus, non simpliciter eam, sicut iacebat, ponentes (erat enim quaedam ei pars omnino non discreta), sed cum competenti et deo placito distribuentes augmento*”. Y continúa en el capítulo I: “*Si quis igitur crediderit et fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem acceperit, is non primum mox adversus mandatorem aut fideiussorem aut sponsorem accedat, neque negligens debitoris intercessoribus molestus sit, sed veniat primum ad eum, qui aurum accepit debitumque contraxit. Et si quidem inde receperit, ab aliis absteineat (quid enim ei in extraneis erit a debitore completo?); si vero non valuerit a debitore recipere aut in partem aut in totum, secundum quod ab eo non potuerit accipere, secundum hoc ad fideiussorem aut sponsorem aut mandatorem veniat et ab illo, quod reliquum est,umat...*”.

29 PETRUCCI, “Osservazioni in tema di legislazione giustiniana sul *receptum argentarii* e sull’ *antiphonēsis*”, *Fides Humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna* 6 (2007) pp. 4223 ss..

gible normalmente al deudor principal. Esta norma que iba en contra de lo establecido en la Novela 4 del 535 para todas las garantías personales, se mantiene para las ἀντιφωνήσεις de los banqueros³⁰.

Abstracción de la promesa del banquero que se confirma y mantiene en el pr del Edicto 9:

ἐδίδαξαν γάρ τινες ἐποφλήσαντας ἢ καὶ ἐποφείλοντας καὶ ἀπαιτουμένους χρυσίον ἢ πράγματα καὶ οὐκ ἔχοντας, ὅθεν τοῦτο διαλύσειαν, αἰτεῖν αὐτοὺς καθαρὰς ἀντιφωνήσεις ὑπὲρ αὐτῶν ὑπεισιέναι ... καὶ ἀγράφως αὐτοῖς ἐντείλασθαι τοῦτο ποιεῖν, ἑαυτοὺς δὲ ταῖς ἐκείνων αἰτήσεσιν ἐνδιδόντας ὀρίζειν χρόνον ῥητὸν πρὸς τοὺς ἐνοχλοῦντας αὐτοῖς ὥστε εἶσω τούτου πάντως τὸν ἀντιφωνητὴν καταθεῖναι τὸ ὄφλημα· ἑαυτοὺς δὲ ἀντιφωνεῖν, εἴτα τῆς προθεσμίας ἐνστάσης ἀπραγμόνως ποιεῖν τὸ ἱκανὸν τοῖς τὰς ἀντιφωνήσεις δεχομένοις, ἀναλαμβάνοντων τῶν ὑπευθύνων ἴσως καὶ τὰς δανειακὰς συγγραφὰς καὶ τὰς ὁμολογίας τὰς αὐτῶν ἢ καὶ διαλύσεις λαμβανόντων, ὡς τὸ ἀσφαλὲς διὰ τῆς ἀντοφωνήσεως ποπιηκότων. Πολλοὺς δὲ καὶ ἐπιτυχεῖν τινος βουλευθέντας ἢ καὶ βουλομένους πράγματος ἐντείλασθαι αὐτοῖς ὑπὲρ αὐτῶν ἀντιφωνῆσαι χρημάτων τινῶν ἢ πραγμάτων δόσεις, καὶ τοῖς μὲν κατορθοῦσθαι τὸ σπουδαζόμενον, αὐτοὺς δὲ ἀμελητὶ κατατιθεῖναι τὸ χρυσίον ἢ τὰ πράγματα, καὶ ἀπλῶς οὕτω γίνεσθαι τὰς ἀντιφωνήσεις ...

Al menos en la práctica, los acreedores liberaban a los deudores principales tan pronto como el banquero había asumido la deuda. Una promesa abstracta proveniente de alguien tan solvente como el banquero, dice Díaz Bautista, equivalía para los acreedores a un pago diferido³¹.

La realidad del tráfico comercial exigía esquemas contractuales de garantía absoluta, concluidos *indefense*; esta necesidad, pues, se impone sobre las tendencias de orden dogmático y moralizante del emperador que intentaba eliminar posibles situaciones injustas de los negocios abstractos³². Ahora, absorbido el *receptum* por el *constitutum*, de marcado carácter accesorio o causal, era necesario articular otras formas que, por razones del tráfico comercial bancario, mantuviesen la independencia de la obligación del banquero con el acreedor respecto a la obligación del banquero con el deudor.

Numerosos testimonios confirman la importancia que el emperador otorga a la función económica y social de los banqueros, así como, de las numerosas concesiones que por razón de esta alta consideración vienen efectuadas³³. En este sentido, señalaba Díaz Bautista que la actividad bancaria, fuertemente decaída desde la crisis del siglo III, debió experimentar un

30 DÍAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina cit., pp. 179 ss..

31 DÍAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina cit., p. 181.

32 En este sentido, DÍAZ BAUTISTA, "Les garanties bancaires dans la législation de Justinien" cit., pp. 185 ss.; LA ROSA, "Le pressione degli *argentarii*" cit. p. 449; FASOLINO, "Sulle tecniche negoziali bancarie" cit., p. 184; PETRUCCI, "Osservazioni in tema di legislazione giustiniana sul *receptum argentarii*" cit., p. 4233.

33 C. 12, 34 [35], 1, 1; N. 4, 3, 1; N. 136 pr.; Ed. 7, 4; Ed. 7, 8, 1; Ed. 9, 2 pr.; Ed. 9, 8. Entre las concesiones atribuidas a los banqueros, por ejemplo, piénsese, en la jurisdicción especial para las controversias bancarias (*praeffectus urbi y comes sacrarum largitionum*), en la posibilidad de acumular intereses *ultra duplum*, en la posibilidad de introducir el *beneficium excussionis*, o en los diversos privilegios otorgados en materia de ejecución forzosa.

pujante desarrollo en tiempos de Justiniano; Bizancio ha sido durante toda su historia una ciudad cruzada por rutas comerciales, cuya riqueza principal era el tráfico mercantil, de aquí que fuera del todo necesaria la celeridad en la contratación, la tendencia a la abstracción que exigía el tráfico y la necesidad de obtener vías rápidas y seguras para la realización de los créditos³⁴.

Apreciamos, pues, que en el derecho justinianeo se rechaza abiertamente la independencia de la obligación banquero-acreedor respecto a la de su cliente deudor, en clara armonía con la política legislativa del emperador de conformidad a la concepción causal del negocio, sin embargo, no obstante esta realidad, igualmente constatamos la vigencia de una reiterada independencia obligacional, que se consigue, quizás, mediante excepciones, pero, sobre todo, mediante otras figuras jurídicas. Y es que el tráfico comercial bancario exigía, como ha quedado demostrado, la necesidad de mantener esta independencia por razones obvias de seguridad y agilidad y celeridad jurídica comercial.

III. En definitiva, El tráfico bancario requería la autonomía de la obligación asumida por el banquero con respecto a la de su cliente deudor. En este sentido, esta independencia obligacional se constata en época de Adriano como atestigua la validez de un *receptum absente et invito debitore* y la imposibilidad de que el banquero pueda liberarse del vínculo obligacional, con independencia de la causa, una vez asumida la obligación de pago. Ciertamente, con anterioridad a esta época no es posible determinar el grado de autonomía existente entre ambas obligaciones, pero, lo cierto es que no era tan absoluto como confirma la probable imposibilidad de un *receptum* contra la voluntad del deudor, y sobre todo, la posibilidad del banquero de interponer excepciones del deudor.

En derecho justinianeo, acorde con la política legislativa del emperador y como prueba fundamentalmente C. 4, 18, 2 pr., se rechaza esta independencia, sin embargo, la necesidad de negocios de garantía absoluta en aras al tráfico comercial bancario se impone condicionando la existencia y manteniendo la plena vigencia de esta autonomía obligacional, la que se consigue bien mediante excepciones bien mediante el reconocimiento de figuras contractuales de garantía absoluta y abstracta, como la ἀντιφωνησις del Edicto 9.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV (CERAMI, DI PORTO, PETRUCCI), *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino, 2004.
- ANDREAU, *Le vie financière dans le monde romain. Le métiers de manieurs d'argent (IV siècle av. J.C. –III siècle ap. J.C.)*, Roma, 1987.
- ARCHI, “Contributi alla critica del *corpus juris*, II. Riforme giustinianee in tema di garanzie personali”, *BIDR* 65 (1962).
- ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito II*, Milano, 1941.
- BEKKER, “Recipere und permutare bei Cicero”, *ZSS* 3 (1882).

³⁴ DÍAZ BAUTISTA, *Estudios sobre la banca bizantina cit.*, pp. 6 ss.; “Les garanties bancaires dans la législation de Justinien” cit., pp. 166 ss..

CUIACIUS, *Opera* X, Napoli, 1758.

DÍAZ BAUTISTA, “Les garanties bancaires dans la législation de Justinien”, *RIDA* 29 (1982).

DÍAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano), Murcia, 1987.

DÍAZ BAUTISTA “La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti (C. 4, 18, 2, 2)”, Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo, Napoli, 1997.

FADDA, Istituti commerciali del diritto romano. Gli argentarii ed il commercio bancario, Napoli, 1903.

FASOLINO, “Sulle tecniche negoziali bancarie: Il *receptum argentarii*”, *Labeo* 46 (2000) 2.

FASOLINO, “Garanzie autonome e attività bancaria”, *Studi Senesi* 1 (2001).

FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. V. I, Le garanzie personali, Padova, 1962.

HUVELIN, Cours élémentaire de droit romain. Le obligations, Paris, 1929.

KRAUT, De Argentariis et nummularis commentatio, Göttingen, 1826.

LENEL, *Das edictum perpetuum*, Leipzig, 1927.

LENEL, “Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare. De maioris partis tribonorum sententiae aut eb eo, cuius de ea re iurisdictio fuit, ea tutela curatiove data erit”, *ZSS* 2 (1881).

LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Roma, 2000.

MAGDELAIN, Le consensualisme dans l’édit du prêteur, Paris, 1958.

MANNA, Degli argentarii in diritto romano, Lanciano, 1886.

PARTSCH, “Der ediktale Garantievertrag durch receptum”, *ZSS* 29 (1908).

PETRUCCI, Mensam exercere. Studi sull’impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - metà del III secolo d. C.), Napoli, 1991.

PETRUCCI, Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione dell’banche romane, Torino, 2002.

PETRUCCI, “Osservazioni in tema di legislazione giustiniana sul *receptum argentarii* e sull’ antiphonesis”, *Fides Humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna* 6 (2007).

PETRUCCI, “Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a. C.” *Ius Antiquum* III (XXVIII), Moscoviae, 2013.

RODRÍGUEZ GÓNZALEZ, El receptum argentarii en el derecho romano clásico. Una propuesta de análisis, Madrid, 2004.

ROSELLO, “Receptum argentariorum”, *AG* (1890).

ROSELLO, Argentarii. Studio di diritto commerciale romano, Lanciano, 1891.

TALAMANCA, “Argentarii”, *NNDI* 8 (1978).

WENGER, “Receptum argentarii”, *RE. P-W*.

LA PROTECCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN NEGOCIOS MERCANTILES: PRECEDENTES ROMANOS Y SU PROYECCIÓN EN EL DERECHO ACTUAL

DRA. M^a TERESA DUPLÁ MARÍN
ESADE Law School, Ramon Llull University

DRA. PATRICIA PANERO ORIA
Universidad de Barcelona

PROF. ELISABETH GARCÍA-CUETO
ESADE Law School, Ramon Llull University
Notario de Barcelona

SUMARIO: La protección a menores y adolescentes en negocios mercantiles: precedentes romanos y su proyección en el derecho actual. 1. *La Lex Plaetoria o Laetoria de circumscriptione adulescentium* y la *cura minorum*: 1.1. Introducción: entorno socio-económico y geográfico de Roma en los s. III y II aC. 1.2. El origen de la *Lex Plaetoria o Laetoria de circumscriptione adulescentium* y la *cura minorum*. 1.3. El fundamento de la protección al que negocia en Roma. 2. El Senadoconsulto Macedoniano. 3. Apunte final: la protección al menor y al adolescente en nuestros días.

1. LA LEX PLAETORIA¹ O LAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADULESCENTIIUM Y LA CURA MINORUM

1.1. Introducción: entorno socio-económico y geográfico de Roma en los siglos III a II aC.²

La *Lex Laetoria de circumscriptione adulescentium* –sobre el engaño de los adolescentes– es una evidencia más, y por tanto no la única, de la gran transformación que sufre

1 La doctrina romanista ha buscado a lo largo de muchos años una respuesta a la duda reflejada en las fuentes que nos han llegado, sobre cual fue realmente la denominación de dicha ley. En este sentido, recogemos la reciente opinión de ANKUM quien, en su trabajo sobre el significado de los términos *minor captus* y *minor circumscriptus*, afirma que la cuestión queda resuelta con la publicación de la *lex Irnitana* (a- 90 aC) en la que aparece la denominación *lege Laetoria*, término que utilizaremos a partir de este momento. Vid. al respecto, ANKUM, *Le minor captus et le minor circumscriptus en Droit Romain classique, Liber Amicorum*, Bordeaux, 1992, p. 36 n. 1.

2 Vid. por todos, ALFÖLDY, *Historia social de Roma*, trad. al español por Alonso Troncoso, Madrid, 1987, pp. 133 y ss.; DI SALVO, *Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II aC.*, Camerino, 1979, pp. 17-113; GARNSEY y SALLER, *El Imperio Romano*, trad. al español por González, Barcelona, 1991, pp. 68 y ss.

el ordenamiento jurídico romano: en primer lugar, con el sometimiento de Italia, fechado hacia el año 265 a.C., hecho éste que convierte a Roma, como indica KUNKEL³, en una de las potencias más fuertes de los estados de la Antigüedad; y en segundo lugar, con las Guerras Púnicas, esto es, como advierte la doctrina, el mayor conflicto de la Antigüedad⁴, y en concreto, con la segunda de estas guerras (218-201 a.C.), la más emblemática, llamada también, Anibálica, y que traerá como consecuencia final del proceso la evolución y el desarrollo del comercio y de la industria⁵. En este sentido, el triunfo de Roma, con que finalizó la gigantesca lucha entre ésta y Cartago supuso, como recuerda KOCH⁶, la supremacía de la raza indogermana en Europa, a la vez que confirmó la hegemonía de la nación latina en Italia.

A partir de entonces extienden los romanos su hegemonía geográfica: son dueños de la mitad occidental del mar mediterráneo, e incorporan a sus dominios Oriente. Roma, en palabras de KUNKEL⁷, era ahora, no ya una gran potencia entre otras, sino dueña y señora de toda la cuenca del mediterráneo -sede de culturas- lo que significaba, para la Antigüedad, el mundo entero. En aquella época se introdujo también el régimen de los latifundios, nefasto, según KOCH⁸, para el desenvolvimiento social de Italia, ya que contribuyó a la ruina completa de los labradores y aldeanos que habían sufrido previamente con la larga guerra púnica en la que se llegaron a destruir más de 400 pueblos. En este sentido, como matiza KUNKEL, las concurrencias de las posesiones de Sicilia, que producían cereales baratos a gran escala y podían enviarlos a Roma por mar, con mayor facilidad que las regiones periféricas de Italia, que no podían prescindir del transporte por tierra, y la fuerza de la atracción de Roma, que crecía muy rápido, determinaron, en el s. II a.C., una decadencia de los campesinos. Desde el año 146 también África se convirtió en proveedor de trigo. Los mercaderes privados eran responsables de transportar el grano a Roma, pero el Senado ejercía un estrecho control. En la agricultura itálica, gracias al aumento de capitales y a la abundante mano de obra esclava, se impulsó un régimen de explotación basado fundamentalmente en el cultivo del vino y del aceite que se extendió a Etruria, el Lacio y la Campania, aunque no estaba ausente de otras regiones de Italia. La producción permitió un flujo de exportaciones sistemático y en continuo aumento a lo largo del siglo II a.C. La protección del Estado sobre los intereses comerciales de Italia, aunque indirecta, nunca estuvo ausente; así puede explicarse la prohibición de Roma a que los pueblos transalpinos plantaran viñas y olivos, evitando una posible competencia. A su vez, los senadores romanos no podían dedicarse al comercio, pero en su calidad de grandes terratenientes, no estaban ajenos a los beneficios que éste reportaba. Parece incluso que muchos terratenientes comerciaban por medio de sus libertos, que podían legalmente poseer grandes barcos y estaban obligados a vender los productos de sus

3 *Historia del Derecho romano*, traducción de la 4^a ed. por Juan Miquel, Barcelona, 6^a reimpr., 2003, p. 42.

4 Vid. al respecto la reciente obra de GOLDSWORTHY, *Las Guerras Púnicas*, Barcelona, 2002.

5 Un interesante resumen de los principales acontecimientos de cada una de las tres guerras púnicas lo encontramos en la reciente obra de CASTRO SÁENZ, en *Compendio Histórico de Derecho Romano, Historia, Recepción y Fuentes*, Madrid, 2004, pp. 150-151.

6 *Historia de Roma*, trad. de José Camón Aznar, Barcelona, 1930, p. 85.

7 *Historia del Derecho romano*, cit., p. 52.

8 *Historia de Roma*, cit., p. 85.

amos, como señala el tratado de agricultura de Catón el Viejo. Eran, asimismo, objetos codiciados por la aristocracia romana, los artículos suntuarios procedentes sobre todo de Oriente: obras de arte, alimentos y vinos raros, especias e incluso esclavos cualificados.

Situados pues en este momento, hecho a destacar es el de la evolución o cambio de una sociedad eminentemente rural, dedicada al pastoreo y la labranza, como indica KOCH⁹, una verdadera república de labradores, a una sociedad urbana, con una economía basada en las transacciones comerciales, y abierta al mundo, en la que el pequeño agricultor se convierte en comerciante¹⁰. La entrada de Roma en la política internacional a partir del s. II a.C. produjo un verdadero cambio en su estructura económica, y de ahí también, por supuesto, el desarrollo a nivel jurídico de un derecho de índole mercantil. Roma llegó a tomar parte en el comercio internacional lo que produjo un hondo cambio en la estructura social de Italia; nacieron los grandes comerciantes y banqueros, surgieron los negocios bancarios y otras empresas, como las sociedades por acciones. Cicerón dice, posiblemente sin exagerar, que Roma fue a menudo a la guerra a causa de sus mercaderes. Esclavos, metales, objetos manufacturados y todo tipo de productos obtenidos en las guerras proporcionaban un constante beneficio para los comerciantes romanos y latinos. El Estado aumentó estas operaciones con la creación de puertos libres o, a veces, con la exención de tasas portuarias. Sólo el comercio de grano fue siempre vigilado y controlado por el Estado.

Desde esta nueva perspectiva económica, la política de guerras y de expansión practicada por Roma contaba, como veremos, con el consenso no sólo del Senado y la oligarquía romana y latina, sino con la de todos los sectores sociales, incluida la clase más desfavorecida. Además, el Tesoro estatal se hizo cada vez más dependiente de los ingresos exteriores: las indemnizaciones, los impuestos y tributos, los aranceles... eran la fuente esencial que permitía financiar los enormes gastos que las guerras suponían.

La creación de las provincias incidió también sobre la agricultura itálica y dio lugar a la creación de nuevos mercados y al flujo de dinero a Italia, tanto en forma de botín, como de indemnizaciones e impuestos. La unificación del mundo conocido propició los intercambios, y los *negotiatores* romanos e itálicos, asentados tanto en las provincias, como en otras regiones no sometidas a Roma, pero bajo control romano, como Egipto, dirigían hacia Italia las corrientes comerciales que ellos controlaban. La única forma de comercio sobre la que el Estado romano ejerció un estrecho control fue el grano. El motivo era asegurar el mantenimiento del ejército y el abastecimiento de Roma, ya que hacia finales del siglo II a.C. comenzará la práctica de la *frumentatio* pública o distribución casi gratuita de trigo a la *plebs* romana.

1.2. La Lex Plaetoria o Laetoria de circumscriptione adulescentium y la cura minorum

Siendo esto así, en la Roma republicana encontramos un claro precedente de protección al menor que negocia, justificado, en apariencia, por un cambio socio económico del que

⁹ Historia de Roma, cit., p. 99.

¹⁰ En este sentido destacan los restos anfóricos que nos han llegado sobre la actividad de los productores de vino y de aceite, las sociedades de intercambio y los navieros transportistas.

hablaremos más adelante. Se trata, en concreto, de la protección que se establece en favor de los menores de 25 años, púberes y por ello, con plena capacidad de obrar, que se inicia con la promulgación de la *Lex Laetoria de circumscriptione adolescentium* –sobre el engaño de los adolescentes–, plebiscito de fecha incierta, entre el 200 y el 191 a.C.¹¹, y que no supone más que el principio de una auténtica y completa, e incluso, quizás extrema, protección al menor, y por tanto también al menor consumidor y que negocia, justificada en términos generales por la falta de experiencia de los mismos; falta de experiencia, que puede ser aprovechada por los demás para engañarlos, o que incluso, sin existir engaño, les puede producir un perjuicio evidente. De todo esto destacamos, por un lado, el hecho de que con esta ley se introduce en el lenguaje jurídico el término “menor” en el sentido de alguien que al no haber cumplido una determinada edad, al menos, precisa de cierta protección; y por otro, que es evidente que en estos supuestos, prima, por encima de todo, el interés del menor negociante, en una normativa que va, con el paso del tiempo y a lo largo de unos seis siglos, incrementándose, en cuanto a medidas concretas de protección se refiere. Tal y como acertadamente indica PUGLIESE¹², en términos generales la protección de los menores en Roma transcurre en dos claras direcciones: una, la más elaborada y estudiada, que se centra en la capacidad de éstos y su sometimiento al poder de otro (tutor); y la otra, mucho menos desarrollada y más tardía, centrada, no tanto en la capacidad como en la concreta protección y asistencia al menor. En esta segunda ubica el autor la protección de los púberes menores de 25 años, apuntando, como veremos más adelante, que en su evolución histórica ésta acabará, de forma natural, perteneciendo a la primera de las direcciones señaladas.

Dicho lo cual, a la protección legal¹³, por la que se estableció que cualquier persona podía interponer una acción penal, infamante, noxal y popular, la *actio legis Laetoria*, contra cualquiera que hubiese engañado a un menor de 25 años, se añade la protección del Derecho honorario. Esto es, el pretor, concede dos medidas más en favor de dichos menores: en primer lugar, la *exceptio legis laetoria*, excepción que puede oponerse contra la acción que interpusiera el autor del engaño para que el menor cumpliera el negocio celebrado; y en segundo lugar, la *restitutio in integrum propter aetatem*, remedio extraprocésal que debía ser solicitado por el menor y que se concedía de forma discrecional por parte del pretor, en los casos en que, habiéndose celebrado el negocio, existiese un perjuicio inherente al mismo, e incluso, en los casos en que no hubiese intención de engañar.

Con el paso del tiempo se hacen evidentes los inconvenientes que se derivan en la práctica, sobre todo en relación a la seguridad jurídica de los negocios celebrados con estos menores, y por ello, ya a finales de la época republicana el pretor, a instancia normalmente

11 Si bien, como apuntó en su momento BONFANTE, *Corso de Diritto Romano*, 1, Milano, 1963 (reimpr. de la ed. de Roma, 1925), pp. 667 y 668 n.1, no existe unanimidad en doctrina en cuanto a su concreta fecha de promulgación y contenido. En este sentido, si bien es cierto que la doctrina suele ligar el origen de la *cura minorum* al nacimiento de esta ley, no se sabe con exactitud si fue la propia ley la que introdujo dicha figura, o ésta apareció más adelante. Vid. resumen de dichos problemas recogidos por DICIENTA MORENO, *La Curatela de la mujer menor de veinticinco años*, (tesis doctoral), Barcelona, 1999, p. 20 n. 7.

12 Precedenti romani della moderna legislazione sui minori, Atti dei Convegni Lincei, 59, 1983, pp. 111-112 n.2.

13 Si bien, como apunta ANKUM en su trabajo *Le minor captus...*, cit., p. 37 n.4, SELB postula que es el pretor quien ha introducido dicha acción penal.

del menor¹⁴, pueda nombrarle a éste un curador –*curator minoris*– con la finalidad última de que le asesore en algunos sus actos jurídicos –*curator ad certam causam*–; puesto que, no lo olvidemos, éste sigue teniendo plena capacidad de obrar¹⁵. Costumbre esta que, como advierte SCHULZ¹⁶, se va generalizando a lo largo del Principado hasta que el emperador Marco Aurelio la convierte en una figura general y estable de protección al menor, prestando su asistencia a éste de modo constante en sus actuaciones en el tráfico jurídico mercantil. El final de este proceso supondrá, como apunta la doctrina, un claro acercamiento entre la *cura minorum XXV annis* y la tutela de los impúberos¹⁷.

Apuntadas las líneas generales de la protección a los menores en Derecho romano, es oportuno matizar que el trabajo que presentamos no tiene mayor pretensión que la de ofrecer una breve reflexión centrada en las razones, internas y externas, que justificaron, en su día, esto es, hace más de veinte siglos, dicha protección del menor. No pretendemos, por tanto, ahondar de nuevo en las concretas medidas de protección, su desarrollo, alcance real y evolución. Este ha sido a lo largo de los últimos siglos¹⁸ el principal objetivo de los numerosos trabajos que, en torno a la *Lex Laetoria* y la *cura minorum*, han ido apareciendo¹⁹; y todo esto, por supuesto, gracias al extenso número de fuentes jurídicas que nos han

14 ALBANESE, en *Le persone nel Diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 552, postula la posibilidad de que fuesen incluso terceras personas las que solicitasen el nombramiento del curador, con la finalidad de asegurar dichas relaciones jurídicas.

15 El curador se nombra para otorgar a los terceros seguridad respecto del acto jurídico celebrado por el menor. Su presencia sirvió para considerar, salvo prueba en contra, que no había habido engaño o error en la actuación negocial del menor, e *in fine*, para que éste no recurra a la *restitutio in integrum* ni a la aplicación de la *Lex Plaetoria*.

16 *Derecho Romano clásico*, Barcelona, 1960 (trad. de la ed. inglesa Oxford 1951, por Santa Cruz Teigeiro), p. 183.

17 Vid. al respecto los interesantes trabajos de CERVENCA, *Studi sulla cura minorum* 2. In tema di excusationes dalla cura minorum, BIDR, 77, 1974, pp. 139-220; *Studi sulla cura minorum* 3. L'estensione ai minori del regime dell' oratio severi, BIDR, 82, 1979, pp. 41-94. In tema di "usurae" dovute dai curatori di "minores XXV annis", IURA, 37, 1986, pp. 94-101; GUZMÁN, "Cura minorum" y "excusationes" en D. 4.4.11.2, *Studi Sanfilippo*, 2, 1982, pp. 59-71.

18 Vid. recopilación de bibliografía anterior al s. XIX realizada por SAVIGNY en *Trattati quattro di giurisprudenza storica. Del patrocinio dei minori, secondo il Diritto romano, ed in specie secondo la Lex Praetoria*, Verona, 1858, p. 53 n.1.

19 Vid. al respecto: SAVIGNY, *Trattati quattro di giurisprudenza storica...*, cit., pp. 52-92; COSTA, *Della data sulla Lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium*, BIDR, 2, 1889, pp. 72-89; SOLAZZI, *La minore età nel Diritto romano*, Roma, 1912; AUDIBERT, *Sur la tutelle et la curatelle*, NRHD, 20, 1914, pp. 355-359; LENEL, *Die cura minorum der klassischen Zeit*, ZSS, 35, 1914, pp. 129-213; ALBERTARIO, *Di alcune innovazioni postclassiche giustiniane riguardanti la cura minorum; Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori; Dell' "oratio Severi" riferita in D. 27,9 e la cura dei minori; Dell' "actio subsidiaria" concessa al minore contro i magistrati; Contributto allo studio della terminologia postclassica e bizantina in tema di minore età*, en *Studi di diritto romano*, I, Pavia, 1915, pp. 417-537; SOLAZZI, *Curator impuberis*, Roma, 1917; SOLAZZI, "Curatores pleni" dei minori, *Scritti di Diritto romano*, II, Napoli, 1957, pp. 177-191 (=Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 75.2, 1916, pp. 1599-1618); *Le nozze della minorene*, *Scritti di Diritto romano*, II, Napoli, 1957, pp. 147-165 (=Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino, 51, 1916, pp. 749-774); *Tutele e Curatele*, *Scritti di Diritto romano*, II, Napoli, 1957, pp. 1-80; ARCHI, v. curatela, ED, 11, 1962, pp. 489-494; LONGO, *Lex Plaetoria*, NNDI, 9, Torino, 1968, pp. 815 y ss.; CERVENCA, *Studi sulla cura minorum*. I. *Cura minorum e restitutio in integrum*, BIDR, 75, 1972, pp. 235-317; DI SALVO, *Lex Laetoria*, Napoli, 1979; *Contribution à l'étude de la Loi Plaetoria*, IURA, 30, 1979, pp. 289-311; D'ORS. A., *La acción del menor restituido (crítica a Kupisch)*, AHDE, 49, 1979, pp. 297-326; PUGLIESE, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, *Studi Biscardi*, IV, Roma, 1979, pp. 469-501; CERVENCA, *Osservazioni sul "curator" della donna minore di venticinque anni*, IURA, 40,

llegado, que hacen referencia, no solo al contenido de la citada ley y sus medidas concretas, a saber, la *exceptio legis laetoria*, la *actio legis laetoria*, la *restitutio in integrum minorum XXV annis*, *ex lege Laetoria o propter aetatem*, sino también al *minor XXV annis*, a la *aetas minor, imperfecta o legitima*²⁰, al *adulescens* (o *adolescens*), a la *aetatis veniam*, y algunas literarias²¹, en las que también se recoge dicha protección.

En esta vuelta a los orígenes hemos tomado como centro de nuestro estudio el *principium* del fragmento de Ulpiano (*XI ad ed.*) con el que se inicia, a su vez, el título IV del Digesto, *De minoribus vigintiquinque annis*, y en el que Ulpiano, de forma sucinta, pero a nuestro juicio muy completa, nos informa acerca de la protección establecida por el pretor en favor de los menores –recordemos, púberes, pero menores de 25 años–²². En dicho fragmento se identifican y sintetizan, de forma muy hábil, las razones últimas que justifican y dan sentido a dicho *auxilium*, y que expondremos en las páginas siguientes.

El punto final de nuestro análisis sobre el pasado da inicio a la segunda parte del trabajo, en la que planteamos, en la misma línea de reflexión, el *status quaestionis* actual. Presentamos, en definitiva, un pasado, entendido la mayoría de las veces, a nuestro juicio, de forma errónea como algo muy lejano; y un presente, que en cierto modo nos ahoga, y por ello, quizás es demasiado actual para detenernos a analizarlo; pasado y presente distintos, pero a su vez similares; con similitudes contextuales, internas y externas, que entendemos deben proporcionarnos un espacio común para reflexionar, cuando menos, sobre el fundamento de la protección a los menores consumidores, y, en síntesis, sobre la realidad de la protección que a día de hoy se les está otorgando.

Teniendo en cuenta todo esto, vamos a centrar nuestro trabajo a partir de este momento, y en lo que se refiere a esta primera parte: en primer lugar, en el análisis del contexto externo en el que surge o nace la citada protección a los menores en Roma; y en segundo lugar, en el análisis de las causas anunciadas por Ulpiano, y que justifican y dan sentido a la misma, con la finalidad última de ahondar en su auténtico fundamento, y por supuesto, porqué no decirlo, en el fondo, con la esperanza puesta en la mejora, en un futuro, de nuestra actual regulación.

1.3. El fundamento de la protección al menor que negocia en Roma

El contexto económico y social descrito, si bien debe entenderse como el escenario en el que nace la protección extraordinaria configurada en torno a los púberes menores de 25 años no tiene, a nuestro juicio, por sí mismo, la consistencia necesaria para justificar una protección a favor del menor que va a prolongarse, e incluso incrementarse, a lo largo de

1989, pp. 22-40; WIEDEMAN, *Adults and Children in the Roman Empire*, London, 1989; MUSUMECI, *L'interpretazione dell'editto sui minori di 25 anni secondo Ofilio e Labeone*, *Nozione Formazione e Interpretazione del Diritto dall'età romana alle esperienze moderne*, II, Napoli, 1997, pp. 39-58.

20 *A sensu contrario*, como advierte SOLAZZI en *Tutele e Curatele*, cit., p. 70, los términos *Iusta, perfecta, sua aetas*, se utilizan por los juristas clásicos para referirse a la pubertad.

21 Vid. ALBERTARIO, *I testi letterarii in materia di capacità di agire del "minor XXV annis"*, *Studi di Diritto romano*, VI, Milano, 1953, pp. 453-456.

22 El texto del edicto con el que el pretor interviene en favor de los menores de 25 años lo conocemos gracias al siguiente fragmento de Ulpiano recogido en el Digesto: *Praetor edicit: "Quod cum minore ,quam vigintiquinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam"* (D. 4,4,1,1 Ulp. XI ad ed.).

los siguientes siglos. Dicho lo cual, y no siendo para nosotros el contexto socio-económico el fundamento último de la protección al menor, nos pareció evidente que debieron existir otras causas por las que en su día se activó y mantuvo el *auxilium* a favor de los menores, las más de las veces, no lo olvidemos, consumidores o negociantes. En este sentido, y de todo lo anteriormente expuesto, tampoco concordamos con DI SALVO²³ cuando afirma que la finalidad última de la ley fuese la de disuadir a los jóvenes de la actividad comercial y financiera para que retornasen a la actividad agraria.

No obstante esto, y antes de entrar en el análisis de dichas causas, creemos que es oportuno detenernos unos instantes para plantear y responder a la siguiente pregunta: ¿quién es realmente el *menor* –consumidor o negociante– en Roma?

El menor del que estamos hablando es, a diferencia del derecho actual, y aunque parezca, como indica la doctrina, *a priori* excesivo²⁴, un menor con plena capacidad para ejercer actos con efectos vinculantes²⁵. Para hablar del menor en Roma, como concepto hoy contrapuesto, desde un punto de vista jurídico, al de mayor edad, sin duda alguna hay que partir de la pubertad. Y es que en este sentido, se hace preciso recordar que los juristas romanos enlazan la llegada a la pubertad, esto es, a la madurez sexual –por tanto atendiendo a la capacidad fisiológica– con lo que hoy entendemos por mayoría de edad; y como consecuencia de ello, y desde la óptica jurídica, como el momento en el que adquieren plena capacidad de obrar²⁶. *A sensu contrario*, como apunta PUGLIESE²⁷, la razón última de la incapacidad y en su caso, del sometimiento a un tutor, no se encontraba en la falta de madurez intelectual y de experiencia en la vida, sino en la falta de madurez sexual en sentido intrínsecamente fisiológico. Así entendido, y como apunta SAVIGNY²⁸, la libre administración de los bienes comenzaba –salvo para las mujeres²⁹– con la llegada a la pubertad, lo que sin duda ponía de manifiesto, como continua dicho autor, la falta de prudencia y experiencia necesarias, ambas, para una buena administración³⁰.

No obstante esto, la expansión territorial y la apertura de Roma traerán, como hemos visto, como consecuencia, la necesidad de promulgar una ley a través de la cual, y de forma

23 Argumento este que el autor defiende a lo largo de todo su trabajo, y más concretamente en las pp. 53-62 y 77-102.

24 Vid. en este sentido, por todos, DEBRAY, Contribution à l'étude de la loi Plaetoria relative à la protection du mineur de 25 ans, Mélanges Girard, I, Paris, 1912, p. 265.

25 Sobre la capacidad de los impúberes vid. el interesante trabajo de BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli impubes in diritto classico*, AG, XIX, 1956, pp. 10-66.

26 Lo que nos lleva a recordar, en este momento, las opiniones contrapuestas mantenidas entre los proculeyanos –quienes entendían la llegada a la pubertad con el cumplimiento de 12 o 14 años, según se tratase de varón o hembra– y la de la escuela de los sabinianos –mantenida en las épocas arcaica y preclásica– quienes apostaban en este tema por la denominada *inspectio corporis* realizada en cada caso para los varones, con la finalidad de averiguar si realmente se había alcanzado la necesaria madurez sexual. Vid. interesante *status quaestionis* realizado por PUGLIESE en *Precedenti romani...*, cit., pp. 116-118 n. 8, y n. 9, en la que se introducen las costumbres de los derechos germánicos y la del common law inglés.

27 *Precedenti romani...*, cit., p. 115 n. 5.

28 Trattati quattro di giurisprudenza storica..., cit., pp. 55-56.

29 Baste recordar que la consideración del sexo, para los romanos, como otra de las circunstancias modificativas de la capacidad de obrar.

30 Una muestra completa de las fuentes en las que se recoge la capacidad del adulto o la del menor respectivamente, y por ende, de los actos que pueden estos realizar, se encuentra en SOLAZZI, *La minore età...*, cit., pp. 5-12.

indirecta, entendemos se inicia el camino hacia lo que en la actualidad calificamos, frente a la idea de mayoría, como minoría de edad; eso sí, todo ello, y como otra muestra más, como se deduce de las palabras de SAVIGNY³¹, del conservadurismo que caracteriza al mundo jurídico romano, sin eliminar la concesión a los menores de la plena capacidad de obrar. En este sentido, como continúa dicho autor, razones tanto privadas como públicas, aconsejan, en su momento, no alterar o modificar la edad establecida para el reconocimiento de la plena capacidad de obrar de las personas. Esto es, y a modo de síntesis, la llegada a la pubertad supone la posibilidad de contraer matrimonio, la posibilidad de exigir el servicio militar, ejercer el derecho de voto etc... Es evidente, por todo ello, que existieron razones de calado suficiente como para que los romanos no modificasen el momento en que se adquiere plena capacidad, pero eso a su vez, no les impidió buscar soluciones, indirectas pero idóneas, para los problemas de orden práctico planteados. Dicho lo cual, conviene recordar, en estos momentos, las palabras con las que SCHULZ³² describe al *curator minoris*: "... el curador nunca fue un funcionario, fue más bien, si se nos permite la expresión, un tío bondadoso, designado oficialmente, o un buen amigo que se contentaba con ser ocasionalmente consultado por el menor o con administrar, a instancia de éste, su patrimonio... La posibilidad de solicitar el nombramiento del curador fue una idea ingeniosa que revela de nuevo el espíritu irreprimiblemente práctico e individualista del Derecho Romano..."

Una vez desarrollada a lo largo de la época clásica la protección a los menores, es en la época postclásica cuando por influencia de las costumbres de los pueblos del Oriente helénico, quienes no distinguen entre falta de pubertad y minoría de edad, se valora la función del curador de éstos, y se le otorga carácter de permanencia. Así, parece que, con el paso del tiempo, ya en época postclásica, si los 12 o 14 años podían considerarse como una mayoría de edad temprana, los 25 años, podía resultar tardía. Es por ello que el emperador Constantino³³, y tras una serie de concesiones aisladas, introduce la posibilidad de solicitar la *venia aetatis* a través de la cual, los varones de 20 años y las mujeres de 18, podían conseguir del príncipe la declaración de finalización de la minoría de edad³⁴.

Sintetizadas las principales características del menor consumidor, sujeto protagonista de nuestro trabajo, volvemos a las causas que, perennes e inmutables con el paso de los siglos, en definitiva, van a permitir el éxito de la protección establecida a favor del menor.

Para ello tomamos, como punto de partida, D. 4.4.1 *pr.* (XI *ad ed.*) de Ulpiano³⁵, en el que se señala lo siguiente:

Hoc Edictum Praetor naturalem aequitatem secutus proposuit, quo tutelam minorum suscepit; nam quum inter omnes constet, fragile esse et infirmum huiusmodi aetatum³⁶

31 Trattati quattro di giurisprudenza storica..., cit., p. 55.

32 *Derecho Romano clásico*, Barcelona, 1960 (trad. de la ed. inglesa Oxford 1951, por Santa Cruz Teigeiro), p. 185.

33 *Th.* 2, 17,1; *C.* 2, 44, 1-4.

34 Con la sola excepción de la donación y enajenación de bienes inmuebles que con Justiniano se extiende a la constitución de hipoteca sobre dichos bienes.

35 Texto que, curiosamente, ha pasado bastante inadvertido a la doctrina, sin darle la importancia que, a nuestro juicio, se merece en atención a la información que nos transmite.

36 Tal y como advierte SOLAZZI, en *Tutele e Curatele*, cit., p. 73, la expresión *huiusmodi aetatum*, en plural, es estilo bizantino.

consilium, et multis captionibus suppositum, multorum insidiis expositum, auxilium iis Praetor hoc Edicto pollicitus est et adversus captiones opitulationem³⁷.

Siguiendo el Pretor la equidad natural propuso este Edicto, en el que tomó a su cargo la protección de los menores; porque constando a todos que es frágil y débil el juicio de los de esta edad, y que está sujeto a muchos engaños, y expuesto a las asechanzas de muchos, el Pretor en este Edicto les prometió auxilio a ellos y protección contra los engaños.

El jurista, en el libro XI de sus comentarios al Edicto, y unos cuantos siglos después de la promulgación de la *Lex Laetoria* y del inicio de la protección del pretor³⁸, presenta en términos generales la protección establecida por el pretor en su edicto en favor de los menores –una *exceptio circumscriptionis*; una *restitutio in integrum propter aetatem*; o como se apunta últimamente, una *actio arbitraria*³⁹–. Como indica MUSUMECI⁴⁰, parece, de las referencias directas que se hacen al Edicto, que Ulpiano lo que hizo fue transcribir el contenido de éste emanado inicialmente del pretor, y que debió permanecer invariable hasta su definitiva sistematización en el Edicto Perpetuo. Además, y como apunta PUGLIESE⁴¹, Ulpiano no menciona la *circumscriptio*⁴² con lo que deja al libre arbitrio del pretor el valorar discrecionalmente la situación para decidir en consecuencia qué tipo de protección otorga al menor, incluyendo, por tanto, el perjuicio por su mera inexperiencia. A lo que hay que añadir, como continua el autor, el hecho de que, en la época en que nace la *Lex Laetoria*, e incluso un poco más adelante, no existía todavía la tutela pretoria contra el dolo; y una vez surgida dicha noción, al ser ésta más rigurosa que el simple engaño, se les abrió a los menores una vía de protección más amplia que la de los demás.

Un análisis detenido del texto de Ulpiano nos lleva a deducir, fuera de lo dicho ya, que el jurista quiso con sus palabras dar noticia de las razones últimas que justifican y dan sentido a dicho *auxilium*:

- a) por un lado, una causa que podríamos calificar de interna, por cuanto tiene de propia y característica de la persona del menor, *fragile esse et infirmum huiusmodi aetatum consilium*: “frágil es y débil el juicio de los de esa edad”, y,
- b) por otro, un efecto, esta vez, externo, consecuencia de lo anterior, pero que proceden de hechos en los que no interviene la voluntad, o que no suponen, en términos generales, actos del menor, *multis captionibus suppositum, multorum insidiis expositum*: “y que está sujeto a muchos engaños, y expuesto a las asechanzas de muchos”.

En nuestra opinión, la suma de ambas, esto es, la causa interna y el efecto externo, en definitiva, es la que provoca la actuación protectora del pretor. Y todo ello, por ende,

37 Sobre el carácter original o no de la última parte de este fragmento vid. *Index Intt.*, 1 y *Supplem.* 1, ad h.l.

38 Lo que se deduce, como indica MUSUMECI en *L'interpretazione dell'editto sui minori...*cit., pp. 41-42.

39 Vid. ANKUM, *Le minor circumscriptus...*, cit., p. 39, quien recoge la novedosa opinión de KUPISCH al respecto.

40 *L'interpretazione dell'editto sui minori...*cit., p. 42.

41 *Precedenti romani...*, cit., p. 122 n. 19.

42 Sobre el sentido de este término en las fuentes jurídicas romanas, vid., por todos, ANKUM, *Le minor circumscriptus...*, cit., pp. 45-50.

como consecuencia de una precedente necesidad social, *–nam quum inter omnes constet–* fruto, además, de una nueva realidad o contexto social de la que el pretor se hace eco y a la que pretende, en el ejercicio de su función, *–naturalem aequitatem secutus–*, dar respuesta.

Centrando nuestra atención en la causa interna alegada por Ulpiano, esto es, *fragile esse et infirmum huiusmodi aetatum consilium*, ésta deja entrever, a nuestro juicio, las principales carencias de las personas menores. Así, la fragilidad y debilidad del juicio de esa edad alegada por Ulpiano en D. 4,4,1 *pr.* describe y resume con bastante exactitud esta circunstancia propia, interna y característica de las personas en ese periodo de tiempo, que transcurre entre la adolescencia y la mayoría de edad. Como matiza SOLAZZI⁴³, el término *infirmia aetas*, que aparece en distintas ocasiones en los textos, lo hace en este fragmento de Ulpiano refiriéndose a los impúberes, y en el mismo sentido que aparece en D. 27.10.9 (I *memb.*) de Neracio, D. 4,4,18, 1 (II *ad ed.*) de Ulpiano y Paul. 1,7,2.

En este sentido hay que poner de manifiesto que los *jurisprudentes* de la época clásica, principalmente Paulo y Ulpiano, y más tarde en la postclásica, los emperadores, se cargan de razones y argumentos a la hora de mostrar lo que en general ha venido a calificarse de inexperiencia en los negocios, propia de los menores, analizada, ésta, desde la perspectiva personal del menor, o si se quiere, atendiendo a las que hemos denominado “causas internas”. Así, y como apuntábamos en las páginas anteriores, en opinión de PUGLIESE⁴⁴, dicha inexperiencia, si bien se toma en un primer momento como una razón para establecer una especial protección a los menores, con el paso del tiempo, se convierte en una auténtica causa de incapacidad. Otras de las numerosas expresiones que hemos encontrado en las fuentes jurídicas romanas, que describen o caracterizan al menor, en su caso, consumidor o negociador, y que entendemos constituyen el fundamento o razón última de dicha protección son, a modo de ejemplo, las siguientes:

- “*propter imperitiam*”: por su impericia⁴⁵ o “*ne ex sua imperitia vel iuvenali calore*”, por su impericia o calor juvenil⁴⁶;
- “*nam post hoc tempus compleri virilem vigorem constat*”: porque después de pasado este tiempo se completa el vigor viril⁴⁷;
- “*aetatis lubrico*”, “*lubricum aetatis*”: por la fragilidad de la edad⁴⁸;

43 *Tutele e Curatele*, cit., pp. 72-73.

44 *Precedenti romani...*, cit., p. 116 n. 6.

45 Paulo, en D. 2,8,8,2 (*XIV ad ed.*) (repasar si es el libro 40 o 14), apela al auxilio a los menores de 25 años por su impericia.

46 Justiniano en C. 5,59,4, pone de manifiesto la necesidad de la presencia de los curadores en las causas criminales, con la finalidad de que los menores, a causa de la impericia o calor juvenil, dejen de decir algo que pueda hacerles provecho o librarles de la sentencia.

47 Ulpiano, en D. 4,4,1,2, (*XI ad ed.*), habiendo anunciado el auxilio del pretor a los menores de 25 años, matiza que esto es así porque se entiende que llegada a esa edad completan el vigor viril, lo que, *a sensu contrario*, debe interpretarse como que antes de llegar a esa edad no tienen pleno vigor viril.

48 Expresión que se repite en múltiples ocasiones y lugares de la compilación de Justiniano, *ad exemplum*: es utilizada por Ulpiano en D. 4,4,11,5 *XI ad ed.*, recogiendo a su vez la opinión de Marcelo en sus notas a Juliano; en C. 2,23 (22), 1 *Imp. Gordianus A. Candiano, militi* y en C. 2, 35 (34), 2 *Imp. Diocletianus et*

- “erroris propii veniae petitionem”: por error propio⁴⁹ o “per errorem iuris”, por error de derecho⁵⁰;
- “aut tam negligenter in ea causa versati sunt”: por actuar de forma negligente en un asunto⁵¹;
- “si quis, iuvenili levitate ductus”: por dejarse llevar por la juvenil ligereza⁵², y finalmente,
- “quod minoribus viginti quinque annis ius ignorare permissum est”: por ignorancia del derecho, ya que a los menores de 25 años les está permitido ignorar el derecho⁵³.

Dicho lo cual, no podemos dejar de tener presente en nuestro análisis la evidente relación de causalidad existente entre dicha causa interna y el efecto externo que ésta provoca, o puede provocar, y que queda también manifestado en el texto de Ulpiano: *multis captio-nibus suppositum, multorum insidiis expositum*. Esto es, que una depende de la otra, o si se quiere, que una es consecuencia de la otra; en suma, que si no existiese inexperiencia, no hablaríamos de engaño al menor.

En síntesis, y para finalizar, en época romana, como indica PUGLIESE⁵⁴, el menor púber era capaz *de iure*, aunque padecía una auténtica incapacidad *de facto*. A día de hoy, sin embargo, nos atrevemos a anticipar que ocurre todo lo contrario, esto es, que si bien el menor es incapaz *de iure*, poco a poco está ostentando una auténtica capacidad *de facto*. Ante lo cual nos cuestionamos y dejamos aquí abiertas las siguientes preguntas: ¿está esta situación actual justificada? o por el contrario ¿existiendo una identidad de causa entre ambas situaciones, la del menor en Roma y la del menor actual, no debiéramos caminar hacia una regulación no idéntica, quizás, al menos si similar a la que se llega en la experiencia jurídica romana con el paso del tiempo?

Maximianus AA. *Et CC. Proculae*, en este último supuesto aplicado a una madre menor de edad en relación a la falta de solicitud de tutor para sus hijos.

49 Hermogeniano en *D. 4,4,17 (I Iuris Ep.)*, en el que el jurista anuncia la posibilidad de solicitar por parte de los Prefectos del Pretorio la restitución por entero contra su sentencia, puesto que ésta contiene la reclamación de venia del error propio, o en su caso, del engaño del tercero.

50 En *C. 2,23 (22), 2 Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Sotericae*, plantean la restitución en el supuesto de un legado no debido que, por error de derecho, es pagado por el menor.

51 Paulo, en *D. 4,24,1 (I Sentent.)*, anuncia que la intervención del pretor está justificada siempre en los casos en que el menor haya actuado con bastante negligencia. En este sentido se hace preciso apuntar, como se indica en *C. 2,41,1 Imp. Alexander A. Cononidi*, que también tiene derecho a la protección el menor de edad que dice estar lesionado, aunque haya actuado de forma habitual con la diligencia de un buen padre de familia y se haya mostrado en los actos públicos hábil, ya que se entiende que dicha manera de actuar no debe afectar a una situación concreta: “num is, qui se minorem annis laesum esse dicit, diligens paterfamilias fuerit, actibusque publicis industrium se docuerit, ut lapsus eum per aetatem verisimile non sit.”

52 Paulo, en *D. 4,24,2 (I Sentent.)*, recoge la opinión de Scevola, en un supuesto en el que el menor deja de aceptar una herencia o la repudia, otorgándole en atención a la mencionada juvenil ligereza la protección que se merece.

53 Nuevamente es Paulo quien en *D. 22,6,9 pr. (libro sing. de iur. et facti ign.)*, tras anunciar la regla general de que a cada cual le perjudica la ignorancia del derecho –*Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere*–, afirma que esta regla no se aplica a los supuestos en los que interviene un menor de 25 años.

54 *Precedenti romani...*, cit., p. 123 ; *Appunti sugli...*, cit., p. 482.

2. EL SENADOCONSULTO MACEDONIANO

El *Senatusconsultum Macedonianum* (en adelante *SCM*) – del S. I dC– es otra clara manifestación de la protección que el Derecho Romano ofrece a los menores y adolescentes consumidores, en el ámbito de los negocios; protección que, también lo anticipábamos, parece incluso mayor en el tráfico mercantil romano que en el actual. Centrándonos en la segunda fuente, en líneas generales, se trata de una disposición senatorial probablemente de época de Vespasiano (69-79dC), que prohíbe los préstamos de dinero a los *fili familias*.⁵⁵

El *SCM* se conoce, sobre todo, gracias a Ulpiano, *libro 29 ad Edictum*, recogido en D.14.6.1pr, fragmento que precisa, su tenor literal: *Verba Senatusconsulti Macedoniani haec sunt...*⁵⁶ y D. 12.1.14, que trata de distintos aspectos procesales del mismo: *Si filius familias contra Senatusconsultum mutuatus pecuniam solverit...*⁵⁷, y en D.14.6.3.3 que delimita su aplicación, excluyéndola cuando el préstamo sustituye a otra deuda⁵⁸ Otras fuentes jurídicas que se refieren a él son: el *Codex Gregorianus*, que le dedica un título entero, 3.5.10 *ad Senatusconsultum Macedonianum*; las *Pauli Sententiae* (2.10)⁵⁹; las *Institutiones Iustiniani* (4.7.7) y la Paráfrasis de Teófilo (*Inst.* 4.7.7)⁶⁰. Tampoco faltan referencias en las fuentes literarias donde es recordado por Suetonio, *Vitae Vespasiani*, 11⁶¹, y para algunos por Tácito, en *Annales*, 11.13⁶².

55 La dinastía Flavia, segunda de las del Principado o Alto Imperio e integrada por Vespasiano, Tito y Domiciano, presenta un principio y fin revelador al abordar el talón de Aquiles de aquél: el problema sucesorio, pues tras el año de anarquía anterior, Vespasiano es aclamado por las legiones provinciales fuera de Roma y Domiciano es asesinado.

56 *Verba senatus consulti Macedoniani haec sunt* : ‘ *Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis nominibus crederet: placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri.* ’

57 *Si filius familias contra senatus consultum mutuatus pecuniam solverit, patri nummos vindicanti nulla exceptio obicietur: sed si fuerint consumpti a creditore nummi, Marcellus ait, cessare conditionem, quoniam totiens conditio datur, quotiens ex ea causa numerati sunt, ex qua actio esse potuisset, si dominium ad accipientem transiisset: in proposito autem non esset. Denique per errorem soluti contra senatus consultum crediti magis est cessare repetitionem.*

58 *Is autem solum Senatusconsultum offendit, qui mutuam pecuniam filiofamilias dedit, non qui alias contraxit, puta vendidit, locavit, vel alio modo contraxit*

59 *Qui filio familias contra interdictum amplissimi ordinis pecuniam mutuam crediderit, post mortem patris ex eo quod vivo patre credidit cum eo agere non potest.*

60 Su autoría ha sido, negada por FERRINI sin embargo, el que el Profesor de Constantinopla Teófilo fuera uno de los encargados de la redacción de las *Institutiones Iustiniani* y que su probable muerte se anude al año 534, son, entre otros, datos que avalan la paternidad de este último, que respeta el orden expositivo de las refridas *Institutiones Iustiniani*. A mayor abundamiento: el que su contenido, en griego, sea tres veces mayor, abunde en ejemplos, comentarios (= parafrasis) y explicaciones hace que presente un contrastado valor didáctico, sin olvidar su propio interés dogmático.

61 *Libido atque luxuria coercente nullo inualuerat; auctor senatui fuit decernendi, ut quae se alieno seruo iunxisset, ancilla haberetur; neue filiorum familiarum faeneratoribus exigendi crediti ius umquam esset, hoc est ne post patrum quidem mortem.*

62 *Et lege lata saevitiam creditorum coercuit, ne in mortem parentum pecunias filiis familias faenori darent.*

Al margen del análisis de su contenido normativo⁶³, debe manifestarse que mucho se ha escrito sobre cuales fueron las circunstancias que motivaron su promulgación y cuales sus posteriores efectos. Para ello, siguiendo metodológicamente a PANERO⁶⁴ y su distinción respecto al Derecho en general (lo que podemos aplicar en particular a nuestro *SCM*), reiteramos que una cosa es aprender y otra distinta comprender, esfera en la que pretendemos colaborar y que comportaría poner el propio *SCM* en conexión con toda la realidad social para lo que sería necesario pasar revista: 1º) a las funciones del Senado en esa época, incluido el valor de sus *senatus consulta*⁶⁵; 2º) a la estructura económico social de la Roma del Principado⁶⁶ en la que es importante destacar, no sólo la gran actividad mercantil, sino

63 Cfr. PERIÑÁN, Bernardo, *Antecedentes y consecuencias del SC Macedoniano*, Valencia, 2000, quien en el tercer capítulo de su obra lleva a cabo un análisis minucioso, pp. 157 y ss., del texto, que le sirve de base, no sólo para la delimitación de su contenido (pp. 125 y ss.), sino también para determinar su finalidad p. 173.

64 Sobre lo expuesto en el texto Cfr. PANERO, Ricardo. *La experiencia jurídica de Roma*, Valencia, 1998, pp. 42-45.

65 Respecto al Senado en general, debemos recordar, que en la República cambia su primitivo carácter de mero órgano asesor del *rex*, pasando a ser el órgano más destacado e influyente, siendo garante por su composición *lectio senatus*, de la estabilidad y continuidad histórica de Roma. Ahora, en el Principado, el Senado inicia una fase de esplendor en la que se le confieren atribuciones electorales y legislativas, hasta el punto de calificarse su naturaleza jurídica, por MOMMSEN, como una diarquía, *Princeps-Senatus*, que se manifiesta, sobre todo, en: sus propios órganos (instituciones republicanas en franca decadencia y figura del *Princeps*, con constante aumento de poder); en la organización provincial (distinción de provincias senatoriales, con *proconsules* y *propraetores* e imperiales, con *legati Augusti*); en la administración financiera (con el *Aerarium populi Romani* o *Saturni* y la fortuna privada del Príncipe, *Fiscus Caesaris*) y en las propias fuentes del Derecho donde (según Gayo 1,4) junto a los *Senatusconsulta*, o sea, lo que el Senado manda y establece *-iubet atque constituit-* que alcanza fuerza de ley, surge (1-5) la *Constitutio principis*, que es aquello que establece el emperador por un decreto, edicto o una epístola *-quod imperator decreto, vel edicto, vel epístula constituit...*. Todas estas atribuciones del Senado, aparentemente compartidas con el Príncipe, terminarán siendo ilusorias cuanto más nos alejamos de Augusto. Siguiendo con el Senado, y respecto a sus funciones más antiguas y tradicionales, baste incidir la sin razón en la República, de un *interregnum*, y el especial interés que cobra la *auctoritas patrum*, que, en el Principado, se manifiesta en materia electoral y legislativa, aunque termina perdiéndolas a favor del Príncipe. Así, las recomendaciones (*commendationes magistratum*), del candidato, en el primer caso, que acaban siendo obligatorias al no comportar la exigencia de procurarse votos o la posibilidad de un fracaso [*sine repulsa et ambitu designandos*, según Tácito] y la sustitución del término *senatusconsulta*, por el de las meras propuestas y motivación del Príncipe en el Senado, en el segundo, *orationes principum in senatu habitae*, nos eximen de más comentario. Cfr. PANERO, R., *Derecho Romano*, Valencia, 2010, p. 88, n. 20. Una *lex de imperio Vespasiani*, de diciembre del 69 (en puridad, un *sc*, seguido de una *sanctio*, obra del primero de los Flavios) y llegada, de manera fragmentaria en una tabla de bronce, descubierta en Roma a mediados del s XIV, parece avalar el otorgamiento en bloque, a los *principes* sucesivos, de todas los poderes que, *paulatim*, le fueron otorgando a Augusto, por el Senado y el Pueblo, empezando por el *imperium proconsulare* y la *potestas tribunitia*. Conservada en el Museo Capitalino, el texto puede consultarse, reproducido además de en CIL, VI, 1, p. 167, n. 930, en DESSAU n. 244; BRUNS p. 202; GIRARD p. 107 o; FIRA I, p. 154, n. 15. Cfr. por todos, el texto en GIRARD, *Les lois des Romains*, 7ª Édition par un groupe de romanistes des "*Textes de droit romain*", II, de P.F Girard et F. Senn, Pub. curata de V. Giuffrè, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 1977, pp. 107-110.

66 Baste recordar: A) En lo territorial, que: a) con los Julios Claudios (hasta el a.67), Roma sigue su política de conquistas y así Claudio llega Britania; b) con los Flavios (hasta el 96) Vespasiano y Tito toman Jerusalén y c) y con los Antoninos (hasta el 192) Trajano supera, en Occidente, el Rhin y el Danubio y en Oriente, el Tigris, logrando la máxima extensión geográfica del Principado. B) En cuanto a la población: el cese de la distinción *cives* y *peregrini* por la *Constitutio Antoniniana* (212) al conceder Antonino Pío, la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio [a sin olvidar las lagunas del papiro 40 Giessen]. C) En lo jurídico: a) el cese, en teoría, de la distinción, *ius civile-ius gentium* y, en la práctica, la romanización de éste y provincialización de aquél; b) el cese,

la gran difusión de los préstamos pecuniarios, y 3^o) y no por ello menos importante, a la estructura de la familia de la Roma clásica, presidida por la *patria potestas*, pilar de la sociedad romana que, como dice TORRENT⁶⁷, ya empezaba en esta época a dar muestras de un proceso evolutivo⁶⁸ dando mayor cabida a la personalidad de los hijos, primero por vía del *ius honorarium* y segundo, por vía de la jurisprudencia.

En este trabajo, no pretendemos ahondar en cada una de las diferentes cuestiones controvertidas que rodean al *SCM*, ni siquiera proceder a una enumeración exhaustiva y crítica ellas, bastando recordar *ad exemplum*, que se discute hasta si fue promulgado por Claudio o por Vespasiano, ya que encuentra su precedente en una *lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum* poco conocida, que parece que castigaba con una multa a quienes prestaran dinero a los *fili familias*⁶⁹. Lo que pretendemos es poner de manifiesto que el Derecho Romano, a través del *SCM* protegía a los *fili familias* hoy diríamos consumidores, a través de esta medida particular: prohibir los préstamos de dinero en los que actuaban como mutuarios. Para ello, nos limitaremos aquí y ahora a hacer un breve *excursus* por el *SCM* centrándonos, exclusivamente, en su contenido, sus efectos y su fundamento.

1) Respecto a la primera cuestión, esto es su contenido, como ya hemos apuntado, el *SCM* determina la imposibilidad de exigir el préstamo de dinero hecho a un *filius familias*, limitando el Senado a través de esta medida, la capacidad de obligarse de estos *fili*, salvo que estuvieran autorizados por su *paterfamilias*⁷⁰. Incluso en el caso de que aquél se con-

formal, en el 130, tras el *Edictum perpetuum*, de la fuerza creadora del *ius edicendi* de los magistrados y el fin, por tanto, evolutivo del *ius honorarium* y c) la aparición de un *ius novum*, que descansa en la voluntad del *Príncipeps*, cobra forma a través de sus *constitutiones* y se basa en un nuevo procedimiento, la *cognitio extra ordinem*. D) En lo social: la diferenciación de tres estratos, *ordines senatorius* (o superior, integrado por la aristocracia de la tierra); *equester* (representado por la aristocracia del comercio) y *decurionum* (integrado por la élite municipal urbana). PANERO, Ricardo, *Derecho Romano*, Valencia, 2008, pp. 84 a 85.

67 Destacamos tres reflexiones a nuestro juicio de interés y que entresacamos del propio TORRENT en su *Diccionario de Derecho Romano*, Madrid, 2005, pp. 868-869 y 876-877. Precisa el autor que, particular importancia revistieron los *peculia*, pues jurídica, y hasta políticamente, abrieron una brecha importante al protagonismo exclusivo del *paterfamilias* y, correlativamente, un ensanchamiento de la capacidad negocial de los *in potestate subiecti*. Por ello, concluye, a través de sus distintos tipos, en época justinianeas, el rígido sistema que regía la familia ha dado una vuelta radical y aun subsistiendo la *patria potestas* vitalicia, en cuanto a sus efectos personales, que de todas formas se han reducido notablemente, la autonomía económica del *filius* es patente.

68 Involutivo, nos atreveríamos a atemperar al maestro.

69 Tácito, en *Annales* 11,13, usa como dos primeras palabras: *At Claudius* para luego, antes de mitad de texto, referirse a una ley relativa a la crueldad de los acreedores prestamistas...: *Et lege lata saevitiam creditorum coercuit, ne in mortem parentum pecunias filiis familias faenori darent*. La doctrina mayoritaria atribuye el *SCM* a Vespasiano, tomando la referencia legislativa de Tácito como precedente poco conocido, de aquél y precisa su promulgación en el año 47. De acuerdo a las alusiones de Suetonio y Tácito. Cfr. sobre las diferentes opiniones doctrinales, PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, pp. 182-187.

70 A pesar de la falta de capacidad jurídica de los *fili familias*, que como apunta Gayo D. 41.1.10.1 (2, *Inst.*) *Nihil suum habere potest*, al gozar de capacidad de obrar pueden éstos llevar a cabo negocios jurídicos patrimoniales de adquisición, pero no de disposición [*nemo dat quod non habet*, se resume de Ulpiano D. 50.17-54 (46, *Ed.*)], convirtiéndose junto con los esclavos, en meros instrumentos de adquisición del *pater*. Sin embargo, el carácter personal de las obligaciones y el principio de vinculación exclusiva de las partes hacen que el *pater* no responda de las deudas contraídas por el hijo y a pesar de que éste pueda ser demandado y condenado *in potestate*, la ejecución de la sentencia no se produce hasta el momento en que el *filius* alcance la posición de *sui iuris*. Cfr. PANERO, R., *Derecho Romano...*, cit., p. 271.

vierta en *sui iuris*, también se considerará de aplicación el acuerdo senatorial, siempre que adquiriera el hijo la condición de *sui iuris* por haber fallecido su *paterfamilias*.

Así, para que el *SCM* sea eficaz, como apunta PERIÑÁN GÓMEZ⁷¹, *a priori* tienen que cumplirse dos premisas; A) Una objetiva, que se trate de un préstamo de dinero y B) Otra subjetiva, que el *mutui accipiens* sea un *filius familias*, o sea, esté: *in patria potestate subiectus*.

A. Préstamo de dinero. Pese a su indudable claridad, huimos de un rigor literal, comparando, en cambio, la opinión de quienes interpretan esta disposición *lato sensu*; es decir, que no se limita a actividades del *filius* que fueran estrictamente préstamos, sino a también a todas sus actividades de crédito o financiación en las que pudieran disponer de una cantidad de dinero; en definitiva, como apunta TORRENT⁷², vetando cualquier operación de crédito o financiación de los hijos de familia, lo que indudablemente, indudablemente nos hace pensar en una mayor protección de estos *filii* que empiezan a actuar por sí mismos en el tráfico mercantil.

B. El mutuuario y su condición de *filius familias*⁷³. Recordemos que en Roma, el concepto de menor, usando terminología moderna –*impubes*– va ligado a la capacidad fisiológica para procrear⁷⁴, y no a la presunta madurez intelectual, y que los *alieni iuris*, con independencia de haber alcanzado la pubertad veían tremendamente limitada su capacidad de obrar sobre todo en el campo del Derecho Privado, y más concretamente en las relaciones patrimoniales⁷⁵. Sin embargo, la situación cambiará durante la época clásica, y poco a poco, aquella antigua concepción de la *patria potestas* irá atenuándose, aumentando de forma paulatina la capacidad patrimonial de los hijos: claro ejemplo de ello es la concesión de la *libera administratio* de un pequeño patrimonio –el *peculio*–, cuyo fin básico es, precisamente, introducir al hijo en la actividad comercial e industrial lucrativa, y la aparición de las denominadas *actiones adiecticiae qualitatis*, en las que el *pater* se hace responsable, en determinados casos, de las actuaciones del hijo⁷⁶. Todo ello desembocará en que en época clásica se admita cierta capacidad para contraer obligaciones civiles a

71 PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, pp. 127 y ss.,

72 TORRENT, A., *Diccionario...cit.*, v. *SCM*, p. 1160.

73 Englobándose en el concepto de *filius familias*, a todo ciudadano, libre, –*tam masculos quam feminas*– sometidos a la patria potestad, sin importar el grado, (hijos, nietos y biznietos o nietos de hijos. C. 4.28.6.. *Cfr.* D. 1.6.4 (*Ulp. 1 Inst.*).

74 *Impubes* es *qui generare non potest*, que se estima adquiere, siguiendo el criterio proculeyano adoptado por Justiniano, entre los 12 años la mujer y 14 el varón. Por ello es *pubes qui generare potest*. El que, en concreto la niña núbil, se denomine en las fuentes *viripotens*, o sea, *quae viro patens potest* nos revela de más comentarios.

75 Recuérdese que los *filii familias* son meros representantes de sus *patres*, pero exclusivamente en el caso de que sus actuaciones sean beneficiosas para éstos, por lo que, partiendo del precepto de que las actuaciones del hijo no pueden empeorar la condición del padre, éste no asumirá ni las deudas ni las responsabilidades derivadas de los negocios realizados por aquel.

76 Denominación que proviene de los glosadores y refleja que se añaden o agregan a las acciones civiles que los acreedores pudieran tener contra los *fili familias*. Baste recordar: 1º) su origen pretorio, ya que se encuentra en el un triple edicto, –*est autem triplex hoc edictum*–; 2º) su fundamento, el evitar el perjuicio de los acreedores derivado del principio de que la actuación del *filius* no puede perjudicar la situación patrimonial del *pater*, y 3º) sus efectos, la responsabilidad de éste de forma ilimitada o ilimitada frente a las actuaciones del hijo: *aut enim de peculio aut de in rem verso aut quod iussu hinc oritur actio*. D. 15.1.1 (*Ulp. 29 ad ed.*).

los *fili familias*⁷⁷, como se desprende, precisamente de nuestro senadoconsulto, ya que la falta de protección procesal que sufre el mutuante que actúa contra esta disposición, no hace otra cosa que reconocer, si bien de forma implícita esa capacidad patrimonial de los *fili*⁷⁸.

A priori puede parecer contradictorio, que por un lado, los *fili* cada vez tengan más autonomía negocial, y por otro, se establecen medidas para limitar su capacidad, como ocurre en el caso de nuestro senadoconsulto. Sin embargo, esto apoya la idea de que lo que hace el Pretor a sugerencia del Senado es brindar a los *fili* la posibilidad de proteger su posible patrimonio, privando de tutela judicial al mutuo, lo que nos conduce de la mano de RABEL que definió al Derecho Romano como un sistema de acciones, a aludir, de forma somera, a la eficacia del senadoconsulto, o sea, de su protección.

2) Esta protección se establece, procesalmente, de dos formas: a) la no concesión de acción (*denegatio actionis*) ante la solicitud del actor, mutuante, *mutuo dans*, por lo que sin entrar en más detalle, se paralizaría el litigio, *ipso iure*; y b) la *exceptio ex sc macedoniani*⁷⁹ que podía ser interpuesta por el *filius*, (o por su *paterfamilias*) frente a una eventual reclamación del préstamo (*condictio mutui* o *actio certae pecuniae* -o incluso *actio iudicati*-), excepción concedida por la Jurisprudencia *in odium creditionis*.

Sin embargo, los textos de Ulpiano referidos al *SCM* no contienen una prohibición expresa de que no se puede prestar dinero a los hijos, sino que se trata de una “recomendación⁸⁰” para que los magistrados intervengan en el ámbito procesal, ya que como es sabido, en el plano sustantivo, el Senado en la génesis del Principado no puede intervenir directamente en el *ius civile* prohibiendo algo que éste permite. Vemos así que se trata de una innovación que afecta al *ius civile* desplegando sus efectos en el *ius honorarium*, a través de la intervención del Pretor⁸¹.

La referencia al posible *odium creditoris* que refleja el tenor literal del texto de Ulpiano, hace pensar a parte de la doctrina, que una de las razones de este senadoconsulto fue castigar a los usureros que estaban causando terror en la sociedad romana del s. I dC⁸², que se encuentra en plena expansión. La vida romana cada día era más lujosa e inmoral lo

77 D. 44.7.39 (Gai ad Ed. Prov.) y D. 46.4.8.4 (ulp. 48 ad Sab).

78 Sobre si la obligación generada por la *datio mutui* puede ser reclamada civilmente, o si por el contrario, genera una obligación natural, la doctrina se muestra dividida: Autores de la talla de BONFANTE o KASER se decantan por el reconocimiento de una obligación natural, sin embargo, romanistas como TALAMANCA o BURDESE creen que se trata de una verdadera obligación civil. Cfr. sobre las diferentes opiniones doctrinales, PERINÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, pp. 231- 236. De todas formas, como apunta TORRENT, A., *Diccionario... cit.*, v. *SCM*, p. 1160, las obligaciones naturales parecen más una categoría postclásica que clásica.

79 Como apunta PERINÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, pp. 143-148, el texto sólo recoge la *denegatio* como medio de aplicación procesal siendo la jurisprudencia la que, influida por el espíritu de la disposición senatorial y probablemente por las limitaciones que plantea el denegarlo a la hora de aplicarla la que promueve la introducción de la *exceptio* en el edicto pretorio. Cfr. sobre el análisis de esta excepción y sus caracteres y su naturaleza jurídica estas mismas páginas.

80 Cfr. SALAZAR REVUELTA, María, “Notas a propósito de un estudio sobre el Senadoconsulto Macedoniano”, *Revista de Estudios Jurídicos*, n° 4 (2003), pp. 157-175, p. 168.

81 LUCREZI, F., *Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli, 1992, pp. 90 y ss.

82 Terror o envidia de los senadores y de la clase alta romana contra los usureros bancarios, se cuestiona MURGA, Jose Luís, “El scm y las acciones adiectitiae qualitatit”, *Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano*, Murcia (1998), pp. 351-374, p. 365.

que afecta a los *fili* que vivían *libido et atque luxuria*⁸³. Todo ello hizo que proliferasen los prestamistas negociantes –*faeneratores*– que incluso concertaban préstamos con esos imprudentes e inexpertos *fili*, que se las veían y se las deseaban para hacer frente a las esas deudas, ante la inflexibilidad de los prestamistas.

3) Esto nos lleva a la tercera cuestión que pretendíamos abordar: el fundamento de dicho Senadoconsulto, problema todavía hoy vigente controvertida en doctrina, que plantea, a su vez, si se trata de una medida a favor del *pater*, en último término responsable de las actuaciones del hijo, (a través de las *actiones adiecticiae qualitatis*) o del propio *filius*.

Ahondando un poco más en esta cuestión, de adoptar la primera postura, podría tratarse de una medida a favor, bien de la vida de propio *paterfamilias*⁸⁴ –recordando el controvertido relato descrito por Teófilo referente al parricidio cometido por Macedo para heredar a su padre y pagar así sus deudas⁸⁵– bien para salvaguardar no su vida, sino su patrimonio, o como apunta, PERIÑÁN, para retrasar el desgaste que la patria potestad estaba sufriendo paulatinamente⁸⁶. Gran parte de la doctrina romanística mantiene esta última postura⁸⁷, considerando que la máxima motivación de la medida senatorial está en el deseo de mantener incólume la patria potestad, que siendo uno de los pilares básicos de la sociedad romana, ya empezaba a tambalearse por la conquista de los *fili familias* de mayor autonomía.

Pese a lo expuesto no falta quien opina, como BESELER⁸⁸, que partiendo de la falsedad del relato de Teófilo, el *SCM* fue una medida dirigida a proteger a los *filiifamilias* frente a su propia imprudencia, impidiendo, o al menos dificultando, que éstos se endeudaran. Lo cierto es que, en cualquier caso, terminó siendo una medida protectora en el ámbito de los negocios en interés de los *filiifamilias*. Si bien es cierto que el *SCM* habla de los *fili*, en sentido general, queremos hacer especial hincapié en la delimitación de esta categoría que, como ya hemos puesto de manifiesto, abarca a todos los sometidos a la patria potestad, incluyendo tanto a los que hoy llamaríamos mayores de edad –púberes– como menores –impúberes–.

Es dentro de ese amplio concepto de *filius familiae: pro aetate* entre impúberes con sus distinciones entre *infantes* e *infantia maiores* (y la subdistinción, a su vez, de *infanti proximi* y *pubertati proximi*), y púberes, con su ulterior matiz entre *maiores viginti quinque annis* o *minores*, donde podemos pensar en el *SCM* como una medida de protección a los jóvenes, *minores* si se prefiere, equiparable a la establecida en la *Lex Laetoria*⁸⁹,

83 Suetonio en *Vitae Vesp.*, 11.

84 Posición defendida entre otros por DAUBE, David, “Did Macedo murder his father?” *ZSS* 65 (1947), pp. 261 y ss.

85 Y que ha dado lugar a las más variadas interpretaciones doctrinales sobre los hechos que originaron su promulgación. Cfr. por todos, PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, pp. 38 y ss.

86 PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, p. 178.

87 Cfr. por todos PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, pp. 167 y ss.

88 BESELER, G., *Beiträge zur kritik der römischen Rechtsquellen*, Vol. IV, Tübingen, 1920, pp. 130 y ss.

89 Recordemos que el objetivo último de esta ley, como ponen de manifiesto DUPLÁ, M^a Teresa, y BARDAJÍ, Lola, en “El fundamento último de la protección del menor consumidor: la inexperiencia en el ámbito patrimonial”, *AFDUC*, 11 (2007), pp. 1-24, es la protección de los menores consumidores.

si bien, no exclusiva para ellos, ya que si así hubiese sido, como apunta PERIÑÁN⁹⁰, el *SCM* habría establecido un límite de edad por debajo del cual se prohibiera el préstamo, independientemente de su condición de *sui* o *alieni iuris*.

Como ya se ha puesto de manifiesto, es esa nueva categoría de *minores*⁹¹ creada por la *Lex Laetoria*, referida a jóvenes o adolescentes (de entre 14 a 25 años), en la que encuadramos el concepto actual del menor consumidor, que puede ahora trasladarse a unas coordenadas espacio-temporales distintas, como son el *SCM* (frente a la *Lex Laetoria*) y el s. I dC (frente al s. I aC) si bien en relación a otro tipo de *minores*: ahora los *alieni iuris* (frente al *minor sui iuris*⁹²). Y al igual que pasaba con estos últimos, los *filiifamilias minores* que adquieran un dinero a préstamo, no sólo gozan de la doble protección otorgada por el *SCM* como hemos visto por vía procesal, 1) la *denegatio actionis* y 2) la *exceptio SC macedoniani*, sino también por vía extraprocesal, a través de una *restitutio in integrum propter aetatem*. Esto se fundamenta en nuestro convencimiento, de que en contra de lo que comúnmente se entiende, esta última protección pretoria, como afirma ANKUM, no sólo afecta a los menores *sui iuris*, sino también a los *alieni iuris*, esto es, los sometidos a la *patria potestad*⁹³.

Por último, y para concluir, podemos afirmar que si bien es cierto que toda la institución guarda una íntima relación con la patria potestad romana, no es menos cierto que posteriormente, la *interpretatio* de la jurisprudencia fue mitigando la prohibición del senadoconsulto, y del mismo modo, la Cancillería imperial modifica el ámbito del *SCM*, y hasta los tiempos de Justiniano va sufriendo constantes restricciones, en el afán de adaptarse a las nuevas necesidades sociales. Sin embargo, a pesar de ir perdiendo fuerza no llega a derogarse nunca, Justiniano lo recoge en la Novela 115.3.13, a pesar de no nombrarla de forma explícita.

Hoy el art. 323 del Cc, modificado por la Ley Orgánica N°1/1996 de Protección jurídica del menor, limita la capacidad del menor emancipado para algunos actos de disposición patrimonial entre los que se encuentra... **tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres, y a falta de ambos de su curador**, lo que indudablemente demuestra cierta conexión con el *SCM*⁹⁴.

90 PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, p. 254.

91 Como apuntan DUPLÁ y BARDAJI, en *El fundamento último...cit.*, p. 4, esta ley introduce en el lenguaje jurídico el término menor, referido a “alguien que al no haber cumplido determinada edad, al menos, necesita de cierta protección”.

92 Recordemos que este menor *sui iuris*, goza de plena capacidad jurídica y de obrar.

93 ANKUM, J.A., “La position juridique du “filius familias” mineur en droit romain classique”, *Mélanges Wubbe*, pp. 1-25, p. 2. Cfr. D. 4.4.3.10 (*Ulp. 11 ad Ed*): *Si autem filius familias sit, qui castrense peculium habeat, procul dubio ex his, quae ad castrense peculium spectant, in integrum restituendus erit quasi in proprio patrimonio captus*). WACKE, Andreas, “La prohibición del crédito para los hijos de familia y el dictado de la razón económica”, *SCDR*, 6 (1994), pp.157 y ss., p. 166, cree que el *SCM* pretende evitar los préstamos a mayores de edad, y no ha faltado quien considera que sólo afecta a los *filiifamilias* mayores de edad, como SOHM, R., *Instituciones de Derecho privado romano. Historia y Sistema*. Traducción por Rocas, W., Madrid, 1936, y citado por PERIÑÁN, B., *SC Macedoniano...cit.*, p.131, n. 18.

94 DAZA MARTÍNEZ, Jesús, - RODRÍGUEZ ENNES, Luis, *Instituciones de Derecho Privado Romano*, Valencia 2009, p. 298 en relación al antiguo art. 317 del Cc.

Ante el precedente senatorial romano, cabe establecer siguiendo a PERIÑÁN⁹⁵, un paralelismo entre este artículo y texto de Ulpiano, observando que tienen en común:

- 1º) su referencia explícita a un préstamo de dinero (mutuo), y si bien en el *SCM* veíamos que se podía ampliar la protección a otros casos similares, PUIG FERRIOL⁹⁶ considera también que “esta limitación deberá hacerse extensiva a cualquier otro negocio jurídico cuya finalidad económica coincida con la del préstamo de dinero”⁹⁷.
- 2º) En ambos, la restricción a la capacidad de obrar del menor cesa si concurre el consentimiento de los padres, del curador⁹⁸ o del cónyuge mayor y del *paterfamilias* en nuestro *SCM*.
- 3º) En relación al concepto de *menor*, también encontramos similitudes, ya que si el art. 323 es más restrictivo y se refiere exclusivamente al menor emancipado, el *SCM* como hemos visto tiene un ámbito de aplicación más amplio: todos los *filiifamilias* entre los que también están los jóvenes y adolescentes. Además, no debemos olvidar, que salvando las distancias, el hijo que contrae un préstamo siendo *alieni iuris*, pero después se convierte en *sui* por el fallecimiento de su *paterfamilias* (emancipado, al fin y al cabo), también está protegido por la disposición senatorial.
- 4º) Para acabar, y en relación al fundamento, algunos civilistas⁹⁹ encuadran el art. 323 en la lucha contra la usura, que tiene exponentes tan conocidos como la Ley de Azcárate de 23 de julio de 1908¹⁰⁰ cuestión esta que, como hemos visto, también ha sido esgrimida por algunos romanistas como fundamento del *SCM*.

A nosotros en cualquier caso, nos parecen ambas medidas de protección de los menores consumidores a los que se trata de amparar sea por su edad, o por su inexperiencia negocial.

3) La protección al menor y al adolescente en nuestros días.

A parte del precedente concreto que acabamos de señalar a la regulación romana del Senadoconsulto Macedoniano, existen múltiples normas, tanto nacionales¹⁰¹ como interna-

⁹⁵ En la forma, si bien separándonos de él en las conclusiones. PERIÑÁN, B., “La recepción del *SCM* en el Derecho Español”, *REHJ*, Valparaíso (2011), pp. 375 a 398, pp. 394 y ss.

⁹⁶ PUIG FERROL, L., *Artículo 323, Comentario del Código Civil*, I, Madrid, 1993, p. 885, citado por PERIÑÁN, B., *La recepción del SCM...*, cit., p. 394, n. 107.

⁹⁷ Siguiendo con el art. 323 Cc y la enumeración de los actos, además de **tomar dinero a préstamo**, [gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor] que el emancipado menor, no podrá hacer sin el consentimiento de sus padres, y a falta de ambos de su curador, la doctrina se muestra unánime al postular una interpretación extensiva, por considerar que el legislador *dixit minus quam voluit*. Por ello, por caso, ante la posible permuta; donación; dación en pago; transmisión por renta vitalicia y un largo etcétera sobre bienes inmuebles se consideran prohibidos y las concretas referencias que expresa comportan el sentido más amplio de prohibición de disponer de bienes raíces.

⁹⁸ La curatela se introduce por Ley de 24 de octubre de 1983.

⁹⁹ PÉREZ DE CASTRO, N., *El menor emancipado*, Madrid, 1988, pp. 166 y ss.

¹⁰⁰ El apelativo obedece a haberse dictado esta ley contra la usura por iniciativa del entonces ministro Gumersindo Azcárate. En su Art 1 habla de nulidad de préstamos, en condiciones tales, que resulten leoninos, habiendo motivos para estimar que han sido aceptados por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

¹⁰¹ Tanto Código Civil como alguna que otra normativa foral, especialmente la catalana y navarra, así como también la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, 1/1996, de 15 de enero, hacen una regulación más o menos extensa al respecto.

cionales¹⁰², que contemplan la regulación del menor, su capacidad y especial protección. Todas ellas conforman la normativa del menor o su estatuto jurídico.

No hay que perder de vista que al cumplir los dieciocho años se tiene capacidad de obrar para todos los actos de la vida civil, a excepción de los supuestos establecidos por el Código Civil¹⁰³ (art. 322); de la misma manera, el menor emancipado puede también regir su persona y bienes como si fuera mayor, con las salvedades previstas en el art. 323 del Cc. antes mencionadas.

El interés del menor es sin duda unos de puntos más importantes a estudiar cuando se trata de este tema. Éste es un concepto jurídico indeterminado y difícil de definir, cuyos límites y forma han sido fijados y limados por la jurisprudencia, caso por caso. De hecho, y pese a la abstracción del concepto, hay que recordar que el uso del mismo es frecuente para dar solución a los conflictos familiares¹⁰⁴, incluso aunque ello implique manifestar cierta desconfianza en los padres.

Este principio descansa en los fundamentos esenciales de nuestro Estado de Derecho, recogidos en la Constitución Española¹⁰⁵, siendo éstas normas de orden público y debiéndose observar en todo caso por los poderes públicos¹⁰⁶. Principio que, sin embargo, que no es nuevo, pero que ha sufrido adaptaciones a las nuevas regulaciones, y que ha conllevado la realización de reformas en nuestro Código Civil¹⁰⁷.

Específicamente hay que tener en cuenta que muchas veces el aplicar el principio no determina que se vaya a traducir en la igualdad de los progenitores, sino en que la persona a proteger va a ser el menor¹⁰⁸. Así ocurre de manera clara en el supuesto del derecho de visitas, donde se le reconoce a terceros la posibilidad de tener una relación con los menores aun existiendo voluntad en contra de sus padres¹⁰⁹. Ello claramente se plasma en el art.

102 Especialmente importante es la regulación contenida por la Convención de los Derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989 (en el seno de las Naciones Unidas), la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, entre otras.

103 En adelante, C.c.

104 En este sentido: en relación a la custodia compartida (STS de 7, 21 y 22 de julio de 2011 y 3 y 5 de octubre de 2011; atribución de la vivienda familiar (STS de 21 de junio y 10 de octubre de 2011); o en temas de derechos de visitas a favor de otras personas como los abuelos (STS de 12 de mayo y 20 de octubre de 2011)

105 Especialmente a lo dispuesto en el artículo 10, de deberes y derechos fundamentales; artículo 14, relativo al principio de igualdad; y el 39, de especial protección a la familia.

106 En este sentido relata DUPLÁ MARÍN T. y BARDAJÍ GÁLVEZ, L.: “*El fundamento último de la protección al menor consumidor: la inexperiencia en el ámbito patrimonial*”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 11, 2007. Pág. 16; y RIVERO HERNÁNDEZ, F.: “*El interés del menor*”. Madrid. 2000. Págs. 31 y 32. Así también la STS 141/2000 y el art. 53.2 y .3 CE.

107 En este aspecto recordar la reforma del año 1981 o las más recientes del año 2003 (*Ley 42/2003, de 21 de noviembre*) y 2005 (*ley 13/2005, de 1 de julio*)

108 A efectos ejemplificativos, la STS 623/2009, que remitía a la STS 25 de mayo de 2012, establece como criterios a tener en cuenta como interés superior del menor “*criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven*”. En este mismo sentido también se pronuncia la STS de 11 de marzo de 2010 y 22 de julio de 2011

109 En este sentido, la STS de 12 de mayo de 2011.

160.2 del Cc. al establecer que “no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados”, pues el menor tiene derecho a tener relaciones con personas con las que le une cierta afección.

El Tribunal Supremo ha declarado en numerosas sentencias¹¹⁰ que el interés superior del menor es un principio de orden público, y que ello ya justifica el hecho de que el juez, de oficio, lo aprecie, conforme a lo dispuesto en el art. 53 de la CE y art. 5 de la LOPJ.

Junto con este principio, inspirador de toda normativa relativa al menor, el Código Civil recoge en los arts. 164 a 168 la regulación relativa a la administración de los bienes de los hijos por los padres¹¹¹. Junto a ella, el art. 154 del C.c. prevé que la administración paterna de los bienes de los hijos, como carga o contenido de la patria potestad. Todo ello en el marco de un reconocimiento pleno a la titularidad de derechos por parte de los menores y de una capacidad progresiva para ejercerlos¹¹².

Ya el art. 164 prevé en su primer párrafo que los padres tienen el deber de administrar los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios; entendiendo, pues, que existe una administración en sentido amplio, ya que incluye además de los actos de conservación, disfrute y rendimiento, también los actos de disposición. Pero lo cierto es que no existe un conjunto de preceptos que permitan delimitar exactamente cuál es la capacidad contractual del menor de edad, debiendo recurrir a la madurez en cada caso del menor, para poder dar una solución al caso en concreto.

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar la aplicación de los preceptos más generales, que a su vez establecen el marco de actuación de las personas a nivel contractual, deviniendo capitales. En este sentido, el art. 1261 del C.c. relativo a los requisitos del contrato, donde el consentimiento de los contratantes es fundamental para la existencia del mismo. Y en segundo lugar, el art. 1263 del C.c. que precisa que los menores no emancipados y los incapacitados no pueden prestar consentimiento. A *sensu contrario*, los menores de edad no pueden contratar. Por tanto, del análisis de ambos preceptos se deduce la necesidad de que las personas que contraten han de ser capaces de comprender las consecuencias y alcance jurídico de sus actos, protegiendo, por ende, a todas aquellas personas que carezcan de madurez y entendimiento suficiente.

Si bien esta constatación parece clara, existen numerosas excepciones, pues a nadie se le escapa que los menores, aun no estando emancipados, realizan en su día a día contratos, especialmente en el ámbito del consumo en establecimientos abiertos al público o transporte (actos de su vida cotidiana, en definitiva); y todo ello, con plena validez y sin la intervención de sus representantes legales. En definitiva, la capacidad natural del menor es reconocida y validada en ciertos ámbitos de su actuación¹¹³.

Junto a ello, en el Código Civil encontramos también preceptos que reconocen estas excepciones de manera expresa: el art. 438 en materia posesoria; en sede de donaciones, los

110 STS de 25 de abril y 31 de mayo de 2011.

111 Concretamente en el Capítulo III del Título VII del Libro Primero del Código Civil.

112 Tal y como reza la Exposición de Motivos de la Ley de Protección Jurídica del Menor.

113 BARDAJÍ GÁLVEZ, L.: “*El fundamento...*”. Oab cit, pág. 15, explica como para una parte de la doctrina en realidad estamos ante una renuncia tácita a la impugnación del negocio jurídico, tanto por parte del menor (cuando alcance la mayoría de edad) como de su representante lega.

arts. 663, 625 y 626; y los arts. 164 y 165 del C.c. ya enunciados anteriormente en sede de ejercicio de la patria potestad. Además, el Estatuto de los Trabajadores permite la admisión al trabajo a los menores mayores de 16 años, con la excepción de los espectáculos públicos, donde existe una relación laboral especial¹¹⁴.

Al hilo de lo dicho en el ámbito patrimonial, encontramos otro importante sector, el consumo, donde el menor está adquiriendo cada vez más, una importancia capital. Aquí, no existe una norma o regulación específica que trate al menor consumidor. Y eso que es habitual ver a menores en centros comerciales o supermercados comprando todo tipo de objetos entre los que podemos encontrar teléfonos móviles, ropa, aparatos electrónicos y demás. ¿Es esta falta de regulación sinónimo a que los menores tienen libertad plena para hacer y deshacer en este ámbito? O por el contrario, ¿existe una falta de regulación tal que el menor se encuentra desprotegido? Éste parece ser el caso, lo que es de relevancia, siendo un sujeto débil y que merece una protección especial que no tiene, pese a que con la nueva normativa recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se ha comenzado a enfatizar en la protección de este sector aún más si cabe. Ahora bien, sigue sin incidir en este colectivo que tanta protección necesita, máxime cuando se le están creando unos hábitos de consumo que no son innatos a la persona cuando nace.

En otro orden de cosas y como mero apunte, pues no es objeto del presente estudio en profundidad, hay que hacer mención a todos aquellos actos relativos a los derechos de la personalidad u otros del menor, de acuerdo con sus condiciones de madurez, ya que podrán ser realizados por el menor sin la intervención de sus padres.

A título de ejemplo nos encontramos el derecho a la salud e integridad física y psíquica del menor. Éste podrá decidir por sí el internamiento por razones de trastorno psíquico, y sólo en caso de no poder hacerlo, lo habrán de promover sus representantes legales¹¹⁵. Lo mismo ocurriría en el caso del tratamiento de deshabitación por causa de intoxicación etílica, drogadicción, etc. Primando en todos estos casos el derecho a la vida y salud del menor. Como excepción encontramos el transplante de órganos, donde el menor no puede ser donante vivo, pero sí receptor de éstos mediando el consentimiento de sus representantes legales.

Respecto al derecho al honor, intimidad y propia imagen del menor se sigue la línea antes citada según la cual si el menor tiene suficiente madurez, podrá ejercitar los derechos de los que es titular, necesitando, en caso contrario, de la intervención de los titulares de la patria potestad, o en su caso, del Juez.

En definitiva, y pese a la multiplicidad de normas que hablan del menor en distintos ámbitos y esferas, la realidad sigue superando a la ley que, en algún momento, deberá reformularse o ampliar su regulación, dando cabida a la protección del menor en materia de consumo, donde de manera evidente este colectivo se encuentra ciertamente desprotegido.

114 Art. 6.1 y 6.4 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) y RD 1433/1985 de 1 de agosto.

115 Art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

DIREITO MARÍTIMO ROMANO. A DISCIPLINA JURÍDICA DO ALIJAMENTO*

RODRIGO DE LIMA VAZ SAMPAIO

*Escola de Direito do CEU-IICS
Universidade de São Paulo*

I. ALIJAMENTO: COMPETÊNCIA DA DECISÃO

Nas palavras de G. RIPERT, o Direito Romano teve um impacto “sobretudo técnico” na navegação¹. Dentre os exemplos, encontra-se o alijamento, em especial, a competência de decidir sua realização.

Ao utilizar o contrato de locação como tutela do alijamento, D. 14, 2, 2 pr., a fim de dividir os danos, cria um modelo tortuoso, cuja explicação é a ausência de qualquer liame jurídico entre os vectores (comerciantes e passageiros)². Ele constrói uma “solidariedade indireta” entre os envolvidos³, embora uma ação direta entre esses, sem intermédio do *magister navis*, teria sido certamente mais efetivo e menos moroso⁴.

* Esse artigo faz parte de tese homônima de doutorado orientada pelo Professor Titular de Direito Romano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Eduardo Cesar Silveira Vita Marchi e defendida em 02 de agosto de 2013 na mesma instituição. O trabalho foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tanto em sua elaboração (Processo 2009/52024-5) quanto na apresentação realizada no XVI Congreso Internacional y XIX Iberoamericano de Derecho Romano (Processo 2013/25970-2).

1 Droit maritime, 3ª ed., Paris, Rousseau, 1929, p. 72 (= n. 53).

2 G. HUBRECHT, Quelques observations sur l'interprétation romaine de la « lex Rhodia de jactu », Bordeaux, L'Université, 1934, p. 3.

3 R. CARDILLI, L'obbligazione di « praestare » e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.c. - II sec. d.c.), Milano, Giuffrè, 1995, p. 265. Também, S. PŁODZIEN, Lex Rhodia de iactu, Lublin, Naukowe, 1961, p. 154.

4 Gl. agere potest a D. 14, 2, 2 pr. (F. ACCURSIO, Glossa, in *Corpus Iuris Civilis Iustiniani - Digestum Vetus*, vol. 1, Lyon, Prost, 1627): “(...) Melius tamen esset ut via recta ageret damnum passus sublato circuito (...)” [= “(...) Todavía, teria sido melhor se quem sofreu o dano agisse pela via imediata (contra os demais), sendo eliminado o desvio (pelo *magister navis*) (...)”].

A continuação desse texto de Paulo parece ser a única referência jurídica à junta deliberativa no período justiniano:

Paul. 34 ad ed., D. 14, 2, 2, 1: “Si conservatis mercibus deterior facta sit navis aut si quid exarmaverit, nulla facienda est collatio, quia dissimilis earum rerum causa sit, quae navis gratia parentur et earum, pro quibus mercedem aliquis acceperit: nam et si faber incudem aut malleum fregerit, non imputaretur ei qui locaverit opus. sed si voluntate vectorum vel propter aliquem metum id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet.”

Paulo, no livro 34 de Comentários ao Edito do Pretor, D. 14, 2, 2, 1: “Se, conservando as mercadorias, a embarcação tenha sido deteriorada - ou se ela foi desarmada em algo - não se deve fazer alguma colação, porque é diferente a situação daquelas coisas, as quais equipam à embarcação, e [a situação] daquelas [coisas], pelas quais alguém tenha recebido um frete. De fato, também se um operário tenha quebrado a bigorna ou o martelo, não é imputado àquele que locou o serviço. Porém, se, pela vontade dos comerciantes ou em razão de algum temor, aquele dano tenha sido feito, é necessário que esse mesmo seja ressarcido.”

No início de D. 14, 2, 2, 1, descreve-se a hipótese dos danos ocasionados à embarcação e às mercadorias durante a realização do transporte marítimo.

A regra é que os danos provocados àquela sejam suportados, em última instância, pelo exercitor navis, já que a embarcação é seu instrumento de trabalho⁵ - da mesma forma que, para o operário, é a bigorna e o martelo⁶ - e aqueles constituem acidentes ordinários da navegação.

Não pode quem explora comercialmente uma embarcação transmitir seus prejuízos aos comerciantes que contrataram o transporte, nem o operário a quem usa de seus serviços.

Assim, não há colação, ou seja, os envolvidos na empreitada marítima não devem uma quota da contribuição⁷.

5 F. DE MARTINO, *Lex Rhodia II* – Note di diritto romano marittimo II, in *Diritto, Economia e Società nel Mondo Romano – Diritto Privato*, vol. 2, Napoli, Jovene, 1995, p. 323 [= *Lex Rhodia II*, in A. DELL’AGLI - T. S. VIGORITA (coords.), *Diritto e società nell’antica Roma II*, Roma, Riuniti, 1982; e, in *Riv. Dir. Nav. (Rivista del Diritto della Navigazione)* 4 (1938)], sustenta que “nulla facienda est collatio” seja uma interpolação e o original de Paulo fosse “actio magistro non competit” [= “não cabe ação ao capitão”].

F. DE MARTINO considera que o texto deveria se referir ao magister navis, pois D. 14, 2, 2 pr., tratava deste. Porém, o capitão não deixa de ser preposto do exercitor navis.

6 E. CHEVREAU, *La lex Rhodia de iactu: un exemple de la réception d’une institution étrangère dans le droit romain*, in *TR (Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue d’Histoire du Droit)* 73 (2005), p. 75; L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia und Agermanent - Der Schiffsrath - Studie zur Geschichte und Dogmatik des Europäischen Seerechts*, in *ZHR (Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht)* 35 (1889), p. 65; e P. HUVELIN, *Études d’histoire du droit commercial romain (Histoire externe – Droit maritime)*, Paris, Sirey, 1929, p. 194. Por se referir aos serviços prestados por alguém, E. CHEVREAU afirma que se trata de uma regra própria da locatio operis (faciendi) e, assim, D. 14, 2, 2, 1 refere-se ao transporte de mercadorias e “vector” significa, no caso, comerciante, não passageiro.

Também, J. BRUNNEMANN, *Commentarius in Quinquaginta Libros Pandectarum* (1670), t. 1, 3ª ed., Leipzig, Günther, 1683, p. 627; e F. DE MARTINO, *Lex Rhodia II* cit. (nota 5), p. 323.

7 A. DE SCHRYVER, *Commentaire de la loi Rhodia de iactu*, Bruxelles, Lesigne, 1844, p. 60; e L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia* cit. (nota 6), p. 65. Dessa forma, se uma embarcação é danificada pela força dos ventos, do

Em seguida, o texto compara esses danos com aqueles que se referem às mercadorias transportadas.

A interpretação de “Si conservatis mercibus - aliquis acceperit” parece depender, a essa altura, do adjetivo “dissimilis”⁸.

G. BESELER indica que o intervalo “quia - acceperit” pode ser considerado interpolado, pois “dissimilis” estabelece uma contradição imperfeita.

O correto, no texto, seria opor não os danos ocasionados à embarcação aos das mercadorias, mas as avarias grossas (um alijamento que tivesse por objeto instrumentos da embarcação) às simples (danos provocados às mercadorias por uma vis maior)⁹.

Para seguir essa lógica, em vez de “dissimilis”, J. CUJAS prefere “similis” [= “semelhante”]¹⁰, R.-J. POTHIER sugere “non dissimilis” [= “não diferente”]¹¹ e P. BONFANTE “haud dissimilis” [= “não diferente”]¹².

Ao igualar as situações, os danos provocados às mercadorias durante o transporte marítimo seriam semelhantes aos reparos feitos na embarcação. Ambos deveriam ser suportados apenas pelo transportador marítimo.

Entretanto, a opinião de A. DE SCHRYVER, pela qual se mantém “dissimilis” - e nenhum manuscrito mostra, de fato, uma variação - parece ser dogmaticamente a melhor¹³.

Além do pagamento do transporte (frete) não corresponder às despesas feitas com a embarcação, mas ser calculado com base nos riscos (deterioração e perda eventuais) das

mar, de uma tempestade ou por ataque de piratas, o exercitor navis arcará sozinho com o prejuízo. T. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani Augusti*, vol. 1, Berlin, Weidmann, 1870, p. 419, mostra que, na primeira correção do manuscrito de Paris, em vez de “quid” - “si quid exarmaverit” - encontra-se “quis” [= “alguém”]. Mesmo que alguém desarme a embarcação (não um evento natural), trata-se de uma obrigação do exercitor navis que ela esteja em ordem.

Para G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, vol. 4, Tübingen, Mohr, 1920, p. 130, “exarmaverit” também é uma interpolação. O texto original seria “ex armamentis perierit” [= “se (algo) tenha perecido dos instrumentos”]. F. DE MARTINO, *Lex Rhodia II cit.* (nota 5), p. 323, acompanha a versão de G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, vol. 1, Tübingen, Mohr, 1910, p. 82: ex armatura perierit” [= “se (algo) tenha perecido do equipamento”]. C. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar*, vol. 14, Erlangen, Palm, 1813, p. 218 (= § 887), sugere “si quaedam armamenta amiserit” [= “se alguma (embarcação) tenha perdido os armamentos”], e J.-M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII.^e siècle*, t. 1, Paris, Royale, 1828, p. 105 [= Us et coutumes de la mer, ou collection des usages maritimes des peuples de l’Antiquité et du Moyen Age I, Paris, Royale, 1847], “exarmata fuerit” [= “tenha sido desarmado”].

8 A. DE SCHRYVER, *Commentaire cit.* (nota 7), p. 60.

9 *Beiträge IV cit.* (nota 7), p. 130. C. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung cit.* (nota 7), p. 218 (= § 887), já explicou que ler o texto sem nenhuma alteração, como G. NOODT, *Commentarium in D. Iustiniani*, in *Opera Omnia*, vol. 2, Leiden, Langerack, 1735, p. 329, desejou, seria impossível.

10 *Observationum Lib. XXVIII*, in *Opera Omnia*, t. 3, Paris, Ofício Eclesiástico, 1658, p. 742.

11 *Pandectae Justinianae*, t. 1, 4^a ed., Paris, Belin-Leprieur, 1818, p. 445.

12 *Notas a GLÜCK C. F., Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar*, trad. em ital., *Commentario alle Pandette*, vols. 14 e 15, Milano, Libraria, 1907, p. 35.

13 *Commentaire cit.* (nota 7), pp. 60-61. Ele acompanha G. NOODT, *Commentarium cit.* (nota 9), p. 329. Nenhuma variação, nessa palavra, é apresentada por G. HALOANDER, *Digestorum seu Pandectarum Libri Quinquaginta*, Nürnberg, s.e., 1529, p. 512; A. KRIEGLER - M. KRIEGLER, *Corpus Iuris Civilis*, vol. 1, 8^a ed., Leipzig, Baumgärtner, 1858, p. 265; e T. MOMMSEN, *Digesta I cit.* (nota 7), p. 419. Também, J.-M. PARDESSUS, *Collection I cit.* (nota 7), p. 105.

mercadorias a serem transportadas¹⁴, a diferença das hipóteses é encontrada não na qualificação jurídica, mas em quem suporta o dano.

Assim como os danos ocasionados à embarcação não constituem avarias grossas (pois essa é instrumento de trabalho¹⁵), aqueles que acontecem às mercadorias (sobre as quais existe um frete para que sejam transportadas) são, sem o alijamento e por decorrerem de uma força maior, também meras avarias simples.

Entretanto, enquanto, no primeiro caso, o exercitor navis suporta o dano ocasionado, no segundo, cada proprietário das mercadorias arcará com esse (“res perit domino”)¹⁶.

Não haveria, assim, necessidade de correção dessa parte do texto.

O trecho “Si conservatis mercibus - aliquis acceperit” refere-se, assim, às avarias particulares. Esse não deve tratar do alijamento, pois, mesmo se for o caso do arremesso de instrumentos da embarcação - Pap. 19 resp., D. 14, 2, 3¹⁷ e Hermog. 2 iur., D. 14, 2, 5, 1¹⁸ -, haveria contribuição e D. 14, 2, 2, 1 decide, certamente, em seu contexto, de forma negativa.

A parte final “sed si - sarciri oportet” descreve a situação oposta a do início, já que, a essa altura, “voluntate vectorum vel propter aliquem metum” [= “pela vontade dos comerciantes ou em razão de algum temor”], existe contribuição dos interessados no alijamento.

14 Em outras palavras, como explica L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia* cit. (nota 6), p. 66, o frete é recebido não pela embarcação e seus instrumentos, mas para o transporte das mercadorias.

15 H. KRELLER, *Lex Rhodia*. Untersuchungen zur Quellengeschichte des römischen Seerechtes, in *ZHR* (*Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht*) 85 (1921), p. 554 (= § 116); L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia* cit. (nota 6), p. 66; G. HUBRECHT, *Quelques observations* cit. (nota 2), p. 6; e P. HUVELIN, *Études d'histoire* cit. (nota 6), p. 193.

Paulo está, assim, conforme a exposição de Jul. 86 dig., D. 14, 2, 6: “Navis adversa tempestate depressa ictu fulminis deustis armamentis et arbore et antenna Hipponem delata est ibique tumultuariis armamentis ad praesens comparatis Ostiam navigavit et onus integrum pertulit: quaesitum est, an hi, quorum onus fuit, nautae pro damno conferre debeant. respondit non debere: hic enim sumptus instruendae magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est.” [= “Uma embarcação atingida por uma difícil tempestade e com equipamentos, mastro e antena inteiramente queimados por um raio, foi levada à Hipona. Nesse local, tendo sido comprados, com pressa, equipamentos, ela navegou até Ostia e desembarcou sua carga de forma íntegra. Perguntou-se se estes, a quem a carga pertence, devem contribuir ao armador da embarcação em razão do dano. Responde-se que não, pois este gasto foi feito mais para equipar a embarcação do que para conservar as mercadorias.”]. Sobre o texto de Juliano, cf. R. L. VAZ SAMPAIO, Estado de Perigo no Código Civil de 2002: Notas Críticas, in *RT* (*Revista dos Tribunais*) 918 (2012), pp. 125-130.

16 P. HUVELIN, *Études d'histoire* cit. (nota 6), p. 184.

17 “Cum arbor aut aliud navis instrumentum removendi communis periculi causa deiectum est, contributio debetur” [= “Se o mastro - ou outro instrumento da embarcação - foi arremessado (ao mar), para remover um perigo comum, a contribuição é devida.”]. H. KRELLER, *Lex Rhodia* cit. (nota 15), p. 302 (= § 6), considera as Respostas de Papiniano (D. 14, 2, 3) mais recentes do que os Comentários ao Edito do Pretor, de Paulo. C. A. CANNATA, *Le disaventure del capitano J. P. Vos*, in *Labeo* (*Rassegna di Diritto Romano*) 41 (1995), pp. 396-397, nota a possível oposição entre D. 14, 2, 2, 1 e D. 14, 2, 3, pois este decide pelas avarias grossas e aquele não.

18 “Arbore caesa, ut navis cum mercibus liberari possit, aequitas contributionis habebit locum.” [= “Sendo cortado o mastro, para que a embarcação possa ser salva com as mercadorias, a equidade da contribuição terá lugar.”].

J.-J. AUBERT, *Dealing with the Abyss: The Nature and Purpose of the Rhodian Sea-Law on Jettison* (*Lex Rhodia De Iactu*, D. 14, 2) and the Making of Justinian’s Digest, in J. W. CAIRNS - P. J. DU PLESSIS (coords.), *Beyond Dogmatics - Law and Society in the Roman World*, Edinburgh, Edinburgh University, 2007, p. 165, afirma que, mesmo sendo soluções opostas, há repetição inútil de conteúdo em D. 14, 2, 2, 1, D. 14, 2, 3 e D. 14, 2, 5, 1.

G. HUBRECHT, *Quelques observations* cit. (nota 2), p. 6, acrescenta a este conjunto de textos ainda Paul. Sent. 2, 7, 3.

Ela deixa, assim, de se referir aos danos causados à embarcação e à carga, enquanto avarias simples¹⁹, e passa às hipóteses das grossas²⁰, por meio do motivo que as geraria, ou seja, a opinião dos comerciantes (“voluntate vectorum”) ou um caso fortuito (“propter aliquem metum”)²¹.

Pode ser que um trecho sobre avarias simples (“Si conservatis mercibus - locaverit opus”) seguido por outro sobre as grossas (“sed si - sarciri oportet”) dificilmente estariam próximos no mesmo texto.

De fato, naquelas, a necessidade é regra - o transportador marítimo deve armar ou reparar a embarcação, sob pena da viagem não continuar - e, nestas, é exceção. Porém, mesmo que não seja uma boa técnica jurídica as hipóteses serem descritas em conjunto²², é possível encontrar um motivo que justifique essa forma de exposição.

O “vel” que une “voluntate vectorum” e “propter aliquem metum” pode ser compreendido, para H. KRELLER, não como situações distintas, mas como duas condições necessárias²³. Assim, no lugar de “vel”, poderia se ler “et”. Nesse sentido, J. CUJAS²⁴, seguido por R.-J. POTHIER²⁵, já tinha decidido eliminar aquela conjunção alternativa.

Assim, “voluntate vectorum” indicaria tão somente que o dano devesse ser “intencional” e não propriamente “dos comerciantes”, ou seja, embora o texto seja expresso quanto a estes, basta apenas ouvi-los²⁶. Torna-se apenas parte da competência de decidir sobre o alijamento.

19 Em Jul. 86 dig., D. 14, 2, 6, também acontece a oposição entre embarcação e carga, segundo H. KRELLER, *Lex Rhodia* cit. (nota 15), pp. 290-291 (= § 4).

20 H. KRELLER, *Lex Rhodia* cit. (nota 15), p. 300 (= § 6).

21 J.-M. PARDESSUS, *Collection I* cit. (nota 7), p. 105, explica que “aliquem” não indica um temor qualquer. Esse evento seria o fundamento de Ulp. 41 ad Sab., D. 19, 5, 14 pr., em “servandarum mercium suarum causa” [= “para que as suas mercadorias fossem salvas”] (Cap. II. 4. 1).

Não se pode confundir o ato de execução do alijamento com o de decisão. Paul. Sent. 2, 7, 3, que não pertence à compilação justinianéia (D. 14, 2, 2, 1 nem se refere às Sentenças de Paulo), refere-se aquele ato (destruição de instrumentos da embarcação, que pode ser feita pelos próprios comerciantes) e não a este.

22 Para H. KRELLER, *Lex Rhodia* cit. (nota 15), p. 300 (= § 6) e A. BERGER, *Iulius (Paulus)*, in RE (Paulys-Wissowa Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft) 10-1 (1914), p. 695, este é o sinal que “sed si - sarciri oportet” não seria da autoria de Paulo [E. LEVY - E. RABEL (orgs.), *Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, t. 1, Weimar, Böhlau, 1929, p. 236]. H. KRELLER indica outros glossemas: “id detrimentum” não combina com os danos ocasionados à embarcação ou às mercadorias; “hoc ipsum” é muito empolado, F. DE MARTINO, *Lex Rhodia II* cit. (nota 5), p. 323, acredita que seja de origem grega, correspondendo a “τὸ αὐτό” [= “este mesmo”], e G. BESELER, *Beiträge IV* cit. (nota 7), p. 130, considera-o uma interpolação, cuja reconstrução seria somente “id” [= “isto”]; e “vel” parece ser indicio de um acréscimo realizado. G. BESELER, *Beiträge IV* cit. (nota 7), p. 130, acredita que “voluntate vectorum vel” seja uma interpolação [E. LEVY - E. RABEL (orgs.), *Index Interpolationum* cit. (nota 22), p. 236].

23 *Lex Rhodia* cit. (nota 15), p. 301 (= § 6). No mesmo sentido, E. CHEVREAU, *La lex Rhodia de iactu* cit. (nota 6), p. 77.

24 *Observationum* cit. (nota 10), p. 742. Para F. BASSET, *Des Avaries Communes (Droit Romain) - Du Connaissement (Droit Français)*, Paris, Rousseau, 1889, pp. 32-33 (= n. 14), J. CUJAS faz esse corte pois a expressão “voluntate vectorum” é “imprópria” (falta-lhe clareza) para designar a relação dos comerciantes a bordo com o alijamento.

25 *Pandectae Justinianae* cit. (nota 11), p. 445. G. L. M. CASAREGI, *Discursus Legales de Commercio - XLV* (1707), t. 1, 2ª ed., Firenze, Regia, 1719, p. 98, entende o trecho como “voluntate vectorum, idest proptem aliquem metum” [= “pela vontade dos comerciantes, ou seja, em razão de algum temor”]. Para ele, a leitura de “vel” é cumulativa ou mesmo exemplificativa.

26 A. DE SCHRYVER, *Commentaire* cit. (nota 7), pp. 60-61.

C. F. GLÜCK entende que “vel” deva ser lido como “veluti” ou “puta” [= “por exemplo”]²⁷. Poderia ser, segundo E. N. DI LAMPORO, a hipótese em que o magister navis, mesmo não considerando necessário o alijamento, cede à pressão dos navegantes²⁸.

Em sentido oposto, P. HUVELIN defende que “voluntate vectorum” e “propter aliquem metum” são duas hipóteses diversas²⁹.

“Voluntate vectorum”, por um lado, não se refere só ao alijamento, mas a qualquer hipótese em que o dano à embarcação seja provocado por acordo da junta deliberativa [“sed si” como “nisi si” (= “exceto se”)]. Não precisa haver um temor e mesmo que fosse uma avaria simples seria tratado como uma grossa³⁰.

Também E. N. DI LAMPORO entende que a expressão “voluntate vectorum” possibilita essa elasticidade do conceito de avarias grossas³¹.

“Propter aliquem metum”, por outro, refere-se a um perigo iminente a todos, e, assim, apenas às avarias grossas³². O magister navis pode decidir sozinho, sem a necessidade da junta³³.

Tratar-se-iam de duas hipóteses diversas, mesmo que o efeito fosse o mesmo (contribuição)³⁴.

H. KRELLER criticou essa interpretação. Para ele, falta a relação de “hoc ipsum sarciri oportet” [= “é necessário que esse mesmo seja ressarcido”] tanto com “voluntate vectorum” (relacionado à decisão sobre o evento), quanto com “propter aliquem metum” (que indica o motivo da avaria)³⁵.

27 Ausführliche Erläuterung cit. (nota 7), p. 218 (= § 887). Segue, assim, G. NOODT, Commentarium cit. (nota 9), p. 329. Para P. BONFANTE, Notas cit. (nota 12), p. 35, “vel” não pode ser emendado como “veluti”, mesmo que seu sentido não mudasse. Cf. C. BERTOLINI, Appunti didattici di diritto romano, vol. 7, Torino, Gerbone, 1908, p. 727 (= § 18); e A. LEFEBVRE D’OVIDIO, La contribuzione alle avarie comuni dal diritto romano all’Ordinanza del 1681, in Riv. Dir. Nav. (Rivista del Diritto della Navigazione) 1 (1935), p. 46 (= n. 7) [= IDEM, Teoria generale delle avarie comuni, Milano, Giuffrè, 1938].

28 De lege Rhodia de jactu (Dig. 14, 2), in AG (Archivio Giuridico “Filippo Serafini”) 27 (1881), p. 336. No mesmo sentido, G. TEDESCHI, Il diritto marittimo dei romani comparato al diritto marittimo italiano, Montefiascone, Silvio Pellico, 1899, p. 194. Essa seria a única hipótese em que haveria contribuição sem ter um real perigo comum aos olhos do magister navis. Já T. MOMMSEN, Digesta I cit. (nota 7), p. 419, tinha a mesma impressão.

29 Études d’histoire cit. (nota 6), p. 194. Da mesma forma, E. N. DI LAMPORO, De lege Rhodia de jactu cit. (nota 28), p. 336; e A. LEFEBVRE D’OVIDIO, La contribuzione cit. (nota 27), p. 47 (= n. 7).

A crítica é direta a J. CUJAS, Observationum cit. (nota 10), p. 742, que desejou suprimir a palavra “vel”, a fim de igualar as hipóteses (“voluntate vectorum propter aliquem metum”). Talvez por T. MOMMSEN, Digesta I cit. (nota 7), p. 419, supor que as palavras “vel propter metum” correspondam a uma pressão que os comerciantes presentes exercem sobre o magister navis, P. HUVELIN, Études d’histoire cit. (nota 6), pp. 193-194, fale erroneamente em “passageiro”, embora talvez desejasse dizer “comerciantes (a bordo)”. Tanto que sua tradução de “vector”, a princípio, é “comerciante”. Cf., também, A. LEFEBVRE D’OVIDIO, La contribuzione cit. (nota 27), p. 46 (= n. 7).

30 L. GOLDSCHMIDT, Lex Rhodia cit. (nota 6), p. 67. L. VACCA, La responsabilità del nauta per il ‘iactus mercium levandae navis gratia’ nel diritto romano classico, in Studi per Dante Gaeta, Milano, Giuffrè, 1984, p. 589, acredita que a frase refere-se simplesmente ao princípio da contribuição.

31 De lege Rhodia de jactu cit. (nota 28), p. 336. Na verdade, não se trata da elasticidade do instituto, mas do uso de uma ficção jurídica, ou seja, a avaria simples, mesmo não sendo, é interpretada como se grossa fosse.

32 P. HUVELIN, Études d’histoire cit. (nota 6), p. 194.

33 L. GOLDSCHMIDT, Lex Rhodia cit. (nota 6), p. 67.

34 P. HUVELIN, Études d’histoire cit. (nota 6), p. 194. Também, E. N. DI LAMPORO, De lege Rhodia de jactu cit. (nota 28), p. 336.

35 Lex Rhodia cit. (nota 15), p. 301 (= § 6).

Entretanto, não parece que essa relação de frases, por si, descaracterize dogmaticamente seja a quem incumbe julgar se o evento é ou não necessário, seja o conceito de avarias grossas.

Tanto a posição de P. HUVELIN (“voluntate vectorum” possibilita a avaria simples tornar-se grossa) como a de H. KRELLER (“voluntate vectorum” e “propter aliquem metum” devem ser entendidas como uma só hipótese de avarias grossas) diagnosticam (ambas) a existência de uma junta deliberativa³⁶.

L. DE SALVO³⁷ e J. ROUGÉ³⁸ defendem que esta fosse um costume no Mediterrâneo. Porém, em Roma, apenas se assim o desejar, o magister navis ouve os interessados no evento. A consulta parecia ser opcional.

De fato, os testemunhos das fontes literárias mostram que a opinião desses era descartável.

Existe apenas uma fonte grega sobre a junta deliberativa e as avarias³⁹. D(EMOSTHENES), *Contra Lacritum* 11⁴⁰ mostra que antes de realizar o alijamento existiria uma deliberação dos navegantes⁴¹.

Por esse texto, entendeu-se que, no século IV a.C., o capitão devesse consultar, antes de realizar o alijamento, os proprietários das mercadorias transportadas ou, na ausência desses, os seus representantes durante a viagem. Trata-se de fato comum no Mediterrâneo antigo os comerciantes acompanharem suas mercadorias⁴².

36 Também, F. WIEACKER, « Iactus in tributum nave salva venit » (D. 14, 2, 4 pr.) - Exegesen zur lex Rhodia de iactu, in *Studi per Emilio Albertario*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1953, p. 531, pela existência da junta, remetendo a H. KRELLER.

37 I corpora naviculariorum, in S. CALDERONE (org.), *KLEIO - Economia Privata e Pubblici Servizi nell'Impero Romano*, Messina, Samperi, 1992, p. 350.

38 *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire Romain*, Paris, SEVPEN, 1966, pp. 226-227.

39 F. DE MARTINO, *Lex Rhodia* – Note di diritto romano marittimo III, in *Diritto, Economia e Società nel Mondo Romano – Diritto Privato*, vol. 2, Napoli, Jovene, 1995, p. 365 [= *Lex Rhodia* III, in A. DELL'AGLI - T. S. VIGORITA (coords.), *Diritto e società nell'antica Roma II*, Roma, Riuniti, 1982; e, in *Riv. Dir. Nav. (Rivista del Diritto della Navigazione)* 4 (1938)]

40 “(...) ἐντελὲς πλὴν ἐκβολῆς, ἣν ἂν οἱ σύμπλοι ψηφισάμενοι κοινῇ ἐκβάλωνται, καὶ ἂν τι πολεμίοις ἀποτείσωσιν (...)” [= “(...) exceto pela dedução realizada quer se os navegantes consideraram, em comum, e arremessem, quer se resgatarem alguma coisa dos inimigos (...)”] (W. RENNIE, *Demosthenis Orationes*, t. 2-1, Oxford, Clarendon, 1921, p. 926). L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia* cit. (nota 6), p. 74, explica que o sentido de “οἱ σύμπλοι” seria correspondente ao de “ἐπιβαταί”, que, aproximadamente, significa “vectores”. Cf. W. ASHBURNER, *NOMOS ΡΟΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - The Rhodian Sea-Law*, Oxford, Clarendon, 1909, pp. CXXXVIII-CXL.

41 H. KRELLER, *Lex Rhodia* cit. (nota 15), pp. 301-302 (= § 6). F. DE MARTINO, *Lex Rhodia* II cit. (nota 5), p. 323, defende que a junta deliberativa já existisse na Grécia. Também, J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation* cit. (nota 38), pp. 226-227; e R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano, Giuffrè, 1946, p. 368.

42 V. HEUTGER, *Lex Rhodia and Unjust Enrichment*, in E. J. H. SCHRAGE (ed.), *Unjust Enrichment and the Law of Contract*, Den Haag, Kluwer, 2001, p. 218; e L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia* cit. (nota 6), pp. 74-75. Para J. L. ZAMORA MANZANO, *Averías y Accidentes en Derecho Marítimo Romano*, Madrid, Edisofer, 2000, pp. 117 e 119, por Demóstenes descrever uma deliberação no momento do alijamento, não se compreende a hipótese de D. 14, 2, 2, 1, que impõe a decisão dos comerciantes ao magister navis. Porém, não deixaria de ocorrer a junta deliberativa em Roma. F. DE MARTINO, *Lex Rhodia* – Note di diritto romano marittimo I, in *Diritto, Economia e Società nel Mondo Romano – Diritto Privato*, vol. I, Napoli, Jovene, 1995, p. 297 [= *Lex Rhodia* I, in A. DELL'AGLI - T. S. VIGORITA (coords.), *Diritto e società nell'antica Roma II*, Roma, Riuniti, 1982; e, in *Riv. Dir. Nav. (Rivista*

Entre os séculos I a.C. e I d.C., duas outras fontes referem-se a esse costume de consultar os que se encontram a bordo, mas não o fazem quanto ao alijamento: Cíc., Phil. 7, 27, no qual Cícero em seus discursos contra o triúnviro Marco Antônio, dirige-se ao cônsul Pansa, aconselhando-o a ouvir os navegantes⁴³; e Act. Ap. 27, 9-12⁴⁴, os quais mostram uma reunião entre o Apóstolo Paulo, o centurião, o piloto, o capitão e os demais a bordo, a fim de discutir a possibilidade ou de continuar a rota, ou de esperar para passar o inverno.

Entretanto, ao contrário da possível obrigatoriedade do costume, que talvez exista no texto de Demóstenes, por Cíc., Phil. 7, 27, e Act. Ap. 27, 9-12, não parece haver obrigatoriedade de se consultar os interessados no Direito Romano⁴⁵.

Nesse sentido, A. LEFEBVRE D'OVIDIO afirma que o consenso dos interessados - expresso (dos presentes) ou tácito (dos ausentes) - não é necessário para o alijamento, uma vez que o *magister navis* é o juiz (competente) de cada decisão e de nenhum texto resulta que ele deva

del Diritto della Navigazione) 3 (1937)]; e IDEM, *Lex Rhodia* III cit. (nota 39), p. 365, afirma que, no texto de Demóstenes, há dúvidas se o alijamento seria exigido pela junta, ou se, após aquele, ocorreria esta. Entretanto, de qualquer forma, existe uma deliberação anterior, que legitima o ato, ou posterior, que o ratifica.

43 “(...) Te ipsum, Pansa, moneo - quamquam non eges consilio, quo uales plurimum, tamen etiam summi gubernatores in magnis tempestatibus a uectoribus admoneri solent (...)” [= “(...) A ti próprio, Pansa, conselho - embora tu não tenhas necessidade de conselho, porque tu estás muito bem; todavia, também os sumos pilotos durante grandes tempestades devem ser aconselhados pelos navegantes - (...)”] (P. FEDELI, *M. Tvlli Ciceronis Scripta Omnia* - In *M. Antonivm Orationes Philippicae XIV*, Leipzig, Teubner, 1986, p. 106).

44 “Ἰκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισηφαλοῦς τοῦ πλοοῦς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρῆναι ὁ Παῦλος / λέγων αὐτοῖς□ ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσσεσθαι τὸν πλοῦν. / ὁ δὲ ἐκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήτῃ μᾶλλον ἐπιείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. / ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμέως ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιτο καταντήσαντες εἰς Φοῖνικα παραχειμαῖσαι” [= “Porém, tendo passado tempo suficiente e já sendo insegura a navegação a essa altura, por este motivo e porque já tivesse passado o jejum, Paulo advertia-os, / dizendo-lhes: ‘Homens, vejo que a navegação começa a ser destinada com violência e muito dano não somente à carga e à embarcação, mas também às nossas almas’. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao capitão do que àquelas coisas, as quais eram ditas por Paulo. E, dado o inconveniente do porto para passar o inverno, muitos julgaram melhor e decidiram, a partir de então, navegar para chegar, com todos os meios possíveis, à Fenícia, para passar o inverno”. Embora a manifestação de Paulo, a deliberação deve ter ocorrido apenas entre o centurião, o piloto e o capitão] (E. NESTLE - K. ALAND et. al., *Novum Testamentum Graece*, 26ª ed., Stuttgart, Bibelgesellschaft, 1990, p. 403). Nesse texto, A. PÓKECZ KOVÁCS, *Les problèmes du ‘iactus’ et de la ‘contributio’ dans la pratique de la lex Rhodia*, in *A bonis bona discere - Festgabe für János Zlinszky*, Miskolc, Bíbor, 1998, p. 181; J. ROUGÉ, *Recherches sur l’organisation cit.* (nota 38), pp. 399-400; e E. L. DE SALVO, *I corpora naviculariorum cit.* (nota 37), p. 350, excluem a possibilidade que o *magister navis* tenha de ouvir os demais interessados.

Porém, como observou H. KRELLER, *Lex Rhodia cit.* (nota 15), p. 301 (= § 6), os Atos dos Apóstolos não podem servir de base, como parece fazer L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia cit.* (nota 6), p. 69, para afirmar que na Grécia não havia junta deliberativa. H. KRELLER afirma que Lucas poderia ter ignorado na descrição do alijamento o momento de sua decisão, pois, para seu público leitor, isso seria irrelevante.

45 J. ROUGÉ, *Recherches sur l’organisation cit.* (nota 38), p. 226. H. KRELLER, *Lex Rhodia cit.* (nota 15), p. 301 (= § 6), expressamente afirma que, no período clássico, a junta deliberativa não apresenta qualquer poder decisório.

consultar os membros da junta deliberativa⁴⁶. F. BASSET está sozinho ao defender, contra essas fontes, a dispensa da decisão do magister navis⁴⁷.

Para P. HUVELIN, em parte, a junta deliberativa seria necessária, na hipótese de uma típica avaria simples ser considerada grossa pela concordância de todos⁴⁸. E o “vel” - “voluntate vectorum vel propter aliquem metum” - deveria ser mantido, pois, segundo J.-M. PARDESUS, se fosse suprimido, a consulta aos comerciantes seria sempre necessária para se decidir o alijamento⁴⁹.

A conjunção também aparece em Bas. 53, 3, 1 - correspondente quase exato de D. 14, 2, 2, 1 - e no qual em vez de “voluntate vectorum vel propter aliquem metum”, lê-se “κατὰ γνώμην τῶν ἐπβατῶν ἢ διὰ φόβον” [= a partir da vontade dos comerciantes ou se (houver) medo]⁵⁰.

O correspondente grego de “vel” - “ἦ” - confirmaria que seriam duas hipóteses diversas⁵¹.

P. HUVELIN traduz essa passagem de Bas. 53, 3, 1 por “par la volonté commune des passagers ou par crainte (d’un danger)” [= “pela vontade comum dos passageiros ou pela crença de um perigo”]⁵².

A. LEFEBVRE D’OVIDIO opõe-se a essa tradução, já que acredita que metus e φόβος também se refiram, respectivamente, a “vectores” e “ἐπβατῶν”: “per la comune volontà o il timore dei vectores” [= “pela vontade comum ou temor (ambos) dos navegantes”]⁵³.

Segundo ele, D. 14, 2, 2, 1, por meio da confirmação desse texto de Bas. 53, 3, 1, afirmaria que os danos provocados à embarcação, sem o alijamento, não originariam a contribuição. Porém, se o mesmo dano é ocasionado pela vontade dos comerciantes ou por um temor deles, haverá ressarcimento (pela lex Aquilia) da parte desses, não contribuição⁵⁴.

46 La contribuzione cit. (nota 27), p. 46 (= n. 7). Segue-o J. C. SAMPAIO LACERDA, Curso de Direito Privado da Navegação - Direito Marítimo, vol. 1, 3ª ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1984, p. 85 (= n. 55). Mesmo no exemplo oferecido por J. CUJAS, Observationum cit. (nota 10), p. 742, semelhante a Paul. Sent. 2, 7, 3, não se pode entender a expressão “voluntate vectorum” como algo diverso do consentimento (iniciativa ou consulta) dos comerciantes a bordo ou passageiros sobre o dano. Não se depreende do texto que a decisão tenha sido deles (embora o ato de execução possa ter sido).

47 Des Avaries Communes cit. (nota 24), p. 30 (= n. 13).

48 Études d’histoire cit. (nota 6), p. 194. Também, E. N. DI LAMPORO, De lege Rhodia de jactu cit. (nota 28), p. 336.

49 Collection I cit. (nota 7), p. 105.

50 “Διὰ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ πλοίου ἢ τὴν ἀποβολὴν τῆς ἐξαρκείας οὐ συνεισάγουσιν, εἰ μὴ ἄρα κατὰ γνώμην τῶν ἐπβατῶν ἢ διὰ φόβον ἢ ζημίᾳ γέγονεν· οὔτε γὰρ εἰ κλασθῇ ἐργαλεῖον τοῦ χαλκῆως, ὁ μισθωσάμενος αὐτὸ ζημιούται.” [= “Em razão do dano da embarcação ou do arremesso dos instrumentos [dessa], a colação não é feita, exceto se, então, a partir da vontade dos comerciantes ou se (houver) medo, ocorreu o dano; e nem, pois, se a ferramenta do operário é quebrada, uma perda é causada àquele que locou (o serviço)”] (texto só presente em SCHELTENA A VII, p. 2448).

51 P. HUVELIN, Études d’histoire cit. (nota 6), pp. 194-195; e A. LEFEBVRE D’OVIDIO, La contribuzione cit. (nota 27), p. 47 (= n. 7).

52 Études d’histoire cit. (nota 6), pp. 194-195.

53 La contribuzione cit. (nota 27), p. 47 (= n. 7).

54 No mesmo sentido, A. PÓKECZ KOVÁCS, Les problèmes cit. (nota 44), p. 181; e J. ROUGÉ, Recherches sur l’organisation cit. (nota 38), pp. 399-400.

P. HUVELIN estaria, em sua opinião, enganado quanto à possibilidade de se tratar de uma avaria comum. Os navegantes teriam que ressarcir todo o dano ocasionado e o magister navis (por não ser uma contribuição) estaria isento de qualquer responsabilidade.

Da mesma forma, J. ROUGÉ afirma que a frase “*voluntate vectorum*” representa não uma reunião, mas um “ato de revolta” ou “motim”, no qual os comerciantes arcam com todos os riscos e o magister navis não deve qualquer contribuição⁵⁵.

F. BASSET defende, ainda, que a expressão “*voluntate vectorum*” refere-se ao fato dos comerciantes realizarem eles mesmos o alijamento⁵⁶.

Entretanto, tanto D. 14, 2, 2, 1 como Bas. 53, 3, 1 são suficientemente claros contra as opiniões de A. LEFEBVRE D’OVIDIO, J. ROUGÉ e F. BASSET. A contribuição não é devida, “mas se” (“sed si”) ou “exceto se” (“*ἐὶ μὴ*”) houver a deliberação da junta. A avaria simples transforma-se, com a deliberação dessa, em grossa.

Dessa forma, na hipótese da avaria simples tornar-se grossa (logo, não do alijamento), a junta deliberativa deve vir a ser consultada. “*Voluntate vectorum*” indica que a consulta é parte do procedimento legítimo da hipótese.

A contrario sensu, no alijamento, parece compreensível que o magister navis escute os envolvidos, caso deseje - embora (juridicamente) não precise - justificar seu ato⁵⁷. Porém, ele não deixa de decidir sobre o evento e pode dispensar ouvir os demais.

Talvez, por “*voluntate vectorum vel*” ser uma interpolação⁵⁸ e não parte de um procedimento relacionado à competência, os compiladores justinianeus destacaram, nesse instituto, apenas a existência do hábito de se consultar a junta deliberativa.

II. DESENVOLVIMENTO POSTERIOR DA HIPÓTESE

É fácil constatar a existência de um jogo de poder entre o magister navis e a junta deliberativa. Em outras palavras, a leitura da *lex Rhodia* deve considerar quem comanda os atos referentes à náutica e, assim, quem pode decidir sobre a realização das avarias grossas.

Esse poder é, no período justinianeus e no alijamento, entregue ao magister navis. E, pela solução de Paulo, seu ato, mesmo sem consultar a junta deliberativa, parece legítimo, uma vez que ele é o responsável pelo transporte marítimo⁵⁹ e não há fontes jurídicas que o obriguem a consultar outrem⁶⁰.

Dessa forma, a junta deliberativa pode ou não ser consultada e corresponderia a um parecer (sem efeitos vinculantes), que o magister navis possa eventualmente se socorrer.

55 *Recherches sur l’organisation cit.* (nota 38), p. 227.

56 *Des Avaries Communes cit.* (nota 24), pp. 30-33 (= ns. 13-14).

57 L. GOLDSCHMIDT, *Lex Rhodia cit.* (nota 6), pp. 68-69.

58 G. BESELER, *Beiträge IV cit.* (nota 7), p. 130 [E. LEVY - E. RABEL (orgs.), *Index Interpolationum cit.* (nota 22), p. 236].

59 Convém lembrar, mais uma vez, D. 14, 1, 1, 1: “*Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est.*” [= “Devemos entender o magister navis como aquele a quem é confiada a direção de toda a embarcação.”].

60 A. LEFEBVRE D’OVIDIO, *La contribuzione cit.* (nota 27), p. 46 (= n. 7); e J. C. SAMPAIO LACERDA, *Curso cit.* (nota 46), p. 85 (= n. 55).

É certo, além disso, que D. 14, 2, 2, 1 - bem como D., Contra Lacritum 11 - não implica a sociedade entre os envolvidos no alijamento. Esse fundamento é apenas inaugurado no período bizantino, com as partes inicial e final de NRN (Nómos Rhodíōn Nautikós) 961.

Esse texto substitui as regras marítimas romanas por um novo sistema, baseado em uma relação mais estreita entre todos os interessados na empreitada marítima⁶².

Mesmo que as funções do ναύκληρος⁶³ tenham crescido no Direito Bizantino, em “Ἐὰν - ποιείτωσαν”, o imperativo “ἐπερωτάτω” exige que este, ao julgar conveniente o alijamento, consulte aqueles que estão a bordo.

Em seguida (“εἰ δὲ - ζημίαν”), refere-se a uma sociedade (κερδοκοινωνία) entre o capitão e os demais⁶⁴, na qual, segundo W. ASHBURNER⁶⁵ e J.-M. PARDESSUS⁶⁶, aquele entrega a embarcação e estes a carga, a fim de dividir perdas e ganhos.

Dessa modo, o texto passa da junta deliberativa à sociedade. A deliberação constitui um ato contratual, sem o qual o alijamento não seria legítimo⁶⁷, ou seja, a deliberação está intrinsecamente relacionada com a formação da sociedade. Esse parece ser também o sen-

61 “Περὶ ναυκλήρου καὶ ἐπιβατῶν περὶ ἀποβολῆς βουλευομένων. Ἐὰν περὶ ἐκβολῆς βουλευῇται ὁ ναύκληρος, ἐπερωτάτω τοὺς ἐπιβάτας οἷς χρήματά ἐστιν ἐν τῷ πλοίῳ. ὅτι δὲ ἐὰν γένηται, τοῦτο ψήφον ποιείτωσαν, (...) εἰ δὲ σύμφωνον κερδοκοινωνίας ἐστί, μετὰ τὸ ἅπαντα συμφηφισθῆναι τὰ ἐν τῷ πλοίῳ καὶ τὸ πλοῖον, κατὰ τὸ κέρδος ἕκαστος ἐπιγινωσκέτω καὶ τὴν προσγενομένην ζημίαν.” [= “Sobre a deliberação do capitão e dos que estão a bordo a respeito do alijamento. Se o capitão julgar conveniente o alijamento, consulte os que estão a bordo e com bens na embarcação. E tudo o que ocorrer, (esses) votem, (...) E se há um acordo sobre o lucro da sociedade, após tudo o que está na embarcação e esta própria tiverem sido levados à contribuição, cada um responda também pela perda que sobreveio em proporção ao lucro.”]. A melhor versão do Nómos Rhodíōn Nautikós parece ser a de W. ASHBURNER, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ cit. (nota 40), pp. 1-125 [= ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ, in J. ZEPI - P. ZEPI (orgs.), Jus Graecoromanum - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (1931), vol. 2, Darmstadt, Scientia Aalen, 1962] O texto reproduzido apresenta-se de forma idêntica em G. L. PERUGI, La legge navale dei Rodi, in Memorie - Istituto “Ferrini, dei Palinsesti, Roma, s. e., 1923, pp. 67-68. A única diferença é sua posição, já que, em vez de ser o nono seria o terceiro.

62 R. DARESTE, La lex Rhodia, in RPh (Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes) 29 (1905), pp. 3, 10-11 [= NRH (Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Étranger) 29 (1905)]

63 G. S. MARCOU, Nómos Rhodíōn Nautikós e la scoperta a Rodi di una colonna di marmo con l'iscrizione di Paolo (D. 14. 2.), in E. T. BULGHERINI (org.), Studi per Antonio Lefebvre d'Ovidio, t. 1, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 624-625, explica que o “capitão”, no Nómos Rhodíōn Nautikós, exerce, a princípio, mais funções que no período justinianeus, em especial a exploração comercial, que era do exercitor navis.

64 W. ASHBURNER, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ cit. (nota 40), pp. CCXXXIV-CCXXXVII, CCXLI-CCXLII; A. D'EMILIA, Diritto bizantino - Parte generale - Le fonti di cognizione, vol. 1, Roma, Pioda, 1963-1964, pp. 395-407; e G. S. MARCOU, Nómos Rhodíōn Nautikós cit. (nota 63), pp. 625-627.

Essa sociedade está presente em outros três textos (apresentados com as respectivas rubricas): “Περὶ πλοίου κλασματισθέντος εἰς γόμον ἀπερχομένου ἐμπόρου ἢ κοινωνίας” [= “Sobre a embarcação quebrada que, na origem, parte com mercadorias de um só comerciante ou que estabelece uma sociedade”] (NRN 27); “Περὶ πλοίου κλασματισθέντος ἐξ αἰτίας ἐμπόρου ἢ κοινωνοῦ” [= “Sobre a embarcação quebrada por causa do comerciante ou da sociedade”] (NRN 28); e “Περὶ πλοίου ναυλωθέντος ἢ κοινωνία πλεόντος καὶ ἐν τῷ ἐμπορίῳ κλασματισθέντος” [= “Sobre a embarcação conduzida pelo comandante, ou, sendo a sociedade iniciada, e, enquanto procura um porto, rompe-se”] (NRN 32).

65 W. ASHBURNER, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ cit. (nota 40), pp. CCXXXV-CCXXXVII.

66 Collection I cit. (nota 7), p. 225.

67 L. GOLDSCHMIDT, Lex Rhodia cit. (nota 6), pp. 328-331

tido da expressão “*voluntate navigantium*”, presente na definição de A. VINNEN⁶⁸ para as avarias grossas.

Nessa autêntica “sociedade de riscos” bizantina⁶⁹, na qual tanto o que se perde, como o que se ganha, entra no cálculo da contribuição, o capitão deixa de ser, ao menos quanto ao alijamento, o “verdadeiro senhor a bordo”⁷⁰.

O poder de decisão sobre este evento deixa de estar com ele e passa à junta deliberativa (a exceção do período justiniano quanto às avarias simples tidas como grossas passa a ser, agora, a regra).

Essa tendência aparece consolidada, como regra geral, no Consolat de la Mar LIV (aproximadamente 1336-1346), que traz o procedimento para um alijamento legítimo⁷¹.

A consulta à junta deliberativa torna-se, de fato, um dever jurídico e constitui parte do procedimento de decisão do alijamento.

Assim, duas tendências são historicamente delineadas. A primeira, mais antiga, sedimentada no decorrer do Direito Romano, e própria do período justiniano (D. 14, 2, 2 pr.-1), que concede o poder de decidir sobre a realização do alijamento ao *magister navis*; e a segunda, relacionada ao Direito Bizantino (NRN 9), que o transfere à junta deliberativa⁷².

Atualmente, os arts. 509 e 764 do CCom Brasileiro tratam do ato de decisão sobre a realização do alijamento⁷³.

68 Notae (1647) a P. PECK, In Titt. Dig. & Cod. ad Rem Nauticam Pertinentes, Commentarii (1556), 3ª ed., Amsterdam, Boom, 1668, p. 193: “Avaria grossa est, cum quaedam merces jaciuntur in mare levandae laborantis navis gratia, aut armamenta navis, malus, anchorae, rudentes, communis periculi removendi causa, dejiciuntur vel caeduntur voluntate navigantium: atque hoc damnum contributione omnium, atque ipsius etiam nautae resarcitur.” [= “A avaria grossa ocorre sempre que algumas mercadorias ou instrumentos da embarcação - mastro, âncoras e cabos - são arremessados ao mar para que essa, por estar em dificuldade, seja aliviada e a fim de remover perigo comum; (as mercadorias ou instrumentos da embarcação) são lançados (ao mar) ou sacrificados pela vontade dos navegantes: este dano é ressarcido tanto por uma contribuição de todos quanto também do próprio armador.”]

69 G. S. MARCOU, *Nómos Rhodíōn Nautikós* cit. (nota 63), p. 627.

70 J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation* cit. (nota 38), p. 399; e G. HUBRECHT, *Quelques observations* cit. (nota 2), p. 7.

71 “(...) lo senyor de la nau deu dir è manifestar à tots los mercaders en oida del notxer è de tots aquells qui en la nau seran: ‘(...) si vos altres, senyors mercaders, voleu que alleviassim (...)’, (...) E si los mercaders se acorden del gitar, tots ò la maior partida; là donchs ells poden gitar. (...) En aquell cas, è en aquella saó pot l’escrivá la convenença scriure (...) [= “(...) o capitão da embarcação deve dizer e manifestar a todos os comerciantes, em presença do contramestre e de todos aqueles que estão a bordo: ‘(...) se vocês, senhores comerciantes, querem que aliviem (...)’ (...) Se os comerciantes - todos ou a maior parte - acordam sobre o arremesso ao mar, então (o capitão) o pode fazer (...) Nesse caso e nesta circunstância, o escrivão tem direito de redigir a convenção (...)”].

Em “Cómo se debe compartir el daño de las mercadorias que echan en la mar por razon de tormenta” [= “Como se deve dividir o dano das mercadorias que são arremessadas ao mar em razão de tempestade”] (*Siete Partidas* 5, 9, 3), já existia uma referência à junta deliberativa: “(...) Et porque tal echamiento como este se face por pro comunalmente de todos los que estan en los navios (...)” [= “(...) E por que um alijamento como este se faz por comum acordo de todos que estão na embarcação (...)”] (*Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio*, t. 3, Madrid, Imprenta Real, 1807, p. 238).

72 Talvez aqui esteja a origem remota da sugestão de G. L. M. CASAREGI, *Discursus XLV* cit. (nota 25), p. 282 (= ns. 28-30), que distingue entre “alijamento regular” e “irregular”. O primeiro ocorre após a deliberação e o segundo, também denominado “quase-naufrágio” devido à urgência da situação, sem esta.

73 Respectivamente, “Nenhuma desculpa poderá desonerar o capitão que alterar a rota que era obrigado a seguir, ou que praticar algum ato extraordinário de que possa provir dano ao navio ou à carga, sem ter precedido deliberação tomada em junta composta de todos os oficiais da embarcação, e na presença dos interessados do navio

O Direito Marítimo brasileiro optou por uma saída intermediária, pela qual o capitão, por um lado, deve ouvir a junta deliberativa (próximo ao Direito Bizantino, já que, no período justinianeu, ele nem, ao menos, precisa se aconselhar), mas, por outro, além de ter o voto de qualidade, com o qual desempata a votação, pode decidir contra esta (o poder, como no período justinianeu, é mantido com o capitão)⁷⁴.

A orientação recente dos principais Códigos - aliás, hoje a lei é, na maioria, a fonte da contribuição, não mais os contratos (autêntica *condictio ex lege Rhodia*) - parece ser a do resgate do papel do capitão, enquanto chefe da embarcação, para que se configurem as avarias grossas⁷⁵. Trata-se, assim:

ou na carga, se algum se achar a bordo. Em tais deliberações, e em todas as mais que for obrigado a tomar com acordo dos oficiais do navio, o capitão tem voto de qualidade, e até mesmo poderá obrar contra o vencido, debaixo de sua responsabilidade pessoal, sempre que o julgar conveniente.” e “São avarias grossas: (...) E, em geral, os danos causados deliberadamente em caso de perigo ou desastre imprevisto, e sofridos como consequência imediata destes eventos, bem como as despesas feitas em iguais circunstâncias, depois de deliberações motivadas (artigo n.º 509), em bem e salvamento comum do navio e mercadorias, desde a sua carga e partida até o seu retorno e descarga.”

74 W. M. FERREIRA, Instituições de Direito Comercial - A Indústria da Navegação Marítima e Aérea, vol. 3, 2ª ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1949, p. 315 (= n. 1331).

A solução é semelhante àquela já apresentada pelos *Rooles ou Jugemens d'Oléron* 8 (séculos XI e XII): “Une neef s'enpart de Burdeaux oud'aillours, et avient que turment la prent en meer et qu'il ne poet eschaper sans jettre hors des darrées de dedans; le mestre est tenu dire as marchantz: 'Seignors, nous ne pouvons eschaper sans jettre des vins et des darrées.' Les marchantz, si en y a, repondront leur volonté qui agréeront bien de ce gietement si que les resons du mestre sont les plus cleres; et s'ils ne gréent mye, le mestre ne doit pas lesses pur ce qu'il n'en gience tant qu'il verra que bien soit (...)” [= “Se uma embarcação que parte de Bordéus - ou de outro lugar - é surpreendida por uma tempestade de tal forma que ela não pode escapar sem arremessar as mercadorias para fora, o seu capitão é obrigado a dizer aos comerciantes: 'Senhores, nós não podemos escapar sem arremessar os vinhos e mercadorias.' Os comerciantes, se aderirem, consentem quanto ao alijamento e (consentem) que as razões do capitão são as mais certas. E se eles não concordarem, este (o capitão) não deve deixar de fazer o arremesso ao mar, que ele crê ser necessário (...)”].

A deliberação, neste caso, segundo T. HARALAMBIDIS, *Des caractères distinctifs des avaries communes - Du fondement de la contribution à ces avaries en droit français et comparé*, 2ª ed., Paris, Générale de Droit et de Jurisprudence, 1924, p. 327, somente prova a existência do estado de necessidade, ou do perigo comum. Tratar-se-ia apenas de uma precaução para evitar sacrifícios inúteis, tanto que o capitão pode decidir contrariamente à junta.

No mesmo sentido, G. SCHAPS, *Das deutsche Seerecht*, in M. MITTELSTEIN - J. GEBBA (orgs.), *Kommentar zum vierten Buche des Handelsgesetzbuchs*, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1921, p. 207, para quem, o capitão pode se utilizar da deliberação prévia como fonte de legitimidade do alijamento (resqúcio bizantino e medieval), mas não depende dela para o realizar.

75 A Ordonnance de la Marine - diploma francês (1681) que serviu de base para as regras marítimas dos Códigos [A. LEFEBVRE D'OVIDIO, *La contribuzione cit.* (nota 27), pp. 126 e 130 (= n. 36)] - 3, 8, 1-2 dispunha: “(...) il en prendra l'avis des Marchands & des principaux de l'équipage.” [= “(...) ele (o capitão) ouvirá a opinião dos comerciantes e dos oficiais da tripulação.”] e “S'il y a diversité d'avis, celui du Maistre et de l'équipage sera suivy.” [= “Se houver divergência de opinião, aquela do capitão e da tripulação será seguida.”]. Segundo R.-J. VALIN, *Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la Marine*, t. 2, La Rochelle, Legier-Mesnier, 1760, p. 175, a opinião dos comerciantes era necessária, já que tinham interesse no evento.

Essa ordenação era provavelmente aplicada à Portugal em matéria marítima, por meio do § 9º da Lei da Boa Razão (1769). Essa estabelece que, nas matérias “Políticas, Economicas, Mercantis e Maritimas”, não se deveria socorrer do Direito Romano, mas das “Leis das Nações Christãs, illuminadas, e polidas”.

Para J. H. CORRÊA TELLES, *Commentário Crítico à Lei da Boa Razão*, Lisboa, Madre de Deus, 1865, pp. 63-64 (= ns. 141-145), as leis comerciais e marítimas existentes em Portugal não formavam um “Código regular

- i) na Alemanha, dos § 588 do HGB⁷⁶ e § 78⁷⁷ da BinnSchG;
- ii) na França, dos arts. 5133-3 e 5133-4 do Code de Transports⁷⁸;
- iii) na Itália, dos arts. 302 e 469 do C. Nav.⁷⁹;
- iv) e, em Portugal, do art. 635, § 1º do CCom Português⁸⁰.

Em outras palavras, o capitão deve “decidir” (ou, se não partir dele a iniciativa, “consentir com”) sua realização⁸¹. É uma questão de competência.

de Commercio” e, logo, a saída seriam as legislações das nações civilizadas da Europa (consideradas todas, menos a Turquia). A melhor opção em matéria marítima, à época, seria a Ordonnance de la Marine.

76 “Werden das Schiff, der Treibstoff, die Ladung oder mehrere dieser Sachen zur Errettung aus einer gemeinsamen Gefahr auf Anordnung des Kapitäns vorsätzlich beschädigt oder aufgeopfert oder werden zu diesem Zweck auf Anordnung des Kapitäns Aufwendungen gemacht (Große Haverei), so (...)” [= “(Se) a embarcação, o combustível, a carga ou outras dessas coisas são deterioradas ou sacrificadas premeditadamente sob ordem do capitão para a salvação de um perigo comum, ou despesas são feitas sob ordem do capitão para o mesmo objetivo (Avaria Grossa), então (...)”]. Antes da SeeHaRefG (Gesetz zur Reform des Seehandelsrechts) [= “Lei para a Reforma do Direito Comercial Marítimo”] (20 de abril de 2013), os §§ 518 e 700 revogs. dispunham: “Wenn der Kapitän in Fällen der Gefahr mit den Schiffsoffizieren einen Schiffsrat zu halten für angemessen findet, so ist er gleichwohl an die gefaßten Beschlüsse nicht gebunden; er bleibt stets für die von ihm getroffenen Maßregeln verantwortlich.” [= “Apesar do capitão considerar adequado, nos casos de perigo, realizar um conselho dos oficiais da embarcação, todavia ele não está vinculado às decisões tomadas. Ele permanece sempre responsável pelas medidas de segurança realizadas.”] e “Alle Schäden, die (...) von dem Kapitän oder auf dessen Geheiß vorsätzlich zugefügt werden (...) sind große Haverei.” [= “Todos os danos, que (...) são premeditadamente provocados pelo capitão ou por sua ordem (...) são avarias grossas.”]. Este último determinava que o capitão decidia sobre a realização do evento, embora não o realizasse pessoalmente.

77 A redação é semelhante ao § 588 do HGB, mas, em vez de “auf Anordnung des Kapitäns”, lê-se “auf Anordnung des Schiffers”.

78 “Les avaries communes sont décidées par le capitaine (...)” [= “As avarias comuns são decididas pelo capitão (...)”] e “(...) avarie commune décidé par le capitaine.” [= “(...) avaria comum decidida pelo capitão.”].

O art. 400 revog. do CCom Francês já seguia essa tendência: “(...) il prend l’avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l’équipage. S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi.” [= “(...) ele (o capitão) ouve a opinião dos interessados na carga que se encontram na embarcação e dos oficiais da tripulação. Se houver divergência de opinião, aquela do capitão e da tripulação é seguida.”].

A. DESJARDINS, *Traité de Droit Commercial Maritime*, t. 4, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1885, pp. 173-174 (= n. 973), defendia que, mesmo com este artigo, não havia necessidade de deliberação prévia, se não fosse possível realizá-la devido à urgência. A distinção entre alijamento regular e irregular, ou seja, com ou sem deliberação, deveria, assim, ser banida.

79 “(...) il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione (...)” [= “(...) o comandante (capitão) deve buscar assegurar o salvamento dessa (expedição) com todos os meios que estão em sua imediata disposição (...)”] e “Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell’articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni (...)” [= “As despesas e os danos diretamente produzidos pelas providências tomadas com moderação, segundo a norma do artigo 302, pelo comandante (capitão), ou por outros em seu lugar, para o salvamento da expedição, são avarias comuns (...)”].

80 “(...) São avarias grossas ou comuns todas as despesas extraordinárias e os sacrifícios feitos voluntariamente, com o fim de evitar um perigo, pelo capitão ou por sua ordem (...)”.

81 P. HECK, *Das Recht der großen Haverei*, Berlin, Müller, 1889, p. 125 (= § 13); L. TULLIO, *La contribuzione alle avarie comuni*, Padova, CEDAM, 1984, pp. 111 e 137 (= ns. 9 e 10); e U. LA TORRE, *Comando e comandante nell’esercizio della navigazione*, Napoli, Scientifiche Italiane, 1997, pp. 187-188 (= n. 50). No mesmo sentido, O. BRANDIS, *Das deutsche Seerecht - Die einzelnen seerechtlichen Schuldverhältnisse: Verträge des Seerechts und außervertragliche Haftung*, vol. 2, Leipzig, Göschen, 1908, p. 89 (= § 26); P. BRÜDERS - R. ULRICH, *Grosse*

Não parece haver, de fato, melhor pessoa para decidir sobre esse ato, uma vez que exerce o comando da embarcação e constitui o “centro de imputação” de todos os interesses envolvidos na empreitada marítima⁸².

Pela *lex Rhodia* ter sido parte do *ius gentium* romano e depois uma *lex Mercatoria* a partir do período medieval⁸³, a fim de manter a uniformidade no Direito Marítimo e evitar a ausência nos ordenamentos jurídicos de uma regra explícita e específica para a competência de decisão das avarias grossas, seria útil uma disposição internacional.

Infelizmente, as YAR (York-Antwerp Rules) 2004 não tratam do sujeito legítimo dessa decisão⁸⁴.

Haverei: Die Havariegrosse-Rechte der wichtigsten Staaten im Originaltext und in Übersetzung nebst Kommentar und einer vergleichenden Zusammenstellung der verschiedenen Rechte - Deutsches Recht, vol. 1, 2ª ed., Berlin, Mittler und Sohn, 1903, p. 32; A. BRUNETTI, *Diritto marittimo privato italiano*, vol. 3-2, Torino, UTET, 1938, pp. 38-39 (= n. 658); A. LUZZATI - P. G. LUZZATI - L. MAFFEI, *Avaria*, in *NNDI (Novissimo Digesto Italiano)* 1 (1957), p. 1630; A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, 12ª ed., Milano, Giuffrè, 2011, p. 560 (= n. 375); W. M. FERREIRA, *Instituições de Direito Comercial III cit.* (nota 488), p. 315 (= n. 1331); e H. WÜNSCH, *Gedanken cit.* (nota 75), p. 538.

82 U. LA TORRE, *Comando e comandante cit.* (nota 81), pp. 139-142 (= n. 37). Em sentido semelhante, M. M. COMENALE PINTO - S. ZUNARELLI *Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti*, vol. 1, 2ª ed., Milano, CEDAM, 2013, p. 585; F. BERLINGIERI, *Delle avarie e della contribuzione nelle avarie comuni - Dottrina, legislazione italiana e diritto comparato*, Torino, UTET, 1888, p. 36 (= n. 21); e R. LOBIANCO, *Le Regole di York e Anversa e la contribuzione alle avarie comuni*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 159.

83 E. CHEVREAU, *La lex Rhodia de iactu cit.* (nota 6), p. 73; J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation cit.* (nota 38), pp. 407-409; e R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations cit.* (nota 75), pp. 406-411. No mesmo sentido, embora de forma incerta, A. PETRUCCI, *Particolari aspetti giuridici dell'organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione*, in P. CERAMI - A. PETRUCCI (orgs.), *Diritto Commerciale Romano - Profilo Storico*, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 2009, pp. 249-261; e R. RICHICHI, *Paul. D. 14. 2. 2 pr. e la contribuzione alle avarie comuni in diritto romano*, in « *Antecessori oblata* ». Cinque studi per Aldo Dell'Oro, Padova, CEDAM, 2001, p. 168.

Nesse sentido, a sentença de 24 de março de 1999, do 4th Circuit (United States Court of Appeals) - Case “R.M.S. Titanic, Inc. v. Haver”, V-A: “(...) Although it would add little to recount the full history here, we note that codifications of maritime law have been preserved from ancient Rhodes (900 B.C.E.), Rome (Justinian's *Corpus Iuris Civilis*) (533 C.E.), City of Trani (Italy) (1063), England (the Law of Oleron) (1189), the Hanse Towns or Hanseatic League (1597), and France (1681), all articulating similar principles. And they all constitute a part of the continuing maritime tradition of the law of nations - the *jus gentium*.” [= (...) “Embora pouco se acrescente recontar toda sua história aqui, nós observamos que as codificações do Direito Marítimo vem sendo preservadas desde a antiga Rhodes (900 a.C.), Roma (*Corpus Iuris Civilis*, de Justiniano; 533 d.C.), Cidade de Trani (Italia; 1063), Inglaterra (*Rôles d'Oléron*; 1189); as cidades da Hanse ou Liga Hanseática (1597); e França (1681), todas articulando princípios similares. E todas elas constituem parte da contínua tradição marítima do direito das nações: o *ius gentium*”. Texto original do ILM (*International Legal Materials*) 38-4 (1999), p. 807].

84 A primeira parte da Rule A trata da competência, mas não a atribui a ninguém: “There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common maritime adventure. (...)” [= “Há um ato de avaria grossa se, e somente se, qualquer sacrifício ou gasto extraordinário é feito ou realizado intencional e razoavelmente para o salvamento comum e com o objetivo de proteger de um perigo os bens envolvidos em uma expedição marítima comum. (...)”].

Segundo A. LUZZATI - P. G. LUZZATI - L. MAFFEI, *Avaria cit.* (nota 81), p. 1631, a redação da Rule A preocupa-se com a identificação do conceito de avarias grossas e não com quem as decide. Porém, dessa forma, a questão fica em aberto e a competência para decidir o alijamento não fica bem delimitada.

A. TORRENTE, *Avaria*, in *ED (Enciclopedia del Diritto)* 4 (1959), p. 588, defende que a ausência de alguém com legitimidade ativa nas YAR não influi no ordenamento jurídico italiano - e nos demais -, pois o art. 469 do C. Nav., concede expressamente o poder ao capitão (ou a alguém de sua hierarquia). E A. KOSSI - F. THOO, *Le règle-*

Embora a consulta à junta deliberativa seja, a partir do NRN 9, em regra, parte do elemento do instituto⁸⁵, deve-se respeitar, em uma possível redação, a tendência atual do jogo de poder, que, como ocorria no período justiniano, tende ao capitão da embarcação⁸⁶ (preocupação típica romana, esboçada nos esquemas de D. 14, 2, 2 pr.): “Antes de realizadas, as avarias grossas devem ser precedidas de uma junta deliberativa, composta pelos oficiais da embarcação e, se existirem, pelos comerciantes a bordo e passageiros⁸⁷, mas a decisão, mesmo se contrária à deliberação, cabe sempre ao capitão e, em sua ausência, a quem tiver o comando da embarcação”.

Assim, parece ser o melhor conselho a ser seguido no alijamento, desde Roma até os dias atuais, aquele oferecido por SALL., Catil. 1, 6 em um contexto militar: “(...) prius quam incipias consulto, et ubi consulueris mature facto opus est.” [= “(...) antes que tu comeces, é preciso deliberar, e, logo que tenhas deliberado, é preciso agir sem demora.”]⁸⁸.

ment contentieux des avaries de la phase de transport maritime en droit comparé entre l’Allemagne et la France, avec le droit substantiel du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria, Münster, LIT, 2003, pp. 36-37, relacionam a competência mencionada na Rule A ao capitão.

Para A. BRUNETTI, *Diritto marittimo III-II cit.* (nota 81), p. 39 (= n. 658), o silêncio da Rule A e do § 700 revog. do HGB seriam um sinal de que a junta deliberativa estaria extinta. Porém, ele esquece da previsão do § 518 revog. (atual § 588). Por fim, em sua obra anterior [A. BRUNETTI, *Commentario al Codice di Commercio - Del commercio marittimo e della navigazione*, vol. 6, Milano, Francesco Vallardi, 1920, p. 975 (= n. 675)], ele admitia que, em regra, havia uma deliberação prévia.

85 Em CHATEAUBRIAND, *Itinéraire*, p. 212, há uma curiosa descrição do que uma tripulação grega normalmente faz na hipótese de perigo no mar: “(...) A la moindre apparence de danger, on déploie sur le pont des cartes françaises et italiennes; tout l’équipage se couche à plat ventre, le capitaine à la tête; on examine la carte, on en suit les dessins avec le doigt; on tâche de reconnaître l’endroit où l’on est; chacun donne son avis (...)” [= “(...) Ao menor indício de perigo, dispõe-se sobre o convés os mapas franceses e italianos; toda a tripulação vai à parte de trás da embarcação (popa), o capitão à frente; examina-se o mapa; em seguida, acompanham-se os desenhos com o dedo; esforça-se para reconhecer a localização em que se está; cada um dá sua opinião (...)”].

86 Segundo U. LA TORRE, *Comando e comandante cit.* (nota 81), p. 185 (= n. 50), esse retorno ao modelo romano já ocorre em *Ordonnance de la Marine* 3, 8, 1-2.

87 A junta deliberativa nos Códigos - em especial, no art. 509 do CCom Brasileiro, no art. 400 revog. do CCom Francês, e no § 518 revog. do HGB - não é formada tipicamente apenas pelos comerciantes a bordo e passageiros, como no Direito Romano (segundo Cíc., *Phil.* 7, 27, e D. 14, 2, 2, 1). Também fazem parte dela os oficiais da embarcação (uma das inspirações pode ser Act. Ap. 27, 9-12, texto que menciona a participação do piloto). O mesmo se lê em *Ordonnance de la Marine* 3, 8, 1-2 e na descrição de CHATEAUBRIAND, *Itinéraire*, p. 212. Talvez o motivo dessa ampliação, seja, segundo J. C. SAMPAIO LACERDA, *Curso cit.* (nota 46), p. 231 (= n. 184), o fato da carga não ser, em regra, no comércio marítimo atual, acompanhada por seus proprietários, ou representantes desses. De qualquer forma, a junta deliberativa, embora varie seus membros, deve ocorrer. E. M. OCTAVIANO MARTINS, *Curso de Direito Marítimo - Teoria Geral*, vol. 1, 4ª ed., Barueri, Manole, 2013, p. 389 (= n. 2), defende, assim, que, ao ser possível, o capitão deve consultar os donos da carga (e os passageiros), a fim de adotar medidas extraordinárias.

88 Texto latino de A. KURFESS, C. Sallustius Crispus - *Catilina Iugurtha Fragmenta Ampliora*, Leipzig, Teubner, 1957, pp. 2-3.

BREVES REFFLEXÕES SOBRE BANQUEIROS, JUROS E USURA– DA LEI DAS XII TÁBUAS AO SÉCULO XXI

ALOÍSIO SURGIK

Universidade Federal do Paraná

“Se alguém coloca o seu dinheiro a juros superiores a 1% ao ano, seja condenado a devolver o quádruplo” (XII Táb. III, 2).

INTRODUÇÃO

A longa história da exploração do ser humano pelo próprio ser humano torna cada vez mais difícil ao estudioso do Direito apresentar um trabalho acadêmico definitivamente completo quanto às reais dimensões das injustiças que vêm ocorrendo há milênios com a usura bancária.

Nos limites da presente comunicação, é possível tão somente formular breves reflexões, mostrando o contraste brutal entre o preceito simples e claro da Lei das XII Tábuas e as absurdas distorções que ocorrem atualmente na atividade bancária.

Usura, em seu sentido amplo e original, são **juros excessivos** cobrados por empréstimo, em determinada quantia de dinheiro.

Na Idade Média, usura e juros eram sinônimos, considerando-se prática proibida, porque se acreditava que dinheiro não poderia gerar dinheiro. Era ainda a época em que a cobrança de juros entendia-se como forma de exploração dos mais fracos, sendo necessário por isso que todos os empréstimos financeiros fossem realizados sem cobrança de taxa alguma.

Com o constante desenvolvimento e imposição do sistema financeiro, os pensadores começaram a considerar justo que o credor recebesse uma parte dos lucros obtidos com seu empréstimo, sob a forma de juros, e no final do século XV surgiram as primeiras tabelas a limitar os valores cobrados pelo empréstimo de dinheiro.

Surgiu então a principal diferença entre juro e usura. Juro era a taxa cobrada dentro dos valores estipulados na tabela prevista em lei, enquanto usura passou a ser o termo utilizado para se referir à cobrança de taxas superiores ao limite máximo permitido.

Ocorre que a palavra **usura**, cujo significado original correspondia, portanto, à ideia de avaréza, ambição, ganância, cobiça ou lucro excessivo, hoje, nem sequer se distingue dos juros, pois estes já ultrapassam até mesmo todos os limites da própria usura.

DINHEIRO A PARTIR DO NADA

“O dinheiro é criado a partir do nada pelos banqueiros que, a partir dessa ilusão, se apoderam da riqueza produzida por todos os outros cidadãos”.¹

Conforme opinião generalizada, o dinheiro é criado pelo poder público, o que não deixa de ser verdade até certo ponto. De fato, esses símbolos de valor de metal e de papel que costumamos pensar como dinheiro são, na verdade, produzidos por uma agência governamental chamada Casa da Moeda. Porém, a grande maioria do dinheiro nem é produto da Casa da Moeda.

A maioria das pessoas pensa que os banqueiros emprestam o dinheiro que lhes foi confiado por depositantes. Porém, isso não é verdade. Importa lembrar que os bancos criam o dinheiro que emprestam, não dos ganhos dos próprios bancos, mas das garantias assumidas pelas mesmas pessoas que pedem o dinheiro emprestado.

O compromisso imposto a quem recebe dinheiro emprestado já é uma garantia de pagamento ao banco referente ao empréstimo, acrescido dos juros e outras obrigações, sob pena de o devedor perder a casa, o carro, assim como qualquer bem que tenha dado em garantia. É um grande compromisso que pesa para o devedor, não para o banco.

De fato, com a formalização de tal negócio, qual poderia ser a obrigação assumida pelo banco? Nenhuma. Ele, simplesmente, faz surgir **do nada** o valor total do empréstimo que inscreve na conta do devedor.

ATIVIDADES BACÁRIAS EM ROMA

Pouco sabemos sobre o sistema bancário romano, ao contrário do que podemos conhecer acerca das instituições gregas, sobretudo pelos escritos de Isócrates e Demóstenes. Seja como for, sabe-se que as movimentações bancárias e o depósito monetário irregular eram, sim, práticas amplamente desenvolvidas em Roma, tanto assim que a própria Lei das XII Tábuas, segundo algumas teorias, teria nascido como decorrência da exploração dos plebeus pelos patrícios.

Entretanto, deve-se ressaltar que, na República Romana, os *argentarii*, como eram denominados os banqueiros em Roma, deviam custodiar e guardar os depósitos com a máxima diligência, podendo o depositante confiar aos banqueiros a realização de pagamentos em seu nome. Estes, por sua vez, aceitavam, igualmente, “depósitos” a prazo, que não eram senão empréstimos ao banco ou contratos de mútuo, sobre os quais os depositantes pagavam juros, tendo os bancos o direito de os usar de acordo com as próprias conveniências durante o prazo fixado. Existem referências a tais práticas que remontam desde o ano 350 antes da nossa era, principalmente em algumas comédias, como por exemplo, *Captivi*, *Asinaria* e *Mostellaria*, de Plauto, e *Formio* de Terêncio, em que se encontram interessantes diálogos com as descrições de operações financeiras, compensações, balanços de contas, envio de cheques e outras atividades afins. De qualquer forma, aparentemente, a atividade bancária era mais controlada e, pelo menos, existia certa consciência do caráter justo ou injusto, graças à contribuição dos jurisconsultos. Isso não significa que todos os banqueiros se

¹ <http://citadino.blogspot.com.br/2013/05/o-dinheiro-e-criado-partir-do-nada.html>. Acesso em 16/02/2014.

comportassem honradamente e não usassem em benefício próprio o dinheiro depositado à vista pelos clientes, principalmente no período imperial. Até existe, neste sentido, um escrito de Adriano aos comerciantes de Pérgamo que se queixavam das exações legais e do mau comportamento dos bancos. Há, ainda, notícias de escritos dirigidos ao imperador Sétimo Severo no sentido de regular a atividade dos banqueiros. Tudo isto indica que, embora fossem talvez menos frequentes do que no mundo helênico, existiram, entretanto, banqueiros com poucos escrúpulos em se apropriar indevidamente dos fundos dos depositantes que, em última instância, acabavam por falir.²

A MAIOR FRAUDE DA HISTÓRIA

Sob este título, vale lembrar e sintetizar em linhas gerais o notável estudo realizado por Nehemias Gueiros Jr, advogado especializado em Direito Autoral e *CyberLaw*, Professor da Fundação Getúlio Vargas/RJ, Professor da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da OAB/RJ e Consultor Jurídico do site CONJUR (www.conjur.com.br). Ele abre sua exposição com duas citações:

“Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis.”

Mayer Amschel (Bauer) Rothschild

“Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda a indústria e comércio, e quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada, de uma forma ou de outra, por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão.”

James Garfield
Presidente dos EEUU, 1881.

Poucas semanas após proferir estas palavras (da segunda citação), dirigidas aos *moneychangers*, o presidente Garfield foi assassinado. E não foi o único presidente dos EEUU morto por eles.³

Já em Roma tinham ocorrido assassinatos de autoridades por terem pretendido implantar leis de reforma limitando a posse de terras ao máximo de 500 acres e liberando a cunhagem de moedas, que era feita pelos especuladores. No ano 48 antes da nossa era, Júlio César recuperou o poder de emitir moeda, tornando-o disponível para qualquer um que possuísse ouro ou prata. Também acabou assassinado. Em seguida, as pessoas comuns perderam suas casas e seus bens, da mesma forma como veio a acontecer recentemente na crise das hipotecas dos Estados Unidos.

² **Moedas, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos** – Instituto Ludwig von Mises Brasil – “Banqueiros em Roma” - Pesquisa Google. Acesso em 23/02/2014.

³ GUEIROS JR Nehemias. **A maior fraude da História**. Fonte: Jornal “Pravda”. Pesquisa Google. Acesso em 23/02/2014.

Ao longo da História, inúmeros banqueiros continuaram a expandir a usura em todos os segmentos da vida, criando expansões e negócios financeiros, de geração em geração, enfrentando monarcas e líderes políticos com disposição de erradicá-la, sempre sem sucesso. A cada bem-sucedida (e rara) tentativa de eliminá-la, a usura voltava com mais força ainda, respaldada pela ganância e o poder dos ricos contra os pobres.

De nada valeu o exemplo da Idade Média, em que a Igreja proibiu a cobrança de juros sobre os empréstimos, e com base nos ensinamentos e na doutrina de Aristóteles e Tomás de Aquino, afirmou que “*o propósito do dinheiro é servir à sociedade e facilitar a troca de bens necessária à condução da vida.*” Entretanto, paradoxalmente, as próprias autoridades eclesásticas passaram a conspirar com o poder civil para acumular dinheiro e consolidar seu poder através dos séculos, controlando os oprimidos. Os argentários continuaram a praticar a usura, hoje consagrada por lei através da prática bancária. Embora vários religiosos e teólogos condenassem a escravização econômica resultante da usura, essa prática expandiu-se ininterruptamente, agravando-se cada vez mais, até hoje.

Na medida em que a usura foi se instalando em todas as camadas sociais, os moneychangers foram ficando cada vez mais ousados em suas manipulações financeiras e foi assim que surgiu o famigerado conceito do fractional reserve lending, o “empréstimo baseado em reserva fracional” ou “empréstimo sem cobertura ou lastro”. Embora de enunciado complexo, a prática é muito simples. Significa emprestar mais dinheiro do que se tem em caixa e transformou-se na maior fraude de todos os tempos, principal responsável pela vasta pobreza que assola o mundo até hoje e pela redução sistemática do valor do dinheiro. A descrição dos economistas sobre os chamados “ciclos econômicos”, nada mais é do que a identificação dos períodos de expansão e retração determinados pelos bancos em todo o mundo, através do fractional reserve lending. Eles simplesmente adotaram as regras do passado e continuaram a praticá-las até hoje.⁴

No início do século XVIII, o alemão Amshel Moses Bauer,⁵ ourives e agiota que vivia em Frankfurt, na Alemanha, começou um negócio a que denominou de *Rothschild*, pois a insígnia na porta da sua loja era uma águia romana sobre um escudo vermelho. *Rothschild*, em alemão, significa “escudo vermelho”. O negócio prosperou tanto que em 1743 ele mudou seu nome para Amshel Moses Rothschild. Seus cinco filhos, ao atingirem a maioridade, foram enviados cada um a uma capital comercial da Europa, a fim de emprestar dinheiro a juros, principalmente às monarquias e reinos. O mais velho, Amschel, ficou em Frankfurt; Solomon foi para Viena; Nathan para Londres, Jacob para Paris e Carl para Nápoles. “Assim foram plantadas as sementes que permitiram à mais poderosa e rica família da história do mundo reinar nos séculos seguintes da evolução da humanidade, com o único propósito de lucro e poder, fosse qual fosse o custo. Gerações seguidas dos Rothschild e seus correligionários exercem — e continuam exercendo — poder sobre a sociedade mundial, utilizando-se da antiga prática da usura e do *fractional reserve lending*.⁶

Com seus cinco filhos tão firmemente encastelados em todos os centros financeiros da Europa, a família Rothschild logo alcançou a mais alta posição das famílias mais ricas do

4 Idem, *ibidem*.

5 Pai de Mayer Amshel Rothschild, autor da afirmação acima citada.

6 GUEIROS JR, Nehemias, cit. *ut supra*.

planeta. “Esta situação persiste até hoje, embora eles professem uma postura de discrição, avessa à mídia e à divulgação. Nenhuma família ou grupo empresarial possui tanto poder e controle financeiro em todos os países do mundo como os Rothschild. E isto há 250 anos.”⁷

Para entendermos a complexa rede de poder que os banqueiros exercem até hoje no mundo, é imprescindível uma ligeira retrospectiva sobre a origem histórica dos bancos centrais.

O primeiro banco central de um país a praticar o fractional reserve lending, ou FRL foi o Bank of England (Banco da Inglaterra), constituído em 1694 e de natureza privada. Era controlado por acionistas fraudulentos e mal-intencionados que utilizaram o mote “people’s bank” (banco do povo), para praticar toda sorte de fraudes visando unicamente o lucro. As dívidas com o Banco da Inglaterra de centenas de gerações posteriores, representadas ou pela própria monarquia inglesa ou pelo governo, foram asseguradas através da criação de taxas impostas à população, que viriam a se transformar no Imposto de Renda como hoje o conhecemos. O modelo do Banco da Inglaterra rapidamente se transformou no modelo para os bancos centrais de todos os países no mundo atual. Os agiotas descobriram que é muito mais lucrativo emprestar para monarcas e governos do que para cidadãos comuns. Através da dívida, tornavam-se literalmente credores e soberanos de nações inteiras.⁸

Assim, da Inglaterra, a experiência do Banco Central se estendeu aos EEUU, e daí, para o mundo.

Nos quase 200 anos que se passaram entre a independência dos EEUU e a criação do Federal Reserve Bank (Banco Central dos Estados Unidos), popularmente conhecido como FED, várias vezes a família Rothschild tentou controlar a emissão de moeda nos EEUU. Em cada tentativa, eles procuraram estabelecer um banco central privado, operando apenas com a finalidade de lucro e não para administrar ou proteger a economia estadunidense. “Cada uma dessas tentativas até 1913 foi oposicionada por políticos decentes e honestos, a maioria dos quais acabou assassinada por encomenda dos moneychangers”.⁹

No dia 22 de dezembro de 1913, às 11h da manhã, com um *quorum* ínfimo de apenas três senadores e apoiada pelo próprio presidente Woodrow Wilson, conforme lembra Gueiros Jr, o *Federal Reserve Act* foi aprovado sem dissidências. Naquele mesmo dia, o congressista Lindbergh alertara: “*Essa lei estabelece um mastodôntico feudo monetário (money trust) na Terra. Quando o presidente assiná-la, um governo invisível representado pelo poder monetário será legalizado em nosso país. As pessoas podem não perceber imediatamente, mas a verdade virá à tona no futuro. O pior crime legislativo da História está sendo perpetrado por essa lei dos banqueiros.*”¹⁰

Esse verdadeiro ato de ganância e traição ao povo dos EEUU foi o resultado de uma longa batalha entre os *moneychangers* da Europa e os políticos estadunidenses honestos. O sistema de *fractional reserve lending* (empréstimo sem lastro) seria para sempre o desejo dos mercadores, agiotas e usurários e efetivamente nunca mudou desde o início do Renascimento quando começou a ser praticado. Outro ingrediente fundamental dessa equação era a taxação do povo e que foi consagrada pela nova lei. A constituição dos EEUU vetava a

7 Idem, *ibidem*.

8 Idem, *ibidem*.

9 Idem, *ibidem*.

10 *Apud* GUEIROS JR, *ut supra*.

imposição de quaisquer taxas sobre a população. “Apenas os estados podiam criar taxas e emolumentos, como fora o desejo dos *founding fathers*. A curiosa coincidência é que apenas semanas antes da promulgação do *Federal Reserve Act*, o congresso havia aprovado uma lei criando o imposto de renda. Até hoje historiadores e estudiosos têm dúvidas se esta lei foi adequadamente ratificada antes de entrar em vigor”.¹¹

O FED começou a operar com cerca de 300 pessoas e outros bancos que adquiriram quotas de US\$ 100.00 (a empresa é fechada, não negocia ações em bolsa) e se tornaram proprietários do *Federal Reserve System*. Criaram uma gigantesca estrutura financeira internacional com ativos incalculáveis, na casa dos trilhões de dólares. O sistema FED arrecada bilhões de dólares em juros anualmente e distribui os lucros aos seus acionistas. Além disso, o congresso dos EEUU concedeu ao FED o direito de emitir moeda através do Tesouro (*Dept. of the Treasury*) sem cobrança de juros. “O FED imprime dinheiro sem lastro, sem qualquer cobertura, e empresta-o a todas as pessoas através da rede de bancos afiliados, cobrando juros por isso. A instituição também compra dívidas governamentais com dinheiro impresso sem lastro e cobra juros ao governo americano que acabam incidindo sobre as contas do cidadão comum pagador de impostos”.¹²

O *Federal Reserve Bank* (Banco Central dos Estados Unidos) é, na realidade, a ponta-líder de um conglomerado de bancos internacionais e pessoas físicas unicamente dedicados a perseguir o lucro, todos eles constituindo a revelação de um dos maiores segredos dos últimos 100 anos:

Rothschild Bank of London
Warburg Bank of Hamburg
Rothschild Bank of Berlin
Lehman Brothers of New York¹³
Lazard Brothers of Paris
Kuhn Loeb Bank of New York
Israel Moses Seif Banks of Italy
Goldman, Sachs of New York
Warburg Bank of Amsterdam
Chase Manhattan Bank of New York
First National Bank of New York
James Stillman
National City Bank of New York
Mary W. Harnman
National Bank of Commerce, New York
A.D. Jiullard
Hanover National Bank, New York

11 Idem, *ibidem*.

12 Idem, *ibidem*.

13 A Lehman Brothers pediu concordata em setembro de 2008, através da Seção Onze do U.S. Bankruptcy Code (*Chapter Eleven*).

Jacob Schiff
Chase National Bank, New York
Thomas F. Ryan
Paul Warburg
William Rockefeller
Levi P. Morton
M.T. Pyne
George F. Baker
Percy Pyne
Mrs. G.F. St. George
J.W. Sterling
Katherine St. George
H.P. Davidson
J.P. Morgan (Equitable Life/Mutual Life)
Edith Brevour
T. Baker

No Século XX, os *moneychangers*, sempre representados pelos Rothschilds e seus áulicos, já estavam firmemente estabelecidos com seus bancos centrais e sua prática do *fractional reserve lending* (empréstimo sem lastro) em todas as grandes capitais da Europa, embora, nos Estados Unidos, desde a proclamação da independência, políticos sérios e comprometidos com o desenvolvimento e o bem-estar da população se insurgissem contra os *moneychangers*.

Reverendo a história do Século XX e a dos Estados Unidos em particular, “podemos observar claramente como a sombra gananciosa e sinistra dos poderosos *moneychangers* manipula a agenda planetária até hoje. A prática de financiar os dois lados de um conflito, por exemplo, tornou-se uma de suas atividades regulares, opondo o capitalismo ao comunismo e este ao socialismo, religiões contra religiões e raças contra raças. Durante todo o século passado, os *moneychangers*, que não têm país, bandeira, hino ou deus, tiveram o controle em suas mãos”.¹⁴

1. ATIVIDADES BANCÁRIAS NO BRASIL

Não é de hoje que o Brasil vem sofrendo o grande peso da dominação de poderosos banqueiros.

Já na década de 1930, em alentada obra sobre o tema, o escritor Gustavo Barroso, conhecido por sua grande contribuição na literatura brasileira, com 128 livros, tendo sido fundador e diretor do Museu Histórico Nacional, membro da Academia Portuguesa da História, assim como da Academia das Ciências de Lisboa e Presidente da Academia Brasileira de Letras, além de outras atividades, deixou uma obra específica sobre a ação dos banqueiros no Brasil.¹⁵

¹⁴ GUEIROS JR, Nehemias, cit. *ut supra*.

¹⁵ BARROSO, Gustavo. **Brasil – Colônia de Banqueiros (História dos empréstimos de 1824 a 1934)**. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S/A, 1936.

Já no primeiro capítulo, referente aos empréstimos do Brasil durante a Monarquia (1824-1889), mencionou um relatório do Ministério da Fazenda à época, lembrando uma afirmação do então Ministro:

“Ousei rasgar o espesso e misterioso véu que cobria o Tesouro, persuadido de que a desconsolação pública e a extinção do patriotismo andam a par da miséria pública; de que a ruína dos Estados, a queda dos Impérios são consequências das desordens das finanças”.

(Relatório do Ministro da Fazenda, Manuel Jacinto Nogueira da Gama, Visconde de Baependi, em 1823).

O grande problema é que o Brasil, apesar de ter conseguido a independência de Portugal em 1822, não conseguiu libertar-se da metrópole comercial inglesa, principalmente em razão dos efeitos do Tratado Preferencial de Comércio, assinado em 10 de fevereiro de 1810. Por ele, os ingleses passaram a dominar comercialmente o Brasil. Era um verdadeiro monopólio comercial. “E passamos a um jugo pior: fomos transformados em colônia da casa bancária judaica Rotschild, em colônia do supercapitalismo internacional, que não tem pátria e como que obedece a leis secretas de aniquilamento de todos os povos”.¹⁶

Toda essa longa história de dominação imposta pelo poder econômico, que até hoje nos aflige, tem origem nessa adesão do Brasil ao sistema capitalista, assim explicado por Gustavo Barroso: “O capitalismo é hoje, no mundo, um permanente proletalizador das massas, um continuo transmutador de valores morais, um açambarcador de economias privadas, um opressor da agricultura, da indústria e do comércio, tudo submetendo ao seu império”.¹⁷

Na demonstração dos estreitos vínculos entre a atividade dos banqueiros e as engrenagens que sustentam o sistema capitalista, Gustavo Barroso foi contundente ao afirmar que, na sua marcha avassaladora, a organização capitalista, antes de tudo, procura penetrar profundamente no organismo das nações, destruindo-as num primeiro momento, pela concessão de “favores” em forma de empréstimos, pois o primeiro passo para tornar qualquer governo verdadeiramente escravo é torná-lo devedor. “Quando essa potestade internacional pretende reduzir um povo às condições de escravo, o que ela faz naturalmente não é mandar exércitos: manda banqueiros. Assim, prossegue a marcha da escravidão de um povo. Os empréstimos se multiplicam; as emissões espinhosas se reproduzem; as operações e negócios estabelecem a trama com que se manietta a nacionalidade. E um país que chegou a esse ponto não tem mais do que deixar-se sugar pelo tremendo polvo que lhe lançou as antenas. Pois a confusão se estabelece em todos os quadrantes da vida nacional”.¹⁸

16 *Idem*, p. 7.

17 *Idem*, p. 9.

18 *Idem*, p. 10.

2. BRASILEIROS REFÊNS DE BANQUEIROS

Em profunda e minuciosa análise de Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, entidade que batalha para que o Brasil faça o mesmo que o Equador fez, em 2007 e 2008,¹⁹ encontramos importantes informações.

Mostra-nos, com base em dados oficiais, que o Estado brasileiro é capturado por banqueiros. Os documentos por ela apresentados são insuspeitos porque extraídos das páginas do próprio Senado:²⁰

SIGA
BRASIL



SENADO
FEDERAL

LOA 2012 - Execução Orçamentária
por Grupo Natureza de Despesa - GND

R\$ 1,00

GND (Cod)	GND	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado (Subelemento)	Pago	RP Pago
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.240.358.158	207.226.920.701	204.501.586.767	203.742.802.606	203.302.565.866	1.071.513.961
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.572.105.992	151.573.168.572	135.057.607.411	134.079.856.059	134.053.618.451	90.313
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.279.350.432	791.791.932.489	756.263.233.369	711.664.395.580	694.143.790.383	47.629.679.221
4	INVESTIMENTOS	80.332.621.096	114.580.838.644	66.662.636.934	22.116.006.442	21.550.132.042	25.323.386.875
5	INVERSOES FINANCEIRAS	48.178.362.783	84.352.319.234	56.787.761.739	40.672.141.789	40.156.122.915	5.400.641.494
6	AMORTIZACAO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	874.165.736.459	888.318.282.321	620.522.695.417	618.941.921.738	618.888.549.837	90.230.659
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.130.587	18.873.775.770	0	0	0	0
NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2.150.458.867.507	2.256.717.237.731	1.839.795.521.637	1.731.217.124.214	1.712.094.779.493	79.515.542.723

Leia-se atentamente a linha de número dois. São mais de R\$ 134 bilhões que o contribuinte brasileiro pagou em juros da dívida brasileira em 2012, segundo dados do próprio governo (embora haja controvérsias, como veremos adiante).

Agora, leia-se a linha de número seis. São mais de R\$ 600 bilhões pagos em amortização/refinanciamento da dívida em 2012.

Sem dúvida, é muito dinheiro! Mas na opinião de Maria Lúcia Fattorelli, se houvesse uma auditoria, o valor devido poderia ter uma redução de até 70%.

A ex-auditora da Receita Federal está certa ao afirmar que existem ilegalidades e irregularidades nas cobranças da dívida brasileira, em benefício dos banqueiros e, obviamente, em prejuízo dos contribuintes. Emprega propositalmente a palavra “contribuintes” porque a dívida é paga com dinheiro de nossos impostos. “Tudo o que o Tesouro brasileiro faz é pendurar a conta em nosso nome. (...) Com juros, muitos juros, razão de viver dos bancos”, diz ela.²¹

¹⁹ <http://www.auditoriacidadada.org.br/>

²⁰ <http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=1007801> - por Luiz Carlos Azenha - Acesso em 16/03/2014.

²¹ FATTORELLI, Maria Lúcia: **Banqueiros capturam o Estado brasileiro**. Publicado em 11 de agosto de 2013: <http://www.viomundo.com.br/denuncias/maria-lucia-fattorelli.html> (acesso em 16/03/2014).

É evidente que a mídia corporativa não explica tudo que ela diz. Por quê? “Porque os bancos são grandes patrocinadores. Por outro lado, mesmo os governos não gostam de falar do assunto. Quanto mais transparência, menor margem de manobra para os acertos de bastidores. Por isso, em geral os governos fazem de conta que o assunto é muito árduo, muito difícil de entender e que você não precisa se preocupar com isso. Ou seja, deve pagar e ficar quieto”.²²

Ela argumenta que, ao fim e ao cabo, é o peso da dívida que acaba por enfraquecer o endividado Estado brasileiro, sendo este o motivo por que os gráficos divulgados pela **Auditoria da Dívida Cidadã** na internet causam controvérsia, a ponto de as autoridades governamentais acharem que só deveriam ser considerados os R\$ 134 bilhões oficialmente declarados como juros pagos em 2012, não os mais de R\$ 600 bilhões que são a soma de juros + amortizações:

Seria o motivo para as concessões de estradas, rodovias, portos e ferrovias anunciadas pelo governo. Para fazer parecer que o problema não é tão grave quanto é, os cálculos do governo sobre a relação entre a dívida e o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, considera a chamada “dívida líquida”, ou seja, o governo desconta as reservas detidas pelo Brasil em dólares, de cerca de US 400 bilhões, da equação. Da mesma forma, quando o governo calcula o pagamento de juros como parte do Orçamento, não inclui os juros que estão “embutidos” no refinanciamento da dívida. Seriam truques para fazer que o problema não é tão grave quanto é. Acabam mascarando o domínio dos banqueiros sobre o “sistema”.²³

Porém, voltemos ao que interessa, como diz Maria Lúcia:

“O poder dos banqueiros sempre foi imenso. Eles definem as regras nas duas pontas: desde as condições de emissão dos papéis em que prometemos pagar até as regras da cobrança.

Faturam com as comissões sobre as transações e com os juros. Juros altos interessam aos banqueiros. Quanto maiores, mais eles recebem emprestando ao governo.

E os cidadãos? Pagam a conta através dos impostos e ficam sem os serviços públicos que o dinheiro dado aos banqueiros poderia financiar”.²⁴

Nestas circunstâncias, não é de estranhar que, em julho de 2012, circulava na internet a notícia: “**Um em cada três brasileiros bilionários é banqueiro**”. Dos 36 brasileiros que figuravam então na lista dos mais ricos do mundo da revista “Forbes”, divulgada no dia 7 de julho de 2012, 14 eram banqueiros, ou seja, praticamente um a cada três.²⁵

22 Idem.

23 Idem, ibidem.

24 Ibidem.

25 <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/03/07/um-em-cada-tres-brasileiros-bilionarios-e-banqueiro.jhtm> (acesso em 17/03/2014).

No entanto, como luz no final do túnel, parece que, aos poucos, começam a mostrar-se algumas rachaduras nas estruturas do capitalismo, cujas contradições confirmam tratar-se de um sistema irremediavelmente autodestrutivo.

3. SINAIS DE ESGOTAMENTO

Na mesma notícia acima, outra notícia já estava incluída: “Diferentemente do ano passado, quando os países que integram o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foram a grande sensação, desta vez o grupo conta com 26 integrantes a menos na lista das maiores fortunas do planeta. A única exceção é o Brasil, que conseguiu somar novos membros ao clube”.²⁶

O ranking geral de 2011 contabilizava o total de 1.226 bilionários, um novo recorde ao qual se somaram, em 2012, outras 16 pessoas, que detinham uma riqueza total de US\$ 4,6 trilhões, frente aos US\$ 4,5 trilhões de 2011, com uma fortuna média de aproximadamente US\$ 3,7 bilhões por pessoa.

Porém, já em 2013, sete dos dez maiores banqueiros brasileiros estavam mais pobres.²⁷

Além do mais, ultimamente, outro fenômeno vem ocorrendo misteriosamente, assombrando o capitalismo de centro: o estranho fato de sucessivas baixas entre os banqueiros.

Seria algum sinal sutil de que o fim poderia estar próximo?

As mortes começaram no domingo, 26 de janeiro de 2014.

Em um período de 4 dias no mês de janeiro de 2014, dois executivos atuantes e um recém aposentado, todos no topo das maiores empresas financeiras dos Estados Unidos, foram encontrados mortos.

A mídia e a polícia foram rápidas em diagnosticar as mortes como suicídios, mesmo antes de os corpos serem autopsiados e os fatos serem comprovados.

Trata-se de uma estratégia bem conhecida que ocorre frequentemente na mídia, quando se dá destaque a uma determinada matéria, com ênfase num ponto, para desviar a atenção de outra matéria, para ludibriar facilmente os leitores

O que estaria ausente ou por trás dessa novela das mortes de banqueiros dos Estados Unidos? O que essas mortes “suicidas” poderiam significar?

Para bom entendedor, meia palavra basta.

É importante a informação de que as três empresas financeiras, onde os executivos mortos trabalhavam, estão sob investigação por fraude financeira potencialmente grave, que poderá brevemente acarretar profundas consequências em outros países.

Mas a trilha sombria de mortes de banqueiros continua. Como informa o jornal *Star*, “um homem de negócios bem sucedido e membro de uma proeminente família local morreu na semana passada no antigo CEO do Banco Nacional do Comércio. James Stuart Jr foi encontrado morto em Scottsdale, Arizona, na manhã do dia 19 de fevereiro. Um porta-voz da família não disse o que causou a morte. Isto faz o total de mortes de banqueiros nas últi-

²⁶ Idem.

²⁷ <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/7-dos-10-maiores-banqueiros-brasileiros-estao-mais-pobres#5> (acesso em 17/03/2014).

mas semanas subir para nove. Stuart morre, infelizmente, deixa três filhos e quatro filhas” (via *The Star Journal*).²⁸

Stuart era natural de Lincoln, formado na Universidade de Nebraska-Lincoln com uma licenciatura em Administração de Empresas.

Em 1969, Stuart organizou o Citibank em Nova York e serviu como um oficial de empréstimo até 1973, quando se juntou à Primeira Commerce Bancshares (então NBC Co.) como vice-presidente executivo. **Ele foi nomeado presidente em 1976, presidente do conselho e CEO em 1978, e também tornou-se presidente e CEO da National Bank of Commerce, em 1985.** Stuart passou a vida construindo a organização e era uma importante voz de negócios em Lincoln, disse o amigo e colega Brad Korell.

“Ele era um banqueiro muito bem sucedido”, disse Korell, que trabalhou com Stuart há mais de 30 anos. “Eu sempre achei que ele era um visionário. Ele realmente fez construir uma das mais bem sucedidas e admiradas organizações bancárias no Centro-Oeste”.²⁹

Stuart passou grande parte de sua carreira na Primeira Commerce Bancshares, um multibanco holding, com sede em Lincoln. Primeiro Comércio vendido ao Wells Fargo em 2000.

Ele foi ex-membro do Nebraska Jogo e Parques e foi nomeado pelo governador Dave Heineman para o conselho do Nebraska Environmental Trust em 2008. Stuart também estava envolvido com grupos de recursos naturais como a Nature Conservancy, Ducks Unlimited e Fundação Nacional Florestal dos EUA.

Atuou no Conselho Internacional da Fundação Diabetes Juvenil e Placas da Universidade de Nebraska Foundation e Nebraska Wesleyan University.

De acordo com Korell, Stuart residia em Scottsdale, ocupando-se de aplicações financeiras da família e praticando o golfe e a pesca.

Além dele, outros banqueiros foram noticiados como mortos (via *Intellihub*):

1. **William Broeksmit**, ex-executivo sênior de 58 anos de idade, do Deutsche Bank AG, foi encontrado morto em sua casa depois de um aparente suicídio em South Kensington, em Londres, no dia 26 de janeiro.
2. **Karl Slym**, diretor de 51 anos da Tata Motors Karl Slym, foi encontrado morto no quarto andar do hotel Shangri-La em Bangkok no dia 27 de janeiro.
3. **Gabriel Magee**, de 39 anos de idade, empregado da JP Morgan, morreu depois de cair do telhado da sede da JP Morgan Europeia em Londres, em 27 de janeiro.
4. **Mike Dueker**, de 50 anos de idade, economista-chefe de um banco de investimento dos EUA, foi encontrado morto perto da Tacoma Narrows Bridge no Estado de Washington.
5. **Richard Talley**, 57 anos de idade, fundador da American Title Services em Centennial, Colorado, foi encontrado morto no início do mesmo mês, depois de aparentemente se matar com uma pistola de pregos.

28 <http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://www.zerohedge.com/news/2014-02-24/another-successful-banker-found-dead> (acesso em 17/03/2014)

29 Idem.

6. **Tim Dickenson**, diretor de comunicações baseadas no Reino Unido, a Swiss Re AG, também morreu no mês anterior, no entanto, as circunstâncias de sua morte ainda são desconhecidas.
7. **Ryan Henry Crane**, um executivo de 37 anos no JP Morgan morreu em um suposto suicídio apenas algumas semanas antes. Nenhum detalhe foi divulgado sobre a sua morte, além deste pequeno anúncio obituário no Stamford Diário Voice.
8. **Li Junjie**, banqueiro de 33 anos de idade, em Hong Kong saltou do JP Morgan HQ em Hong Kong esta semana.³⁰

4. BANQUEIROS “SUICIDADOS”

Vale aqui transcrever literalmente o interessante e irônico texto postado por Laura Botelho, em seu blog, acerca dos mais recentes **eventos onde banqueiros foram “suicidados”**.³¹

“William Broeksmit, alto executivo do Deutsche Bank, que se aposentou em 2013, f’oi encontrado **enforcado** em sua casa, South Kensington, Londres.

Broeksmit estava entediado numa tarde fria de inverno e resolveu se enforcar. Não passava nada de bom na TV.

Eric Ben- Artzi, um ex-analista de risco, foi encontrado morto no dia seguinte a Broeksmit (acho que ambos tinham a mesma TV a cabo). Eric esteve na Universidade de Auburn, Alabama, esclarecendo suas alegações, de que **o banco - Deutsche Bank.- teria ocultado US\$ 12 bilhões** em perdas com **o conhecimento dos seus altos executivos**, durante a crise financeira.

O **Deutsche Bank** e a **JPMorgan** estão sendo investigados pela Subcomissão Permanente de Investigações do Senado dos EUA por potencial manipulação nos mercados cambiais. Estão sob a mesma investigação por possível envolvimento na **manipulação das taxas de câmbio** e suspeita de **má conduta nos mercados de commodities físicas** nos EUA e em Londres.

Gabriel Magee foi o terceiro a ser “suicidado” dois dias após o primeiro caso – em **28 de janeiro** – Magee era um americano de 39 anos de idade, **vice-presidente do JP Morgan em Londres**.

Gabriel caiu do **33º andar do telhado** da sede europeia do JPMorgan em Canary Wharf. Magee fazia tudo muito bem, era um excelente planejador. Arquitetava tudo tão minimamente que obteve acesso fácil ao telhado de um dos prédios mais seguros de Londres. Ele deve ter convencido alguém que pular do 33º andar seria muito bom para baixar as taxas de juros no planeta. De acordo com o perfil de Magee no **LinkedIn**, ele estava envolvido na **“arquitetura técnica para supervisão do planejamento, desenvolvimento e operação de sistemas de títulos de renda fixa e derivativos de taxa de juros”**. O que faz muito sentido agora...

³⁰ <http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://www.zerohedge.com/news/2014-02-24/another-successful-banker-found-dead> (acesso em 17/03/2014)

³¹ <http://bloglaurabotelho.blogspot.com.br/2014/02/banqueiros-suicidados-sao-sinais-sutis.html>

Os pais de Magee, Bill e Nell Magee, não aceitam a história oficial e nem os relatórios da imprensa, e viajaram dos Estados Unidos para Londres para saberem a verdade. Quem sabe eles conseguem, né? Acho muito difícil, mas nada é impossível. Elefantes voam sozinhos se a CIA assim desejar.

Nell Magee, a mãe do saltador, disse em depoimento que seu filho era “uma pessoa feliz e que estava feliz com sua vida”. Seus amigos estão igualmente perplexos, afirmando que ele tinha um relacionamento feliz e duradouro com sua namorada.

Isso não prova nada. A CIA logo irá deduzir que ele era pedófilo e se envolveu emocionalmente com o jovem Just Bimba que recusou ser molestado por ele, daí ele não teve outra alternativa a não ser corromper um funcionário que tinha as chaves e acesso ao telhado mais seguro de Londres para se matar, mesmo sabendo que seria muito mais fácil se suicidar fazendo passeatas no Rio.

Michael Dueker foi o próximo a ser “suicidado”. Ele resolveu isso um dia após a morte de Magee, na quarta-feira, **29 de janeiro de 2014**. Dueker tinha 50 anos e era Economista-chefe da Russell Investments, e ao invés de fazer passeata no eixo Rio – São Paulo – Venezuela – “foi caído” de um barranco com 15 metros de altura no estado de Washington.

A biografia oficial de Dueker, antes de ingressar na Russell Investments e virar saltador de barrancos, diz que ele foi vice-presidente assistente e economista de pesquisa no Federal Reserve Bank of St. Louis de 1991 a 2008.

De acordo com uma reportagem do New York Times, em novembro do ano passado, a **Russell Investments** foi uma das várias empresas que receberam intimações dos órgãos reguladores do Estado de Nova York, que **estão investigando o esquema de compra de favores envolvendo os fundos de pensão** com sedes em Nova Iorque.

Richard Talley, foi o seguinte a ser “suicidado”. Aos 57 anos de idade foi suicidado de forma mais original que todos os outros. A porta-voz de um médico legista disse que Talley foi encontrado morto com **sete ou oito ferimentos autoinfligidos** de uma **pistola de pregos** que disparou em seu próprio **peito e cabeça** em sua garagem. PQP... esse foi difícil de matar.

Talley estava sendo investigado por parte da Divisão de Seguros do Colorado, que regula as empresas de títulos.

O caso mais estranho é o do repórter **David Bird** que desapareceu sem deixar vestígios (foi abduzido com certeza) na tarde de **11 de janeiro 2014**. O repórter era especialista em assuntos de **mercados de petróleo** e havia trabalhado no Wall Street Journal por 20 anos.

O **repórter Bird** saiu de sua casa em Long Hill, NJ, naquele sábado, dizendo à sua esposa que estava indo para uma “caminhada” (não confunda com passeata!)

O “pássaro” voou para bem longe vestindo uma jaqueta vermelha brilhante e sem o seu remédio de uso diário, imprescindível à sua vida, resultante de um transplante de fígado. Apesar de uma busca contínua desde o seu desaparecimento, por centenas de voluntários, pela polícia local e pelo FBI, Bird nunca foi localizado...

O repórter não cobria passeatas nem incursões da polícia nos morros, mas estava intimamente envolvido com um mercado de commodities - petróleo – (**o que dá no mesmo**) – um fato que está sendo investigado pela Subcomissão Permanente de Investigações do Senado dos EUA por **uma possível manipulação**.

Quando uma série de acontecimentos trágicos ocorre dentro de um espaço de **18 dias**, a probabilidade estatística de que esses eventos não sejam aleatórios é muito remota.

Suicídios à parte, mas você que está atento a tudo que acontece nesse planeta não acha que algo muuuuito bizarro está para ocorrer em breve? Há uma grande probabilidade de que **o fim desse mundo que você conhece** irá ocorrer em torno de **04 de março de 2014**, pois a economia dos EUA pode falhar totalmente em torno dessa data.

Quem afirmou isso foi **Grady Means**, num artigo para a **Washington Times** em **25 de outubro de 2012**. Means é um empresário, ex-assistente do vice-presidente **Nelson Rockefeller** e ex-economista do Departamento dos EUA de Saúde, Educação e Bem-Estar.

Se isso realmente ocorrer como ele previu agora no início de março, poderia **derrubar todas as economias do mundo** e toda a esperança de uma recuperação para um futuro previsível - e certamente ao longo de nossas vidas.

As taxas de juros vão disparar, as empresas irão falir, o desemprego vai para níveis recordes, materiais e escassez de alimentos estarão fora de controle o que poderá gerar grande agitação social...

“Qualquer ilusão de que a América está em uma “recuperação” e que “as coisas estão melhorando” é uma ilusão”, diz Means em seu artigo.

“O problema central é que a América é o banco do mundo. O que isto significa, simplesmente, é que o dólar é a moeda do mundo (muitas vezes chamado de “moeda de reserva”). Em todo o mundo, quase todos os bens de capital, petróleo, principais commodities, imóveis, etc, são denominados em dólares.”

“A corrida ao banco começará de repente, construindo rapidamente uma bola de neve”

“**Haverá levantes** - pense nas ruas na Espanha e na Grécia hoje - em todos os lugares. Os avanços tecnológicos que tradicionalmente impulsionam o aumento da produtividade e do crescimento econômico não serão capazes de manter-se com este colapso”

Bom... Vamos recapitular

Temos hoje muita neve, muito frio, muita água subindo, muito vulcão, muito terremoto, muitos buracos (SINKHOLE) no solo sem explicação. Milhares e milhares de gastos com as mudanças climáticas irreversíveis. Muita seca, muito calor e **futuros apagões de escala continental**. Muita agitação, muita rebelião, muita desordem e caos social. Muita descrença, muita perda de respeito do poder público. Estamos fazendo nossas próprias leis, julgando e condenando, estamos punindo e resolvendo coisas que a justiça não resolve.

Países latinos estão mergulhados na **escuridão de seus governantes**. Não há salvadores, não há mártir, não há herói, apenas picaretas sendo desmascarados...

Será que sou eu que estou querendo ver ou isso parece um script dos antigos textos Mayas nos avisando que tudo mudaria?

... seja lá como for, tudo já foi dito, tudo já foi avisado.

laura Botelho

E eu achando que estava fazendo piada com isso tudo...”

5. CAPITALISMO DE CENTRO E DE PERIFERIA

Enquanto o capitalismo de centro vem ceifando vidas numa sucessão interminável de banqueiros “suicidados”, o capitalismo de periferia, como é o caso do Brasil, apesar de importantes avanços no campo da investigação policial,³² faz acontecer até mesmo a proeza de um banqueiro virar o jogo, passando de acusado a acusador.³³

Por outro lado, na ciranda do mercado de capitais a subverter e sufocar a atividade empresarial, a ponto de um bilionário em meteórica ascensão se ver repentinamente cair no abismo, com seu gigantesco patrimônio virando pó,³⁴ é possível esperar que grandes transformações venham a ocorrer em futuro talvez não muito distante.

Realmente o capitalismo revela cada vez mais suas profundas contradições, na medida em que se desvia do sentido social ao enveredar para o campo da mera especulação, com objetivo exclusivo do lucro em favor de aproveitadores de ocasião.

De fato, pode-se afirmar que o capitalismo é autofágico por ter apenas três regras: 1) o lucro; 2) só o lucro; 3) nada mais além do lucro. Ou seja: só lucro, concentrado em mãos de poucos.

Por isso, o capitalismo gera as guerras assim como as nuvens produzem as tempestades.

Felizmente, ao que parece, a Humanidade acorda. Uma equipe de cientistas sociais e naturais patrocinada pela Nasa desenvolveu um modelo que analisa a queda de civilizações pela evolução da população, clima, água, agricultura e energia, em face de dois fatores cruciais – o abuso dos recursos naturais e a estratificação social. Os resultados deste estudo merece profunda reflexão.

“Aplicado à civilização industrial dos últimos séculos, o modelo indica que o consumo excessivo da elite provocará a fome das massas. Primeiro sofrerão os mais pobres, mas depois a própria minoria dominante será atingida e a civilização desmoronará”.³⁵

Ainda é possível evitar isso se a sociedade contemporânea reduzir o ritmo de esgotamento dos recursos, distribuindo-os de forma equitativa.

É o que pensa Jeremy Rifkin, em artigo intitulado “*Avanço tecnológico desafia capitalismo*”,³⁶ que pode servir-nos como baliza para a conclusão do presente trabalho.

6. CONCLUSÃO

“Estamos começando a testemunhar um paradoxo no coração do capitalismo. O dinamismo inerente de mercados competidores está baixando de tal forma os custos que muitos

32 Vide, QUEIROZ, Protógenes. *Operação Satiagraha – Os bastidores da maior operação já feita pela Polícia Federal*. Universo dos Livros Editora Ltda., São Paulo, 2014, 144 p.

33 VALENTE, Rubens. *Operação banqueiro* – Uma trama brasileira sobre poder, chantagem, crime e corrupção. A incrível história de como o banqueiro Daniel Dantas escapou da prisão com apoio do Supremo Tribunal Federal e virou o jogo, passando de acusado a acusador. Geração Editorial, São Paulo, 2013. 462 p.

34 LEO, Sérgio. *Ascensão e queda do império X* – Eike Batista, as trapaças e os bastidores da história de uma fortuna de mais de US\$ 34 bilhões que virou pó. Editora Nova Fronteira S.A. 2014. 263 p.

35 Revista *Carta Capital*, 26 de março de 2014, p. 26.

36 *The New York Times*, 25/03/2014. Trad. de Celso Paciornik. Pesquisa Google, acesso em 30/03/2014.

bens e serviços estão se tornando quase gratuitos, abundantes, e não mais sujeitos às forças do mercado. A revolução tecnológica está trazendo esses custos a quase zero”.³⁷

Os primeiros indícios do paradoxo surgiram em 1999, permitindo que milhões de pessoas compartilhassem música de graça, causando estragos na indústria fonográfica musical. O mesmo aconteceu com as indústrias de publicação de jornais e livros.

Apesar de ainda estarmos pagando caro a tecnologia de energia solar e eólica, o custo de capturar tal energia, depois de instalada, é baixo. Este fenômeno atingiu até o setor manufatureiro. Milhares de amadores estão fazendo seus próprios produtos a um custo quase zero.

O número de pessoas dispostas a pagar pelos bens e serviços especiais é limitado. Agora, o fenômeno está prestes a afetar a economia como um todo. Uma nova infraestrutura de tecnologia – a da internet – está surgindo com o potencial de empurrar boa parte da vida econômica para um custo marginal quase zero nas próximas duas décadas.

A questão ainda não resolvida é como esta economia do futuro funcionará quando milhões de pessoas puderem fazer e compartilhar bens e serviços quase de graça. A resposta está na própria sociedade civil, que poderá organizar-se sem fins lucrativos em novo modelo de vida compartilhada em comunidade.

Estamos em condições de construir uma infraestrutura das coisas que aprimora a colaboração e acesso universal, cruciais para a criação de capital social, e marcar o início de uma economia solidária. Esta abordagem colaborativa em vez de capitalista diz respeito mais ao acesso compartilhado que à propriedade privada. Por exemplo, milhões de pessoas em todo o mundo poderiam integrar serviços de compartilhamento de carros.

“O fenômeno do custo marginal nulo é particularmente impactante no mercado de trabalho, onde fábricas e escritórios sem trabalhadores, varejo virtual e redes automatizadas de logística e transporte estão prevalecendo. Não surpreende que as novas oportunidades de emprego estejam na comunidade cooperativa em campos que tendem a ser não lucrativos e que fortalecem a infraestrutura social – educação, saúde, ajuda aos pobres, recuperação ambiental, atendimento infantil e atendimento a idosos, promoção das artes e recreação”.³⁸

O sistema capitalista pode até permanecer por algum tempo, ainda que com papel mais delimitado, principalmente como agregador de serviços e soluções de rede, sob controle da sociedade, não do poder econômico. Poderemos, sim, entrar em um mundo parcialmente fora dos mercados, onde se poderá viver numa comunidade cada vez mais interdependente, cooperativa, global e verdadeiramente solidária.

Em suma, futuramente, a Humanidade será muito feliz. Não se trata de vaga esperança, mas é certeza. Por quê? Simplesmente porque o ser humano é racional e chegará o dia em que se conscientizará plenamente da sua racionalidade, fazendo com que a estupidez seja derrotada pela razão.

Quando isso acontecerá?

Depende de cada um de nós, porque nós fazemos a História.

37 Idem.

38 Idem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- BARROSO, Gustavo. **Brasil – Colônia de banqueiros (História dos empréstimos de 1824 a 1934)**. 5ª. Ed. Civilização Brasileira, S.A. Rio de Janeiro, 1934.
- GUEIROS, Nehemias. **A maior fraude da História**. Fonte: Jornal “Pravda”. Pesquisa Google.
- INSTITUTO LUDWIG VON MISES. **Moedas, créditos e ciclos econômicos**. Pesquisa Google.
- FATTORELLI, Maria Lúcia. **Banqueiros capturam o Estado brasileiro**. Publ. 11 de agosto de 2013. Pesquisa Google.
- LEO, Sérgio. **Ascensão e queda do império X**. Ed. Nova Fronteira, S.Paulo, 2014.
- QUEIROZ, Protógenes. **Operação Satiagraha**. Ed. Universo, S. Paulo, 2014.
- VALENTE, Rubens. **Operação banqueiro**. Ed. Geração. S. Paulo, 2013.
- Revista **Carta Capital**, 26/03/2014.
- The New York Times, 25/03/2014.

¡¡¡comprobar griego!!!

**LA “DATIO IN SOLUTUM” COMO FIGURA SUSTITUTIVA
DEL PAGO DEL CRÉDITO; SUS ANTECEDENTES EN
DERECHO ROMANO Y SU CONSIDERACIÓN EN EL
DERECHO ACTUAL”**

**THE “DATIO IN SOLUTUM” LIKE SUBSTITUTE FIGURE
OF THE PAYMENT OF THE CREDIT; ITS ANTECEDENTS
IN ROMAN LAW AND BRIEF CONSIDERATION IN THE
PRESENT LAW”**

LUIS MARIANO ROBLES VELASCO
Universidad de Granada

SUMMARIUM: LOS ANTECEDENTES EN EL DERECHO GRIEGO ANTIGUO.

1. El llamado enechyron. 2. En la praxis epi lysei. 3. La pepramena. 4. La hypothêkê. 5. La apotimema. LA DATIO IN SOLUTUM EN DERECHO ROMANO. 1. Origen de la datio in solutum. 2. La Datio in solutum en la época clásica y post-clásica. 3. La datio in solutum en el derecho Justiniano. LA DATIO IN SOLUTUM EN LA TRADICIÓN JURÍDICA ROMANISTA MEDIEVAL. 1. En la Glosa y Comentaristas. 2. En Las Partidas. LA DATIO IN SOLUTUM EN LA DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ACTUAL. 1. La cuestión en la doctrina civilista. 2. En la Jurisprudencia Civil. 3. En la Legislación Civil e Hipotecaria. 4. La cuestión en otros ordenamientos jurídicos. 5. La cuestión en la jurisprudencia española, europea y legislación estatal actual. 6. La respuesta legislativa en la legislación autonómica.

Recientemente y parece que está de rabiosa actualidad, el tratar de la extinción del derecho real de garantía hipotecaria mediante la realización por parte del deudor de una *dación en pago*, ante la imposibilidad de pagar su deuda, intente hacer frente a su insolvencia mediante la entrega al acreedor (o *entidad financiera*) del inmueble que pudo adquirir precisamente a través de la concesión del préstamo hipotecario¹, esto es lo que se ha dado

1 SALAS CARCELLER, A. (coordinador), EJECUCION HIPOTECARIA. SOLUCIÓN A TIEMPOS DE CONFLICTO. Ed. Thompson Reuter (Aranzadi), BELINCHÓN ROMO, M^a Raquel, (cap. II, “Extinción de la deuda garantizada con hipoteca y dación en pago”, p. 34), Navarra 2012, pp 813.

a conocer como la *dación en pago*. Incluso, hay un importante movimiento popular a favor que sea la propia Ley, la que posibilite al deudor librarse de la deuda financiera entregando dicha vivienda en pago².

LOS ANTECEDENTES EN EL DERECHO GRIEGO ANTIGUO

Y aunque ya en anterior trabajo³ me ocupé de la posibilidad de la influencia de algunas figuras negociales conocidas en el “*Mare Nostrum*” del derecho griego antiguo y su influencia posterior en el Derecho Romano⁴. Ya entonces, me preguntaba:

¿Es posible que tales figuras tuvieran repercusión siglos después en el Derecho romano? Así, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de la influencia de ciertos principios, como el *principio de la anepafia* (ανεπαφια)⁵ y de ciertas formas de garantías antiguas de las que brevemente, haremos referencia.

Ya BISCARDI⁶, consideraba que las dos formas más antiguas de garantías reales en el antiguo derecho griego fueron el *enechyron* (ενεχηψρον) y la llamada *praxis epi lysei* (πραξις επι λυσει)⁷, a las que se les puede añadir algunas mas, como la denominada *hypothêkê* (ηψποττηκε), la *apotimema* (αποτιμεμα), y otras.

2 DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: un drama legal y un problema social, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014. (Sección 5ª, Soluciones Extrajudiciales): ALVAREZ ROYO-VILLANOVA, S., Soluciones extrajudiciales al sobreendeudamiento familiar, pp. 683 ss.

3 Comunicación presentada en el IX CONGRESO INTERNACIONAL Y XII IBEROAMERICANO DE DERECHO ROMANO: “EL DERECHO COMERCIAL DE ROMA AL DERECHO MODERNO”. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1, 2, y 3 de Febrero de 2.006 y publicado en “EL DERECHO COMERCIAL, DE ROMA AL DERECHO MODERNO”, Capítulo titulado: “La practica comercial marítima y su influencia en las formas de garantía”, del Vol., II. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Servicio de Publicaciones, ISBN 978-84-96718-68-5. Pp. 795-806.

4 En cuanto que hacía referencia a la cuestión de la posible influencia de algunas formas negociales del derecho ático (y en zonas de influencia griega como ciertas colonias griegas) en el derecho romano posterior. ROBLES VELASCO, LM., “EL COMERCIO MARÍTIMO Y SU INFLUENCIA EN LAS FORMAS DE GARANTÍA”. Publicado en la Revista “*Novos Estudos Jurídicos*”, revista Semestral do Curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI UNIVERSIDADE DO VALE ITAJI - ITAJAI (SANTA CATARINA) BRASIL - VOL. XI, número 2, JUL-DEZ 2006, pp. 375-384, ISSN 1413-2117. Revista indexada nº CSA Social Science Collection. San Diego- USA).*

5 BISCARDI, “El régimen de la pluralidad hipotecaria desde la jurisprudencia clásica hasta Justiniano”, *TDR*, Barcelona 1997, p. 68, n. 6.

6 BISCARDI, *Diritto greco Antico*, Milano, 1982, pp. 219.

BISCARDI, *Appunti sulle garanzie reali in diritto romano*, Padua 1931, (reimp. Milano, 1976). BISCARDI, “La Lex Commisoria nel sistema delle garanzie reali”, *Studi Betti*, 2, pp. 575 ss.

BISCARDI, *Il dogma della collisione alla luce del diritto romano*, Citá di Castello, 1935, pp. 58 ss.

BISCARDI, “Ancora in tema di colisiones”, *SDHI*, 4 (1938); ZSS, 86 (1969), pp. 146 ss.

BISCARDI, “Die mehrfache Verpfändung einer sache vom attischen bis zum spätschen Recht”, *ZSS* 86 (1969), pp. 146 ss.

BISCARDI, “Le régime de la pluralité hypothecarie en droit grec et romain”, *JJP*, 19 (1983), pp. 41 ss.

7 BISCARDI, “Le régime de la pluralité hypothecarie en droit grec et...”, op. Cit. pp. 41 ss.

BISCARDI, “El régimen de la pluralidad hipotecaria desde la jurisprudencia clásica hasta Justiniano”, *TDR*, (1987), p. 65.

1. El *enechyron* (ενεχηψρον)

1. El llamado *enechyron* (ενεχηψρον), consistía en una figura en la cual se producía la entrega efectiva de la posesión al acreedor, pudiendo esta recaer sobre todo tipo de bienes, pero sin una precisa diferenciación de las cosas muebles e inmuebles objeto de la garantía, considerándose en algunos aspectos similar a la figura del *pignus datum* romano.

2. La *praxis epi lysei* (πραξις επι λψσει)

En la *praxis epi lysei* (πραξις επι λψσει), el propio acreedor se convertía en propietario de la cosa que había sido ofrecida en garantía, al menos hasta que se produjera el pago por parte del deudor, lo que significaba según Arangio Ruiz⁸, que el acreedor se convertía en dueño exclusivo desde el día del contrato, dejando al deudor el goce en precario, figura con ciertas similitudes con la *fiducia* romana.

3. La *pepramena* (πεπραμενα)

En la *pepramena* (πεπραμενα) según afirma Biscardi⁹, algunas fuentes áticas recogen casos de mantenimiento de la posesión por el acreedor (ηψποκειμενα ο ηψποκειμενα), aún cuando dicho acreedor hubiera sido pagado al vencimiento de la deuda, pero aun restaran otras por pagar. Ello producía un efecto de *continuidad posesoria*, similar a la que se producía cuando el acreedor convertido en adquirente continuaba con la propiedad de la cosa en la *praxis epi lysei* (πραξις επι λψσει). Tal situación de *continuidad posesoria* recibía el nombre de *pepramena* (πεπραμενα).

Sin embargo no parece que las diferencias entre ambas formas de garantía, la entrega de la posesión en el *enechyron* (ενεχηψρον) y la retención de la propiedad por parte del acreedor en la *praxis epi lysei* (πραξις επι λψσει), estuviera tan marcada como ocurría en Derecho Romano con la *fiducia cum creditore*¹⁰ y el *pignus conventum*¹¹. Era necesario algo mas evolucionado, y esto llegó con la *hypothêkê* (ηψποτηκε).

4. La *hypothêkê* (hypotheke)

Algunos textos literarios griegos así como algunos discursos de oradores, aluden a una forma de garantía en la cual no se producía la pérdida de la posesión por el deudor, a la cual le llaman *hypothêkê* (ηψποτηκε).

⁸ ARANGIO RUIZ, *Arch. giur.*, IV, 23 (1932).

⁹ BISCARDI, “El régimen de la pluralidad hipotecaria desde la...” op. Cit. p. 66.

¹⁰ KRELLER, “Formula fiduciae und Pfandedikt”, *ZSS*, 62 (1942), p. 143. Sobre la misma cuestión, vid. LONGO, “Fiducia cum creditore”, *Centen. Codificaz.*, (Pavia), p. 795. BELLOCCI, “La tutela della fiducia nell’epoca repubblicana”, *Studi Senesi*, 85 (1973), p. 321.

¹¹ ARIAS RAMOS, “La doctrina de la *conventio* y el origen de la hipoteca romana”, *RDP*, 313 (1943), pp. 213-223.

Se trataba de una convención o pacto, en virtud de la cual el deudor podía continuar con la posesión del bien en garantía, pero que facultaba al acreedor para que llegado el momento del vencimiento, si el deudor no pagaba podía tomar posesión de aquellos bienes que habían quedado sujetos o asignados en garantía.

La *hypothékê* (ὑποθήκε) más que un nuevo tipo de garantía, es simplemente un pacto añadido, que permitía al deudor a mantener sobre ciertos bienes una cierta posesión y facultando al acreedor a volver a obtener la posesión, en caso de impago del crédito, al menos hasta que el deudor no pague. Esto no era identificable con una *datio in solutum* plenamente solutoria, sino más bien una especie de moratoria con retención de la posesión por el acreedor. Una especie de *pignus* forzoso y continuado, al menos hasta que el deudor pague la deuda.

5. La *apotimema* (ἀποτιμema)

Según Paoli¹², bajo el nombre de *apotimema* (ἀποτιμema), se podían configurar una institución que con algunas variedades se podía considerar como similar a una *datio in solutum*, como una forma de pago.

La *apotimema* (ἀποτιμema) en realidad era un **pacto añadido** y predeterminado que incluía una eventual *Datio in solutum* llegado el caso. Este **convenio de garantía**, que iba acompañada de un efectivo desplazamiento de la posesión (al modo de un *pignus possessionis romano*). Era una forma de prenda en la cual al vencimiento de la obligación, si el deudor no paga, transformaba la posesión del acreedor en propiedad.

La *apotimema* (ἀποτιμema), este **convenio** conllevaba una cierta publicidad, porque en lugar del desplazamiento efectivo de la posesión, se hacía patente un desplazamiento ficticio mediante la inscripción en los *horoi*.

Paoli¹³, considera que posiblemente las que seguramente se darían en la realidad serían *apotimema* (ἀποτιμema) como equivalente a una *datio in solutum*, reflejada en las lápidas insertas en las fincas u *horoi* (ῥοροι), de las que se tienen documentadas y justifican el hecho de que las fuentes aludan a estas garantías hipotecarias con términos que indican posesión.

LA DATIO IN SOLUTUM EN DERECHO ROMANO

Siguiendo a BLANCH NOUGUÉS¹⁴, cuando el deudor no podía llevar a cabo el cumplimiento exacto de su obligación mediante el pago o *solutio*, recurría a la *datio in solutum* como modo de remediar su insolvencia. Llegado a este punto, el deudor, ofertaba una *satisfactio* al acreedor ofreciéndole la entrega de otra cosa al modo de prestación sustitutiva (δατιο ἰν σολυτυμ), lo que había de ser necesariamente aceptado por éste.

12 PAOLI, “Sul diritto pignoratizio attico”, *ASDGR*, (1976), p. 396.

13 PAOLI, “La datio in solutum nel diritto attico...”, *Op. cit.* p. 396.

14 J. M. BLANCH NOUGUÉS, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*) en Derecho Romano. (RI §408465), *Iustel (Revista General de derecho Romano)*, N.º 13, DICIEMBRE 2009.

1. Origen de la datio in solutum

Prescindiendo de antecedentes más remotos, ya referidos, el origen de la *datio in solutum*, como forma de extinción de las obligaciones, se puede situar en la sociedad romana republicana, un mundo fundamentalmente agrario en el que los campesinos estaban obligados a hacer frente a sus deudas pecuniarias mediante entregas de trigo.

Las fuentes refieren los primeros casos documentados de *datio in solutum* en época de la República¹⁵. MELILLO¹⁶ sitúa así el origen de la *datio in solutum*¹⁷ o el cambio de una prestación por otra en las relaciones obligatorias (“*aliud pro alio*”) en época republicana, y así hace referencia a supuestos del mismo en *Cato*¹⁸, en la *Lex de Gallia Cisalpina*¹⁹ y en la *Tabula Heracleensis*²⁰. SACCOCCIO²¹ reconoce que el *aliud pro alio* debió estar muy generalizado en esta época como lo prueba *Tito Livio*, 26, 35,1-4, en donde refiere un préstamo solicitado a los ciudadanos romanos por el Senado en el 210 a.C. para sufragar los daños producidos por Aníbal en la segunda guerra púnica:

“El préstamo debía devolverse en tres plazos, y sucedió que no hubo problemas respecto a los dos primeros, mientras que en el tercero surgieron dificultades financieras que determinaron la imposibilidad de hacer frente al pago del mismo²².”

Fue entonces cuando el Senado, ante las protestas de grupos de ciudadanos que reclamaban la devolución de sus créditos, ofreció en pago la entrega de fincas situadas en las cercanías de Roma, lo cual fue gustosamente aceptado por dichos ciudadanos descontentos²³.”

Otra cosa es el tratamiento doctrinal de la *datio in solutum* por la jurisprudencia romana como forma de extinción de las obligaciones. Así STEINER²⁴, que reflexiona sobre el ori-

15 Siendo razonable pensar que este modo de extinción de las obligaciones sería ampliamente utilizado por los romanos en sus usos y costumbres. Según Blanch Nougés, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)...*Op. Cit.*, nota 3.

16 MELILLO, G., *In solutum dare. Contenuto e dottrine negoziali nell'adempimento inesatto*, Napoli, 1970, p. 136 ss.

17 Siguiendo a Blanch Nougés, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)...*Op. Cit.*, nota 4.

18 CATO, de agric. 146, 2, (III-II a.C.).

19 neque id solvet satisve faciet...; 21,14-19 (s. I a.C.).

20 ...non solverit neque satisfecerit...; 40-45 (s. I a.C.). SACCOCCIO, A., *Aliud pro alio... cit.*, p.16 ss., ha criticado recientemente estos postulados y no cree que estas fuentes estuviesen estableciendo realmente supuestos de *aliud pro alio*.

21 SACCOCCIO, A., *Aliud pro alio... cit.*, p.16 ss.

22 (Tito Livio, 29,16,1-3).

23 SACCOCCIO, A., *Aliud pro alio... cit.*, p. 20 ss.; *Finanze e debito pubblico nel III a. C.: i c.d. trientabula*, INDEX, 32, Napoli, 2004, p. 319 s.

24 “en cuanto que la *solutio* no era otra cosa que una posibilidad de liberación de la responsabilidad del deudor mediante el pago de una suma de dinero, cualquiera que fuese el objeto de la obligación”. Solo cuando se distingue entre deber y responsabilidad (*Schuld* y *Haftung*), entre deuda y responsabilidad o la garantía para hacer frente al pago de esa deuda, es cuando se puede hablar de la *datio in solutum* como institución autónoma; hasta ese momento, la *solutio* se habría limitado exclusivamente al *eius quod debetur*, esto es al exacto cumplimiento de la obligación; lo que explica que los Proculyanos, por ejemplo, dudaran en reconocer un efecto extintivo *ipso iure* a la *datio in solutum*. STEINER, H., *Datio in solutum*, cit., p. 45 ss. y 77 ss. (cit., SACCOCCIO, A., *Aliud pro alio... cit.*, p. 12).

gen de la *datio in solutum*, considera que la *datio in solutum* aparece en época tardía en el Ordenamiento jurídico romano ya que en una primera época, carecía de regulación.

MELILLO²⁵ considera que dicha labor sistemática no pudo ocurrir por tanto hasta los primeros siglos del Principado en cuanto que la *dación en pago* era considerada como una práctica habitual entre las clases humildes (*humiliores*) de Roma pero no entre la *nobilitas et honestiores*, que como es sabido era la extracción social de dicha jurisprudencia. Como indicamos anteriormente²⁶, es la *datio in solutum* pactada y voluntaria, la que aparece en las fuentes clásicas debido a la necesidad del consentimiento por parte del acreedor para que la *datio* surta efecto.

A este respecto BETTI²⁷, reconstruyó la evolución jurídica de la *datio in solutum* a lo largo de tres fases de la Historia del Derecho Romano:

- a. En la época arcaica, se conceptúa como un acto que procura la *satisfactio* del acreedor ante la imposibilidad del deudor por el incumplimiento de la obligación.
- b. En la época clásica la *datio in solutum* era concebida como una subrogación pactada del cumplimiento en vez del pago debido (*solutio eius quod debetur*).
- c. Y en la época postclásica la *datio in solutum* aparece como un pacto de subrogación consensual pero dotada de efectos obligatorios y enmarcada dentro de los negocios bilaterales de carácter oneroso (como la venta, permuta, o la prenda) que generaba una *actio empti utilis* en caso de evicción.

Aunque se haría necesario distinguir, entre la *datio in solutum voluntaria* y la llamada *datio in solutum necesaria* que es la que tiene lugar cuando la ley “*obliga*” al acreedor a aceptar la prestación substitutiva substitutoria ofrecida por el deudor.

En sede negocial, está claro que la procedente aquí es la *datio in solutum voluntaria*²⁸, en cuanto que es la surge mediante el pacto por el que se entrega una *res*, a cambio de la *satisfactio* del crédito previo (*datio in solutum o pro pecunia*) con eficacia liberatoria *solvendi causa*.

25 MELILLO, G., *In solutum dare...* cit., p. 143 ss.

26 BLANCH NOUGUÉS, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)...*Op. Cit.*, nota 8.

27 BETTI, E., *Appunti di teoria dell'obbligazione*, Roma, 1958, p. 314 ss.; *Istituzioni di diritto romano*, II,1, Padova, 1962, p. 464 ss. (cit., SACCOCCIO, A., *Aliud pro alio...* cit., p. 65-66), BLANCH NOUGUÉS, Una aportación sobre *datio in solutum*...*Op. Cit.*, p. 8.

28 Entre la extensa bibliografía que recoge Blanch Nougés, se puede citar: SACCOCCIO, A., *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*, Milano, 2008, p. 128 ss. STEINER, H., *Datio in solutum*, München, 1914, p. 120 ss.; SOLAZZI, S., *L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano*, P, Napoli, 1935, p. 154 ss.; ASTUTI, G., s.v. *Dazione in pagamento (storia)*, ED., 11, Varese, 1962, p. 727 ss. (p.728); TALAMANCA, M., s.v., *Delegazione (dir. rom.)*, ED., 11, Varese, 1962, p. 923 ss.; CERAMI, P., *D. 39,5,21,1 (Cels. 28 dig.) (Una controversa testimonianza celsina in tema di “delegatio promittendi donationis causa”)*, SDHI, 44, Roma, 1978, p. 185 ss., nt. 105; THIELMANN, G., *Schenkung durch Delegation, Sodalitas*, Scritti in onore di A. Guarino, V, Napoli, 1984, p. 2310. SACCONI, G., *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano, 1971, p. 216.

En la doctrina española, véanse las aportaciones de LÓPEZ-BARAJAS MIRA, M.R., *Sobre delegación y novación*, Labeo, 46, Napoli, 2000, p. 218 ss., y de ALONSO, J.L., *Estudios sobre la delegación, I, La doble atribución patrimonial (Segunda parte)*, Santiago de Compostela, 2001, p. 264 ss.

2. La *Datio in solutum* en la época clásica y post-clásica

Un texto de Ulpiano, recogido en D. 13,7,24 pr., reconoce una *actio utilis ex empto* para el caso de evicción de la cosa dada *pro soluto*, asimilando la *datio in solutum* a un contrato sinalagmático de compraventa:

D. 13,7,24 pr., Ulp., 30 ed.: Eleganter apud me quaesitum est, si impetrasset creditor a Caesare, ut pignus possideret idque evictum esset, an habeat contrariam pigneraticiam et videtur finita esse pignoris obligatio et a contractu recessum immo utilis ex empto accomodata est, quemadmodum si pro soluto ei res data fuerit, ut in quantitatem debiti ei satisfiat vel in quantum eius intersit, et compensationem habere potest creditor, si forte pigneraticia vel ex alia causa cum eo agetur²⁹.

En este caso, Ulpiano da respuesta a la cuestión planteada si en caso de cesión de la cosa dada *in solutum*, si procede una acción *contrariam pigneraticiam*, o una *actio utilis ex empto* para reclamar el *id quod interest* por los daños y perjuicios ocasionados por la evicción, inclinándose por proporcionar al acreedor una acción típicamente de compraventa, como si de ésta se tratase³⁰.

Y en C. 8, 44,4:

Si praedium tibi pro soluto datum aliis creditoribus fuerat obligatum, causa pignoris mutata non est. igitur si hoc iure fuerit evictum, utilis tibi actio contra debitorem competit. nam eiusmodi contractus vicem venditionis obtinet³¹.

Se trata aquí de una constitución del emperador Antonino Caracalla, donde claramente establece una asimilación entre la *datio in solutum* y la compraventa, hasta el punto que en caso de evicción atribuye una *acción útil* contra el deudor-vendedor.

Nuestra jurisprudencia más reciente no es ajena a esta concepción, que ya elaboraron los juristas romanos, equiparando a la dación en pago a la compraventa³².

29 D. 13, 7,24 pr.: Si un acreedor hubiese alcanzado del César la concesión de la posesión definitiva de la prenda, y ésta fue **objeto de evicción**, se me planteó elegantemente la cuestión de si tendrá la acción pignoraticia contraria. Y parece que se extinguió la prenda y se resolvió el contrato; es más, se proporcionó al acreedor una **acción de compra**, como si la cosa le hubiese sido dada a causa de pago, con el fin de que se le satisfaga la cantidad de la deuda o el interés que tiene, y pueda el acreedor hacer la compensación si se le demanda con la acción pignoraticia o por otra causa. GARCIA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo I, p. 752.

30 Se trata de un fragmento que en realidad ha dado lugar a muy diversas interpretaciones y que, en cualquier caso, se ha considerado en mayor o menor medida interpolado por la doctrina romanística en general como Indica Blanch Nougues, siguiendo a Nardi. E., *Radiografia dell'aliud pro alio...* cit., p. 115 ss.

31 C. 8,44,4: Si el predio que se te dio en pago había estado obligado a otros acreedores, no se alteró la causa de la prenda. Así pues, si con arreglo a derecho se hubiere **hecho evicción de la misma, te compete la acción útil contra el deudor**. Porque un contrato de tal naturaleza hace las veces de venta. . GARCIA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo V, Código, p. 377.

32 SSTs de 8 de noviembre de 1966, 7 de diciembre de 1983, 13 de febrero de 1989, 19 de octubre de 1992. Vid., también la RDGRN de 20 de septiembre de 1933.

3. La *datio in solutum* en el derecho Justiniano

La regulación de *datio in solutum* en su modalidad *necessaria* se debe a Justiniano que en Nov. 4,3 (a. 535):

Quod autem de cetero humanis auxiliatur curis, licet quibusdam creditoribus non forte sit gratum, a nobis tamen propter clementiam sancitur. Si quis enim mutuaverit aurum debitoris substantiae credens, at ille ad restitutionem auri non sit idoneus, substantiam autem immobilem habeat verum creditor ardeat aurum omnimodo quaerens, illi vero non sit facile, neque ulla mobilis substantia: damus creditori licentiam volenti immobiles res accipere pro auro³³.

Esta Constitución imperial del año 535, permitía que los acreedores pudieran recibir mediante dación en pago, bienes inmuebles del deudor cuando éste no disponía de dinero ni de otros bienes muebles y hubiere intentado inútilmente vender aquellos inmuebles.

Dicho precepto se enmarca en la crisis económica en la que se encontraba el Imperio Romano por esas fechas. Asimismo, Justiniano también reguló otro caso de *datio in solutum necessaria* en Nov. 120, 6,2 (ann. 544) a favor de las *venerabiles domus*, es decir, de los establecimientos cristianos de beneficencia y caridad,

Hoc etiam super ipis venerabilibus domibus definire praevidimus, ut, si quaedam ex eis sive pro publicis collationibus, sive pro alia necessaria causa eiusdem domus debitis obnoxiae fiant, et non est possibile de rebus mobilibus eadem persolvere debita, primo quidem ordine in speciali pignore dari rem immobilem creditori, ut eius, fructus colligens, reputet sibi tam in ipsis debitis mutuis pecuniis, quam in usuris non amplius quarta parte centesimae³⁴.

Estos establecimientos cristianos, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus deudas o contribuciones fiscales, y no pudiendo entregar bienes muebles para ello, se permitía la entrega al acreedor de inmuebles, al modo de una enfiteusis (*quae in emphyteusin*

33 Novela 4,3: Más aquello con que por lo demás se auxilia á los cuidados humanos, aunque acaso no sea grato para algunos acreedores, es, no obstante, sancionado por nosotros por razón de clemencia. Porque si alguno hubiere dado en mutuo dinero, confiando en los bienes del deudor, mas éste no fuera solvente para la restitución del dinero, pero tuviera bienes inmuebles, y el acreedor apremiara reclamando de todos modo dinero, pero aquel no le fuera fácil tenerlo, ni tuviera ningunos bienes muebles, **le damos licencia al acreedor, que quiera, para recibir bienes inmuebles en lugar de dinero.** GARCÍA DEL CORRAL, *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, tomo 6, *Novelas, Constituciones*, p. 25.

34 Novela 120,6, 2: Y también .hemos considerado, conveniente determinar esto sobre las mismas venerables casas, que, si algunas de ellas se obligaran por deudas o por las contribuciones públicas, o por otra causa necesaria de la misma casa, y no es **posible que dichas deudas sean pagadas con los bienes muebles, se le dé ciertamente en primer lugar al acreedor una cosa inmueble en prenda especial**, para que percibiendo los frutos de ella se los aplique tanto para las mismas cantidades recibidas en mutuo y debidas, como para los intereses, no mayores de la cuarta parte del uno por ciento mensual. GARCÍA DEL CORRAL, *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, tomo 6, *Novelas, Constituciones*, p. 413.

datur) con rebaja de una sexta parte (*relevationem sexta parte redditus*) para que percibiendo los frutos se los aplique a las cantidades recibidas en mutuo con intereses no mayores de la cuarta parte del uno por ciento mensual (3% anual) de tal modo que el pago *debía ser aceptado* por sus acreedores.

Es de destacar que DÍAZ BAUTISTA³⁵, nuestro querido y añorado D. Antonio, en relación a la *datio in solutum necessaria*³⁶ en el campo de los negocios de los banqueros³⁷ en tiempos de Justiniano, reconoce que: “en la Novela 136, 3 se había establecido una subrogación real a favor de los banqueros que podían reivindicar los bienes adquiridos por sus deudores con dinero procedente de mutuos concedidos por aquellos e impagados:

Atque illud profecto non alienum a ratione dicere visi sunt, si cuidam ad res quasdam mobiles vel immobiles emendas pecuniam credant vel antea crediderint, et certam pecuniam dederint, et ex nummis creditis res acquisita sit, omnium se in ipsa re praecipua habere iura neque debere ullum pati damnum, sed si plane probent, pecuniis suis rem comparatam esse, neque illis debitores pecunia satisfacere possint, ipsa res pecunia eorum empti eis addicatur, quasi revera ab illis empti, sola vero emptoris appellatio interposita esset³⁸.

Nos aclara DÍAZ BAUTISTA³⁹ que “este importante privilegio, pese a que atribuía a los banqueros una propiedad sobre los bienes, debía actuar en la práctica como un “*pignus*” con pacto comisorio sobre bienes singulares. Si lo que establecía era una verdadera reivindicación, es evidente que operaría también frente a terceros adquirentes incluso de buena fe”.

Esto resolvería el problema en la *datio necessaria* de qué hacer con los terceros adquirentes y con las cargas posteriores al propio gravamen que graviten sobre los bienes objeto de la garantía, verdadero caballo de Troya, en la doctrina y legislación actuales.

35 DÍAZ BAUTISTA, Antonio, Estudios sobre la Banca Bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano), Murcia, 1987, p. 160 ss: n. 25 vid supra, cap II, &13: “la respuesta de Justiniano a la petición de los banqueros aparece recogida en la Novela 136, 3 y no solo acoge la solicitud de aquellos, sino que según se afirma “aun mas de lo que pidieron” puesto que se les conceden derechos preferentes sobre las cosas compradas con su dinero... Estos derechos preferentes podían operar sin necesidad de probar el impago de la deuda por parte de los prestatarios...”

36 La *dación en pago necesaria* ha tenido una notable importancia a lo largo del Derecho común europeo hasta que los principios liberales que inspiraron la codificación del siglo XIX determinaron su arrinconamiento o casi desaparición de las legislaciones europeas, salvo excepciones, si bien, hoy en día sigue vigente en diversas legislaciones de países iberoamericanos. BLANCH NOUGUÉS, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)...Op. Cit., p. 5.

37 Novella CXXXVI “De Argentariorum contractibus”.

38 Novela 136, 3: Y ciertamente no parece que dijeron sin razón, que si a alguien le prestaran o antes le hubieren prestado dinero para comprar algunos bienes muebles ó inmuebles, y le hubieren dado cantidad cierta, y con el dinero prestado hubiera sido adquirida la cosa, deberían tener ellos contra todos derechos preferentes sobre la misma cosa, y no sufrir perjuicio alguno, pero que **si claramente probaran que la cosa fue comprada con dinero de ellos, y que los deudores no podían satisfacerles el dinero, se les adjudicara la misma cosa comprada con el dinero de ellos, como si en realidad la cosa hubiese sido comprada por ellos**, y se hubiese interpuesto solamente el nombre del comprador. GARCÍA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo 6, Novelas, Constituciones, p.481.

39 DÍAZ BAUTISTA, Antonio, Estudios sobre la Banca Bizantina...Op. Cit, p. 160.

En este sentido, en base al Código de Justiniano [C.8, 34 (33), 3]⁴⁰, podemos ver cómo se prevé la posibilidad de una adjudicación del dominio al acreedor de la prenda, pero concediéndole al deudor por consideraciones humanitarias una adjudicación temporal al acreedor, ofreciéndole a este el dominio de la cosa por la deuda con los intereses y los daños y perjuicios. Una vez transcurridos los dos años, la cosa quedaría irrevocablemente en poder del acreedor como dueño. En el caso que el acreedor le interesara más el pago de su crédito que la entrega de la cosa, conservaría su acción por la prenda. El deudor conservaría el derecho al excedente, teniendo derecho a caución por el importe del sobrante.

III. LA DATIO IN SOLUTUM EN LA TRADICIÓN JURÍDICA ROMANISTA MEDIEVAL

Es de destacar que el empleo de la expresión “*datio in solutum*” no aparece en realidad en las fuentes romanas⁴¹, sino que surge con posterioridad siendo un producto de la tradición jurídica romanista⁴². Lo cierto es que las fuentes utilizan el término “*solvere*”, o “*solutio*” para referirse al cumplimiento exacto de la prestación por el deudor (y a veces para cualquier otra forma de liberación del deudor)⁴³ y en cambio “*satisfactio*” en un sentido más amplio de extinción de la obligación.

40 C. 8.34 (33).3: «tenga el deudor, por consideraciones de compasión, humanitaria acción sobre su propia cosa dentro del término de dos años, contaderos desde el día de la sacra resolución [por la que se le adjudica al acreedor en dominio la prenda], y séale lícito ofrecer al acreedor, que ya fue hecho dueño, la deuda con los intereses y los perjuicios causados por su falta al acreedor, cuya cuantía debe manifestar bajo juramento el acreedor, y recuperar su prenda. Más si hubieren transcurrido los dos años, tenga el acreedor y también dueño plenísimamente la cosa ya hecha suya irrevocablemente.

Más si verdaderamente se hallara que importa menos la prenda y más la deuda, tenga el acreedor íntegra toda su acción respecto a lo que se conoce que importa más su crédito. Pero si por una y otra parte se hallara igual la cantidad, retenga sin ninguna duda toda la cosa antes empeñada. Y si verdaderamente importara menos la deuda y más la prenda, en este caso se le reservarán por nuestra ley al deudor íntegros todos los derechos sobre lo que excede de la deuda, no quedando ciertamente obligado a los acreedores del prestamista, sino reservado para otros acreedores del deudor o para el mismo deudor. Y para que por virtud de la comunidad no resulte alguna dificultad, se le dará licencia al acreedor o al dueño para ofrecerle al deudor o al acreedor del deudor, con la competente caución que respecto a él se debe prestar, el importe de lo sobrante.

Más si después que **con derecho de dominio poseyera el acreedor la cosa hubiere querido venderla**, séale ciertamente lícito hacerlo, pero reservándole al deudor el sobrante que hubiera. Pero si hubiere surgido duda respecto a la venta, como por haber sido hecha por más bajo precio, sea compelido el acreedor a prestar juramento de que no empleó ningún ardid o engaño, sino **que vendió la cosa por tanto en cuanto pudo ser vendida**; y devuélvase solamente lo que en virtud del juramento se hubiere visto que sobraba. Más también si por el juramento se hallara que obtuvo menos el acreedor, tenga íntegra acción por lo restante”.

41 BLANCH NOUGUÉS, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)...*Op. Cit.*, p. 5, que en las fuentes no aparece la expresión “*datio in solutum*” sino otras como las de *in solutum dare* 12, *in solutum suscipere* 13, *aliud pro alio (consentiente creditore) solvere* 14, *rem pro re solvere* 15, *pro eo quod debeo aliquid solvere* 16, *rem pro pecunia solvere* 17, *pro soluto rem dare* 18, *pro debito solvere (dare)*.

42 MELILLO, G., *In solutum dare*...*cit.*, p. 134-135, advirtió que la expresión *datio in solutum* no aparece ni en el Digesto ni en otros escritos jurisprudenciales y que es muy limitado el uso de *datio* entre la jurisprudencia clásica. Por el contrario, señala que el cambio convencional del objeto obligado es referido a través de locuciones como “*aliud commutare*”, o “*aliud pro alio permutare*” o “*in quantitatem debiti satisfacere*”. *Cit.* BLANCH NOUGUÉS, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)...*Op. Cit.*, nota 11.

43 MELILLO, G., *In solutum dare*...*cit.*, p. 1 ss. *Cit.* por Nougés, *op. Cit.* p. 7.

1. En la Glosa y Comentaristas

SACCOCCIO señala que la Glosa acursiana utilizó expresiones tales como “*aliud pro alio solvere*”, “*dare in solutum*” o “*in solutum dare*”, pero no específicamente la de “*datio in solutum*”. No obstante, dicho autor destaca que Acursio ya utilizó la expresión de “*datio in solutum*” en algunos casos aislados en los que “*mediante la aproximación hacia la compraventa, lo que parece tal vez indicar una mayor conceptualización de la institución*”.

Entre los comentaristas⁴⁴ mientras Bártolo de Sassoferrato (1314-1357+) no empleó aún, prácticamente, la frase “*datio in solutum*”, la misma aparece ya con otras expresiones análogas en los escritos de Baldo de Ubaldis (1327-1400) y en los de Giason del Maino (1435-1519), siendo ya habitual dicho empleo en las obras de juristas franceses del siglo XVI como Douaren (1509-1559) o Cuyacio (1522-1590) y, con carácter general, en la doctrina civilista europea de la Edad Moderna, según nos recuerda Blanch Nougés⁴⁵.

2. En las Partidas

Nuestro Rey sabio, D. Alfonso, en el siglo XIII, en La Partida 5^a⁴⁶, se pueden encontrar trazas de una entrega al acreedor, previo conocimiento judicial de la estimación de suerte que prevalezca la estimación de la prenda, aunque la deuda sea mayor o menor.

IV. LA DATIO IN SOLUTUM EN LA DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ACTUAL

1. La cuestión en la doctrina civilista

La doctrina civilista actual⁴⁷ se ha manifestado en línea con la tradición jurídica europea de base romanista, de la asimilación de la dación en pago con un *contrato de compraventa*,

44 SACCOCCIO, A., *Datio in solutum*... cit., p. 4897. Cit. por Nougés, op. Cit. p. 7.

45 En este último sentido, se ha manifestado un amplio sector de la doctrina y jurisprudencia italiana (SACCOCCIO, A., L'evizione nella c.d. in solutum dal diritto romano all'art. 1197 CO. 2 CC. IT. 1942, en *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 2, Napoli, 2006, p. 269 ss. (p. 337 ss.)). BLANCH NOUGÉS, Una aportación sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la dación en pago (*datio in solutum*)... Op. Cit., p. 11.

46 Partida 5, 13, 44: “Queremos que competa al conocimiento judicial la estimación de la prenda, mientras permanezca **en poder del acreedor y dueño**, ya si respecto a la **deuda es de mayor o menor cantidad**, de suerte que prevalezca respecto a la estimación de la prenda lo que sobre esto hubiere determinado el juez».

47 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. R., *Naturaleza jurídica de la dación en pago*, Anuario de Derecho Civil, 10,3, julio-septiembre, Madrid, 1957, p. 753 ss.; Díez-PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, II, Las relaciones obligatorias* (6), Madrid, 2008, p. 631 ss. ALBALADEJO GARCÍA, M., *La dación en pago*, en Extinción de las obligaciones, (dir., Ferrándiz Gabriel, J.R.), Madrid, 1996 p. 425 ss. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,- VALLADARES RASCÓN, E., *Comentario al art. 1166 del CC*. Comentarios al CC dirigidos por M. Albaladejo, t. XVI, vol. 1º, Madrid, 1991, p. 117 ss. SERRANO ALONSO, E., *Consideraciones sobre la dación en pago*, Revista de Derecho Privado, LXII, Madrid, 1978, p. 421. SERRANO CHAMORRO, Mª. E., *Entrega de cosa distinta a la pactada*, Cizur Menor (Navarra), 2006. En la doctrina francesa actual: BICHERON, F., *La datio en paiement*, Paris, 2006.

siguiendo los antecedentes romanos y afirmando en general, la naturaleza contractual de la *datio in solutum*, a igual que ocurre en nuestra legislación civil en sintonía con otros ordenamientos jurídicos⁴⁸.

Ahora bien, dentro de esta figura contractual, la posiciones oscilan entre los que afirman el carácter novatorio del convenio entre acreedor y deudor dirigido al cambio del objeto de la obligación con el consiguiente efecto extintivo del mismo (SASTRE PAPIOL⁴⁹), o los que defienden que mas que una novación por cambio de objeto, lo que en realidad se produce es un pacto modificativo del objeto de la obligación que no da lugar a la extinción total de la misma, siendo una figura de naturaleza compleja (CASTAN TOBEÑAS⁵⁰).

Entre la más reciente, MARTÍN BRICEÑO⁵¹ en RCDI en 2013, señala que “la dación en pago ha reaparecido en la escena jurídica. Se ha tratado de recuperar como modo de extinción de las deudas pendientes con las entidades financieras acreedoras”.

Su finalidad en la actualidad es la de paliar los graves efectos sociales derivados del crecimiento desmesurado de los procesos de ejecución hipotecaria, agudizados por la crisis, ante el impago de los préstamos hipotecarios. Ante una ejecución por impago de deudas garantizadas con hipoteca, se pensaba que el problema se solucionaba con la entrega de la vivienda al acreedor, lo que ocurre es que esto choca abiertamente con nuestra legislación que se basa en el principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 del CC)⁵².

48 En cuanto a la **legislación española** el CC español en este punto como en tantos otros sigue al Código Civil francés de 1804, no regulando una verdadera normativa sobre la dación en pago; así, el artículo 1166 del CC.: “*El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor*”. Simplemente se limita a admitir implícitamente la posibilidad de que el deudor se libere del cumplimiento de la obligación ofreciéndole al acreedor una prestación distinta siempre que éste acepte (también se alude a la dación en pago en los artículos 1521 (“*El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago*”), 1636 (“*Corresponden recíprocamente al dueño directo y al útil el derecho de tanteo y el de retracto, siempre que vendan o den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica. Esta disposición no es aplicable a las enajenaciones forzosas por causa de utilidad pública*”). Y finalmente en el 1849 del CC, en los dos primeros se la aproxima al contrato de compraventa y en el art. 1849 se trata de la *extinción de las fianzas en virtud del acuerdo de dación en pago*, lo que ha dado lugar, a su vez, a una larga discusión doctrinal sobre si dicho precepto significa una aceptación implícita del Código Civil de la teoría de la novación de la obligación). En el Derecho Foral vemos también como la Ley 495 del **Fuero Nuevo de Navarra** contiene una somera regulación de esta materia. Frente a ese tipo de regulación de los códigos latinos se encuentran el parágrafo 1414 del **A.B.G.B. austriaco** que configura la dación en pago como un negocio oneroso, o el **B.G.B. alemán** que regula la dación en pago en los parágrafos 364 y 365 y, siguiendo a la pandectística alemana, viene a acercar su naturaleza al *contrato de compraventa*, en consonancia con la tradición jurídica romanística.

49 SASTRE PAPIOL, S., La dación en pago. Su incidencia en los convenios concursales, Barcelona, 1990, p. 220.

50 CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho Civil Español*, III (7), Madrid, 1953, p. 257.

51 MARTÍN BRICEÑO, M^a R., “La dación en pago: sustitución del cumplimiento estricto en una relación obligatoria”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, N.º 735 (2013), págs. 359 a 388.

52 Esto hace que si el valor de la vivienda, en el momento de la ejecución, no es suficiente para saldar la deuda, el acreedor aún puede perseguir y embargar otros bienes del deudor hasta obtener plena satisfacción de lo que se le debe por principal, intereses y costas (arts. 105 de la LH y 579 de la LEC). GÓMEZ GÁLLIGO, JAVIER, *Presente y futuro de la garantía hipotecaria* Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, (RCDI), Enero 2013, numero 735, págs. 19 a 35.

2. En la Jurisprudencia Civil

Algunas sentencias⁵³ han dado pie a un fuerte debate sobre si la actuación prepotente del acreedor al ejercitar una doble acción personal y real reclamando el crédito hipotecario que en la mayoría de las veces excedía del valor obtenido por la vivienda, podía suponer un abuso de derecho, considerando que si el deudor debe de hacer frente a las consecuencias de sus compromisos, también las entidades financieras debieran asumir el riesgo derivado de la tasación inicial del bien y de la concesión de préstamos arriesgados para la adquisición de viviendas que después se hubian desvalorizado.

Por ello se pensaba que la *dación en pago* de la finca dada en garantía debería ser suficiente para dar por extinguida la deuda. En un principio, la mayoría de la jurisprudencia se inclinó por entender que no se estaba ante un ejercicio abusivo del derecho, sino que se trataba de una opción permitida por nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto que no se producía enriquecimiento injusto por parte de la entidad financiera⁵⁴.

3. En la Legislación Civil e hipotecaria

La dación en pago como fórmula legal, si que era admitida para bienes muebles en caso de prenda en el art. 1872 CC⁵⁵ al permitir que “*si la segunda subasta no diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso está obligado a dar carta de pago de la totalidad de la deuda*».

Y si era admisible en bienes muebles, ¿por qué no en los inmuebles? De hecho, Gómez Gállico⁵⁶, considera que no es algo insólito en materia inmobiliaria, porque ya en la regulación de la llamada *hipoteca inversa*⁵⁷ se articula un *régimen de limitación de responsabilidad de los herederos a los propios bienes recibidos por herencia*, en clara contradicción del principio general del artículo 1911 del Código Civil⁵⁸: “*Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros*”.

Tratándose de dación en pago convencional⁵⁹ teóricamente no plantea problemas su admisibilidad, salvo lo relativos a la cancelación de cargas posteriores a la hipoteca pactada,

53 SSTS de 29 de abril de 1991, *RJ* 1991/3106 (2); STS de 18 de noviembre de 1996, *RJ* 1996/8639 (3); SAP de Alicante (Sección 7.ª) de 1 de febrero de 2002, *JUR* 2002/112215, SAP de Navarra (Sección 2.ª) de 19 de abril de 2004, *JUR* 2004/151845.

54 GÓMEZ GÁLLIGO, JAVIER, Presente y futuro de la garantía hipotecaria...op. Cit., p. 19.

55 Art. 1872 CC: «El acreedor a quien oportunamente no hubiere sido satisfecho su crédito podrá proceder a la realización de la prenda. Esta enajenación deberá hacerse precisamente en subasta pública, y con citación del deudor y del dueño de la prenda en su caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso está obligado a dar carta de pago de la totalidad de la deuda».

56 GÓMEZ GÁLLIGO, JAVIER, Presente y futuro de la garantía hipotecaria...op. Cit., p. 20

57 En la Disposición Adicional primera de la Ley 41/2007.

58 Art. 1911 CC.: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

59 la *dación en pago obligatoria* sería muy dañina para el conjunto de la economía y de la hipoteca en particular, pero nada impide adoptar medidas de impulso de la *dación en pago voluntaria* y de instrumentos procesales que vinculen al acreedor a la tasación realizada, así como de soluciones excepcionales que permitan

ya que legalmente se posibilita a través del *pacto de limitación de responsabilidad hipotecaria* a la propia finca hipotecada en el art. 140 LH. Donde se dispone:

Artículo 140 LH.-“No obstante lo dispuesto en el artículo 105⁶⁰, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.

En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor...”

Al tratar de la hipoteca de Responsabilidad Limitada⁶¹, que regula el Art. 140 LH, vemos que cuando dice: “no obstante, podrá válidamente pactarse...” lo que marca una diferencia con el Art. 105 LH donde se establece que “la hipoteca no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el art. 1911 del CC....”.

La realidad, es que Art. 140 LH., nunca se pacta; cualquiera que haya firmado una hipoteca o simplemente la haya solicitado a un banco, si la entidad no concede el préstamo, o no lo autoriza, simplemente la hipoteca no se constituye⁶².

Aunque seamos realistas: la potestad de decisión última está pues en manos de la entidad financiera, pues es necesaria su libre voluntad para aceptar el inmueble como forma de pago, y en segundo lugar, de darse por satisfecha y otorgar carta de pago de la obligación.

O reclamar mayor cantidad, considerando la dación un pago parcial⁶³. Lo cierto es que según ADÁN GARCÍA se ha constatado en las oficinas registrales un considerable aumento de daciones en pago de la deuda hipotecaria contraída con las entidades de crédito. Se trata de este modo, de corregir la morosidad y de evitar acudir a la vía ejecutiva⁶⁴.

4. La cuestión en otros ordenamientos jurídicos⁶⁵

En otros ordenamientos, como en los países anglosajones, la entrega del bien hipotecado al acreedor extingue la obligación garantizada y libera al deudor de responsabilidad; así en

la liberación del deudor con la entrega de la vivienda a determinados deudores en situaciones de exclusión o de insolvencia. GÓMEZ GÁLLIGO, JAVIER, *Presente y futuro de la garantía hipotecaria...op. Cit.*, p. 35.

60 Artículo 105 LH: “La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 del Código Civil”.

61 PAU PEDRÓN, Antonio, La hipoteca de Responsabilidad Limitada, en “DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: un drama legal y un problema social”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 19.

62 La cuestión es si al hacer la tasación, el bien daba cobertura suficiente al crédito concedido... ¿Cómo es posible que al hacer la adjudicación se admita una desvalorización en algunos casos del 40 %? ¿Para qué sirven los analistas y las prospectivas de los expertos de las entidades? ¿No podían preverlo? ...y si lo previeron y optaron por la solución más favorable unilateralmente para sus entidades, aun cuando ello significara un gravísimo perjuicio económico, personal o social para sus clientes ¿no podían haberlo advertido a sus clientes?

63 JIMÉNEZ PARÍS, TERESA A., Dación en pago de la vivienda hipotecada y pacto comisorio, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, N.º 724, págs. 1043 a 1214, p. 1159.

64 ADÁN GARCÍA, M.º E., «La dación en pago», en *Jornadas sobre la hipoteca ante la crisis económica*. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2009, pág. 509 y sigs.

65 BELICHON ROMO, M.R., La dación en pago en el Derecho español y en el Derecho comparado. Madrid, 2012.

países como Estados Unidos, el hipotecado que no puede hacer frente a su cuota mensual del crédito, puede adjudicar al Banco la vivienda y liquidar así su deuda con la entidad acreedora, sea cual sea el valor de la vivienda⁶⁶.

Pero no ocurre así en el Derecho español.

Como señala INSA⁶⁷, no es suficiente devolver la vivienda para cancelar la hipoteca, puesto que si el valor en ese momento de la vivienda es inferior al del capital que falta por amortizar, el deudor seguiría debiendo al banco la diferencia al contrario de lo que sucede en otros sistemas financieros.

A partir de ahí, el particular deberá responder con otros bienes patrimoniales, si es que los tiene o con la nómina de su trabajo (si es que no está en situación de exclusión social, y sin rentas laborales) el pago del importe restante, que seguirá devengando los intereses pactados a favor del banco con las actualizaciones establecidas⁶⁸.

Lo paradójico es que la dación en pago pueda ser el instrumento jurídico utilizado por los extranjeros insolventes, que probablemente no poseen otros bienes en territorio nacional mas que los hipotecados, siendo en la práctica su único patrimonio, de modo que *su responsabilidad de facto no irá mas allá del importe de los bienes hipotecados* (como establece el artículo 140 LH *limitación de la responsabilidad hipotecaria, y ello sin necesidad de haberlo pactado expresamente*), y que los españoles o los sujetos a la legislación española tengan que responder como dice el 1911 del Código Civil ... *con todos sus bienes, presentes y futuros*⁶⁹.

De todas formas sería interesante distinguir la dación en pago⁷⁰ (*cessio pro soluto* o *datio in solutum*) de la cesión de bienes para pago (*cessio pro solvendo*)⁷¹. En la *cessio pro solvendo*, esto es, en el pago por cesión sólo libera al deudor de su responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos (Art. 1175 CC.), mientras que en la *cessio pro soluto*, la entrega produce automáticamente la extinción de la primitiva obligación⁷².

66 JIMÉNEZ PARÍS, TERESA A., Dación en pago de la vivienda hipotecada...op. Cit., p. 1159.

67 INSA, Mireia, "¿Qué hacer ante la imposibilidad de pagar la cuota hipotecaria? La dación en pago como vía para saldar la deuda hipotecaria", en *Inmueble. Revista del Sector Inmobiliario*, núm. 94, 2009, págs. 35 a 38.

68 Además el Banco no tendría por qué aceptar como valor de la vivienda para una dación en pago el que aparece en la escritura de hipoteca a efectos de subasta. Ese valor es a efectos de subasta, no un compromiso perpetuo de recompra a un precio pactado. INSA, Mireia, «¿Qué hacer ante la imposibilidad de pagar la cuota hipotecaria? La dación en pago como vía para saldar la deuda hipotecaria», en *Inmueble. Revista del Sector Inmobiliario*, núm. 94, 2009, págs. 35 a 38.

69 JIMÉNEZ PARÍS, TERESA A., Dación en pago de la vivienda hipotecada...op. Cit., nota 11.

70 BELICHON ROMO, M.R., La dación en pago en el Derecho español y en el Derecho comparado. Madrid, 2012.

71 Regulada en el artículo 1175 del Código Civil. Como señala la STS de 1 de marzo de 1969: «la cesión de bienes a los acreedores no debe confundirse con la dación en pago, pues, como ha precisado la doctrina de este Tribunal, aquella implica abandono de los bienes del deudor en provecho de los acreedores para que éstos apliquen su importe líquido a la satisfacción de su crédito restituyendo el remanente al deudor» (STS de 3 de enero de 1977. RJ 1977/1).

72 En este sentido, SSTs de 11 de mayo de 1912, 9 de diciembre de 1943, 13 de mayo de 1973, 13 de febrero de 1989, 7 de octubre y 19 de octubre de 1992 y 28 de junio de 1997.

5. La cuestión en la jurisprudencia europea y legislación estatal actual

Como dijimos al principio, el tema es de tan candente actualidad, que recientemente se ha celebrado en Granada un *CONGRESO NACIONAL SOBRE DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: “UN DRAMA SOCIAL Y UN PROBLEMA LEGAL”*, durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013⁷³.

Entre lo mas reciente, es de destacar “La Stia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de Marzo de 2013 donde declara contraria a la Directiva 93/13 de CEE, la normativa española en sede de ejecución hipotecaria en cuanto que no permite formular oposición basada en el carácter abusivo de ciertas clausulas contenidas en los contratos de préstamo hipotecario. Lo que dice es que “no es legal un procedimiento de ejecución en el que el Juez no puede entrar a valorar esa posible alegación (nulidad basada en el carácter abusivo de ciertas clausulas) realizada por el ejecutado...”⁷⁴.

Entre las medidas de protección de los deudores hipotecarios, es de destacar la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social.

Ley que ha nacido sin el consenso, ni concurso de los distintos actores parlamentarios. Es una ley que no resuelve el tema de fondo del drama social de la falta de recursos económicos de personas en el umbral de exclusión, y que nace sin vocación de perdurabilidad, pues fija su plazo de vigencia en 2 años⁷⁵.

Esta ley pretende reforzar la independencia de las sociedades de tasación respecto a las entidades de crédito (*según su Exposición de motivos*), estableciendo en su art. 4, *la necesidad de una homologación previa de los servicios de tasación de las Entidades de Crédito* pero no ha conseguido llevar a cabo la necesaria garantía de independencia, prohibiendo directamente que los servicios de tasación no tuvieran relación con los bancos de los que dependían, remitiéndose a un reglamento interno de conducta de dichas entidades Tasadoras.

73 Donde tuve el honor que me nombraran miembro del comité científico y vocal del tribunal de comunicaciones del Congreso. De esta manera, pude acceder al contenido de muchas de las intervenciones de los ilustres ponentes recogidas en libro de reciente publicación: OLMEDO CARDENETE, M. / SANCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, I., *DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: un drama legal y un problema social*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014.

74 REVISTA *EL NOTARIO DEL SIGLO XXI*, Marzo-Abril 2013, Editorial, p. 3.

75 Esta Ley ha sido una ley sin el consenso, ni concurso de los distintos actores parlamentarios. Es una ley que no resuelve el tema de fondo que no es otro que el drama social y la falta de recursos económicos de personas en el umbral de exclusión, que nace sin vocación de perdurabilidad, pues fija su plazo de vigencia en 2 años. La pretensión de una dación en pago [voluntaria] ha sido desatendida por la ley de 2013, considerando que esa no es la panacea, sino la caja de pandora para aquellos acreedores que tuvieran cargas posteriores sobre el bien hipotecado, que esté incurso en una solución extrajudicial como es la dación en pago LLEDÓ YAGÜE, Francisco, *La Ley 1/2013 de 14 de mayo (BOE 15/mayo/2013). El drama DE LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS. DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: un drama legal y un problema social*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 78.

Según PAU PEDRÓN⁷⁶, si el valor de tasación es independiente del valor que se obtiene en la ejecución, esto supone que al final la pérdida la asume el deudor.

En tanto que la adjudicación a favor del banco extingue el derecho de hipoteca, pero no la deuda hipotecaria procedente del crédito concedido para la adquisición de la vivienda; al final, la cantidad no satisfecha se sigue debiendo al banco por el deudor⁷⁷. La adjudicación a favor del banco produce la transmisión a su favor de la propiedad de la vivienda⁷⁸, pero no la cancelación de la totalidad de la deuda.

6. LA RESPUESTA LEGISLATIVA EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

Por lo que hace referencia a la Legislación Autonómica, es de mencionar la reciente legislación de Andalucía (es previsible que las demás hagan lo propio), con la ley 7/2013 de 9 de Abril de la Comunidad Andaluza, dictada para asegurar la función social de la vivienda, destinada a personas en situación de especial emergencia (*en riesgo de exclusión social*) incursas en procedimiento de desahucio, pero de aplicación a las viviendas adjudicadas únicamente a los bancos por impago del préstamo, declarando en tales casos la expropiación de urgente⁷⁹.

La solución dada por la ley Andaluza es la de expropiar a la entidad adjudicataria el derecho de uso y disposición, subrogándose la Junta de Andalucía en el lugar del adquirente (usualmente la entidad financiera), y convirtiéndose en arrendataria del desahuciado a cambio de una renta testimonial, que lo mismo no paga *-porque no puede-*... y al que probablemente no puede desahuciar al afortunado con tal medida porque estaría feo e ilógico que lo hiciera con el mismo al que facilita la medida habitacional.

Al final, como vimos en época de la República el caso que nos refiere *Tito Livio*⁸⁰, ante la imposibilidad de pagar las deudas a los ciudadanos romanos el Senado de Roma ofreció en pago ciertas fincas, corría entonces el año 210 a.C...

Lo dicho: como dice el Eclesiastés (1, 10): *Nihil novum sub sole*, [No hay nada nuevo bajo el sol...]

76 PAU PEDRÓN, Antonio, La hipoteca de Responsabilidad Limitada, en "DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: un drama legal y un problema social", Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 19.

77 PAU PEDRÓN, Antonio, La hipoteca de Responsabilidad Limitada, op. Cit., p. 19.

78 Esto sin tener en cuenta además que el banco tendría que abonar los gastos de comunidad, servicios y suministros. El banco pagaría el IBI y los seguros (aunque el RD ley 27/2012 no lo aclara), lo mismo que si el banco tiene que hacer frente a las reparaciones necesarias de la vivienda. CARRASCO PAPER, Ángel, "Hipotecas sin desahucios". *DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS: un drama legal y un problema social*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p.42.

79 CARRASCO PAPER, Ángel, "Hipotecas sin desahucios", p. 42.

80 TITO LIVIO, 26, 35,1-4.

LA NAVE COMO UNIDAD JURÍDICA EN DERECHO ROMANO: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A D. 47, 9, 3, 8 (ULP. 56 AD EDICT.)

EMILIA MATAIX FERRÁNDIZ

Universidad de Alicante

El presente artículo centra el objeto de su estudio en una única fuente –D. 47, 9, 3, 8 (Ulp. 56 *ad edictum*)– que trata el robo de clavos de una nave naufragada mediante un senadoconsulto (en adelante, SC) de época del emperador Claudio, así como la punición del *naufragium suppressum* a través por otro SC de época indeterminada la extensión de la *Lex Cornelia de sicariis*¹. La cuestión que nos concierne –de la cual, hasta ahora no hemos encontrado un estudio sobre el particular–, es la que se centra en la concepción de nave como unidad jurídica, problema que afrontaremos desde el ángulo en que nos sitúa Ulpiano diciendo:

D. 47, 9, 3, 8 (Ulp. 56 *ad edictum*). Senatus Consultum Claudianis temporibus factum est, tu si quis ex naufragio clavos vel unum ex qui abstulerit, omium rerum nomine teneatur. Item alio senatus consultu cavetur eos, quorum fraude aut consilio naufragi supressi per vim fuissent, ne navi vel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae de sicariis lata est, poenis adficiendos: eos autem, qui quid ex miserima naufragorum fortuna rapuissent lucrative fuissent dolo malo, in quantum edicto praetoris actio daretur. Tantum et fisco dare debere.

1 En cuanto a la contribución jurisdiccional de Claudio, GAUDEMETJ. *L'empereur interprète du droit*, en *Festschrift Rabel*, 2, Tubinga, 1954, p.174, “l'oeuvre interprétative des premiers empereurs semble avoir été modeste et prudente. Claude, dont l'engouement pour le droit suscitait les railleries de Suétone, légiféra, jugea, provoqua des lois ou des SC, mais en paraît pas avoir été souvent sollicité d'interpréter le droit”; MAY, G. *L'activité juridique de l'empereur Claude*, RHD, 1936, pp.76ss., que indica que la situación particular que lleva a Claudio a ocupar el puesto de emperador fue determinante para que éste decidiera colaborar de forma cercana con el Senado, motivo por el cual se aprecia una gran intervención suya en la transformación del derecho bajo Claudio, al mismo tiempo que el príncipe se convertía en colaborador asiduo del senado. En la época de Claudio el tribunal imperial formado por el emperador y el Senado ya había alcanzado el gran desarrollo que inició y que pretendía lograr su predecesor Augusto, *vid.* PUGLIESE, G. *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, en ANRW, 14.2, Berlin-Nueva York, 1982, p.739; CHASTAGNOL, A. *Le Senat Romain à l'époque impériale: recherches sur la composition de l'assemblée et le statut de ses membres*, Paris, 1992

De su lectura podemos inferir la noción de la concepción de la nave como unidad jurídica a través del hecho que la punición impuesta al sujeto que quitaba los clavos de la nave se daría por razón del daño a toda la nave concebida como un todo orgánico. Pero para lograr el análisis de esta noción de nave, debemos estudiar la concepción de sus elementos y su cualificación por parte de la jurisprudencia romana.

La delimitación o definición de un concepto en Derecho romano es una tarea bastante compleja y que suele generar confusión, ya que a pesar de la teoría de Carcaterra de que los latinos tenían tendencia a precisar y definir conceptos –como el mismo autor indicaba– no es habitual encontrar definiciones en la literatura jurídica republicana y clásica². Por este motivo, la actuación más habitual a la hora de intentar delimitar o definir un concepto, será la de acudir a los diversos fragmentos del Digesto que traten temas relacionados con éste, y que de ahí intentemos reconstruir una noción de nave más adecuada al fin que nos proponemos. De entre los diversos fragmentos que aquí se citan, podremos observar que se incluyen tanto los que se corresponden a comentarios de libros *ad sabinum* como *ad edictum*. Ello es un rasgo que nos muestra que la concepción de determinados objetos como unidad jurídica era ya un problema que preocupaba a los juristas ya en el s. I a.C., pues como es sabido el pensamiento de Sabino conectaba con la doctrina de Q. Mucio Escévola.

Teniendo en cuenta esta limitación, dedicaremos la primera parte de nuestro estudio a intentar llevar a cabo una recapitulación de datos que nos permitan trazar el concepto y características de la nave en Derecho romano. La segunda parte se centrará en el análisis de la pena aplicable al caso teniendo en cuenta el texto en su conjunto, y por lo tanto la influencia del segundo SC contenido en el fragmento.

*Nota aproximativa a la concepción romana de nave.

Son varios los estudios que han tratado de aproximar una noción jurídica de nave en derecho romano³. De su lectura podemos extraer dos observaciones principales; A/ no existe una “doctrina de la nave” elaborada por los juristas clásicos. Este hecho se produjo en parte porque –como hemos mencionado anteriormente– los juristas de la época en general rechazaban definir los conceptos⁴. B/ Las opiniones doctrinales coinciden en que la nave formaba parte del paradigma de las cosas móviles, aunque una cuestión controvertida es la que se centra en si ésta constituía una cosa compuesta⁵ y de particular naturaleza.

2 CARCATERRA, A. *Le definizioni dei giuristi romani. Metodo, mezzi e fini*. Nápoles, 1966, pp. 167 ss.; libro que se complementa – o ha sido superado- en relación con su tema de estudio, por MARTINI, R. *Le definizioni dei giuristi romani*, Milán, 1966.

3 De los cuales destacamos GANDOLFO, L. *La nave nel diritto romano*, Génova, 1883; DE MARTINO, F. *Navis eadem navis*, RDN, III, 1935, pp. 41ss.; MANARA, G. *La nozione giuridica di nave*, en *Studi in onore di Francesco Berlingieri*, Roma, 1933, pp. 380ss.; RICHICHI, R. *L'inquadramento della nave nelle categorie delle “res” in diritto romano*, Rivista de diritto romano, I, 2001, en <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>; MOSCHETTI, C.M. *Nave*, en *Enc.dir.* 27, 1977, pp. 565-76; RIGHETTI, G. *Contributo alla teoria giuridica della nave*, en *Studi in onore di Giorgio Berlingieri*, Génova, 1964, pp.448ss. *Ead.* *Auct, Nave*, en NNDI, XI, Turín, 1965, pp. 79ss.

4 DE MARINI AVONZO, F. *Coesistenza e connessione tra “iudicium publicum” e “iudicium privatum”*. Ricerche sul diritto tardo classico, BIDR, LIX-LX, 1956, p.126; MARTINI, R. *Le definizioni*, 343-4; WATSON, A. *The Spirit of Roman Law*, Athens (Georgia), 1995, p. 123.

5 O una cosa colectiva, *vid.* A propósito MENTXAKA, R. *La pignoración de las colectividades en el Derecho romano clásico*, Bilbao, 1986, pp. 217 ss.

Partiendo de una concepción que se centrase en el carácter instrumental de la nave, podríamos identificarla como una construcción capaz de flotar, hecho que no dejaban de tener en cuenta los juristas clásicos, y que podemos ver reflejado por Ulpiano en D. 7, 1, 12, 1 (Ulp. Lib. 17 *ad Sabinum*):

navis usu fructu legato navigandum mittendam puto, licet naufragii periculum imminet: navis etenim ad hoc paratur, ut naviget.

Una vez establecida esta premisa acerca de la utilidad de la nave, debemos preguntarnos si ésta se concebía únicamente para un tipo de navegación o si el concepto era más extenso. En respuesta a ello, encontramos D. 14, 1, 1, 6 (Ulp. 28 *ad ed.*) en el que Ulpiano, de acuerdo con el carácter didáctico propio de su lenguaje⁶, aportaba una aclaración a la cuestión indicando:

Navem accipere debemus sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget sive schedia⁷ sit.

Fragmento por el que podemos ver confirmado que la característica principal de la nave era su utilidad para llevar a cabo la navegación, sin importar el hecho de si esta actividad se realizaba en un río, estanque o bien en el mar.

En este punto hemos partido del concepto romano de nave que entendía ésta como un todo orgánico, pero para perfilar mejor los rasgos de esta noción, debemos de matizar que los romanos identificaban la nave como una *res mobilis*, algo que podíamos ver reflejado en D. 43, 24, 20, 4, (Paulo, 13 *ad sabinum*) *Quod in nave fit vel in alia qualibet re vel amplissima, mobili tamen, non continetur hoc interdicto*, y como una *res connexa*⁸, rasgo que apreciamos en la lectura de D. 41, 3, 30pr (Pomp. Lib. 30 *Ad Sabinum*) *Tria autem genera sunt corporum: (...) alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συννημμένον (connexum) vocatur, tu aedificium, navis, armarium*. En resumen, la nave conformaría un objeto mueble flotante en el que todas sus partes se unían para formar una unidad de hecho y de derecho⁹. Todo esto puede parecer bastante

6 HONORÉ, T. *Ulpian*, Oxford, 1982, p. 247, "what sort of lawyer was he? Not a man of keen analytical power, certainly no genius. His importance remains in the part he played in the transmission of Roman legal heritage."

7 Un hecho destacado por algunos autores (DE MARTINO, F. *Navis*, 43ss.; RICHICHI, R. *L'inquadramento*, 2), que la palabra *schedia* en este fragmento suponía un préstamo del griego, por contraposición al término latino *ratis*.

8 Característica que también mencionaban: Macr. *Sat.* 2.6.2; Quint. *Inst.* VI, 3, 87

9 MOSCHETTI, C.M. *Nave*, 566 ss.; que indica acertadamente como fuentes que indican la definición jurídica de nave, D. 14, 1, 1, 6 (Ulp. 28 *ad ed.*); 43, 12, 1, 14 (Ulp. 68 *ad edict.*); también en ALBANESE, B. *La nozione di furtum fino a Nerazio*, AUPA, 23, 1953, pp. 81-2, 140 ss. En esta últimas páginas Albanese realiza un análisis de los diversos apartados de este fragmento del Digesto, en el que nuestro interés se centra principalmente en el fragmento 4. En éste se presenta el caso de la sustracción del asa de una copa por un sujeto que dice ser el dueño de ésta, hecho que Ulpiano, conforme a la concepción orgánica que vamos defendiendo, entiende que se trata de un robo de la copa entera.

obvio, pero no deja de tener importancia confirmar las definiciones de sobra conocidas en la actualidad con las fuentes antiguas.

La identificación de los elementos que conformaban la estructura de la nave se debe llevar a cabo también a partir del examen de los testimonios de los textos jurídicos que nos proporciona el Digesto. De su lectura podemos observar que ésta estaba formada por:

- *membra*¹⁰ o *partes*¹¹ (elementos esenciales sin los cuales la nave no podía funcionar y que forman esencialmente la unidad, por ejemplo el casco o los clavos)
- *instrumenta* (bienes que estaban destinados al servicio de la nave, como las velas)¹²
- *armamenta* (elementos técnicos de la nave y que formaban parte de sus utensilios, como el ancla)¹³.

De la enumeración de los elementos que formaban la nave, se debe destacar que los más importantes de los mencionados son los designados como *partes o membra*, y que de esta denominación se extrae una cuestión dudosa, relacionada con la calificación de la nave dentro del paradigma de la *res*, sin hacer gala de ningún elemento distintivo dentro de ésta. Ello ha sido una cuestión discutida por Manara¹⁴, que sostenía que la nave era una *res* compuesta de naturaleza particular o diferente del resto de las *res mobilis*, ya que sus elementos constitutivos no se llamaban *partes* sino *membra*, creyendo a su vez que en esta visión del jurista clásico se pudiera intuir un eco del apólogo de Menenio Agripa.

Creemos que la opinión de Manara resulta discutible, y de hecho ésto es contrastable si leemos algunos fragmentos del Digesto en los cuales los autores tratan de forma indiferente los elementos de la nave como *partes o membra*. Si partimos de la lectura de los fragmentos D. 21, 2, 44 (Alf. 2 *digest a Paul epit.*), y D. 50, 16, 242 pr. (Jav. Lib 2 *ex post Lab.*), se puede observar que los elementos de la nave son designados de las dos formas, *membra* en el primero, y *partes* en el segundo. Aunque en el caso del texto de Alfeno éste se corresponda al s. I a.C., y el texto de Javoleno al s. I d.C., no creemos que el momento en el que se escribieron ambos textos tuviera influencia en el hecho de que

10 D. 21, 2, 44 (Alf. 2 *digest. A Paul epit.*) *Scapham non videri navis esse respondit nec quicquam coniunctum habere, nam scapham ipsam per se parvam naviculam esse: omnia autem, quae coniuncta navi essent (veluti gubernacula malus Antemnae velum), quasi membra navis esse.*

11 D. 50, 16, 242 pr. (Jav. lib 2 *ex post Lab.*) *Malum navis esse partem, artemorem autem non esse Labeo ait, quia pleraeque naves sine mao inutiles essent, ideoque pars navis habetur: artemo autem magis adiectamento quam pars navis est*

12 D. 33, 7, 2, 9 (Labeo libr. *primo Pithanon*) *Si navem cum instrumento emisti, praestari tibi debet scapha navis. Paulus: immo contra. Etenim scapha navis non est instrumentum navis: etenim mediocritate, non genere ab ea differt, instrumentum autem cuiusque rei necesse est alterius generis esse atque ea quaequae sit: quod Pomponio libro septimo epistularum placuit.*

13 D. 6, 1, 3 (Ulp. 16 *ad edict.*) *armamenta navis singula erunt vindicanda: scapha quoque separatim vindicabitur, o D. 14, 2, 6 (Iulianus libr. 86 digestorum) Navis adversa tempestate depressa ictu fulminis deustis armamentis et arbore et antemna hipponem delata est ibique tumultuariis armamentis ad praesens comparatis ostiam navigavit et onus integrum pertulit: quaesitum est, an hi, quorum onus fuit, nautae pro damno conferre debeant. Respondit non debere: hic enim sumptus instruendae magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est.*

14 MANARA, G. *La nozione giuridica di nave*, 385

se les llamasen *partes* o *membra* a los elementos de la nave, ya que como podemos ver en Ovid. *Tristia*, I, 2, 2 (s. I d.C) el autor decía:

Di maris et caeli –quid enim nisi uota supersunt?– soluere quassatae parcite membra
ratis, neue, precor, magni subscribite Caesaris irae

De este fragmento podemos inferir como indistintamente a la época se han citado tanto *pars* como *membra* para referirse a la estructura de la nave –opinión que ya anteriormente había manifestado Bonfante¹⁵– y que por tanto nos llevaría a la conclusión que la nave no poseía rasgos que la distinguiesen de la categoría general de las *res*.

Por otra parte, un punto a destacar sería la mención por parte de Manara al apólogo de Menenio Agripa, que consideramos importante por la concepción de la unidad necesaria del cuerpo formado por *membra*. Son varios los textos en los que podemos encontrar descrito este discurso¹⁶, y en éste se contaba como Menenio Agripa, embajador de los patricios, convenció a los soldados insurrectos y establecidos en el Monte Sacro de que volvieran a Roma, al hablarles de la necesidad de que los miembros del cuerpo colaborasen entre sí y alimentasen al vientre, para que éste repartiese los nutrientes en el cuerpo y de este modo lograr funcionar. De forma similar, la nave aparecía como un todo orgánico en el que sus *pars* o *membra* forman el conjunto que permite que ésta realice su función, hecho por el que se la catalogaba como unidad de hecho y de derecho. La clave de ésta no se basaba en la materia sino en la utilidad, ya que para cumplir con el fin perseguido, debía conformar esta unión de todos sus elementos.

En otro fragmento como era D. 47, 2, 21 pr. (Ulp. Lib 40 *ad Sabinum*)¹⁷, se puede observar que para explicar la *contractatio* –tema que trataremos más tarde– de una acumulación, Ulpiano –citando a Trebacio– indicaba como caso de ejemplo destacable el cuerpo humano, mediante la expresión de *nam et qui aurem alicuius tetigit, inquit Trebatius, totum eum videri tetigisse* (fr. 2, 21 pr). Mientras que el resto de ejemplos citados en el fragmento tratan de objetos que formaban una unión por acumulación de materia, al incluir el caso del cuerpo humano de Trebacio, nos parece que Ulpiano esté tratando de mostrar al lector un claro ejemplo que le mostrase qué quería decir exactamente que tocar una parte conllevaba tocar todo el conjunto. Porque aunque el resto de objetos (el montón de trigo, el vino en el

15 BONFANTE, P. *Corso di Diritto romano*, Milán, 1963, p. 139

16 Hom. *Eneid*, I,148-53; Liv., *Ad urb.* II. 16, 32, 33; Dionisio de Hal. C. 44-47; vi. 49-89, 96; Zonaras. VII. 13,14; aparte de ello, también recordaban esta fábula Rabelais en su *tercer libro de Pantagruel* (1546); y Shakespeare, W. Acto I, escena I de Coriolano, incluye el apólogo incluyendo en él ciertos detalles que lo enriquecían respecto al descrito por Tito Livio, que a su vez reproducía libremente la fábula de Esopo que aparecía bajo el título *El estómago y los pies*.

17 D. 47, 2, 21 pr (Ulp. 40 *ad Sabinum*) *Vulgaris est quaestio, an is, qui ex acervo frumenti modium sustulit, totus rei furtum faciat, an vero eius tantum, quod abstulit. Ofilius totius acervi furem esse putat; nam et qui aurem alicuius tetigit, inquit Trebatius, totum eum videri tetigisse, proinde et qui dolium aperuit, et inde parum vini abstulit, non tantum eius, quod abstulit, verum totius videtur fur esse. Sed verum est, in tantum eso furti actione teneri, quantum abstulerunt; nam et si quis armarium, quod tollere non poterat, aperuerit, et omnes res, quae in eo erant, contractaverit, atque ita discesserit, deinde reversus unam ex his abstulerit, et antequam se reciperet, quo destinaverat, deprehensus fuerit, eiusdem rei et manifestus, et nec manifestus fur erit. Sed et qui segetem luce secatur, et contractat, eius, quod secatur, manifestus, et nec manifestus fur est.*

ánfora) conformasen unidad, eran la suma de un cúmulo de partes, mientras que el ejemplo del cuerpo resultaba confuso, ya que a pesar de estar formado por miembros, éste no es una acumulación de elementos sino una única unidad indivisible. Aparte de ello, creemos que el hecho de comparar la nave al cuerpo humano hacía que la concepción de unidad resultase más asimilable para el lector del texto jurisprudencial, ya que de este modo el sujeto podía identificar la concepción del objeto consigo.

Por último, y llevando nuestro discurso un poco más lejos, el caso contenido en D. 5, 1, 76 (Alf. Lib 6 Digest.)¹⁸, que decía:

ex quibus particulis minimis constiteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent

De este modo el texto indicaba que la nave era la misma aunque se cambiaran sus partes, porque estaba destinada a formar un objeto idéntico. De nuevo el jurista hacía otra referencia comparatista del caso de la nave a la unidad del cuerpo humano, que continuaba siendo el mismo a pesar de estar formado por partículas o átomos que se movían día a día, pero que se unían de nuevo formando la misma unidad. En esta comparación se puede observar la influencia de la plataforma atomística de Demócrito¹⁹ —a la que más tarde se unió Epicuro—, hecho que se puede observar en la propia redacción del fragmento, en el que Alfeno indicaba *quod, ut philosophi dicerent*.

En resumen, siguiendo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con Gandolfo²⁰ se podría concluir indicando que la nave, en la estructura que conforman sus *partes* o *membra*

18 D. 5, 1, 76 (Alf. Lib 6 Digest.) Itemque navem, si adeo saepe refecta esset, tu nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nihilo minus eandem navem esset existimari. Quod si quis putaris partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno fuisset, propterea quod, tu philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis constiteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. Quapropter cuius rei species eadem consisteret, re, quoque eandem esse existimari. Fragmento que encaja con la redacción de D. 21, 2, 44 (Alf. 2 digest. A Paul epit.). Acerca de este texto, destacamos la conferencia ofrecida por MANTOVANI, D. con el título *l'identità del soggetto nel tempo, fra diritto romano e filosofia*, el 5 de mayo de 2014 en la Universidad Carlos III de Madrid, en el congreso internacional y seminarios de Derecho romano, El Digesto de Justiniano entre historia e historiografía. Fundamentos de la identidad jurídica europea. El profesor Mantovani indicaba como colofón que probablemente la identificación del sujeto como una identidad única era fruto de un interés legalista, por el que al jurista le resultaría de mayor interés identificar al sujeto como unidad para su interés jurisprudencial. Por analogía, y siguiendo esta hipótesis del autor, quizá se podría plantear si la concepción de la nave como unidad jurídica no será asimismo fruto del interés jurídico-práctico.

19 D'ORTA, M. *Giurisprudenza ed Epicureismo* (Nota su Cic. "ad fam" 7, 12, 1-2), IURA, 42, 1992, pp. 132-3

20 GANDOLFO, E. *La nave*, 119-143, el autor dice en éstas páginas *meum est quidquid ex meum superest*, indicando que la nave constituye una *res connexa*, por lo que se la considera una unidad, y jurídicamente el propietario de la misma lo será también de los materiales que la forman, de igual forma que el propietario de la lana sigue siendo propietario del chaleco. D. 41, 3, 30 (Pomp.30 *ad Sabinum*); PEROZZI, S. *Sul possesso di parti di cosa*, en *Scritti giuridici*, 1. *Proprietà e possesso*, Milán, 1948, p. 641; RICHICHI, R. *L'inquadramento*, 7ss., se considera la nave como una *res* compuesta, a causa de que está formada de varios elementos independientes que se unen de forma que componen un conjunto coherente. Por su parte, MADDALENA, P. *Possesso del tutto e possesso della parte nei corpi composti*, en *Synthese* Arangio-Ruiz, pp. 366-8. destaca mediante los fragmentos D. 41, 3, 23; 43, 24, 8; 41, 4, 2, 6; 10, 4, 7, 1; y 41, 2, 30 pr, que la doctrina romana proclamaba como principio general,

no era divisible, sino que se concebía como una unidad jurídica en Derecho romano, hecho que podemos ver también reflejado en un fragmento como D. 21, 2, 36 (Paul. Libr. XXIX *ad edictum aedilium curulium*)²¹. Con este razonamiento era normal que la responsabilidad del sujeto se concibiera *ad integrum*.

Mediante estos ejemplos, podemos confirmar nuestra teoría que la nave formaba un todo orgánico, ya no por los materiales de los que estuviera formada, sino por su propia naturaleza de hecho, y por el fin para el que se construyó. Este hecho tuvo repercusión en el tratamiento jurídico del caso, algo que podremos comprobar en el siguiente apartado.

* *Furtum partis/membri navis- omnium rerum nomine teneatur?*

En el fragmento correspondiente al título del Digesto 47, 9, 3, 8 se describía la conducta mediante la cual el sujeto quitaba los clavos de la nave. Podemos analizar el supuesto de hecho de dos formas distintas; A) Si procedieramos al aislamiento de este primer SC del segundo del fragmento, únicamente se podría apreciar que el culpable estaba llevando a cabo la *contrectatio* necesaria para llevar a cabo el *furtum*. En el caso mediaría una situación de naufragio, lo que agravaría el hecho ilícito porque el infractor estaría aprovechando la situación de catástrofe y la confusión que con ésta se generaba. Por otro lado, B) si concebimos el texto en su conjunto, podemos comprobar que el caso se encontraba relacionado con la práctica del *naufragium suppressere*²², por lo que no se trataría únicamente de un robo de clavos, sino de una actuación que se llevaba a cabo con intención de cometer *furtum*, pero que podía tener como consecuencia la muerte de la tripulación.

El tratamiento punitivo que se debería aplicar será de muy distinta índole según si partimos del punto de vista de A) o de B). Mediante un razonamiento lógico podemos observar que si Ulpiano decidió incluir ambos SC en un mismo fragmento de su libro 56 *ad edictum*, era para tratar de dar solución a un caso en su conjunto, por lo que tendría más sentido la opción B). De todos modos, no queremos dejar de analizar la propuesta que se recoge en A), ya que el caso tiene mucha relación con los comentarios de Ulpiano al edicto de *incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, que ocupa el título al que nuestro fragmento pertenece.

Pero aparte de este hecho, creemos que resulta también curioso aislar el SC del fragmento, para entender la responsabilidad que se impondría al hecho culpable ajeno al supuesto de naufragio, es decir, imaginando que el acto ilícito se hubiera cometido estando la nave varada en tierra firme. En resumen, en el presente apartado pretendemos llevar a cabo una

válido para todas las hipótesis de cuerpos coherentes, que la posesión del todo es independiente de la posesión de la parte, en el sentido que se puede poseer el todo y no la parte.

21 D. 21, 2, 36 (Paul. Libr. XXIX *ad edictum aedilium curulium*) nave aut domu empta singula caementa vel tabulae emptae non intellegitur ideoque nec evictionis nomine obligatur venditor quasi evicta parte

22 Además, ROUGÉ, J. *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée avant de l'établissement de la domination de Rome*, París, 1966, 330, nos indica que el concepto de nave no siempre ha sido idéntico en todas las etapas de Roma, sino que dependía de la magnitud y poder económico que se tenía en Roma en ese momento, así, en la república se consideraban naves hasta las más pequeñas, mientras que en el Imperio, y concretamente en la época Severiana, en la que el comercio alcanza su mayor apogeo, sólo se consideraban naves las que poseían una cierta magnitud. De nuevo, al caer el Imperio tras la muerte de Alejandro Severo y las sucesivas dictaduras militares, el concepto de nave vuelve a abarcar a las más modestas.

sucinta descripción de las actuaciones punitivas a interponer, de forma que se pueda observar la actuación en un supuesto civil o en un supuesto de tipo penal.

A) *Robo de clavos de la nave aprovechando la situación de catástrofe*

Es importante destacar que una fuente del derecho como era el SC, en época de Claudio tenía carácter vinculante (Gay. *Inst.* I, 4), pero que en nuestro caso probablemente Ulpiano sólo recogió este SC al estimarlo útil respecto al supuesto tratado²³, ya que en su época por lo general se aplicarían las penas propias de la *cognitio extra ordinem*. Al respecto, De Marini Avonzo formuló una teoría por la que afirmaba que en nuestro caso el SC no tenía valor de ley para los juristas, pero que se retenían como precedentes reveladores impuestos por un órgano jurisdiccional tan importante como era el Senado²⁴. Probablemente Ulpiano recogió este SC al estimarlo útil respecto al supuesto tratado, y éste se aplicaría atendiendo a la capacidad discrecional de la que gozaba el juez en la época²⁵, por lo que se podía optar por esta disposición legislativa o bien por una pena *extra ordinem*²⁶.

En cuanto al supuesto que se describe en el SC, para tratar el caso debemos remitirnos al fragmento D. 47, 9, 1, 5 en el que Ulpiano, también en su libro 56 del comentario al edicto, nos indicaba que cometer un delito con ocasión de naufragio suponía perpetrarlo tanto mientras éste estuviera aconteciendo, como tras él *Item ait praetor: "si quid ex naufragio" hic illud quaeritur, utrum, si quis eo tempore tulerit, quo naufragium fit, an vero et si alio tempore, hoc est post naufragium*. Siguiendo la explicación de Ulpiano, podemos entender que el infractor podría estar sujeto a la pena prevista en el edicto *de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, ya que estaría cometiendo rapiña con *dolo malo*, al aprovecharse de la situación de catástrofe acontecida. Por lo tanto, la pena aplicable siguiendo el texto que encontramos en D. 47, 9, 1 pr correspondería al *quadruplum intra annum et post in simplum*.

En lo que concierne al hecho en sí, podríamos observar que se trataba de una *contrectatio* de un elemento de la nave ligada al supuesto de rapiña, pero con la particularidad que al considerarse la nave como unidad jurídica, el infractor respondería por toda ella y no únicamente por los clavos sustraídos.

Todo ello nos recuerda al caso recogido en el fragmento D. 47, 2, 21 pr (Paul. 40 *ad Sabinum*), citado anteriormente. En este fragmento se describía un caso en el que se consi-

23 De todas formas, dejamos para un próximo trabajo el tema que trata la evolución, así como la relación existente entre las *leges Corneliae*, y *edictio de incendio ruina naufragio rate nave expugnata* para la represión de sus correspondientes supuestos penales.

24 DE MARINI AVONZO, F. *La funzione giurisdizionale del Senato romano*, Milán, 1957, pp.44ss.

25 SANTALUCIA, B. *Derecho penal romano*, trad, Paricio, J y Velasco, C del original *diritto e processo penale nell'antica Roma*, Madrid, 1990, pp.115-6; CUQ, E. *De la nature des crimes imputés aux Chrétiens d'après Tacite*, MAH, 6, 1886, p.135, de acuerdo con D. 48, 19, 13 (Ulp. Libr 1 de apellat.)

26 El complejo tema de la dualidad *civiliter-criminaliter*, y la posibilidad de que el sujeto accediera en época de Ulpiano a ambos procesos según su pretensión, queda patente en algunos textos como BALZARINI, M. *In tema di repressione extra ordinem del furto nel diritto classico*, BIDR, 72, 1969, p. 277, o ZANON, G. *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*. Padua, 1998, pp. 54, 63, 93, 94. nt. 107, 110. nt. 24, destacando la iniciativa de carácter acusatorio del sujeto afectado.

deraba que el robo de un puñado de trigo de un montón se correspondería con el robo del montón²⁷. Astolfi²⁸ afirmaba que era la propia naturaleza de estos objetos la que generaba que el robo de una parte de éstos fuera equivalente al robo del objeto íntegro, hecho que Sirks ha calificado de “responsabilidad extensiva”, ya que por tomar una parte del objeto, la responsabilidad se extendía al sujeto como si éste hubiera robado la unidad²⁹. Establecido este punto debemos distinguir entonces dos tipos de objetos;

- (1) Los que conformaban una unidad; y por lo tanto la *contractatio* de una parte, o el hecho de tocar una parte del objeto con ánimo de robarlo generaría que se penalizase al infractor como si hubiera puesto las manos sobre todo el objeto con intención furtiva (este tipo de res son *nave, aedes, acumulación de material o conjunto de líquido, etc*).
- (2) La otra clase son los objetos que conforman un contenedor en el que se depositan otros cuerpos, y que por tanto el ladrón sólo será responsable de las piezas que efectivamente coge. Este es el caso que encontramos en D. 47, 2, 22, 1 (Paul. 9 *ad Sab.*)³⁰, respecto a un baúl que contenía perlas.

El supuesto ha sido desarrollado en un artículo por Thomas, que nos decía “if I touch, with intent to gain, a thing which constitutes a unity, I am thief of the whole; if I take from a container some of its contents, I am thief only of the individual things that I take; and this is the answer to be adopted when I take part of an accumulation”.

En conclusión, en el caso de que los infractores estuvieran robando parte de una nave cocebida como una unidad, éstos responderían como si hubiesen robado la nave entera. Y al cumplirse el supuesto que se recogía en el edicto *de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*³¹, podemos entender que partiendo de la penalización que estableció el pretor en D. 47, 9, 1 pr³², el infractor respondería en el primer año desde que cometió el robo por el cuádruplo del valor de la nave, y tras éste, por el *simplum* de su valor en el momento de la comisión de la rapiña.

27 Otra conclusión que se puede extraer de la última parte de este fragmento es que en estos casos, aunque un sujeto sólo robe parte de un todo, porque es lo único que puede transportar del objeto, al considerarse éste como unidad, se consideran dos casos de *furtum*: un *furtum flagrante* del objeto efectivamente sustraído, y un *furtum non flagrante* que sería el objeto íntegro que no se ha sustraído físicamente. Adaptándolo a nuestro fr. 3, 8, en caso de sustraer los timones, anclas o velas sería *manifestum*, mientras que la nave en sí conformaría el caso de *furtum nec manifestum*.

28 ASTOLFI, R. *Sabino e il “furtum fundi”*, SDHI, 51, 1985, pp. 402-4, y que la *contractatio* en el caso de estos objetos no precisa el *tollere*, sino el *tangere*.

29 SIRKS, B. D. 47, 2, 21 and *contractatio*, en *Fides humanitas Ius. Studi in honore di Luigi Labruna*, VII, Nápoles, 2007, p.5202

30 D. 47, 2, 22, 1 (Paul. *Coment ad Sab. Lib 9*) *Si eo consilio arca refracta sit tu uniones puta tollerentur, hique furti faciendo causa contractati sint, eorum tantummodo furtum factum videri: quod est verum. Nam ceteraeres quae seponuntur tu ad uniones perveniatur, non furti faciendo causa contractatur*

31 LENEL, O. *Das edictum perpetuum*³, Leipzig, 1927, § 187, p. 391

32 D. 47, 9, 1 pr (Ulp. 56 *ad edictum*) Praetor ait: “In eum, qui ex incendio ruina naufragio rate nave expugnata, quid rapuisse recepisse dolo malo damnive quid in his rebus dedissetur: in quadruplum in anno, quo prima de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo. Item in servum et in familiam iudicium dabo”

En última instancia, y siguiendo la teoría que hemos defendido en nuestra tesis doctoral³³, si asumieramos el hecho que la *actio vi bonorum raptorum* (D. 47, 9, 8, 2 pr) era posterior a la *actio de naufragio* y recogía el supuesto de hecho previsto en esta última, podríamos entender que el ilícito recogido en D. 47, 9, 3, 8 se penalizara por esta última acción. De todos modos, este apunte se ha hecho a efectos de matizar las posibles vías de actuación *civiliter* frente al caso, ya que la punición del caso tanto por la *actio de naufragio* como por la *actio vi bonorum raptorum* sería la misma, *in quadruplum intra annum et post in simplum*.

Aparte de ello, en la *laudatio edicti* de Ulpiano que aparecía en D. 47, 9, 1, 134 quedaba reflejada la posible alternatividad de los procedimientos del *ordo* y de la *cognitio*, así como la tardía contraposición *civiliter-criminaliter* (no siempre de origen postclásico). En el fragmento el jurista decía *attamen recte praetor fecit, qui forenses quoque actiones criminibus istis praeposuit*, lo que viene a demostrar que las dos posiciones pública y privada, podían asumirse frente a una misma realidad en determinados supuestos, como en nuestro caso. Esta duplicidad en relación con los procedimientos de ambos supuestos es una cuestión compleja y de la cual aunque no conocemos detenidamente las raíces, sabemos que no se trata siempre de crigen postclásico. El desarrollo y estudio de esta cuestión queda pendiente de un estudio posterior y más extenso.

B) Quitar los clavos de la nave para cometer naufragium suppressere

La práctica del llamado “*naufragium suppressere*” suponía un ataque al barco, que a nivel de indicios se podría describir como la situación en la que sobre las aguas no queda ningún resto visible de la nave ni de sus pasajeros. Esta actuación venía detallada en D. 48, 8, 3, 4 (*Marcian. 14 inst.*), que decía:

Item is, cuius familia sciente eo apiscendae recipiendae possessionis causa arma sumpserit: item qui auctor seditionis fuerit: et qui naufragium suppresserit: et qui falsa indicia confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens circumveniretur: et qui hominem libidinis vel promercii causa castraverit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur.

Ésta actuación se llevaba a cabo por piratas o asaltantes que sólo interesados en los objetos de valor de la nave, no dudaban en hacerla naufragar sin dejar restos ni de ésta ni de sus tripulantes³⁵, pero sin llevarse la carga, que se hundía intacta con los restos de la nave.

³³ MATAIX FERRÁNDIZ, E. El edicto de incendio ruina naufragio rate nave expugnata (D. 47,9, 1). Responsabilidad penal por cuestión de naufragio. Tesis defendida en la Universidad de Alicante, el día 20/03/2014, de próxima publicación.

³⁴ D. 47, 9, 1, 1 (Ulp. 56 ad ed.) Huius edicti utilitas evidens et iustissima severitas est, si quidem publice interest, nihil rapi ex huiusmodi casibus. Et quamquam sint de his facinoribus etiam criminum executiones, attamen recte praetor fecit, qui forenses quoque actiones criminibus istis praeposuit.

³⁵ Jenof. *Efes.* I, 13-14; Heliod. *Etiop.* I, 3.; Aquiles *Tacio. Leucipo y Clitofonte*, III, 20; esta práctica se encontraba seguramente ligada al incremento del comercio que se dio entre 200 a.C. Y el año 400 d.C., hecho que se encuentra ligado al incremento de pago de tasas monetarias, en opinión de HOPKINS, K. *Taxes and Trade*

Fue bajo el gobierno del emperador Claudio cuando se inició esta vigorosa política de incremento del transporte marítimo, y a él corresponden las provisiones para favorecer el transporte *annonario*³⁶. A través de la protección establecida para estos casos en el senadoconsulto, podemos inferir que Claudio procedía a concesiones de servicios de pública utilidad, como el de la protección de los transportes por vía marina, y por ello resultaba necesario prever la protección de estas naves frente a los ataques de los posibles asaltantes.

En opinión de Moschetti, mediante la utilización del término *nave* en época severa –como corresponde a nuestro fr. 3, 8– sólo se incluían las naves comerciales de gran tonelaje, ello de acuerdo con el gran desarrollo comercial que se vivió en este periodo³⁷. Podría ser que, por la eficacia de este SC de época de Claudio, Ulpiano decidiera rescatarlo para hacer frente a un problema que estaba aconteciendo en las naves de transporte de mercancías del imperio. Ciertamente es que la única manera de proteger el comercio y de esta forma favorecer

in the Roman Empire (200 b.C.- a.D. 400), JRS, 70, 1980, pp. 101, 103, 105-6; PURPURA, G. *Il naufragio nel diritto romano. Problemi giuridici e testimonianze archeologiche*, AUPA, XLIII, 1995, p.463-476, que destaca que resultaba difícil en un principio verificar la existencia de esta práctica dada la desaparición total de los restos del naufragio; aunque algunos restos arqueológicos nos han aportado el testimonio de naves hundidas con su carga completa, algo que nos detallaba en p.472, destaca al respecto los restos encontrados del naufragio de Villasius en Cerdeña (S. I d.C.), en el que una de las maderas de la nave se presenta como serrada; y también GIANFROT-TA, P.A. *Commerci e pirateria: prime testimonianze archeologiche sottomarine*, MEFRA, 93, 1981; p.233, “anche l'affondamento della nave, invece della sua cattura, con la mancata asportazione del carico, o almeno di gran parte di esso, rimasto a bordo del relitto, può essere interpretato come una necessaria precauzione da parte degli assalitori per eliminare il corpo del reato. Una volta impossessatisi degli oggetti più preziosi e facilmente smerciabili e avere deciso la sorte (soppressione o rapimento a fine di riscatto o per la vendita come schiavi) di eventuali prigionieri, si rendeva spesso opportuno per sperare di farla franca affondare la nave con la parte più ingombrante del carico.”; PARKER, A.J. *Ancient shipwrecks of the Mediterranean and the Roman provinces*, Oxford, 1992, pp.29-30, indica que las joyas o tesoros son raros de encontrar, mientras que los hallazgos de armas o blindaje son relativamente comunes en los naufragios. Quizá los soldados navegaran como guardianes de la propiedad estatal o de suministros militares, pero la mayor parte de los naufragios romanos con armas o blindaje (unos 20) escasamente ofrecen vías que nos permitan pensar esto, no existe duda de que la mayoría de las armas fueron para uso privado, o para vigilantes del puerto. Aparte de este caso, otro supuesto que puede estar incluido dentro del supuesto que castiga el falso naufragio, del que nos habla Demost. *Contra Zénot.* 5-6, aunque se conoce la existencia de la práctica del “falso naufragio” (hundir viejas embarcaciones y hacer pagar bien al gobierno, bien a los empresarios privados), aún no se han encontrado unos restos que nos permitan distinguir cuando las maderas han sido serradas antes de que se produjera el hundimiento. ROUGÉ, J. *Recherches*, 359, como el prestamo marítimo juega para la economía antigua un rol similar al de las antiguas aseguradoras, en el caso en el que el poder público sustituye a los particulares, éste asume las responsabilidades por lo que le pueda acontecer al *receptum nautarum*. Así, Livio nos narra un caso acontecido durante la segunda guerra púnica Liv. *Hist.*XXV.2; y XXIII, 49, 1

36 Suet. *Claud.* XVIII, 2-19; hecho que encontramos reflejado en artículos como REMESAL RODRIGUEZ, J. *Providentia et annona. Cum ventri tibi humano negotium est*, en *Religión y propaganda política en el mundo romano*, Marco Simón F., Pina Polo F., Remesal Rodríguez J. (Eds.), Actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 5 y 6 de junio de 2001. Col·lecció Instrumenta vol. 12 Ceipac, Barcelona, 2002, p. 124, *id.* *La Bética en el Concierto del Imperio Romano*, Real Academia de la Historia, 2, Madrid, 2011, pp. 47ss., indicando que Claudio, que llegó al poder en un año de hambruna, terminó por dar privilegios a los que traían alimentos desde lugares lejanos de Roma. Claudio fue también el creador de las flotas provinciales, esta teoría ha sido mayoritariamente defendida por COURTOIS, CH., *Les politiques navales de l'Empire romain*, *Revue historique*, 1939, pp.17-47; 225-259; y discutido, aunque no rebatido por REDDÉ, M. *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'empire romain*, Roma, escuela francesa de Roma, pp. 502-509, PINZONE, A. *Naufragio, fisco, e trasporti marittimi in età di Caracalla*, en *Quaderni Catanesi di studi classici e medievali*, 4, 1982, pp. 97-108.

37 MOSCHETTI, C.M. *Nave*, 566

la economía, era protegiendo a los navegantes, por ello se comprende el porqué de esta intervención del poder público, que podía actuar incluso si sólo hubieran tocado los clavos de la nave.

Cuando mencionamos *supprimere naufragia*, nos referimos al fin de la actuación en sí por la que se producía el hundimiento de la nave con su carga y tripulación. En lo que concierne a la nave, ésta se calificaba como *nave expugnata*. Este concepto nos venía detallado por Calistrato en D. 47, 9, 6 (Call. libr. 1 *edict monit.*), que rezaba como sigue:

*Expugnatur navis, cum spoliatur aut mergitur aut dissolvitur aut pertunditur aut funes eius praeciduntur aut vela conscinduntur aut ancorae involantur de mare*³⁸.

Esta definición describía prácticas previas a la comisión de la supresión total de la nave o *naufragium supprimere*. Como el lector podrá observar, en el § 6 se describen una serie de conductas aisladas, mediante el empleo de la conjunción disyuntiva *aut* (*aut mergitur, aut dissolvitur*). En cambio, en nuestro fr. 3, 8 se indica que el que quitase los clavos, o al menos uno de ellos, estará obligado por todas las cosas. Por lo que en nuestro caso, aunque sólo hubiera quitado o dañado uno de los clavos de la nave, este hecho se tendría en cuenta a efectos jurídicos como si se hubiere cometido el supuesto de hundimiento por completo de la nave y no dejando rastro visible. De este modo resulta sencillo pensar que dio lugar a una sentencia severa, contra la cual el autor del expolio seguramente intentaría apelar frente al máximo tribunal extraordinario³⁹.

De la lectura del fragmento en su conjunto, podemos extraer que en caso de comisión de conductas como la de quitar los clavos con ocasión de un naufragio, provocando que la nave quedase despedazada y se hundiese por completo se preveían las penas propias de la *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, que introdujo (o más probablemente reorganizó) una *quaestio* capital que tenía por objeto la persecución de diversas formas de atentado contra la vida ajena⁴⁰.

En nuestro fragmento se recoge una conducta que por sus consecuencias suponía provocar la muerte del sujeto, lo que según lo establecido en D. 48, 8, 15 (Ulp. 7 *ad Legem Iuliam et Papiam*)⁴¹, se consideraba equivalente a matar directamente a un sujeto. Este

38 MARTINI, R. *Le definizioni*, 265, 267, el autor destaca el carácter sistemático de las definiciones de Calistrato; PULIATTI, S. *Il "de iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milán, 1992, p. 27, que destacaba en el comentario al *edicti monitorii*, Calistrato se mostraba como un técnico interesado y atento a la resolución de problemas de la realidad provincial, en la que se basa la obra. Como otro dato de interés.

39 DE MARINI AVONZO, F. *La funzione giurisdizionale*, p.45, y nt.101

40 ROTONDI, G. *Leges Publicae Populi Romani*, Milán, 1922, pp.357ss; indicando como fuentes jurídicas principales en las que aparecía esta *Lex*: *Pau.Sent.* V, 23; D. 48, 8; *Coll.* 1, 2, y 3; *CI.* 9, 16 y *C.Th.* 9, 14. BAUMAN, R.A. *Crime and Punishment in Ancient Rome*, Londres, 1996, p.24, de forma similar, SANTALUCIA, B. *Derecho penal*, p.84, el autor nos dice que probablemente esta *lex* reorganizó más que introducir la represión penal de un crimen, porque se encuentran indicios de la represión, previa a la restauración Silana, de estas *quaestiones*. En el caso de las *quaestiones de sicariis*, en *Cic. Rosc.Am.* IV, 11, 23, 64-65; y en relación con las *quaestiones de veneficiis*, existe la posibilidad de que una inscripción que podemos consultar en *CIL* VI n. 1283, que hace referencia a C. Claudio Pulcro, *iudex questionis de veneficiis* se refiera a la existencia de un tribunal permanente para casos de envenenamiento.

41 D. 48, 8, 15 (Ulp. Lib 7 *ad Legem Iuliam et Papiam*) *Nihil interest occidat quis an causam mortis praebeat.*

fragmento 3, 8 mostraba un nuevo ilícito que precisaba protección, ya que el homicidio no era un supuesto que se contemplara en el edicto *de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, hecho por el cual entendemos que se tuviera que extender mediante un SC la protección de la *Lex Cornelia*.

Mediante el texto que encontramos en D. 48, 8, 5, podemos observar como Marciano introducía la gradación de la pena en función de la pertenencia a un determinado orden social, práctica propia de la *cognitio extra ordinem* y del momento en el que Marciano escribió sus *Instituta* (s. III d.C.). La pena establecida para los supuestos de la *Lex*, de acuerdo con Marciano⁴², era la deportación y confiscación de todas las posesiones; aunque también el jurista nos recordaba que para los casos más graves se puede añadir la pena de muerte, dependiendo del orden social al que pertenecieran los sujetos (se preveía la pena de *bestiis subicere* para los *humiliores*, mientras que se mantenía la pena de *deportatio* para los *honestiores*). Seguramente en un principio, el sujeto habría sido condenado a la *interdictio aqua et igni*⁴³ de acuerdo con la *Lex Cornelia de sicariis*, pero en la época en la que Claudio emanó este SC, ésta ya había sido sustituida por la *deportatio*⁴⁴. Esta pena era la más dura de las que implicaban un desplazamiento de domicilio del sujeto; respecto al *exilium* y la *relegatio*. En la época que concierne a nuestro fragmento Ulpiano (tras el 212 d.C.), la *deportatio* había sido introducida en el proceso de la *cognitio* y podía implicar la circunscripción a una isla.

En un fragmento de Ulpiano que podemos encontrar en la *Coll. XII, 5, 1-2 (de naufragis et incendiariis)*⁴⁵, se establece que el naufragio suponía un ilícito por el que se debía remitir a los culpables a la *Lex Cornelia* para los sicarios. Como se puede observar, las penas que se recogen en la *Collatio* se correspondían con las mencionadas en este fragmento D. 48, 8, 3, 5 (Marc. Lib 14 *inst.*), algo que muestra la homogeneidad en la consideración de las penas para el caso de que la comisión del naufragio hubiera tenido como consecuencia la muerte. Además, este fragmento de la *collatio* justifica que Ulpiano utilizara el SC para extender la pena de la *Lex Cornelia* al caso contenido en el fragmento, ya que el jurista estaba buscando imponer al supuesto la pena correspondiente para su época, y para ello tuvo que servirse de este instrumento legal aunque en su época se encontrase en desuso.

42 D. 48, 8, 3, 5 (Marciano 14 *Inst*) *Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum ademptio. Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant: humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam*. Es un tratamiento similar que el que se les ofrece a los incendiarios en D. 47, 9, 12, 1; el uso de *solent* indica que el hecho se encuentra sujeto a represión extraordinaria, en opinión de BRASIELLO, U. *La repressione penale in diritto Romano*, Nápoles, 1937, p. 204

43 ROBINSON, O.F. *The Criminal Law of Ancient Rome*, Londres, 1995, p. 46.

44 SÁNCHEZ-MORENO ELLART, C. Voz “*Deportation*”, en *The Encyclopedia of Ancient History*, Hoboken-New Jersey, 2013, pp. 2038-2040.

45 *Coll. XII, 5, 1 (de naufragiis et incendiariis)* *Incendiariis lex quidem cornelia aqua et igni interdicti iussit, sed re varie sunt puniti. Nam qui data opera in civitate incendium fecerunt, si humillimo loco sunt, bestiis subici solent, si in aliquo gradu et Romae id fecerunt, si humillimo loco sunt, capite puniuntur: aut certe [2] [deportationis poena] adficiendi sunt qui haec comittunt. Sed eis qui non data opera incendium fecerint plerumque ignoscitur, nisi in lata et incauta negligentia vel lascivia fuit*

CONCLUSIÓN

A modo de colofón, tras esta explicación de ambos casos y su punición, creemos poder concluir, que en la opción que hemos descrito como el robo a la nave varada tenía mayor relevancia el hecho que se considerara la nave como unidad, ya que ello influiría en la cuantía que se debería satisfacer siguiendo la pena establecida según el edicto *de incendio ruina naufragio*. En cambio, en el sujeto que se trata el caso del *naufragium suppressere*, tenía mayor relevancia el hecho de matar a los tripulantes al provocar el naufragio quitando los clavos en el acto de rapiña, por lo que la noción de unidad jurídica de la nave se situaría en un plano secundario. Todo esto nos lleva a pensar, que por lo menos en nuestro caso, la concepción de nave como unidad jurídica tenía importancia, pero que las consecuencias de esta concepción eran muy diversas del tratamiento civil del supuesto de hecho a su represión penal. Mediante la penalización establecida por el pretor para el supuesto de robo de los clavos con ocasión del naufragio, el hecho de concebir la nave como unidad influiría en que el sujeto debiera satisfacer una cuantía u otra. Sin embargo, en la represión penal del supuesto, podemos observar que siendo que en época ulpianea probablemente el juez impusiera una condena *extra ordinem*, o bien en caso de imponerse la penalización recogida en la *Lex Cornelia*, en el hecho que influye la concepción de unidad jurídica de la nave, es que por esta concepción, se considera que el sujeto hunde completamente la nave, y provoca la muerte a los tripulantes. Por lo tanto, el robo de clavos es el detonante de la muerte de varios sujetos de acuerdo con la noción de unidad de la nave.

Esta concepción de nave como todo unitario sobrevive aún hoy día (y resulta de gran importancia para la compraventa de buques), y aparte de su importancia para el caso en el cual nuestro fragmento centraba la atención, es también relevante para el tratamiento de otros temas como la usucapión, la adquisición de propiedad por especificación, o el saneamiento por evicción en la *emptio venditio*. Dejamos estos temas de lado para un posible estudio posterior, concluyendo con la idea de que la nave suponía uno de los ejes más importantes de la costumbre jurídica y la práctica marítima en la antigüedad, de manera que resulta de gran importancia conocer su *status* para poder lograr la comprensión del resto de prácticas de la navegación en la antigüedad.

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA

- ALBANESE, B. *La nozione de furtum fino a Nerazio*, AUPA, 23, 1953, pp. 5-199.
 ASTOLFI, R. *Sabino e il "furtum fundi"*, SDHI, 51, 1985, pp. 402-6.
 BALZARINI, M. *In tema di repressione extra ordinem del furto nel diritto classico*, BIDR, 72, 1969, pp. 203-311.
 BAUMAN, R.A. *Crime and Punishment in Ancient Rome*, Londres, 1996.
 BONFANTE, P. *Corso di Diritto romano*, Milán, 1963.
 BRASIELLO, U. *La repressione penale in diritto Romano*, Nápoles, 1937.
 CUQ, E. *De la nature des crimes imputés aux Chrétiens d'après Tacite*, MAH, 6, 1886, pp. 115-38.
 CARCATERRA, A. *Le definizioni dei giuristi romani. Metodo, mezzi e fini*. Nápoles, 1966.

- CHASTAGNOL, A. *Le Senat Romain à l'époque imperiale: recherches sur la composition de l'assemblée et le statut de ses membres*, Paris, 1992.
- COURTOIS, CH., *Les politiques navales de l'Empire romain*, *Revue historique*, 1939, pp.17-47; 225-259.
- DE MARINI AVONZO, F. *Coesistenza e connessione tra "iudicium publicum" e "iudicium privatum"*. *Ricerche sul diritto tardo classico*, BIDR, LIX-LX, 1956
- DE MARINI AVONZO, F. *La funzione giurisdizionale del Senato romano*, Milán, 1957.
- D'ORTA, M. *Giurisprudenza ed Epicureismo (Nota su Cic. "ad fam" 7, 12, 1-2)*, IURA, 42, 1992, pp. 123-46.
- GANDOLFO, L. *La nave nel diritto romano*, Génova, 1883.
- GAUDEMET, J. L'empereur interprète du droit, en *Festschrift Rabel*, 2, Tubinga, 1954, pp. 169-203.
- GIANFROTTA, P.A. *Commerci e pirateria: prime testimonianze archeologiche sottomarine*, MEFRA, 93, 1981, pp. 227-42.
- HONORÉ, T. *Ulpian*, Oxford, 1982.
- HOPKINS, K. *Taxes and Trade in the Roman Empire (200 b.C.- a.D. 400)*, JRS, 70, 1980, pp. 101-25.
- LENEL, O. *Das edictum perpetuum*³, Leipzig, 1927.
- MADDALENA, P. *Possesso del tutto e possesso della parte nei corpi composti*, en *Synteletía Arangio-Ruiz*, pp. 366 ss.
- MANARA, G. *La nozione giuridica di nave*, en *Studi in onore di Francesco Berlingieri*, Roma, 1933, pp. 380Ss.
- MANTOVANI, D. *Identità del soggetto nel tempo, fra diritto romano e filosofia*, conferencia ofrecida el 5 de mayo de 2014, Universidad Carlos III (Madrid) en el congreso internacional y seminarios de Derecho romano, *El Digesto de Justiniano entre historia e historiografía. Fundamentos de la identidad jurídica europea*.
- MARTINI, R. *Le definizioni dei giuristi romani*, Milán, 1966.
- MARTINO, F. *Navis eadem navis*, RDN, III, 1935, pp. 41Ss.
- MAY, G. L'activité juridique de l'empereur Claude, RHD, 1936, pp. 55-97.
- MENTXAKA, R. *La pignoración de las colectividades en el Derecho romano clásico*, Bilbao, 1986.
- MOSCHETTI, C.M. *Nave*, en *Enc.dir.* 27, 1977, pp. 565-76.
- PARKER, A.J. *Ancient shipwrecks of the Mediterranean and the Roman provinces*, Oxford, 1992.
- PINZONE, A. *Naufragio, fisco, e trasporti marittimi in età di Caracalla*, en *Quaderni Catenesi di studi classici e medievali*, 4, 1982, pp. 97-108.
- PUGLIESE, G. *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, en ANRW, 14.2, Berlin-Nueva York, 1982, pp. 722-89.
- PULIATTI, S. *Il "de iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milán, 1992.
- PURPURA, G. *Il naufragio nel diritto romano. Problemi giuridici e testimonianze archeologiche*, AUPA, XLIII, 1995, p. 463-476.
- REDDÉ, M. *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'empire romain*, Roma, escuela francesa de Roma, pp. 502-509.

- REMESAL RODRIGUEZ, J. *La Bética en el Concierto del Imperio Romano*, Real Academia de la Historia, 2, Madrid, 2011.
- REMESAL RODRIGUEZ, J. *Providentia et annona. Cum ventri tibi humano negotium est*, en *Religión y propaganda política en el mundo romano*. Marco Simón F., Pina Polo F., Remesal Rodríguez J. (Eds.). Actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 5 y 6 de junio de 2001. Collecció Instrumenta vol. 12 Ceipac, Barcelona, 2002, pp. 119-25.
- RICHICHI, R. *L'inquadramento della nave delle categorie delle "res" in diritto romano*, Rivista de diritto romano, I, 2001
- RIGHETTI, G. *Contributo alla teoria giuridica della nave*, en *Studi in onore di Giorgio Berlingieri*, Genova, 1964, pp. 448ss.
- RIGHETTI, G., *Nave*, en NNDI, XI, Torino, 1965, pp. 79ss.
- ROBINSON, O.F. *The Criminal Law of Ancient Rome*, Londres, 1995.
- ROTONDI, G. *Leges Publicae Populi Romani*, Milán, 1922.
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART, C. Voz "Deportation", en *The Encyclopedia of Ancient History*, Hoboken-New Jersey, 2013, pp. 2038-2040.
- SANTALUCIA, B. *Derecho penal romano*, trad, Paricio, J y Velasco, C del original *diritto e processo penale nell'antica Roma*, Madrid, 1990.
- SIRKS, B. *D. 47, 2, 21 and contrectatio*, en *Fides humanitas Ius. Studi in honore di Luigi Labruna*, VII, Nápoles, 2007, pp. 5194-5210.
- WATSON, A. *The Spirit of Roman Law*, Athens (Georgia), 1995.
- ZANON, G. *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*. Padua, 1998.

EL SECRETO BANCARIO: PRECEDENTES ROMANOS

PAULA DOMÍNGUEZ TRISTÁN

I. El secreto bancario resulta de suma importancia en la economía internacional y es objeto de muchos debates incluso en la actualidad, pero el punto que más controversia suscita no es tanto lo que protege, sino lo que a través de él se facilita: la elusión y evasión de impuestos, así como el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas, lo que justifica que, en los últimos años, se hayan producido fuertes presiones para que los países limiten la confidencialidad bancaria, en aras de un interés público superior, y se produzcan, como así ha sido en la mayoría de los casos, reformas legislativas¹.

De entre las múltiples definiciones propuestas por la doctrina mercantilista, me parece bastante ajustada la que conceptúa el secreto bancario como “el deber de la institución crediticia de no suministrar información sobre las cuentas de su cliente, así como de aquellos hechos de que tenga conocimiento como consecuencia de sus actividades, salvo en los casos excepcionales previstos por la ley, o bien, como el derecho de las citadas instituciones a rehusar suministrar información sobre los citados datos”².

Al hilo de lo expuesto, y aún reconociendo la dificultad de encontrar referencias directas al hoy llamado secreto bancario en los primeros momentos de la Historia debido a la escasez de fuentes, en especial, de carácter jurídico, considero de interés realizar una serie de observaciones sobre el contexto en que se desarrolla en sus primeros orígenes la actividad

1 En el Derecho español actual la Disposición adicional primera de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su última modificación de 30 de noviembre de 2013 establece al respecto:

1. Las entidades y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación.

2. Se exceptúan de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o las leyes permitan su comunicación o divulgación a terceros o que, en su caso, les sean requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión. En este caso, la cesión de la información deberá ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente o por las leyes.

3. Quedan asimismo exceptuadas del deber de confidencialidad los intercambios de información entre entidades de crédito pertenecientes a un mismo grupo consolidable.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición será considerado infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

2 RUÍZ GARCÍA, J. R., *Secreto bancario y Hacienda Pública*, Madrid, 1988, p. 15.

bancaria, pues en él, como postula la doctrina mayoritaria, ya están presentes algunas de las características de la contratación bancaria que permitirán, en cierto modo, entender y explicar el nacimiento de una institución, el secreto bancario, cuyos precedentes se remontan al inicio mismo de la citada actividad³, que se sitúa en los primeros templos de la Antigüedad (así, Mesopotamia, Babilonia...etc.)⁴.

Estos templos disponían de recursos que podían destinar a actividades de préstamo (obviamente en especie), pues además de la explotación de sus tierras contaban con las donaciones y ofrendas de los fieles. El carácter misterioso y oculto que presidiría las actividades allí desarrolladas, consecuencia de la inviolabilidad de los templos y de su respeto, espontáneo o forzado, dada la divinidad que representaban, daría lugar a una discreción también presente en los negocios bancarios celebrados.

La consecuencia de lo dicho es que los sacerdotes “banqueros” adquirieron el carácter de confidentes y se vieron envueltos en un hábito de discreción, de manera que los rudimentarios negocios bancarios heredaron, desde sus orígenes más remotos, un carácter que, adecuándose a las diversas y cambiantes circunstancias históricas, ya no le abandonaría jamás: “el silencio”, “su obligado desconocimiento para los terceros”, del que actualmente es fiel exponente la figura del secreto bancario.

En esta línea cabe destacar que el templo Rojo de Uruk, en Mesopotamia, se considera el edificio bancario más antiguo que se ha conocido en la Historia de la humanidad⁵, y sus sacerdotes los primeros “banqueros” de los que se tiene noticia⁶.

3 Cfr. DAUPHIN-MENIER, A., *Histoire de la Banque*, 2ª ed., Paris, 1959; COLLING, A., *Banque et banquiers de Babylone a Wall Street*, Paris, 1962; FARHAT, R., *Le secret bancaire. Etude de Droit Comparé* (France, Suisse, Liban), Paris, 1970; BATLLE SALES, G., *El derecho a la intimidad privada y su regulación*, Alcoy, 1972, p. 114; CAZORLA PRIETO, L. M., *El secreto bancario*, Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda, Madrid, 1978, pp. 34 ss; TERMES, R., *El fin del secreto bancario* (título de un fragmento de su informe de 1987 a la Asamblea general de la Asociación española de Banca Privada), Desde la banca, vol. II, Madrid, 1991, p. 1.104; AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M. J., *El secreto bancario*, Barcelona, 2001, p. 58. Por el contrario, como destaca esta última autora, op. cit., p. 57, para otro sector doctrinal no puede hablarse del secreto bancario en sentido propio hasta los albores del s. XV, con la aparición en nuestro entorno cultural de los bancos de depósito y giro (en tal sentido, cfr. MOLLE, G., *Il segreto bancario, Banca, borsa e titoli di credito*, 1937, p. 176 y GARRIGUES, J., *Contratos bancarios*, Madrid, 1975, p. 51), incluso llegándose a afirmar la inutilidad de intentar demostrar que la banca ha observado desde siempre silencio respecto a las operaciones de sus clientes (cfr. HENRION, R., *Le secret professionnel du banquier*, Bélgica, 1963, p. 26).

4 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *ibidem*, p. 58. En lo mismos términos se manifiesta PÉREZ BENECH, V., *La nueva regulación sobre el secreto bancario en la Ley nº 17.948*, *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo*, 14 (2008) pp. 109-148, p. 112, aunque habla, propiamente, del “secreto profesional” como característica inherente desde sus inicios a la actividad bancaria. Sobre esta última cuestión DO EGITO COELHO, W., *Control de informaciones y secreto bancario. Cursillo de Derecho bancario*, Montevideo, 1981, p. 193, matiza que el secreto bancario sería una ramificación del secreto profesional y del secreto comercial.

5 Entre los años 5.400 a 3.200 a. C., surgen en él los primeros vestigios de organización bancaria.

6 La arqueología nos ha proporcionado evidencias de que dichos sacerdotes recibían dones y ofrendas, contando, por tanto, con cuantiosos recursos que hicieron multiplicar al conceder préstamos. En el templo se entregaban en préstamo cereales a interés a los agricultores y comerciantes de la región que lo solicitaban; asimismo se ofrecía anticipos a los esclavos que querían redimirse y a los prisioneros de guerra para ser liberados. Todas estas operaciones se realizaban en especie, ya que todavía no existía la moneda. Sin embargo, su adelanto fue tal que en el interior del templo se han descubierto, como señala MELIS, F., *Storia della Ragioneria (Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica)*, Bolonia, 1950, p. 121, abundantes

La existencia de documentos que datan de la III dinastía de Ur (2.294-2.187 a. C.), prueban el desarrollo del comercio bancario en Babilonia⁷. Por desgracia, observa AZAUSTRE FERNÁNDEZ⁸, el documento jurídico más importante de la época, el Código de Hammurabi⁹, datado hacia el año 1.760 a. C., no se refiere a los contratos bancarios. Tan sólo las leyes 100 a 107 contienen normas relativas al contrato de comisión¹⁰, regulándose la prueba de la entrega de fondos entre comisionista y comitente¹¹.

Pero no es hasta el s. VII a. C. cuando el comercio bancario en Babilonia experimenta una gran expansión desarrollándose nuevas prácticas, como por ejemplo, la del servicio de caja a favor del cliente, los pagos a cargo de sus depósitos o transferencias a otros lugares¹². Los banqueros asumen funciones de notarios, empezando a intervenir en la redacción de documentos de las relaciones contractuales ajenas. Además, los particulares van concurrendo, paulatinamente, con los templos en el ejercicio de la actividad bancaria, al empezar a coexistir con éstos los grandes propietarios¹³, circunstancia que determinará que pueda hablarse ya del inicio de la laicización de la banca¹⁴.

Definitivamente, en esta breve reseña sobre los primeros orígenes del hoy llamado secreto bancario, y antes de pasar a examinar sus precedentes romanos, objeto del presente

documentos gráficos, textos contables, contratos, recibos, cartas comerciales, grabados en planchas o tablillas de arcilla cruda, que acreditan la masificación y efectividad de tal actividad.

7 Cfr. DAUPHIN-MENIER, *Histoire de la Banque*, cit., p. 7. MARTÍN MOLINA, P. B. y VEIGA COPO, A. B., Los libros de contabilidad: un apunte histórico, *Boletín de la Facultad de Derecho (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)*, 13 (1998) pp. 395-414, p. 396, destacan que la mayor parte de estos documentos pertenecen a la contabilidad de los templos y son propios de una economía agraria. GOLDSCHMIDT, L., *Storia universale del diritto commerciale*, 1ª traducc. italiana por V. Pouchain y A. Scialoja, Torino, 1913, p. 44, pese a lamentar la escasez de noticias jurídicas de este periodo, ya se refirió a la actividad bancaria en una época tan temprana en los siguientes términos: “Ante la penuria de otras noticias jurídicas de la época, son de inestimable importancia los documentos de negocios jurídicos (tablas de terracota con caracteres cuneiformes), pero hasta ahora sólo descifrados en una pequeñísima parte, en la época más reciente asiria y babilónica (siglos VII-VI) contienen fórmulas breves y concisas fórmulas de negocios verdaderamente típicos. Se encuentran sociedades comerciales..., compras a crédito y contratos a término, operaciones bancarias de dinero...”.

8 El secreto bancario, cit., p. 58.

9 Rey de Babilonia desde el año 1.792 al 1.750 a. C., según la cronología del Antiguo Oriente Próximo.

10 Por él sabemos, nos dicen MARTÍN MOLINA y VEIGA COPO, *Los libros de contabilidad*, cit., p. 396, que los mandatarios y comisionistas estaban obligados, en Babilonia, a llevar una contabilidad detallada de todas las operaciones en que participaran en calidad de intermediarios, contabilidad que especificaba los beneficios obtenidos en las operaciones por el mandante o comitente.

11 FARHAT, *Le secret bancaire*, cit., p. 15, sostiene, por el contrario, que dicho Código mencionaba la posibilidad que tenía el banquero de levantar el velo de sus archivos en caso de conflicto con el cliente, lo que le lleva a pensar que en los demás supuestos el banquero estaba obligado a guardar silencio. En el mismo sentido se manifiesta PÉREZ BENECH, *La nueva regulación sobre el secreto bancario*, cit., p. 113. Sin embargo, para AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *El secreto bancario*, cit., p. 58, n. 3, en el Código de Hammurabi no se encuentra disposición alguna que autorice a llegar a semejante conclusión. Lo único que se regula, en palabras de la autora, “es la sanción correspondiente al comisionista o comitente, según los casos, para el supuesto de que la contraparte consiga probar la entrega o recepción de los fondos, pero sin hacer referencia alguna a los medios de prueba, sino tan sólo a que ésta se realice <<ante Dios y los testigos>>”.

12 Como la economía babilónica no conocía la moneda numeraria, siguieron siendo los cereales (la cebada) los que regularon la mayoría de los cambios.

13 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *op. cit.*, p. 59.

14 Vid. DAUPHIN-MENIER, *Histoire de la Banque*, cit., p. 11.

trabajo, no puedo dejar de mencionar la actividad bancaria griega, en sus inicios, también en íntima relación con los templos¹⁵, por ser Grecia y, en particular, Atenas, el antecedente más importante de la banca romana¹⁶, pues no hay que olvidar que los primeros banqueros de Roma procedían de Grecia.

Dicha actividad, de modo paralelo al muy desarrollado comercio, alcanzó una gran relevancia, sobre todo, en Atenas¹⁷. A esto pudo contribuir, según la doctrina, el uso de la moneda a partir del s. VII a. C.¹⁸, amén de ciertas condiciones jurídicas del Ática, como la equiparación jurídica con los mercaderes extranjeros, la ausencia de forma en los contratos, la autorización desde los tiempos de Solón¹⁹, hacia el año 594 a. C., de préstamos con intereses sin fijar tasa alguna,...etc.²⁰

Se puede decir, por tanto, que la Banca en Grecia fue ya un negocio en muchos aspectos modernos: se llevaban, con minuciosidad, las cuentas, había amplias redes de corresponsales y se prestaban a la clientela servicios diversos, desde los depósitos de dinero u objetos preciosos, pasando por los pagos de facturas, las transferencias y el cambio, hasta la concesión de créditos y garantías, los seguros marítimos o la intervención en sucesiones y subasta públicas²¹.

Tenemos conocimiento de las prácticas bancarias griegas merced a los discursos de Demóstenes e Isócrates²². En ellos, como reconoce la *communis opinio*, se encuentra la primera manifestación escrita de la que se infiere la existencia en Grecia del secreto bancario, esto es, la reserva del banquero (*trapezita*) respecto de los negocios celebrados con sus clientes²³, pues como afirma Isócrates, estos negocios eran concluidos sin la presencia de

15 Las primeras operaciones bancarias fueron realizadas por los sacerdotes en los templos, lugares preferidos para la custodia de los depósitos. Aunque no se sabe a ciencia cierta si se pagaban o no intereses, sí se sabe que aquéllos no permanecían ociosos, sino que fueron utilizados para dar préstamos con intereses.

16 A juicio de REHME, P., *Historia universal del Derecho mercantil*, traducc. al español por E. Gomez Orbaneja, Madrid, 1941, p. 58, la recepción de las prácticas bancarias griegas, así como del propio Derecho bancario griego por parte de Roma, se ve confirmada si se presta atención a los contratos marítimos como el préstamo marítimo (*foenus nauticum*) y la avería gruesa (*lex Rhodia de iactu*).

17 En torno al s. V a. C. empezamos a asistir, apuntan MARTÍN MOLINA y VEIGA COPO, *Los libros de contabilidad*, cit., p. 397, a la especialización del comercio con dinero, y los primeros bancos privados se establecen junto a los bancos de los templos. Los banqueros o *trapezitas*, depositarios de ahorro y dispensadores del crédito, desempeñaron un importante papel en estos hechos. Así, mediante sus operaciones de crédito confirieron un relevante auge e impulso a las transacciones comerciales. Sobre el desarrollo del comercio bancario en Grecia, vid. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, cit., p. 49.

18 La introducción de la moneda modificó en Grecia el régimen económico establecido desde siglos. Se atribuye su invención a Gyges, un joven pastor de Lidia que se convirtió en Rey asesinando al Rey Candaulo, fundando la dinastía de los Gyges, que sustituyó los lingotes de plata, de peso y forma variables, que hasta entonces se utilizaban como unidad de cambio, por fragmentos de metal uniformes acuñados por medio de una señal que garantizaba oficialmente su valor. El "dracma" de Atenas se convirtió en la moneda internacional del mundo mediterráneo (Cfr. BAUCNE GARCADIENGO, M., *Operaciones bancarias*, México, 1985, p. 1).

19 Legislador ateniense, uno de los siete sabios de Grecia (640-558 a. C.).

20 GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, cit., p. 47.

21 PEÑALVER RODRÍGUEZ, M. A., *La banca en Roma*, Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936-1986), tom. III, coord. de la edición Jaime Roset, Madrid, 1988, p. 1.533.

22 Años 436-338 a. C. y 380-320 a. C., respectivamente.

23 Demóstenes en su *Discurso contra Calipo* (*Discursos Privados*, tom II, traducc. al español y notas por J. M. Colubi Falcó, Madrid, 1983, pp. 153 ss.), nos proporciona un claro ejemplo de la discreción con la que había de proceder el banquero en la Grecia clásica. El caso contemplado es el siguiente: un extranjero, Licón, deposita una

testigos²⁴, correspondiendo al *trapezita* la función de redactar el contrato que luego pasaba a sus libros que habrían de servir de prueba en un litigio²⁵.

De conformidad con lo apuntado cabe asimismo destacar que los banqueros griegos llevaban dos libros de contabilidad: los diarios (*ephemerides*), en que anotaban las operaciones a medida que se iban concluyendo, y los libros de cuentas (*trapezitica grammata*), en los que cada cliente tenía una cuenta abierta a su nombre, con una página para el activo y otra para el pasivo²⁶. La exactitud y lealtad con que se llevaban los libros²⁷ les confería, por ello, un valor probatorio de primer orden²⁸.

En último término, el breve contexto descrito de la actividad bancaria en sus primeros orígenes nos enseña que la confianza en la persona del banquero fue y, con el devenir del tiempo, continuará siéndolo, factor decisivo para el desarrollo de los negocios bancarios.

II. Aunque es verdad, como se ha indicado, que la reserva en el manejo de la información bancaria ha envuelto siempre la actividad de los “agentes” que actúan en la “interposición de los recursos financieros”, encontrándose ya en Atenas la primera manifestación escrita del sigilo del banquero respecto de los negocios realizados con sus clientes; es en

cantidad en el Banco con la orden de ser entregada, cuando muera, a Cefisíades. Tras su muerte, acude al Banco un tal Calipo, preguntando si conocían a Licón de Heraclea. Ante su respuesta afirmativa, interroga al banquero sobre si el fallecido había sido cliente del Banco. En lugar de contestar inmediatamente el *trapezita* responde “¿por qué lo preguntas?”. Calipo esgrime que siendo el próxeno de los heracleotas había de ocuparse de todos ellos por si habían dejado algún dinero y, por esta razón, pide ver los libros del banquero. El orador continúa con estos términos: “Habiéndole oído Formión, jueces, se los enseñó inmediatamente, de momento. Como le hubiera mostrado la documentación, después de haberla leído él y ningún otro, y visto que estaba escrito en ella: <<Licón, heracleota, mil seiscientos cuarenta, hay que entregárselas a Cefisíades; Arquebíades de Lamprtras presentará a Cefisíades>>, partió, alejándose en silencio”.

24 Discurso *Sobre un asunto bancario* (*Discursos Privados*, tom. 1, traducc. al español por J. M. Guzmán Hermida, Madrid, 1979, p. 112). Se trata de una defensa judicial escrita por Isócrates a favor de su cliente, un joven extranjero, mercader de Crimea, hijo de Sapeo, en contra del banquero Pasión, al que se acusaba de haberse apropiado del dinero que el joven mercader le había dado en depósito. En esta defensa, conocida como “Oración *trapezita*”, se puede leer: “Lo más difícil de todo, jueces, es haber topado con tales adversarios. Porque los tratos con gentes de banca se celebran sin testigos, y tienen por fuerza que arriesgarse los perjudicados ante tales gentes, que tienen muchos amigos, manejan mucho dinero y parecen de confianza por razón de su oficio”. Concretamente, a este pasaje se refiere PALMIERI, A., *Nouve breccia nel segreto bancario?*, *Banca, borsa e titoli di credito*, 1981-I, p. 77, considerándolo como un precedente del secreto bancario. En el mismo discurso, el orador griego prosigue diciendo: “Creo que la mayor prueba de que Pasión me quitó el dinero es lo siguiente: que no quiso entregar al esclavo que sabía lo del depósito para que fuera interrogado con tormento. ¿Qué prueba sería más firme que ésta en los tratos con los banqueros? Pues no usamos con ellos testigos”.

25 En esta línea GARRIGUES, *Depósito irregular y Derecho Mercantil*, R. C. D. I, 1932, pp. 253-254, citado por AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *El secreto bancario*, cit., p. 60, n. 57, apunta que el crédito del banquero debía estar muy bien cimentado en aquella época, basándose, precisamente, en la no intervención de testigos en la formalización del depósito irregular y en la eficacia probatoria atribuida a los libros y registros del banquero.

26 Sobre la existencia de fuentes epigráficas y literarias que vislumbran la técnica contable en Atenas, vid. VLAEMMINCK, J., *Histoire et Doctrines de la Comptabilité*, traducc. al español por J. M^a González Ferrando, Madrid, 1961, p. 17, cita que se basa en PERROT, G., “*Demosthène et ses contemporains*”, *Revue des Deux-Mondes*, 15 de noviembre de 1873, pp. 405-439.

27 REHME, *Historia universal del Derecho mercantil*, cit., p. 52, señala que así como consta el deber de levanza de contabilidad por parte del banquero, no ocurre lo mismo con otros comerciantes.

28 MARTÍN MOLINA y VEIGA COPO, *Los libros de contabilidad*, cit., p. 397.

Roma, sin embargo, donde el secreto bancario abandona, definitivamente, el terreno de lo religioso y sagrado, que tanta trascendencia tuviera en su nacimiento, empezando a ser objeto de regulación propiamente jurídica, reconociéndose su existencia y concretándose, a su vez, sus límites.

A estos efectos cabe anticipar que el testimonio ofrecido por Gayo, en D. 2, 13, 10, 2 *1 ad ed. prov.*²⁹, constituye pieza clave en mi estudio, pues en él, como veremos, se encuentra lo que puede considerarse la primera formulación jurídica, cuando menos, de la que tenemos noticia, del hoy denominado secreto bancario y, por tanto, el antecedente histórico jurídico de la moderna disciplina de dicha institución.

El Título 13, “*De edendo*,” del libro II del Digesto comprende los comentarios jurisprudenciales al *edictum de argentariis rationibus edendi*³⁰, edicto que impone a los banqueros³¹ *edere rationes*³², es decir, comunicar antes del juicio, o, eventualmente, en juicio³³, su libro de cuentas o *codex rationum* en la parte correspondiente a las partidas del cliente, con expresión de la fecha (*die et consule*)³⁴, siempre y cuando éste lo hubiera solicitado para aportar dicha documentación como prueba escrita en una *litis*³⁵ y sin que

29 ...scilicet ut non totum cuique codicem rationum totasque membranas inspiciendi describendique potestas fiat, sed ut ea sola pars rationum, quae ad instruendum aliquem pertineat, inspiciatur et describatur.

30 El título “*De edendo*”, como señala FERNÁNDEZ BARREIRO, A., *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona, 1969, p. 3, recoge comentarios relativos a dos edictos distintos y con entidad propia cada uno de ellos: uno, que podemos denominar *de formula edendo*, relativo al deber del demandante de comunicar extraprocesalmente al adversario la fórmula y los medios de prueba de carácter documental (*instrumenta*) que piensa utilizar contra él en el futuro proceso; y el otro, *de argentariis rationibus edendi*.

31 El nombre tradicional de banquero en Roma es el de *argentarius* (o *trapezita*, equivalente latino del mismo vocablo griego), pues el mismo se utiliza para designar a los primeros banqueros que aparecen en Roma hacia finales del s. IV a. C. En las fuentes romanas se usan también otros términos, posteriores en el tiempo, como *nummularius*, *coactor argentarius*, *mensarius*, *mensularius*...etc., para denominar las nuevas profesiones bancarias.

32 Las fuentes, como señala GIOMARO, A. M^a, *Actio in factum adversus argentarios*, *Studi Urbinati*, año XLV, Urbino, 1976-1977, p. 61, utilizan tres expresiones distintas (*edere*, *exhibere* y *reddere rationes*) a propósito de la presentación de documentos y, en particular, en relación con las cuentas. Sobre su significado técnico, así como sus analogías y diferencias, vid. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., pp. 127-141; PEÑALVER RODRÍGUEZ, *La banca en Roma*, cit., pp. 1.548-1.549.

33 Coincido con FERNÁNDEZ BARREIRO, *ibidem*, p. 145, que la *editio rationum*, como regla general, era un acto de realización extraprocesal, lo que resulta, a su modo de ver, del examen del lugar en que podía ser exigida la comunicación de las cuentas y, sobre todo, de la forma de practicarla para dar cumplimiento al deber pretorio. Vid su argumentación, en pp. 145 ss.

34 D. 2, 13, 4 pr. *Ulp. 4 ad ed.*: *Praetor ait: “argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule”*. El tenor literal del edicto, según la reconstrucción de LENEL, O., *EP*, 3a. ed., Leipzig 1927 (reimpr. 1956), pp. 61 ss, aceptada por toda la doctrina, sería: *Argentariae mensae exercitores rationem ei qui iuraverit non calumniar causa postulare se edi sibi rationem quae ad se pertinet, edant adiecto die et consule*. Dicho edicto se completaba con la indicación de la fórmula de la acción *in factum* que podría interponerse contra el banquero cuando no hubiera respetado la prescripción pretoria de exhibir las cuentas. El texto de esta acción no nos ha llegado directamente, sólo a través de breves referencias de los juristas. Para la reconstrucción de dicha fórmula, vid. LENEL, *EP*, cit., p. 61; FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., pp. 229 ss.; PETRUCCI, A., *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a. C.-metà del III secolo d. C.)*, Napoli, 1991, pp. 155 ss.; MANTOVANI, D., *Le formule del processo privato romano*, Padova, 1999, p. 72.

35 Dos textos de Ulpiano 4 ad. ed. nos informan del lugar de presentación del libro de cuentas, así: D. 2, 13, 4, 5: *Sed ibi quis compellitur edere, ubi argentariam exercuit, et hoc est constitutum. Quod si instrumentum argentariae in alia provincia habeat, in alia administraverit, ibi puto cogendum edere, ubi argentariam exercuit:*

ello supusiera, *per se*, la cancelación de la cuenta ni, por tanto, la entrega del *reliquum*, ya que el mencionado deber no comporta la obligación del banquero de rendir cuentas (*reddere rationes*)³⁶.

El edicto de *edendo* relativo a los *argentariae mensae exercitores*³⁷ fue pronunciado, con probabilidad, en el curso del s. II a. C.³⁸, esto es, en un periodo en que la actividad bancaria habría asumido una particular relevancia en la economía romana³⁹, tal y como constatan algunas fuentes literarias y epigráficas⁴⁰.

La *ratio* de este edicto, en palabras de Ulpiano (D. 2, 13, 4, 1 4 *ad. ed.*), descansa en la *aequitas*, concretada en la necesidad de mostrar con fines probatorios la documentación contable redactada en interés y por causa del propio cliente y, por ello, en cierto modo, considerada de su propiedad⁴¹:

Huius edicti ratio aequissima est: nam cum singulorum rationes argentarii conficiant, aequum fuit id quod mei causa confecit meum quodammodo instrumentum mihi edi.

hoc enim primum deliquit, quod alio instrumentum transtulit. Quod si in alio loco argentariam exercet, alibi autem ad editionem compelletur, minime hoc facere cogitur: nisi descriptum velis ubi de ea re agitur eum tibi dare, tuis videlicet sumptibus; y D. 2, 13, 6 pr.: Si quis ex argentariis, ut plerique eorum, in villa habeat instrumentum vel in horreo: aut ad locum te perducet aut descriptas rationes dabit.

36 En esta línea Pomponio, en D. 50, 16, 89, 2 6 *ad Sab.*, observa que entre “presentar” y “rendir las cuentas” hay mucha diferencia, y aquél a quien se le ordena que las presente no debe devolver el sobrante, porque también se considera que el banquero presenta la cuenta, aunque no pague el saldo que queda en su poder (*Inter “edere” et “reddi rationes” multum interest: nec is, qui edere iussus sit, reliquum reddere debet: nam et argentarius edere rationem videtur, etiamsi quod reliquum sit apud eum, non solvat*).

37 Expresión utilizada por Ulpiano en el fragmento reproducido en n. 34, D. 2, 13, 4 pr., con ocasión de su comentario al edicto referente a la *editio rationum* de los banqueros. Para PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., p. 19, en este edicto se encontraría la referencia más antigua de una fuente jurídica a una empresa bancaria, pues con esa acepción se utiliza el término “*mensae argentariae*”.

38 Vid. PETRUCCI, *ibidem*, pp. 19 ss, pp. 141 ss.; *Profili giuridici della attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, p. 140; CERAMI, P.-DI PORTO, A.-PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 2ª ed., Torino, 2004, pp. 175-176. Sin embargo, para FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., pp. 233-234, la fecha del edicto debe colocarse entre algunos años después del 50 a. C y el jurista Labeón.

39 Para un examen del desarrollo económico y tendencias “capitalistas” a partir del s. II a. C., vid. KOVALIOV, S. I., *Historia de Roma*, 3ª ed., traducc. al español por M. Ravoni, Madrid, 1970, pp. 367 ss; ROS-TOVTZEFF, M., *Historia social y económica del Imperio romano*, I, traducc. al español por L. López Ballesteros, Madrid, 1998, pp. 53 ss.

40 Vid. textos de las comedias de Plauto (*ad exemplum*, *Asinaria*, 436-440; *Aulularia*, 525-530; *Curculio*, 506-511, 535-544; *Persa*, 433-436), de Terencio (*Phornio*, 921-922), de la Historia de Polibio (31, 27, 1-8) y el epígrafe de Delos en honor del banquero romano M. Minazio. Sobre estas fuentes vid. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., pp. 67 ss, y bibliografía allí citada.

41 ANDREAU, J., *Banque et affaires dans le monde romain. IVe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.*, Paris, 2001, p. 93. Sin embargo, FERNÁNDEZ BARREIRO, *op. cit.*, pp. 141-142, postula que los motivos que aconsejaron la imposición al *argentarius* del deber de *edere rationes* no pudieron basarse, simplemente, en razones de equidad, como pretende hacernos creer, a su entender, el autor de la glosa o interpolación de D. 2, 13, 4, 1. Para el autor la *ratio edicto* del *argentarius* se encuentra en que éste es un gestor cualificado y de mayor relevancia en el tráfico negocial que cualquier otra persona que tuviese a su cargo, como él, funciones de gestión y administración de negocios y bienes ajenos.

Si se tiene en cuenta, como acreditan las fuentes, que la creación en Roma de un cuerpo específico de “normas” referentes a la actividad de los banqueros, a su organización y jurisdicción sobre ellos⁴², encuentra su razón de ser en la tutela de la confianza que los clientes tienen en los banqueros (*fides y fides publica*)⁴³, así como en la utilidad pública de la función que éstos desempeñan⁴⁴, se entiende que el contexto más amplio del régimen del citado edicto lo constituya la necesidad de proteger la confianza del que contrata con un banquero⁴⁵, cuya labor es considerada de interés público y que, por ello, dicho régimen, que, en un principio, se aplicaría a los *argentarii* (D. 2, 13, 4 pr.) se amplíe después, por parte de la jurisprudencia, a los *nummularii*⁴⁶.

El motivo de tal extensión se halla en que, como opina Pomponio, del que nos da noticia Paulo, en D. 2, 13, 9, 2 3 *ad ed.*, no es injusto que también los cambistas -*nummularii*⁴⁷- sean obligados a comunicar las cuentas, porque también éstos las confeccionan, ya que, al igual que los *argentarii*, en parte, reciben dinero y, en parte, lo entregan, valiendo como prueba de ello, sobre todo, la escritura y sus libros; y con frecuencia se recurre a la fe de los mismos:

Nummularios quoque non esse iniquum cogi rationes edere Pomponius scribit: quia et hi nummularii sicut argentarii rationes conficiunt, quia et accipiunt pecuniam et erogant per partes, quarum probatio scriptura codicibusque eorum maxime continetur: et frequentissime ad fidem eorum decurritur.

42 Es obvio, como manifiesta SALAZAR REVUELTA, M., El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos, RIDROM, 11 (octubre 2013) pp. 88-149, pp. 92-93, en la línea de lo ya indicado por otros romanistas, que no encontramos en el Derecho romano un campo jurídico o una rama autónoma relativa a la materia comercial. Si bien es cierto que esta materia no conforma un todo independiente, sino que se encuentra diseminada a lo largo del Corpus Iuris, lo dicho no debe ser razón para excluir una falta de preocupación por parte del Derecho romano en este sentido (sobre esta cuestión, vid. bibliografía citada por SALAZAR, ibidem, p. 93, n. 4). En definitiva, hay que coincidir con GARCÍA GARRIDO, J. M., El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, Madrid, 2001, pp. 34 y 74, que aunque conviene observar una cierta cautela a la hora de transplantar nociones y prácticas actuales a la Antigüedad, no se puede caer en el extremo opuesto de negar valor de precedentes a los abundantes testimonios sobre las actividades financieras de los romanos (Cfr. TALAMANCA, M., Recens. a Petrucci, Mensam exercere, cit., BIDR 96-97 (1993-1994), pp. 828 ss.

43 Vid. D. 2, 13, 9, 2 Paul. 2 *ad ed.* (“*ad fidem eorum decurritur*”) y D. 42, 5, 24, 2 Ulp. 64 *ad ed.* (“*fidem publicam*”).

44 Vid. D. 2, 13, 10, 1 Gai. 1 *ad ed. prov.* (“*quia officium eorum atque ministerium publicam habet causam*”) y D. 16, 3, 8 Pap. 9 *quaest.* (“*idque propter necessarium usum argentariorum ex utilitate publica receptum est*”).

45 Vid. n. 43.

46 Cfr. entre otros, CERAMI-DI PORTO-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., pp. 181-182; SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho romano*, México, 2007, p. 105; SALAZAR, *El deber de información*, cit., p. 111. Sobre la extensión del citado edicto, por obra de la jurisprudencia, a los *nummularii*, vid. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., pp. 198 ss; PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., pp. 24 ss.

47 Comparto con SALAZAR, *op. cit.*, p. 97, que a pesar de que el término propiamente dicho designe a quienes se dedican al cambio de las monedas, algo bastante frecuente en la práctica de los negocios de la 2ª mitad de s. II a. C., dado el incremento del tráfico comercial entre ciudades, ya a partir del s. II d. C., como ya señaló ANDREAU, *Banque et affaires*, cit., p. 97, las actividades de estos cambistas se ampliarían a otras operaciones bancarias como los depósitos y los préstamos.

Si bien es cierto que en Roma no sólo los banqueros llevaban cuentas⁴⁸, sin embargo, únicamente ellos tenían el deber de comunicarlas con ocasión de un litigio y “no otras personas”, porque como advierte Gayo, en D. 2, 13, 10, 1 *ad ed. prov.*, el oficio y servicio de los banqueros tiene algo de causa pública, es decir, de interés público y, además, su principal deber es formalizar con diligencia las cuentas de sus negocios:

Ideo autem argentarios tantum neque alios ullos absimiles eis edere rationes cogit, quia officium eorum atque ministerium publicam habet causam et haec principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant.

Por ello, aunque otras personas están obligadas también a llevar las cuentas de las operaciones que concluyen por desempeñar funciones de administración y gestión de bienes ajenos, como destaca Paulo, en D. 2, 13, 9 pr. 3 *ad ed.*, respecto al *procurator*, al socio e incluso al tutor, *nec tamen a praetore per hoc edictum compelluntur*⁴⁹. Estas personas, en efecto, están obligadas civilmente a *edere rationes* (*Quaedam sunt personae, quas rationes nobis edere oportet...*), como parte de su obligación de rendir cuentas (*reddere rationes*), pero no es ésta la razón de su exclusión del régimen del edicto, sino el hecho de no concurrir en ellas el requisito necesario de la profesión bancaria⁵⁰.

Así pues, resulta incuestionable, a tenor de lo expuesto, la importancia que asumieron en la práctica bancaria romana, sobre todo, como elemento probatorio en un proceso, las *rationes* o anotaciones que el banquero transcribía en su libro contable (*liber* o *codex rationum*)⁵¹, docu-

48 PEÑALVER RODRÍGUEZ, *La banca en Roma*, cit., p. 1.544, apunta que en época de Cicerón, e incluso antes, todos los *patresfamilias* en Roma, o al menos los que tenían un cierto patrimonio, llevaban sus libros de contabilidad. Se trataba de una contabilidad sencilla, compuesta tan sólo de un libro o diario de notas y un libro fundamental, en general, conocido con el nombre de *codex accepti et expensi*, que se llevaba muy cuidadosamente y en el que, con una periodicidad mensual, como afirma Cicerón, en *Pro Roscio*, 2, 8, se pasaban todos los apuntes derivados de las notas del mes que, por lo común, constarían en el libro diario.

49 *Quaedam sunt personae, quas rationes nobis edere oportet nec tamen a praetore per hoc edictum compelluntur. Veluti cum procurator res rationesve nostras administravit, non cogitur a praetore per metum in factum actionis rationes edere: scilicet quia id consequi possumus per mandati actionem. Et cum dolo malo socius negotia gessit, praetor per hanc clausulam non intervenit: est enim pro socio actio. Sed nec tutorem cogit praetor pupillo edere rationes: sed iudicio tutelae solet cogi edere.*

50 Cfr. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., pp. 192-193, que, a su vez, analiza la genuinidad del citado fragmento, en pp. 193-195.

51 Se trataba de un libro Mayor propio del negocio bancario en el que cada cliente tenía una cuenta abierta a su nombre. En él se anotaban, por tanto, por orden cronológico (*cum die et consule*) y mezcladas, las entradas y salidas del patrimonio, las obligaciones derivadas de los negocios jurídicos o los bienes existentes, ya que las anotaciones por partida doble no se conocieron hasta la Edad Media. Para SALAZAR, *El deber de información*, cit. p. 107, n. 34, del examen de los textos referentes al edicto de *rationibus edendis* no se infiere que se usaran unos libros especiales para la actividad bancaria. A su juicio, sólo Gayo, en D. 2, 13, 10, 2 *ad ed. prov.*, menciona el *codex rationum* y, por ello, no pueden descartarse otros libros utilizados, por lo común, en el registro de la contabilidad en general, así: el libro diario o de notas provisionales (los *adversaria*), de duración mensual y que luego se transcribían en el libro contable; el tradicional libro de caja o de ingresos y gastos (*codex accepti et expensi*), libro contable que reflejaba la situación patrimonial de los *patresfamilias*; y el *kalendarium* o libro de vencimientos. Sin embargo, PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., p. 169, tras reconocer que el fragmento gayano, D. 2, 13, 10, 2, es el único de todo el título D. 2, 13 que califica expresamente como *codex rationum* el libro donde se registran las operaciones singulares que nacen de las diversas cuentas

mentando de esta manera las operaciones derivadas de los diversos negocios concluidos con sus clientes⁵², por lo común, sin la intervención de testigos.

En definitiva, la obligación de los banqueros de confeccionar diligentemente las cuentas de sus negocios, con exactitud y corrección⁵³, obligación principal inherente a su oficio, en Roma, encuentra su reflejo práctico, precisamente, en el deber que el pretor les impone de comunicar sus cuentas, siempre que concurren ciertos presupuestos.

Llegados a este punto, aunque las fuentes jurídicas permiten una reconstrucción bastante detallada del régimen clásico de la *editio rationum*⁵⁴, el objeto del presente trabajo justifica que, a continuación, centre mi atención en aquellos aspectos de la regulación que, directa o indirectamente, inciden en el secreto de las operaciones bancarias, así como en sus límites.

En esta línea cabe observar que las personas que pueden solicitar y obtener la *editio rationum* son, como regla general, los clientes del banquero, aquéllos en cuyo favor, o en consideración a los cuales, hubiesen sido realizadas las cuentas (*rationes ad se pertinentes*)⁵⁵, siempre y cuando concurren los siguientes requisitos: 1º) que necesiten esa documentación contable para fundamentar en ella sus alegaciones en un proceso, ya sea con el mismo banquero o con otra persona (D. 2, 13, 10 pr. *Gai. 1 ad ed. prov.*)⁵⁶; y 2º) que pres-ten el *iusiurandum non calumniae causa postulare se edi sibi*⁵⁷, en otras palabras, el previo

y su resultado contable, sostiene, no obstante, que gracias a este texto podemos considerar, con suficiente seguridad, que en D. 2, 13, 6, 7 *Ulp. 4 ad ed. (codicem proferre)* y D. 2, 13, 9, 2 *Paul. 3 ad. ed. (codices)*, la referencia sea también a dicho *codex*. En base a estos comentarios jurisprudenciales se puede ver, observa el autor, como el edicto *de edendo* supone una contribución decisiva en la individualización del *codex rationum* como el libro o uno de los libros fundamentales en el ejercicio de la banca. En general, sobre este tema, vid. bibliografía citada por SALAZAR, *ibidem*, pp. 107-108, n. 34.

52 En D. 2, 13, 6, 3 *Ulp. 4 ad ed.* se define la ratio o cuenta bancaria en los siguientes términos: *Rationem autem esse Labeo ait ultro citro dandi accipiendi, credendi, obligandi solvendi sui causa negotiationem: nec ullam rationem nuda dumtaxat solutione debiti incipere. Nec si pignus acceperit aut mandatum, compellendum edere: hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi constituit, argentarius edere debet: nam et hoc ex argentaria venit.* Sobre el contenido de la cuenta bancaria a la luz de la definición transcrita en el citado fragmento, vid. bibliografía citada por SALAZAR, *op. cit.*, p. 108, n. 25.

53 Sobre la misma, vid. PEÑALVER, *La banca en Roma*, cit., p. 1.544-1.546 y SALAZAR, *El deber de información*, cit., pp. 108-109.

54 Del edicto de *argentariis rationibus edendis*, tan sólo se han conservado los textos recogidos por los compiladores, quienes, como en tantas ocasiones, utilizaron para la elaboración del título *de edendo*, sobre todo, los comentarios *ad edictum* de Ulpiano, en los que intercalaron pasajes de Paulo correspondientes a los mismos comentarios y de Gayo al edicto provincial. Los compiladores recogieron también en el mencionado título sendos fragmentos de Modestino, Calístrato y Mauricio. Vid. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., pp. 6-7, ns. 6, 7, 8, 9, 11 y 12.

55 Partiendo del comentario de las palabras edictales “*rationem, quae ad se pertinet*” (D. 2, 13, 4 pr. *Ulp. 4 ad ed.*) la jurisprudencia estimó, como destaca FERNÁNDEZ BARREIRO, *ibidem*, pp. 179-181, que la *editio* podía ser exigida por aquél en cuyo favor, o en atención al cual, fueron realizadas las *rationes*, tanto en el caso que hubiese intervenido personalmente en las relaciones comerciales con el banquero, como si lo hubiese hecho un procurador en ausencia del *dominus negotii* (vid. D. 2, 13, 6, 5 *Ulp. 4 ad ed.*), o un hijo o esclavo en favor de cuyo padre o amo se redactaron las *rationes* (vid. D. 2, 13, 9, 4 *Paul. 3 ad ed.*).

56 *Argentarius rationes edere iubetur: nec interest cum ipso argentario controversia sit an cum alio.*

57 Así resulta, admite la communis opinio, de lo dispuesto en la primera cláusula del edicto, según la reconstrucción de LENEL, *EP*, cit., p. 63: *Argentariae mensae exercitores rationem ei qui iuraverit non calumniae causa postulare se edi sibi rationem quae ad se pertinet, edant adiecto die et consule.*

juramento de no solicitar la *editio calumniae causa*, es decir, con la única finalidad de perjudicar o vejar al banquero (D. 2, 13, 6, 2 *Ulp. 4 ad ed.*⁵⁸ y D. 2, 13, 9, 3 *Paul. 3 ad. ed.*⁵⁹).

Sobre la base de este juramento el pretor pronunciaría el *decretum editionis*⁶⁰, decreto con el que impondría al banquero la presentación con vistas a un litigio de las *rationes* pertinentes a la causa⁶¹.

No obstante, como acreditan las fuentes, el pretor admite excepcionalmente que el cliente, por segunda vez, y el propio banquero, soliciten y obtengan la *editio rationum*, pero en estos supuestos aquél no decreta directamente la orden tras la solicitud, sino que la concederá o no “previo conocimiento de causa” (*causa cognita*)⁶², esto es, tras examinar la concurrencia de determinados presupuestos necesarios para que la *editio* pudiera exigirse con éxito en cada caso concreto⁶³.

Si el edicto, como hemos visto, sólo permite solicitar y obtener la comunicación de las cuentas a aquéllos en cuyo favor e interés se hubieran realizado (*rationes ad se pertinentes*), la consecuencia que se deduce es clara: no se podría pronunciar el *decretum editionis* cuando el banquero alegara con fundamento que no concurría en el solicitante dicho requisito⁶⁴. Por ello, los terceros, en contra de lo que opina PEÑALVER RODRÍGUEZ⁶⁵, no

58 *Exigitur autem ab adversario argentarii iusiurandum non calumniae causa postulare edi sibi: ne forte vel supervacuas rationes vel quas habet edi sibi postulet vexandi argentarii causa.*

59 *Ceterum omnibus postulantibus et iurantibus non calumniae causa petere rationes, quae ad se pertineant, edi iubet.*

60 Las disposiciones del edicto fueron objeto de una importante labor interpretativa por la jurisprudencia, cuyos testimonios nos permiten integrar algunos de los elementos de dicho edicto, como que la orden del pretor revestía la forma de decreto y, por ello, en caso de incumplimiento representaba el momento al que el juez debía referir el interés del cliente (*id quod interest*), según lo establecido en D. 2, 13, 8, 1 *Ulp. 4 ad ed.* y en la primera parte de D. 2, 13, 10, 3 *Gai. 1 ad ed. prov.*; cuestión ésta, la de la responsabilidad del banquero por incumplimiento de la orden pretoria, que excede del ámbito y propósito de este estudio.

61 De los fragmentos mencionados *supra* en el texto, D. 2, 13, 6, 2 y D. 2, 13, 9, 3, se infiere que el banquero debía realizar la *editio* en todo caso, salvo que existiera una actitud dolosa en el que la solicitaba. A estos efectos, la única garantía que concedía el pretor, como señala FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., p. 177, era exigir al interesado el referido juramento, sin entrar, por tanto, en el examen de si existía o no por parte del solicitante un verdadero interés. Vid. GIOMARO, *Actio in factum adversos argentarios*, cit., pp. 68 ss.

62 D. 2, 13, 6, 8 *Ulp. 4 ad ed.*: *Praetor ait: “argentario eive, qui iterum edi postulabit, causa cognita edi iubebo”*. Este régimen especial venía establecido por el pretor en la segunda cláusula del edicto (LENEL, *EP*, cit., p. 63).

63 En relación a la aplicación práctica de la citada cláusula edictal nos dan importantes noticias dos textos del Digesto, concatenados entre sí, extraídos de los comentarios al edicto: D. 2, 13, 6, 9-10 *Ulp. 4 ad ed.*: *Prohibet argentario edi illa ratione, quod etiam ipse instructus esse potest instrumento suae professionis: et absurdum est, cum ipse in ea sit causa, ut edere debeat, ipsum petere ut edatur ei. An nec heredi argentarii edi ratio debeat, videndum: et si quidem instrumentum argentariae ad eum pervenit, non debet ei edi, si minus, edenda est ex causa. Nam et ipsi argentario ex causa ratio edenda est: si naufragio vel ruina vel incendio vel alio simili casu rationes perdidisse probet aut in longinquo habere, veluti trans mare.* 10. *Nec iterum postulanti edi praetor iubet, nisi ex causa:* (D. 2, 13, 7 pr. *Paul. 3 ad ed.*) *Veluti si peregre habere quod primum editum est doceat: vel minus plene editum: vel eas rationes, quas casu maiore, non vero negligentia perdidit. Nam si eo casu amisit, cui ignosci debeat, ex integro edi iubebit.* Sobre esta cuestión, vid. FERNÁNDEZ BARREIRO, *op. cit.*, pp. 182 ss; PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., pp. 184 ss; SALAZAR, *El deber de información*, cit., pp. 122 ss.

64 FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., p. 178.

65 *La banca en Roma*, cit., p. 1.545.

pueden pedir la *editio* de unas cuentas *ad se non pertinentes*, es decir, de unos documentos contables que no se han practicado en su interés y por su causa.

Por lo que respecta a las personas que tienen el deber de presentar las cuentas basta aquí indicar⁶⁶, a modo de síntesis, que están obligadas a ello, según lo dispuesto en los textos: los banqueros propiamente dichos (*argentarii*)⁶⁷, aunque hayan dejado de actuar como tales⁶⁸, a los que se equiparan, a estos efectos, como vimos, los cambistas (*nummularii*)⁶⁹; el *filius familias* y el esclavo que ejercen la profesión bancaria o, en muchos de estos casos, su padre o dueño⁷⁰; y también los sucesores del banquero⁷¹.

En suma, cabe concluir con FERNÁNDEZ BARREIRO que el deber de *edere rationes* se basa en una doble exigencia, así, en la nota de la profesionalidad, esto es, ejercer la profesión de banquero (*argentariae mensae executores*) y, precisamente, por ello, estar en posesión de las *rationes* cuya *editio* se exige⁷².

Lo dicho justifica que si terceras personas que no se dedican a la banca poseen las *rationes*, quedarán comprendidas en los términos del edicto cuando esa posesión derive de alguna relación que pueda fundamentar la subrogación o sucesión de la persona del tercero en la del banquero que es, en definitiva, el que practicó las cuentas y a quien se dirige el edicto.

Por último, paso a referirme al testimonio ofrecido por Gayo en D. 2, 13, 10, 2 *1 ad ed. prov.*, sin lugar a dudas, pieza fundamental en mi estudio, pues en él se encuentra, como ya anticipé, lo que puede considerarse la primera formulación jurídica, cuando menos, de la que tenemos noticia, del hoy denominado secreto bancario y, por tanto, el antecedente histórico jurídico de la moderna disciplina de dicha institución.

66 Vid. amplio tratamiento en FERNÁNDEZ BARREIRO, *ibidem.*, pp. 188 ss; PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., pp. 158 ss.

67 D. 2, 13, 4 pr. Ulp. 4 ad ed: *Praetor ait: "argentariae mensae executores rationem, quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule"*;

68 D. 2, 13, 4, 4 Ulp. 4 ad ed.: *Etiam is qui desit "desiit" argentariam facere, ad editionem compellitur.*

69 D. 2, 13, 9, 2 Gai. 3 ad ed.: *Nummularios quoque non esse iniquum cogi rationes edere Pomponius scribit: quia et hi nummularii sicut argentarii rationes conficiunt, quia et accipiunt pecuniam et erogant per partes, quarum probatio scriptura codicibusque eorum maxime continetur: et frequentissime ad fidem eorum decurritur.*

70 D. 2, 13, 4, 2 Ulp. 4 ad ed.: *Sed et filius familias continetur his verbis, ut vel ipse cogatur edere: an et pater, quaeritur. Labeo scribit patrem non cogendum, nisi sciente eo argentaria exercetur: sed recte Sabinus respondit tunc id admittendum, cum patri quaestum refert; y D. 2, 13, 4, 3: Sed si servus argentariam faciat (potest enim), si quidem voluntate domini fecerit, compellendum dominum edere ac perinde in eum dandum est iudicium, ac si ipse fecisset. Sed si inscio domino fecit, satis esse dominum iurare eas se rationes non habere: si servus peculiarem faciat argentariam, dominus de peculio vel de in rem verso tenetur: sed si dominus habet rationes nec edit, in solidum tenetur.*

71 D. 2, 13, 9, 1 Paul. 3 ad. ed: *Nihil interest, si successores aut pater aut dominus argentarii eiusdem fuerunt professionis: quia cum in locum et in ius succedant argentarii, partibus eius fungi debent. Is autem, cui argentarius rationes suas legavit, non videbitur contineri, quia iuris successor his verbis significatur: non magis, quam si ei vivus eas donasset. Sed nec heres tenebitur, cum nec possideat nec dolo malo fecerit: sed si ei, antequam eas legatario traderet, renunciatum fuerit, ne ante eas tradat, tenebitur quasi dolo fecerit: item antequam eas tradat, tenebitur. Quod si nihil dolo fecerit, causa cognita legatarius cogendus est edere; D. 2, 13, 6, 1 Ulp. 4 ad ed.: Cogentur et successores argentarii edere rationes. Quod si plures sunt heredes et unus habeat, solus ad editionem compellitur: sed si omnes habeant et unus ediderit, omnes ad editionem compellendi sunt. Quid enim si humilis et deploratus unus edidit, ut dubitare quis merito de fide editionis possit? Ut igitur comparari rationes possint, etiam ceteri edere debent aut certe unius editioni subscribere. Hoc idem erit et si plures fuerint argentarii, a quibus editio desideratur. Nam et si plures tutores tutelam administraverunt simul, aut omnes edere debent aut unius editioni subscribere.*

72 FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., p. 190.

En este texto, tras reconocerse que se muestra o exhibe una cuenta si se hace desde el principio, ya que en caso contrario no se podría entender, sólo se permite al cliente examinar y copiar aquella parte de las *rationes ad se pertinent* y que, como he reiterado en varias ocasiones, le interesan a fines probatorios con ocasión de su contienda (*sed ut ea sola pars rationum, quae ad instruendum aliquem pertineat, inspiciatur et describatur*), negándose, por tanto, de modo expreso, el derecho a inspeccionar y copiar todo el libro contable o *codex rationum*⁷³, con todas sus páginas (*scilicet ut non totum cuique codicem rationum totasque membranas inspiciendi describendique potestas fiat*).

El libro de cuentas abiertas a los clientes recogía unas a continuación de otras, siendo parte esencial de ellas, según el propio texto edictal (D. 2, 13, 4 pr.), que en su inicio constase la fecha (*edent adiecto die et consule*)⁷⁴. A cada cuenta correspondía una específica y separada documentación, pero todas eran recogidas, como se desprende de D. 2, 13, 6, 6 Ulp. 4 ad ed.⁷⁵, en un único libro que comprendía, día por día, una después de otra, las anotaciones relativas a las operaciones singulares que nacían de las diversas cuentas de los clientes⁷⁶.

Lo dicho está en consonancia, por tanto, con lo dispuesto en la primera parte del texto en examen, D. 2, 13, 10, 2, la necesidad de mostrar e inspeccionar una cuenta desde el principio, pues quien ha solicitado la *editio* debe estar en condiciones de conocer las referencias cronológicas de las diversas operaciones de su cuenta, ya que en caso contrario ésta no se podría entender.

La facultad de examinar y copiar las *rationes*, como se precisa en la segunda parte del paso gayano, no se extendía a todas las páginas del libro contable, sino que se limitaba, *stricto sensu*, a aquella parte de la documentación en que se encontraban las referidas al cliente y siempre que las necesitase para fines probatorios en un litigio. Esta limitación reviste una gran importancia, ya que, evidentemente, como he indicado, tiene por objeto proteger el secreto de las operaciones concluidas entre la banca y los clientes, excluyendo, por tanto, de la publicidad todo lo que no estuviera relacionado con la litis de la que deriva la petición de *edere rationum*, esto es, las cuentas de terceras personas también comprendidas en el libro contable de los banqueros e, incluso, aquellas operaciones registradas en la cuenta del cliente solicitante ajenas al proceso en curso⁷⁷.

73 Vid. n. 51.

74 Por ello, leemos en D. 2, 13, 6, 6 Ulp. 4. ed.: *Si initium tabularum habet diem, in quibus titii ratio scripta est, postmodum mea sine die et consule, etiam mihi edendus est dies et consul: communis enim omnis rationis est praepositio diei et consulis*.

75 Vid. n. anterior.

76 A estos efectos debe tenerse presente, como observa PETRUCCI, *Mensam execere*, cit., pp. 167-168., que el término *ratio* asume en la cláusula edictal un doble significado. Por una lado, designa la cuenta entre cliente y banquero, que nace, por ejemplo, de un depósito realizado por el primero, o bien de un préstamo concedido por el segundo, y que dará lugar a una serie de negocios y operaciones entre ellos o respecto a terceros; y por otro, presupone la documentación en que se registran tales negocios y operaciones, así como las variaciones pecuniarias que resultan de las mismas. A la primera acepción se refiere la definición de *ratio* propuesta por Labeón y de la que tenemos conocimiento por Ulpiano en D. 2, 13, 6, 3 4 ad ed. (vid. n. 52), y a la segunda diversos fragmentos, como los ya citados D. 2, 13, 10, 2 Gai. 1 ad ed. prov. y D. 2, 13, 6, 6 Ulp. 4 ad ed.

77 Para FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario*, cit., p. 151, sin embargo, no pude considerarse cumplido el deber de *editio* si no se permitió el examen completo de las *rationes ad se perti-*

El análisis acometido sobre diversos aspectos de la disciplina de la *editio ratiounum* permite, por tanto, afirmar, a modo de conclusión, que en su regulación subyace, en última instancia, un reconocimiento jurídico, cuando menos, implícito, del secreto bancario, pues aunque en Roma no existen “normas” que lo contemplen y regulen de modo expreso, sin embargo, las disposiciones que de alguna manera le afectan, como ocurre con las que he examinado, suponen excepciones o limitaciones, precisamente, de dicho secreto, excepciones que, a su vez, constituyen los primeros antecedentes de los preceptos actuales que imponen el levantamiento del secreto bancario en determinados supuestos.

En definitiva, la regulación pretoria, magistralmente completada por la actividad interpretativa de los juristas, logró equilibrar la exigencia de la afirmación y consolidación de la banca con la protección de los intereses de los clientes, en relación a un sector tan importante y delicado como el de la contabilidad⁷⁸. El examen realizado en estas páginas del deber edictal de *edere rationes* pone de manifiesto dicho equilibrio, ya que si bien se impone a los banqueros el citado deber, se atenúa el mismo estableciéndose, como hemos visto, determinados límites, con el fin de garantizar la preservación del secreto de las operaciones bancarias.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDREAU, J., Banque et affaires dans le monde romain. IVe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C., Paris, 2001.
- AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M. J., *El secreto bancario*, Barcelona, 2001.
- BATLLE SALES, G., El derecho a la intimidad privada y su regulación, Alcoy, 1972.
- BAUCNE GARCADIAGO, M., *Operaciones bancarias*, México, 1985.
- CAZORLA PRIETO, L. M., *El secreto bancario*, Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda, Madrid, 1978.
- CERAMI, P.-DI PORTO, A.-PETRUCCI, A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 2ª ed., Torino, 2004.
- COLLING, A., Banque et banquiers de Babylone a Wall Street, Paris, 1962.
- DAUPHIN-MENIER, A., *Histoire de la Banque*, 2ª ed., Paris, 1959.
- DO EGITO COELHO, W., Control de informaciones y secreto bancario. Cursillo de Derecho bancario, Montevideo, 1981.
- FARHAT, R., Le secret bancaire. Etude de Droit Comparé (France, Suisse, Liban), Paris, 1970.
- FERNÁNDEZ BARREIRO, A., La previa información del adversario en el proceso privado romano, Pamplona, 1969.
- GARCÍA GARRIDO, J. M., El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, Madrid, 2001.
- GARRIGUES, J., *Contratos bancarios*, Madrid, 1975.

nentes. A mi entender, como ya señaló PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., p. 169, esta interpretación es contraria a lo dispuesto en el fragmento (D. 2, 13, 10, 2).

⁷⁸ Cfr. CERAMI-DI PORTO-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., p. 186; SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, navegación y otras empresas*, cit., p. 110.

- GIOMARO, A. M^a., *Actio in factum adversos argentarios*, Studi Urbinati, año XLV, Urbino, 1976-1977.
- GOLDSCHMIDT, L., *Storia universale del diritto commerciale*, 1^a traducc. italiana por V. Pouchain y A. Scialoja, Torino, 1913.
- HENRION, R., *Le secret professionnel du banquier*, Bélgica, 1963.
- KOVALIOV, S. I., *Historia de Roma*, 3^a ed., traducc. al español por M. Ravoni, Madrid, 1970.
- LENEL, O., *EP*, 3a. ed., Leipzig, 1927 (reimpr. 1956).
- MANTOVANI, D., *Le formule del processo privato romano*, **Padova, 1999.**
- MARTÍN MOLINA, P. B. y VEIGA COPO, A. B., Los libros de contabilidad: un apunte histórico, Boletín de la Facultad de Derecho (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), 13 (1998) pp. 395-414.
- MELIS, F., *Storia della Ragioneria (Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica)*, Bolonia, 1950.
- MOLLE, G., *Il segreto bancario, Banca, borsa e titoli di credito*, 1937.
- *Depósito irregular y Derecho Mercantil*, R. C. D. I, 1932.
- PALMIERI, A., *Nouve brecces nel segreto bancario?*, Banca, borsa e titoli di credito, 1981-I.
- PEÑALVER RODRÍGUEZ, M. A., *La banca en Roma, Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936-1986)*, tom. III, coord. de la edición Jaime Roset, Madrid, 1988.
- PÉREZ BENECH, V., *La nueva regulación sobre el secreto bancario en la Ley n° 17.948*, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, 14 (2008) pp. 109-148.
- PERROT, G., “*Demosthère et ses contemporains*”, Revue des Deux-Mondes, 15 de noviembre de 1873, pp. 405-439.
- PETRUCCI, A., *Mensam exercere. Studi sull’impresa finanziaria romana (II secolo a. C.–metà del III secolo d. C.)*, Napoli, 1991.
- *Profili giuridici della attività e dell’organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002.
- REHME, P., *Historia universal del Derecho mercantil*, traducc. al español por E. Gomez Orbaneja, Madrid, 1941.
- ROSTOVTZEFF, M., *Historia social y económica del Imperio romano*, I, traducc. al español por L. López Ballesteros, Madrid, 1998.
- RUÍZ GARCÍA, J. R., *Secreto bancario y Hacienda Pública*, Madrid, 1988.
- SALAZAR REVUELTA, M., *El deber de información, transparencia y responsabilidad ante los depósitos de los clientes por parte de la banca: precedentes romanos*, RIDROM, 11 (octubre, 2013) pp. 88-149.
- SORIANO CIENFUEGOS, C., *Banca, navegación y otras empresas en el Derecho romano*, México, 2007.
- TERMES, R., *El fin del secreto bancario* (título de un fragmento de su informe de 1987 a la Asamblea general de la Asociación española de Banca Privada), *Desde la banca*, vol. II, Madrid, 1991.
- VLAEMMINCK, J., *Histoire et Doctrines de la Comptabilité*, traducc. al español por J. M^a González Ferrando, Madrid, 1961.
- TALAMANCA, M., Recens. a Petrucci, *Mensam exercere*, cit., BIDR 96-97 (1993-1994) pp. 828 ss.

NEGOCIOS FINANCIEROS EN LA LEGISLACIÓN DE DIOCLECIANO FINANCIAL BUSINESS IN DIOCLETIAN LAW

ADOLFO A. DÍAZ-BAUTISTA CREMADES

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

Muchos autores coinciden en señalar la grave crisis económica que sufrió el imperio Romano a lo largo del siglo III, y que dio lugar a un acusado descenso de la circulación monetaria y a la práctica desaparición de la banca. Tal ha sido al menos la conclusión casi unánime hasta hace unos años¹. Sin embargo, la historiografía más moderna, aun admitiendo el declive económico, trata de matizar su extensión y alcance², señalando, principalmen-

1 APARICIO PÉREZ refleja la controversia doctrinal sobre la existencia de negocios bancarios en torno al siglo IV y, citando a GARCÍA GARRIDO, concluye que *La tesis más acertada es que los argentarii (banqueros) y los coactores argentarii (intermediarios y prestamistas en las subastas) desde la segunda mitad del siglo III han desaparecido en el mediterráneo occidental...* APARICIO PÉREZ, A.: *Las grandes reformas fiscales del Imperio Romano: reformas de Octavio Augusto, Diocleciano y Constantino*, Oviedo, 2006, pág. 49. En el mismo sentido, GIMÉNEZ BARRIOCANAL, F.: *La actividad económica en el Derecho Romano. Análisis contable*, Dykinson, Madrid, 2003, pág. 43-44, señala la práctica desaparición de la economía monetaria, aunque –con cita de GARNSEY y SALLER, añade que “se produjo todo un proceso de regulación del sector bancario, sociedades, seguros marítimos...”, lo cual parece casar poco con las afirmaciones anteriores. En la misma línea incide TORRENT RUIZ, al sostener que *en mi opinión no puede afirmarse la total desaparición de la actividad financiera en época diocleciana-constantiniana, porque está demostrado que después de todas las reformas monetarias ocurridas desde Aureliano a Constantino, se reservaba un lugar prominente en los espectáculos públicos a las corporaciones de aurarii*. Lo cual, reconoce este autor, es un dato secundario pero relevante. TORRENT RUIZ, A.: *Actividad bancaria e inflación en época diocleciana-constantiniana*, en *IURA: Rivista internazionale di diritto romano e antico*, 2008-09(57) 80-81

2 GOLDSWORTHY, en *La caída del Imperio Romano*, (Trad. Madrid, 2009, p. 190 ss.) se muestra muy cauto a la hora de aceptar la crisis económica del siglo III, aunque reconoce los indicios arqueológicos que la sugieren. Señala la falta de datos y la variabilidad de las zonas. También hace hincapié en que, con todo, la realidad económica era mayor que los siguientes 1.000 años. En el mismo sentido, PETRUCCI, con cita de CARRIÉ, rechaza las posturas más pesimistas, señalando cómo *en la historiografía contemporánea muchos consideran el intervalo entre la entronización de Aureliano (270) y la muerte de Constantino (337) como un período de saneamiento del imperio, tras la crisis de las décadas centrales del siglo III, con el restablecimiento de la situación militar, la reforma de las instituciones y la instauración de un nuevo estilo de gobierno, la ejecución de reformas fiscales y monetarias y un amplio renacimiento de las actividades económicas*. PETRUCCI, A.: *La tutela de los contratantes frente a los empresarios en algunas disposiciones legislativas de Diocleciano (284-305)*, *Revista General de Derecho Romano*, 13(2009), pág. 3.

te, el error que supone generalizar, para todo el Imperio y para todas las épocas, lo que –de modo particular– sugieren los rastros arqueológicos.

Sin entrar a rebatir los argumentos de unos y otros, el presente estudio pretende aportar algún elemento en el debate, partiendo de la hipótesis de que la evolución de la economía tendrá, lógicamente, su reflejo en las constituciones imperiales de la Tetrarquía, y quizás el estudio de las fuentes desde esta perspectiva nos ayude a comprender algún aspecto de las estructuras económicas y financieras de la sociedad romana en los albores del siglo IV. Para ello analizaremos las transacciones económicas reflejadas en algunos rescriptos de la Tetrarquía³, aun asumiendo que la colección de fragmentos que conocemos (a través del Codex de Justiniano y de la Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio) posiblemente no sea la totalidad de los textos imperiales y que la mayor parte de los mismos corresponde a la mitad oriental del Imperio, lo que indudablemente, sesgará nuestro estudio. Pese a todo, la extensa colección legislativa de la cancellería diocleciana (1216 fragmentos) nos puede permitir una aproximación a la situación financiera del imperio en el periodo estudiado, sobre la base de que una mayor litigiosidad sobre determinadas cuestiones es reflejo de una importante actividad en torno a la figura tratada, así como una total ausencia de referencias a ciertos negocios puede ser indicio de desuso. Especialmente trataremos de rebatir, a través del estudio de las fuentes, la afirmación de que –en el Imperio del año 300– llegó a desaparecer totalmente el dinero⁴, acudiéndose, de manera general, al intercambio directo o trueque.

Para analizar la actividad financiera hemos tratado de aislar los fragmentos⁵ que se refieren principalmente al mutuo, aunque también trataremos otros textos que, aun refiriéndose a cuestiones distintas, pueden ser indicadores de la actividad económica y monetaria.

I. LEGISLACIÓN FISCAL

Una de las áreas que pueden arrojar datos sobre la actividad económica es el Derecho fiscal. Aparecen en el Código siete fragmentos dedicados expresamente a la gestión de tributos. Se trata de C.11.55.1 (sin fecha), C.2.17.4 (294), C.4.15.4 (293), C.2.17.3 (293), C.4.46.2 (sin fecha), C.10.1.5 (sin fecha) y C.10.3.4 (290).

³ Señala TORRENT RUIZ, con cita de TOZZI, que hoy además ya no se puede sostener que los juristas romanos no tuvieran una cierta visión económica que subyace en las soluciones aportadas a los problemas jurídicos... TORRENT RUIZ, A.: *Moneda, crédito y Derecho penal monetario en Roma* (S. IV aC- IV dC), *Documenta Historiae et Iuris*, 70 (2007) pág. 112.

⁴ La importancia de la moneda es un tema clásico y recurrente en la historiografía económica. TORRENT RUIZ (*Moneda, crédito...* oc pág. 111) señala las cuatro funciones que cumple el dinero en la economía: 1) *Su tenencia es depósito (y signo) de riqueza*; 2) *Servir de medio de pago*; 3) *Actuar como unidad de cuenta*; 4) *Servir como instrumento de cambio*. También reseña las consecuencias del proceso de desmonetización de la sociedad: a) *Se hace difícil contar con instrumentos fungibles signos de valor*; b) *Los intercambios se limitan a lo indispensable, lo que implica una actividad económica muy restringida*; c) *No se ahorra o se ahorra mucho menos de lo que sería conveniente para mantener una economía productiva que requiera empleo intensivo de capital*.

⁵ La selección de textos y las traducciones que se manejan en el presente trabajo han sido tomadas de DÍAZ BAUTISTA ET ALII: *Conspectus constitutionum Diocletiani*, Dykinson, Madrid, 2013

El primero de ellos⁶, de fecha incierta, establece cierta limitación a la presión fiscal ejercida sobre los campesinos, evitando los abusos de los contadores. Decretan los Tetrarcas que no se exija a la plebe campesina más que los impuestos establecidos para ellos⁷, estando exentos de cualquier otra prestación tributaria.

Los siguientes tres fragmentos –C.2.17.4 (294)⁸, C.4.15.4 (293)⁹ y C.2.17.3 (293)¹⁰– tratan de delimitar la acción fiscal, estableciendo su naturaleza y extensión. Así, el primero determina que la condición de deudor tributario no empece a la responsabilidad que el sujeto tuviera frente a otros acreedores, frente a los cuales podrá oponer, en su caso, las excepciones que procedan en virtud de sus relaciones particulares (*secundum leges uti potes*).

Los siguientes textos están destinados a regular de qué forma puede el Fisco subrogarse en las acciones del deudor. En C.4.15.4 se establece, como norma general, la subsidiariedad de la subrogación del fisco en las acciones del deudor tributario (*nisi patuerit principales reos idoneos non esse*), si bien se permite tal ejercicio indirecto de los créditos del deudor sin necesidad –al parecer– de cesión expresa, en contra de lo que, con carácter general, se establece en C.4.15.5 (294)¹¹, según el cual la cesión de créditos no conlleva, automáticamente, el traspaso de las acciones que lo protegen (aunque ello podía ser salvado con una acción útil).

Finalmente, en C.2.17.3, los Emperadores prohíben taxativamente que se utilice al fisco para reclamar una deuda particular. La terminante redacción del rescripto parece dar a entender que el ejercicio subsidiario de las acciones del contribuyente por parte del Fisco podría haber sido utilizado en interés del deudor, para compeler a sus deudores al pago. De este modo, los Tetrarcas aclaran que la facultad subrogatoria es una prerrogativa de Derecho público, destinada a proteger el interés del Erario, y no un mecanismo del que puedan servirse los particulares en su propio beneficio.

6 C.11.55.1 Diocl. et Maxim. ad Charisium (sin fecha): ne quis ex rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam detulit, annuam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur.

7 Capitatio y annona.

8 C.2.17.4 Diocl. et Maxim. Achilli (294): ad fraudem creditoribus faciendam invidiam fiscalem contra saeculi nostri tranquillitatem implorari non decet. Redde itaque fisco nostro quod debes, ac si conventus velut a creditore fueris, quem tibi numerasse pecuniam negas, exceptione non numeratae pecuniae secundum leges uti potes.

9 C.4.15.4 Diocl. et Maxim. Zosimo (293): non prius ad eos, qui debitoribus fisci nostri sunt obligati, actionem fiscalem extendi oportere, nisi patuerit principales reos idoneos non esse, certissimi iuris es.

10 C.2.17.3 Diocl. et Maxim. Amphioni (293): abhorret saeculo nostro sub praetextu debiti procurationem contra privatos fiscum praestare.

11 C.4.15.5 Diocl. et Maxim. Nanidia (294) in solutum nomine dato non aliter nisi mandatis actionibus ex persona sui debitoris adversus eius debitores creditor experiri potest. Suo autem nomine utili actione recte utetur.

Por su parte, C.4.46.2¹² (sin fecha), C.10.1.5¹³ (sin fecha) y C.10.3.4 (290)¹⁴, están dedicados a la ejecución de los bienes del contribuyente. El primero de ellos declara la afección real de los predios del contribuyente al pago de las deudas tributarias, significando que pueden venderse los predios en caso de necesidad, cuando el comprador obra de buena fe y paga el justo precio, siempre que el deudor cuente con autorización del Presidente (*ex permissu praesidis*), debiendo ser revocada la venta en caso de no contar con dicha autorización.

Una vez incumplida la obligación tributaria, el Fisco puede tomar los bienes del deudor, previa disposición de los Augustos (*quam a nobis forma fuerit data*), como señala C.10.1.5. A partir de dicha autorización imperial, los poseedores de los bienes están obligados a entregarlos a los agentes.

El fragmento C.10.3.4, por su parte, regula la forma de realizar posturas en las subastas fiscales.

II. PRÉSTAMOS DE DINERO

Tomando en cuenta los fragmentos referidos al mutuo (8), incluyendo los que tratan de modo específico la problemática del devengo y cobro de intereses (6 textos) y los referidos a la variante del *foenus nauticum* (4), localizamos en las fuentes un total de 18 fragmentos destinados a la regulación del préstamo de dinero¹⁵. A ellos deben añadirse dos textos –C.4.34.7 (sin fecha) y C.4.34.8 (293)– relativos al depósito irregular, que –como es sabido– es en realidad un mutuo enmascarado de depósito para facilitar el cobro de intereses. Tal número de textos relativos a esta institución, en relación a otras figuras análogas¹⁶ nos permite constatar una discreta actividad crediticia, si bien la proporción con el total de fragmentos conservados (1216) nos indica que el préstamo monetario no era, indudablemente, el motor de la economía en los albores del siglo IV. Por otra parte,

12 C.4.46.2 Diocl. et Maxim. Atinae Plotinae (sin fecha) si deserta praedia ob cessationem collationum vel reliqua tributorum ex permissu praesidis ab his, quibus periculum exactionis tributorum imminet, distracta sincera fide iusto pretio sollemniter comparasti, venditio ob sollemnes praestationes necessitate facta convelli non debet. Sin autem venditio nulla iusta auctoritate praesidis praecedente facta est, hanc ratam haberi iura non concedunt, idque quod frustra gestum est revocari oportet, ita ut indemnitati tributorum omnibus modis consulatur. Quae omnia tractari convenit praesente eo, quem emptorem extitisse proponis.

13 C.10.1.5 Diocl. et Maxim ad Flaccum (sin fecha): Prohibitum est cuiuscumque bona, qui fisco locum fecisse existimabitur capi prius, quam a nobis forma fuerit data. Et ut omni improvisionis genere occursum sit caesarianis, sancimus licere universis quorum interest obicere manus his, qui ad capienda bona alicuius venerint, qui succubuerit legibus, ut, etiamsi oficiales ausi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis privatis resistentibus a facienda iniuria arceantur. Tunc enim is, cuius interest bona alicuius non interpellari, officialibus volentibus ea capere debet adquiescere, cum litteris nostris cognoverit non ex arbitrio suo caesarianos ad capiendas easdem venisse facultates, sed iustitiae vigorem id fieri statuisse.

14 C.10.3.4 Diocl. et Maxim. Marcellinae (290): Si tempora, quae in fiscalibus hastis statuta sunt, patiuntur, cum etiam augmentum te facturam esse profitearis, adi rationalem nostrum, ut iuxta ius pretii uberius oblationem admittat.

15 Ciertamente el mutuo y sus variantes constituyen un préstamo de bienes fungibles, no solamente dinero. Pero como veremos, la regulación diocleciana se refiere, por lo general, al préstamo de dinero.

16 Al comodato se destinan sólo cuatro fragmentos y seis al depósito propio.

el estudio detallado de los rescriptos nos dará a conocer qué particularidades tenía el préstamo de dinero y qué problemas suscitaba a los litigantes.

Todos los fragmentos conservados relativos al mutuo están fechados en los años 293 y 294. El primero de ellos, en orden sistemático, es el recogido en C.4.2.5.1 y nos muestra una de las ideas presentes en toda la legislación diocleciana: la espiritualización de las formas negociales:

C.4.2.5. Diocl. et Maxim. (293) pr. Si non singuli in solidum accepta mutua quantitate vel stipulanti creditori sponte vos obligastis, licet uni numerata sit pecunia, vel intercessionis nomine hanc pro rea suscepistis obligationem, frustra veremini, ne eius pecuniae nomine vos convenire possit, quam alii mutuo dedit, si intra praestitutum tempus rei gestae quaestionem detulistis.

El texto advierte de que no se le puede reclamar por el mutuo a quien no ha sido parte en el préstamo ni ha quedado vinculado como garante¹⁷. La cuestión es, sin duda, que el acreedor pretendía demandar a quien realmente se había beneficiado del préstamo, o había recibido las cosas compradas con el dinero prestado, pretendiendo, probablemente, una suerte de subrogación real de las cosas compradas con el dinero prestado¹⁸ que aparece muy frecuentemente en las consultas dirigidas a Diocleciano y que la cancellería imperial rechaza con firmeza¹⁹. Esta misma cuestión aparece tratada en C.4.2.13²⁰, del año 294, aunque la expresión *non contemplatione domini rerum eam fenori dante*, parece señalar, como excepción, que cierta cualidad (propietario de determinados bienes, o de especial relevancia o solvencia) del destinatario real del dinero (tercero en la relación negocial) pudiera haber sido relevante en la conclusión del acuerdo, en cuyo caso sí estaría legitimado el actor para dirigirse frente a dicho beneficiario.

En cualquier caso, estos textos muestran de una tendencia que aparece con mucha frecuencia en los rescriptos de Diocleciano, y que supone la exigencia de atender a la voluntad interna y real de las partes antes que a la manifestación²¹.

17 Esta idea de inoponibilidad del contrato frente a terceros aparece recogida en numerosas decisiones de los Tetrarcas. Vid. DÍAZ-BAUTISTA CREMADES, A.: La regla *res inter alios acta* en la legislación de Diocleciano sobre contratos reales, en *Estudios sobre Diocleciano*, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 93 ss.

18 Sólo de este modo se entiende la regulación contenida en C.4.2.11 (294), conforme al cual la obligación de restituir el dinero tomado en préstamo no se extingue por el incendio (de las cosas compradas con dicho dinero, se entiende).

19 DÍAZ BAUTISTA, A: Verba contra veritatem en los rescriptos de Diocleciano, en *Estudios sobre Diocleciano*, Cit., pág. 78, señala que la tendencia a identificar el dinero prestado con los objetos adquiridos no sólo es una muestra del naturalismo propio del Derecho postclásico sino también una influencia del Derecho griego, que, como es bien sabido, mantenía que el dinero prestado continuaba perteneciendo al prestamista y que la venta se perfeccionaba solamente por el pago o afianzamiento del precio, transfiriéndose el dominio de la cosa a quien era propietario del dinero pagado.

20 C.4.2.13 Diocl. et Maxim. Frontoni (294) Eum, qui mutuam sumpsit pecuniam, licet in res alienas, creditore non contemplatione domini rerum eam fenori dante, principaliter obligatum obnoxium remanere oportet.

21 Al respecto, DÍAZ BAUTISTA (o.c. pág. 68) manifiesta que se trata de una postura presente ya en Derecho clásico, aunque reconoce que la cuestión es controvertida, *Nos limitaremos a recordar* –sostiene DÍAZ BAUTISTA– *que los contratos enmascarados merecieron una atención considerable por parte de la Cancillería de Diocleciano. Si se tratase de una doctrina postclásica habría que considerarla surgida en un momento muy temprano: justa-*

En el mismo año 293 la Cancillería señala a una tal Pactumeia que, en la relación comercial del mutuo, la procedencia del dinero prestado carece de relevancia; siendo necesario atender, tan sólo, al carácter con que interviene el prestamista.

C.4.2.7 Diocl. et Maxim Pactumeiae (293) Non unde originem pecunia quae mutuo datur habet, sed qui contraxit si propriam numeravit, in huiusmodi obligationibus requiritur.

De la misma manera que, según se señala en C.4.2.14 (293), una persona no queda obligada a la restitución si no recibió realmente el dinero, aunque suscribiera los documentos como mutuuario:

C.4.2.14 Diocl. et Maxim Hadriano (293) Mutuae pecuniae, quam aliis dedit, creditor citra sollemnitatem verborum subscribentem instrumento non habet obligatum.

La vinculación de las partes al negocio (y su carácter relativo) queda patente en la respuesta de los Tetrarcas a Charidemo recogida en C.4.2.15, del año 294:

C.4.2.15 Diocl. et Maxim. Charidemo (294): non adversus te creditores, qui mutuam pecuniam sumpsisti, sed eius, cui hanc credideras, heredes experiri contra iuris evidenter postulas formam.

En el rescripto, la Cancillería rechaza de manera tajante (*contra iuris evidenter postulas*) la posibilidad de que el prestatario, que a su vez prestó el dinero recibido a un tercero, desvíe la acción de su mutuante hacia sus propios deudores.

La *condictio* del mutuante, por tanto, sólo puede dirigirse contra el mutuario, o sus herederos, salvo que se hubiera realizado una novación subjetiva por cambio de deudor, como advierte C.4.10.8 (294)

C.4.10.8 (294) Diocl. et Maxim Crescentioni: Si quidem donationis causa ei, quem adfectione patris te dilexisse proponis, tuam accipere pecuniam permisisti, et hanc tuam liberalitatem remunerans te a procuratore suo aliam pecuniam sumere praecepit, rebusque humanis ante perceptionem fuit exemptus, nec quod dederas recuperare, cum perfectam habuit donationem, nec quod tibi dari mandaverat, necdum tibi traditum petere potes a procuratore. Quod si mutuo dedisti nec a delegato dari novandi causa stipulatus es, successores eius solutioni parere compellentur.

mente en el crepúsculo entre la etapa clásica y la postclásica. Debe advertirse, en todo caso, que los textos analizados en este trabajo hacen prevalecer siempre la voluntad real, salvo que se hubiera establecido una *stipulatio*, en cuyo caso deben atenerse las partes a lo declarado en ella.

Como hemos observado, hasta ahora las cuestiones planteadas a la Cancillería imperial se referían a préstamos de dinero, pese a que, como ya dijimos, el mutuo puede referirse a cualquier cosa fungible, y por tanto, genera la obligación de devolver, no la misma cosa, sino otro tanto de la misma calidad y especie. Parece evidente que, en una sociedad fuertemente monetarizada como la actual, y como sería la Roma clásica, los supuestos de préstamos de bienes fungibles distintos del dinero carecerían de entidad ya que la propia función del dinero (bien de intercambio universal) hace innecesario acudir al intercambio directo de otros bienes. Por ello consideramos interesante al objeto de este estudio analizar, de manera separada, aquellos textos que se refieren a préstamos de consumo sobre especies diferentes del dinero, ya que su presencia en las fuentes puede tomarse como indicio de la disminución monetaria señalada por los autores.

En concreto hacemos referencia a tres textos. El primero, C.4.2.5.1, a cuyo principio ya nos hemos referido *supra*, indica que si se entregó dinero se debe restituir numerario, aunque en el documento se reflejara una entrega de aceite, salvo que la obligación de restitución se recogiera en una estipulación (en cuyo caso debe estarse a la literalidad de lo expresado²²). Quizás hubiera una razón fiscal que explicaría por qué las partes, habiendo prestado dinero, pactaron la restitución en aceite. O tal vez simplemente era esa la voluntad de los contratantes: una especie de compraventa en la que el denominado mutuante entregaba dinero a cambio de una entrega aplazada del objeto adquirido (aceite), y que por alguna razón, se documentó como un mutuo.

C.4.2.5 Diocl. et Maxim. (293) 1. Ac multo magis inanem timorem geritis, si pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vere factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est.

Los otros dos textos (C.4.2.8, de 293; y C.4.32.23, de 294) se refieren a la problemática del devengo de intereses en los préstamos en especie. En estos casos cabían distintas opciones, en el primero de los fragmentos se parte de un acuerdo entre prestamista y prestatario por el que se atribuye a la especie prestada (*argentum vel iumenta vel alias species*) un valor estimado (*consensu aestimatas accepisti*), en cuyo caso los intereses –en dinero– se generaban sobre dicha valoración:

C.4.2.8 Diocl. et Maxim (293): Si pro mutua pecunia, quam a creditore poscebas, argentum vel iumenta vel alias species utriusque consensu aestimatas accepisti, dato auro pignori, licet ultra unam centesimam usuras stipulanti spondesti, tamen sors,

22 Resulta una idea recurrente en la legislación diocleciana el mantenimiento de la voluntad declarada por las partes cuando estaba recogido en una *stipulatio*, acudiéndose a la voluntad interna –por encima de la declarada– en los demás casos. Como ocurre, por ejemplo, en C.4.2.6 (293), en el que se obliga al prestatario a “restituir” la cantidad confesada en la estipulación aunque se haya demostrado haber recibido un importe inferior: *Si ex pretio debitaе quantitatis facta novatione per stipulationem usuras licitas contra quem supplicas stipulatus es, falsa mutuae datae quantitatis demonstratio praemissa, cum obligationis non defecerat substantia, quominus usque ad modum placitum usurae possint exigi, nihil nocet*. Como explica DÍAZ BAUTISTA (*O.c.*, pág. 75), en estos casos la obligación nacida verbis había sustituido a la anterior, surgida re.

quae aestimatione partium placito definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte petitur. Nec quicquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus quod dedisti proponis, quominus huius quantitatis solutioni pareas.

Este fragmento plantea, por otro lado, una cuestión interesante, a propósito de la constitución de una prenda en oro (*dato auro pignori*), en garantía de la restitución de las caballerías o la plata recibidas en préstamo. En el texto, el Emperador rechaza que la deuda del mutuuario se reduzca por el menor valor de la prenda²³.

Cabe también señalar, en relación a este mismo supuesto, que la constitución de una prenda en oro (no acuñado, se entiende) en garantía de un préstamo en especie refleja, para este caso concreto, la desaparición de la moneda como elemento de intercambio, aunque la valoración en dinero que las partes atribuyen a los bienes prestados (así como la referencia a la minusvaloración del oro empeñado) señalan como el dinero continuaba presente, aunque de manera virtual (como elemento de valoración y no de cambio).

En otros casos, como C.4.32.23, el dinero desaparece por completo, por lo que la remuneración del prestamista (ya asumida como algo natural en el mutuo²⁴) se produce incrementando, razonablemente, la cantidad de aceite u otras especies que el prestatario habrá de entregar al mutuante:

C.4.32.23 Diocl. et Maxim. (294): Oleo quidem vel quibuscumque fructibus mutuo datis incerti pretii ratio additamenta usurarum eiusdem materiae suasit admitti.

La regulación de los intereses y la prohibición de la usura motiva un buen número de rescriptos imperiales²⁵ en los cuales se insiste en la prohibición de pactar intereses superiores a la tasa establecida²⁶.

Como sabemos, los intereses meramente pactados no podían ser reclamados junto con el principal en la *condictio*, aunque el acreedor podía retenerlos si se abonaban volunta-

23 Parece obvio, dada la diferenciación del contrato principal con el de garantía, que la disminución del valor de la prenda no pueda afectar al importe de la deuda que deriva del contrato de préstamo. Sin embargo, el hecho de que tal planteamiento sea rechazado quiere decir que, como tal, fue planteado por el solicitante con tal firmeza como para suscitar un rescripto imperial. También hoy día, en medios extrajurídicos (y a veces también forenses) se reclama la reducción de los préstamos hipotecarios por la devaluación de los bienes sobre los que se constituyó hipoteca en garantía de los préstamos.

24 El dinero *debe* producir intereses si se administra de manera adecuada, según declara la Cancillería imperial en C.4.32.24 (294), donde se exige a una madre los intereses devengados por la administración del dinero de su hijo.

25 Como ha señalado SALAZAR REVUELTA (La represión penal de la usura en la República romana y su evolución, *REHJ*, 26(2004) págs. 85-111), con Diocleciano se retoma la sanción penal de la usura, imponiéndose una nota infamante a quien prestare a interés superior al establecido: C.2.11.20 Diocl. et Max. Fortunato: "*Improbum foenus exercentibus et usuris usurarum illicite exigentibus infamiae macula irroganda est*"

26 TORRENT RUIZ (*Moneda, crédito... cit.*, Pág. 127) sostiene que a lo largo del período clásico existió, en la práctica, y pese a los intentos legislativos (lex Genucia yedictos de Lucullo y Cicerón), una franca libertad en el establecimiento de intereses, precisamente hasta la legislación de Diocleciano que permite al deudor recuperar, como indebidas, las cantidades pagadas en concepto de intereses usurarios, lo cual pone el profesor TORRENT en relación con el declive de la banca en este período.

riamente²⁷, por lo que su régimen jurídico se acercaba al de las obligaciones naturales²⁸. Tal regulación se mantiene en la legislación diocleciana, como puede desprenderse de C.4.32.22 (sin fecha):

C.4.32.22 Diocl. et Maxim. Cominio Carino (sin fecha): Pignoribus quidem intervenientibus usurae, quae sine stipulatione peti non poterant, pacto retineri possunt. Verum hoc iure constituto, cum huiusmodi nullo interposito pacto tantum certae summae poenam praestari convenisse proponas, nec peti nec retineri quicquam amplius et ad pignoris solutionem argueri te disciplina iuris perspicis.

La novedad aquí resulta de la traslación del régimen jurídico de los intereses al pignorante que garantizó con un bien propio una deuda ajena, sosteniéndose por la cancellería, que si los intereses no fueron estipulados, no se le pueden reclamar al pignorante, quien puede recuperar su prenda tan pronto como se pagó el principal, lo cual no obsta, advierte el jurista, a la justa retención de los intereses por parte del acreedor, si se pagaron voluntariamente (*pacto retineri possunt*).

En general, la tendencia de la cancellería es equiparar el tratamiento de los garantes del préstamo al deudor principal²⁹, como se señala en C.4.32.20 (sin fecha):

C.4.32.20 Diocl. et Maxim Aelio Nicopolitano (sin fecha): Constitutionibus sacris, quae ultra certum modum usuras fenebris exigi pecuniae prohibent, mandatoribus etiam vel fideiussoribus subventum est: quibus quasi mandator vel fideiussor conventus uti potes.

El *fenus nauticum*

Como sabemos, el *fenus nauticum* o *pecunia traiecticia* era el mecanismo empleado desde época tardorrepública para financiar las operaciones comerciales marítimas. Importado probablemente del Derecho griego³⁰, se considera un antecedente del moderno contrato de seguro al desplazar el riesgo económico de la actividad marítima del armador al prestamista, que sólo podía exigir la restitución del capital prestado en el caso de que el barco llegara felizmente a puerto. La dinámica del contrato, que suponía la asunción de un enorme riesgo por parte del mutuante, hacía necesario el establecimiento de cuantiosos intereses, así como de otras cautelas en favor del prestamista, lo que aleja a esta figura del

²⁷ En cambio el deudor que abonaba intereses indebidos podía obtener su devolución: C.4.32.18 Diocl. et Maxim. Aurelio Castori (sin fecha): *Indebitas usuras, etiam si ante sortem solutae non fuerint ac propterea minuere eam non potuerint, licet post sortem redditam creditori fuerint datae, exclusa iuris varietate repeti posse pensa ratione firmatum est.*

²⁸ D'ORS, A.: *Derecho Privado Romano*, Pamplona, 1989, pág. 448, n. 2

²⁹ Esta tendencia se verá completada por Justiniano en C.7.54.3.3 (531) al extender a los fiadores y garantes, el mismo plazo de espera establecido para los deudores en la ejecución de créditos. Vid. DÍAZ-BAUTISTA CREMADES, A.: *El embargo ejecutivo en el proceso cognitorio romano* (pignus in causa iudicati captum), Madrid, 2013, pág. 79.

³⁰ TORRENT, A.: *Diccionario de Derecho Romano*, v. *fenus nauticum*, Edisofer, Madrid, 2005.

auténtico mutuo³¹. Precisamente, el primer texto diocleciano que analizamos sobre esta figura (C.4.33.2, de 286) incide en la diferente naturaleza y régimen del *nauticum foenus* respecto del *mutuum*, precisamente por el desplazamiento del riesgo al prestamista:

C.4.33.2 (286) Diocl. et Maxim. Scribonio Honorato: Traiecticiam pecuniam, quae periculo creditoris datur, tamdiu liberam esse ab observatione communium usurarum, quamdiu navis ad portum appulerit, manifestum est.

A sensu contrario, el siguiente fragmento (C.4.33.3, también de 286), establece que si se prestó dinero para financiar una operación marítima, sin asumir el prestamista el riesgo, no se trata propiamente de un *foenus nauticum* y no pueden aplicársele sus reglas:

C.4.33.3 (286) Diocl. et Maxim. Cosmianae: cum dicas pecuniam te ea lege dedisse, ut in sacra urbe tibi restitueretur, nec incertum periculum, quod ex navigatione maris metui solet, ad te pertinuisse profiteris, non dubium est pecuniae creditae ultra licitum te usuras exigere non posse.

En el mismo sentido, el fragmento contenido en c.4.33.5 (294), precisa que esta traslación del riesgo de naufragio al prestamista debe pactarse expresamente, para que realmente nos encontremos ante un *foenus nauticum*, pues de otro modo el préstamo de dinero se considerará un mutuo ordinario:

C.4.35.5 (294) Diocl. et Maxim Pullo Iuliano Eucharisto: Traiecticiae quidem pecuniae, quae periculo creditoris mutuo datur, casus, antequam, ad destinatum locum navis perveniat, ad debitorem non pertinet, sine huiusmodi vero conventionem infortunio naufragii non liberabitur.

Igualmente regulan los Tetrarcas, en un rescripto sin fecha ni lugar, destinado a Aurelia Iuliana (C.4.33.4), las consecuencias de que el naviero, que había recibido dinero de un prestamista, desviara el rumbo, cargando mercancías ilícitas, posteriormente decomisadas por el Fisco. Se pregunta la consultante si el prestamista debía asumir las consecuencias económicas del decomiso, contestándosele que no, ya que la pérdida de las mercancías no obedeció a una tempestad, sino a la mala actuación del deudor. Se delimita por tanto, en este rescripto, la responsabilidad del prestamista, que sólo deberá responder cuando la actuación del naviero sea lícita y diligente.

C.4.33.4 (sin fecha) Diocl. et Maxim. Aureliae Iulianae: Cum proponas te nauticum foenus ea condicione dedisse, ut post navigium, quod in africanam dirigi debitor adseverabat, in salonitanorum portum nave delata fenebris pecunia tibi redderetur,

31 TORRENT (*Diccionario.. cit.*) señala además la concurrencia de un derecho de retención (*pignus*) sobre las mercancías en garantía del pago de los intereses (generalmente de un 100% sobre el capital prestado), así como la forma cuasi esencial del contrato (*De hecho, se contraía siempre a través de una stipulatio que contenía siempre las usurae ex pacto*).

ita ut navigii dumtaxat quod in africanam destinabatur periculum suscepis, perque vitium debitoris, nec loco quidem navigii servato, illicitis comparatis mercibus quae navis continebat fiscum occupasse: amissarum mercium detrimentum, quod non ex marinae tempestatis discrimine, sed ex praecipiti avaritia et incivili debitoris audacia accidisse adseveratur, adscribi tibi iuris publici ratio non permittit.

Otros contratos

En las compilaciones aparecen muchos otros fragmentos dedicados a contratos que reflejan transacciones económicas, como puede ser el depósito irregular³², las garantías reales (más de 50 fragmentos dedicados al *pignus*), fianzas³³ ³⁴ y compraventa, que ciertamente pueden constituir negocios financieros y reflejan una discreta actividad comercial y monetaria, pero que no pueden ser analizados en este trabajo por razones de espacio.

III. CONCLUSIONES

Los textos analizados, con las precauciones y advertencias señaladas en el inicio, permiten afirmar sin lugar a dudas que en los albores del siglo IV se realizaban en el Imperio, o en algunas zonas del mismo, complejos y cuantiosos negocios financieros, lo que obliga, a matizar las afirmaciones, excesivamente generalistas, de que en época postclásica desapareció “toda” actividad mercantil e incluso la circulación monetaria³⁵. Probablemente, a la vista de los textos, resulten más ajustadas las cautelosas conclusiones de GOLDSWOTHY, TORRENT y PETRUCCI (*vid. supra* notas 1 y 2), en el sentido de acusar un descenso generalizado del comercio y una creciente crisis económica que afectó –probablemente- de manera desigual a las distintas provincias. A dicha conclusión contribuye el hecho de que aparezcan, con relativa frecuencia, textos que recogen operaciones realizadas en especie, lo que ciertamente resulta sintomático de que, en casos puntuales, podría haberse abandonado el uso de la moneda, pero no parece que tal sea el caso de todo el Imperio sino de lugares o momentos concretos.

³² C.4.34.7 y C.4.34.8

³³ Un estudio pormenorizado de la fianza, y de otras garantías personales, en los rescriptos de Diocleciano, puede encontrarse en DÍAZ BAUTISTA, A.: Las garantías personales en los rescriptos de Diocleciano, *Estudios sobre Diocleciano*, o. c.

³⁴ No encontramos, en cambio, referencia alguna al *receptum argentarii*, lo cual puede tener una doble explicación: o bien, tal como señala Justiniano en C.4.18.2, había caído en desuso la práctica del *receptum*, o bien, como pensamos, la labor depurativa de la comisión codificadora acabó con todo vestigio de la figura aparentemente suprimida por Justiniano; si bien, como señala DÍAZ BAUTISTA, en *Estudios sobre la banca bizantina*, Murcia, 1987, p. 195, el emperador restituyó el negocio de aval bancario mediante la *kazara antifwnesio*, que reguló en el Ed. 9, por lo que –afirma nuestro maestro- *quizás no se pueda llegar a saber jamás si Justiniano declaró al receptum argentarii desusado y obsoleto, obró conforme a la realidad, incurrió en grave error, o, en fin, profirió una burda mentira*.

³⁵ Como sugiere PETRUCCI (*O. c.*) la propia existencia del Edicto de Precios Máximos, del año 301, probablemente incardinada en la reforma monetaria de la Tetrarquía, demuestra la presencia e importancia del flujo monetario en los albores del siglo IV.

ASPECTOS SOBRE LA TUTELA PROCESAL DEL COMODATARIO Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

JAVIER BELDA MERCADO

Universidad de Granada

El enorme interés que suscita la problemática de la responsabilidad contractual para el estudioso del derecho romano está fuera de toda duda. Dentro de esta compleja y relevante cuestión ha ocupado un lugar preferente el estudio de la responsabilidad del comodatario¹,

1 ARANGIO RUIZ, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli 1987 pp. 62 ss.; ARIAS BONET, “La responsabilidad del comodatario en Partidas 5,2,2-4”, *AHDE* 31 (1961) pp.473 ss.; BETTI, *La struttura della obbligazione romana e il problema della sua genesi*, Milano 1955; BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni. II. Struttura dei rapporti di obbligazione*, Milano 1953; CANNATA, *Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano I*, Milano 1966, pp.23 ss.; CARDILLI, *L’obbligazione di praestare e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II.a.C-II d.C)*, Milano 1995; CARRESI, *Il comodato. Il mutuo. Trattato di dir. civ. it. (diretto da F. Vassalli)*, Torino 1857, pp. 10 ss.; CASTRO SÁENZ, “Responsabilidad y duplicidad formularia: los casos del depósito y del comodato en época clásica”, *Actas del Congreso Iberoamericano de Derecho Romano* (Burgos 2001) pp.183-201; CERAMI, “Il comodato”, *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al prof. Murga Gener* (Madrid 1994) pp. 301 ss.; CICOGNA, “Ancora sull’ uso nel comodato” *BIDR* 19 (1907) pp. 235 ss.; DE ROBERTIS, *La disciplina della responsabilità contrattuale nel sistema della Compilazione giustiniana II*, Bari 1966, pp. 321 ss.; DE RUGGIERO, “Contributo alla teoria delle interpolazioni”, *BIDR* 19 (1907) pp. 5 ss.; ID., “*Depositum vel commodatum*”, *BIDR* 19 (1907) pp. 245 ss.; DOMÍNGUEZ LÓPEZ, *La gratuidad y la utilidad como factores determinantes de la responsabilidad del comodatario*, Granada 2001; ID., “La responsabilidad del comodatario en las Partidas”, *Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho romano* (Murcia 1997) pp.281-295 D’ORS, “Observaciones sobre el *Edictum de rebus creditis*”, *SHDI* 19 (1953) pp. 131 ss.; ID., “*Creditum*” y “*Contractus*”, *AHDE* 26 (1956) pp. 183 ss. (=ZSS 74 (1957) pp.73 ss.); ID., “A propósito dell’ *actio commodati*”, *IURA* 34 (1983) pp. 90 ss.; FERRINI, “Storia e teoria del contratto di commodato nel diritto romano”, *AG* 52 (1894) pp.469 ss.; (=AG 53 (1894) pp.41 ss., 257 ss.; *Opera* 3 (Milano 1929) pp. 81 ss.; FUSCO, “*Pecuniam commodare*”, *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C*, Perugia 1980; GARCÍA GARRIDO, “El *furtum usus* del depositario y del comodatario”, *Atti Accademia Romanistica Costantiniana* (1981) pp. 853 ss.; ID., “Realidad y abstracción en los casos jurisprudenciales romanos”. Extractos casuísticos en los supuestos de comodato de caballerías”, *Estudios Iglesias I* (Madrid 1988) pp.249-262; KASER, *Das Römische Privatrecht I*, 2ªed., München 1971, pp. 525 ss., pp. 523 ss.; II, 1975, pp. 371 ss., pp. 406 ss.; LUZZATTO, *Caso fortuito e forza maggiore come limite alla responsabilità contrattuale. I. La responsabilità per custodia*, Milano 1938, pp. 72 ss.; ID., “*Commodati vel contra*”, *Labeo* 2 (1956) pp. 337 ss.; MAGDELAIN, *Le consensualisme dans l’édit du prêteur*, Paris 1958, pp. 93 ss.; MASCHI, *La categoria dei contratti reali*, Milano 1973, pp. 148 ss.; METRO, *L’obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano 1966, pp. 150 ss.; ID., “*Custodiam praestare*”, *Labeo* 13 (1967) pp. 60 ss.; MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962, pp. 95 ss.; PARICIO, “La responsabilidad en el comodato romano a través de la casuística jurisprudencial”, *Estudios en homenaje al profesor Iglesias I* (1988) pp. 459-504; ID., “La primitiva protección procesal del *commodatum*” (A propósito de una reciente monografía de Zannini), *AHDE* 54 (1984) pp. 587

y se explica tan notable interés atendiendo a las noticias que al respecto nos ofrecen las fuentes, muchas veces contradictorias entre sí, y en cualquier caso de difícil interpretación.

Así pues, la responsabilidad contractual del comodatario presenta una riquísima problemática en el estado actual de la investigación romanística. En este sentido, discutidos han sido por la doctrina los criterios establecidos para determinar la responsabilidad del comodatario en las distintas épocas.

Una de las teorías más aceptadas al respecto es la defendida por ARANGIO RUIZ², según la cual el comodatario, en la época clásica, en virtud de lo que nos dice Gayo en sus Instituciones 3,106, respondía por custodia –en sentido técnico–.

Posteriormente, los compiladores postclásicos sustituyeron la original expresión gayana *praestare custodiam* del libro 2^a de las *Res cottidianae* por *exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur*, con lo que el antiguo criterio de responsabilidad viene sustituido por un criterio subjetivo³.

Por tanto, la primitiva figura de responsabilidad del comodatario, en el ámbito de la fórmula *in factum*, es la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por custodia. Pero con la aparición de la fórmula *in ius*, en la que se valora, en el ámbito de la *bona fides*, el comportamiento del deudor, se abre camino la valoración de la *diligentia* como responsabilidad de naturaleza subjetiva.

Así pues, la responsabilidad contractual del comodatario debe ser puesta en relación con la estructura jurídica del comodato. Al respecto, el concepto de responsabilidad contractual en Derecho Romano no responde a una figura dogmática preestablecida, sino que se ha ido formando en el ámbito de varios negocios, en relación a las atribuciones concretas del deudor y a los medios procesales que los sancionaban, especialmente si se consideraba la duplicidad formularia, la cual importaría una doble valoración del negocio: por un lado, en la fórmula *in factum*, se imponía una valoración *stricti iuris*; por otro, en la fórmula *in ius*,

ss.; ID., “Una nota complementaria sobre la pretendida fórmula de buena fe del comodato (Contraposición entre D.13,6,13 pr. y D.12,6,17,5), *Studi Biscardi* 6 (1987) pp. 355 ss.; ID., “La pretendida fórmula “*in ius*” del comodato en el Edicto pretorio”, *RIDA* 29 (1982) pp. 235 ss.; PASTORI, *Il commodato nel diritto romano. Contributo allo studio della responsabilità contrattuale*, Milano 1954; ID., “Comodato” (dir. romano), *NNDI* 3 (1959) pp. 688 ss.; ID., “Sulla duplicità formulare dell’*actio commodati*”, *Labeo* 2 (1956) pp. 89 ss.; ID., *Comodato, contratto, responsabilità*, Milano 1981 (reimp. 1986); ID., “Comodato e furto: spunti d’interpretazione dialettica”, *Labeo* 19 (1973) pp. 161 ss.; SCHERILLO, “Comodato” (dir. romano), *ED* 7 (1960) pp. 981 ss.; SCHMIDT, *Das commodatum und precarium. Eine Revision der Grundlehren beider*, Leipzig 1841 (reimp.1852); SEGRÈ, “Sull’età dei giudizi di buona fede di commodato e pegno” *Studi Fadda* 6 (Napoli 1906) pp.331 ss.; (= *Scritti Torino* (1952) pp. 61 ss.); SOLAZZI, “La responsabilità del commodatario nelle Istituzioni di Gaio”, *IURA* 6 (1955) pp.139 ss.; STOCK, *Zum Begriff der donatio insbesondere im Verhältnis zum commodatum*, Leipzig 1932; VOCI, “*Diligentia*”, “*Custodia*”, “*culpa*”: i dati fondamentali”, *SHDI* 56 (1990) pp. 65 ss., 104 ss.; ID., *La dottrina romana del contratto*, Milano 1946; ID., *The Law of Obligations in the later Roman Republic*, Oxford 1965, pp.167 ss.; WUBBE, “I contratti reali alla fine della repubblica”, *Contractus e Pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tardo-repubblicana*, *Atti Convent. Copanello* 1987 (Napoli 1990) pp. 109 ss.; ZANNINI, *Spunti critici per una storia del commodatum*, Milano 1983; VARELA, “La sistematización de la responsabilidad del comodatario en las leyes de Partidas”, *Actas del IV Congreso Internacional y VII Congreso Iberoamericano de Derecho romano* (Burgos 2001) pp.895-907.

² ARANGIO RUIZ, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli 1987, pp. 62 ss.; CASTRO SAENZ, “Responsabilidad y duplicidad formularia: los casos del depósito y del comodato en época clásica”, *Actas del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano* (Burgos 2001) pp.183-201.

³ PASTORI, “Comodato”, *NNDI* 3 (1959) pp. 688 ss..

una valoración al amparo de la *bona fides*; al dar lugar a un *iudicium bonae fidei... quidquid dare facere oportet ex fide bona*, permitía al juez valorar más ampliamente la relación⁴, valorando todas las circunstancias que rodearon el incumplimiento en el caso concreto, y fijar, atendiendo al criterio de la buena fe contractual, el importe exacto de la condena.

Ello es evidente particularmente en el comodato, en donde la primera valoración hecha por el ordenamiento fue de naturaleza procesal, o sea, la tutela acordaba a la figura del pretor mediante la fórmula *in factum*. Tal fórmula, de origen procesal, referidos a casos concretos de préstamo de uso gratuito, no presuponía un concepto abstracto de responsabilidad, sino que ello derivaba de la estructura de dicha fórmula. La responsabilidad objetiva del comodatario respecto a la restitución de la cosa se explica relacionándolo con la fórmula *in factum* del comodato, ya que planteaba como presupuesto de la *condemnatio* la circunstancia de la falta de restitución del comodatario, y prescindía de considerar el elemento intencional del deudor.

Así, vemos que en la fórmula *commodati in factum conceptae*, al contemplarse la hipótesis de *non redere rem*⁵, sólo se sancionaba la no restitución de la cosa, quedando fuera otras obligaciones del comodatario, como las de no deteriorar la cosa o no abusar de la misma, las cuales habrían quedado comprendidas en el ámbito de la fórmula *commodati in ius concepta*.

Se aprecia una conexión entre fórmula *in factum* -obligación de restitución- responsabilidad objetiva por custodia, de un lado, y fórmula *in ius* -obligación de no usar y de no deteriorar la cosa-, responsabilidad subjetiva por culpa, de otro⁶.

Tales fórmulas habrían determinado diversos criterios en la valoración de responsabilidad contractual del comodatario. A la responsabilidad objetiva sancionada por la fórmula *in factum* se contraponen una responsabilidad más acorde con los criterios de la *bona fides* en la fórmula *in ius*, abriéndose paso a través de aquella el concepto de responsabilidad culposa.

En cuanto al encuadramiento dogmático del comodato, la jurisprudencia clásica llega sólo a fijar el concepto de *credere*: el concepto de contrato real, que aparece en G.2.90, donde, a propósito del mutuo, se habla de *re contrahere obligationem*, y la formación de la categoría de los contratos reales, se afirma sólo en época postclásica, una vez desarrollados los conceptos clásicos.

En la relación jurídica del comodato⁷, sustentada en la entrega de la cosa, es el comodatario el deudor de la relación obligatoria, aquél que asume la obligación prioritaria de devolverla transcurrido el plazo convenido, y la obligación derivada de custodia, así como el que responde por el incumplimiento, derivado de la no devolución, en sentido estricto, de la devolución con retraso o de la devolución de la cosa en mal estado.

4 MASCHI, La categoria dei contratti reali cit., p.231; TARDIVO, "Studi sul commodatum" cit., p.247; CERAMI, Il comodato cit., p.311.

5 Vid. Gai 4.47.

6 ARANGIO RUIZ, Responsabilità contrattuale in diritto romano cit., pp. 62 ss.; LUZZATTO, Caso fortuito e forza maggiore cit., pp. 62 ss..

7 Antes de ser reconocido el comodato como una figura propiamente contractual, constituía una relación de hecho, básicamente, como prueba del consentimiento.

La *actio commodati in factum*, que tutela en época clásica el comodato, se estructura en función del modelo de la *condictio*, y tiene como ésta una función recuperatoria.

Es la jurisprudencia la que limitará tal responsabilidad exceptuando el caso de fuerza mayor, obedeciendo ello a la aplicación del principio de la buena fe, generalizado en el ordenamiento romano a partir del s.III a.C. de modo progresivo, y que domina toda la actuación del pretor.

No apreciamos una neta distinción entre el derecho clásico y postclásico y justiniano en tema de responsabilidad contractual en el comodato, sino sólo un desarrollo lógico u gradual. Por tanto, la responsabilidad en el comodato sigue desde el derecho clásico al justiniano una línea lógica de evolución: junto a la primitiva custodia, se da entrada en el derecho clásico a la responsabilidad culposa.

Así pues, presenta un interés relevante la evolución histórica de la responsabilidad del comodatario en las distintas épocas: en el derecho clásico, en el postclásico y en el justiniano.

La valoración de la responsabilidad en el ámbito de la *bona fides* supondría una conexión entre la responsabilidad objetiva por custodia, reflejo de la fórmula *in factum*, y las figuras de responsabilidad típicas del derecho postclásico o justiniano. La responsabilidad por culpa o por diligencia podrían representar la definición formal de criterios de valoración implícitos en la *bona fides*.

Esta se afirma a través de una interpretación del *factum debitoris* en el ámbito de la *bona fides*, la cual recoge el criterio empírico de la *diligentia*. Así, el derecho postclásico fija las figuras de la responsabilidad por *diligentia* y por *culpa*, los cuales en el derecho clásico habían cristalizado en la realidad jurídica, sin todavía obtener una explícita enunciación dogmática.

Justiniano construye después una teoría, en la cual la responsabilidad *per diligentia*, que se plantea como fundamento de la responsabilidad contractual, se distingue en varias figuras correspondientes a diversos grados de intensidad.

La responsabilidad del comodatario en el derecho justiniano se reduce a la culpa⁸: habría que advertir que el parámetro de la culpa no es la *diligentia* del *bonus paterfamilias*, sino una *exacta (exactissima) diligentia custodiendae rei* –I.3,14,2, D.44.7,1,4 (*Gaius*, lib. II *Aureorum*)–, o bien una *diligentia diligentissimi patris familias* –D.13,6,18 pr. (*Gaius*, lib. IX *ad Edictum provinciale*)–, la cual encontraría sólo el límite del caso fortuito y de la fuerza mayor.

Su responsabilidad llega generalmente no sólo hasta la *culpa leve*, sino a aquella modalidad esencial de *custodiam praestare*, que le hace responsable del hurto de la cosa por un tercero. El verdadero caso fortuito se excluye, salvo que no haya destinado la cosa a usos no pactados. En casos excepcionales, en los que hay en el contrato un interés evidente para el comodante, la responsabilidad del comodatario queda limitada excepcionalmente al dolo.

8 La compilación justiniana presenta varios criterios mediante los cuales se considera la responsabilidad del comodatario; en el sistema del derecho justiniano, deben ser interpretados presuponiendo el concepto de *diligentia exactissima in custodiendo*, criterio general introducido por los compiladores.

En época clásica⁹ responde por custodia¹⁰, que comprende el hurto de la cosa dada en comodato¹¹. En época justiniana desaparece el concepto originario de custodia, reconduciéndolo al ámbito de la culpa, pero se busca someter al comodatario a una responsabilidad mayor que la de la *culpa levis*, o de la *culpa in concreto*: se afirma que está obligado a la observancia de una *exacta diligentia custodiendae rei*-, precisando en un pasaje interpolado (D.13,6,18 pr.) que *talis diligentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus pater familias suis rebus adhibet*, lo que supone la exigencia de un cuidado tan extremo que no todos los obligados observarían. Del mismo modo, son interpolados varios pasajes clásicos; en las Instituciones justinianas (4,1,16) al citar el pasaje de Gayo, se advierte: *sed nostra providentia etiam hoc in decisionibus nostris emendavit*, añadiendo que en caso de robo de la cosa prestada, su propietario puede actuar directamente contra el ladrón con la *actio furti*, o bien contra el comodatario con la *actio commodati*; de esto se deduce que los bizantinos no seguían ya la idea de que el comodatario estaba obligado a realizar una actividad positiva para preservar la cosa prestada de actuaciones de terceros.

Los compiladores, al fijar la responsabilidad del comodatario en el ámbito de la culpa, no se limitan al grado de la *culpa levis* o *culpa in concreto*, sino que al exigirle una *exacta diligentia custodiendae rei*, a veces se obliga el comodatario –en la conservación de la cosa prestada– a un cuidado superior al que observa en sus propias cosas, de tal manera que se hace responsable siempre que otro más diligente hubiera podido conservarla –I.3,1,4,2– –*si modo alius diligentior poterit aem rem custodire*–.

No obstante, si la cosa ha sido dada en interés exclusivo del comodante, la responsabilidad queda limitada al dolo, –D.13,6,5,2 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*) y si es en interés común, a la *culpa in concreto* –D.13,6,18 (*Gaius*, lib. XVIII *ad Edictum provinciale*)

En el derecho clásico es responsable por dolo y culpa; las fuentes afirman que debe también *praestare custodiam*¹². Este debe entenderse en el sentido de que está obligado a

9 Se trata de examinar la posición del derecho postclásico respecto al derecho clásico: no existen históricamente soluciones de continuidad entre la responsabilidad por *diligentia* típica de la primera, y la responsabilidad por custodia, típica de la segunda.

A tal propósito se debe considerar el alcance de la responsabilidad por custodia en el derecho clásico y su ámbito de aplicación, para ver si en ella o junto a ella se habrían podido desarrollar concepciones que justificasen su evolución postclásica.

10 La responsabilidad por custodia encontró su típica aplicación en el ámbito de la fórmula *in factum*, en orden a la obligación de restitución, mientras la fórmula *in ius*, con la mención de la *bona fides*, no es idónea en principio para sancionar una responsabilidad objetiva, pero en su ámbito, a través del comportamiento del comodatario en el cumplimiento de sus obligaciones, se crean las premisas de aquella responsabilidad subjetiva, la cual encontrará en el derecho justiniano su definición formal.

11 La responsabilidad por custodia es una responsabilidad típica del comodatario, que abarca el hurto de la cosa. Esto quiere decir que el comodatario responderá por el hurto de la cosa, aun cuando haya puesto la diligencia máxima en el cuidado de la misma, precisamente porque se trata de una responsabilidad objetiva, absolutamente independiente de la voluntad del comodatario.

12 La jurisprudencia va elaborando paulatinamente el concepto de custodia, y perfilándolo en el sentido de entender que consiste en una responsabilidad no sólo por hurto, sino también por pérdida de la cosa, que no se deba a un acontecimiento imprevisible, lo que se llama *vis maior*: un terremoto, un incendio, un naufragio etc... Responde también igualmente ante el comodante si la cosa perece por un caso fortuito, como un incendio, un naufragio, cuando teniendo la posibilidad de realizar actos convenientes para salvarla, los haya omitido; Paul. Sententiae 2, 4,2-3: *Si factio incendio ruina naufragio aut quo alio simili casu res commodata amissa sit, non tenebitur eo*

observar aquellas normas de prudencia y de conducta que son propias de un hombre normal, y además, a realizar la actividad necesaria para que se cumpla el objeto de las obligaciones que ha asumido, es decir, que la cosa sea preservada de la destrucción y del deterioro, y sea restituida al comodante al término del contrato.

La obligación de *praestare custodiam* que incumbe al comodatario aparece clara por la afirmación explícita de Gayo 3,206, confirmada por *Pauli Sent.* 2,4,2-3, que sostiene que varios textos del Digesto, entre ellos algunos tomados de los *Libri Rerum Cottidianarum* de Gayo, que no mencionan el *custodiam praestare*, estarían interpolados.

Precisamente, el punto de partida para la reconstrucción de la responsabilidad del comodatario lo constituye la regla enunciada en Gayo 3,206:

Quae de fullone aut sarcinatore diximus eadem transferemus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam praestare.

El pasaje contendría la norma según la cual el comodatario estaría legitimado activamente a la *actio furti*, ya que debe *custodiam praestare*: es responsable frente al comodante de la falta de restitución de la cosa objeto de comodato.

La cuestión que ocupa al jurista en estos fragmentos es la legitimación para ejercer la *actio furti*¹³, más que al problema de la responsabilidad contractual en sí. Por la misma razón que el comodatario responde por custodia, la acción de hurto le corresponde a él, es decir, estará activamente legitimado para entablar dicha acción penal y no el dueño, ya que la víctima del hurto ha sido el comodatario, que se verá obligado a pagar su valor si no devuelve la misma cosa que le han prestado. El dueño, por su parte, ya tiene la acción de comodato -*actio commodati*- para exigir que le restituyan el valor de la cosa que ha sido hurtada, y que él había prestado para que el comodatario usara de ella.

El comodatario es considerado responsable, independientemente de las circunstancias en las que el hurto sea cometido. No existe duda, por tanto, que el derecho clásico habría reconocido en el comodatario una responsabilidad de naturaleza objetiva denominada custodia.

Así, si la cosa es robada, responde ante el comodante, y puede él mismo actuar contra el ladrón con la *actio furti*, precisamente porque él estaba obligado a llevar a cabo las actividades necesarias para que la cosa no fuese robada.

En el fragmento en examen, el jurista precisa también el nombre y fundamento de la responsabilidad que grava a los citados deudores, haciéndoles responder por el robo de la cosa: igual que el *fullo* y el *sarcinator*, al recibir una retribución, deben responder por custodia (...*nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant...*, el comodatario, en cuanto recibe

nomine is cui commodata est, nisi forte, cum posset rem commodatum salvam facere, suam praetulit. Servus vel equus a latronibus vel in bello occisi, si in aliam causam commodati sunt, actio commodati datur; custodia enim et diligentia rei commodatae praestanda est. El término *diligentia* al lado de custodia es interpretado por los autores de diferentes maneras. Por eso, responder por custodia significa responder por la pérdida de una cosa específica que no se deba a fuerza mayor.

13 A la legitimación para ejercer la *actio furti* del comodatario se refiere también otro fragmento de los comentarios de Ulpiano *ad Sabinum*: D.47,2,14,10 (*Ulpianus*, lib. XXIX *ad Sabinum*).

el uso gratuito de una cosa, debe responder también por custodia (...*ita hic quoque utendi commodum percipiendo similiter necesse habet habet custodiam praestare*). En suma, el recurso a la *utilitas contrahentium* se impone de manera lógica en el discurso de Gayo.

El comodatario, al igual que el *fullo* y el *sancinator*, responden por custodia porque el negocio les beneficia a ellos, deduciéndose tal ventaja o provecho, respectivamente, de la *merces* o contraprestación recibida, y del uso gratuito que se hace del uso de la cosa ajena.

Por su parte, D.13,6,5 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*) constituye un texto fundamental en el tratamiento de la responsabilidad contractual del comodato. Examina, caso por caso, si el comodatario respondería o no de custodia. Ulpiano, acerca de la responsabilidad del comodatario, no podría pensar sólo en la responsabilidad por custodia, de donde se obtienen los distintos supuestos de comodato, extraídos del título del Digesto XIII, 6, *Commodati vel contra*, estableciendo la responsabilidad en época de Justiniano.

En un conocidísimo y al mismo tiempo controvertido pasaje ulpiano, extraído del libro 28 *ad Edictum*, el problema de responsabilidad del comodatario se plantea en el contexto de un *excursus* de carácter general sobre los criterios y los límites de responsabilidad contractual¹⁴:

D.13,6,5,2-3 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*):

Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, utrum dolus an et culpa an vero et omne periculum. Et quidem in contractibus interdum dolum solum, interdum et culpam praestamus: dolum in deposito: nam quia utilitas eius versatur apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus.. Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praestatur. Commodatum autem plerumque solam utilitatem continet eius cui commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententiae existimantis et culpam praestandam et diligentiam et, si forte res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo, qui aestimationem se praestaturum recepit.

Las figuras de responsabilidad introducidas por Ulpiano eran sobre todo la custodia, sustituidas en el texto de la Compilación por la culpa y la *diligentia*, y también en casos excepcionales, *omne periculum*.

Los compiladores tienden después a sostener la custodia con el fin de superar la regla clásica, la cual contrasta con el nuevo régimen, según el cual, la responsabilidad del comodatario estaría encuadrada en los límites de la *diligentia*. Atendiendo a D.13,6,5, el texto debía constituir con toda seguridad la parte introductoria del comentario ulpiano a la fórmula de la *actio commodati in ius concepta*.

Ulpiano atiende a un encuadramiento sistemático del fundamento, de los criterios y de los límites de responsabilidad en los diversos contratos, y concretamente, en el *commodatum*. En el párrafo segundo, el jurista individualiza dos criterios de imputación de la responsabilidad, sobre la base de la específica articulación de la *utilitas contrahentium*.

14 Cf. D.13,6,5,6 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*), como supuesto de responsabilidad por custodia en el caso de comodato de esclavos.

En el párrafo tercero, Ulpiano analizaba la responsabilidad contractual con especial referencia a la *actio commodati*. El pasaje es significativo bajo distintos aspectos:

- a) atestigua el papel fundamental desarrollado por la *actio commodati* en la reflexión jurisprudencial sobre la responsabilidad contractual;
- b) porque al mencionar a *Quintus Mucius Scaevola*, prueba que las líneas esenciales de la responsabilidad del comodatario habían sido trazadas ya antes de la concesión de la *actio in ius*;
- c) que la responsabilidad del comodatario había sido siempre relacionada con criterios subjetivos de imputación: dolo, culpa, asunción del riesgo..

Al fundamento de la responsabilidad del comodatario se refiere la expresión *commodatum autem plerumque solam utilitatem continet eius cui commodatur*¹⁵.

La frase *et culpam praestandam et diligentiam et, si forte res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo*, denota los criterios de imputación de la responsabilidad del comodatario.

Específicamente, la expresión *et culpam praestandam et diligentiam* significa que el comodatario, en la mayoría de las ocasiones, no responde tan sólo de dolo, como sucede en los pocos casos en los que el comodato se constituya *causa commodantis*, (D.13,6,10) sino también por culpa, que, lejos de circunscribirse al dolo, se extiende, en sentido propio, a la omisión de diligencia. En ausencia de culpa, el comodatario no responde, a menos que no haya asumido convencionalmente *omne periculum*, como en la hipótesis de *res aestimata*.

Los datos aportados por Ulpiano en D.13,6,5,3 en orden al pensamiento de *Q. Mucius Scaevola* pueden ser integrados y confrontados con algunos pasajes de las *lectionum libri ad Quintum Mucium* de Pomponio:

D.13,6,23 (Pomp. lib. XXI ad Quintum Mucium): Si commodavero tibi equum, quo uteris usque ad certum locum, si nulla culpa tua interveniente in ipso itinere deterior equus factus sit, non teneri commodati; nam ego in culpa ero, qui in tam longum iter commodavi, qui eum laborem sustinere non potuit, donde se hace alusión a la culpa del comodante (nam ego in culpa ero.... non potuit), confirmando el papel fundamental que aún en su época jugaba el criterio a la hora de atribuir al comodatario responsabilidad por daños a la cosa prestada.

D.13,1,16 (Pomponius, lib. XXXVIII ad Quintum Mucium):

Qui furtum admittit vel re commodata, vel deposita utendo, conditione quoque ex furtiva causa obstringitur. Quae differt ab actione commodati hoc, quod, etiamsi sine

¹⁵ Se consideraría interpolado el *plerumque*, sobre el hecho que en el derecho clásico el préstamo de uso habría sido constituido siempre en ventaja exclusiva del comodatario, y tendía a subrayar que el préstamo de uso era constituido en ventaja del comodatario tan sólo en la mayoría de los casos, pero no siempre necesariamente (precisamente, Ulpiano, en el párrafo 10 del mismo D.13,6,5, nos trae hipótesis de comodato realizado *causa commodantis*).

dolo malo et culpa eius interierit res, conditione tamen tenetur, quum in commodati actione non facile ultra culpam, et in depositi non ultra dolum malum teneatur is, cum quo depositi agetur.

D.47,2,76 (*Pomponius*, lib. XXXVIII *ad Quintum Mucium*).

Qui re sibi commodata vel apud se deposita usus est deposita usus est aliter, atque accepit, si existimavit, se non invito domino id facere, furti non tenetur; sed nec depositi ullo modo tenebitur. Commodati an teneatur, in culpa aestimatio erit, id est, an non debuerit existimare, id dominum permissurum.

Pomponio contempló aquí concretamente como hecho suficiente para que pudiera ejercitarse la *actio commodati contraria* frente al comodante, en caso de *usus contrarius*, el hecho de haber obrado este con culpa.

En estos fragmentos extraídos del lib. XXXVIII, es de observar que la configuración del *usus contrarius* como hipótesis de *furtum* era un tema expresamente afrontado por *Quintus Mucius* en sus *Libri iuris civilis*, como atestigua *Gellio* en sus *Nottes Atticae*, 6,15,2:

Itaque Q.Scaevola in librorum, quos de iure civili composuit, XVI verba haec posuit: Quod cui servandum datum est, si id usus est, sive, quod utendum accipit, ad aliam rem, atque accipit, usus est, furti se obligavit.

La diferencia entre la citación gelliana y la *actio pomponiana* es del todo evidente: en el primer caso, el discurso muciano se ciñe a la *actio furti*; en el segundo se extiende a la *actio commodati*. De ahí se ha podido deducir que la extensión de la *actio commodati* sea obra de Pomponio.

Las precedentes lecciones pomponianas vienen a aportarnos fielmente la esencia del pensamiento muciano, que resulta del todo coherente con los datos aportados por Ulpiano en D.13,6,5,3. En particular, los dos pasajes prueban que:

- a) el comodatario, en caso diverso de aquél pactado, era obligado con la *actio commodati*, sólo si el uso diverso de la cosa le fuese imputable a título de culpa;
- b) a continuación del hurto, si pereciese la cosa sin culpa del comodatario, éste último sería llamado a responder con la *condictio furtiva*, pero no con la *actio commodati*.

Con Quinto Mucio, las directrices fundamentales de la responsabilidad contractual del comodatario resultan definitivamente trazadas, e incluso el posterior desarrollo jurisprudencial tiene en cuenta las bases mucianas.

En torno a D.13,6,5,5, el comentario ulpiano prueba que la locución *custodiam praestare* no alude de hecho a una forma de responsabilidad objetiva, sino a una responsabilidad subjetiva (culpa) derivada de la falta de observancia de la obligación de *diligentia*.

Por último, el comentario ulpiano muestra claramente que en la perspectiva de los juristas romanos venían valorados en términos de culpa también la hipótesis de *casus* o

vis maior (D.13,6,5,4 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*); D.13,6,18 pr. (*Gaius*, lib. IX *ad Edictum provinciale*); *Pauli Sententiae* 2,4,1-2), en el sentido que se considera responsable el comodatario que *cum possit res commodatas salvas facere, suas praetulit*¹⁶.

Resulta confirmado que Ulpiano, partiendo precisamente de la *formula in ius concepta*, desarrolla el tema de la responsabilidad contractual del comodatario sobre la base de las líneas ya trazadas antes por *Quintus Mucius* en relación a la *actio in factum*. De ello deriva que a la duplicidad formularia de la *actio commodati* no correspondía de hecho una naturaleza diferente de la responsabilidad del comodatario: objetiva (*per custodia*) en la fórmula *in factum*; subjetiva, en la fórmula *in ius*.

La diferencia de las dos fórmulas atendían esencialmente a la diversidad de los poderes atribuidos al juez, pero no se reflejaba sobre criterios de imputación de la responsabilidad, sino de modo indirecto, con referencia a la validez o no de la cláusula *minuendae vel augendae obligationis causa*.

Cohherentemente con los principios de la buena fe, la jurisprudencia excluye, *in commodato*, la validez del pacto *ne dolus praestetur* (D.13,6,17 pr.) sobre la base de una línea interpretativa trazada por Celso (D.50,17,23), jurista al cual pertenece, probablemente, la propuesta de la fórmula *commodati in ius concepta bonae fidei*.

Precisamente, la jurisprudencia clásica, desde tiempos de Gayo, otorga al criterio de la utilidad un papel decisivo para delimitar la responsabilidad de los deudores de contratos que benefician a una sólo de las partes, como es el caso del comodato o del depósito¹⁷.

Así, mientras el depósito ve limitada su responsabilidad al dolo, por no obtener ventaja de alguna relación, al comodatario se le atribuye un grado muy elevado de responsabilidad, como es la custodia, y se justifica *expressis verbis* por la ventaja que en exclusiva obtiene del contrato.

Se trata en ambos casos de contratos gratuitos cuyos deudores detentan una cosa ajena, y sin embargo, mientras al comodatario se le impone un grado de responsabilidad muy elevado, como es la custodia, el depositario responde única y exclusivamente por dolo, justificándose tal diversidad de tratamiento por la ausencia de ventaja o beneficio del depositario frente al comodatario, único beneficiado con tal relación.

Gayo se cuestiona la posible atenuación de la responsabilidad del comodatario en caso de mediar también provecho del comodante, constituyendo una novedad en el planteamiento de dichos criterios, aunque deja sin resolver el problema de la responsabilidad del comodatario en caso de beneficiarse junto con el comodante de la relación.

La primera referencia directa a la *utilitas* como factor determinante de la responsabilidad del comodatario la encontramos en un texto de la Instituciones de Gayo 3,206.

¹⁶ D.13,6,5,4 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*).

¹⁷ La *utilitas* es un criterio que se utiliza que se recurre con frecuencia en las fuentes romanas para justificar el grado de responsabilidad exigido a los deudores en algunas relaciones. Parece indudable que la *utilitas contractuum* encontró una aplicación preferente en los contratos gratuitos, en particular en el comodato y en el depósito, constituyendo un criterio prevalente para atribuir la responsabilidad a los respectivos deudores.

También lo podemos ver en algunos textos de Africano¹⁸, donde se aprecia el papel fundamental que tendrá la regla de la *utilitas* en las decisiones jurisprudenciales relativas a la responsabilidad, como aquel extraído del lib. VIII *Quaestionum* de Africano¹⁹.

Circa commodatum autem merito aliud existimandum, videlicet eius solius commodum, qui utendum rogaverit, versetur; itaque eum, qui commodaverit, sicut in locatione, si dolo quid fecerit, non ultra pretium servi quid amissurum, quin etiam paulo remissius circa interpretationem doli mali debere non versari, quoniam, ut dictum sit, nulla utilitas commodantis interveniat, en cuanto a la responsabilidad del comodante por el daño causado al comodatario, donde debe procederse con más indulgencia de la normal a la hora de apreciar el eventual lucro del acreedor. Ello es así porque el comodatario se beneficia de manera exclusiva del contrato, siendo por ello justo que se limite la responsabilidad del acreedor, permitiéndole siempre la entrega del esclavo al comodatario, salvo que ni al valorar su comportamiento sea posible excluir el dolo²⁰.

Así como en diversos textos de Ulpianus, como D.19,5,17,2 (Ulpianus, lib. 28 ad Edictum):... si cui inspiciendum dedi sive ipsius causa, sive utriusque, et dolum, et culpam mihi praestandam esse dico propter utilitatem, periculum non....²¹, donde la responsabilidad de estos deudores viene determinada por el criterio de la utilidad²², de forma que sufre variaciones según cuál de las dos partes contratantes, deudor o acreedor, obtenga beneficio de la relación.

La aplicación del criterio de la *utilitas contrahentium* es un claro indicio de que a la jurisprudencia de aquel tiempo no escapaba la importancia y alcance del criterio, y comenzaba ya a plantearse su efectividad en el ámbito de la responsabilidad.

En cuanto al esquema de los distintos grados de responsabilidad fundados sobre el criterio de la *utilitas contrahentium*, es generalmente afirmado que este criterio se refiera a los *bonae fidei iudicia*, ya que entre estas relaciones encontramos mencionadas tanto el comodato como la prenda. Como *iudicia bonae fidei*, se habría puesto en relación la responsabilidad del comodatario según hubiese recibido la cosa en su propio interés, o también en interés del comodante.

Así, si el comodato reporta sólo beneficio para el deudor -comodatario-, responde por custodia; si beneficia sólo al acreedor -comodante-, responderá sólo por dolo²³; y finalmente, en caso de mediar utilidad para ambas partes del negocio, la responsabilidad del comodatario es por culpa²⁴.

18 Cf. D.47,2,62,5 (Africanus, lib. VIII *Quaestionum*).

19 D.47,2,62,6 (Africanus, lib. VIII *Quaestionum*);

20 MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962, pp. 336 ss.; NÖRR, "Die Entwicklung des Utilitätsgedankens im römischen Haftungsrecht", ZSS 73 (1965) pp. 68-119.

21 Vid. también D.13,6,10,1 (Ulpianus, lib. XXIX *ad Sabinum*).

22 La *utilitas contrahentium*, más que un criterio a tener en cuenta, según los casos, era una regla o principio de aplicación general en el ámbito de la responsabilidad contractual.

23 La responsabilidad del comodatario era limitada al dolo, cuando el contrato no se celebrase en su exclusivo interés: principio comprensible de cara a G.3,206, en el cual la custodia se justifica por el *utendum commodum percipiendo*; Gayo 3,206 justifica la responsabilidad por custodia del comodatario con el hecho de que él obtiene exclusiva ventaja del negocio.

24 Por tanto, se establece una clasificación tripartición de los contratos en función de la regla de la utilidad, distinguiéndose entre contratos celebrados en interés del acreedor (como el depósito), de ambas partes (así, la com-

Correlativamente, se atribuye a los deudores de estas categorías contractuales un diverso grado de responsabilidad:

- a) mínimo para los del primer grupo, como es el dolo;
- b) un grado de responsabilidad algo superior para los del segundo, como es la culpa.
- c) por fin, un grado muy elevado de responsabilidad para los deudores del tercer grupo (*culpa y diligentia*). La jurisprudencia en época de Gayo no se muestra unánime al respecto, y parece que ya en época de Ulpiano, la cuestión ha quedado resuelta, en el sentido de atribuir al comodatario un idéntico grado de responsabilidad en caso de obtener ventaja de la relación, ya sea de manera exclusiva, ya sea junto al comodante.

No puede descartarse que Gayo, en D.13,6,18 (*Gaius*, lib. IX *ad Edictum provinciale*), hubiera avanzado la solución que ahora Ulpiano reconoce como definitiva –D.19,5,17,2 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*), pero es posible que aquel jurista se hubiera inclinado hacia un criterio menos elevado de responsabilidad, como es la culpa. En todo caso, la jurisprudencia posterior, ya posiblemente en tiempos de Ulpiano, va a tener en cuenta más que nada el provecho que el comodatario obtiene de la relación, considerando en este sentido un motivo insuficiente para disminuir su responsabilidad el hecho de que también el comodante pueda verse beneficiado de la misma.

D.13,6,10,1 (*Ulpianus*, lib. XIX *ad Sabinum*):

Si rem inspectori dedi, an similis sit ei, cui commodata res est, quaeritur. Et, si quidem mea causa dedi, dum volo pretio exquirere, dolum mihi tantum praestabit; si sui, et custodiam, et ideo furti habebit actionem. Sed et si, dum refertur, periit, si quidem ego mandaveram, per quem remitteret, periculum meum erit; si vero ipse, cui volui EL commisit, aequè culpam mihi praestabit, si sui causa accepit.

Por su parte, D.13,6,5,10 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*) aborda un caso de responsabilidad del comodatario en caso de interés común, y que se engloba en aquel tratamiento general que acomete Ulpiano en el libro 28 de sus comentarios *ad Edictum*, y que aparece recogido en D.13,6,5 (paragr. 2-10). Concretamente, en D.13,6,5,10²⁵ alude a dos supuestos en que se exceptúa la norma general, limitándose tal responsabilidad del comodatario al dolo: a) el primero, cuando tal disminución ha sido libremente acordada por las partes (*...si quis ita convenit*), b) y el segundo, cuando el contrato se celebra en interés exclusivo del comodante (*...si sua dumtaxat causa commodavit*). Todo ello constituye una causa de limitación de la responsabilidad del comodatario.

pra, arrendamiento, prenda y sociedad) y contratos celebrados en interés exclusivo del deudor (como el comodato).

En aquellos contratos que reportan beneficios para ambas partes contratantes, la utilidad jugaba un papel menos importante que en aquellos otros en que el beneficio surge para una de las partes implicadas en el mismo, en los cuales constituía un factor determinante para establecer el grado de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación –caso del comodato y depósito-. Vid. D.13,6,5,2,3 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*).

25 D.13,6,5,10 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*): Interdum plane dolum solum in re commodata praestanda est, ut etiam in ea, quae sequitur rem commodatam, praestari debeat; ut puta equam tibi commodavi, quam pullus comitabatur, etiam pulli te custodiam praestare debere, veteres responderunt.

La responsabilidad del comodatario se justifica por la ventaja que recibe de manera exclusiva de la relación²⁶. Faltando tal requisito, se requiere el recurso a un criterio menos elevado de responsabilidad, como pueda ser efectivamente el dolo.

Los textos de Ulpiano dan muestra de la importancia de la utilidad como criterio prevalente para atribuir la responsabilidad, y su aplicación preferente al comodato y al depósito. Al final del periodo clásico se produce un notable giro en el ámbito de la responsabilidad contractual, que tendrá una repercusión clara y directa sobre la regla de la *utilitas*. Y al ofrecerse como única alternativa el dolo y la culpa, se produce una asimilación entre el comodatario y los deudores de otras relaciones bilaterales a los que antes se les exigía un grado de responsabilidad inferior. Y esto conduce efectivamente a una quiebra del principio de utilidad, pues no encuentra justificación que el comodatario responda por culpa en los supuestos que sólo él obtiene ventaja de la relación, y aplicar un idéntico grado de responsabilidad para los deudores de otras relaciones de las que surge interés o utilidad para ambas partes, como la compraventa o el arrendamiento.

Una vez superada esta disyuntiva, mediante la introducción de la *diligentia*, criterio flexible de responsabilidad que puede resultar superior a la simple culpa, los compiladores proponen una clasificación tripartita de las diversas relaciones contractuales sobre la base de una triple *utilitas*:

- a) así, se distingue entre contratos celebrados en interés del acreedor, en los que la responsabilidad del deudor se ve limitada al dolo;
- b) contratos celebrados en interés del acreedor y deudor, cuyos deudores responden también por culpa.
- c) contratos celebrados en interés exclusivo del deudor, en los que éste responde tanto de la culpa como de la *diligentia*²⁷.

Atendiendo a los términos que se conjugan en la expresión *custodiam praestare*, se desprende que la misma hace referencia a la obligación que se impone al deudor de algunas relaciones (en particular al comodatario) de garantizar al acreedor el cumplimiento de la obligación principal de *reddere rem*²⁸, asumiendo el riesgo de incumplimiento debido a eventos evitables con la custodia —*custodiam praestare*—.

26 Cf. *Gai* 3,206; D.13,6,5,3 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*). En D.13,6,5,2, el jurista expone tanto los criterios que conforman por norma el contenido del *praestare* del comodatario como el fundamento de tal responsabilidad, esto es, la utilidad que el mismo obtiene del contrato de manera exclusiva (*Commodatum autem plerumque solam utilitatem continet eius cui, praestandam et diligentiam*).

27 Pero esta tendencia a erigir el criterio de la *utilitas contrahentium* no llega a cristalizar en este periodo; los maestros bizantinos tampoco logran establecer un conexión efectiva entre triple *utilitas* y diversos grados de responsabilidad, aplicando preferentemente el criterio a los contratos de comodato y depósito.

28 Exceptuando D.13,6,5,2-3. en ningún otro se sigue este enunciado genérico de la teoría de la utilidad. Por ello, no creemos que deba atribuirse a los compiladores justinianos la regla de la *utilitas* hasta convertirse en criterio de aplicación general. En las Instituciones justinianas no sólo se alude a este criterio en una ocasión, en relación a la responsabilidad del acreedor pignoraticio, omitiéndose por los demás toda mención al mismo, incluso en aquellos textos que se refieran al comodato y al depósito, por lo que muestra el desinterés de los compiladores bizantinos hacia tal criterio; cf. .3,14,2,3.

El comodatario responde automáticamente verificado el incumplimiento, y en este sentido es indiferente lo que pudo o no pudo hacer, hizo o dejó de hacer realmente, es decir, las circunstancias que rodean en el caso concreto el incumplimiento son irrelevantes.

Esta particular forma de responsabilidad, conocida y aplicada ya en tiempos de jurisprudencia republicana, va ampliando paulatinamente su ámbito de aplicación. Prácticamente limitada en tiempo de los *veteres* a las hipótesis de fuga y robo²⁹, se convierte en una responsabilidad objetiva por la pérdida o deterioro de la cosa³⁰, cualquiera sea la causa que la origine, con tal que se considere evitable con una adecuada actividad de custodia o vigilancia sobre la misma. Un momento destacado de esta evolución corresponde a aquel en el que Marcelo resuelve incluir en el ámbito de la custodia la hipótesis de *damnum ab alio iniuria datum*.

Cuando el incumplimiento de la obligación no deriva de factores externos, sino que está conectado directamente al propio comportamiento del comodatario, entra en juego la culpa, criterio al que recurren ya los juristas republicanos. Y se considera que el comodatario *in culpa esse*, y en consecuencia, responde siempre que no observe en el cuidado de la cosa la diligencia presumible en una persona con dotes normales de cautela y prudencia.

Así, el comodatario responde si hace un uso de la cosa diverso al acordado, provocando así su desaparición o menoscabo, aunque tal resultado esté conectado directamente a una circunstancia constitutiva de fuerza mayor; e igualmente responde si ante un caso de naufragio, incendio o similar, decidió salvar sus cosas antes que las del comodante, que tenía en préstamo.

A partir de Juliano se aprecia ya una clara tendencia a valorar la responsabilidad por custodia; tal concepción de la custodia se refleja nítidamente en la definición que nos ofrece Ulpiano: *Custodiam plane commodatae rei etiam diligentem debet praestare* (D.13,6,5,5,) que fija la diligencia como criterio interpretativo de la misma. Ciertamente, debe responder de la custodia, aún de la diligencia, de la cosa dada en comodato.

La definitiva transformación de la custodia en una responsabilidad subjetiva por *negligentia in custodiendo* no se lleva a cabo, en cambio, hasta la época justiniana. El desprecio hacia las formas objetivas de responsabilidad³¹ se advierte de manera especialmente intensa en el periodo postclásico-antejustiniano, en que se ofrecen como únicos criterios posibles el dolo y la culpa, como podemos apreciar en la obra de un jurista clásico, como es Modestino, *Collatio*, 10,2,1³²: “Mientras el comodatario responde por culpa, el depositario sólo debe

29 Vid. D.13,6,5,6 (*Ulpianus*, lib. XXVIII *ad Edictum*).

30 En algunos casos, el comodatario responde por la pérdida debida a fuerza mayor; los textos coinciden en afirmar que el comodatario responde por el perecimiento debido a fuerza mayor, *ove culpam praecessit casum*.

La responsabilidad por custodia encuentra el límite de la *vis maior*; es evidente que en los casos en los cuales el comodatario responde por pérdida debido a *vis maior*, el fundamento de tal responsabilidad debe buscarse al margen de la custodia.

31 Con el afianzamiento progresivo de la culpa como eje del sistema de la responsabilidad contractual, habría conducido al siguiente resultado: a los contratos en que se responde sólo por dolo, como el depósito y el mandato, ahora se contraponen aquellos en que se responde sólo por culpa, produciéndose una asimilación entre comodato y otras relaciones respecto de las que se afirmaba antes un grado inferior de responsabilidad, precisamente la culpa.

32 *Collatio* 10,2,1: *Commodati iudicio conventus et culpam praestare cogitur: qui vero depositi conventur; de dolo, non etiam de culpa, condemnatus est. Commodati et ibi dolus tantum praestatur*. Vid. también *Collatio* 10,2,2,3 y D.50,1,7,23 (*Ulpianus*, lib. XXIX *ad Edictum*).

responder por dolo, y ello es así porque en el comodato media utilidad de ambas partes, en tanto que el depósito sólo beneficia a aquél que deposita”. Aquí se observa en primer lugar que el autor parte de un sistema de responsabilidad contractual centrado exclusivamente en el binomio dolo-culpa). Todo el discurso se construye en torno a estos dos criterios como únicas posibilidades en materia de responsabilidad, y en esta función de dualidad se articula precisamente una bipartición de las diversas figuras o relaciones contractuales, según que se responda en las mismas sólo por dolo, bien por dolo y culpa.

La segunda idea, conectada estrechamente a la anterior, es el enunciado de la *utilitas contrahentium*. Frente a la distinción que en los textos anteriores se realizaba entre contratos realizados en interés del deudor, y contratos celebrados en interés del acreedor, se ofrece ahora una nueva alternativa: negocios concluidos en interés del acreedor (como el depósito) y negocios concluidos en interés de ambas partes (comodato), y se afirma que mientras en los primeros el deudor responde sólo por dolo, en estos últimos su responsabilidad abarca también la culpa.

Por su parte, Modestino habría afirmado simplemente que el comodatario respondería por custodia debido a la ventaja que en exclusiva recaba de la relación, mientras que el depositario, que no obtiene ventaja alguna del negocio, sólo responde por dolo, debiéndose a posteriores interpolaciones la sustitución de la custodia por la culpa, y la mención a la utilidad común como presupuesto de la misma.

A aquellos se suma por obra de los compiladores la *diligentia*, entendida también como criterio propio de responsabilidad articulado en géneros y grados, que van desde la *magna neglegentia* a la *diligentia exactissima*, pasando por la *diligentia diligentis* y la *diligentia quam suis*. Esto es, se admite un tercer grado de responsabilidad más elevado que la culpa, como es la *diligentia*. Ahora ya pueden distinguirse entre tres grupos de contratos, haciendo corresponder a cada uno de ellos un criterio diverso de responsabilidad: dolo, culpa y *diligentia*.

En este contexto, se establece como criterio general interpretativo de la responsabilidad del comodatario el de la *exactissima diligentia* o *diligentia diligentissimi patresfamilias*, que no encuentra más límites que la *vis maior o casus cui humana infirmitas resistere non potest*, con el cual se alcanzan idénticos resultados prácticos que con la custodia clásica.

En cuanto a los problemas de duplicidad formularia, las razones del comodante encuentran tutela en una *actio commodati*, la cual presenta el fenómeno de la duplicidad formularia. Gayo 4,47 afirma que el pretor, para la tutela de algunas relaciones –*veluti depositi et commodati*–, propone en el edicto dos fórmulas, un *in factum*, y otra *in ius*. Gayo se refiere las dos fórmulas de la *actio depositi*, advirtiendo que *similes etiam commodati formulae sunt*.

La fórmula *in factum* de la *actio commodati*, al igual que aquélla de la *actio depositi*, sin duda recoge en la *intentio* la circunstancia de la falta de restitución de la cosa, y en la *condemnatio* la referencia a su valor de mercado al momento de la sentencia (*quanti ea res erit*): (D.13,6,3,2)

La diferencia estriba precisamente en la medida de la responsabilidad, ya que mientras la *actio depositi* recoge la mención del dolo como premisa de la condena, estando la figura de la responsabilidad apegada al depositario, la *actio commodati* no mencionaba el dolo, en cuanto el comodatario respondía por custodia.

La fórmula *in ius* de la *actio commodati*, como aquélla de la *actio depositi*, era *ex fide bona*, y como todas las fórmulas de buena fe, reflejaban en la *intentio* la relación contractual, y otorgaba al juez el poder de juzgar, con referencia a la *bona fides*, *quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet*.

Los medios por los que encuentra tutela el comodatario son diversos: a) las fuentes afirman que el comodatario tiene un *ius retentionis* de la cosa comodada para los gastos necesarios derivados de la conservación de la cosa; b) una *compensatio*, dirigida a disminuir la condena cuando el comodatario tenga derecho a una indemnización (D.13,6,18,4 (*Gaius*, lib. IX *ad Edictum provinciale*) c) y sobre todo, una *actio* denominada *contraria* en cuanto se oponga a la pretensión del comodante (D.13,6,7,5; D.13,6,17,3; D.13,6,18,2-3-4; D.13,6,21 pr.; D.13,6,22).

De las dos fórmulas de la *actio commodati*, la fórmula *in factum* debe considerarse la más importante, como fundamento de la obligación de restitución del comodatario³³. La *actio commodati* no es colocada en la rúbrica edictal de *bonae fidei iudicia*, como habría requerido la fórmula *in ius civile*, sino en la rúbrica *de rebus creditis*, obviamente sobre la base de la fórmula *in factum*.

El motivo por el que se introduce la fórmula *in ius* debe verse en los límites de la tutela pretoria; sancionando la fórmula *in factum* exclusivamente, la obligación del comodatario de restituir la cosa —el *non reddere* es el supuesto de la *condemnatio*—, se hace necesaria la creación de un medio procesal dirigido a sancionar las obligaciones del comodatario, de no abusar de la cosa comodada, y de no deteriorala, y tal medio es precisamente la fórmula de buena fe del *ius civile*.

Habíamos visto que en el derecho clásico, las relaciones en las que el deudor estaría obligado por custodia tendrían una tutela *in factum*³⁴. La fórmula *in factum* del comodato, además de constituir el más antiguo medio de tutela del comodato, se presenta en consonancia con la valoración de la responsabilidad mediante criterios objetivos, ya que hace depender la condena de la falta de restitución, sin recurrir a otros criterios, siendo precisamente ésta (la obligación de restitución) el primer aspecto apreciado por la conciencia social en el ámbito del negocio: como supuesto de la misma aparece la circunstancia de la falta de restitución de cosas confiadas al deudor, de aquí que la jurisprudencia elabore la figura de la responsabilidad por custodia.

La fórmula *in factum* sancionaría una responsabilidad por custodia, mientras en el ámbito de los juicios de buena fe, se habría afirmado una responsabilidad subjetiva. Sólo mediante la tutela de tal obligación, el comodato dejó de ser un mero negocio de la praxis social, y fue encuadrado en la órbita jurídica: sólo a este punto la jurisprudencia tuvo la posibilidad de considerar tal figura, elaborando la modalidad relativa a los límites del uso concedido al comodatario, a la actividad que éste debía emplear en la conservación de la cosa y la responsabilidad del comodatario.

33 Existe una fórmula *in factum*, por la que él responde por custodia. Es evidente que también en el comodato la responsabilidad por custodia debe ser puesta en relación con la fórmula *in factum*. No se puede negar que la responsabilidad por custodia habría encontrado su origen y su típica aplicación en al ámbito de la fórmula *in factum*.

34 Para sancionar las obligaciones del comodatario de no abusar de la cosa y de preservar la misma de los daños, viene introducida un medio de tutela por el *ius civile*, una fórmula de buena fe.

En el derecho clásico, el comodatario, en razón a la restitución de la cosa dada en comodato, responde *per custodia*, figura de responsabilidad objetiva, la cual prescinde de la valoración del elemento intencional, afirma la existencia del nexo de causalidad entre el comportamiento del comodatario y la falta de restitución, con el límite que ésta haya sido determinada por *vis maior*, como los casos en los que el comodatario haya perdido la cosa como consecuencia de un naufragio, incendio, terremoto o robo.

La justificación de tal responsabilidad debe verse en la *utilitas contrahentium*, la cual va dirigida exclusivamente al comodatario, que puede usar la cosa gratuitamente. El comodatario está legitimado con la *actio furti* respecto al ladrón, y con preferencia respecto al *dominus* de la cosa, al cual corresponde sobre el ladrón la *condictio ex causa furtiva*.

Estando el comodatario obligado por custodia, en el caso en el que la *res commodata* haya sido perdida como consecuencia del furto, el *dominus* puede dirigirse contra el comodatario con la *actio commodati* y obtener la indemnización: de aquí que el sujeto interesado en la conservación de la cosa no sea el *dominus*, sino el comodatario, sobre el cual gravan las consecuencias dañosas del hurto. Tal régimen jurídico se relaciona con la norma enunciada por Gayo 3,203, por el cual la *actio furti* no pertenece en general al *dominus* de la cosa robada, sino a aquél *cuius interest rem salvam esse*, norma aplicable, además de al comodatario, también al *fullo* y al *sarcinator*, igualmente responsables *per custodia*, y al acreedor pignoraticio, interesado en la conservación de la cosa, constituyendo ésta la garantía de su crédito.

Por ello, la responsabilidad por custodia, denominada también en la doctrina custodia técnica, debe distinguirse de la denominada “custodia atécnica”, que denota la mera actividad de custodiar la cosa y la relativa obligación: el depositario, por ejemplo, tiene la obligación de custodiar la cosa depositada, si bien no soporta una responsabilidad por custodia, sino que responde sólo por dolo.

Naturalmente, la responsabilidad *per custodia* deriva de la cristalización de la actividad de vigilancia del sujeto, con referencia a los casos típicos en los que la cosa podía perderse, como en los supuestos de hurto, la *amissio rei* y la fuga de la cosa animada.

La responsabilidad *per custodia* es la primitiva y típica figura de responsabilidad del comodatario, y como se ha dicho, se aplica en el ámbito de la fórmula *in factum*, la cual no otorga al juez el poder de examinar el comportamiento del comodatario, condicionando la *condemnatio* al *non reddere*, refiriéndose a la obligación principal del comodatario, esto es, la obligación de restituir la cosa.

Con la aparición de la fórmula *in ius*, encaminada a sancionar la obligación del comodatario de no abusar de la cosa comodada (el abuso, cuando fuese acompañado del dolo del comodatario era perseguible con la *actio furti*, concretando tal supuesto los extremos del *furtum usus* (Gai 3,197)- y de no deteriorarla, tiende a afirmarse una responsabilidad en consonancia con la buena fe: importando la *bona fides* una consideración por parte del juez del comportamiento personal, con referencia al comportamiento de la persona concreta, se pone en antítesis con la afirmación de una responsabilidad objetiva. El comodatario, en el uso de la cosa dada en comodato, debe atenerse a la modalidad establecida en el contrato. El comodatario encuentra a tal propósito una obligación particular, y en orden a ella no responde por custodia, y ni siquiera su responsabilidad tiene un contenido objetivo.

La responsabilidad del comodatario tiene un contenido estrictamente subjetivo, tanto que se debe pensar que se haya elaborado en un terreno diverso de aquél en el que se formó la responsabilidad por custodia: veremos cómo aquélla se ha elaborado en el ámbito de la *bona fides*, siendo *ex fide bona* el juicio que sancionaba tal obligación. Tal juicio derivaba de la fórmula *in ius* del comodato, la cual habría sido introducida para sancionar la obligación del comodatario, de modo diverso a la obligación de restitución, la cual habría encontrado tutela en la antigua fórmula *in factum*. En el ámbito de la *bona fides* encuentra una oportuna valoración el *factum debitoris*, el cual entendido inicialmente como mero nexo de causalidad, viene interpretado en sentido más técnico, con referencia a la calificación del comportamiento de aquella persona correcta, o sea del *bonus paterfamilias*, no considerado como una figura teórica, sino empírica.

De esta manera se da entrada a la valoración de la *diligentia*, la cual viene a ser el criterio interpretativo del *factum debitoris*, y de la culpa, originariamente sinónimo de *factum debitoris*, y tiende a acercarse al concepto de *diligentia*. Al final de época clásica, la *diligentia* tiende a cristalizarse en una figura bien definida, y viene a ser una responsabilidad técnica *per diligentia*, de la cual es paralela la responsabilidad *per culpa*, entendida como *neglegentia*³⁵.

En el derecho clásico se tiende a ver una línea de continuidad entre la fórmula *in factum* del comodato, la obligación de restituir y la responsabilidad *per custodia*, de un lado, y por otro, entre la fórmula de buena fe, las obligaciones del comodatario de no restituir la cosa íntegra y una responsabilidad de naturaleza subjetiva, en consonancia con una valoración empírica de la *diligentia*.

Y una situación similar se aprecia también en el ámbito de la *actio commodati contraria*, en cuya fórmula *in factum* sanciona la obligación incondicionada de restituir al comodatario los gastos necesarios, mientras la fórmula *in ius*, sobre el fundamento de la *bona fides*, sanciona el resarcimiento del daño a favor del comodatario cuando se verifique por dolo del comodante. Se puede explicar, también en vía de hipótesis, el motivo por el que, después de que el comodato estuviera provisto de tutela por obra del *ius civile* mediante la fórmula de buena fe, la más antigua fórmula *in factum* no se suprime, sino que continuó teniendo aplicación –como demuestran los comentarios jurisprudenciales–, al determinar la posición edictal del comodato en la rúbrica *de rebus creditis*: la fórmula *in factum* continúa teniendo una importante función, ya que consiente, al contrario que la fórmula de la buena fe, en caso de falta de restitución de la cosa, el atribuir al comodatario la más grave responsabilidad *per custodia*.

De aquí que una peculiar diferencia entre el comodato y el depósito sería la fórmula *in factum*, la cual limita al dolo la responsabilidad del depositario, y deja de cumplir una práctica función frente a la posterior fórmula de buena fe, y junto a ésta se mantiene por mera inercia histórica, ya que la tutela del depósito es sistematizada en el edicto en la rúbrica *de bonae fidei iudiciis*.

Basándonos en el fundamento de la fórmula *in factum*, fue en cambio acorde al régimen positivo del *commodatum* en todo el periodo clásico el concepto de *credere*: de aquí se

35 *Pauli Sententiae* 2,4,3; *Collatio*, 10,2,1.

explica la no de mención, en Gayo 4,62, del *iudicium commodati* en el elenco clásico de los juicios de buena fe, sin que se deba pensar en una imperfección del manuscrito veronés.

Al final de época clásica, unificándose el *iudicium commodati* en el ámbito de la *cognitio extra ordinem*, se unifica también el régimen de responsabilidad: a la aproximación de la custodia a la *diligentia*, que recogen las fuentes postclásicas (*Pauli Sententiae* 2,4,3; *Collatio*, 10,2,1-4), sigue la fusión de las dos figuras por obra de Justiniano, con la concepción de la *diligentia exactissima in custodiendo* o *diligencia diligentissimi patris familias*³⁶. Con la *diligentia exactissima in custodiendo*, Justiniano encuadra la responsabilidad del comodatario en el ámbito de la *diligentia*, pero habiendo atribuido a aquél un *diligentia* escrupulosísima, la cual venía a ser muy dificultosa, termina por imputar al comodatario una responsabilidad no distinta de la responsabilidad *per custodia*; en definitiva, Justiniano, conserva de hecho la responsabilidad del comodatario, simplemente cambiando el presupuesto teórico.

Como conclusión, la figura de la *diligentia diligentissima patris familias* se afirma particularmente en los autores bizantinos, para los cuales era menos intenso el vínculo a la tradición clásica, y en consecuencia, no tenían interés en recordar, aunque sólo fuese formalmente, la custodia³⁷.

36 D.44,7,1,4; D.13,6,18 pr.

37 Ej. *Paraphr.* 4,1,16; *Basilic.* II, 3 23; *Basilic.* XIII, 1 5,2.).

LA PUBLICIDAD DE LA CONVENTIO PIGNORIS

MARGARITA FUENTESECA

Universidad de Vigo

La publicidad de los derechos reales de garantía es un tema del que ya me he ocupado con anterioridad¹ y respecto al cual he reconsiderado algunas ideas, que expongo aquí con ánimo presentar una visión más completa sobre esta cuestión tan debatida.

La seguridad del tráfico de bienes exige que los derechos reales de garantía constituidos entre un acreedor y un deudor no afecten o no perjudiquen a un tercero, ajeno a esa relación. Hoy en día la protección del tercero exige que los derechos reales de garantía estén dotados de un sistema que garantice su publicidad, para que así puedan ser oponibles *erga omnes*. Pero no se debe trasladar esta necesidad al mundo romano. El afán por buscar alguna forma de publicidad en la *conventio pignoris* romana ha llevado a afirmar, con toda rotundidad, que el romano era un sistema clandestino. En realidad, como voy a demostrar, el funcionamiento de la *conventio pignoris* romana por sí mismo evitaba o, llegado el caso, resarcía el perjuicio que se había causado a un tercero.

1. LA VENTA CUM SUA CAUSA

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación en Roma el acreedor y el deudor acordaban la *conventio pignoris*, mediante la cual una cosa quedaba sujeta al pago de una deuda (*res pignori data* o *res obligata*). El conflicto podía crearse cuando la cosa pignorada era adquirida por un tercero, porque el acreedor, con la *actio Serviana*, podía exigir la *restitutio rei* frente a cualquiera, incluido este tercero adquirente.

La *actio Serviana* que tenía el acreedor pignoraticio nació como acción con la que se podía pedir la *restitutio rei* de la cosa pignorada frente a cualquier poseedor, también en el caso de que se tratase de un tercero adquirente. Gracias a esta acción, la *conventio pignoris* se convirtió en un derecho real oponible *erga omnes*, pero también en un instrumento que facilitó la realización de operaciones crediticias y que contribuyó al enorme desarrollo del tráfico mercantil y de la economía pecuniaria romana.

¹ Vid. *Pignus e hypotheca en su evolución histórica*, ed. Andavira, Santiago de Compostela, 2013; *La hipoteca en Roma*, Estudios de Derecho Privado en homenaje a J. J Rivas Martínez II, Dykinson (Madrid 2013), p. 1253-1276.

Si el acreedor podía perseguir la cosa pignorada allí donde estuviese, ésta no quedaba fuera del tráfico comercial hasta que se pagara la deuda, sino que podía ser objeto de negocio jurídico. De ahí que el deudor pudiese vender la cosa pignorada, ya se tratase de una *res pignori data* o de una *res obligata*, porque, como consecuencia necesaria de la oponibilidad *erga omnes* de la *actio Serviana*, la cosa se transmitía con ese gravamen real.

Los juristas romanos afirmaron claramente que la venta de la cosa pignorada no eliminaba el gravamen que recaía sobre ella. Según Paulo D. 13.7.18.2², si se vende un fundo dado en prenda, subsiste la causa de la prenda, porque se transmite el fundo con su propia condición: *cum sua causa*, igual que sucede con el parto de la esclava que nació después de la venta.

La combinación de la venta *cum sua causa* y de la *actio Serviana* del acreedor permitió que la *conventio pignoris* sobrepasara su finalidad inicial, más primitiva, que era garantizar el cumplimiento de una obligación. En época clásica, en plena expansión de la economía pecuniaria en Roma, la venta de la cosa pignorada podía tener por finalidad, en realidad, una operación crediticia, consistente en que, una vez obtenido el crédito por el deudor, cuya devolución se garantizaba con la constitución del derecho real de garantía, podía éste vender la cosa pignorada con la condición de que fuera el comprador el que, como parte del pago del precio, saldase con el acreedor pignoraticio la deuda.

Esta operación crediticia debió ser corriente en época clásica romana, ya que se previó incluso la imposición de una caución al comprador como garantía de que pagaría al acreedor, que es descrita por Marciano en un pasaje del *libro singulari ad formulam hypothecariam* (D. 20.6.8.10³): el deudor que le pida al acreedor el consentimiento para vender la cosa pignorada, para pagarle con mayor facilidad, deberá pedirle al comprador que dé caución, antes de la venta, de que pagará al acreedor el precio de la cosa vendida hasta el importe de la deuda⁴.

Pero en realidad este consentimiento del acreedor pignoraticio para vender la cosa pignorada no era necesario, como recuerda Diocleciano en un rescripto (año 293, C. 8.27.12): si el deudor vende una cosa pignorada sin el consentimiento del acreedor transmite al comprador la propiedad de la cosa con el gravamen (*si debitor rem tibi iure pignoris obligatam te non consentiente distraxit dominium cum sua causa transtulit emptorem*).

2 D. 13.7.18.2, Paulus libro XXIX ad Edictum.- ... Si fundus pignorat us venierit, manere causam pignoris, quia cum sua causa fundus transeat, sicut in partu ancillae, qui post venditionem natus sit.

3 D. 20.6.8.10, Marcianus libro singulari ad formulam hypothecariam.- Tutius tamen est, si debitor a creditore petat, ut ei permittat pignus vendere, quo magis satisfaciatur, ante cautionem accipere ab eo, qui rem empturus erit, ut pretium rei venditae usque ad summam debiti creditori solvatur.

4 Cabía también, previo consentimiento del acreedor, la permuta y la transmisión de la cosa pignorada por medio de donación o dote por parte del deudor pignorante. Según Ulpiano en D. 20.6.4.1 *libro LXXIII ad Edictum*.- Si in venditione pignoris consenserit creditor, vel, ut debitor hanc rem permutet, vel donet, vel in dotem det, dicendum erit, pignus liberari, nisi salva causa pignoris sui consensit vel venditione vel ceteris; nam solent multi salva causa pignoris sui consentire..., si el acreedor dio su consentimiento a la venta de la prenda, o para que el deudor permute la cosa, o la done o la entregue en dote, se debería decir que la prenda queda liberada, salvo si se consintió la venta o lo demás con reserva de la prenda. Según Ulpiano, por tanto, en estos casos hay una transmisión de la cosa pignorada *salva causa pignoris*.

2. EL PACTO DE NO VENDER LA COSA PIGNORADA

Si con la *actio Serviana* se podía perseguir la cosa pignorada, incluso cuando estuviese en poder del tercero adquirente, resulta extraño que el jurista Marciano, en su libro sobre la fórmula de la acción hipotecaria, se pregunte qué sucedía en el caso de que deudor y acreedor hubiesen pactado la ilicitud de la venta (D. 20.5.7.2⁵). Responde que si las partes pactaron que no sea lícito al deudor vender la prenda o la hipoteca, la venta por el deudor de la cosa pignorada será nula.

No se comprende porqué Marciano menciona un pacto cuya conclusión entre las partes, en realidad, tenía poco sentido, porque la cosa pignorada era perseguible frente a cualquiera que la tuviese en su poder con la *actio Serviana*. Podría explicarse como una antigua reminiscencia proveniente de la más arcaica *conventio pignoris* romana, que se realizaba con *traditio possessionis*⁶. A ésta se le podía añadir el pacto con el que se le prohibía al deudor la venta de la cosa pignorada. Se lograba así el mismo efecto que con la *conventio pignoris* sin *traditio possessionis*. El pacto de no vender, por tanto, fue el primer paso que se dio hacia la admisión de la *conventio pignoris* en la que era irrelevante si había habido o no *traditio possessionis*.

La *conventio pignoris* sin *traditio possessionis* se generalizó a partir de que se consolidó la utilización de la *actio hypothecaria*. Era la misma *actio Serviana*, pero a partir de que se admitió su interposición también frente al propio deudor. La *actio hypothecaria* era una acción mixta, tanto real o reipersecutoria como personal, que servía para la exigir la *restitutio rei* frente a cualquier poseedor y también para exigirle al deudor el pago de la deuda. Una vez generalizada ésta, como *actio Serviana* o *hypothecaria*, no importaba si había habido o no *traditio possessionis* y si había o no un pacto de no vender la cosa. Con la *conventio pignoris* la *res* quedaba *obligata*, y el acreedor podía interponer la acción contra el tercero poseedor, o bien contra el propio deudor.

Al afirmar que sería nula la venta realizada por el deudor en contra del pacto de no vender, el jurista Marciano no añade nada nuevo, sino solamente alude a la posible existencia de este pacto que podía acompañar a la más antigua *conventio pignoris* con *traditio possessionis*.

Si con la *actio Serviana* el acreedor podía perseguir la cosa allí donde estuviese, la venta de la cosa pignorada se tenía por no hecha, o, como dice Marcelo, era nula. Por tanto, el comprador de la cosa pignorada debía restituirla al acreedor. Pero, como vamos a ver a continuación, el Derecho romano se presenta de nuevo como un ordenamiento jurídico encaminado a la resolución de conflictos: el propio funcionamiento de la *conventio pignoris* evitaba la creación de un conflicto con el adquirente, como sucedía en el caso

5 D. 20.5.7.2, Marcianus libro singulari ad formulam hypothecariam.- Quaeritur, si pactum sit a creditore, ne liceat debitori hypothecam vendere vel pignus, quid iuris sit; et an pactio nulla sit talis, quasi contra ius sit posita, ideoque venire possit? Et certum est, nullam esse venditionem, ut pactioni stetur.

6 En los más antiguos arrendamientos rústicos se pignoraban los aperos del colono y todo lo que en el fundo se producía y nacía, entrando en vigor la *conventio pignoris* con la entrada del colono en el fundo arrendado, momento en el cual el arrendador adquiría la posesión (mediata) sobre lo que se había introducido o allí se producía o nacía que podía defender con el *interdictum Salvianum*. Vid. *Pignus e hypotheca en su evolución histórica*, cit. p. 35-57.

de los fundos pignorados, o proporcionaba resarcimiento al comprador por el perjuicio causado cuando se veía privado de la cosa adquirida por el acreedor pignoraticio.

3. LA *ACTIO FURTI* FRENTE AL DEUDOR PIGNORANTE

La venta de la cosa pignorada podía provocar un conflicto, si el deudor no pagaba la deuda, en el que colisionaban los intereses de tres personas.

Por un lado, el acreedor pignoraticio podía perseguir con la *actio Serviana* o *hypothecaria* la *restitutio rei* frente al comprador de la cosa pignorada. Si éste era condenado a restituirla al acreedor, el conflicto se planteaba entre él y el vendedor, que se resolvía con la interposición de la *actio furti* contra el vendedor. Según Paulo (que se apoya en la opinión de Juliano en D. 47.2.66pr.7), cometía *furtum* el que vendió una cosa dada en prenda, tanto si se había hecho la *traditio* al acreedor, como si se había obligado a ello por medio de un pacto especial.

Nos encontramos aquí con otra remisión a la más antigua forma de *conventio pignoris* que apareció en Roma, que se realizaba con *traditio possessionis*, a la que se le podía añadir el pacto de no vender, que he descrito en el epígrafe precedente. Según Paulo, el *furtum* lo cometía el deudor tanto si había habido *traditio possessionis* de la cosa pignorada al acreedor, como cuando se había obligado a hacer la *traditio*, —esto es, a no disponer de la cosa—, por medio de un pacto especial.

Pero el *furtum* que podía cometer el deudor pignorante se describe, en cambio, de forma más amplia en las Instituciones de Gayo y de Justiniano como un caso de *furtum* en cosa propia (*furtum suae rei*). Según Gayo 3.200 (*aliquando etiam suae rei quisque furtum committit, ueluti si debitor rem, quam creditori pignori dedit, subtraxerit...*⁸ =I. 4.1.10), el *furtum* del deudor pignorante consiste de forma general en la sustracción de la cosa pignorada.

En esta descripción tan amplia del *furtum* se incluía la venta por el deudor de la cosa pignorada, que era el caso más grave, ya descrito como *furtum* por Paulo, porque se le causaba un perjuicio a un tercero, ajeno a la relación entre deudor y acreedor. Pero comprende también los casos en que el deudor cometía *furtum* frente al acreedor pignoraticio y esto sucedía no sólo cuando sustraía la cosa pignorada del poder de éste, sino también cuando, teniendo la cosa en su poder, la sustraía del alcance del acreedor o la alteraba⁹. En las Instituciones de Gayo y en las de Justiniano se hace una descripción más amplia del *furtum* que se corresponde con la generalización, por medio de la utilización de la *actio Serviana sive hypothecaria*, de la *conventio pignoris* sin *traditio possessionis*.

7 D. 47.2.66pr, Paulus libro VII ad Plautium. Si is, qui rem pignori dedit, vendiderit eam, quamvis dominus sit, furtum facit, sive eam tradiderat creditori, sive speciali pactione tantum obligaverat; idque et Iulianus putat.

8 FIRA², p. 142.

9 En estos casos la *actio furti* la podía interponer el propio acreedor pignoraticio contra el deudor, como afirma Gayo (vid. FIRA², p. 143, Gayo 3.204: *Vnde constat creditorem de pignore subrepto furti agere posse; adeo quidem, ut quamvis ipse dominus id est ipse debitor, eam rem subriperit, nihilo minus creditori competat actio furti*); el acreedor pignoraticio tiene la acción de *furtum* incluso contra el propio deudor. La sustracción la podía cometer el deudor no sólo estando la cosa pignorada en poder del acreedor (Ulpiano, D. 47.2.12.2) sino también cuando el propio deudor la tenía en su poder, si la hacía desaparecer, o la sustraía de cualquier manera, por ejemplo, cambiando la cosa pignorada por otra distinta (Ulp. D. 13.7.36pr).

En todo caso, al comprador de la cosa pignorada se le concedía la *actio furti* contra el vendedor y esta era una medida protectora de la seguridad del tráfico de bienes. Según Gayo 3.190 (y también según Aulo Gelio, N. A. 11.15) la pena del *furtum* no manifestase se estableció en las XII Tablas al doble y esta misma pena se imponía todavía en su época por el pretor. De esta forma se resarcía el tercero adquirente frente al vendedor, por el doble del precio pagado, cuando había sido condenado a la *restitutio rei* a favor del acreedor pignoraticio.

4. EL CASO ESPECIAL DEL FUNDO PIGNORADO

La *actio furti*, sin embargo, no se podía interponer en el caso de que la cosa pignorada fuese un fundo. La pignoración de los fundos tenía una forma peculiar, por tratarse de una cosa fructífera sobre la que se asentaba la obtención de riqueza en la antigua Roma.

En las fuentes se utiliza el término *praedia pignori data* porque la pignoración se realizaba con *traditio possessionis* del fundo a favor del acreedor¹⁰. Éste adquiriría la *possessio* sobre los frutos del fundo, porque sólo de esta forma un fundo podía servir para garantizar el pago de una deuda en una economía agrícola. Y para que el deudor no viese disminuida su capacidad de hacer frente a la deuda, podía el acreedor, a su vez, darle en arriendo el mismo fundo o concedérselo en precario¹¹.

Pero desde el momento en que el acreedor se veía privado de los frutos (o rentas) del fundo, ya fuese por el mismo deudor, o, si éste había vendido el fundo, por el comprador, también tenía la *actio Serviana* o *hypothecaria* para ejecutar su derecho real de garantía. La acción en estos casos presentaba la especialidad de que, debido a la naturaleza de la cosa pignorada –los frutos, cosa consumible–, se podía interponer sólo contra el propio deudor¹². La *actio Serviana*, nacida, como hemos visto, para perseguir las cosas pignoradas frente a terceros, se podía interponer solamente contra el propio deudor en cuanto el acreedor perdía la *possessio* de los frutos del fundo.

10 En varios textos del Digesto se menciona la *traditio possessionis* que acompaña a la *conventio pignoris* de los fundos. En D. 41.2.36 Juliano menciona la *traditio pignoris causa* del fundo al acreedor, aunque, según aclara, la posesión de éste no impide la usucapión del deudor. En D. 13.7.15 afirma Ulpiano que el acreedor pignoraticio de un predio debe garantizar, cuando devuelve la prenda, también los derechos del deudor, en el caso de que, habiendo dejado de usarlas, se hubiesen extinguido las servidumbres. Además, Pomponio menciona en D. 13.7.8pr la existencia de un *fundum, quem pignoris causa acceperim*, en relación con los gastos que haya hecho el acreedor pignoraticio en el fundo pignorado. Hay, por tanto, testimonios claros en las fuentes de la existencia de la *traditio possessionis* de los fundos, que convertía al acreedor en *possessor*, con derecho a la obtención de los frutos. El deudor pignorante, en cambio, conservaba solamente la posesión *ad usucapionem*.

11 Vid. Pignus e hypotheca en su evolución histórica, cit. p. 89-107.

12 La pignoración del derecho de usufructo era un caso análogo al de la pignoración del fundo. Porque cuando hay una *conventio pignoris* que recae sobre el usufructo también hay *traditio possessionis* de la cosa pignorada al acreedor (D. 20.4.11.3). El acreedor adquiere la posesión sobre los frutos y el pretor le amparará, como afirma Papiniano (D. 20.1.11.2) igual que lo haría con el comprador del usufructo. Para los juristas clásicos la pignoración de usufructo fue también un caso híbrido entre el *pignus datum* y la *hypotheca*. En este caso, igual que en el de pignoración de los fundos, se utiliza también en las fuentes también el término mixto *pignus hypothecae*, como sucede en D. 20.6.8.pr: *usu fructo ex stincto pignus hypothecae perit* y en D. 20.1.11.2: *usus fructus... pignori hypothecae dari*.

Este es el motivo por el cual la pignoración de los fundos se configuró como un caso singular, lo cual se deduce claramente de las fuentes, donde aparece descrita de forma mixta o híbrida: cuando se realizaba una *conventio pignoris* sobre un fundo, éste se hallaba en un estado intermedio entre *res pignori data* (con traslado de la posesión) y la *res obligata* (sin traslado de la posesión). En el caso de los fundos se trataba más bien de una *datio hypothecae*, como se pone de manifiesto en un texto de Marciano (D. 20.1.16.pr: *si fundus hypothecae datus sit, deinde alluvione maior factus est, totus obligabitur*): hay una *datio hypothecae* de los fundos (*fundus hypothecae datus*) de forma que todo el fundo (incluida la accesión por aluvión) quedaba obligado al pago de la deuda (*totus obligabitur –res obligata–*).

Además, en las fuentes que se refieren a la pignoración de los fundos se utilizan simultáneamente los términos *pignus hypothecae*. El jurista Scaevola se refiere en D. 32.38.pr a los *praedia* que se habían transmitido a título de prenda-hipoteca (*filius praedia...creditorum pignoris hypothecae nomine transtulit*) y asimismo aparece la combinación de los dos términos en D. 20.4.12.8: *praedium suum pignori hypothecaeve esset...*

Como hemos visto, los fundos pignorados podían ser vendidos *cum sua causa* (según Paulo en D. 13.7.18.2, cit.). El acreedor pignoraticio era titular de los frutos del fundo hasta que la deuda se saldase, de forma que si a partir de la venta no recibía los frutos del fundo, podía interponer la *actio Serviana sive hypothecaria* directamente contra el deudor para exigir el importe –o lo que restase– de la deuda.

Por tanto, en Roma, la venta de un fundo pignorado no creaba nunca un conflicto con el tercero adquirente. Era esencial que el deudor declarara en el momento de la venta que existía este gravamen sobre el fundo para evitar que el acreedor ejecutase directamente la deuda frente a él si dejaba de percibir los frutos, con la *actio Serviana sive hypothecaria*. En beneficio del propio vendedor, el comprador necesariamente tenía que conocer el gravamen que recaía sobre el fundo.

5. CONCLUSIÓN

Se puede descartar definitivamente la acusación de clandestinidad que se imputa generalmente, también por los romanistas, al sistema romano de derechos reales garantía. Es verdad que en Roma no existió ninguna forma de publicidad de la *conventio pignoris*, pero porque no hacía falta, ya que en ciertos casos no se creaba ningún conflicto con el tercero adquirente y en otros, en los que no se podía evitar el conflicto, se resarcía por el vendedor el perjuicio causado al comprador con el doble del precio pagado.

UT HONESTAS POSTULAT: EL CONTROL TRIBUTARIO EN EL TRÁFICO MERCANTIL

ROSALÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
Universidad de Almería

I. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL IMPERIO DE ORIENTE

El tráfico mercantil en los territorios del Imperio experimenta modificaciones en la Antigüedad tardía, que se intensifican en época protobizantina, como consecuencia de transformaciones a nivel institucional, de la geografía del planeamiento urbanístico, de la geopolítica, y de los nuevos equilibrios de poder que se van conformando. Consecuentemente, la economía pasa a estar basada fundamentalmente en las actividades del Estado, o de sus instituciones financieras y administrativas, en los territorios dentro del control político imperial¹. Un lugar destacado en el marco mercantil merecen las corporaciones que en tiempos de Justiniano se conforman con una tipología diversa²: De un lado, los Colegios obligatorios (estatales), y de otra los independientes. Los primeros operan en Constantinopla y están reguladas por el Prefecto de la Ciudad. Se dedican a la producción, venta y exportación de seda y textiles de alta calidad, obras de arte en oro, plata y metales preciosos, e iconos y manuscritos de lujo para la Corte, la Iglesia, y regalos diplomáticos. Estas corporaciones Incluyen también actividades estratégicas como la acuñación de moneda, manufactura de armas, minas de oro y plata; producción, distribución y venta de bienes básicos como la sal, aceite de oliva, trigo y vino; actividad de banqueros profesionales, notarios, prestamistas y cambistas. Por lo que se refiere a los Colegios independientes, actúan como asociaciones voluntarias con autogobierno. Estas asociaciones libres incluyen a comerciantes de importantes industrias (las edilicias, cristal, metal, madera, grano molido, lino, lana), y las profesionales (médicos, propietarios de barcos y mercaderes)³. Probablemente funcionan conforme a los mecanismos del mercado, con una ratio de beneficio impuesta por el Poder público.

1 MAAS,M., The Cambridge companion to the age of Justinian, Cambridge 2005, p. 35.

2 RAGUZ,A.M., The resilient Empire: Institutional reform in Byzantium, California 2007, pp. 81-82.

3 CHOISI,A., El arte de construir en Bizancio, Madrid 1997, pp. 180-185. GEANAKOPOLOS,D.J., Byzantium. Church, Society and Civilization seen through Contemporary eyes, Chicago 1984, pp. 293-298.

En este amplio periodo (330-610 d.C.) las más grandes ciudades del Mediterráneo, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Tesalónica, pertenecen al Imperio, y disponen de talleres, ferias y mercados para atender a las necesidades de una amplia población urbana y rural. Constantinopla, no sólo cuenta con un potente comercio sino también con un poderoso entramado fabril y artesanal que abastece de productos elaborados a todo el Mediterráneo. Tanto es así que sólo los talleres artesanales pertenecientes al patriarcado suman más de 1.100, y éstos en modo alguno superan en número a los que pertenecen a propietarios privados o al Emperador; la calidad de estos productos es supervisada no sólo por las asociaciones de artesanos, sino sobre todo por las autoridades. Gaza, Damasco y Tiro son también grandes emporios fabriles y comerciales que aprovechan las desgracias acaecidas en Antioquía para arrebatarse sus mercados tradicionales⁴.

Comparado con el sector agrícola, la industria privada y el comercio se desenvuelven a pequeña escala, focalizados en entornos urbanos⁵. El correo público mantiene la red de carreteras, e indirectamente las vías vecinales, reanimando las comunicaciones no gubernamentales⁶; y ello determina el nivel de comercio, aunque una grave dificultad estriba en el alto coste de los transportes. La actividad principal está en los puertos⁷, que ya en sí mismos se conciben íntimamente ligados a actividades mercantiles⁸. En este sentido Vizcaíno apunta que el Imperio se muestra como una potencia basada en el comercio marítimo, desde Inglaterra hasta Occidente, la India o el Mar Rojo, pues a modo de talasocracia el Poder público fundamenta su dominio en los puertos mediterráneos. Antes de entrar propiamente a abordar el control tributario del comercio en este periodo es importante tener claro el escenario en que se mueven *mercatores* y *negotiationes*.

Las ciudades han ido cambiando no solamente su fisonomía, sino también su funcionalidad. Desde el punto de vista urbanístico, ya desde el Bajo Imperio, los comercios tienden a trasladarse del foro y del ágora a las calles porticadas; no obstante, tales espacios persisten como elementos representativos en Oriente, y más raramente en Occidente (como es el caso en Italia, de Roma y Benevento)⁹. Aunque no hay una regla fija, pues, por ejemplo en Tesalónica, a diferencia de otras ciudades de los Balcanes, el ágora retuvo su significado

4 SOTO CHICO J., *Bizantinos, sasánidas y musulmanes cit.*, pp. 208-9, señala que ciudades como Alejandría contaban con un comercio que enlazaba Constantinopla por el Oeste con Britania, África, Sicilia e Italia, y por el Este con Siria, Abisinia, Arabia, India y Ceilán por el Este.

5 HALDON J.F., "Economy and administration. How did the Empire work", *Age of Justinian*, New-York-Cambridge 2006, p. 30. RAGUZ A.M., *The resilient Empire cit.*, pp. 75, 82-83.

6 Mc CORMICK M., *Origins of the European economy: Communications and Commerce AD. 300-900*, Cambridge 2001, p. 75.

7 DURLIAT J., "Les conditions du commerce au VI^e siècle", *The sixth Century: Production, distribution and exchange*, Leiden 1998, pp. 89-90.

8 D. 50,16,59: "Se llama puerto al lugar cerrado donde se importan y exportan mercancías"; Isid. Etym. 14,8,40: "El puerto es un lugar al abrigo de los vientos que suelen soplar en tiempos de invierno. Se le denomina puerto por el transporte de mercancías".

9 VIZCAÍNO SÁNCHEZ J., *La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII) cit.*, pp. 289, 354-359, escribe que aún en el s. VI d.C. se conserva el de Barcino. En Carthago Spartaria el foro parece haber perdido sus funciones (ideológica, administrativa y urbanística), y se muestra como una de las zonas que más informa sobre la desarticulación de su coherencia urbana, y ocupada por estructuras de tipo doméstico, inclusive vertederos, como consecuencia de la presión demográfica. En general se puede decir que en provincias los foros terminan utilizándose como áreas artesanales, funerarias, defensivas o de habitación.

comercial¹⁰; o en el Tratado de reglamentación urbana de la ciudad de Ascalón (s. VI d.C.) se protegen, entre otros bienes públicos, los pórticos públicos, las avenidas comerciales, los pasajes, las calles, las avenidas, y las plazas¹¹. Otro elemento reseñable en esta etapa se instala con el Cristianismo, al multiplicarse la edificación de iglesias en el tejido urbano, que indirectamente conlleva una revalorización de la zona, al activarse la actividad comercial con la afluencia de fieles y peregrinos.

Desde el punto de vista económico las ciudades se presentan a modo de aglomeraciones urbanas, centradas en sus funciones administrativas, que viven en simbiosis con el mundo rural circundante, con el que mantienen mutuos intercambios (artesanía, animales, etc.): Existe una correlación bastante nítida entre prosperidad rural y prosperidad urbana. Los pueblos son parte de una amplia red de intercambios, que engloba varias comunidades dentro de una región particular, de la cual los habitantes pueden obtener bienes y servicios que no producen ellos mismos, y a través de los cuales, quizá a través de una feria anual que se celebra en una particular fecha religiosa, pueden atraer comercio de zonas más alejadas. Sólo las grandes ciudades, fundamentalmente aquellas con acceso al puerto o al mar, disponen de recursos para importar bienes diversos a los locales, y principalmente de lujo. La dependencia entre centros distantes de producción es posible porque este tipo de comercio es sufragado por el gobierno imperial¹², que está interesado en el fomento de la actividad mercantil, con el fin último de cohesionar el Imperio; el comercio a larga distancia refleja la prosperidad de regiones donde ciertos bienes son producidos¹³.

El aprovisionamiento constituye, pues, un asunto importante de la vida social, lo que explica su utilización por el Emperador y las clases dirigentes para ganarse la simpatía de la población, y la presión a la que son sometidos los campesinos¹⁴. También para la revitalización urbanística es necesario disponer de materias primas y materiales constructivos elaborados. El comercio trata de procurar bienes indispensables o de lujo que faltan en el lugar, pero no se desenvuelven en base a la existencia de excedentes¹⁵; los productos de

10 CURTA,F., "Peasants as 'Makeshift Soldier por the Occasion': Sixth-Century Settlement Patterns in the Balkans", *Urban Centers and rural contexts in late Antiquity*, Michigan 2001, pp. 199-217. CURTA,F., *The making of the slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700*, Cambridge 2001, p. 124, escribe que en las ciudades del s. VI d.C. en la costa del Mar Negro se desplegó signos de prosperidad y actividad económica; un amplio grupo de mercaderes y artesanos de clase media asumieron las tareas tradicionales de los decuriones.

11 RODRÍGUEZ LÓPEZ,R., *Urbanismo y Derecho en el Imperio de Justiniano (527-565 d.C.)*, Madrid 2012, pp. 181-193

12 MAAS,M., *The Cambridge companion cit.*, p. 31. VIZCAÍNO SÁNCHEZ,J., *La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII) cit.*, pp. 289-290, al tratar de la Hispania bizantina, indica que mientras que las posesiones imperiales garantizan un abastecimiento intenso y diverso, complementando la iniciativa particular y la estatal, las zonas no dominadas por los *milites* sólo pueden confiar en la iniciativa privada, si bien la vecindad respecto a aquellas otras a veces juega a su favor. Para el éxito de la campaña de reconquista justiniana es importante el adecuado abastecimiento de los cuadros administrativos, religiosos o militares que se envían a la provincia de que se trate.

13 MAAS,M., *The Cambridge companion cit.*, p. 35.

14 DURLIAT,J., *De la ville antique à la ville byzantine: le problème des subsistances*, Roma 1990, pp. 559-562; 576-588, subraya que la población se sentía atraída por los repartos gratuitos o a bajo precio, y los empleos y las comodidades urbanas .

15 DURLIAT,J., *Les conditions du commerce au VIe siècle cit.*, pp.114-115.

lujo son demandados por las élites económicas, y se extienden a los artículos más diversos, desde bienes consumibles a no consumibles¹⁶. El comercio y la industria se ha retrotraído respecto a épocas pasadas, y la actividad económica deriva esencialmente hacia una agricultura *extra urbem*¹⁷. En Siria, por ejemplo, hay un desplazamiento de la actividad artesanal hacia los pueblos, con lo que decae el comercio con las ciudades, y se produce una huida de los artesanos hacia el campo; además, el crecimiento de los monasterios, absorbe artesanos y campesinos, lo que contribuye también al debilitamiento de las ciudades¹⁸.

Según Dragon, en Oriente existen ciertas aglomeraciones que no son ni ciudades ni pueblos, con población aproximada entre 1000 y 5000 habitantes, y que él califica como aldeas dependientes de grandes propietarios; su modo de vida es semiagrícola-semiciudadano, semiartesanal, y con un urbanismo incompleto. Estas Kômai tienen sus implicaciones fiscales, a veces simbolizadas a través de un Patrono, ya laico, ya eclesiástico, ya imperial¹⁹, con independencia respecto a la autoridad imperial²⁰. No obstante, estas unidades territoriales y urbanas son difícilmente individualizables, pues se analiza una época en la que el número y tamaño de las ciudades es muy desigual de una provincia a otra, con intereses comerciales, eclesiásticos y defensivos muy diversos a lo largo de todo el Imperio; y ello lleva a una evolución o involución de los centros poblacionales (ciudades, pueblos, aldeas, villas y centros religiosos), prácticamente imprevisible²¹.

II. FRONTERAS Y RELACIONES COMERCIALES CON OTROS PUEBLOS

El programa de reconstrucción de defensas fronterizas comienza en el 528 d.C., cuando el emperador Justiniano manda al general Belisario construir un puesto de avanzada en la frontera persa²². Esta actividad se potencia al hilo de la reconquista territorial del Imperio,

16 SODINI,J.P., "Le commerce des marbles à l'époque protobyzantine", *Hommes et richesses dans l'Empire byzantine, I (Ire-VII^e siècle)*, Paris 1989, pp. 163-186.

17 KODER,J., "The urban character of the early Bizantine empire: some reflections on a settlement geographic approach to the topic", *17 th. International Byzantine Congress. Major Papers*, Dumbarton Oaks/Georgetown University, Washington, D.C., August 3-8, New York 1986, p. 158.

18 MANGO,C., *Byzantium. The Empire of the new Rome*, New York 1980, p. 66.

19 BELL,H.I., "An Agyptian village in the age of Justinian", *Journal of Hellenic Studies* 64 (1944) pp. 21-36, expone como la aldea de Afrodito se pone bajo el patronazgo imperial de Teodora para seguir conservando su independencia frente al los grandes dominios privados.

20 DRAGON,G., "Entre village et cite: la bourgade rurale des IV^e-VII^e siècles en Orient", *Koinônia* 3 (Napoli 1979) pp. 29-52. Procop. Arc. 30,18-19 refiere que un rector de Cesarea de Palestina quiso compra una Kôme, y Justiniano anula la trasacción por estar fuera de comercio esta entidad local. No obstante, en la Nov. 24 (535 d.C.) el Emperador se alarma ante la radical independencia de las aldeas de Pisidia.

21 CURTA,F., *Peasants as 'Makeshift Soldier por the Occasion' cit.*, pp. 199-207, comenta que en muchos casos, antiguas ciudades se contrajeron y reagruparon en torno a acrópolis defensivas, normalmente dominadas por una iglesia; los núcleos urbanos se desintegraban en pequeñas unidades, y las antiguas villas rústicas se convertían en fuertes, siendo escaso tanto los asentamientos rurales como los monasterios. Los edificios se parcelaban, se reutilizaban los materiales arquitectónicos y las nuevas construcciones recurrían al ladrillo y al barro. Grandes ciudades se remplazaban por pequeños fuertes, la población urbana de la región se empobreció, y se concentró fundamentalmente en ciudades costeras. Las únicas edificaciones destacables eran las iglesias, con suelos cubiertos de mosaicos; y estas, a veces, obstruían la antigua red de calles.

22 EVANS, J.A.S., *The age of Justinian the circumstances of imperial power*, London 2007, p. 221.

enmarcada dentro de un plan más ambicioso, la *renovatio Imperii*, que directa e indirectamente beneficia al comercio²³. Así, por ejemplo, desde el 534 d.C., el Emperador reconquista África, Cerdeña y la costa meridional de España, lo que implica la reconstrucción de ciudades y de sus antiguos castillos, además de que planifica nuevas obras de defensa, especialmente desde el 540 d.C. Estas fortificaciones no sólo tienen una justificación militar, sino a veces también comercial²⁴. La obra de Procopio, *De aedificiis*, es un relato muy interesante para conocer esta concreta labor edilicia, pese a todas las objeciones que puedan realizarse.

Un efecto muy interesante de la vida en las zonas fronterizas está siendo puesto en valor por los arqueólogos, quienes han comprobado la dinamización de los territorios enemigos limítrofes a las fronteras del Imperio, como consecuencia de las relaciones comerciales, inevitables, entre la población de ambos lados de la línea divisoria; en este sentido, Curta señala que el proyecto edilicio de Justiniano en las fronteras del Danubio y en los Balcanes genera tal revolución comercial en la población bárbara que habita limítrofe al Imperio que es decisiva para la configuración de la entidad eslava²⁵.

La flota imperial une las cuencas del Mediterráneo oriental y occidental. En el Mediterráneo oriental circula una cerámica de una uniformidad insólita, que delata la existencia de una economía de consumo curiosamente homogénea, que funciona a impulsos de la demanda existente en un Imperio unificado²⁶. En este contexto, Constantinopla es el gran centro de intercambios entre los mundos europeo y asiático; como recuerda Teófanos en su Crónica, en esta ciudad hay muchas transacciones entre romanos y hunos²⁷. Pero también el mercado florece en otras regiones, como en Siria, que es un rico centro mercantil e industrial, y que importa productos de lujo, especialmente especias, gemas y seda. Constantinopla se beneficia del mediterráneo, que sigue siendo un espacio óptimo para el comercio, pese a la presencia de pueblos romano-bárbaros en algunos territorios de Occidente, con los que mantiene fluidas relaciones comerciales, como sucede entre bizantinos y visigodos²⁸. Respecto a Italia, Soto aporta pruebas de que es un mercado rico y provechoso para Alejandría. Los comerciantes italianos que adquieren estos cargamentos con bienes de lujo son inmensamente ricos e integrados en los grandes circuitos del comercio internacional de la época; y

23 La misma legislación justiniana reconoce la importancia de las nuevas políticas públicas en el comercio; así, por ejemplo, la Nov. 32, pr.: “Ya ciertamente hemos mejorado también otras muchas administraciones de provincias, que antes eran humildes y viles y no eran suficientes para utilidad alguna; pero como las constituimos en superior categoría, fueron hechas más capaces para todo y así amparan los negocios, de suerte que todo ha sido cambiado a mejor estado. ..., y hallamos la causa del mal en la debilidad creada a aquella administración ” (536 d.C.).

24 DE’ MAFFEI,F., Edificio di Giustiniano nell’ambito dell’Impero, Spoleto 1988, p. 4.

25 CURTA,F., The making of the slavs cit., pp. 120 ss.

26 BROWN,P., The rise of Western Cristendom. Triumph and Diversity, AD 200-1000, Oxford 2003, p. 114

27 Theoph. 176; MANGO,C.- SCOTT,R., The chronicle of Theophanes confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, Oxford 1977, p. 267.

28 MARIEZKURRENA,S.I., “Puertos y comercio marítimo en la España visigoda”, *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica* 11 (1999), pp. 135-160; D’ORS,A., “Los transmarini negotiatores en la legislación visigótica”, *Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al profesor C. Barcia Trelles*, Santiago de Compostela 1958, pp. 467-483.

esos posibles compradores de cargas tan valiosas sólo pueden ser los grandes terratenientes de Apulia, de Emilia, el Piceno y la región de Rávena. Hombres ricos cuya fortuna se basa en una fecunda tierra. Por ejemplo, los trigos italianos y sicilianos son tan abundantes y competitivos, que atraen la atención de Alejandría, ciudad comercial enclavada en un territorio cerealístico por excelencia²⁹. Ahora bien, los negocios no terminan en el negocio del grano (del Norte de África a Italia, y de Egipto a Constantinopla), sino que los capitanes de barcos aprovechan las oportunidades mercantiles de tales trayectos; así se les permite llevar una cierta cantidad de productos por su cuenta para la venta privada a cambio de un porcentaje del precio obtenido³⁰.

Ahora bien, estos son parte de los efectos de la diplomacia puesta al servicio de los intereses económicos en Occidente³¹, pero también se emplea para reforzar los contactos con pueblos del Mar Negro, Cáucaso y Caspio, llegando a Crimea y a Ceylan, en el deseo de adquirir nuevos productos en las rutas comerciales del océano Índico³². De manera similar los abisinios cooperan en sus objetivos comerciales con el Imperio romano, principalmente en productos de lujo³³. Las relaciones con la India son igualmente fluidas, como se desprende de la Topografía cristiana de Cosmas Indicopleustes, escrita hacia el 550 d.C. Igualmente los negocios con China son muy lucrativos, en concreto la importación secreta de gusanos del lejano Oriente, con lo que se logra la independencia del Imperio en un producto tan suntuoso y esencial para el mercado internacional³⁴, hasta el punto de constituir un artículo negociable de alta demanda, usado como sustituto del dinero, a modo de inversión patrimonial, o para regalos imperiales; el monopolio chino en la seda se rompe en el reinado de Justiniano, creándose respecto a este producto un monopolio estatal bizantino³⁵.

29 SOTO CHICO J., Bizantinos, sasánidas y musulmanes. El fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente. 565-642, Tesis doctoral, Granada 2010, pp. 199-200, refiere que a través de la Vida de Juan de Chipre conocemos que una gran flota de 13 barcos del tipo que los armadores egipcios llamaban "gacela" y que cargaban hasta 10.000 artabes de carga (es decir, 80.000 modios) era enviada por el Patriarca de Alejandría todos los años desde su ciudad a los puertos adriáticos de Italia. La flota comercial alejandrina enviada a Italia es tan importante y rica que la pérdida de la carga en una tempestad en el mar Adriático, una carga constituida por artículos de lujo (ricos vestidos con brocados de oro y plata, y frutas secas) es evaluada en 34 centenarios (244.800 sólidos de oro) y provoca una reunión de urgencia del consejo, de buena parte de la población de la ciudad y de su Patriarca.

30 MAAS, M., The Cambridge companion cit., p. 35.

31 BURY, J. B., *History of the later roman Empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian*, II, Dover 1958, pp. 292-333, & a la diplomacia y al comercio, y la bibliografía allí citada sobre el comercio durante el s. VI d.C.

32 La *renovatio imperii* exigía la aprobación de numerosas constituciones, a un ritmo que vendría calibrado por los diferentes acontecimientos políticos. Al respecto, PULIATTI, S., *Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare Della prefectura africana*, Milano 1980, pp. 2-21; 30, escribe que en el intervalo de poco más de un quinquenio, entre el 535 y el 539 d.C., se dictaron un conjunto de constituciones imperiales con el objetivo de reformar amplios sectores de la Administración periférica y algunos de la Administración central. Sobre la *renovatio imperii*, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., *Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano*, Murcia 1997, pp. 147-148.

33 BARKER, J. W., *Justinian and the later Roman Empire*, Wisconsin 1966, p. 129.

34 MAIER, F. G., *Bizancio*, Buenos Aires 2002, p. 53.

35 RAGUZ, A. M., The resilient Empire cit., p. 77.

III. JUSTINIANO Y EL CONTROL TRIBUTARIO DE LAS ACTIVIDADES MERCANTILES

La expresión “*Ut honestas postulat*”, inserta en el título de este artículo, se extrae de una constitución de Valentiniano y Valente del 364 d.C. (C. 4,63,1), haciendo hincapié en el principio fiscal de satisfacción de impuestos³⁶; actuación que ha de realizarse por los contribuyentes conforme al decoro³⁷. Ya Constantino había establecido tiempo atrás la *collatio auri et argenti*, que recaía sobre los *negotiatores* o mercaderes que compraban o vendían cualquier objeto. Los *negotiatores* tenían la obligación de inscribirse en la matrícula de su ciudad, por lo que era difícil escapar de esta imposición. Anastasio suprime este impuesto y destruye sus registros, en beneficio de los comerciantes de las ciudades; la *collatio* no es suprimida en Occidente, y continúa vigente con la reconquista justiniana de Italia³⁸. En el texto también se incluía a mendigos y prostitutas; la reputación de comerciantes había sido baja desde tiempos de la Antigua Roma. De ahí que se prohíba a los curiales, a las clases altas³⁹, clérigos y demás miembros de la jerarquía eclesiástica dedicarse al comercio⁴⁰. Ahora bien, grandes propietarios, especialmente en el Norte de África, funcionan como empresas privadas con comercio sobre el cultivo de sus explotaciones agrícolas, así como operaciones a pequeña escala de cultivo comercial. Esta producción es sometida a im-

36 Véase al respecto, FÉRNANDEZ DE BUJÁN, A., “*Ius fiscale*: Instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario”, *Estudios en Homenaje al prof. Rodríguez Bereijo, I*, Madrid 2010, pp. 103-134.

37 C. 4,63,1, Emperadores Valentiniano y Valente: “Sean requeridos, como lo exige el decoro, los negociantes, si algunos pertenecen a nuestra Casa, y también los dependientes de los potentados, a satisfacer la debida necesidad de impuestos, de modo que a todos los que buscan los emolumentos en las negociaciones se les haga tolerables los efectos de la contribución que deben pagar” (364 d.C.).

38 AGUDO RUÍZ, A., “Observaciones sobre algunas leyes fiscales del emperador Anastasio”, *Iustel* 15 (2010) pp. 12-13.

39 DURLIAT, J., *Les conditions du commerce au VIe siècle cit.*, p. 110, el comercio es prohibido por ley para los curiales, por lo que un comerciante que entra en la Curia debe vender su “empresa” y comprar tierras con ese dinero (CTh. 12,1,72). Las clases altas son consumidores, no comerciantes (CTh. 4,63,3), aunque quizá actúan como prestamistas; tienen honores y patrimonio, y no deben ejercer comercio peligroso para las ciudades, sino dejar a los plebeyos y comerciantes vender y comprar entre ellos. C. 4,63,3, Emperadores Honorio y Teodosio: “Prohibimos que los más nobles por su nacimiento, y los conspícuos por el brillo de sus honores, y los más ricos por su patrimonio, ejerzan el comercio, pernicioso para las ciudades, a fin de que entre plebeyos y comerciantes sea más fácil el comercio para comprar y vender”.

40 Nov. 56,1: “Porque queremos que los servicios y los ministerios del señor Dios se desempeñen no mediante venta, ó por comercio alguno, sino puramente y sin tráfico; porque así se harán dignos de la cosa, no haciéndose ninguna venta y negociación”. No obstante, en C. 1,3,2, Emperador Constancio se aclara: “... porque si hubieren acumulado o con su economía, o con su previsión, o con su comercio, compatible sin embargo con su honestidad, deberá destinarse para uso de los pobres y de los necesitados, ...”. HOLLERICH, M. J., “The alexandrian bishops and the grain trade: Ecclesiastical Commerce in late Roman Egypt”, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 25,2 (1982) pp. 187-207, señala que se percibe una intensa labor en el comercio del grano de los Obispos de Alejandría con todo el Imperio romano. También sobre las actividades comerciales de la Iglesia, véase Nov. 60,2 “Es, por tanto, conveniente que á los ecónomos y a los defensores, amantes de Dios, se les conserven siempre, exentos de tributos y sin disminución, los susodichos mil cien obradores, y que hayan de ser suplidos por el gloriosísimo Prefecto de esta feliz ciudad, si de algún modo ocurriera la pérdida de alguno, ó cambio en el aspecto ó en el comercio de ellos, ...”.

sición⁴¹. Igualmente el Poder público (emperadores Honorio y Teodosio) se inmiscuye en la organización interna de los *collegia* o corporaciones, determinando incluso el número máximo de miembros, y ello para aumentar el control fiscal de sus actividades⁴². Con la misma finalidad se prohíbe que, sin autorización del Conde del comercio, se de albergue a comerciantes extranjeros, bajo pena de confiscación de bienes y destierro perpétuo; es decir, estamos hablando de nuevo de licencias, y de control fiscal de estas actividades lucrativas⁴³.

Justiniano se encuentra en el 527 d.C., con una serie de factores complejos⁴⁴, y la supervivencia del Imperio pasa irremediamente por la adopción de medidas urgentes para emprender reformas sociales, económicas y administrativas, y promover la estabilización social, que afecta a la actividad comercial, y al aumento de las cifras tributarias, como medios indispensables para la feliz ejecución de sus planes⁴⁵. La corrupción está extendida a todos los ámbitos y niveles, y el comercio tampoco queda libre de sospechas. Ya en el prefacio de la Nov. 8 (535 dc.) el Emperador censura la injusticia y violencia ejercida desde hace tiempo sobre los súbditos, a quienes se les ha reducido a la inopia, corriendo el riesgo de llegar a extrema penuria y de no poder pagar los legítimos tributos; por ello reclama a los Presidentes de las provincias una política de manos limpias. Por tanto es posible que algunas autoridades recaudatorias fueran fraudulentas, por la dificultad real de ejercer un control exhaustivo de sus funciones, pero ello se realiza vulnerando el régimen legal vigente; subraya el texto legal que en este contexto incluso se produce “la confusión de los actos de comercio”⁴⁶. Con la reconquista territorial de parte de las provincias del antiguo Imperio romano, Justiniano intenta también controlar los flujos comerciales y las implicaciones fiscales del mundo mercantil. Así, por ejemplo, en la Nov. Const. 1,26 (*Pragmatica sanctio*)

41 MAAS.M., *The Cambridge companion* cit., p. 37.

42 C. 4,63,5, Emperadores Teodosio y Honorio: “Cesando toda ambición, y toda licencia, subsista el número de quinientos sesenta y tres colegiados, y a nadie le quede facultad para aumentarlos o cambiarlos, ...”.

43 C. 4,63,6, Emperadores Teodosio y Honorio: “Si se hubiese descubierto que algunos pasaban de las ciudades designadas nominalmente en las antiguas leyes, o que sin autorización del Conde de comercio daban albergue a comerciantes extranjeros, no se librarán ni de la proscripción de sus bienes, ni además de la pena de destierro perpétuo. ...”.

44 RODRÍGUEZ LÓPEZ.R., “*Debitorum publicorum*. Un outil pour la *renovatio imperii*”, RIDA 59 (2011) pp. 339-340, enumero diversos factores: problemas migratorios; ruptura de los vínculos de los tributarios emigrados con los lugares propios en los que estaban censados; debilitamiento de las estructuras municipales y desprestigio de sus curias, así como fortalecimiento del poder de las villas rústicas, y con ello la retracción de la actividad artesanal, y el abandono de la tierra por parte de los medianos y pequeños inversores; huida de los colonos explotados; revueltas sociales, bandolerismo e inestabilidad de las fronteras de la Romanía; y con ello, también la pérdida de muchas rutas comerciales; crisis de orden público por la extensión del banditaje, de la delincuencia organizada y de la violencia.

45 MAIER.F.G., *Bizancio* cit., p. 52. Sobre el conjunto de medidas político-administrativas adoptadas, véase BONINI.R., “La última legislación publicista de Justiniano (543-565)”, *Discursos pronunciados en el acto de investidura como doctor ‘Honoris Causa’ de R.Arié*, R.Bonini, A.Fiori, Granada 1988, pp. 51-83.

46 Nov. 8: “...Porque, ¿quién no robará sin peligro, quién no cometerá latrocinios sin culpa, mirando al que ejerce la administración? Porque viendo que éste todo lo vende por dinero, y confiando en que cualquier cosa ilícita que hubiere hecho la redimirá dando dinero, nacerán de aquí los homicidios, los adulterios, las invasiones, las heridas, los raptos de vírgenes, la confusión de los actos de comercio, y el menosprecio de las leyes y de los jueces, juzgando todos que estas cosas están expuestas a la venta, como si fueran algún vil esclavo” (535 d.C.).

se dirige a los poseedores de las provincias de Calabria y de la Pulla para comunicarles que se prohíbe a los *negotiatores* repercutir el gravamen fiscal de la transacción⁴⁷.

Y al igual que anteriormente hemos comentado como la corrupción e inestabilidad social afectan a la actividad mercantil, también inciden negativamente las revueltas y sediciones. En la ciudad de Constantinopla durante la revuelta de Nika el fuego alcanza el *Praetorium*, y los insurrectos destrozan los archivos que albergan la información sobre tasas e impuestos, y durante los días que dura la revuelta no se celebra ningún tipo de comercio en Constantinopla⁴⁸.

Una cuestión a tener muy presente es la relativa monetarización del mercado, lo que implica que desarrollándose los intercambios comerciales en general sin apenas transferencia de moneda⁴⁹, el sistema monetario juega un papel esencial en la promoción de la actividad económica; fundamentalmente el sólido de oro es el pilar del sistema y provee un consistente estandar de valor. Los *solidi* son estimadas incluso en Ceilán y considerados la divisa del Imperio más grande del mundo⁵⁰. Además, el sistema impone una tasa a las transacciones comerciales⁵¹. La carga de impuestos sobre el comercio y la artesanía es cada vez mayor⁵². El comercio terrestre está gravado con un impuesto personal, que afecta a los beneficios del comercio. Tradicionalmente se había aplicado un impuesto por el valor de un octavo de los beneficios obtenidos en las ventas en el mercado (la *Octava*). Otros derechos son percibidos por los Prefectos del Pretorio sobre patentes para determinados productos y para las marcas de fabricación; especiales funcionarios se encargan de aplicar los punzones de control sobre piezas de plata o de orfebrería que garantizan la pureza de tales metales. El máximo de calidad es representado por cinco incisiones de punzón⁵³.

Las aduanas existen a la salida y entrada del puerto de Bizancio, para exigir una tarifa a la importación. En la Nov. 80 (539 dc.) se establece que el Cuestor sitúe puestos de vigilancia de la inmigración, pero que sin duda son también aprovechados con fines aduaneros; la libertad aduanera concedida como privilegio a los militares es suprimida en un momento

47 Nov. Const. 1,26 (Pragmatica sanctio): “Ut per negotiatores coëmptiones fiant: Además de esto hemos sabido que a los poseedores de las provincias de Calabria o de la Pulla se les impuso, para que no hubieran de ingresar las compras, un título de recargo por cada millar, por lo que las compras se hacían cada año por negociantes, pero que al presente los negociantes intentando rehusar las compras de especies amenazan a los poseedores de la provincia tanto con el título de recargo, como con el gravamen de la compra; y siendo muchos los mercaderes por medio de los que se puede hacer la compra, mandamos, que, examinando esto tu grandeza, se ingresen, si es posible, por negociantes las especies compradas, y de ningún modo sean gravados los contribuyentes de la provincia, porque, una vez que se les ha impuesto el título de recargo, sería imposible que levantaran también la carga de la compra” (554 d.C.).

48 *Chronicon Paschale*, p. 621-628. WHITBY,M.- WHITBY,M., *Chronicon Paschale* 284-628 A.D., Liverpool 1989, pp. 118-127.

49 DURLIAT,J., *Les conditions du commerce au VIe siècle cit.*, pp. 94-95, 115. Por el contrario, SARRIS,P., *Economy and Society in the Age of Justinian*, New-York-Cambridge 2006, descubre a través de los papiros egipcios de Oxirrindo evidencias de un modo de explotación agrícola de las élites locales provinciales que estaba racionalizado, fuertemente comercializado y monetarizado, y bien conectada con la Corte imperial.

50 BROWN,P., *The rise of Western Christendom cit.*, p. 114

51 HARVEY,A., “The economy”, *The Oxford handbook of Byzantine Studies*, Oxford 2008, p. 631.

52 MAIER,F.G., *Bizancio cit.*, p. 53.

53 DI RENZO,F., *Il sistema tributario romano*, Napoli 1950, p. 208.

incierto, entre el 365 dc. y la época de Justiniano⁵⁴; con anterioridad a este emperador los derechos sobre la circulación de mercancías se aplicaban sólo a las naves que tocaban Constantinopla⁵⁵. En los puertos situados en Abidos sobre el Helesponto y los sitios sobre el Bósforo, los agentes fiscales tienen la única función de asegurarse que las naves no transporten armas, ni productos prohibidos a la importación, y que tengan todos los registros de a bordo en regla⁵⁶. La innovación de Justiniano es transformar estos puestos de policía (que exigían el pago derechos portuarios) en aduanas⁵⁷; encargándose los agentes de aplicar los derechos de aduana a la importación de mercancías en la misma medida en que son exigidos en el puerto de Constantinopla⁵⁸. Tales funcionarios reciben un salario fijo y un porcentaje de la recaudación. Respecto a las tasas sobre la exportación siguen percibiéndose en Constantinopla⁵⁹. También es controlado en estos puestos el tráfico de armas y las mercancías permitidas y prohibidas en el comercio con los bárbaros. Justiniano recoge en el Código,

54 Nov. 80,9: “Mas le damos al que tenga esta magistratura facultad ...si bien le pareciere situar a algunos de sus oficiales en puntos del otro lado del mar, para que también averigüen quiénes vienen de fuera, y recogiendo a los que de aquí fueron remitidos los dirijan a las provincias, hágalo también persiguiendo por todos los medios lo que es útil a la República” (539 d.C.)

55 Sobre la historia de este impuesto, ZAMORA MANZANO, J.L., *Algunos aspectos sobre el regimen fiscal aduanero en el derecho romano*, Madrid 2009.

56 Procop. Arc. 6,24,33: “A ambos lados de Bizancio existen estrechos, uno en el Helesponto entre Ses-tos y Abidos, el otro en la desembocadura del Ponto Euxino, donde está situado un lugar llamado Hierón. Ahora bien, en el estrecho del Helesponto no había existido nunca una aduana oficial, pero un funcionario enviado por el Emperador se situaba en Abidos, y vigilaba a los barcos que llevaban armas a Bizancio sin el consentimiento del Emperador, y a los que partieran de Bizancio sin llevar los correspondientes papeles firmados por los oficiales adecuados; porque nadie puede salir del Puerto de Bizancio sin haber pasado antes por el despacho del Magister. Otro deber del representante del Emperador consistía en obtener de los propietarios de los barcos un peaje que no hacía daño a nadie pero era una especie de tarifa que el magistrado consideraba que le correspondía como recompensa por las molestias que se tomaba. ...En cuanto Justiniano hubo ascendido al trono, estableció aduanas en ambos estrechos, enviando regularmente a dos funcionarios asalariados”.

57 Justiniano reguló el portazgo al tratar de las provincias egipcias y alejandrinas, en relación con el trigo que había de exportarse a Constantinopla (Edicto 13,7-8): “... Queremos, pues, que en lo sucesivo no tenga el cobrador de los portazgos facultad para inmiscuirse en cualesquiera tributos públicos, hacer condonaciones a algunos deudores, recibir las que se llaman gratificaciones, descuidar por ellas los tributos fiscales, exigirles a otros más de lo que es justo, y a algunos con más rigor y de manera no acostumbrada, y dar con ello ocasión y principio a la perturbación de esta cosa, pretendiendo siempre que no se pueden rehusar los portazgos, pero buscando con la perturbación de la cosa su propio provecho, desatendiendo ciertamente las cajas de tu tribunal, e intentando igualmente atraerlo todo a sí por causa de lucro. Mas como tu excelencia, gobernándolo todo diligentemente, nos manifestó, cuanto importa reunido el canon de portazgos, que por Alejandría se satisface, esto es, ochenta mil sueldos, y como también la feliz remesa de trigo ascienda a ochenta mil, queremos que de las indicadas provincias, y por las ciudades, lugares y rentas se les den al cobrador de los portazgos estos ochenta mil sueldos. ...; y soporte el prefecto augustal en unión de su cohorte, al mismo tiempo en todo el trabajo y la responsabilidad juntamente con el mismo cobrador de los portazgos, con sus tribunos en aquellas localidades, porque es conveniente que de todos modos se complete el importe de los portazgos, y se le dé al cobrador, que los invertirá del modo conveniente y acostumbrado, y se los entregará por toda la contribución pública a los patrones de naves...”.

58 OIKONOMIDÈS, N., “Commerce et production de la soie à Byzance”, *Hommes et richesses dans l'empire byzantin, IV-VIe siècle, I*, Paris 1989, pp. 187-192; DURLIAT, J., “La peste du VIe siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines”, *Hommes et richesses cit.*, pp. 187-193. DI RENZO, F., *Il sistema tributario romano cit.*, p. 207.

59 DE LAET, S. J., *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque de Haut-Empire*, Bruges 1949, pp. 469-477, menciona que aunque no se saben las tarifas aplicadas, debieron de ser

bajo el título “De los comerciantes y de los mercaderes” diversas constituciones imperiales que regulan las materias que se permite traficar con los bárbaros⁶⁰, incluso los límites geográficos dentro de las fronteras persas hasta donde pueden celebrarse ferias, bajo pena de confiscación⁶¹. En estos puestos de control se persiguen negocios ilegales tales como la producción armamentística privada, ajena al control público⁶², y el tráfico de “blancas”⁶³.

Procopio, en su controvertida y desgarradora descripción del reinado de Justiniano, nos pone en la pista de datos que luego son confirmados por otras fuentes:

- a) Procopio acusa a Justiniano de no seguir el uso de las *laxitates*, tradicional en los emperadores precedentes⁶⁴, y de que “prácticamente toda la población se encontró de súbito reducida a la mendicidad”⁶⁵. No obstante, los hechos no se producen exac-

altas, pues forzaban a los comerciantes a mantener precios muy elevados para sus mercancías; y cita a Joh Mal. 18,432, quien situó la reforma justiniana de las aduanas entre el 528-529 d.C.

60 C. 4,63,2, Emperadores Valentiniano y Valente: “No solamente no se les dé en manera alguna oro a los bárbaros, sino que por el contrario se les quite con sutil ingenio, si se hallare en poder de ellos. Si en lo sucesivo se hubiere llevado por los mercaderes a los países bárbaros oro en pago de esclavos, o de cualesquiera especies, quedarán sujetos no ya a daños, sino a suplicios...”.

61 C. 4,63,4, Emperadores Teodosio y Honorio: “Los comerciantes, tanto los sujetos a nuestro Imperio, como los que al rey de los Persas, no deben de ninguna manera celebrar ferias más allá de los lugares en que se convino entre nosotros, y la mencionada nación al tiempo de la alianza, a fin de que no escudriñen los secretos del otro reino, cosa que no es conveniente. ... lugares prohibidos para comerciar ...”.

62 Nov. 86,1-3: “... los operarios de armería no las vendan a ningún particular, ni los armeros, ... Guarden también esto los que están destinados a los depósitos de ballestas bajo la responsabilidad de los padres de las ciudades, bajo cuya dependencia constituimos también a los mismos ballesteros, y pusimos el cuidado y guarda de los depósitos públicos de armas, de suerte que si se viere a algunos o diputados, o fabricantes de armas, que venden armas, provean los jueces de las localidades que sean ellos sometidos a suplicios, y quitenles además sin precio las armas □ los que las compraron, y reivindíquelas para el fisco. Así, pues, imponiéndonos Dios este pensamiento, mandamos por la presente ley, que en ninguna ciudad o provincia de nuestra república tengan licencia los particulares u otro cualquiera para hacer o vender armas, o de cualquier modo comerciar con ellas, sino que solamente los que están comprendidos entre los fabricantes de armas las construyan y las lleven a nuestro sacro depósito de armas. ... en ninguna ciudad o provincia ” (539 d.C.).

63 C. 1,4,33.pr.: “A aquellos que en cualquier provincia arrastran a la escena o a la orquesta, contra su voluntad a una mujer (libre o esclava), así como los fiadores que las obligaban, y aquellos que les prohibían apartarse de ese comercio, se les confiscan sus bienes y se les expulsa de su ciudad” (534 d.C.); C. 5,4,29.

64 Procop. Arc. 6,23,9: “En Segundo lugar, los medos y los sarracenos habían assolado la mayor parte de Asia, y los hunos y eslavos, el resto de Europa; habían arrasado con algunas ciudades y obligado a otras a pagar hasta la última moneda; se habían llevado poblaciones enteras con todas sus pertenencias en calidad de esclavas, y habían vaciado en sus invasiones diarias a cada distrito de sus habitantes. Sin embargo Justiniano no eximió a nadie de sus impuestos, excepto que relevó a las ciudades cautivas de sus impuestos por un año. Y, sin embargo, si, como el emperador Anastasio, hubiera decidido aliviar a las ciudades cautivas de todos los pagos por un periodo de siete años, creo que aún así hubiera hecho menos de lo que debiera, considerando que Cabades había causado un daño mínimo a los edificios marchándose luego, en tanto que Cosroes había incendiado ciudades enteras...”. BARROS MONTESINO, J.-H., En torno a la idea de restauración del Imperio romano bajo el gobierno del emperador Justiniano I (527-565 d.C.), Tesis doctoral. Chillán 2008, p. 50, escribe que desde tiempos muy antiguos se utilizaba como costumbre que la persona que estuviese al frente del Imperio eximiera a sus súbditos de los atrasos en el pago de sus deudas hacia el Estado, para que los que no tuvieran recursos y no tenían medio alguno para pagar los atrasos no se vieran en la necesidad de dar pretextos a los recaudadores. Esta medida nunca fue utilizada durante el gobierno de Justiniano; por esta razón quienes carecían de recursos tuvieron que huir abandonando las tierras después de entregar sus bienes a los delatores o al Fisco.

65 Procop. Arc. 3,25.

tamente así, pues ante la penuria de una gran parte de la población, el Poder público emite condonaciones a los incumplidores fiscales⁶⁶. Indica Bonini que se pueden individualizar en este periodo tres condonaciones generales a los deudores fiscales entre los años (527 ó 528; 544 ó 545; 554 d.C.)⁶⁷; y efectivamente para comprender el fundamento de estas condonaciones se puede atender a diversas variables⁶⁸, aunque la más importantes es la puramente económica, conforme a la cual es necesario no despauperizar a la sociedad por una triple consideración: no axfisiar el flujo del pequeño comercio afectado por la falta de capacidad adquisitiva de los súbditos, y no acrecentar el número de personas dependientes de los servicios estatales y eclesiásticos, así como la bajada de los niveles de salud de la población⁶⁹.

- b) Procopio en su afán de desprestigiar la política imperial arremete contra la política exterior, convirtiendo los frutos de los tratados de paz en fracasos civiles y económicos⁷⁰. Es cierto que Justiniano, para contrarrestar el poder de Persia, inicia una política de alianzas con otras grandes potencias que, llegado el caso, pueden transformarse en peligrosos rivales de Persia, al tiempo que trata de quebrar la hegemonía comercial de ésta sobre el comercio con Arabia meridional, India y China. Así con tales alianzas Justiniano logra establecer un cerco diplomático-militar en torno al pueblo enemigo, y privarlo de una de sus mayores fuentes de ingresos monetarios: la procedente de sus aduanas con el Imperio⁷¹. Ciertamente, la paz con los persas en el 561-562 d.C. requiere el pago de grandes cantidades de oro⁷², pero también supone la tranquilidad del comercio y de la ciudadanía, y la permanencia de los ingresos de las aduanas.
- c) Procopio Igualmente se refiere al intervencionismo estatal, emitiendo un juicio muy crítico sobre los monopolios⁷³, la regulación máxima de precios, el mercado negro, y

66 DURLIAT,J., Les conditions du commerce au VI^e siècle cit., p. 107.

67 BONINI,R., “La última legislación publicista de Justiniano (543-565)”, Discursos pronunciados en el acto de investidura como doctor ‘Honoris Causa’ de R.Arié, R.Bonini, A.Fiori, Granada 1988, p. 77.

68 PATLAGEAN,E., *Povertà ed emarginazione a Bisanzio, IV-VII secolo*, Roma 1986, p. 188, profundiza en las diversas causas de condonación de los débitos fiscales tenidas en cuenta por Justiniano durante su mandato.

69 MORLEY,N., “The poor in the city of Rome”, *Poverty in the Roman World*, Cambridge 2006, p. 32, al abordar el estudio sobre la pobreza en la Antigüedad, señala que es evidente que una dieta pobre afecta a la salud y a la capacidad para trabajar.

70 Procop. Arc. 2,8,10: “De tiempo en tiempo entraba en contacto con los hunos, y los regaba con dinero, por ‘servicios al Estado’. El resultado inevitable era que el territorio romano estaba expuesto a constantes incursiones”; Procop. Arc. 3,11,11: “Estos jefes comenzaron de inmediato la esclavización del Imperio romano, siendo pagados continuamente por el Emperador. Su ejemplo fue seguido por otros, que se unieron al pillaje de los infortunados romanos, y, estando en la cumbre de éste, recibieron como recompensa por sus correrías la extravagante largueza del Emperador”.

71 MAIER,F.G., Las transformaciones del mundo 2mediterráneo: siglos III-VIII, Madrid 1994, p. 197; SOTO CHICO,J., Bizantinos, sasánidas y musulmanes cit.010, p. 106.

72 MAAS,M., “Roman questions, byzantine answers. Contours of the age of Justinian”, *Age of Justinian*, Cambridge 2005, p. 8. También al respecto GREATREX,G., “Byzantium and the East in the sixth century”, *Age of Justinian*, Cambridge 2005, pp. 477-509.

73 Procop. Arc. 6,24,33: “A ambos lados de Bizancio existen estrechos, uno en el Helesponto entre Sestos y Abidos, el otro en la desembocadura del Ponto Euxino, donde está situado un lugar llamado Hierón. Ahora bien, en el estrecho del Helesponto no había existido nunca una aduana oficial, pero un funcionario enviado por el Emperador se situaba en Abidos, y vigilaba a los barcos que llevaban armas a Bizancio sin el consentimiento del Empera-

la emigración de comerciantes a Persia⁷⁴. Respecto a este último efecto, un Tratado bizantino-persa del 562 d.C. refuerza la importancia del comercio oficial de ciudades y rutas, para combatir así el contrabando ilegal, y para reforzar la recaudación fiscal⁷⁵; en dicho Tratado se especifican los temas comerciales a tratar, que son de gran relevancia⁷⁶. Justiniano crea un monopolio imperial en la fabricación de armas, y de hecho un monopolio del tejido de la seda en las fábricas imperiales, gestionadas por los *Sacrae largitiones*⁷⁷.

Para finalizar, mencionar que en el prólogo de un Tratado militar anónimo del s. VI d.C. se hace referencia a los comerciantes y al control tributario del tráfico mercantil. El texto es rico en información⁷⁸; y por lo que se refiere a los inspectores de Hacienda dice entre otros: “Serán hábiles en la investigación de los hechos, ...”. Con medidas intervencionis-

dor, y a los que partieran de Bizancio sin llevar los correspondientes papeles firmados por los oficiales adecuados; porque nadie puede salir del Puerto de Bizancio sin haber pasado antes por el despacho del Magister. Otro deber del representante del Emperador consistía en obtener de los propietarios de los barcos un peaje que no hacía daño a nadie pero era una especie de tarifa que el magistrado consideraba que le correspondía como recompensa por las molestias que se tomaba. ...En cuanto Justiniano hubo ascendido al trono, estableció aduanas en ambos estrechos, enviando regularmente a dos funcionarios asalariados. ...puso casi todos los artículos de consumo en manos de los ‘monopolios’, oprimiendo así inexorablemente a los posibles compradores, salvo las roperías... hoy en día, el Tesorero ocupa abiertamente el puesto de único importador y revendedor de esta mercancía (la manufactura de prendas de seda)... Año tras año todo el beneficio de este comercio iba a parar a manos de un hombre, el Tesorero, pero se guardaba el grueso para él, enriqueciéndose a costa de la miseria pública...”. Al respecto, EVANS, J.A.S., *The Empress Theodora: Partner of Justinian*, Texas 2002, p. 57.

74 Sobre la vitalidad del Imperio persa durante el s. VI d.C., véase HOLMES, W.G., *The age of Justinian and Teodora: A history of sixth century*, London 1905 (reed. 2002) pp. 365-419.

75 FELTHAM, H.B., “Justinian and the International Silk Trade, *Sino-platonic papers* 194 (2009) pp. 1-39.

76 Men. Hist. 6,2-5: “[2] ni los persas atacarán a los romanos, ni los romanos a los persas. Conducirán sus negocios conforme a la práctica establecida a través de los específicos puestos aduaneros (Esto es, según lo dispuesto en C. 4,36,4); [3] Los mercaderes romanos y persas de todo tipo de productos, así como similares comerciantes; [4] Los embajadores y otras personas que usen el correo público para entregar mensajes, tanto los que viajen hacia territorio romano o persa, serán cada uno de ellos honrado de acuerdo a su status y rango, y recibirán la atención apropiada. Ellos deberán ser devueltos sin retraso, y ellos podrán intercambiar los productos de comercio que ellos trajeron sin impedimento o cualquier impuesto; [5] Está acordado que los sarracenos y todos los demás comerciantes barbaros de cualquier estado no viajaran por carreteras extrañas, pero pasaran por Nisibis y Daras, y no se internarán en territorio extranjero sin permiso oficial. Pero si ellos se atreven a algo contrario al acuerdo (es decir, si ellos tratan de evadir los impuestos), ellos serán perseguidos por los oficiales de frontera y entregados para su castigo junto a la mercancía que ellos portan, ya asiria o romana”.

77 SCARCELLA, A.S., *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, pp. 397-402, explica como León I prohibió la concesión de monopolios privados (C. 4,59,1), y Zenón puso las bases para la creación de monopolios imperiales (C. 4,59,2).

78 Al respecto, DENNIS, G.T., *Three byzantine military treatises*, Washington 1985. Anom. Strat. 15-31: “(15) Luego viene la clase mercantil, que incluye los comerciantes de grano, de vino, de carne. Hay quienes ofrecen productos de moda de varios materiales, tales como el hierro y el cobre. Luego vienen los que alquilan sus servicios a los directores de obras públicas, los portadores de madera y piedra. (25) El Comercio prevé necesidades. Nadie tiene todo lo que necesita. Pero la actividad comercial permite a cada persona proveerse de las cosas que le falta. (28) Los Mayoristas nos dan los materiales, por lo que los proyectos no tienen que ser abandonados debido a la escasez de material. Muy a menudo podemos tener mucho dinero, pero puede estemos sin ninguno de los bienes que necesitamos. Varias personas, (30) entonces, nos proporcionan hierro, nafta, o lo que sea necesario a cambio de oro o plata”. Véase al respecto, RODRÍGUEZ LÓPEZ, R., “El arte de gobernar y los deberes ciudadanos en un Tratado del s. VI d.C.”, *Revista General de Derecho Romano* 16 (2011) pp. 1-24.

tas el Poder público vela para que el comercio se desenvuelva dentro de unas prácticas de buena conducta⁷⁹. De nuevo vuelve el tema que marca el título de este trabajo: “*Ut honestas postulat*”.

IV. NOTAS CONCLUSIVAS

En la sociedad estamental protobizantina los comerciantes no gozan de una estima social elevada, pero su presencia, incluso su bonanza, es signo incontestable de prosperidad. En este periodo la economía es fundamentalmente agraria, pero incluso en esta situación el mercado fluye, como se percibe en la celebración de ferias a nivel local y regional⁸⁰. Justiniano es muy consciente de la importancia de la actividad mercantil para el éxito de su *renovatio imperii*, y para ello genera todo un contexto propicio, con un ambicioso plan de reforma y mejora de las estructuras públicas. Los triunfos militares se ligan a la *pax romana* (mantiene el *limes* del Danubio y del frente oriental, recupera África, Italia, las islas del Mediterráneo occidental y el sureste de España, además de determinados territorios en la frontera Oriental), así como aumenta el poderío militar de la Romania; lo que tiene efectos directos e indirectos sobre el comercio. Además, como una inversión para revitalizar la economía, se aumentan los niveles de gasto respecto a los emperadores inmediatamente precedentes. Urbanísticamente se asienta un nuevo modelo de ciudad, la ciudad cristiana, para suplir la decadencia del modelo de ciudad antigua, y con ello se favorece la vida ciudadana y el comercio.

Pero, Justiniano tiene que enfrentarse en el desempeño del gobierno a otras cuestiones mayores, de gran gravedad, como son las epidemias de peste, los terremotos, y los ataques de pueblos bárbaros, que debilitan los esfuerzos por estabilizar la actividad mercantil a lo largo y ancho del Imperio⁸¹; la peste diezma la población urbana y cae en picado la

79 Anom. Strat. 77-87: “Los supervisores del comercio deben tener un buen sentido de la justicia y estar familiarizados con las operaciones comerciales en general. No deben permitir a los vendedores defraudar a sus clientes mediante la mezcla de bienes de menor calidad o para hacer una ganancia excesiva. Esto es particularmente cierto en la venta de productos alimenticios, y cualquier persona que cobra (80) un precio excesivo debe ser castigado. Aquellos que proveen los materiales deben ser ingeniosos y deben comprender a fondo su trabajo. Deben procurar el material cercano a la casa, no desde una gran distancia. Deben proporcionar productos sin defectos. Muchos mayoristas son culpables de la mezcla de sus productos. Algunos los recolectan en la estación equivocada, (85) y devienen inútiles. Los árboles, por ejemplo, cortados en hoja completa no pueden ser utilizados por el carpintero, ni el bálsamo mantener su pleno vigor cuando es adelgazado con aceite”.

80 Nov. 51,1: “Por lo cual, mandamos que no tenga validez absolutamente ninguna pignoración en nuestra República, ni en los mercados (cosa que hemos hallado que principalmente allí se hacía), ..., sino que el que por otro se atreviere a exigir de alguien en forma de pignoración dinero o alguna otra cosa, ...” (537 d.C.). DE LIGT.L., *Fairs and markets in the roman Empire. Economic and social aspect of periodic trade in a pre-industrial society*, Amsterdam 1993, pp. 79-80, señala que Justiniano prohíbe la *enechyrismos*, práctica extendida de buscar seguridad en deudas pendientes pasando la deuda a un tercero para que la cobre; así los visitantes de feria frecuentemente sufrían esta práctica ilegal. Ya sobre este tema, C. 4.60 (De *nundinis et mercationibus*) de los emperadores Valentiniano y Valente.

81 BROWN, P., *The rise of Western Christendom cit.*, p. 114, indica que Cuando la peste bubónica salió de su lugar de origen, la zona de los grandes lagos de África, empezó a propagarse rápidamente hacia Occidente. En el verano de 542 había alcanzado ya Pelusium, el puerto a través del cual llegaba hasta el Mediterráneo el comercio

demanda de bienes de lujo⁸². No obstante, a la altura del 550 d.C., la producción agrícola se ha recuperado, el comercio transmediterráneo sigue fuertemente activo, y determinados productos se hacen imprescindibles para el comercio internacional⁸³.

Si el comercio requiere de la paz en el Imperio y de una buena red de transportes y de comunicaciones, el Poder público reclama del mercado y de los mercaderes que contribuyan económicamente al sostenimiento de las arcas públicas, y que no se sitúen al margen de la legalidad; de ahí que el Emperador controle las rutas por tierra y mar, así como refuerce la diplomacia y las alianzas en el lucrativo comercio con Oriente, que devenga sustanciosos derechos aduaneros⁸⁴. La importancia de la fiscalidad en época justiniana es evidente, así como los deberes que se exigen como contribuyentes a *mercatores* y *navicularii*⁸⁵. Un Tratado miliar anónimo viene a reforzar la idea que se desprende de las fuentes jurídicas, control y contribución tributaria como postula la honestidad del tráfico comercial.

del mar Rojo con el indico. Despobló las ciudades de la costa y dejó una inquietante estela de aldeas desiertas y de campos abandonados a través de las principales rutas de Asia Menor.

82 LAIOU, A.E.-MORRISON, C., *The byzantine economy*, Cambridge 2007, p. 24.

83 SHAHÍD, I., *Byzantium and the Arabs in the sixth century*, Washington 2009, pp. 61, aborda la importancia de las aduanas en la zona Oriental del Imperio, y la riqueza del comercio árabe-bizantino.

84 VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., *La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII) cit.*, pp. 337-338, cita fuentes epigráficas para demostrar la importancia de la fiscalidad en el comercio marítimo en época justiniana.

85 MAAS, M., *The Cambridge companion cit.*, p. 30, explica que los *navicularii*, organizados en corporaciones, concertaban contratos públicos, proporcionando las provisiones requeridas y trabajando para el Gobierno con tarifas fijas y bajo la supervisión gubernamental a cambio de privilegios fiscales y legales (principalmente exenciones de ciertas cargas fiscales obligatorias).

VENTAJA COMPETITIVA DE ROMA EN EL MARE NOSTRUM. ESPECIAL REFERENCIA AL PUERTO DE CARTHAGO NOVA

MARÍA DOLORES PARRA MARTÍN

Universidad de Murcia

“Sic transit gloria mundi”

Los cretenses fueron los primeros navegantes que se interesaron por el comercio marítimo, seguidos de egipcios, fenicios, griegos y romanos. La actividad comercial tuvo como consecuencia la creación de ciudades-colonias y por tanto, civilizaciones con una organización predominantemente marítima. Nos encontramos ante naciones que vivían del mar centrándose sus rutas comerciales en las distintas ciudades portuarias desde las que se controla la actividad económica de todo el país y por tanto, la riqueza. La bonanza de los puertos era paradigma de prosperidad y poder.

Estrabón en su tratado Geografía (Libro III) refería como los fenicios fueron el máximo exponente del comercio en el mediterráneo¹ y ello debido a que poseían una ventaja competitiva frente a otros pueblos, el conocimiento de rutas ignoradas por otros². Cuenta Estrabón que “(...) *Las islas Casitérides son diez, vecinas entre sí, situadas en alta mar al septentrión del Puerto de Artabros. Una de ellas está desierta, las demás habitadas por hombres vestidos de negro, con unas túnicas que llegan hasta los pies, ceñidos junto al pecho, andando con báculos, y procurando conservar las barbas como de cabrito. Viven*

1 En el año 980 antes de Cristo, el rey Hiram I de los fenicios se propuso controlar las rutas comerciales de Asia. Para ello comenzó los acuerdos con Israel para explotar las rutas marítimas. Hacia el año 900, menos de un siglo después, los fenicios tenían inversiones en Israel, Siria y Anatolia, en el Mediterráneo oriental. En menos de otro siglo estaban presentes y controlaban todos los tráfico marítimos del Mediterráneo occidental. En poco más de siglo y medio, por lo tanto, con aquellos medios, los fenicios se convirtieron en los líderes indiscutibles de un territorio que iba desde Persia hasta Portugal.

2 Según Heródoto (nacido en 484 a C) fue una expedición fenicia auspiciada por el faraón Neco II la primera en circunnavegar el continente africano. Cuenta Heródoto que varias naves fenicias realizaron una penosa travesía efectuando largas paradas para conseguir provisiones, y que tardó tres años en llegar al estrecho de Gibraltar. La veracidad de esta hazaña fue cuestionada durante mucho tiempo, pero a favor de Heródoto está el testimonio que transcribe de los marineros fenicios, que informaban que en las proximidades del cabo de Buena Esperanza el sol de mediodía está al norte, es decir, las sombras se proyectan en dirección opuesta a lo que es lo normal lo que ocurre cuando se abandona el hemisferio norte y se cruza la línea del ecuador.

con el ganado, vagando sin asiento fijo. Tienen metales de estaño y plomo, en lugar de éstos y de pieles, reciben o toman de sus mercaderes hechuras de barro, sales y obras de cobre. En los primeros tiempos sólo los Fenicios iban a negociar aquí desde Gades ocultando a otros ésta navegación; pero habiendo seguido los romanos a cierto navegante, para saber donde eran dichos Emporios, este por envidia, cuidó poner su nave en el vado, logrando guiar las otras al peligro. Libre así del naufragio, recibió del Erario público el precio de las mercancías perdidas. Últimamente los romanos, haciendo varias tentativas aprendieron la navegación. Hasta aquí vino por mar Publio Craso, y viendo que los metales se podían obtener sin cavar mucho, y que los habitantes, deseosos de la paz, en medio de su ocio, querían estudiar la navegación, se la enseñó a algunos; pues más habían de transitar éste mar, que el perteneciente a Bretaña". El navegante salvaguardo la ventaja competitiva a través de la que su pueblo era líder del comercio en el mar Mediterráneo, logró que las naves romanas naufragaran obteniendo como recompensa del Erario público el precio de las mercancías.

La primera globalización comercial conocida se produjo en tiempos del Imperio Romano y ello al ser articulado mediante una importante red de comunicaciones que conectaban los distintos lugares del imperio, "*omnes viae Romam ducunt*"³. El desarrollo del Imperio, introdujo en la práctica comercial el concepto de centralización y de división internacional del trabajo al servicio de un centro dominante, Roma y sus necesidades en los diferentes territorios. Las autoridades romanas contribuyeron a cohesionar la economía imperial mejorando las comunicaciones terrestres y legislando en orden a los aspectos económicos a través de la integración de los territorios del imperio. Todo ello favoreció la especialización de los diferentes territorios que suministraban diferentes servicios y productos. A través de este modelo de globalización económica, Roma consiguió un alto grado de integración territorial así como de mejoras locales al relacionarse los ámbitos provinciales en el conjunto. Sin embargo, la contrapartida fue el control estatal, que establecía rigideces tanto por las exigencias del control como por las necesidades militares, que superaban las posibilidades técnicas de su mantenimiento. A partir del siglo II después de Cristo se llegó al punto de unas graves deseconomías de escala que empezaron a destruir la unidad, por vía tanto de elevación de precios y de impuestos, como por la debilidad política y militar que acabó apareciendo al ser de gran complejidad ejercer un control férreo sobre el territorio. En este sentido afirma González Enciso que "*la globalización centralizada tiene unos límites, que están en función de la capacidad de control. Esa capacidad es a su vez función tanto de cuestiones políticas, como de posibilidades técnicas. Superados aquellos límites se impone la descentralización, la subcontratación, o la autodeterminación de los distintos ámbitos o*

3 El comercio de asirios, fenicios, griegos o romanos de la Antigüedad se basaba en una progresiva integración de los mercados que obligaba a tener constantemente en cuenta nuevos territorios y nuevas posibilidades, también nuevos competidores: se producía para esos mercados, circulaba el dinero metálico y se practicaba el préstamo financiero. El desarrollo tecnológico fue menor -por eso se pudo llegar a ámbitos menos extensos que hoy, pero existió, como lo atestiguan algunos avances en infraestructuras de comunicaciones: los puertos, las calzadas romanas, que permitieron también la mayor integración del interior. La Primera Globalización se dio con los romanos, cuando éstos articularon un imperio, construyendo caminos y canales de riego, impusieron su sistema legal, forzaron el uso de su moneda y protegieron el comercio contra los piratas.

territorios, según de qué se trate. Los romanos no consiguieron completar ese proceso por el excesivo predominio de los objetivos políticos, y la cohesión se rompió”⁴.

Los romanos conocían la importancia del dominio del mar Mediterráneo para alzarse como la primera potencia en el mundo conocido. Por este motivo, colonizaron enclaves estratégicos en los que construyeron importantes puertos⁵, articularon un sistema legal, crearon mercados centrales a través de la fundación de ciudades y un sistema de comunicaciones terrestres y marítimas efectivas, protegieron el comercio contra piratas, forzaron el uso de su moneda en los intercambios económicos (el uso de una moneda común simplificó las transacciones de negocios y las hizo compatibles en todo el imperio).

El pragmatismo de los romanos les permitió la generación de un comercio dinámico sustentado en unas instituciones que le permitían ser floreciente. Citemos a modo ejemplificativo instituciones como el matrimonio (existían tres variantes) y la esclavitud. Además, consolidaron la idea de propiedad siendo protegida y garantizada en los intercambios entre partes. Los postulados estoicos influyeron decisivamente al establecer que los hechos acontecidos en el mundo no suceden sin razón alguna sino que todos responden a un por qué, distinguiéndose entre ética, moral y política⁶. Además usaron la *Pax Romana* o Paz Romana como estímulo principal en la formación del imperio⁷. Esto aseguro que los comerciantes fueran capaces de viajar con seguridad y rapidez por caminos construidos, mantenidos y protegidos por las legiones romanas y sus tropas afiliadas. Todas estas acciones contribuyeron al funcionamiento del sistema de mercado y a una reducción de la incertidumbre en los negocios y el comercio internacional.

El conflicto con Cartago y, en consecuencia, la necesidad de hacer frente a una potencia eminentemente marítima evidenció las carencias del estado romano en el ámbito marino y propició como respuesta la entrada de Roma en el escenario marítimo del Mediterráneo. Tal como refiere Polibio: “... *Pero los cartagineses eran dueños absolutos del mar y por esto la guerra a los romanos, les resultaba de signo indeciso... por todo lo cual vieron que la guerra se les alargaba; entonces, y no antes, emprendieron la construcción de navíos, de cien quinquerremes y de 20 trirremes...*”⁸. La integración romana en este escenario no sólo significaría con el tiempo el control del mar, sino la clave de acceso para lograr el dominio de los vastos territorios que conocemos como Imperio Romano y con ello la globalización comercial.

4 Vid Agustín González Enciso, “La globalización en la historia” Artículo publicado en la Revista “Empresa y Humanismo”, Vol. V, N° 1/02. Universidad de Navarra.

5 Las primeras referencias arqueológicas con las que contamos en relación a la construcción de puertos la encontramos en la isla de Pharos, en Egipto, famosa por la torre iluminada que servía de guía a los barcos y que ha dado nombre genérico a estas construcciones. El citado puerto fue construido bajo el reinado del faraón Serunet, destruido y sepultado bajo las aguas posteriormente por un terremoto y reconstruido más tarde por Alejandro Magno.

6 Por contrapartida el triunfo del Cristianismo primitivo supuso una rémora profunda en el avance económico, ya que como indicaba San Agustín de Hipona en su obra “Las Confesiones”: *la búsqueda de la felicidad no depende de lo material sino de lo espiritual*.

7 La época de la *Pax Romana* (31 a.C. al 200 d.C.) permitió la evolución de los barcos de carga según las necesidades reales del comercio, que fueron muchas y en constante incremento. Los barcos mercantes romanos eran generalmente veleros puros, de 350 a 450 toneladas, y estaban excepcionalmente bien construidos. Los mejores eran los denominados “cargueros del trigo”.

8 Polibio, Historias, I, 20, 9-10, s II a.C

El mar mediterráneo comenzó a ser testigo del desarrollo de la actividad portuaria desde el cuarto milenio antes de Cristo. Los puertos se constituyeron en pilares fundamentales de las civilizaciones mediterráneas en época romana. El dominio romano del mediterráneo fue fundamental para su apogeo como civilización pese a no ser su principal actividad. La elección de enclaves de puertos estratégicos sería clave en el control del Mar Mediterráneo por Roma. En Roma se alcanzó la cima en la construcción de los citados enclaves comerciales, durante más de 1.500 años nadie lograría superar sus obras portuarias⁹. Ello responde al hecho de que las guerras y la necesidad de control del imperio condujeron a la necesidad de abrirse al mar, aglutinando todas las técnicas empleadas por otras civilizaciones anteriores a lo largo de casi 3.000 años. Los romanos nombraron al Mediterráneo *Mare Nostrum*¹⁰ -nuestro mar- y desde el puerto de Ostia establecieron la ruta de comercio marítimo más completa que se haya conocido, constituyéndose en puerto de la capital del imperio hasta que se produjo el descubrimiento de América.

La construcción del Puerto de Ostia tuvo lugar el año 634 a. de C y pronto se puso de manifiesto uno de los problemas técnicos más importantes que tuvieron que combatir los romanos: los aterramientos. Se trataba de la progresiva deposición de sedimentos a la entrada de los puertos lo que ocasionaba que dejaran de ser navegables. Este problema se produjo en el puerto de Ostia, para evitarlo se modificó su ubicación inicial trasladándose 40 kilómetros al norte. La construcción del puerto motivó que la antigua colonia sufriera una severa transformación, la población aumentó y el urbanismo se adaptó a las nuevas necesidades portuarias. Ostia era una ciudad bulliciosa, en la que habitaban muchos trabajadores empleados en el puerto, algunos en su propia construcción o dedicados a la manufactura de los productos que llegaban desde el mar. Para albergar a la numerosa población se modificó la arquitectura del lugar, las antiguas casas unifamiliares de una sola planta, de tradición republicana, se sustituyeron por bloques de edificios de hasta cinco pisos de altura (*insulae*).

9 De estas grandes obras marítimas que no pudieron ser han quedado numerosos restos, algunos de los cuales siguen en uso incluso hoy en día. Ejemplos de estas construcciones son los puertos de Ostia (Roma), Centum Collae (Civitavecchia), Massilia (Marsella), Leptis Magna (Libia). Además de esta época han sobrevivido los primeros textos y tratados que versan sobre construcción portuaria, como el de Vitrubio, siendo el único compendio sobre construcción que ha llegado a nosotros. El capítulo 13 del libro V lo dedica a la construcción en el mar y en los capítulos 4º y 7º del libro I hay alguna referencia sobre puertos. Los romanos también promovieron la construcción de faros a lo largo de las costas mediterránea y atlántica, incluyendo los de Ostia, Boulogne (Francia), Dover (Reino Unido), o el faro de Hércules (A Coruña), que en la actualidad sigue aún en funcionamiento.

10 Gráficamente lo describe la Profesora Alfaro Giner en su obra *La navegación romana* « Historia Económica y Técnica del Mundo Antiguo » Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Valencia. Enero de 2007. “Desde la primera victoria naval en aguas de Mylae (Milazzo) en el año 260 a.C., la repercusión de determinadas intervenciones navales marcaría la expansión y consolidación del poderío romano en el Mediterráneo. El triunfo en las islas Egadas (241 a.C.) supondría la evacuación cartaginesa de Sicilia y la posterior conquista romana de Córcega y Cerdeña, el desembarco en la costa tarraconense durante el 218 a.C. el inicio de la ocupación romana en la Península Ibérica y el arribo a costas norteafricanas en el 204 a.C. la derrota de Cartago en la Segunda guerra púnica. En la zona oriental, a mediados del siglo III a.C. la intervención en la costa dálmatina contra la piratería iliria aseguraría el tráfico marítimo en el Adriático, iniciando una etapa de arbitraje que, de modo previo a la conquista, llevaría a Roma a intervenir en los asuntos de los reinos helenísticos. Sin embargo, sería la victoria naval en Actium, la que en el año 31 a.C. culmina frente a la alianza de Antonio y Cleopatra con el poder único de Octavio, abriéndole las puertas de Egipto. Los límites del Imperio quedaban prácticamente trazados. El *Mare Nostrum* era ya una realidad”.

Lo que viene a evidenciar que la creación de una ciudad portuaria suponía una modificación sustancial en la ubicación elegida, en la vida cotidiana y costumbres del entorno.

El comercio marítimo a gran escala lo realizaban los *navicularii*, propietarios de los barcos, con representantes en los grandes puertos. Otras profesiones relacionadas con la actividad marítima eran los *negotiatores*, mercaderes especializados en determinados tipos de mercancías como los *frumentarii* (de grano) o los *vinarii* (de vino). La actividad comercial se encontraba regulada por la ley y existían impuestos específicos para el tráfico de mercancías¹¹. En los grandes puertos se agrupan las mercancías llegadas de diferentes puntos y, desde aquí, se fletan de nuevo barcos hacia otros puertos secundarios, generalmente mediante rutas de cabotaje. De esta forma se redistribuían las mercancías de los diferentes puntos del Mediterráneo por todo el territorio¹².

Un problema importante en relación al tráfico marítimo fue el de la piratería. El crecimiento de la piratería fue paralelo al engrandecimiento de Roma, que se adueñaba progresivamente del Mediterráneo e iba sometiendo nuevos pueblos. A mediados del siglo I a.C., los piratas pasaron a ser una amenaza seria para el comercio y la paz¹³. Erradicar la piratería se convirtió en uno de los principales objetivos del Senado.

Al efecto recordar como en el año 78 a.C., una flota romana comandada por Servilio Vatia venció a las naves piratas en las islas Caledonias; en 74 a.C., fue el joven Julio César quien luchó duramente con una banda pirata en Rodas; aquel mismo año también los combatió Marco Antonio, y fueron otras muchas las acciones represivas que se llevaron a cabo sin un resultado definitivo, sino todo lo contrario: aparecían nuevas naves piratas por todas partes y cada vez con mejores prestaciones. Entre 74 y 76 a.C., los piratas habían apoyado revueltas, secuestrado cónsules y pretores, e incluso secundado la rebelión de los esclavos de Espartaco; hasta llegaron a capturar una flota de galeras en Ostia, el puerto por excelencia de Roma. Pero cuando lograron bloquear el comercio del trigo, ese hecho fue la gota que

11 Las mercancías, transportadas a través del imperio, tenían que pagar múltiples derechos cuyo conjunto formaba lo que se llamaba el *portorium*. El *portorium* consistía en tres clases de impuestos o de tasas; la aduana, el arbitrio, el peaje: los romanos no diferenciaban estas tasas. El conjunto del mundo romano estaba dividido, desde el punto de vista de las aduanas, en diez circunscripciones además de Italia. Las diversas tasas, percibidas a lo largo del recorrido que seguían las mercancías, aumentaban considerablemente el precio de estas. La percepción del *portorium* ven sus múltiples formas tenía una gran importancia para las finanzas del estado.

12 El Mediterráneo se constituye en un gran mercado por el que transitan productos de todo el Imperio. El comercio se produce sobre todo desde las provincias a Roma. Abunda el vino galo e hispano, el trigo egipcio, los tejidos orientales, el aceite producido en el valle del Guadalquivir, las salazones del área del Estrecho, los mármoles y las piedras duras lujosas para la construcción de edificios públicos, las especias, los esclavos. Se explota oro, estaño, plomo y plata.

13 Los piratas más activos y peligrosos eran los dálmatas, de origen ilirio, que operaban desde sus bases escondidas en las costas de Dalmacia, plagadas de islas e intrincados brazos de mar que ellos conocían a la perfección. Los filibusteros actuaban en connivencia con los habitantes de las islas, con los que compartían un código de señales que les advertía de la presencia de las galeras romanas. Eran también excelentes navegantes y, a menudo, habían actuado como mercenarios, como lo habían hecho en la primera flota Romana en la batalla de Milazzo y a lo largo de las restantes batallas de las guerras Púnicas. De hecho, desde el inicio del poder naval de Roma, algunos piratas habían sido contratados como instructores de maniobras para entrenar a los oficiales romanos, a los que enseñaron también las técnicas del pilotaje costero. Los piratas ilirios navegaban con un tipo de embarcación ligera muy maniobrable que disponía de un solo orden de remos y sobre cuyo diseño se inspiró la posterior *liburna* romana.

colmó el vaso de la paciencia del Senado. Roma se enfrentó al problema con su arma más infalible: la administración. El Senado tomó la decisión de dar carácter al Mediterráneo de “provincia de mar” y encargar su gobierno a un solo jefe. En 67 a.C., se dictaminó la *Lex Gabina*, por la cual un magistrado recibía durante tres años el mando supremo de las costas hasta 50 millas mar adentro, con derecho a reclutar él máximo 25 legados, armar 500 barcos y ordenar zarpar a voluntad. El primer magistrado, Pompeyo Magno, general y cónsul, un héroe de las campañas militares en África e Hispania, dispuso de un contingente de naves y soldados con el que logró controlar la piratería del Mediodía occidental hasta las costas de Sicilia¹⁴ que tanto daño causaba al comercio marítimo.

Es ilustrativo sobre el tema de la piratería el artículo de Fernández Vizcaíno “Comercio y piratería en Roma en la época republicana”, en el que concluye que la piratería nunca fue totalmente erradicada. Literalmente afirma “*Ahora bien, aunque ciertas fuentes declaran que tras Pompeyo no se volvió a ver piratas en el Mediterráneo, esto es una exageración, pues el hecho de que tras su campaña se continuasen enviando gobernadores de rango consular o proconsular a Cilicia indica que se seguía necesitando la dirección de magistrados con imperium. El problema de la piratería ha continuado presente en el mar en mayor o menor medida durante siglos, incluso siendo apoyada por los Estados como medio de control del comercio internacional, o de rivalidad entre potencias estatales, apareciendo con mayor virulencia en épocas de crisis, como ya ocurría en la antigüedad*”¹⁵.

La conquista de territorios estratégicos como avanzamos en líneas anteriores fue clave en el proceso de globalización comercial del Imperio Romano siendo uno de los citados territorios el de Carthago Nova¹⁶, colonia romana que dio nombre a toda la Provincia Cartaginense, siendo denominada como tal con el objeto de distinguirla de la antigua Cartago en África¹⁷.

14 Pompeyo disponía de 270 barcos; nombró a 13 delegados y dividió el mar en sectores, destinando una escuadra a cada uno y reservándose para él Creta y Sicilia, donde quería dar el golpe decisivo. La efectividad de Pompeyo logró un éxito espectacular: en tres meses capturó 846 barcos, 120 asentamientos fueron destruidos, 10.000 piratas resultaron muertos y 20.000 hechos prisioneros. Pompeyo fue aclamado por el pueblo de Roma y considerado como el “pacificador de los mares”. Por vez primera, Roma dominaba efectivamente el mar. Pompeyo realizó otras campañas de gran éxito, entre ellas la guerra contra Mitridates de Siria y, tras enemistarse con el Senado al haber solicitado tierras para sus legionarios y no serle concedidas, fue perseguido por Julio César Augusto. Enfrentados ambos en la batalla de Farsalia (48 a.C.), Pompeyo fue derrotado. Aquel mismo año, el “pacificador de los mares” murió asesinado en Pelusio por orden del egipcio Tolomeo XIII (hermano de Cleopatra).

15 Afirma la citada romanista: Así, en el año 62 a.C. el gobernador de Asia necesitó una flota para luchar contra los piratas, como afirma Cicerón en su *Cic. pro Flacc.* 31-32. Y Siria fue asolada por los piratas durante la restauración de Ptolomeo XII en el 55 a.C., mientras era gobernador Gabinio. Además *vid.* AMELA, L., “La campaña de Pompeyo Magno contra los piratas en Hispania (67 a.C.)”, en *Hispania Antiqua, Revista de Historia Antigua*, 30, *op.cit.*, p. 17; ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, A., *Los piratas contra Roma, Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a.C.)*, *op.cit.*, pp. 61 y 70. *Flor. Epit.* 1, 41, 15; *Cic. Flacc.* 28-30.

16 La toma de Carthago Nova, episodio clave de la Segunda Guerra Púnica en la península ibérica, se narró por primera vez en las *Historiae* de Polibio (mediados del siglo II a. C.) y se desarrolló posteriormente en la literatura latina (Tito Livio, Floro, Silio Itálico, Apiano, Dion Casio), con secuelas hasta el siglo VI. Como tema iconográfico aparece en la pintura del Renacimiento, y continuó siendo muy desarrollado por la pintura de historia hasta el siglo XIX.

17 Fundada por Asdrúbal, capitán de los Cartagineses. Polib. lib.2; Strab.lib 3; Mel lib 2.c.6.

“Cartagena está situada hacia el punto medio del litoral español, en un golfo orientado hacia el Sudoeste. La profundidad del golfo es de unos veinte estadios y la distancia entre ambos extremos es de diez; el golfo, pues es muy semejante a un puerto. En la boca del golfo hay una isla (Escombreras) que estrecha enormemente el paso de penetración hacia dentro, por sus dos flancos...”¹⁸.

Carthago Nova constituía un enclave estratégico para el Imperio debido a la comodidad del puerto, la inmediación a África y la abundancia y fertilidad de sus campos y minas¹⁹. Estrabón refiere citando a Polibio la abundancia y extensión de estas últimas, cuenta que ocupaban 400 estadios en círculo, y que en ellas se empleaban a cuarenta mil trabajadores, añadiendo que producían cada día al pueblo romano un valor de veinticinco mil dracmas²⁰. Evoca Estrabón la admiración de Posidonio (II.9) por la inagotable riqueza minera de la Península Ibérica, hasta el punto de que “(...) *El mundo subterráneo no está habitado por Hades, sino por Plutón*”, describiendo minuciosamente las minas de plata de Carthago Nova²¹.

Vitruvio en el capítulo de su libro (V, 13) en relación al enclave y construcción de puertos refiere: “...Pero si no hubiera un lugar naturalmente apropiado para proteger los navíos durante las borrascas, parece que debe procederse de este modo: si hubiese en aquel lugar un pico que constituyera un abrigo contra las tempestades, sino que sólo por una parte hubiera una playa apropiada, entonces es preciso levantar del otro lado, con ayuda de mampostería, espolones o escolleras que lleguen a formar un puerto cerrado...”

En el sentido descrito por Vitruvio, el puerto de Cartagena se constituye en uno de los puertos naturales privilegiados del litoral mediterráneo en la Península Ibérica constituyendo un itinerario marítimo de referencia durante toda la antigüedad. El geógrafo Estrabón destacaba la calidad del puerto de la ciudad de Carthago Nova, un emporio comercial en el cual se intercambiaban productos hispanos y otros venidos del exterior por mar²².

18 Polibio (X, 10, 1-12)

19 El hallazgo de un barco hundido es un excelente documento histórico, ya que todos los objetos transportados se encontraban en uso en el momento del hundimiento, lo que permite obtener dataciones fiables. A la entrada de la bahía de Cartagena, en la isla de Escombreras, se han excavado los restos de seis barcos de distinta cronología, entre los que destaca el Escombreras-I. Se trata de un barco mercante romano típico que lleva un cargamento de vino envasado en ánforas, vajilla de mesa y cerámica de cocina. Por su estudio se sabe que procede de un puerto napolitano. Seguramente hizo una escala en Ibiza antes de llegar a Carthago Nova, donde se hundiría hacia el año 155-150 a.C. Investigadores del museo nacional de Arqueología Subacuática (Arqua), de Cartagena, han hallado en los fondos de ese puerto murciano un barco romano de entre finales del siglo IV y principios del V después de nuestra era y otro hundido a finales del XVIII. El barco romano transportaba un cargamento heterogéneo de ánforas de origen africano que contuvieron vino y aceite, así como otras béticas y lusitanas para conservas de pescado y lucernas y otros objetos de la tripulación, algunos con símbolos cristianos impresos. A falta de un estudio más detallado, parece ser un barco que redistribuía productos desde un puerto andaluz hasta Cartagena o, en un trayecto más largo, a las costas italianas, como documentan barcos similares como el Dramont E francés o el Punta Ala A italiano.

20 Estrabón lib.III. Geograph.

21 De hecho, la riqueza minera de la zona parece ser uno de los factores determinantes para la fundación púnica de la ciudad. En este sentido, la evidencia de una explotación intensiva de las minas de plata del sureste y de la Bética por parte de los Bárquidas se deduce de un texto de Plinio, que hace referencia a los pozos abiertos por Aníbal y, en concreto, al pozo Baebelo. Es por ello por lo que también Roma se verá impelida a la conquista de la ciudad, para privar a los cartagineses no ya sólo de una de sus principales plazas sino, sobre todo, de las minas de plata que sufragan en gran parte las guerras.

22 Estrabón III, 4, 6.

Los romanos conscientes de la importancia estratégica del puerto de Carthago Nova mostraron gran tesón en su conquista. Su riqueza y opulencia servían de cebo para acentuar el valor de los soldados romanos. Escipión conocedor del espíritu codicioso de sus legiones las animó a la toma con la promesa de grandes riquezas y tesoros a disfrutar tras la consecución de la victoria. Polibio con expresión de Xenofonte, otorgó a Cartagena el título honorífico de “Taller de la Guerra”, tanto por el continuo ejercicio a través del cual Escipión disciplinaba a sus legiones romanas, como por la afición del pueblo al combate y a las luchas de gladiadores.

Refiere Tito Livio en relación a Escipión que “(...) Decidió comenzar con un ataque contra Carthago Nova., una ciudad que no solo era rica por sus propios recursos, sino por albergar los depósitos de guerra enemigos con sus armas, los caudales y los rehenes de toda Hispania. Tenía también la ventaja adicional de su situación, pues ofrecía una base ideal para la invasión de África y un puerto capaz de albergar una flota por grande que fuese y, hasta donde yo sé, el único puerto en aquella parte de la costa que enfrenta a nuestro mar ...”²³.

Polibio realiza un análisis exhaustivo de las razones que llevaron a Escipión a lanzar el ataque sobre la ciudad púnica: «Sabía, en cambio, que la ciudad de Cartagena, que ya he citado, era útil al enemigo y que, precisamente en la guerra de entonces, perjudicaba mucho a los romanos. Durante el invierno había reunido informaciones de gente que conocía bien sus peculiaridades. Lo primero que supo fue que era prácticamente la única ciudad de España dotada de un puerto capaz de albergar una flota, es decir, fuerzas navales; averiguó además, que su situación era excepcionalmente favorable para los cartagineses, para sus navegaciones desde el África y sus travesías por mar. En segundo lugar se enteró de que los cartagineses guardaban en este sitio prácticamente todos sus fondos y los bagajes de sus ejércitos, además de sus rehenes procedentes de toda España. Lo más importante era que hombres verdaderamente expertos en la guerra allí había sólo mil como guarnición de la ciudadela, porque jamás nadie llegó a sospechar que hubiera quien planeara asediar la plaza, dominando, como dominaban, prácticamente, los cartagineses toda España. Le informaron de que había allí un gran número de hombres, pero que eran artesanos, obreros o marineros, sin ninguna experiencia bélica. Supuso que esto, más bien, embarazaría a la ciudad en caso de una aparición inesperada»²⁴.

Es evidente que Escipión se encontraba muy bien informado sobre las características estratégicas y riqueza de Carthago Nova²⁵, pero hay disparidad de opiniones acerca de cómo conseguía la información. Beltrán, por ejemplo, cree que la consiguió a través de prisioneros o informadores indígenas, extremo éste difícil de confirmar²⁶. Lo que es indudable es que la conquista no fue fruto del azar habiendo planeado el general romano todos sus movimientos, así por ejemplo era conocedor de la ubicación de los ejércitos púnicos,

23 Tito Livio (XXVI, 42).

24 Pol. X, 8, 1-5. Véanse también Liv. XXVI, 43, 3-8 y App. Iber., 19.

25 N. J. E. Austin y N. B. Rankov, *Explorado. Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic World to the Battle of Adrianople*, London- New York 1995, 10. Sobre la importancia del secretismo en las operaciones militares, Pol. IX, 13, 1-5. Tenemos un ejemplo parecido en Polyae. Strat., V, 10, 2: Himilcón entrega unas tablillas a los timoneles fijando el punto donde debían reunirse en caso de que se dispersaran en el mar.

26 A. Beltrán, «La conquista de Cartagena por Escipión», *Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria*, XXL 1946, 101. Véase, por ejemplo Goldsworthy, *The Roman Army at War: 100 BC-AD 200*, Oxford 1998, 126.

lo que le otorgaba un enorme margen de tiempo; conocía también el número de hombres que guardaban la ciudad y sabía que eran superados en número de forma abrumadora por las tropas romanas; tenía el dominio marítimo, lo que le aseguraba una rápida retirada en caso de necesidad; y contaba con un elemento de suma importancia estratégica: la sorpresa. En definitiva, era mucho lo que se podía ganar y poco lo que perder ante un enemigo que, pese a sus recientes victorias, se encontraba en un momento muy delicado. Momento que aprovecho Escipión para propiciar el ataque motivando a sus legiones.

Polibio nos advierte de ello: “Comelio Escipión divulgó siempre, entre el pueblo, que realizaba sus proyectos por inspiración divina y, así, infundía confianza y ánimo en sus subordinados ante las empresas difíciles. Sin embargo, lo que se va a exponer evidencia que lo hizo todo con cálculo y reflexión; coronó con éxito sus acciones de una manera perfectamente lógica”²⁷.

Los cartagineses se confiaron y cometieron un error fatal dejando la zona levantina totalmente desprotegida. Con Asdrúbal en la Carpetania, cerrando el paso hacia la actual Andalucía, Escipión fijó su atención en Carthago Nova, cuyo control *«permite dominar por completo la vía costera hasta la zona de Almería, y abre un posible camino meridional para penetrar en la Hética, que aunque no parece utilizarse, garantiza otra posibilidad de retirada y hace poco probable un ataque desde este sector»*. Además, era allí donde los cartagineses retenían los rehenes a través de los cuales mantenían el control sobre muchos pueblos indígenas. Seguramente los mandos púnicos no esperaban la maniobra de Escipión, puesto que lo normal hubiera sido ir en busca de uno de los tres ejércitos púnicos y presentar batalla. El propio Polibio²⁸ menciona la posibilidad de avanzar hacia uno de los tres ejércitos con la garantía de que ninguno de ellos podría pedir auxilio, pero Escipión ni siquiera podía estar seguro de que los cartagineses fueran a presentar batalla, y mucho menos podía arriesgarse a sufrir una nueva derrota de la que sus tropas difícilmente se recuperarían. Por otra parte, aunque los cartagineses intuyeran la remota posibilidad de que su base pudiera sufrir un ataque, confiaban sin duda en las lecciones con las que Aníbal los adoctrinó²⁹ dejando la zona de levante carente de protección.

Conquistada Carthago Nova, Escipión ordenó reunir el botín en el agora para ser repartido entre sus hombres al día siguiente³⁰. El general romano procedió también a la entrega de la *corona muralis*, distinción con la que se premiaba al primer hombre que coronaba la muralla. Fueron dos los hombres que se la disputaron; Quinto Trebelio, un centurión de la Legión Cuarta, y Sexto Digitio, un marinero al mando de Lelio. Según Livio, Escipión concedió finalmente la corona a ambos. No hay certeza sobre este episodio, pudiendo ser una invención del escritor latino. A continuación, Escipión se ocupó de los casi 10.000 rehenes, siendo los ciudadanos puestos en libertad. Los artesanos unos 2.000 fueron convertidos en esclavos públicos, pero se les prometió la libertad al final

27 Pol. X, 2, 12-13.. Sobre la leyenda de Escipión, véase Mansfield, 1976, 9-29; Tisé, 2002,49-50.

28 Pol. X, 7, 6-7.

29 P. Barceló, Aníbal de Cartago. Un proyecto alternativo a la formación del Imperio Romano, Madrid 2001, 172

30 Sobre el reparto del botín en el ejército romano: Goldsworthy, 2002, 324; Guillen, 2001,484-486.

de la guerra. Finalmente, de los prisioneros restantes –esclavos en su mayoría– fueron escogidos los más aptos para servir como remeros en la flota romana³¹.

Con la conquista de la base púnica, los romanos asestaron un durísimo golpe al poder cartaginés. El botín capturado incluía materiales preciosos y objetos de gran valor, grandes cantidades de trigo y cebada, así como diverso material de guerra, destacando las diferentes máquinas³². Además, con la captura de la flota que allí había, los romanos se convirtieron a partir de este momento en dueños absolutos del Mar Mediterráneo.

Gracias al control de Carthago Nova Roma dominaba las minas de plata y la producción de sal de la zona, privando con ello a los púnicos de recursos para pagar a sus mercenarios”. Los romanos se apoderaban también de la vía más rápida de comunicación del enemigo con Italia y con Cartago, de una zona rodeada de importantes campos de cultivo, entre los que destacaban los de esparto –material imprescindible para la construcción naval–, y abrían la ruta del Guadalquivir, lo que tuvo sus consecuencias inmediatas en las batallas de Baecula e Hipa. No menos importante fue el paso a manos romanas de los rehenes que los cartagineses mantenían en la ciudad. Con su «liberación», los púnicos empezaron a sufrir las defecciones de numerosas tribus. Livio menciona un intento de reconquistar la ciudad por parte de los púnicos en el año 206 a. C., pero los romanos no cometieron el mismo error que sus enemigos y pusieron mucho cuidado en fortificar una ciudad que además podían defender desde el mar debido a la configuración natural del puerto.

Para finalizar recordar las palabras de Mommsen “la proximidad de Italia y las cómodas y baratas comunicaciones por mar abrían en esta época, sobre todo a los centros españoles del litoral mediterráneo y levantino, una ruta magnífica para poder colocar sus ricos productos en el primer mercado del Universo, y es muy probable que Roma no llegase a mantener con ningún país del mundo un comercio al por mayor tan voluminoso y tan sostenido como con España”³³

La base militar establecida en Carthago Nova después de la toma de la ciudad atrajo a comerciantes y artesanos incrementándose los contactos comerciales con el mundo itálico, lo que se evidencia a través de los restos arqueológicos que muestran la presencia de cerámicas de barniz negro y la importación masiva de productos fabricados en la Península Ibérica³⁴. Con el devenir de los años el puerto de Cartagena se fue transformando en un importante centro de comercio al que llegaban productos del mediterráneo oriental y occidental y desde el que se exportaban los productos del interior³⁵. A partir del siglo II a.C alcanzó un gran desarrollo convirtiéndose en el puerto más importante de la Península Ibérica³⁶.

31 Pol. X, 17, 6-14; Liv. XXVI, 47, 1-3. Pol. X, 15, 9; 16, 1

32 Sobre el material de asedio capturado, véase F. Romeo Marugán y J.I. Garay Toboso, «El asedio y toma de Sagunto según Tito Livio XXI. Comentarios sobre aspectos técnicos y estratégicos», en Gerión 13, 1995, 261. Un cálculo de las ganancias romanas en Gracia Alonso, 2003, 158.

33 Mommsen, Th, El mundo de los Césares, México, 1945, pp 93 ss.

34 S. Ramallo, “Pavimentos de opus signium en el Conventus Carthaginensis”, Pyrenae 15-16, 1979-80, p.287.

35 Estrabón 3,4,6.

36 Es ilustrativa al respecto la obra de María del Mar Llorens Forcada, La ciudad de Carthago Nova: las emisiones romanas. Universidad de Murcia, Secretariado de publicaciones, p, 23 ss. La importancia comercial de

BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO GINER, C, La navegación romana « Historia Económica y Técnica del Mundo Antiguo” Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Valencia. Enero de 2007.
- AUSTIN, N. J. E. Y RANKOV, N.B, Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople, London- New York 1995, 10.
- BARCELÓ, P, Aníbal de Cartago. Un proyecto alternativo a la formación del Imperio Romano, Madrid 2001, 172.
- ANDRÉ, J.-M, La villégiature romaine , Paris, PUF, 1992.
- ANDRÉ, J.-M, BASLEZ, M.-F.: Voyager dans l’Antiquité , Paris, Fayard, 1993.
- CASSON, L, Travel in the Ancient World, 1975.
- CHEVALLIER, R, Voyages et déplacements dans l’Empire romain, Paris, Armand Colin, 1988.
- FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, D, La toma de Carthago Nova por Publio Cornelio Escipión. ¿leyenda o realidad?.
- FERNANDEZ VIZCAINO, B, “Comercio y piratería en Roma en la época republicana”, Libro Homenaje al Profesor D. Antonio Díaz Bautista, Murcia 2014.
- GOZALBES CRAVIOTOH, E, Observaciones acerca del comercio en la época romana entre Hispania y en norte de África In Antiquités africaines, 29, 1993. pp. 163-176.
- GONZÁLEZ ENCISO, A, Globalización mundial, Revista Empresa y Humanismo, Vol. V, N° 1/02, Universidad de Navarra.
- LÁZARO GUILLAMÓN, C, Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a Carthago Nova: Esempio di economia sociale? En Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 11, 2013.
- Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana a la luz de una inscripción de Carthago Nova –CIL II, 5929– , Actas Congreso Internacional e Iberoamericano de Derecho Romano, Vol I, pag 425-439, Las Palmas de Gran Canaria, 2007.
- MOMMSEN, Th, El mundo de los Césares, México, 1945, pp 93 ss.
- POLIS. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica 17, 2005, pp. 31-72.
- ROLDÁN, J- M, Historia de Roma , Salamanca, ed. Universidad, 1995.

Carthago Nova se fundamentó en la producción y comercialización de tres productos minerales, esparto y *garum sociorum*.

EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL EN NEGOCIOS BANCARIOS

JUAN RAMON ROBLES REYES

Universidad de Murcia

1. INTRODUCCIÓN

La actividad de la banca no puede datarse en el tiempo, del mismo modo que no puede ponerse fecha a la práctica en virtud de la cual una persona prestaba o cambiaba oro, plata u otro material que servía para adquirir bienes. Lo cierto es que la aparición del dinero puede servirnos de punto de partida para hablar de contratos bancarios, caracterizados por el préstamo de dinero a cambio de unos intereses. Esta es la actividad esencial de los *argentarii*, aunque también aparecen en los textos actividades paralelas, como son las de cambistas, depositarios de dinero, avalistas o administradores de patrimonios ajenos, aunque no sea ésta última la actividad que más los identifique.

También hay que destacar la estrecha vinculación de la banca con el poder político y militar, convirtiéndose en un poder fáctico de primer orden en la sociedad, de cuya actividad dependía la prosperidad económica y la paz social¹. Esta relación se produjo, en un primer momento, por la necesidad de los reyes y gobernantes del dinero necesario para pagar a los miembros de la administración y las campañas militares. Posteriormente, porque los magistrados hubieron de recurrir a préstamos para financiar campañas políticas y los generales pagar a sus ejércitos de mercenarios². Esta situación generó el favor, y la deuda, de los poderosos respecto a los banqueros quienes utilizaron su situación de influencia para que las

1 TORRENT, A. *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, *Annali del Seminario Giuridico Università de gli Studi di Palermo (AUPA)* ,(56,2013), Torino., recoge el supuesto del banquero Calisto que por su mala gestión había arrastrado a la ruina a gran cantidad de personas poniendo en entredicho la “honorabilidad” de los *argentarii*.

2 En algún caso los propios magistrados se debieron dedicar a la actividad del préstamo, como se desprende de *Mod. 10 Pand. D.12.1.33* al recordar este jurista que las constituciones de los príncipes prohibían que los que gobernaban las provincias, e incluso los que estuviesen cerca de ellos, (sin especificar si eran familiares, amigos u funcionarios menores a su cargo) diesen dinero en mutuo o se dedicasen a la usura: *..ne hi qui provinciam regunt quive circa eos sunt negotientur mutuamve pecuniam faenusve exerçant*. Paulo viene matizar la cuestión en *Paul. 2 sent. D. 12.1.34 pr.* al señalar que los oficales del presidente sí podían dar dinero en mutuo o prestarlo a interés, en atención a que “perpetui sunt”. Quizás se refiriese esta autorización a que su nombramiento y estancia en la provincia no estaba sujeta a plazo, como si lo era la de los presidentes. Por el contrario no se le prohibía al presidente tomar dinero prestado a interés.

normas jurídicas fuesen dictadas beneficiando sus intereses y privilegios de clase³. En esta perspectiva se encuadra este trabajo que pretende hacer un breve recorrido sobre la evolución que se produjo en materia jurisdiccional en aquellos procedimientos en que intervenían banqueros, ya fuere como demandantes, ejercitando acciones contra sus deudores incumplidores, ya fuere como demandados cuando incumplían los contratos en que actuaban como depositarios o administradores. Este último supuesto era bastante infrecuente, pero su existencia la atestiguan textos del Corpus, como el fragmento de Ulpiano D.42.5.24.2⁴, en donde se recoge el orden de preferencia de créditos cuando se habían de vender los bienes de un banquero ejecutado, o C.2.11.20 (*Dioc. Max.*), castigando a los que cobran intereses excesivos, algo ya prohibido en las XII Tablas, o los intereses de intereses⁵. Como conclusión de lo expuesto, se puede afirmar que siempre hubo una jurisdicción bien delimitada para los supuestos en que intervenían banqueros, sobre todo en la época de Justiniano, a los que protegió como se desprende de la lectura de las Novelas.

En nuestra tarea de delimitar qué órganos jurisdiccionales y judiciales eran los competentes para tramitar el procedimiento y dictar sentencia en los litigios en que intervenían banqueros, habría que recordar que su actividad fue diversa pues no se desarrolló sólo formalizando contratos de mutuo. También se sirvieron de otras figuras jurídicas y contratos para el cumplimiento de sus fines, como fueron las estipulaciones y los depósitos irregulares. Del mismo modo hay que recordar que la historia de Roma se desarrolla durante casi mil quinientos años, en amplios territorios y con leyes y jurisdicción diversa. A pesar de ello, y siendo conscientes que la amplitud del tema, la generalización y la obligada concisión del trabajo dejará muchas excepciones y temas sin tratar, expondremos los criterios generales en un recorrido a lo largo de toda la historia de Roma.

2. EXPANSIÓN TERRITORIAL Y MAGISTRADOS COMPETENTES. ESPECIAL REFERENCIA AL PUERTO DE OSTIA

En el s. V a.C. las XII Tablas contemplaban ya la posibilidad de realizar préstamos lícitos de dinero, así como el castigo a quien intentase cobrar intereses abusivos, estableciendo que el tipo máximo de interés permitido era el cinco por ciento mensual⁶. En los

3 Sobre contratos bancarios, vid. DÍAZ BAUTISTA, A., *Estudios sobre la Banca Bizantina (negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987; Aunque son muchas las disposiciones dictadas a favor de banqueros, sirva como muestra la Nov. 136 (*Just.* 541), en la que el emperador les reconoce diversos privilegios procesales en la ejecución de créditos, en atención a que *son útiles a muchos, aceptando consignaciones y mutuos, llenos de toda suerte de peligros...*

4 *Ulp. ad ed.* D.42.5.24.2 se refiere, tanto a los acreedores del banquero que depositaron dinero y no se les devolvió, como de los que tenían derecho al cobro de intereses por las cantidades depositadas y no los recibieron En C.2.11.20 (*Dioc. Max.*), aunque sin hacer referencia expresa a los banqueros, se tacha de infamia a los que se dedican al cobro inmoderado de intereses o el cobro ilícito de intereses de intereses.

5 Sobre la evolución del anatocismo vid, MURILLO, A., *Anatocismo. Historia de una prohibición*, en AHDE 59, 1999, pp. 497-518.

6 En la Tabla III se prescribía que cualquier ciudadano que cobrase más del cinco por ciento mensual sería condenado al cuádruplo de la suma prestada. En dicho texto el pueblo consiguió que se incluyese una norma de derecho público fundamental, como era el que no se concediesen privilegios a ninguno, -Tab. IX-, por lo que los banqueros no pudieron incluir en este texto ninguna resolución que les favoreciese como clase. Vid. RASCÓN,

supuestos en que los deudores no cumpliesen el contrato, devolviendo principal e intereses, ya se recogía el cobro coactivo mediante la venta *trantiberin*, precedido de los procesos iniciados por una *legis actio per sacramentum in personam*, seguida habitualmente de la *legis actio per manus iniectum*. Aunque el texto no nombra expresamente a los banqueros, y de hecho la protección al acreedor frente al deudor incumplidor es genérica, lo cierto es que llama la atención la extensión de la Tabla III, *De rebus creditis*, y que los dos primeros preceptos se refieran al depósito y al dinero prestado. Posteriormente, una Ley Silia del s.III a.C. introdujo la *legis actio per condictioem* que prescribió su uso para los supuestos de reclamaciones de deudas pecuniarias de cantidad determinada. En todos estos casos estaríamos ante las normas generales y se tramitaría el proceso ante el magistrado ordinario (rey o pretor, según el momento histórico), y resolvería el juez privado.

El problema surge cuando Roma comienza la expansión territorial y se plantean litigios alejados de la urbe. Entonces nos encontramos, de una parte la jurisdicción en la ciudad de Roma, de otra la de las provincias conquistadas y de otra, la de los territorios con *foedus* o acuerdo que le otorgaba un estatuto jurídico especial.

Partiendo de que la diversidad de territorios dominados por Roma, la fecha de su incorporación y el estatuto con el que se incorporaron a la misma se puede afirmar que en la ciudad de Roma administró justicia el Pretor Urbano. En la península itálica, tras la guerra social, los municipios tuvieron sus propios magistrados municipales, *duumviri* o *quatuorviri*, quienes dirigían los asuntos con cierta independencia respecto a la urbe, sólo limitada por temas de pena o cuantía elevada. En estos supuestos se creó la figura del *praefectus iure dicundo*, quien, como magistrado delegado del pretor de Roma, se desplazaba a los lugares alejados de la urbe para administrar justicia en todos aquellos asuntos competencia de aquél y que no fuesen de jurisdicción voluntaria⁷. En las provincias regiría el estatuto provincial, que bajo la suprema jurisdicción del gobernador, tendría las especialidades que para los municipios privilegiados suponía su propio estatuto municipal. Como se recoge por Gayo y aparece en diversos estatutos municipales, tales como Irni, Malaca o en la *Lex Rubria* de la Galia Cisalpina, el límite competencia competencial de los magistrados municipales estaba en torno a los diez y veinte mil sestercios, según la categoría del municipio y su relación con Roma⁸. Por encima de dichas cantidades era el gobernador provincial el que tenía asignada la competencia.

C., *Estudio comparativo de la versión de las XII Tablas de Maymó y Ribes (1712-1775)*, en *Actas del III Congreso Iberoamericano de Derecho Romano*, León, 1997, pp.319-341. ; MOMMSEN, TH., *Le droit public romaine*, cit. p. 187, señala que, entre las funciones de los ediles curules estaba la de imponer sanciones por delitos de usura, en virtud de las XII Tablas y leyes posteriores de contenido análogo, apoyando su afirmación en textos de Tito Livio, 7.28 y; 10.23 y Plinio, H., 33.1.19.

⁷ La jurisdicción voluntaria seguía dirigida en la mayor parte de los casos por el propio cónsul. La magistratura del *praefectus iure dicundo*, según Mommsen fue abolida en s. S. I por Augusto, al considerarlo inútil e incompatible con el nuevo sistema administrativo y jurisdiccional implantado. Vid. MOMMSEN, TH., *Le droit public romaine*, cit. III, p. 362.

⁸ Sobre la cuestión de la competencia de los magistrados municipales por razón de la cuantía. vid. TORRENT, A., *"Jurisdictio" de los magistrados municipales*. Universidad de Salamanca, 1970, pp.159 y ss.; D'ORS A. y D'ORS J., "Lex Iritana", en Cuadernos Compostelanos (88,1), Universidad de Santiago de Compostela, 1988; PUGLIESE, G., *Il processo formulare*, cit. pp. 145 y ss.

Cuando fue modificada la estructura administrativa por Diocleciano y Constantino, creando nuevas circunscripciones administrativas, nos encontramos junto a *praesides*⁹, vicarios y prefectos, con la importante magistratura del *praefectus urbi*¹⁰, con competencia exclusiva en la vigilancia de los cambistas. Como señala Chastañol, el *praefectus* habría atraído a su jurisdicción todas las demandas derivadas de alteración del orden público; esta competencia era, en sus palabras, *un complemento a la vigilancia del prefecto sobre todos aquellos aspectos que por su naturaleza podían suscitar desórdenes. A este género pertenecían los negocios bancarios pertenecientes a causas pecuniarias en los que intervenían banqueros o cambistas. Desde Adriano el prefecto tenía la jurisdicción en todos los procesos incoados por, o contra, banqueros en materia de usura*¹¹. Entre sus competencias cabe destacar también las derivadas del comercio en el puerto de Ostia. Este puerto tuvo siempre una importancia vital para las comunicaciones, milicia pero, sobre todo, para el aprovisionamiento de la ciudad. Su vigilancia se desarrolló por diversos funcionarios que, con el paso del tiempo, fueron cambiando de nombre y ampliando sus competencias ya que el comercio llevaba implícito el cobro de una ingente cantidad de impuestos. Esta causa justifica que la mayor cantidad de noticias que nos ha llegado en esta materia se refiere a funcionarios con competencias recaudatorias y judiciales. Como señala Rougé¹² existía en el puerto un tribunal dirigido por el *quaestor Ostiensis*, con funciones judiciales, aunque en el s.I acabó desapareciendo. Sus competencias fueron asumidas sucesivamente por funcionarios imperiales como eran los *procuradores portus ostiensis*, *utriusque portus* y de la *annonae*¹³. A estos siguieron otros, como el *vicarius*,

9 Hermogeniano en D. 1.18.10 señala que corresponde a los corregidores y presidentes de provincia el conocimiento de todas las causas de que en Roma conocen el *praefectus urbi*, o el prefecto del pretorio, cónsul y restantes magistrados. Es decir, todas, todas las causas no atribuidas al propio emperador.

10 Ulpiano nos refiere en D. 1.12.1.9 que el prefecto de la ciudad, además de velar por buen trato a esclavos, vigilancia de la legalidad de tutores y curadores, entre otras funciones, tenía la de cuidar de que los cambistas se comportasen de forma honesta absteniéndose de realizar actos prohibidos: *Praeterea curare debet praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotium suum et temperent his, quae sunt prohibita...* Sobre creación y competencias del prefecto de la ciudad vid. DE MARTINO, F, *Storia della costituzione romana*, Nápoles, 1974, vol. V, pp. 641 y ss.

11 CHASTAÑOL, A., *La praefectura urbaine á Roma sous le bâs empire*. París, pp.100 y ss.; *Paul. Lib. sing. de off. praef. urb.* D.1.12.2: *Adiri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis potest*. VARELA GIL, C., *El estatuto del empleado público en Roma*, Madrid, 2007, p.121.

12 ROUGE, J., *L'Organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire Romain*, París, 1966, pp. 201 y ss.

13 Para Pomponio, los prefectos de la annona no eran realmente magistrados (D.12.2.33), siendo su creación, según MOMMSEN, TH., *Römisches Stastrecht*. Leipzig, 1987=*Le Droit Public Romain*, Trad, Girard P.F., V, pp.340 y ss., obra de Augusto para reemplazar a los *praefecti frumenti dandi*, también llamados *curatores frumenti*, con oposición del pueblo, pues suponía suplantar magistraturas de corte edilicio elegidas por el pueblo. Pero las fuentes le atribuyen competencias jurisdiccionales, como en *Paul. 1 decr.* D.14.5.8, en donde resuelve un conflicto dictando sentencia en un tema derivado de la huida de un esclavo que habitualmente arrendaba almacenes y daba y tomaba dinero en préstamo en nombre de su señor. Se dice en dicho fragmento que su sentencia fue apelada al emperador, aunque de las fuentes parece desprenderse que las sentencias de estos prefectos requerirían previamente la apelación al *praefectus urbi*. Sobre el prefecto de la *annonae* vid. PAVIS D'ESCURAC, *La prefecture de l'annone service imperial d'Auguste á Constantin* (Bibliothèque des écoles francaises d'Athenes et de Rome. Fas.226), París,Roma, 1976; VARELA GIL, C., *El estatuto del empleado público en Roma*, cit., p.122; DE MARTINO, F, *Storia della costituzione romana*, cit. vol. V, pp. 654-655.

de quien se tiene noticia en la época de Constantino; finalmente fueron sustituidos por el *Comes portuum*, asistido por su subordinado el *centenarius portus* y el *vicarius portus*¹⁴.

3. FUEROS COMPETENCIALES

A la par que se fue incrementando el número de procesos, haciendo más compleja la aplicación del sistema jurisdiccional tradicional, se fueron estableciendo unos criterios que permitieron que las partes litigantes supieran dónde habían de interponer la demanda o contestar a la misma, con una más rápida y eficaz tramitación del procedimiento. El criterio prioritario recogido por jurisconsultos y constituciones imperiales fue el que consideraba que el demandante debía interponer la demanda en lugar en el que tuviese su domicilio el demandado (*forum domicilii*). A este fuero general se añadieron otros especializados, como el del lugar de comisión del delito (*forum delicti commissii*) o el lugar donde se hallaban los bienes objeto de litigio (*forum rei sitae*), pero, entre todos ellos destacaron, en materia civil, dos fueros que, en ocasiones eran coincidentes, y en otras pugnaban, dando lugar a múltiples pleitos, como eran el *forum contractus* y el *forum domicilii*. De hecho, aparecen dos fragmentos en el Digesto haciendo referencia a los citados fueros que establecen el lugar en el que debe desarrollarse el proceso cuando intervienen banqueros, y su solución es, al menos aparentemente, totalmente contrapuesta.

El fragmento que resume el criterio de aplicación de referencia durante la mayor parte de tiempo republicano y hasta la época justiniana aparece en C. 3.19.3 al prescribir que el actor sigue el fuero del reo, ya se trate del ejercicio de una acción real, ya se trate de una acción personal¹⁵. Esta prescripción se encuentra también en otras constituciones, como la de Diocleciano y Maximiano en la que los emperadores se oponen a la petición de que se invierta el orden del derecho, de manera que sea el reo el que siga el fuero del actor. Esta constitución es sumamente interesante, pues añade que *donde el reo tiene el domicilio, o lo tuvo al tiempo del contrato, aunque después lo hubiere trasladado, allí tan solo debe ser demandado*¹⁶. De acuerdo con lo expuesto, los banqueros habrían de seguir el fuero del demandado y litigar en el lugar de su domicilio¹⁷. Pero esta solución se complicaba cuando, en el transcurso de

14 Debido a la crisis económica que padeció el imperio, todos estos magistrados se convirtieron en despiadados cobradores de los impuestos de aduana que eran temidos, no tanto por el cumplimiento de la ley como por su avaricia. Vid. *Cassiodoro, Variae*, VII, 9.

15 C.3.19.3 (*Val.Theod. Arc.385*) establece el fuero general en materia de acciones personales y reales, pero habría que hacer constar dos matices. El primero que dicha constitución permite que se pueda ejercitar también en el lugar donde se hallan los bienes por los que se litiga y, en segundo lugar, que su aplicación está sujeta a excepciones por razón de materia, personas u oficios establecidos por el propio emperador en las constituciones del mismo libro.

16 C.3.13.2 (*Diocl. Max. 287-304*). Este precepto se ve apoyado por otros, como C.3.13.7, en donde se dice por el emperador Anastasio, en una fecha tan tardía como es el año 502, que es muy injusto que se pretenda declinar la jurisdicción de ciertos jueces alegando que se desempeña una determinada profesión o comercio. En esta constitución parece proscribirse la sumisión de las partes a juez incompetente, por cuanto señala de modo expreso que, tanto en las causas públicas como en las privadas, las partes deben acudir a la juez competente, con la sola excepción de la milicia, que responderá ante sus propios jueces.

17 El término domicilio debió ser concretado por la jurisprudencia y los propios emperadores. Papiniano en D. 50.1.17.13 recuerda que *sola domus possessio, quae in aliena civitate comparantur, domicilium non fecit* y, junto a la negación de que la compra de una vivienda en otra ciudad no constituye domicilio, Paula añade en D. 50.1.20 que no basta

la vigencia del contrato, el demandado variaba su domicilio, ya fuere de una forma casual o maliciosa. En estos supuestos el fuero del demandado variaba y, de hecho, podía variar tantas veces como quisiera el demandado. Esta situación generaba incertidumbre y una situación de injusticia para los banqueros que veían peligrar la solución de un pleito favorable ante una excepción procesal de *plurispetitio loco*. A remediar esta situación vino la llamada acción de *eo, quod certo loco dari oportet*. Su regulación aparece en el Título IV del Libro XIII del Digesto. Esta acción tenía otra virtud, aparte de la de posibilitar la demanda en dos lugares si el deudor cambiaba de domicilio, y ésta era la de tener carácter arbitrario, por lo que se autorizaba a juez a moderar en su sentencia el cambio de valor de los bienes por la diferencia de lugar en el que se hallaban estos. Su formulación aparece recogida en diversos fragmentos y constituciones, como D.13.4.1 o C.3.19.18 en los que se establecen los supuestos de su aplicación, así como los de su exclusión explícita. En D. 13.4.5 y 13.4.6, se refiere por los juristas Paulo y Pomponio que *compete la acción arbitraria, tanto si se hubiera mandado al testador por el heredero que diera alguna cosa en cierto lugar como si se hubiera dado en mutuo dinero para que se devuelva en lugar determinado*. En el fragmento siguiente al amplio margen que concede la ley a los jueces en juicios de buena fe, Paulo afirma que *en los juicios de buena fe, aunque al contratar se haya convenido que se entregase alguna cosa en un determinado lugar, compete la acción de compra o de venta, o de depósito y no la acción arbitraria*, salvo que la entrega tuviese su origen en una estipulación¹⁸.

El panorama competencial cuando intervenían banqueros teniendo dinero ajeno depositado, prestando dinero o realizando labores de administración de bienes, se veía alterado por la existencia de normas especiales por razón de su oficio. Nos referimos a las recogidas en Libro quinto del Digesto referido *al lugar en donde se deban de celebrar los juicios*. En él se recoge el fragmento de Ulpiano en D. 5.1.19.1, en el que se establece que el lugar para entablar pleitos contra quienes desarrollaron actividades de administración, como son los banqueros, es aquél en el que se realizó la administración. Por el contrario en otro fragmento de Papiniano, recogido en D. 5.1.45.1 pr, se establece que el lugar donde se debía realizar la reclamación contra el banquero era el lugar en donde tuvo lugar el contrato. En ambos fragmentos se aprecian criterios contrapuestos pues, en el primero primaría el lugar en donde se encuentran los libros de cuentas y es más fácil demostrar la actividad realizada, mientras que en el segundo, lo que prima es el *forum contractus*, con independencia de que los libros se hallen en un lugar o en muchos lugares. No hay que olvidar que la actividad y cuentas de una persona se podrían desarrollar en muchos lugares de forma simultánea, siendo complejo elegir el lugar en donde se encontraban la mayor o más importante parte de los libros o información.

una mera declaración, sino que, para que exista un cambio de domicilio, éste debe ser efectivo y real. A este respecto es sumamente clara la constitución de Diocleciano y Maximiano recogida en C.10.40(39).7, estableciendo que será domicilio *el lugar donde cada cual constituyó sus lares, y el conjunto de sus cosas y fortuna, y de donde no haya de alejarse otra vez, si nada le obliga, y de donde cuando partió, se considera que de viaje, y cuando volvió, que dejó ya de viajar*. Sobre concepto de domicilio vid. ROBLES REYES, J.R., *La competencia jurisdiccional y judicial*, cit. pp. 34 y ss.

18 Paul. 28 ad ed. D. 13.4.7: *In bona fidei iudiciis, .etiamsi in contrahendo convenit, ut certo loco quid praestetur, ex empto vel vendito, vel depositi actio competit, non arbitrario actio, ...* Una cuestión distinta es la recogida en Ulp. 47 ad. Sab. D. 13.4.9, en donde se contempla el supuesto de que sea el deudor el que desee pagar, pero en un lugar escogido por él a su voluntad. En este caso Ulpiano señala que el que prometió pagar en un determinado lugar no puede hacerlo válidamente en otro distinto, salvo que el acreedor se lo consienta.

En *Ulp. 60 ad Ed. D. 5.1.19.1* se recoge: *Si quis tutelam, vel curam, vel negotia, vel argentariam, vel quid aliud, unde obligatio oritur, certo loci administravit: etsi ibi domicilium non habuit, ibi se debebit defendere etsi non defendat "neque ibi domicilium habeat", bona possideri patietur...* En este texto se menciona de forma expresa a los banqueros o *argentarii*, que debían defenderse de las reclamaciones que se formulaban contra ellos en el lugar en que nace la obligación, siendo indiferente que tuviera allí su domicilio o no pues, como prescribe el jurista, para asegurar el cumplimiento de una eventual condena, si rehusare defenderse en dicho lugar sufriría el embargo de sus bienes. Este fragmento guarda relación con los recogidos en el T. XIII del L. II del Digesto, que lleva por título *De edendo*, en el que se hace referencia a la exhibición de documentos que se han de presentar en juicio siendo las citas de banqueros y cambistas frecuentes. En *D. 2.13.4*¹⁹, se recoge expresamente la obligación del responsable del banco de exhibir los libros de cuentas en el lugar en el que se realizó la actividad. Incluso se plantea el supuesto de que fueran distintos los lugares en donde se desarrolló la actividad y en donde se encuentran los libros, supuesto que podía ser frecuente por desarrollarse aquella en diversos lugares. En este supuesto se prescribe que donde se desarrolló la actividad es el lugar en donde ha de realizarse la exhibición de libros, no debiendo éstos de haber estado en otro lugar. Frente a estos fragmentos que dejan clara la importancia del lugar en que se desarrolló la actividad, por ser el lugar en donde se hallan los instrumentos en los que figuran los hechos controvertidos, siendo así más fácil su comprobación, nos encontramos con otro fragmento, en este caso de Papiniano, en el que de forma tajante indica que el banquero debe ser demandado en el lugar en el que se formalizó el contrato²⁰:

Pap. 3 resp. D.5.1.45pr: Argentarium ubi contractum est, conveniri oportet, nec in hoc dilationem nisi ex iusta causa, dari, ut ex provincia codices adferantur. Idem in actione tutelae placuit.

Este precepto podría conciliarse con los anteriormente citados señalando que en aquellos no se hace referencia expresas a la demanda a banqueros, sino a cambistas, lo cual sería forzado por la frecuencia con la que aquellos se dedicaban también a esta actividad. Pero lo que es más difícil de conciliar es el final del fragmento de Papiniano, cuando se dice que los documentos deben ser traídos desde la provincia al lugar donde se sigue el litigio, al igual

¹⁹ *Ulp. 4 ad ed. D.2.13.4 pr.* prescribe la obligación de exhibir los libros de cuentas con mención de la fecha, es decir, citando día y cónsul. Su obligatoriedad viene justificada en el párrafo siguiente, cuando el jurista señala que los libros de cuentas son, de algún modo, no sólo del cambista, sino también de quien los encargó y de donde traen causa.: *Praetor ait: argentariae mensae exercitores rationem, quae ad "se pertinet", edent adiecto die et consule.* En *Gai ad Ed. D. 2.13.10.1*, se incide más en este tema, afirmando que los libros de cuentas *ministerium publicum habet*, es decir, tienen una cierta naturaleza pública, debiendo ser formalizados con diligencia. *..ideo autem argentarios tantum, neque ullos ubsimiles iis edere rationes cogit, quia officium eorum atque ministerium publican habet causam; et haec principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant;* Si se tratare de reclamación contra un esclavo que hacía de cambista, la acción sólo podrá dirigirse contra el dueño si conocía dicha actividad o se beneficiaba de ella, por ejemplo al realizarse con el peculio del esclavo. En caso contrario, bastará el mero juramento del dueño para quedar eximido de reclamación. Estos supuestos no se daban contra mujeres por la prohibición de su ejercicio por ser considerado oficio viril (*Call. 1 ad. Ed. Mon. D. 2.13.12*).

²⁰ En el mismo sentido *D.3.21.1(Dioc. Max.293): Eum qui, aliena negotia sive ex tutela sive quocumque alio titulo administravit, ubi hacet gessit, rationem oportet reddere.*

que sucede con la tutela. Pero un estudio de los fragmentos citados y los concordantes, nos llevaría, en mi opinión, a una solución que explicaría con pleno sentido las aparentes contradicciones entre ambos fragmentos. Con carácter previo a la reclamación a un banquero o cambista se podría ejercitar contra él la *actio ad exhibendum* para que mostrase los libros de cuentas que reflejaban la correcta ejecución de las cláusulas por aquél, de acuerdo con lo establecido en el contrato. En este caso no era preciso dirigirse al lugar en que se formalizó el contrato, que pudo ser en un lugar alejado, ya que la finalidad de la acción sólo era la exhibición de los libros y no la exigencia de responsabilidad por el contenido de los mismos. Una vez exhibidos y comprobados los libros de cuentas por el que contrató con el banquero o cambista podía no iniciar actividad judicial alguna o, por el contrario, ejercitar una acción en el lugar en que se celebró el contrato, debiendo los libros ser llevados a este lugar, aunque se encontrasen en las provincias. Regía en este último caso el *forum contractus* y, de acuerdo con el fragmento citado, recogido en D. 5.1.19.1, si el banquero se negase se negase a defender en dicho lugar vería sus bienes embargados.

4. ÚLTIMAS CONCLUSIONES

Como conclusión de lo expuesto en los anteriores párrafos, el fuero competente en los litigios en que se demandaba a un banquero o cambista era el *forum contractus*, y no el de su domicilio. Por el contrario, en los supuestos en que era el banquero el que demandaba al deudor que no devolvía la cantidad prestada o interés convenidos, el fuero general relativo al *forum domicilii* podía verse modificado por la *actio de eo quod certo dari oportet*, permitiendo el inicio y desarrollo del proceso en el lugar en el que tuviese su residencia el demandado en el momento de la demanda. Pero este sistema entraría en crisis por diversas causas. En primer lugar por la implantación del nuevo sistema de la *extraordinaria cognitio*, que atribuía mayores facultades a los funcionarios imperiales y, en segundo lugar, por las profundas crisis sociales, económicas y militares que fracturaron el imperio. Como señala Declareuil²¹, la crisis económica y municipal, unida a que las provincias aumentaron en número, disminuyendo su extensión, permitió comparecer ante el *praesides* provincial con mayor facilidad, en detrimento de los magistrados municipales. Posteriormente, la remodelación territorial y administrativa realizada por Diocleciano vino a modificar el panorama jurisdiccional durante todo el Bajo Imperio. Cada uno de los nuevos territorios tenía su representante del emperador y cada uno de ellos ostentaba, salvo casos expresamente mencionados, la competencia jurisdiccional de su territorio y derecho de apelación respecto de las circunscripciones menores. Tampoco hay que olvidar la imposibilidad de vivir o negociar en lugar distinto al de la provincia en que se tenía el domicilio, de manera que los problemas de la época clásica en la que una persona tenía tierras o negocios en lugares alejados ya no se producían²².

21 DECLAREUIL, J., *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales*, París, 1911, (reimpr. 1973), pp. 258 y ss.

22 Sobre prohibiciones al comercio con extranjeros vid. C.4.41.1 en donde se establece que nadie podrá transportar a tierras bárbaras vino, aceite u otros líquidos, ya fuere para cualquier uso o comercio.

En este breve recorrido por la competencia jurisdiccional romana, se puede afirmar que los magistrados citados anteriormente fueron los más importantes y los que más perduraron en el tiempo. A pesar de ello surgieron dos nuevas figuras que, por su importancia merecen ser destacadas. Una de ellas es el obispo y, la segunda, el *defensor civitatis*. La primera surgió por la implantación del cristianismo como religión oficial, siendo el obispo persona existente en todos los territorios que suplió el vacío dejado por las curias locales y evitó la lejanía o complejidad jurídica de litigar ante el *praesides*. Esta *episcopalis audientia*²³ actuaba como arbitraje privilegiado permitiendo a todo tipo de litigante, especialmente a los más pobres, dirigirse a una persona revestida de *auctoritas* y, de forma indirecta, también *potestas*, ya que los diversos emperadores concedieron a los obispos abundantes prerrogativas. La otra figura, a quien se otorgó un amplio abanico de competencias administrativas y jurisdiccionales es el *defensor civitatis*²⁴ que, en litigios en que intervenían banqueros tenía competencia en pleitos de poca importancia, siendo su límite los cincuenta sólidos²⁵.

Como conclusión final, se puede afirmar que los banqueros influyeron en la redacción de las normas legales y jurisdiccionales, especialmente a partir del s. I. a.C. Con la implantación del Principado y Dominado su poder fue creciendo, a la par que creciendo a la par que las necesidades imperiales. A tal efecto, fueron muchos los fueros privilegiados existentes en el Bajo Imperio y que el mismo Justiniano amplió, tal y como se recoge, entre otras, en la Novela 136²⁶ *De argentariarum contractus*. Pero fue la Nov. 69 la que el emperador estableció un criterio competencial que debió de resumir el practicado en los juzgados durante los siglos precedentes y zanjaba cualquier duda en materia competencial. Señaló de forma expresa que *en la provincia en que uno delinque, o en la que es constituido reo en negocio civil o criminal, o en cuestión de terrenos y límites, o de propiedad o cuestiones de posesión o hipoteca o de cualquiera otra cuestión, allí también esté cada cual sujeto al derecho, y no pretenda litigar fuera de aquél término*²⁷. De este modo, y salvo litigios en vía de apelación, los presidentes provinciales al que estaban sujetos los litigantes serían los llamados a resolver los litigios de importancia en que intervenían banqueros.

23 CUENA BOY, F.J., *La episcopales audiencia. La justicia episcopal en las causas civiles entre laicos*. Valladolid. 1985.

24 El *Defensor Civitatis*, como protector de los administrados contra los abusos de poderosos, ya fueren particulares o miembros de la propia administración, debió de ser creado en el principado, aunque las fuentes no lo precisan con claridad. Paulo en D. 50.4.16.3 ya lo menciona como defensor de las cosas públicas: *defensionem rei publicae amplius quema semen suscipere nemo cogitur, sinsi id fieri necessitas postulet*. En sendas constituciones del s. IV, C.Th.1.29.5 (Valent. Val.370) y C. 155.4 (Grac. Val. Theod. 385) lo presentan como *padre de la plebe*, supliendo la inocente rusticidad de la población más débil.

25 C.1.55.1(Valent. Val. 365): *Si quis de tenioribus ac minusculariis rebus interpellandum te esse crediderit, in minoribus causis, id est usque ad quinquaginta solidorum summam, acta iudicialia conficias,....*

26 La Nov. 136 cit. comienza alabando a los banqueros por su utilidad a la sociedad y toda la suerte de peligros que deben afrontar en su actividad de préstamos y consignación de dinero y les autoriza a cobrar el ocho por ciento de interés, así como tener derecho de ejecución privilegiado en las ejecuciones de terceros frente a sus deudores.

27 Nov. 73 (Just. 538). En esta novela no se hace mención si han de dirigirse los litigantes en primer lugar a los magistrados de la ciudad o, por el contrario, a la jurisdicción del presidente. Esta última solución no era descabellada; en primer lugar, porque la constitución tenía como finalidad última, según recoge expresamente, proteger a los más débiles para que no tuviesen que ir a litigar a la ciudad de Constantinopla, en beneficio de los poderosos, y, en segundo lugar, por la época en que se promulga, pues las provincias tenían un territorio mucho más reducido que en la época clásica y era más fácil el acceso al presidente de la provincia.

